

PART 01

총론

제1장 지식재산권

제2장 특허제도 일반

제3장 특허법 일반

제4장 발명

제5장 행위능력, 대리인 및 대표자

제6장 기일과 기간

제7장 특허에 관한 절차 일반

제8장 절차의 진행 일반

제9장 보칙

제1장

지식재산권

제1절 서 설

1) 「지식재산권(intellectual property)」이란 생각에서 비롯된 창작, 표지 및 영업에 관한 무형적인 이익을 객체로 하고,¹⁾ 이를 독점적으로 이용하는 것을 내용으로 하는 권리로서²⁾ 특허권, 실용신안권, 상표권, 상호, 디자인권, 저작권, 반도체배치설계권, 식물신품종보호권 등을 그 예라고 할 수 있다.

2) 농경사회에서 산업사회로 전환되는 시기에 태동하여 오늘에 이르고 있는 지식재산권은 인간의 정신활동의 산물에 대하여 소유권과 유사한 권리를 부여하는 것에서 출발하고 있다. 종래의 물건적 개념인 소유권이 유형물에 대한 사용, 수익, 처분과 같은 권리를 인정하는 것에서 출발점을 찾을 수 있다면, 지식재산권은 인간 정신 활동의 산물인 무형물에 대한 권리를 인정하는 것에서 찾을 수 있다. 이처럼 지식재산권은 본질적으로 사유재산제도 및 자본주의에서 그 뿌리 및 발전을 가늠해 볼 수 있다.

3) 이러한 지식재산권은 그 개념이 고정되어 있다기보다는 시대의 발전과 더불어 그 외연이 점차 확대되어가고 있다고 볼 수 있다. 농경사회에서 산업사회로의 변혁 시기에 사유재산 제도가 정립되었던 것처럼, 현대는 산업사회에서 지식사회로 변혁되는 시기로 지식재산권 제도가 정립되어가는 시기로 볼 수 있다. 특히 인터넷의 등장으로 인해 지식에 대한 접근권(access right)이 민주화되었다고 볼 수 있고, 이로 인해 종래와는 다른 새로운 개념의 지식재산이 등장하고 있으며, 기존의 지식재산과는 그 모양을 달리하고 있다.

1) 지식재산 기본법 제3조제1호에 의하면, “지식재산이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말한다”라고 정의되어 있다.

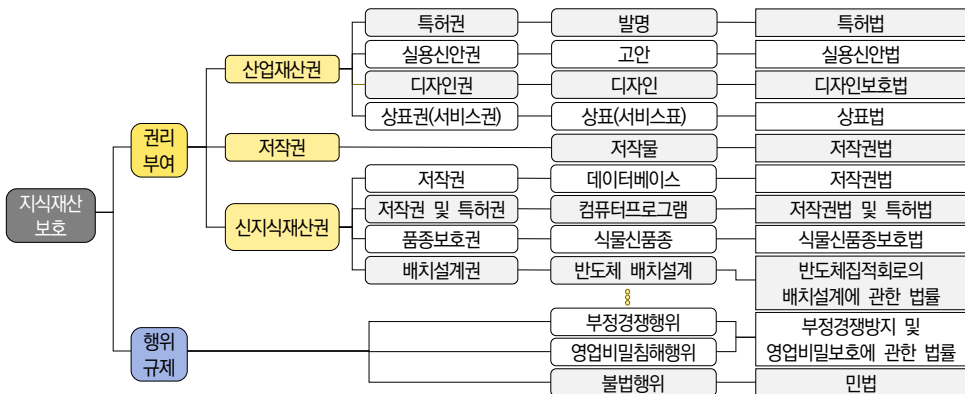
2) WTO/TRIPs에 따르면, 제1조제2호에서 「지식재산(지적재산)」이라는 용어는 제2부 제1절에서 제7절까지의 대상인 모든 범주의 지식재산을 지칭하는 것으로 정의하고 있으며, 제2부에서는 제1절 저작권 및 저작 인접권, 제2절 상표, 제3절 지리적 표시, 제4절 디자인, 제5절 특허, 제6절 집적회로 배치설계, 제7절 미공개정보의 보호가 규정되어 있다.

4) 한편 사유재산제도가 산업사회의 틀을 마련하였던 것처럼 지식재산제도는 지식사회의 기본적인 틀로서 작용할 것이다. 따라서 지식재산제도는 사회를 구성하는 각 구성원이 어떻게 사회에 이바지할 수 있으며, 그 구성원이 이바지한 것이 어떠한 형태로 그에게 보상될 수 있는지를 고려하며, 이것이 궁극적으로 인류사회에 득이 될 것인지를 고려하여 제도가 만들어져야 할 것이다.

5) 무릇 인류사회의 각 제도는 그 구성원에게 인류사회에 기여할 수 있는 기회의 평등을 제공하고 그 기여한 바에 따른 보상을 적정하게 해 주는 것을 기본으로 한다고 할 수 있을 것이며, 지식재산제도 역시 그와 같은 커다란 맥락에서 이해되어야 할 것이다.

제2절 지식재산권의 목적

1) 헌법 제22조제2항에서 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다”라고 규정하고 있다. 이러한 헌법의 이념에 따라 지식재산권법들이 제정되었으며 지식재산권법은 산업, 문화, 경제발전이라는 목적이 있다. 지식재산권법은 이러한 목적을 달성하기 위한 수단으로서 일반적으로 지식재산에 대한 독점·배타적인 권리를 부여하고 있다. 독점·배타적인 권리를 부여함으로써 저작자·발명가·과학기술자와 예술가들은 시장에서 이윤을 창출하게 되고, 이는 더욱더 많은 잠재적 저작자·발명가·과학기술자와 예술가들을 창작 활동으로 유인하게 되어 궁극적으로 산업, 문화, 경제발전을 가져오게 하는 것이다. 한편 지식자산을 보호하기 위해 항상 권리를 부여하는 것은 아니며 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등은 권리를 부여하기보다는 특정한 행위를 규제하고 있다.



【그림 1-1】 지식재산의 보호 체계

2) 각 지식재산권법의 목적을 더욱 상세히 살펴보면, 특허법 및 실용신안법은 발명 및 실용적인 고안을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 궁극적으로 산업발전에 이바지함을 목적으로 하고 있고, 디자인보호법 역시 디자인의 보호 및 이용을 도모함으로써 디자인의 창작을 장려하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다. 한편 창작을 보호하는 특허법, 실용신안법, 디자인보호법과 달리, 상표법은 상표를 보호함으로써 상표사용자의 업무상의 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. 저작권법은 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지함을 목적으로 한다. 즉 단순히 창작자만을 보호하는 것이 아니라 창작물을 공중에 이용하도록 전파하는 역할을 하는 저작인접권자들도 보호함으로써 저작물이 더 신속하게 공중의 이용에 제공되도록 하고 있다. 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률도 이와 유사하게 반도체 집적회로의 배치설계에 관한 창작자의 권리를 보호하고 배치설계의 공정한 이용을 도모하여 반도체 관련 산업과 기술을 진흥함으로써 국민경제의 건전한 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있으며, 식물신품종 보호법은 식물의 신품종에 대한 육성자의 권리를 보호함으로써 농림수산업 발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다.

3) 한편 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 국내에 널리 알려진 타인의 상표·상호(商號) 등을 부정하게 사용하는 등의 부정경쟁행위와 타인의 영업비밀을 침해하는 행위를 방지하여 건전한 거래질서를 유지함을 목적으로 하고 있다.³⁾

【표 1-1】 지식재산법의 목적

지식재산법		목 적				
		산업발전	수요자의 이익	문화 및 관련 산업의 향상발전	국민경제의 건전한 발전	건전한 거래질서 유지
권리 부여	특허법	○				
	실용신안법	○				
	디자인보호법	○				
	상표법	○	○			
	저작권법			○		
	반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률				○	
	식물신품종 보호법	○ (농림수산업의 발전)				
행위 규제	부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률					○

3) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 권리를 부여하는 것은 아니기 때문에 “지식재산권법”의 범주에 속하지 아니할 것이나 편의상 함께 설명하기로 한다.

제3절 지식재산권의 분류

I. 분류기준

전통적인 분류에 의하면 지식재산권은 보호의 목적에 따라 산업발전에 이바지할 수 있는 창작물 등을 객체로 하는 권리인 「산업재산권」과 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지할 수 있는 창작물을 객체로 하는 권리인 「저작권」으로 구별된다. 「산업재산권(industrial property)」은 발명, 고안, 디자인, 상표 등을 보호하는 권리인 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권으로 다시 분류할 수 있다.⁴⁾ 한편 지식재산권의 보호 객체인 지식재산은 그 개념이 고정되어 있다기보다는 경제·사회 또는 문화의 변화나 과학기술의 발전에 따라 그 외연이 점차 확대되어 종래와는 다른 새로운 개념(예를 들어 컴퓨터 프로그램, 반도체 배치설계, 식물신품종, 데이터베이스 등)에서의 보호되어야 할 지식재산이 등장하고 있다.⁵⁾ 이러한 새로운 지식재산에 대해서는 기존의 전통적인 권리의 테두리 안에서 보호하거나 새로운 법을 제정하여 권리로서 보호하려는 노력을 하고 있으며, 이를 「신지식재산권」이라고 부르고 있다.

II. 전통적인 분류에 의한 지식재산을 보호하는 권리

1. 발명이나 고안을 보호하는 특허권 또는 실용신안권

발명이란 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것」을 말하고,⁶⁾ 고안이란 「자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작」을 말한다.⁷⁾ 발명은 특허권으로, 고안은 실용신안권으로 보호될 수 있다. 특허권과 실용신안권은 본질적으로는 보호대상이 기술적 사상의 창작으로서 동일하다고 할 수 있으며, 다만 고도성의 정도만이 차이라고 볼 수 있다.

2. 디자인을 보호하는 디자인권

디자인이란 「물품⁸⁾의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 일으키게 하는 것」을 말한다.⁹⁾ 이러한 물품의 디자인은 디자인권으로 보호될 수 있다. 디자인을 보호하기 위한 제도는 나라별로 많은 차이를 보이고 있으며 크게 특허적인 보호(patent

4) 「산업재산권」이란 특허법·실용신안법·디자인보호법 또는 상표법에 의하여 등록된 특허권·실용신안권·디자인권 및 상표권을 말한다(발명진흥법 2IV).

5) 지식재산 기본법 제3조제2호 참조.

6) 특허법 제2조제1호.

7) 실용신안법 제2조제1호.

8) 디자인보호법 제2조에 따르면 물품은 물품의 부분 및 글자체를 포함하는 것으로, 글자체란 기록이나 표시 또는 인쇄 등에 사용하기 위하여 공통적인 특징을 가진 형태로 만들어진 한 별의 글자꼴로서 숫자, 문장부호 및 기호 등의 형태를 포함한 것을 말한다.

9) 디자인보호법 제2조제1호.

approach), 저작권적인 보호(copyright approach)로 나누어 볼 수 있다. 전자는 심사 제도를 두고 심사를 통과하는 경우에는 동일한 것뿐만 아니라 유사한 것에도 보호를 부여하되 독립적 창작인 경우에도 당연히 침해로 보는 것임에 반하여, 후자의 경우에는 창작과 동시에 보호가 부여되며 독립적 창작인 경우에는 침해로 보지 아니한다. 우리나라의 경우 공업상 이용가능성이 있는 물품의 디자인에 대해서는 특허적인 보호를 하고 있으며, 응용미술에 대해서는 저작권적인 보호를 하고 있다.

3. 상표를 보호하는 상표권

상표란 「자기의 상품(지리적 표시가 사용되는 상품의 경우를 제외하고는 서비스 또는 서비스의 제공에 관련된 물건을 포함한다. 이하 같다)과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장(標章)」을 말한다.¹⁰⁾ 여기서 표장이란 「기호, 문자, 도형, 소리, 냄새, 입체적 형상, 홀로그램·동작 또는 색채 등으로서 그 구성이나 표현방식에 상관없이 상품의 출처(出處)를 나타내기 위하여 사용하는 모든 표시를 말한다.¹¹⁾ 상표는 상표권에 의하여 보호될 수 있다. 상표법은 다른 산업재산권과는 달리 창작이 아닌 표장의 선택을 보호하고 있으며, 산업발전에의 이바지뿐만 아니라 수요자의 이익 보호를 목적으로 한다는 점에 특징이 있다.¹²⁾

4. 저작물을 보호하는 저작권

저작물은 「인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물」을 말한다.¹³⁾ 저작권은 이러한 저작물을 창작한 저작권자를 보호하는 권리로서, 창작과 동시에 발생하며 어떠한 절차나 형식의 이행을 필요로 하지 아니한다.¹⁴⁾ 저작권은 저작인격권과 저작재산권으로 구별할 수 있는데,¹⁵⁾ 「저작인격권」은 공표권, 성명표시권, 동일성유지권과 같이 저작자의 인격과 밀접한 관련이 있는 권리이고, 「저작재산권」은 복제권, 공연권, 방송권, 전송권, 전시권, 배포권, 2차적 저작물 작성권 등과 같이 저작자가 창작한 저작물로부터 이익을 추구할 수 있는 권리이다.

10) 상표법 제2조제1호.

11) 상표법 제2조제2호.

12) 상표법 제1조.

13) 저작권법 제2조제1호.

14) 저작권등록제도는 저작권에 관한 분쟁이 있을 경우, 정당한 저작자가 누구인지 창작시기는 언제인지 등에 관한 추정효를 부여하는 기능을 갖는다.

15) 우리나라 저작권법은 저작자의 권리인 저작권 외에, 저작자와 밀접한 관련을 가지고 있으며 저작물의 이용 도모에 기여하고 있는 실연가, 방송사업자, 출판업자 등과 같은 자들에 관한 저작인접권도 규정되어 있다 (著作權法 1).

Ⅲ. 신지식재산을 보호하는 권리

1. 데이터베이스를 보호하는 저작권

1) 데이터베이스는 넓은 범위에서 편집물의 하나로, 창작성이 있는 경우에는 기존의 저작권에서 편집저작물로서 보호가 이루어지고 있다고 할 수 있었다. 그러나 새로이 논의가 전개되었던 것은 비록 소재의 선택 및 배열의 창작성이 인정되지 아니한 데이터베이스인 경우에도 일응 보호하여야 할 법익이 존재한다는 데에서 출발한 것이다. 이에 관해서 유럽을 필두로 데이터베이스 보호에 대한 입법이 이루어져 왔으며 우리나라에서도 2003년에 입법되기에 이르렀다. 지식사회의 발전에 의하여 데이터베이스 및 디지털 콘텐츠의 수요가 급증함에 따라 데이터베이스를 제작하거나 그 갱신·검증 또는 보충을 위한 투자 노력을 보호하기 위한 것이었다.

2) 저작권법은 편집물, 편집저작물, 데이터베이스를 각각 다음과 같이 정의하고 있다. 먼저, 편집물은 저작물이나 소재의 집합물을 말하되, 데이터베이스를 포함하는 것으로 정의되어 있고,¹⁶⁾ 편집저작물은 편집물로서 그 소재의 선택·배열 또는 구성에 창작성이 있는 것을 말하는 것으로 규정하고 있다.¹⁷⁾ 또한 데이터베이스는 「소재를 체계적으로 배열 또는 구성한 편집물로서 그 소재를 개별적으로 접근 또는 검색할 수 있도록 한 것」으로 규정하고,¹⁸⁾ 이와 같은 데이터베이스를 제작 또는 그 소재의 갱신·검증 또는 보충에 인적 또는 물적으로 상당한 투자를 한 자를 데이터베이스 제작자로 정의하면서, 데이터베이스 제작자에게 그 데이터베이스의 전부 또는 상당한 부분을 복제·배포·방송 또는 전송할 권리를 갖도록 하였다.¹⁹⁾ 요컨대, 저작권법은 기본적으로 창작물을 보호하기 위한 법임에도 불구하고 데이터베이스의 경우에는 창작성 유무에 상관없이 데이터베이스를 구축한 자의 노력을 보상하기 위하여 인접권과 유사한 권리를 부여한 것이라 할 수 있다.

3) 다만 다른 저작물에 주어지는 저작권과 달리 데이터베이스 제작자가 가지는 권리는 데이터베이스의 제작을 완료한 때에 발생하며 그 다음 해부터 기산하여 5년간 존속한다. 또한 데이터베이스의 갱신 등을 위하여 인적 또는 물적으로 상당한 투자가 이루어진 경우에 갱신한 때부터 발생하며, 그 다음 해부터 기산하여 5년간 존속하도록 함으로써 상대적으로 짧은 기간 동안만 권리를 누릴 수 있도록 하고 있다.²⁰⁾

16) 저작권법 제2조제17호.

17) 저작권법 제2조제18호.

18) 저작권법 제2조제19호.

19) 저작권법 제93조. 동조에 따르면 데이터베이스의 개별 소재는 해당 데이터베이스의 상당한 부분으로 간주되지 아니한다. 다만 데이터베이스의 개별 소재 또는 그 상당한 부분에 이르지 못하는 부분의 복제 등이라 하더라도 반복적이거나 특정한 목적을 위하여 체계적으로 함으로써 해당 데이터베이스의 통상적인 이용과 충돌하거나 데이터베이스제작자의 이익을 부당하게 해치는 경우에는 해당 데이터베이스의 상당한 부분의 복제 등으로 보도록 하고 있다. 또한 데이터베이스의 보호가 구성 소재가 갖는 저작권에 영향을 미치지 않도록 규정하고 있다.

2. 식물신품종을 보호하는 품종보호권

1) 품종이란 「식물학에서 통용되는 최저분류 단위의 식물군으로서 유전적으로 나타나는 특성 중 한 가지 이상의 특성이 다른 식물군과 구별되고 변함없이 증식될 수 있는 것」으로, 식물신품종 보호법²¹⁾은 신규성, 구별성, 균일성, 안정성을 갖추고 품종 명칭이 있는 경우에는 심사를 거쳐서 품종보호권을 부여한다. 품종보호권을 보유하는 경우에는 업으로서 보호품종의 종자를 증식·생산·조제·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 독점적으로 품종보호권의 설정등록일부터 20년(과수 및 임목의 경우에는 25년) 동안 행할 수 있다.²²⁾

2) 품종보호권이 침해된 경우, 품종보호권자는 침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구를 할 수 있다. 또한 식물신품종보호법상 침해죄, 위증죄, 허위표시의 죄, 비밀누설죄 등이 규정되어 있고, 침해죄의 경우에는 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있는 친고죄로 규정되어 있으며 침해가 명백한 경우에는 7년 이하 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

3. 반도체 배치설계를 보호하는 배치설계권

1) 배치설계란 「반도체집적회로를 제조하기 위하여 여러 가지 회로소자 및 그들을 연결하는 도선을 평면적 또는 입체적으로 배치한 설계」를 말한다.²³⁾ 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률에 의하여 주어지는 배치설계권은 등록된 배치설계를 영리목적으로 이용할 수 있는 권리이다. 배치설계를 이용한다는 것은 배치설계를 복제하는 행위, 배치설계에 의하여 반도체집적회로를 제조하는 행위, 배치설계, 그 배치설계에 의하여 제조된 반도체집적회로 또는 그 반도체집적회로를 사용하여 제조된 물품을 양도·대여하거나 전시 또는 수입하는 행위를 의미한다.²⁴⁾ 배치설계권은 설정등록일부터 10년간 존속하되, 영리를 목적으로 그 배치설계를 최초로 이용한 날부터 10년 또는 그 배치설계의 창작일부터 15년을 초과할 수 없다.²⁵⁾

20) 한편 2022. 4. 20. 시행된 개정 부정경쟁방지법(법률 제18548호)에서는 건전한 데이터 시장질서를 확립하고자 데이터 부정사용행위(제2조제1호(카)목)를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 구체적으로 「데이터 부정사용행위(제2조제1호(카)목)」라 함은 데이터(「데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법」 제2조 제1호에 따른 데이터 중 업(業)으로서 특정인 또는 특정 다수에게 제공되는 것으로, 전자적 방법으로 상당량 축적·관리되고 있으며, 비밀로서 관리되고 있지 아니한 기술상 또는 영업상의 정보를 말한다. 이하 같다)를 부정하게 사용하는 행위를 말한다. 결국 본문의 보호대상 데이터는 '공개된 데이터 중 비정형 데이터'이다. 즉 '비공개된 데이터'는 부정경쟁방지법상 영업비밀로서 보호받을 수 있고, '공개된 데이터 중 소재가 체계적으로 배열·구성되어 있는 정형 데이터'는 저작권법상 편집저작물(창작성이 있는 경우) 또는 데이터베이스(창작성이 없는 경우)로서 보호받을 수 있기 때문이다.

21) 개정되기 전의 종자산업법은 종자의 보충·유통관리 등에 관한 실체적 규정과 품종보호 관련 절차적 규정이 혼재되어 법률의 체계 및 내용이 복잡하고 이해하기 어려운 면이 있었는데, 「종자산업법」 중 식물신품종의 출원·심사 및 등록 등에 관한 절차적 규정을 분리하여 식물신품종 보호법을 2012년 6월 1일자로 제정(시행은 2013년 6월 2일자임)함으로써 식물신품종과 그 육성자의 권리를 체계적으로 보호하려고 하고 있다.

22) 식물신품종보호법 제55조.

23) 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제2조제2호.

24) 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제2조제4호.

2) 반도체 배치설계는 등록을 요건으로 하고 있으나 심사를 필요로 하지는 아니한다. 따라서 배치설계권을 얻고자 하는 배치설계를 창작한 자 또는 그 승계인은 영리를 목적으로 그 배치설계를 최초로 이용한 날부터 2년 이내에 지식재산처장에게 그 배치설계권의 설정등록을 신청하여야 한다. 배치설계권자는 침해에 대해서 침해금지청구, 손해배상청구 등의 민사적 구제뿐만 아니라 형사적 구제²⁶⁾ 받을 수 있다.

4. 컴퓨터 프로그램을 보호하는 저작권 및 특허권

1) 컴퓨터 프로그램이란 「특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치(이하 “컴퓨터”라 한다) 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 창작물」을 말한다.²⁷⁾ 컴퓨터 프로그램 자체는 저작권에 의하여 보호되며 무단 복제를 금지하고 있으나, 컴퓨터 프로그램의 호환에 필요한 부분에만 허락을 받지 아니하고 프로그램 코드 역분석을 할 수 있다.²⁸⁾ 기존에는 컴퓨터 프로그램을 컴퓨터 프로그램 보호법으로 보호하였으나, 2009년 4월 22일 시행된 현행법(법률 제9625호)에서는 컴퓨터 프로그램 보호법을 폐지하면서 저작권법 내에서 그 내용을 규율하고 있다.

2) 한편 컴퓨터 프로그램 자체는 자연법칙을 이용하지 않기 때문에 발명의 정의 규정에 반하여 특허권에 의하여 보호되지 않으나, 그 프로그램이 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기 시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 있다는 것을 명확히 적시한 경우, 즉 하드웨어와의 유기적 결합관계를 갖는 컴퓨터 프로그램 관련 발명에 한해서는 특허권에 의하여 보호되고 있다.

제4절 지식재산권의 이해

1) 지식재산권 제도에서 창작을 보호하는 두 가지 커다란 축으로 작용하고 있는 특허권과 저작권을 대비하여 살펴봄으로써 지식재산권 제도 전반에 대한 이해를 도모하기로 한다. 표현과 아이디어 이분법(expression/idea dichotomy)이 말해주는 바와 같이 아이디어는 특허권에 의한 보호가 주어지지만 표현은 저작권에 의한 보호가 주어진다. 여기서 주목하여야 할 사항은 아이디어가 동일하다고 하더라도 표현은 다양하게 이루어질 수 있다는 것이다. 따라서 보호의 광범을 따진다면 특허권이 저작권을 능가한다고 볼 수 있다. 그러나 권리의 발생 측면에서 본다면 저작권이 훨씬 용이함을 알 수 있다. 저작권은 창작과 동시에 어떠한 절차나 형식의 이행을 요구하지 아니한

25) 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제2조제4호.

26) 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제45조 내지 제49조로서 침해죄, 허위표시죄, 거짓행위죄, 비밀 누설죄 및 양벌규정이 있다. 침해죄는 친고죄이며 3년 이내의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

27) 저작권법 제2조제16호.

28) 저작권법 제100조의3 및 제100조의4 참조.

무방식주의인 데 반하여, 특허권은 엄격한 방식주의가 적용되어 법에서 정한 절차를 밟아야 할 뿐만 아니라 심사를 통과하고 등록을 완료하여야만 비로소 권리가 주어진다. 즉 발명하였다고 하더라도 출원을 하지 않으면 특허권은 주어지지 않게 되는 것이다.

2) 또한 저작권과 특허권은 보호기간에도 상당한 차이를 보이고 있다. 저작권은 저작자가 생존하는 동안 및 저작자 사후 70년 동안 보호됨에 반하여²⁹⁾ 특허권은 특허권의 설정등록이 이루어진 후 보호가 시작되어 출원일로부터 20년 후에 보호가 종료된다.

3) 동일성이 있는 별개의 독립적 창작에 대해서 저작권은 각각 권리가 인정될 수 있음에 반하여 특허권은 법에서 정해진 방식에 의하여 정해진 자에게만 권리가 부여된다. 예를 들어 홍화백과 임화백이 한 명은 부산에서 또 한 명은 목포에서 그림을 그렸는데 공교롭게도 그림이 거의 유사할 경우 홍화백과 임화백은 서로 다른 사람의 권리에 영향을 받지 않고 독자적인 저작권을 각각 취득하게 된다. 이와 달리, 특허권의 경우에는 흥연구원과 임연구원이 각각 휴대폰의 문자 입력 방식을 연구개발하여 이를 각각 특허출원하였다면 우리나라의 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 특허를 부여받을 수 있다. 이처럼, 먼저 출원한 자만이 특허를 받을 수 있는 시스템을 선출원주의라고 한다.

4) 또한 특허권은 신규성(novelty)을 충족하여야 함에 반하여 저작권은 독창성(originality)을 충족하기만 하면 되는 것이다. 즉 신규성이란 발명을 한 사람이 무엇으로부터 복제한 것인지를 묻는 것이 아니라 동일성 여부만을 판단하는 것임에 반하여, 독창성은 비록 동일하다고 하더라도 무엇인가로부터 복제한 것이 아니라면 인정되는 것이다.

5) 같은 맥락에서 독립적 창작에 대한 침해 여부에 대해서도 특허권과 저작권은 상반된 태도를 견지하고 있다. 즉 특허권은 독립적 창작인지의 여부에 상관없이 결과물이 청구범위의 각 청구항의 보호범위에 속하는지 여부에 따라 침해 여부가 판가름 남에 반하여 저작권은 독립적 창작이면 저작권 침해가 아니라고 보는 것이다.

6) 창작을 보호하기 위한 지식재산권법은 위의 특징을 가진 특허권과 저작권의 각 요소를 선택적으로 취하고 있다고 보인다. 즉 특허권과 저작권을 양대 축이라고 할 때 창작 관련 지식재산권의 구체적인 법은 특허권과 저작권이 이루는 스펙트럼의 어느 한 부분에 있는 것으로 파악할 수 있을 것이다. 예를 들어 물품의 디자인을 보호하기 위한 디자인보호법의 경우에는 동법 제92조 디자인권의 효력에 따라 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 그 디자인과 유사한 디자인을 실시할 권리를 독점한다. 여기서 등록디자인의 보호범위는 디자인등록출원서의 기재사항 및 그 출원서에 첨부한 도면·사진 또는 견본과 도면에 기재된 디자인의 설명에 표현된 디자인에

29) 2013년 7월 1일에 시행된 개정 저작권법에 따르면, 공동저작물인 경우에는 맨 마지막으로 사망한 저작자의 사망 후 70년간 존속하며, 무명 또는 이명 저작물의 경우에는 공표된 때부터 70년간 존속하도록 하고 있다. 다만 무명 또는 이명 저작물의 경우 그 기간에 저작자가 사망한지 70년이 경과하였다고 인정할만한 정당한 사유가 발생한 경우에는 그 저작재산권은 저작자 사망 후 70년이 경과하였다고 인정되는 때에 소멸한 것으로 보도록 하고 있다(著作權法 39). 또한 단체명의 저작물 및 영상저작물의 경우에는 공표한 때로부터 70년간 존속하되, 창작 후 50년 이내에 공표되지 아니한 경우에는 창작 후 70년간 존속하도록 하고 있다(著作權法 40, 41). 영상저작물의 경우에는 공표한 때로부터 70년간 존속하며, 때부터 50년 이내에 공표되지 아니한 경우에는 창작한 때부터 70년간 존속한다.

의하여 정하여진다. 따라서 독립적 창작인지의 여부와 관계없이 등록디자인과 동일 또는 유사한 디자인을 실시한 자는 디자인권을 침해하게 되는 것이다. 물품의 디자인인 경우에도 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 경우에는 저작권법 제2조에 따른 응용미술저작물에 해당되어 저작권에 의한 보호가 부여된다. 따라서 이 경우에는 독립적으로 창작된 물품 디자인은 설령 그 결과물이 유사성이 있는 경우에도 침해가 되지 아니한다.

7) 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 또한 기술 창작물인 반도체 배치설계를 보호하는 것임에도 불구하고 저작권과 유사한 보호 방식을 많이 채택하고 있으며 독립적 창작에 대해서는 배치설계권을 침해하지 아니한 것으로 보고 있다. 좀 더 구체적으로 살펴보면 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률에 따른 배치설계권은 창작성 있는 배치설계를 지식재산처에 설정등록함으로써 발생하는 것으로 저작권의 무방식주의와는 달리 일정한 절차를 밟아야만 권리가 발생하도록 하고 있다. 그러나 동법 제9조제1항제3호에서 배치설계권자가 아닌 자가 제작한 것으로서 창작성이 있는 동일한 배치설계에는 배치설계권의 효력이 미치지 아니하도록 규정함으로써³⁰⁾ 독립적 창작을 비침해로 보고 있다. 즉 컴퓨터 프로그램, 반도체배치설계 등은 기술의 발전과 더불어 새로이 보호가 요구되어온 것으로서 우리나라의 경우 특허와 유사하게 등록 제도를 두었지만, 독립적 창작에 대해서는 비침해로 하는 등 저작권과 유사한 보호 체계를 가지고 있다고 할 수 있다.

30) 반도체 집적회로의 배치설계에 관한 법률 제9조에 따르면, 독립적 창작 외에도 교육·연구·분석 또는 평가 등의 목적이거나 개인이 비영리적으로 사용하기 위한 배치설계의 복제 또는 그 복제의 대행 및 그에 따른 연구·분석 또는 평가 등의 결과에 의하여 제작된 것으로서 창작성이 있는 배치설계에도 배치설계권의 효력이 미치지 않도록 규정하고 있다.

제2장

특허제도 일반

제1절 특허제도의 존립근거

I. 서설

특허제도는 산업발전의 이바지라는 대명제를 근간으로 하여 인간의 정신적 창작의 결과물인 발명을 보호하기 위해 출원인에게 일정 기간 독점·배타적인 특허권을 부여하는 제도를 말한다. 즉 발명을 공개한 출원인에게는 일정 기간 특허권이라는 독점·배타권을 부여하고, 일반 공중인 제3자에 대해서는 그 공개된 발명을 이용할 수 있도록 하여 궁극적으로는 산업발전을 유도하기 위한 제도라고 할 수 있다. 이러한 특허제도를 긍정하는 근거가 무엇인지에 대해서는 학설의 대립이 있는데 「자연권설」과 「산업정책설」이 이에 해당한다.

II. 자연권설

1) 「자연권설」은 개인적 정의에 입각한 견해로서 발명자가 그 발명에 대하여 독점권을 받을 수 있는 것은 당연하다는 주장이다. 이러한 자연권설은 i) 기본적 재산권설(소유권설)(eigentumstheorie)과 ii) 기본적 수익권설(보상설)(belohnungstheorie)로 다시 나뉜다. 「기본적 재산권설」이란 모든 신규한 사상은 본래 이를 생각해낸 자의 소유에 속하므로, 산업적 발명은 그 창작자에게 귀속시키는 것이 이론상 당연하며 사회나 일반대중은 이를 재산권으로 인정하여야 한다는 견해이다.

2) 「기본적 수익권설」이란 사람은 사회에 대해서 한 유익한 공헌정도에 비례해서, 본래 사회로부터 그 보상을 받을 권리가 있다는 생각으로, 발명은 사회에 대단히 유익한 공헌을 한 것이므로 사회는 이에 대한 최적의 보상으로서 그 발명을 전용할 수 있는 권리를 발명자에게 주어야 한다는 견해이다.

III. 산업정책설

「산업정책설」은 특허제도는 산업정책상의 견지에서 채용된 것이라는 설로서, 오늘날 가장 유력한 견해이다. 산업정책설은 i) 발명의 공개 대가로서 특허권을 부여한다는 「비밀공개설」, ii) 발명의 완성과 사업화·기업화를 장려하기 위해 특허법이 존재한다는 「발명장려설」, iii) 특허제도가 없는 경우 기업 간의 경쟁이 국내·외적으로 불공정하게 이루어지는 것이 불가피하므로 기업 간의 부

경쟁을 유효하게 방지하고 경업질서를 확보하기 위해서는 발명자에게만 독점권을 부여하는 특허제도가 공정하고 합리적인 방법이라는 「과당경쟁방지설」로 크게 나누어 볼 수 있으며, iv) 기술 선진국에는 국제시장에서 고도한 기술을 고부가 가치있는 재화로 만들어주고 개발도상국에서는 선진국의 특허발명 기술을 도입하여 자국의 기술발전에 이바지하도록 한다는 데에서 특허제도의 본질을 찾을 수 있다는 「국제교류설」을 이에 포함시키는 견해도 있다.

IV. 결 토

자연권설은 i) 특허권은 모든 신규발명자에게 부여되는 것이 아니라 최선발명자 또는 최선 출원인에게만 부여되는 점, ii) 발명을 한 사람이 특허출원을 하지 아니한 경우에는 특허가 부여되지 아니한 점, iii) 1국에 부여된 특허는 그 나라에만 적용되는 소위 특허권의 속지주의 원칙 등을 설명할 수 없다. 따라서 현재는 산업정책설이 다수설의 입장이다. 다만 산업정책설의 각 견해 또한 특허제도의 본질 중 어느 한 면만을 강조한 것이므로 어느 설이 옳다고 할 수는 없으며, 비밀공개설, 발명장려설, 과당경쟁방지설 및 국제교류설을 일체로 하여 종합적으로 판단하여야 함이 타당하다.

제2절 특허제도의 연혁

I. 서 설

일반적으로 사용하는 특허제도에서의 patent라는 말의 어원은 「공개된 것(be opened)」을 뜻하는 라틴어의 「patere」에서 유래되었는데, 이러한 특허제도의 간접적인 유래라고 할 수 있는 독점권이나 특권 등은 「독점은 원칙적으로 이익을 낳는다」라는 생각으로 통치자나 권력자의 보상 또는 은혜의 수단으로서 고대 그리스부터 존재했다.³¹⁾ 유럽대륙에서는 약 700년 전에 발명자에 대하여 일정 기간 발명을 독점적으로 사용할 수 있는 권리를 부여한 사실이 있는데, 발명특허를 제도적으로 채택한 최초의 국가는 베니스(베네치아)로서 1474년에 특허법을 제정하였다. 베네치아 특허법은 1550년까지 약 75년간이나 존속하였으며 이후 네덜란드를 거쳐 영국으로 전해져 현재의 특허제도의 기초가 되었다.

31) 특허제도의 기원으로 문헌상 남아있는 최초의 기록으로 볼 수 있는 고대 남부 이탈리아의 그리스 식민도시인 시바리스(sybaris, 720-510 B.C.) 법률은 다른 사람이 더욱 훌륭한 요리를 만드는 노력을 하도록 유인하기 위해서 요리 특허권에 관해서 규정하고 있다. 구체적으로 요리사가 독특하고 훌륭한 요리를 창작한 경우, 그 창작자를 제외하고는 누구도 일 년 동안 그 요리를 만들 수 없도록 하고 있다. 호화로운 생활을 영위하였던 것으로 알려진 시바리스에서는 새로운 요리에 대한 욕구가 강하여 이를 창작한 자에게 특허를 부여하여 요리의 창작을 촉진하고자 하였던 것이다(Giles S. Rich, "The Exclusive Right Since Aristotle", 14 Fed. Cir. B.J. 2004. p.217). 다만 이러한 시바리스의 법률의 진위에 대해서는 논란이 있다(Donald S. Chisum et al., 「Principles of Patent Law, 3rd ed., Foundation Press, 2004. p.7).

II. 영국의 전매조례

영국의 특허제도는 국왕으로부터 신하에게 부여하는 상공업에 관한 독점권에서 유래하고 있다. 16세기 중반, 당시 유럽대륙과 비교하여 공업이 뒤떨어져 있던 영국은 국왕이 이를 진흥시킬 목적으로 대륙기술자가 국내에서 안전하고 자유롭게 영업할 수 있도록 하는 특권의 표시로서 특허장(letters patent)을 부여하였다. 이와 같은 통치권자에 의한 특권은 점차 소금이나 기름 등 생활 필수품에까지 독점권을 부여하게 되는 등 이를 남용하기에 이르렀고, 결국 제임스 1세는 1610년 엘리자베스 1세의 선언 취지를 확인한 은혜의 서(book of bounty)를 공포하였고, 이후 1624년 4월 5일 의회에서 심의·통과된 독점권에 관한 법안인 전매조례(statute of monopolies)를 제가하게 되었다. 전매조례는 왕권 제한의 하나로 특허권 부여 권한을 법으로 규정하면서 왕권과의 타협으로 특허권을 성립시킨 시민항쟁의 결과물이다. 이러한 전매조례는 새로운 발명에 대한 특허 이외의 독점을 금지한다고 하는 점에서 사실상 산업재산권의 보호에 관한 최초의 법령(성문법)으로서 많은 나라가 이를 본받아 오늘날의 특허제도에 이르게 되었다.

III. 우리나라 특허제도의 연혁

청일전쟁과 러일전쟁에서 승리한 일본이 한국을 지배하게 되자 일본이 한국 내에서의 자국의 지식재산권 보호를 요구하여 최초로 체결된 것이 1908년 8월 12일 한국에 있어서 발명·디자인·상표 및 저작권에 관한 한일조약(韓日條約)이다. 이 조약에 의하여 1908년 8월 12일 한국 특허령³²⁾이 공포되어 1908년 8월 16일부터 당시 일본 특허법이 한국에 의용(依用)되었다가 1910년 8월 29일부터 한일병합에 의하여 그나마 명목상 유지되어 오던 한국특허령이 일본 칙령 제336호에 의하여 폐지되었고, 일본의 특허법이 한국에 직접 시행되게 되었다(일본 칙령 제335호). 한편 1945년 8월 15일 일제로부터 해방된 이후 미군정 초기에는 일단 잠정적으로 일제시대의 산업재산권 제도가 그대로 답습되었다. 1946년 10월 15일 미국 특허법 및 일본 특허법을 참고로 한 특허법이 군정법령 제91호로 공포되고 1946년 10월 15일부터 시행되었는데 이것을 우리나라에서 최초로 제정된 이른바 「1946년 특허법」이라 한다. 이후 우리나라에서의 독자적인 특허법의 개정이 이루어졌고 오늘에 이르게 되었다.

32) 동 특허령에 의한 발명특허 제1호는 정인호 씨의 말총모자에 관한 발명이다.

제3장

특허법 일반

제1절 특허법의 특징

제1관 특허법의 성격

I. 산업입법으로서의 성격

특허법의 궁극적인 목적은 기술발전의 촉진을 통하여 산업발전에 이바지함에 있다(法 1). 특허법은 산업발전이라는 목적을 달성하기 위하여 타법(특히 보편성과 항구성을 가지는 소유권 등 물건에 관한 법)과는 달리 국가의 산업정책이나 자국의 기술수준에 따라 영향을 많이 받는 법규범이다.

II. 사적독점보장법으로서의 성격

특허법은 발명의 공개를 조건으로 발명에 대한 독점권을 부여함으로써 영업상·경쟁상 우위를 확보할 수 있도록 하고 있다. 이처럼 일정한 요건을 갖춘 발명에 대하여 특허를 허여하고, 특허권자에게 일정 기간 적극적인 발명의 독점을 인정하고 있다는 점에서 특허법은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 “공정거래법”이라 한다)의 예외법이라고 할 수 있다.³³⁾ 구체적으로 공정거래법 제59조에 의하면 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”라고 규정되어 있다. 다만 이 규정이 경쟁질서의 유지라는 공정거래법의 목적달성을 불가능하게 할 정도로 특허권을 남용하는 행위(지식재산권의 부당한 행사)까지 배제하는 것은 아니다. 「특허권을 남용하는 행위」란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 그 실질이 특허제도의 취지를

33) 다만 특허법에서 규정하고 있는 발명에 대한 특허권에 의한 독점과 전통적인 독점은 차이가 있다. 특허법의 독점은 애초에 존재하지 않던 기술을 새로이 창출한 자에게 그 기술에 대한 공개를 대가로 반대급부로 권리를 보장하는 것이며, 전통적인 독점은 이미 존재하는 이익을 독점권자가 독점하여 다른 자가 그 혜택을 공유할 수 없도록 하는 것이다. 반독점법(anti-trust law)이 상정하는 독점은 완전히 차단하였을 때 공중이 입은 피해는 없고 이익만 있는 반면, 특허의 독점은 완전히 차단하는 경우 새로운 발명의 공개 및 이용이 현저히 제한되어 결과적으로 산업발전을 저해하게 되는 것이다(정차호, “특허의 침해금지권에 대한 ebay 판결”, 지적재산21, 2006년 07월, 52-53면).

벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 해당 특허권의 내용과 아울러 해당 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단하여야 한다.³⁴⁾ 공정거래위원회는 공정거래법 제59조와 관련하여 지식재산권의 행사가 정당한 것인지를 판단하는 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사 지침」을 마련하고 부당한 행사에 해당하는 유형을 예시하고 있다.

III. 혼재적 성격

1. 절차법 및 실체법

1) 특허법은 발명의 완성에서부터 출원·심사·결정·등록 및 심판절차에 대한 절차법으로서의 특성을 갖는 동시에 특허를 받을 수 있는 권리, 특허권의 발생·존속·소멸 등에 관한 내용을 규율하는 실체법으로서의 특성을 함께 갖는다. 특허법은 이 혼재적 특성에 따라 법이 정한 엄격한 방식 및 실체심사를 거쳐 특허권이 확정되고 창설되는 데 반해 물적 소유권은 권리의 확정 절차가 없으며, 저작권 또한 저작물의 창작과 동시에 그 권리가 원시적으로 저작자에게 귀속되고 일정한 사전의 심사 절차를 거칠 필요가 없다는 점에서 구별된다.

2) 절차법의 궁극적인 목적은 법적 안정성의 추구에 있으며, 실체법의 궁극적인 목적은 구체성 타당성의 도모에 있다. 특허법은 절차법적인 특성뿐만 아니라 실체법적인 특성도 가지고 있으므로 법적 안정성과 구체적 타당성이라는 양 가치가 충돌할 때 해결방안이 문제 된다. 이때 특허법의 전반적인 해결방안은 일단 법적 안정성을 우선시하면서 구체적 타당성을 보완하는 형식을 취하고 있다.

2. 사법 및 공법

특허법에는 사법 및 공법의 특성이 혼재한다. 즉 특허법은 발명자 개인에 대한 법률관계를 규율한다는 점에서 기본적으로 사법임과 동시에 국가와 개인 간의 법률관계를 규율한다는 점에서는 공법적인 성격을 갖는다. 한편 특허권의 객체가 특수한 무체재산이므로 일정 범위에서 사법인 민법·상법과 특별법적인 관계를 가지며, 특허에 관한 절차는 당사자뿐만 아니라 그 공익적·산업정책적인 특성에 따라 제3자에게 영향을 미친다는 점에서 형법·행정법·형사소송법·민사소송법 등의 공법과도 일정 범위에서 특별법적 관계를 가진다.

34) 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498.

IV. 국제적 성격

1. 서

특허법의 보호 대상인 발명은 인류 모두의 정신적 활동의 소산으로서 인류공동의 것이다. 그 결과 특허법은 지방적 색채나 민족적 색채가 가장 작은 법률이라 할 수 있다. 이러한 특허 제도의 국제적 성격에 의하여 우리 특허법 역시 파리조약 규정의 대부분을 반영하고 있을 뿐만 아니라 특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원에 관한 규정을 특허법의 체계(제10장)에 포함하고 있다.

2. 조약과 국내법과의 관계

1) 헌법 제6조제1항에서는 “헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법 규는 국내법과 같은 효력을 가진다”라고 규정되어 있다. 그런데 조약의 국내법 체계로의 수용, 즉 「헌법에 의하여 체결·공포」되어 국내법과 같은 효력을 가지기 위해서는 국회의 동의 절차가 필요하며 헌법 제60조제1항에는 국회는 “상호원조에 관한 조약, 안전보장에 관한 조약, 중요한 국제조직에 관한 조약, 우호통상항해조약, 주권의 제약에 관한 조약, 강화조약, 국가나 국민에게 중대한 재정적 부담을 지우는 조약 또는 입법사항에 관한 조약의 체결·비준에 대한 동의권을 가진다”라고 국회의 동의 절차가 필요한 조약을 규정하고 있다.

2) 국회의 비준 동의로 조약이 국내법 체계로 들어오면, 국내법과의 저촉·충돌이 발생했을 때 이를 어떻게 해결할 것인지에 대해서는 상위법 우선의 원칙, 대등한 법 규정 상호 간에는 특별법 우선의 원칙, 후법 우선의 원칙, 국제법 우호적인 해석의 원칙 등이 적용되고 있다.³⁵⁾ 한편 현행 특허법이 조약과 직접적으로 충돌하는 경우는 거의 없으나, 특허법보다 조약에 상세한 내용이 규정된 경우가 있는 경우³⁶⁾ 이를 참조할 필요가 있다.

35) 구법 제26조에서는 “특허에 관하여 조약에 이 법에서 규정한 것과 다른 규정이 있는 경우에는 그 규정에 따른다”라고 하여 조약이 특허법보다 우선한다는 조약(국제법) 우위설의 입장을 취하고 있었다. 그러나 이는 i) 헌법 제6조제1항의 조약의 국내법과 동일시하는 규정에 부합하지 않을뿐더러, ii) 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환」의 이행법과 관련하여, 미국은 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환」이 미국법을 개정하거나 수정하는 것으로 해석될 수 없다고 하는 데 반해, 한국은 제26조에 의하여 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환」이 국내법보다 우위에 있다면 상호주의에 맞지 않기 때문에 2012. 3. 15. 시행된 현행법(법률 제11117호, 2011. 12. 2. 개정)에서는 제26조를 삭제하였다.

36) 예를 들면 특허법 제54조에는 제1국 출원을 특허출원만 규정하고 있으나 파리조약에서는 제1국 출원이 특허, 실용신안, 디자인출원 및 발명자증일 경우도 당사국에 우선권주장출원을 할 수 있도록 규정되어 있어 제1국 출원이 특허출원 이외에 실용신안등록출원 등 다른 형태의 출원인 경우에도 우선권을 인정하고 있다 (지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 1108면).

제2관 특허법과 타법의 관계

I. 헌법·행정법과의 관계

1. 헌법과의 관계

헌법 제22조제2항은 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다”라고 규정하여 헌법이 특허법 제정의 근거가 됨을 분명히 하고 있다.

2. 행정법과의 관계

특허법은 행정법의 일부를 구성하고 있다. 정부조직법에 의한 국무총리 산하의 지식재산처의 조직은 행정조직의 일부이며, 특허출원·심사·등록·심판 등은 특수성은 있으나 행정행위·행정쟁송의 일종이다. 따라서 심사나 심판에 관하여 특허법에 특별한 규정이 없는 한 일반 행정법의 원리가 적용된다고 할 것이다.

II. 민법·형법과의 관계

1. 민법과의 관계

특허법은 일반사법인 민법에 대하여 특별법적 지위에 있으므로, 특허법에 규정이 없는 경우에 민법이 보충적으로 적용된다. 특허권의 보호대상인 발명이 무체재산이므로 민법의 규정을 그대로 적용하기에는 적합하지 아니한 것도 있으나, 민법이 특허법에 적용되는 범위는 민법의 기본원칙을 비롯하여 총칙·물권·채권·친족·상속에 걸쳐 매우 광범위하며, 양 법은 그와 같은 범위에서 특별법과 일반법으로서의 관계를 가지고 있다.

2. 형법과의 관계

특허법은 여러 가지 형벌규정을 두고 있는데(제12장) 이 규정들은 형법에 대한 특별규정이다. 형법에 관하여 특허법에 특별규정을 둔 것은 보호대상이 무체재산이라는 특수성 때문이다. 그러나 이 경우에도 형법 총칙규정이 보충적으로 적용된다(刑法 8).

III. 민사소송법·형사소송법과의 관계

1. 민사소송법과의 관계

민사소송법 중 절차적 규정은 특허법 중 절차에 관한 규정에 많이 준용되고 있다. 대리인에 관한 규정(法 12), 재외자의 재판관할(法 13), 심리조서(法 154), 증거조사 및 증거보전(法

157), 재심의 청구(法 178) 등이 그것이다. 따라서 민사소송법이 절차에 관한 일반법이라면 특허법 중의 절차에 관한 규정은 절차에 관한 특별법이라 할 수 있다.

2. 형사소송법과의 관계

변리사 등이 업무상 위탁을 받은 관계로 알게 된 사실로서 타인의 비밀에 관한 것은 증언을 거부할 수 있다(刑訴法 149).

제2절 특허법의 구성

1) 특허법에 관하여 가장 중요한 성문법원으로서는 법률의 형식으로 규정된 「특허법」이 있고, 그 이외에 대통령령으로 된 「특허법 시행령」과 총리령인 「특허법 시행규칙」이 특허법의 하위 법령으로서 존재한다. 그 밖의 특허법령으로서 대통령령인 「특허권의 수용·실시 등에 관한 규정」과 「특허권 등의 등록령」이 있으며, 총리령인 「특허권 등의 등록령시행규칙」과 「특허료 등의 징수규칙」 등이 있다. 특히 특허법은 산업재산권 4법 중에서 가장 기본이 되는 법으로서 실용신안법, 디자인보호법, 상표법은 특허법의 규정을 다수 준용하고 있다.

2) 특허법의 내용은 i) 제1장 총칙(法 1-28의5), ii) 제2장 특허요건 및 특허출원(法 29-56), iii) 제3장 심사(法 57-78), iv) 제4장 특허료 및 특허등록 등(法 79-86), v) 제5장 특허권(法 87-125의2), vi) 제6장 특허권자의 보호(法 126-132), vii) 제6장의2 특허취소신청(法 132의2-132의15), viii) 제7장 심판(法 132의16-176), ix) 제8장 재심(法 178-185), x) 제9장 소송(法 186-191의2), xi) 제10장 특허협력조약에 의한 국제출원(法 192-214), xii) 제11장 보칙(法 215-224의5) 및 xiii) 제12장 벌칙(法 225-232)으로 이루어져 있다.

【표 1-2】 지식재산법 체계도

헌법	법 률	대통령령	부 령
제 22 조 발 명 보 호	지식재산 기본법	◦ 지식재산 기본법 시행령	
	특허법	◦ 특허법 시행령 ◦ 특허권 등의 등록령 ◦ 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정	◦ 특허법 시행규칙 ◦ 특허권 등의 등록령 시행규칙 ◦ 특허료 등의 징수규칙
	실용신안법	◦ 실용신안법 시행령 ◦ 특허권 등의 등록령	◦ 실용신안법 시행규칙 ◦ 특허권 등의 등록령 시행규칙
	디자인보호법	◦ 디자인보호법 시행령 ◦ 특허권 등의 등록령	◦ 디자인보호법 시행규칙 ◦ 특허권 등의 등록령 시행규칙
	상표법	◦ 상표법 시행령 ◦ 특허권 등의 등록령	◦ 상표법시행규칙 ◦ 특허권 등의 등록령 시행규칙
	발명진흥법	◦ 발명진흥법시행령 ◦ 공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정	◦ 공무원직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정 시행규칙
	부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률	◦ 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 시행령	
	반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률	◦ 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 시행령	◦ 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 시행규칙
	변리사법	◦ 변리사법시행령	◦ 변리사법시행규칙
	정부조직법	◦ 지식재산처와 그 소속기관 직제	◦ 지식재산처와 그 소속기관 직제 시행규칙
	국제조약	◦ 세계 지식재산기구(WIPO) 설립 협약 ◦ 특허협력조약 (PCT) ◦ 상표법 조약 ◦ 상표법 조약 규칙 ◦ 무역 관련 지적재산권에 관한 협정 ◦ 국제특허 분류에 관한 스트라스부르그 협정 ◦ 공업소유권의 보호를 위한 파리 협약 ◦ 특허절차상 미생물기타의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약 ◦ 표장의 국제 등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서 ◦ 표장의 등록을 위한 상품 및 서비스의 국제분류에 관한 니스 협정	

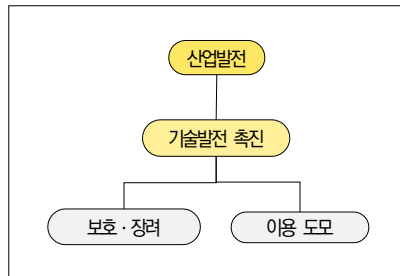
제3절 특허법의 목적

제1조【목적】

이 법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다. [전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 그 목적으로 한다(法 1). 즉 특허법은 발명의 보호·장려라는 사익적 측면과 제3자의 이용 도모라는 공익적 측면의 조화를 통해 기술발전을 촉진하고, 그 결과 산업발전에 이바지하고자 한다. 특허법의 목적을 규정하고 있는 제1조 이외의 나머지 규정들은 특허법의 목적을 달성하기 위해 존재한다고 할 수 있다. 따라서 제1조의 특허법 목적은 모든 조문의 해석기준이 되며, 나머지 규정들이 서로 충돌할 때는 제1조에 부합하게 해석하여야 한다.



【그림 1-2】 특허법 목적의 개념도

II. 발명의 보호

1. 실체적 보호

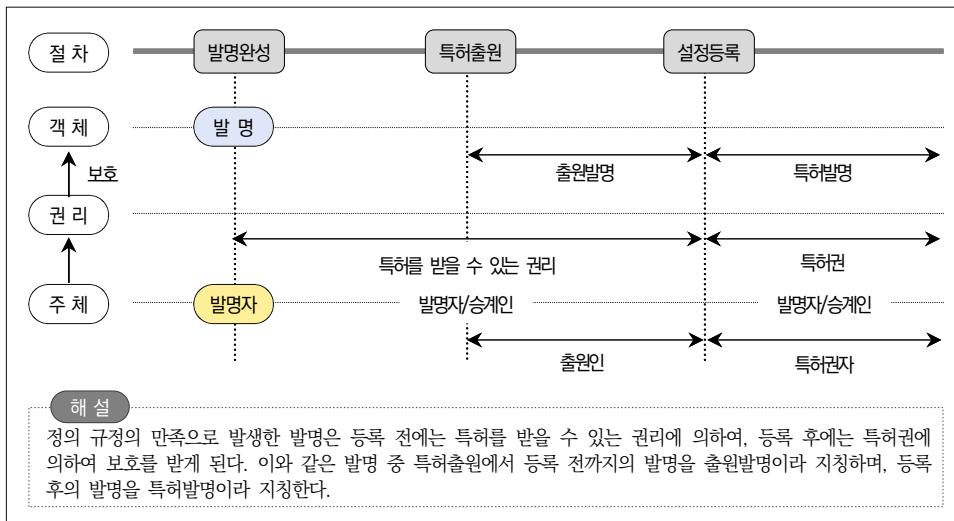
(1) 특허를 받을 수 있는 권리에 의한 보호

1) 완성된 발명은 특허를 받을 수 있는 권리에 의한 보호를 받을 수 있다. 구체적으로 발명자는 특허를 받을 수 있는 권리에 의하여 i) 특허출원 전에는 국가에 대하여 특허부여를 요구하는 특허부여청구권과 발명에 대한 일정한 이익 상태를 지배하는 발명자권을 가지게 되며, ii) 특허출원 후에는 출원공개시 제3자의 실시에 의한 불이익을 보전하기 위하여 보상금청구권을 인정받을 수 있다.

2) 발명을 특허권으로 보호받을 것인지 아니면 영업비밀로 보호받을 것인지는 발명자의 자유로운 선택이나 특허권으로 보호받지 않을지라도 i) 선사용권(法 103), ii) 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ)과 같은 규정에 의하여 특허법상 발명에 대하여 최소한도의 보호가 이루어진다.

(2) 특허권에 의한 보호

특허출원하여 설정등록되면 발명은 특허권이라는 독점·배타권의 보호를 받는다. 따라서 정당한 권원 없이 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로 실시하면 특허권 침해가 성립되고, 특허권자는 이에 대하여 민사상 침해금지청구권(法 126), 손해배상청구권(法 128) 및 신용회복청구권(法 131) 등을 행사할 수 있으며, 형사상 고의가 있는 경우 침해죄(法 225)를 물을 수 있다.



【그림 1-3】 발명의 실체적 보호

2. 절차적 보호

1) 출원인은 특허출원·심사·특허결정·설정등록 절차를 거쳐서 비로소 특허권을 취득하게 된다. 이 과정에서 출원인의 권리취득 편의를 위해 특허법은 i) 특허출원 전에 공지 등에 의하여 신규성 또는 진보성을 상실된 발명을 보호하기 위한 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30)에 관하여 규정하고 있으며, ii) 특허출원 후 단계에서는 출원에 대한 보정제도(法 46, 47, 51), 분할출원(法 52), 분리출원(法 52의2), 변경출원(法 53), 조약우선권주장출원(法 54) 및 국내우선권주장출원(法 55, 56)을 규정하여 출원일 또는 판단시점의 소급효를 인정함으로써 발명을 보호하고 있고, iii)

심사단계에서는 우선심사제도(法 61) 및 신청에 의한 출원공개제도(法 64, 65) 등을 규정하여 권리화에 필요한 절차의 신속한 진행 및 권리구제를 인정하고 있다.

2) 또한 특허법은 iv) 지식재산처의 최종적 행정처분인 특허거절결정에 불복할 때는 재심사 청구(法 67의2), 거절결정에 대한 심판(法 132의17)을 청구할 수 있도록 하고 있으며, v) 등록 후 정정심판(法 136) 청구와 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판 중에 특허의 정정(法 132의3, 133의2, 137③④) 청구를 인정하여 대응하도록 하고 있다.

【표 1-3】 발명의 보호

구 분	출원 전 보호	출원 후 설정등록 전 보호	설정등록 후 보호
실제적	특허를 받을 수 있는 권리(法 33, 37, 38)		특허권(法 94)
	1. 선사용권(法 103) 2. 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ)	보상금청구권(法 65)	
절차적	공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30)	1. 보정(法 46, 47, 51) 2. 분할출원(法 52) 3. 분리출원(法 52의2) 4. 변경출원(法 53) 5. 조약우선권(法 54) 6. 국내우선권(法 55, 56) 7. 각종 불복 8. 거절이유의 법정(法 62)	1. 특허의 정정(法 132의3, 133의2, 137) 2. 특허정정심판(法 136)

Ⅲ. 발명의 이용

1. 의 의

발명의 「이용」은 「발명의 공개」와 「발명의 실시」라는 의미를 지니고 있다. 발명이 이용된다는 것은 그 발명이 공개되어 일반 공중에게 발명의 존재를 알고 동일발명의 중복연구를 피함과 동시에 그 공개된 발명을 기초로 하여 개량된 발명을 할 수 있도록 하고, 또한 발명을 적극적으로 실시하여 발명자가 이익을 얻음과 동시에 실시된 발명이 사회의 기술발전에 사용되도록 함을 의미한다.³⁷⁾

2. 공개에 의한 이용

(1) 기술문헌으로 이용

특허출원일로부터 1년 6개월이 지난 후 그 출원발명을 일반 공중에게 공개하여 중복투자 및 중복연구를 방지하고, 일반 공중이 기술문헌으로 활용할 수 있도록 함으로써 개량된 기술을 개발하도록 유도하고 있다(法 64).

37) 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 49면.

(2) 발명의 설명 기재요건의 법정화

명세서의 기재사항 중 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재하도록 규정함으로써(法 42③ I). 발명의 설명이 출원공개된 경우에 기술문헌적인 역할을 하도록 하고 있다.

3. 실시예 의한 이용

(1) 특허권자의 실시

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(法 94①). 따라서 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로 실시하면 특허권의 침해를 구성하게 되고, 특허권자는 특허권의 침해에 대하여 민·형사적 제재를 할 수 있다. 한편 특허권자의 실시는 특허권자의 의무이기도 하므로 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나 불충분하게 실시할 때는 재정에 의한 강제실시권(法 107)을 제3자에게 허락하여, 제3자가 특허발명을 실시하도록 하는 제재를 가하고 있다.

(2) 제3자의 실시

실시권 등의 정당한 권원이 있는 경우, 특허권 존속기간의 만료, 특허권 포기 등으로 인해 특허권이 소멸한 경우나 연구 또는 시험을 위한 실시의 경우 등 제3자는 특허권의 침해가 되지 않거나 특허권의 권리행사가 인정되지 아니한 범위 내에서 그 특허발명을 자유롭게 실시할 수 있다.

IV. 발명의 장려

출원인에 대한 특허권의 부여와 절차상·실체상의 보호는 결과적으로 출원인 본인은 물론 관련 기술분야의 타인에게도 발명의욕을 고취하게 한다. 특허법은 발명의 장려를 위하여 학생이나 개인발명 및 중소기업의 발명 등에 대해서는 수수료 및 특허료 등을 면제하거나 감면해 주고 있다(法 83). 또한 발명진흥법은 발명진흥보조금의 지급을 규정하고 있는 한편³⁸⁾ 우수발명의 발굴 포상과 사업화 지원제도 등을 두고 있으며, 벤처기업에 대해서 발명 및 출원의 장려를 위해 여러 가지 혜택을 주고 있다.

38) 기존에는 발명진흥보조금의 지급과 관련하여 특허법 제27조에서 규정하고 있었으나, 2001. 7. 1. 시행된 현행법(법률 제6411호, 2001. 2. 3. 개정)에서는 제27조를 삭제하고, 다음과 같이 발명진흥법 제4조에서 그 내용을 규정하고 있다.

발명진흥법 제4조[발명진흥보조금의 지급 등] ① 정부는 발명 진흥을 위하여 예산의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 보조금을 지급할 수 있다. <개정 2013.7.30.>

1. 발명자와 그 승계인(承繼人)

2. 발명의 연구나 진흥사업을 수행하는 개인 또는 단체

② 제1항에 따른 보조금의 지급대상 사업, 교부신청 및 관리 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2013.7.30.>

V. 산업발전

앞에서 살펴본 바와 같이 발명의 보호·장려 및 발명의 이용은 특허제도의 두 중심축이라고 할 수는 있으나 이를 특허법의 궁극적인 목적이라고 할 수는 없다. 이들은 목적달성을 위한 수단에 불과하며 특허법의 궁극적인 목적은 발명의 보호·장려 및 발명의 이용을 통하여 기술의 발전을 촉진하고 이로 인해 산업을 발전시키려는 데 있다.

제4절 특허법의 기본원칙

각국은 자국의 국가산업발전이라는 국익을 위해 산업발전 정도에 따라 특허제도를 상이하게 운용하고 있다. 따라서 특허를 누구에게 줄 것인지, 어떤 발명에 대하여 특허를 줄 것인지, 어떠한 절차를 밟아야 하는지 등 구체적인 사항은 국가별로 서로 차이가 있다. 우리나라 특허법은 i) 권리의 발생요건으로는 등록주의를 채택하고 있으며, ii) 등록의 전제로서 심사주의를 취하고 있다. 나아가 iii) 동일발명에 대하여 출원이 경합하였을 때 선출원주의에 의하여 선출원자에게 특허를 부여하며, iv) 특허에 관한 절차에 대해서는 직권주의를 원칙으로 하고 있다. 그 밖에도 v) 서면주의, 도달주의, 수수료 납부주의 등 여러 원칙을 채택하고 있으며, 이에 대해서는 각각 해당하는 부분에서 상세하게 설명하기로 한다.

【표 1-4】 특허법상 諸 원칙

구 분		내 용
출원 절차	권리주의	특허법상 보호의 가치가 있는 발명의 실체는 이미 출원 전에 존재하였으며 국가는 제도상 이를 확인하여 보호하는데 지나지 아니한다는 뜻으로서 은혜주의와 대립하는 개념임
	도달주의	1. 원칙 도달주의(法 28①) 2. 예외 등기우편으로 서류를 제출할 때는 발신주의(法 28②본문) 3. 예외의 예외 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류나 국제출원서류는 예외없이 도달주의(法 28②단서)
	수수료 납부주의	특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 내야 함(法 82①). 수수료를 불납한 경우에는 보정명령의 대상(法 46)이고, 이에 불응 시 그 절차를 무효로 할 수 있음(法 16①)
	1건 1통주의	1. 원칙 지식재산처에 제출하는 서류는 1건마다 1통씩 작성(施規 2) 2. 예외 특허에 관한 절차를 밟는 자가 2이상의 절차를 동시에 또는 순차적으로 밟을 때에 증명서의 내용이 동일한 경우에는 하나의 절차 또는 먼저 밟은 절차에 대하여만 증명서의 원본을 제출하고, 나머지 절차 또는 이후에 밟는 절차에는 서류를 원용하여 증명서의 사본을 제출하거나 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 기재함으로써 그 증명서를 갈음(施規 10)
심사 절차	심사주의	1. 특허를 받기 위한 특허요건 전부를 심사하여 특허를 부여하는 심사주의를 채택함 2. 다만 심사청구제도와 출원공개제도를 가미하여 전통적 심사주의의 폐해를 보완함
	선출원주의	동일발명이나 고안에 대하여 둘 이상의 출원이 있는 경우에는 먼저 출원한 자에게만 특허를 부여하는 것으로서 선발명주의와 구별되는 개념임
	보정 및 보정제한주의	보정을 통해 명세서 등의 미비점을 적절하게 치유할 기회를 부여함으로써 출원인을 보호함과 동시에, 심사지연과 제3자의 불이익을 방지하기 위해 보정의 내용 및 시기적 측면에서 일정한 제한을 두고 있음
	공개주의	출원일 후 1년 6개월이 지나거나 그 이전이라도 출원인의 신청이 있으면 그 출원발명의 내용을 일반에 공표함으로써 제3자가 이를 기술정보로서 이용하여 중복투자 및 연구를 방지할 수 있도록 함
등록 절차	등록주의	특허권의 보호 및 효력발생의 요건으로서 행정청의 설정등록이 필요한지 여부에 따라 등록주의와 무등록주의로 구분됨. 특허권의 존재 여부 및 그 범위의 명확화를 위하여 각국은 대체로 등록주의를 채택하고 있으며, 우리 특허법도 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정함(法 87①)
	특허료 납부주의	특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자는 특허료를 내야 함(法 79). 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 낸 특허료에 해당하는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸한 것으로 간주함(法 81③).
기타	서면주의 등	1. 서면주의 ① 특허출원서나 그 밖의 제반서류는 서면 또는 전자문서로 작성하여 제출하여야 함 ② 다만 쉽게 입수할 수 없는 미생물을 출원하는 경우 미생물을 출원 전 기탁하여야 함 2. 양식주의(요식주의) 법령이 정하는 일정한 양식에 따라야 함 3. 국어주의 i) 외국어특허출원, ii) 위임장, 국적증명서 및 우선권증명서류를 제외하고는 국어로 적어 제출해야 함(施規 4)
	직권주의	절차의 개시와 심판의 대상 특정에 있어서는 당사자주의에 의하지만, 심리나 그 밖의 제반 절차에서는 특허권의 대세효 및 특허제도의 공익성 등을 이유로 직권주의에 의함

제4장

발명

제1절 발명의 성립성

제2조 [정의]

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 10., 2025. 1. 21.>

1. “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.
2. “특허발명”이란 특허를 받은 발명을 말한다.
3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.
 - 가. 물건의 발명인 경우 : 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위
 - 나. 방법의 발명인 경우 : 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위
 - 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 : 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서설

1. 의의

「발명」이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다(法 2 I). 즉 특허법상 발명이 되기 위해서는 i) 자연법칙을 이용한 것이어야 하고, ii) 기술적 사상이어야 하고, iii) 창작이어야 하며, iv) 그 창작의 정도가 고도한 것이어야 한다.

2. 정의 규정을 둔 취지

어떠한 기술적 창작을 특허법상 보호되어야 할 발명으로 볼 것이냐는 각국의 산업정책적 견해나 기술수준에 따라 정해지고 있으며, 발명의 정의를 특허법에 규정할 것인가 아니면 학설이나 판례에 위임할 것인가는 입법정책적인 문제라고 할 수 있다. 우리 특허법은 보호하는 대상을 명확히 하는 한편 법 적용상의 편리성 및 예측가능성을 증가시키기 위하여 발명의 정의 규정(法 2 I)을 두고 있다. 그러나 고정된 정의 규정을 특허법의 테두리 안에 두면서 엄격히 적용하는 것은 경제·사회 또는 문화의 변화나 과학기술의 발전에 따라 새로이 탄생되는 발명을 폭넓게 수용할 수 없다는 문제가 있다. 따라서 발명의 정의 규정은 탄력적으로 해석됨이 바람직할 것이다.³⁹⁾

【표 1-5】 발명 정의 규정의 필요성

구 분	정의 규정의 존재	정의 규정의 부존재
예측가능성 (법적 안정성)	○	×
새로운 발명 수용 (구체적 타당성)	×	○
특허법의 태도	1. 법적 안정성을 위해 정의 규정을 두고 있음(法 21) 2. 단점을 보완하여 정의 규정을 탄력적으로 해석 ① 컴퓨터 프로그램 관련 발명(자연법칙을 전체적으로 이용하지 아니하지만, 시대적 흐름에 부응하고자 예외적으로 발명의 성립성 인정) ② 식물발명(일정한 확실성 및 반복가능성이 문제가 되며, 육종경과를 상세히 적으면 발명의 성립성 인정) ③ 미생물 발명(일정한 확실성 및 반복가능성이 문제가 되며, 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 없는 경우 기탁을 통해 이를 보완) ④ 용도발명(발견이지만 물질로부터 새로운 용도를 발견하고 이를 새로운 용도로 이용하는 과정에서 존재하는 창작적 요소가 보호할 가치가 있으므로 예외적으로 발명의 성립성 인정)	

II. 발명의 성립성의 내용

1. 자연법칙의 이용

(1) 자연법칙

1) 「자연법칙」이란 사람의 감성·사고력이나 그 밖의 정신적 기능을 제외한 자연계에 존재하는 원리·원칙으로서 뉴턴의 만유인력의 법칙, 가속도의 법칙과 같이 과학상의 법칙 이외에 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른대거나 통나무가 물에 뜨는 것과 같은 경험칙도 포함된다.

2) 발명은 자연법칙을 이용하여야 하므로 자연법칙 자체는 발명이 아니다. 자연법칙은 만들어진 것이 아니라 원래부터 존재하던 것이므로 발견의 대상이 될 뿐이다. 한편 자연법칙에 반하는 영구운동장치 역시 발명의 대상이 될 수 없다.

(2) 자연법칙의 이용

① 전체로서 이용

발명은 자연법칙을 전체로서 이용하여야 한다. 발명을 이루는 구성요소 중 일부라도 자연법칙을 이용하지 아니한 부분이 있는 것은 특허법상 자연법칙의 이용이라 할 수 없다.⁴⁰⁾ 다만 후술하는 컴퓨터 프로그램 관련 발명과 같이 자연법칙의 전체적 이용은 실무상 엄격히 적용하지 않고 있다.

39) 세계적으로 특허법에서 발명의 정의 규정을 두고 있는 예는 드물며, 미국에서처럼 “발명이란 발명과 발견을 말한다”와 같이 형식적으로는 정의 규정을 두고 있으나 실질적으로는 그 내용이 정의되어 있지 아니한 경우도 있다.

40) 특허법원 2006. 12. 21. 선고 2005허11094; 2007. 6. 27. 선고 2006허8910 등.

② 일정한 확실성 및 반복가능성

그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(통상의 기술자)의 수준에서 발명은 일정한 확실성을 가지고 동일결과를 반복할 가능성이 있어야 한다.⁴¹⁾ 다만 이러한 확실성 또는 반복가능성은 일정 수준이면 충분하고 항상 100%일 필요는 없다.⁴²⁾ 오히려 개척(원천)발명일 수록 그 확실성이 낮은 경우가 많을 것이다.

③ 인식 不要

발명자가 자연법칙에 대하여 반드시 정확하고 완전한 인식을 가질 필요는 없다. 즉 발명자는 자연법칙을 결과로써 이용하여 경험상 그가 의도하는 기술적인 실현가능성에 대한 인식만 있으면 충분하다. 예를 들어 물이 위에서 아래로 떨어지는 성질을 이용하여 물레방아를 발명하였을 때 발명자가 물이 위에서 아래로 떨어지는 성질이 중력에 의한 것이라는 정확한 인식을 가질 필요는 없다.

2. 기술적 사상

1) 「기술」이란 일정한 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로서 실제 이용할 수 있는 것을 의미한다. 또한 기술은 구체성 이외에 제3자에게 그대로 전달될 수 있는 객관성이 있어야 하며, 이러한 측면에서 기능 또는 기예⁴³⁾와 구별된다.⁴⁴⁾

2) 「사상」이란 추상적이고 개념적인 착상을 말하는 것으로서 특허법상 발명은 반드시 기술일 필요는 없으며 기술적 사상이면 된다. 즉 발명은 기술과 같이 현실적으로 구체성을 띤 것이 아니라 장차 기술로서 실현가능성이 있으면 된다. 기술과 기술적 사상의 구별 실익은 i) 특허법상 보호범위가 기술 자체로 제한되는 것이 아니라 기술적 사상에까지 최대한 넓게 미친다는 점과, ii) 특허대상이 구체적인 물건에 한정되는 것이 아니라 추상적인 물질·방법·용도도 포함된다는 데에 있다.

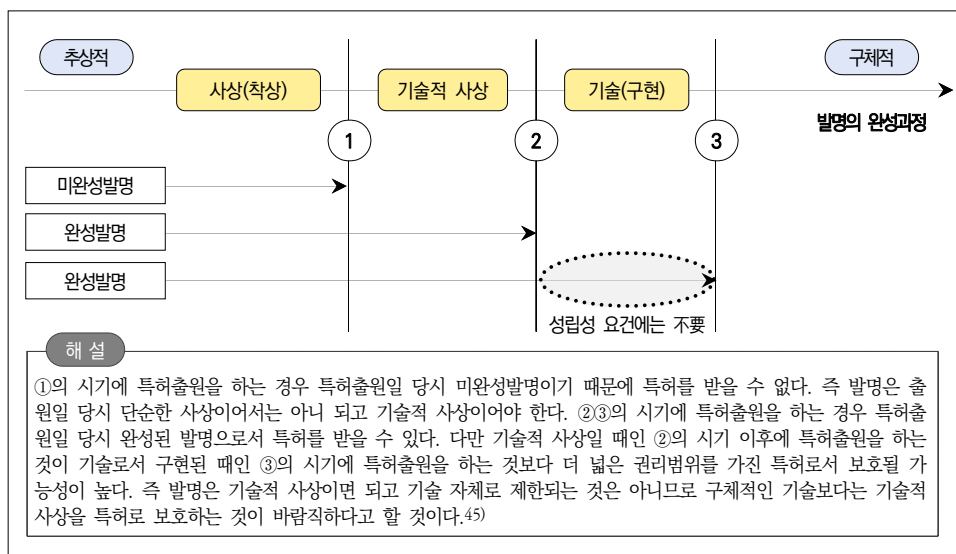
3) 발명은 「기술적 사상」이므로 발명의 본질은 형체(形體)일 수 없으며, 비록 발명을 유형물로 구체화한다고 하더라도 형체 내에 존재하는 무형(無形)의 개념으로 이해하여야 한다.

41) 특허발명은 학습만화(마법천자문)에 관한 것으로 그 기술분야는 만화 및 애니메이션 산업분야라 할 것이므로, 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이라면 특허발명에 개시된 기술적 수단을 이용하여 특허발명을 쉽게 반복실시할 수 있을 것으로 보이고, 발명의 실시자에 따라 그 효과에 있어서 어느 정도의 차이가 발생할 수 있음은 이 특허발명의 경우뿐만 아니라 다른 발명의 경우에도 마찬가지라 할 것이고, 특허발명에 반복재현성이 있는지 여부를 판단함에 있어 발명의 실시자를 특허발명이 속하는 기술분야인 만화 및 애니메이션 산업분야의 통상의 기술자로 보아야 할 것인 점에 비추어 보면, 발명의 실시자에 따라 특허발명의 반복실시가 어렵다고 할 정도로 그 효과가 달라진다고 볼 수 없다(특허법원 2009. 10. 16. 선고 2009허351).

42) 특허법원 2001. 12. 20. 선고 2000허7748.

43) 악기연주방법, 투구방법 등을 예로 들 수 있다.

44) 오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법은 사람의 행위가 주요 구성요소로 되어 있는 것으로서 이를 시행하는 각 개인의 숙련도에 의해서 달라질 수 있는 일종의 기능에 해당하는 성질을 가지므로, 이 사건 특허출원의 명세서 기재만으로는 통상의 기술자가 이를 반복하여 재현할 수 있다고 볼 수 없다(특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허4501).



【그림 1-4】 기술적 사상의 의미

3. 창작성

1) 발명은 인간의 인위적인 정신활동에 의하여 「만들어진 것」이어야 하며, 이러한 측면에서 발견과 구별된다.⁴⁶⁾ 발견은 이전부터 이미 존재한 것을 찾아내는 것인데 반해 발명은 이전에는 없던 새로운 것을 만들어 내는 것이라는 점에서 양자는 본질적으로 다르다. 예를 들어 번개에 전기적 성질이 있다는 것을 찾아내는 것은 발견이지만, 낙뢰를 피하려고 피뢰침을 만들어 내는 것은 발명이다.

2) 창작성에 대하여 종래에 있었던 것인지 또는 어느 정도 개량되었는지를 따지는 것은 실익이 없다. 그와 같은 문제는 특허부여의 요건인 신규성과 진보성으로서 심사되는 것인바, 새로운 것을 포함하지 않더라도 발명자가 창작한 것이라면 발명으로 취급한다. 즉 창작성은 어떤 창작물을 모사(copy)하지 아니하면 인정되는 상대적인 개념이고, 신규성과 진보성은 모사 여부와는 관계없이 출원 시를 기준으로 새로운 것인지에 대한 절대적인 개념이다.⁴⁷⁾

45) 물론 강력한 특허 장벽(특히 포트폴리오)을 구축하기 위해서는 기술적 사상과 기술에 해당하는 발명 모두를 특허로 보호하여야 한다.

46) 발명 'invention'의 어원인 라틴어의 'inventio'는 생각이 떠오르다는 의미를 가지고 있다.

47) 박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002, 146면.

4. 고도성

「고도성」이란 기술적 사상의 창작으로서 그 수준이 높아야 함을 의미한다. 특허법이 발명의 개념을 정의하면서 고도성을 드는 것은 실용신안의 고안과 구별하기 위한 것으로 기술적 사상의 창작 중 비교적 기술의 정도가 높은 것은 발명으로, 그렇지 못한 것은 고안으로 본다는 취지이다.⁴⁸⁾ 고도성의 판단 주체는 발명자이고, 심사관은 발명의 성립성에서 고도성을 판단하지 아니한다. 발명자는 자신의 발명이 고도성이 없다고 판단하는 경우뿐만 아니라 고도성이 있다는 판단에도 불구하고 쉽게 등록받기 위하여 실용신안으로 출원할 수 있다. 이는 실용신안법에서 등록요건인 진보성을 적용할 때 특허법보다 더 낮은 수준을 요구하고 있기 때문이다.

Ⅲ. 발명의 성립성의 판단

1. 주체적 기준

심사단계에서는 심사관이, 심판단계에서는 심판관 합의체가, 법원에서는 법관이 심사한다.

2. 객체적 기준

발명이 완성되었는지는 청구범위를 기준으로 청구항별로 출원 당시의 기술수준에 따라 발명의 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 작용효과 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시예에 한정되어 인정되는 것은 아니다.

3. 시기적 기준

(1) 원 칙

특허법은 발명의 성립성의 판단시기에 대하여 명문의 규정을 두고 있지 않다. 이론적으로는 특허를 받을 수 있는 권리가 발명의 완성에 의하여 발생하기 때문에 발명의 완성 시를 기준으로 발명의 성립성을 판단하는 것이 타당해 보이나 실무는 판단의 어려움으로 인해 특허출원 시를 기준으로 판단하고 있다.⁴⁹⁾

(2) 예 외

i) 무권리자에 대한 정당한 권리자 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ii) 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, iii) 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, iv) 국제특허출원의 경우 우선일의 출원 시를 기준으로 판단한다.

48) 대법원 1983. 11. 22. 선고 83후42 등.

49) 대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810 참조.

4. 발명의 성립성이 없는 예

(1) 의 의

통상의 기술자가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다.⁵⁰⁾ 발명의 성립성이 없는 발명, 소위 불성립발명으로는 출원 시점에서 제2조제1호에서 규정하는 발명의 정의 규정에 위반된 「비(非)발명」과 아이디어인 사상을 기술로써 구체화하지 못한 「미완성발명」이 있다. 미완성발명은 장래에 구체성을 갖추는 경우 완성된 발명이 될 수 있다는 점에서 비발명과 구별된다.

(2) 비발명⁵¹⁾

① 자연법칙 그 자체(자연법칙의 이용 위반)

자연법칙 자체는 이미 자연계에 존재하는 법칙이고 발명은 이 자연계에 존재하는 법칙, 즉 자연법칙을 이용하여 주어진 과제를 해결하기 위한 기술적 사상을 창작하는 것이므로 만유인력의 법칙이나 가속도의 법칙, 열역학의 법칙, 에너지 보존의 법칙 등과 같은 자연법칙 그 자체는 발명에 해당되지 아니한다.

② 자연법칙에 위반된 것(자연법칙의 이용 위반)

발명은 자연법칙을 이용한 것이어야 하므로 영구운동의 기계장치나 영구발동기 등과 같이 자연법칙에 위반되는 것⁵²⁾은 발명에 해당되지 아니한다. 이 경우 청구항에 기재된 구성 일부에라도 자연법칙에 위반되는 부분이 있으면 발명에 해당되지 아니한다.

③ 자연법칙을 이용하지 아니한 것(자연법칙의 이용 위반)

1) 청구항에 기재된 발명이 자연법칙 이외의 법칙(경제법칙, 수학공식, 논리학적 법칙, 작도법 등), 인위적인 약속(게임의 규칙 등),⁵³⁾ 또는 인간의 정신활동(영업계획, 금융방법 그 자체 등)을 이용하고

50) 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 참조.

51) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3102-3106면.

52) 양수조로부터 급수조로 낙하하는 물을 이용하여 수력발전기를 돌려 에너지를 얻고, 급수조에 낙하된 물을 다시 제네바 기어장치, 노즐회전관 및 복수의 공기실을 이용한 연속적인 수격작용(水擊作用)에 의하여 폐수되는 물이 없이 전량을 양수조로 끌어 올려서 재순환시킴으로써 계속적인 에너지 추출이 가능하도록 하는 것을 요지로 하는 출원발명은 일정한 위치에너지로 유지되는 수조의 물을 수격작용에 의하여 그 수조의 물의 자유표면보다 일정 높이 위에 위치한 수조로 끌어 올리는 공지된 양수펌프에서와 같이 수조로부터 낙하되는 물의 상당 부분을 폐수하고 남은 일부분의 물만을 높은 위치의 수조로 양수하는 것이 아니라, 외부의 에너지 공급 없이 급수조에서 낙하하는 물 전부를 폐수되는 물이 없이 보다 높은 위치의 양수조로 끌어 올린다는 것이 되어 에너지 보존 법칙에 위배되므로, 출원발명은 자연법칙에 어긋나는 발명으로서 특허법 제29조제1항 본문에서 규정한 발명의 요건을 충족하지 못한다(대법원 1998. 9. 4. 선고 98후744).

53) 문제가 된 청구항은 「외국어 발음표기 문자를 형성하는 방법에 있어서, 문제에 대한 한글과 외국어의 발음상의 차이에 의하여 표기시에 차이가 생기는 문자들의 표시를 위하여 그 문자의 발음시에 형성되는 사람의 목구멍의 형상과 혀소리가 발음상 변화를 일으키는 현상과 이에 따른 입술모양에 따라서 문자를 변형시켜서 형성하는 것을 특징으로 하는 외국어 발음표기 문자의 형성방법」으로서 이와 같은 외국어 발음표기문자의 형성방법은 인위적인 약속에 지나지 않기 때문에 자연법칙을 이용한 것이 아니다(특허법원 2002. 1. 17. 선고 2001허3453).

있는 경우에는 발명에 해당되지 아니한다. 다만 논리적인 법칙이나 수학적 원리 그 자체 또는 이를 직접적으로 이용하는 방법에 대하여 특허를 청구하는 것이 아니고, 수학적 연산을 통하여 변환되는 데이터를 이용하여 특정한 기술수단의 성능을 높인다거나 제어함으로써 유용하고 구체적이고 실용적인 결과를 얻을 수 있는 기술적인 장치 또는 방법으로 청구할 때는 그와 같은 장치나 방법이 특정한 목적을 달성하기 위한 합리적인 수단으로서 보편성과 반복성 및 객관성을 갖는 것이라면 발명으로 취급된다.

2) 특허법상의 발명에 해당하기 위한 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로 판단하여야 한다. 따라서 청구항에 기재된 발명 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있어도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때는 특허법상의 발명에 해당하지 아니하고, 반대로 청구항에 기재된 발명 일부에 자연법칙을 이용하고 있지 아니한 부분(예: 수학적 공식 등)이 있어도 청구항을 전체로 파악했을 때 자연법칙을 이용하고 있다고 판단될 때는 특허법상의 발명에 해당한다.

3) 청구항에 기재된 발명 일부에 자연법칙을 이용하는 부분이 있어도 발명의 일부 구성이 비과학적인 행위를 구성요소로 하고 있어 발명의 주목적이나 효과가 사회통념을 벗어나는 비상식적이면 청구항 전체로서는 자연법칙을 이용하지 않는 발명에 해당한다.⁵⁴⁾

④ 컴퓨터 프로그램 언어 자체, 컴퓨터 프로그램 자체(자연법칙의 이용 위반)

컴퓨터 프로그램은 컴퓨터를 실행하는 명령에 불과한 것으로 컴퓨터 프로그램 자체는 발명이 될 수 없다. 다만 컴퓨터 프로그램에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현될 때는 해당 프로그램과 연동해 동작하는 정보처리장치(기계), 그 동작 방법, 해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체 또는 매체에 저장된 해당 프로그램은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 발명에 해당한다.

⑤ 반복하여 동일한 효과를 얻을 수 없는 것(자연법칙의 이용 위반)

발명의 목적을 달성하기 위한 수단이 형식적으로 제시되어 있으나 그 제시한 수단에 의하여 발명자가 얻은 성과와 객관적으로 동일한 결과를 얻을 수 없는 경우, 즉 반복하여 실시할 수 없는 것은 발명에 해당할 수 없다.

⑥ 정보의 단순한 제시(기술적 사상 위반)

단순히 제시되는 정보의 내용에만 특징이 있는 것으로 정보의 제시를 주된 목적으로 할 때는 발명에 해당하지 아니한다(예: 녹음된 음악에만 특징이 있는 CD, 컴퓨터 프로그램 리스트 자체 등). 그러나 정보의 제시가 신규한 기술적 특징을 가지고 있으면 그와 같은 정보의 제시 그 자체, 정보제시수단, 정보를 제시하는 방법은 발명에 해당할 수 있다(예: 문자, 숫자, 기호로 이루어지는 정보를 양각으로 기록한 플라스틱 카드(정보의 제시 수단에 기술적 특징이 있는 경우)).

54) 「사주·운세를 이용하여 당첨 확률이 높은 로또 번호를 제공하는 방법」에 관한 발명은 비과학적인 행위인 사주나 운세를 발명 일부로 이용하고 있고, 주목적·효과인 당첨 확률이 높은 로또 번호의 제공은 과학적으로 구현할 수 없는 비상식적인 목적이나 효과라고 할 수 있으므로, 이 발명은 자연법칙을 이용하지 않는 발명으로 볼 수 있다.

⑦ 미적 창작물(기술적 사상 위반)

미적 창작물은 기술적인 면 이외의 시각적인 면을 가지며 그 평가도 주관적으로 이루어지는 것이다. 따라서 미적 효과 그 자체(예: 회화, 조각 그 자체 등)는 발명에 해당하지 아니한다. 그러나 미적 효과가 기술적 수단에 의하여 얻어지는 경우 미적인 효과를 얻기 위한 수단은 발명에 해당할 수 있다.

⑧ 기능(기술적 사상 위반)

악기연주방법, 공을 손가락으로 잡는 방법과 공을 던지는 방법에 특징이 있는 투구방법 등의 기능은 개인의 숙련에 의하여 달성될 수 있는 것으로서 제3자에게 지식으로서 전달될 수 있는 객관성이 없다. 따라서 기능은 발명에 해당되지 아니한다.

⑨ 발견(창작성 위반)

발견이란 자연계에 이미 존재하는 것을 단순히 찾아내는 것으로서 창작이 아니므로, 천연물이나 세균 등의 발견 자체만으로는 발명에 해당되지 아니한다. 그러나 천연물에서 특정물질을 인위적으로 분리하는 방법을 개발하였으면 그 방법은 발명에 해당하며, 또 그 분리된 화학물질 또는 미생물 등도 발명에 해당한다.

(3) 미완성발명

1) 발명의 과제해결을 위한 수단은 제시되어 있으나 자연법칙 상으로 보아 발명의 과제해결(효과)이 현저하게 의심스러운 경우에는 미완성발명이다. 다만 이 경우에 신용할 수 있는 제3자에 의하여 확인된 실험성적 증명서나 실험데이터 등에 의하여 과제를 해결할 수 있는 것이 증명될 수 있거나 이론적으로 해명될 수 있으면 완성발명으로 될 수 있다.

2) 발명의 과제해결을 위한 수단이 완전하게 기재되어 있지 않고 추상적 이론 또는 희망적 사항을 열거한 데 불과한 것은 미완성발명이다.

3) 발명의 과제해결을 위해서 청구항의 기재된 사항이 여러 구성요소의 결합이 필요한 경우 그 구성요소의 일부가 미해결로서 현재의 기술수준으로는 실현불가능하고 장래의 실현가능성도 불명확한 것은 미완성발명이다. 다만 장래에 그 발명의 미해결부분이 해결되면 그때 비로소 완성발명이 된다.

5. 발명의 성립성이 문제되는 경우

(1) 미생물 발명 및 식물발명

1) 미생물 발명 및 식물발명은 일정한 확실성 및 반복가능성이 미약하므로 발명의 성립성이 문제가 된다. 미생물 발명의 경우 통상의 기술자가 미생물 등을 쉽게 입수할 수 없는 경우에는 특허출원 전에 미생물을 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 기탁하고, 55) 출원서에 그 취지를 적고 그 증명서류를 첨부하여야 하며(국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에

55) 이를 서면주의의 예외 또는 서면주의의 보완이라 한다.

해당 미생물을 기탁한 경우에는 증명서류 제출 생략 가능), 명세서에 수탁번호를 적어야만 발명의 성립성이 인정된다. 다만 통상의 기술자가 미생물 등을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 입수방법을 명세서에 적으면 된다(승 2, 3).

2) 식물발명의 경우, 일정한 반복생산가능성을 위해 발명의 특성을 재현할 수 있는 육종경과를 상세히 적어야만 발명의 성립성이 인정된다.

(2) 용도발명

「용도발명」이란 특정의 물질 또는 화합물에 대하여 물질 자체가 지니는 특성(용도)을 발견하고 새로운 용도로의 이용과정에서 창작적 요소가 존재하는 것으로서, 원칙적으로는 발견이지만 창작적 요소가 특허법상 보호해줄 가치가 있으므로 특허법상 발명의 성립성이 인정된다.

(3) 컴퓨터 프로그램 관련 발명

자연법칙을 이용한 구성을 갖는 기계와 컴퓨터 소프트웨어가 합해져서 특정한 목적을 달성하는 것은 발명의 구성요소 전체가 자연법칙을 이용한 것이 아니므로 원칙적으로는 발명의 성립성을 인정하여서는 아니 된다. 그러나 지식재산청은 산업정책적인 목적으로 컴퓨터 프로그램 관련 발명에 대해서 일정한 경우에 예외적으로 발명의 성립성을 인정하고 있다.⁵⁶⁾

IV. 흠결의 효과

1. 등록 전 · 후에 있어서 취급

(1) 제29조제1항 본문 위반

심사관은 심사의 객관성을 확보하기 위하여 제62조의 제한열거적인 거절이유에 해당하면 특허거절결정을 하여야 하며, 제62조의 거절이유에 해당하지 아니하면 특허결정을 하여야 한다. 그런데 제62조의 제한열거적인 거절이유에 발명의 정의 규정인 제2조제1호가 제외되어 있어 문제이다. 제62조에 제2조제1호가 제외되었다고 하여 발명의 성립성이 인정되지 아니함에도 불구하고 특허를 부여하는 것은 온당치 않으므로, 심사 실무⁵⁷⁾⁵⁸⁾에서는 우회적으로 제29조제1항

56) 출원발명이 기본위드에 서브위드를 부가하여 명령어를 이루는 제어입력포맷을 다양하게 하고 위드의 개수에 따라 조합되는 제어명령어의 수를 증가시켜 하드웨어인 수치제어장치를 제어하는 방법에 관한 것으로서, 결국 수치제어입력포맷을 사용하여 소프트웨어인 서브위드 부가 가공프로그램을 구동시켜 하드웨어인 수치제어장치에 의하여 기계식별·제어·작동을 하게 하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기시켜 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있다는 이유로 그 출원발명을 자연법칙을 이용하지 아니한 순수한 인간의 정신적 활동에 의한 것이라고 할 수는 없다(대법원 2001. 11. 30. 선고 97후2507).

57) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3107면.

58) 특허법 제2조제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 발명으로 정의하고 있고, 위 특허법 제2조제1호가 혼시적인 규정에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로 자연법칙을 이용하지 아니한 것을 특허출원하였을 때에는 특허법 제29조제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명의 요건을 충족하지 못함을 이유로 특허법 제62조에 따라 그 특허출원이 거절된다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149).

본문의 「산업상 이용할 수 있는 발명」 위반으로 특허거절결정하고 있다. 또한 발명의 성립성이 없는 경우 제29조제1항 본문 위반으로 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)이다.

(2) 제42조제3항제1호 위반

1) 「미완성 발명」은 발명이 완성되지 못한 것을 의미하지만, 「발명의 설명 기재불비(法 42③I)」는 발명이 그 자체로는 완성되었음을 전제로 다만 발명의 설명에 그 발명의 내용에 대한 공개가 제대로 이루어지지 아니한 것을 의미한다.⁵⁹⁾ 이처럼 특허부여의 요건으로서 발명의 완성 여부와 발명의 설명 기재요건의 충족 여부는 구별되어야 하지만, 미완성 발명이면 발명의 설명 기재불비에도 해당하는 경우가 많다. 즉 발명 미완성의 개념(발명으로서의 구체성이 부족한 발명)과 개시가 불충분한 발명의 개념(쉽게 실시하기 어려운 발명) 자체는 특허법상에서의 법조문을 명백히 달리 하는 것이지만, 발명의 완성 여부가 명세서에 의해서만 판단되기 때문에 현실적으로는 이들의 구분이 명확하지 않다.

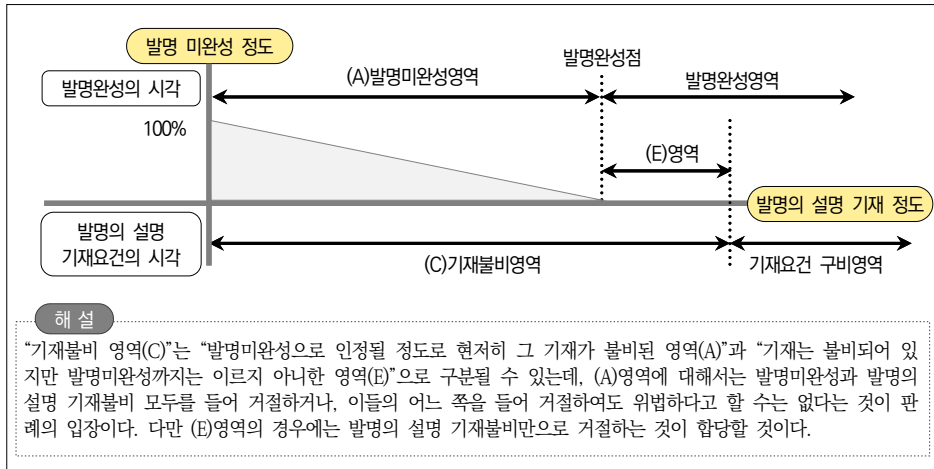
2) 발명의 완성 여부 판단과 관련하여, 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결은 “통상의 기술자가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있으면 발명은 완성되었다고 보아야 한다”라고 판시하였다. 기존의 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 판결 등은 “기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지” 기재하여야만 한다고 하였으나 2017후523 판결에서는 “기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도까지” 기재하여야 한다고 하여 발명의 완성 요건을 상당히 완화시켜 주고 있다. 이는 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결에서 “물건발명의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, i) 물건발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, ii) 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다”라고 하여 발명의 설명 기재불비인지 판단을 실질적 재현설의 입장에서 판시한 것에 비춰 봤을 때, 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 기재되지 아니한 경우 발명의 완성 요건 위반이 아닌 기재불비로서 일관성 있게 처리하려는 것으로 이해된다.⁶⁰⁾⁶¹⁾

59) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산소송실무, 박영사(2006), 81면.

60) 손천우, “미완성 발명의 판단기준 -대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결을 중심으로-”, 지식재산연구 제14권 제4호, 2019년 12월, 한국지식재산연구원, 126-165면 참조.

61) 이처럼 발명의 완성 여부는 명세서 기재요건의 충족 여부와는 구별되어야 할 것인바, 완성된 발명에 이르지 못한 이른바 미완성 발명은 발명의 과제를 해결하기 위한 구체적인 수단이 결여되어 있거나, 또는 제시된 과제해결수단만에 의하여는 과제의 해결이 명백하게 불가능한 것으로서, ① 발명이 복수의 구성요소를 필요로 할 경우에는 어느 구성요소를 결여한 경우, ② 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 그 해결수단을 제시하지 못한 경우, ③ 해결과제-해결수단이 제시되어 있어도 그 수단으로 실행하였을 때 효과가 없는 경우, ④ 용도를 밝히지 못한 경우, ⑤ 발명의 기술적 사상이 실현가능하도록 완성된 것이지만 그 실시의 결과가 사회적으로 용납되지 않는 위험한 상태로 방치되는 경우 등에 해당하면 일반적으로 그 발명은 미완성 발명으로

3) 한편 발명의 설명과 청구범위 모두 “기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도”까지 기재되지 아니한 경우 발명의 성립성 위반뿐만 아니라 발명의 설명 기재불비도 될 수 있을 것이다. 다만 발명의 성립성 위반과 발명의 설명 기재불비는 법조문을 달리하는 별개의 거절이유이고, 발명의 성립성 위반으로 거절되면 발명의 설명 기재불비로 거절된 것과 달리 확대된 선출원이 적용되지 않아서 법률적 효과가 상이하므로 이 경우에는 발명의 성립성 위반으로 거절함이 적절하다고 생각된다.⁶²⁾



【그림 1-5】 발명의 설명 기재요건과 미완성 발명과의 관계⁶³⁾

(3) 신규사항추가

미완성발명을 완성발명으로 하는 보정은 신규사항추가(法 47②전단)이기 때문에 부적법한 보정이 된다. 다만 미완성발명인지에 관한 판단은 청구범위를 기준으로 발명의 설명을 참작하기 때문에, 미완성 발명이라는 취지로 거절이유통지가 있더라도 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 완성발명이 기재되어 있다면 보정을 통해 거절이유의 해소가 가능할 것이다.⁶⁴⁾

- 볼 것이며, 어떤 특허출원이 특허법 제42조 제3항에서 정한 명세서의 기재요건을 충족하지 못하였다고 하여 이를 미완성 발명이라고 단정할 수는 없다고 할 것이다(특허법원 2001. 7. 20. 선고 2000허7038).
- 62) 심사 실무(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3107면)는 명세서에 기재된 발명이 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 충분히 기재되어 있지 아니하며 또한 동일한 이유로 그 발명이 미완성발명인지 여부가 불분명한 경우에는 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 아니한다는 이유(제29조제1항 본문)에 우선하여 발명의 설명 기재불비(제42조제3항제1호)에 근거하여 거절이유를 통지하는 것이 바람직하다는 입장이다. 이는 심사관이 발명의 내용을 잘못 이해하여 미완성발명이라고 판단할 수 있다는 점, 미완성발명을 전제로 거절이유통지를 하는 경우 이를 완성시키는 보정을 하면 신규사항추가가 되어 부적법한 보정이 될 수 있으므로 출원인의 대응 기회를 박탈할 수 있다는 점 등을 고려한 것으로 생각된다.
- 63) 이재웅, “최근 대법원 판례동향(2)”, 지적재산 21, 2003년 1월, 211면 참조.

(4) 권리범위의 불인정

판례는 “특허발명의 청구범위 기재나 발명의 설명, 그 밖의 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요소 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다”⁶⁵⁾고 하거나 “이 사건 등록고안은 실시가 불가능한 고안에 해당하여 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속할 여지가 없다”⁶⁶⁾라고 하여 발명을 제대로 공개시키지 아니하여 공중의 이용 도모에 기여하지 않았음에도 불구하고 착오로 등록된 특허발명, 즉 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없거나 특허발명의 실시가 불가능한 경우 특허취소신청에 의한 취소결정이나 특허무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허권의 권리범위를 부정하고 있다.

2. 불성립발명의 등록금지적 효력

(1) 공지기술의 지위

판례⁶⁷⁾는 “신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비 발명이나 고안은 반드시 그 기술적 구성요소 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명(고안) 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 경험칙에 의하여 극히 쉽게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있다”라고 하여 미완성발명도 공지기술임을 명확히 밝히고 있다.

(2) 확대된 선출원의 지위

판례⁶⁸⁾는 “특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명이란 그 기술내용이 타 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것으로서 완성된 발명을 말하는 것이고, 완성된 발명인지의 여부는 특허출원의 명세서에 기재된 해결과제, 해결수단 및 효과 등을 전체적으로 고려하여 출원 당시의 기술수준에 입각하여 판단하여야 한다”라고 하여 미완성발명의 확대된 선출원의 지위를 부정하고 있다.

(3) 선출원의 지위

미완성 발명에 대한 특허출원은 거절결정이 확정될 것이고, 거절결정이 확정된 출원에 대해서는 제36조제4항에 의하여 선출원의 지위를 부정한다.

(4) 검 토

이상에서 살펴본 바와 같이 미완성발명의 경우 판례에 의하면 공지기술의 지위는 긍정되나 확대된

64) 손천우, “미완성 발명의 판단기준 -대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 판결을 중심으로-”, 지식재산연구 제14권 제4호, 2019년 12월, 한국지식재산연구원, 160면.

65) 대법원 1998. 10. 13. 선고 97후1344; 2002. 6. 14. 선고 2000후235.

66) 대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 등.

67) 대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270.

68) 대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656.

선출원의 지위는 부정되고, 제36조제4항에 의하면 선출원의 지위가 부정된다. 실무적으로는 인용대상에 의하여 신규성, 확대된 선출원, 선출원주의 위반으로 취소신청이나 무효심판이 청구되었을 때 특허권자가 완성발명인 본원발명과 달리 인용대상이 미완성발명임을 증명하여 그 취소사유, 무효사유를 극복하는 방안으로 활용되고 있다. 인용발명이 미완성발명이고, 본원발명이 완성발명인 경우에는 인용발명의 선출원의 지위, 확대된 선출원의 지위가 인정되지 않고, 또한 양자 간의 동일성이 없기 때문이다.

V. 유사개념과 구별

1. 실용신안법상 고안과 구별

실용신안법상의 고안도 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이기는 하나 발명과 달리 고도성을 필요로 하지 아니한다. 다만 고안이 실용신안으로 보호받기 위해서는 물품의 형상, 구조 또는 그 조합에 관한 것이어야 한다(實用 4①).

2. 노하우(know-How)와 구별

「노하우」란 공개되지 아니한 것을 전제로 보호되는 것으로서 노하우의 의미 및 범위는 계약이나 그 밖의 법률관계에 의하여 확정된다. 노하우는 특허의 보호객체인 발명보다 범위가 넓어서, 발명뿐만 아니라 기술제조방법, 판매방법, 경영방법 등을 포함하는 개념으로 해석된다. 발명을 완성한 발명자는 발명을 특허출원하여 특허로 보호할 수 있지만, 공개하지 아니한 것이 더욱 적절하다고 판단된다면 노하우로 보호할 수도 있다.⁶⁹⁾

69) 특허출원을 하는 경우 발명을 공개함으로써 잃는 손해보다 독점적 사용·실시권 허락·타인의 특허권에 대한 방어 특허권으로 취득하는 이익이 더 크다고 판단하기 때문인데 만약 공개시키지 아니함으로써 얻는 이익이 특허권으로 보호받을 수 있는 이익보다 크다면 노하우로서 보호받는 것이 더 바람직하다. 대표적인 예로 코카콜라 제조기술은 특허로서가 아닌 노하우로서 보호되고 있다(손영식, “직무발명성격 및 보상제도에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원, 석사, 2002, 44면).

【표 1-6】 특허와 노하우의 구별

구 분	특 허	노 하 우
공개여부	有	無
성립요건	발명의 정의 규정(法 21) 만족	특별한 정의 규정 ×
특허요건	필요	불필요
보호기간	일정 기간	비밀이 유지되는 한 제한 × (단, 타인이 특허를 받더라도 일정한 경우 특허법 제96조제1항 제3호, 제103조 ⁷⁰⁾ 에 의하여 보호 가능)
보호범위	청구범위 기재발명	불명확
독점·배타성	有	無
침해에 대한 구제	특허법상 권리에 의한 민형사상 조치: 권리부여	계약내용에 의하여 보호 (단, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 ⁷¹⁾ 또는 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 등에 의하여 일정행위를 민형사상 규제가능: 행위규제)

70) 비밀이 유지된 상태에서 노하우로써 보호하다가 제3자가 특허권을 행사하려고 하는 경우 선사용권(法 103)으로 대항할 수 있다. 다만 선사용권이 있음은 실시하고 있는 자가 증명하여야 하므로 증명의 용이성을 위해 기술관련서류, 사업관련서류, 제품, 영상 등을 잘 관리하여야 하며, 공증사무소에 가서 공증일자를 받아 두는 것도 좋은 방안이 될 수 있다. 최근에는 한국지식재산보호원에서 운영하는 영업비밀보호센터(www.tradesecret.or.kr)에서 영업비밀 원본 증명 서비스를 개시하였으며, 이를 적극적으로 활용하는 것도 검토해 볼 필요가 있다.

71) 노하우가 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 의하여 보호받기 위해서는 영업비밀의 성립요건을 만족하여야 한다. 「영업비밀」이란 공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조제2호). 즉 영업비밀로 성립하기 위해서는 ① 비공시성, ② 경제적 유용성 및 ③ 비밀관리성의 3가지의 요건을 충족하여야 한다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에서는 영업비밀에 대하여 권리를 부여하기보다는 행위를 규제하고 있는데, 구체적으로 영업비밀을 부정취득 또는 부정공개하여 침해하는 행위(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조제3호(가)목 내지 (바)목)에 대해서 침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구를 할 수 있으며, 일정한 행위에 대한 형사처벌을 할 수 있다. 다만 노하우가 영업비밀에 해당하여 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」에 의하여 보호를 받는다고 하더라도 그 보호의 강도는 특허법이 훨씬 높다고 할 수 있다. 구체적으로 특허권의 경우에는 특허된 발명을 권리자 이외의 다른 사람들이 의도적으로 복제하는 것을 금지시킬 뿐만 아니라, 그들이 독자적으로 개발한 경우에도 그것의 제조·판매를 금지시킬 수 있지만, 영업비밀은 신뢰관계의 파괴(破壞)나 그 밖의 부정한 수단에 의하여 획득한 경우에만 그 사용을 금지시키고, 스스로 개발하였거나 그 밖의 정당한 방법, 예컨대 역설계(reverse engineering) 등으로 그 비밀인 발명을 획득한 경우는 그 사용을 금지시킬 수 없다(지식재산청, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서」, 2008, 18면).

제2절 발명의 성립성이 문제되는 발명

제1관 용도발명

I. 서 설

「용도발명」⁷²⁾이란 물질로부터 새로운 속성을 발견하고 새로운 용도로 이용하는 과정에서 창작적 요소가 존재하는 발명을 말한다. 용도발명의 개념은 미국 특허법에서 유래되었다. 미국 특허법 제100조(a)에서는 발명(invention)의 정의를 발명(invention) 또는 발견(discovery)이라 하고 있는데, 여기서 발견(discovery)은 단순한 발견을 의미하는 것이 아니라 기존 물질의 새로운 유용성을 발견하기까지 통상의 기술자에게 자명하지 아니한 발명적 노력을 가한, 비자명한 발견을 의미한다. 이러한 미국 특허법의 규정은 미국의 실용주의 정신이 구현된 것으로서, 특허법상 발명의 범위를 기술적 사상의 창작인 발명 이외에 자명하지 아니한 유용성을 드러내는 발견까지 확대한 것이다.

II. 특허요건 등

1. 용도발명의 성립성

발견은 기존에 존재하는 것을 단순히 찾아내는 것에 불과하여 창작성이 없으므로 원칙적으로 발명의 정의 규정(法 2 I)에 부합하지 아니한다. 그러나 특허법은 비록 발견이지만 산업상 이용 가치가 높은 새로운 용도로 이용하고, 그 용도로 이용하는 과정에서 발명으로서 보호할 가치가 인정되는 경우 용도발명의 성립성을 인정하고 있다. 용도발명의 성립성이 인정되기 위해서는 새로운 속성의 발견에 상당한 정도의 노력과 수고가 요구되며, 새로운 속성의 발견과 새로운 용도로의 이용과정에서는 창작적 요소가 존재하여야 한다. 창작적 요소가 존재하지 아니한 경우에는 단순한 발견에 불과하며, 새로운 용도로 이용할 수 없는 경우에는 구체성을 결여한 미완성발명이 될 수 있다. 한편 그 용도가 당시까지 알려지지 않았던 새로운 것이면 충분하고, 그 물질이나 그 물질의 다른 용도가 출원 이전에 공지되어 있어야 하는 것은 아니다.⁷³⁾

2. 명세서의 기재

1) 용도발명은 별개의 독립된 카테고리 아니므로 물건발명 또는 방법발명 중 어느 한쪽으로 특정할 수 있다. 예를 들어 DDT라는 공지의 물질에 살충효과가 있음을 발견한 경우 「DDT를 성분으로 하는 살충제」 또는 「DDT를 살포하여 살충하는 방법」으로 특정할 수 있다.⁷⁴⁾⁷⁵⁾

72) 미국의 경우 「new use」, 유럽의 경우 「second use」, PCT에서는 「a use of product」라고 표현된다.

73) 특허법원 2012. 8. 24. 선고 2012허2166.

74) 특허출원발명의 청구항 제1항은 발기부전치료를 위한 장정볼로단이라는 환의 제조방법에 관한 발명의 형식으로

2) 신규성 등의 특허요건을 판단할 때 청구항에 용도를 한정하는 기재가 포함된 경우 발명의 설명 및 도면의 기재와 그 기술분야의 출원 시의 기술상식을 참작하여 그 용도로 사용되는데 특별히 적합한 물건만을 의미하면 그 용도를 포함하여 발명을 특정하고, 그렇지 아니한 경우에는 그 용도를 배제하고 발명을 특정하여야 한다.

3. 그 밖의 특허요건

용도발명은 일반적인 발명과 동일하게 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성, 선출원주의 등을 만족하여 제62조의 거절이유에 해당하지 아니하여야 한다. 신규성, 진보성 판단과 관련하여 물건발명이 신규성 또는 진보성이 있다면 그 물건의 용도발명 역시 신규성 또는 진보성이 있으며, 물건발명이 신규성 또는 진보성이 없다면 그 물건의 용도발명은 신규성 또는 진보성을 개별적으로 판단하여야 한다.

III. 특허권의 효력

1. 적극적·소극적 효력

특허권자는 업으로서 용도발명을 실시할 권리를 독점하며(法 94①), 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로 실시하면 침해를 이유로 민·형사상 제재를 할 수 있다. 용도발명은 물건발명을 그대로 이용한 것이므로 물건발명이 특허를 받았으면 이용관계에 있다. 이 경우 용도발명의 특허권자는 물건발명 특허권자의 허락을 받거나(法 98), 통상실시권허락심판(法 138)에 의하는 등 정당한 권원을 획득하지 아니하고는 용도발명을 실시할 수 없다.

2. 연장된 특허권의 효력

용도발명의 실시를 위하여 타법의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간에서 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다(法 89). 이 경우 연장등록된 특허권의 효력은 그

되어 있지만, 환제를 만드는 데 보편적으로 사용되는 기술을 사용하고 있어서 그 제조방법 자체에는 별다른 기술적 특징이 없는 점, 그 명세서의 발명의 설명에서 장정볼로단이라는 조성물의 유용성을 발기부전치료라는 의약적 용도로 기술하고 있는 점, 그 청구범위에 발기부전치료를 위한 장정볼로단이라고 적어 제조방법에 의하여 제조되는 조성물의 의약용도를 구성요소로 포함하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 특허출원발명의 청구항 제1항은 장정볼로단이라는 특정한 조성물을 발기부전치료에 사용한다는 의약용도를 구성요건으로 하는 의약의 용도발명이라고 봄이 타당하고, 그에 따라 그 발명의 설명에 약리효과가 구체적으로 기재되어 있어야 한다(특허법원 2012. 8. 24. 선고 2012허2166).

75) 일본의 실무관행도 어느 쪽을 택해도 무방하다고 한다(吉藤幸綱 著, 유미특허법률사무소 譯, 「특허법개설」, 제13판, 유미특허법률사무소, 2000, 90면).

연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다(法 95).

IV. 의약발명

1. 의 의

「의약발명」이란 사람의 질병을 진단·치료·처리·예방을 하는 물질인 의약의 발명 이외에 둘 이상의 의약을 혼합하여 하나의 의약을 조제하는 방법의 발명까지 포함하는 발명을 말한다.⁷⁶⁾

2. 특허요건 등

(1) 의약발명의 성립성

의약발명 중 물질발명의 대부분은 천연물질에서 인체의 치료에 필요한 특정 성분을 발견하고 추출하여 의약으로 이용하는바, 용도발명의 일종이라 할 수 있다. 이처럼 특정 성분을 발견하고 의약으로 이용함에 있어서, 무수한 노력, 실험 및 투자뿐만 아니라 창작적 요소가 있고, 그 의약은 인간의 생명과 건강 증진에 도움을 주어 관련 산업발전에 기여하기에 유인을 장려할 필요가 있어서 발견임에도 불구하고 발명의 성립성을 인정하고 있다.

(2) 발명의 설명 기재

약리효과와 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 발명의 설명 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다.⁷⁷⁾

(3) 청구범위의 기재

① 의약용도발명의 구성요소는 물질과 용도

76) 구체적으로 의약발명에는 ‘의약용도발명’(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 등), ‘선택발명’(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 등), ‘이성질체 발명’(대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 등), ‘염(鹽)발명’, ‘결정형 발명’(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후 2865 등), ‘제형발명’(대법원 2011. 10. 13. 선고 2009후432 2), ‘투여용법 또는 투여용량을 구성요소로 하는 의약용도발명’(대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체), ‘제법발명’(특허법원 2017. 12. 21. 선고 2016허9035) 등이 있다.

77) 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730, 2015후727. 비아그라 의약용도발명에 대한 무효심판사건과 관련된 대상판결에서는, i) 약리기전이 명확히 밝혀진 경우의 의미와 관련하여, 특정 물질의 약리적 효과가 추정되는 경우나 특정 물질과 유사기전을 가진 물질이 해당 의약의 용도를 갖는다는 점이 출원 전에 공지된 사정만으로는 특정 물질의 약리기전이 명확히 밝혀진 경우로 볼 수 없다, ii) 약리효과에 대한 약리데이터 등이 나타난 시험예의 기재정도와 관련하여서도 투여량의 범위, 구체적인 투여방법, 투여 대상의 규모, 이 가운데 치료 효과를 보았다고 평가한 비율, 투여 전과 투여 후의 상태를 비교하여 치료효과를 얻었다고 판단한 근거 정도가 기재되어야 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재한 것으로 인정할 수 있다고 하여 그 기준을 제시하고 있다.

의약용도발명에 있어서는 특정 물질이 가지고 있는 의약용도가 발명의 구성에 해당하므로 청구범위에는 특정 물질의 의약용도를 대상 질병 또는 약효로 명확히 기재하는 것이 원칙이나, 특정 물질의 의약용도가 약리기전만으로 기재되어 있다 하더라도 명세서 등 발명의 설명의 다른 기재나 기술상식에 의하여 의약으로서의 구체적인 용도를 명확하게 파악할 수 있는 경우에는 제42조제4항제2호가 정한 청구항의 명확성 요건을 충족하는 것으로 볼 수 있다.⁷⁸⁾

② 의약용도발명의 구성요소가 물질, 약리기전 및 용도로 기재된 경우

의약용도발명에서는 특정 물질과 그것이 가지고 있는 의약용도가 발명을 구성하는 것이고,⁷⁹⁾ 약리기전은 특정 물질에 불가분적으로 내재한 속성으로서 특정 물질과 의약용도와의 결합을 도출해내는 체계에 불과하다. 따라서 의약용도발명의 청구범위에 기재되어 있는 약리기전은 특정 물질이 가지고 있는 의약용도를 특정하는 한도 내에서만 발명의 구성요소로서 의미를 가질 뿐 약리기전 그 자체가 청구범위를 한정하는 구성요소라고 보아서는 아니 된다. 구체적인 사례로는 i) 물질과 용도로 기재된 청구항에 약리기전을 추가하는 정정을 하는 것은 내적한정이 아니라 용도를 중복적으로 기재하는 것에 불과하여 청구범위의 감축이 아니기 때문에 허용되지 않는다는 사례,⁸⁰⁾ ii) 물질, 약리기전 및 용도로 기재된 청구항은 물질과 용도의 구성요소를 가지는 발명으로 이해하여야 한다는 사례⁸¹⁾가 있다.

③ 투여용법과 투여용량을 구성요소로 볼 수 있는지 여부

1) 의약용도발명의 투여용법과 투여용량에 대한 기재와 관련하여, 종전의 대법원판결⁸²⁾에서 조성물인 의약물질을 구성하는 부분이 아니라 의약물질을 인간 등에게 투여하는 방법이어서 특허를 받을 수 없는 의약을 사용한 의료행위이거나, 조성물 발명에서 비교대상발명과 대비 대상이 되는 그 청구범위 기재에 의하여 얻어진 최종적인 물건 자체에 관한 것이 아니어서 발명의 구성요소로 볼 수 없다는 취지로 판시하였다. 그러나 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 전원합의체 판결에서 의료행위 그 자체가 아니라 의약이라는 물건이 효능을 온전하게 발휘하도록 하는 속성을 표현함으로써 의약이라는 물건에 새로운 의미를 부여하는 구성요소가 될 수 있다고 보아야 하고, 이와 같은 투여용법과 투여용량이라는 새로운 의약용도가 부가되어 신규성과 진보성 등의 특허요건을 갖춘 의약에 대해서는 새롭게 특허권이 부여될 수 있다고 하여 종전의 판결을 변경하였다. 의약발명에 대한 최적의 투여용법과 투여용량을 찾아내는 것은 상당한 노력, 비용 및 투자 등이 소요되며 창작적 요소가 있기에 특허법상 보호할 가치가 있다는 점, 의료산업에 대한 기술발전을 촉진하여 환자의 생명 또는 건강과 관련된 보편적 인권을 보호할 필요가 있다는 점에서 종전의 판결을 모두 변경한 대법판결은 적절하다고 보인다.

78) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후5215. 즉 특허법 제42조제4항제2호의 명확성 요건을 판단함에 있어서 발명이 명확하게 적혀 있는지는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563).

79) 대법원 2009. 1. 30. 선고 2006후3564.

80) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664.

81) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238.

82) 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2926; 2009. 5. 28. 선고 2007후293.

2) 한편 제약기업들이 의약의 물질특허에 대한 투여용법과 투여용량을 한정하여 특허출원하는 것에 대하여 존속기간을 연장하기 위한 수단으로써 활용할 수 있다는 비판이 있을 수 있으나, 이는 의약발명에 대한 진보성 판단을 통해 등록 여부를 결정함으로써 충분히 해결할 수 있을 것으로 보인다.

(4) 산업상 이용가능성과 불특허발명

인체를 직접적인 구성요소로 하지 아니하여야만 산업상 이용가능성(法 29①본문)이 인정되고, 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하지 아니하여야만 공서양속에 위반되거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명(法 32)에 해당하지 않는다.

(5) 신규성

화학물질이나 의약품 등의 경우에는 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없어 신규성이 상실되지 아니한다. 불특정다수인이 발명의 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓인 점에 대해서는 이를 주장하는 자가 증명하여야 한다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에 이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 특허발명과 대비되는 선행발명의 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다.⁸³⁾

(6) 진보성

① 투여용법과 투여용량이 포함된 발명의 진보성 판단

투여용법과 투여용량에 관한 용도발명의 진보성이 인정되기 위해서는 의약개발 과정에서는 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위하여 적절한 투여용법과 투여용량을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로 출원 당시의 기술수준이나 공지기술 등에 비추어 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.⁸⁴⁾ 즉 특정한 투여용법이나 투여용량으로 인하여 나타난 유리한 효과가 통상의 기술자의 기술수준에서 예측되는 범위를 넘는 현저한 경우이거나 또는 통상의 기술자가 당해 의약발명의 약리효과가 온전히 유지되면서 독성이나 부작용이 최소화되는 특정한 투여용법이나 투여용량을 선행발명 또는 공지의 발명으로부터 예측할 수 없었던 경우에 진보성을 인정받을 수 있다.⁸⁵⁾

② 임상시험 등에 의한 효과가 확인된 발명의 진보성 판단

의약용도발명에서는 통상의 기술자가 선행발명들로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 그 진보성이 부정되고, 이러한 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.⁸⁶⁾

83) 특허법원 2018. 1. 11. 선고 2017나1247.

84) 대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702.

85) 특허법원 2017. 2. 3. 선고 2016허830.

86) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502. 그러나, 선행발명들이 단순한 선언적 진술에 불과하거나 막연한 기대

③ 결정형 발명의 진보성 판단

1) 결정형 발명이란 의약화학물 분야에서 선행발명에 공지된 화합물과 화학구조는 동일하지만 결정 형태가 다른 특정한 결정형의 화합물을 청구범위로 하는 발명을 말한다. 의약화학물의 제제설계(製劑設計)를 위하여 그 화합물이 다양한 결정 형태 즉 결정다형(polymorph)을 가지는지 등을 검토하는 다형체 스크리닝(polymorph screening)은 통상 행해지는 일이다. 하지만 그것만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다. 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험이라는 것과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개의 문제이기 때문이다. 한편 결정형 발명과 같이 의약화학물 분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다.⁸⁷⁾⁸⁸⁾

2) 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 발명에서 청구한 특정한 결정형의 구조와 제조방법, 선행발명의 내용과 특징, 통상의 기술자의 기술수준과 출원 당시의 통상적인 다형체 스크리닝 방식 등을 기록에 나타난 자료에 기초하여 파악한 다음, 선행발명 화합물의 결정다형성이 알려졌거나 예상되었는지, 결정형 발명에서 청구하는 특정한 결정형에 이를 수 있다는 가르침이나 암시, 동기 등이 선행발명이나 선행기술문헌에 나타나 있는지, 결정형 발명의 특정한 결정형이 선행발명 화합물에 대한 통상적인 다형체 스크리닝을 통해 검토될 수 있는 결정다형의 범위에 포함되는지, 그 특정한 결정형이 예측할 수 없는 유리한 효과를 가지는지 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다.⁸⁹⁾

3) 결정형 발명의 효과가 선행발명 화합물의 효과와 질적으로 다르거나 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.⁹⁰⁾ 결정형 발명의 효과의 현저성은 그 발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고, 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.⁹¹⁾

또는 가능성을 제시하는 것만으로는 부족하고, 선행발명들에 특정 질병의 발생 기전과 이에 대응되는 예방 및 치료 원리, 특정 물질의 과학적·기술적·기능적 특성과, 그러한 물질의 특성과 질병의 발생 및 치료 원리와의 관련성 등이 포함되어 있어서 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 합리적으로 예측할 수 있을 정도에 이르러야 한다(특허법원 2025. 6. 19. 선고 2024허14162).

87) 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등에서 특별한 사정이 없는 한 효과의 현저성을 가지고 결정형 발명의 진보성을 판단한 것도 결정형 발명의 위와 같은 특성으로 인해 구성이 곤란한지 불분명한 사안에서 효과의 현저성을 중심으로 진보성을 판단한 것으로 이해할 수 있다.

88) 대법원 2022. 04. 05. 선고 2018후10923; 2023. 3. 13. 선고 2019후11800.

89) 대법원 2022. 04. 05. 선고 2018후10923; 2023. 3. 13. 선고 2019후11800.

90) 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결 등 참조.

91) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결 등 참조.

3. 특허권의 효력

(1) 적극적·소극적 효력

특허권자는 업으로서 용도발명을 실시할 권리를 독점하며(法 94①), 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로 실시하면 침해를 이유로 민·형사상 제재를 할 수 있다. 다만 「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고를 위한 연구 또는 시험의 경우에는 특허권의 효력이 미치지 아니하고(法 96① I), 둘 이상의 의약(사람의 질병의 진단·경감·치료·처치(處置) 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다)이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다(法 96②).

3) 또한 특허발명을 실시하려는 자는 수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 지식재산처장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다(法 107). 즉 공익적인 목적으로 재정에 의한 강제실시권을 인정함으로써 의약품에 대한 특허권의 효력을 제한하고 있다.

(2) 연장된 특허권의 효력

의약발명의 실시를 위하여 타법의 규정에 의하여 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간에서 그 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다(法 89). 이 경우 연장등록된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정한 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다(法 95).

제2관 전자상거래 관련 발명

I. 서 설

1. 의 의

「전자상거래 관련 발명(Business Method(Model)): BM」이란 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터기술에 의하여 구현된 발명을 말한다.

2. 취 지

1) 전자상거래 관련 발명은 자연법칙을 100% 이용하지 아니하고 있지만, 인터넷 기술의 발달과 전자상거래의 확대, 세계 각국의 발명으로서 인정경향 등을 반영하여 특허법상 발명으로서 인정하고

있다. 이에 지식재산차는 심사의 효율화와 출원인의 편익을 도모하고 행정작용의 명확화를 위해 심사기준을 마련하여 운영하고 있다.

2) 다만 특허법은 전자상거래 관련 발명을 포함한 컴퓨터 프로그램과 관련된 발명에 대해서는 특허를 허여하고 있으나 컴퓨터 프로그램 그 자체는 특허법의 보호대상이 아니라고 하여 특허를 허여하지 아니한다. 이러한 컴퓨터 프로그램 자체는 저작권법에 의하여 보호받을 수 있다.

II. 특허요건 등

1. 발명의 성립성

전자상거래 관련 발명은 크게 i) 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형과 ii) 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 유형으로 구분될 수 있는데, 순수한 영업방법과 추상적 아이디어와 같은 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형은 발명의 성립성이 부정된다. 그러나 청구항에서 영업방법의 각 단계가 컴퓨터상에서 수행되게 하기 위한 구성을 한정하고 있는 유형은 발명의 성립성이 인정될 수도 있다. 구체적으로 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결⁹²⁾ 등⁹³⁾에서는 “비즈니스 방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다. 한편 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다”라고 판시하여 전자상거래 관련 발명의 성립성이 인정되기 위한 판단기준을 제시하고 있다.⁹⁴⁾⁹⁵⁾

92) 「배출자 신상정보가 입력된 바코드 스티커와, 배출쓰레기가 표시된 달력지는 관할 관청에서 각 배출자에게 배포하고 각 배출자들은 정해진 규정에 의해 정확하게 분리된 쓰레기를 규정 쓰레기 봉투에 담아서 배출하되 반드시 배출자 신상정보가 입력된 바코드 스티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하며, 수거자는 배출된 쓰레기를 요일별로 정확하게 분리 수거하여 집하장으로 이송하여 재활용쓰레기와 매립 소각될 쓰레기를 선별하여 처리과정을 거치며, 잘못분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정명령을 지시하는 각 과정에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활쓰레기를 종합관리하도록 하는 생활쓰레기 재활용종합관리방법」은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며, 그 각 단계가 컴퓨터의 온라인(on-line) 상에서 처리되는 것이 아니라 오프라인(off-line) 상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니어서 이른바 비즈니스모델 발명의 범주에 속하지도 아니하므로 이를 특허법 제29조 제1항 본문의 “산업상 이용할 수 있는 발명”이라고 할 수 없다.

93) 대법원 2008. 12. 11. 선고 2007후494; 2008. 12. 24. 선고 2007후265 등.

94) 한편 이 기준을 조금 더 구체화한 특허법원 2007. 6. 27. 선고 2006허8910 판결에서는 “비즈니스 방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하며, 여기에서 「소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다」는 것은 소프트웨어가 컴퓨터에 의하여 단순히 읽혀지는 것에 그치지 않고, 소프트웨어와

2. 명세서의 기재

(1) 발명의 설명 기재

청구항에 기재된 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되게 하는 구현기술의 구체적인 내용이 발명의 설명에 실시가능하도록 기재되어야 한다.

(2) 청구범위의 기재

전자상거래 관련 발명을 포함하는 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 청구항 작성형태에 대하여 살펴보면, 컴퓨터 프로그램에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용해 구체적으로 실현되고 있는 경우에 해당 컴퓨터 프로그램과 협동해 동작하는 정보 처리 장치(기계) 및 동작 방법을 각각 물건발명과 방법발명으로 청구할 수 있다. 또한 해당 컴퓨터 프로그램을 설치하고 실행하거나 유통하기 위해 사용되는 “해당 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체” 또는 “하드웨어와 결합하여 특정과제를 해결하기 위하여 매체에 저장된 컴퓨터 프로그램(애플리케이션)”을 물건발명으로서 청구할 수 있다. 다만 매체에 저장되지 아니한 컴퓨터 프로그램은 컴퓨터 프로그램 자체를 청구한 것이므로 허용되지 아니한다.

하드웨어가 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 사용목적에 따른 정보의 연산 또는 가공을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되는 것을 말한다. 그리고 비즈니스 방법발명이 발명으로서 완성되기 위해서는 청구범위의 기재가 단순한 아이디어를 제기하는 수준에 머물러서는 안 되고, 발명의 목적을 달성하기 위한 필수불가결한 모든 구성들이 구체적이고 명확하게 기재되어야 한다. 따라서 BM 발명이 성립하려면, 전체로서 판단된 청구항이 사람의 정신활동 등을 이용한 것이거나 단순히 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능을 이용하고 있는 것이어서는 안 되고, 컴퓨터 시스템상에서 소프트웨어와 하드웨어의 구체적인 상호 협동 수단에 의하여 특정한 목적 달성을 위한 정보의 처리를 구체적으로 수행하는 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축됨으로써 컴퓨터나 인터넷이 단순히 이용되는 것 이상의 새로운 효과를 발휘할 수 있는 것이어야 한다”라고 판시하였다.

- 95) 미국에서는 1998년 미국 CAFE의 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc. 사건에서, 컴퓨터를 이용한 펀드의 자금운용방법과 같은 영업방법 관련 발명의 성립성을 인정하되, 그 근거로는 “기계로 일련의 수식계산을 실행함으로써 금액 표시에 대응하는 데이터를 최종주가로 변환하는 것은, 유용하며 (useful), 구체적인(concrete) 동시에 유형(tangible)의 결과를 가져오기 때문에 청구항의 발명이 알고리즘, 공식 또는 계산이 아닌 실용적인 응용(practical application)에 해당한다”라는 것이었다. 다만 그 후 2008년 미국 CAFC의 In re Bilski 사건에서 종전에 방법발명이 특허의 대상이 되는지의 여부 판단시 “유용하고, 구체적이며 유형의 결과 발생”이라는 종전의 기준을 전면적으로 부정하지는 않았으나 제한적으로만 그 유용성을 인정하고, 근본적인 기준으로서 “특정기계와의 결합 또는 물질/물체의 변형(machine-or-transformation)”이라는 새로운 엄격한 기준을 제시하고 있다. 이는 “자연법칙, 자연현상, 추상적 아이디어와 같은 기본원리는 과학기술의 발전을 위한 재료(building block)로 사용되어야 하며, 누군가에 의하여 독점권이 허여되어서는 아니 되기 때문이고, “machine-or-transformation”의 기준에 의하면, 1) 문제가 되는 물품(machine)이 아닌 다른 물품으로 변형시킬 수 있고, 2) 동일한 물품이라도 청구항과는 다른 방법으로 변형(transformation)시킬 수 있으며, 3) 특정 물품에 대하여 변형 이외 모든 행위를 하는 것이 배제되지 않기 때문에 특허가 허용될 수 있다”라는 것이다. 다만 In re Bilski 사건에서는 향후 과학 기술의 발전에 의하여 “machine-or-transformation” 기준이 수정되거나 다른 것으로 대체될 수 있다는 점을 배제하지 않고 있다(김판식, 「특허법 주해 I」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 31-36면 참조).

3. 그 밖의 특허요건

(1) 신규성

영업방법상의 특징과 컴퓨터 기술 구성상의 특징이 결합하여 있으므로 출원발명과 인용대상이 동일한 영업방법상의 특징을 가지고 있더라도 그 컴퓨터 기술 구성상의 차이가 있으면 신규성이 있는 것으로 판단된다.

(2) 진보성

출원발명과 인용대상의 구성요소를 대비하여 판단하며, 구체적으로 i) 종래의 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 경우 진보성이 없는 것으로 판단되며, ii) 종래의 영업방법을 새로운 기술로 구현한 경우 또는 새로운 영업방법이 새로운 기술로 구현된 경우에는 진보성이 인정될 수 있다. 한편 새로운 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 경우에는 개별적으로 진보성을 달리 판단하여야 할 것이다.

III. 특허권의 효력

1) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하며(法 94①), 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로 실시하면 침해로 이유로 민·형사상 제재를 할 수 있다. 여기서 제3자의 실시 발명이 특허발명의 보호범위에 속하기 위해서는 그 실시 발명에 특허발명인 전자상거래 관련 발명의 구성요소와 구성요소 사이의 유기적 결합관계가 그대로 포함되어 있어야 한다.⁹⁶⁾

2) 한편 기존에는 컴퓨터 프로그램을 기록매체(USB, CD 등)에 저장한 후 이를 복제하여 실시하였으나 현재는 대부분 온라인 전송을 통하여 복제한 후 실시하고 있는데, 기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램만을 특허법에서 보호함으로써 온라인 전송행위에 대해서는 권리행사를 할 수 없다는 문제점이 있었다. 이에 2020. 3. 11. 시행된 현행법(법률 제16804호, 2019. 12. 10. 개정)에서는 방법발명 실시의 정의에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 추가하여, 컴퓨터 프로그램 실행(방법의 사용)을 위한 온라인 전송행위(청약)를 방법발명 실시의 일 유형으로 포섭함으로써 특허권의 침해가 될 수 있도록 하였다(法 2Ⅲ나). 다만 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 제한하고 있다(法 94②). 따라서 방법의 사용을 청약하는 행위에는 제130조의 과실추정 규정이 적용되지 않으며, 특허권자로부터 침해 경고를 받은 이후에 실시를 중단하면 특허권의 침해가 되지 않는다.⁹⁷⁾

96) 특허법원 2007. 12. 26. 선고 2007허2957.

97) 제2조제3호(나)목의 개정에 의하여 제2조제3호(다)목에서 물건을 생산하는 방법발명(제법발명)의 실시는 i) 물건을 생산하는 방법을 사용하는 행위(물건의 생산), ii) 물건을 생산하는 방법의 사용(물건의 생산)을 청약하는 행위, iii) 물건을 생산하는 방법에 의하여 생산된 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위로 구분될 수 있다. 그런데 새로 도입된 ii)의 행위

제3관 미생물 발명

I. 서 설

1. 의 의

「미생물」이란 곰팡이·세균 등 미세한 크기의 생명을 가진 물체로서, 「미생물 발명」이란 미생물 자체의 발명, 미생물을 생산하는 방법에 관한 발명, 미생물을 이용하는 발명 등을 총칭한다.

2. 미생물 발명의 특허 여부

종래에는 미생물이 창작물이 아닌 단순한 발견이고 반복생산가능성이 없으므로 발명으로서의 성립성을 갖추고 있지 않다는 이유로 특허성을 부정하였으나, 최근에는 i) 유전공학의 발달로 인하여 DNA 구조가 규명됨으로서 단순한 발견이 아니라는 것이 밝혀지고, ii) 서면주의의 예외를 인정하여 반복생산가능성에 대한 문제가 해결됨으로서 미생물의 특허성을 인정하고 있다.

II. 특허요건 등

1. 발명의 성립성

(1) 일 반

1) 미생물 발명은 일정한 확실성 및 반복생산가능성이 문제이다. 일정한 확실성 및 반복가능성이 미약한 경우, 즉 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 없는 경우에는 이를 보완하기 위하여 기탁기관에 기탁을 하여야 한다. 이는 극미(極微)의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 통상의 기술자가 그 발명을 재현하여 산업상 이용할 수 없기 때문이다.⁹⁸⁾

2) 여기서 「통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 미생물」이란 그 미생물이 공지 또는 공연실시되어 시판되고 있거나 신용할 수 있는 기탁기관에 보존되어 있는 한편 자유로이 분양되는 것 등을 말하며 그 미생물이 현존하는 이상 반드시 국내에 현존하는 것이어야 할 필요는 없고 국외에 현존하는 것이라 하더라도 국내의 통상의 기술자가 이를 쉽게 얻을 수 있다고 인정될 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 보아야 한다. 나아가 발명에서 이용하는 미생물이 출발미생물이 아니라

(물건생산의 청약)와 관련하여, 특허법에서 물건생산의 청약이라는 개념을 상정할 수 있는지 여부, ii)의 행위는 제2조제3호(가)목에서 물건발명의 실시에 포함되지 않은 행위인데 제법발명의 실시가 물건발명에 대한 특허권의 침해가 되지 않는 것이 적절한 지 여부 등이 검토되어야 할 것이다. 사건으로는 입법불비라고 판단되며, 제2조제3호(다)목을 “물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위나 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”로 개정하여, 제법방법의 실시에서 ii)의 행위를 배제함이 적절하다고 사료된다.

98) 대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238.

출발미생물을 이용하여 생성된 중간생성물 또는 최종생성물에 해당하는 것이라 하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 통상의 기술자가 쉽게 얻을 수 있는 것이고, 또 그 출발미생물과 공지의 균주 등을 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 통상의 기술자가 쉽게 재현할 수 있도록 발명의 설명에 기재되어 있다면, 결국 통상의 기술자가 이를 쉽게 얻을 수 있는 것이라 볼 것이어서 이러한 최종생성물이나 중간생성물은 기탁하지 아니하여도 된다.⁹⁹⁾

3) 그 미생물들이 공지의 균주이거나 통상의 기술자가 쉽게 얻을 수 있는 것인지는 명세서 제출 당시인 출원 시를 기준으로 판단한다.¹⁰⁰⁾

(2) 통상의 기술자가 쉽게 입수가능하지 아니한 경우

① 출원 전 기탁기관에 기탁

1) 미생물에 관계되는 발명에 대하여 특허출원을 하려는 자는 특허출원 전에 기탁기관에 지식재산처장이 정하여 고시하는 방법에 따라 해당 미생물을 기탁하여야 하고, 기탁한 특허출원인은 특허출원서에 취지를 적어야 한다(승 2①②). 이처럼 특허출원을 할 때 서면으로 제출하는 출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서 이외에 기탁이라는 절차를 더 밟아야 하는 것을 「서면주의의 보완 또는 예외」라고 한다. 다만 미생물을 기탁하였다고 해서 명세서에 기재하는 것을 생략하거나 간략히 하는 것은 허용되지 아니한다.

2) 기탁기관에는 지식재산처장이 지정한 국내기탁기관¹⁰¹⁾, 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약」에 의한 국제기탁기관¹⁰²⁾ 또는 지정기탁기관이 있다. 부다페스트조약은 미생물의 기탁에 관한 국제조약으로서 조약 동맹국이 승인한 하나의 국제기탁기관에 기탁만으로 다수국에 출원할 수 있으며, 국제기탁기관은 영속적으로 존재하기 때문에 안전하게 이용할 수 있다.¹⁰³⁾ 지정기탁기관이란 부다페스트 조약의 당사국이 아니지만 해당 국가의 특허담당 정부기관의 장이 대한민국 국민에게 특허절차상 미생물기탁에 대하여 대한민국과 동일한 조건의 절차를 인정하기로 지식재산처장과 합의한 국가에서 미생물 기탁 및 분양에 관한 업무를 담당하는 전문기관으로 지정한 기관을 말한다.

99) 대법원 1992. 3. 31. 선고 90후1260 등.

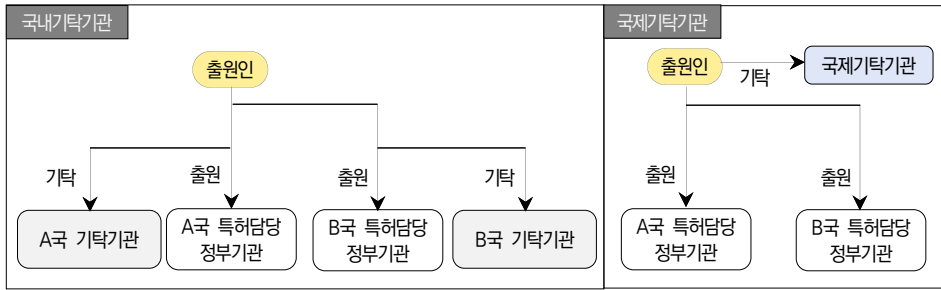
100) 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658.

101) 기탁기관은 다음과 같다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2603면).

구분	생물자원센터 (KCTC)	한국미생물보존센터 (KCCM)	한국세포주연구재단 (KCLRF)	농업유전자원센터 (KACC)
국내기탁기관	○	○	-	○
국제기탁기관	○	○	○	○

102) 미생물 기탁의 상호 승인을 위한 국제조약으로서 1977년 체결되었으며, 우리나라는 1987년 12월에 가입하였다. 동 조약 제1조제1항은 “체약국은 모든 국제기탁 당국에 대한 미생물의 기탁을 자국의 특허절차상 승인하며, 국제기탁기관이 발행하는 수탁증과 사본을 요구할 수 있다”라고 규정하고 있다.

103) 지식재산처장은 출원인이 특허출원할 때 필요하거나 특허출원을 심사(국제출원에 대한 국제조사 및 국제예비심사를 포함한다)할 때에 필요하다고 인정하면 전문기관에 미생물의 기탁·분양 업무를 의뢰할 수 있다(法 58①).



【그림 1-6】 국내기탁기관과 국제기탁기관의 비교

② 기탁증명서 제출

미생물을 기탁한 자는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류(국제기탁기관에 기탁한 경우에는 「특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 규칙」 제7규칙에 따른 수탁증 중 최신의 수탁증 사본을 말한다)를 첨부하여야 한다. 다만 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 미생물의 기탁 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 않을 수 있다. 한편 미생물의 기탁에 대하여 특허출원후 새로운 수탁번호가 부여된 때에는 지체없이 그 사실을 지식재산처장에게 신고하여야 한다(令 2②③). 구체적으로 미생물수탁번호변경신고서에 새로운 수탁번호를 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다(施規 22).

③ 기탁사실의 기재

미생물을 기탁한 경우에는 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 그 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에서 부여받은 수탁번호를 적어야 한다(令 3).

④ 부적법한 기탁 절차의 취급

1) i) 특허출원 시 출원서에 취지를 기재하지 아니하고 그 사실을 증명하는 서류만 첨부한 경우, ii) 출원서에 취지만을 기재하고 그 사실을 증명하는 서류를 첨부하지 아니한 경우 또는 iii) 출원인이 미생물에 관계되는 발명에 대한 취지를 기재한 출원서와 그 사실을 증명하는 서류를 제출하였으나 특허출원 전에 기탁되지 아니하거나 출원서와 그 사실을 증명하는 서류에 수탁번호 등을 잘못 기재한 경우 지식재산처장 등은 방식을 위반한 것으로 보아 제46조 규정에 따라 보정을 명하고 보정명령에도 불구하고 지정된 기간 이내에 그 흠결을 보정하지 못한 경우 「특허기탁과 관련된 절차」를 무효로 할 수 있다.¹⁰⁴⁾

2) 통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수가능하지 아니한데도 불구하고 기탁하지 않고 특허출원한 경우이거나 특허기탁과 관련된 절차가 무효가 된 경우 특허출원은 발명의 성립성이 없으므로 제29조제1항 본문 또는 제42조제3항제1호 위반을 이유로 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)에 해당한다.¹⁰⁵⁾

104) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2606면.

(3) 통상의 기술자가 쉽게 입수가능한 경우

통상의 기술자가 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우에는 기탁하지 아니할 수 있으며, 이 경우 명세서에 그 미생물의 입수방법을 적어야 한다(습 3).¹⁰⁶⁾

2. 그 밖의 특허요건

산업적 규모로 생산되어 산업에 실제로 이용가능성이 있어야 산업상 이용가능성이 있으며, 미생물 자체 발명의 경우 성질이 신규성 판단의 기준이 되며, 미생물을 이용하는 발명은 이용한 미생물의 사회일반에 대한 공지 여부가 신규성 판단의 기준이 된다. 한편 미생물 발명의 진보성은 공지의 종으로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명가능한지를 판단하며, 미생물의 성질과 특유의 효과를 고려하여 판단한다. 그 밖의 미생물발명이 특허를 받기 위해서는 확대된 선출원(法 29③), 선출원주의(法 36) 등 제62조의 거절이유에 해당하지 아니하여야 한다.

3. 미생물의 분양 및 이용금지

(1) 미생물의 분양

기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 총리령¹⁰⁷⁾으로 정하는 바에 따라 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다(습 4①②).¹⁰⁸⁾

- i) 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우
- ii) 제63조제1항(제170조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 의견서를 작성하기 위하여 필요한 경우
- iii) 미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 경우

(2) 제3자의 이용금지

미생물을 분양받은 자는 그 미생물을 타인에게 이용하게 해서는 아니 된다(습 4③).

105) 대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003.

106) 「쉽게 입수할 수 있는 미생물」로는 i) 시중에서 판매되고 있는 미생물, ii) 그 출원 전에 신용할 수 있는 보존기관에 보존되며 보존기관이 발행하는 카탈로그 등에 의하여 자유롭게 분양될 수 있는 사실이 확인된 미생물(이 경우 해당 미생물의 보존기관, 보존번호를 출원 시 명세서에 기재하여야 한다), iii) 명세서의 기재에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 제조할 수 있는 미생물 등이 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 2603-2604면).

107) 구체적으로 미생물의 분양을 받으려는 자는 미생물분양자격 증명신청서에 i) 기탁기관에 제출할 분양신청서, ii) 분양사유에 해당함을 소명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다(施規 23).

108) 특허출원이 공개된 경우에는 제3자에게 정보제공 기회를 주기 위해, 설정등록된 경우에는 제3자에게 특허취소신청, 특허무효심판청구의 기회를 주기 위해 분양받을 수 있도록 하고 있다. 다만 출원공개된 이후에는 계속적으로 분양받을 수 있기 때문에 「설정등록된 경우」란 출원공개되지 않고 설정등록된 경우를 말한다.

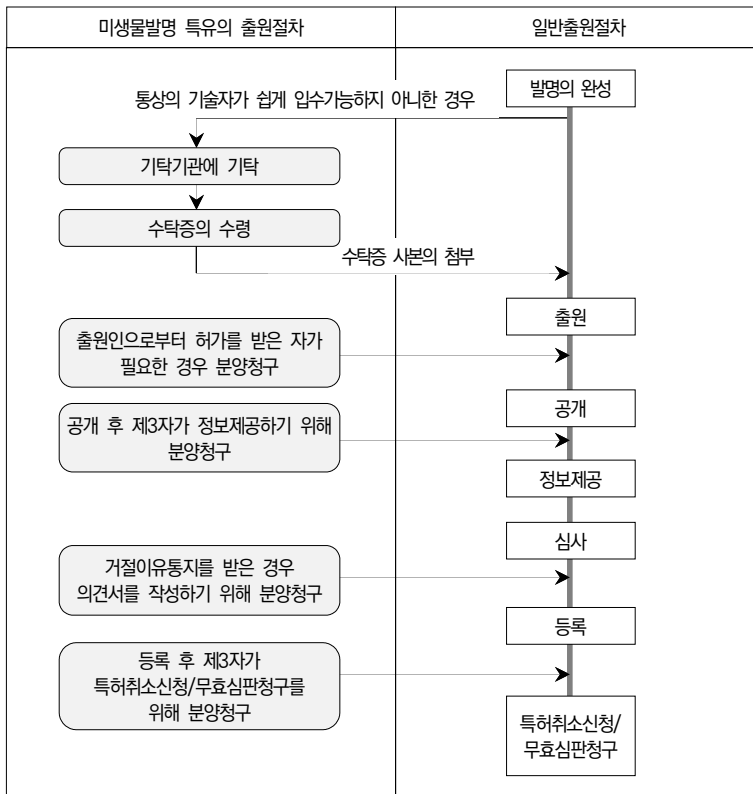
Ⅲ. 특허권의 효력

1. 적극적·소극적 효력

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하며(法 94①), 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로 실시하는 경우 특허권자는 침해를 이유로 민·형사상 제재를 할 수 있다.

2. 연장된 특허권의 효력

미생물 발명이 의약품, 농약 또는 농약원제의 발명으로서 허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 장기간 실시할 수 없는 경우에는 5년의 기간까지 그 미생물 특허권의 존속기간을 한 차례만 연장할 수 있다(法 89).



【그림 1-7】 일반출원과 미생물출원의 비교

제4관 그 밖의 발명

I. 식물발명

1. 식물발명의 특허법상 보호

WTO/TRIPs 제27조제3항의 규정에서는 식물변종의 발명에 관해서는 불특허대상으로 할 수 있되 이를 불특허대상으로 한 경우에는 특별법으로 보호하여야 함을 의무화하고 있다. 이에 구법 제31조에서는 “무성적으로 반복생식할 수 있는 변종식물을 발명한 자는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다”라고 규정하는 한편 식물신품종보호법에 의하여 식물품종을 보호하고 있었다. 다만 현대 과학기술의 발달에 따라 유성변식식물이라도 유전공학적인 방법으로 반복생식할 수 있다면 특허법의 테두리 안에서 보호할 필요가 있으므로 2006. 10. 1. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정)에서는 제31조를 삭제하였다.

【표 1-7】 식물발명의 특허법과 식물신품종보호법에 의한 보호의 비교

구 분		특 허 법	식물신품종보호법
보호 대상	유성변식식물	○	식물의 품종 ○
	무성변식식물	○	
	유전자	○	×
	식물세포	○	×
	육종방법	○	×
등록요건	· 신규성, 진보성, 반복가능성, 산업상 이용가능성		· 신규성, 구별성, 균일성, 안정성, 품종의 명칭
보호시기	· 1946년부터		· 1997년부터
비 고	· 특허제도(특허법)와 식물신품종보호제도(식물신품종보호법)는 보호대상, 등록요건 등이 서로 다른 상호 독립된 제도로써 일방의 제도가 적용되면 타방의 제도가 불필요한 것이 아니라 양 제도는 상호 보완의 관계에 있음 · 식물신품종보호제도는 각각의 식물품종 그 자체만이 해당하나, 일반적인 개념의 식물, 육종 방법, 식물유전자 등의 식물관련 기술은 특허제도에 의해서만 보호될 수 있음		

2. 식물발명의 특허요건

식물발명이 특허를 받기 위해서는 일반적인 특허요건을 만족하여야 하며, 제62조의 거절이유에 해당하지 아니하여야 한다. 특히 제29조제1항의 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하기 위해서는 출원발명이 완성된 발명이어야 할 것이고, 발명으로서 완성되었다고 하려면 통상의 기술자가 반복 실시할 수 있고, 발명이 목적하는 기술적 효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있어야 한다.¹⁰⁹⁾ 통상의 기술자가 이 사건 출원발명을

109) 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523 참조.

반복하여 실시할 수 있다는 의미는 통상의 기술자가 동일한 육종소재를 사용하여 동일한 육종 과정을 반복하면 명확히 동일한 식물을 재현시킬 수 있다는 것을 말한다.¹¹⁰⁾ 한편 식물발명 역시 필요한 경우 천식물 또는 종자, 세포 등을 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 기탁할 수 있으나, 그 결과물인 식물 또는 식물소재를 기탁함으로써 명세서의 기재를 보충하거나 그것을 대체할 수 없다.¹¹¹⁾

3. 식물신품종 보호에 관한 조약의 가입

우리나라는 2002년 1월 7일 50번째로 식물신품종 보호에 관한 조약(International Union for the Protection of New Varieties of Plants : UPOV)에 가입하였다. 그 결과 UPOV 신규 회원국인 우리나라는 가입한 그해에 15개 이상의 작물을, 10년 후에는 모든 작물에 대하여 「품종보호제」를 실시하여야 한다. 또한 등록된 품종에 대하여 품종개발자는 「품종사용료」를 요구할 수 있으며, 그 품종을 사용하는 농가는 사용료를 지불하여야 한다.

II. 동물발명

동물발명에 대하여 특허를 허용할 것인지에 대해서는 특허법상 규정이 없다. 그러나 오늘날 유전공학의 발달과 더불어 기술적 창작으로서 새로운 동물의 창작이 가능하므로 일률적으로 특허권을 부정할 것이 아니라 제32조의 공서양속에 어긋날 우려가 있는지에 따라 구체적으로 판단하여야 할 것이다.

110) 특허법원 2002. 10. 10. 선고 2001허4722.

111) 배 신품종에 속하는 식물에 관한 출원발명을 실시하기 위해서는 반드시 출원발명에서와 같은 특징을 가진 돌연변이가 일어난 배나무가 있어야 하고 그 다음 그 배나무 가지 또는 배나무의 눈을 이용하여 아접에 의하여 육종함으로써 그 목적을 달성할 수 있는 것인바, 출원발명의 명세서에는 그 출발이 된 배나무와 같은 특징을 가지고 있는 배나무 가지를 돌연변이시키는 과정에 대한 기재가 없고, 또 자연상태에서 그러한 돌연변이가 생길 가능성이 극히 희박하다는 점은 자명하므로, 그 다음의 과정인 아접에 의한 육종과정이 쉽게 실시할 수 있다고 하더라도 출원발명 전체는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 재현할 수 있을 정도로 기재되었다고 할 수 없어 결국 출원발명은 그 명세서의 기재불비로 인하여 특허법 제42조제3항제1호에 따라 특허를 받을 수 없다(대법원 1997. 7. 25. 선고 96후2531).

제3절 발명의 종류

제1관 물건발명과 방법발명

제2조 【정의】

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.
2. “특허발명”이란 특허를 받은 발명을 말한다.
3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다. <개정 2019. 12. 10., 2025. 1. 21.>
 - 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위
 - 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위
 - 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「물건발명」이란 기술적 사상의 창작이 물건 자체에 구체화된 발명을 말하며, 「방법발명」이란 일정한 목적을 향한 관련성이 있는 복수 개의 행위 또는 현상이 시계열적으로 구체화된 발명을 말한다.

2. 종 류

물건발명에는 i) 기계, 기구, 장치 등과 같이 유형적인 것으로서 그 구성요소가 상호 간에 일정한 관계를 갖고 배열 결합하여 공간적인 구성을 이루고, 이 배열 결합으로 기술적 효과를 얻을 수 있는, 즉 물품성이 있는 「협의의 물건발명」과 ii) 화학물질, 조성물, 음식물, 의약품 등과 같이 물품성이 없는 「물질발명」이 있다. 한편 방법발명에는 i) 「물건을 생산하는 방법발명(제법발명)」과 ii) 통신방법, 측정방법, 제어방법 등과 같이 물건의 생산을 수반하지 아니한 「통상의 방법발명」이 있다.

II. 구별기준

물건발명과 방법발명의 구별은 발명의 명칭이나 청구범위의 표현에 따라 결정되는 것이 아니라 발명의 실체에 따라 정하여진다. 구체적으로 발명의 실체가 「時の 요소」를 발명구성상의 필수요건으로 하는 때에는 방법발명으로 보고, 이와 같은 「時の 요소」를 필요로 하지 아니한 것일 때에는 물건발명으로 보는 것이 원칙이다. 예를 들어 「A 와 B 로 구성된 것을 특징으로

하는 물건」과 「B 와 A 로 구성된 것을 특징으로 하는 물건」은 동일한 물건발명이지만, 「X 공정 후 Y 공정을 거치는 물건의 제조방법」과 「Y 공정 후 X 공정을 거치는 물건의 제조방법」은 구성요소 사이의 時의 흐름이 변화되었기 때문에 동일한 방법발명이라 할 수 없다.¹¹²⁾

Ⅲ. 구별실익

1. 특허요건의 판단

(1) 물건발명과 제법발명/용도발명의 신규성, 진보성 판단

물건발명과 제법발명/용도발명은 1 대 多의 관계에 있다. 즉 하나의 물건을 만드는 제법발명 또는 용도발명은 수없이 많이 존재한다. 따라서 물건발명이 신규성 또는 진보성이 있는 경우 제법발명 또는 용도발명은 당연히 신규성 또는 진보성이 있다. 반면 물건발명이 신규성 또는 진보성이 없는 경우 제법발명 또는 용도발명은 개별적으로 신규성 또는 진보성 여부를 판단하여야 한다.

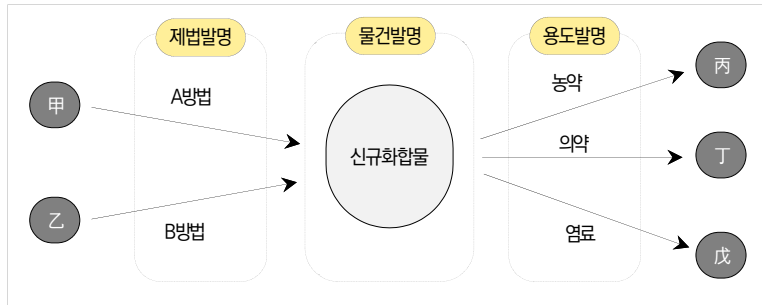
(2) 물건발명과 제법발명의 병존가능성

1) 물건발명(이하 “物”이라 한다)과 제법발명(이하 “方1”이라 한다)의 병존 가능성에 대하여 살펴보면, 하나의 物에 대해서는 수없이 많은 물건을 생산하는 방법의 발명이 존재할 수 있다. 그 결과 物과 方1을 각각 청구범위에 기재하여 특허출원하는 경우 方1의 발명의 설명에는 物이 반드시 기재되어야 하지만, 物의 발명의 설명에는 方1이 아닌 다른 제법발명이 기재될 수 있다. 따라서 方1이 선출원이고 物이 후출원이면 후출원인 物은 제29조제1항 각호의 신규성 또는 제29조제3항 및 제4항의 확대된 선출원 위반으로 특허를 받을 수 없게 된다. 또한 후출원인 物은 方1과 발명의 표현을 달리하여 범주가 다르지만 실질적 동일성이 있으므로 선출원주의 위반이기도 하다. 만약 동일성이 없다면 方1보다 특허권의 효력이 강한 物이 등록되어 方1의 실시에 대하여 침해를 주장할 수 있게 되어 부당하기 때문이다.

2) 한편 物이 선출원이고 方1이 후출원이면 후출원인 方1은 物과 동일성이 없어 선출원주의 위반이 아니다. 方1이 등록되더라도 그 제조방법의 사용에 의하여 생산된 물건에 대해서만 효력이 미치게 되고, 이미 공지된 기존의 제조방법에 사용에 의하여 생산된 物에 대해서는 침해를 주장할 수 없어 기존의 제조방법을 실시하여 그 물건을 생산, 판매하고 있는 자를 제한하지 않기 때문이다. 따라서 物 출원의 발명의 설명에 기재된 제법발명과 方1이 다른 경우 특허를 받을 수 있다. 물론 이 경우에도 物 출원의 공개 시가 方1의 출원 시보다 빠르다면 제29조제2항의 진보성을 검토해 보아야 한다.

112) 방법발명이라 함은 특정한 목적을 달성하기 위한 시간상의 일련의 연속적인 단계들로 이루어진 발명으로서, 방법발명에서는 개별 구성요소의 배치 순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있으므로, 개별 구성요소의 시계열적인 배치 순서 역시 발명의 중요한 요소로 보아야 한다. 따라서 이 사건 제2항 발명과 선행발명 1은 앞서 본 바와 같이 ‘압착’과 ‘건조’의 구성요소의 시계열적인 배치 순서에 차이가 있어 그 구성이 다른 것으로 봄이 상당하다(특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874).

3) 物 출원과 方1 출원이 동일자 출원이면 양 발명이 실질적으로 동일한 경우를 제외하고는 양자 모두 등록될 수 있다.



【그림 1-8】 물건발명, 제법발명 및 용도발명의 상관도

2. 실시의 유형 및 특허권의 효력

(1) 실시의 유형

특허법은 제2조제3호에서 물건발명, 단순한 방법발명 및 물건을 생산하는 방법발명의 실시 유형을 달리 규정하고 있다. 구체적으로 i) 물건발명인 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위, ii) 방법발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위, iii) 물건을 생산하는 방법발명(제법발명)인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 실시행위로 본다.

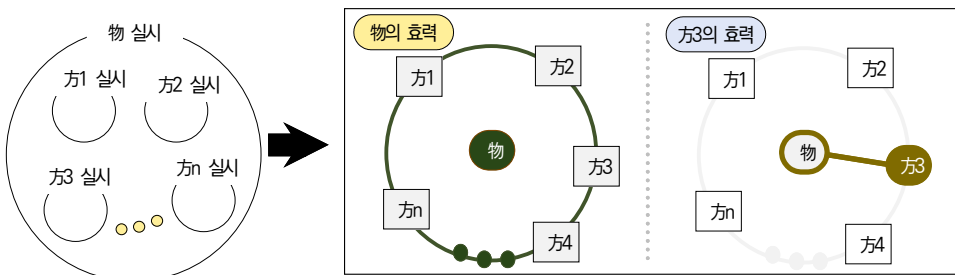
(2) 특허권의 효력 및 생산방법의 추정

1) 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(法 94①). 그런데 발명의 종류에 따라 실시의 유형이 달라지기 때문에 특허권의 효력범위에도 차이가 있다. 예를 들어 제법발명의 실시는 그 방법을 사용하는 행위(즉 물건을 생산하는 행위) 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위와 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위인데, 이는 그 방법의 사용(물건생산)을 청약하는 행위를 제외하고는 물건발명의 실시에 포함된다.¹¹³⁾ 따라서 물건발명에 대한 특허권의 효력이 제법발명에 대한

113) 제2조제3호(나)목의 개정으로 제2조제3호(다)목의 물건을 생산하는 방법발명(제법발명)의 실시는 i) 물건을 생산하는 방법을 사용하는 행위(물건의 생산), ii) 물건을 생산하는 방법의 사용(물건의 생산)을 청약하는 행위, iii) 물건을 생산하는 방법에 의하여 생산된 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위로 구분될 수 있다. 그런데 새로 도입된 ii)의 행위(물건생산의 청약)와 관련하여, 특허법에서 양도 또는 대여의 청약을 전제로 하지 않는 생산만의 청약이라는 개념을 상정할 수 있는지, 또한 설사 그러한 개념을 상정할 수 있다고 할지라도 ii)의 행위는 제2조제3호(가)목의 물건발명

특허권의 효력보다 강하다. 구체적으로 물건발명에 대하여 특허권이 설정등록되었는데 제3자가 제법발명을 실시한다면 물건발명에 대한 특허권의 침해가 된다.¹¹⁴⁾ 그러나 제법발명에 대하여 특허권이 설정등록되었는데 제3자가 물건발명을 실시한다고 하여 항상 제법발명에 대한 특허권의 침해가 되는 것은 아니다. 즉 특허받은 방법이 아닌 다른 방법에 의하여 물건을 생산하고 그 생산된 물건의 양도 등을 할 때는 제법발명의 실시가 아니기 때문에 제법발명에 대한 특허권의 침해가 아니다.

2) 다만 물건을 생산하는 방법의 특허출원 전에 그 물건이 i) 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건 또는 ii) 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건이 된 경우가 아니라면 물건을 생산하는 방법에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허받은 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다(法 129). 이는 신규의 동일물은 동일한 방법에 의하여 생산될 것이라는 개연성이 높다는 경험칙에 따라 신규의 동일물이면 동일한 방법에 의하여 생산된 것으로 법률상 추정케 함으로써 증명책임을 전환(法 129)하여 특허권자를 증명의 곤란에서 구제하려는 점에서 의의가 있다. 이 경우 제3자는 다른 방법에 의하여 물건을 생산하고 있다는 것을 증명함으로써 특허권자의 침해주장에서 벗어날 수 있다.



【그림 1-9】 제법발명과 물건발명의 실시 및 효력범위

(3) 허락 또는 통상실시권허락심판의 청구

물건발명이 선출원이고 제법발명/용도발명이 후출원이면 양자 모두 등록될 수 있다. 다만 제법발명/용도발명을 실시하는 경우 물건발명의 실시(제법발명의 경우 물건생산을 청약하는 행위 제외)가 되어 물건발명에 대한 특허권의 침해가 된다. 이 경우 제법발명/용도발명의 특허권자는 물건발명에 대한 특허권자의 허락을 받거나(法 98) 통상실시권허락심판(法 138)에 의하는 등 정당한 권원을 획득하지 아니하고는 제법발명/용도발명을 실시할 수 없다.

실시에 포함되지 않은 행위인데 제법발명의 실시가 물건발명에 대한 특허권의 침해가 되지 않는 것이 적절한지 여부 등이 검토되어야 할 것이다. 사건으로는 입법불비라고 판단되며, 제2조제3호(다)목을 “물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위나 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위”로 개정하여, 제법방법의 실시에서 ii)의 행위를 배제함이 적절하다고 여겨진다.

114) 대법원 2022. 01. 14. 선고 2019후11541 판결 참조.

3. 도면의 첨부

협회의 물건발명의 경우 도면을 첨부하고 발명의 설명에 도면의 간단한 설명을 적어야 한다. 그러나 방법발명 또는 물질발명의 경우 필요한 경우에만 도면을 첨부하고 도면의 간단한 설명을 적으면 된다. 그러므로 제42조제2항에서는 특허출원할 때 첨부서류의 하나로써 「도면」이 아닌 「필요한 도면」이라고 표현하고 있다. 한편 도면을 첨부하지 아니한 경우 도면의 간단한 설명을 적지 아니하여도 된다.

4. 실용신안법의 보호대상

실용신안등록을 받기 위해서는 물품의 형상, 구조 또는 그 조합에 관한 고안, 즉 물품성이 있는 고안이어야 한다(實用 4①). 따라서 물품성이 있는 협회의 물건발명 경우에만 물질발명이나 방법발명과 달리 실용신안으로 보호받을 수 있다.¹¹⁵⁾

제2관 실무상·강학상 발명의 구별

I. 기본발명과 개량발명

1. 구별기준

「기본발명」이란 그 발명이 속하는 기술분야에서 기술문제의 해결을 위한 기초적인 발명을 말하며 개척(원천)발명(Pioneer Invention)이라고도 한다. 한편 「개량발명」이란 기본발명에 대한 기술적 흠결을 해결한 발명을 말한다. 즉 기본발명과 개량발명은 기술적 성질에 따라 구별된다.

2. 구별실익

특허권은 출원 시의 공지기술과 비교하여 개량진보를 가져와 산업의 발전에 기여한 것에 대한 대가로 부여되는 것이기 때문에 출원 시의 기술수준 내지는 그 개량의 정도를 고려하여 특허발명의 보호범위를 결정하는 것은 지극히 당연한바, 이를 「공지기술참작의 원칙」이라 한다. 따라서 기본발명은 개량발명과 비교해 발명적 기여가 크고 발명이 포괄하는 기술적 범위도 넓으므로 그 보호범위를 넓게 해석하여 균등물, 균등수단이 인정되는 폭도 넓게 인정된다.¹¹⁶⁾

115) 협회의 물건발명과 물질발명/방법발명의 구별실익은 다음과 같다.

구 별	실용신안보호대상	도면 첨부
협회의 물건발명	○(·: 물품의 형상·구조·조합에 관한 고안)	필수
물질발명/방법발명	×	선택

116) 어떠한 기술적 과제의 해결수단이 다수 밀집되어 있는 기술분야일수록 과제 해결원리의 공통 내지 동일성의 폭은 좁아질 수밖에 없다(특허법원 2007. 6. 22. 선고 2007허1008).

II. 독립발명과 종속발명

1. 구별기준

1) 「독립발명」이란 다른 발명을 실시할 필요가 없이 자신의 발명을 실시할 수 있는 발명을 말하며, 「종속발명」이란 다른 발명을 실시하지 않으면 자신의 발명을 실시할 수 없는 발명을 말한다.

2) 종속발명에는 발명의 범주(카테고리)가 다른 경우와 발명의 범주가 같은 경우가 있다. 발명의 범주가 다른 경우란 선행발명이 물건발명이고 본원발명이 「제법발명」인 경우를 말한다. 발명의 범주가 같은 경우에는 본원발명이 선행발명에 다른 구성요소를 부가하여 선행발명의 이용분야를 외연적으로 확장한 「결합발명」인 경우와 선행발명을 상위개념으로 하여 그 하위개념적인 범위에서 선행발명의 인식 이외의 새로운 작용효과를 알아내거나 기술문제를 독립적으로 해결한 「선택발명」인 경우가 있다.

2. 구별실의

종속발명에 대한 특허권자는 독립발명에 대한 특허권자와는 달리 선행발명에 대한 특허권의 침해가 되지 않으려면 원칙적으로 선행발명에 대한 특허권자의 허락을 받거나(法 98), 통상실시권허락심판(法 138)에 의하는 등 정당한 권원을 획득하여 실시하여야 한다. 다만 통상실시권허락심판(法 138)의 청구는 종속발명이 특허등록되어 이용관계가 성립되는 경우에만 가능하다.

3. 제법발명

(1) 의 의

「제법발명」이란 선행발명인 물건을 생산하는 방법에 대한 발명을 말한다.

(2) 제법발명의 출원에 대한 등록가능성 판단

제법발명은 선행발명인 물건발명과 동일성이 없다. 따라서 기존의 물건을 생산하는 방법과 다른 발명이라면 진보성이 인정됨을 전제로 등록받을 수 있다. 하나의 물건발명을 제조하는 방법을 수없이 많이 존재하는데 기존의 제조방법을 개량한다면 이에 대한 특허를 부정할 이유가 없기 때문이다.

(3) 제법발명의 실시에 대한 침해 판단

제법발명의 실시(물건생산을 청약하는 행위는 제외)는 선행발명인 물건발명에 대한 특허권의 침해가 된다. 제법발명의 실시는 그 방법을 사용하는 행위(즉 물건을 생산하는 행위) 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위와 그 방법에 의하여 생산된 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위인데, 이는 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 제외하고는 물건발명의 실시에 포함되기 때문이다.

4. 결합발명

(1) 의 의

「결합발명」이란 하나의 기술적 문제해결을 위하여 여러 개의 장치 또는 수단·방법 등 기술적 사상을 결합한 발명을 말한다.

(2) 결합발명의 출원에 대한 등록가능성 판단

1) 결합발명은 선행발명에 구성요소를 더 부가한 것으로 일반적으로 선행발명과 동일성이 없으므로 신규성은 인정되나, 진보성에 위반되는지가 문제이다. 결합발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 발명은 전체로서 고려되어야 하며 구성요소 각각이 공지 또는 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정할 수 없다. 즉 청구항에 기재된 발명의 과제해결원리를 배제한 채 청구항에 기재된 구성을 하나하나 분해한 후 선행기술의 대응 구성요소로부터 도출이 곤란한지만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제해결원리에 기초하여 그 발명에 채용된 특유한 구성요소들과 나머지 구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 진보성을 살펴보아야 한다.¹¹⁷⁾

2) 결합발명은 진보성 여부에 따라 공지기술의 단순한 집합인 「주합발명(agggregation)」과 공지기술의 새로운 결합인 「조합발명(combination)」으로 구별될 수 있다. 주합발명(agggregation)은 조합발명(combination)¹¹⁸⁾과 달리 진보성이 없어서 등록될 수 없다는 점에서 차이가 있다. 구체적으로 여러 공지기술을 인용하여 특허의 진보성을 판단할 때 그 인용되는 공지기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 교시(teaching), 암시(suggesting), 동기(motivation) 등이 공지기술에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 해당 특허출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 조합 또는 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 주합발명으로서 진보성이 부정된다.¹¹⁹⁾

(3) 결합발명의 실시에 대한 침해 판단

결합발명의 실시가 선행발명에 대한 특허권의 침해인지 여부와 관련하여 촉매부가발명을 예로 들어 설명하면, 종래의 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결에서는 촉매의 부가로 인해 작용효과상의 우월성이 있다면 후출원 특허발명이 선행발명을 이용하지 아니한다고 판시하였다. 그러나 이는 특허요건의 판단과 침해 여부판단을 혼동하는 것으로서 현저한 효과로 인해 진보성(法 29②)에 위반되지 아니하여 등록되더라도 일체성을 상실하지 않았다면 침해, 즉 이용발명으로 봄이 타당하다. 이와 관련하여 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결에서 “화학반

117) 대법원 2010. 9. 9. 선고 2009후1897.

118) 공지공용의 기술을 결합한 고안이라고 할지라도 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과와 단순한 집합이 아니라 결합 전과 비교하여 증진된 작용효과가 인정되고 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 손쉽게 이를 실시할 수 없을 때에는 신규성 및 진보성이 있는 고안이라 할 것이다(대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990; 2003. 1. 10. 선고 2001후2269 등).

119) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3277; 2009. 7. 9. 선고 2008후3377.

응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성요소의 일체성, 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다”라고 판시하여 종전의 대법원판결의 잘못된 점을 바로 잡고 있다.

5. 선택발명

(1) 의 의

1) 「선택발명」이란 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명으로서, 선행 또는 공지의 발명에는 직접적으로 개시되어 있지 아니한 사항을 선택한 발명을 의미한다. 예를 들어 선행발명 A의 명세서 본문에는 a1, a2에 대하여만 개시되어 있었는데, 후에 A의 개념에 포함되는 a3을 선택하였을 때 a3의 발명을 선택발명이라 한다.

2) 형식적으로 본다면 선택발명은 선행발명과 중복특허가 되는 것이기 때문에 특허성을 인정할 수 있을지에 대하여 의문이 들 수 있다. 그러나 i) 특허법의 보호대상인 발명은 기술이 아닌 기술적 사상인데 새롭게 개척된 영역을 선택하는 것 자체가 하나의 기술적 사상이라 할 수 있으며, ii) 선행발명의 개시를 넓게 하여 발명활동을 장려하고, 해당 선행발명을 적은 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지 아니한 유익한 발명에 특허권을 부여함으로써, 선행발명의 활발한 활용을 촉진하는 것이 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지한다는 특허법 목적에 부합하므로 선택발명의 특허성을 인정하고 있다.¹²⁰⁾

(2) 선택발명의 출원에 대한 등록가능성 판단

1) 선택발명이 특허등록을 받기 위해서는 일반적인 발명으로서의 특허요건을 구비하여야 하는데 그 중 특히 신규성, 진보성에 위반되는지가 문제이다. 먼저 신규성에 위반되지 않기 위해서는, 선행발명이 선택발명을 구성하는 그 하위개념을 구체적으로 개시하지 않고 있어야 하고, 「개시」에는 선행발명을 적은 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.¹²¹⁾

120) 박길채, “특허법상 정정의 요건에 관한 소고”, 지적재산21, 2004년 5월, 77-78면.

121) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736; 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 등.

2) 다음으로 진보성에 위반되지 않기 위해서는, 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 공지된 상위개념인 선행발명과 비교하여 구성의 곤란성이 인정되어야 한다. 구성의 곤란성이 인정되는지와 관련해서는 i) 상위개념의 크기, ii) 선행발명이 선택발명을 선택할 동기를 제공하거나 선행발명에 암시가 있는지, iii) 선행발명에 기재된 하위개념발명과 선택발명이 구조적으로 유사한지 아닌지 등이 고려되어야 한다.¹²²⁾ 다만 구성의 곤란성을 따져보지 않고 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단해서는 안 된다.

3) 한편 선택발명의 진보성을 판단할 때는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동기나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 실질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고,¹²³⁾ 만일 그 효과가 의심스러울 때는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.¹²⁴⁾

4) 하나의 청구항에 여러 개의 하위개념을 포함하는 선택발명이 있는 경우 효과의 현저성이 인정되기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 진보성이 인정되어야 한다.¹²⁵⁾ 한편 효과의 현저성에 의하여 진보성을 판단할 때 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명과 비교하여 실질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그중 일부라도 선행발명과 비교하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다.¹²⁶⁾

(3) 선택발명의 실시에 대한 침해 판단

선택발명의 실시가 선행발명에 대한 특허권의 침해인지 여부와 관련하여, 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960 판결에서는 선택발명이 특허발명과 비교하여 현저히 향상된 작용효과 있는 경우

122) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609.

123) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234.

124) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609.

125) 선택발명에 포함되는 하위개념의 실시형태 중 가장 열등한 것의 효과가 선행발명에 개시된 실시형태 중 가장 우수한 것의 효과와 비교하여 현저하다는 관계가 인정되지 않는다면, 선택발명에 포함되는 하위개념의 실시형태 중 일부의 효과가 선행발명에 개시된 실시형태 중 일부의 효과보다 뛰어나 보인다고 하여 선택발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 볼 수는 없다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2013후1887).

126) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424.

확인대상발명은 특허발명과 다른 발명으로서 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다. 다만 특허발명의 보호범위는 그 배타적 효력이 미치는 범위를 어떻게 설정하느냐의 문제이고, 침해 대상으로 거론되는 선택발명이 특허요건을 갖추어 선행발명인 특허발명과 별개의 권리로서 성립할 수 있느냐의 문제와는 무관한 것으로서, 선택발명이 그 기본이 되는 선행발명의 기술적 사상을 그대로 이용하고 있으며 일체성이 상실되지 않았다면 특허발명의 침해로 보아야 할 것이다.

III. 단독발명과 공동발명

1. 구별기준

1) 「단독발명」이란 발명의 완성을 1명이 한 발명을 말하며, 「공동발명」이란 2명 이상의 자연인이 실질적으로 협력하여 함께 완성한 발명을 말한다. 공동발명자가 되기 위해서는 이루는 기술적 사상의 창작에 실질적 협력하였다는 객관적 요건과 상호 협력하여 발명행위를 수행한다는 주관적 요건이 필요하다.¹²⁷⁾ 「실질적 협력」이란 발명의 착상단계에서 구체화하는 단계에 실질적으로 관여하는 것을 의미한다. 따라서 단순한 보조자, 관리자, 위탁자, 자본주 등은 공동발명자가 되지 못한다.¹²⁸⁾ 이처럼 단독발명과 공동발명은 발명의 주체에 따라 구별된다.

127) 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, i) 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, ii) 연구자를 일반적으로 관리하였거나, iii) 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, iv) 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, i) 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, ii) 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, iii) 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 그 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정하여야 한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178). 공동발명자에 해당하는 자와 해당하지 아니한 자의 구체적인 예는 다음과 같다.

구 분	내 용
발명자에 해당하는 자	- 어떤 문제를 해결하기 위한 기술적 수단을 착상한 자 - 타인의 착상에 의거 연구를 하여 발명을 완성하게 한 자 - 타인의 착상에 대하여 구체화하는 기술적 수단을 부가하여 발명을 완성한 자 - 구체화하기 위해서 약간 불완전한 착상을 하고 타인에게 일반적인 지식의 조언 또는 지도를 얻어 발명을 완성한 자 - 타인의 발명에 힌트를 얻고 다시 그 발명의 범위를 확대하는 발명을 한 자 - 화학발명의 경우 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여한 자
발명자에 해당하지 아니한 자	- 발명자에게 자금을 제공하거나 설비이용의 편의를 주는 등 발명의 완성을 원조하거나 위탁한 자(단순후원자, 위탁자) - 희망조건만 제시하고 그것을 해결할 착상을 제공하지 아니한 자 - 타인이 제시한 착상 속에서 실용성이 있을 것을 선택한 것에 지나지 아니한 자 - 그 발명에 관하여 착상만 하고 구체화하는 과정에서 실질적으로 관여하지 아니한 자 - 발명의 과정에서 연구자의 지시로 단순히 데이터를 정리하거나 제시된 제도, 실험 등을 한 것에 지나지 아니한 자(단순보조자) - 단지, 일반 지식의 조언 또는 제시를 주기만 한 자 - 구성을 변경했지만 기술적 사상의 창작에 기여하지 않은 자

2) 공동발명이 되는 경우는 하나의 발명을 기준으로 판단하는 경우와 하나의 출원을 기준으로 하는 경우가 있다. 예를 들어 $x+y$ 로 구성된 발명 중 甲이 구성요소 x 의 착상과 구현에 관여하고, 乙이 구성요소 y 의 착상과 구현에 관여하였으면 甲과 乙이 공동발명자가 되고, 청구항 1에 기재된 A발명과 청구항 2에 기재된 B발명 중 丙이 A발명을 하고 丁이 B발명을 한 경우 丙과 丁 역시 공동발명자가 된다.

2. 구별실익

공동발명의 경우에는 단독발명의 경우와는 달리 권리의 양도·질권설정시 다른 공유자의 동의를 얻도록 하고 있다. 구체적으로 공동발명을 하면 특허를 받을 수 있는 권리가 공유이며(法 33②), 공동출원하여야 한다(法 44). 또한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있고(法 37③), 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있으며, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(法 99②④).

IV. 대발명과 소발명

1. 구별기준

「대발명」이란 특허법상 보호대상인 발명을 말하며, 「소발명」이란 실용신안법상 보호대상인 고안을 말한다.

2. 구별실익

대발명은 특허출원과 실용신안등록출원 중 택일할 수 있으나, 소발명의 경우에는 실용신안 등록출원을 하여야 하며 특허출원을 할 때는 일반적으로 제29조제2항의 진보성 위반으로 특허를 받을 수 없다.

128) 미국 특허법에서는 공동발명자로 인정되기 위해서는 우선 i) 2명 이상의 복수인이 발명의 완성에 참여하여야 하고, ii) 동일한 산업상 이용분야에서의 일정한 기술문제 해결을 위한 연구가 있어야 하며, iii) 실질적인 상호 협력이라는 공통인식이 있어야 한다(공동발명자의 3요소). 이러한 공동발명자로서 인정되기 위한 요건을 갖추는 한, 비록 공동발명자가 물리적으로 함께 또는 동시에 연구하지 않았거나, 동종 또는 대등한 기여(contribution)를 하지 아니한 때 혹은 청구항의 주제(subject matter)에 관하여 기여하지 아니한 때라도 공동발명자로 보고 있다(미국 특허법 제116조 후단).

제5장

행위능력, 대리인 및 대표자

제1절 행위능력

제3조 【미성년자 등의 행위능력】

- ① 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차(이하 “특허에 관한 절차”라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 제132조의2에 따른 특허취소신청(이하 “특허취소신청”이라 한다)이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제4조 【법인이 아닌 사단 등】

법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 출원심사의 청구인, 특허취소신청인, 심판의 청구인·피청구인 또는 재심의 청구인·피청구인이 될 수 있다.

<개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제5조 【재외자의 특허관리인】

- ① 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자(이하 “재외자”라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 “특허관리인”이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다.
- ② 특허관리인은 위임된 권한의 범위에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제7조의2 【행위능력 등의 흠에 대한 추인】

행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자나 법정대리인이 추인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

「특허법상 행위능력(절차능력)」¹²⁹⁾이란 당사자로서 스스로 유효하게 특허에 관한 절차상의 행위를 하거나 그 효과를 받을 수 있는 능력을 말한다. 특허법은 행위능력이 제한된 제한능력자를 보호하는 한편 특허에 관한 절차의 명확화 및 안정을 위하여 행위능력에 관한 규정을 두고 있다. 구체적으로 특허법은 행위능력에 관하여 국내에 주소 또는 영업소를 가지고 있는 자(이하 “재내자”라 한다)와 국내에 주소 또는 영업소를 가지고 있지 아니한 자(이하 “재외자”라 한다)로 구분하여 달리 취급하고 있는바, 이하 구체적으로 살펴본다.

II. 재내자의 행위능력

1. 원 칙

특허법상 행위능력은 민사소송법상의 소송능력에 대응되는 개념이므로, 민사소송법 제51조의 “당사자능력, 소송능력, 소송무능력자의 법정대리와 소송행위에 필요한 권한의 수여는 이 법에 특별한 규정이 없으면 민법, 그 밖의 법률에 따른다”를 유추 적용할 수 있다. 따라서 민법상 행위능력을 가지는 만 19세의 성년에 달한 자로서 피한정후견인, 피성년후견인이 아닌 자나 법인은 원칙적으로 특허법상 행위능력을 가진다.

2. 문제되는 경우

(1) 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인의 경우

미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차(이하 “특허에 관한 절차”라 한다)를 밟을 수 없다. 다만 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다(法 3①).¹³⁰⁾ 미성년자, 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우로서 특허에 관한 절차와 관련하여 예상되는 행위는 영업에 관한 행위와 만 19세에 달하지 않았으나 혼인하여 성년으로 의제된 자의 행위 등이 있을 수 있다. 한편 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 않고는 직접 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다.

129) 우리 특허법은 행위능력이라는 용어를 사용하고 있으나 행위능력 유무의 문제가 주로 특허에 관한 절차의 유·무효 여부에서 발생한다는 점을 감안할 때 실체법상 용어인 행위능력보다는 절차능력이라는 용어를 사용하는 것이 타당해 보인다.

130) 제한능력자가 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우로는 권리만 받거나 의무만 면하는 행위(民法 5①), 처분이 허락된 재산의 처분행위(民法 6), 영업의 허락을 받은 경우 그 영업에 관한 행위(民法 8①), 대리행위(民法 117), 유언행위(民法 1062), 무한책임 사원으로서 한 행위(商法 7) 등이 있다.

(2) 비법인 사단·재단의 경우

「비법인 사단·재단」이란 법인설립등기 등을 하지 아니하여 법인격을 부여받지 못한 단체로 종친회, 동창회, 교회, 학회 등을 말한다. 비법인 사단·재단은 권리능력이 없어 당연히 행위능력이 없어야 하지만, 특허법은 예외적으로 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 i) 출원심사의 청구인, ii) 특허취소신청인, iii) 권리능력을 전제로 하지 아니한 심판의 청구인 및 피청구인 또는 iv) 권리능력을 전제로 하지 아니한 재심의 청구인 및 피청구인이 될 수 있도록 하고 있다(法 4).¹³¹⁾ 이 같은 경우는 특허절차진행상 행위능력을 인정해 주더라도 취지상 무리가 없기 때문이다.¹³²⁾

Ⅲ. 재외자의 행위능력

1. 원 칙

재외자는 특허관리인에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소를 제기할 수 있다(法 5①). 이는 재외자의 특허출원 절차상의 번거로움을 피하고 절차의 원활을 기하기 위한 것이다.

2. 예 외

i) 재외자가 국내에 체류하는 경우(法 5①), ii) 국제특허출원의 출원인인 재외자가 기준일 전에 절차를 밟는 경우에는 제5조제1항의 규정에 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다(法 206①).¹³³⁾

131) 예를 들어 비법인 사단·재단은 권리능력이 있음을 전제로 하는 i) 출원인, ii) 특허거절결정에 대한 심판청구인, iii) 정정심판청구인, iv) 무효심판의 피청구인, v) 적극적 권리범위확인심판의 청구인, vi) 소극적 권리범위확인심판의 피청구인, vii) 통상실시권허락심판의 피청구인, viii) 존속기간연장등록출원의 출원인이 될 수 없다.

132) 민사소송법 등에서는 비법인 단체도 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 단체의 이름으로 당사자가 될 수 있도록 하는바, 이를 소위 형식적 당사자능력이라 한다(民訴法 52). 이러한 규정은 오늘날과 같이 복잡한 사회구조 속에서 비법인 단체의 절차상 주체성까지 부인한다면, 그 단체를 상대로 절차를 밟고자 하는 자는 단체의 구성원 모두를 개별적으로 상대하지 않으면 안 되게 되어 절차적 불편과 번잡이 따르게 됨을 막기 위한 것이다. 또한 단체 측으로서도 단체의 이름으로 절차를 밟는 것이 편리한 경우가 적지 않다. 그러므로 민사소송법은 실체법과는 입장을 달리하여 형식적 당사자능력을 인정하는 것이며, 특허법에서도 심사청구 등 특정 절차에 한하여 제한적으로 이를 인정하고 있다(지식재산처, 「출원방식심사지침서」, 2015, 76면).

133) 다만 私見으로는 특허관리인이 없는 재외자가 국내에 체류한다는 이유만으로 절차를 밟을 수 있다고 하는 것은 지식재산처의 입장에서 절차의 수행에 어려움이 따르므로, 특허관리인을 선임한 재외자가 국내에 체류하는 때에만 재외자가 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다고 해석함이 타당하다. 즉 원칙적으로 재외자는 특허관리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 절차를 밟지 못하는데 단, 국내에 체류할 때는 이미 선임해놓은 특허관리인에 의하는 방법 외에 자신이 직접 절차를 밟을 수도 있다고 해석하여야 한다.

IV. 행위능력 흠결의 효과

1. 절차의 무효 또는 결정각하

1) 지식재산처장, 특허심판원장, 심판장은 재내자가 행위능력이 없는데 특허에 관한 절차를 밟은 경우(예를 들어 미성년자가 법정대리인의 동의를 받지 아니하고 임의대리인을 통하여 절차를 밟는 경우) 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 지식재산처장, 특허심판원장은 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 해당 보정을 명한 절차를 무효로 할 수 있고(法 16①), 심판장은 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정하지 아니하거나 보정한 사항이 요지변경인 경우(法 140②, 140의2② 위반)에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다(法 141).

2) 그러나 행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차는 보정된 당사자¹³⁴⁾나 법정대리인이 추인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다(法 7의2).¹³⁵⁾ 다만 추인하지 아니한 경우 상술한 바와 같이 지식재산처장 등이 그 절차를 무효로 할 수 있으므로 절차의 명확화 및 안정을 위해 법정대리인의 취소권은 인정되지 아니한다.¹³⁶⁾

2. 불수리

지식재산처장·심판원장은 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 출원서류 등을 제출한 경우 소명기회를 주고 소명하지 않거나 소명이 적법하지 아니하면 불수리하여야 한다(施規 11). 다만 특허관리인에 의하지 아니한 채 제출된 재외자의 서류가 반려되지 않고 특허에 관한 절차가 진행된 경우 i) 특허관리인제도는 지식재산처가 국내에 거주하지 아니한 자와 직접 절차를 수행함에 따른 번잡과 절차지연을 피함으로써 원활한 절차수행이 가능하게 하기 위함에 그 의의가 있는 점, ii) 재외자라 하더라도 국내에 체류할 때는 직접 절차를 밟을 수 있는 점, iii) 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 그 절차를 밟았다고 하여 이를 제한열거적인 특허거절이유나 특허무효사유로는 하고 있지 아니한 점 등에 비추어 볼 때, 지식재산처장이 사후에 이를 이유로 제출된 서류의 절차상 하자를 주장할 수는 없다.¹³⁷⁾

134) 보정된 당사자란 예를 들어 최초 절차를 밟는 때에는 미성년자였으나, 이후 만 19세에 달하여 행위능력자로 된 자 등을 말한다.

135) 대법원 2010. 6. 10. 선고 2010다5373.

136) 민법상의 법률행위에 관한 규정은 민사소송법상의 소송행위에는 특별한 규정 기타 특별한 사정이 없는 한 적용이 없는 것이므로 소송행위가 강박에 의하여 이루어진 것임을 이유로 취소할 수는 없다(대법원 1997. 10. 10. 선고 96다35484).

137) 대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182 참조.

3. 선임명령

지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되는 때에는 대리인에 선임하여 그 절차를 밟도록 명할 수 있다(法 10①).

4. 절차의 중단

특허에 관한 절차의 진행 중에 행위능력을 상실하면 그 절차는 중단되고, 행위능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인의 수계에 의하여 다시 절차가 진행된다. 다만 임의대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다(法 20-22).

5. 국제출원의 경우

지식재산처장은 국제출원에 관한 절차가 행위능력에 관한 규정에 위반되면 기간을 정하여 보정을 명하여야 하며(法 195), 그 기간에 보정이 이루어지지 아니한 경우에는 그 국제출원을 취하된 것으로 간주한다(法 196①).

【표 1-8】 권리능력과 행위능력의 구별

구 분		내 용
권리능력	내국인	■ 자연인과 법인에 대하여 권리능력 인정 (재내외자 불문)
	외국인	■ 재내자 - 권리능력 인정(法 25본문의 반대해석) ■ 재외자 1. 원칙 - 권리능력 불인정 2. 예외 - 권리능력 인정(상호주의(法 25 I, II), 조약에 의한 경우(法 25III))
행위능력 (내외국인 불문)	재내자	■ 원칙 - 행위능력 인정 ■ 문제되는 경우 1. 제한능력자(法 3①) → 행위능력 불인정(·제한능력자의 보호) ① 법정대리인의 의한 절차(法 3②) ② 위반시 취급 - 원칙 → 보정명령(法 46) 후 절차의 무효(法 16①본문) - 예외 → 추인의 소급효(法 7의2) 2. 비법인 사단·재단 - 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우 그 사단·재단의 이름으로 심사청구인, 특허 취소신청인, 심판청구인·피청구인, 재심청구인·피청구인이 될 수 있음(法 4)
	재외자	■ 원칙 - 행위능력 불인정(法 5①)(·절차의 원활한 진행) → 특허관리인에 의한 절차 수행(法 5②) ■ 예외 1. 국내에 체류하는 경우(法 5①본문) 2. 국제특허출원의 기준일 전까지(法 206①) ■ 위반시 취급 → 불수리

제2절 대리인

제3조 【미성년자 등의 행위능력】

- ① 미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인은 법정대리인에 의하지 아니하면 특허에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차(이하 “특허에 관한 절차”라 한다)를 밟을 수 없다. 다만, 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항의 법정대리인은 후견감독인의 동의 없이 제132조의2에 따른 특허취소신청(이하 “특허취소신청”이라 한다)이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차를 밟을 수 있다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제5조 【재외자의 특허관리인】

- ① 국내에 주소 또는 영업소가 없는 자(이하 “재외자”라 한다)는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 “특허관리인”이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다.
- ② 특허관리인은 위임된 권한의 범위에서 특허에 관한 모든 절차 및 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 관한 소송에서 본인을 대리한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제6조 【대리권의 범위】

국내에 주소 또는 영업소가 있는 자로부터 특허에 관한 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다. 특허관리인의 경우에도 또한 같다. <개정 2016.2.29.>

1. 특허출원의 변경·포기·취하
2. 특허권의 포기
3. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
4. 신청의 취하
5. 청구의 취하
6. 제55조제1항에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
7. 제132조의17에 따른 심판청구
8. 복대리인의 선임

[전문개정 2014.6.11.]

제7조 【대리권의 증명】

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인을 포함한다. 이하 같다)의 대리권은 서면으로써 증명하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제7조의2 【행위능력 등의 흠에 대한 추인】

행위능력 또는 법정대리권이 없거나 특허에 관한 절차를 밟는 데 필요한 권한의 위임에 흠이 있는 자가 밟은 절차는 보정(補正)된 당사자나 법정대리인이 추인하면 행위를 한 때로 소급하여 그 효력이 발생한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제8조 【대리권의 불소멸】

특허에 관한 절차를 밟는 자의 위임을 받은 대리인의 대리권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있어도 소멸하지 아니한다.

1. 본인의 사망이나 행위능력의 상실
2. 본인인 법인의 합병에 의한 소멸

3. 본인인 수탁자(受託者)의 신탁임무 종료
4. 법정대리인의 사망이나 행위능력의 상실
5. 법정대리인의 대리권 소멸이나 변경

[전문개정 2014.6.11.]

제9조 【개별대리】

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 2인 이상이면 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 각각의 대리인이 본인을 대리한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제10조 【대리인의 선임 또는 교체 명령 등】

- ① 지식재산처장 또는 제145조제1항에 따라 지정된 심판장(이하 “심판장”이라 한다)은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리(口述審理)에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 대리인을 선임하여 그 절차를 밟을 것을 명할 수 있다.
- ② 지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는 데 적당하지 아니하다고 인정되면 그 대리인을 바꿀 것을 명할 수 있다. <개정 2019. 12. 10.>
- ③ 지식재산처장 또는 심판장은 제1항 및 제2항의 경우에 변리사로 하여금 대리하게 할 것을 명할 수 있다.
- ④ 지식재산처장 또는 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 대리인의 선임 또는 교체 명령을 한 경우에는 제1항에 따른 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 제2항에 따른 대리인이 그 전에 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다. <개정 2019.12.10>

[전문개정 2014.6.11.]

제12조 【「민사소송법」의 준용】

대리인에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「민사소송법」 제1편제2장제4절을 준용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「대리인」이란 본인의 이름으로 특허에 관한 제반절차를 밟는 자를 말하며, 대리인이 밟은 절차의 법률적 효과는 본인에게 귀속된다.

2. 취 지

특허법은 i) 사적 자치를 보충하는 측면에서 법정대리인 제도를, ii) 사적 자치를 확장하는 측면에서 임의대리인 제도를 두고 있다. 한편 특허법상의 대리 제도는 대리권의 증명 필요성(法 7), 임의대리권의 불소멸에 관한 규정(法 8) 등 민법상의 대리 제도와는 다르고 민사소송법상의 대리 제도와 유사하다.

II. 대리인의 종류

1. 법정대리인과 임의대리인

(1) 구별기준

대리인은 법정대리인과 임의대리인으로 구별된다. 「법정대리인」이란 본인의 의사와 무관하게 법률의 규정이나 법원의 선정에 의하여 대리인이 된 자를 말하며, 「임의대리인」이란 본인의 의사에 의하여 대리인이 된 자를 말한다.

(2) 구별실익

법정대리인과 임의대리인은 대리권의 범위 측면에서 차이가 있다. 임의대리인의 대리권은 수권행위에 의하여 위임을 받은 특허에 관한 절차(심결취소소송 포함)에 대해서만 범위가 미치는데 반해¹³⁸⁾ 법정대리인의 대리권은 법률에 의하여 정해지며 특허에 관한 절차 전반에 걸쳐 광범위하게 미칠 뿐만 아니라 권리의 처분권까지 인정된다. 「권리의 처분권」이란 침해에 대한 민·형사소송, 각종 실시권 설정 및 양도행위 등을 할 수 있는 권한을 의미한다.

2. 친권자와 후견인

(1) 구별기준

법정대리인은 친권자와 후견인으로 구별될 수 있다. 「친권자」란 미성년자인 자에 대한 친권을 행사하는 父 또는 母를 말하며(民法 911), 「후견인」이란 미성년자·피성년후견인·피한정후견인을 보호·교양하고 그자의 행위를 대리하며 그 재산을 관리하는 사무를 담당하는 자를 말한다.

(2) 구별실익

친권자와 후견인은 특허에 관한 절차를 밟는 데 있어서 후견감독인 동意的 필요 여부에 차이가 있다. 친권자는 심판 또는 재심을 포함한 모든 절차에 있어서 후견감독인의 동의를 받지 않더라도 절차를 밟을 수 있는데 반해 후견인은 후견인의 전횡(專橫)으로부터 제한능력자를 보호하기 위하여 원칙적으로 후견감독인의 동意的 있어야 대리행위를 할 수 있도록 하여 친권자인 경우보다 그 권한이 제한된다. 다만 후견인이라 하더라도 특허취소신청이나 상대방이 청구한 심판 또는 재심에 대한 절차, 즉 수동적인 절차는 제한능력자의 이익을 위해 후견감독인의 동의를 받지 아니하고 절차를 밟을 수 있다(法 3②).

138) 변리사는 지식재산처 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정(鑑定)과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업(業)으로 한다(辨理士法 2). 변리사가 아닌 자는 업으로 하는지와 관계없이 변리사법 제2조에 따른 대리 업무를 하지 못한다.

3. 통상의 위임대리인과 특허관리인

(1) 구별기준

임의대리인은 통상의 위임대리인과 특허관리인으로 구별된다. 「통상의 위임대리인」이란 재내자로부터 특허에 관한 절차를 위임받은 대리인을 말하며, 「특허관리인」이란 재외자로부터 특허에 관한 절차를 위임받은 대리인으로서 국내에서 주소 또는 영업소를 가지는 자를 말한다.

(2) 구별실익

재외자의 재판관할(法 13), 재외자의 특허관리인의 특례(法 206), 재외자에 대한 송달(法 220)의 측면에서 특허관리인과 통상의 위임대리인은 구별의 실익이 있다. 구체적으로 재외자의 재판관할(法 13)과 관련하여, 재외자의 특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 i) 특허관리인이 있으면 그 특허관리인의 주소 또는 영업소를, ii) 특허관리인이 없으면 지식재산처 소재지를 「민사소송법」 제11조에 따른 재산이 있는 곳으로 본다(法 13).¹³⁹⁾ 재외자의 특허관리인의 특례(法 206)와 관련하여, 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있으나, 출원번역문을 제출한 재외자가 기준일이 지난 후 2개월 이내에 특허관리인을 선임하여 지식재산처장에게 신고하지 아니한 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다(法 206). 재외자에 대한 송달(法 220)과 관련하여, 그 재외자에 송달할 서류는 특허관리인이 있으면 특허관리인에게 송달하여야 하나, 특허관리인이 없으면 그 재외자에게 항공등기우편으로 발송하여야 하고 이 경우 그 발송일에 송달된 것으로 본다.

Ⅲ. 대리권의 내용

1. 대리권의 범위

임의대리인은 특별히 권한을 위임¹⁴⁰⁾받아야만 다음의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 수 있다(法 6).¹⁴¹⁾

139) 민사소송법 제11조에서 “대한민국에 주소가 없는 사람 또는 주소를 알 수 없는 사람에 대하여 재산권에 관한 소를 제기하는 경우에는 청구의 목적 또는 담보의 목적이나 압류할 수 있는 피고의 재산이 있는 곳의 법원에 소를 제기할 수 있다”라고 규정하여 재산소재지 특별재판관할을 인정하고 있으나, 특허권 등은 무체재산권이고 그 실체는 지식재산처에서의 등록이라는 사실을 통해서면 확인된다는 점에서 특별히 재산의 소재지가 존재한다고 할 수 없다. 그러나 재산권으로서의 특허권 등은 엄연히 존재하고 있으며 이로 인한 분쟁도 필연적으로 발생하게 되어 이의 해결을 위한 조치로서 마련된 것이다(지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 67면 참조).

140) 예를 들면 대리권을 위임하는 관에 대리권 범위를 「본원 00출원에 관한 일체의 건」 등으로 적은 경우에는 특별히 권한을 위임받지 아니한 것으로 본다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 1207-1208면).

141) 기존에는 통상의 위임대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 i) 내지 vi) 중 어느 하나의 행위를 할 수 있도록 하는 반면, 특허관리인은 통상의 위임대리인과 달리 포괄적인 권한을 가지며, 특별히 권한을 위임받지 않더라도 i) 내지 vi) 중 어느 하나의 행위를 할 수 있다는 입장이었다. 그러나 2015. 1. 1. 시행된 현행법(법률

- i) 특허출원의 변경·포기·취하
- ii) 존속기간연장등록출원의 취하
- iii) 신청의 취하
- iv) 청구의 취하
- v) 국내우선권주장이나 취하
- vi) 거절결정불복심판의 청구¹⁴²⁾
- vii) 복대리인의 선임
- viii) 특허권의 포기

2. 대리권의 증명

(1) 원 칙

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인(특허관리인을 포함한다)의 대리권은 서면(위임장)으로써 증명하여야 한다(法 7). 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인에게 대리권을 수여하는 데에는 일정한 방식이 요구되지 않아서 특허법상 대리인의 대리권 존재 유무를 제3자(지식재산처 포함)가 알 수 없으므로 서면 증명을 통해 특허에 관한 절차의 안정 및 명확화를 기하기 위함이다.¹⁴³⁾

(2) 예 외

i) 둘 이상의 절차를 동시에 밟는 경우나 이미 위임장을 제출한 자가 다시 위임장을 제출하여야 할 때는 이미 제출된 위임장의 사본을 제출하거나 해당 서식의 첨부서류란에 그 취지를 기재함으로써 위임장에 갈음할 수 있으며(施規 10①②), ii) 대리인선임신고에 의하여 선임된 대리인이 그 위임사항의 범위에서 특허에 관한 절차를 밟는 경우나 포괄위임등록을 한 대리인이 그 포괄위임의 범위에서 특허에 관한 절차를 밟을 때는 위임장의 제출을 생략할 수 있다(施規 10③).

제12753호, 2014. 6. 11. 개정)은 재외자인 본인의 특허절차에 대한 권리 보호를 강화하기 위해 특허관리인도 통상의 위임대리인과 마찬가지로 특별히 권한을 위임받아야만 i) 내지 viii) 중 어느 하나의 행위를 할 수 있도록 하였다.

142) 본인에게 불이익이 없는 거절결정불복심판청구에 대하여 특별히 권한을 위임받도록 한 것은 임의대리인이 출원을 대리하여 특허거절결정을 받았기 때문에 계속하여 다음 단계의 절차를 위임할 것인지에 대한 재신임을 받도록 하기 위한 것으로 해석된다(지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 19면).

143) 이미 출원한 사건의 특허에 관한 절차 또한 포괄위임의 대상이 되고, 포괄위임등록 신청을 위해 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 지식재산처장에게 제출한 이상 포괄위임 대상 사건에 관한 대리권의 서면 증명은 이루어졌다고 볼 수 있다(대법원 2023. 7. 13. 선고 2021두63099).

【표 1-9】 포괄위임제도

구 분	내 용
의 의	포괄위임제도란 특허에 관한 절차를 대리인에 의하여 밟을 때 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄적으로 위임을 하도록 하여, 일단 지식재산처에 포괄위임등록을 하면 그 등록된 범위에서는 개개의 절차마다 위임장을 제출할 필요 없이 특허에 관한 절차를 대리할 수 있도록 하는 제도(施規 5의2)
포괄위임등록대상	대리인에 의하여 절차를 밟는 경우 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 포괄적으로 가능(심판에 대해서도 포괄위임 가능)
포괄위임등록신청	1. 포괄위임등록신청서에 포괄위임장을 첨부하여 지식재산처장에게 제출. 이 경우 대리인은 포괄위임을 하려는 자에게 포괄위임에 대하여 설명하고 포괄위임장에 포괄위임을 하려는 자의 서명 또는 날인을 받아야 함(포괄위임을 하거나 포괄위임등록사항을 변경하려는 자가 포괄위임장을 온라인 제출하거나 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 때는 지식재산처에서 제공하는 소프트웨어나 지식재산처 홈페이지를 이용하여 그 포괄위임장에 전자서명을 하여 전자문서로 제출하거나, 휴대전화로 전송되는 인증번호를 입력하고 출원인이 서명 또는 날인한 포괄위임장의 전자적 이미지를 첨부하여 제출) 2. 지식재산처장은 포괄위임등록번호를 부여하고 이를 신청인에게 통지
포괄위임의 효과	포괄위임등록을 한 대리인이 절차를 대리하는 경우 포괄위임 등록번호를 기재하면 위임장 제출의 생략이 가능(施規 10③)
포괄위임의 원용 제한	포괄위임을 한 자가 특정한 사건에 대하여 포괄위임의 원용을 제한하려는 경우에는 그 신고서를 지식재산처장에게 제출(施規 5의3)
포괄위임의 철회	포괄위임을 한 자가 포괄위임을 철회하려는 경우에는 포괄위임등록철회서를 지식재산처장에게 제출(施規 5의4)

3. 대리권의 불소멸

특허에 관한 절차를 밟는 자의 임의대리인의 대리권은 i) 임의대리인의 사망·성년후견의 개시 또는 파산(民法 127), ii) 본인에 대한 사임, iii) 본인의 해임, iv) 그 밖의 위임관계 종료로 소멸한다. 그러나 임의대리인의 대리권은 i) 본인의 사망이나 행위능력의 상실, ii) 본인인 법인의 합병에 의한 소멸, iii) 본인인 수탁자의 신탁임무 종료, iv) 법정대리인의 사망이나 행위능력의 상실, v) 법정대리인의 대리권 소멸이나 변경으로 인하여 소멸하지 아니한다(法 8). 특허에 관한 절차의 원활·확실화 및 수계자를 위해서 대리권을 소멸시키지 아니한 것이 바람직하므로 절차가 중단되는 사유가 발생한다고 하더라도 임의대리인이 있는 경우에는 임의대리권이 소멸하지 않고 절차가 중단되지 않도록 하고 있다(法 20).

【표 1-10】 대리권의 소멸/불소멸 사유의 구별

구 분	임의대리권	법정대리권
불소멸사유	1. 본인의 사망이나 행위능력의 상실 2. 본인인 법인의 합병에 의한 소멸 3. 본인인 수탁자의 신탁 임무 종료 4. 법정대리인의 사망이나 행위능력의 상실, 대리권의 소멸이나 변경	1. 본인의 행위능력상실 2. 유언집행인의 경우 상속인의 존재가 불분명한 경우
소멸사유	1. 임의대리인의 사망, 성년후견의 개시 2. 임의대리인의 파산 3. 본인에 대한 사임 4. 본인의 해임 5. 그 밖의 위임관계 종료	1. 본인의 사망 2. 법정대리인의 사망, 파산, 성년후견의 개시 3. 법정대리인의 친권 상실 4. 후견인의 사임 또는 해임 등 자격 상실 5. 본인이 행위능력을 갖거나 회복한 때 6. 법정대리인의 임무종료(상속인의 존재가 분명해진 경우)

4. 개별대리

특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인이 2명 이상이면 지식재산처장 또는 특허심판원장에 대하여 각각의 대리인이 본인을 대리한다(法 9). 특허절차의 지연 및 상대방의 불편을 방지하기 위해 개별대리 원칙을 채용하고 있다. 이러한 개별대리의 원칙은 강행규정이기 때문에 수인의 대리인이 공동대리의 특약을 한 경우라 하더라도 대외적으로는, 즉 지식재산처나 그 밖의 제3자에 대해서는 효력이 없다. 예를 들어 다수의 대리인이 공동대리의 특약을 하였다 하더라도 대리인 각자의 의사에 따라 대리권을 행사할 수 있다. 다만 공동대리의 특약은 본인과 대리인 간에 대내적으로는 의미가 있으므로 이 특약을 위반하면 민사상 책임을 물을 수는 있다.

5. 대리인의 선임·교체

(1) 선임·교체명령

지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 대리인이 그 절차를 원활히 수행할 수 없거나 구술심리에서 진술할 능력이 없다고 인정되는 등 그 절차를 밟는데 적당하지 아니하다고 인정되면 대리인을 선임하거나 그 대리인을 바꿀 것을 명할 수 있으며(法 10①②), 이 경우 변리사로 하여금 대리할 것을 명할 수도 있다(法 10③). 한편 변리사라 하더라도 건강상의 이유 등으로 실질적으로 특허에 관한 절차를 원활히 수행할 수 없을 때는 바꿀 수 있다. 이는 본인이나 대리인이 행위능력 또는 진술능력 때문에 행정절차를 원활히 수행할 수 없다고 인정되는 경우 행정상 편의와 본인의 이익을 보호하기 위해서이다.

(2) 절차의 무효

지식재산처장 또는 심판장은 대리인의 선임 또는 대리인의 교체 명령을 한 경우에는 특허에 관한 절차를 밟는 자 또는 대리인이 대리인을 선임하거나 교체하기 전에 지식재산처 또는 특허심판원에 대하여 한 특허에 관한 절차의 전부 또는 일부를 무효로 할 수 있다(法 10④).

6. 민사소송법의 준용

대리인에 관하여는 이 법에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「민사소송법」 제1편제2장제4절을 준용한다(法 12). 특허법에 명문규정이 없어 민사소송법이 준용되는 규정은 법률에 의한 소송대리인의 권한(民訴法 92), 당사자의 경정권(民訴法 94) 등을 들 수 있다.

IV. 흠결의 효과

1. 절차의 무효 또는 결정각하

지식재산처장, 심판원장 또는 심판장은 i) 행위능력이 없는 자가 법정대리인에 의하지 않고 특허에 관한 절차를 밟은 경우, ii) 임의대리인이 대리권의 범위(法 6)를 위반한 경우, iii) 위 임장이 첨부되어 있지 아니한 경우 등 절차보정사유에 해당하는 경우 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 지식재산처장, 특허심판원장은 지정된 기간에 보정하지 아니하면 해당 보정을 명한 절차를 무효로 할 수 있고(法 16①), 심판장은 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정하지 아니하거나 보정한 사항이 요지변경인 경우(法 140②, 140의2② 위반)에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다(法 141).

2. 불수리

지식재산처장·심판원장은 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 출원서류 등을 제출한 경우 소명기회를 주고 소명하지 않거나 소명이 적법하지 아니하면 불수리하여야 한다(施規 11).

3. 절차의 중단

법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실하면 지식재산처에 계속 중인 절차는 중단된다. 다만 임의대리인이 있는 경우에는 중단되지 아니한다(法 20).

4. 재심사유

대리권의 흠결은 재심사유에 해당하며 이를 이유로 재심을 청구하는 경우, 재심사유를 안 날로부터 30일 중 「안 날」은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다(法 180②).

V. 관련문제

1. 국제출원의 경우

(1) 대리권 흠결의 취급

국제출원에 관한 절차를 대리인이 밟는 경우 법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 하여야 한다(法 197③). 지식재산처장은 대리권의 흠결이 있는 경우 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고, 그 기간에 보정이 이루어지지 아니한 경우에는 그 국제출원을 취하된 것으로 간주한다(法 196①).

(2) 재외자의 특허관리인의 특례

재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있으나, 출원번역문을 제출한 재외자가 기준일이 지난 후 2개월 이내에 특허관리인을 선임하여 지식재산처장에게 신고하지 아니한 경우에는 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다(法 206).

2. 법인 등의 대표자

법인 또는 비법인 단체가 특허에 관한 절차의 당사자가 된 경우에 특허에 관한 절차는 그 대표자에 의하여 행해진다. 이때 그 대표자를 법정대리인에 준하여 취급하여야 한다(民訴法 64 준용). 따라서 법인 등의 대표자는 특허에 관한 일체의 절차행위를 할 수 있으며, 법인이 아닌 단체의 대표자나 관리인은 제4조에서 규정한 사항에만 일체의 행위를 할 수 있다.

3. 복대리인

(1) 의의 및 선임권한

「복대리인」이란 대리인이 대리권의 범위에서 그의 책임으로 선임한 본인의 대리인을 말하며, 복대리인을 선임할 수 있는 권한을 「복임권」이라 한다. 법정대리인은 항상 복임권을 가지며 그의 책임으로 복대리인을 선임할 수 있으나, 임의대리인은 복대리인을 선임하기 위해서는 본인으로부터 특별히 권한을 위임받아야 한다(法 6).

(2) 복대리인의 수권범위

복대리인의 수권범위는 대리인의 수권범위를 초과할 수 없다. 예를 들어 임의대리인이 복대리인을 선임할 수 있는 권한과 다른 특별히 권한을 위임받은 사항(예를 들어 출원의 취하)을 본인으로부터 수권 받으면 특별히 권한을 위임받은 사항이라 하더라도 복대리인에게 수권할 수 있다. 다만 대리인이 비록 복대리인을 선임할 권한을 수권 받았다고 할지라도 다른 특별히 권한을 위임받은 사항에 대하여 수권을 받지 않았다면 복대리인의 대리권 범위는 다른 특별히 권한을 위임받은 사항을 포함할 수 없다.

(3) 대리인이 사망한 경우

복대리인의 대리권은 본인 또는 대리인이 수권행위를 철회하면 당연히 소멸하지만, 대리인의 사망에 의하여 소멸하지 아니한다.¹⁴⁴⁾ 대리인이 사망하더라도 복대리인이 본인을 위해 절차를 밟는 것이 특허에 관한 절차의 신속·원활한 진행과 본인의 이익을 위한 것이기 때문이다.

4. 국선대리인

특허심판원장은 총리령으로 정하는 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라 대리인(이하 “국선대리인”이라 한다)을 선임하여 줄 수 있다. 다만 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다. 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 심판절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있다(法 139의2).

제3절 복수당사자의 대표

제11조 【복수당사자의 대표】

① 2인 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항을 제외하고는 각자가 모두를 대표한다. 다만 대표자를 선정하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다. <개정 2016.2.29.>

1. 특허출원의 변경·포기·취하
2. 특허권 존속기간의 연장등록출원의 취하
3. 신청의 취하
4. 청구의 취하
5. 제55조제1항에 따른 우선권 주장 또는 그 취하
6. 제132조의17에 따른 심판청구

② 제1항 단서에 따라 대표자를 선정하여 신고하는 경우에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1) 「복수당사자의 대표」란 공동으로 절차를 밟는 2명 이상의 복수당사자 중 특정인을 선정하여 지식재산처에 신고된 자를 의미한다. 예를 들면 A, B, C, D, E 5인이 특허에 관한 하나의 절차를 밟고 있을 때 A는 자기의 대표자로 B를 선정할 수 있고, C는 D를 자기의 대표자로 선정할 수 있다. 또한 A, C, D, E 모두가 B를 대표자로 선정할 수 있다. 대표자는 2명 이상도 선정할 수 있으며, 이 경우 각자 대표의 원칙이 준용된다(法 11). 특허법은 수인의 당사자가 특허에 관한 절차를 밟을 때 반드시 수인의 당사자 모두가 함께하여야 한다면 절차진행의 번잡, 송달사무의 폭주 등으로 인해 특허에 관한 절차의 처리가 지연될 우려가 있으므로 수인의 당사자 중에서 대표자를 선임한 후 그 자에게 스스로 절차를 수행할 수 있게 하여 절차의 간편·단순화를 도모하고 있다.

144) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 135면.

2) 특허출원 및 심판청구는 복수당사자의 대표자 선임 여부와 상관없이 별도의 규정이 있으므로 제11조의 복수당사자 대표에 관한 규정은 특허출원 및 심판청구 이외의 절차에 적용되는 규정으로 해석함이 타당하다. 즉 제11조제1항 본문에 규정된 「2명 이상이 특허에 관한 절차를 밟는 때」는 2명 이상이 공동으로 특허출원 또는 심판청구를 하고 그 출원 또는 심판에 관계된 절차를 밟는 때를 의미한다고 할 수 있다.

II. 특허출원 및 심판청구

1. 특허출원

1) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다(法 44). 여기서 「공동출원」한다는 것은 출원서에 출원인 모두의 명의를 기재함과 동시에 모두의 인장을 날인함을 의미한다. 공동발명임에도 불구하고 1명이 단독으로 출원하면 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)이다. 다만 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권 지분의 이전을 청구할 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 법원에의 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 해당 특허권과 보상금 지급 청구권(法 65②, 207④)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 이전청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다(法 99의2). 한편 이전청구에 기초하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지분의 이전등록(法 99의2)이 있으면 특허무효심판의 특허무효사유에서 제외된다(法 133①Ⅱ단서).

2) 존속기간연장등록출원 역시 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간연장등록출원을 하여야 하며(法 90③, 92의3③), 이에 위반하여 단독으로 출원하면 거절이유(法 91, 92의4), 존속기간연장등록무효사유(法 134①②)이다.

2. 심판청구

1) 특허무효심판(法 133), 특허권의 존속기간연장등록무효심판(法 134), 정정무효심판(法 137) 또는 권리범위확인심판(法 135)을 청구하는 자가 2명 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다(法 139①). 그러므로 모두가 공동으로 심판을 청구할 수도 있고 각자가 개별적으로 심판을 청구할 수도 있다.

2) 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法 139③). 이에 위반되면 심판관 합의체는 심판청구를 심결각하하여야 한다(法 142).

Ⅲ. 그 밖의 절차

1. 대표자를 선정하지 아니한 경우

특허에 관한 절차를 밟는 자가 복수인 경우, 대표자를 선임하여 신고하지 아니한 경우에는 당사자 각자가 모두를 대표한다. 다만 i) 특허출원의 변경·포기·취하, ii) 특허권 존속기간 연장등록출원의 취하, iii) 신청의 취하, iv) 청구의 취하, v) 국내우선권주장 또는 그 취하, vi) 특허거절결정에 대한 심판청구의 경우에는 복수당사자 모두가 함께 절차를 밟아야 한다(法 11①본문).¹⁴⁵⁾

2. 대표자를 선정한 경우

1) 대표자를 선정하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다(法 11①단서). 다만 제11조제1항 각호의 행위의 경우에도 대표자가 단독으로 할 수 있는지가 문제이다. 이에 대하여 원칙적으로 대표자의 절차수행독점을 인정하고 있으나, 대표자는 다른 당사자의 동의를 받지 않고 단독으로는 제11조제1항 각호에 규정된 행위를 할 수 없다는 것이 심사 실무¹⁴⁶⁾의 태도이다.

2) 대표자를 선정하여 지식재산처 또는 특허심판원에 신고한 때에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다(法 11②). 대표자의 선정신고는 선임된 대표자가 대표자 선정신고서에 대표자임을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다(施規 6①). 한편 선임된 대표자의 변경 또는 해임을 신고하려는 자는 대표자 변경·해임신고서에 신고내용을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다(施規 6②).

Ⅳ. 함결의 효과

1. 절차의 무효

지식재산처장, 특허심판원장은 i) 대표자가 다른 당사자의 동의를 받지 아니하고 제11조제1항 각호에 따른 절차를 밟는 경우, ii) 출원인 모두를 대리하지 아니한 대리인 또는 출원인 중 일부의 자만이 다른 당사자의 동의를 받지 아니하고 제11조제1항 각호에 따른 절차를 밟는 경우에 기간을 정하여 보정을 명하고 기간에 보정하지 아니하면 그 보정을 명한 절차를 무효로 할 수 있다(法 16①본문).

145) 변경출원과 거절결정불복심판은 대표자가 선임되어 있다 하더라도 복수 당사자 모두가 함께하여야 한다(法 44, 139③). 따라서 私見으로는 제11조제1항각호에서 삭제하는 것이 바람직하다고 여겨진다.

146) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 1216면.

2. 절차의 중단

복수당사자의 선정대표자가 사망하거나 그 자격이 상실된 경우에는 새로운 대표자 또는 각 당사자가 수계할 때까지 절차가 중단된다. 다만 임의대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다(法 20-22).

V. 관련문제

1. 국제출원의 경우

2명 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에는 대표자가 제192조부터 제196조까지 및 제198조에 따른 절차를 밟을 수 있는데(法 197①), 2명 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 때에는 지식재산처에 국제출원할 자격을 가지는 대한민국 국민 또는 국내에 주소나 영업소를 갖는 외국의 출원인 중 출원서에 최초로 기재되어 있는 출원인을 대표자로 정할 수 있다(法 197②, 施規 106의4).

2. 공동출원인 중 일부의 자만 대리인이 있는 경우

절차를 밟는 자가 복수이고 그중 일부의 자만이 대리인을 선임하면 그 선임된 대리인은 제11조제1항 각호에 따른 절차가 아닌 범위에서 단독으로 절차를 밟을 수 있다. 즉 일부의 자에 의하여 선임된 대리인은 제11조제1항 각호의 경우에는 대리인을 선임하지 아니한 모든 자와 공동으로 절차를 밟아야 한다.¹⁴⁷⁾

3. 재외자와 재내자의 공동출원인 경우의 취급

1) 제44조의 규정에 의하면 특허를 받을 수 있는 권리가 공유일 때 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 하므로 재내자와 재외자가 공동으로 출원한 경우 그 출원은 적합하다. 특허출원 후 재내자는 단독으로 제11조제1항의 각호에 규정된 절차(특허출원의 포기 등)를 제외하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있는데 반하여 재외자는 특허관리인을 선임하지 않고 특허에 관한 절차를 밟을 수 없다. 그러나 재내자라 하더라도 제11조제1항 각호 규정에 의한 특허에 관한 절차는 단독으로 밟을 수 없으며, 이들 절차는 재외자가 선정한 특허관리인과 공동으로 그 절차를 밟아야 한다. 물론 재내자와 재외자는 동일인을 대리인(특허관리인)으로 선임할 수 있다.

2) 재내자가 대표자로 선정되면 재내자만이 절차를 밟을 수 있으나 제11조제1항 각호 규정에 의한 특허에 관한 절차는 재외자의 동의를 받아야 한다.

147) 대리인이 출원인 모두를 대리하지 아니하는 경우에는 출원서의 【대리인】란의 【주소】란 다음 행에 【특기 사항】란을 만들어 「출원인 ○○○의 대리인」이라고 적는다.

제6장

기일과 기간

제14조 【기간의 계산】

이 법 또는 이 법에 따른 명령에서 정한 기간의 계산은 다음 각 호에 따른다. <개정 2025. 11. 11.>

1. 기간의 첫날은 계산에 넣지 아니한다. 다만, 그 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우에는 계산에 넣는다.
2. 기간을 월 또는 연(年)으로 정한 경우에는 역(曆)에 따라 계산한다.
3. 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산(起算)하지 아니하는 경우에는 마지막의 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다. 다만, 월 또는 연으로 정한 경우에 마지막 월에 해당하는 날이 없으면 그 월의 마지막 날로 기간이 만료한다.
4. 특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「노동절 제정에 관한 법률」에 따른 노동절 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제15조 【기간의 연장 등】

- ① 지식재산처장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의17에 따른 심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ② 지식재산처장·특허심판원장·심판장 또는 제57조제1항에 따른 심사관(이하 “심사관”이라 한다)은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 경우에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 지식재산처장 등은 그 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 아니하도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다.
- ③ 심판장은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기일을 정한 경우에는 청구에 따라 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제16조 【절차의 무효】

- ① 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.
- ② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
- ③ 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제17조 【절차의 추후보완】

특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>

1. 제132조의17에 따른 심판의 청구기간
2. 제180조제1항에 따른 재심의 청구기간

[전문개정 2014.6.11.]

제1절 기 일

I. 의 의

「기일」이란 당사자와 심판관이 특허절차를 밟기 위하여 일정한 장소에서 모이는 일정한 시점을 말한다.

II. 지정기일의 변경

기일은 법률에 의하여 정해놓을 수 없으므로 지정기일밖에 없으며 지정기일은 변경할 수 있다. 즉 심판장은 기일을 미리 지정하여 통지하지만, 청구에 따라 또는 직권으로 변경할 수 있다(法 15③).

제2절 기 간

I. 의 의

「기간」이란 어느 한 시점에서 다른 한 시점까지의 연속된 시간을 말하는 것으로 시간의 계속성에 관한 개념이다. 기일은 시간의 계속성이 없는 한순간을 지칭하는 것이나, 기간은 기산일로부터 만료일까지를 의미하는 것이다.

II. 종 류

1. 법정기간 및 지정기간

1) 「법정기간」이란 특허권에 관한 법률 또는 이에 근거한 명령으로 정한 기간을 말한다. 이러한 법정기간은 원칙적으로 기간의 연장이 불가능한 불변기간이나, 거절결정불복심판청구기간(法 132의17)만 예외적으로 연장이 가능한 가변기간이다.

2) 「지정기간」이란 출원·청구나 그 밖의 절차를 밟는 자에 대하여 지식재산처장·심판원장, 심판장 또는 심사관이 특허권에 관한 법률 또는 이에 근거한 명령에 근거하여 발하는 지시에서 정한 기간으로서, 지정기간은 연장 또는 단축이 가능한 가변기간이다.¹⁴⁸⁾

2. 부가기간

「부가기간」이란 본래의 기간 이외에 별도의 기간을 더 주는 것을 말하는 것으로서, 본래의 기간을 늘려주는 「기간의 연장」과 구별된다. 특허법은 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 심판장이 직권으로 심결 등에 대한 취소소송의 제소기간이 불변기간임에도 불구하고 부가기간을 정할 수 있도록 하여 심결취소소송을 제기하는 자의 편의를 도모하고 있다(法 186⑤).¹⁴⁹⁾ 즉 심판장이 당사자, 참가인 또는 해당 심판에 참가 신청을 하였으나 신청이 거부된 자에게 심결등본을 송달할 때 직권으로 별도의 부가기간을 더 줄 수 있다.

III. 기간의 계산

1. 기산일의 결정

기간의 기산일¹⁵⁰⁾을 결정할 때는 원칙적으로 기간의 첫날은 계산에 넣지 아니한다. 다만 그 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우에는 계산에 넣는다(法 14 I). 예를 들면 「법정·지정기간의 연장(法 15)」의 경우에는 원 기간의 만료일의 다음 날 오전 0시부터 계산되므로 첫날을 계산에 넣는다. 한편 기간의 기산일을 결정할 때 기간의 첫날이 공휴일인지 여부는 영향을 미치지 아니한다.

2. 계산방법의 결정

기간의 계산방법에는 「자연적 계산방법」과 「역법적 계산방법」의 두 가지가 있다. 전자는 순간에서 순간까지 계산하는 방법으로서 정확하지만 불편하고, 후자는 曆에 따라 계산하는 방법으로서 편하지만 부정확하다. 특허법은 제14조제2호에서 “기간을 월 또는 연(年)으로 정한 경우에는 역(曆)에 따라 계산한다”라고 하여 장기간(연, 월)에 대해서는 역법적 계산방법, 단기간(주, 일)에 대해서는 자연적 계산방법에 따름을 명확히 밝히고 있다. 한편 기간계산과 관련하여 필요한 부분은 민법의 규정(民法 155-161)¹⁵¹⁾을 보충적으로 적용한다.

148) 법 제46조, 법 제141조 또는 법 제203조제3항제1호에 따라 지식재산처장·특허심판원장 또는 심판장이 정할 수 있는 보정기간은 1개월 이내로 하고, 법 제63조제1항에 따른 의견서제출기간은 4개월 이내로 하며, 법 제203조제3항제2호에 따른 보정기간 등 법령에 따라 지식재산처장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 정할 수 있는 기간은 이를 2개월 이내로 한다. 다만 특허에 관한 절차에 관련된 시험 및 결과측정에 시일을 요하는 때에는 그 지정기간은 해당 시험 및 결과측정에 소요되는 기간으로 한다(施規 16).

149) 법 제186조제5항의 규정에 의하여 심판장이 직권으로 정할 수 있는 부가기간은 30일 이내로 한다(施規 16⑤).

150) 기간의 기산일이란 기간의 계산에 넣는 최초의 날이고 만료일이란 기간의 계산에 넣는 최후의 날이다.

【표 1-11】 자연적/역법적 계산방법의 구체적인 예

첫날 (단, 0시부터 시작 x)	자연적 계산방법 (30일)	역법적 계산방법 (1개월)	비 고
9월 29일	10월 29일	10월 29일	○ 자연적 계산방법 - 정확 + 불편 ○ 역법적 계산방법 - 부정확 + 편리
9월 30일	10월 30일	10월 31일	
10월 1일	10월 31일	11월 1일	

3. 만료일의 결정

1) 월 또는 연의 처음부터 기간을 기산(起算)하지 아니하는 경우에는 마지막 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다(法 14Ⅲ본문).

2) 다만 월 또는 연으로 정한 경우에 마지막 월에 해당하는 날이 없으면 그 월의 마지막 날로 기간이 만료한다(法 14Ⅲ단서).¹⁵²⁾ 한편 특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「노동절 제정에 관한 법률」에 따른 노동절 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다(法 14Ⅳ).¹⁵³⁾ 이는 특허에 관한 절차를 밟는 자의 편의를 고려한 것이다. 다만 특허에 관한 절차가 아닌 기간은 원래의 해당일에 종료한다. 예를 들어 i) 심사와 관련이 깊은 기간으로서 국내우선권 주장에 있어서 선출원의 취하로 보는 때, ii) 출원을 공개하여야 할

151) 민법 제155조 내지 제161조는 다음과 같다.

제155조【본장의 적용범위】 기간의 계산은 법령, 재판상의 처분 또는 법률행위에 다른 정한 바가 없으면 본장의 규정에 의한다.

제156조【기간의 기산점】 기간을 시, 분, 초로 정한 때에는 즉시로부터 기산한다.

제157조【기간의 기산점】 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 그러나 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다.

제158조【연령의 기산점】 연령계산에는 출생일을 산입한다.

제159조【기간의 만료점】 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료한다.

제160조【역에 의한 계산】 ① 기간을 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다.

② 주, 월 또는 연의 처음으로부터 기간을 기산하지 아니한 때에는 최후의 주, 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다.

③ 월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.

제161조【공휴일과 기간의 만료점】 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다.

152) 특허법 제63조에 따른 의견서 제출기간을 통지일로부터 1개월로 정한 거절이유통지서를 1월 28일과 1월 31일에 각각 발송하였다면 1개월의 기간 만료일은 모두 2월 28일이 되고 다시 1개월의 연장기간이 추가된 경우 연장기간의 기산일은 모두 3월 1일이 되어 연장기간의 만료일은 모두 3월 31일이 된다 할 것이 다(기간의 만료일에 관한 유권해석 사례 - 법무부 법심 61010 - 221호, 95. 4. 24).

153) 특허법에 의한 기간을 계산함에 있어 기간의 첫날은 계산에 넣지 아니하고, 특허에 관한 출원·청구나 그 밖의 절차에 관한 기간의 마지막 날이 공휴일에 해당될 때에는 그 다음 날을 기간의 마지막 날로 한다고 규정하고 있는바, 1990년 曆에 의하면 원심이 명세서 보정기간이 만료되었다고 인정한 1990년 1월 27일은 설날 연휴이고, 1월 28일은 일요일로서 공휴일에 해당함이 명백하므로 위 보정기간은 그 다음 날인 1월 29일에 만료된다고 할 것이고, 따라서 출원인의 1990년 1월 29일자 보정서는 적법한 기간에 제출되었다고 할 것이다(대법원 1991. 2. 8. 선고 90후1680).

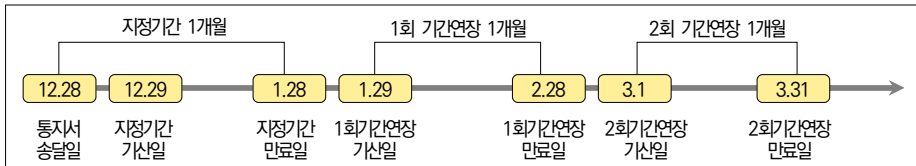
때, iii) 공시송달의 효력이 발생한 때 또는 iv) 특허권의 존속기간이 만료될 때 등은 기간의 마지막 날이 공휴일이라 하더라도 기간의 마지막 날은 그 다음 날로 연장되지 아니한다.

3) 한편 「특허에 관한 절차」는 특허에 관한 출원·청구나 그 밖의 절차를 말하는 것으로서, 심결에 대한 소의 제소기간은 이에 포함되지 아니한다. 예를 들어 노동절인 5월 1일이 심결취소소송제기 기간의 만료일인데 5월 2일에 소 제기를 한 경우에는 기간 경과로 부적법하다할 것이다.¹⁵⁴⁾

4) 전자문서를 제출하려는 자가 그 전자문서를 기한 전에 정보통신망을 이용하여 발송하였으나 정보통신망의 장애, 지식재산처가 사용하는 컴퓨터 또는 관련 장치의 장애(정보통신망, 지식재산처가 사용하는 컴퓨터 또는 관련 장치의 유지·보수를 위하여 그 사용을 일시 중단한 경우로서 지식재산처장이 사전에 공지한 경우에는 이를 장애로 보지 아니한다)로 인하여 기한 내에 제출할 수 없었던 경우에는 그 장애가 제거된 날의 다음 날에 그 기한이 도래한 것으로 본다(施規 9의4③).

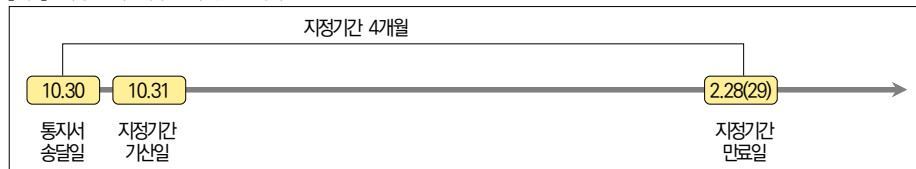
154) '심결에 대한 소'의 제소기간 계산에는 구 특허법 제14조제4호가 적용되지 아니하고, 그에 관하여 특허법이나 행정소송법에서 별도로 규정하고 있는 바도 없으므로, 결국 행정소송법 제8조에 따라 준용되는 민사소송법 제170조에 따라 "기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 기간은 그 익일로 만료한다"라고 규정한 민법 제161조가 적용된다고 할 것이다. 그리고 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전부 개정되기 전의 것. 이하 같다)은 구 특허법의 위 규정들을 모두 준용하고 있으므로, 위와 같은 법리는 실용신안에 관하여도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후1573).

【예1】 기간 연장일이 월 또는 년의 첫날부터 기간을 기산하는 경우



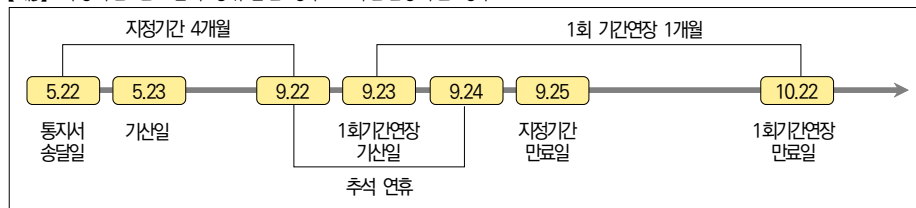
기간을 월 또는 년의 처음부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 마지막 월 또는 년에서 그 기산일에 해당하는 날의 전날로 기간이 만료한다(지정기간 만료일). 또한 기간연장 기산일이 월 또는 년의 첫날부터 기산한 때에는 마지막 월 또는 년의 마지막 날로 기간이 만료한다(2회의 기간연장 만료일).

【예2】 최종월에 해당일이 없는 경우



특허법상 기간의 계산에 있어서 첫날은 계산에 넣지 아니한다. 다만 기간이 오전 0시부터 시작하는 경우에는 계산에 넣는다. 상기 예에서 통지서 발송을 10. 30. 오전 0시에 한 경우에는 기간의 기산일은 10. 30. 이 되고 0시부터 시작하지 아니한 경우에는 기산일은 10. 31. 이 된다. 또한 마지막 월에 해당일이 없는 경우 그 월의 마지막 날로 기간이 만료한다. 즉 상기 예에서 2. 30.이 없으므로 2월의 마지막 날인 2. 28.(2. 29.까지 있는 경우에는 2. 29.)로 지정기간이 만료한다.

【예3】 지정기간 만료일이 공휴일인 경우로 기간연장하는 경우



특히에 관한 절차에 있어서 기간의 마지막 날이 공휴일인 경우에는 기간은 그 다음 날로 만료한다. 따라서 상기 예에서 기간연장이 없었다면 기간은 9. 25.로 만료된다. 그러나 기간의 기산일이 공휴일인 경우라도 기간의 기산일은 공휴일부터 시작된다. 따라서 기간연장의 만료일은 10. 22. 이 된다. 또한 상기 예에서 지정기간 만료일이 9. 25.로 된 경우 9. 25.까지 지정기간 연장 신청을 할 수 있으나 신청이 비록 9. 25.에 있었다 하더라도 기간연장의 기산일은 9. 23.이 되고 기간연장 만료일은 10. 22.이 된다.

【그림 1-10】 기간계산의 구체적인 예

IV. 기간의 연장 또는 단축

1. 법정기간의 연장

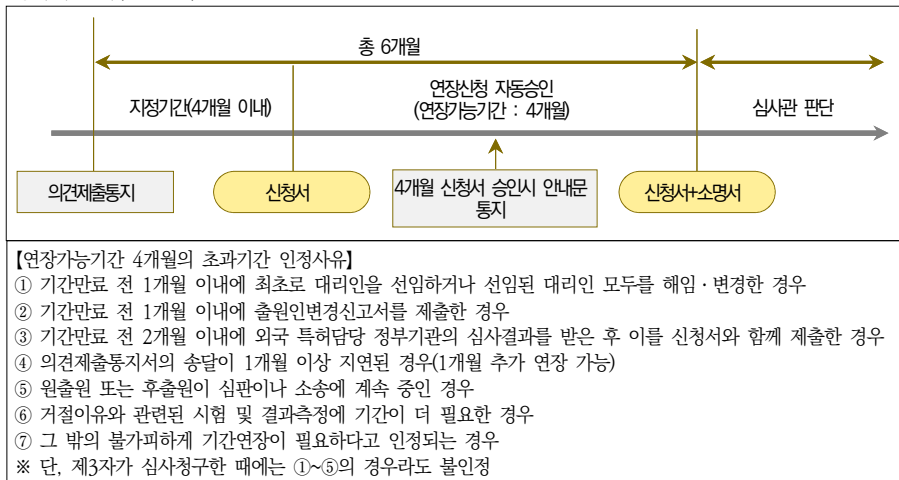
지식재산처장은 청구에 따라 또는 직권으로 거절결정불복심판의 청구기간을 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 총리령¹⁵⁵⁾으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다(法 15①).

2. 지정기간의 연장 또는 단축

지식재산처장·특허심판원장·심판장 또는 심사관은 이 법에 따라 특허에 관한 절차를 밟을 기간을 정한 경우에는 청구에 따라 그 기간을 단축 또는 연장하거나 직권으로 그 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 지식재산처장 등은 그 절차의 이해관계인의 이익이 부당하게 침해되지 않도록 단축 또는 연장 여부를 결정하여야 한다(法 15②).¹⁵⁶⁾ 구법에서는 지정기간의 연장만 가능하였으나, 2007. 7. 1. 시행된 현행법(법률 제8197호, 2007. 1. 3. 개정)에서는 지정기간 만료 이전에도 신속히 절차를 진행하려는 당사자의 청구에 의하여 그 절차에 대한 처분을 할 수 있도록 지정기간의 단축도 인정하고 있다.¹⁵⁷⁾

155) 법 제15조제1항 단서에 따라 지식재산처장이 추가로 연장할 수 있는 횟수는 1회로 하고, 그 기간은 30일 이내로 한다(施規 16④)

156) 방식심사와 관련된 지정기간의 연장은 매회 1개월 이내로 하고, 4회까지 연장할 수 있음을 원칙으로 한다. 실제심사와 관련된 지정기간은 4개월 이내로 하고, 최대 4개월까지 자동 연장할 수 있으며, 4개월이 초과된 경우에는 소명서를 바탕으로 심사관이 초과기간 인정사유에 해당하는지 여부를 판단하여 인정 여부를 결정하게 된다(施規 16).



157) 기간의 연장신청 또는 단축신청은 기간연장(단축)신청서에 의한다. 다만 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 및 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 보정서를 제출하는 때에는 해당 보정서에 기간 단축의 취지를 기재함으로써 그 신청서에 갈음할 수 있다(施規 16②).

【표 1-12】 기간연장·단축 및 기일변경의 비교

구 분		법정기간의 연장(法 15①)	지정기간의 연장·단축(法 15②)	지정기일의 변경(法 15③)
성 격		재량행위		
요 건	주 체	1. 지식재산처장 2. 청구 또는 직권	1. 지식재산처장, 특허심판원장, 심판장, 심사관 2. 단축 - 청구 3. 연장 - 청구 또는 직권	1. 심판장 2. 청구 또는 직권
	대 상	거절결정불복심판의 청구기간(法 132의17)	모든 지정기간	모든 지정기일
효 과		1회에 한해 30일 이내 기간 연장(단, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장가능)	기간의 단축 또는 연장(단, 이해관계인의 이익 부당 침해×)	기일의 변경

V. 기간의 경과와 구제방법

1. 기간의 경과에 대한 취급

「기간의 경과」란 당사자나 그 밖의 이해관계인이 정해진 기간에 정해진 절차를 밟지 아니하여 기간이 지난 것을 의미한다. 특허에 관한 절차를 밟은 자가 기간을 경과한 경우에는 원칙적으로 그 절차를 밟을 수 없으며 그 기간을 경과함으로써 발생하는 불이익을 감수하여야 한다. 예를 들어 지식재산처장 또는 심판원장의 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정하지 아니하면 그 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있고, 심사관으로부터 의견서를 제출할 수 있는 기회를 받은 출원인이 의견서를 제출하지 아니한 경우 심사관은 출원에 대하여 특허거절결정을 할 수 있으며, 법정기간을 지나서 심판청구를 하는 경우 심판관 합의체는 피청구인에게 답변서 제출기회도 주지 아니하고 심판청구를 심결로써 각하할 수 있다.

2. 구제방법

(1) 무효처분의 취소

1) 지식재산처장 또는 특허심판원장은 절차의 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하여 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 정당한 사유¹⁵⁸⁾에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에

158) 기존에는 절차의 무효(法 16②), 특허출원의 회복(法 67의3), 특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등(法 81의3)의 규정에서 책임질 수 없는 사유를 요구하였으나 책임질 수 없는 사유는 천재지변에 한정되는 경우가 많고 실무상 매우 제한적으로 해석되고 있어, 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 이를 정당한 사유로 변경하였다. 정당한

보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다(法 16②). 무효처분을 취소 받으려는 경우에는 기간경과구제신청서에 경과사유를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다(施規 17).

2) 지식재산처장 또는 심판원장은 무효처분의 취소처분을 할 때에는 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 하며(法 16③), 무효처분취소통지서에 무효처분을 취소한 때부터 당초 보정기간에 해당하는 기간에 보정할 수 있다는 취지를 병기하여 보정할 수 있도록 한다. 한편 무효처분 후 무효처분취소 전까지 특허에 관한 절차 또는 심사가 진행된 경우에는 사안별로 검토하여 무효처분의 취소 여부에 따른 영향과 신뢰보호원칙 등을 고려하여 그 절차 및 심사결과의 효력 여부를 결정한다.¹⁵⁹⁾

(2) 추후보완

「추후보완」이란 기간을 지나서 절차를 밟았지만, 기간에 절차를 밟은 것으로 간주해 주는 것을 말한다. 특허에 관한 절차를 밟는 자가 책임질 수 없는 사유¹⁶⁰⁾¹⁶¹⁾로 i) 거절결정불복심판의

사유로 변경할 경우 기존에 인정되지 않았던 사례 중 상당한 주의의무를 다한 것인지 여부(예를 들어 출원인의 지병, 특허고객상담센터의 오안내, 특허료(등록료) 납부 오류 등은 정당한 사유에 포함된 것으로 판단)에 따라 보다 많은 출원인 등의 권리를 구제할 수 있을 것으로 보인다(채수근 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안, 디자인보호법 일부개정법률안, 상표법 일부개정법률안 검토보고(송갑석 의원 대표발의)(의안번호 제2104891호, 제2104892호 및 제2104893호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2. 14-15면). 다만 특허법 제67조의3과 제17조 모두 그 적용대상을 달리하는 추후보완이라고 할 수 있는데, 민사소송법 제173조를 고려하여 특허법 제17조를 개정하지 않고 기존의 책임질 수 없는 사유를 유지하는 것은 바람직하지 않다고 생각한다. 더욱이 제17조에서의 거절결정불복의 심판청구기간(法 132의17)과 제67조의3에서의 재심사청구기간(法 67의2①)이 모두 거절결정등본송달일로부터 3개월로서 동일한 기간임을 고려하면 동일한 기간에 차별을 두는 것을 적절하지 않는 것으로 보인다.

- 159) 예를 들어 심사관의 거절이유통지에 따른 명세서 등의 보정서 제출시 수수료 납부에 흠결이 있어 심사관이 보정을 명하였으나, 이 흠결을 지정된 기간에 보정하지 못하여 명세서 보정절차를 무효처분하고 이에 따라 출원이 거절이유를 해소하지 못하여 특허거절결정한 경우, 이후 무효처분을 취소하였다면 특별한 이유가 없는 한 특허거절결정을 취소하고 수수료의 흠결을 보정할 수 있는 기회를 부여하는 등 심사절차를 진행한다.
- 160) 「책임질 수 없는 사유」란 일반인이 보통의 주의를 다하여도 피할 수 없는 사유로서 천재·지변 기타 불가피한 사유가 해당되는 물론이며, 서류를 당사자가 아닌 자에게 송달한 경우를 포함한다. 다만 공시송달 사실을 몰랐다는 이유는 특별한 사유가 없는 한 책임질 수 없는 사유에 포함되지 않는다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 1408면).
- 161) 「특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임을 질 수 없는 사유」라 함은 특허에 관한 절차를 밟은 자가 그 절차를 밟기 위하여 일반적으로 하여야 할 주의를 다하였음에도 불구하고 그 기간을 준수할 수 없었던 사유를 가리키고, 그 「특허에 관한 절차를 밟은 자」에는 본인뿐만 아니라 대리인 및 대리인의 보조인도 포함된다(대법원 1999. 6. 11. 선고 99다9622; 2007. 10. 26. 선고 2007다37219 등). 이 사건 거절결정 등본이 원고의 출원대리인인 변리사에게 적법하게 송달되었음에도, 변리사가 그에 대한 불복심판을 청구하지 아니하였는바, 그에 대하여 변리사에게 책임질 수 없는 사유가 있다는 점에 대한 원고의 아무런 주장·증명이 없다. 또한 원고가 주장하는 사정, 즉 출원대리인인 변리사가 이 사건 거절결정 등본을 송달받고도 이에 대하여 당시 국외에 있던 원고에게 아무런 고지를 하지 아니하여 원고가 이 사건 거절결정 사실을 몰랐다는 사정만으로는 원고가 구 특허법 제132조의3 소정의 기간 내에 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하지 못한 데 구 특허법 제17조 소정의 「특허에 관한 절차를 밟은 자가 책임질 수 없는 사유」가 있

청구기간(法 132의17), ii) 재심청구기간(法 180①)을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날로부터 2개월 이내 및 그 기간의 만료일로부터 1년이 지나기 전까지 지키지 못한 절차를 추후보완할 수 있다(法 17). 절차의 추후보완을 받으려는 자는 기간경과구제신청서에 경과사유를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다(施規 17). 이 경우에는 지정기간의 경과로 인한 절차무효의 취소조치(法 16②)와 같은 지식재산처장의 조치가 별도로 필요한 것은 아니다. 적법하게 추후보완을 하면 법정기간 이내 서류를 제출한 것과 동일한 취급을 한다.

(3) 특허출원의 회복

1) 특허출원인이 정당한 사유로 다음의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일로부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다(法 67의3①).

i) 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간

ii) 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간

2) 이처럼, 출원심사의 청구나 재심사의 청구가 있는 경우에는 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다(法 67의3②).

【표 1-13】 추후보완 및 특허출원의 회복

제 도	추후보완(제17조)		특허출원의 회복(제67조의3)
의 의	기간을 지나서 절차를 밟았지만 기간에 절차를 밟은 것으로 간주해 주는 것		
요 건	주체적	책임질 수 없는 사유로 기간을 경과	정당한 사유로 기간을 경과
	객체적	① 거절결정불복심판청구기간(法 132의17) → 거절결정등본송달일로부터 3개월 ② 재심청구기간(法 180①) → 안 날로부터 30일 cf) 상기 규정한 심판 외에는 특별히 심판청구기간을 법률에서 정하고 있는 심판이 없으므로 추후보완의 인정 문제 不要	1. 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간(法 59 ②③) → 출원일로부터 3년 2. 재심사의 청구를 할 수 있는 기간(法 67의 2①) → 거절결정등본송달일로부터 3개월
	시기적	그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내. 단 그 기간의 만료일로부터 1년이 지난 후에는 불가	
절 차	기간경과구제신청서를 지식재산처장에게 제출(施規 17)		
효 과	적법	적법하게 심판청구된 것으로 보고 심판 진행	적법하게 심사청구/재심사청구된 것으로 보고 심사 진행
	부적법	심판청구를 할 수 있는 기간 경과로 심결각하	1. 심사청구를 할 수 있는 기간 경과로 출원 취하 간주 2. 재심사청구를 할 수 있는 기간 경과로 거절결정의 확정

다고 볼 수도 없다(특허법원 2017. 9. 15. 선고 2017허4853).

(4) 특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원 또는 특허권의 회복

① 서

i) 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허출원이 포기간주되거나 특허권이 소멸간주되는 경우 또는 ii) 정당한 사유가 아니더라도 특허권자의 부지(不知)나 실수로 인해 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허권이 소멸되는 경우 너무 가혹하므로 일정요건하에서 회복할 기회를 주고 있다.

② 요 건

1) 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 i) 그 사유가 소멸한 날로부터 2개월 및 ii) 추가납부기간의 만료일과 보전기간의 만료일 중 늦은 날로부터 1년 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다(法 81의3①).

2) 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다(法 81의3③). 이 규정은 특허권자 등의 사업 연속성을 지원하여 특허권자의 경쟁력 향상에 기여하기 위한 것이다.

③ 절 차

특허료를 추가납부기간에 추가로 내거나 또는 보전기간에 보전하려는 자는 설정특허료 납부서 또는 연차특허료 납부서 또는 특허료 보전서에 그 취지를 기재하고 i) 특허출원인 또는 특허권자가 정당한 사유로 납부기간에 내지 아니하였음을 증명하는 서류 1통, ii) 대리인에 따라 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통을 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 81의3⑦, 施規 55의2).

④ 효 과

특허료를 내거나 보전한 자는 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다(法 81의3②③). 이처럼 회복된 특허출원 또는 특허권의 효력은 특허료 추가납부기간 또는 보전기간이 지난날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 “효력제한기간”이라 한다) 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다(法 81의3④). 효력제한기간 중 국내에서 선의로 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 81의3⑤⑥).

【표 1-14】 특허법상 주요 법정기간(1)

종 류		근거조문	기준일(만료일의 시작일)	기간
무효처분의 취소		法 16②	· 정당한 사유소멸일	2개월
			· 단, 기간 만료일 1년 이내	
절차의 추후보완		法 17	· 책임질 수 없는 사유소멸일	2개월
			· 단, 기간 만료일 1년 이내	
공지예의 적용	출원	法 30①	· 공지일	12개월
	증명서류	法 30②	· 공지예외적용출원일	30일
정당한 권리자의 출원		法 34	· 특허를 받지 못하게 된 날	30일
		法 35	· 무효심결이 확정된 날	30일
청구범위제출유예		法 42의2	· 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)	1년 2개월
			· 단, 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날로부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날	
외국어특허출원의 국어번역문 제출		法 42의3	· 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)	1년 2개월
			· 단, 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날로부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날	
분할출원		法 52①	· 특허거절결정등본송달일	3개월
분리출원		52의2①	· 거절결정불복심판의 기각심결등본송달일	30일
변경출원		法 53①	· 최초 특허거절결정등본송달일	3개월
분할출원·변경출원의 조약우선권증명서류 제출		法 52⑥, 53⑥	· 분할·변경출원일	3개월
분할출원·변경출원의 국어번역문 제출		法 52⑦, 53⑦	· 분할·변경출원일	30일
			· 단, 명세서 또는 도면의 보정이나 출원인의 심사청구가 있는 경우에는 불가	
분할출원·변경출원의 청구범위제출유예		法 52⑧, 53⑧	· 분할·변경출원일	30일
조약우선권주장	출원	法 54②	· 최초 제1국 출원일	1년
	증명서류	法 54⑤	· 최우선일	1년 4개월
	보정 또는 추가	法 54⑦	· 최우선일	1년 4개월
국내우선권주장	출원	法 55①	· 선출원일	1년
	보정 또는 추가	法 55⑦	· 최선출원일	1년 4개월
	선출원의 취하	法 56①	· 선출원일	1년 3개월
	우선권주장의 취하	法 56②	· 선출원일	1년 3개월
심사청구		法 59②	· 출원일	3년
		法 59③	· 분할출원·분리출원·변경출원·정당한 권리자 출원일	30일
출원공개		法 64①	· 출원일 또는 우선권주장의 최우선일	1년 6개월

【표 1-15】 특허법상 주요 법정기간(2)

종 류		근거조문	기준일(만료일의 시작일)	기간
재심사의 청구		法 67의2①	· 특허거절결정등본송달일	3개월
			· 단, 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부 결정이 있는 경우, 거절결정불복심판청구가 있는 경우(제 176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외 한다) 또는 그 특허출원이 분리출원인 경우에는 불가	
특허출원의 회복		法 67의3①	· 정당한 사유소멸일 · 단, 기간 만료일 1년 이내	2개월
특허료 납부	납부기간	法 79②	· 특허결정등본 송달일	3개월
	추납기간	法 81①	· 납부기간이 지난 후	6개월
	보전기간	法 81의2②	· 보전명령받은 날	1개월
	회복기간	法 81의3①	· 정당한 사유소멸일 · 단, 추납기간과 보전기간 만료일 중 늦은 날부터 1년	2개월
		法 81의3③	· 추가납부기간 또는 보전기간 만료일	3개월
과오납 반환청구		法 84③	· 과오납 통지 도달일	5년
존속기간		法 88①	· 출원일 · 단 기산일은 설정등록일	20년
허가 등에 따른 존속기간연장등록출원		法 90②	· 허가 등을 받은 날	3개월
			· 존속기간 만료 전	6개월
등록지연에 따른 존속기간연장 등록출원	연장가능기간	法 92의3②	· 출원일	4년
			· 심사청구일	3년
	출원	法 92의3②	· 설정등록일	3개월
통상실시권 설정의 재정		法 107②	· 출원일	4년
특허취소신청기간		法 132의2	· 특허권의 설정등록일로부터 등록공고일 후	6개월
특허거절결정 등에 대한 불복심판		法 132의17	· 거절결정등본송달일	3개월
재심청구		法 180	· 재심사유를 안날	30일
			· 단, 특허취소결정 또는 심결확정일로부터	3년
특허법원에 소 제기		法 186③	· 심결 · 결정등본송달일	30일
보상금 · 대가에 불복의 소		法 190②	· 등본송달일	30일
도면 제출일		法 194④	· 취지통지일	2개월
국어번역문제출기간		法 201①	· 우선일	31개월
			· 단, 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 연장 취지를 적은 서면을 제출한 경우에는 국내서면 제출기간 만료일부터 1개월	
선출원이 국제특허출원인 경우 취하간주		法 202③Ⅲ	· 국제출원일로부터 1년 3개월이 지난 때와 기준일 중 늦은 때	
특허관리인선임신고		法 206②	· 기준일	2개월
공시송달효력발생		法 219③	· 공보게제일	14일
소송기록 열람 금지 기간		法 224의5②	· 열람청구일	2주일

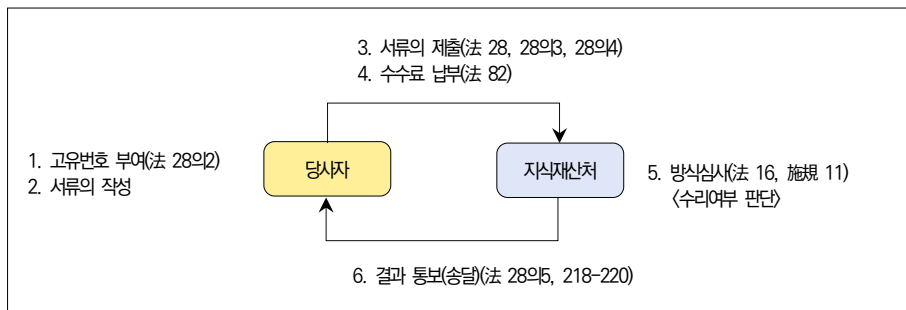
제7장

특허에 관한 절차 일반

제1절 서 설

1) 절차법적인 성질을 가진 특허법은 절차의 명확화 및 안정성을 중시한다. 따라서 지식재산처에 대하여 일정한 절차를 밟으려는 자는 특허법에서 정한 양식에 따라 서류를 작성한 후(양식주의) 서면 또는 전자문서(서면주의¹⁶²)로 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 1건마다 지식재산처에 제출하여야 한다. 절차를 밟으려는 자는 서류를 제출할 때 각 서류의 표지에 제출인의 성명(법인의 경우에는 명칭)과 미리 부여받은 고유번호를 적을 수 있으며, 이처럼 고유번호를 적으면 절차를 밟으려는 자의 특정을 위한 주소를 적지 아니하여도 된다(施規 2).

2) 절차를 밟으려는 자가 서류를 제출하면 접수번호가 부여되며, 그 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 수수료를 납부하면 지식재산처장 등이 방식심사를 하게 된다. 「방식심사」란 지식재산처장 등이 절차를 밟으려는 자의 서류를 수리할 것인지를 심사하는 것을 말한다. 지식재산처장 등은 방식심사 결과 제출된 서류에 흠결이 있으면 절차의 무효나 반려(불수리) 처분을 하게 된다.



【그림 1-11】 특허에 관한 절차 일반

162) 전자문서에 의한 서류의 제출도 서면에 의한 서류의 제출과 동일한 효과가 발생하기 때문에 광의의 서면주의는 전자문서에 의한 제출까지 포함하는 개념이다.

제2절 고유번호의 부여 및 기재 등

제28조의2 【고유번호의 기재】

- ① 특허에 관한 절차를 밟는 자 중 총리령으로 정하는 자는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 자신의 고유번호의 부여를 신청하여야 한다.
- ② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항에 따른 신청을 받으면 신청인에게 고유번호를 부여하고, 그 사실을 알려야 한다.
- ③ 지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차를 밟는 자가 제1항에 따라 고유번호를 신청하지 아니하면 그에게 직권으로 고유번호를 부여하고, 그 사실을 알려야 한다.
- ④ 제2항 또는 제3항에 따라 고유번호를 부여받은 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우에는 총리령으로 정하는 서류에 자신의 고유번호를 적어야 한다. 이 경우 이 법 또는 이 법에 따른 명령에도 불구하고 그 서류에 주소(법인인 경우에는 영업소의 소재지를 말한다)를 적지 아니할 수 있다.
- ⑤ 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인에 관하여는 제1항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.
- ⑥ 고유번호의 부여 신청, 고유번호의 부여 및 통지, 그 밖에 고유번호에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

특허에 관하여 절차를 밟는 자는 지식재산처로부터 고유번호를 부여받게 되며, 이를 제출서류에 적으면 주소를 적지 아니하여도 된다. 이와 같이 고유번호에 의한 절차를 밟게 하여 출원인과 대리인의 정보를 관리함으로써 주소 등의 정보 변경이 있는 경우에 한 번의 절차로 지식재산처에서 밟고 있는 모든 절차에 관한 정보가 변경되는 효과를 거둘 수 있게 되었다.¹⁶³⁾ 이러한 고유번호에는 특허고객번호와 대리인번호가 있다.

II. 특허고객번호의 부여방법

1. 신청에 의한 부여

특허에 관한 절차를 밟는 자는 i) 출원인, ii) 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인, iii) 심사청구인, iv) 정정청구인, v) 우선심사신청인, vi) 특허출원에 대한 정보제공인, vii) 재심사청구인, viii) 심판청구인·심판피청구인 및 심판참가인, ix) 특허권자, x) 전용실시권자 또는 통상실시권자, xi) 질권자는 이미 고유번호를 부여받은 자를 제외하고는 지식재산처 또는 특허심판원에 자신의 고유번호 부여를 신청하여야 하는데(法 28의2①, 施規 9①), 이 경우 고유번호의 부여를 신청하려는 자는 소정 양식의 고유번호부여신청서를 지식재산처장 또는 특허심

163) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 155면.

판원장에게 제출하여야 한다(施規 9②). 지식재산처장 또는 특허심판원장은 고유번호 부여의 신청을 받으면 신청인에게 고유번호를 부여하고 그 사실을 알려야 한다(法 28의2②). 한편 지식재산처장은 특허고객번호가 이중으로 부여되었거나 잘못 부여된 경우 직권으로 특허고객번호를 정정하거나 말소할 수 있다. 이 경우 직권으로 정정하거나 말소한 사실을 특허고객번호를 부여받은 자에게 통지하여야 한다(施規 9⑤).

2. 직권에 의한 부여

지식재산처장 또는 특허심판원장은 상술한 특허에 관한 절차를 밟는 자가 고유번호를 신청하지 아니하면 직권으로 고유번호를 부여하고 그 사실을 알려야 한다(法 28의2③).

Ⅲ. 특허고객번호의 기재

1) 고유번호를 부여받은 자가 특허에 관한 절차를 밟을 때는 절차에 관한 서류에 자신의 고유번호를 적어야 한다. 따라서 서면출원이면 지식재산처에 대한 절차 수행시 모든 출원서류 및 중간서류의 출원인 기재란에 고유번호를 적어야 하며, 전자출원이면 출원서류 작성용 소프트웨어를 이용하여 전자문서를 작성할 때 출원인 기재란에 고유번호를 적고 암호화키를 통해 암호화하여야 한다. 이렇게 서류에 고유번호를 적은 경우에는 원칙적으로 서류에 주소를 적어야 함에도 불구하고 그 서류에 「주소」(법인인 경우에는 영업소의 소재지)를 적지 아니할 수 있다(法 28의2④).

2) 고유번호를 부여받은 자는 주소, 인감 등의 변경신고서를 제출하여 이를 변경할 수 있고 또한 고유번호를 이중으로 부여받았거나 잘못 부여받은 경우에도 이를 신청에 따라 정정할 수 있다(施規 9③④).

Ⅳ. 대리인번호의 준용

고유번호의 부여 및 기재는 특허에 관한 절차를 밟는 자의 대리인에 관하여 이를 준용한다(法 28의2⑤).

제3절 서류제출방식의 선택

I. 서면에 의한 제출

제28조 【서류제출의 효력발생시기】

- ① 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서, 청구서, 그 밖의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다. <개정 2014.6.11.>
- ② 제1항의 출원서, 청구서, 그 밖의 서류를 우편으로 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 날에 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다. 다만, 특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 「특허협력조약」 제2조(vii)에 따른 국제출원(이하 “국제출원”이라 한다)에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 그 서류가 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 효력이 발생한다. <개정 2014.6.11.>
1. 우편물의 통신일부인(通信日附印)에 표시된 날이 분명한 경우: 표시된 날
 2. 우편물의 통신일부인에 표시된 날이 분명하지 아니한 경우: 우체국에 제출한 날을 우편물 수령증에 의하여 증명한 날
- ③ 삭제 <1998.9.23.>
- ④ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 우편물의 지연, 우편물의 망실(亡失) 및 우편업무의 중단으로 인한 서류제출에 필요한 사항은 총리령으로 정한다. <개정 2014.6.11.>
- [제목개정 2014.6.11.]

1. 효력발생시기

(1) 원 칙

이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 출원서, 청구서, 그 밖의 서류(물건을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 날부터 제출의 효력이 발생한다(法 28①). 이른바 도달주의의 원칙을 취하고 있다.

(2) 예 외

출원서, 청구서, 그 밖의 서류를 우편으로 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 경우에는 i) 우편물의 통신일부인에 표시된 날이 분명한 경우에는 그 표시된 날, ii) 그 표시된 날이 불분명한 경우에는 우체국에 제출한 날을 우편물의 수령증에 의하여 증명한 날에 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 도달한 것으로 본다(法 28②본문). 도달주의만을 관철하면 지식재산처와 당사자와의 지리적 원근에 따라 불공평한 결과가 발생하기 때문에 우편으로 출원서·청구서 등을 제출할 경우에는 실질적으로 발신주의를 취한다. 다만 우편물의 통신일부인이 불분명하거나 우편물의 수령증이 없는 경우에는 지식재산처에 도달된 날에 효력이 발생한다.

(3) 예외의 예외

특허권 및 특허에 관한 권리의 등록신청서류와 국제출원에 관한 서류를 우편으로 제출하는 경우에는 예외의 예외를 인정함으로써 도달주의의 원칙에 서 있다(法 28②단서). 등록신청서류는 권리변동을 수반할 수 있으므로 등록의 순위를 명확히 하기 위한 것이다. 특허협력조약에 의한 국제출원의 경우에는 기본적 요건이 충족되어 있음을 확인하는 것을 조건으로 그 수리일을 국제출원일로 인정하도록 규정(특허협력조약 제11조)되어 있기 때문이다. 그러나 이는 국제출원일 부여와 관계되는 국제출원서 또는 보관에 관한 서류 등에 한정되며, 국제출원 후에 PCT 출원에 관한 번역문이나 의견서 등의 서류 취급은 통상의 제출된 서류와 동일한 취급을 한다.

2. 우편물의 지연·망실의 경우

1) 국제출원에 관한 서류로서 제출기간이 정하여져 있는 것을 등기우편에 의하여 제출한 경우에 우편물의 지연 또는 망실로 인하여 그 서류가 제출기간에 도달되지 아니한 때에는 출원인은 그 서류를 제출기간의 만료일 5일 전까지 우편으로 발송한 사실을 증명하는 증거 또는 망실한 서류를 대신하는 새로운 서류 및 새로운 서류가 망실한 서류와 동일하다는 것을 증명하는 증거를 지식재산처장에게 제출할 수가 있다(施規 86①본문, 97).

2) 이를 제출할 수 있는 기간은 서류의 도달지연 또는 망실을 알게 된 날 또는 상당한 주의를 했더라면 알 수 있었던 날부터 1개월 이내인데, 그 최대한의 기간은 서류의 제출기간의 만료일로부터 6개월 이내이다. 위와 같은 조건이 충족되면 서류가 제출기간에 도착한 것으로 본다. 다만 그 서류를 항공우편으로 발송할 수 있고 또한 항공우편외의 방법으로는 도달에 통상적으로 3일 이상 소요되는 것이 명백한 경우 그 서류를 항공우편으로 발송하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다(施規 86①단서, 86②③, 87).

II. 전자문서에 의한 제출

제28조의3 【전자문서에 의한 특허에 관한 절차의 수행】

- ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 이 법에 따라 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 특허출원서, 그 밖의 서류를 총리령으로 정하는 방식에 따라 전자문서화하고, 이를 정보통신망을 이용하여 제출하거나 이동식 저장장치 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 제출된 전자문서는 이 법에 따라 제출된 서류와 같은 효력을 가진다.
- ③ 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 그 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다.
- ④ 제1항에 따라 전자문서로 제출할 수 있는 서류의 종류·제출방법, 그 밖에 전자문서에 의한 서류의 제출에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제28조의4 【전자문서 이용신고 및 전자서명】

- ① 전자문서로 특허에 관한 절차를 밟으려는 자는 미리 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고를 하여야 하며, 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 전자문서에 제출인을 알아볼 수 있도록 전자서명을 하여야 한다.
- ② 제28조의3에 따라 제출된 전자문서는 제1항에 따른 전자서명을 한 자가 제출한 것으로 본다.
- ③ 제1항에 따른 전자문서 이용신고 절차, 전자서명 방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제28조의5 【정보통신망을 이용한 통지 등의 수행】

- ① 지식재산처장·특허심판원장·심판장·심판관 또는 심사관은 제28조의4제1항에 따라 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 및 송달(이하 “통지등”이라 한다)을 하려는 경우에는 정보통신망을 이용하여 통지등을 할 수 있다.
- ② 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 한 서류의 통지등은 서면으로 한 것과 같은 효력을 가진다.
- ③ 제1항에 따른 서류의 통지등은 그 통지등을 받을 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다.
- ④ 제1항에 따라 정보통신망을 이용하여 하는 통지등의 종류·방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

1. 서 설

(1) 의 의

「전자문서에 의한 제출」이란 작성한 서류를 전자문서화하고, 지식재산처장 또는 특허심판원장에 정보통신망을 이용하여 제출(이하 “온라인 제출”이라 한다)하거나 이동식 저장장치 등 전자적 기록매체에 수록하여 제출(이하 “전자적 기록매체를 이용한 제출”이라 한다)하는 것을 말한다.

(2) 취 지

특허법은 전자문서에 의한 서류의 제출을 인정함으로써 i) 원거리에 있는 출원인 및 대리인 등이 효과적으로 서류 제출을 할 수 있도록 하는 한편 ii) 지식재산처의 입장에서도 서류의 송달시 출원인 또는 대리인에게 전자문서의 형식으로 송달하여 기존의 우편송달 등에 의한 경우보다 비용을 절약할 수 있게 되었다.

2. 전자문서에 의한 제출의 요건

(1) 전자문서의 이용신고 및 전자서명

전자문서로 특허에 관한 절차를 밟으려는 자는 미리 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 전자문서 이용신고(164)를 하여야 하며, 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출하는 전자문서에 제출인을 알아볼 수 있도록 전자서명을 하여야 한다(法 28의4①). 이 경우 제출된 그 전자문서는 그 전자서명을 한 자가 제출한 것으로 본다(法 28의4②).

(2) 전자문서로 제출할 수 있는 서류의 종류

1) i) 전자문서 첨부서류 등 물건제출서, ii) 특허증 정정발급 신청서, iii) 조약 제2조(vii)에 따른 국제출원의 사용언어가 일본어인 관련서류, iv) 제214조제1항(결정에 따라 특허출원으로 되는 국제출원)에 따른 결정신청서를 제외하고는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 전자문서로 제출할 수 있다(施規 9의2①). 다만 시행령 제11조에 의한 분류기준에 해당하는 국방관련 특허출원의 경우에는 보안유지의 해제통지를 받거나 비밀해제의 통지를 받기 전까지 전자문서로 제출할 수 없다(施規 9의2③).

2) 전자출원을 쉽게 할 수 있도록 특허에 관한 절차 또는 심판절차를 밟는 자가 전자문서로 서류를 제출하는 경우 그 첨부서류를 전자적 이미지로 작성하여 제출할 수 있다(施規 3의2).

3. 전자문서에 의한 제출의 절차

(1) 전자문서의 제출방법

① 온라인 제출

1) 전자문서는 지식재산처에서 제공하는 소프트웨어 또는 지식재산처 홈페이지를 이용하여 전자서명을 하여 제출하여야 한다. 다만 국제출원의 경우에는 국제사무국에서 제공하는 소프트웨어 또는 국제사무국 홈페이지를 이용하여 「특허협력조약 시행세칙」에 따른 전자서명을 하여 제출하여야 한다(施規 9의4①). 온라인 제출을 하려는 자는 전자서명에 필요한 인증서를 사용하여 제출하여야 한다(施規 9의6). 한편 전자문서를 제출하려는 자가 그 전자문서를 기한 전에 정보통신망을 이용하여 발송하였으나 정보통신망의 장애, 지식재산처가 사용하는 컴퓨터 또는 관련 장치의 장애(정보통신망, 지식재산처가 사용하는 컴퓨터 또는 관련 장치의 유지·보수를 위하여 그 사용을 일시 중단한 경우로서 지식재산처장이 사전에 공지한 경우에는 이를 장애로 보지 아니한다)로 인하여 기한 내에 제출할 수 없었던 경우에는 그 장애가 제거된 날의 다음 날에 그 기한이 도래한 것으로 본다(施規 9의4③).

2) 특허에 관한 절차(국제출원에 관한 절차를 제외한다)를 밟는 자가 온라인 제출을 하는 경우 이에 첨부하여야 하는 서류 중 온라인 제출시 이를 첨부하지 아니한 서류는 온라인 제출 접수번호를 확인한 날부터 3일 이내에 전자문서첨부서류등 물건제출서에 첨부하여 서면으로 제출하여야 한다(施規 9의5).¹⁶⁵⁾

164) 전자문서 이용신고는 전자서명에 필요한 인증서를 사용하여 전산정보처리조직을 통하여 이루어진다. 이 경우 전자서명을 위한 인증서의 내용은 특허고객번호의 출원인 정보와 일치하여야 한다(施規 9의3).

165) 첨부서류의 유형으로는 승계인임을 증명하는 서류(施規 7①), 제3자의 허가 등에 관한 증명(施規 7②), 대리인의 선임 등(施規 5), 포괄위임(施規 5의2), 복수당사자의 대표자 선정신고(施規 6), 법인증명 또는 법인국적증명(施規 8①), 국적증명서(施規 8①) 등이 있다(지식재산처, 「출원방식심사지침서」, 2015, 33-34면).

② 전자적 기록매체를 이용한 제출

전자적 기록매체를 이용하는 경우에는 전자문서첨부서류등 물건제출서와 전자문서를 수록한 전자적 기록매체를 지식재산처에 제출한다. 이 경우 전자적 기록매체에 제출할 수 없는 서류는 전자문서첨부서류등 물건제출서에 첨부하여 제출하여야 한다(施規 9의4).

(2) 동시제출의 특례

법령에 따라 동시에 하도록 되어 있는 둘 이상의 절차를 온라인 제출로 하는 경우에는 연속하여 입력하여야 하며, 둘 이상의 절차 중에 하나의 절차를 전자적 기록매체 또는 서면으로 제출하는 경우에는 그 둘 이상의 절차를 같은 날에 행하여야 한다(施規 9의7).

4. 전자문서에 의한 제출의 효력

(1) 적법하게 제출된 전자문서의 효력

온라인이나 전자적 기록매체로 제출된 전자문서는 특허법에 의하여 제출된 서류와 같은 효력을 가진다(法 28의3②). 한편 온라인 제출된 전자문서는 그 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다(法 28의3③).

(2) 부적법하게 제출된 전자문서의 효력

지식재산처장, 특허심판원장은 i) 지식재산처에서 배포한 소프트웨어로 작성되지 아니한 경우, ii) 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 형태로 접수된 경우 및 iii) 전자적 이미지의 첨부 서류가 판독이 곤란하여 해당 서류를 서면으로 제출하라는 명령을 받고 이를 기간에 제출하지 아니한 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우 출원인 등에게 소명기회를 주고 소명하지 않거나 소명이 적법하지 아니하면 불수리한다(施規 11).

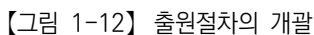
5. 정보통신망에 의한 통지 및 송달

(1) 대 상

전자문서 이용신고를 한 자 중 전자문서로 통지 또는 송달을 받으려는 자에 대해서는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 모든 서류를 온라인을 이용하여 통지 또는 송달할 수 있다(施規 9의8).

(2) 효 력

지식재산처장·특허심판원장·심판장·심판관 또는 심사관은 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 및 송달(이하 "통지 등"이라 한다)을 하려는 경우에는 정보통신망을 이용하여 통지등을 할 수 있고, 서류의 통지 등은 서면으로 한 것과 같은 효력이 있으며, 「그 통지 등을 받을 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때」에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다(法 28의5).



제4절 수수료의 납부

제82조 【수수료】

- ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 내야 한다.
- ② 특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구 범위에 적은 청구항의 수가 증가한 경우에는 그 증가한 청구항에 관하여 내야 할 심사청구료는 특허출원인이 내야 한다.
- ③ 제1항에 따른 수수료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제83조 【특허료 또는 수수료의 감면】

- ① 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허료 및 수수료는 제79조 및 제82조에도 불구하고 면제한다.
 1. 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료
 2. 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항에 따른 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료
- ② 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 제79조 및 제82조에도 불구하고 총리령으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다. <개정 2016. 3. 29., 2021. 8. 17.>
 1. 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자
 2. 「재난 및 안전관리 기본법」 제36조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제60조에 따른 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중 총리령으로 정하는 요건을 갖춘 자
 3. 그 밖에 총리령으로 정하는 자
- ③ 제2항에 따라 특허료 및 수수료를 감면받으려는 자는 총리령으로 정하는 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
- ④ 지식재산처장은 제2항에 따른 특허료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 자에 대하여는 총리령으로 정하는 바에 따라 감면받은 특허료 및 수수료의 2배액을 징수할 수 있다. 이 경우 그 출원인 또는 특허권자가 하는 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 총리령으로 정하는 기간 동안 제2항을 적용하지 아니한다. <신설 2021. 8. 17.>

[전문개정 2014.6.11.]

제84조 【특허료 등의 반환】

- ① 납부된 특허료 및 수수료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다. <개정 2015. 5. 18., 2016. 2. 29., 2016. 3. 29., 2021. 8. 17., 2021. 10. 19.>
 1. 잘못 납부된 특허료 및 수수료
 2. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이나 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
 3. 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
 4. 특허출원(분할출원, 분리출원, 변경출원 및 제61조에 따른 우선심사의 신청을 한 특허출원은 제외한다) 후 1개월 이내에 그 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 낸 수수료 중 특허출원료 및 특허출원의 우선권 주장 신청료
 5. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료
- 가. 제36조제6항에 따른 협의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정한다)

- 나. 삭제 <2021. 8. 17.>
 다. 제63조에 따른 거절이유통지
 라. 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달
 5의2. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액
 가. 제5호가목에 따른 신고 명령 후 신고기간 만료 전까지
 나. 제5호다목에 따른 거절이유통지(제47조제1항제1호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의견서 제출기간 만료 전까지
 6. 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
 7. 제176조제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 심판 또는 재심 중 제170조제1항에 따라 준용되는 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 보정이 있는 경우는 제외한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료(재심의 경우에는 재심청구료를 말한다. 이하 이 조에서 같다)
 8. 심판청구가 제141조제2항에 따라 결정으로 각하되고 그 결정이 확정된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액
 9. 심리의 종결을 통지받기 전까지 제155조제1항에 따른 참가신청을 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
 10. 제155조제1항에 따른 참가신청이 결정으로 거부된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
 11. 심리의 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액
 ② 지식재산처장 또는 심판원장은 납부된 특허료 및 수수료가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 한다. <개정 2016.3.29.>
 ③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 5년이 지나면 할 수 없다. <개정 2022. 10. 18.>
 [전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

「수수료」란 특허출원, 심사청구 등 특허에 관한 절차를 밟는 특정의 이용자로부터 국가가 제공한 역무에 대한 반대급부 또는 보수의 성격으로 징수하는 요금을 말한다. 수수료의 징수 근거 및 수수료를 내야 할 자는 제82조제1항 및 제2항에 규정되어 있으며, 수수료의 납부방법, 납부기간 등은 동조 제3항의 규정에 의하여 총리령인 「특허료 등의 징수규칙」으로 정하도록 규정되어 있다.

II. 납부주체 및 방법

1. 납부주체

특허에 관한 수수료는 그 절차를 밟는 자가 내야 한다. 따라서 출원인이나 등록권자가 아닌 자가 밟을 수 있는 특허에 관한 절차의 수수료는 그 절차를 밟는 자가 내야 한다. 다만 심사청구 후에 보정에 의하여 심사청구료가 증가된 경우(새로운 청구항이 신설되어 그 항에 대한 심사청구료가 추가된 경우 등)에는 그 증가된 심사청구료는 출원인이 내야 한다(法 82①②).

2. 납부방법

수수료의 납부방법은 특허료 등의 징수규칙 제8조에 규정되어 있으며 수수료의 납부방법은 다음과 같다.

1) 특허료·등록료 및 수수료는 제출서류에 대한 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 하여 국고수납은행 또는 우체국에 그 다음 날까지 내야 하며 가산료는 기본료와 합산하여 내야 한다. 한편 수수료의 납부일이 공휴일(「노동절 제정에 관한 법률」에 따른 노동절 및 토요일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫번째 근무일까지 납부하여야 한다(徵收規則 8①②③).

2) 특허료·등록료 및 수수료를 내는 자는 이를 인터넷지로 등 정보통신망을 이용한 전자적 수단으로 내거나 수수료납부신청서에 기재사항을 적어 현금으로 내야 한다. 이 경우 지식재산처장은 정보통신망을 이용한 전자적 수단으로 납부한 자에 대해서는 납입영수증을 발급할 수 있다. 한편 우편으로 특허료·등록료 및 수수료를 내야 하는 서류를 제출하는 경우에는 통상환을 동봉하여 제출하여야 한다(徵收規則 8⑫⑬).

3) 심사청구료·재심사 청구료·우선심사청구료는 심사청구·재심사 청구·우선심사신청을 하는 자가 심사청구·재심사 청구·우선심사신청 시 접수번호를 부여받아 그 다음 날까지 내야 하되, 심사청구와 동시에 특허출원심사 또는 실용신안등록출원심사의 유예를 신청한 경우에는 심사를 받으려는 시점으로부터 2개월 전까지 심사청구를 하였을 때의 심사청구료를 내야 한다. 심사청구 후에 보정에 따라 심사청구료가 증가된 경우(새로운 청구범위의 항이 추가되어 그 항에 대한 심사청구료가 추가된 경우를 포함한다)에는 출원인이 보정서를 제출할 때 접수번호를 부여받아 그 다음 날까지 그 증가액을 내야 한다(徵收規則 8④).

4) 접수번호를 부여받은 날의 다음 날이 지나서 낸 특허료·등록료 및 수수료는 이를 반환한다(徵收規則 8⑭).

Ⅲ. 수수료 등의 면제 및 감면

1. 수수료 등의 면제

지식재산처장은 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료와 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료 전체를 면제한다(法 83①). 다만 국가와 국가 이외의 자가 공동으로 특허권의 설정등록을 받고자 하거나 이들이 공유특허권자인 경우에는 면제되지 아니한다.¹⁶⁶⁾

2. 수수료 등의 감면

1) 지식재산처장은 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대하여 총리령으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다(法 83②).

166) 지식재산처, 「등록업무편람」, 2022, 126면.

- i) 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자
- ii) 「재난 및 안전관리 기본법」 제36조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제60조에 따른 특별 재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중 총리령으로 정하는 요건을 갖춘 자
- iii) 그 밖에 총리령으로 정하는 자

2) 지식재산처장은 특허료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 자에 대하여는 총리령으로 정하는 바에 따라 감면받은 특허료 및 수수료의 2배액을 징수할 수 있다. 이 경우 그 출원인 또는 특허권자가 하는 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 총리령¹⁶⁷⁾으로 정하는 기간 동안 특허료 및 수수료를 감면하지 아니한다(法 83④).¹⁶⁸⁾

IV. 수수료 등의 반환

1. 반환대상

납부된 특허료 및 수수료는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 따라 반환한다(法 84①).

- ① 잘못 납부된 수수료 및 특허료
- ② 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분¹⁶⁹⁾
- ③ 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
- ④ 특허출원(분할출원, 분리출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1개월 이내에 그 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부된 수수료 중 특허출원료 및 특허출원의 우선권주장 신청료
- ⑤ 출원심사청구를 한 이후 다음의 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료
 - i) 동일인의 동일출원(同日出願)에 따른 지식재산처장의 협의 결과 신고 명령(法 36⑥)
 - ii) 거절이유통지(法 63)
 - iii) 특허결정등본의 송달(法 67②)

167) 징수금액 고지를 송달받은 날로부터 1년을 의미한다(徵收規則 13의2②③).

168) 부모의 특허출원임에도 불구하고 미성년자인 자녀를 발명자로 포함하는 등 발명에 기여하지 않은 감면 대상자를 발명자에 포함하여 부당하게 수수료를 감면받은 사례가 발생하는 문제점이 있어서, 2022. 2. 18. 시행되는 현행법(법률 제18409호, 2021. 8. 17. 일부개정)에서는 감면받은 특허료 및 수수료의 2배를 추징하고 일정 기간 감면을 제한함으로써 제도의 악용을 방지하고 공정성을 제고하게 되었다(채수근 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안 검토보고(이철규 의원 대표발의(의안번호 제2105036호 및 제2105093호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2. 7-8면).

169) 청구항별로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되거나 특허권을 포기한 경우에는 해당 해의 다음해부터의 특허료 해당분을 해당 청구항별로 반환한다(法 215).

- ⑥ 출원심사의 청구를 한 이후 다음의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액¹⁷⁰⁾
 - i) 동일인의 동일출원(同日出願)에 따른 지식재산처장의 협의 결과 신고 명령 후 신고기간 만료 전까지
 - ii) 거절이유통지(제47조제1항제1호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의견서 제출기간 만료 전까지
- ⑦ 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
- ⑧ 제176조제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 심판 또는 재심 중 제170조제1항에 따라 준용되는 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 보정이 있는 경우는 제외한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료(재심의 경우에는 재심청구료를 말한다. 이하 이 조에서 같다)
- ⑨ 심판청구가 제141조제2항에 따라 결정으로 각하되고 그 결정이 확정된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액
- ⑩ 심리의 종결을 통지받기 전까지 제155조제1항에 따른 참가신청을 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
- ⑪ 제155조제1항에 따른 참가신청이 결정으로 거부된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
- ⑫ 심리의 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액

2. 통지 및 반환청구

지식재산처장 또는 심판원장은 특허료 및 수수료가 반환대상에 해당하는 경우 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 하며, 그 통지를 받은 자는 통지를 받은 날로부터 5년이 되는 날까지 납부된 특허료 및 수수료의 반환을 청구할 수 있다(法 84②③).

170) 동일인의 동일출원(同日出願)에 따른 지식재산처장의 협의 결과 신고 명령 후 신고기간 만료 전이거나 거절이유통지가 있는 후 최초 의견서 제출기간이 지나지 않은 경우 실제 투입된 행정 처리 비용을 고려해 심사청구료의 3분의 1을 반환하도록 하고 있다(채수근 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안 검토보고(이철규 의원 대표발의(의안번호 제2105036호 및 제2105093호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2. 13-14면 참조).

제5절 방식심사

제1관 서 설

1) 「방식심사」란 지식재산처장 등이 출원인의 행위능력, 대리인의 대리권 범위, 제출된 서류의 기재방식 및 첨부서류, 수수료 납부사항 등 절차에 대한 흠결 유무를 심사하는 것을 말한다. 지식재산처장 등은 방식심사를 통해 출원인 등이 제출한 서류의 수리 여부를 결정하게 된다. 이와 같은 방식심사는 특허요건 등을 심사하는 실체심사와는 구분되는 개념으로서 특허에 관한 제반절차에서 행해지는데, 특허에 관한 방식과 절차를 통일함으로써 특허행정의 원활한 수행을 기하기 위하여 특허법은 출원인·청구인 등에게 일정한 방식에 의하여 절차를 밟도록 요구하고 있다.

2) 특허출원에 대한 방식심사를 예로 들면, 우리 특허법은 중복특허를 배제하는 방법으로서 선발명주의가 아니라 판단이 쉬운 선출원주의를 채택하고 있다. 선출원주의하에서는 누가 먼저 출원하였는지가 중요한 문제인데 선·후출원의 판단은 지식재산처장의 방식심사를 통해 부여된 출원일자에 의하여 이루어진다. 지식재산처장은 방식심사 결과 방식에 흠결이 없는 경우에는 출원번호, 출원일자 및 세계지식재산기구의 전자적 접근 서비스(DAS, Digital Access Service)에 접근하기 위하여 필요한 고유번호(이하 “접근코드”라 한다)를 적은 출원번호통지서를 출원인에게 송달한다(施規 24). 한편 지식재산처장은 방식심사 결과 i) 제46조에 해당하는 보정할 수 있는 경미한 하자가 있는 경우에는 일단 출원일자를 인정하여 출원번호통지서를 출원인에게 송달하는 한편 출원인에게 보정기회를 준다. 그러함에도 불구하고 경미한 하자가 해소되지 아니한 경우 지식재산처장은 그 보정을 명한 출원절차를 종료시켜 선출원의 지위를 상실하게 하려고 출원절차를 무효 처분할 수 있다. 또한 지식재산처장은 ii) 시행규칙 제11조에 해당하는 보정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우에는 출원일자를 인정하지 않고 소명기회를 준 후 중대한 하자가 해소되지 아니한 경우 그 출원서류를 수리하지 않고 출원인에게 반려하여야 한다.

【표 1-16】 특허출원의 심사

구 분			내 용
방식심사 - 지식재산처장 - 출원서류제출순서 - 출원서류전체	방식흡결이 없는 경우		출원일자 인정
	보정가능한 경미한 흡결의 경우		1. 출원일자 인정 후 보정명령 2. 출원인의 보정서/의견서 제출 3. 보정에 의하여 하자가 치유된 경우 - 소급효 4. 보정에 의하여 하자가 치유되지 아니한 경우 - 그 보정을 명한 출원절차를 무효(재량)
	방식 흡결이 있는 경우	보정불가능한 중대한 흡결의 경우	1. 출원일자 인정하지 않고 소명기회 부여 2. 출원인의 소명서 제출 3. 소명에 의하여 하자가 치유된 경우 - 처음 서류를 제출한 때를 기준으로 출원일자 인정 4. 소명에 의하여 하자가 치유되지 아니한 경우 ① 반려요청한 경우 - 소명기간 내라도 즉시 그 소명기회를 준 출원서류를 불수리(기속) ② 반려요청을 하지 아니한 경우 - 소명기간이 지난 후 그 소명기회를 준 출원서류를 불수리(기속)
실체심사 - 심사관 - 심사청구순서 - 청구범위를 중심으로 발명의 설명·도면 참작	특허요건흡결이 없는 경우 (제62조에 해당×)		특허결정(기속)
	특허요건흡결이 있는 경우 (제62조에 해당○)		1. 거절이유통지하여 의견서를 제출할 수 있는 기회부여 2. 출원인의 의견서/보정서 제출 3. 거절이유가 해소된 경우 - 특허결정(기속) 4. 거절이유가 해소되지 아니한 경우 - 특허거절결정(기속)

제2관 절차의 무효

제16조 【절차의 무효】

- ① 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제46조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있다. 다만, 제82조제2항에 따른 심사청구료를 내지 아니하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다.
- ② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항에 따라 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만, 지정된 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
- ③ 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항 본문·단서에 따른 무효처분 또는 제2항 본문에 따른 무효처분의 취소처분을 할 때에는 그 보정명령을 받은 자에게 처분통지서를 송달하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제46조 【절차의 보정】

지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다. 이 경우 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출할 수 있다.

1. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우
2. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우
3. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우

I. 서 설

1. 의 의

「절차의 무효」란 출원인·청구인 등이 지식재산처에 대하여 밟은 특허출원, 청구 등 특허에 관한 절차에 일정한 흠결이 있는 경우 그 절차의 효력을 소급하여 소멸시키는 지식재산처장 등의 행정처분을 말한다. 절차의 무효가 된 경우 해당 특허에 관한 절차는 처음부터 없었던 것으로 본다.

2. 법적성질

절차의 무효는 지식재산처장 등이 필요하다고 인정될 때 행할 수 있는 지식재산처장 등의 재량에 일임하는 행정행위이다. 따라서 기간이 지난 후 곧바로 무효로 할 것인지 또는 다시 보정명령을 할 것인지는 지식재산처장 등의 재량에 속하지만, 이 재량권은 합리적이고 공평한 범위에서 행사되어야 한다.

II. 무효사유(절차보정사유)

1. 서

i) 제3조제1항의 행위능력이 없는 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우, ii) 제6조의 대리권의 범위에 흠결이 있는 경우, iii) 법령이 정하는 방식에 위반된 경우, iv) 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우에 해당되어 절차의 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니한 경우이다(法 46각호). 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

2. 제3조제1항의 행위능력이 없는 자가 특허에 관한 절차를 밟는 경우

미성년자·피한정후견인 또는 피성년후견인이 법정대리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 출원·청구, 그 밖의 절차를 밟는 경우를 말한다. 다만 미성년자와 피한정후견인이 독립하여 법률행위를 할 수 있는 경우에는 절차무효의 대상이 되지 아니한다.

3. 제6조의 대리권의 범위에 흠결이 있는 경우

임의대리인이 특별히 권한을 위임받지 아니하고 특허출원의 변경·포기·취하, 특허권의 포기, 특허권의 존속기간의 연장등록출원의 취하, 신청의 취하, 청구의 취하, 국내우선권주장이나 그 취하, 거절결정불복심판청구 또는 복대리인의 선임을 한 경우를 말한다.

4. 법령이 정하는 방식에 위반된 경우

방식에 위반된 경우에 대해서는 일률적으로 나열할 수 없지만, 구체적인 예로는 공지의예외적용주장이나 우선권주장이 방식에 위반된 경우, 발명의 명칭이나 발명자의 성명 및 주소를 적지 아니한 경우, 도면이 첨부되었음에도 도면의 간단한 설명을 적지 아니한 경우, 요약서를 제출하지 않았거나 요약서의 기재가 부적법한 경우 등이 있다.

5. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우

i) 특허에 관한 절차를 밟는 자가 수수료를 내야 하는데 수수료를 내지 아니한 경우와 ii) 특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 출원인이 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구범위에 적은 청구항의 수가 증가하였는데 그 증가한 청구항에 관하여 출원인이 심사청구료를 내지 아니한 경우이다.

Ⅲ. 주체 및 대상

1. 주 체

지식재산처장 또는 특허심판원장이 할 수 있다.

2. 대 상

(1) 특허에 관한 절차

무효처분의 대상은 보정을 명한 특허에 관한 절차이다. 여기서 「보정을 명한 특허에 관한 절차」란 특허출원절차뿐만 아니라 지식재산처장 등의 보정명령을 받은 개별적 행위(심사청구, 보정 등)도 포함한다. 예를 들어 출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 심사청구에 대한 심사청구료를 내지 아니한 경우 지식재산처장은 보정명령 후 「심사청구」를 무효로 할 수 있다.

(2) 제3자의 심사청구 후 출원인의 보정에 의하여 청구항이 증가된 경우

특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 출원인이 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구범위에 적은 청구항의 수가 증가하였는데 그 증가한 청구항에 관하여 특허출원인이 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다(法 16①단서). 기존에는 「보정을 명한 특허에 관한 절차」가 제3자의 심사청구절차인지 아니면 출원인의 명세서 보정절차인지가 명확하지 않았으나, 2001. 7. 1. 시행된 현행법(법률 제6411호, 2001. 2. 3. 일부개정)에서 제16조제1항단서를 신설하여 이를 명확히 하고 있다.

IV. 절 차

1. 보정명령

출원인은 지식재산처장, 특허심판원장의 보정명령이 없다고 하더라도 자진하여 보정할 수 있다. 한편 지식재산처장 또는 특허심판원장은 절차보정사유(法 46)에 해당하면 기간을 정하여 보정을 명하는데 이 경우에는 정한 기간에 절차보정을 하여야 한다. 해당 절차를 밟는 자에게 보정기회를 주지 않고 무효처분을 하는 것은 가혹하므로 보정명령은 반드시 하여야 하는 기속적 행정행위이다.

2. 절차의 보정

1) 보정명령을 받은 자는 그 기간에 그 보정명령에 대한 의견서를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 제출할 수도 있고(法 46단서), 그 보정을 명한 절차를 보정할 수도 있다. 문제가 되는 것은 보정기간이 지난 후에 보정서가 제출된 경우이다. 이 경우 지식재산처장 등의 보정기간이 지난 후 출원무효처분 통지서의 발송일 전에 보정서가 제출되어 절차보정사유(法 46)가 해소되었으면, 보정기간이 불변기간은 아니기 때문에¹⁷¹⁾ 무효처분을 하지 아니하고 보정서를 수리한다.¹⁷²⁾ 그러나 무효처분 통지서의 발송일 후에 제출된 보정서는 반려한다. 한편 무효처분통지서 발송일 이전에 우편 등을 통하여 제출되었으나, 무효처분당시 보정내용의 제출사실을 알지 못하고 무효처분한 경우에는 보정내용을 검토하여 흠결을 해소하였으면 무효처분을 취소하고 보정을 인정한다. 또한 무효처분통지서를 발송한 날에 제출된 보정도 동일하게 취급한다.

2) 한편 특허법 시행규칙 제13조제1호는 특허법 제46조에 따라 보정을 하려는 자는 특허법 시행규칙 별지 제9호 서식의 보정서에 보정 내용을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장 등에게 제출하도록 규정하고 있으나, 이는 행정청의 편의를 위한 규정으로 보정 내용을 증명하는 서류의 제출은 엄격한 형식을 요하지 아니하는 서면행위라고 해석되고, 이러한 경우 행정청으로서는 그 서면을 가능한 한 제출자의 이익이 되도록 처리할 필요가 있다. 따라서 특허법 제46조에 따른 지식재산처장 등의 보정명령을 받은 사람으로부터 지식재산처장 등에게 보정 내용을 증명하는 서류가 제출되었을 때에는 그 표제 등의 여하를 불문하고 이를 위 보정명령에 대한 대응조치로 보아야 한다.¹⁷³⁾

171) 대법원 1978. 9. 5. 선고 78마233.

172) 출원무효처분이 행정처분으로서 효력을 발생하기 전에 보정이 되어 하자가 치유된 경우에는 내부적으로 성립되어 있던 출원무효처분을 철회하고 절차를 속행하여야 한다(동경재판소 判他 326호324).

173) 대법원 1995. 11. 7. 선고 94누10061 판결, 대법원 2000. 6. 9. 선고 98두2621 판결 등 참조. 예를 들어 특허에 관한 절차를 밟는 자가 대리인에게 대리권을 수여하는 데에는 일정한 방식이 요구되지 않고, 다만 그 대리권의 증명은 특허법 제7조에 따라 서면으로써 하여야 한다. 그런데 특허법 시행규칙 제5조의2제1항은 대리인에게 현재 및 장래의 사건에 대하여 미리 사건을 특정하지 아니하고 특허에 관한 절차 진행을 포괄위임하려는 경우에는 포괄위임등록 신청서에 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다고 규정하므로, 이미 출원한 사건의 특허에 관한 절차 또한 포괄위임의 대상이 되고, 포괄위임등록 신청을 위해 대리권을 증명하는 서류인 포괄위임장을 지식재산처장에게 제출한 이상 포괄위임 대상 사건에 관한 대리권의 서면 증명은 이루어졌다고 볼 수 있다(대법원 2023. 7. 13. 선고 2021두63099).

V. 효 과

1. 보정에 의하여 하자가 치유된 경우

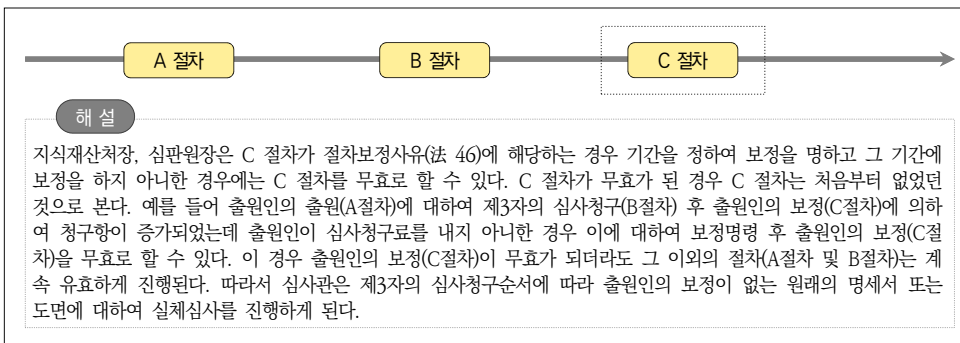
지식재산처장 등은 보정서를 검토한 결과 절차보정사유(法 46)가 해소되었다고 판단되면 소급효를 인정하여 보정된 내용대로 해당 보정을 명한 특허에 관한 절차의 서류를 제출한 것으로 간주한다.

2. 보정에 의하여 하자가 치유되지 아니한 경우

(1) 절차의 소급적 소멸

1) 지식재산처장 등은 절차보정사유(法 46)에 해당함을 이유로 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 그 보정을 명한 특허에 관한 절차를 무효로 할 수 있으며, 무효처분을 한 경우 그 보정명령을 받은 자에게 처분 통지서를 송달하여야 한다(法 16③).

2) 무효가 된 경우 해당 특허에 관한 절차는 처음부터 없었던 것으로 본다(法 16①). 그러나 무효처분 이외의 절차는 계속 유효하게 진행된다.



【그림 1-13】 무효처분의 대상 및 효과

(2) 특허출원절차 무효의 효과

① 출원 계속의 종료

1) 「특허출원의 무효」란 지식재산처장이 특허출원에 대한 방식심사를 한 결과 특허출원절차에 일정한 흠결이 있는 경우 그 특허출원절차의 효력을 소급하여 소멸시키는 행정처분을 말한다. 「특허의 무효」가 등록된 특허권의 무효사유가 있을 때 특허무효심판의 무효심결 확정에 의하여 그 특허권을 처음부터 또는 장래를 향해 소멸시키는 의미인데 반면, 「특허출원의 무효」는 특허권이 아닌 출원 계속의 효과를 소멸시키는 의미라는 점에서 차이가 있다.

2) 특허출원절차가 무효로 되어 출원 계속의 효과가 소멸하면 선출원의 지위를 갖지 않으므로(法 36④), 신규성 등 다른 특허요건을 충족하는 한 원출원인은 물론 누구든지 재출원할 수 있다. 다만 특허출원절차가 출원공개 이후에 무효가 되었다면 특허출원일의 다음 날로부터 출원공개 전에 출원된 발명에 대해서는 확대된 선출원의 지위가 인정되며, 출원공개 후에 출원된 발명에 대해서는 신규성, 진보성의 판단대상이 되는 공지기술의 지위가 인정된다.

② 조약우선권의 기초

조약우선권의 선출원은 출원의 정규성만 인정되면 되기 때문에 선출원의 출원절차가 무효로 되어도 이를 기초로 조약우선권을 주장할 수 있다(法 54).

③ 보상금청구권의 소멸

특허출원절차가 무효된 경우 보상금청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다(法 65⑥).

VI. 구 제

1. 행정소송 또는 행정심판

지식재산처장 또는 특허심판원장으로부터 무효처분을 받은 자는 행정심판을 청구하거나 행정소송법에 의한 취소소송을 제기하여 그 당부를 다툴 수 있다(法 224의2②).

2. 무효처분의 취소

지식재산처장 또는 특허심판원장은 절차의 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하여 특허에 관한 절차가 무효로 된 경우로서 지정된 기간을 지키지 못한 것이 보정명령을 받은 자가 정당한 사유에 의한 것으로 인정될 때에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 보정명령을 받은 자의 청구에 따라 그 무효처분을 취소할 수 있다. 다만 지정된 기간의 만료일로부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다(法 16②). 한편 무효처분취소를 한 경우 지식재산처장 또는 특허심판원장은 그 보정명령을 받은 자에게 그 처분통지서를 송달하여야 한다(法 16③).

제3관 절차의 불수리

I. 서 설

1. 의 의

「절차의 불수리」란 특허에 관한 출원·청구 등의 절차에 보정하기 어려운 중대한 하자가 있을 때 그 출원서나 청구서 등을 수리하지 아니하는 지식재산처장 등의 행정처분을 말하며, 제출한 「서류의 반려」라고도 한다(施規 11).

2. 법적성질

절차의 불수리는 불수리사유에 해당하면 지식재산처장 등이 반드시 하여야 하는, 즉 재량이 인정되지 아니하는 기속적 행정행위이다.

II. 불수리사유

① 1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우

② 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우

기재내용이 극히 부실하여 서류의 종류를 알 수 없는 경우나 특허법 등 관련 규정에 정하여져 있지 않은 종류의 서류를 제출한 경우를 말한다.

③ 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 특허고객번호[특허고객번호가 없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]가 기재되지 아니한 경우

④ 국어로 적지 아니한 경우(단, i) 외국어(영어)로 적은 명세서 및 도면, ii) 위임장, 국적증명서 및 우선권증명서류 등 외국어로 적은 서류는 제외한다)

다만 명세서의 기재에 있어서 용어의 일부 또는 도면의 일부가 국어 또는 영어가 아닌 외국어로 기재되어 있으나, 외국어로 적혀 있는 사항을 제외하여도 출원 발명을 이해하기에 어려움이 없는 경우에는 반려하지 않고 보정을 명한다.

⑤ 출원서에 명세서(명세서에 발명의 설명이 기재되어 있지 아니한 경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우

명세서 또는 도면이 극히 부실하게 기재된 경우도 포함한다.

⑥ 청구범위를 적지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허출원한 정당한 권리자출원으로서 그 특허출원 당시에 이미 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)이 지났을 경우

⑦ 출원서에 임시 명세서를 첨부한 출원(施規 21⑤전단)의 보정 전에 명세서, 요약서 또는 도면을 보정한 경우

⑧ 분리출원으로서 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적은 경우

⑨ 분리출원을 기초로 새로운 분할출원, 분리출원 또는 변경출원을 하는 경우

⑩ 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 특허출원, 특허권의 존속기간의 연장등록출원 또는 심판에 관한 서류·건본 그 밖의 물건(이하 “출원서류 등”이라 한다)인 경우

특허출원서뿐만 아니라 특허관리인에 의하지 아니하는 다른 특허에 관한 절차의 서류도 모두 불수리된다.

- ⑪ 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간에 제출되지 아니한 서류인 경우
 법정기간이 지나서 제출된 서류를 말한다. 다만 지정기간이 지나서 제출된 서류는 반력하지 아니한 것을 원칙으로 한다.
- ⑫ 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간 연장신청서인 경우
 거절결정불복심판의 청구기간(法 132의17)을 제외한 법정기간연장 신청 서류를 제출한 경우를 말한다.
- ⑬ 거절결정불복심판의 청구기간(法 132의17) 또는 지식재산처장·특허심판원장·심판장 또는 심사관이 지정한 기간을 지나서 제출된 기간연장신청서인 경우
- ⑭ 특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우
 원출원에 관한 절차가 종료된 후 제출된 분할출원서, 분리출원서, 변경출원서 등을 말한다.
- ⑮ 해당 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우
 타인의 출원에 대한 보정서 등과 같이 절차를 밟을 권한이 없는 자가 밟는 절차와 관련된 서류를 제출한 경우를 말한다. 예를 들면 분할출원, 분리출원 또는 변경출원 당시 분할출원, 분리출원, 변경출원의 출원인이 원출원의 출원인과 일치하지 아니한 경우(복수인 경우에는 모두 일치)이다.
- ⑯ 포괄위임등록신청서, 포괄위임원용제한신고서, 포괄위임등록철회서, 특허고객번호부여신청서 또는 직권으로 특허고객번호를 주어야 하는 경우로서 해당 서류가 불명확하여 수리할 수 없는 경우
- ⑰ 정보통신망이나 전자적 기록매체로 제출된 특허출원서나 그 밖의 서류가 지식재산처에서 제공하는 소프트웨어 또는 지식재산처 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니하였거나 전자문서로 제출된 서류가 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우
- ⑱ 전자적 이미지의 첨부서류가 판독이 곤란하여 해당 서류를 서면으로 제출하라는 명령을 받고 이를 기간에 제출하지 아니한 경우
- ⑲ 특허절차를 밟는 자의 국적·법인증명서류 등의 제출명령을 받고 소명기간에 제출하지 아니한 경우(施規 8)
- ⑳ 특허출원인이 i) 청구범위가 기재된 명세서를 첨부하지 아니하거나 ii) 외국어특허출원인데 국어번역문을 제출하지 아니하고 제출한 출원심사청구서의 경우
- ㉑ i) 청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원, ii) 국어번역문을 제출하지 아니한 외국어특허출원 및 iii) 등록공고를 한 특허는 출원공개의 대상이 되지 아니한데 이에 대하여 조공개신청서를 제출한 경우
- ㉒ 특허출원이 i) 분할출원, 분리출원 또는 변경출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우 중 어느 하나에 해당하여 특허여부결정을 보류할 수 없는 경우
- ㉓ 특허출원이 i) 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우, iii) 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우 중 어느 하나에 해당하여 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 없는 경우

- ㉔ 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면의 보정없이 재심사를 청구한 경우, 재심사에 따른 특허 여부결정이 있는 경우, 거절결정불복심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다) 또는 그 특허출원이 분리출원인 경우 중 어느 하나에 해당하여 재심사를 청구할 수 없는 경우
- ㉕ 번역문을 제출하지 않고 보정, 분할출원, 변경출원, 출원인의 심사청구, 조기공개신청이 있는 경우
- ㉖ 동일한 출원인등이 이미 제출한 서류와 중복되는 서류를 제출한 경우

III. 주체 및 대상

1. 주 체

지식재산처장 또는 특허심판원장이 할 수 있다.

2. 대 상

1) 불수리처분의 대상은 소명기회를 준 특허에 관한 절차이다. 여기서 「소명기회를 준 특허에 관한 절차」는 출원절차에 한정되지 않고 심사청구절차, 보정절차 등도 포함된다. 예를 들어 출원인이 보정기간을 지난 후 보정서를 제출하면 지식재산처장은 이에 대하여 소명기회를 준 후, 이에 불응시 보정서 제출을 불수리하여야 한다.

2) 심판에 관한 서류나 그 밖의 물건이 불수리 사유에 해당할 때도 불수리된다. 다만 심판청구서는 불수리의 대상이 아닌 것으로 운용되고 있으며 심판청구서 이외의 서류에 보정할 수 없는 흠결이 있으면 불수리 대상이다.¹⁷⁴⁾

IV. 절 차

1. 소명기회 부여

지식재산처장 또는 심판원장은 부적법한 것으로 보이는 출원서류 등을 반려하려는 경우에는 출원서류 등을 제출한 출원인·심판청구인 또는 제출인(이하 “출원인 등”이라 한다)에 대하여 출원서류 등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 적은 서면을 송부하여야 한다. 다만 특허절차를 밟는 자가 국적·법인증명서류 등의 제출명령을 받고 소명기간에 제출하지 아니하면 이미 소명기회(국적·법인증명서류 등의 제출기회)를 부여했기 때문에, 반려이유를 고지하고 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다(施規 11②).

174) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 45면.

2. 소명서 제출 또는 반려요청

반려취지 등을 서면으로 송부받은 출원인 등이 소명하려는 경우에는 소명기간에 소명서를, 소명 없이 출원서류 등을 소명기간에 반려받으려는 경우에는 반려요청서를 지식재산처장 또는 심판원장에게 제출하여야 한다(施規 11③). 한편 지식재산처장이 정하여 고시하는 서류의 경우에는 방식집사 전에 반려요청을 할 수도 있다(施規 11의2).

V. 효 과

1. 소명에 의하여 하자가 해소된 경우

지식재산처장 등은 소명서를 검토한 결과 불수리 사유가 존재하지 아니하다고 판단되는 경우 해당 제출서류를 처음 제출한 날에 효력이 발생한 것으로 간주한다.

2. 소명에 의하여 하자가 해소되지 아니한 경우

1) 지식재산처장 또는 심판원장은 반려요청을 받은 때에는 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다. 한편 지식재산처장 등은 출원인 등이 소명기간에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명의 내용이 이유 없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 출원서류 등을 반려하여야 한다(施規 11④)

2) 지식재산처장 등은 출원서류 등을 반려한 경우에는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 적법한 출원서류 등으로 보지 아니한다(施規 11①). 즉 불수리처분된 경우 해당 소명 기회를 준 제반절차의 효과는 발생하지 아니한 것으로 본다.

VI. 불 복

지식재산처장이나 특허심판원장이 한 불수리처분에 대해서는 행정심판 또는 행정소송을 제기하여 다툴 수 있다(法 224의2②).

제8장

절차의 진행 일반

제1절 절차의 효력 승계 및 절차의 속행

제18조 【절차의 효력 승계】

특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밋은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미친다.

[전문개정 2014.6.11.]

제19조 【절차의 속행】

지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 지식재산처 또는 특허심판원에 계속(係屬) 중일 때 특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행(續行)하게 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 절차의 효력 승계

1. 의의 및 취지

특허권 또는 특허에 관한 권리(예컨대 실시권, 질권 등)에 관하여 밋은 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미친다(法 18). 이는 특허절차를 밋는 도중에 권리 관계에 변동이 생긴 경우 동일한 절차를 반복하는 불편과 낭비를 피하고자 행정 편의상 인정된 제도이다.

2. 내 용

「절차의 효력」이란 당사자(또는 출원인)가 지식재산처에 대하여 밋는 절차 외에도 지식재산처가 당사자에게 취한 제반절차의 효력을 모두 포함하는 의미이다. 예를 들어 원래의 특허에 관한 권리가 거절이유통지서나 그 밖의 통지서를 받은 후 의견서 등의 제출 전에 특허에 관한 권리를 승계인에게 양도했을 때, 이미 지식재산처가 양도인에게 행한 절차의 효력은 당연히 승계인(양수인)에게 미친다. 이 경우 승계인은 원권리자에게 이미 통보된 거절이유에 대한 의견서 제출 등의 절차를 수행하여야 한다. 반대로 원권리자가 지식재산처에 대하여 수행한 절차의 효력도 당연히 승계인에게 미친다.

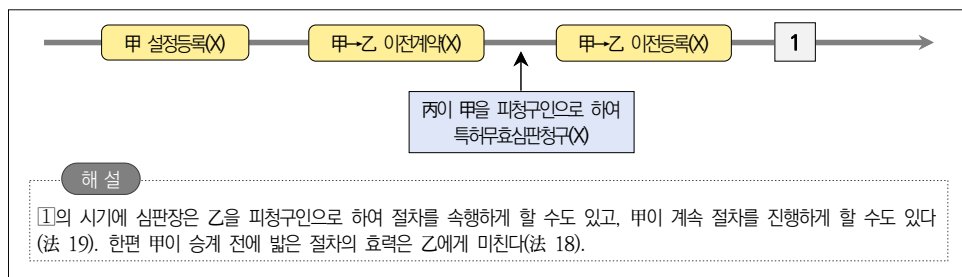
II. 절차의 속행

1. 의의 및 취지

지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중일 때 특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다(法 19). 이 규정도 권리관계의 변동에 따라 같은 절차를 거듭 반복하게 하는 번잡을 피하기 위한 것이다. 제18조는 승계 전에 밝은 절차의 효력에 관한 규정인 데 반해, 제19조는 승계 후의 절차 진행에 관한 규정이라는 점에서 구별된다. 한편 지식재산처장 또는 심판장이 이처럼 승계인에 대하여 출원·청구, 그 밖의 절차를 속행하게 한 때에는 그 사실을 상대방(승계인 외의 당사자)에게 서면으로 통지하여야 한다(施規 18).

2. 내 용

예를 들어 심판장은 특허무효심판계속 중 특허권자가 변경되었다면 변경된 특허권자를 실질적인 피청구인으로 하여 절차를 속행하게 할 수 있다. 다만 승계인(변경된 특허권자)에게 속행하게 하는 것은 재량행위이므로 심판장이 반드시 절차의 속행을 명하여야 하는 것은 아니다. 즉 심사 또는 심판이 종결의 단계에 이르러서 승계인을 절차에 관여시킬 필요성이 없는 경우와 같이, 상황에 비추어 적당하다고 인정되는 때에는 종전의 당사자에게 절차를 수행하게 할 수 있다.¹⁷⁵⁾¹⁷⁶⁾ 한편 특허에 관한 절차가 「계속 중일 때」에 이전이 있어야 하며 특허에 관한 절차가 시작되기 전 또는 종료된 후에 이전이 있는 경우에는 이에 해당하지 아니한다.



【그림 1-14】 특허무효심판계속 중 권리가 이전된 경우의 취급

175) 등록무효심판계속 중 피심판청구인이 그 등록권리를 제3자에게 이전하였다 하더라도 당사자로서의 지위에는 영향을 받지 아니한다(대법원 1967. 6. 27. 선고 67후1).

176) 실용신안권의 권리범위확인심판청구인이 그 심판계속 중에 그 실용신안 물건의 제조판매영업권을 양도하였다 하더라도 본법상의 이해관계인임에는 변함이 없으므로 심판청구인에 대한 심결이나 판결의 효력은 그 승계인에게도 미치는 것이므로 심판청구인은 종국에 이르기까지 당사자로서 자기 또는 승계인을 위하여 행위 할 당사자적격을 가진다(대법원 1977. 12. 27. 선고 76후33).

제2절 절차의 정지

제20조 【절차의 중단】

특허에 관한 절차가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 중단된다. 다만, 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 당사자가 사망한 경우
2. 당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우
3. 당사자가 절차를 밟을 능력을 상실한 경우
4. 당사자의 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우
5. 당사자의 신탁에 의한 수탁자의 임무가 끝난 경우
6. 제11조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따른 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우
7. 파산관재인 등 일정한 자격에 따라 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우

[전문개정 2014.6.11.]

제21조 【중단된 절차의 수계】

제20조에 따라 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차가 중단된 경우에는 다음 각 호의 구분에 따른 자가 그 절차를 수계(受繼)하여야 한다.

1. 제20조제1호의 경우: 사망한 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 속행할 자. 다만, 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다.
2. 제20조제2호의 경우: 합병에 따라 설립되거나 합병 후 존속하는 법인
3. 제20조제3호 및 제4호의 경우: 절차를 밟을 능력을 회복한 당사자 또는 법정대리인이 된 자
4. 제20조제5호의 경우: 새로운 수탁자
5. 제20조제6호의 경우: 새로운 대표자 또는 각 당사자
6. 제20조제7호의 경우: 같은 자격을 가진 자

[전문개정 2014.6.11.]

제22조 【수계신청】

- ① 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 할 수 있다. 이 경우 그 상대방은 지식재산처장 또는 제143조에 따른 심판관(이하 “심판관”이라 한다)에게 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여 수계신청할 것을 명하도록 요청할 수 있다.
- ② 지식재산처장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청이 있으면 그 사실을 상대방에게 알려야 한다.
- ③ 지식재산처장 또는 심판관은 제20조에 따라 중단된 절차에 관한 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정하면 결정으로 기각하여야 한다.
- ④ 지식재산처장 또는 심판관은 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대해서는 수계하게 할 것인지를 결정하여야 한다.
- ⑤ 지식재산처장 또는 심판관은 제21조 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 중단된 절차를 수계하지 아니하면 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 한다.
- ⑥ 제5항에 따른 기간에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날에 수계가 있는 것으로 본다.
- ⑦ 지식재산처장 또는 심판관은 제6항에 따라 수계가 있는 것으로 본 경우에는 그 사실을 당사자에게 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제23조 【절차의 중지】

- ① 지식재산처장 또는 심판관이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차는 그 사유가 없어질 때까지 중지된다.
- ② 당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 지식재산처장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 그 절차의 중지를 명할 수 있다.
- ③ 지식재산처장 또는 심판관은 제2항에 따른 결정을 취소할 수 있다.
- ④ 제1항 또는 제2항에 따른 중지나 제3항에 따른 취소를 하였을 때에는 지식재산처장 또는 심판장은 그 사실을 각각 당사자에게 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제24조 【중단 또는 중지의 효과】

특허에 관한 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그 기간의 진행은 정지되고, 그 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행하였을 때부터 다시 모든 기간이 진행된다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「절차의 정지」란 출원·청구, 그 밖의 특허에 관한 절차의 계속 중에 법률상 절차를 진행할 수 없는 상태로 되는 것을 말한다.

2. 취 지

특허법은 i) 특허절차의 진행이 불가능하게 되거나 곤란하게 될 때 지식재산처 또는 특허심판원이 특허절차를 진행하는 경우 절차에 관여할 수 없는 당사자의 선의의 피해를 막고, ii) 특허분쟁사건의 특수성에 따라 일정한 경우 특허절차의 정지를 통해 심사·심판 및 재판을 공정히 하기 위해 본 제도를 두고 있다.

3. 종 류

정지에는 중단과 중지가 있다. 양자 모두 당사자의 절차권을 보장하고 심사·심판 및 재판의 공정을 기하기 위한 제도라는 점에서는 공통되나, 「중단」은 절차를 수행하는 자가 교체되는 정지이고 「중지」는 절차를 수행하는 자가 교체되지 아니하는 정지라는 점에 차이가 있다.

II. 절차의 중단

1. 의 의

「절차의 중단」이란 절차 계속 중 당사자에게 절차수행을 할 수 없는 사유가 발생하였을 때 새로운 수행자가 절차에 관여할 수 있을 때까지 법률상 당연히 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다.

2. 절차의 중단사유(法 20) 및 수계자(法 21)

(1) 당사자가 사망한 경우

수계할 수 있는 자는 사망한 당사자의 상속인·상속재산관리인 또는 법률에 따라 절차를 속행할 자이다. 다만 상속인은 상속을 포기할 수 있을 때까지 그 절차를 수계하지 못한다. 상속인은 상속개시 있음을 안 날로부터 3개월 이내에 단순승인이나 한정승인 또는 포기를 할 수 있다. 그러나 그 기간은 이해관계인 또는 검사의 청구에 따라 가정법원이 이를 연장할 수 있다(民法 1019).

(2) 당사자의 행위능력 상실, 법정대리인이 사망하거나 그 대리권을 상실한 경우

수계할 수 있는 자는 절차를 밟을 능력(행위능력)을 회복한 당사자 또는 새로운 법정대리인이 된 자이다.

(3) 당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우

수계할 수 있는 자는 합병에 따라 설립되거나 합병 후 존속하는 법인이다. 당사자인 법인이 합병에 따라 소멸한 경우만을 중단의 사유로 한 것은 합병 이외의 사유로 해산된 때에는 청산 법인이 존재하여 절차를 수행할 수 있기 때문이다.

(4) 당사자의 신탁¹⁷⁷⁾에 의한 수탁자의 임무가 끝난 경우

수계할 수 있는 자는 새로운 수탁자이다.

(5) 복수당사자의 대표자가 사망하거나 그 자격을 상실한 경우

수계할 수 있는 자는 새로운 대표자 또는 각 당사자이다.

(6) 파산관재인 등 일정한 자격에 따라 자기 이름으로 남을 위하여 당사자가 된 자가 그 자격을 잃거나 사망한 경우

수계할 수 있는 자는 파산관재인, 정리회사의 관재인, 유언집행자 등 일정한 자격을 갖춘 자이다.

3. 중단된 절차의 수계

(1) 신청에 의한 수계

① 수계신청

수계신청은 새로운 수계자가 할 수 있다. 이 경우 그 상대방은 지식재산처장 또는 심판관에게 수계자에 대하여 수계신청할 것을 명하도록 요청할 수 있다(法 22①). 지식재산처장 또는 심판관은 중단된 절차에 관한 수계신청이 있으면 그 사실을 상대방에게 알려야 한다(法 22②).

177) 「신탁」이란 신탁설정자(위탁자)와 신탁을 인수하는 자(수탁자)가 특별한 신임관계에 기하여 위탁자가 특정의 재산권을 수탁자에게 이전하거나 그 밖의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한 자의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위하여 그 재산권을 관리·처분하게 하는 법률관계를 말하며(信託法 1), 수탁자의 임무가 종료한 경우에는 이해관계인은 새로운 수탁자의 선임을 법원에 청구할 수 있다(信託法 17).

② 수계신청에 관한 결정

지식재산처장 또는 심판관은 수계신청에 대하여 직권으로 조사하여 이유 없다고 인정한 때에는 결정으로 기각하여야 한다(法 22③). 또한 지식재산처장 또는 심판관은 수계신청이 이유 있다고 하더라도 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에 중단된 절차에 관한 수계신청에 대해서는 수계하게 할 것인지를 결정하여야 한다(法 22④). 결정 또는 심결의 등본을 송달한 후에는 수계 실익이 없을 수가 있기 때문이다.

(2) 명령에 의한 수계

지식재산처장 또는 심판관은 수계자가 중단된 절차를 수계하지 아니하면 직권으로 기간을 정하여 수계를 명하여야 하며(法 22⑤), 기간에 수계가 없는 경우에는 그 기간이 끝나는 날의 다음 날에 수계가 있는 것으로 본다(法 22⑥). 이 경우 지식재산처장 또는 심판장은 그 사실을 당사자에게 통지하여야 한다(法 22⑦). 수계자가 있음에도 불구하고 수계를 하지 않았다는 이유로 절차의 진행이 계속적으로 정지된 것은 절차의 안정성을 해하게 되므로 명령에 의한 수계를 인정하고 있다.

4. 중단의 예외

중단사유에 해당하더라도 절차를 밟을 것을 위임받은 대리인이 있는 경우에는 절차가 중단되지 아니한다(法 20단서). 절차의 중단사유가 발생하여도 당사자의 대리인이 있으면 그 대리권이 계속 존재하여 대리인이 절차를 계속 진행할 수 있기 때문이며, 아울러 수계자를 위한 것이기 때문이다. 이때 대리인은 수계절차를 밟지 아니하여도 새로운 절차수행자(당사자)의 대리인이 된다.

Ⅲ. 절차의 중지

1. 의 의

「절차의 중지」란 지식재산처 또는 특허심판원이나 당사자에게 절차의 진행을 할 수 없는 사실상의 장애가 생겼거나 절차진행이 곤란하거나 부적당한 사유가 발생하였을 때 법률상 당연히 또는 결정으로 특허에 관한 절차의 진행이 정지되는 것을 말한다.

2. 절차의 중지사유

(1) 당연중지사유

지식재산처장 또는 심판관이 천재지변이나 그 밖의 불가피한 사유로 그 직무를 행할 수 없으면 절차중지의 결정이 필요 없이 절차중지사유가 없어질 때까지 당연히 그 절차는 중지되는데 이를 당연중지라 한다(法 23①).

(2) 결정중지사유

당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우에는 지식재산처장 또는 심판관은 결정으로 장애사유가 해소될 때까지 그 절차의 중지를 명할 수 있는데 이를 결정중지라 한다(法 23②). 여기서 「당사자에게 일정하지 아니한 기간 동안 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중인 절차를 속행할 수 없는 장애사유가 생긴 경우」란 지식재산처는 직무를 수행할 수 있으나 당사자가 특허에 관한 절차를 밟을 수 없는 장애사유가 발생한 경우를 말한다. 예를 들어 당사자가 거주하는 지역에 전쟁 또는 그 밖의 사유로 통신이 두절되어 당분간 회복될 전망이 보이지 않거나 당사자가 급작스러운 중병 등으로 지식재산처와 연락 등을 할 수 없게 된 경우 등이 있다.

(3) 다른 절차와의 관계에서 필요한 경우

특허출원의 심사에 있어서 필요한 경우에는 특허취소신청에 대한 결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 심사절차를 중지할 수 있다(法 78①). 심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다(法 164①). 법원은 소송에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허여부결정, 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다(法 78②, 164②). 또한 허가 등에 따른 연장등록출원의 심사에 필요한 경우에는 제92조의4 및 제92조의5에 의한 등록지연에 따른 연장등록거절결정 또는 연장등록결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 허가 등에 따른 연장등록출원 심사 절차를 중지할 수 있다. 심사와 심판 또는 소송중인 사건들이 상호 관련성이 있을 때 이 사건 간에 상호 모순·저촉되는 결과를 예방하고, 나아가 심사, 심판 및 소송 등의 소송경제를 도모하기 위해서이다. 다만 절차를 중지할 것인가는 재량사항이다.¹⁷⁸⁾¹⁷⁹⁾

(4) 제척·기피신청에 의한 중지

제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심사·심판절차를 중지하여야 한다. 다만 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다(法 153).

178) 특허권에 대한 침해대상제품 등과 동일 또는 유사한 발명에 대하여 적극적 권리범위확인을 구하는 심판이 특허심판원에 계속 중에 있더라도, 그 특허권에 기초한 침해금지 청구 및 손해배상청구 등의 침해소송을 중지할 것인지 여부는 법원이 합리적인 재량에 따라 직권으로 정하는 것이다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다46712).

179) 상표법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전) 제10조에 따라 준용되는 심사절차의 중지에 관한 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전) 제96조제1항은 임의규정이므로 출원상표에 대한 심사에 있어서 이와 유사하다는 인용상표에 대한 등록무효심결이 대법원에 계속 중이더라도 그 심사절차를 중지하지 아니하고 심사 및 심리를 한 것이 위법하다고 할 수 없다(대법원 1990. 3. 23. 선고 89후2168).

3. 중지의 해소 및 통지

(1) 중지의 해소

i) 당연중지의 경우에는 그 사유가 소멸함과 동시에 ii) 결정중지의 경우에는 지식재산처장이나 심판관의 중지결정취소에 의하여, iii) 다른 절차와의 관계에서 필요한 경우의 중지는 심사관·심판관·법원의 중지결정취소에 의하여, iv) 제척·기피 신청에 의한 중지는 제척·기피신청에 대한 결정에 의하여 해소된다(法 23③).

(2) 통 지

지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 중지되거나 중지가 해소되면 그 사실을 각각 당사자에게 알려야 한다(法 23④).

IV. 절차 정지의 효과

1. 절차의 진행정지

특허에 관한 절차가 중단되거나 중지된 경우에는 그동안의 특허에 관한 절차는 전면적으로 정지된다. 따라서 절차의 중단사유가 있음에도 지식재산처가 이를 간과하고 심사의 절차를 계속하여 각종 처분을 한 경우에는 그 절차는 취소하고 다시 절차를 밟아야 한다. 예컨대 대리인이 없는 출원인이 사망하였으나 이를 알지 못하고 심사관이 거절이유를 통지한 후 거절이유를 해소하지 못했다는 이유로 특허거절결정한 경우에 있어서 거절이유통지에 따른 의견서 제출에 관한 절차는 제20조에 따라 지식재산처 또는 출원인의 상속인 등이 별도의 조치를 하지 않더라도 당연히 중단되므로 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 특허거절결정할 수 없다. 따라서 특허거절결정을 취소하고 수계 후 다시 의견제출통지서를 발송하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.¹⁸⁰⁾

2. 절차의 속행

특허에 관한 절차의 수계통지를 하거나 그 절차를 속행하였을 때부터 다시 모든 기간이 진행된다(法 24). 예를 들어 지식재산처장이 절차보정사유(法 46)에 해당함을 이유로 1개월 이내에 특허에 관한 절차를 보정할 것을 명하였으나 보정명령 후 15일 후에 특허에 관한 절차가 중

180) 강표원의 사망 당시 그의 소송대리인이 있었으므로 소송절차가 중단되지 아니하여 그 1심판결의 선고는 적법하게 되었다 할 것이지만, 심급대리의 원칙상 동 판결이 선고되어 소송대리인에게 제1심판결 정본이 송달됨과 동시에 그 소송절차는 중단되었다 할 것이고, 그러하다면 원심에서는 위 강표원의 사망으로 소송절차를 수계할 상속인들이 법률상 소송행위를 할 수 없는 상태에서 소송절차가 진행되어 원심판결이 선고된 것이므로 여기에는 마치 대리인에 의하여 적법하게 대리되지 않았던 경우와 마찬가지로의 위법이 있다고 보아야 할 것이다(대법원 1997. 10. 10. 선고 96다35484).

단되었고 이후 수계되었다면, 수계 후 보정할 수 있는 기간은 남은 기간이 아닌 모든 기간인 1개월 이내이다.

V. 관련문제

1. 심판참가인의 경우

참가인에게 심판절차의 정지원인이 있으면 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다(法 155⑤).

2. 공동심판의 경우

청구인이나 피청구인 중 1명에게 심판절차의 정지원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다(法 139④).

제9장

보 칩

제215조 【둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙】

둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 제65조제6항, 제84조제1항제2호·제6호, 제85조제1항제1호(소멸의 경우만 해당한다), 제101조제1항제1호, 제104조제1항제1호·제3호·제5호, 제119조제1항, 제132조의13제3항, 제133조제2항·제3항, 제136조제7항, 제139조제1항, 제181조, 제182조 또는 「실용신안법」 제26조제1항제2호·제4호·제5호를 적용할 때에는 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 본다.

<개정 2016.2.29., 2016.3.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제215조의2 【둘 이상의 청구항이 있는 특허출원의 등록에 관한 특칙】

- ① 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 청구항의 포기에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제216조 【서류의 열람 등】

- ① 특허출원, 특허취소신청, 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다.

<개정 2016.2.29.>

- ② 지식재산처장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다.

<개정 2016.2.29.>

1. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다)에 관한 서류
2. 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류
3. 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류

[전문개정 2014.6.11.]

제217조 【특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지】

- ① 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 외부로 반출할 수 있다.

<개정 2016. 2. 29., 2016. 12. 2., 2017. 11. 28., 2018. 4. 17., 2021. 8. 17., 2024. 2. 6.>

1. 제58조제1항, 제3항 또는 제4항에 따른 선행기술의 조사 등을 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우
- 1의2. 제164조의2제2항에 따른 조정을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우

2. 「산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」 제12조제1항에 따른 산업재산문서 전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
3. 「전자정부법」 제32조제2항에 따른 온라인 원격근무를 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
4. 외국 특허담당 정부기관 또는 국제기구와의 업무협약을 이행하기 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우
- ② 특허출원·심사·특허취소신청·심판 또는 재심으로 계속 중인 사건의 내용이나 특허여부결정·심결 또는 결정의 내용에 관하여는 감정·증언하거나 질의에 응답할 수 없다. <개정 2016.2.29.>
- ③ 제1항제4호에 따른 반출 요건·절차, 서류의 종류 등에 필요한 사항은 총리령으로 정한다. <신설 2017.11.28.>

[전문개정 2014.6.11.]

제217조의2 삭제 <2024. 2. 6.>

제218조 【서류의 송달】

이 법에 규정된 서류의 송달절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제219조 【공시송달】

- ① 서류를 송달받을 자의 주소나 영업소가 분명하지 아니하여 송달할 수 없는 경우에는 공시송달(公示送達)을 하여야 한다.
- ② 공시송달은 서류를 송달받을 자에게 어느 때라도 발급한다는 뜻을 특허공보에 게재하는 것으로 한다.
- ③ 최초의 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 그 효력이 발생한다. 다만, 같은 당사자에 대한 이후의 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음 날부터 효력이 발생한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제220조 【재외자에 대한 송달】

- ① 재외자로서 특허관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다.
- ② 재외자로서 특허관리인이 없으면 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 서류를 항공등기우편으로 발송한 경우에는 그 발송일에 송달된 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

제221조 【특허공보】

- ① 지식재산청장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 특허공보를 발행하여야 한다.
- ② 특허공보는 총리령으로 정하는 바에 따라 전자적 매체로 발행할 수 있다.
- ③ 지식재산청장은 전자적 매체로 특허공보를 발행하는 경우에는 정보통신망을 활용하여 특허공보의 발행사실·주요목록 및 공시송달에 관한 사항을 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제222조 【서류의 제출 등】

지식재산청장 또는 심사관은 당사자에게 특허취소신청, 심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 그 밖의 물건의 제출을 명할 수 있다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제223조 【특허표시 및 특허출원표시】

- ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허표시를 할 수 있다. <개정 2016.2.29., 2017.3.21.>
1. 물건의 특허발명의 경우: 그 물건에 “특허”라는 문자와 그 특허번호를 표시

2. 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우: 그 방법에 따라 생산된 물건에 “방법특허”라는 문자와 그 특허번호를 표시
 3. 삭제 <2017.3.21.>
 - ② 특허출원인은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 특허출원의 표시(이하 “특허출원표시”라 한다)를 할 수 있다. <개정 2017.3.21.>
 1. 물건의 특허출원의 경우: 그 물건에 “특허출원(심사중)”이라는 문자와 그 출원번호를 표시
 2. 물건을 생산하는 방법의 특허출원의 경우: 그 방법에 따라 생산된 물건에 “방법특허출원(심사중)”이라는 문자와 그 출원번호를 표시
 - ③ 제1항 또는 제2항에 따른 특허표시 또는 특허출원표시를 할 수 없는 물건의 경우에는 그 물건의 용기 또는 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 할 수 있다. <신설 2017.3.21.>
 - ④ 그 밖에 특허표시 또는 특허출원표시에 필요한 사항은 총리령으로 정한다. <신설 2017.3.21.>
- [전문개정 2014.6.11.]
- [제목개정 2017.3.21.]

제224조 【허위표시의 금지】

누구든지 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
2. 제1호의 표시를 한 것을 양도·대여 또는 전시하는 행위
3. 제1호의 물건을 생산·사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
4. 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법을 사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

제224조의2 【불복의 제한】

- ① 보정각하결정, 특허여부결정, 특허취소결정, 심결이나 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하 결정에 대해서는 다른 법률에 따른 불복을 할 수 없으며, 이 법에 따라 불복할 수 없도록 규정되어 있는 처분에 대해서는 다른 법률에 따라 불복을 할 수 없다. <신설 2016.2.29.>
- ② 제1항에 따른 처분 외의 처분의 불복에 대해서는 「행정심판법」 또는 「행정소송법」에 따른다.

[전문개정 2014.6.11.]

제224조의3 【비밀유지명령】

- ① 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀에 대하여 다음 각 호의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다. 다만, 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 제1호에 규정된 준비서면의 열람이나 증거 조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 제 132조제3항에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 것

2. 제1호의 영업비밀이 해당 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것
- ② 제1항에 따른 명령(이하 “비밀유지명령”이라 한다)의 신청은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다.
 1. 비밀유지명령을 받을 자
 2. 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실
 3. 제1항 각 호의 사유에 해당하는 사실
- ③ 법원은 비밀유지명령이 결정된 경우에는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하여야 한다.
- ④ 비밀유지명령은 제3항의 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다.
- ⑤ 비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제224조의4【비밀유지명령의 취소】

- ① 비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 제224조의3제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원(소송기록을 보관하고 있는 법원이 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다.
- ② 법원은 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판이 있는 경우에는 그 결정서를 그 신청을 한 자 및 상대방에게 송달하여야 한다.
- ③ 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다.
- ④ 비밀유지명령을 취소하는 재판은 확정되어야 효력이 발생한다.
- ⑤ 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 법원은 비밀유지명령의 취소신청을 한 자 또는 상대방 외에 해당 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우에는 그 자에게 즉시 비밀유지명령의 취소 재판을 한 사실을 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제224조의5【소송기록 열람 등의 청구 통지 등】

- ① 비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송은 제외한다)에 관한 소송기록에 대하여 「민사소송법」 제163조제1항의 결정이 있었던 경우, 당사자가 같은 항에서 규정하는 비밀 기재 부분의 열람 등의 청구를 하였으나 그 청구 절차를 해당 소송에서 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 밟은 경우에는 법원서기관, 법원사무관, 법원주사 또는 법원주사보(이하 이 조에서 “법원사무관등”이라 한다)는 「민사소송법」 제163조제1항의 신청을 한 당사자(그 열람 등의 청구를 한 자는 제외한다. 이하 제3항에서 같다)에게 그 청구 직후에 그 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알려야 한다.
- ② 제1항의 경우에 법원사무관등은 제1항의 청구가 있었던 날부터 2주일이 지날 때까지(그 청구 절차를 밟은 자에 대한 비밀유지명령 신청이 그 기간 내에 이루어진 경우에는 그 신청에 대한 재판이 확정되는 시점까지) 그 청구 절차를 밟은 자에게 제1항의 비밀 기재부분의 열람 등을 하게 하여서는 아니 된다.
- ③ 제2항은 제1항의 열람 등의 청구를 한 자에게 제1항의 비밀 기재부분의 열람 등을 하게 하는 것에 대하여 「민사소송법」 제163조제1항의 신청을 한 당사자 모두가 동의하는 경우에는 적용되지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙

1. 대 상

1) 둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관하여 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 보는 경우로는 보상금청구권의 소멸(法 65⑥), 특허를 무효로 한다는 심결이

확정되거나 특허권을 포기한 해의 다음해부터의 특허료 해당분의 반환(法 84①Ⅱ, Ⅵ), 특허권의 소멸등록(法 85①Ⅰ), 특허권 및 전용실시권의 등록 효과(法 101①Ⅰ), 무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상실시권(法 104①), 특허권 포기의 제한(法 119①), 특허취소신청에 의한 소멸(法 132의13③), 특허무효심판에 의한 소멸(法 133②③), 정정심판의 청구(法 136⑦), 이해관계인의 공동심판청구(法 139①), 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한(法 181), 재심에 의하여 회복한 선사용자의 통상실시권(法 182)이 있다.

2) 다만 「보상금청구권의 소멸(法 65⑥)」 중 특허출원의 취하, 포기 및 무효, 특허출원에 대한 거절결정의 확정은 청구항별로 되지 않으며, 「정정심판의 청구(法 136⑦)」는 청구항별로 소멸한 때도 할 수 있으나, 정정심판을 청구한 사항이 일체불가분의 한 개의 사항이기 때문에 청구항별 정정심판청구가 허용되지 아니한다.

2. 특허출원의 등록

특허출원의 포기는 출원 자체를 포기하여야 하며 청구항별로 포기할 수 없음이 원칙이다. 다만 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다(法 215의2). 청구항별로 포기하려는 자는 설정특허(등록)로납부서에 그 취지를 적어 지식재산처장에게 제출하여야 한다(施規 19의2).

【표 1-17】 둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 대한 특칙(法 215-215의2)

조 문	내 용	비 고
제65조제6항	보상금청구권의 소멸	출원의 취하·포기·무효, 특허출원에 대한 거절결정확정은 준용×
제84조제1항제2호, 제6호	특허를 무효로 한다는 심결이 확정되거나 특허권을 포기한 해의 다음해부터의 특허료 해당분의 반환	
제85조제1항제1호	특허권의 소멸등록	특허권의 발생·이전·처분·존속기간의 연장은 청구항별 불가
제101조제1항제1호	특허권 및 전용실시권의 등록 효과	1. 청구항별 특허권의 이전·처분의 제한× 2. 청구항별 특허권의 포기 ○
제104조제1항제1호, 제3호, 제5호	무효심판청구등록 전의 실시에 의한 통상 실시권	
제119조제1항	특허권 포기의 제한	
제132조의13제3항	특허취소신청에 의한 소멸	
제133조제2항, 제3항	특허무효심판에 의한 소멸	
제136조제7항	정정심판의 청구시기	
제139조제1항	공동심판의 청구	
제181조	재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한	
제182조	재심에 의하여 회복한 선사용자의 통상실시권	
제215조의2	둘 이상의 청구항이 있는 경우 특허출원의 등록	

II. 서류의 열람 등

특허출원, 특허취소신청, 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급,¹⁸¹⁾ 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다(法 216①). 지식재산처장 또는 특허심판원장은 신청이 있더라도 다음의 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다(法 216②).

- i) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(국내우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다¹⁸²⁾)에 관한 서류
- ii) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 특허거절결정에 대한 심판(法 132의17)에 관한 서류
- iii) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류

III. 특허출원 등에 관한 서류 등의 반출 및 감정 등의 금지

1) 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심서류 또는 특허원부는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에만 외부로 반출할 수 있다(法 217①).

- i) 제58조제1항, 제3항 또는 제4항에 따른 선행기술의 조사 등을 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우
- ii) 제164조의2제2항에 따른 조정을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
- iii) 「산업재산 정보의 관리 및 활용 촉진에 관한 법률」 제12조제1항에 따른 산업재산문서 전자화업무의 위탁을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
- iv) 「전자정부법」 제32조제2항에 따른 온라인 원격근무를 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 반출하는 경우
- v) 외국 특허담당 정부기관 또는 국제기구와의 업무협약을 이행하기 위하여 특허출원 또는 심사에 관한 서류를 반출하는 경우

181) 「등본」이란 서류의 원본 그대로를 사기(寫記)한 것을 말하며, 「초본」이란 원본 중 관계부분을 사기(寫記)한 것을 말한다. 또한 「원본(原本)」이란 일정한 사실관계 또는 법률관계를 기술한 원문서를 말한다.

182) 국내우선권주장을 수반하는 출원의 발명에 대하여 무효 여부를 다투기 위해서는 선출원의 발명과 동일성 여부 및 출원시기 소급적용의 적법성 여부에 대한 확인을 하여야 한다는 점에서, 2017. 3. 1. 시행된 현행법(법률 제14035호, 2016. 2. 29. 개정)에서는 국내우선권주장을 수반하는 출원이 출원공개 또는 설정등록 되면 그 선출원의 열람을 허가하고 있다. 다만 원출원일로부터 1년 6개월 전에 변경출원이 되어 원출원이 변경출원과 동시에 취하간주된 경우에도 원출원의 발명과 동일성 여부 및 출원시기 소급적용의 적법성 여부를 확인할 필요성이 있는데 개정된 현행법이 이에 대한 내용을 포함하고 있지 않은 것은 입법불비라고 여겨진다.

2) 특허출원·심사·특허취소신청·심판 또는 재심으로 계속 중인 사건의 내용이나 특허여부 결정·심결 또는 결정의 내용에 관하여는 감정·증언하거나 질의에 응답할 수 없다(法 217②).

IV. 서류의 송달

1. 서

(1) 의 의

「서류의 송달」이란 지식재산청이 당사자나 그 밖의 이해관계인에게 특허절차에 관한 서류의 내용을 알리기 위해 일정한 방식으로 서류를 발급하는 행위를 말한다. 송달에 있어서는 특허법 또는 시행령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 송달을 받는 자에게 그 서류의 등본을 발급하여야 하며, 송달할 서류의 제출에 갈음하여 조서를 작성한 때에는 그 조서의 등본이나 초본을 발급하여야 한다(令 18④).

(2) 성 질

송달은 기간계산의 효력이 생기는 기준이 된다는 점에서 단순히 내용을 알리는 고지나 공고와는 그 성질이 다르다.

2. 송달의 종류

(1) 교부에 의한 송달

「교부송달」이란 지식재산청에서 당사자 또는 그 대리인이 직접 이를 수령하는 것을 말한다. 교부송달에 의하면 당사자 또는 그 대리인이 이를 직접 수령할 때 효력이 발생한다. 교부송달의 경우에는 수령자로부터 그가 수령한 일자 및 성명을 적은 수령증을 받아 비치하여야 한다(令 18②).

(2) 우편에 의한 송달

① 의 의

「우편송달(郵便送達)」이란 송달할 서류를 등기우편으로 발송하는 것을 말한다. 지식재산청 또는 특허심판원에서 당사자 또는 그 대리인이 이를 직접 수령하거나 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우를 제외하고는 일반적으로 등기우편으로 발송하여야 한다(令 18①). 등기우편으로 발송하는 경우에는 등기우편물 수령증을 보관하여야 한다(令 18②).

② 특별송달

심판·재심·통상실시권 설정의 재정 및 특허권의 취소에 관한 심결 또는 결정의 등본을 송달하는 경우에는 우편법령에 따른 특별송달의 방법으로 하여야 한다. 다만 제28조의4 제1항에 따른 전자문서 이용신고를 한 자에게 송달하는 경우에는 정보통신망을 이용하여 할 수 있다(令 18③).

③ 효력발생시기

우편송달의 경우 원칙적으로 송달받을 자에게 도달한 때 효력이 발생하나, 송달을 받을 자가 상당한 사유 없이 송달받기를 거부함으로써 송달을 할 수 없게 된 때에는 발송을 한 날에 송달된 것으로 본다(令 18①). 이는 송달받을 자의 고의적인 절차지연을 방지하기 위해서이다. 다만 송달을 거부하였는지가 불분명한 경우에는 후술하는 공시송달을 의뢰하여야 한다.

(3) 정보통신망에 의한 송달

① 의 의

일반적인 우편(서면)에 의한 송달의 예외로서 전자문서 이용신고를 한 자에 대해서는 정보통신망을 이용한 송달도 가능하다. 구체적으로 지식재산처장·특허심판원장·심판장·심판관 또는 심사관은 전자문서 이용신고를 한 자에게 서류의 통지 등을 하려는 경우에는 정보통신망을 이용하여 통지 등을 할 수 있고, 서류의 통지 등은 서면으로 한 것과 같은 효력이 있다(法 28의5②).

② 효력발생시기

이렇게 한 서류의 통지 등은 「그 통지 등을 받을 자가 자신이 사용하는 전산정보처리조직을 통하여 그 서류를 확인한 때」에 지식재산처 또는 특허심판원에서 사용하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 도달한 것으로 본다(法 28의5③).

(4) 공시송달

① 의 의

「공시송달」이란 서류를 송달받을 자의 주소 또는 영업소가 분명하지 아니하여 송달할 수 없는 경우¹⁸³⁾에 하는 송달을 말한다(法 219①). 「주소나 영업소가 분명하지 아니하여 송달할 수 없는 경우」란 송달을 할 자가 선택한 관리자의 주의를 다하여 송달을 받아야 할 자의 주소나 영업소를 조사하였으나 그 주소나 영업소를 알 수 없는 경우를 의미한다.¹⁸⁴⁾ 한편 공동출원인에 대하여 공시송달을 실시하기 위해서는 「공동출원인 모두의 주소 또는 영업소가 불분명하여 송달받을 수 없는 때」에 해당하여야 하고, 이러한 공시송달 요건이 구비되지 아니한 상태에서 공동출원인 중 1명에 대하여 이루어진 공시송달은 부적법하고 그 효력이 발생하지 아니한다.¹⁸⁵⁾

② 송달방법

공시송달은 서류를 송달받을 자에게 어느 때라도 발급한다는 뜻을 특허공보에 게재하는 것으로 한다(法 219②). 당사자 또는 대리인이 정보통신망을 이용하여 수령하는 경우에는 지식재산처 또는 특허심판원이 운영하는 발송용 전산정보처리조직의 파일에 기록된 내용을 보관하여야 한다(令 18②).

183) 피심판청구인에 대하여 청구서 사본을 등록원부상의 주소로 1회 송달하여 본 후 반송되자 바로 내부결재를 받아 그 이후의 서류송달을 공시송달의 방법에 의하고 있으나, 등록원부에 피심판청구인의 주민등록번호가 기재되어 있어 관련 행정기관에 조회하는 등의 방법으로 직권 조사하여 보는 등 피심판청구인의 실재주소를 알 수 있는 방법이 없는 것이 아님에도 불구하고, 그러한 노력도 없이 바로 공시송달 결정을 한 것은 적절한 절차의 진행이라고 볼 수 없는 것이다(대법원 1991. 10. 8. 선고 91후59).

184) 특허법원 2004. 11. 4. 선고 2004허3980; 1991. 10. 8. 선고 91후59 등.

185) 대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182.

③ 효력발생시기

최초의 공시송달은 특허공보에 게재한 날부터 2주일이 지나면 그 효력이 발생한다. 다만 같은 당사자에 대한 이후의 공시송달은 특허공보에 게재한 날의 다음 날부터 효력이 발생한다(法 219③).

3. 송달의 수신인 및 장소

(1) 송달의 수신인

① 행위제한능력자에 대한 송달

행위제한능력자에 대한 송달은 그 법정대리인에게 하여야 한다(令 18⑤).

② 수인이 공동으로 대리권을 행사하는 경우

수인이 공동으로 대리권을 행사하는 경우에는 그 중 1인에게 송달한다(令 18⑥). 그러나 대리인이 여러 사람이 있는 경우에는 개별대리(法 9)가 원칙이며, 시행령 제18조 제6항이 적용되지 않는다. 따라서 대리인 모두에게 각각 송달하여야 하고, 그 같은 경우 효력은 대리인 1인에게 최초로 송달되었을 때 발생한다.¹⁸⁶⁾

③ 교도소·구치소에 구속된 자에 대한 송달

교도소 또는 구치소에 구속된 자에 대한 송달은 그 소장에게 한다(令 18⑦).

④ 당사자가 수인인 경우

당사자 또는 그 대리인이 2명 이상인 경우로서 서류를 송달받기 위한 대표자 1명을 선정하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 신고한 경우에는 그 대표자에게 송달한다(令 18⑧).

⑤ 재외자에 대한 송달

재외자로서 특허관리인이 있으면 그 재외자에게 송달할 서류는 특허관리인에게 송달하여야 한다(法 220①). 다만 재외자로서 특허관리인이 없으면 그 재외자에게 송달할 서류는 항공등기우편으로 발송할 수 있으며(法 220②), 이는 재외자로서 특허관리인을 선임하지 아니하거나 일단 선임된 특허관리인을 해임하는 등의 이유로 특허관리인이 없이 일단 절차가 진행된 때에는 서류의 송달불능을 방지하기 위하여 그 재외자에게 송달할 수 있음을 규정한 것이다. 다만 서류를 항공등기우편으로 발송한 경우에는 그 발송일에 송달된 것으로 본다(法 220③). 특허관리인을 두지 아니한 경우 재외자에게 서류송달일에 관하여 불이익을 받도록 함으로써 재외자의 특허관리인 선임을 유도하고 있다.

(2) 송달의 장소

송달할 장소는 이를 받을 자의 주소 또는 영업소로 한다. 다만 송달을 받으려는 자가 송달을 받으려는 장소(국내의 경우에만 해당한다)를 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 미리 신고한 경우에는 그 장소로 한다(令 18⑨). 한편 송달을 받을 자가 장소를 변경한 때에는 지체없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다(令 18⑩).

186) 대법원 2011. 9. 29.자 2011마1335 결정.

V. 특허공보

1) 「특허공보」란 특허와 관련된 사항을 일반인에게 알리기 위하여 지식재산청이 발행하는 관보를 말한다. 특허공보는 전자적 매체(CD-ROM 등)로 발행할 수 있으며, 전자적 매체로 특허공보를 발행하는 경우 지식재산청장은 전산망을 활용하여 특허공보의 발행사실·주요목록 및 공시송달에 관한 사항을 알려야 한다(法 221).

2) 이러한 특허공보는 크게 등록특허공보와 공개특허공보로 구분한다(令 19①). 등록특허공보에는 다음의 사항을 게재한다(法 87③, 令 19②).

i) 다음의 구분에 따른 사항

가. 특허권자가 자연인인 경우: 성명 및 주소

나. 특허권자가 법인인 경우: 법인의 명칭 및 영업소의 소재지

ii) 출원번호·분류기호 및 출원연월일

iii) 발명자의 성명 및 주소

iv) 특허번호 및 설정등록연월일

v) 등록공고연월일

vi) 우선권주장에 관한 사항

vii) 제30조에 따른 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 발명에 관한 사항(해당하는 경우만 게재한다)

viii) 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관한 사항

ix) 특허출원서에 첨부된 명세서·도면 및 요약서(제87조제2항에 따른 설정등록 시에 첨부된 명세서·도면 및 요약서를 말한다)

x) 출원공개번호 및 공개연월일

xi) 제66조의2에 따른 직권보정에 관한 사항

xii) 제133조의2, 제136조 또는 제137조에 따라 정정된 내용

xiii) 그 밖에 지식재산청장이 필요하다고 인정하는 사항

3) 공개특허공보에는 다음의 사항을 게재한다. 다만 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공공의 위생을 해할 염려가 있다고 인정되는 사항은 게재하지 아니한다(令 19③).

i) 다음의 구분에 따른 사항

가. 출원인이 자연인인 경우: 성명 및 주소

나. 출원인이 법인인 경우: 법인의 명칭 및 영업소의 소재지

ii) 출원번호·분류기호 및 출원연월일

iii) 발명자의 성명 및 주소

iv) 출원공개번호 및 공개연월일

v) 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면. 다만 제42조의3제1항에 따라 명세서 및 도면을 국어가 아닌 언어로 적은 특허출원(이하 “외국어특허출원”이라 한다)과 제199조

제1항에 따른 국제특허출원 중 국어가 아닌 언어로 적은 국제특허출원(이하 “외국어국제특허출원”이라 한다)의 경우에는 다음의 구분에 따른 명세서(외국어국제특허출원의 경우에는 발명의 설명 및 청구범위를 말한다.) 및 도면으로 한다.

- 가. 외국어특허출원의 경우: 제42조의3제5항에 따라 보정한 것으로 보는 명세서 및 도면
나. 외국어국제특허출원의 경우: 제201조제5항에 따라 보정한 것으로 보는 명세서 및 도면

vi) 특허출원서에 첨부된 요약서

vii) 제42조의2제2항에 따른 명세서 보정에 관한 사항

viii) 우선권주장에 관한 사항

ix) 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관한 사항

x) 제60조제2항에 따른 출원심사의 청구사실. 다만 출원공개시에 그 사실이 게재되지 아니한 경우에는 해당 출원의 공개번호·분류기호 및 출원번호를 그 심사청구사실과 함께 추후 발행되는 공개특허공보에 게재하여야 한다.

xi) 제63조의2의 규정에 의하여 누구든지 그 특허출원이 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 지식재산처장에게 제공할 수 있다는 취지

xii) 기타 특허출원의 공개에 관계되는 사항

4) 다만 지식재산처장은 등록특허공보 및 공개특허공보에 자연인인 특허권자, 자연인인 출원인 또는 발명자의 주소를 게재하는 경우 그 특허권자, 출원인 또는 발명자의 신청이 있으면 그 주소의 일부만을 게재할 수 있다(令 19④).

5) 특허에 관한 사항이 특허공보에 게재되어 공포되면 일정한 효과가 발생하게 된다. 구체적으로 출원내용이 공개특허공보를 통하여 공포되면 출원발명과 동일한 발명을 무단으로 실시하는 자에게 적법한 경고를 한 경우에는 보상금청구권이 발생하며, 특허권의 설정등록일로부터 등록특허공보의 발행일 후 6개월 이내에는 누구든지 특허취소신청을 할 수 있다.

VI. 서류 등의 제출명령

지식재산처장 또는 심사관은 당사자에게 특허취소신청·심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 그 밖의 물건의 제출을 명할 수 있다(法 222). 이는 명세서 및 도면의 기재에 의하여 발명의 내용을 이해할 수 없거나 또는 이해가 곤란한 경우에는 제42조제3항제1호에 따라 거절이유통지를 하는 것이 원칙이나, 예외적으로 심사의 효율적인 진행을 위하여 필요한 경우에는 출원인에게 심사를 위하여 필요한 서류, 견본이나 그 밖의 물건(이하 “서류·견본 등”라 한다)을 제출하도록 하여 효율적이고 신속·공정한 심사에 기여하려는 제도이다. 특허취소신청·심판 또는 재심에 관한 절차에서는 당사자를 직접 심문(法 132의15, 147③, 184)할 수 있으므로 특별히 본 규정이 적용되지 않는다.

VII. 특허표시 및 특허출원표시

1. 의 의

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 i) 물건의 특허발명의 경우 그 물건, ii) 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우 그 방법에 의하여 생산된 물건, iii) 물건에 특허표시를 할 수 없을 경우 그 물건의 용기 또는 포장에 특허표시를 할 수 있다(法 223①③). 구체적으로 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건에 「특허」라는 문자와 그 특허번호를, 물건을 생산하는 방법의 특허발명에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 「방법특허」라는 문자와 그 특허번호를 표시한다. 출원인은 물건의 특허출원에 있어서는 그 물건에 「특허출원(심사중)」이라는 문자와 그 출원번호를, 물건을 생산하는 방법의 특허출원에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 「방법특허출원(심사중)」이라는 문자와 그 출원번호를 표시한다(法 223②).¹⁸⁷⁾ 특허표시, 특허출원표시는 권장사항이고 의무는 아니다. 특허표시 및 특허출원표시제도는 그 물건이 특허제품, 특허출원제품임을 공시하여 그에 대한 침해를 예방함으로써 특허권자를 보호하고 또한 상품선택의 기준을 제시함으로써 일반 제3자를 보호함에 그 취지가 있다.

2. 허위표시의 금지

1) 허위표시란 특허된 것이 아닌 물건이나 특허출원 중이 아닌 물건 등에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 것을 말하는 것으로서 특허법에 규정된 허위표시의 유형은 다음과 같다(法 224).

- i) 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
- ii) i)의 표시를 한 것을 양도·대여 또는 전시하는 행위
- iii) i)의 물건을 생산·사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
- iv) 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법을 사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위

2) 특허를 받은 구성의 일부를 변경한 제품에 특허표시를 한 것과 관련하여 대법원 2015. 8. 13. 선고 2013도10265 판결에서는 “특허법 제224조 제3호는 같은 조 제1호의 특허된 것이 아

187) 법 제223조제1항 및 제2항에 따라 특허표시 또는 특허출원의 표시를 하는 경우 특허번호 또는 특허출원번호를 기재한 인터넷주소를 표시함으로써 특허번호 또는 특허출원번호의 표시를 갈음할 수 있다(施規 121).

닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건을 생산사용양도하기 위하여 광고 등에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시(이하 ‘특허된 것 등으로 표시’라 한다)를 하는 행위를 금지하고 있다. 위 규정의 취지는 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써 거래의 안전을 보호하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 통상의 기술자가 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다”라고 판시하였다. 즉 일반적인 판단기준은 “공중을 오인시킬 정도에 이르렀는지 여부”이고, “그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우”는 일반적인 판단기준을 구체화한 것에 불과하고, “등”을 부가하여 구체화된 기준과는 다른 기준이 적용될 수 있음을 판시하였다. 그 결과 광의의 동일성 판단기준보다 넓은 범위를 상정함으로써, 특허된 것으로 표시된 물건이 특허된 물건과 다소 다른 점이 있게 되었다고 하더라도 특허로 인한 재산상의 유리함 및 특허에 대한 공중의 신뢰를 악용하여 공중에게 오인될 정도가 아니라면 허위표시로 보지 않게 된다.

3. 문제가 되는 표시

(1) 특허출원 중의 특허표시

특허출원 중의 물품에 대하여 특허출원 제○○○호(또는 PAT pending No. ○○○)의 표시를 하는 것은 출원증임을 분명히 하고 있고, 「특허표시와 유사한 표시」에 해당하지 않으므로 허위표시로 되지 아니한다.

(2) 실용신안권·디자인권의 특허표시

실용신안등록·디자인등록된 물건에 대하여 특허 제○○호 등으로 표시하는 것은 허위표시로 된다. 그러나 실용특허, 디자인특허 등과 같이 실용신안 또는 디자인제품에 특허라는 용어를 사용하는 것은 거래의 관행을 참작할 때 허위표시로 되지 아니한다.

(3) 침해품의 특허표시

허위표시를 금하는 취지는 일반품을 특허제품으로 생각하게 하여 거래상 유리한 지위를 가지려고 하는 부정한 행위를 방지하기 위함이라고 한다면, 침해품이라도 그것이 특허발명을 이용하여 생산된 것이라면 특허제품이므로 침해품에 특허표시를 하는 것은 허위표시에 해당하지 아니한다는 견해도 있으나 침해품 그 자체는 특허된 것이 아니고 특허표시를 하여 제3자에게

특허제품인 것으로 믿게 하여 거래상 유리한 지위를 갖는 것을 방지하는 것은 그 규정의 취지에 반하므로 이러한 경우도 허위표시죄를 구성한다고 본다.

(4) 외국어로 적은 특허의 표시

국산의 특허제품에 대하여, 예컨대 PAT No. ○○○과 같이 표시하는 것은 허위표시로 되지 아니한다.

4. 허위표시죄

허위표시의 금지(法 224) 규정에 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(法 228). 본 죄는 특허제품 또는 특허방법이 아닌 것에 특허표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 함으로써 특허에 대한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인케 하는 행위를 처벌하려는 규정으로써 그 보호법익은 사회의 거래안전이라고 할 수 있다.

Ⅷ. 불복의 제한

1) 보정각하결정, 특허여부결정, 특허취소결정, 심결이나 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대해서는 다른 법률에 따른 불복을 할 수 없으며, 이 법에 따라 불복할 수 없도록 규정되어 있는 처분에 대해서는 다른 법률에 따라 불복을 할 수 없다(法 224의2①). 특허거절결정에 대하여 불복하려는 경우에는 제132조의17에 따라 특허심판원에 심판을 청구할 수 있도록 규정되어 있고, 특허취소결정·심결·특허취소신청서·심판청구서나 재심청구서의 각하결정에 대하여 불복하려는 경우에는 제186조에 따라 특허법원에 소를 제기하도록 규정되어 있으며, 특허결정에 대해서는 출원인에게 불이익이 없기 때문이다.¹⁸⁸⁾ 한편 이 법에 따라 각 처분에 대한 불복을 인정하지 아니한 것¹⁸⁹⁾에 대해서는 다른 법률에 따라라도 불복을 인정하지 아니하는 것이 소송경제에 비추어 합리적이기 때문이다.

2) 그러나 불복절차가 마련된 처분 외의 처분의 불복에 대해서는 「행정심판법」¹⁹⁰⁾ 또는 「행정소송법」¹⁹¹⁾에 따른다. 예를 들어 절차가 무효로 되거나 불수리된 경우에는 행정심판이나 행정소송을 제기할 수 있다.

188) 대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274.

189) 예를 들어 제78조의 심사 또는 소송절차의 중지 결정, 제152조제4항의 심판관 제척 또는 기피에 관한 결정, 제156조제2항의 심판참가에 대한 결정 등이 있다.

190) 행정심판법 제3조(행정심판의 대상) ① 행정청의 처분 또는 부작위에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 법에 따라 행정심판을 청구할 수 있다.

191) 행정소송법 제8조(법적용예) ① 행정소송에 대하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법이 정하는 바에 의한다.

IX. 특허관련 민사소송에서의 비밀유지명령

1. 서

2012. 3. 15. 시행된 현행법(법률 제11117호, 2011. 12. 2. 개정)은 법원이 특허 침해에 관한 소송에서 비밀유지명령을 내릴 수 있도록 하고, 이를 위반하면 형사벌을 부과할 수 있도록 하는 근거 규정을 신설하였다. 이는 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환」을 국내법에 반영한 것으로서, 본 제도의 도입으로 i) 소송절차에서 알려지게 된 영업비밀이 보호됨에 따라 기업의 경영활동 위축을 막을 수 있고, ii) 자료제출(法 132) 거부를 남용하는 사례가 대폭 감소하여 손해 증명이 쉬워지고, 심리의 충실을 도모할 수 있을 것으로 보인다.

2. 비밀유지명령

(1) 요 건

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 그 당사자가 보유한 영업비밀¹⁹²⁾에 대하여 다음의 사유를 모두 소명한 경우에는 그 당사자의 신청에 따라 결정으로 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자에게 i) 그 영업비밀을 그 소송의 계속적인 수행 외의 목적으로 사용하거나¹⁹³⁾ ii) 그 영업비밀에 관계된 이 항에 따른 명령을 받은 자 외의 자에게 공개하지 아니할 것을 명할 수 있다.¹⁹⁴⁾ 다만 그 신청 시점까지 다른 당사자(법인인 경우에는 그 대표자), 당사자를 위하여 소송을 대리하는 자, 그 밖에 그 소송으로 인하여 영업비밀을 알게 된 자가 준비서면의 열람이나 증거조사 외의 방법으로 그 영업비밀을 이미 취득하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다(法 224의3①).

- i) 이미 제출하였거나 제출하여야 할 준비서면, 이미 조사하였거나 조사하여야 할 증거 또는 자료의 제출명령(法 132③)에 따라 제출하였거나 제출하여야 할 자료에 영업비밀이 포함되어 있다는 것
- ii) 영업비밀이 그 소송 수행 외의 목적으로 사용되거나 공개되면 당사자의 영업에 지장을 줄 우려가 있어 이를 방지하기 위하여 영업비밀의 사용 또는 공개를 제한할 필요가 있다는 것

192) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조제2호에서는 영업비밀을 “공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 생산방법, 판매방법, 그밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보”로 정의하고 있다.

193) 소송 수행 목적으로의 그 영업비밀의 사용에 대해서는, 비밀 유지 명령의 대상에서는 제외되어 있다. 이는 소송 당사자의 방어권을 확보하기 위해서 이와 같은 사용을 인정할 필요가 있는 점에 기인한 것으로 보인다.

194) 소송 수행 목적이라도 그 영업비밀의 공개는 금지되며, 비밀유지명령의 대상이다(단, 비밀유지명령을 받은 자에게는 공개 가능하다). 이것은 소송 수행 목적이라 하더라도 그 영업비밀이 공개되었다면, 영업비밀의 요건 중 하나인 비공지성이 결여되어 그 가치가 두드러지게 손상되기 때문이다.

(2) 절 차

1) 비밀유지명령의 신청은 다음의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다(法 224의3②).

- i) 비밀유지명령을 받을 자
- ii) 비밀유지명령의 대상이 될 영업비밀을 특정하기에 충분한 사실
- iii) 제224조의3 제1항 각호의 사유에 해당하는 사실

2) 법원은 비밀유지명령이 결정된 경우에는 그 결정서를 비밀유지명령을 받은 자에게 송달하여야 한다(法 224의3③).

(3) 효력 및 불복

비밀유지명령은 결정서가 비밀유지명령을 받은 자에게 송달된 때부터 효력이 발생한다. 비밀유지명령의 신청을 기각하거나 각하한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다(法 224의3④⑤).

3. 비밀유지명령의 취소

(1) 요건 및 절차

비밀유지명령을 신청한 자 또는 비밀유지명령을 받은 자는 제224조의3 제1항에 따른 요건을 갖추지 못하였거나 갖추지 못하게 된 경우 소송기록을 보관하고 있는 법원(소송기록을 보관하고 있는 법원이 없는 경우에는 비밀유지명령을 내린 법원)에 비밀유지명령의 취소를 신청할 수 있다. 법원은 비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판이 있는 경우에는 그 결정서를 그 신청을 한 자 및 상대방에게 송달하여야 한다(法 224의4①②).

(2) 효력 및 불복

비밀유지명령의 취소신청에 대한 재판에 대해서는 즉시항고를 할 수 있다. 비밀유지명령을 취소하는 재판은 확정되어야 효력이 발생한다. 비밀유지명령을 취소하는 재판을 한 법원은 비밀유지명령의 취소신청을 한 자 또는 상대방 외에 그 영업비밀에 관한 비밀유지명령을 받은 자가 있는 경우에는 그 자에게 즉시 비밀유지명령의 취소 재판을 한 사실을 알려야 한다(法 224의4③④⑤).

4. 소송기록 열람 등의 청구 통지 등

(1) 청구 통지

비밀유지명령이 내려진 소송(모든 비밀유지명령이 취소된 소송은 제외한다)에 관한 소송기록에 대하여 「민사소송법」 제163조제1항¹⁹⁵⁾의 결정이 있었던 경우, 당사자가 같은 항에서 규정하는

195) 민사소송법 제163조(비밀보호를 위한 열람 등의 제한) ① 다음 각 호 가운데 어느 하나에 해당한다는 소명이 있는 경우에는 법원은 당사자의 신청에 따라 결정으로 소송기록중 비밀이 적혀 있는 부분의 열람·복사, 재판서·조서중 비밀이 적혀 있는 부분의 정본·등본·초본의 교부(이하 “비밀 기재부분의 열람 등”이라 한다)를 신청할 수 있는 자를 당사자로 한정할 수 있다.

비밀 기재 부분의 열람 등의 청구를 하였으나 그 청구절차를 그 소송에서 비밀유지명령을 받지 아니한 자가 밝은 경우에는 법원서기관, 법원사무관, 법원주사 또는 법원주사보(이하 이 조에서 “법원사무관등”이라 한다)는 「민사소송법」 제163조제1항의 신청을 한 당사자(그 열람 등의 청구를 한 자는 제외한다. 이하 제3항에서 같다)에게 그 청구 직후에 그 열람 등의 청구가 있었다는 사실을 알려야 한다(法 224의5①). 이는 비밀유지명령을 받지 아니한 자의 소송기록 열람 등의 청구에 따른 영업비밀 누출의 위험으로부터 효율적으로 영업비밀을 보호하기 위함이다.

(2) 열람

법원사무관등은 청구가 있었던 날부터 2주일이 지날 때까지(그 청구절차를 밝은 자에 대한 비밀유지명령신청이 그 기간 내에 이루어진 경우에는 그 신청에 대한 재판이 확정되는 시점까지) 그 청구절차를 밝은 자에게 비밀 기재 부분의 열람 등을 하게 하여서는 아니 된다(法 224의5②). 다만 열람 등의 청구를 한 자에게 비밀 기재 부분의 열람 등을 하게 하는 것에 대하여 「민사소송법」 제163조제1항의 신청을 한 당사자 모두가 동의하는 경우에는 적용되지 아니한다(法 224의5③).

5. 비밀유지명령 위반죄

국내외에서 정당한 사유 없이 제224조의3 제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 비밀유지명령 위반죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다(法 229의2).¹⁹⁶⁾ 이는 민사소송 절차에서 생산되거나 교환된 비밀정보의 보호에 관한 사법명령의 위반에 대하여 사법당국이 제재를 부과할 수 있는 권한을 규정한 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환」을 반영한 것이다.

-
1. 소송기록 중에 당사자의 사생활에 관한 중대한 비밀이 적혀 있고, 제3자에게 비밀 기재부분의 열람 등을 허용하면 당사자의 사회생활에 지장이 클 우려가 있는 때
 2. 소송기록 중에 당사자가 가지는 영업비밀(부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률 제2조 제2호에 규정된 영업비밀을 말한다)이 적혀 있는 때
 - ② 제1항의 신청이 있는 경우에는 그 신청에 관한 재판이 확정될 때까지 제3자는 비밀 기재부분의 열람 등을 신청할 수 없다.
 - ③ 소송기록을 보관하고 있는 법원은 이해관계를 소명한 제3자의 신청에 따라 제1항 각 호의 사유가 존재하지 아니하거나 소멸되었음을 이유로 제1항의 결정을 취소할 수 있다.
 - ④ 제1항의 신청을 기각한 결정 또는 제3항의 신청에 관한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.
 - ⑤ 제3항의 취소결정은 확정되어야 효력을 가진다.
- 196) 비친고죄로 구성하는 경우, 피해자가 형사재판을 원하지 아니하여도 검사가 기소하면 공판 절차가 개시되므로 형사처벌을 통해 보호를 도모하려는 영업비밀이 형사소송 과정에서 다시 공개되어 버릴 가능성이 있다. 따라서 친고죄로 구성하여 피해자가 비밀유지명령 위반에 대하여 자신의 영업비밀이 누설되는 것을 감수하고서라도 형사소추를 하여 처벌할 것인지 아니면 영업비밀을 중시하여 소추를 하지 않을 것인지 여부를 스스로 비교衡量 하여 판단할 수 있도록 하는 것이 타당하다.

PART 02

특허요건

제1장 서론

제2장 특허를 받을 수 있는 발명

제3장 특허를 받을 수 없는 발명

제4장 특허를 받을 수 있는 자

제5장 특허를 받을 수 있는 출원

제1장

서론

1) 「특허요건」이란 특허출원한 발명이 특허를 받기 위하여 만족하여야 하는 요건을 말한다. 모든 발명이 특허를 받을 수 있는 것은 아니며 특허법에서 규정하고 있는 특허요건을 만족하는 발명만이 특허를 받을 수 있다. 특허법상 협의의 특허요건은 제29조에서 규정하고 있는 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 및 확대된 선출원을 의미하고, 광의의 특허요건은 제62조에서 규정하고 있는 거절이유에 해당하지 아니한 것을 의미하는데, 일반적으로 특허요건이란 후자를 지칭한다.

2) 출원번호, 출원일자를 부여받아서 특허출원으로 인정되기 위해서는 특허출원서류를 제출한 후 지식재산처장의 방식심사를 통해 제출한 서류가 수리되어야 하고, 설사 수리되어 특허출원으로 인정되었다고 하더라도 설정등록되어 특허권이 발생하기 위해서는 심사청구를 한 후 심사관의 실체심사를 통해 특허결정되어야 한다. 심사관은 실체심사를 할 때 특허요건을 만족하는 발명만 특허결정을 한다. 이하에서는 특허요건을 특허를 받을 수 있는 발명, 특허를 받을 수 없는 발명, 특허를 받을 수 있는 자 및 특허를 받을 수 있는 출원으로 구분하여 구체적으로 살펴본다.

제2장

특허를 받을 수 있는 발명

제1절 산업상 이용가능성

제29조 【특허요건】

- ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명
 - ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.
 - ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
 2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것
 - ④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것
 2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것
 - ⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.
 - ⑥ 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.
 - ⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「산업상 이용가능성」이란 발명이 산업에서 실제로 실시될 수 있는 것을 의미하는 특허요건을 말한다. 특허법은 제29조제1항에서 특허요건으로서 「산업상 이용할 수 있는 발명」일 것을 규정하고 있다.

2. 취 지

특허법은 산업발전에 이바지하려는 법 목적을 달성하기 위해 산업상 이용가능성이 없는 발명은 특허를 받을 수 없도록 하고 있다. 즉 획기적인 기술, 기발한 아이디어로 발생한 발명일 지라도 그것이 실제로 산업에 이용할 수 없는 대상이라면 그 발명에 대하여 특허권을 부여할 이유가 없는 것이다.

II. 산업상 이용가능성의 의미

1. 산 업

(1) 산업의 의미

산업은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 최광의 개념으로 해석된다. 파리조약 제1조(3)에서도 “산업재산권은 최광의로 해석되어 엄격한 의미의 공업 및 상업뿐만 아니라 농업 또는 채취산업의 분야 및 제조 또는 천연의 모든 산품, 예컨대 포도주, 곡물, 담뱃잎, 과일, 가축, 광물, 광천수, 맥주, 꽃, 밀가루에 대하여도 적용된다”라고 하여 산업의 범위를 최광의로 해석하고 있으며, 특허협력조약¹⁾도 동일한 취지에서 산업을 규정하고 있다.

(2) 개인적·학술적·실험적 이용 배제

심사 실무²⁾는 산업의 범위를 넓게 해석하기 위하여 개인적·학술적·실험적으로만 이용될 수 있어서 업(業)으로써 이용될 가능성이 없는 것만을 배제하고 산업상 이용가능성이 있다는 소극적인 입장을 취하고 있다. 다만 개인적·학술적·실험적으로 이용될 수 있는 것이라도 시판 또는 영업의 가능성이 있는 것은 산업상 이용가능성이 있는 발명에 해당한다.

(3) 서비스업의 경우

농·수산업인 1차 산업, 광·공업인 2차 산업이 특허법상 이용될 수 있는 산업에 포함된다면 것에는 이론의 여지가 없으나 생산이 뒤따르지 아니한 3차 산업인 서비스업도 산업에 포함되는지에 대해서는 논란이 있을 수 있다. 기존에는 운수업·광고업·세탁업 등 일부 서비스업은

1) 특허협력조약 제33조제4항에서도 “산업이란 용어는 산업재산권 보호에 관한 파리조약과 마찬가지로 광의로 해석한다”라고 하고 있다.

2) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 3117면.

산업에 포함되지만, 보험업·금융업 등의 서비스업은 산업의 범위에 포함되지 아니한다고 보는 것이 일반적이었다. 그러나 컴퓨터와 결합된 보험방법 또는 금융방법발명의 경우, 즉 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 경우 특허를 허용하고 있는 현실을 고려할 때 보험업·금융업 등의 서비스업을 일률적으로 산업에서 제외하는 것은 타당하지 않다.

2. 이용가능성

1) 일반적으로 「이용」이란 제2조제3호의 실시와 같은 의미라고 해석하며, 「이용가능성」이란 동일결과를 반복 실시할 수 있는 가능성으로서 그 발명이 실제로 즉시 실시될 것을 의미하는 것이 아니라 장래 이용될 가능성만 있으면 되는 것으로 해석하는 것이 일반적이다. 이는 발명의 산업적 실시에는 상당한 물리적인 시간과 장기적인 경영적 판단이 요구되기 때문이다.

2) 그러나 특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다.³⁾

III. 산업상 이용가능성의 판단

1. 주체적 기준

심사단계에서는 심사관이, 심판단계에서는 심판관 합의체가, 법원에서는 법관이 심사한다.

2. 객체적 기준

청구범위의 청구항에 기재된 발명을 중심으로 판단하되, 발명의 설명·도면을 참작하고 기술분야를 고려한다.

3. 시기적 기준

(1) 원 칙

산업상 이용가능성의 판단시기에 대하여 특허법은 명문의 규정을 두고 있지 않다. 다만 심사실무는 출원 시를 기준으로 산업상 이용가능성을 판단하고 있다.

3) 특허출원발명의 출원일 당시 수지상 세포는 혈액 단핵세포의 0.5% 미만으로 존재하고 분리된 후에는 수일 내로 사멸하기 때문에 연구하기가 쉽지 아니하여 혈액으로부터 충분한 양의 수지상 세포를 분리해 내는 것은 기술적으로 쉽지 않고, 출원일 이후 기술의 발전에 따라 사람의 혈액으로부터 수지상 세포를 추출하고 이를 이용하여 면역반응을 유발시키는 기술이 임상적으로 실시되고 있다는 것이므로, 결국 출원발명의 출원일 당시를 기준으로 수지상 세포를 사람의 혈액으로부터 분리하여 출원발명에 사용하는 기술이 장래에 산업상 이용가능성이 있다고 보기는 어렵다(대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801).

(2) 예 외

i) 무권리자에 대한 정당한 권리자 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ii) 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, iii) 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, iv) 국제특허출원의 경우 우선일의 출원 시를 기준으로 판단한다.

4. 판단방법

(1) 의료업의 경우

1) 의료업의 경우에는 의료행위⁴⁾를 하는 의사들의 양심과 윤리에 관한 문제로서 이러한 치료방법들을 특허에 의하여 보호하여 특정인의 재산적 이익을 도모하는 것보다 인류의 생명과 건강에 기여하여야 한다는 점에서 특허의 대상으로 되지 아니한다는 것이 원칙이지만,⁵⁾⁶⁾ 예외적으로 산업상 이용가능성을 인정하여 특허의 대상이 되기도 한다. 구체적으로 의료업의 경우 인체를 직접적인 구성요소로 하는지가 판단기준이다. 예를 들어 i) 인간을 대상으로 하는 수술방법, 치료방법⁷⁾, 진단방법⁸⁾, ii) 인체로부터 채취한 것을 채취한 자에게 치료를 위해 되돌려 줄 것을 전제로 하여 처리하는 방법(예 : 혈액투석방법) 등 인체를 직접적인 구성요소로 하는 발명은 산업상 이용가능성이 인정되지 아니한다.⁹⁾

4) 특허권의 대상에서 제외되는 '인간을 수술하거나, 치료하거나 진단하는 방법'이 반드시 의료법상 의료인에 의하여 수행되는 것으로만 제한된다고 보기 어렵다(특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018허3062).

5) 위와 같은 의료행위에 대한 특허성 부인의 근거로서 특허법원 2004. 7. 1. 선고된 2003허6104 판결은, i) 의료행위는 인간의 존엄 및 생존에 깊이 관계되어 있는 점, ii) 모든 사람은 의사의 도움을 통하여 질병의 진단, 치료, 경감 또는 예방할 수 있는 의료방법을 선택하고 접근할 수 있는 권리가 보호되어야 한다는 점, iii) 의료행위에 관한 발명을 특허의 대상으로 하게 되면 의사가 의료행위를 수행할 때 특허의 침해 여부를 신경 쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어렵게 되는 점 등을 들고 있다.

6) 다만 i) 기존에는 의료행위의 연구개발이 대학, 대학병원 등에서 영리의 목적이 없이 연구행위로써 이루어졌기 때문에 특허제도에 의한 인센티브를 부여할 필요성이 높지 않았으나, 현재는 의료기술의 개발이 생명과학기술을 이용한 유전자치료, 재생의료기술과 같이 기업의 연구소 등에서 영리 목적으로 연구되고 있어 충분히 산업상 이용될 수 있다는 현실을 반영하지 못한다는 점, ii) 윤리적인 이유로 산업상 이용가능하지 않다고 하는 것은 무리라는 점을 들어 비판하는 견해가 있다(서계원, 「특허법 주해 I」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 422-440면 참조). 이와 관련하여 i) 특허를 부여하지 아니한 것은 타당하나 제32조의 불특허사유를 적용하는 것이 타당하다는 견해(윤권순, “의료발명의 특허성에 대한 비판적 고찰”, 창작과 권리, 제14호, 1999년 봄호, 4-5면 참조), ii) 특허취득을 인정하고 그 효력을 사후적으로 제한할 필요가 있다는 견해(김병일, “의료방법과 특허”, 한국비교사법학회, 비교사법 제11권 제4호, 2004.12, 399면)를 참고할 필요가 있다.

7) 이 사건 출원발명은 온구기를 사용하여 사람의 등 부위의 경혈과 배 부위의 경혈을 자극하는 방법에 관한 것으로, 온구기의 시구 순서와 시구 시의 몸의 자세 등으로 구성되어 있는바, 이는 사람의 질병을 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한 것이고, 인체를 필수 구성요소로 하고 있는 것이어서 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없어 특허의 대상이 될 수 없다(대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후1936). 다만 온구기 자체는 인체를 구성요소로 하지 아니하기 때문에 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.

8) 인간의 질병을 치료하는 방법이거나 적어도 치료를 위한 예비적 처치 방법 또는 건강상태를 유지하기 위한 처치방법에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없다(특허법원 2008. 6. 26. 선고 2007허13827).

9) 심사 실무상 산업상 이용가능성이 부정되는 예시는 다음과 같다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3109-3112면).

2) 그러나 인체를 간접적인 구성요소로 하거나 인체를 구성요소로 하지 아니한 경우에는 의료업의 경우라도 산업상 이용가능성이 있다. 이는 의료행위를 돕는 장비 등의 발명에 까지 특허를 부여하지 않게 되면 의료장비의 개발과 첨단화를 기대할 수 없어 결과적으로 의료수준의 퇴보를 낳게 되며, 기계나 장비의 경우 일단 판매가 되면 권리의 소진이 일어나 그 이후 특허침해의 우려 없이 이를

구분	발명의 예시	구분	예시
1. 수술 방법 발명	1. 수술적 방법에 의한 피임방법 2. 배내장을 제거하는 수술방법 3. 뼈 안에 박힌 보철을 제거하는 방법	3. 진단 방법 발명	1. 육안검사를 통해 피부의 짓무른 정도를 확인하는 방법 2. 진맥에 의한 질병 및 건강 진단방법 3. 내시경 판독을 통해 위의 손상된 정도를 확인하기 위한 내시경 검사 방법 4. 알레르겐을 피부에 직접 접촉시켜 알레르기 반응 여부를 검사하는 방법 5. 환자의 시료로부터 항원-항체 반응을 통해 암마커 A를 검출하고 이를 통해 대장암의 유무를 판단하는 대장암 진단방법 6. X선 조사 조건을 설정하는 단계; 조영제 주입전과 주입후에 X선 촬영을 실시하는 단계; 및 조영제 주입전과 주입후의 X선 영상을 분석하여 질병의 유무를 판단하는 단계를 포함하는 X선 진단방법 【설명】 ‘질병의 유무를 판단하는 단계’는 의사의 정신적 활동인 임상적 판단이 포함된 것으로 해석되어 의료행위에 해당한다.
2. 치료 방법 발명	1. 투약, 주사 또는 침술방법 2. 치아 임플란트 부착 방법 3. 지압방법 4. 혈액 투석 방법 5. 유전자 치료방법 6. 신체부위의 소독방법 7. 치료 효과를 높이기 위한 보조적 처치 방법 【설명】 보조적 처치 방법에는 재활훈련 방법 등이 있다. 8. 면역자극에 의한 감기 예방방법 9. 욕창 방지 방법 10. 심장박동 조절 방법에 있어서, 검지된 심박수와 메모리에 저장된 표준 심박수를 비교하는 단계; 검지된 심박수와 표준 심박수의 차에 따라서 심장에 펄스를 제공하는 단계를 포함하는 심장박동 조절 방법 【설명】 ‘심장에 펄스를 제공하는 단계’는 의료인이 심장병 환자를 대상으로 심장 박동 제어에 관여하는 것으로 해석되어 심장질환의 치료를 위한 의료행위에 해당한다. 다만 심장박동 조절방법의 각 단계를 심장박동 조절장치의 제어부가 수행하는 제어 방법인 경우에는 산업상 이용가능성이 인정될 수 있다. 11. A 유전자에 특이적인 가이드 RNA 및 CAS 단백질을 암호화하는 핵산을 포함하는 조성물을 유기체에 도입하여 A 유전자를 제거하는 방법 【설명】 발명의 설명에 B 질환을 야기하는 원인 유전자인 A를 제거하면 B 질환을 치료할 수 있는 것으로 기재되어 있는 경우에는 ‘유기체에서 A 유전자를 제거하는 방법’은 결과적으로 인간을 치료하는 방법에 해당한다.	4. 청구 범위에 의료 행위 및 비의료 행위 구성 요소가 혼재하는 방법 발명	1. 수술적 방법에 의하여 동물로부터 시료를 얻는 단계; 및 시료를 항체와 반응시키는 단계로 이루어진 단백질 A를 검출하는 방법 【설명】 동물에는 사람(인간)이 포함되고 ‘시료를 얻는 단계’에서 수술적 방법을 사용하기 때문에 의료행위에 해당한다. 2. 환자의 시료로부터 항원-항체 반응을 통해 암마커 A를 검출하는 단계; 암마커 A가 검출된 환자의 치료에 적합한 약물을 인체에 주입하는 단계를 포함하는 환자 맞춤형 환자 치료방법 【설명】 암마커 A를 검출하는 단계는 환자의 시료에 대해서 항원-항체 반응을 통해 수행되는 것이므로 의료행위에 해당하지 아니하나, ‘약물을 인체에 주입하는 단계를 포함하는 환자 맞춤형 치료방법’은 인간을 치료하는 방법이므로 의료행위에 해당한다.

자유로이 사용할 수 있는 경우가 대부분이기 때문이다.¹⁰⁾ 예를 들어 i) 사람으로부터 자연적으로 배출된 것(예: 소변, 변, 태반, 모발, 손톱) 또는 채취된 것(예: 혈액, 피부, 세포, 종양, 조직)을 처리하는 방법이 의료행위와는 분리 가능한 별개의 단계로 이루어진 방법인 경우 또는 단순히 데이터를 수집하는 방법인 경우, ii) 인체를 직접적인 구성요소로 하지 아니한 의료행위에 사용하는 의료기기·장치 또는 의약품인 경우, iii) 의료기기의 작동방법 또는 의료기기를 이용한 측정방법 발명(다만 그 구성에 인체와 의료기기 간의 상호작용이 인체에 직접적이면서 일시적이 아닌 영향을 주는 경우 또는 실질적인 의료행위를 포함하는 경우를 제외), iv) 인간 이외의 동물에 한정함을 청구범위에 명시하는 경우,¹¹⁾ v) 진단방법이라고 할지라도 의사의 임상적 판단(의학적 지식 및 경험을 바탕으로 질병 또는 건강상태를 판단하는 정신적 활동)을 포함하지 아니한 경우¹²⁾ 등은 산업상 이용가능성이 인정된다.¹³⁾

3) 인체를 필수구성요소로 하는 발명이라 하더라도 인체에 행하여지는 수술 또는 치료방법 등 의료행위에 해당하지 아니하면(예: 모발의 웨이브방법에 관한 발명), 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하여 제32조 소정의 「공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명」에 해당되어 특허가 허용될 수 없는 경우를 제외하고는, 산업상 이용가능성이 있어 특허로서 보호받을 수 있다.¹⁴⁾¹⁵⁾

4) 문제가 되는 것은 치료 효과와 비치료 효과를 동시에 가지는 데 이를 구별 및 분리할 수 없는 방법이다. 인체를 치료하는 방법이 치료 효과와 비치료 효과(예: 미용효과)를 동시에 가지는 경우, 치료 효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료방법으로 간주하여 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 않는다. 다만 i) 그 청구항이 비치료적 용도(예: 미용용도)로만 한정되어 있고, ii) 명세서에 기재되어 있는 발명의 목적, 구성 및 효과를 종합적으로 고려할 때 비치료적 용도로 그 방법의 사용을 분리할 수 있으며, iii) 어느 정도의 건강증진 효과가 수반된다고 하더라도 그것이 비치료적인 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적 효과인 경우에는, 치료방법에 해당한다고 볼 수 없다.¹⁶⁾¹⁷⁾ 한편 수술방법의 경우에는 미용 목적 및 용도로 한정하더라도 산업상 이용 가능한 것으로 인정하지 아니한다.¹⁸⁾

10) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 86면.

11) 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250. 이는 구성요소완비의 원칙에 의해 등록 후에 동물에만 특허의 권리범위가 미치기 때문이다. 한편 이와 같이 청구항에서 일정한 사항을 제외하는 보정(이른바 ‘제외 클레임’ 보정)은, 그러한 제외하는 한정이 최초 명세서 등에 기재된 것으로 볼 수 없는 새로운 기술적 사항이 도입되는 것이 아니라면 허용된다. 특히 의료방법 관련 발명의 대상이 사람인지 동물인지가 명시되어 있지 아니한 경우, 그 발명이 특정 동물만을 대상으로 하는 것은 아닌 것이 자명할 때 사람에게 해당하는 부분을 삭제하기 위하여 한정하는 보정은 신규사항이 추가된 것으로 보지 않는다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 4202-4206면).

12) 생명공학과 전자 및 광학, 원자력 기술이 의료분야에 활용되면서 의사의 소견이 포함되지 아니한 진단기술이 속속 등장하고 있으며, 전 세계적으로도 의사의 임상적 판단이 배제된 과학기술 분야의 진단기술은 과학기술로 간주하여 특허영역에 포함해야 한다는 의견이 꾸준히 제기되어 왔기 때문에 이를 반영한 결과이다.

13) 심사 실무상 산업상 이용가능성이 긍정되는 예시는 다음과 같다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3113-3116면).

구분	발명의 예시	구분	예시
1. 의료 기기의 작동 방법 또는 측정 방법 발명	1. 자동혈압 측정기의 자동혈압측정 방법에 있어서, 수축기 혈압과 이완기 혈압을 비침습적으로 측정하여 전기신호로 변환하는 단계; 측정된 전기신호를 증폭한 후 필터링하는 단계; 필터링 후 전기신호로부터 혈압을 연산하여 자동혈압 측정기의 표시창에 혈압을 표시하는 단계를 포함하는 자동혈압 측정방법 2. 심장박동조절기의 제어방법에 있어서, 제어부가 검지된 심박수와 메도리에 저장된 표준 심수와 표준 심박수의 차에 따라서 심장에 제공될 펄스 신호를 생성하는 단계로 이루어진 심장박동조절기의 제어방법 3. 초음파 검사 장치의 초음파 스캐닝 방법에 있어서, 대상체로부터 수신된 신호를 처리하여 오류가 없는 초음파 영상을 제공하기 위한 초음파 스캐닝 방법	4. 임상적 판단을 포함하지 않는 진단 관련 방법 발명	1. 대장암 진단에 필요한 정보를 제공하기 위하여 환자의 시료로부터 항원-항체 반응을 통해 암마커 A를 검출하는 방법 2. 항원-항체 복합체를 검출하는 것을 특징으로 하는 시료 내 A 단백질의 농도를 측정하는 방법 3. 인체로부터 유래한 시료 중에 함유된 미토콘드리아 DNA 양을 정량하여 그 양을 대조군의 미토콘드리아 DNA 양과 비교함을 특징으로 하는 분석방법 4. 채혈한 혈액으로부터 혈당량을 측정하는 방법 5. 신장 질환의 진단을 위해 요(尿)로부터 알부민을 검출하는 방법 6. 대장암 진단에 필요한 정보를 제공하기 위한 방법으로 의료기기를 이용하여 환자의 시료로부터 항원-항체 반응을 통해 암마커 A를 검출하는 방법 7. 의료기기에서 인공지능 알고리즘을 수행하여 암을 예측하거나 암 예측을 위한 정보를 제공하는 방법 8. X선 진단장치를 이용한 암 진단을 위한 정보를 제공하는 방법에 있어서, 전처리 모듈이 X선 영상으로부터 노이즈를 제거하는 단계; 인공지능 모듈이 노이즈가 제거된 X선 영상을 입력받아 암 진단을 위한 정보를 추출하는 단계를 포함하는 암 진단을 위한 정보를 제공하는 방법 9. 대상체의 생물학적 시료로부터 A 유전자의 프로모터 부위의 CpG 섬(CpG island)의 메틸화 수준을 측정하는 단계를 포함하는, 암진단에 필요한 정보를 제공하는 방법 10. 컴퓨터에서 수행되는 위암에 대한 개체의 감수성을 예측하는 방법으로서, (a) 개체에게 존재하는 하나 이상의 위암 대립유전자 변이들의 데이터를 컴퓨터에 입력하는 단계; (b) 위암 대립유전자 변이 및 상기 변이와 연관된 위암에 관한 정보를 포함하는 컴퓨터에 저장된 데이터베이스와 상기 데이터를 비교하는 단계; 및 (c) 상기 비교에 근거하여 상기 개체가 위암에 걸리기 쉬운지를 결정하는 지표를 산출하는 단계;를 포함하는 위암에 대한 개체의 감수성을 예측하는 방법 【설명】명세서 전반의 내용으로 보아 해당 결정단계들이 컴퓨터 상에서 이루어지는 정보처리방법임이 명백한 경우에는 산업상 이용 가능한 발명으로 본다.
2. 인간으로부터 배출 또는 채취된 것을 처리하는 방법 발명	1. 인체로부터 분리된 세포에 A 단백질을 코딩하는 DNA를 도입하는 단계를 포함하는 B 기능이 향상된 세포를 제조하는 방법 2. 분리된 종양 세포를 C 배지에서 배양하는 단계를 포함하는 암 세포 배양방법 3. 고분자 지지체에 인간 세포를 배양하는 단계를 포함하는 인공피부 제조방법 4. A 유전자에 특이적인 가이드 RNA 및 Cas 단백질을 암호화하는 핵산을 포함하는 조성물을 분리된 세포에 도입하여 A 유전자를 제거하는 방법		
3. 사람(인간)을 제외한 동물의 수술, 치료 또는 진단 방법 발명	1. 가축의 수술방법 2. 사람을 제외한 포유동물의 치료방법 3. 인간을 제외한 포유동물의 진단방법		

(2) 경제성 유무

경제성 유무는 사회·경제적 여건에 따라 결정되는 상대적 개념이므로 고려할 필요가 없다. 발명의 경제성이란 경제적·사회적 조건들에 의하여 결정되는 문제이지 기술적 평가와는 원칙적으로 관계가 없기 때문이다. 또한 경제적 불이익을 초래하는 발명이라 하더라도 통상적으로 개량발명이나 다른 기술적 수단의 부가로서 극복될 수도 있으므로 경제성이 없다고 하여 발명의 특허성을 부정한다는 것은 불합리하다.¹⁹⁾

(3) 불성립발명

1) 불성립발명과 산업에 이용될 수 없는 발명은 구별되는 개념이지만, 발명의 성립성 위반이 제한열거적인 거절이유(法 62)에 기재되어 있지 않기 때문에 실무²⁰⁾상 우회적으로 산업상 이용가능성이 흠결된 것을 이유로 거절한다.

2) 예를 들어 i) 오존층의 감소에 따른 자외선의 증가를 방지하기 위하여 지구표면 전체를

14) 인체를 발명의 구성요소로 하는 경우 산업상 이용가능성 인정 여부의 판단은 다음과 같다.

산업상 이용가능성	의료업	비의료업	비고
인체를 직접적인 구성요소로 하는 경우	불인정	인정	단, 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 경우 불특허발명(法 32)에 해당
인체를 직접적인 구성요소로 하지 아니하는 경우	인정	인정	

15) 특허법원 2004. 7. 1. 선고 2003허6104.

16) 이 발명은 인체를 필수 구성요건으로 하고는 있지만, 이 사건 출원발명 그 자체가 수술·치료·진단을 목적으로 하는 것이 아닐 뿐만 아니라 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이 아니라 는 점은 분명하다. 또한 이 발명은 '소정의 방식에 의하여 피부를 마사지함으로써 화장품이 피부에 잘 스며들도록 하는 피부미용법에 관한 출원이어서, 건강증진의 효과가 수반된다고 하더라도, 이는 어디까지나 피부미용의 목적과 효과를 달성하기 위한 과정에서 나타나는 부수적인 효과일 뿐이지, 이를 가리켜 의료행위에 해당한다거나 사람에 대한 수술방법 또는 비수술적 치료방법 내지 진단방법에 해당한다고 볼 수는 없다. 그러나 오케스트라의 연주기법에 의한 피부미용법은 사람의 행위가 주요 구성요소로 되어 있는 것으로서 이를 시행하는 각 개인의 숙련도에 의해서 달라질 수 있는 일종의 기능에 해당하는 성질을 가지므로, 이 사건 특허출원의 명세서 기재만으로는 통상의 기술자가 이를 반복하여 재현할 수 있다고 볼 수 없다. 따라서 이 사건 특허출원 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성 및 작용효과 등을 전체적으로 고려하면 이 사건 출원발명은 통상의 기술자가 반복 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적·객관적으로 구성되어 있는 발명이라고 할 수 없으므로 산업상 이용가능성이 결여될 뿐만 아니라, 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 그 명세서가 기재되어 있지도 않다고 봄이 옳다(특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허4501).

17) 예를 들어 「특정물질을 포함하는 조성물을 이용하여 치아의 플라그를 제거하는 방법」의 경우, 치아의 플라그 제거는 잇몸 치료의 효과와 미용 효과가 수반되므로 의료행위에 해당하여 산업상 이용가능성이 인정되지 않는다(지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3112면). 그러나 「물질 A와 물질 B를 포함하는 미용 조성물을 피부 표면에 적용하는 것을 특징으로 하는 피부미백 개선을 위한 미용방법」의 경우 청구항이 비치료적 용도인 미용방법으로 한정되어 있고, 미용산업은 산업적으로 의료행위와 분리 가능하며, 피부미백 개선으로 인한 건강 증진 효과가 부수적인 것으로 인정되므로 산업상 이용 가능한 것으로 본다(지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3116면).

18) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3113면.

19) 특허법원 2004. 10. 15. 선고 2003허6524 참조.

20) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3117면.

자외선흡수 플라스틱 필름으로 둘러싸는 방법, ii) 지구와 달을 연결하는 다리 등과 같이 현실적으로 명백하게 실시할 수 없는 발명은 사상으로서 기술적 사상으로 구체화되지 못한 미완성 발명이므로, 산업상 이용가능성 위반으로 특허거절결정된다.

(4) 타법과의 관계

타법의 규제를 배제하는 것은 아니지만, 타법에 의하여 산업상 이용가능성이 제한받지는 아니한다. 예를 들어 유연물질의 검출에 따른 의약품의 허가규정 및 기준에 대한 적합성 여부는 특허성의 판단과는 무관하므로, 유연물질이 의약품 허가규정에서 정한 양보다 높게 검출되었다는 이유로 특허법이 정하는 산업상 이용가능성이 없는 발명이라고 볼 수는 없다.²¹⁾²²⁾

(5) 결과물과의 관계

산업상 이용가능성은 「발명」 자체를 기준으로 판단하며 발명을 이용하여 생산된 「결과물」의 활용 상태까지 고려하지는 아니한다. 예를 들어 전투용 소총에 관한 생산방법에 관한 발명도 비록 그 결과물이 전투용 소총으로서 일반산업에 이용할 수 없는 것이라 하더라도, 생산방법 그 자체는 제조업(군수산업)에 이용가능성이 있다고 할 수 있다. 따라서 전투용 소총에 관한 생산방법에 관한 발명이라 하더라도 이는 산업상 이용가능성이 있는 것으로 보아 특허를 인정할 수 있을 것이다.

IV. 흠결의 효과

산업상 이용가능성(法 29①본문)에 위반되는 경우 등록 전에는 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)에 해당하며, 등록 후에는 특허무효사유(法 133①)에 해당한다.²³⁾

21) 특허법원 2003. 6. 13. 선고 2002허420.

22) 한편 특허법은 이처럼 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 의한 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장해 주는 허가 등에 따른 존속기간연장제도를 두어 특허권자의 불이익을 구제할 수 있도록 하고 있다(法 89).

23) 산업상 이용가능성 위반이 취소신청이유에 포함되는지와 관련하여, 심판 실무(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 947면)는 “특허취소신청 제도의 도입 취지가 부실특허를 예방하고자 누구든지 하자가 있는 특허에 대하여 선행기술정보에 기초한 특허취소이유로 특허취소신청을 하면, 심판관이 해당 특허의 취소 여부를 신속하게 결정하는 것임으로 보아, 특허취소신청의 심리 대상은 선행기술 정보에 기초한 특허취소이유를 포함하고 있어야 하며, 산업상 이용가능성은 선행기술 정보에 기초한 특허취소이유가 아니므로 심리대상에서 제외된다”라고 하여 산업상 이용가능성 위반을 취소신청이유에서 제외하고 있으나, 명확한 법적인 근거를 두지 않고 이를 제외하는 것은 적절치 않다고 여겨진다.

제2절 신규성

제29조 【특허요건】

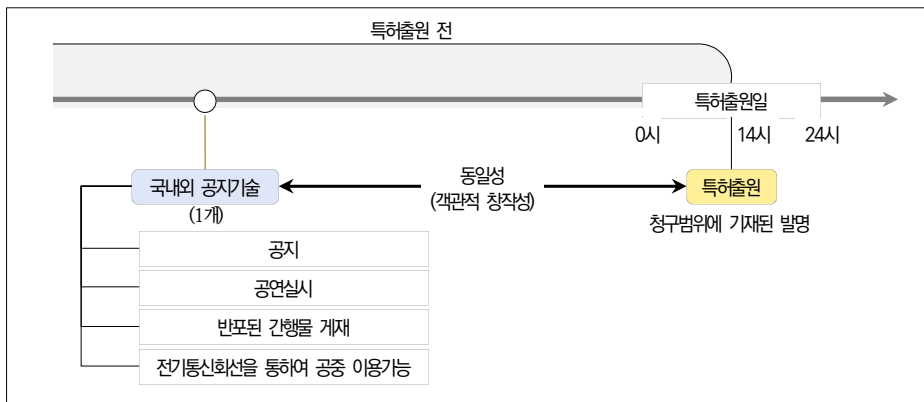
- ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
 1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명
- ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.
- ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
 2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것
- ④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것
 2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것
- ⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.
- ⑥ 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.
- ⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「발명의 신규성(novelty)」이란 발명의 내용이 사회일반에 아직 알려지지 아니한 발명으로서 「객관적 창작성」이 있는 것을 말한다. 특허법은 제29조제1항에서 “산업상 이용할 수 있는 발명으로서 i) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, ii) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명 중 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다”라고 하여 신규성 상실사유를 규정하고 있다.



【그림 2-1】 신규성 일반

2. 취 지

특허법은 i) 신규한 발명을 공개한 자에 대하여만 공개의 대가로서 특허권을 부여하고 ii) 공개된 기술을 이용하여 산업발전에 이바지하기 위해 신규성을 특허요건으로 규정하고 있다. 다만 신규성 상실사유를 소극적으로 규정하여 제한열거적인 신규성 상실사유에 해당하지 아니하면 신규성이 상실되지 아니한 것으로 봄으로써 객관성을 확보하고 있다.

II. 신규성 상실사유

1. 공지(公知)(法 29① | 전문)

1) 「공지」란 불특정인이 널리 알 수 있는 상태에 놓여있는 것을 의미한다.²⁴⁾ 여기서 「불특정인」이란 비밀유지의무가 없는 자를 말하며 다수의 일반 대중을 의미하는 것은 아니다. 1명에게라도 비밀유지상태가 해제되었으면 공지된 발명으로 취급되지만, 반면 다수인이 발명을 알 수 있는 상태라고 하더라도 그 다수인 모두에게 비밀유지의무가 있다면 공지된 발명이 아니다. 비밀유지의무가 있는 자로는 i) 법령상 인정되는 경우(변리사, 변호사 등), ii) 관습상 인정되는 경우(바이어, 운송업자 등)²⁵⁾, iii) 계약상 인정되는 경우(종업원, 용역계약자 등)²⁶⁾ 등이 있다. 예를 들어 학회지 등의 원고의 경우 원고가 접수되어도 그 원고의 공표시까지의 일반적으로 불특정인이 볼 수 있는 상태에 놓여진 것이 아니므로 공지된 발명으로 인정할 수 없다.

2) 한편 알 수 있는 「상태」에 놓이면 되고, 불특정인이 발명 내용을 알고 있을 것, 즉 「인식(認識)」을 요구하지 아니한다.²⁷⁾ 다만 출원인이 아닌 제3자가 발명을 인식하고 있다고 해도 불특정인이 알 수 있는 상태에 놓이지 않았다면 공지라고 할 수 없다. 예를 들어 동일한 A 발명을 甲과 乙이 발명하고 甲이 먼저 특허출원을 한 경우에 乙이 먼저 A 발명을 하였다고 비밀 상태로 유지하고 있다면, 甲의 출원은 신규성을 상실하지 아니한다.²⁸⁾

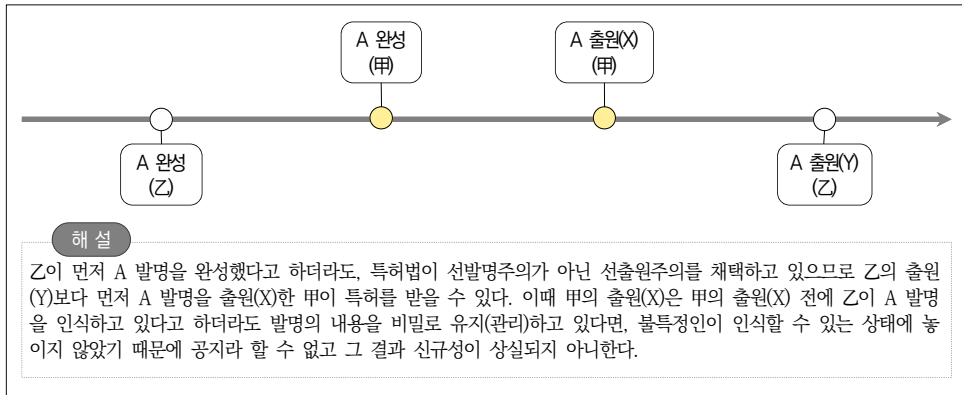
24) 대법원 1963. 2. 28. 선고 62후14; 1983. 2. 8. 선고 81후64.

25) 특허법원 2016. 9. 22. 선고 2016허2072, 대법원 1997. 11. 14. 선고 96후1804. 예를 들어 샘플용 및 시험용 제품을 특정인에게 공급한 일이 있다 하여 바로 이 사건 등록고안이 그 출원 전에 불특정다수인에게 공지된 것이라고 단정할 수 없다(대법원 1997. 11. 14. 선고 96후1804).

26) 특허법원 2010. 6. 11. 선고 2009허9693.

27) 디자인은 등록이 되면 지식재산처 직원의 디자인에 대한 비밀유지의무가 소멸되므로 비록 디자인등록공보에 게재되기 전이라도 디자인의 설정등록일을 기준으로 불특정인이 등록디자인의 내용을 객관적으로 인식할 수 있는 상태에 있다고 보아야 할 것이므로 공지되었다고 할 수 있다(특허법원 1999. 6. 3. 선고 99허1027). 한편 특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019허4833 판결에서는 “특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때(등록료 납부서가 접수되거나, 지식재산처장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우 등록료의 수납정보가 지식재산처 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 때) 지식재산처장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권 설정등록이 된 것으로 보아 특허가 공지된 것으로 볼 수는 없는바, 선행발명 1은 특허등록원부가 생성된 시점에서야 특허권 설정등록이 이루어진 것이고, 달리 등록료 수납정보가 지식재산처에 도달한 시점부터 선행발명 1에 대한 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 시점까지 선행발명 1의 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람·복사가 이루어졌다고 볼 수도 없으므로, 선행발명 1은 등록료 수납정보가 지식재산처에 도달한 시점이 아니라 출원발명의 출원일 이후로서 선행발명 1에 대한 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 시점에 공지되었다고 보아야 한다”라고 판시하여 특허료 납부시점이 아니라 등록원부가 생성된 시점을 공지시점으로 인정하였다.

28) 발명의 출원시에 이미 그 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 제3자가 있는 경우에 그 제3자와 그 발명의 특허권에 대한 관계를 구 특허법 제103조의 소정의 선사용권자의 통상실시권에 의하여 규율하는 점을 고려하면, 그러한 제3자가 존재하더라도 그 발명의 출원 전에 그 제3자가 자기 발명의 내용을 비밀로 유지한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 발명은 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시된 것이라고 볼 수 없다. 한편 구 특허법 제29조제1항제1호에서의 공지 또는 공연히 실시된 발명이라는 점은 특허 무효를 주장하는 자가 주장·증명하여야 하나, 비밀유지의무의 존재는 공지 또는 공연실시를 부인하는 특허권자가 주장·증명하여야 한다(특허법원 2019. 7. 12. 선고 2018허1349).



【그림 2-2】 상태와 인식의 구별

2. 공연(公然)실시(法 29① I 후문)

1) 「공연 실시」란 실시에 의하여 발명이 불특정인에게 공연히 알려진 상태 또는 알려질 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다. 여기서 「공연」이란 발명의 주요부에 대하여 비밀상태가 해제된 것을 의미한다. 단 1회의 실시라도 공연실시에 해당하나 발명의 주요부 중 일부분에 비밀유지상태가 확보되면서 실시할 때는 공연실시에 해당되지 않을 수 있다. 예를 들어 자동차의 내부에 발명이 있는 신제품을 공중 앞에서 사용(운전)한 후 그 발명자가 특허출원하더라도 그자는 타인에 대하여 전면적으로 비밀상태를 해제한 것이라 볼 수 없으므로 신규성이 상실되었다고 볼 수는 없다.²⁹⁾³⁰⁾ 또한 화학물질이나 의약품 등의 경우에는 통상의 기술자가 특허발명의 출원일 또는 우선권 주장일 전에 사용할 수 있었던 분석방법을 통해 과도한 노력을 기울이지 않고 그 조성이나 성분을 알 수 없었다면 비록 공연히 판매되었더라도 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태였다고 볼 수 없다. 이러한 증명은 판매된 제품의 모든 성분이나 조성을 정확히 재현하는 정도에 이를 필요는 없으나 적어도 그로부터 출원발명과 대비되는 구성요소를 확인할 수 있을 정도여야 한다.³¹⁾

2) 「실시」란 제2조제3호의 실시를 말하는데 공연히 실시되었다고 할 때는 실시의 유형 중 사용이 큰 비중을 차지한다.

29) 불특정인에게 공장을 견학시킨 경우, 그 제조상황을 보면 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 기술내용을 알 수 있는 상태인 때에는 「공연히 실시」된 것으로 본다. 또한 그 제조상황을 보았을 경우에 제조공정의 일부에 대하여는 장치의 외부를 보아도 그 제조공정의 내용을 알 수 없는 것으로서, 그 내용을 알지 못하면 그 기술의 전체를 알 수 없는 경우에도 견학자가 그 장치의 내부를 볼 수 있거나 그 내부에 대하여 공장의 종업원에게 설명을 들을 수 있는 상황(공장측에서 설명을 거부하지 않음)으로서 그 내용을 알 수 있을 때에는 그 기술은 공연히 실시된 것으로 본다(특허법원 2000. 9. 21. 선고 99허6596).

30) 공연히 실시된 발명이란 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명의 내용을 쉽게 알 수 있는 상태로 실시하는 것. 즉 그 기술사상을 보충 또는 부가하여 다시 발전시킴이 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있는 것임을 요한다(대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688).

31) 특허법원 2018. 1. 11. 선고 2017나1247.

3. 반포된 간행물에 게재(法 29①II 전문)

(1) 반 포

① 의 의

「반포」란 불특정인이 열람할 수 있는 상태에 놓여져 있는 것을 의미한다.³²⁾ 따라서 i) 반포할 목적으로 인쇄·제본되었으나 아직 발행자의 손안에 있어서 반포에 이르지 못한 것이나, ii) 반포를 위해 발송 중인 간행물, iii) 도서관 사서과에는 간행물이 도착하였으나 열람실에 비치되지 아니한 경우 등은 반포되었다고 할 수 없다. 그러나 도서관의 열람실에 비치되었으면 아무도 이를 읽지 아니하는 경우라 하더라도 반포된 것으로 본다.

② 심사 실무³³⁾상 간행물 반포시기의 결정³⁴⁾

1) 간행물에 발행시기가 기재되어 있는 경우로서 i) 발행의 연도만이 기재되어 있으면 그 연도의 마지막 날에 반포된 것으로 추정하고, ii) 발행의 연·월이 기재되어 있으면 그 연·월의 마지막 날에 반포된 것으로 추정하며, iii) 발행의 연·월·일까지 기재되어 있으면 그 연·월·일에 각각 반포된 것으로 추정한다.

2) 간행물의 발행시기가 기재되어 있지 아니한 경우에는 i) 외국간행물로서 국내에 입수된 시기가 분명한 때에는 그 입수된 시기로부터 발행국에서 국내에 입수되는데 소요되는 통상의 기간을 소급한 시기에 반포된 것으로 추정하고, ii) 해당 간행물에 대하여 서평·발췌 카탈로그 등을 게재한 간행물이 있으면 그 발행시기로부터 해당 간행물의 반포시기를 추정하며, iii) 해당 간행물에 관하여 중판 또는 재판 등이 있고, 여기에 초판의 발행시기가 기재되어 있을 때는 그 초판의 발행일을 반포시기로 추정한다. 다만 재판의 경우에는 재판과 초판의 인용하는 부분의 내용이 상호 일치할 것을 전제로 한다. iv) 그 밖에 적당한 근거가 있으면 그것으로부터 반포시기를 추정 또는 인정한다. 다만 이와 같은 추정은 반증에 의하면 얼마든지 번복될 수 있다.

③ 판례에 의한 반포시기의 결정

1) 카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장(死藏)하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그의 반포, 배부되었음을 부인할 수는 없다.³⁵⁾ 즉 카탈로그란 기업이 자사(自社)의 선전 또는 자사제품(自社製品)의 소개·선전을 위하여 제작하는 것이므로 그 카탈로그가 반포되지 않았다는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 제작되었으면 반포된 것으로 추정할 수 있다.³⁶⁾

32) 대법원 1968. 8. 30. 선고 68후10; 1970. 12. 29. 선고 70후64; 1971. 11. 23. 선고 71후18.

33) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3204면.

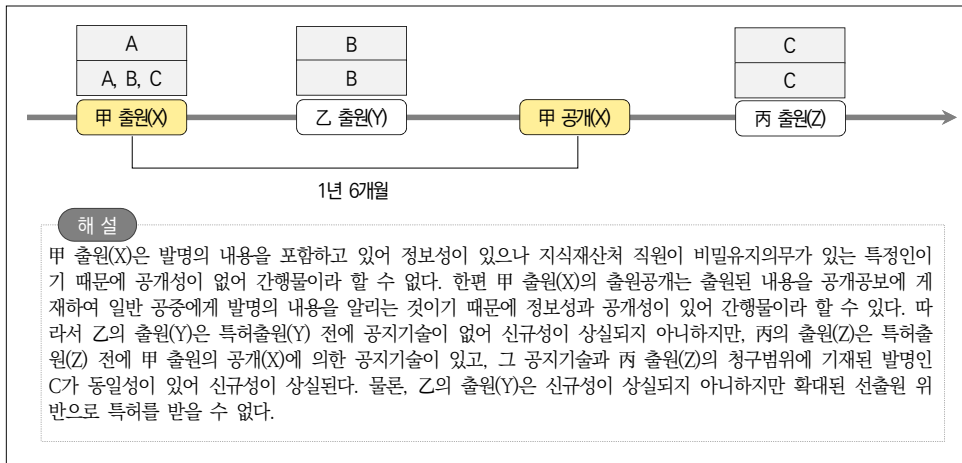
34) 심사 실무를 요약해 보면, 될 수 있으면 늦게 반포된 것으로 하여 신규성이 상실되지 아니한 것으로 추정 또는 인정하고 있다.

35) 대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270.

2) 학위논문의 반포시점은 그 내용이 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한 최종 심사를 거쳐서 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 불특정인에게 배포된 시점을 반포시기로 인정한다.³⁷⁾ 여기서 「입고」되었다는 것은 도서관에 등록되어 서가에 진열된 경우를 의미하며, 반포시점 이전인 도서관에서의 등록시 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 그 기재 내용이 공지로 되는 것이 아니라고 할 것이다.³⁸⁾

(2) 간행물

1) 「간행물」이란 인쇄나 그 밖의 기계적·화학적 방법에 의하여 공개할 목적으로 복제된 정보성과 공개성이 있는 문서·도면 등의 정보전달매체를 의미한다.³⁹⁾ 따라서 공개를 목적으로 하지 아니한 회사 내의 사문서나 비밀문서 등은 간행물이 아니나, 공개를 목적으로 하는 한정 출판물, 비매품, 카탈로그, 마이크로필름, CD-ROM 등은 간행물이다. 한편 출원 명세서를 내포한 공개특허공보나 등록특허공보는 간행물이지만 출원할 때 출원서에 첨부된 명세서 원본 자체는 공개성이 없으므로 간행물이 아니다.



【그림 2-3】 특허출원 및 출원공개의 공지기술 지위 인정 여부

36) 대법원 1985. 12. 24. 선고 85후47.

37) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689; 1996. 6. 14. 선고 95후19 등.

38) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689.

39) 대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377.

2) 판례⁴⁰⁾는 고문서에 해당 발명과 동일내용의 기술이 공개되어 있음이 밝혀지면 신규성이 부정된다고 하여 고문서도 간행물이라는 것을 판시하고 있다.

(3) 게 재

1) 「게재」는 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도이어야 한다. 예를 들어 고안이 간행물에 게재되어 있다고 하려면 적어도 고안이 어떤 구성을 가지고 있는가가 제시되어 있어야 할 것이고, 따라서 내부에 특징이 있는 고안에 대하여 그 외형 사진만이 기재되어 있는 경우에는 그 고안은 게재된 것이 아니라고 할 것이다.⁴¹⁾ 이는 기술적 기여가 없는 공지기술에 의하여 기술적 기여를 하고 있는 당해 발명에 대한 특허를 저지하는 것은 바람직하지 않기 때문이다.

2) 언어의 종류는 불문하기 때문에 일반인들이 알기 어려운 언어가 사용되었다고 하더라도 그 발명의 내용 자체가 명확하기만 하면 게재된 발명이라고 해석하는 것이 타당하다.

4. 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용가능(法 29①Ⅱ 후문)⁴²⁾

(1) 전기통신회선

「전기통신회선(telecommunication line)」이란 인터넷은 물론 전기통신회선을 통한 공중게시판, 이메일 그룹 등이 포함되며, 앞으로 기술의 발달에 따라 새로이 나타날 수 있는 전기·자극적인 통신방법도 포함된다. 즉 전기통신회선은 반드시 물리적 회선(line)을 필요로 하는 것은 아니며 유선은 물론 무선, 광선 및 기타의 전기·자극적 방식에 의하여 부호·문헌·음향 또는 영상을 송신하거나 수신할 수 있는 것이면 모두 포함된다(電氣通信基本法 2 I 참조).

(2) 공중의 이용가능성

전기통신회선을 통하여 공개되었다 하더라도 공개된 발명에의 접근이 일반인에게 허용되지 않고 특정인에게만 접근이 허용된다면 그 발명은 공중, 즉 불특정인이 이용가능하게 된 발명이라고 볼 수 없다. 예를 들어 i) 일반적인 검색엔진에 의하여 접근할 수 없는 경우, ii) 암호를 부여하여 불특정 다수인의 접근이 불가능한 경우, iii) 접근을 위하여 과다한 요금을

40) 고려시대의 고려도경에도 인삼을 술에 삶아서 익히면, 장기보존할 수 있다고 기록되어 있음은 피청구인이 자인하고 있는바, 이러한 방법은 공지의 사실로부터 쉽게 착상하여 실시할 수 있다 할 것이고, 고도의 기술적 창작성이 없고, 이미 공지 또는 공연실시된 원리를 다소 응용한 데 지나지 아니한다고 할 것이어서 피청구인이 특허받은 인삼 방부방법은 신규의 발명이라고 보기 어려우며, 따라서 특허법에 정한 특허의 대상이 된다할 수 없다(대법원 1969. 5. 13. 선고 67후13).

41) 특허법원 1998. 7. 9. 선고 98허3767.

42) 2013. 3. 22. 시행된 현행법(법률 제11654호, 2013. 3. 22. 개정)은 특허를 받을 수 없는 요건을 「대통령령으로 정하는 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명」에서 「대통령령으로 정하는」 부분을 삭제하여 모든 「전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명」으로 변경하였다. 이는 컴퓨터 등이 보편화됨에 따라 대다수의 기술공개가 네이버·다음 등의 인터넷 포털과 같이 대통령령으로 정하지 아니한 전기통신회선을 통해서 이루어지고 있는 현실과 심사 실무에서 대통령령으로 정하지 아니한 전기통신회선을 통해서 공중이 이용할 수 있는 발명을 제29조제1항제1호에 따라 공지된 발명이라는 이유로 특허거절하고 있는 실정을 고려한 것이다.

요구하는 경우 등과 같이 공중의 이용가능성이 없는 경우를 사안별로 검토하여야 하며, 공중이 이용가능한 경우에만 신규성을 부정할 수 있다.⁴³⁾⁴⁴⁾

III. 신규성의 판단

1. 주체적 기준

심사단계에서는 심사관이, 심판단계에서는 심판관 합의체가, 법원에서는 법관이 심사한다.

2. 객체적 기준

(1) 원 칙

청구범위의 청구항에 기재된 발명을 제29조제1항 각호의 신규성 상실사유인 공지기술과 비교한다. 청구항에 기재된 발명을 특정할 때 청구항에 기재된 용어의 의미·내용이 불명확한 경우에는 i) 발명의 설명 또는 도면을 참작하여 발명을 인정하나, ii) 발명의 설명 또는 도면을 참작하여 해석하여도 청구항에 기재된 용어의 의미·내용이 불명확한 경우에는 발명을 인정하지 아니한다. 이러한 경우에는 신규성에 대하여 심사를 하지 않고 제42조제4항 위반으로 거절이 유를 통지하게 된다.⁴⁵⁾ 다만 청구항에 기재된 발명이 발명의 설명이나 도면의 기재에 의하여 제한 해석되어서는 아니 된다.⁴⁶⁾

43) 전기통신회선을 통한 공개의 경우 먼저 해당 전기통신회선의 인지도, 일반 공중의 이용빈도, 운영주체의 신뢰도, 운영기간 등을 고려하여 그 공개내용공개시점의 신뢰성을 검토하고, 검토 결과 공개사실의 신뢰성이 있는 것으로 판단되면 공지기술로 인용할 수 있다. 실제 게재일을 확인하기 위해서는, 해당 전기통신회선의 정보 게재에 관한 권한이나 책임이 있는 자에게 게재사실을 문의하거나 미국의 비영리단체인 인터넷 아카이브가 운영하는 www.archive.org에 저장된 내용 및 게재일 자료를 활용할 수 있다. 전기통신회선에서의 공개시점은 전기통신회선에 해당 발명을 게재한 시점이다. 따라서 이미 반포된 간행물을 전기통신회선을 통하여 공개한 경우라도 전기통신회선에 공개된 발명을 인용하는 경우에는 발명이 전기통신회선에 공개된 시점을 공개일로 하여야 한다. 참고로, 네이버, 다음 블로그 등은 인터넷 아카이브에서 확인이 되지 않을 수 있으므로, 주의를 요한다(특허심판원, 「심판판람」, 제14판, 2024, 311-312면).

44) 유튜브에 일단 동영상상을 업로드 한 후 영상 일부를 삭제하거나 조명, 색상을 수정하는 등의 편집을 할 수는 있으나, 동영상 자체를 교체하는 경우 새로운 URL이 부여되므로 기존 URL 및 게시일의 변경 없이 영상을 교체할 수 없는 사실을 인정할 수 있다. 한편 유튜브에 영상을 업로드 할 때 일반인들이 영상을 열람하지 못하도록 '비공개'로 설정할 수 있는 사실이 인정되기는 하나, 다음과 같은 이유로 선행발명 모두 최초 업로드 당시부터 일반인들이 자유롭게 열람할 수 있도록 '공개' 상태로 설정되어 있었다고 봄이 타당하다(특허법원 2018. 2. 1. 선고 2017허1519).

45) 대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499.

46) 청구항에 '크림'이 기재되어 있고 발명의 설명에는 실시예로서 '팔소보다 수분함량이 적어 보전성이 우수한 크림'이 기재되어 있는 경우, 크림이라는 용어는 통상적으로 수분 함량과 관계없이 우유에서 분리된 지방분을 의미하는 것으로서 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게 명확하게 이해될 수 있는 것이므로 발명의 설명의 실시예로 제한 해석해서는 아니 된다(대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496).

(2) 공지기술과 관련하여

① 공지기술의 수

신규성 판단시에는 하나의 공지기술(인용대상)과 대비하여야 하며 복수의 공지기술을 조합하여 청구항에 기재된 발명과 대비하여서는 아니 된다.⁴⁷⁾ 이를 「Single Source Anticipation Rule」이라고 하는데, 출원기술의 신규성을 상실시키기 위해서는 하나의 공지기술에 출원기술의 모든 요소가 명시적으로 또는 본래적으로 포함되어 있을 것을 필요로 한다는 의미이다. 복수의 공지기술의 조합에 의하여 특허성을 판단하는 것은 후술하는 진보성의 문제이고 신규성의 문제는 아니다.⁴⁸⁾ 또한 하나의 공지기술에 2이상의 실시예가 개시되었으면 2 이상의 실시예를 인용대상으로 특정하고 상호 결합하여 청구항에 기재된 발명의 신규성을 판단해서도 아니 된다.⁴⁹⁾

② 미완성발명이 공지기술인지 여부

판례⁵⁰⁾는 “신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비 발명이나 고안은 반드시 그 기술적 구성요소 전체가 명확하게 표현된 것뿐만 아니라, 미완성 발명(고안) 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라 하더라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 경험칙에 의하여 극히 쉽게 기술내용의 파악이 가능하다면 그 대상이 될 수 있다”라고 하여 미완성발명도 공지기술이라는 것을 판시하고 있다.

3. 시기적 기준

(1) 원 칙

1) 특허출원 시를 기준으로 판단한다. 즉 특허출원 시 전에 공지기술이 존재하여야 한다. 법문상 「특허출원 전」의 해석결과이다. 「특허출원일 전」이란 출원일과 공개일이 동일(同日)인 경우에는 적용되지 아니한다는 의미인 데 반해 「특허출원 전」이란 출원일과 공개일이 동일(同日)인 경우에도 적용된다는 의미이다. 출원일과 공개일이 동일인 경우에 적용되기 위해서는 시·분·초까지 고려⁵¹⁾하여야 하는데 이를 「시각주의」라 한다. 예를 들어 발명이 명확히 기재된

47) 특허법원 2005. 5. 20. 선고 2004허5160.

48) 다만 공지기술이 별개의 간행물 등을 인용하고 있는 경우(예: 어떤 특징에 관하여 더욱 상세한 정보를 제공하는 문헌)에는 별개의 간행물은 공지기술에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다. 또한 공지기술에 사용된 특별한 용어를 해석할 목적으로 사전 또는 참고문헌을 인용하는 경우에도 사전 또는 참고문헌은 공지기술에 포함되는 것으로 취급하여 신규성 판단에 인용할 수 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 3225-3226면). 다만 사전 또는 참고문헌이 선행기술의 내용을 설명하기 위한 용도가 아닌 확장하기 위한 용도로는 사용되어서는 안 된다(In re Baxter Travenol Labs., 952 F.2d 388, 390 (Fed. Cir. 1991)).

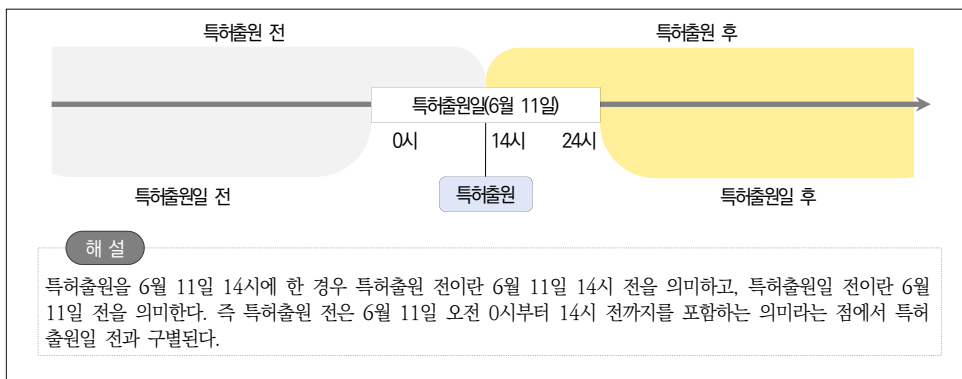
49) 특허법원 2005. 5. 20. 선고 2004허5160. 다만 그 기술분야의 출원 시의 기술상식으로 고려할 때 둘 이상의 실시예로부터 하나의 인용대상이 자명하게 도출되는 경우에는 그러하지 아니하다.

50) 대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270; 1997. 8. 26. 선고 96후1514.

51) 외국에서 공지된 경우에는 한국시간으로 환산한 시간을 고려한다.

간행물이 오전에 반포되고, 같은 날 오후에 출원이 이루어졌으면 그 출원발명은 신규성을 상실한 발명이다. 다만 특허출원 시점과 간행물 반포시점에 대한 선후 여부의 판단이 모호한 경우에 실무⁵²⁾는 신규성이 있는 것으로 취급한다.

2) 한편 특허출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이며, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있고, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 한다.⁵³⁾ 다만 「특허출원 전」의 의미는 발명의 공지 또는 공연 실시된 시점이 특허출원 전이라는 의미이지 그 공지 또는 공연 실시된 사실을 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니므로, 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 어떤 발명 또는 기술이 특허출원 전에 공지 또는 공연 실시된 것인지를 인정할 수 있다.⁵⁴⁾



【그림 2-4】 특허출원일 전과 특허출원 전의 구별

(2) 예 외

i) 무권리자에 대한 정당한 권리자 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ii) 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, iii) 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, iv) 국제특허출원의 경우 우선일의 출원 시를 기준으로 판단한다.

52) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3222면.

53) 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37.

54) 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660.

4. 지역적 기준

제29조제1항 각호의 공지기술인지는 「국내 또는 국외」를 기준으로 판단한다.⁵⁵⁾ 즉 국제주의를 채택하고 있는데, 이는 교통·통신의 발달과 무역의 활발화 및 국가 경쟁력 강화 등을 고려한 것이다. 제29조제1항제1호의 공지·공연실시의 경우 기존에는 증명 및 판단의 어려움으로 인해 국내를 기준으로 판단하였다. 그러나 인터넷을 비롯한 정보통신의 발달로 외국에서 공지·공연실시된 발명을 쉽게 접할 수 있으며, 외국에서 자유롭게 실시할 수 있는 발명을 국내에서 특허로 보호해 주는 것은 제3자에게 불측의 손해를 발생시키고 나아가 국내산업의 기술경쟁력을 저해하는 요인으로 작용할 수 있어, 2006. 10. 1. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정)에서 공지·공연실시의 판단 기준에 국내뿐만 아니라 국외를 포함시켰다.

5. 판단방법

(1) 원 칙

청구항에 기재된 발명을 공지기술과 비교하여 동일성이 있는지 판단한다. 즉 청구항의 구성과 공지기술을 대비하여 구성요소가 동일한가에 의하여 판단하고 발명의 효과도 참작하되, 구성요소에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 서로 동일성이 있다고 하여야 한다.⁵⁶⁾

(2) 발명의 범위가 다른 경우(상·하위 개념 발명)⁵⁷⁾

① 공지기술이 하위개념이고 청구항에 기재된 발명이 상위개념인 경우

공지기술이 하위개념으로 표현되어 있고, 청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되었으면 동일성이 있어 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다. 예를 들어 청구항에 기재되어 있는 발명이 금속(상위개념)으로 기재되어 있고 공지기술이 구리(Cu; 하위개념)로 기재되어 있으면, 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다.

② 공지기술이 상위개념이고 청구항에 기재된 발명이 하위개념인 경우

공지기술이 상위개념으로 표현되어 있고 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되었으면 동일성이 없어 통상적으로 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있다. 예를 들어 청구항에 리벳트에 관한 사항이 기재되어 있고 공지기술에는 체결구로만 기재되어 있으면 공지기술인 체결구에 의해서 청구항에 기재된 리벳트에 관한 발명의 신규성이 상실되지 아니한다. 다만 출

55) 국외에서 반포된 간행물은 반드시 국내에 입수되어 반포되어야 하는 것은 아니므로, 인용고안이 기재된 국외 간행물이 어떠한 경로를 통하여 우리나라에 입수되었는지 및 그 배부범위 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 이를 증거로 채택하여 인용고안으로 판단할 수 있다(대법원 1999. 10. 22. 선고 97후3203).

56) 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 등.

57) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 3225면.

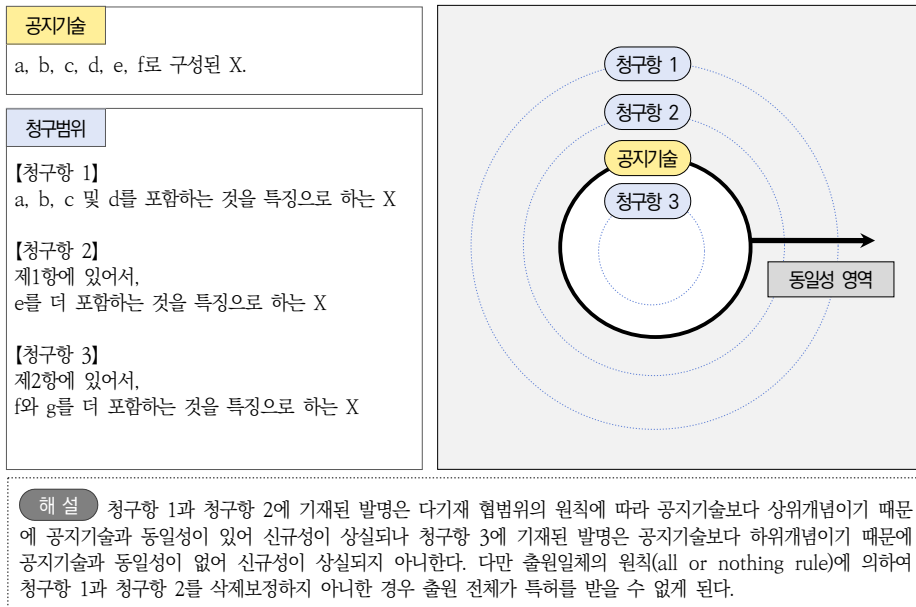
원당시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과 상위개념으로 표현된 공지기술로부터 하위개념으로 표현된 발명이 도출될 수 있으면⁵⁸⁾ 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 것으로 인정할 수 있다.

(3) 발명의 범주가 다른 경우(물건발명, 제법발명 및 용도발명의 관계)

물건발명의 신규성이 있으면 제법발명 또는 용도발명은 당연히 신규성이 있다. 반면 물건발명의 신규성이 없으면 제법발명 또는 용도발명은 개별적으로 신규성 여부를 판단하여야 한다. 하나의 물건을 만드는 제법발명이나 그 물건을 이용하는 용도발명은 수없이 많이 있기 때문이다. 즉 물건발명과 제법발명(용도발명)이 1 대 多(1 : 多)의 관계에 있기 때문이다.

(4) 독립항과 종속항의 관계

독립항의 신규성이 있으면 종속항은 당연히 신규성이 있다. 독립항의 신규성이 있다는 것은 독립항이 공지기술보다 하위개념이라는 것이고 독립항은 종속항보다 상위개념이므로 종속항은 항상 공지기술보다 하위개념이 되어 동일성이 없기 때문이다. 반대로 독립항의 신규성이 없으면 종속항은 개별적으로 신규성 여부를 판단하여야 한다. 독립항이 공지기술보다 상위개념이라고 하더라도 종속항은 공지기술보다 하위개념이 되어 동일성이 없을 수도 있기 때문이다.



【그림 2-5】 독립항과 종속항의 관계

58) 단순히 개념상으로 하위개념이 상위개념에 포함되거나 상위개념의 용어로부터 하위개념의 요소를 열거할 수 있다는 사실만으로는 하위개념으로 표현된 발명이 도출될 수 있다고 할 수 없다.

IV. 흠결의 효과

1) 등록 전에는 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)이며, 등록 후에는 특허취소사유(法 132의2①), 특허무효사유(法 133①)이다. 다만 특허취소사유(法 132의2①)에서 제29조제1항제1호의 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명에 해당되어 신규성에 위반된 경우는 제외되고, 등록특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청(法 132의2)을 할 수 없다.

2) 한편 판례⁵⁹⁾는 특허발명이 공지기술과 동일하여 신규성이 없음에도 불구하고 착오로 등록되었으면 특허취소신청에 의한 취소결정확정이나 특허무효심판에 의한 무효심결확정에 의하여 특허권이 소멸하기 전이라도 특허권의 보호범위를 부정하고 있다. 이는 새로운 발명을 공개시키지 아니한 자에게는 독점·배타적인 효력을 인정하여 특허권자를 보호할 필요가 없기 때문이다.

V. 신규성 상실의 예외

공지 등이 되어 신규성을 상실하더라도 일정 기간에 특허법에서 정한 절차를 밟아 출원하면 공지 등이 되지 아니한 것으로 볼 수 있다(法 30).

제3절 진보성

제29조 【특허요건】

- ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
 1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명
- ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.
- ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
 2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고된 특허출원일 것

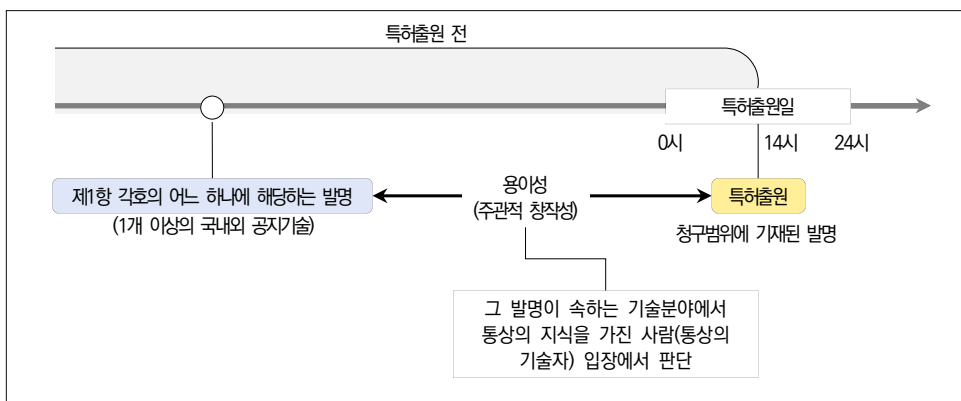
59) 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 등.

- ④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것
 2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것
- ⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.
- ⑥ 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.
- ⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.
- [전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「발명의 진보성(inventive step)」이란 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제29조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 없는 것으로서 「주관적 창작성」을 말한다.



【그림 2-6】 진보성 일반

2. 취 지

진보성이 없는 발명에 대하여 특허를 허여하는 것은 i) 특허권의 난립으로 특허분쟁을 유발할 우려가 있을 뿐만 아니라 ii) 창의적인 발명보다는 남의 발명을 모방하는 경향이 짙어 발명의 질을 저하시킴으로써 오히려 산업발전을 저해하기 때문에, 공지기술보다 비약적이고 누진적인 발명에 대해서만 특허를 허여하기 위해 특허요건으로서 진보성을 규정하고 있다.

II. 판단기준

1. 주체적 기준

(1) 원 칙

심사단계에서는 심사관이, 심판단계에서는 심판관 합의체가, 법원에서는 법관이 그 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(통상의 기술자)의 입장에서 판단한다.

(2) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(통상의 기술자)

「그 발명이 속하는 기술분야」는 원칙적으로 그 발명이 이용되는 기술분야를 의미하나, 이에 국한할 것이 아니라 그 출원발명의 구성이 가지고 있는 기능으로 보아서 객관적으로 파악되는 관련 분야까지도 포함한 의미로 해석하여야 한다.⁶⁰⁾ 「통상의 지식을 가진 사람」이란 출원 시에 있어서 그 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, 연구개발(실험, 분석, 제조 등을 포함한다)을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있으며, 출원 시의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자로 가정한 특허법상 상상의 인물을 말한다.⁶¹⁾ 즉 「통상의 기술자(a person having ordinary skill in the art)」는 심사관이 진보성 판단에 객관성을 부여하기 위해 가정한 상상의 인물로서 자연인이다.⁶²⁾

60) '그 발명이 속하는 기술분야'란 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말하고(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059), 그 범위를 정할 때에는 발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과 등을 종합하여 객관적으로 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2002후987).

61) 특허법원 2010. 3. 19. 선고 2009허1965.

62) 미국 Emtl. Ltd. v. Union Oil Co. 사건에서 CAFC는 통상의 기술자 기술수준을 심사관이나 심판관이 임의로 결정할 수 없음을 분명히 하는 한편 통상의 기술자 기술수준을 평가하는 기준으로 ① 발명자의 교육수준(educational level of the inventor), ② 해당 기술분야에서 마주치게 되는 기술상의 문제점들(type of problems encountered in the art), ③ 그와 같은 문제점들을 해결하기 위한 선행기술의 해결책(prior art solutions to those problems), ④ 해당 기술분야에서 기술혁신이 이루어지고 있는 속도(rapidity with which innovation are made), ⑤ 해당 기술분야에서 기술의 복잡성(sophistication of the technology), ⑥ 해당 기술분야에서 활동하는 기술자가 가지는 학력의 정도(educational level active workers in the field)를 고려하여야 한다고 판시하였다(조영선, 「특허법 주해 I」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 348-352면).

2. 객체적 기준

(1) 원 칙

청구범위의 청구항에 기재된 발명을 제29조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 발명과 대비하여 판단한다.

(2) 제29조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 발명(공지기술)과 관련하여

① 인용대상이 발명으로 제한되는지 여부

진보성 판단의 인용대상이 「발명」이어야 하는지 문제이다. 제29조제1항 각호에서는 i) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, ii) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명에 관해 규정해 놓았으나 이외에도 해당 특허출원 전에 반포된 실용신안공보에 기재되어 있는 고안이나 디자인등록된 창작 등도 인용대상이 되며, 해당 출원발명의 특허출원 전에 존재하는 모든 관련기술의 자료(예를 들어 학술지, 논문, 제품기술 설명서 등)들도 포함된다. 즉 진보성 판단의 인용대상은 공지발명보다 넓은 개념인 공지기술로 해석된다.⁶³⁾

② 둘 이상의 인용대상(공지기술)을 상호 조합 가능

진보성 판단시에는 둘 이상의 인용대상을 상호 조합하여 판단할 수 있다는 점에서 신규성과 차이점이 있다. 다만 인용대상의 수가 많을수록 사후적 고찰 또는 합당한 거절이유가 결여되어 있는 경우에 해당할 가능성이 커진다는 점에도 유의하여야 한다. 두 개 이상의 다른 인용대상을 결합하기가 쉬운지를 결정할 때 i) 통상의 기술자가 결합할 가능성이 있는지 여부, ii) 인용대상의 출처가 동일하거나 인접 기술분야인지 여부, iii) 결합을 위해 서로 관련지를 만한 합리적인 근거가 있는지 여부를 고려하여야 한다.⁶⁴⁾

③ 다른 기술분야의 공지기술을 인용대상으로 채택할 수 있는지 여부

신규성의 경우에는 인용대상의 범위가 매우 넓어서 모든 기술분야를 대상으로 하는 대신에 발명의 동일성이라는 엄격한 판단방법에 의한다. 그러나 진보성의 경우에는 둘 이상의 인용대상으로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우도 포함되므로 판단이 넓게 이루어지는 대신에 기술분야의 범위는 좁게 해석하게 되며, 일반적으로는 국제특허분류(IPC)의 해당 분류의 기술범위를 기준으로 하고 있다. 그러나 이는 절대적이라 할 수는 없으며,⁶⁵⁾ 기술분야의 관련성, 과제해

63) 실용신안의 목적은 실용적 가치에 있고 디자인은 심미적 가치를 목적으로 하는 것이기는 하나, 그것은 모두 물건의 형상, 모양에 구현되는 것이므로 심미적 가치를 목적으로 디자인의 대상이 되는 동시에 실용신안의 대상이 될 수도 있는 것이므로, 선출원된 인용디자인의 형상 및 모양이 본원실용신안과 동일 또는 유사한 것인 이상 그 출원 이전에 동 분야에서 공지, 공용된 것인지 여부 즉 신규성 유무의 판단자료로 삼았다 하여 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 1985. 11. 12. 선고 84후9).

64) 지식재산저, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3327면.

65) 실용신안에서의 고안은 기술적 창작이라는 무형의 소산을 대상으로 하고 있기 때문에 그 권리범위가 대상물품과 동일 또는 유사한 것에 한정되지도 아니하는 것이어서 본진 고안과 인용고안이 국제특허분류표상

결의 동일성, 기능의 동일성 등 인용의 타당성을 검토하여 상이한 기술분야의 공지기술을 인용할 수도 있다. 이와 관련하여 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결도 “공지기술의 기술적 구성이 i) 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고(범용성) ii) 해당 특허발명의 산업분야에서 통상의 기술을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성(채택용이성)이라면, 이를 해당 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술(인용대상)로 삼을 수 있다”라고 하여 다른 기술분야의 공지기술을 선행기술로 하기 위한 조건으로서, 범용성과 채택용이성을 제시하고 있다.

3. 시기적 기준

(1) 원 칙

특허출원 시를 기준으로 판단한다. 즉 특허출원 시 전에 공지기술이 존재하여야 한다. 법문상 「특허출원 전」의 해석결과이다. 출원일과 공개일이 동일인 경우에 적용되기 위해서는 시·분·초까지 고려하여야 한다. 구체적인 내용은 신규성 판단의 시기적 기준과 동일하다.

(2) 예 외

i) 무권리자에 대한 정당한 권리자 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ii) 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, iii) 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, iv) 국제특허출원의 경우 우선일의 출원 시를 기준으로 판단한다.

4. 지역적 기준

공지기술인지는 제29조제1항 각호에 의하여 판단하여야 하므로 국제주의이다. 예를 들어 일본의 특허공개공보도 진보성 판단의 인용대상이 될 수 있다. 한편, 통상의 기술자의 수준의 결정과 관련하여 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결에서는 “구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제29조 제2항, 제1항 제2호의 규정의 취지는 어떤 발명이 그 특허출원 전에 국내뿐만 아니라 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명에 의하여 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에도 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 데에 있으므로, 이와 달리 발명의 진보성 판단은 국내의 기술 수준을 고려하여 국내에 있는 당해 기술분야의 전문가의 입장에 판단하여야 한다는 상고이유의 주장은 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다”라고 판시하였다. 대상판결은 간행물의 게재는 제29조제1항제2호의 국제주의이기 때문에(구 특허법에서는 제29조제1항제1호는 국내주의임), 국외의 간행물을 배제하고 진보성 판단을 해서는 안 된다는 것이다. 그러나 통상의 기술자의 수준을 결정하는

분류번호가 다른 물건이라 하더라도 본건 고안이 진보성이 없다면 그 실용신안등록은 무효라 할 것이다(대법원 1993. 5. 11. 선고 92후1387).

것과 판단 객체로서 인용발명의 지역적 기준을 결정하는 것은 구분되어야 하는 것으로서, 통상의 기술자의 수준을 결정함에 있어서는 특허독립의 원칙상 국가별로 사정을 달리한다고 해석하는 것이 바람직할 것이다.⁶⁶⁾

III. 판단방법

1. 판단의 전제

(1) 판단의 대상이 되는 발명

제29조제1항의 산업상 이용가능성 및 신규성을 만족하는 발명이여야 한다. 이는 제29조제2항 중 「제1항에도 불구하고」의 해석결과이다. 예를 들어 청구항에 기재된 발명이 신규성이 없는 경우에는 그 사유만으로도 특허를 받을 수 없으므로 진보성을 판단할 필요가 없다.⁶⁷⁾ 다만 심사관은 심사절차의 간소화 및 출원인의 대응 용이성을 위해 신규성이 없다고 판단되는 발명에 대하여 진보성도 없다는 거절이유를 함께 통지할 수 있다.⁶⁸⁾

(2) 자의적 판단의 배제

진보성 판단은 객관적 타당성에 의하여야만 하고 판단기준의 고정화를 지양하여야 한다. 또한 출원인의 입장과 기술분야의 특수성을 고려하여 판단하여야 하며 사후적 고찰(ex post facto)을 해서는 아니 된다. 그 이유는 통상의 기술자로서 해당 특허의 이론을 알고 난 후에는 공지기술로부터 해당 특허의 발명적 해결을 손쉽게 이끌어 낼 수 있는 경우가 극히 많기 때문이다. 따라서 심사관·심판관·기술적 전문가로서는 해당 특허발명의 출원 전의 상태로 돌아가서 해당 특허의 지식을 알지 못한다는 상태에서 발명의 진보성 여부를 따져보아야 한다.⁶⁹⁾

66) 특허법원 2013. 7. 18. 선고 2013허2811 판결에서는 “원고는, 이 사건 출원발명은 남아프리카공화국 등 외국에서 특허등록되었으므로 진보성이 있다는 취지로 주장하므로 살펴건대, 발명의 진보성 여부 판단에 있어서는 그 출원 당시의 기술수준, 대비되는 발명의 유무 등에 따라 나라마다 사정을 달리할 수 있으므로, 당해 발명이 외국에서 특허등록되어 있다고 하더라도 그러한 사정만으로 국내에서 그 발명의 진보성이 부정될 수 없는 것은 아니고, 국내 특허출원발명의 등록 가부는 우리나라의 특허법에 따라 독립적으로 판단할 것이지만 법 제도 등이 다른 외국의 등록례에 구애받을 것도 아니므로, 원고가 주장하는 바와 같이 이 사건 출원발명이 남아프리카공화국 등에서 특허등록되었다는 사정만으로 이 사건 출원발명의 진보성이 부정되지 않는다고 볼 수 없다”라고 판시하고 있다. 이는 국가별로 그 출원 당시의 기술수준 등이 달라서 진보성 판단을 달리한다는 것으로서 통상의 기술자의 수준을 국가별로 달리 결정해야 함을 나타낸다고 할 수 있다.

67) 대법원 1992. 6. 2. 선고 91마540.

68) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3303면.

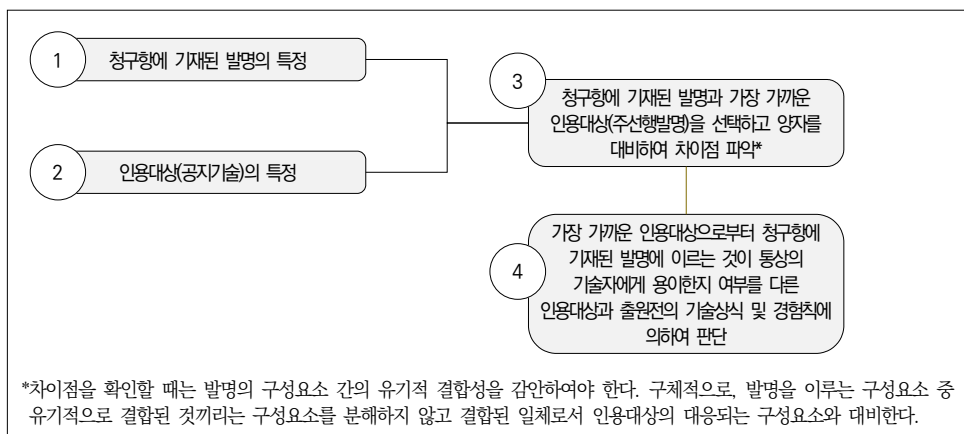
69) 대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138; 2009. 11. 12. 선고 2007후3660 등.

2. 일반적 판단방법

(1) 원 칙

1) 특허출원된 청구범위의 청구항에 기재된 발명이 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 있는지 (용이성)를 판단한다. 심사 실무⁷⁰⁾는 용이성 여부에 대하여, 출원 당시에 통상의 기술자가 직면하고 있던 기술수준 전체를 생각하도록 노력하는 동시에 발명의 설명 및 도면을 감안하고 출원인이 제출한 의견을 참작하여 출원발명의 목적(해결하고자 하는 과제), 기술적 구성(해결 수단), 작용효과를 종합적으로 검토하되, 청구항에 기재된 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 판단하도록 하고 있다.

2) 대법원도 “발명의 진보성 유무를 판단할 때에는, 적어도 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 기술수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 의하여 파악한 다음, 이를 기초로 하여 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 살펴보아야 하는 것이다”⁷¹⁾라고 하는 한편 용이성과 관련해서는 “진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이도는 그 구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하는 것이므로, 특허된 기술의 구성이 선행기술과 차이가 있을 뿐 아니라 그 작용효과에 있어서 선행기술과 비교하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는, 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 특허발명의 진보성을 인정하여야 한다”⁷²⁾라고 하여 구성의 곤란성과 효과의 현저성에 따라 진보성을 판단하고 있다.



【그림 2-7】 심사 실무⁷³⁾상 진보성 판단절차

70) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3303-3304면.

71) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660.

72) 대법원 1997. 12. 9. 선고 97후44; 1999. 4. 9. 선고 97후2033 등 참조

(2) 구성의 곤란성

1) 「구성의 곤란성」이란 통상의 기술자가 공지기술로부터 i) 동기 유발에 의하여 또는 ii) 통상의 창작능력 발휘를 통하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 생각해낼 수 있는지에 대한 판단기준이다.

2) 「동기 유발에 의하여 청구항에 기재된 발명을 쉽게 생각해 낼 수 있는 경우」의 구체적인 유형으로는, i) 공지기술의 내용 중에 청구항 발명에 대한 시사(示唆)가 있는 경우, ii) 공지기술과 청구항 발명의 과제가 공통되는 경우, iii) 기능·작용이 공통되는 경우, iv) 기술분야의 관련성이 있는 경우 등이 있다.

3) 공지기술의 일반적인 응용, 알려진 물리적 성질로부터의 추론, 알려진 과제의 해결을 위한 다른 기술분야 참조 등으로 일상적인 개선을 이루는 것은 통상의 기술자가 가지는 통상의 창작능력 발휘에 해당한다. 「통상의 창작능력 발휘」에 해당하는 구체적인 유형으로, i) 일정한 목적 달성을 위한 공지의 재료 중에서 가장 적합한 재료의 선택, ii) 수치범위의 최적화(最適化) 또는 호적화(好適化), iii) 균등물(均等物)에 의한 치환, iv) 기술의 구체적 적용에 따른 단순한 설계변경, v) 단순한 용도의 변경 등이 있다.⁷⁴⁾ 청구항에 기재된 발명과 인용대상의 차이점이 이와 같은 점에만 있는 경우에는 달리 진보성을 인정할 근거가 없는 한 통상적으로 그 발명의 진보성은 부정된다.

(3) 효과의 현저성

1) 「효과 of 현저성」이란 그 발명으로부터 초래되는 효과가 출원 당시의 기술수준으로 보아서 예측할 수 없는 유리한 효과인지에 대한 판단기준이다. 여기서 말하는 유리한 효과란 i) 인용대상의 효과와는 그 성질을 달리하는 이질적(異質的)인 효과나 ii) 그 성질은 동질(同質)이나 인용대상이 갖는 효과와 비교하여 현저하게 우수한 효과로서, 그 발명의 출원 시의 기술수준에서 통상의 기술자가 예측할 수 없었던 효과를 말한다.⁷⁵⁾ 대법원⁷⁶⁾은 앞서 설명한 구성의 곤란성 이외에도 효과의 현저성 여부를 중요한 요소로 파악하여 진보성이 있는지를 판단하고 있다. 현저한 효과는 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있기 때문이다. 나아가, 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 출원발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 다만 구성의 곤란성을 따져보지 않고 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단해서는 안 된다.⁷⁷⁾

73) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3304면.

74) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3310면.

75) 특허 선택발명이나 화학분야의 발명 등과 같이 물건의 구성에 의한 효과의 예측이 쉽지 아니한 기술분야의 경우에는 공지기술과 비교되는 더 나은 효과를 갖는다는 것이 진보성의 존재를 인정하기 위한 중요한 사실이 된다(대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 참조).

76) 대법원 1999. 3. 12. 선고 97후2156; 1998. 4. 24. 선고 96후2364; 1997. 11. 28. 선고 96후1972; 1997. 10. 24. 선고 96후1798 등.

77) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609.

2) 한편 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 한다.⁷⁸⁾ 특허발명의 유리한 효과가 발명의 설명에 기재되어 있지 아니하더라도 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재로부터 유리한 효과를 추론할 수 있을 때는 출원일 이후에 의견서에서 추가적인 실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 주장·증명하는 그 효과도 참작하여 진보성을 판단한다.⁷⁹⁾ 그러나 발명의 설명에 기재되어 있지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재로부터 통상의 기술자가 미루어 짐작할 수 없는 경우에는 의견서 등에서 주장·증명하는 효과는 참작해서는 아니 된다.

3. 참고적 판단방법

1) 구성의 곤란성 및 효과의 현저성을 비교하여 진보성을 판단함이 원칙이나 진보성이 있는지 모호한 경우 진보성 긍정의 참고자료가 될 수 있는 예도 있다. 구체적으로 i) 상업적 성공에 의한 모방품의 발생,⁸⁰⁾ ii) 기술적 효과가 큼에도 불구하고 오랫동안 해결되지 못하였던 과제의 해결, iii) 발명이 그 기술분야에서 특정 기술과제에 관한 연구 및 개발을 방해하는 기술적 편견으로 인해 통상의 기술자가 포기하였던 기술적 수단을 채용하여 그 기술과제를 해결한 경우, iv) 출원발명이 다른 사람이 해결하려고 하다가 실패한 기술적 곤란을 극복하는 방안을 제시하였거나 과제를 해결하는 방안을 제시하는 경우,⁸¹⁾ v) 출원발명이 새로운 첨단 기술분야(brand-new technology)에 속해 있어 관련된 선행기술이 전혀 없는 경우 또는 가장 가까운 선행기술이 출원발명과 차이가 현격한 경우 등은 진보성을 판단할 때 진보성 긍정 자료로서 참고하여야 한다. 다만 이러한 참고적 판단방법 자체만으로 진보성이 있는지를 판단해서는 아니 된다. 예를 들어 상업적 성공은 발명품이 가지는 우수성과는 아무런 상관없이 시장의 판매여건이나 적극적인 광고의 전략, 판매자의 독점적 지위, 제조설비나 관련 작업자의 우수성 등에 의하여 달성될 수도 있기 때문이다.⁸²⁾

78) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609.

79) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234.

80) 상업적 성공 또는 이에 준하는 사실은 그 상업적 성공이 청구항에 기재된 발명의 기술적인 특징에 의한 성공으로서, 판매기술, 선전·광고기술 등 발명의 기술적 특징 이외의 요인에 의한 것이 아니라는 사실을 출원인이 주장·증명하는 경우에는 진보성 인정의 긍정적인 근거로 참작할 수 있다(대법원 1996. 10. 29. 선고 95후1302; 1995. 11. 28. 선고 94후1817 등).

81) 대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052.

82) 원고는 이 사건 특허발명이 상업적으로 성공하였으므로 진보성이 인정되어야 한다는 취지로도 주장하나, 발명품의 판매가 종래품을 누르고 상업적 성공을 거두거나 업계로부터의 호평, 그 밖의 모방품의 출현 등은 일응 진보성이 있는 것으로 볼 자료가 될 수 있을지라도 그 자체로 진보성이 있다고 단정할 수는 없고, 진보성에 대한 판단은 우선적으로 명세서에 기재된 내용, 즉 발명의 목적, 구성 및 효과를 토대로 판단되어야 하는 것이며 아무리 우수한 발명이라도 발명이 갖고 있는 특징을 명세서에 적절히 기재하고 있지 못하다면 그 발명은 특허받을 수 없는 것이므로 위 주장은 이유 없다(대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546; 2008. 5. 29. 선고 2006후3052).

- 2) 한편 i) 파리조약 3대 원칙 중 하나인 특허독립의 원칙상 외국에의 대응특허 여부,⁸³⁾
ii) 발명의 완성 과정은 진보성 인정의 근거로 참작할 수 없다.

4. 그 밖의 판단시 유의사항

(1) 독립항과 종속항의 경우

독립항의 진보성이 인정되면 그 독립항에 종속되는 종속항도 진보성이 인정된다.⁸⁴⁾ 그러나 독립항의 진보성이 인정되지 아니하면 그 독립항에 종속되는 종속항에 대해서는 별도로 진보성을 판단한다.

(2) 물건발명, 물건의 제법발명 및 용도발명의 관계

물건발명의 진보성이 인정되면 그 물건의 제법발명 및 용도발명은 원칙적으로 진보성이 인정된다. 그러나 물건발명의 진보성이 인정되지 아니하면 그 물건의 제법발명 및 용도발명에 대해서는 별도로 진보성을 판단한다.

(3) 청구항이 마쿠쉬 형식으로 기재된 경우

1) 청구항에 기재된 발명이 마쿠쉬(markush) 형식 등으로 기재되었을 때 그 선택요소 중 어느 하나를 선택하여 인용대상과 대비한 결과 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항에 기재된 발명 전체에 대하여 진보성이 없는 것으로 인정한다. 하나의 청구항에 다수의 발명이 있을 때 그중 일부라도 특허요건의 흠결이 있으면 청구항 전체에 특허요건의 흠결이 있는 것으로 처리하기 때문이다.⁸⁵⁾ 이 경우 출원인은 진보성이 없는 것으로 지적된 선택요소를 삭제하여 거절이유를 해소할 수 있다. 한편 마쿠쉬 형식 또는 구성요소가 선택적으로 기재된 청구항의 진보성을 판단하면서 선택요소 중 어느 하나에 대한 효과를 출원발명 전체의 효과로 확대하여 인정하지 않도록 주의하여야 한다.⁸⁶⁾

2) 청구항에 기재된 발명이 신규성이 없는 경우에는 그 사유만으로도 특허를 받을 수 없으므로 진보성 판단을 할 필요가 없다. 그러나 마쿠쉬 형식의 청구항 등 1개의 청구항에 둘 이상의 발명이 기재된 경우(복수의 항이나 구성요소를 선택적으로 인용하는 경우 등)에 대해서는 신규성이 없다는 거절이유와 진보성이 없다는 거절이유를 동시에 통지할 수 있다.⁸⁷⁾ 일부 발

83) 발명의 신규성이나 진보성은 특허출원된 구체적 발명에 따라 개별적으로 판단되어지는 것이고 다른 발명의 심사예에 구애받을 것은 아니며 더욱이 법제와 관습을 달리하는 다른 나라의 심사예는 고려대상이 될 수 없는 것이므로 이에 대한 원고의 주장은 그 자체로서 이유 없다(대법원 2004. 11. 26. 선고 2002후1775 참조).

84) 대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2252.

85) 예를 들어 공지기술이 a, b, c로 구성된 발명이고 청구항이 a, b와 (c1, d 및 e 중 적어도 어느 하나)로 구성된 발명일 때 청구항에 기재된 발명 중 a, b, c1 발명의 진보성이 인정되지 아니하면, a, b, d 발명과 a, b, e 발명의 진보성 인정 여부와 무관하게 청구항의 진보성이 인정되지 아니한다.

86) 지식재산저, 『특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)』, 2025, 3330면.

87) 예를 들어 공지기술이 a, b, c로 구성된 발명이고 청구항이 a, b와 (c 및 c1 중 적어도 어느 하나)로 구성된 발명일 때 청구항에 기재된 발명 중 a, b, c 발명이 신규성 위반이고 a, b, c1 발명이 진보성

명에 대해서만 신규성 또는 진보성이 없다는 거절이유를 통지할 때는 해당 거절이유가 있는 발명을 구체적으로 지적하여야 한다(法 63②).

(4) 퇴보적 발명의 경우

특허를 허여하여 독점권을 부여해도 실시되는 일이 없을뿐더러 실시하는 자는 오히려 실시에 따른 헛된 노력의 폐해만 일으킬 수 있으므로 진보성이 없는 발명으로 거절된다.

(5) 주지관용기술⁸⁸⁾에 의한 경우

1) 지식재산치의 심사 및 특허심판원의 심판절차에서는 주지관용기술이 심사관, 심판관 사이에 현저한 사실이므로 별도의 증거없이 이를 인정할 수 있다. 구체적으로 심사관, 심판관은 주지관용기술에 해당한다고 인정하는 경우 증거자료를 첨부하지 않고 거절이유를 통지할 수 있으나, 출원인이 주지관용기술이 아니라고 주장하는 경우 심사관, 심판관은 원칙적으로 그 거절이유에 대한 증거자료를 제시하여야 한다.⁸⁹⁾

2) 그러나 심결취소소송절차에서는 주지관용기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에 증명을 필요로 한다(변론주의 원칙). 다만 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여 주지관용의 기술을 인정할 수 있으나(직권주의 가미), 변론종결 후 제출된 참고자료까지 여기의 증거 등 기록에 나타난 자료에 포함된다고 볼 수는 없다.⁹⁰⁾⁹¹⁾

(6) 부정적 교시(teaching away)

제시된 선행문헌을 근거로 어떤 발명의 진보성이 부정되는지를 판단하기 위해서는 진보성 부정의 근거가 될 수 있는 일부 기재만이 아니라 그 선행문헌 전체에 의하여 통상의 기술자가

위반이라면(a, b, c로부터 용이함을 전제), 청구항에 대하여 신규성이 없다는 거절이유와 진보성이 없다는 거절이유를 동시에 통지할 수 있다.

88) 주지기술은 그 기술분야에서 일반적으로 알려져 있는 기술이고, 관용기술은 주지기술이면서 널리 사용되고 있는 기술을 의미하며, 어느 기술이 주지관용의 기술에 해당하는지의 여부는 해당 기술의 내용, 공지문헌의 성격과 활용 정도, 공지되거나 공연실시된 횟수 등을 고려하여 객관적으로 판단하여야 한다(특허법원 2008. 6. 26. 선고 2007허10743).

89) 다만 문헌 등에 의한 증거자료의 제시가 곤란한 경우라면 심사관은 주지관용기술이라는 점에 관하여 충분히 설명하거나 주지관용기술이 아니라는 출원인의 주장이 적절하지 아니한 이유를 지적하여 거절할 수 있다. 주지관용기술임을 나타내는 증거자료로는 교과서, 초학자를 대상으로 하는 서적, 기술 표준 사전, 해당 기술분야의 국가표준(KS) 규격 등이 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3331면).

90) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후436.

91) 변론종결 후 제출된 참고자료까지 근거로 삼아 주지관용기술을 인정한다면 이는 서면심리에 의하여 판단하는 특허심판원 절차와 별반 다를 것이 없어지고, 소송절차로서의 본질에 반한다는 문제가 있다. 심결취소소송은 원칙적으로 민사소송절차에 따라 기술변론과 증거조사를 통해 심결의 위법 여부를 심리, 판단하는 절차이지, 서면심리에 의하여 판단하는 절차가 아니다. 또한 아무리 정식으로 증거조사된 것 이외의 자료를 판단의 근거로 삼는다고 하더라도 이는 어디까지나 상대방에게 송달 등의 방법으로 현출되어 다룰 수 있는 기회가 부여됨을 전제로 하는 것이지, 이러한 기회 부여도 없이 함부로 주지관용기술 판단의 근거로 삼을 수는 없다고 할 것이다(박태일, “변론종결 후 제출된 참고자료에 의하여 주지관용기술을 인정할 수 있는지 여부”, 대법원판례해설 제96호, 법원도서관, 2013, 292면).

합리적으로 인식할 수 있는 사항을 기초로 대비 판단하여야 한다. 그리고 위 일부 기재 부분과 배치되거나 이를 불확실하게 하는 다른 선행문헌이 제시된 경우에는 그 내용까지도 종합적으로 고려하여 통상의 기술자가 해당 발명을 용이하게 도출할 수 있는지를 판단하여야 한다.⁹²⁾ 특히 선행발명이 특허발명에 이르지 못하도록 저해하는 기재(부정적 교시)가 있다면, 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 유력한 근거가 된다. 특허발명을 도출하기 위해 선행기술의 부정적 교시를 무시했어야만 했다면 사후적 고찰이라는 점이 강하게 추정될 수 있기 때문이다.⁹³⁾ 한편 복수의 선행문헌들이 서로 충돌하는 교시를 할 경우, 각각의 문헌들이 어느 정도로 통상의 기술자에게 해결책을 제안할 수 있는지와 각 선행문헌의 실험조건과 신뢰도 등을 평가하여 선행기술의 부정적 교시를 무시하고 특허발명을 도출할 수 있는 동기가 있다고 볼 수 있는지를 구체적으로 따져 보아야 한다.⁹⁴⁾

IV. 흠결의 효과

1) 등록 전에는 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)이며, 등록 후에는 특허취소사유(法 132의2①), 특허무효사유(法 133①)이다. 다만 특허취소사유(法 132의2①)에서 제29조제1항제1호의 특허출원전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성에 위반된 경우는 제외되고, 등록특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청(法 132의2)을 할 수 없다. 이러한 진보성 흠결은 심사·심판 실무상의 거절이유 중 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

2) 한편 착오로 등록된 특허발명과 관련하여 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 판결에서는 “특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 해당 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초하여 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다”라고 판시하였다. 위 대법원 판결은 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 아니하면 특허발명의 보호범위는 부정되지 아니한다는 종래 대법원판결⁹⁵⁾의 태도를 유지하면서도, 특허권 침해소송에서 진보성 여부에 대하여 심리할 수 있고, 특허에 무효사유가 존재함이 명백한 때에는 그 권리행사를 제한하고 있다는 점에 특색이 있다.

92) 대법원 2016. 1. 14. 선고 2013후2873, 2880.

93) 신혜은, “제시된 선행문헌을 근거로 발명의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법”, 지식재산정책 32권, 한국지식재산연구원, 2017, 125-126면.

94) Donald S. Chisum, 『Chisum on Patents』, volume 2, LexisNexis, 2014, p.5-157; 이현, 「발명의 진보성 판단에 관한 연구」, 경인문화사, 2017, 69면에서 재인용.

95) 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095.

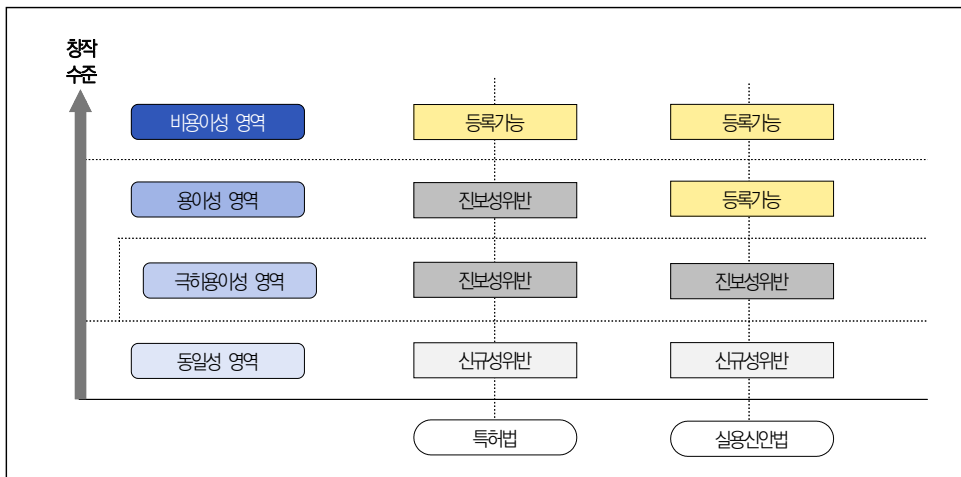
V. 관련문제

1. 발명의 고도성과의 관계

발명의 고도성은 성립요건으로서 고안과 구별하기 위한 척도이며 주관적 성질을 가지지만, 진보성은 특허요건으로서 객관적 성질을 갖는다. 출원인은 자신의 주관적 판단하에 자연법칙을 이용한 기술적 사상이 고도하다고 생각되면 특허출원을, 그렇지 아니하다고 생각되면 실용신안등록출원을 하게 된다. 이 경우 심사관은 고도성이 있는지는 판단하지 아니하며, 진보성 판단에 의하여 특허 여부를 결정하게 된다.

2. 고안의 진보성과의 관계

실용신안법 제4조제2항은 “제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 고안에 의하여 「극히 쉽게」 고안할 수 있으면 그 고안에 대해서는 제1항에도 불구하고 실용신안등록을 받을 수 없다”라고 규정하고 있다. 즉 고안의 진보성 위반에는 발명의 「용이성」보다 낮은 정도의 창작성인 「극히 용이성」이 요구된다. 따라서 진보성 위반으로 거절이유통지 또는 특허거절결정을 받은 출원인은 발명이 실용신안등록의 보호대상인 물품의 형상·구조 또는 조합인 경우에 최초 특허거절결정 등본송달일로부터 3개월 이내 실용신안으로 변경출원하는 것을 고려해 볼 수 있다.



【그림 2-8】 발명과 고안의 창작수준에 따른 법적 취급의 비교

3. 진보성 상실의 예외

공지 등이 되어 진보성을 상실하더라도 일정 기간에 특허법에서 정한 절차를 밟아 출원하면 공지 등이 되지 아니한 것으로 볼 수 있다(法 30).

4. 특수한 발명의 신규성 및 진보성 판단

(1) 결합발명

1) 「결합발명」이란 하나의 기술적 문제해결을 위하여 여러 개의 장치 또는 수단·방법 등 기술적 사상을 결합한 발명을 말한다. 결합발명은 선행발명에 구성요소를 더 부가한 것으로 일반적으로 선행발명과 동일성이 없으므로 신규성은 인정되나, 진보성에 위반되는지가 문제이다. 결합발명의 진보성을 판단할 때에는 청구항에 기재된 발명은 전체로서 고려되어야 하며 구성요소 각각이 공지 또는 자명하다고 하여 청구항에 기재된 발명의 진보성을 부정할 수 없다. 즉 진보성 판단의 기초가 되는 기술적 구성의 곤란성을 평가할 때, 과제해결원리를 배제한 채 청구항에 기재된 구성을 하나하나 분해한 후 선행기술의 대응 구성요소로부터 도출이 곤란한지만을 따져서는 아니 되고, 특유의 과제해결원리에 기초하여 그 발명에 채용된 특유한 구성요소들과 나머지 구성요소들 사이의 결합관계를 포함하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 살펴보아야 하며⁹⁶⁾, 이때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.⁹⁷⁾

2) 구체적인 예로는 발명의 기술적 과제를 달성하기 위하여 공지기술들에 기재된 기술적 특징을 종합하여 새로운 해결수단으로 구성한 결합발명을 들 수 있다. 결합발명은 진보성 여부에 따라 공지기술의 단순한 집합인 「주합발명(agggregation)」과 공지기술의 새로운 결합인 「조합발명(combination)」으로 구별될 수 있다. 양 발명 모두 신규성은 있다는 점에서 공통되나, 주합발명(agggregation)은 조합발명(combination)⁹⁸⁾과 달리 진보성이 없어서 등록될 수 없다는 점에서 차이가 있다. 구체적으로 여러 공지기술을 인용하여 특허의 진보성을 판단할 때 그 인용되는 공지기술을 조합 또는 결합하면 해당 특허발명에 이를 수 있다는 교시(teaching), 암시(suggesting), 동기(motivation) 등이 공지기술에 제시되어 있거나⁹⁹⁾ 그렇지 않더라도 해

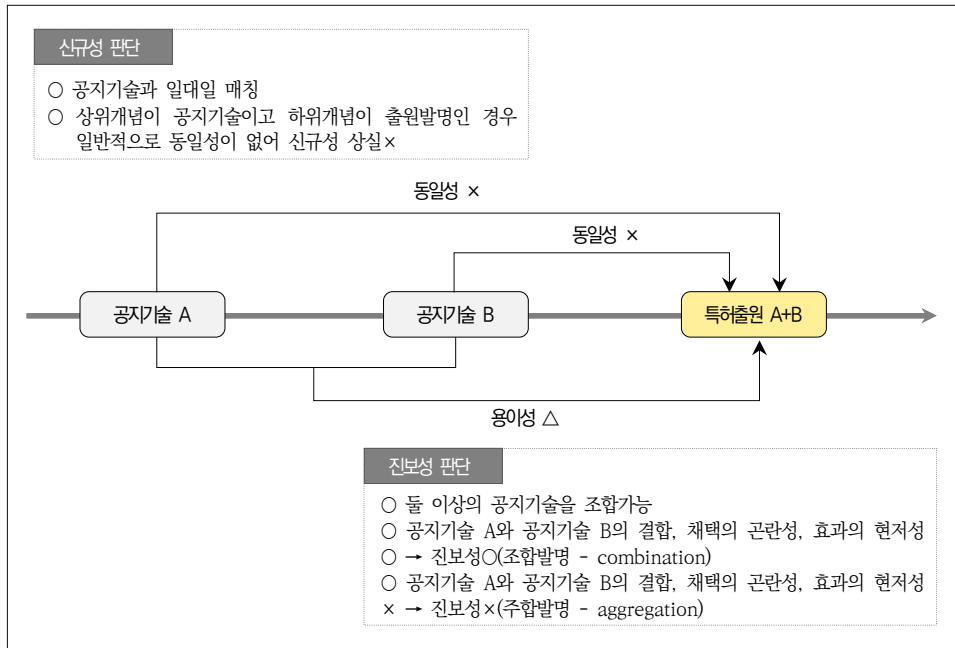
96) 대법원 2010. 9. 9. 선고 2009후1897.

97) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609.

98) 공지공용의 기술을 결합한 고안이라고 할지라도 결합 전에 각 기술이 가지고 있던 작용효과의 단순한 집합이 아니라 결합 전과 비교하여 증진된 작용효과가 인정되고 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 손쉽게 이를 실시할 수 없을 때에는 신규성 및 진보성이 있는 고안이라 할 것이다(대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990; 2003. 1. 10. 선고 2001후2269 등).

99) 청구범위에 기재된 청구항이 개개의 선행발명의 권리범위에 포함되지 않는 새로운 기술구성에 대한 것임에도 불구하고, 통상의 기술자가 여러 개의 선행발명으로부터 일부 구성요소들을 분리해낸 뒤 이를 조합 또는 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정되고 특허등록을 받을 수 없다고 하기 위해서는, 단순히 그러한 조합 또는 결합으로 청구항의 구성에 이를 수 있다는 것만으로는 부족하고, 통상의 기술자가 쉽게

당 특허출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적인 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 조합 또는 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 주합발명으로서 진보성이 부정된다.¹⁰⁰⁾



【그림 2-9】 결합발명의 신규성, 진보성 판단

(2) 선택발명

1) 「선택발명」이란 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명으로서, 선행 또는 공지의 발명에는 직접적으로 개시되어 있지 아니한 사항을 선택한 발명을 의미한다. 예를 들어 선행발명 A의 명세서 본문에는 a1, a2에 대하여만 개시되어 있었는데, 후에 A의 개념에 포함되는 a3을 선택하였을 때 a3의 발명을 선택발명이라 한다.

그러한 시도를 할 수 있고 그 결과를 예측할 수 있다고 볼만한 사정, 즉 선행발명들에 그러한 구성요소들을 조합 또는 결합하면 해당 발명에 이를 수 있다는 암시·동기 등이 제시되어 있거나, 해당 발명이 공지된 구성요소들을 알려진 방법으로 조합 또는 결합한 것에 불과하고 그로 인한 효과 또한 알려져 있거나 예측 가능한 정도에 그치는 등 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다(특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017허4228).

100) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3277; 2009. 7. 9. 선고 2008후3377 참조.

2) 선택발명이 신규성에 위반되지 않기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 그 하위 개념을 구체적으로 개시하지 않고 있어야 하고, 「개시」에는 선행발명을 적은 선행문헌에 선택 발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다.¹⁰¹⁾

3) 다음으로 진보성에 위반되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 공지된 상위개념인 선행발명과 비교하여 구성의 곤란성이 인정되어야 한다. 구성의 곤란성이 인정되는지와 관련해서는 i) 상위개념의 크기, ii) 선행발명이 선택발명을 선택할 동기를 제공하거나 선행발명에 암시가 있는지, iii) 선행발명에 기재된 하위개념발명과 선택발명이 구조적으로 유사한지 아닌지 등이 고려되어야 한다.¹⁰²⁾ 다만 구성의 곤란성을 따져보지 않고 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단해서는 안 된다.¹⁰³⁾

101) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736; 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 등.

102) 예를 들어 선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되지만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져보아야 한다. 위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609).

103) 지금까지 대법원은 선택발명은 본질적으로는 선행발명에 대한 중복발명에 해당하여 특허를 받을 수 없으나 산업의 발달과 공익의 증진 도모를 위하여 예외적으로 특허를 허용한다는 관점에서, 이질적 또는 현저한 효과라는 일반적인 발명보다 엄격한 특허요건을 요구해 왔다. 그러나 대법판결에서는 선택발명에도 일반적인 진보성 판단방법이 적용되므로 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 긍정된다고 판단하였다. 그러면서 종래의 이질적 또는 현저한 효과 중심의 법리는 구성의 곤란성이 인정되지 않는 경우 적용되는 것으로서 여전히 유효하므로, 기존 판례의 변경이 아니고 단지 구성의 곤란성 기준을 추가한다는 의미에서 전원합의체 판결을 하지 않고 소부에서 이 판결을 선고한 것으로 보인다. 그러나 이질적 또는 현저한 효과 중심의 지금까지 실무를 완전히 바꾸어 놓는다는 의미에서 사실상 판례의 변경에 해당한다고 볼 수 있다. 또한 기존에 대법원은 선택발명의 효과 판단과 관련하여 발명의 설명에 '이질적 또는 현저한 효과가 있음을 명확히 기재'할 것을 요구하면서, 그 효과가 의심스러울 때에는 출원일 이후에 구체적인 비교실험자료를 제출하는 등의 방법에 의하여 그 효과를 주장·증명하면 된다고 하기도 하고(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결), 위의 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 발명의 설명에 '질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재'가 있어야 한다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결)고 판시하기도 하였다. 두 판시 중 전자가 보다 완화된 기준인 것으로 보였었는데, 대법판결은 전자의 판시를 인용함으로써 보다 완화된 기준을 선택하였다고 볼 수 있다. 게다가 이 판결은 효과의 현저성은 발명의 설명에 '명확히' 기재할 것이 아니라, '명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 한다'고 판시하기도 하였다. 다만 이 사건에서처럼 구성의 곤란성이 있는 선택발명의 경우에는 효과의 증명 역시 일반 발명과 마찬가지로 볼 것이지만, 구성의 곤란성이 없는 선택발명에서는 여전히 종래의 엄격한 기준은 유효하다고 볼 여지도 남아 있다. 그리고 그 효과가 의심스러울 때에는 '그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서' 출원일 이후에 추가적인 실험자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다고 하여 추가 실험자료 제출의 한계를 두기도 하였다. 그동안 대법원 단계에서 선택발명이 유효로 판단된 예는 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결, 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424 판결, 대법원 20

4) 선택발명의 진보성을 판단할 때는 그 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다. 선행발명에 이론적으로 포함되는 수많은 화합물 중 특정한 화합물을 선택할 동거나 암시 등이 선행발명에 개시되어 있지 않은 경우에도 그것이 아무런 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우라면 그와 같은 선택에 어려움이 있다고 볼 수 없는데, 발명의 효과는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있기 때문이다. 또한 화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다. 나아가 구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다. 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고,¹⁰⁴⁾ 만일 그 효과가 의심스러울 때는 그 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장·증명하는 것이 허용된다.¹⁰⁵⁾

5) 하나의 청구항에 여러 개의 하위개념을 포함하는 선택발명이 있는 경우 효과의 현저성이 인정되기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 진보성이 인정되어야 한다.¹⁰⁶⁾ 한편 효과의 현저성에 의하여 진보성을 판단할 때 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명과 비교하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그중 일부라도 선행발명과 비교하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다.¹⁰⁷⁾

(3) 수치한정발명

1) 「수치한정발명」이란 청구항에 기재된 발명의 구성요소 일부가 수량적으로 표현된 발명을 의미한다. 수치한정발명의 신규성과 관련하여, 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경

17. 5. 11. 선고 2014후1631 판결 정도에 불과하였다. 하지만 이 사건 판결의 선고로써 유효로 판단되는 선택발명이 늘어날 것으로 예상됨에 따라 보다 적극적인 출원전략이 필요할 수 있을 것이다. 특히 선행발명에 선택지가 많을 경우는 더욱 그러하다(구민승, “상위개념이 공지된 물질특허(선택발명)의 진보성 판단 기준의 변화(대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609 판결)”, 특허와상표 회원기고 (<http://kpaanews.or.kr/news/view.html?section=86&category=88&page=1&no=4886>), 2021.05.07.)

104) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234.

105) 대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609. 대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738에서도 동일한 취지로 판결하였다.

106) 선택발명에 포함되는 하위개념의 실시형태 중 가장 열등한 것의 효과가 선행발명에 개시된 실시형태 중 가장 우수한 것의 효과와 비교하여 현저하다는 관계가 인정되지 않는다면, 선택발명에 포함되는 하위개념의 실시형태 중 일부의 효과가 선행발명에 개시된 실시형태 중 일부의 효과보다 뛰어나 보인다고 하여 선택발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 볼 수는 없다(대법원 2016. 1. 28. 선고 2013후1887).

107) 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424.

우에 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 아니한다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위의 수치가 공지된 발명을 적은 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 한편 i) 수치한정이 공지된 발명과 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의미를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 ii) 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다.¹⁰⁸⁾

2) 한편 수치한정발명의 진보성과 관련하여, 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에는 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 특허발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, 공지된 발명과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이라면 진보성이 부정된다.¹⁰⁹⁾ 즉 수치한정발명의 진보성이 인정되기 위해서는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나 공지된 발명과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과 차이가 생겨야 한다.¹¹⁰⁾

3) 수치한정발명에 대하여 특허를 받으려는 자는 수치한정을 통하여 얻으려는 현저한 작용 효과를 명세서에 명확하게 적어야 하며, 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 아니하면 그와 같이 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다.¹¹¹⁾ 수치한정한 범위 전체에서 이질적이거나 양적으로 현저한 효과가 있어야 한다는 점, 출원 명세서에 그 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 명세서 기재 자체를 통하여 인식할 수 있을 정도로 기재되어 있지 아니한 이상 추후 실험자료에 의하여 인정되거나 확인되는 수치한정의 기술적 의미를 가지고서 해당 수치한정 발명의 진보성 여부를 판단할 수는 없다.¹¹²⁾¹¹³⁾

108) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015.

109) 대법원 2023. 7. 13. 선고 2022후10180.

110) 대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998 참조.

111) 대법원 1994. 5. 13. 선고 93후657; 2005. 4. 15. 선고 2004후448 등.

112) 특허법원 2009. 5. 22. 선고 2008허1722.

113) 해당 발명의 성격이나 기술내용 등에 따라서는 발명의 설명에 실시예가 기재되어 있지 않다고 하더라도

(4) 파라미터발명

1) 「파라미터발명」이란 출원인이 자기의 발명을 표현하기 위하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 관용되지 아니한 화학적·물리적 특성으로 특정하거나 출원인이 임의로 창출한 기술적 변수를 포함하는 발명 내지는 복수의 변수를 상관적으로 규정한 요건을 포함하는 발명을 말한다.¹¹⁴⁾ 파라미터발명은 청구항의 기재 자체만으로는 기술적 구성을 명확하게 이해할 수 없는 예도 있으므로, 파라미터발명의 신규성, 진보성은 명세서 또는 도면 및 출원 시의 기술상식을 참작하여 발명을 명확하게 파악한 후에 판단한다.

2) 파라미터발명은 파라미터 자체를 청구항 일부로 하여 신규성을 판단하되 청구항에 기재된 파라미터가 신규하다고 해서 그 발명의 신규성이 인정되는 것은 아니고, 파라미터에 의한 한정이 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성 등을 시험적으로 확인한 것에 불과하거나, 파라미터를 사용하여 표현방식만 달리한 것이라면 청구항에 기재된 발명의 신규성은 부정된다.¹¹⁵⁾ 구체적으로 파라미터 발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정 방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 발명의 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 다를 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 파라미터 발명은 신규성이 부정된다.¹¹⁶⁾

통상의 기술자가 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우도 있으므로 제42조제3항제1호에서 정한 발명의 설명 기재요건을 충족하기 위해서 항상 실시예가 기재되어야만 하는 것은 아니다. 또한 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명의 경우, 그러한 수치한정이 단순히 발명의 적당한 실시범위나 형태 등을 제시하기 위한 것으로서 그 자체에 별다른 기술적 특징이 없어 통상의 기술자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하다면, 그러한 수치한정에 대한 이유나 효과의 기재가 없어도 통상의 기술자로서는 과도한 실험이나 특수한 지식의 부가 없이 그 의미를 정확하게 이해하고 이를 재현할 수 있을 것이므로, 이런 경우에는 발명의 설명에 수치한정의 이유나 효과가 기재되어 있지 않더라도 제42조제3항제1호에 위배된다고 할 수 없다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582).

- 114) 파라미터발명은 물질의 구조를 특정하여 청구범위를 기재하는 것이 아니라, 그 물질이 갖는 물성이나 특성에 대한 파라미터를 사용하여 청구범위가 특정되므로 권리범위를 넓게 설정할 수 있고, 권리침해의 주장 및 증명이 쉽다. 또한 새로이 창작된 파라미터를 이용하는 경우 그 파라미터에 대응되는 선행기술을 찾기 어려우므로 현실적으로 등록가능성이 커진다.
- 115) 파라미터발명은 일반적으로 공지기술과 신규성 판단을 위한 구성의 대비가 곤란하기 때문에, 심사관은 양자가 동일한 발명이라는 「합리적인 의심」이 있는 경우에는 공지기술과 엄밀하게 대비하지 않고 신규성이 없다는 거절이유를 통지한 후, 출원인이 제출한 의견서 및 실험성적서 등을 참작하여 판단한다. 신규성 판단에서 동일한 발명이라는 합리적인 의심이 드는 경우에는 ① 청구항에 기재된 발명에 포함된 파라미터를 다른 정의 또는 시험·측정 방법으로 환산하였더니 공지기술과 동일해지는 경우, ② 공지기술의 파라미터를 명세서에 기재된 측정·평가방법에 의하여 평가하였더니 청구항에 기재된 발명이 한정하는 것과 동일한 사항이 얻어질 것으로 예상되는 경우, 및 ③ 명세서에 기재된 출원발명의 실시형태와 공지기술의 실시형태가 동일한 경우 등이 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 3224년).
- 116) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298. 이는 동일성의 유형을 문언적 동일, 내재적 동일성 및 실질적 동일성으로 구분하였을 때 내재적 동일성에 대한 판단법리를 제시한 것으로 여겨진다.

3) 파라미터발명은 청구항에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상 이를 발명의 구성에서 제외하고 선행기술과 대비할 수 없으므로, 파라미터 발명의 경우 파라미터로부터 기인하는 성질 또는 특성 등을 감안하여 쉽게 발명될 수 있는지에 의하여 진보성을 판단한다. 구체적으로 먼저 파라미터의 도입에 기술적 의의가 있는지를 살펴야 하는바, 청구항에 기재된 파라미터가 출원 전 공지된 물성을 표현방식만 달리하여 나타낸 것에 불과하거나 공지된 물건에 내재된 본래의 성질 또는 특성을 시험적으로 확인한 것에 불과한 경우 또는 파라미터와 더 나은 효과와의 인과관계가 부족한 경우에는 기술적 의의를 인정할 수 없으므로 진보성을 부정한다. 그러나 파라미터가 공지된 발명과 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그로 인해 특유한 효과를 갖는다고 인정되는 경우에는 진보성이 부정되지 않는다.¹¹⁷⁾ 한편 파라미터 발명이 수치한정발명의 형태를 취하고 있는 경우에는, 즉 파라미터의 도입 자체에 대하여는 위와 같은 기술적 의의를 인정할 수 없더라도 발명이 새롭게 도입한 파라미터를 수치로 한정하는 형태를 취하고 있는 경우에는 수치한정발명의 진보성 판단기준을 그대로 적용할 수 있으므로 비록 파라미터 자체만으로는 기술적 의의가 없더라도 수치한정에 의하여 이질적 또는 동질이라도 현저한 작용효과가 인정된다면 진보성을 인정할 수 있다.¹¹⁸⁾¹¹⁹⁾

117) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298.

118) 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298.

119) 심사관은 청구항에 포함된 파라미터를 이해하기 곤란하거나 시험 측정 및 환산이 곤란하여 인용대상의 대응되는 것과 대비하기 곤란하더라도, 그 파라미터발명이 인용대상으로부터 쉽게 발명될 수 있다고 「합리적으로 의심」할 만한 사정이 있다면, 그 구성을 엄밀하게 대비하지 않고 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지한 후, 출원인이 제출한 의견서 및 실험성적서 등을 참작하여 판단한다. 진보성 판단에서 쉽게 발명될 수 있다는 합리적인 의심이 드는 경우로는 ① 청구항에 기재된 발명의 파라미터를 다른 정의 또는 시험·측정 방법으로 환산하였더니 청구항에 기재된 발명이 인용대상으로부터 쉽게 발명될 수 있는 경우, ② 인용대상의 파라미터를 명세서에 기재된 측정·평가방법에 의하여 평가하였더니 청구항에 기재된 발명이 한정하는 것과 유사하게 되어 진보성을 부정할 수 있는 경우, 및 ③ 명세서에 기재된 출원발명의 실시형태와 인용대상의 실시형태가 유사하여 진보성이 부정될 수 있는 경우 등이 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3320면).

1. 서 설

동일성과 용이성 판단은 i) 출원발명의 특정, ii) 인용대상의 특정 및 iii) 구성과 효과를 비교하여 판단하는 단계를 거쳐서 이루어진다. 구체적으로 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 서로 실질적으로 동일성이 있는 것이고¹²⁰⁾, 통상의 기술자의 입장에서 살펴볼 때 구성이 인용대상과 차이가 크지 않고(구성 of 的 性이 없고), 그 효과가 현저하지 아니한 경우에는 용이성이 있는 것이다¹²¹⁾.

2. 구체적인 예

(1) 하나의 인용대상에 출원발명의 구성요소가 모두 포함된 경우 동일성이 있음

출원발명	인용대상1	인용대상2	인용대상3	조합(or)
A	○	○	○	○
B	○	○	×	○
C	×	○	○	○
D	×	○	×	○
설명	- 인용대상2에 출원발명의 구성요소가 모두 포함되어 있으므로 동일성이 있음			

(2) 여러 개의 인용대상을 조합(or)한 결과 출원발명의 구성요소가 모두 포함된 경우 용이성이 있음 (단, 조합의 어려움이 없다는 것을 전제로 함)

출원발명	인용대상1	인용대상2	인용대상3	조합(or)
A	○	×	○	○
B	○	○	×	○
C	×	×	○	○
D	×	○	×	○
설명	- 인용대상 1 내지 3 각각에 출원발명의 구성요소가 모두 포함되어 있지 않기 때문에 동일성이 없음 - 인용대상 1 내지 3을 조합하면 출원발명의 구성요소가 모두 포함되어 있으므로 용이성이 있음 - 단, 출원발명의 구성의 결합에 특유의 과제해결원리에 기초한 결합관계가 있다면 그 결합관계 역시 구성으로 파악해야 함			

(3) 여러 개의 인용대상을 조합(or)한 결과 출원발명의 구성요소가 모두 포함되지 않은 경우 등록가능 (단, 조합의 어려움이 없다는 것을 전제로 함)

출원발명	인용대상1	인용대상2	인용대상3	조합(or)
A	○	×	○	○
B	○	○	×	○
C	×	×	×	×
D	×	○	×	○
설명	- 인용대상 1 내지 3 각각에 출원발명의 구성요소가 모두 포함되어 있지 않기 때문에 동일성이 없음 - 인용대상 1 내지 3을 조합하더라도 출원발명의 구성요소가 모두 포함되어 있지 않기 때문에 용이성이 없음			

(4) 여러 개의 인용대상을 조합(or)한 결과 출원발명의 구성요소와 차이가 있는 경우 용이성 판단(단, 조합의 어려움이 없다는 것을 전제로 함)

출원발명	인용대상1	인용대상2	인용대상3	조합(or)
A	○	×	○	○
B	○	○	×	○
C	×	×	△(C1)	△
D	×	○	×	○
설명	- C1에서 C를 도출하는 것에 대한 곤란성이 없고 효과의 현저성이 없다면 용이함 - 그렇지 아니하면 용이성이 없어서 등록가능함			

(5) 하나의 인용대상과 출원발명의 구성요소가 차이가 있는 경우 동일성과 용이성 판단

출원발명	인용대상1	인용대상2	인용대상3	조합(or)
A	○	×	○	○
B	○	○	×	○
C	△(C1)	×	×	△
D	○	○	×	○
설명	- C1과 C의 차이가 주지관용기술의 부가, 삭제, 변경 등에 불과하여 그 차이로 인하여 새로운 효과가 발생하지 않는다면 동일성이 있음 - C1에서 C를 도출하는 것에 대한 곤란성이 없고 효과의 현저성이 없다면 용이함 - 그렇지 아니하면 용이성이 없어서 등록가능함			

120) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179.

121) 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660; 1997. 12. 9. 선고 97후44 등.

제4절 선출원주의

제36조 【선출원】

- ① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
- ② 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인¹²²⁾만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 경우에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.
- ③ 특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것이면 제1항을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것이면 제2항을 준용한다.
- ④ 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
 2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
- ⑤ 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항부터 제3항까지의 규정을 적용할 때에는 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ⑥ 지식재산처장은 제2항의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 제2항에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「선출원주의」란 동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허출원이 있는 경우 가장 먼저 특허출원한 자에게 특허를 허여하는 주의를 말한다.

2. 취 지

특허제도는 공개의 대가로 일정 기간 독점배타적인 특허권을 부여하는 제도로써, 하나의 기술사상에 대하여 이중으로 특허권을 부여하는 것은 특허제도의 본질에 반하므로 중복특허 배제의 원칙(이를 1발명 1특허 원칙이라고 한다)을 구현하려고 한다. 우리 특허법은 이러한 중복특허 배제의 원칙을 구현하는 방법으로서 발명의 조기 공개를 유도하는 한편 권리의 안정성을 확보하기 위해서 선출원주의(first to file)를 채택하고 있다.

122) 私見으로는 「하나의 특허출원인」은 「하나의 특허출원」으로 개정함이 타당하다고 생각된다. 동일출원(同日出願)의 경우 협의제를 취하는 이유는 하나의 발명에 대한 하나의 권리의 지분을 나누어 갖도록 유도하기 위함이고, 그렇다면 하나의 특허출원에 대하여 특허출원인은 다수가 될 수 있기 때문이다.

3. 선발명주의와 비교

1) 경합하는 2개 이상의 발명이 있는 경우 어느 발명에 대하여 특허를 허여할 것인지에 대하여 선출원주의와 선발명주의라는 두 개의 대립하는 입법례가 있다. 「선발명주의」는 출원 선후와 관계없이 먼저 발명한 자에게 특허를 허여하는 제도로써, 진정한 발명자를 보호할 수 있으며 완벽한 명세서를 갖추어 출원하도록 함으로써 특허제도의 이상에 부합한다는 장점이 있지만 출원을 서두르지 아니하여 조기공개를 유도하지 못하며, 누가 먼저 발명하였는지 판단이 어렵다는 단점이 있다.

2) 선출원주의는 발명 완성의 선후와 관계없이 먼저 출원한 자에게 특허를 허여하는 제도로써, 자신의 발명을 누구보다도 먼저 사회에 공개하여 사회 이익에 기여한 자에게 반대급부로서 독점권인 특허권을 부여한다는 취지에 입각한 제도이다. 선출원주의에 의하면 발명자는 될 수 있으면 빨리 출원하려고 하므로 조기공개를 유도할 수 있으며, 선출원주의의 판단기준인 출원일자를 지식재산처장의 방식심사에 의하여 부여하기 때문에 판단이 쉽다. 다만 진정한 발명자를 보호하기 어렵다는 단점이 있다.¹²³⁾

3) 우리나라 특허법은 선출원주의를 채택하고 있으며 선출원주의의 단점인 진정한 발명자 보호에 대한 미흡을 보완하기 위해 i) 출원일 또는 판단시점의 소급효, ii) 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ)에 대한 특허권의 효력 제한, iii) 선사용권(法 103)의 인정, iv) 발명자 동일한 경우 확대된 선출원 부적용(法 29③④단서) 등 선발명주의적 요소를 가미하고 있다.

【표 2-1】선출원주의와 선발명주의의 비교

구 분	선출원주의	선발명주의
진정한 발명자 보호 (구체적 타당성)	× (선출원자 보호)	○ (선발명자)
판단의 용이성 (법적 안정성)	○	×
조기공개유도	○	×
특허법의 태도	1. 선출원주의의 채택 2. 진정한 발명자 보호에 미흡한 점을 보완 - 선발명주의적 요소의 가미 ① 출원일 또는 판단시점의 소급효 ② 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ) ③ 선사용권(法 103) ④ 발명자 동일 시 확대된 선출원 부적용(法 29③④단서)	

123) 2011년 9월 8일에 미국은 기존에 미국만이 채택하고 있던 선발명주의를 포기하고 선출원주의를 도입하는 법 개정을 단행하였다. 미국의 선출원주의는 개정법 발효일로부터 18개월 이후인 2013년 3월 9일부터 시행되고 있다.

II. 선출원주의의 내용

1. 이일출원(異日出願)의 경우

동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으며, 이는 실용신안등록출원과 경합하는 경우에도 준용한다(法 36①③). 다만 디자인보호법의 보호대상인 디자인은 기술적 사상의 창작이 아닌 물품의 외관에 관한 미적 창작이기 때문에 특허출원과 디자인등록출원 사이에서는 선출원주의가 적용되지 아니한다.

2. 동일출원(同日出願)의 경우

(1) 협의제

1) 동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 특허출원인 간에 협의하여 정한 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 다만 협의가 성립하지 아니하거나(不成) 협의를 할 수 없는 경우(不能)에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다. 이는 실용신안등록출원과 경합하는 경우에도 준용한다(法 36②③). 이처럼 특허법이 협의제를 채택하고 있는 이유는 하나의 발명에 대하여 두 개의 권리를 허여할 수는 없으므로 하나의 발명에 대한 하나의 권리의 지분을 나누어 갖도록 유도하기 위함이다.

2) 「협의를 할 수 없을 경우」란 구체적으로 i) 상대방이 협의에 응하지 아니한 등의 이유로 협의를 할 수 없는 경우 또는 ii) 동일한 발명에 대한 둘 이상의 출원 중 어느 한 출원이 특허된 경우를 말한다. ii)의 경우에는 협의명령을 하지 않고, 나머지 출원에 대하여 제36조에 따른 거절이유를 통지한다. 물론, 이 경우 등록된 특허는 특허무효사유를 가지고 있다.¹²⁴⁾

(2) 협의명령

지식재산처장은 동일출원의 경우에 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의제(法 36②)에 따른 협의는 성립되지 아니한 것(不成)으로 본다. 한편 협의결과에 따른 신고서를 제출하는 경우에는 경합된 출원에 대하여 협의결과에 따른 절차를 동시에 취하여야 한다(施規 34②).

3. 선출원의 지위가 없는 경우

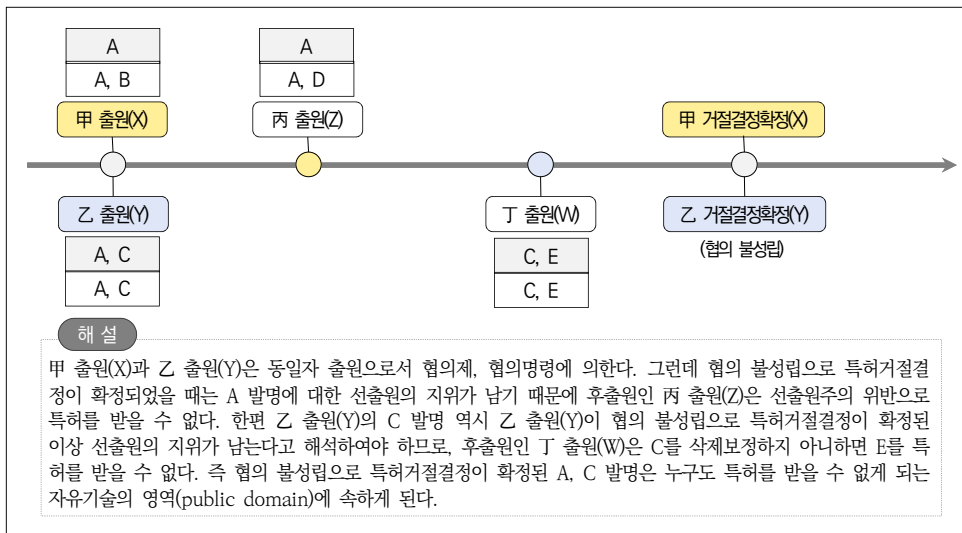
1) 선출원주의에서 선후출원의 판단은 선출원의 지위가 있음을 전제로 한다. 즉 선출원의 지위가 있을 때 동일한 후출원 발명을 배제할 수 있다. 예를 들어 甲이 A 발명을 먼저 출원하고

124) 한편 동일인이 동일 발명을 동일자에 특허출원한 경우에는 「협의를 할 수 없는 경우」에 해당하여 바로 거절결정하여야 한다는 과거의 판례(대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14)가 있었으나 동일인이라고 하여 모든 출원에 대하여 권리를 부정하는 것은 1발명 1권리주의에 반하며 다른 출원인과 동일자에 경합하는 경우와 비교해도 형평성에 어긋나기 때문에, 동일 출원인이라도 그중 하나를 취하, 포기하였다면 협의가 이루어진 것으로 간주하여 특허를 허여함이 타당하다.

乙이 A 발명을 나중에 출원했다고 하더라도 甲의 출원이 무효, 포기 등으로 선출원의 지위가 없어졌다면 乙의 출원은 선출원주의에 위반되지 아니한다.

2) i) 특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 특허거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우,¹²⁵⁾ ii) 발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원의 경우에는 선출원의 지위가 없다(法 36④⑤).

3) 그러나 동일자 출원에 대하여 제36조제2항단서(제3항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 협의의 불성립 등으로 특허거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우에는 선출원의 지위가 인정된다(法 36④단서). 이는 협의의 불성립 등으로 특허거절결정이 확정된 특허출원은 자유기술의 영역(public domain)에 속한다고 할 수 있는데, 그 일방 또는 제3자가 재특허출원하여 특허를 받을 수 있는 것은 타당하지 않기 때문이다.



【그림 2-10】 협의의 불성립으로 특허거절결정이 확정된 경우의 취급

125) 구법에서는 포기된 출원, 특허거절결정이 확정된 출원에 대해서 선출원의 지위가 인정되었다. 그러나 심사인력의 증원을 통해 심사기간을 출원공개 전으로 단축할 경우 발생할 수 있는 문제점을 사전에 예방하기 위해 2006. 3. 3. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정)에서는 선출원의 지위를 인정하지 않고 있다. 구체적으로 공개 전 거절 또는 포기된 출원에 대하여 선출원의 지위를 부여할 경우에는 i) 실질적인 영업비밀 보호수단으로 작용하고, ii) 제3자가 추후 선의로 그 기술을 발명하여 특허권을 획득할 수 있는 기회를 봉쇄하는 수단으로 작용하고, iii) 동일한 후발명에 대하여 포기 또는 거절된 발명을 인용문헌으로 의견제출통지서와 함께 출원인에게 송부하여야 하는데, 이 행위는 선출원 발명을 제3자에게 공개하는 행위로서 심사관의 비밀유지의무에 반하는 문제점이 있다. 한편 거절 또는 포기되어 공개되지 아니한 발명은 보완하여 재출원 및 공개하도록 유도하는 것이 산업발전의 이바지라는 특허법 목적에 부합하기도 한다.

III. 선출원주의의 판단

1. 주체적 기준

심사단계에서는 심사관이, 심판단계에서는 심판관 합의체가, 법원에서는 법관이 판단한다.

2. 객체적 기준

1) 동일한 발명 또는 발명과 고안이 동일한 경우에 적용된다. 여기서 「발명이 동일하다」는 것은 특허출원의 청구범위에 기재된 발명이 동일하다는 것을 의미하고 「발명과 고안이 동일하다」는 것은 특허출원의 청구범위에 기재된 발명과 실용신안등록출원의 청구범위에 기재된 고안이 동일하다는 것을 의미한다. 즉 선출원주의는 선·후출원의 청구범위에 기재된 발명을 청구항별로 판단한다. 보정한 경우 보정 후의 청구범위를 기준으로 판단하며, 선출원주의는 1발명 1권리주의를 달성하기 위한 제도이므로 발명자 또는 출원인이 동일한 경우에도 적용된다.

2) 외국어특허출원의 경우 국어번역문이 보정의 효과가 있으므로, 국어번역문의 청구범위에 기재된 발명과 대비하여 판단한다. 다만 국어번역문이 신규사항을 포함할 때는 그 발명에 대해서는 선출원의 지위를 인정하지 아니한다.¹²⁶⁾

3. 시기적 기준

(1) 원 칙

출원 시각을 증명하는 것이 어려울 뿐만 아니라 동일한 내용의 발명이 같은 날에 출원되는 경우가 드물다는 심사 경험에 비추어 출원일을 기준으로 선·후출원을 판단한다.¹²⁷⁾

(2) 예 외

i) 무권리자에 대한 정당한 권리자 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ii) 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, iii) 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, iv) 국제특허출원의 경우 우선일을 기준으로 판단한다.

126) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5519-5520면.

127) 출원일의 판단은 도달주의가 원칙이지만 우편으로 제출하는 경우 발신주의에 의한다. 정보통신망을 이용하여 제출된 전자문서는 그 문서의 제출인이 정보통신망을 통하여 접수번호를 확인할 수 있는 때에 지식재산청 또는 특허심판원에서 사용하는 접수용 전자정보처리조직의 파일에 기록된 내용으로 접수된 것으로 본다(法 28의3③). 단 국제특허출원에 관한 서류에 있어서는 우편의 경우에도 도달주의이다.

4. 지역적 기준

선출원주의의 판단은 특허독립의 원칙상 국내만을 고려하여 판단한다.¹²⁸⁾ 예를 들어 일본에서 선출원한 동일한 발명을 우리나라에서 후출원한다고 하더라도 일본 출원과 우리나라 출원 사이에서는 선출원주의가 적용되지 아니한다.

5. 판단방법

(1) 원 칙

청구범위에 기재된 발명(고안)을 비교하여 동일성이 있는지 판단한다. 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결에서는 “양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용 효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다”라고 판시하여 구성의 변경이 있는 경우 신규성, 확대된 선출원과는 달리 실질적 동일성의 범위를 넓게 인정하고 있다. 다만 이러한 실질적 동일성 판단기준은 i) 진보성 판단과의 경계가 모호해질 우려가 있다는 점, ii) 확대된 선출원 규정이 선출원주의를 보완하기 위해 제도인데 양자의 실질적 동일성을 달리 판단할 이유가 없다는 점을 고려할 때 그 운영에 신중을 기할 필요가 있다.¹²⁹⁾

(2) 동일(同日)출원의 실질적 동일성 판단

1) 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결에서는 “두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져 보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다”라고 하여 실체를 중심으로 판단하여야 한다는 일반적인 법리를 제시하고 있다.

2) 실질적 동일성은 인용대상과 본원발명이 동일한 기술사상에 기반하고, 차이가 있더라도 미소한 차이에 불과한 것으로서, i) 물건발명과 방법발명과 같이 발명의 범주(카테고리)가 다른 경우, ii) 상·하위 개념 발명과 같이 발명의 범위가 다른 경우(부분적 일치)가 있는 경우, iii)

128) 각 국가의 특허는 서로 독립적이며, 그 효력은 특허를 받은 국가에서만 인정되는 속지주의에 의하므로 국내의 법조문상 별다른 언급없이 「특허출원」이라고 기재되어 있는 경우 국내의 특허출원을 의미하는 것이라고 이해된다.

129) 조영선, “발명(고안)의 동일성 판단”, 「특허판례연구」, 박영사, 2009, 97-98면 참조. 한편 최근의 특허 법원 2017. 10. 12. 선고 2017허1021 판결에서는 분할출원된 발명과 원출원 발명의 동일성이 있는지와 관련하여, “분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일한지 여부는 청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 실질적으로 동일한지 여부를 기준으로 하여야 하며, 청구범위의 기재가 문언적으로 일치하지 않더라도 그 차이가 동일한 기술적 구성에 대해 기능·성질·효과 등으로 표현을 달리한 것에 불과하거나 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 수단에서 주지관용기술을 부가·삭제·변경한 것 또는 단순히 수치 범위를 달리한 것에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 실질적으로 동일한 발명에 해당한다”라고 하여 확대된 선출원 규정의 동일성 판단과 맥락을 같이 하고 있으며, 향후 대법원의 입장 변화가 있을지 주목된다.

발명의 구성 중 일부가 변경된 경우(단순한 구성의 변경이 있는 경우)의 유형으로 구분될 수 있다. 이러한 유형의 발명을 동일자 출원하면 실질적 동일성의 범위를 좁게 해석하여 양 발명 모두 등록을 시켜주고 등록 후 자유롭게 실시할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 판단된다. i) 동일자 출원이기 때문에 특허권의 존속기간이 부당하게 연장되지 않는다는 점, ii) 발명의 범주가 다른 경우에 있어서는 물건발명과 방법발명은 특허권자가 누릴 수 있는 권리의 내용에 큰 차이가 있는 점, iii) 특허 출원인이 동일한 경우에는 하나의 출원서에 복수의 청구항으로 기재하여 출원하는 경우라면 모두 유효하게 등록될 수 있었을 것이라는 점(대법원 1995. 9. 26. 선고 94후1558) 등을 고려해야 하기 때문이다.¹³⁰⁾

IV. 함결의 효과

1) 등록 전에는 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)이며, 등록 후에는 특허취소사유(法 132의2①), 특허무효사유(法 133①)이다. 다만 등록특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청(法 132의2)을 할 수 없다.

2) 한편 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결에서는 “등록된 특허발명이 그 출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명으로서 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선출원주의 위반은 특허발명 내지 후출원발명과 선행발명 내지 선출원발명의 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선출원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다”라고 판시하여 선출원주의에 위반되었음에도 착오로 등록된 특허발명은 특허취소신청에 의한 취소결정확정이나 특허무효심판에 의한 무효심결확정 전이라도 권리범위를 부정하고 있다.

V. 관련문제

1. 선출원주의의 보완

i) 특허법상 보정(法 47), ii) 선사용권(法 103), iii) 무권리자에 대한 정당한 권리자의 출원(法 34, 35), iv) 이용·저촉(法 98)에 의한 통상실시권허락심판(法 138), v) 확대된 선출원(法 29③④), vi) 심사청구제도(法 59⑤), vii) 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96① III)에 관한 규정을 두어 선출원주의를 보완하고 있다.

2. 선출원주의의 예외

무권리자의 출원·특허에 대한 정당한 권리자의 출원(法 34, 35), 분할출원(法 52②), 분리출원

130) 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 박사, 2013, 103-108면 참조.

(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우에는 출원일이 소급되고, 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우에는 판단시점이 소급되므로 선출원주의의 예외가 된다.

3. 동일출원이 모두 등록된 경우

(1) 문제의 소재

둘 이상의 동일자 특허출원 또는 실용신안등록출원 간에는 협의제·협의명령을 적용하여 어느 하나의 출원만이 특허 또는 등록실용신안을 받을 수 있음이 원칙이다. 그런데 협의제·협의명령을 하지 않고 양 출원이 모두 착으로 등록되었을 때 특허법에 직접적인 처리 규정이 존재하지 않기 때문에 문제이다.

(2) 판례의 태도

대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103 판결에서는 “동일인이 동일고안에 대하여 같은 날에 경합출원을 하여 모두 등록된 경우에 그 후 어느 한쪽의 등록이 무효로 확정되었다면 나머지 등록을 유지, 존속시켜 주는 것이 타당하고 당초에 경합출원이었다는 사실만으로 나머지 등록 까지 모두 무효로 볼 것이 아니다”라고 판시하였고, 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결에서는 “특허권이나 실용신안권의 포기에 의하여 경합출원의 하자가 치유되어 제3자에 대한 관계에서 특허권의 효력을 주장할 수 있다고 보는 것은 명문의 근거가 없을 뿐만 아니라 권리자가 포기의 대상과 시기를 임의로 선택할 수 있어 권리관계가 불확정한 상태에 놓이게 되는 등 법적 안정성을 해칠 우려가 있는 점, 특허권이나 실용신안권의 포기는 그 출원의 포기와는 달리 소급효가 없음에도 결과적으로 그 포기에 소급효를 인정하는 셈이 되어 부당하며, 나아가 특허권 등의 포기는 등록만으로 이루어져 대외적인 공시방법으로는 충분하지 아니한 점 등을 종합하여 보면, 출원이 경합된 상태에서 등록된 특허권이나 실용신안권 중 어느 하나에 대하여 사후 권리자가 그 권리를 포기하였다고 하더라도 경합출원으로 인한 하자가 치유된다고 보기는 어렵다”라고 판시하여, 특허권의 무효와 포기에 대하여 달리 취급하고 있다.

(3) 소 결

특허권의 무효는 특허출원이 처음부터 없었던 것으로 보는 출원의 무효와 달리 특허권이 처음부터 없었던 것으로 보기 때문에(法 133③), 특허권의 포기와 마찬가지로 선출원의 지위를 상실하였다고 보지 아니한 것이 타당할 것이다. 다만 경합출원이 등록되기 전 협의제, 협의명령을 하였다면 협의를 한 하나의 출원에 대해서는 적법하게 특허권의 발생을 유도할 수 있었는데, 심사관의 심사 미진으로 인해 양 권리가 모두 등록되었다는 이유로 양 권리를 모두 특허취소사유, 특허무효사유로 규정하는 것은 특허권자 보호 측면에서 바람직하지 아니하게 보인다. 私見으로는 둘 이상의 경합출원이 등록된 후에도 협의제·협의명령을 통해 어느 하나의 권리를 포기하고 특허권의 공유를 유도함으로써 1발명 1권리주의의 원칙을 관철함과 아울러 양 권리자의 이익을 보호해주는 한편 협의가 성립되지 않거나 협의를 할 수 없는 경우에는 양 권리를 둘 다 제36조제2항 위반으로 특허취소사유, 특허무효사유에 해당하도록 하는 입법론적 재고가 필요하다고 하겠다.

제5절 확대된 선출원

제29조 【특허요건】

- ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.
 1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명
 2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(公衆)이 이용할 수 있는 발명
- ② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.
- ③ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 다른 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 다른 특허출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 그 특허출원일 전에 출원된 특허출원일 것
 2. 그 특허출원 후 제64조에 따라 출원공개되거나 제87조제3항에 따라 등록공고¹³¹⁾된 특허출원일 것
- ④ 특허출원한 발명이 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 고안(考案)과 동일한 경우에 그 발명은 제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 그 특허출원의 발명자와 실용신안등록출원의 고안자가 같거나 그 특허출원을 출원한 때의 출원인과 실용신안등록출원의 출원인이 같은 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 그 특허출원일 전에 출원된 실용신안등록출원일 것
 2. 그 특허출원 후 「실용신안법」 제15조에 따라 준용되는 이 법 제64조에 따라 출원공개되거나 「실용신안법」 제21조제3항에 따라 등록공고된 실용신안등록출원일 것
- ⑤ 제3항을 적용할 때 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제3항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.
- ⑥ 제4항을 적용할 때 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우 제4항 본문 중 “출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, 같은 항 제2호 중 “출원공개”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개”로 본다.
- ⑦ 제3항 또는 제4항을 적용할 때 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원은 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 보지 아니한다.

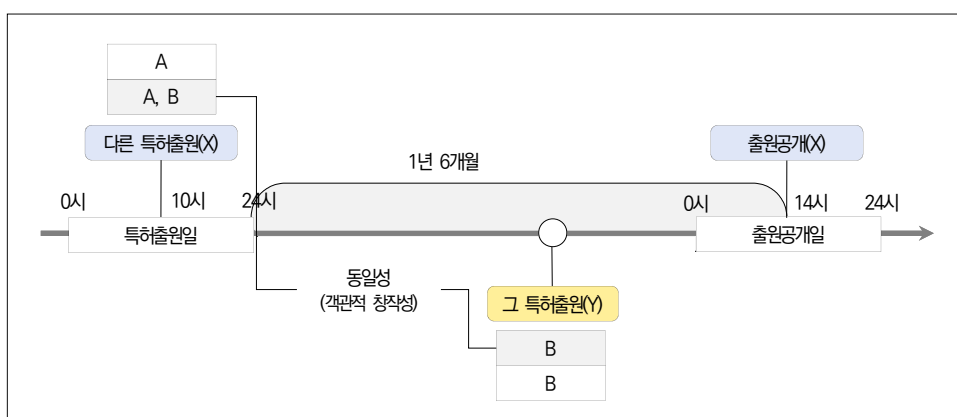
[전문개정 2014.6.11.]

131) 私見으로는 「등록공고」는 「설정등록」으로 개정함이 타당하다고 생각된다. 제216조의 서류의 열람과 관련하여, 기존에는 출원공개 또는 등록공고를 요건으로 서류의 열람을 하였으나, 2009. 1. 30. 시행된 현행법(법률 제9381호, 2009. 1. 30. 개정)에서는 출원공개 또는 설정등록을 요건으로 서류의 열람을 할 수 있도록 하고 있고, 열람된 이후에는 신규성(法 29①각호), 진보성(法 29②)을 적용할 수 있는데, 굳이 확대된 선출원을 중복 적용할 필요가 없기 때문이다.

I. 서 설

1. 의 의

「확대된 선출원」이란 특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 그 특허출원 후에 출원공개되거나 등록공고된 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에는 그 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없도록 선출원의 지위를 부여하는 것을 말한다. 「확대된 선출원」이란 강학상 용어로서 출원공개 또는 등록공고를 요건으로 특허출원일 후 출원공개 또는 등록공고 전 사이에서, 선출원으로서 후출원을 배제할 수 있는 범위가 청구범위에서 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면 전체에 기재된 발명으로 확대된 것을 의미한다.



【그림 2-11】 확대된 선출원 일반

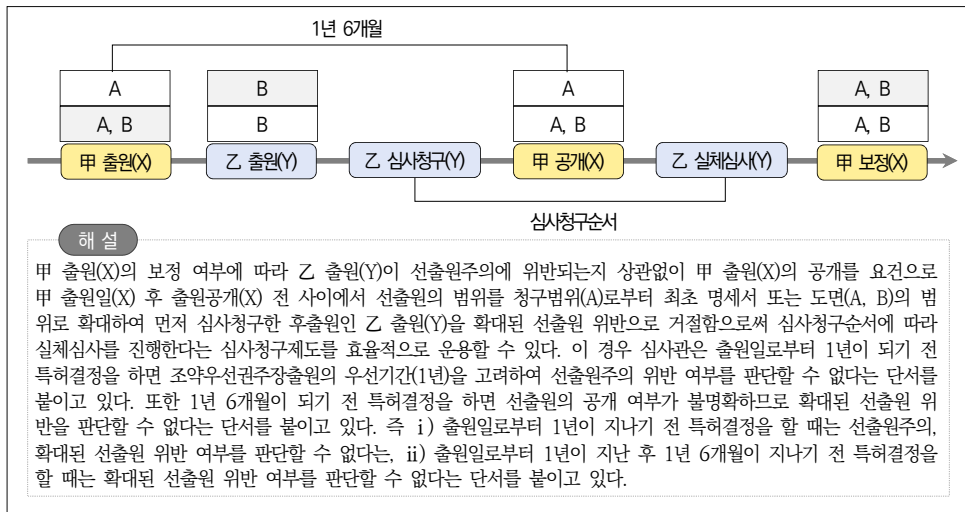
2. 취 지

(1) 새로운 발명을 공개시킨 자에게만 특허권 부여

i) 그 특허출원(후출원)의 청구범위에 기재된 발명이 다른 출원(선출원)의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에는 사실상 새로운 기술을 공개하는 것이 아니기 때문에 신규의 발명을 공개시킨 자에게 특허권을 부여한다는 특허법의 목적에 부합하지 아니한다. 또한 ii) 다른 출원의 청구범위에는 기재되지 않고 발명의 설명에만 기재가 되어 있는 발명은 다른 출원의 출원인이 공중에게 자유롭게 실시할 수 있게 한 자유기술의 영역(Public domain)이라 할 수 있는데 이를 해당 출원의 특정인에게 특허권을 부여하여 사유화시키는 것은 타당하지 않기 때문에 확대된 선출원을 적용하여 거절하고 있다.

(2) 심사청구제도와 출원공개제도의 원활한 활용

확대된 선출원과 출원공개제도를 이용하려면 심사청구제도의 원활한 활용이 가능하다. 만약 선출원주의만 적용이 된다면 선출원주의에서는 출원발명에 대한 선·후출원 판단을 청구범위에 기재된 청구항을 대상으로 하므로 선출원의 청구범위에는 기재되지 않고 발명의 설명·도면에만 기재된 발명에 대해서는 선출원의 보정 여부에 따라 후출원의 거절 여부가 달라진다. 그 결과 선출원의 심사 결과가 확정될 때까지 먼저 심사청구한 후출원에 대한 심사를 진행할 수 없으므로 심사청구순서에 따라 실제심사를 한다는 심사청구제도의 취지에 반하게 된다. 확대된 선출원은 선출원의 출원공개 또는 등록공고를 요건으로 후출원을 배제할 수 있는 범위를 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명까지 확대하여 먼저 심사청구한 후출원을 심사 가능하게 함으로써 심사청구제도의 실효성을 확보하고 있다.



【그림 2-12】 확대된 선출원과 출원공개제도를 활용한 심사청구제도의 운영

(3) 방어출원의 감소

확대된 선출원을 인정함으로써 타인의 등록을 저지시키기 위해 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 청구범위에 기재하여 특허출원하는 방어출원을 줄여 심사부담을 경감시킬 수 있다.

II. 판단기준

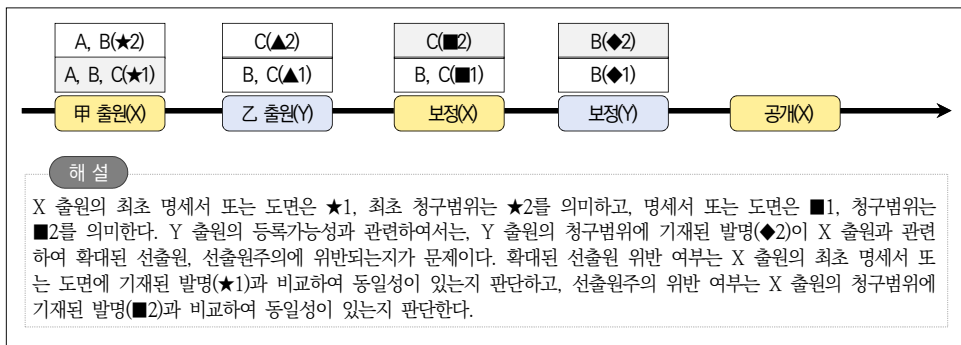
1. 주체적 기준

심사단계에서는 심사관이, 심판단계에서는 심판관 합의체가, 법원에서는 법관이 판단한다.

2. 객체적 기준

(1) 원 칙

그 특허출원의 청구범위의 청구항에 기재된 발명과 다른 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 대비하여 판단한다. 「최초」란 출원할 때 처음으로 첨부된 것을 기준으로 한다는 의미이며, 보정을 했을 때 판단대상을 결정하는 기준이 된다. 구체적으로 보정에 의하여 추가된 내용이라도 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있지 않으면 확대된 선출원이 인정되지 않으며,¹³²⁾ 보정에 의하여 삭제된 내용이라도 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있다면 확대된 선출원이 인정된다.



【그림 2-13】 최초 명세서 또는 도면의 의미

(2) 미완성발명이 다른 출원에 해당하는지 여부

대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결에서는 “최초 명세서 등의 기재라 함은 그 명세서 등에 직접적으로 명확하게 기재되어 있는 사항 및 명시적으로는 기재되어 있지 않으나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 출원 시의 기술수준을 참작하여 명세서 등에 기재된 사항에 의하여 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개시되어 있는 「완성된 발명」을 말한다”라고 판시하여 미완성발명은 확대된 선출원 규정을 적용함에 있어서 다른 출원의 지위가 없음을 밝히고 있다.

3. 시기적 기준

(1) 그 특허출원일 전에 다른 출원이 있어야 한다.

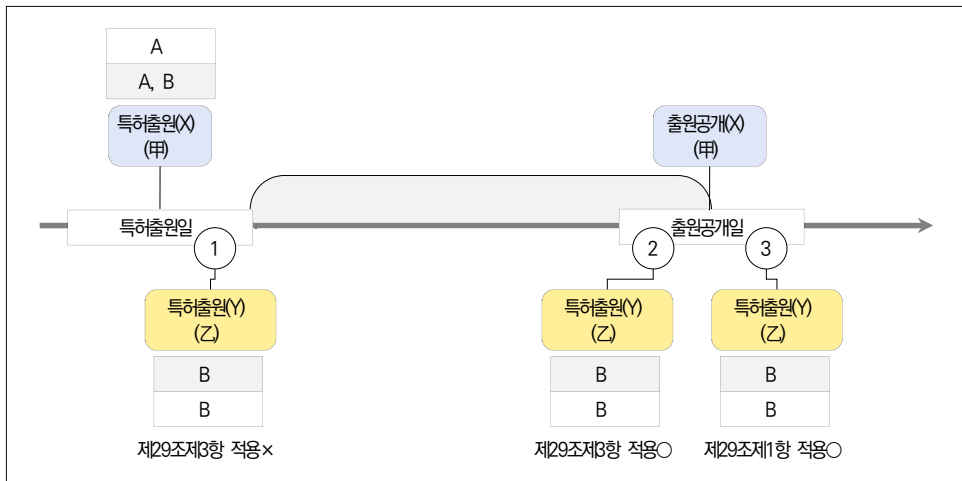
「그 특허출원일 전」에 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여야 한다. 즉 출원일을 기준으로 판단하여 그 출원일 전에 다른 출원이 있어야 하며, 그 출원의 출원일과 다른 출원의 출원일이 동일(同日)자 출원의 경우에는 본 규정이 적용되지 아니한다.

132) 특허법원 2005. 2. 3. 선고 2004허1984.

(2) 그 특허출원 후 다른 출원의 출원공개 또는 등록공고가 있어야 한다.

1) 그 특허출원 후 출원공개되거나 등록공고된 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원이 있어야 한다. 「그 특허출원 후」이기 때문에 그 특허출원일과 다른 출원의 공개일이 同日인 경우에 본 규정이 적용된다. 즉 출원 시를 기준으로 판단하여 i) 그 특허출원의 출원 시가 다른 출원의 공개 시보다 더 빠르면 확대된 선출원이 적용되며, ii) 그 출원의 출원 시가 다른 출원의 공개 시보다 더 늦으면 신규성(法 29①각호)이 적용되며, iii) 출원 시와 공개 시를 알 수 없는 경우에는 심사 실무상 최대한 늦게 공개된 것으로 추정되므로 확대된 선출원이 적용된다.

2) 본 규정은 「출원공개 또는 등록공고」를 적용요건으로 한다. 다른 출원이 출원공개 또는 등록공고가 되지 아니한 경우 공중의 이용 도모에 기여한 것이 아니기 때문에 해당 특허출원 발명에 대하여 본 규정을 적용할 수 없다. 예를 들어 다른 출원이 공개 전 무효·취하·특허거절결정의 확정 또는 포기되었다면 본 규정이 적용되지 않으나 다른 출원이 무효·취하·특허거절결정의 확정 또는 포기되더라도 공개된 이후라면 본 규정이 적용된다. 한편 일반적으로 출원공개가 등록공고보다 먼저 되기 때문에 「등록공고」를 요건으로 확대된 선출원이 적용되는 경우는 출원공개되지 않고 등록공고된 경우이다.



【그림 2-14】 그 특허출원의 출원일과 다른 출원의 출원일 또는 공개일이 동일자인 경우 적용

4. 지역적 기준

확대된 선출원 판단은 선출원주의 판단과 마찬가지로 특허독립의 원칙상 국내만을 고려하여 판단한다.

III. 판단방법

그 특허출원의 청구범위의 청구항에 기재된 발명과 다른 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 대비하여 동일성이 있는지 판단한다. 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1181 판결¹³³⁾에서는 “구성요소에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주·관용기술의 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다”라고 판시하여 확대된 선출원에서 발명의 실질적 동일성 판단은 진보성 판단과 구분되는 개념으로서, 동일성의 범위를 부당하게 확대해서는 안 된다는 것을 명확히 하고 있다.¹³⁴⁾

IV. 함결의 효과

1) 등록 전에는 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)이며, 등록 후에는 특허취소사유(法 132의2①), 특허무효사유(法 133①)이다. 다만 등록특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청(法 132의2)을 할 수 없다.

2) 한편 특허법원 2009. 9. 18 선고 2009허2432 판결은 “권리범위확인심판절차에서 특허 발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지여서 신규성이 없는 경우, 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우에 있어서는 확인대상발명은 특허발명과 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것인바, 이와 같은 법리는 특허발명이 특허법 제29조제3항 및 제4항 본문에서 규정하고 있는 선출원주의 규정에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에도 마찬가지라고 할 것이다”라고 판시하여 확대된 선출원에 위반되었음에도 착오로 등록된 특허발명의 권리 범위를 부정하고 있다.

V. 적용의 예외

1. 발명자가 동일한 경우

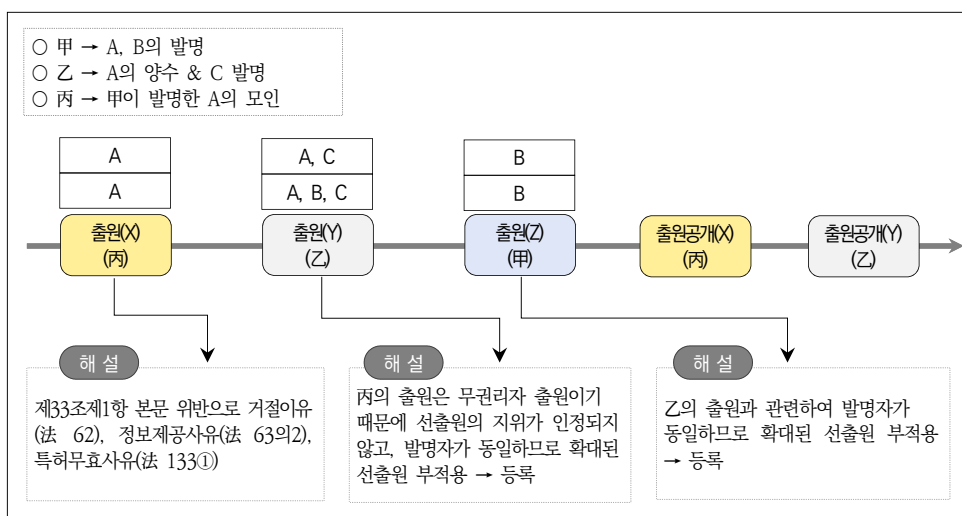
1) 그 특허출원의 발명자와 다른 특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우에는 확대된 선출원의 적용이 배제된다.¹³⁵⁾ 이는 선발명주의적 요소를 가미한 것으로, 발

133) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179; 대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2017후2376(병합)도 동일한 취지로 판시하고 있다.

134) 유영선, “특허법 제29조 제3항(확대된 선출원) 규정에서의 ‘발명의 동일성’ 판단기준(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결)”, 대법원판례해설 제88호, 법원도서관, 2011, 509면.

명자가 동일한 경우는 i) 다른 출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명의 발명자가 특허출원한 경우, ii) 무권리자의 출원 이후에 발명자 또는 승계인이 출원한 경우 등이 있다.

2) 다만 발명자가 동일하더라도 후출원은 선출원이 출원공개 또는 등록공고되기 전에 출원되어야 하며, 자기의 선출원이라 하더라도 이미 출원공개 또는 등록공고가 된 상태에서는 보호받을 수 없다. 선출원이 공개된 후 후출원이 되었다면 후출원의 내용은 이미 발명자가 권리로서 주장할 수 없는 영역, 즉 「자유기술의 영역(Public domain)」에 속하게 된 것이기 때문이다.



【그림 2-15】 발명자가 동일한 경우의 구체적인 예

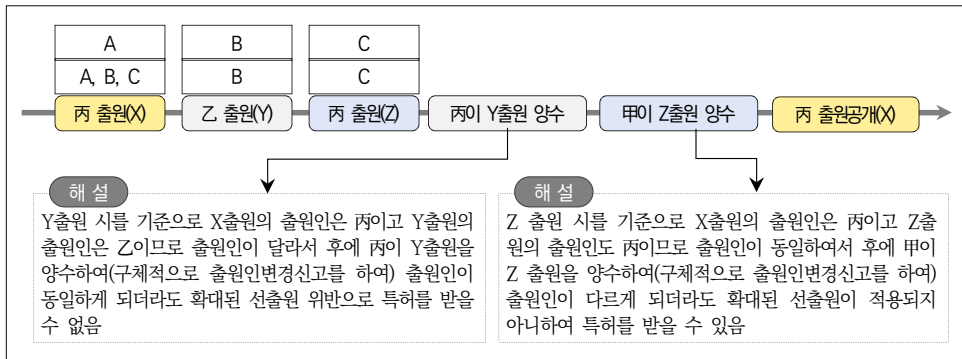
2. 그 특허출원한 때의 출원인이 동일한 경우

1) 그 특허출원한 때의 특허출원인과 다른 특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 적용되지 아니한다. 이는 다른 출원의 출원서에 최초로 첨부한 발명의 설명 또는 도면에 기재된 발명을 보호받으려는 출원인의 이익을 위해서이다.¹³⁶⁾¹³⁷⁾

135) 표시상 완전히 일치하지 않더라도 실질적으로 동일한 발명자로 판단되면 발명자가 동일한 것으로 인정된다(대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525). 다만 발명자가 동일하다는 것은 출원인이 증명하여야 한다. 한편 출원인이 제29조제3항 및 제4항에 위반된 것을 염려하여 발명자의 추가나 정정신청을 한 경우 심사관은 진정한 발명자인지를 증명할 수 있는 서류를 출원인에게 요구할 수 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3406-3407면).

136) 출원인에게 특허권을 부여하더라도 제3자에게 불측의 손해를 끼칠 염려가 없으며 다른 출원의 발명의 설명 또는 도면에 기재된 발명은 출원인이 공개시킨 것으로서 먼저 출원하여 공개시킨 자에게 특허권을 부여한다는 특허법의 목적에도 부합한다.

2) 출원인은 발명자와는 달리 바뀔 수 있으므로 출원인의 동일은 「그 특허출원을 할 때」를 기준으로 하고 있다.¹³⁸⁾ 그 결과 원래는 출원인이 서로 달랐지만, 그 특허출원 후에 출원인의 변경으로 인해 출원인이 동일하게 된 경우에는 확대된 선출원의 규정이 적용된다. 그러나 그 특허출원을 할 때를 기준으로 볼 때는 다른 출원과 그 특허출원의 출원인이 동일하나, 추후 특허출원인의 변경에 의하여 출원인이 다르게 된 경우에는 확대된 선출원의 규정이 적용되지 아니한다.



【그림 2-16】 그 특허출원한 때의 출원인이 동일한 경우의 구체적인 예

VI. 관련문제

1. 각종 제도와와의 관계

(1) 다른 출원이 분할출원·분리출원·변경출원인 경우

다른 출원이 분할출원, 분리출원, 변경출원인 경우 확대된 선출원을 적용할 때 출원일이 소급되지 않고 분할출원일, 분리출원일, 변경출원일을 기준으로 판단한다(法 52②I, 52의2②, 53②I). 원출원의 최초 명세서 또는 도면에는 포함되어 있지 아니하지만, 분할출원, 분리출원, 변경출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함된 발명에 의하여 원출원과 분할출원, 분리출원, 변경출원 사이의 제3자의 출원을 거절하는 것은 먼저 출원하여 공개시킨 자에게 독점·배타적인 특허권을 부여한다는 특허법의 목적에 반하기 때문에 확대된 선출원을 적용하는 경우 소급효가 인정되지 않고 현실의 분할출원일, 분리출원일, 변경출원일을 기준으로 한다.¹³⁹⁾

137) 이 경우 출원인은 별도의 출원뿐만 아니라 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 보정하거나 분할출원, 국내우선권주장출원을 하여 보호받을 수도 있을 것이다.

138) 그 특허출원할 때를 기준으로 한 것은 심사 시나 결정 시를 기준으로 한다면 그 때가 일정하지 않고 또 그 때에 일일이 출원인의 동일 여부를 확인하여야 하는 등 심사상 불편하기 때문이다.

139) 다만 원출원의 최초 명세서의 발명의 설명에만 기재된 발명을 변경출원의 발명의 설명에만 적어 원출원일로부터 1년 6개월이 지나기 전에 변경출원을 하는 경우 원출원과 변경출원 사이에 그 발명을 청구범위에 적은 제3자의 출원에 대한 등록을 저지시킬 수 없어 입법상 미비점이 있다. 특허법의 목적에

(2) 다른 출원이 조약우선권주장출원·국내우선권주장출원인 경우

1) 다른 출원이 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원인 경우 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 선출원일 후 우선권주장출원의 출원공개 또는 등록공고 전 사이에 출원된 제3자의 발명에 대하여 확대된 선출원을 적용한다. 한편 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되지 아니한 발명은 우선권주장출원일 후 우선권주장출원의 출원공개 또는 등록공고 전 사이에 출원된 제3자의 발명에 대하여 확대된 선출원을 적용한다(法 55④).

2) 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원의 선출원은 선출원의 지위, 확대된 선출원의 지위가 인정되지 아니한다. 조약우선권주장출원의 선출원은 외국출원이기 때문에, 국내우선권주장출원의 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월을 지난 때에 일반적으로 출원공개되지 않고 취하 간주되기 때문이다. 이 경우 선출원과 우선권주장출원 사이에 제3자 출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원의 최초 명세서·도면에 기재된 발명과 동일한 경우 제3자의 출원에 대하여 특허를 허여함은 공개와 독점의 조화라는 특허법의 목적에 반하기 때문에 일정 범위에 대하여 판단시점의 소급효를 인정해 주고 있다. 다만 국내우선권주장출원이 출원공개 또는 설정등록된 때에는 국내우선권주장출원의 적법성을 판단하기 위해서 선출원의 열람을 허가하고 있으므로 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명의 공지기술의 지위가 인정된다.

3) 국내우선권주장출원의 선출원이 국내우선권주장 또는 조약우선권주장을 수반하는 경우에는 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는, 즉 이중우선의 경우에는 제29조제3항, 제4항을 적용할 때 판단시점의 소급효가 인정되지 아니한다(法 55⑤). 이러한 경우에도 확대된 선출원의 소급효를 인정하는 것은 국내우선권주장을 2번 연속으로 주장한 것을 인정하는 것과 같기 때문이다. 따라서 선출원(선출원의 조약·국내우선권주장의 기초가 되는 특허출원을 말한다), 선출원 및 후출원 모두에 기재된 발명에 대해서는 후출원일의 다음날로부터 후출원의 출원공개 또는 등록공고 전에 출원된 제3자의 발명에 대하여 확대된 선출원 규정을 적용하게 된다.

2. 다른 출원이 국제특허출원(국제실용신안등록출원)인 경우

1) 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 확대된

비추어 보면 제3자의 출원에 기재된 발명은 출원을 통해 일반 공중에게 공개한 새로운 발명이 아니기 때문에 이를 독점·배타적인 특허권으로 보호할 이유가 없다.

선출원 규정(法 29③④) 중 「출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」은 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」으로, 같은 항 제2호 중 「출원공개」는 「출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개」로 본다(法 29⑤⑥).

- i) 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우
- ii) 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우

2) 즉 특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원을 하여 그 특허출원 후에 「출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개」되거나 등록공고된 다른 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원의 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에는 그 발명에 대해서는 확대된 선출원 위반으로 특허를 받을 수 없다. 외국어 국제특허출원의 원문(국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면)이 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면으로 간주되기 때문에(法 200의2①②) 확대된 선출원을 적용할 때 원문 기준으로 다른 출원의 지위를 인정하고 있다.¹⁴⁰⁾

3) 다만 출원인이 국내서면제출기간에 발명(고안)의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하된 것으로 보는 국제특허출원(국제실용신안등록출원)은 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위를 갖지 아니한다(法 29⑦). 따라서 외국어 국제특허출원(국제실용신안등록출원)은 최종 국어번역문이 확정되기 전까지는 확대된 선출원 적용을 보류하여야 한다. 물론, 국어로 국제특허출원한 경우에는 국제특허출원이 우리나라의 특허출원(法 199①)이고, 국제공개가 국내공개로 간주(法 207②)되기 때문에 국내단계로 진입 여부와 상관없이 확대된 선출원이 인정된다.

140) 심사 실무상 외국어 명세서 및 도면과 그 번역문의 내용은 일치할 개연성이 매우 높으므로, 일반적으로 국어번역문을 가지고 확대된 선출원 위반 여부를 판단한다. 다만 번역문이 원문과 다르다는 의문이 생긴 경우에는 원문과 대조하여 확대된 선출원 위반 여부를 판단한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5518-5519면 참조).

【표 2-2】 선출원주의와 확대된 선출원의 비교

요 건			선출원주의		확대된 선출원					
서	의 의		동일한 발명에 대하여 둘 이상의 특허출원이 있는 때에 가장 먼저 특허출원한 자에게 특허를 허여하는 주의를 말한다.		특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 특허출원 또는 실용신안등록출원하여 그 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에는 특허를 받을 수 없도록 선출원의 지위를 부여하는 것을 말한다.					
	취 지		발명조기공개, 중복특허금지, 권리의 안정성		선출원주의의 단점 보완, 출원공개제도와 심사청구제도의 효율적 운영, 방어출원의 감소					
판단	기 준	주 체 적	판단자		심사단계 → 심사관, 심판단계 → 심판관		합의제, 법원 → 법관			
			발명자·출원인 동일		동일 여부와 관계없이 적용		발명자나 그 출원할 때의 출원인이 동일한 경우에는 부적용			
		객 체 적	범 위		청구항별로					
			대 상		선·후출원의 청구범위		다른(선) 출원의 최초 명세서·도면과 그(후)출원의 청구범위			
			선출원 보정	삭제	선출원의 지위 불인정		최초 명세서·도면에 기재되어 있으면 인정			
				추가	선출원의 지위 인정		최초 명세서·도면에 기재되어 있지 않으면 불인정			
			분할·분리·변경출원		원출원일로 출원일이 소급		분할·분리·변경출원이 다른 출원에 해당하는 경우 분할·분리·변경출원일을 기준으로 확대된 선출원을 적용			
			무효·취하·포기·특허거절결정 확정				무효·취하·포기·특허거절결정 확정 전 출원공개·등록공고되었으면 확대된 선출원을 적용			
			무권리자		선출원의 지위 불인정 (단, 협의 불성립 등으로 특허거절결정이 확정되면 선출원의 지위 인정)		무권리자의 출원이 출원공개·등록공고되었으면 제3자에 대해서는 확대된 선출원을 적용하나, 정당한 권리자에 대해서는 발명자가 동일하므로 확대된 선출원을 부적용			
		시 기 적	동일출원		협의제, 협의명령에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 특허 가능		적용하지 아니함(· 그 특허출원일 전의 해석결과)			
			출원공개·등록공고		출원공개·등록공고 여부와 관계없이 적용		다른 출원이 출원공개·등록공고된 경우에만 확대된 선출원을 적용			
		방 법			동일성 판단					
흡 결 효 과	등록 전		거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)							
	등록 후		특허취소사유(法 132의2①), 특허무효사유(法 133①)(단, 등록특허공보에 게재된 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청(法 132의2) 불가)							

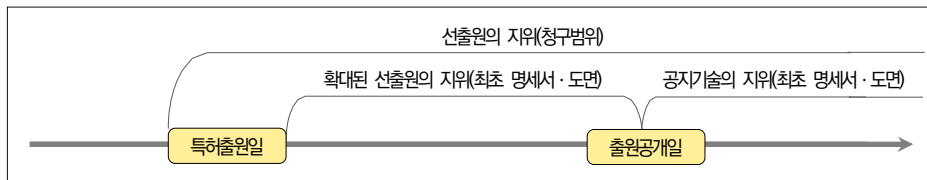
I. 제29조 및 제36조의 판단의 비교

판 단	산업상 이용가능성	신규성	진보성	확대된 선출원	선출원주의
판단 기준	주제적	심사관, 심판관, 법관	- 심사관, 심판관, 법관 - 통상의 기술자의 입장에서 판단	심사관, 심판관, 법관	
	객체적	x vs 청구범위	공지기술(1개) vs 청구범위	다른 출원의 최초 명세서 또는 도면 vs 그 출원의 청구범위	선출원의 청구범위 vs 후출원의 청구범위
	시기적	법규정 x (실무상 출원 시)	특허출원 전(출원 시)	- 그 특허출원일 전 다른 출원-역일주의 (단, 동일자 적용 x) - 그 특허출원 후 다른 출원의 공개-시각주의	- 역일주의 - 이일: 최선출원 - 동일: 협의제 협의명령
	지역적	x	국제주의	국내주의(속지주의 원칙)	
판단방법	정확한 기준 x	동일성	용이성	동일성	

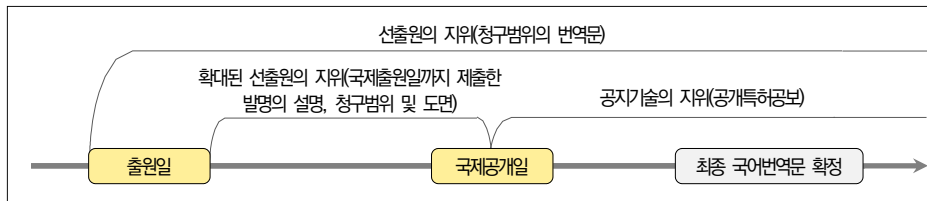
II. 출원발명의 등록금지적 효력

다른 출원 (인용대상)의 지위	공지기술의 지위	선출원의 지위	확대된 선출원의 지위
시기	출원공개 또는 설정등록된 후부터 발생(法 216)	출원한 날부터 발생	출원한 날의 다음 날부터 발생하여 출원공개 또는 등록공고 전까지 인정
범위	최초 명세서 또는 도면	청구범위	최초 명세서 또는 도면
지역	국제주의	국내주의	국내주의
판단	동일성과 용이성 판단	동일성 판단	동일성 판단
비고		출원이 무효, 취하, 포기, 거절결정 확정(단, 협의의 불성립으로 거절결정 확정 제외)된 경우나 무권리자 출원의 경우 부적용	발명자나 그 특허출원할 때의 출원인 동일의 경우 부적용

1. 통상의 국내출원의 경우

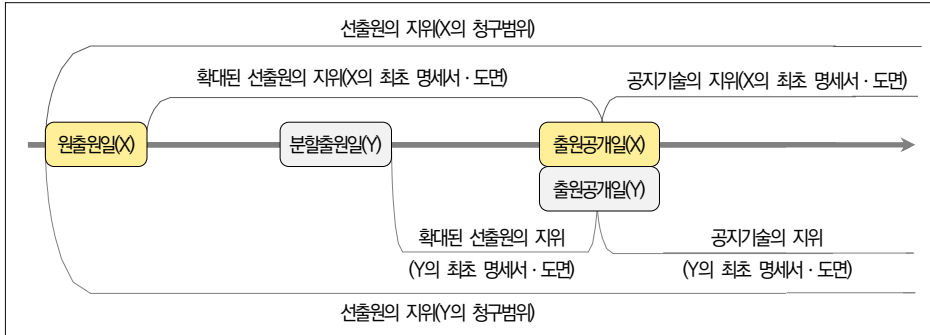


2. 외국어국제특허출원의 경우

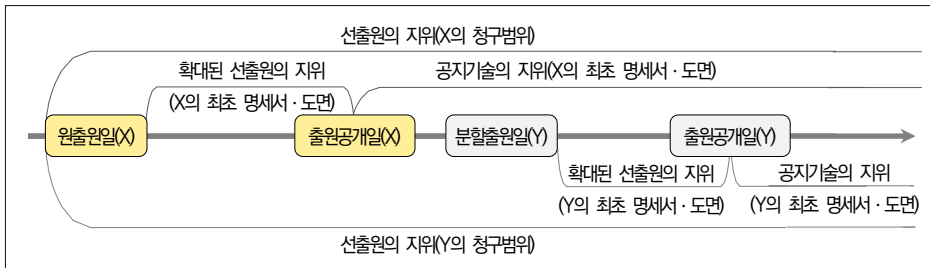


3. 분할출원, 분리출원의 경우

(1) 원출원의 출원공개 전 분할출원, 분리출원한 경우

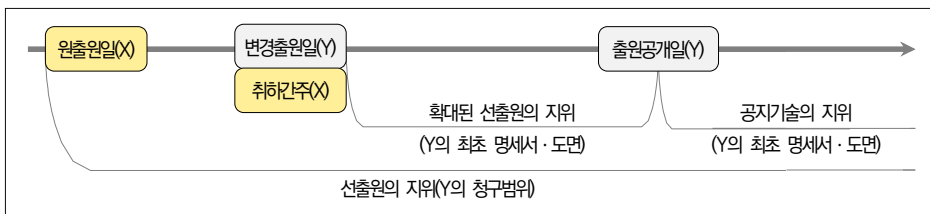


(2) 원출원의 출원공개 후 분할출원, 분리출원한 경우

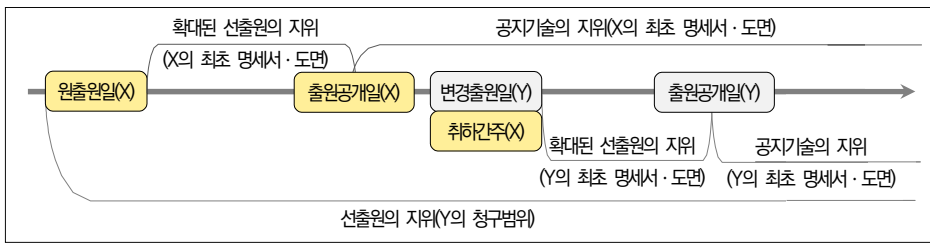


4. 변경출원의 경우

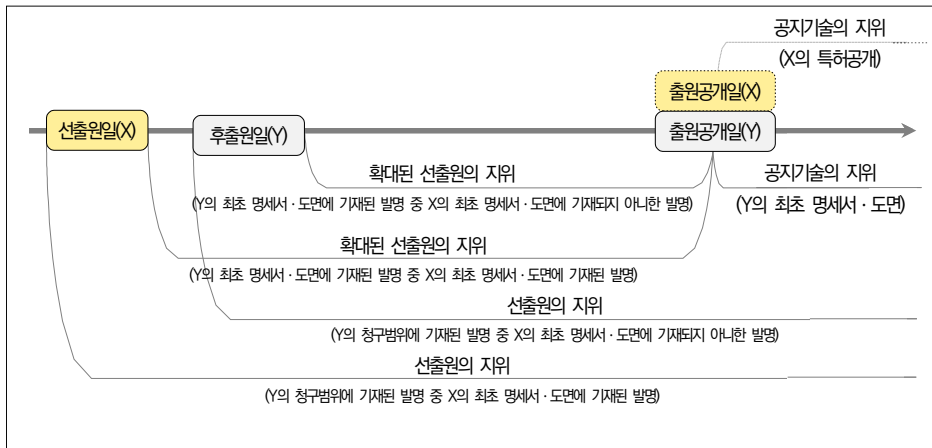
(1) 원출원의 출원공개 전 변경출원한 경우



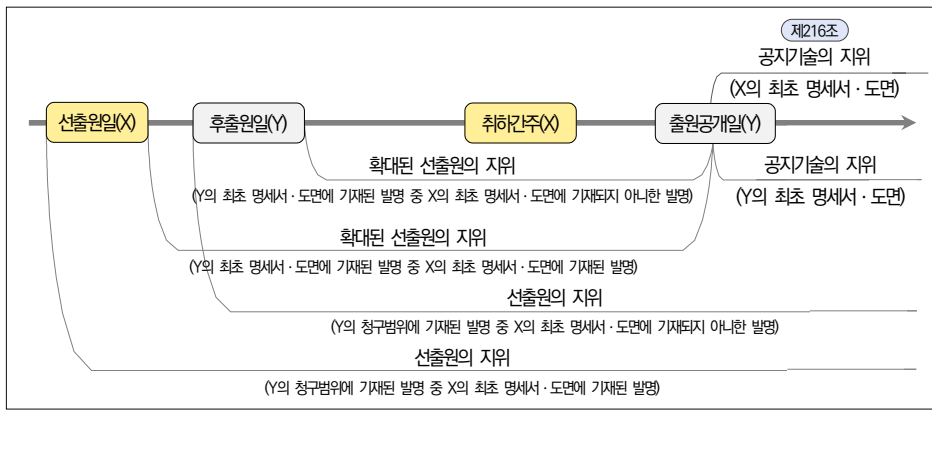
(2) 원출원의 출원공개 후 변경출원한 경우



5. 조약우선권주장출원의 경우



6. 국내우선권주장출원의 경우



제3장

특허를 받을 수 없는 발명

제1절 불특허발명

제32조 【특허를 받을 수 없는 발명】

공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서는 제29조제1항에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1) 특허법은 특허를 허여하는 것이 사회·공익적, 국가의 산업정책적인 면에서 적합하지 아니한 경우가 있으므로 특허를 받을 수 없는 발명에 관하여 명문 규정(法 32)을 두어 특허제도를 둘러싼 사익과 공익의 조화를 꾀하고 있다.

2) 특허법의 목적은 국가산업발전에 있으므로 「특허를 받을 수 없는 발명」에 대한 규정도 그 국가의 산업발전 정도나 과학기술수준에 따라 차이가 있다. 기술선진국으로 갈수록 완화되어 상당한 범위까지 특허를 인정하는 반면 후진국일수록 자국의 산업보호를 위해 불특허사유를 광범위하게 인정한다. 그러나 1997년에 체결된 WTO/TRIPs 제27조제2항에 의하면 각 당사국은 i) 인간, 동물 또는 식물의 생명 또는 건강의 보호를 포함하여 필요한 경우, ii) 공공질서 또는 공서양속을 보호하거나, 또는 iii) 환경에의 심각한 피해를 회피하기 위한 경우를 제외하고는 불특허사유로 규정할 수 없도록 하였는바, 선진국과 후진국 사이에 이러한 불특허사유의 차이는 없어질 것으로 예측된다.

3) 우리나라는 1987년 특허법 개정시 의약 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 하나의 의약을 조제하는 방법발명, 화학물질발명 및 그 용도발명을, 1990년 특허법 개정시 음식물 또는 기호물의 발명을, 1995년 특허법 개정시 WTO/TRIPs 제27조제1항을 반영하여 원자핵 변환방법에 의하여 제조될 수 있는 물질의 발명을 불특허사유에서 삭제하여 특허대상의 범위가 확대되었다.

II. 공서양속에 어긋날 우려가 있는 발명

1. 의의 및 취지

공공의 질서, 선량한 풍속에 어긋난 발명, 즉 소위 공서양속 위반의 발명은 특허를 인정하지 아니한다. 여기서 「공공의 질서」는 국가사회의 일반적 이익을 의미하고, 「선량한 풍속」은 사회의 일반적·도덕적 관념을 의미한다. 이처럼 공서양속에 어긋난 발명에 대하여 특허를 허여해서는 안 된다는 것은 사회 통념상 당연하다.

2. 구체적인 예

(1) 일 반

일반적으로 i) 女體에 해를 미칠 염려가 있는 피임기구와 같이 일면 발명이 어떤 유용한 효과가 인정되더라도 보통의 경우 이를 사용할 때 공서양속을 해할 염려가 있는 경우, ii) 아편 흡입기구, 위조지폐 제조기구와 같이 발명의 본래 목적이 사회질서 등을 해할 염려가 있는 발명으로서 실제 해하지는 않더라도 해할 개연성이 있는 경우, iii) 발명의 공개 또는 사용이 공서양속에 반하는 경우 등이 있으며, 문제가 되는 경우는 다음과 같다.

(2) 인체를 구성요소로 하는 경우

인체를 직접적인 구성요소로 하지만 비의료업인 경우와 인체를 간접적인 구성요소로 하는 경우의 발명은 산업상 이용가능성이 인정된다. 그러나 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상하거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명¹⁴¹⁾ 및 인간의 존엄성을 손상하는 결과를 초래하는 발명은 공서양속에 반하여 특허가 부여되지 아니한다. 예를 들어 의료업 중 사람의 피부 등을 일부 채취하여 환자의 상처를 치유하는 것¹⁴²⁾이나, 뼈의 이식¹⁴³⁾ 등 인체로부터 분리된 것을 처리하는 방법이나 비의료업 중 모발의 웨이브방법¹⁴⁴⁾은 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이 아니므로 공서양속에 반하는 발명에 해당되지 아니한다.¹⁴⁵⁾ 다만 식품관련발명의 경우 질병치료 등의 특수한 목적이 아닌 일상적 섭취를 위한 것임을 고려해볼 때, 인체 일부 또는 인체의 배출물을 식품의 재료로써 사용하는 것은 윤리적으로 허용될 수 없으므로 불인정한다.¹⁴⁶⁾

141) 특허법원 2001. 8. 17. 선고 2000허6387.

142) 예를 들어 사람의 혈액·태반을 원료로 하는 의학의 제법발명, 사람의 혈액·태반을 원료로 하는 화장 재료는 공서양속에 반하는 발명으로 취급되지 아니한다. 그 이유로 태반의 예를 들자면, 태반은 임신에 의하여 새로 만들어지는 하나의 내분비 장기라 생각되지만, 태반 자체는 그 기능을 끝낸 후 자연히 배출되는 것으로 이러한 자연배출 후의 것이라면 이것을 사용하여도 특별히 인간의 존엄성을 훼손하게 하는 것이라고는 보이지는 않기 때문이다.

143) 이 사건 출원발명의 구성요소인 인간의 뼈는 다른 물(物)의 제조를 위한 원료 등으로 사용되는 것이 아니라 인간에게 직접 이식되기 위해 사용되는 것이고 사람의 사후에 인체의 일부인 장기를 기증받아 타인에게 이식되는 것이 사회적으로 통상적으로 행해지고 있는 상황에서 인체 조직의 일부인 뼈의 이식만이 다른 장기의 이식과 달리 공서양속에 위반된다고 할 수는 없다(심판번호 2000원917).

144) 특허법원 2004. 7. 1. 선고 2003허6104.

145) 김준학, “특허를 받을 수 없는 발명”, 지적재산21, 2004년 9월, 58-59면.

(3) 성(보조)기구의 경우

특허발명의 대상인 물건이 i) 노골적으로 사람의 특정 성적 부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 음란한 물건에 해당하거나, ii) 발명의 실시가 공연한 음란행위를 필연적으로 수반할 것이 예상되거나(따라서 공연성이 인정되지 않는 사적인 공간에서 음란행위가 수반되는 것이 예상되는 경우는 제외된다고 할 것이다), iii) 이에 준할 정도로 성적 도의 관념에 반하는 발명의 경우 공서양속에 반하여 특허를 받을 수 없다.¹⁴⁷⁾

(4) 본래 목적 이외의 목적에 사용할 경우

공서양속 위반은 본래 목적으로 발명을 사용하는 경우뿐만 아니라 발명의 목적과 구성으로 보아 누구든지 공서양속에 위반되게 할 다른 목적에 사용될 가능성을 극히 쉽게 발견할 수 있고 또한 그와 같이 사용될 우려가 다분히 인정되는 경우에 해당된다고 할 것이다.¹⁴⁸⁾ 다만 본래

146) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3602면.

147) 대법원 2015. 4. 9. 선고 2015후31 심리불속행기각(원심판결은 특허법원 2014. 12. 4. 선고 2014허4555) 판결에서는 ① 특허법 제32조의 ‘선량한 풍속’은 불확정 개념으로 위 나.항에서 본 바와 같이 형법, 관세법, 상표법 등 다수의 법령에 포함되어 있는바, 비록 형법, 관세법 등은 특허법과 달리 규제법의 영역이기는 하나, 대법원은 형법, 관세법 등에서의 ‘음란’의 의미에 대하여 같은 취지로 해석하고 있고, 그 구체적인 의미에 대하여 “사회통념상 일반 보통인의 성욕을 자극하여 성적 흥분을 유발하고 정상적인 성적 수치심을 해하여 성적 도의관념에 반하는 것”이라고 일관되게 해석하고 있는바(성적 도의관념에 반한다는 것은 결국 선량한 풍속에 반한다는 것과 같은 의미로 보인다), 같은 용어가 여러 법령에 사용된 경우 입법 취지를 고려하여 달리 해석해야 할 특별한 사정이 없는 한 관련 법령과의 조화로운 해석을 위하여 통일적으로 해석되어야 할 것인 점, ② 특허법에서는 “발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다”라고 규정하고 있는바(제1조), 성기구 등 성 관련 발명이 기술의 발전을 촉진할 수 있고 관련 산업발전에 이바지할 수 있다면, 성기구 등 성 관련발명에 대하여 특허등록을 허용하더라도 위와 같은 특허법의 입법취지에 반한다고 단정하기 어려운바(헌법 제22조에서는 모든 국민은 학문과 예술의 자유를 갖고, 발명가·과학기술자의 권리는 법률로써 보호하도록 규정하고 있고, 특허법은 이와 같은 헌법의 취지에 따라 제정된 법률로 보아야 할 것이므로, 학문과 예술의 자유 및 발명가·과학기술자의 권리는 헌법에서 유래하는 권리로 볼 것이다), 그렇다면 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 없어야 한다는 취지의 특허법 제32조를 다른 법령과 달리 해석해야 할 특별한 사정으로 보기 보다는 성 관련 발명에서 특허법에 의한 보호를 할 것인지의 한계를 정하는 소극적 의미로 작용한다고 보는 것이 합리적인 해석이라고 할 것인 점, ③ 성기구 등 성 관련 기술분야에서도 발기부전치료제, 조루치료제 등 신체적 장애가 있는 사람들에게 필요한 의약·물건 등에 관한 발명에 대하여 특허를 부여하는 것이 위와 같은 특허법의 입법취지에 반한다고 단정하기 어려운 점, ④ 특허법 제32조가 도덕적 차원에서 발명을 규제하기 위한 조항이라고 보기는 어려운 점(따라서 피고 주장과 같이 무익하게 성욕을 흥분시키거나 성기 등에 필요 이상의 자극을 주어 성감을 증대시키기만 하면 ‘선량한 풍속’을 문란하게 할 염려가 있는 경우에 해당한다고 단정하기 어렵다), ⑤ 남용의 우려가 있거나 청소년을 보호해야 한다는 등을 이유로 발명의 실시를 제한할 필요성이 있는 경우에는 시대의 변화에 따라 탄력적으로 개별 법령을 제·개정함으로써 충분히 그와 같은 필요에 효율적으로 대처할 수 있을 것으로 보이는 점(성기구 등 성관련 물건으로부터 청소년을 보호해야 할 필요성이 있다는 등의 공익적 목적의 실현은 청소년보호법(제2조, 제28조, 제58조), 학교보건법(제6조, 제19조) 등 개별 법령의 규제에 의하여 달성할 수 있을 것으로 보인다)을 그 근거로 하고 있다.

148) 심판번호 98원3860.

목적 이외의 목적에 변칙적이거나 부당하게 사용한 결과 사회질서 등을 해할 염려가 있는 경우¹⁴⁹⁾ 등은 적용되지 아니한다고 봄이 타당하다.

III. 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명¹⁵⁰⁾

1. 의의 및 취지

특허법은 공서양속에 반하는 발명 이외에 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 대해서도 특허를 받을 수 없는 발명으로 규정하고 있다. 다만 특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하기 위한 법률이다. 따라서 현재 안전성·품질면에서 다소 뒤지는 발명일지라도 금후의 발명을 자극하고 촉진하여 기술적 진보를 가져오는 기초나 유인으로 작용할 수 있으므로 장려되어야 하고, 제품의 안전성·품질을 확보하는 것은 다른 법률로써 규정할 문제이므로, 제32조 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 명백한 때에만 제한적으로 적용하여야 한다.¹⁵¹⁾

2. 구체적인 예

(1) 발명의 실시로 필연적으로 공중의 위생을 해하는 경우

발명의 실시로 필연적으로 공중의 위생을 해하는 경우 그 발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명에 해당되어 특허를 받을 수 없다. 예로서 정부고시에서 인체 또는 환경에 위해성이 크다는 이유로 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지한 물질(이하 ‘금지물질’이라 한다)이 발명의 실시를 위해 필연적으로 제조·활용되는 발명인 경우를 들 수

149) 예를 들면 과일칼을 살상용으로 사용하는 경우를 말한다. 또 다른 예로는 당해 발명에 관계되는 기구(병고)가 순수한 오락용으로 제공되는 것을 목적으로 한 것이고, 도박행위 그 밖의 부정행위용으로 제공하는 것을 목적으로 한 것이 아님이 명세서의 기재 내용상 분명하고, 또한 당해 발명의 내용에 비추어 당해 장치를 순수한 오락용으로 제공하고 부정행위용으로 제공하지 않는다는 것이 가능하다고 인정되는 경우에는 당해 장치가 부정행위의 용도로 제공될 수 있다는 이유만으로 공서양속을 문란하게 할 염려가 있다고는 할 수 없다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3602면).

150) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3603-3606면.

151) 특허법 제32조에 따라 특허가 거절된다고 하더라도 타 법령에서 발명의 실시를 금지하고 있지 않은 이상 해당 발명의 실시 자체를 금지할 수 있는 효과가 전혀 없기 때문에, 특허법 제32조의 기능은 사회적으로 바람직하지 않다고 평가되는 기술에 대한 독점권을 얻어 오히려 바람직하지 않은 발명으로 더 많은 이익을 얻거나 그와 같은 독점 이익을 누리기 위하여 바람직하지 않은 발명에 연구개발이 유인되는 것을 막고, 일반 대중에 의하여 특허제도가 폄하되고 특허 심사에 관여하는 국가기관의 평판이 훼손되는 것을 방지하는 데 있다. 따라서 그 경우 특허법 제32조의 “공중의 위생을 해칠 우려”란 발명에 유익한 목적이 전혀 없이 오로지 인체에 위해만을 야기하는 것이 청구항 자체로 자명한 경우로 매우 좁게 해석하는 것이 타당하다(이원복, 「특허법 제32조 “공중의 위생을 해칠 우려” 규정의 기능과 해석」, 사법 제56호, 사법발전재단, 2021년 여름호, 159-200면 참조).

있다. 한편 그 위해가 필연적이지 않거나 발명의 본래 목적에서 벗어난 실시로 인한 것이면 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명이 아니다.

(2) 부작용으로 인한 경우

발명 본래의 유익한 목적은 달성되지만, 그 결과 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 경우에도 그 해를 제거하는 수단이 존재한다면, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것으로 보지 않는다. 또한 그 해를 제거하는 수단이 없더라도, 그 효과의 유익성과 위해성을 비교 형량하여 그 실시로 인한 부작용이 본래의 유익한 목적에서 허용될 수 있는 수준이라면 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것으로 보지 아니한다.

(3) 제조방법의 경우

발명이 제조방법인 경우 그 방법 자체가 공중위생을 해칠 우려가 있는지를 판단하여야 할 뿐만 아니라 그 제조방법의 목적생성물이 공중위생을 해칠 우려가 있는지도 고려하여야 한다.

(4) 학술서에 유해하다고 기재된 경우

발명이 학술서에서 유해하다고 되어 있는 경우라도 국내외 관련 관청으로부터 제조 또는 사용허가를 받았으면 해당 학술서의 기재만으로 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 경우에 해당한다고 할 수 없다.¹⁵²⁾

IV. 특허발명의 판단

1. 판단시기

공서양속의 개념은 시대 및 사회변화에 따라 변화하는 동태적(動態的) 개념이므로, 출원 시에는 비록 공서양속에 반한다고 하더라도 「특허여부결정 시」에 사회통념적 기준으로 공서양속에 반하지 않게 된 경우에는 특허를 허여하는 것이 타당하다.¹⁵³⁾

152) 식품의약품안전처로부터 제품품목허가를 받은 실시제품인 ‘알비스정’을 청구하는 경우에, 알루미늄이 더 많이 용출되어 체내 흡수가 증가되고 알루미늄의 흡수 증가가 질병의 원인이 될 수 있다는 학술서가 있더라도 이는 학술적 가능성을 제시한 것일 뿐이고, 대부분 의약품은 어느 정도의 부작용을 가지고 있고, 의약품의 약효와 부작용을 비교해 볼 때 그 약효가 부작용을 감수할 만한 유용성을 가지고 있다고 판단될 경우에 의약품으로 허용되므로, 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명이라 할 수 없다(특허법원 2011. 11. 24. 선고 2011허4240).

153) 이에 대한 명문규정은 없으나 국내우선권주장출원의 소급효를 나타내는 제55조제3항에서 소급효가 인정되는 법 규정을 제한열거적으로 나열하고 있는데, 여기서 제32조를 제외하고 있는 것으로부터 간접적으로 파악할 수 있다. 다만 최근 특허법원 2014. 12. 4. 선고 2014허4555 판결에서는 판단시기를 특허출원한 때, 즉 특허출원 시라고 판시하고 있다.

2. 판단방법

(1) 심사절차 내에서 판단

공서양속 및 공중의 위생에 위반되었는지는 특허출원에 대한 심사절차에서 판단하여야 한다. 따라서 타법에 의하여 실시에 대한 인·허가 등을 받았다고 하여 특허를 받을 수 있는 것은 아니고,¹⁵⁴⁾ 인·허가 등을 받지 못하였다고 하여 특허를 받을 수 없는 것은 아니다.¹⁵⁵⁾ 즉 특허된 상품 또는 특허된 공정에 의하여 생산된 상품의 판매가 국내법이나 계약이나 제한을 받고 있음을 근거로 하여 특허의 부여를 거절하거나 무효로 할 수 없다(파리조약 4의4).¹⁵⁶⁾ 이는 현재 판매가 제한되어 있다고 하더라도 판매 제한품 등에 대한 사고방식의 변화로 인하여 향후 판매 제한의 해제가 가능하기 때문이다.

(2) 합리적 의심이 드는 경우의 판단¹⁵⁷⁾

1) 심사관은 청구항에 기재된 발명이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명인지 합리적인 의심이 들 때는 제32조 위반으로 거절이유를 통지한 후,¹⁵⁸⁾ 출원인의 의견서 및/또는 실험성

154) 철분이 30 내지 50중량% 함유되어 이것이 식품으로서 기능을 갖는다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 복용량에 대한 구체적인 언급이 없으며 철분분말을 단독으로 배합하였고, 그 혼합비율 역시 너무 과다하여 인체에 유해한 결과를 초래하리라는 것을 일반적인 상식을 가진 자라면 예측할 수 있어서 안정성 시험성적표를 제시하여야 함에도 이를 제출하지 아니한 본원 발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명으로 인정되고, 특정한 한 사람이 출원발명의 제품을 복용한 결과 아무런 위해가 없었다는 사실만으로 출원발명이 일반 공중의 위생을 해할 우려가 없다고 단정할 수는 없다. 또한 특허출원이 공중위생을 해할 우려가 있는지 여부는 특허절차에서 심리되어야 할 것이고 이것이 단순히 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 식품위생법 등 관련제품 허가법규에서만 다룰 문제가 아니다(대법원 1991. 11. 8. 선고 91후110).

155) 음식물 쓰레기를 분쇄함과 동시에 미생물을 함께 투입하여 싱크대 배수구를 통하여 배출하는 방법을 청구하는 경우에, 비록 환경부고시에서 음식물 찌꺼기 등을 분쇄하여 오수와 함께 배출하는 분쇄기의 판매와 사용을 금지하고 있지만, 위 고시는 우리나라의 하수도관 설치 현황 등을 고려할 때 음식물 쓰레기를 분쇄하여 하수도관으로 그대로 배출하는 경우 하수도 관내에 분쇄물질이 퇴적하여 악취가 발생하는 문제를 방지하기 위하여 제정된 것에 불과하다. 위와 같은 법 규정은 시대의 흐름에 따라 그리고 하수처리시설의 확장 내지는 신기술 개발 등에 의하여 얼마든지 변경될 수 있으며, 음식물 쓰레기를 분쇄하여 하수도를 통해 배출한다고 하여 반드시 공중의 위생을 해할 우려가 있다고 볼 만한 근거가 없으므로, 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명이라 할 수 없다(심판번호 2010당2102)

156) WTO/TRIPs 협정 제27조에서도 실시가 우리나라에서 금지되었다는 이유만으로 특허대상에서 제외해서는 아니된다고 규정하고 있다.

157) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3603-3605면.

158) 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명이라는 거절이유를 통지할 때는 위해성에 의심을 갖게 된 이유를 구체적으로 기재하며, 이때 심사관은 공중의 위생을 해칠 우려가 자명한 경우를 제외하고는 거절이유의 근거가 되는 자료를 첨부하거나 출원인이 쉽게 그 자료를 확인할 수 있도록 해당 정보를 제공한다. 이에 대하여 출원인은 객관적인 증명자료 등을 제출하여 안전성 또는 위해 제거가능성을 증명하거나 청구항에서 위해 요소를 삭제하는 등으로 거절이유를 해소할 수 있다.

【예1】금속입자 표면에 Ag를 함유한 무기 세라믹 코팅층이 형성되어 있는 항균성을 갖는 환원수 제조용 금속입자를 청구하는 경우에, 금속입자 표면에 음용수가 접촉하면 환원반응 등에 의하여 Ag이 용출되어 인체에 유해한 결과를 초래하리라 예측되므로, 심사관은 거절이유를 통지할 수 있다. 이에 대하여 출원인이 음용수에 Ag가 검출되지 않았다는 공인인증기관의 실험성적서를 제출하면 거절이유가 해소된 것으로 본다[2007원11674].

【예2】광석 A가 포함되어 있는 침대를 청구하고 있는 출원에 대해서, 천연 방사성 핵종이 포함된 것으

적증명서 등의 제출을 기다릴 수 있다. 출원인의 반론에 의하여 거절이유를 유지할 수 없는 경우에는 거절이유가 해소되나, 합리적 의심이 해소되지 않을 때는 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명이라는 이유로 거절결정할 수 있다. 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명인지 합리적인 의심이 드는 경우에는 해당 발명이 i) 금지물질을 포함하는 경우 또는 ii) 위해성이 널리 알려진 물질을 포함하고, 그 발명의 실시가 공중의 위생에 필연적으로 위해를 가할 것으로 명백하게 예측되며, 실시로 인한 부작용이 유익한 목적에서 허용될 수 있는 수준을 넘어섬에도 그 해를 제거하는 수단이 마땅히 알려진 바 없는 경우 등¹⁵⁹⁾이 있다.

2) 합리적인 의심이 드는 경우 외에도, 심사관은 청구항에 기재된 발명이 일상생활과 밀접한 관련이 있는 소위 생활밀착형 제품에 관한 발명으로서 위해성이 널리 알려진 물질을 포함하고 있어, 그 발명의 실시가 공중의 위생에 위해를 가할 가능성이 있는 것으로 의심이 드는 경우¹⁶⁰⁾에는 그 근거자료(언론보도자료, 논문 등)를 첨부하여 제32조 위배로 거절이유를 통지할 수 있다. 한편 위해성이 알려진 물질이라 하더라도 생활용품이 아니라 산업용으로 사용되는 경우¹⁶¹⁾에는 이를 적용하지 아니한다.

V. 불특허발명의 법적취급

1. 출원공개의 예외

특허출원은 출원공개를 할 당시에 지식재산처에 출원 계속 중이어야 한다. 다만 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 특허출원이 출원 계속 중이라 하더라도 출원공개가 되지 아니한다(令 19③).

2. 거절이유 등

불특허발명(法 32)에 해당하면 등록 전에는 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)에 해당하며, 등록 후에는 특허무효사유(法 133①)에 해당한다.

로 알려져 있는 광석 A에 장기간 노출되면 인체에 유해한 결과를 초래할 것으로 의심이 드는 경우에, 심사관은 거절이유를 통지할 수 있다. 이에 대하여 출원인은 광석 A를 청구항 등 명세서에서 삭제하면 거절이유가 해소된 것으로 본단(신체에 착용하거나 장시간 밀착되어 사용되는 제품에 모나자이트 등 원료물질을 사용하는 경우에는 안전기준범위와 상관없이 특허법 제32조 위반으로 거절이유통지를 하고, 삭제보정한 경우에 한해 거절이유를 해소한 것으로 한다).

159) 예를 들어 금지물질로 지정된 DDT를 포함하는 살충제의 제조방법, PHMG 인산염 또는 PGH를 포함하는 가습기 살균제 조성물 등이 있다.

160) 예를 들어 모나자이트를 포함하는 침대가 이에 해당한다.

161) 예를 들어 모나자이트를 포함하는 광석으로부터 희토류를 추출하는 방법이 이에 해당한다.

제2절 국방상 필요한 발명

제41조 【국방상 필요한 발명 등】

- ① 정부는 국방상 필요한 경우 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만, 정부의 허가를 받은 경우에는 외국에 특허출원을 할 수 있다.
- ② 정부는 특허출원된 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대해서는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.
- ④ 제2항에 따라 특허하지 아니하거나 수용한 경우에는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다.
- ⑤ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다.
- ⑥ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다.
- ⑦ 제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 및 비밀취급의 절차, 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 수용, 보상금 지급의 절차, 그 밖에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제106조 【특허권의 수용】

- ① 정부는 특허발명이 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허권을 수용할 수 있다.
- ② 특허권이 수용되는 경우에는 그 특허발명에 관한 특허권 외의 권리는 소멸된다.
- ③ 정부는 제1항에 따라 특허권을 수용하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 한다.
- ④ 특허권의 수용 및 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제229조의3 【외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령 위반죄】

제41조제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

[본조신설 2025. 1. 21.]

제230조 【양벌규정】

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조제1항, 제228조, 제229조 또는 제229조의3의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2025. 1. 21.>

1. 제225조제1항의 경우: 3억원 이하의 벌금
2. 제228조 또는 제229조의 경우: 6천만원 이하의 벌금
3. 제229조의3의 경우: 1억원 이하의 벌금

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1) 「국방상 필요한 발명」이란 국가안보와 관련되는 발명으로서 방위산업분야의 발명을 말한다. 정부는 국방상 필요한 발명의 경우 외국에의 특허출원을 금지하거나 비밀취급명령을 할 수 있다. 다만 WTO/TRIPs 협정내용을 국내법에 반영하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 수용은 국방상 필요한 발명으로서 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에만 할 수 있도록 제한하여 권리자의 이익을 보호해주고 있다.

2) 이와 같은 제한은 헌법 제23조의 “국민의 재산권은 보장되나 그 재산권이 공공복리를 위하여 필요한 경우에는 법률에 의하여 수용·사용 또는 제한될 수 있다”에 기인한 것이라 할 수 있다. 즉 국가 안보라는 공공복리를 도모하기 위하여 국방상 필요한 발명에 대하여 일정한 제한을 가하고 있다.

II. 외국에의 특허출원 금지 및 비밀취급명령

1. 의 의

정부는 국방상 필요한 경우 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명할 수 있다. 다만 정부의 허가를 받은 경우에는 외국에 특허출원을 할 수 있다(法 41①). 지식재산처장은 방위사업청장과 협의 후에 외국에의 특허출원을 허가할 수 있다(令 16). 한편 국방상 필요한 발명으로서 비밀취급명령을 받은 경우에는 비밀취급 해제시까지 전자문서로 제출할 수 없으며(施規 9의2③), 출원공개 또는 등록공고를 보류하여야 하고, 비밀취급이 해제된 때에는 지체없이 출원공개 또는 등록공고를 하여야 한다. 다만 그 특허출원이 설정등록된 경우에는 출원공개를 하지 아니한다(法 64③, 87④).

2. 보상금의 지급

정부는 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실에 대해서는 정당한 보상금을 지급하여야 한다(法 41③). 특허출원인은 외국에의 특허출원이 금지됨에 따른 손실 또는 비밀로 취급됨에 따른 손실에 대한 보상금을 방위사업청장에게 청구할 수 있다. 이 경우 특허출원인은 보상금청구서와 손실을 증명할 수 있는 증거자료를 제출하여야 한다. 한편 방위사업청장은 특허출원인으로부터 보상금청구를 받은 경우에는 보상액을 결정하여 지급하여야 하며, 필요한 경우에는 지식재산처장과 협의할 수 있다(令 14).

3. 비밀취급절차 및 비밀에서의 해제 등

(1) 비밀취급절차

① 비밀분류기준의 선정

지식재산처장은 국방상 필요하여 비밀로 분류하여 취급하여야 하는 발명의 선별에 필요한 비밀분류기준을 방위사업청장과 협의하여 정하여야 한다(令 11).

② 방위사업청장에게 조회

지식재산처장은 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자의 특허출원이 비밀분류기준에 해당되는 경우에는 방위사업청장에게 비밀로 분류하여 취급할 필요가 있는지 여부를 조회하여야 하며(令 12①). 방위사업청장에게 조회한 경우에는 그 특허출원의 발명자·출원인·대리인 및 그 발명을 알고 있다고 인정하는 자(이하 “발명자 등”이라 한다)에게 그 사실을 통지하고 보안을 유지하도록 요청하여야 한다(令 12②).

③ 방위사업청장의 회신

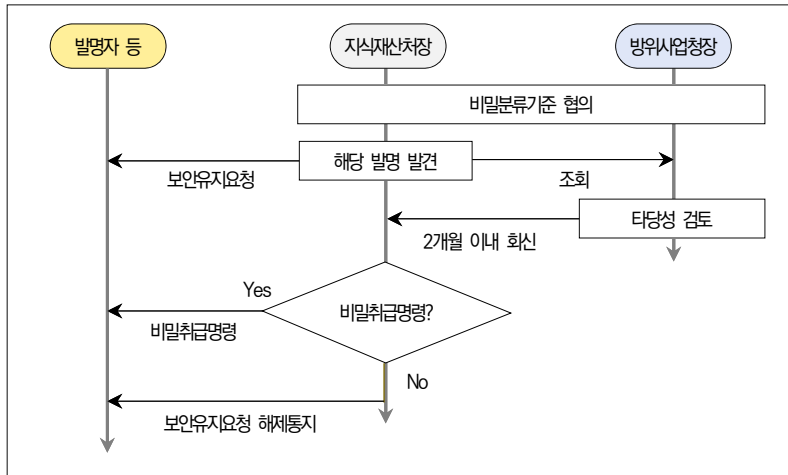
방위사업청장은 지식재산처장으로부터 비밀취급 여부를 조회받은 경우에는 2개월 이내에 회신하여야 하며, 비밀취급이 필요하다고 인정되는 경우에는 지식재산처장에게 비밀로 취급하도록 요청하여야 한다(令 12③).

④ 비밀취급명령 또는 보안유지요청 해제통지

방위사업청장으로부터 비밀로 취급하여 줄 것을 요청받은 경우에는 지식재산처장은 지체없이 보안업무규정에 따라 필요한 조치를 취하고 그 특허출원의 발명자 등에게 비밀로 분류하여 취급하도록 명하여야 하며, 비밀로 분류하여 취급할 것을 요청받지 아니하면 그 특허출원의 발명자 등에게는 보안유지 요청의 해제통지를 하여야 한다(令 12④⑤).

(2) 비밀에서의 해제 등

지식재산처장은 비밀로 분류하여 취급할 것을 명한 특허출원에 대해서는 비밀에서의 해제, 비밀보호기간의 연장 또는 비밀등급의 변경 여부를 연 2회 이상 방위사업청장과 협의하여 필요한 조치를 하여야 한다. 한편 비밀로 분류하여 취급할 것을 명령받은 발명자 등은 지식재산처장에게 비밀의 해제 또는 비밀등급의 변경이나 특허출원된 발명의 일정 범위의 공개 또는 실시의 허가를 청구할 수 있다(令 13). 이 경우 지식재산처장은 방위사업청장과 협의 후에 비밀로 취급하고 있는 발명의 일정 범위의 공개 또는 실시를 허가할 수 있다(令 16).



【그림 2-17】 비밀취급절차

4. 위반시 취급

1) 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 보고(法 41⑤), 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급에 따른 손실보상금의 청구권을 포기한 것으로 본다(法 41⑥). 특허를 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 간주하였는데 출원한 경우에는 무권리자 출원으로 취급하여야 한다.

2) 또한 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(法 229의3). 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 이를 위반하는 행위를 하면 행위자를 벌하는 외에 그 법인에게에는 1억원 이하의 벌금형을, 그 개인에게에는 5천만원 이하의 벌금형을 과한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다(法 230). 2025. 7. 22. 시행되는 개정법(법률 제20700호, 2025. 1. 21. 일부개정)에서는 i) 국방상 중요한 기술 등이 해외유출되는 것을 방지하기 위한 실효적인 조치로서 처벌 규정을 도입할 필요가 있다는 점, ii) 미국, 일본, 독일 등 주요국가에서 위와 같은 비밀취급명령 등을 위반한 자를 형사처벌하고 있어 외국 의 입법례를 참고할 필요가 있다는 점을 고려하여 형사처벌에 대한 규정을 신설하였다.¹⁶²⁾¹⁶³⁾

162) 지식재산처에 의하면, 2015년부터 2024년 9월까지 국방 관련 출원 중 비밀취급건수는 14건이며 이를 위반한 사례는 없는 것으로 확인되고 있다.

163) 박희석 수석전문위원, “특허법 일부개정법률안 심사보고서(이철규 의원 대표 발의(의안번호 2203858))”, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2024.12. 4~6면.

Ⅲ. 불특허 및 특허를 받을 수 있는 권리의 수용

1. 의 의

정부는 특허출원된 발명이 국방상 필요한 경우에는 특허를 하지 아니할 수 있으며, 전시·사변¹⁶⁴⁾ 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(法 41②).

2. 보상금의 지급

정부는 특허하지 아니하거나 수용한 경우에는 정부는 정당한 보상금을 지급하여야 한다(法 41④).

Ⅳ. 특허권의 수용

1. 의 의

정부는 특허발명이 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허권을 수용할 수 있다(法 106①).

2. 특허권 이외의 권리의 소멸

특허권이 수용되는 경우에는 그 특허발명에 관한 특허권 외의 권리는 소멸된다(法 106②). 「특허권 외의 권리」란 실시권·질권 등을 의미한다.

3. 보상금의 지급

정부는 특허권을 수용하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 한다(法 106③). 다만 질권자는 물상대위(法 123)할 수 있으므로 보상금을 지급하지 아니하여도 된다.

164) 「사변(事變)」이란 천재나 그 밖의 변고, 경찰의 힘으로 막을 수 없는 병력을 사용하는 내란, 국가 간의 선전포고 없는 전쟁 등을 의미한다.

【표 2-3】 국방상 필요한 발명 등의 취급

구 분	규 정	취 급	요 건	보 상	비 고
등 록 전	제41조 제1항	외국에의 출원금지	국방상 필요	○(法 41③)	1. 위반시 특허를 받을 수 있는 권리 포기, 보상금청구권 포기 간주(法 41⑤⑥) 2. 위반시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금형(法 229의3), 양벌규정 적용(法 230)
		비밀취급 명령			
	제41조 제2항	불특허		○(法 41④)	
		수용			
등 록 후	제106조 제1항	수용	전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요	○(法 106③)	1. 특허권 이외의 권리 소멸 (法 106②) 2. 질권자는 보상받지 못함 (∴물상대위가능(法 123))

제4장

특허를 받을 수 있는 자

제1절 출원인이 될 수 있는 자

제25조 【외국인의 권리능력】

재외자 중 외국인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 특허권 또는 특허에 관한 권리를 누릴 수 없다.

1. 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우
2. 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우
3. 조약 또는 이에 준하는 것(이하 “조약”이라 한다)에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우

[전문개정 2014.6.11.]

제33조 【특허를 받을 수 있는 자】

① 발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 다만, 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다.

② 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제44조 【공동출원】

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

출원된 발명이 특허를 받기 위해서는 출원의 객체인 발명이 특허요건을 구비하고 있음은 물론 특허를 받을 수 있는 자가 특허출원을 하여야 한다. 특허를 받을 수 있는 자가 되기 위해서, 즉 출원인이 되기 위해서는 i) 일반적인 권리의 주체가 될 수 있는 능력인 권리능력이 있어야 하며, ii) 권리능력이 있는 자라 하더라도 해당 발명에 대한 권리의 주체가 될 수 있는 권리적격이 있어야 한다.

II. 권리능력자

1. 의 의

「권리능력」이란 특허법에 의하여 부여되는 일반적인 권리·의무의 주체가 될 수 있는 법률상의 지위 또는 자격을 말한다. 특허법은 권리능력에 관하여 민법의 규정을 유추 적용하되, 외국인에 대해서는 특별히 별도의 규정을 두고 있다.

2. 내국인의 권리능력

1) 내국인인 자연인과 법인에 대해서는 재내외자를 불문하고 권리능력이 인정된다. 다만 법인은 특허법상 권리능력이 인정된다고 하더라도 발명능력이 없으므로 승계에 의해서만 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권의 권리자가 될 수 있다.

2) 청산 중인 법인에 대해서도 권리능력이 인정되는지가 문제 되는데, 법인은 비록 해산되어도 청산의 목적 범위에서는 법인격이 유지된다는 민법 제81조의 규정을 고려해 볼 때, 이 한도 내에서는 관리인의 특허법상의 권리능력을 인정하는 것이 타당하다.¹⁶⁵⁾

3) 국가는 법률에 특별한 규정은 없지만, 법인으로 의제되어 권리주체가 된다. 그러나 입법부, 사법부 및 행정각부¹⁶⁶⁾는 물론, 그 산하기관과 소속기관, 국립연구기관, 국립대학¹⁶⁷⁾ 등은 법

165) 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 의한 회생절차개시결정이 있는 때에는 채무자의 업무의 수행과 재산의 관리 및 처분을 하는 권리는 관리인에게 전속하고(제56조 제1항), 채무자의 재산에 관한 소송에서는 관리인이 당사자가 되며(제78조), 이 조항의 '재산에 관한 소송'에는 회생회사와 관련된 특허의 등록무효를 구하는 심판도 포함된다고 할 것이므로, 그러한 심판에서 회생회사에게는 당사자적격이 없고 관리인에게만 당사자적격이 있다 그럼에도 심판청구인이 당사자적격이 없는 회생 회사를 당사자로 표시하였다면 특허심판원은 심판청구서의 당사자 표시만에 의할 것이 아니고 심판청구의 내용을 종합하여 당사자를 확정하여야 한다는 점, 그리하여 확정된 당사자가 관리인이라면 당사자의 표시를 관리인으로 보정하게 한 다음 심리판단하여야 하고, 확정된 당사자가 회생회사라면 당사자적격이 없으므로 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 1995. 1. 12. 선고 93후1414 판결, 대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3371 판결, 대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다68279 판결 등 참조). 특허심판원이 이와 같은 조치를 취하지 아니한 채 당연히 회생회사를 당사자로 하여 심결을 함으로써 심결상의 당사자가 심결취소의 소를 제기한 경우에 심결취소소송의 사실심리를 담당하는 특허법원으로서의 소장의 당사자 표시만에 의할 것이 아니고 청구의 내용을 종합하여 당사자를 확정하여야 한다. 그리하여 확정된 당사자가 관리인이라면 당사자의 표시를 관리인으로 정정하게 한 다음 심리판단하여야 하고, 확정된 당사자가 회생회사라면 당사자적격이 없어 심결이 위법하다고 판단하여야 한다(대법원 2016. 12. 29. 선고 2014후713).

166) 국가, 지방자치단체, 영조물법인, 공공조합 등은 공법인으로서 민법상의 권리능력을 갖기 때문에 당사자능력이 있으나, 국가의 행정기관임에 그치는 행정청(농촌진흥청)이나 국가의 입법기관인 국회 등은 당사자능력이 없다(특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허2757). 따라서 국가기관이 출원을 하기 위해서는 그 출원인을 대한민국으로 표시하여야 한다(대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825).

167) 특허법에서는 특허출원의 주체가 될 수 있는 자나 당사자능력에 관한 규정을 따로 두고 있지 않으므로 특허권과 특허법의 성질에 비추어 민법과 민사소송법에 따라 거기에서 정하고 있는 권리능력과 당사자능력이 있는 자라야 특허출원인이나 그 심판, 소송의 당사자가 될 수 있다고 할 것인바, 이 사건 출원인인 경북대학교는 국립대학으로서 민사법상의 권리능력이나 당사자능력이 없으며 명백하므로 특허출원인이나 항고심판청구인, 상고인이 될 수 없다 할 것이다(대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825). 다만 국립대학교 자체는 권리능력이 없지만, 국립대학교 내에 설치된 산학협력재단은 별도 법인이므로 권리능력이 인정된다. 또한 국립대학이라고 할지라도 별도의 법률에 의하여 국립대학법인(예를 들어 국립대학법인 서울대학교, 인천대학교)이 된 경우에는 권리능력이 인정될 수 있다.

인격이 없으므로 특허에 관한 권리의 주체가 될 수 없다. 한편 지방자치법 제3조의 규정에 따르면 “지방자치단체는 법인으로 한다”라고 규정되어 있으므로 지방자치단체도 권리의 주체가 될 수 있다. 지방자치단체의 종류에는 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도, 시, 군 및 구가 있으며, 구의 경우에는 「특별시와 광역시의 관할구역 안에 있는 구(자치구)」에 한정된다.

3. 외국인의 권리능력

1) 특허법은 산업 입법이기 때문에 우리나라 산업발전에 이바지할 수 있는지에 따라 외국인의 권리능력을 별도로 규정하고 있다. 즉 우리나라 산업발전에 이바지할 개연성이 높은 재내자의 경우에는 권리능력을 인정하지만, 개연성이 상대적으로 낮은 재외자의 경우에는 원칙적으로 권리능력을 인정하지 아니한다.

2) 다만 재외자라 하더라도 i) 상호주의¹⁶⁸⁾에 의한 경우, ii) 조약 또는 이에 준하는 것(이하 “조약”이라 한다)에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우에 한해서는 예외적으로 권리능력이 인정된다(法 25).

3) 여기서 「상호주의」란 i) 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우 또는 ii) 대한민국이 그 외국인에 대하여 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우에는 그 외국인이 속하는 국가에서 대한민국 국민에 대하여 그 국가의 국민과 같은 조건으로 특허권 또는 특허에 관한 권리를 인정하는 경우를 말한다.

4) 「조약에 따라 특허권 또는 특허에 관한 권리가 인정되는 경우」란 i) 조약 당사국 국민 또는 ii) 당사국 국민이 아닌 자로서 당사국에 주소 또는 영업소가 있는 준당사국 국민(무국적자는 준당사국 국민에 준해서 취급함) 등을 의미한다.¹⁶⁹⁾ 이는 파리조약에 포함된 내·외국인 평등주의를 반영한 것이다.

III. 권리적격자

1. 의 의

「권리적격」이란 그 발명에 대한 권리·의무의 주체가 될 수 있는 법률상의 지위 또는 자격을 말한다. 특허법은 제33조제1항 본문에서 “발명을 한 사람 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 따라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다”라고 하여 발명자 또는 승계인이 권리적격자(정당한 권리자)임을 명확히 밝히고 있다.

168) 외국인의 권리능력에 대해서는 그 나라가 자국민에 대하여 어떠한 대우를 하는 것과 관계없이 자국민과 평등한 권리능력을 인정하는 「평등주의」와 그 나라가 자국민에 대하여 정하는 것만큼 인정하는 「상호주의」가 있다. 우리나라는 외국인 중 재외자의 권리능력에 대하여는 상호주의의 입장에 있다.

169) 대법원 1976. 4. 27. 선고 74후61.

2. 발명자

(1) 일반적인 경우

1) 특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 완성한 때 발명자(발명을 한 사람)에게 원시적으로 귀속한다(法 33①본문). 발명은 법률행위가 아닌 사실행위이므로 자연인만이 발명자가 될 수 있고, 법인은 발명자가 될 수 없다.¹⁷⁰⁾ 미성년자, 피한정후견인, 피성년후견인과 같은 행위제한능력자는 자연인이기 때문에 발명자가 될 수 있다. 한편 법인은 발명자가 될 수 없어서 원시적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 못한다. 법인이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지기 위해서는 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 승계인이 되어야 한다.

2) 최근에 인공지능(AI)이 생성한 결과물에 대하여 발명의 성립성이 인정될 때, 발명자를 누구로 해야 하는지 문제가 되고 있다. 인공지능은 알고리즘에 따라 최적의 해를 계산해내는 발명을 위한 도구이고, 자연인(사람)이 아니기 때문에 발명자가 될 수 없다고 할 것이다.¹⁷¹⁾ 이 경우 문제인식과 문제해결방안 등을 창작하고 알고리즘을 설계하여 인공지능을 학습시킨 인공지능의 조작자를 발명자로 인정해 주는 것이 적절하다고 보여진다. 이는 문제인식과 문제해결방안 등을 제시하는 것에 “기술적 사상의 창작에 실질적 기여”가 있다고 할 수 있기 때문이다.

(2) 공동발명의 경우

1) 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하며(法 33②), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 특허출원을 하여야 한다(法 44).¹⁷²⁾

170) 특허법원 2003. 7. 11. 선고 2002허4811. 발명진흥법 제2조제2호에서 직무발명의 주체를 “종업원, 법인의 임원 또는 공무원” 등 자연인으로 한정한 것도 발명자는 자연인만을 의미한다는 근거가 될 수 있다(김광남, “인공지능시대를 맞이하는 특허법상 도전과 혁신: 인공지능이 한 발명의 법적취급을 중심으로”, 저스티스 통권 182-2호, 2021, 204면).

171) 지식재산처에 따르면, 미국의 한 AI 개발자(스티븐 테일러, 출원인)가 AI를 발명자로 표시한 국제특허출원(PCT 출원)을 2021. 5. 17. 국내에 출원(진입)하면서 우리 역사상 최초로 AI가 발명자가 될 수 있는지에 대한 첫 특허심사 사례가 발생했다. 출원인이 최초의 AI 발명가라고 주장하는 AI 프로그램의 이름은 ‘다부스(DABUS)’이다. 해당 출원인 자신은 이 발명과 관련된 지식이 없고, 자신이 개발한 ‘다부스’가 일반적인 지식에 대한 학습 후 식품 용기 등 2개의 서로 다른 발명을 스스로 창작했다고 주장하고 있다. 용기의 결합이 쉽고 표면적이 넓어 열전달 효율이 좋은 식품 용기와 신경 동작 패턴을 모방하여 눈에 잘 띄도록 만든 빛을 내는 램프라는 것이 각각 발명의 핵심이다. 지식재산처는 ‘자연인이 아닌 AI를 발명자로 적은 것은 특허법에 위배되므로 자연인으로 발명자를 수정하라’는 보정요구서를 보냈고, 최종적으로 2022. 9. 28. 특허출원을 무효처분하였다(“인공지능은 발명자가 될 수 없다” 특허출원 무효처분, 지식재산처 보도자료, 2022.10.03.). 한편 이에 대해 서울행정법원을 거쳐 서울고등법원에 불복하였으나 i) 현행법상 자연인만이 발명자로 인정된다는 점, ii) 인공지능은 물건에 해당할 가능성이 높아 독자적 권리능력을 인정할 수 없다는 점, iii) 인공지능을 발명자로 인정한다고 하더라도 관련 발명이 더 적극적으로 이루어져서 산업발전에 기여할 것이라고 단정하기 어렵다는 점 등을 이유로 지식재산처의 판단을 지지하였다(서울고등법원 2024. 5. 16. 선고 2023누52088).

172) 공동발명에 대한 공동출원의 요구는 i) 공동발명자 사이에 권리의 취득 여부에 관하여 의견의 불일치가 존재할 수 있다는 점, ii) 공동발명자 사이에 권리를 둘러싼 분쟁이 일어나는 것을 미연에 방지하고자 한다는 점, iii) 특허권의 부여를 업무로 하는 지식재산처로서 각자 출원을 허용하는 경우 심사의 중복으로 인하여 행정 부담이 증가된다는 점을 반영한 것이다(최영덕, “특허권의 공동소유에 관한 법률관계”, 한국비교사법학회, 비교사법 제38권, 2007년 9월, 652면).

「공동발명」이란 2명 이상이 실질적으로 협력하여 완성한 발명을 말한다. 공동발명자가 되기 위해서는 이루는 기술적 사상의 창작에 실질적 협력하였다는 객관적 요건과 상호 협력하여 발명행위를 수행한다는 주관적 요건이 필요하다. 「실질적 협력」이란 발명의 착상단계에서 구체화하는 단계에 실질적으로 관여하는 것을 의미한다. 따라서 단순한 보조자, 관리자, 위탁자, 자본주 등은 공동발명자가 되지 못한다.

2) 공동발명의 경우 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 비율에 대해서는 특허법에 아무런 규정이 없으므로 공동발명자 사이에 특약이 없는 한 민법의 일반 원칙¹⁷³⁾에 따라 공동발명자는 공동발명자의 수에 기초하여 균등한 지분을 갖는다고 추정한다.

(3) 직무발명의 경우

종업원 등이 직무발명을 완성한 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자인 종업원 등에게 귀속하나(法 33①본문), 사용자 등은 예약승계 등을 통해 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 취득할 수 있다(發振法 10③). 공무원 등의 직무발명은 국가 또는 지방자치단체(국·공립학교 교직원의 경우 전담조직)가 승계할 수 있으며, 승계하면 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하게 된다(發振法 10②).

3. 승계인

(1) 의 의

「승계인」이란 당사자 간의 약정이나 상속, 그 밖의 일반승계에 의하여 발명자로부터 적법하게 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받은 자로서 자연인뿐만 아니라 법인도 승계인이 될 수 있다.¹⁷⁴⁾ 승계인은 특허출원 전·후를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 있으며 권리의 전부뿐만 아니라 일부도 승계할 수 있다.

(2) 승계의 증명

지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟으려는 경우에 필요하다고 인정되는 때에 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있다(施規 7①). 즉 출원인이 승계인이라는 것을 항상 증명하여야 하는 것은 아니다.

(3) 외국에의 출원권 승계 여부

특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 승계인이 외국에의 특허출원할 수 있는 권리까지 승계

173) 물건이 지분에 의하여 수인의 소유로 된 때에는 공유로 하고, 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정한다(민법 제262조).

174) 이를 도표로서 나타내면 다음과 같다.

권리능력	권리적격	발명자	승계인
	자연인	○	○
법 인		×(·발명행위가 사실행위)	○

한 것인지 문제이다. 이는 발명자와 승계인의 입장에서 모두 중요한 문제로써 긍정설¹⁷⁵⁾과 부정설¹⁷⁶⁾이 서로 대립하고 있으나 속지주의 원칙상 부정설이 더 타당시되고 있다. 따라서 승계인이 외국에서도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하기 위해서는 계약서에 이를 미리 명시해 두는 것이 필요하다.

4. 문제가 되는 경우

(1) 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원

지식재산처 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다(法 33①단서). 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원도 발명하면 자연인이기 때문에 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있으나, 특허관계 업무를 다루고 있으므로 타인의 출원내용을 모인할 가능성이 있을뿐더러, 심사관 또는 심판관으로서의 직책을 수행하고 있는 직원은 자기가 출원을 하여 자기에게 특허를 허여할 가능성도 있으므로 이러한 피해를 방지하기 위해 특허를 받을 수 없도록 하고 있다. 그러나 지식재산처 직원 또는 특허심판원 직원도 상속이나 유증에 의해서는 특허를 받을 수 있다. 이는 아무리 특허 업무의 대국민 공정성을 위한다고 하더라도 특허를 받을 수 있는 권리의 상속이나 유증까지도 못하게 하는 것은 본인이나 상속인에게 너무 가혹하기 때문이다.¹⁷⁷⁾

(2) 무권리자

① 의 의

무권리자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자를 말한다. 일반적으로 발명자가 아닌 자로서 승계인이 아닌 자가 무권리자에 해당하고, 무권리자가 특허출원하면 제33조제1항 본문에 위반되어 특허를 받지 못한다.

② 무권리자 출원의 등록금지적 효력

1) 무권리자의 특허출원은 정당한 권리자 또는 제3자의 출원과의 선출원주의 적용에 있어서 처음부터 없었던 것으로 본다. 정당한 권리자는 물론 제3자에게도 선출원의 지위가 인정되지 아니한다(法 36⑤).

175) 본래 발명은 모든 국가에서 보호되고 이용되어야 하므로, 승계인이 모든 국가에 대하여 출원할 수 있는 권리를 당연히 향유하는 것이라 한다. 또 오늘날의 기업 활동이 국제적이므로 발명 이용의 무대를 국내에 한정한다는 것은 사회통념상으로도 불합리하다는 것이다.

176) 특허법은 국가마다 별개로 독립되어 있는 것이고 그 효력범위도 자기나라에만 국한하여 미치는 속지주의를 취하고 있어서 특허를 받을 수 있는 권리도 나라마다 별개의 것으로 이행되어야 한다는 것이다. 따라서 발명자와의 명시적 특약이 없는 한 승계인의 특허출원할 수 있는 권리는 그 나라에 국한된다(吉藤幸翔 著, 유미특허법률사무소 譯, 「특허법개설」, 제13판, 유미특허법률사무소, 2000, 232면).

177) i) 지식재산처 재직자가 출원 후 권리를 이전하는 경우, ii) 재직 중 출원 후 퇴직하는 경우에 대해서는 특허법 제33조제1항단서 위반은 아니다. 다만 해당 분류의 담당심사관이 외부 선행기술조사기관에 심사대상 출원을 조사의뢰한 이후 심사절차를 진행하며 등록 대상 출원으로 판단되면 3인의 심사관이 협의심사를 통해 등록 여부를 최종 결정한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2110면).

2) 무권리자의 출원이 출원공개 또는 등록공고되면 정당한 권리자의 출원이 아닌 제3자의 후출원에 대해서 확대된 선출원을 적용한다(法 29③④). 정당한 권리자의 출원에 대해서는 i) 정당한 권리자의 출원일이 무권리자의 출원일로 소급하기 때문에 동일자 출원의 경우에는 확대된 선출원을 적용하지 않으며, ii) 설사 정당한 권리자 출원의 출원일이 소급하지 않더라도 발명자가 동일하므로 제29조제3항 및 제4항단서에 의하여 확대된 선출원을 적용하지 아니한다.

3) 한편 무권리자의 제29조제1항 각호에 의한 공개는 공지기술의 지위가 인정된다. 다만 무권리자의 공개는 정당한 권리자의 입장에서는 제30조제1항제2호의 의사에 반한 공지에 해당하기 때문에 공개된 날로부터 1년 이내 정당한 권리자가 출원했다면 공지가 되지 아니한 것으로 보아서 신규성, 진보성 위반을 판단하지 않게 된다. 그러나 공개된 날로부터 1년을 지나서 정당한 권리자가 출원했다면 정당한 권리자의 출원이 그 공개에 의하여 신규성, 진보성에 위반되었는지를 판단하여야 한다.

③ 법정실시권의 인정 여부

무권리자는 악의의 무권리자(冒認者)와 선의의 무권리자로 구분될 수 있다. 「악의의 무권리자」란 진정한 발명자의 의사에 반하여 사기, 협박, 산업스파이 등을 통하여 해당 발명을 모인자(冒認者)를 말하며, 「선의의 무권리자」란 악의의 무권리자를 정당한 권리자로 믿고, 그로부터 해당 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 양도받은 선의의 승계인을 말한다. 즉 악의의 무권리자란 자신이 특허를 받을 수 있는 권리가 없다는 것을 알고 있는 자이고, 선의의 무권리자란 자신이 적법하게 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인임을 의심하지 아니한 자이다. 선의의 무권리자는 악의의 무권리자와는 달리 특허권이 설정된 후에 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권(法 103의2), 중용권(法 104)이 발생할 수 있다는 점에서 구별의 실익이 있다.

④ 민·형사상의 제재

정당한 권리자는 무권리자의 고의 또는 과실에 의한 위법행위에 의하여 손해가 발생하였으면 민법상 무권리자에게 손해배상청구를 할 수 있으며, 형법상 절도죄, 거짓행위의 죄¹⁷⁸⁾ 등을 물을 수 있다. 예를 들어 모인에 의하여 노하우로 하여 은닉할 것인지 출원할 것인지의 선택권을 침해받았고 발명자가 자신의 이름이 기재되어야 할 인격권도 침해받았으므로 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 불법행위를 고려할 수 있을 것이다.¹⁷⁹⁾

178) 무권리자가 「거짓이나 그 밖의 부정한 행위로써 특허를 받은 자」에 해당하는 경우, 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다(法 228).

179) 竹田和彦, 「特許の知識 理論と實際」, 제6판, グイヤモンド社, 1999, 249면.

IV. 흠결의 효과

1. 등록 전·후에 있어서의 취급

(1) 일 반

i) 외국인으로서 특허에 관한 권리를 누릴 수 없는 자가 특허출원한 경우(法 25), ii) 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원한 경우(法 33①본문), iii) 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원이 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고 재직 중 특허출원한 경우(法 33①단서), iv) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공유자 모두가 공동으로 출원하지 아니한 경우(法 44) 등록 전에는 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)이며, 등록 후에는 특허무효사유(法 133①)이다.

(2) 제33조제1항 본문 위반과 관련하여

1) 심사 실무¹⁸⁰⁾상 출원서에 발명자로 기재된 사람이 진정한 발명자가 아니라는 합리적인 의심이 드는 경우에는 해당출원에 대하여 발명자 기재방식 위반으로 보정명령하는 것을 원칙으로 하고, 보정명령에 대응하여 발명자를 정정하지 않거나, 진정한 발명자임을 증명할 수 있는 자료(예: 발명노트 등)를 제출하지 않을 때는 특허출원을 무효로 할 수 있다(法 46, 16). 또한 출원서에 출원인으로 기재되어 있는 사람이 진정한 발명자나 그 승계인이 아니라는 의심이 드는 경우에는 거절이유를 통지할 수 있다. 거절이유통지에 대응하여 출원인을 정정하지 않거나, 그 출원인이 진정한 발명자나 정당한 승계인임을 증명할 수 있는 자료(예: 발명노트, 양도증 등)를 제출하지 않을 때는 거절결정할 수 있다(法 62).

2) 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 승계인이 다시 특허를 받을 수 있는 권리를 재양도한 후 출원하였으면 무권리자 출원에 해당한다.¹⁸¹⁾ 발명자가 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 스스로 특허출원한 경우에도 무권리자인지를 단순히 “발명자 또는 승계인”이 아닌 자료 형식상 파악할 것이 아니라 실질적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있지 아니한 자료 봄이 적절하므로 무권리자 출원으로 인정해야 한다.¹⁸²⁾

3) 문제가 되는 것은 발명자의 발명을 모인한 후 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경한 경우에도 무권리자에 해당하는지이다. 기존의 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결에서는 구성과 효과의 차이가 있다면 무권리자가 아니라고 판시하였으나, 최근 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결에서는 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차

180) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2105면. 예를 들어 출원인은 L씨로 기재되어 있으나, [발명자]란에 발명하였을 것이라고 인정되지 않는 5세의 유아가 발명자로 기재되어 있어 발명자가 잘못 기재된 것이 명백한 경우, 발명자 기재에 대한 방식 흠결을 이유로 보정명령을 할 수 있다.

181) 특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허6143.

182) 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018.

이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 아니한 경우도 무권리자에 포함된다고 판시하였다. 즉 일반적인 판단기준은 “기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여했는지 여부”이고, “그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우”는 일반적인 판단기준을 구체화한 것에 불과하고, “등”을 부가하여 구체화된 기준과는 다른 기준이 적용될 수 있음을 판시하였다. 무권리자인지를 판단하면서 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여했는지를 가지고 판단한다는 발명자(무권리자)의 결정기준은 일응 이해가 되나,¹⁸³⁾¹⁸⁴⁾ 그 구체화된 기준으로서 진보성 판단에 준하는 판단을 하는 것은 i) 정당한 권리가 무권리자 특허출원으로 인정된 발명 전체에 대하여 별도 출원에 의한 출원일 소급을 인정받거나 특허권의 이전 청구를 통해 특허권을 획득할 수 있는데 지나치게 정당한 권리를 두텁게 보호한다는 점, ii) 무권리자출원 이후의 이와 동일한 개량발명을 한 제3자에게 불측의 손해를 끼칠 수 있다는 점에서 다시 한번 고려해 볼 필요가 있다고 여겨진다.¹⁸⁵⁾

4) 다만 무권리자의 특허출원에 기재된 발명이 정당한 권리의 발명과 비교하여 전혀 다른 발명이 있는 경우 정당한 권리의 발명과 같은 발명을 삭제보정하거나 다른 발명만 분할출원한다면 무권리자의 특허출원은 특허를 받을 수도 있을 것이다.

(3) 제44조 위반과 관련하여

1) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 중의 1명이라도 특허출원을 원하지 않거나 공유자와 연락이 안 되면 단독으로 특허출원한 다른 공유자는 제44조 위반으로 특허를 받을 수 없고, 이를 강제할 방법이 없다. 다만 공유자가 다른 공유자를 제외한 채 특허출원을 하여 공동출원 규정(法 44)에 위반된 경우라도 공유자 중 일부가 나머지 공유자로부터 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 모두를 이전받아 단독 권리가 된다면 그 하지는 치유된다고 보아야 할 것이다.¹⁸⁶⁾

2) 공동발명하지 않고 단독으로 발명한 후 지분의 일부 양도 등에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하게 되었는데 단독으로 특허출원한 경우 제44조 위반인지 여부와 관련하여,

183) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178; 2012. 12. 27. 선고 2011다67705 판결에서도 공동발명자 결정기준으로서 기술적 사상의 창작에 실질적 기여를 했는지 여부를 제시하고 있다.

184) 위 대법원판결은 정당한 권리의 발명을 아무런 권리 없이 무단으로 출원한 종전의 강학상의 모인출원에 대한 판시기준을 정당한 권리의 발명과 동일한지 아닌지를 바탕으로 등록된 특허의 무효를 판단하지 아니하고, 특허법의 원칙으로 돌아가서 발명자 내지 출원인이 해당 발명을 실제로 창작하였거나 그로부터 권리를 승계받은 자인지 여부에 따라 판단한 최초의 판결이라는 점에서 의의가 있다(박창수 강학상의 모인 출원 -“기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우”, 한국특허법학회 42차 정기학회, 2012. 10. 20. 발표문, 7면). 종전 2003후2218 판결은 기본적으로 모인출원에 관하여 특허발명과 모인대상발명 사이의 동일성을 요구하는 종전의 실무에서 벗어나지 못한 한계가 있고, 이러한 종전의 실무의 태도는 2009후2463 판결에서 제시된 ‘기술적 사상의 창작에 대한 실질적 기여’라는 탄력적인 기준에 따라 향후 바뀔 것으로 예상된다(성창익, “모인대상발명을 변형 또는 개량하여 특허등록한 경우 모인출원이 성립하는지 여부” 『특허판례연구』, 박영사, 2012, 332면).

185) 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 박사, 2013, 166면-169면 참고.

186) 특허법원 2005. 7. 8. 선고 2004허5894 판결.

기존의 특허법원 1998. 10. 1. 선고 98허2405 판결은 제44조는 “제33조제2항의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허출원을 하여야 한다”라고 규정되어 있어 공동발명하여 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에만 적용되므로 제44조 위반이 아니고, 채무불이행의 문제로 해결하여야 한다는 입장을 취하고 있었다. 다만 판례가 제44조 위반을 너무 협소하게 해석하여 특허법의 테두리 안에서 불합리한 절차 진행을 막지 못한다는 비판이 있었고, 이에 2013. 3. 22. 시행된 현행법(법률 제11654호, 2013. 3. 22. 개정)은 제44조에서 “제33조제2항의 규정에 의한”을 삭제하여, 공동발명하여 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우뿐만 아니라 공동발명하지 않고 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에도 공동출원하지 아니한다면 이를 적용하도록 하였다.

(4) 무효심판청구와 관련하여

① 무효심판청구인

특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하여 제33조제1항 본문을 위반한 경우나 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여 제44조를 위반한 경우에는 이해관계인이라도 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허무효심판을 청구할 수 있다. 이는 사적 이익이기 때문에 이해관계인의 범위를 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로 제한하고 있다.

② 증명책임

무권리자의 출원을 무효사유로 한 특허무효심판 및 그에 따른 심결취소소송에서 위와 같은 무효사유에 관한 증명책임은 무효라고 주장하는 당사자(무효심판청구인)에게 있다.¹⁸⁷⁾ 무권리자에 대하여 특허무효가 되기 위해서는 모인대상발명과 실제로 출원되어 특허를 받을 발명 사이에 i) 실질적인 동일성(2009후2463 판결에 의한 판단법리를 적용)이 인정되어야 하고, ii) 정당한 권한없이 무단으로 출원된 것이어야 한다.¹⁸⁸⁾ 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있지 아니하여 정당한 권한이 없다는 것에 대한 증명책임은 무효심판청구인이 모인대상발명과 특허발명 사이에 실질적 동일성이 있음이 증명된 후, 특허권자가 정당한 권한이 있음에 대하여 구체적이고 합리적인 주장을 한 경우에 현실화된다고 보는 것이 타당하다고 생각된다.¹⁸⁹⁾

③ 후발적 사유로 무효심결확정된 경우의 효과

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만 특허된 후에 특허권자가 외국인의 권리능력 규정(法 25)에 따라 특허권을 누릴 수 없는

187) 대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268.

188) 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218.

189) 무권리자의 출원행위는 통상적으로 정당한 권리자의 영업비밀 침해의 문제가 수반되는 경우가 많아 관련 형사사건이나 가처분, 침해금지사건이 계속되는 경우가 종종 있다. 정당한 권리자의 발명이나 영업비밀이 유출되는 경로는 다양한데, 대부분 동업관계나 고용, 도급계약, 위임계약 관계에 있는 일방에 의하여 영업비밀이나 발명이 유출되는 경우가 많으므로 특허권자가 정당한 권리자와 이러한 계약관계에 있거나 계약관계에 있는 자로부터 정보를 넘겨받은 사실이 증명된다면 무권리자의 특허출원을 인정할 수 있는 유력한 간접사실이 될 수 있다(손천우, “무권리자의 특허출원(冒認出願)에 대한 새로운 판단 기준”, 사법논집 제58집, 법원도서관, 2014, 499면).

자가 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우에는 후발적 무효사유에 해당하고, 특허무효심판에 의하여 무효가 되면 그 사유가 발생한 날로부터 장래를 향하여 특허권이 소멸한다(法 133③).

(5) 법원의 이전청구와 관련하여

i) 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나(法 33①본문) ii) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여(法 44)¹⁹⁰⁾ 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 법원에서의 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 해당 특허권과 보상금 지급 청구권(法 65②, 207④)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 이전청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다(法 99의2). 한편 이전청구에 기초하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록(法 99의2)이 있으면 이전등록된 특허권(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)은 특허무효심판을 청구할 수 있는 대상에서 제외된다(法 133①Ⅱ단서).

2. 불수리

권리능력이 없는 자가 특허에 관한 절차를 밟으면 이를 심사관의 실체적 심사에 맡겨야 한다는 판례¹⁹¹⁾도 있으나, 실무¹⁹²⁾상 방식심사 단계에서도 권리능력 유무에 관한 판단을 하여야 하며, 절차를 밟는 자의 구체적인 확인이 필요한 경우에는 관련 증명서류를 제출하도록 명

190) 2017. 3. 1. 시행된 현행법(법률 제14035호, 2016. 2. 29. 개정) 전의 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결에서는 “중업원 등이 공동발명자인 제3자와 공모하여 특허를 받을 수 있는 권리를 먼저 예약승계계약을 한 자(사용자)를 제외한 채 제3자에게 양도하고, 제3자가 단독으로 특허출원하여 설정등록을 받은 사건과 관련하여, 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 중업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있고, 동시에 중업원 등을 상대로 사용자에게 순차적으로 이전등록할 것을 청구할 수 있다. 다만 위 특허권(중업원 지분)에 대하여 직접 사용자에게 이전등록할 것을 청구할 수는 없다”라고 판시하였다. 대상판결은 공유인 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허출원한 나머지 공유자로부터 그 지분을 이전받은 경우에는 그 하자가 치유된다는 것이다. 또한 대상판결에 의하면 나머지 공유자가 제3자에게 직접 이전등록청구를 할 수 없고, 채권자대위권을 행사하여 나머지 공유자에게 지분이 이전되었을 때 다시 나머지 공유자를 대상으로 이전등록청구를 할 수 있다는 것이다. 다만 이처럼 순차적으로 이전되도록 해석하여 특허를 받을 수 있는 권리의공유자를 보호하는 것은 너무 번거롭고 오랜 시간이 걸린다는 문제점이 있었고, 개정법은 직접 제3자에게 이전청구를 할 수 있도록 하였다.

191) 기재사항에 흠결이 있거나 구비서류가 갖추어지지 아니한 경우와 같은 형식적인 문제를 벗어나서 외국인인 권리능력을 가지는가 또는 출원인이 특허를 받을 수 있는가(공동발명의 경우) 등의 실질적인 사항에 관한 것은 포함하지 아니한다고 볼 것이다. 따라서 그와 같은 실질적인 사항에 관한 것은 곧바로 수리하지 아니하는 처분을 할 수는 없고, 일단 수리한 다음 심사관에게 실질적인 심사를 하게 하여야 한다(대법원 1982. 9. 28. 선고 80누414).

192) 특허심판원, 「심판판람」, 제14판, 2024, 91면.

령한다.¹⁹³⁾ 그 결과, 지식재산처장 또는 특허심판원장은 특허절차를 밟는 자가 국적·법인증명서류 등의 제출명령을 받고 소명기간에 제출하지 아니한 경우 불수리한다(施規 8, 11).

V. 국제출원의 경우

지식재산처장에게 국제출원을 할 수 있는 자는 i) 대한민국 국민, ii) 대한민국에 주소 또는 영업소를 가진 외국인, iii) 대한민국에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 외국인으로서 대한민국 국민이나 대한민국에 주소 또는 영업소를 가지는 외국인을 대표자로 하여 공동으로 국제출원을 하는 자, iv) i) 내지 iii)에 해당하지 아니하는 자로서 1명 이상의 대한민국 국민 또는 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인과 공동으로 국제출원을 하는 자이다(法 192, 施規 90).

제2절 특허를 받을 수 있는 권리

제37조 【특허를 받을 수 있는 권리의 이전 등】

- ① 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다.
- ② 특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다.
- ③ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제38조 【특허를 받을 수 있는 권리의 승계】

- ① 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제 3자에게 대항할 수 있다.
- ② 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있으면 특허출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.
- ③ 동일한 자로부터 동일한 발명 및 고안에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 및 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 특허출원 및 실용신안등록출원이 있으면 특허출원인 및 실용신안등록출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다.
- ④ 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다.
- ⑤ 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.
- ⑥ 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다.
- ⑦ 제2항·제3항 또는 제6항의 경우에는 제36조제6항을 준용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

193) 다만 특허에 관한 절차를 밟는 자가 특허고객번호 정보에 인감 또는 서명을 등록한 경우(「특허권 등의 등록령」 제22조제1항제7호에 해당하는 경우는 제외한다)에는 그 인감 또는 서명을 확인하는 것으로 서류의 제출명령을 갈음할 수 있다(施規 8①단서).

I. 서 설

1. 의 의

「특허를 받을 수 있는 권리」란 발명의 완성에 의하여 발생하고 발명자에게 원시적으로 귀속되는 권리로서, 특허출원에 대한 특허거절결정이 확정되거나 설정등록되기 전까지 인정되는 권리를 말한다. 이러한 발명자의 법률상의 지위를 영미법에서는 inventorship이라고 한다.

2. 취 지

특허법은 발명완성 후 특허권이 발생하기 전까지는 장기간이 소요되기 때문에, 특허권의 발생이전 단계에서 발명자 또는 승계인을 보호하기 위한 소정의 권리부여가 요구되어 특허를 받을 수 있는 권리를 규정하고 있다.

3. 법적성질

특허법은 특허를 받을 수 있는 권리의 이전(法 37, 38), 수용·제한(法 41), 정당한 권리자의 보호(法 34, 35) 등의 명문 규정을 두고 있으나 특허를 받을 수 있는 권리의 성질 및 내용에 대해서는 구체적인 명문 규정을 두고 있지 아니하여 해석에 논란이 있다. 특허를 받을 수 있는 권리의 성질에 대해서는 i) 국가에 대하여 특허권의 부여라는 행정처분을 구하는 공법상의 청구권이라는 특허부여 요구권설(공권설), ii) 발명자가 발명의 완성과 동시에 출원 전이라도 사용·수익·양도할 수 있는 권리라는 발명자권설(사권설)이 있으나 다수설은 특허부여 요구권설과 발명자권설을 병합하는 병합설¹⁹⁴⁾을 취하고 있다.

II. 발 생

1. 발생시점

발명이 완성되면 인정된다는 주관설과 특허요건을 구비하고 있다는 전제하에서 인정된다는 객관설이 있으나 특허법이 특허출원 이전에 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(法 38①)에 관한 규정을 둔 것을 감안할 때 특허를 받을 수 있는 권리는 특허요건의 구비 여부와는 별개로 발명의 완성에 의하여 발생하는 권리라는 주관설이 타당하다.¹⁹⁵⁾

194) 병합설(절충설)은 특허를 받을 수 있는 권리를 일면적으로만 보지 않고, 국가행정기관(지식재산청)에 대하여 특허부여라는 행정처분을 청구할 수 있는 권리라는 점에서는 공권이지만, 한편 발명의 완성과 함께 발명권이라는 사권이 원시적으로 발생하므로 특허를 받을 수 있는 권리는 이러한 두 가지의 측면이 병합된 권리라는 견해이다(東京地判 昭和 30. 7. 5, 下民 6권 7호, 1303면).

195) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 참조.

2. 귀 속

특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 그 승계인이 가진다(法 33①본문). 다만 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원은 상속이나 유증의 경우를 제외하고는 재직 중 특허를 받을 수 없다(法 33①단서). 2명 이상이 공동으로 발명한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 공유하며(法 33②), 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 특허출원을 하여야 한다(法 44).

III. 효 력

1. 특허부여 요구권적 효력

(1) 권리부여의 요구

정당한 권리자인 발명자 또는 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리에 기인하여 국가에 대하여 특허부여를 요구할 수 있으며 이를 특허출원이라 한다. 「특허출원」이란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명의 공개를 전제로 하여 지식재산처에 대하여 특허권을 받으려는 의사를 객관적으로 표시하는 행위를 말한다.

(2) 타인출원의 등록금지

정당한 권리자가 특허를 받을 수 있는 권리에 기인하여 특허출원한 후 출원공개된 경우에는 선출원의 지위(法 36), 공지기술의 지위(法 29①각호, 29②), 확대된 선출원의 지위(法 29③)에 의하여 타인의 등록을 금지시킬 수 있는 효력이 발생한다.

2. 발명자권적 효력

(1) 의 의

특허를 받을 수 있는 권리는 인격권적 효력과 재산권적 효력이 있다. 발명자는 일신전속적인 인격권적 효력에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 타인에게 이전하더라도 특허증에 발명자로서 기재될 권리를 가지게 된다. 발명자 또는 승계인은 재산권적 효력에 의하여 발명을 실시할 수도 있고, 특허를 받을 수 있는 권리의 침해행위에 대하여 보호받을 수 있다.

(2) 인격권

1) 발명자는 발명의 완성과 동시에 발명자 인격권(구체적으로 발명자 성명표시권)을 갖는다. 파리조약 제4조의3은 “발명자는 특허증에 발명자로서 기재되는 권리를 갖는다”라고 규정되어 있고, 발명자 인격권은 간접적으로 발명자 기재권으로 인정되고 있다. 특허법은 발명자 인격권에 대하여 직접적인 명문 규정을 두지는 않고 있으나, 특허출원서, 특허증에 발명자의 성명 및 주소를 기재하도록 하고 있다(法 42①Ⅳ, 86). 이러한 발명자 인격권은 일신전속적 권리로서 양도할 수 없지만 포기할 수 있으며, 이 경우 출원인은 발명자 표시의무를 지지 아니한다.

2) 등록 전 출원인과 등록 후 특허권자는 발명자의 추가, 정정을 할 수 있다. 등록 전 특허

출원인이 착오로 인하여 특허출원서에 발명자의 기재를 일부 누락하거나 잘못 적은 경우에는 발명자를 추가 또는 정정할 수 있다. 다만, 특허출원인은 법 제66조에 따른 특허결정이 있는 때부터 법 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받기 전까지는 발명자를 추가할 수 없고 발명자의 동일성이 유지되지 않는 경우 발명자를 정정할 수 없다. 특허출원인은 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에는 보정서에 i) 발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서, ii) 특허출원인 및 추가 또는 정정의 대상이 되는 발명자¹⁹⁶⁾가 서명 또는 날인한 확인서류(다만, 발명자의 사망 등으로 서명 또는 날인이 불가한 특별한 사유가 있는 경우에는 그 사유를 확인 서류에 기재하고 서명 또는 날인을 생략할 수 있다.)를 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다. 다만, 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 일부 누락되거나 발명자를 잘못 적은 것임이 명백한 경우에는 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다(施規 28①②).¹⁹⁷⁾

3) 등록 후 특허권자도 발명자의 추가, 정정을 할 수 있다. 특허권자가 발명자를 추가 또는 정정하려는 경우에는 정정발급신청서에 i) 발명자의 추가 또는 정정 이유를 기재한 설명서, ii) 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류¹⁹⁸⁾를 첨부하여 지식재산처장에게 제출해야 한다. 다만, i) 특허출원서에 적은 발명자의 기재가 일부 누락된 경우¹⁹⁹⁾, ii) 발명자를 잘못 적은 것임이 명백한 경우, iii) 특허권자가 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자인 경우에는 확인서류를 첨부하지 않을 수 있다(施規 28③④).

4) 진실한 발명자가 발명자로 표시되지 않았으면 발명자는 특허증에 발명자로 기재된 권리를 제한받았기 때문에 특허권자에게 발명자 인격권의 침해에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.²⁰⁰⁾ 그러나 특허증에 발명자로 표시되는 것은 직무발명의 보상 등과 같은 개인적인 만족을 넘어서 입시, 인사 등에서 사회적으로 유의미한 이익을 누리도록 하는 기능이 있고, 수수료를 감면받거나 확대된 선출원을 회피할 목적으로 악용될 소지가 있으므로 제한하고 있다. 또한 감면 대상자를 발명자에 포함하여 부당하게 수수료를 감면받은 경우 2022. 2. 18. 시행되는 현행법(법률 제18409호, 2021. 8. 17. 일부개정)에서는 감면받은 특허료 및 수수료의 2배를 추징하고 일정 기간 감면을 제한(法 83④)함으로써 제도의 악용을 방지하고 공정성을 제고하고 있다.²⁰¹⁾

196) 예를 들어 출원인 A가 발명자를 B, C에서 C, D로 변경하고자 하는 경우 출원인 A, 발명자 B, D의 서명 또는 날인한 확인서류가 필요하다.

197) 구시행규칙(산업통상자원부령 제579호, 2024. 10. 31. 개정된 시행규칙 이전)에서는 설정등록전에 발명자의 추가 또는 정정을 어느 시기에도 가능하고 별다른 증명서류없이 보정서만 제출하면 가능하였다. 그러나 심사절차가 종료된 특허결정후 설정등록전에 발명자를 정정, 추가하여 수수료 감면을 받거나 진정 발명자가 아닌 자가 공보에 게재되도록 악용하는 문제점이 있었다. 따라서 현행시행규칙에서는 특허결정후 설정등록전 발명자의 동일성이 유지되는 경우(발명의 개명, 단순오타, 주소변경 등)를 제외하고는 정정, 추가할 수 없도록 하였으며 출원이후 설정등록전에 발명자의 추가, 정정을 위해서는 원칙적으로 출원인 및 추가, 정정되는 발명자가 서명한 확인서류를 제출토록 하고 있다.

198) 예를 들어 특허권자 A가 발명자를 B, C에서 C, D로 변경하고자 하는 경우 특허권자 A, 발명자 B, C, D의 서명 또는 날인한 확인서류가 필요하다.

199) 예를 들어 출원서에는 발명자가 甲과 乙이었으나, 특허증에는 발명자가 甲으로 표시된 경우 乙을 추가할 수 있다.

200) 서울행정법원 2011. 11. 4. 선고 2011구합21942.

다만 인격권을 침해하였다고 하여 등록된 특허가 제한열거적인 무효사유(法 133①각호)에 해당하지 않는다.²⁰²⁾

(3) 재산권

① 발명의 실시

1) 특허권 발생 이전에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있어도 발명의 실시에 관하여 특별한 권리가 발생하는 것은 아니지만,²⁰³⁾ 정당한 권리자는 타인의 권리 또는 법에 저촉되지 않는 한 발명을 자유롭게 실시할 수 있다.

2) 한편 정당한 권리자의 발명 실시가 공연실시가 아니라면 이에 의거하여 동일발명에 관한 타인 특허출원의 등록을 금지시킬 수 없고, 오히려 타인이 먼저 특허출원을 한다면 타인이 특허권을 획득하여 타인 특허권의 침해를 이유로 정당한 권리자의 실시를 금지시킬 수 있다. 다만 정당한 권리자는 일정한 경우 선사용에 의한 통상실시권(法 103) 또는 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ)에 관한 규정에 의하여 보호받을 수 있다. 예를 들어 코카콜라의 제조방법은 현재 불특정인이 알 수 있는 상태에 놓여 있지 않으므로 공지기술이라 할 수 없고, 누군가 코카콜라의 제조방법을 발명하게 되어 특허출원한다면 특허를 받을 수 있다. 다만 코카콜라의 제조방법발명의 특허출원 전에 국내에서 그 제조방법을 사용하여 코카콜라를 제조, 판매하는 등 실시사업을 하는 회사는 선사용에 의한 통상실시권(法 103)을 가지고 있으므로 그 코카콜라의 제조방법 특허권의 침해가 아니게 된다.

② 침해행위에 대한 보호

1) 특허를 받을 수 있는 권리를 침해하는 대표적인 유형은 무권리자의 특허출원, 무단공표, 무단실시행위가 있다. 무권리자의 특허출원에 대해서는 정당한 권리자의 출원에 출원일 소급효 인정(法 34, 35)이나 특허의 이전청구(法 99의2)를 통해, 무단공표에 대해서는 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(法 30)에 의하여, 무단실시행위에 대해서는 보상금청구권(法 65)을 통해 특허법상 보호받을 수 있다. 다만 보상금청구권이 인정된다고 하더라도 특허를 받을 수 있는 권리는 배타적인 효력이 없으므로 특허권 발생 이전에는 타인의 실시를 금지시킬 수 없다.

2) 한편 정당한 권리자의 발명이 영업비밀에 해당한다면 영업비밀을 부정취득하는 행위, 그 취득한 영업비밀을 사용하거나 공개하는 행위 등의 영업비밀 침해행위에 대하여 침해금지청구권을 행사하거나 손해배상책임 등을 물을 수 있고, 일정한 경우 형사적인 규제 방법을 취할 수 있다.²⁰⁴⁾

201) 채수근 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안 검토보고(이철규 의원 대표발의(의안번호 제2105036호 및 제2105093호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2. 7-8면).

202) 대법원 2018. 7. 20. 선고 2015후1669.

203) 윤선희, 「특허법」, 제5판, 법문사, 2012, 262면.

204) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제10조-제12조, 제18조-제19조.

IV. 변동 등

1. 이 전

(1) 의 의

「특허를 받을 수 있는 권리의 이전 내지 승계」²⁰⁵⁾란 특허를 받을 수 있는 권리의 내용은 변동이 없이 그 주체가 변경되는 것을 말하는 것으로서 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있다(法 37①). 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다.²⁰⁶⁾

(2) 특허출원 전의 승계

1) 특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다(法 38①). 즉 출원 전 승계는 출원이 대항요건이다. 「대항요건」이란 계약의 양 당사자 이외의 제3자에 대하여 효력을 주장할 수 있는 것을 말하며, 구체적으로 발명에 대한 둘 이상의 승계인이 있는 경우 먼저 승계하였다고 하더라도 먼저 출원하지 않으면 지식재산처에 대하여 승계인이라고 주장할 수 없다. 특허를 받을 수 있는 권리는 다른 재산권과 같이 의사표시에 의해서 이전될 수 있으나, 특허출원 전의 특허를 받을 수 있는 권리는 어떠한 공시수단도 없고, 무체재화(無體財貨)이므로 점유라는 것도 있을 수 없으므로 이처럼 규정하고 있다.²⁰⁷⁾ 한편 여기서 「제3자」란 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람을 말한다.²⁰⁸⁾ 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 자는 제3자에 포함되지 아니한다. 따라서 발명자 또는 승계인이 특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 자기 명의로 특허출원을 한 경우에는 제38조제1항에서의 제3자가 아닐뿐더러 무권리자 출원에 해당한다.²⁰⁹⁾

205) 「승계취득」은 「이전적 승계」와 「설정적 승계」로 나누어진다. 「이전적 승계」는 전주가 권리를 잃으면서 그의 권리가 취득자에게 그대로 취득되는 것이며, 매매에 의한 소유권의 취득, 양도에 의한 전세권의 취득 등이 그 예이다. 「설정적 승계」는 전주가 권리를 잃지 않으면서 그의 권리의 일부를 제한하여 취득자가 이용하고, 그 관계가 종료되면 전주는 원래의 권리를 회복하게 되는 취득이다. 설정에 의한 지상권의 취득, 담보계약에 의한 저당권의 취득 등이 그 예이다. 「이전적 승계」는 다시 「일반승계」와 「특정승계」로 나누어진다. 「일반승계」는 하나의 법률상의 원인에 의하여 당사자의 의사와 관계없이 다수의 권리가 일괄하여 취득되는 것이며, 상속·포괄유증·합병 등이 그 예이다. 「특정승계」는 개개의 법률상의 원인에 의하여 당사자의 의사에 따라 개별적 권리가 특정되어 취득되는 것이다. 교환·증여 등에 의한 소유권의 취득 등이 그 예이며, 일반승계의 경우를 제외한 이전적 승계가 모두 이에 속한다.

206) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705.

207) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2002, 109면.

208) 대법원 2020. 5. 14 선고 2020후10087.

209) 무권리자 출원이 착오로 등록되어 특허무효사유가 있는데, 이러한 특허권을 이전받은 양수인 역시 제38조제1항에서 말하는 제3자가 아니다. 또한 이 경우는 특허를 받을 수 있는 권리의 양도가 아닌 특허

2) 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리(실용신안등록을 받을 수 있는 권리)를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원 또는 실용신안등록출원이 있으면 특허출원인(실용신안등록출원인) 간에 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력이 발생한다(法 38②③). 한편 지식재산처장은 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의제(法 38②③)에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다(法 38⑦). 협의제, 협의명령에도 불구하고 협의가 성립하지 아니하면 그 승계는 효력이 발생하지 않으므로, 모든 출원은 무권리자에 의한 출원에 해당하고, 따라서 심사관은 제33조제1항 위반으로 거절이유를 통지한다.²¹⁰⁾

권의 이전이기 때문에 제38조제1항의 적용 사안이라고 할 수도 없다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087). 특허를 받을 수 있는 권리는 그 권리자가 지식재산처장에게 특허를 출원하여 등록을 구할 수 있는 권리이자 타인에게 양도할 수 있는 권리이다. 이러한 점에서 특허법 제38조 제1항에서 정한 권리양도의 대항요건인 ‘승계인의 (지식재산처장에 대한) 특허출원’은, 비록 행위의 주체가 다르기는 하지만, 민법 제450조 제1항에서 정한 지명채권양도의 대항요건인 ‘양도인의 채무자에 대한 통지’와 구조가 유사한 측면이 있으므로, 그에 관한 논의를 살펴볼 필요가 있다. 민법 제450조 제1항은 “지명채권의 양도는 양도인이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자 기타 제3자에게 대항하지 못한다”라고 규정하고 있다. 채권양도의 대항요건을 갖춘 경우에 대항할 수 있는 상대방이 되는 제3자는 그 채권에 대하여 양수인의 지위와 양립하지 않는 법률상의 지위를 가진 자 또는 그 채권에 대하여 법률상의 이익을 가지는 자를 뜻한다. 이러한 의미에서의 제3자는 양도된 채권의 양도인으로부터 이중으로 양수한 자, 양도된 채권의 위의 질권자, 양도된 채권을 압류한 양도인의 채권자, 양도인이 파산한 경우 파산채권자 등이 있다. 그러나 양도행위의 무효 기타에 의한 무권리자, 채권의 양도에 의하여 간접적으로 영향을 받는 데 그치는 제3자는 포함되지 않는다. 제3자에게 대항하지 못한다는 것은 동일한 채권에 관하여 양립할 수 없는 법률상의 지위를 취득한 자 사이에서 우열을 결정하는 의미를 가진다. 위와 같은 논의를 참조하면, “특허출원 전에 이루어진 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있다”라고 규정한 특허법 제38조 제1항에서 말하는 제3자는 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한한다고 볼 수 있다(이한상, “무권리자의 특허와 특허법 제38조 제1항에서 규정한 ‘제3자’의 의미”(2020. 5. 14. 선고 2020후10087 판결: 공2020하, 1128)”, 대법원판례해설 제124호, 2020, 222면).

210) 제38조제2항, 제3항 및 제7항은 제36조제2항, 제3항 및 제6항과 관련하여 어떻게 해석하여야 하는지 문제이다. 동일자 출원의 경우에 협의를 유도하고 협의가 성립하지 않거나 협의를 할 수 없는 경우에는 양자 모두 특허를 받을 수 없음은 동일하나, 제38조의 제2항, 제3항 및 제7항이 적용되는 경우 제33조제1항 본문 위반으로 특허거절결정되어 선출원의 지위가 없기 때문이다. 私見으로는 협의를 하지 아니하여 특허거절결정이 된 경우 공중의 영역(public domain)에 속하도록 하는 것이 타당하다고 사료되며, 따라서 법 적용의 통일화를 기하기 위해 제38조제2항, 제3항은 삭제하는 것이 바람직할 것이다.

(3) 특허출원 후의 승계

1) 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다(法 38④).²¹¹⁾ 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하기 위함이다.²¹²⁾ 특허출원인변경신고를 하려는 자는 특허출원인변경의 원인을 증명하는 서류 등을 첨부한 변경신고서를 그 특허출원의 등록 전까지 지식재산처장에게 제출하여야 한다(施規 26).

2) 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계의 경우에는 상속, 그 밖의 일반승계가 된 때와 특허출원인변경신고 사이에 권리의 단절을 막기 위해 상속, 그 밖의 일반승계된 때 승계의 효력이 발생한다. 다만 특허를 받을 수 있는 권리의 상속, 그 밖의 일반승계가 있는 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다(法 38⑤).

3) 동일한 자로부터 동일한 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 둘 이상인 경우 그 승계한 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원인변경신고가 있으면 신고를 한 자 간에 협의하여 정한 자에게만 신고의 효력이 발생한다(法 38⑥). 한편 지식재산처장은 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고, 그 기간에 신고가 없으면 협의제(法 38⑥)에 따른 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다(法 38⑦). 협의제, 협의명령에도 불구하고 협의가 성립하지 아니하면 그 신고는 효력이 발생하지 않으므로, 심사관은 협의가 이루어지지 않았다고 하여 해당 특허출원에 대하여 거절이유 등을 통지하는 것이 아니라 출원인변경신고가 없었던 것으로 보고 심사를 진행한다.

211) 특허법 제186조는 제2항에서 특허심판원의 심결에 대한 취소의 소는 당사자, 참가인, 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자가 제기할 수 있다고 규정하고, 제3항에서 그 취소의 소는 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다고 규정하고 있다. 한편 특허법 제38조 제4항은 특허출원 후에는 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속, 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하여야만 그 효력이 발생한다고 규정하고 있다. 이러한 규정들에 의하면, 특허출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 특정승계인은 특허출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 특허심판원의 거절결정 불복심판 심결에 대하여 취소의 소를 제기할 수 있는 당사자 등에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다. 특정승계인이 취소의 소를 제기한 후 특허출원인변경신고를 하였더라도, 그 변경신고 시기가 취소의 소 제기 기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 취소의 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하다는 마찬가지이다(대법원 2017. 11. 23. 선고 2015후321).

212) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2017후1274.

이전		범조문	구체적 예
특허출원 전	승계	제38조 제1항	
		제38조 제2항, 제3항 및 제7항	
특허출원 후	특정승계	제38조 제4항	
		제38조 제6항 및 제7항	
	일반승계	제38조 제4항 및 제5항	

이전시기	이전형식	
	일반승계	특정승계
특허출원 전	1. 사유발생시 효력발생 2. 승계인이 특허출원 → 제3자 대항요건(法 38①) 3. 동일자 출원 ① 협의제, 협의명령(法 38②③⑦) → 협의하여 정한 자에게만 승계의 효력발생 ② 협의가 성립되지 아니하면 승계의 효력 불발생 → 무권리자 출원으로 간주	
특허출원 후	1. 사유발생시 효력 발생(·권리의 단절 막기 위해) 2. 승계인이 지식재산처장에 신고 요(法 38⑤)	1. 승계인의 출원인변경신고 → 효력발생요건 2. 동일자 출원인변경신고 ① 협의제, 협의명령(法 38⑥⑦) → 협의하여 정한 자에게만 출원인변경신고의 효력발생 ② 협의가 성립되지 아니하면 출원인변경신고의 효력 불발생 → 피승계인이 출원인인 상태로 출원절차 진행

【그림 2-18】 특허를 받을 수 있는 권리의 이전

2. 실시허락의 계약

실시권은 특허권의 침해가 되지 아니한 정당한 권원 중 하나로서 특허권에 부수적인 권리이기 때문에 특허권이 존재하여야만 발생할 수 있다. 다만 정당한 권리자는 제3자에게 특허권의 획득을 전제로 그 발명에 대한 실시를 허락할 수 있다. 이 경우 특허권을 획득하지 못한 경우 실시 허락을 받은 자에게 채무불이행의 책임을 져야 할 것이고(예를 들어 실시 허락 후 제3자로부터 받은 실시료는 부당이득으로 반환을 해야 할 것이다), 출원과정에서 보정을 통해 청구 범위가 감축되거나 변경되었을 때 이를 어떻게 처리할 것이냐는 문제가 발생할 수 있다.

3. 질권설정의 금지

특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적으로 할 수 없다(法 37②). 이처럼 특허법이 특허를 받을 수 있는 권리에 대한 비담보성(질권설정금지)에 관한 규정을 둔 이유에 대해서는 i) 불확실한 권리이므로 이를 담보에 제공하면 선의의 제3자에게 예측하지 못한 손해를 입힐 염려가 있다는 「제3자 보호설」, ii) 부정확한 권리로서 특허권에 비해 저렴한 것이 보통이므로 이를 담보의 목적물로 삼는다면 자본가에게 이용당할 우려가 있으므로 발명자를 보호하기 위해 질권을 금지한 것이라는 「발명자 보호설」, iii) 질권을 설정하면 채무불이행일 때 권리의 강제이전이 있게 되는데, 이 경우 권리를 훼손하기 때문에 권리의 성질상 허용되지 아니한다는 「권리 성질설」, iv) 담보권의 실행은 경매 등의 방법에 의하게 되므로 이 경우 발명의 내용이 일반에 공개되어 그 가치가 감소한다고 하는 「공시방법 결여설」 등 여러 견해가 있으며, 상기 견해를 종합적으로 고려함이 타당할 것이다.²¹³⁾

4. 수용 등

정부는 특허출원한 발명이 국방상 필요한 경우에는 외국에 특허출원하는 것을 금지하거나 발명자·출원인 및 대리인에게 그 특허출원의 발명을 비밀로 취급하도록 명하거나 불특허할 수 있으며, 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 수용할 수 있다(法 41①②).

5. 강제집행 여부

특허를 받을 수 있는 권리는 질권의 목적이 될 수 없는 것과 같이 권리의 성질상 강제집행의 대상도 될 수 없다고 보인다.

213) 다만 양도담보 설정은 발명이 공개되지 않기 때문에 가능할 것이다.

V. 소 멸

1. 출원 계속의 소멸에 의한 소멸

출원의 무효·취하·포기 또는 출원에 대한 특허거절결정이 확정되거나 설정등록²¹⁴⁾이 되면 특허를 받을 수 있는 권리는 소멸한다. 다만 출원의 무효·취하·포기 또는 특허거절결정의 확정에 의한 소멸은 선출원의 지위가 남지 않으므로 출원공개 전이라면 재출원할 수 있어 상대적 소멸이라 할 수 있다.²¹⁵⁾

2. 권리능력상실에 의한 소멸

외국인이 권리능력을 상실하거나 상속인이 존재하지 아니한 경우 등 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 권리능력이 소멸하면 특허를 받을 수 있는 권리는 소멸한다.²¹⁶⁾

VI. 공 유

1. 의 의

「특허를 받을 수 있는 권리의 공유」란 하나의 특허를 받을 수 있는 권리를 2명 이상이 지분에 의하여 공동으로 소유하는 것을 말한다. 2명 이상이 공동으로 발명한 경우(法 33②) 또는 단독발명 후 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 일부를 타인에게 이전하는 경우 특허를 받을 수 있는 권리는 공유가 된다. 특허를 받을 수 있는 권리의 객체인 발명은 무형인 기술적 사상의 창작으로서 점유를 수반하지 아니하여 지분비율에 상관없이 공유자 모두가 발명 전체를 실시할 수 있다. 따라서 다른 공유자의 자본력·신용력·기술력 등이 공유자 사이에 큰 영향력을 미치는 특수성을 지닌다.

214) 설정등록의 경우는 특허를 받을 수 있는 권리가 소멸했다고 보는 대신, 본래의 목적을 달성하여 보다 완전한 권리로 변화했다고 보는 것이 타당할 수도 있다(강기중, “무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호”, 법조 53권 5호, 2004, 14면).

215) 출원공개 전후 특허 계속의 소멸에 의한 특허출원한 발명의 등록금지적 효력은 다음과 같이 차이가 있다.

시기	선출원의 지위	확대된 선출원의 지위	공지기술의 지위
공개 전 소멸	불인정	불인정	불인정
공개 후 소멸	불인정	인정	인정

216) 명문의 규정은 없으나 제124조의 「상속인이 없는 경우 등의 특허권의 소멸」 규정에 따라 상속인이 없으면 특허를 받을 수 있는 권리도 소멸한다고 해석하여야 할 것이다. 민법에서는 상속인이 없는 재산권은 국유로 하나 특허법은 이를 소멸시킴으로써 일반 공중이 자유롭게 사용하도록 하는 점에서 차이가 있다.

2. 지분의 양도

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(法 37③). 이는 새로운 공유자의 자본력·신용력·기술력 여하 등이 다른 공유자의 이해관계에 지대한 영향을 미치기 때문이다. 다만 지분의 상속은 다른 공유자에게 불측의 손해를 끼칠 염려가 없으므로 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 할 수 있으며 공유자끼리의 지분양도는 공유자 사이의 지분 비율의 변동에 불과하므로 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 가능하다.

3. 공동출원

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허출원을 하여야 한다(法 44). 특허를 받을 수 있는 권리가 공유임에도 불구하고 1명이 단독으로 출원하였으면 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)이다. 다만 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권 지분의 이전을 청구할 수 있다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 법원에의 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 해당 특허권과 보상금 지급 청구권(法 65②, 207④)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다. 이전청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제 99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다(法 99의2). 한편 이전청구에 기초하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 지분의 이전등록(法 99의2)이 있으면 특허무효심판을 청구할 수 있는 대상에서 제외된다(法 133①Ⅱ단서).

4. 공동심판청구

특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法 139③). 이에 위반하여 단독으로 심판을 청구한 경우에 심판청구인은 다른 공유자를 추가하는 보정(추가되는 공유자의 동의가 있는 경우로 한정한다)을 할 수 있으나, 보정하지 아니한 경우 심판청구는 심결각하된다(法 142).

5. 심결취소소송의 제기

거절결정불복심판의 기각심결에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 중 일부가 심결취소소송을 제기할 수 있는지와 관련하여 아무런 규정을 두고 있지 않아서 문제이다. 대법원²¹⁷⁾은 i) 모두가 심결취소소송을 제기하여야 하는 경우 다른 공유자의 협력을 얻지 못하거나 다른

217) 대법원 2024. 12. 22. 선고 2024후10825.

공유자가 행방불명이 된 경우 등에는 소송을 제기하지 못하고 출소기간의 만료와 동시에 심결이 확정되고 권리가 소멸하게 되는 불이익을 초래하게 되는 점, ii) 공유자의 일부가 심결취소소송을 제기하더라도 그 소송에서 심결을 취소하는 판결이 확정되면 취소의 효력이 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개되고(행정소송법 제29조제1항) 심결취소청구를 기각한 판결이 확정되어 심결이 유지된 경우에는 심결에 불복하지 않은 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 않아서, 결국 합일확정의 요청에 반하지 않는다는 점 등을 고려하여 이를 긍정하고 있다.

6. 공동절차수행

특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우 2명 이상이 특허에 관한 절차를 밟을 때에는 i) 특허출원의 변경·포기·취하, ii) 특허권의 존속기간연장등록출원의 취하, iii) 신청의 취하, iv) 청구의 취하, v) 국내우선권주장 또는 그 취하, vi) 특허거절결정에 대한 심판청구를 제외하고는 각자가 모두를 대표한다. 다만 대표자를 선정하여 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 신고하면 그 대표자만이 모두를 대표할 수 있다. 대표자를 선정하여 신고하는 경우에는 대표자로 선임된 사실을 서면으로 증명하여야 한다(法 11).

제3절 직무발명

발명진흥법 제2조 [정의]

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2010. 1. 27., 2010. 6. 8., 2013. 7. 30., 2015. 5. 18., 2023. 1. 3., 2024. 2. 6.>

1. “발명”이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
2. “직무발명”이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자 등”이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다.
3. “개인발명가”란 직무발명 외의 발명을 한 자를 말한다.
4. “산업재산권”이란 「특허법」·「실용신안법」·「디자인보호법」 또는 「상표법」에 따라 등록된 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권을 말한다.
5. “특허관리전담부서”란 사용자 등에서 산업재산권에 관한 기획, 조사 및 관리 등의 업무를 담당하는 부서를 말한다.
- 5의2. “공익변리사”란 제26조의2에 따라 설치된 공익변리사 특허상담센터에서 업무를 수행하는 변리사를 말한다.
6. 삭제 <2024. 2. 6.>
7. 삭제 <2024. 2. 6.>
8. 삭제 <2024. 2. 6.>
9. “산업재산권 서비스업”이란 산업재산권의 창출·보호·활용을 지원하는 다음 각 목의 서비스업을 말한다.
 - 가. 산업재산권에 관한 정보를 수집·분석·가공·번역·유통 또는 관리하거나 이와 관련한 소프트웨어 또는 시스템을 개발하거나 구축하는 업
 - 나. 「변리사법」 제2조에서 규정하는 업
 - 다. 산업재산권의 경제적 가치 및 기술적 우수성을 가액(價額)·등급 또는 점수 등으로 평가하는 업

라. 산업재산권의 양도 또는 실시권의 설정·허락 등 산업재산권의 거래행위를 중개·알선하는 업
마. 그 밖에 대통령령으로 정하는 업

10. “산업재산권 서비스사업자”란 산업재산권 서비스업을 영위하는 자를 말한다.

발명진흥법 제10조【직무발명】

① 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.7.30>

1. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
2. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정

② 제1항에도 불구하고 공무원 또는 국가나 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자(이하 “공무원등”이라 한다)의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계할 수 있으며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원등의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원 등의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원 등의 직무발명에 대한 특허권 등은 그 전담조직의 소유로 한다. <개정 2021. 4. 20.>

③ 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.

④ 제2항에 따라 국유로 된 특허권 등의 처분과 관리(특허권 등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 지식재산처장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.1.30., 2010.1.27>

발명진흥법 제10조의2【공무원등의 직무발명 처분의 특례】

「국유재산법」 제65조의11제2항 단서에도 불구하고 지식재산처장이 정하여 고시하는 경우에는 제10조제2항에 따라 국유로 된 특허권등에 관한 전용실시권 설정을 한 번 이상 갱신할 수 있다. [본조신설 2021. 4. 20.]

발명진흥법 제11조【직무발명보상제도의 실시와 지원시책】

① 정부는 종업원 등의 직무발명을 장려하기 위하여 직무발명보상제도 등의 실시에 관한 지원시책을 수립·시행하여야 한다.

② 제1항에 따른 지원시책에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다. <개정 2013.7.30>

1. 표준이 되는 보상규정의 작성 및 보급
2. 보상과 관련된 분쟁을 예방 및 해결하기 위한 합리적인 절차규정의 작성 및 보급
3. 직무발명보상제도의 실시·운영에 관한 상담 등의 지원

③ 정부는 직무발명에 대한 보상을 실시하는 사용자 등에 대하여는 제3장과 제4장에 따른 발명의 권리화와 사업화를 촉진하기 위한 조치를 먼저 하여야 한다.

발명진흥법 제11조의2【직무발명보상 우수기업 인증 등】

① 지식재산처장은 제11조제1항에 따른 직무발명보상제도의 활성화를 위하여 직무발명보상제도를 모범적으로 운영하는 기업을 직무발명보상 우수기업(이하 “우수기업”이라 한다)으로 인증할 수 있다. <개정 2024. 2. 6.>

② 우수기업 인증을 받고자 하는 기업은 지식재산처장에게 신청하여야 한다. <신설 2024. 2. 6.>

- ③ 지식재산차장은 제2항에 따른 인증신청을 받은 경우에는 인증을 받으려는 기업에 대한 심사를 하고, 인증기준에 적합하면 유효기간을 정하여 인증을 하여야 한다. <신설 2024. 2. 6.>
- ④ 지식재산차장은 인증받은 우수기업이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 인증을 취소할 수 있다. 다만, 제1호에 해당하는 경우에는 인증을 취소하여야 한다. <신설 2024. 2. 6.>
 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인증을 받은 경우
 2. 제6항에 따른 인증기준에 적합하지 아니하게 된 경우
- ⑤ 국가 및 지방자치단체는 인증받은 우수기업에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. <신설 2024. 2. 6.>
- ⑥ 우수기업 인증의 기준, 절차, 재인증, 유효기간, 그 밖에 인증에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2024. 2. 6.>

[본조신설 2013. 3. 22.]

[제목개정 2024. 2. 6.]

발명진흥법 제12조 【직무발명 완성사실의 통지】

종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 알려야 한다. 2명 이상의 종업원 등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 알려야 한다. <개정 2022. 11. 15.>

발명진흥법 제13조 【직무발명의 권리승계】

- ① 제12조에 따라 통지를 받은 사용자 등이 종업원 등의 직무발명에 대하여 미리 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자 등에게 승계된다. 다만, 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원 등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2024. 2. 6.>
- ② 제1항에 따른 계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 제12조에 따라 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다. 이 경우 사용자 등은 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다. <개정 2024. 2. 6.>
- ③ 사용자 등이 제2항에 따른 기간에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 제10조제1항에도 불구하고 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다. <개정 2024. 2. 6.>

[제목개정 2024. 2. 6.]

발명진흥법 제14조 【공동발명에 대한 권리의 승계】

종업원 등의 직무발명이 제삼자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다.

발명진흥법 제15조 【직무발명에 대한 보상】

- ① 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.
- ② 사용자 등은 제1항에 따른 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다. <개정 2013.7.30., 2022. 11. 15.>
- ③ 사용자 등은 제2항에 따른 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원 등과 협의하여야 한다. 다만, 보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 해당 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다. <개정 2013.7.30.>
- ④ 사용자 등은 제1항에 따른 보상을 받을 종업원 등에게 제2항에 따른 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 한다. <신설 2013.7.30.>

- ⑤ 사용자 등이 제3항에 따라 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원 등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2013.7.30>
 - ⑥ 사용자 등이 제2항부터 제4항까지까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 본다. 다만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2013.7.30>
 - ⑦ 공무원 등의 직무발명에 대하여 제10조제2항에 따라 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다.
- <개정 2013. 7. 30., 2021. 4. 20.>

발명진흥법 제16조 【출원 유보시의 보상】

사용자 등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원(出願)하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다. 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다.

발명진흥법 제16조의2 【승계한 권리의 포기 및 종업원 등의 양수】

- ① 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제2조제6호에 따른 공공연구기관(이하 이 조에서 “공공연구기관”이라 한다)이 국내 또는 해외에서 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수 있는 권리 또는 특허권등(이하 “직무발명에 대한 권리”라 한다)을 종업원 등으로부터 승계한 후 이를 포기하는 경우 해당 직무발명을 완성한 모든 종업원 등은 그 직무발명에 대한 권리를 양수할 수 있다.
- ② 제1항에도 불구하고 공공연구기관의 장이 대통령령으로 정하는 바에 따라 공공의 이익을 위하여 특별히 직무발명에 대한 권리를 포기할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 권리를 종업원 등에게 양도하지 아니할 수 있다. 이 경우 공공연구기관의 장은 제3항의 기간 내에 종업원 등에게 그 사유를 구체적으로 알려야 한다.
- ③ 제1항에 따라 직무발명에 대한 권리를 포기하려는 공공연구기관의 장은 대통령령으로 정하는 기간 내에 해당 직무발명을 완성한 모든 종업원 등에게 그 사실을 통지하여야 한다.
- ④ 제3항에 따른 통지를 받은 종업원 등은 직무발명에 대한 권리를 양수하려는 경우 통지를 받은 날부터 대통령령으로 정하는 기간 내에 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 공공연구기관의 장에게 서면으로 알려야 한다. <개정 2022. 11. 15.>
- ⑤ 제4항에 따라 종업원 등이 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 경우 제4항의 기간이 끝난 날의 다음 날부터 그 권리가 종업원 등에게 양도된 것으로 본다. 이 경우 공공연구기관이 직무발명에 대한 권리를 제3자와 공유한 경우에는 공공연구기관의 장이 다른 공유자 모두의 동의를 받은 때에 한정하여 그 권리가 양도된 것으로 본다.
- ⑥ 제4항에 따라 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 종업원 등이 2명 이상인 경우에는 그 권리를 공유한다.
- ⑦ 공공연구기관의 장과 종업원 등은 공공연구기관이 직무발명에 대한 권리를 계속 유지하기 위한 비용을 종업원 등이 일부 부담하는 대신 직무발명에 대한 종업원 등의 보상을 조정하는 방안을 제3항의 기간 내에 상호 협의할 수 있다.
- ⑧ 공공연구기관의 장은 제5항 전단에 따라 직무발명에 대한 권리가 종업원 등에게 양도된 것으로 보는 날 이후 그 권리와 관련하여 발생하는 비용(세금을 포함한다)을 종업원 등에게 청구할 수 있다.

[본조신설 2021. 4. 20.]

발명진흥법 제17조 【직무발명심의위원회의 운영 등】

- ① 사용자 등은 종업원 등의 직무발명에 관한 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 설치·운영할 수 있다. <개정 2013.7.30>
- 1. 직무발명에 관한 규정의 작성·변경 및 운용에 관한 사항

2. 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관한 종업원 등과 사용자 등의 이견 조정에 관한 사항
3. 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항
- ② 심의위원회는 사용자 등과 종업원 등(법인은 제외한다)을 각각 대표하는 같은 수의 위원으로 구성하되, 필요한 경우에는 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있다. <개정 2013.7.30>
- ③ 그 밖에 심의위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <산설 2013.7.30>

발명진흥법 제18조 【직무발명 관련 분쟁의 조정 등】

- ① 종업원 등은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사용자 등에게 심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있다. <개정 2024. 2. 6.>
 1. 직무발명인지 여부에 관하여 사용자 등과 이견이 있는 경우
 2. 사용자 등이 제10조제3항을 위반하여 종업원 등의 의사와 다르게 직무발명 외의 발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
 3. 사용자 등이 제13조제2항을 위반하여 종업원 등의 의사와 다르게 직무발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
 4. 사용자 등이 제10조제1항 단서 또는 제13조제3항을 위반하여 통상실시권을 주장하는 경우
 5. 사용자 등이 제시한 보상규정에 이견이 있는 경우
 6. 사용자 등과의 협의 또는 동의 절차에 이견이 있는 경우
 7. 사용자 등이 제15조제4항에 따라 통지한 보상액 등 보상의 구체적 사항에 이견이 있는 경우
 8. 사용자 등이 제15조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상하지 아니하는 경우
 9. 그 밖에 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 사용자 등과 종업원 등 간에 이견이 있는 경우
- ② 제1항에 따른 권리는 제1항 각 호의 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 행사하여야 한다. 다만, 제1항 제7호의 경우에는 종업원 등이 통지를 받은 날부터 30일 이내에 행사하여야 한다.
- ③ 사용자 등은 제1항에 따른 요구를 받은 경우에 60일 이내에 심의위원회를 구성하여 심의하도록 하여야 한다. 이 경우 심의위원회에는 직무발명 관련 분야의 전문가인 자문위원이 1명 이상 포함되도록 하여야 한다.
- ④ 제3항에 따른 심의위원회는 심의의 결과를 사용자 등과 종업원 등에게 지체 없이 서면으로 통지하여야 한다.
- ⑤ 정부는 사용자 등의 요청에 따라 관련 분야의 전문가를 제3항에 따른 자문위원으로 파견할 수 있으며, 이에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ⑥ 제3항에 따른 심의위원회의 심의 결과에 불복하거나 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 사용자 등 또는 종업원 등은 제41조에 따른 산업재산분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다.

발명진흥법 제19조 【비밀유지의 의무】

- ① 종업원 등은 사용자 등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만, 사용자 등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.7.30>
- ② 제18조제3항에 따라 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. <산설 2013.7.30>

발명진흥법 제58조 【벌칙】

- ① 국내외에서 정당한 사유 없이 제55조의9제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <산설 2024. 2. 6.>
- ② 제19조를 위반하여 부정한 이익을 얻거나 사용자 등에 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자에 대하여는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2024. 2. 6.>
- ③ 제31조제7을 위반한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <산설 2023. 1. 3., 2024. 2. 6.>
- ④ 제1항 및 제2항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자 및 사용자 등의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다. <개정 2023. 1. 3., 2024. 2. 6.>

I. 서 설

1. 의 의

「직무발명」이란 종업원·법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라 한다)이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자 등”이라 한다)의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(發振法 2Ⅱ). 직무발명에 대해서는 원시적으로 발명자인 종업원 등에게 특허를 받을 수 있는 권리가 귀속한다고 하는 한편 사용자 등에게는 그러한 종업원 등의 직무발명에 대한 법정실시권과 예약승계를 인정하고 있다.

【표 2-4】 종업원 발명의 법적 취급

구 분	종업원 등의 권리 및 의무	사용자 등의 권리 및 의무
직무발명	■ 특허를 받을 수 있는 권리의 원시적 취득 ■ 발명완성사실통지의무 ■ 비밀유지의무	■ 법정실시권(단, 대기업의 경우 예약승계 계약의 체결 또는 근무규정의 작성에 있는 경우에 한함) ■ 예약승계 - 예약승계계약이나 근무규정에 근거한 승계취득 - 승계한 경우 정당한 보상 의무
자유발명	■ 특허를 받을 수 있는 권리의 원시적 취득	■ 승계한 경우 정당한 보상 의무

2. 취 지

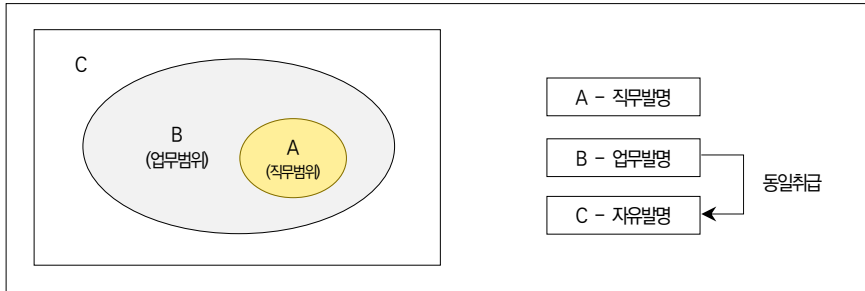
1) 종업원 발명은 서로 대립되는 2개의 법 영역에 걸쳐 있는 소위 한계영역에 속하는 특수한 발명이다. 구체적으로 종업원 발명은 종업원 등에 의한 것이므로 노동법의 적용영역일 뿐만 아니라 발명이기 때문에 특허법의 적용영역이기도 한 것이다. 이 경우 직무발명의 귀속이 문제가 되는데 발명자 원칙을 채용하여 진실로 발명을 완성한 자에 대해서만 특허를 받을 수 있는 권리를 인정하고 있는 현행 특허법에 규정에 의하면 특허를 받을 수 있는 권리는 당연히 발명자인 종업원 등에게 원시적으로 귀속된다. 그러나 노동법에 의하면 노동의 성과는 모두 사용자 등에게 귀속되기 때문에 전자를 강조하면 발명은 종업원 등에게 귀속되며, 후자를 강조하면 발명은 사용자 등에게 귀속된다.

2) 이러한 이유로 발명진흥법은 발명하도록 연구개발투자자나 시설 등을 제공한 사용자 등과 창작의 노력을 제공하여 발명한 종업원 등 사이에 합리적인 이익배분을 함으로써, i) 사용자 등에게 보다 적극적인 투자를 하도록 유도하고 ii) 종업원 등에게는 발명을 할 동기를 부여하여 국가경제 발전에 이바지하기 위해 직무발명에 관한 규정(發振法 2, 10-19 및 58)을 두어 사용자 등과 종업원 등 간의 관계를 법정하고 있다.²¹⁸⁾

218) 기존에는 직무발명 관련규정이 특허법과 발명진흥법에 산발적으로 규정되어 있어 직무발명의 개념, 직무발명 완성부터 사용자 승계까지의 절차 및 권리귀속관계, 보상 및 분쟁해결 등 직무발명 관련 절차를

3. 종 류

강학상 종업원 발명은 i) 종업원 등의 직무 및 사용자 등의 업무범위에 속하는 직무발명, ii) 사용자 등의 업무범위에만 속하는 업무발명, iii) 종업원 등의 직무 및 사용자 등의 업무와 무관한 자유발명이 있다. 다만 발명진흥법 제2조제3호에서는 “개인발명자란 직무발명 외의 발명을 한 자를 말한다”라고 규정하여 직무발명 외의 발명인 업무발명과 자유발명(이하 양 발명을 합해 “자유발명(개인발명)”이라 한다)에 대해서는 동일한 취급을 하고 있다.



【그림 2-19】 종업원 발명의 종류

II. 직무발명의 성립요건

1. 종업원 등이 발명하였을 것

(1) 종업원 등

1) 「종업원 등」이란 종업원·법인의 임원 또는 공무원 등과 같이 사용자와 고용계약이나 그 밖의 관계에 의하여 타인의 사무에 종사하는 자로서, 상근·비상근, 보수지급유무, 근로기준법상의 최하 연령 등을 불문하고 사용자와 고용관계에 있는 한 종업원 등이다. 「고용관계」란 민법²¹⁹⁾이나 근로기준법에서 말하는 고용관계보다 더 넓게 해석하여 계약의 종류나 내용에 상관없이 사실상 타인에게 노무를 제공할 의무를 부담하는 관계를 말한다.

2) 문제가 되는 것은 파견된 종업원 등의 지위인데 일반적으로 사용자 간 파견계약에 정함이 있다면 그에 따르며, 그러한 정함이 없다면 당해 발명의 직무관련성, 시설·설비 등의 이용관계, 지시·지휘·명령·감독 관계, 지원 여부 등을 요소로 하여 파견 사용자 등과 사용 사용자 등 중에서 어느 사용자 등의 종업원 등에 해당하는지 판단하여야 한다.²²⁰⁾

체제적, 통일적으로 규율하는데 한계가 있었으나, 개정된 발명진흥법(법률 제7869호, 2006. 3. 3. 개정 / 2006. 9. 4. 시행)에서 발명진흥법으로 직무발명법제를 단일화함으로써 제도 활성화를 위한 법적 토대가 마련되었다. 이러한 직무발명의 규정은 발명진흥법 속에 녹아있는 경제적 약자에 대한 보호 규정이라 할 수 있으며, 민법상 고용관계의 일반원리(民法 655)에 대한 특별규정의 성격을 지닌다.

219) 민법상 고용관계란 일방이 상대방에게 노무를 제공할 것을 약정하고 상대방이 이에 대하여 보수를 지급할 것을 약정하는 계약을 맺은 관계를 말한다(民法 655).

(2) 발 명

「발명」이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도성이 있는 것을 말한다(法 2 I). 종업원 등이 어떤 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단을 새로 착상하거나 새로운 기술적 수단을 구체화하였으면 발명자²²¹⁾가 된다.

2. 사용자 등의 업무범위에 속할 것

(1) 사용자 등

「사용자 등」이란 종업원 등을 선임하여 특정 사무에 종사하게 하고 그 지휘 및 감독을 하는 자를 말하며 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체 등을 의미한다. 개인회사의 경우에는 일률적으로 누가 사용자 등인지 단정할 수는 없으며 개인회사가 법인이나, 법인이 아니냐에 따라 판단하여야 할 것이다. 예컨대, 법인격을 갖춘 개인회사인 경우에는 대표자(자연인)와 회사(법인)는 각각 법률상 별개의 인격체로서 대표자라 할지라도 사용자 등이 아니라고 보아야 하나, 법인격을 갖추지 못한 소규모의 개인회사의 경우에는 대표자가 당연히 사용자 등이 되어야 한다.

(2) 업무범위

1) 사용자 등의 업무범위에 관한 문제는 종업원 등의 발명이 사용자 등의 업무범위에 속하지 아니하면 직무발명이라 할 수 없으므로 중요하다. 「업무범위」란 사용자 등이 수행하는 사업의 범위로서 사용자가 개인, 법인 및 국가인지에 따라 각각 달리 해석된다. 먼저, 사용자 등이 「개인」일 경우 그 개인이 추구하는 현실적인 사업내용을 중심으로 업무범위를 파악하여야 한다. 예를 들면 나사를 생산·판매하는 것을 목적으로 하는 개인사업자의 업무범위는 나사와 관련된 생산·판매 등이 사용자 등의 업무범위로 볼 수 있다.

2) 다음으로, 사용자 등이 「법인」일 경우에는 일반적으로 정관을 중심으로 그 밖의 부수하는 사업까지를 업무범위로 본다.²²²⁾ 그러나 사용자 등의 업무범위는 법인이 정관으로 정한 목적의 범위가 아니라 객관적으로 현재 또는 장래에 행할 예정인 업무와 기술적인 관련성이 있는 범위라고 해석함이 타당하다.²²³⁾²²⁴⁾ 예를 들면 주방용 기계·기구를 제조·판매하는 기업이라면

220) 지식재산처, 「직무발명제도」, 2012, 35면.

221) 발명자의 결정 및 기여율의 결정은 발명자에 대한 보상, 업적평가 등에 있어 매우 중요하다. 발명자가 한 사람일 경우에는 문제가 없으나 공동발명의 경우에는 현실적으로 누가 진정한 발명자인지 쉽게 판단할 수 없으며, 특히 다수인이 참여하여 특정의 프로젝트를 수행하는 도중 발명을 할 경우 더욱 그러하다. 진정한 발명자인지는 해당 발명을 중심으로 실질적 협력자인지 단순한 협력자인지를 기준으로 판단하여야 하며, 단지 신분상 또는 직제상 지위가 높다는 이유로 발명에 기여하지 아니한 자를 발명자로 적는다든가 기여 실적이 미미함에도 불구하고 기여율을 높여주는 등 불합리한 일이 없도록 하여야 한다.

222) 천효남, 「특허법」, 제9판, 법경사, 2003, 248면.

223) 왜냐하면 직무발명은 사용자와 종업원 간 권리관계의 조정을 도모하지만, 정관에서 정하고 있는 회사의 목적은 주주의 보호를 위하여 회사와 거래 상대방 사이에서 회사의 권리능력을 확정하기 위한 것이지 사용자와 종업원 간 이해의 조정을 도모하기 위한 것이 아니기 때문이다. 특히 정관의 목적 범위를 개정

선반, 그릇 넣는 장치, 배수장치 기계·기구 등 부수 사업에 해당한다.

3) 마지막으로, 사용자 등이 「국가」일 경우에 업무범위를 기업 등 법인의 경우와 같이 해석하게 되면 전 국가의 업무가 모두 포함되기 때문에 불합리하게 된다. 따라서 발명한 공무원이 소속된 기관의 직제와 사무분장규칙에 정해진 업무범위로 한정하여 해석하여야 한다.

3. 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것

(1) 발명을 하게 된 행위가 직무에 속할 것

「발명을 하게 된 행위」란 발명을 착상하고 구체화하여 완성하기까지의 행위로서 발명을 의도하였는지와 상관없이 이론적 추구, 문헌조사 등 정신적 활동뿐만 아니라, 이것에 부수하는 연구소에서의 실험, 공장에서의 제조 작업 등 육체적 활동도 포함하며,²²⁵⁾ 근무시간의 내외 또는 직무 내외를 불문한다. 「직무」란 종업원 등이 사용자 등의 요구에 따라 사용자 등의 업무 일부를 담당하는 것을 말하는 것으로,²²⁶⁾ 「직무」인지 여부는 그 종업원 등의 지위·급여·발명과 수행하였던 업무와 연관성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 할 것이다.²²⁷⁾ 따라서 「발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 직무에 속하는 발명」이란 종업원 등이 발명에 대한 구체적인 과제를 사용자 등으로부터 부여받지 아니하였을지라도 종업원 등이 담당하는 직무내용과 책임범위로 보아 발명을 피하고 이를 수행하는 것이 당연히 예정되거나 기대되는 경우를 말한다.²²⁸⁾ 예를 들어 연구소의 연구원, 설계부의 설계사, 공장장, 기술담당이사의 발명은 직무에 속하는 것으로 해석될 수 있다.

(2) 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명일 것

1) 직무발명은 종업원 등이 현재에 담당하고 있는 직무에 속하는 발명은 물론이고 과거에 담당하고 있던 직무에 속하는 발명도 포함된다. 예를 들어 과거에 A전자회사의 TV 영상회로 연구소에서 근무하던 자가 A전자회사 TV 완성품 검사부서에 근무하면서 발명한 TV회로에 관한 발명과 TV의 품질검사를 자동으로 할 수 있는 방법에 관한 발명은 모두 직무발명에 속한다. 여기에서 TV회로에 관한 발명은 과거의 직무에 속하는 발명이고, TV의 품질검사를 자동으로

하지 않고 경기변동 또는 사업다각화를 위하여 새로운 사업을 추진하는 경우가 있는데 이러한 경우를 직무발명에서 제외한다면 행평의 원리에 반한다고 하여야 할 것이다(정진옥, “자유발명으로 의제된 직무발명”, 한국상사판례학회, 상사판례연구, 제15권, 2003, 101- 102면).

224) 서울동부지방법원 2007. 7. 13. 선고 2006가합16244.

225) 송영식·이상정·황종환, 「지식재산권법(상)」, 육법사, 1999, 270면.

226) 서울중앙지방법원 남부지원 2002. 8.22. 선고 2001가합13977).

227) 서울동부지방법원 2007. 7. 13. 선고 2006가합16244.

228) 약기 회사의 공작과 기능직 사원으로 입사하여 회사를 퇴직할 때까지 공작과 내 여러 부서에 숙련공으로 근무하면서 금형제작, 센터편압입기 제작, 치공구 개발 등의 업무에 종사한 자가 피아노 부품의 하나인 플랜지의 구멍에 붓싱을 효과적으로 감입하는 장치를 고안한 경우, 위 근무기간 중 위와 같은 고안을 시도하여 완성하려고 노력하는 것이 일반적으로 기대되므로 위 고안은 직무발명에 해당한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113).

할 수 있는 방법에 관한 발명은 현재의 직무에 속하는 발명이다. 그러나 TV영업부에 근무하는 자가 발명한 새로운 TV회로는 직무발명이 아니다.

2) 여기에서의 「현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명」이란 동일 기업 내에서 해당 종업원 등이 담당하였던 현재 또는 과거의 직무를 말한다. 특히 문제가 되는 것은 고용관계가 이미 종료된 후, 즉 퇴직 후의 발명이 직무발명인지 여부이다. 현재 또는 과거의 직무란 발명진흥법 제2조제2호의 문리해석상 종업원 등이 「발명완성 당시」에 사용자 등과 고용관계에 있는 경우에서의 직무만을 의미한다고 해석되므로 재직 중에 발명을 완성하고 퇴직하였으면 직무발명이지만 퇴직 후에 발명을 완성하였으면 원칙적으로 자유발명이라고 해석함이 타당하다.²²⁹⁾²³⁰⁾ 한편 발명완성시기가 퇴직 전·후인지는 사용자 등 측에 증명책임이 있으므로 사용자는 적절한 연구관리(예를 들어 연구일지의 작성의 의무화 및 체크 등)를 할 필요가 있다.

Ⅲ. 직무발명에 대한 법적취급

1. 종업원 등의 권리 및 의무

(1) 특허를 받을 수 있는 권리의 원시적 취득

우리나라는 발명자주의²³¹⁾를 채택하고 있으므로 특허를 받을 수 있는 권리는 발명자인 종업원 등에게 원시적으로 귀속한다(法 33①본문). 이 경우 종업원 등은 특허를 받을 수 있는

229) 직무발명에 해당하는지 여부를 판단하는 기준은 그 발명이 완성될 당시라고 할 것이므로, 비록 등록된 발명의 출원은 발명자의 퇴직 이후에 이루어졌더라도 이미 재직 중에 완성된 발명을 나중에 출원한 것이라면 직무발명에 해당한다(특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허6280).

230) 다만 퇴직 후에 완성한 발명이라도 재직기간이 비교적 길고 그 기간에 체득한 지식과 경험이 발명완성 당시에 큰 역할을 한 경우 등 특별한 사정이 있는 경우라면 발명진흥법 제2조제2호에 저촉되지 아니하는 범위에서 직무발명이라고 인정될 수 있어야 한다. 미국의 경우, 판례상 기업내에서 이루어진 발명은 퇴직 후에도 공공의 질서에 반하지 아니한 한도 내에서 해당 발명을 추적할 수 있다. 이와 같은 판례에 근거해서 사용자와 종업원의 계약에 이른바 추적조항(trailing clause)을 마련하는 것이 통례로 되어 있다. 추적조항은 퇴직 후 일정한 기간에 한 발명으로 전사용자의 업무범위에 속하는 것은 전 사용자가 승계하도록 하는 특약조항이다. 그러나 이러한 추적조항은 종업원의 새로운 고용기회를 제한할 뿐만 아니라 자유발명을 직무발명으로 간주하는 등 종업원에게 불리하게 작용할 수 있어 남용되어서는 안 될 것이다(지식재산처, 「직무발명제도」, 2012, 49-50면 참조).

231) 사용자주의와 발명자주의를 비교하면 다음과 같다(박상욱, “직무발명제도에 관한 고찰”, 연세대 특허법 무대학원, 석사, 1996, 18면).

구 분	사용자주의	발명자주의
기본이념	고용의 원칙(민법 제655조) 은혜주의와 밀접	발명은 개인의 지적산물 권리주의와 밀접
권리귀속	사용자	원시적으로 발명자
직무발명규정	불필요	필요
출원자	사용자	사용자 또는 발명자
대가의 성격	포상	보상

권리를 이전할 수 있으며(法 37①), 특허권을 취득한 후 권리행사도 자유롭게 할 수 있다. 다만 사용자 등과 예약승계계약이나 근무규정이 체결 또는 작성되는 경우에는 발명을 완성한 때부터 사용자 등에게 승계된다(發振法 13)

(2) 발명완성사실의 통지의무

종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체없이 그 사실을 사용자 등에게 서면(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제2조제1호에 따른 전자문서를 포함한다. 이하 같다)으로 통지하여야 한다. 2명 이상의 종업원 등이 공동으로 직무발명을 완성한 경우에는 공동으로 통지하여야 한다(發振法 12). 이처럼 종업원 등에게 통지의무를 부과하는 것은 i) 직무발명 관련 내부 규정이 없는 기업의 경우 비록 종업원 등이 직무발명을 완성했다 하더라도 이를 사용자 등에게 통지할 의무가 없다면 기술유출의 우려가 있으며, ii) 또한 직무발명 관련 내부 규정의 유무와 관계없이 직무발명에 대하여 종업원 등 또는 승계인이 특허를 받았으면 사용자 등에게 무상의 통상실시권이 인정(단, 대기업은 제외)되나 사용자 등이 통상실시권을 행사하기 위해서 종업원 등의 신고 등 협조가 필요하기 때문이다.

(3) 비밀유지의무

종업원 등은 사용자 등이 직무발명을 출원할 때까지 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지하여야 한다. 다만 사용자 등이 승계하지 아니하기로 확정된 경우에는 그러하지 아니하다(發振法 19). 이를 위반하여 부정한 이익을 받거나 사용자 등에게 손해를 가할 목적으로 직무발명의 내용을 공개한 자는 사용자의 고소가 있을 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(發振法 58). 이는 직무발명이 완성되기까지는 사용자 등이 많은 투자를 하였고, 그 완성된 발명이 타경쟁 업체에 누설되면 심각한 손실을 볼 우려가 있기 때문이다.

2. 사용자 등의 권리 및 의무

(1) 무상의 통상실시권 취득

① 의 의

1) 사용자 등은 종업원 등이 출원한 직무발명이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 경우 법정실시권인 통상실시권을 취득한다(發振法 10①본문). 이는 종업원 등이 발명을 완성하기까지 사용자 등이 공헌한 바가 크므로 종업원 등에게는 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 부여하되, 특허권이 형성되면 사용자 등에게는 일정한 권리를 부여하는 것이 공평의 관념에서 타당하기 때문이다. 이때의 통상실시권은 발명진흥법 제10조제1항에 따라 당연히 발생하는 것으로서 무상이며, 실시범위에 제한이 없고 해당 특허권의 소멸시까지 유효하다. 또한 통상실시권은 제118조제2항에 따라 등록하지 아니하여도 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여 실시권의 효력을 주장할 수 있다.

2) 직무발명에 대한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자 등은 종업원 등이 직무발명을 완성할 당시의 사용자 등이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 하여 등록 당시의 사용자 등이 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다.²³²⁾ 이는 발명완성 당시에 고용관계에 있는 사용자 등을 기준으로 직무발명인지 여부를 판단하기 때문이다.

3) 다만 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 다음의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 사용자 등은 통상실시권을 취득하지 못한다(發振法 10①단서). 이는 대기업의 직무발명보상제도 도입을 적극적으로 유도함으로써 기업 전반에 상당한 보상문화를 정착시켜 지식산업시대의 기업경쟁력과 국가경쟁력을 강화하기 위해 2013. 7. 30. 시행된 현행 법(법률 제11960호, 2013. 7. 30. 개정)에서 도입되었다.

- i) 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
- ii) 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정

4) 중소기업의 경우 예약승계계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니하여도 법정실시권이 인정되지만, 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 미승계통지를 하거나, 승계통지를 하였으나 종업원 등의 의사와 달라서 직무발명에 대한 권리의 승계가 되지 않아야 한다. 즉 사용자 등이 승계 여부를 통지하지 아니한 경우에는 법정실시권이 발생하지 아니한다(發振法 13③).

5) 한편 예약승계계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하여 이를 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자 등에게 승계되기 때문에 법정실시권은 혼동에 의해 소멸하나, 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 종업원 등에게 미승계통지를 한 경우에는 법정실시권이 인정된다(發振法 13①).

② 동의권

실시권이나 질권 등은 특허권이 소멸하면 같이 소멸되는 부수성을 가지고 있으므로 실시권자 또는 질권자는 특허권의 소멸이나 변경에 이해관계가 있다고 할 수 있다. 따라서 특허권자가 특허권을 포기하거나, 그 특허발명의 명세서·도면에 대한 특허의 정정 또는 정정심판을 청구할 때 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 질권자 및 직무발명에 대한 통상실시권자(사용자 등)의 동의(다만 특허권자가 특허의 정정, 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)를 받아야 한다(法 119①, 132의3③, 133의2④, 137④ 준용 133의2④, 136⑧). 직무발명에 대한 통상실시권자인 사용자 등은 다른 동의권자와는 달리 특허권자의 의사에 의한 것이 아닌 법률에 의하여 통상실시권자가 되었음에도, 사용자 등의 이익 보호를 위해 동의권을 인정하고 있다.

232) 대법원 1997. 6. 27. 선고 97도516.

(2) 직무발명에 대한 예약승계할 수 있는 권리 인정

① 의 의

1) 사용자 등은 근무규정이나 계약에 의하여 미리 종업원 등의 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계하거나 전용실시권을 설정하게 할 수 있는데 이를 강학상 「예약승계」라 한다. 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다(發振法 10③).

2) 「직무발명 외의 종업원 등의 발명」이란 자유발명을 의미하고, 「미리」란 발명완성 전을 의미한다. 즉 발명완성 전에는 사회적·경제적 약자인 종업원 등에게 계약이 불리하게 체결될 가능성이 크기 때문에 직무발명에 대해서만 사용자 등이 특허를 받을 수 있는 권리, 특허권을 승계취득하거나 전용실시권을 설정할 수 있도록 하여 사용자 등에 대하여 약한 입장에 있는 종업원 등의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하려는 점에 발명진흥법 제10조제3항의 입법취지가 있다 할 것이다.²³³⁾ 따라서 모든 발명에 대한 예약승계하기로 약정을 한 경우 자유발명에 대한 부분은 무효이지만 직무발명에 대한 부분은 유효하다 할 것이다.²³⁴⁾

3) 발명완성 후에는 직무발명이 아니라고 하더라도 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 양도, 특허권의 양도, 전용실시권을 설정하기로 하는 승계의 합의(계약)는 가능하다(法 37①, 99①, 100①).²³⁵⁾ 여기서 사용자 등에게 승계시키는 합의는 종업원 등의 의사가 명시적으로 표시된 경우뿐만 아니라 묵시적 의사를 추인할 수 있는 명백한 사정이 인정되는 경우도 포함된다.²³⁶⁾ 또한 발명완성 전이라도 통상실시권을 가지도록 하는 계약이나 근무규정은 유효하다. 즉 자유발명에 대해서도 사용자 등이 미리 계약 또는 근무 규정에 따라 종업원 등에게 발명을 신고하게 하여 통상실시권을 허락받을 수는 있다.

233) 대법원 1977. 2. 8. 선고 76다2822.

234) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676.

235) 대구고등법원 1976. 11. 12. 선고 76나590.

236) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834.

【표 2-5】 종업원 발명에 대한 승계

구 분		발명완성 전 예약승계	발명완성 후 승계
직무 발명	특허를 받을 수 있는 권리 승계계약	가능	가능
	특허권 승계계약	가능	
	전용실시권 설정계약	가능	
	통상실시권 허락계약	종업원 등 또는 승계인이 특허를 받은 경우 법정실시권 발생하기 때문에 불필요 (단, 대기업의 경우 예약승계계약의 체결 또는 근무규정의 작성이 된 경우에 한함)	
자유 발명	특허를 받을 수 있는 권리 승계계약	불가능	가능
	특허권 승계계약	불가능	
	전용실시권 설정계약	불가능	
	통상실시권 허락계약	가능	

② 공동직무발명인 경우

종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 갖는다(發振法 14). 이 경우 지분의 이전에 대하여 제37조제3항에 의하여 제3자인 다른 공유자의 동의를 받아야 하는지 문제인데, 대법원²³⁷⁾은 이미 공동개발을 할 때 다른 공유자의 묵시적 동의가 있는 것으로 간주하여 별도의 동의절차를 밟을 필요가 없는 것으로 해석하고 있다.

③ 이중양도의 경우

1) 종업원 등이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 양도한다는 예약승계계약이나 근무규정(發振法 10③)과 발명완성사실의 통지의무(發振法 12)에 위반하여 직무발명을 완성한 후에 제3자에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였으면 문제가 된다. 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 사용자 등이 특허출원을 하여야 제3자에게 대항할 수 있으므로(法 38①) 출원 전에 제3자가 종업원 등으로부터 그 권리를 이중양도 받아서 사용자 등보다 먼저 특허출원을 하면 사용자 등은 그 승계사실을 제3자에게 주장할 수 없게 된다.²³⁸⁾ 이 경우 사용자 등은 고용계약 위반을 이유로 종업원 등에 대하여 징계처분 또는 해고 등을 하거나 민법상 채무불이행에 의한 손해배상을 청구 또는 이중양도로 취한 이득에 대하여 부당이득반환 청구를 하여 불이익을 회복할 수 있다. 또한 사용자 등은 종업원 등에게 비밀유지의무(發振法 19) 위반에 대하여 형사책임(發振法 58)과 형법상 배임죄(刑法 355)²³⁹⁾의 책임을 물을 수도

237) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676.

238) 광주지방법원 2012. 2. 2. 선고 2011가합13793.

239) 배임죄가 성립하기 위해서는 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로써 재산상의 이

있다. 그 밖에 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률(제36조-제39조) 또는 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률(제18조-제20조)²⁴⁰⁾의 적용을 고려해 볼 수도 있다.

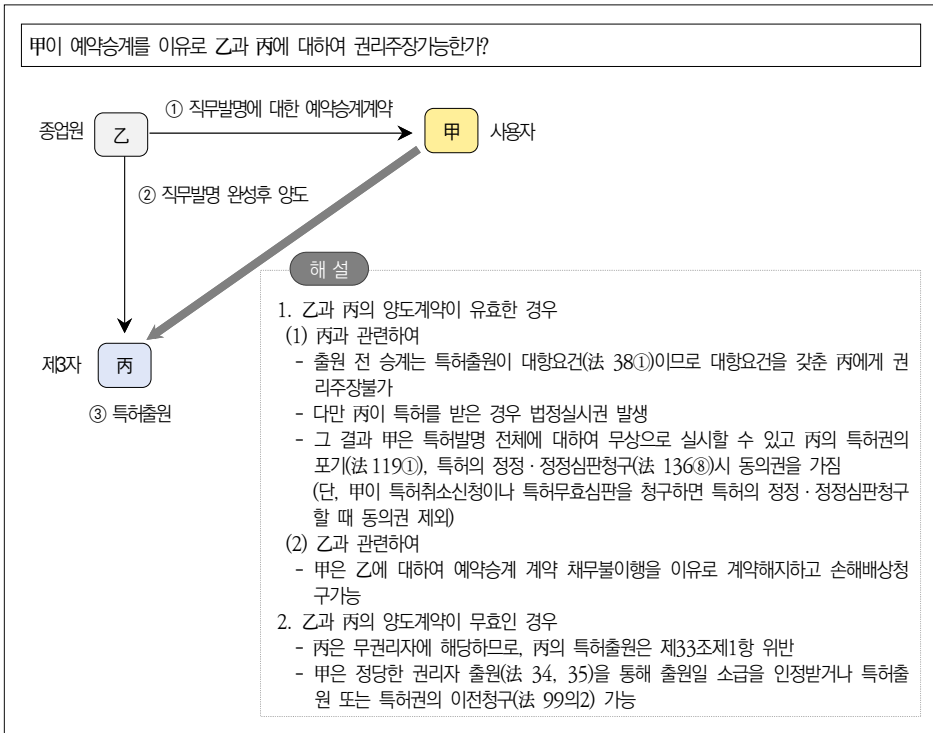
2) 다만 종업원 등과 제3자의 이중양도계약이 민법 제103조 위반의 반사회적 법률행위로서 무효인 경우(예를 들어 특허를 받을 수 있는 권리가 이미 사용자 등에게 양도된 사실을 잘 알면서도 발명자인 종업원 등과 이중계약을 체결하여 그 이중양도행위에 적극적으로 가담한 경우) 제3자의 출원은 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 무권리자 출원이 되므로 제33조제1항 본문 위반으로 거절이유 등에 해당한다.²⁴¹⁾²⁴²⁾ 이 경우 사용자는 정당한 권리자의 특허출원(法 34, 35)을 통해 출원일의 소급을 인정받거나 특허출원 또는 특허권의 이전청구(法 99의2)를 할 수 있을 것이다.

익을 취득하거나 제삼자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 손해를 가해야 한다(刑法 355). 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 등을 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등은 사용자 등이 이를 승계하지 아니하기로 확정되기 전까지는 임의로 위와 같은 승계 약정 또는 근무규정의 구속에서 벗어날 수 없는 상태에 있는 것이어서, 종업원 등이 그 발명의 내용에 관한 비밀을 유지한 채 사용자 등의 특허권 등 권리의 취득에 협력하여야 할 의무는 자기 사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 가지게 되므로, 이러한 경우 종업원 등은 배임죄의 주체인 '타인의 사무를 처리하는 자'의 지위에 있다고 할 것이다. 따라서 위와 같은 지위에 있는 종업원 등이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676; 2014. 11. 13. 선고 2011다77313.).

240) 발명자주의에 따라 직무발명을 한 종업원에게 원시적으로 발명에 대한 권리가 귀속되는 이상 위 권리가 아직 사용자 등에게 승계되기 전 상태에서는 유기적으로 결합된 전체로서의 발명의 내용 그 자체가 사용자 등의 영업비밀로 된다고 볼 수는 없으므로, 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 승계한다는 취지를 정한 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원 등이 비밀유지 및 이전절차협력의 의무를 이행하지 아니한 채 직무발명의 내용이 공개되도록 하는 행위를 발명진흥법 제58조제1항, 제19조에 위배되는 행위로 의율하거나, 또는 직무발명의 내용 공개에 의하여 그에 내제되어 있었던 사용자 등의 개개의 기술상의 정보 등이 공개되었음을 문제삼아 누설된 사용자 등의 기술상의 정보 등을 개별적으로 특정하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)상 영업비밀 누설행위로 의율할 수 있음은 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 직무발명의 내용 공개가 곧바로 부정경쟁방지법 제18조제2항에서 정한 영업비밀 누설에도 해당한다고 볼 수는 없다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676).

241) 특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282, 부산지방법원 2003. 8. 20. 선고 2002가합11918.

242) 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018.



【그림 2-20】 직무발명의 이중양도

(3) 직무발명의 권리승계

① 예약승계계약의 체결 또는 근무규정의 작성이 있는 경우

1) 직무발명 완성사실의 통지를 받은 사용자 등이 종업원 등의 직무발명에 대하여 미리 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키거나 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정을 정한 경우에는 그 권리는 발명을 「완성한 때」부터 사용자 등에게 승계된다. 다만 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리를 승계하지 아니하기로 종업원 등에게 통지하는 경우에는 그러하지 아니하다(發振法 13①). 2024. 8. 7. 시행된 개정법(법률 제 20917호, 2024. 2. 6. 일부개정)에서는 사용자 등이 직무발명에 대한 권리를 승계받는 시점을 「승계 통지 시」에서 「발명 완성 시」로 변경하였다. 기존에는 직무발명이 사용자 등의 「승계 통지」를 조건으로 사용자 등에게 승계되었으나 현행법은 승계 통지없이도 사용자 등에게 승계되되, 사용자 등의 「미승계 통지」가 있으면 승계가 되지 않은 것으로 바뀐 것이다. 즉 사용자 등의 직무발명 승계조건이 예약승계계약(근무규정 포함)과 승계 통지였는데, 승계 통지라는 별도의 승계 절차를 삭제함으로써 사용자 등이 보다 효율적으로 권리를 승계할 수 있도록 하고 있다.

2) 한편 이러한 개정의 다른 취지에서는 구법의 경우 승계 통지 전까지 불확정적 권리관계로 인해 종업원이 제3자에게 직무발명에 대한 권리를 승계하는 이중양도 문제가 발생하는 문제가 있었는데, 현행법은 이를 해결하기 위함을 밝히고 있다.²⁴³⁾ 그러나 권리 승계 시점을 「발명 완성 시」로 앞당긴다고 하여 이중양도 문제가 해결되었다고 할 수는 없을 것이다. 앞서 살펴본 것처럼 종업원 등이 이중양도한 사안에서, 제3자가 먼저 특허출원을 하면 사용자 등은 그 승계사실을 제3자에게 주장할 수 없게 된다(法 38①). 따라서 현행법은 이중양도의 문제해결이 아니라 「발명 완성 시」에 사용자 등에게 승계됨을 명확히 하여 종업원 등이 타인의 사무를 처리하는 자로서 선관주의의무가 있음을 주지시키는 면에서 의미가 있다고 보아야 할 것이다.²⁴⁴⁾

② 예약승계계약의 체결과 근무규정의 작성이 없는 경우

1) 예약승계계약 또는 근무규정이 모두 없는 사용자 등(국가나 지방자치단체는 제외한다)이 직무발명 완성사실의 통지를 받은 경우에는 대통령령으로 정하는 기간에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다. 이 경우 사용자 등은 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없다(發振法 13②). 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자인 종업원 등에게 귀속되고, 종업원 등은 발명완성 후 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자 등에게 이전할 수 있다(法 37①). 발명진흥법 제13조제2항은 그 절차를 규율하고 있는 것이라고 할 수 있다. 발명완성 후에는 사적인 개별계약에 의하면 될 것인데, 이와 같이 사용자 등의 일정기간 내 종업원 등에게 권리의 승계 여부 통지 의무를 부과한 것은 종업원 등의 직무발명에 대한 권리를 사용자 등에게 양도하고자 하는 의사가 있을 때 사용자 등에게 우선 양도받을 수 있는 기회를 주는 한편 사용자 등의 승계 의사가 없는 경우 종업원 등에게 직무발

243) 이상헌 수석전문위원, 발명진흥법 일부개정법률안, 검토보고(김한정 의원 대표발의(의안번호 제2122391호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2023.9. 15-16면.

244) 현행법은 일본 개정 특허법의 영향을 받은 것으로 보인다. 일본은 특허법 제35조에서 직무발명에 대한 규정을 두고 있는데, 2015년 개정(2016. 4. 1. 시행)에서 제3항을 “종업원 등이 한 직무발명에 대해서는 계약, 근무 규칙, 그 밖의 규정에서 미리 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리를 취득하게 할 것을 규정한 때에는 그 특허를 받을 수 있는 권리는 그 권리가 발생한 때부터 사용자 등에게 귀속한다”라고 개정하여 사용자의 직무발명 원시귀속을 명시하고 있다. 일본과 같이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자 등에게 원시귀속되는 경우에는 종업원 등이 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도하고 제3자가 출원하였을 때, 국내에서도 이를 무권리자 출원으로 취급하여 사용자 등을 보호(法 34, 35, 99의2)할 수 있을 여지가 있다(대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087 참조). 그러나 국내에서는 자연인이 아닌 법인은 발명능력이 없어서 발명자가 될 수 없기에 원시적으로 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 못하고(특허법원 2003. 7. 11. 선고 2002허4811), 승계를 통해서만 특허를 받을 수 있는 권리를 가질 수 있다(法 33①참조). 이번에 개정된 발명진흥법 제13조제1항도 이를 반영하여 사용자 등에게 특허를 받을 수 있는 권리가 원시귀속된다고 규정하지 않고, 자연인인 종업원 등이 발명을 완성한 때 사용자 등에게 승계됨을 규정하고 있는 것이라 할 수 있다. 그렇다면 종업원 등의 이중양도 사안에서 특허법 제38조제1항이 적용될 수밖에 없기에 현행법이 이중양도를 막을 수 있는 방안이 될 수 없다. 이를 해결하기 위해서는 직무발명에 대한 법인의 발명능력을 인정하여 특허를 받을 수 있는 권리의 원시 귀속에 관한 명시적 규정을 입법하거나, 특허법 제37조, 제38조에 대한 예외 규정을 둘 필요가 있다(강명수, “직무발명 권리승계 규정에 대한 고찰”, 민사법의 이론과 실무 제22권 제2호, 민사법의 이론과 실무학회, 2019.4. 152, 153, 162, 164, 172, 173면 참조).

명의 활용방안(종업원 등의 출원, 제3자에게 권리의 양도 등)를 신속히 모색할 기회를 주어 사용자 등과 종업원 등 간의 안정적인 권리관계형성을 유도하기 위해서이다. 사용자 등이 승계 의사 없음을 종업원 등에게 통지(미승계 통지)하면, 사용자 등은 종업원 등 또는 승계인이 그 발명에 대하여 특허를 받을 경우 무상의 통상실시권(단, 대기업은 제외)을 가질 수 있다.

2) 다만 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 승계 여부를 통지하지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 본다. 이 경우 사용자 등은 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없다(發振法 13③).²⁴⁵⁾ 이는 사용자 등의 성실한 통지 의무 이행을 유도하고, 통지 의무를 이행치 아니한 경우 제재 (penalty)를 가한 것이라 할 수 있다. 따라서 사용자 등은 승계의사가 없는 경우에도 반드시 이를 종업원 등에게 통지하여야 한다.²⁴⁶⁾

245) 동의하에 인정되는 통상실시권은 더 이상 법정실시권이 아니라 종업원의 의사에 의한 허락실시권이라 할 것이다.

246) 예약승계계약과 근무규정 여부에 따라 직무발명의 승계 조건은 다음과 같이 달라진다.

구분	예약승계계약/근무규정이 있는 경우	예약승계계약/근무규정이 없는 경우
승계방법	계약 또는 근무규정	개별합의
승계시점	발명 완성 시	개별합의
승계 여부 통지	미승계시만 통지(승계시는 불필요)	승계/미승계 모두 통지
비고	-	승계 여부 통지를 하지 않은 경우 종업원 등의 동의없이 법정실시권 불인정

한 규정이 없는 경우에도 종업원 등은 발명진흥법 제15조제1항에 따라 보상금청구권²⁴⁹⁾을 당연히 취득한다.

② 보상규정의 작성 및 변경

1) 사용자 등은 보상에 대하여 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 서면으로 알려야 한다(發振法 15②). 사용자 등은 보상규정의 작성 또는 변경에 관하여 종업원 등과 협의하여야 한다(發振法 15③).²⁵⁰⁾ 또한 보상규정을 종업원 등에게 불리하게 변경하는 경우에는 그 계약 또는 규정의 적용을 받는 종업원 등의 과반수의 동의를 받아야 한다(發振法 15③). 이는 종업원 등의 협상력 및 절차적 권리를 강화하여 실질적으로 보상과정에 참여하도록 하기 위함이다.

2) 사용자 등이 협의하여야 하거나 동의를 받아야 하는 종업원 등의 범위, 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다(發振法 15⑤).²⁵¹⁾

248) 서울중앙지방법원 2003. 7. 3. 선고 2002가합3727.

249) 이러한 보상금청구권은 발명이 승계된 시점에 발생한다고 보아야 할 것이며, 보상금의 종류로는 출원보상금, 등록보상금, 실시보상금, 처분보상금 등이 있다. 즉 보상금은 승계시에 확정된 일정금액이 분할 지급되는 방식으로 이해하여야 할 것이다. 특허를 받을 수 있는 권리가 불확정적이고 실시가 되지 아니하면 사용자가 받을 이익을 산정하기 곤란하므로 분할지급방식을 허용하는 것이 타당하다. 한편 승계시에 발생한 보상금 청구권은 특허법상 규정이 없으나 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성된다고 본다(정진욱, “자유발명으로 의제된 직무발명”, 한국상사판례학회, 상사판례연구, 제15권, 2003, 111면). 보상금청구권 소멸시효의 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178). 한편 사용자가 직무발명에 관한 근무규정을 변경하였는데 그러한 변경 이전에 이미 종업원이 퇴직하였다면 그 종업원이 사용자와 사이에 변경된 근무규정을 적용하기로 합의하는 등의 특별한 사정이 없는 한 변경된 근무규정은 변경 이전에 이미 퇴직한 종업원에게는 적용되지 않는다(대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463).

250) 종업원과의 협의 절차는 i) 개별 근로계약에 의한 경우, ii) 노사협의회에 의한 경우, iii) 단체교섭에 의한 경우 및 iv) 취업규칙에 의한 경우를 상정해 볼 수 있다. 그러나 i) 개별 근로계약에 의한 경우에는 종업원이 현실적으로 유리한 보상규정의 적용을 받기 어렵다는 문제점이 있으며, ii) 노사협의회에 의한 경우에는 일정규모 이상의 사업장에서는 보상규정을 의무적 협의사항으로 하여 협의를 할 수는 있으나 협의를 이행하지 않은 경우의 강제수단이 없는 문제점이 있다. 한편 iii) 단체협약에 의한 경우에는 서로 대응한 지위에서 자율적인 교섭이 이루어질 수 있으나, 우리나라의 노동조합의 조직율이 미약하다는 것을 고려할 때 그 적용범위가 협소하다는 문제점이 있다. 따라서 iv) 취업규칙에 의하여 협의하는 것이 가장 적절하다고 할 수 있으며, 취업규칙에 직무발명 보상제도를 필수적으로 기재하도록 하는 것이 필요하다(김성중, “직무발명 보상규정의 노동법적 접근”, 사회법연구 제39호, 2019, 359-377면 참조).

251) 발명진흥법 시행령 제7조의2(협의하거나 동의를 받아야 하는 종업원 등의 범위 등) ① 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체(이하 “사용자 등”이라 한다)가 법 제15조제3항에 따라 협의하거나 동의를 받아야 하는 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 “종업원 등”이라 한다)의 범위는 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 협의: 새로 작성하거나 변경하려는 보상규정의 적용을 받게 되는 종업원 등(변경 전부터 적용 받고 있는 종업원 등을 포함한다)의 과반수

2. 동의: 불리하게 변경하려는 보상규정의 적용을 받고 있는 종업원 등의 과반수

② 사용자 등은 새로 작성하거나 변경하는 보상규정(불리하게 변경하는 보상규정을 포함한다)을 적용하려는 날의 15일 전까지 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준 및 지급방법 등에 관하여 종업원 등에게 알려야 한다.

③ 사용자 등은 법 제15조제3항에 따라 협의하거나 동의를 요청하는 경우 성실한 자세로 임하여야 한다.

③ 보상사항의 통지

사용자 등은 보상을 받을 종업원 등에게 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 서면으로 알려야 한다(發振法 15④).

④ 보상규정에 따른 보상의 효력

1) 사용자 등이 발명진흥법 제15조제2항부터 제4항까지의 규정에 따라 종업원 등에게 보상한 경우에는 상당한 보상을 한 것으로 본다. 다만 그 보상액이 직무발명에 의하여 「사용자 등이 얻을 이익」²⁵²⁾과 「그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도」²⁵³⁾를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다(發振法 15⑥).²⁵⁴⁾²⁵⁵⁾ 사용자 등과 종업원 등의 신뢰를 바

252) 「사용자 등이 얻을 이익」이란 사용자 등은 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상 실시권을 가지므로, 「사용자 등이 얻을 이익」은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 등). 사용자 등이 얻을 이익과 관련된 판례는 다음과 같다.

i) 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178).

ii) 사용자가 직무발명을 제3자에게 양도한 이후에는 더 이상 그 발명으로 인하여 얻을 이익이 없을 뿐만 아니라, 직무발명의 양수인이 직무발명을 실시함으로써 얻은 이익은 양수인이 처한 우연한 상황에 따라 좌우되는 것이어서 이러한 양수인의 이익액까지 사용자가 지급하여야 할 직무발명 보상금의 산정에 참작하는 것은 불합리하므로, 사용자가 직무발명을 양도한 경우에는 특별한 사정이 없는 한 그 양도대금을 포함하여 양도시까지 사용자가 얻은 이익액만을 참작하여 양도인인 사용자가 종업원에게 지급하여야 할 직무발명 보상금을 산정하여야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다26769).

iii) 甲이 자신의 직무발명에 대한 권리를 승계한 乙 주식회사를 상대로 직무발명보상금 지급을 구한 사안에서, 乙 회사가 실시한 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있었던 것으로 보이므로, 乙 회사가 직무발명 실시로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 단정할 수 없으므로, 乙 회사가 甲에게 직무발명과 관련하여 실시보상금을 지급할 의무가 없다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507).

iv) 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다. 한편 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 등의 특허무효사유가 있고 경쟁관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 용이하게 알 수 있어서 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우가 아닌 한 단지 직무발명에 대한 특허에 무효사유가 있다는 사정만으로는 특허권에 따른 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 직무발명보상금의 지급을 면할 수는 없고, 이러한 무효사유는 특허권으로 인한 독점적·배타적 이익을 산정할 때 참작요소로 고려할 수 있을 뿐이다(대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347).

253) 「사용자 등이 공헌한 정도」란 사용자 등이 발명을 완성하는데 제공한 연구개발비, 연구설비비, 연구자 제비, 급여 등의 공헌한 정도를 말한다.

탕으로 한 합리적인 보상규정 작성과 투명한 보상문화의 정착을 유도하기 위함이다. 한편 직무발명에 대한 보상이 계약 또는 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 정하고 있더라도 사용자 등의 이익과 사용자 등과 종업원 등의 공헌 정도를 고려하여 적절한 수준으로 이루어지지 아니한다면 법원이 보상액의 적정 여부를 판단하게 된다.

⑤ 출원유보시의 보상

1) 사용자 등이 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 발명진흥법 제15조에 따라 정당한 보상을 하여야 한다(發振法 16본문).²⁵⁶⁾ 종업원 등에 대한 사용자 등의 보상의무는 출원 여부와 관계없이 직무발명에 대한 권리의 승계시 당연히 발생(發振法 15①)함에도 불구하고, 직무발명보상제도에 대한 사용자 등의 전반적인 인식 부재로 인해 출원유보시에 대한 보상실시가 미흡한 상태이기 때문에 출원유보 보상에 대한 사용자 등의 인식을 제고하여 종업원 등의 보상받을 권리를 강화하기 위해 이를 법률에 명확히 밝히고 있다.

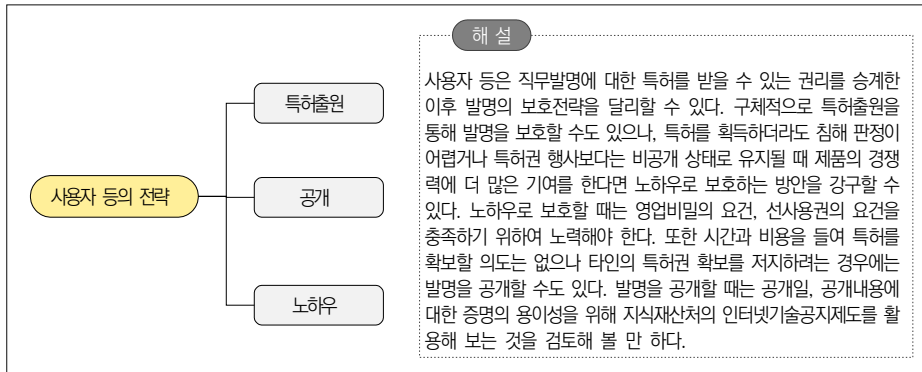
2) 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었다면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 한다(發振法 16단서). 사용자 등이 직무발명을 출원하지 않고 유보하여 영업비밀로서 보호할 때도 적극적인 보상이 이루어질 수 있도록 고려사항을 법률로써 규정하고 있다.

254) 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제39조제1항의 직무발명에 해당하는 회사 임원의 발명에 관하여 회사와 그 대표이사가 임원의 특허를 받을 수 있는 권리를 적법하게 승계하지 않고 같은 법 제40조에 의한 보상도 하지 아니한 상태에서 위 임원을 배제한 채 대표이사를 발명자로 하여 회사 명의의 특허등록을 마침으로써 임원의 특허를 받을 수 있는 권리를 침해한 경우, 위 임원이 입은 재산상 손해액은 임원이 구 특허법 제40조에 따라 받을 수 있었던 정당한 보상금 상당액이다. 그 수액은 직무발명제도와 그 보상에 관한 법령의 취지를 참작하고 증거조사의 결과와 변론 전체의 취지에 의하여 밝혀진 당사자들 사이의 관계, 특허를 받을 수 있는 권리를 침해하게 된 경위, 위 발명의 객관적인 기술적 가치, 유사한 대체기술의 존재 여부, 위 발명에 의하여 회사가 얻을 이익과 그 발명의 완성에 위 임원과 회사가 공헌한 정도, 회사의 과거 직무발명에 대한 보상금 지급례, 위 특허의 이용 형태 등 관련된 모든 간접사실들을 종합하여 정함이 상당하고, 등록된 특허권 또는 전용실시권의 침해행위로 인한 손해배상액의 산정에 관한 특허법 제128조제4항을 유추적용하여 이를 산정할 것은 아니다(대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370).

255) 결국 직무발명보상금의 산정법은 다음과 같다고 할 것이다.

$\begin{aligned} \text{보상금} &= [\text{직무발명으로 의하여 사용자 등이 얻을 이익(=사용자이익액)}] = [\text{사용자 등이 승계취득한 특허권의 전제가치-사용자 등이 가지는 무상의 통상실시권의 가치}] = [\text{직무발명으로 인한 매출액} \times \text{독점권기여도} \times \text{실시료율}] \times [\text{발명자인 종업원 등의 공헌도(=발명자보상률)}] = [1-\text{사용자 등의 공헌도}] \times [\text{발명자 개인의 기여도(=발명자기여율, 공동발명인 경우)}] = [1-\text{다른 공동발명자의 기여도}] \end{aligned}$
--

256) 그 직무발명에 대해 특허가 실제로 출원·등록되었는지 여부, 사용자가 그 직무발명 내지 이에 기초한 특허를 실제로 실시하였는지 여부, 또는 그 특허의 등록이 무효가 되었는지 여부 등의 후발적 사정은 직무발명 보상금청구권의 발생에 장애가 되지 아니하고, 다만 보상금의 액수 산정에 위와 같은 사정이 고려될 수 있다(서울중앙지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합101887).



【그림 2-22】 특허를 받을 수 있는 권리의 승계한 사용자 등의 전략

IV. 관련문제

1. 공무원 직무발명의 취급

(1) 공무원 직무발명의 승계

1) 공무원 또는 국가나 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자(이하 “공무원 등”이라 한다)의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계할 수 있으며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원 등의 직무발명에 대한 특허권 등은 국유나 공유(公有)로 한다(發振法 10②본문).²⁵⁷⁾ 즉 지방자치단체의 직무발명은 지방자치단체와 공무원이 공동으로 특허를 받을 수 있는 권리를 공유(共有)하는 것이 아니라 지방자치단체의 소유(公有)가 된다.

2) 「고등교육법」 제3조에 따른 국공립학교 교직원의 직무발명은 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권은 전담조직의 소유로 한다(發振法 10②단서). 이는 국공립대학 교직원의 직무발명 창출의욕을 고취하고, 특허권의 민간이전을 통해 산업경쟁력을 제고하자는 취지에서 국공립대학 교직원의 직무발명에 대한 특허권을 국가가 아닌 해당 전담조직이 승계하도록 하고 있다.²⁵⁸⁾

257) 2021. 10. 21. 시행되는 현행법(법률 제18094호, 2021. 4. 21. 일부개정)에서는 공무원의 직무발명 승계규정을 강행규정에서 임의규정으로 변경하였다(發振法 10②. 13①). 그 결과 공무원 등의 경우에도 국가나 지방자치단체가 직무발명에 대한 권리의 승계 여부를 결정할 수 있도록 하여 우수 직무발명에 대한 지원을 집중할 수 있게 되어, 국유특허의 품질과 활용성파를 높일 수 있을 것으로 생각된다. 직무발명을 승계하지 않기로 결정하였으면 발명한 공무원 등이 발명에 대한 권리를 승계할 수 있으므로, 개인 차원에서 발명을 보다 발전시키거나 적극적으로 사업화할 수 있는 여지도 있을 것으로 보인다. 한편 개정된 현행법은 국가나 지방자치단체가 공무원이 아닌 자의 직무발명에 대해서도 승계·보상할 수 있도록 하였다. 국가나 지방자치단체에 소속된 비공무원의 직무발명에 대해서도 보상을 실시하여 비공무원의 발명의욕을 고취할 수 있을 것으로 생각된다(채수근 수석전문위원, 발명진흥법 일부개정법률안 검토보고서(정태호 의원 대표 발의(의안번호 제2103870호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2020.11. 3, 5, 6, 8면).

(2) 국유특허권의 처분·관리

1) 국유로 된 특허권의 처분 및 관리(특허권의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조²⁵⁹⁾에도 불구하고 지식재산처장이 이를 관장하며, 그 처분 및 관리에 필요한 사항은 대통령령²⁶⁰⁾으로 정한다(發振法 10④).

2) 한편 「국유재산법」 제65조의11제2항 단서에도 불구하고 지식재산처장이 정하여 고시하는 경우에는 국유로 된 특허권 등에 관한 전용실시권 설정을 한 번 이상 갱신할 수 있다(發振法 10의2). 국유재산법에 의하면 국유특허의 전용실시가 최대 2회(6년~10년)로 제한되어 있어서, 의약·바이오 분야와 같이 사업화에 대규모의 비용과 10년 이상의 장기간이 필요한 기술의 경우 민간 이전이 어려운 상황임을 고려하여, 국유특허의 전용실시권 설정을 한 번 이상 갱신할 수 있도록 하고 있다.

(3) 보 상

공무원 등의 직무발명을 국가, 지방자치단체 또는 전담조직이 승계한 경우에는 공무원에게 상당한 보상금을 지급하여야 하고, 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령이나 조례로 정한다(發振法 15⑦).²⁶¹⁾

258) 이를 표로 정리하면 다음과 같다.

대 상	승 계	소 유
공무원 등	국가 지방자치단체	국유 공유
국공립학교교직원	전담조직	전담조직

259) 제8조【국유재산 사무의 총괄과 관리】 ① 총괄청은 국유재산에 관한 사무를 총괄하고 그 국유재산(제3항에 따라 중앙관서의 장이 관리·처분하는 국유재산은 제외한다)을 관리·처분한다. <개정 2011. 3. 30.>

② 총괄청은 일반재산을 보존용재산으로 전환하여 관리할 수 있다.

③ 중앙관서의 장은 「국가재정법」 제4조에 따라 설치된 특별회계 및 같은 법 제5조에 따라 설치된 기금에 속하는 국유재산과 제40조제2항 각 호에 따른 재산을 관리·처분한다. <개정 2011. 3. 30.>

④ 중앙관서의 장은 제3항 외의 국유재산을 행정재산으로 사용하려는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 총괄청의 승인을 받아야 한다. <신설 2011. 3. 30.>

⑤ 총괄청은 제4항에 따른 사용승인을 할 때 제40조의2에 따른 우선사용예약을 고려하여야 한다. <신설 2020. 3. 31.>

⑥ 이 법에 따른 총괄청의 행정재산의 관리·처분에 관한 사무는 그 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 중앙관서의 장에게 위임할 수 있다. <신설 2011. 3. 30., 2020. 3. 31.>

260) 「공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정」을 말한다. 구체적으로 살펴보면 처리절차는 다음과 같다.

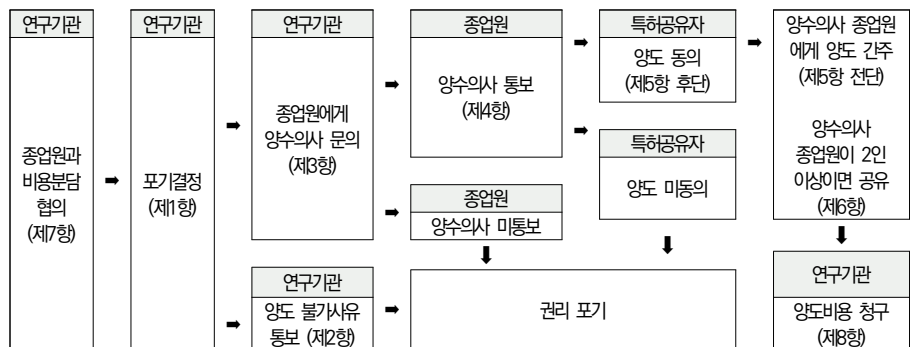
공무원의 발명신고 → 발명기관장의 국가승계 결정 → 발명기관장의 출원 (발명기관의 장을 부기하여 대한민국 명의로 출원) → 특허결정(지식재산처) → 발명기관장의 국가승계요청 → 국가명의로 등록(지식재산처)

261) 공무원 등의 직무발명 보상기준은 다음과 같다(공무원직무발명의처분·관리및보상등에관한규정 16 -18 참조).

(1) 의의 및 취지

(2) 유지 및 비용분담 협의

보상종류	보 상 내 용
등록보상금	■ 특허권 : 50만원 ■ 실용신안권 : 30만원 ■ 디자인권 : 20만원
처분보상금	■ 처분수입금의 50%
기관포상금	■ 처분수입금이 1,000만원 초과~5,000만원 이하 : 100만원 ■ 처분수입금이 5,000만원 초과~1억원 이하 : 500만원 ■ 처분수입금이 1억원을 초과 : 1,000만원



(3) 종업원 등의 양수

직무발명에 대한 권리를 포기하려는 공공연구기관의 장은 대통령령으로 정하는 기간 내에 해당 직무발명을 완성한 모든 종업원 등에게 그 사실을 통지하여야 하고, 통지를 받은 종업원 등은 직무발명에 대한 권리를 양수하려는 경우 통지를 받은 날부터 대통령령으로 정하는 기간 내에 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 공공연구기관의 장에게 서면으로 알려야 한다. 종업원 등이 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 경우 기간이 끝난 날의 다음 날부터 그 권리가 종업원 등에게 양도된 것으로 본다. 이 경우 공공연구기관이 직무발명에 대한 권리를 제3자와 공유한 경우에는 공공연구기관의 장이 다른 공유자 모두의 동의를 받은 때에 한정하여 그 권리가 양도된 것으로 본다(發振法 16의2③④⑤). 직무발명에 대한 권리의 양수 의사를 알린 종업원 등이 2명 이상인 경우에는 그 권리를 공유한다(發振法 16의2⑥). 한편 공공연구기관의 장은 직무발명에 대한 권리가 종업원 등에게 양도된 것으로 보는 날 이후 그 권리와 관련하여 발생하는 비용(세금을 포함한다)을 종업원 등에게 청구할 수 있다(發振法 16의2⑧).²⁶⁴⁾

(4) 종업원 등의 양수 불가

공공연구기관의 장이 대통령령으로 정하는 바에 따라 공공의 이익을 위하여 특별히 직무발명에 대한 권리를 포기할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 권리를 종업원 등에게 양도하지 아니할 수 있다. 이 경우 공공연구기관의 장은 대통령령으로 정하는 기간 내에 종업원 등에게 그 사유를 구체적으로 알려야 한다(發振法 16의2②).

3. 대학교수의 발명

1) 대학교수의 발명이 직무발명인지 여부가 문제이다. 이는 대학교수 직무의 본질에 학생의 교육 이외에 연구의무가 포함되어 있는지와 관련되어 있다. 연구를 대학교수의 본질적 직무로 본다면 직무발명이 될 가능성이 크고, 본질적 직무로 보지 아니한다면 자유발명이 될 가능성이 크다. 교수의 직무발명은 대학 내의 전담조직의 소유로 되고, 자유발명은 교수 개인 소유로 된다는 점에서 대학교수 발명의 성격을 어떻게 규정할 것인가 하는 문제는 중요한 의미가 있다.²⁶⁵⁾

2) 대학연구의 목적은 투자자본에 대한 이익을 얻으려는데 있는 것이 아니고 교육 및 학술연구의 발전을 꾀함에 있으므로 원칙적으로 자유발명으로 봄이 타당하다. 다만 교수가 i) 대학으로부터 특정연구비를 지원받았거나 특별한 연구목적을 위해서 설치된 연구설비를 사용하여 한 발명, 즉 대학의 자원을 특별히 이용한 경우에는 대학의 직무발명이라고 할 수 있으며,

264) 직무발명에 대한 권리를 종업원 등에게 무상으로 양도할 때도 일정 기간 부가세 부과 대상이 되므로(부가가치세법 시행령 제66조), 공공연구기관이 비용부담을 이유로 직무발명에 대한 권리를 포기하는 것을 방지하기 위하여 그 양도비용을 종업원 등에게 청구할 수 있도록 하는 취지이다(채수근 수석전문위원, 발명진흥법 일부개정법률안 검토보고서(정태호 의원 대표발의(의안번호 제2103870호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2020.11, 14면).

265) 손영식, “직무발명성격 및 보상제도에 관한 연구”, 충남대학교 특허법무대학원, 석사, 2002, 47면.

ii) 외부 기업체의 연구개발의뢰에 의하여 연구비를 받고 특정연구과제(Project)를 수행하여 발명을 완성한 경우나 외부 기업체의 기술고문으로 재직 중 그 기술분야의 발명을 완성한 경우에는 기업의 직무발명이라고 할 수 있다. 현실적으로는 대학교수의 발명은 대부분 직무발명이라고 여겨진다.

4. 직무발명보상제도의 실시 및 지원시책

1) 정부는 종업원 등의 직무발명을 장려하기 위하여 직무발명보상제도 등의 실시에 관한 지원시책을 수립·시행하여야 하며, 지원시책에는 다음의 내용이 포함되어야 한다(發振法 11①②).

- i) 표준이 되는 보상규정의 작성 및 보급
- ii) 보상과 관련된 분쟁을 예방 및 해결하기 위한 합리적인 절차규정의 작성 및 보급
- iii) 직무발명보상제도의 실시·운영에 관한 상담 등의 지원

2) 정부는 직무발명에 대한 보상을 실시하는 사용자 등에 대하여는 명의 권리화와 사업화를 촉진하기 위한 조치를 먼저 하여야 한다(發振法 11③).

5. 직무발명보상 우수기업 인증 등

1) 지식재산처장은 직무발명보상제도의 활성화를 위하여 직무발명보상제도를 모범적으로 운영하는 기업을 직무발명보상 우수기업(이하 “우수기업”이라 한다)으로 인증할 수 있다. 지식재산처장은 우수기업 인증을 받고자 하는 기업이 신청하면 심사를 하고, 인증기준에 적합하면 유효기간을 정하여 인증을 하여야 한다. 지식재산처장은 우수기업이 i) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인증을 받은 경우에는 인증을 취소하여야 하고, ii) 인증기준에 적합하지 아니하게 된 경우에는 인증을 취소할 수 있다(發振法 11의2①②③④).

2) 국가 및 지방자치단체는 인증받은 우수기업에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 행정적·재정적 지원을 할 수 있다(發振法 11의2⑤). 현재 인증받은 우수기업의 특허출원, 실용신안등록출원, 디자인출원은 우선심사의 대상이고, 등록료의 일부분을 감면받을 수 있으며, 정부 지원사업 선정 시 가점 등의 혜택을 받을 수 있다.

6. 직무발명심의위원회의 운영 등

1) 사용자 등은 종업원 등의 직무발명에 관한 다음의 사항을 심의하기 위하여 직무발명심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)를 설치·운영할 수 있다(發振法 17①).

- i) 직무발명에 관한 규정의 작성·변경 및 운용에 관한 사항
- ii) 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관한 종업원 등과 사용자 등의 이견 조정에 관한 사항
- iii) 그 밖에 직무발명과 관련하여 필요한 사항

2) 심의위원회는 사용자 등과 종업원 등(법인의 임원은 제외한다)을 각각 대표하는 같은 수의 위원으로 구성하되, 필요한 경우에는 관련 분야의 전문가를 자문위원으로 위촉할 수 있으며, 그 밖에 심의위원회의 구성 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다(發振法 17②③).

7. 직무발명 관련 분쟁의 조정 등

1) 종업원 등은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 사용자 등에게 심의위원회를 구성하여 심의하도록 요구할 수 있다(發振法 18①).

- i) 직무발명인지 여부에 관하여 사용자 등과 이견이 있는 경우
- ii) 사용자 등이 제10조제3항을 위반하여 종업원 등의 의사와 다르게 직무발명 외의 발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
- iii) 사용자 등이 제13조제1항을 위반하여 종업원 등의 의사와 다르게 직무발명에 대한 권리의 승계 또는 전용실시권의 설정을 주장하는 경우
- iv) 사용자 등이 제10조제1항 단서 또는 제13조제3항을 위반하여 통상실시권을 주장하는 경우
- v) 사용자 등이 제시한 보상규정에 이견이 있는 경우
- vi) 사용자 등과의 협의 또는 동의 절차에 이견이 있는 경우
- vii) 사용자 등이 제15조제4항에 따라 통지한 보상액 등 보상의 구체적 사항에 이견이 있는 경우
- viii) 사용자 등이 제15조제2항부터 제4항까지의 규정에 의하여 종업원 등에게 보상하지 아니하는 경우
- ix) 그 밖에 직무발명에 대한 권리 및 보상 등에 관하여 사용자 등과 종업원 등 간에 이견이 있는 경우

2) 종업원 등의 심의 요구는 사유가 발생한 날부터 30일 이내에 행사하여야 한다. 다만 보상액 등 보상의 구체적 사항에 이견이 있는 경우에는 종업원 등이 통지를 받은 날부터 30일 이내에 행사하여야 한다(發振法 18②).

3) 사용자 등은 심의 요구를 받은 경우에 60일 이내에 심의위원회를 구성하여 심의하도록 하여야 한다. 이 경우 심의위원회에는 직무발명 관련 분야의 전문가인 자문위원이 1명 이상 포함되도록 하여야 한다.²⁶⁶⁾²⁶⁷⁾ 심의위원회는 심의의 결과를 사용자 등과 종업원 등에게 지체 없이 서면으로 통지하여야 한다(發振法 18③④).

4) 정부는 사용자 등의 요청에 따라 관련 분야의 전문가를 제3항에 따른 자문위원으로 파견할 수 있으며, 이에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다(發振法 18⑤).

5) 심의위원회의 심의 결과에 불복하거나 직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 사용자 등 또는 종업원 등은 제41조에 따른 산업재산분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있다(發振法 18⑥). 조정은 당사자 간에 합의된 사항을 조서에 기재함으로써 성립되며, 조서는 재판상 화해와 동일한 효력이 있다. 다만 당사자가 임의로 처분할 수 없는 사항에 관한 것은 그러하지 아니하다(發振法 46).

266) 자문위원으로 심의위원회에 참여하거나 참여하였던 사람은 직무상 알게 된 직무발명에 관한 내용을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다(發振法 19②).

267) 이를 위반하여 심의위원회를 구성하지 아니하거나 심의하도록 하지 아니한 자는 1천만원 이하의 과태료를 부과한다(發振法 60①).

제5장

특허를 받을 수 있는 출원

제1절 특허출원에 필요한 서류

제42조 【특허출원】

- ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 지식재산청장에게 제출하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 3. 발명의 명칭
 4. 발명자의 성명 및 주소
- ② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명·청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
- ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것
 2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것
- ④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 “청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것
 2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것
- ⑤ 삭제 <2014.6.11.>
- ⑥ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다. <개정 2014.6.11.>
- ⑦ 삭제 <2014.6.11.>
- ⑧ 제2항에 따른 청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2014.6.11.>
- ⑨ 제2항에 따른 발명의 설명, 도면 및 요약서의 기재방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. <개정 2014.6.11.>

[제목개정 2014.6.11.]

제42조의2 【특허출원일 등】

- ① 특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 지식재산청장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 아니할 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다.
- ② 특허출원인은 제1항 후단에 따라 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 제42조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 보정을 하여야 한다.

- ③ 특허출원인이 제2항에 따른 보정을 하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.

[본조신설 2014.6.11.]

제42조의3 【외국어특허출원 등】

- ① 특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 총리령으로 정하는 언어로 적었다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다.
- ② 특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 “외국어특허출원”이라 한다)을 한 경우에는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만, 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 제64조제1항 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다.
- ③ 제2항에 따라 국어번역문을 제출한 특허출원인은 제2항에 따른 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 명세서 또는 도면을 보정(제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우
 2. 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우
- ④ 특허출원인이 제2항에 따른 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다.
- ⑤ 특허출원인이 제2항에 따른 국어번역문 또는 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다. 다만, 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 “최종 국어번역문”이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ⑥ 특허출원인은 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다.
- ⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2016.2.29>

[본조신설 2014.6.11.]

제43조 【요약서】

제42조제2항에 따른 요약서는 기술정보로서의 용도로 사용하여야 하며, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1) 발명자 또는 그 승계인은 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다. 그러나 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 하여 곧바로 특허를 받을 수 있는 것은 아니다. 특허를 받기 위해서는 법정양식에 맞추어 지식재산처에 대하여 특허출원을 한 다음 제반 절차를 밟아야 한다. 「특허출원」이란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명의 공개를 전제로 하여 지식재산처에 대하여 특허를 받으려는 의사를 객관적으로 표시하는 행위를 말하며, 특허절차는 출원

으로부터 시작된다. 출원에 관한 사무는 확실 및 신속이 요청되므로 특허법은 이에 관하여 일정한 방식에 따라(要式主義) 서면에 의하도록 하고 있다(書面主義, 施規 2). 다만 서면주의의 예외로서 통상의 기술자가 쉽게 입수 가능하지 아니한 미생물 발명의 경우 출원서류와 함께 미생물의 기탁이 필요한 앞서 살펴본 바와 같다.

2) 이처럼 특허에 관한 제반절차에서 서면주의를 요구하고 있는 것은 발명의 내용을 서면으로 특정함으로써 심사의 편의나 적정화는 물론 특허권의 권리내용을 명확히 할 필요가 있을 뿐만 아니라 발명을 사회일반에 널리 공개하여 이를 타인이 이용하게 하기 위해서는 서면에 의하지 아니하면 어렵기 때문이다.

II. 특허출원서

1. 의 의

「특허출원서」는 발명자 및 출원인에 대한 인적사항이나 특허출원을 하는데 필요한 기초적 사항, 그리고 특허법상 제도의 적용을 받기 위한 각종 취지를 적은 서면을 말한다.

2. 기재사항

1) 특허출원서에는 i) 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지), ii) 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명), iii) 발명의 명칭 및 iv) 발명자의 성명 및 주소를 적어야 한다(法 42①).²⁶⁸⁾

2) 이외에도 특허출원서에는 특허출원 시에 할 수 있는 특허에 관한 절차에서 요구하는 사항도 적을 수 있는데, i) 출원 시 심사청구를 한 경우에는 심사청구사항, ii) 수수료 계산사항, iii) 공지예외적용 취지, iv) 신청에 의한 출원의 조기공개에 관한 취지에 관한 사항 등을 적을 수 있다.

3. 함결시 법적취급

(1) 불수리

지식재산처장은 i) 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 특허고객번호[특허고객번호가 없는 경우에는 성명·주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]가 기재되지 아니한 경우, ii) 1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우 및 iii) 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우 중 어느 하나에 해당한 경우 소명기회를 주고 소명이 적법하지 않거나 소명하지 아니하면 출원을 불수리하여야 한다(施規 11).

268) 특허출원인 또는 대리인은 특허출원서에 특허고객번호 또는 대리인번호를 적은 경우 주소를 적지 않을 수 있다.

(2) 무 효

지식재산처장은 출원 시 i) 대리권 범위의 흠결(法 6)이 있는 경우, ii) 발명자의 성명 또는 주소가 기재되지 아니한 경우 및 iii) 발명의 명칭이 기재되지 아니한 경우 중 어느 하나에 해당하면 기간을 정하여 보정을 명하고 출원인이 그 기간에 보정하지 아니하면 출원을 무효로 할 수 있다(法 16).

III. 명세서

1. 의 의

1) 「명세서(description)」란 특허를 받으려는 발명의 기술적인 내용을 문장을 통해 명확하고 상세하게 적은 서면을 말한다. 명세서에는 i) 발명의 설명 및 ii) 청구범위를 적도록 법정되어 있다(法 42②). 발명의 설명 기재는 i) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것 및 ii) 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것의 요건을 모두 충족하여야 한다(法 42③).

2) 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 “청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 i) 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것, ii) 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것의 요건을 모두 충족하여야 한다(法 42④). 또한 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다(法 42⑥). 이에 대한 구체적인 내용은 「제2절 명세서의 역할 및 기재방법」에서 후술한다.

2. 청구범위 제출의 유예

(1) 의 의

특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 지식재산처장에게 도달한 날로 한다. 이 경우 명세서에 청구범위는 적지 않을 수 있으나, 발명의 설명은 적어야 한다(法 42의2①). 2015. 1. 1. 시행된 현행법(법률 제12753호, 2014. 6. 11. 개정)은 특허출원할 때 청구범위 적는 것을 유예하여 i) 출원인에게 신속한 출원을 할 수 있도록 하고(논문 등의 내용을 그대로 출원 가능하도록 함), ii) 특허권 취득 후의 이용전략을 충분히 검토하여 효과적인 청구범위를 작성할 기회를 주는 한편 iii) 청구범위가 포함된 완벽한 상태로 공개되도록 함으로써 국제적인 공개제도와 조화를 꾀하고 있다.²⁶⁹⁾²⁷⁰⁾

269) 이와 유사한 제도로는 미국의 가출원제도(provisional application)가 있다. 청구범위 제출 유예제도와 가출원제도를 비교하면 다음과 같다.

(2) 유예기간

① 원 칙

특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다(法 42의2②본문).

② 제3자가 심사청구하는 경우

심사청구는 누구든지 할 수 있다(法 59②). 출원인은 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월 이전에 제3자의 심사청구가 있는 경우 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다(法 42의2②단서). 이는 출원공개 전이라도 심사청구가 있으면 심사청구순서에 따라 실체심사를 진행하기 때문이다.

③ 분할출원, 변경출원, 분리출원의 경우

특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원, 변경출원에 관하여는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 분할출원, 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다(法 52⑧, 53⑧). 출원인의 출원 편의성을 제고하기 위해 분할출원 또는 변경출원 후 청구범위를 적는 보정을 할 수 있도록 허용하고, 청구범위를 적는 데 필요한 최소한의 기간을 보장하고 있다. 다만 분리출원의 경우에는 청구범위제출유예를 할 수 없다(法 52의2③).

청구범위제출유예 제도	미국의 가출원 제도
· 정규출원 · 1년 2개월이 지나기 전까지 청구범위를 적을 수 있음 · 발명의 설명 필요 · 국어 또는 영어로 출원	· 임시출원 · 1년 이내에 청구범위가 포함된 정규출원을 다시 제출하여야 함 · 발명의 설명에 대한 형식·내용 제한 없음 · 언어에 제한 없음

270) 기존에 청구범위제출유예 가능 기간은 1년 6개월이었으나 출원인이 1년 6개월 시점에 청구범위를 적는 보정을 할 때 보정 절차에 하자(수수료 미납, 대리인 증명서류 미제출 등)가 있으면, 그 보정 절차의 하자가 치유될 때까지 보정 서류가 수리되지 않아 출원공개가 지연될 수 있으며, 출원공개가 지체된 경우 출원공개된 기술을 활용해야 하는 일반 공중에게 불측의 피해가 발생할 수 있는 문제점이 있었다. 따라서 현행 실무상 출원 절차에 하자가 있는 경우 최대 4개월까지 지정기간을 연장해 주는 것을 고려할 때, 합리적인 출원공개를 위해 출원공개 기간인 1년 6개월에서 출원 절차의 하자 보정을 위한 최대 지정기간인 4개월을 제외한 1년 2개월로 청구범위제출유예 기간을 설정하는 것은 타당해 보인다. 또한 외국 어특허출원 제도(法 42의3③)의 국어번역문 제출기간인 1년 2개월과의 형평성을 도모하고 기간을 통일하여 운영하는 것이 출원인의 혼란을 최소화할 수 있을 것이다.

(3) 출원인 심사청구의 제한

특허출원인은 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 출원심사의 청구를 할 수 없다(法 59② I). 특허출원할 때 청구범위제출을 유예하여 출원인이 신속한 출원을 할 수 있도록 하는 한편 청구범위에 의하여 실체심사를 진행하기 때문에 출원인이 청구범위를 기재한 후에만 심사청구할 수 있도록 제한하고 있다.

(4) 출원공개의 예외

명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 출원공개를 하지 아니한다(法 64② I). 일반적으로 명세서에 청구범위를 적지 아니하면 1년 6개월 전에 출원이 취하간주되어(法 42의2③) 출원공개되지 아니하기 때문에, 이 규정은 1년 6개월 전에 조기공개신청을 한 경우에도 출원공개되지 아니한다는 의미로 이해할 수 있다.

(5) 발명의 설명 기재 형식의 유예

2020년 3월 30일에 시행된 특허법 시행규칙(산업통상자원부령 제368호) 제21조 제5항과 제6항에서는 청구범위제출유예제도를 이용할 때, 출원서에 취지를 기재한다면 형식적 기재방법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(임시 명세서)를 제출할 수 있도록 하고, 임시 명세서를 보정할 때 보정서에 형식적 기재방법을 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부하여 지식재산처장에게 제출하도록 하였다. 이는 형식적 기재방법에 맞추어 명세서를 작성하는 데 상당한 시간이 소요됨에 따라 출원이 지연되는 문제점을 해결하기 위함이다.

3. 흡결시 법적취급

(1) 불수리

지식재산처장은 i) 출원서에 명세서(명세서에 발명의 설명을 적지 아니한 경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우나 ii) 명세서가 국어 또는 총리령이 정하는 언어(영어)로 기재되지 아니한 경우, iii) 분리출원으로서 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에 출원을 불수리하여야 하며, iv) 특허출원서에 임시 명세서를 첨부한 출원(施規 21⑤전단)의 보정 전에 명세서, 요약서 또는 도면을 보정한 경우 보정을 불수리하여야 한다(施規 11).

(2) 무 효

지식재산처장은 출원 시 i) 발명의 명칭이 기재되지 아니한 경우 또는 ii) 도면을 제출하였지만, 도면의 간단한 설명이 기재되지 아니한 경우 등 총리령으로 정하는 발명의 설명에 대한 형식적 기재 요건(法 42⑨)에 위반된 경우 기간을 정하여 보정을 명하고 출원인이 그 기간에 보정하지 아니하면 출원을 무효로 할 수 있다(法 16).

(3) 취하간주

특허출원인이 명세서에 청구범위를 적지 아니하고 특허출원한 경우 i) 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월 또는 ii) 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3

개월이 되는 날 중 빠른 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하지 아니하면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(法 42의2③).

(4) 거절이유 등

출원발명이 일반적인 발명의 설명 기재방법(法 42③ I), 청구범위 기재방법(法 42④) 위반이면 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)에 해당하고, 발명의 설명 중 배경기술 기재(法 42③ II), 다항제 기재방법(法 42⑧) 위반이면 거절이유(法 62)에 해당한다. 한편 판례²⁷¹⁾는 “명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우에 있어서는 확인대상발명은 특허발명과의 구체적인 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다”라고 판시하고 기재불비로 기술적 범위를 특정할 수 없는데 착오로 등록된 특허발명의 권리범위를 부정하고 있다.

IV. 필요한 도면

1. 의 의

「도면(drawing)」은 발명의 실시예를 구체적으로 표시하여 발명의 실체를 파악하는 데 도움을 주는 서면으로서 명세서의 보조수단으로 이용되며, 어떤 경우에 도면이 필요한지는 특허법에 규정이 없다. 실무상 협의의 물건발명은 물질발명이나 방법발명과 달리 발명의 특징을 위해 도면의 첨부이 반드시 요구되고 있다. 도면은 처음부터 발명의 요점을 충분히 이해할 수 있도록 작성하여야 한다. 한편 발명의 기술적 특징을 이해하는 데 필요한 경우에는 도면의 인용부호를 청구범위에 적을 수 있으며, 이 경우 해당 발명의 기술 내용은 부호를 사용하여 도시한 것에 한정 해석되지 아니한다.²⁷²⁾

2. 기재사항

1) 도면의 도시방법은 제도법에 따라 평면도·입면도를 흑백으로 선명하게 도시하여야 하며, 필요한 때에는 사시도, 단면도 및 일부 절개도를 사용할 수 있으며, 도면의 번호로서 Fig 1, Fig 2 등의 표시도 인정되므로 제1도, 제2도 등으로 보정할 필요가 없다. 도면은 출원서의 첨부서류 중 명세서 다음에 첨부되어야 하며, 요약서 및 명세서의 일련번호에 연속하여 일련번호를 붙여야 한다.

2) 결정구조, 금속조직, 섬유의 형상, 입자의 구조, 생물의 형태, 오실로 파형 등과 같이 특허법 시행규칙 제63조의 제도법에 따라 작도하기가 극히 곤란한 경우에는 이들을 표현한 사진으로 도면을 대용할 수 있다. 이 경우, 사진은 명료한 것으로 공보에 게재할 수 있는 것만 인정하며, 칼라사진은 식물발명과 같이 필수적인 경우에만 인정한다.

271) 대법원 1998. 10. 13. 선고 97후1344; 2001. 12. 27. 선고 99후1973; 2002. 6. 14. 선고 2000후235 등.

272) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 123면.

3. 흠결시 법적취급

지식재산처장은 출원 시 도면이 기재방식에 위반되었으면 기간을 정하여 보정을 명하고 출원인이 그 기간에 보정하지 아니하면 출원을 무효로 할 수 있다(法 16).²⁷³⁾ 한편 i) 다른 출원의 도면을 첨부하는 등 출원된 내용과 전혀 관계없는 도면을 첨부한 경우, ii) 도면의 첨부 오류가 원인이 되어 제42조제3항제1호의 거절이유가 발생하였다면 그 취지를 적어 거절이유를 통지한다. 도면의 첨부 오류가 청구항에 기재된 발명을 쉽게 실시하는데 전혀 영향을 미치지 아니한 경우에는 다른 거절이유를 통지할 때 참고사항으로 적어 통지하되, 이를 이유로 특허 거절결정해서는 아니 된다. 다만 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 새로이 제출된 도면은 신규사항추가금지(法 47②전단)에 위반될 가능성이 크다.

V. 요약서

1. 의 의

「요약서(abstract)」는 기술정보로서의 용도로 사용하기 위해 제출을 의무화한 것으로서, 요약서는 제42조제2항에 따라 출원서에 첨부하도록 규정되어 있다. 요약서 제도는 출원건수의 증가 및 기술내용의 복잡화 추세에 대응하여 특허정보의 효율적 이용을 위한 대책으로 도입되었다. 이러한 요약서는 그 기재가 매우 간략히 표현되고 있으므로 기술정보의 용도로 사용하려면, 특허발명의 보호범위를 정하는 데에는 사용할 수 없다(法 43).

2. 기재사항

요약서는 「요약」, 「대표도」를 기재하며 「요약」은 발명의 기술적 내용을 요약하되 그 발명의 기술적 관점에서 진보성과 발명의 단일성을 고려하여 발명의 기술분야, 해결하고자 하는 과제와 해결의 요점과 주요한 용도를 간결하게 10줄 내지 20줄 정도로 적어야 한다(法 42⑨). 「요약」은 그 성질상 통상의 기술자가 그 발명의 기술적인 내용을 금방 알 수 있게 함으로써 선행기술의 조사(search) 또는 기술정보의 분류에 편리하게 작성하여야 한다. 「대표도」는 도면이 있는 경우 발명의 내용을 가장 잘 표현하고 있는 도면을 「도 2」와 같이 기재하거나 이미지로 직접 입력할 수도 있다.

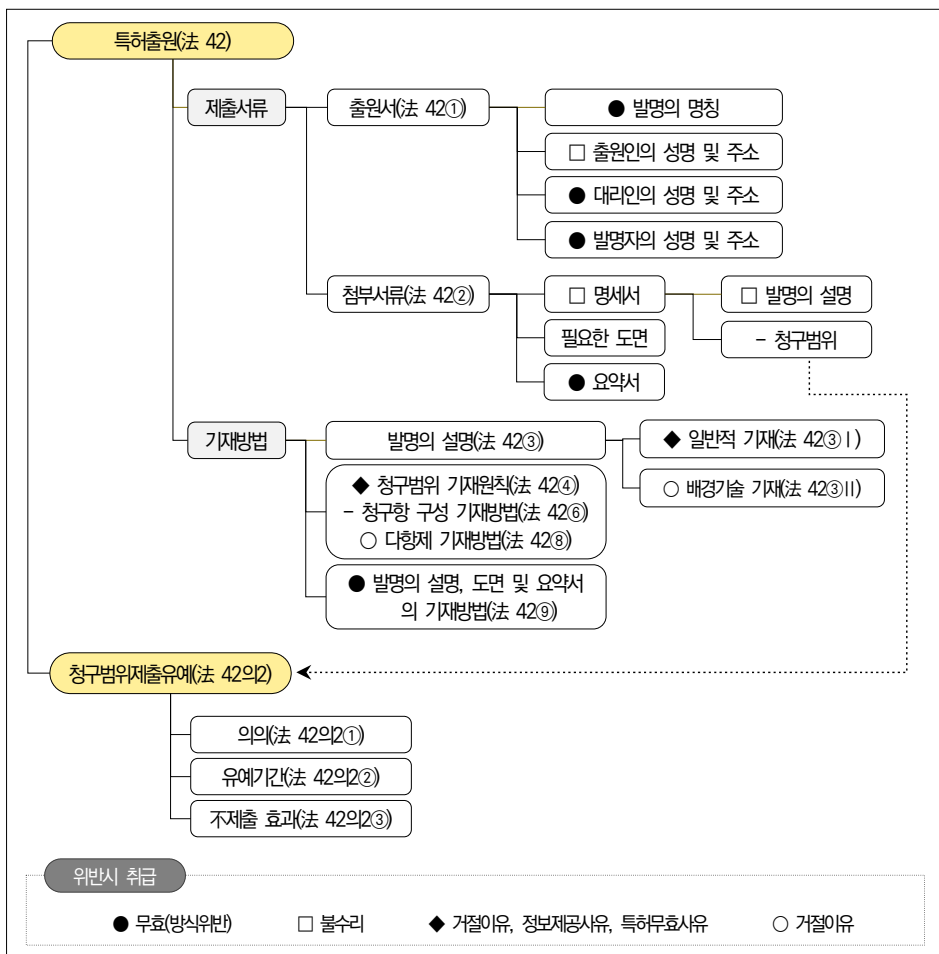
3. 흠결시 법적취급

지식재산처장은 출원 시 요약서가 기재방식에 위반되거나 제출되지 아니한 경우 기간을 정하여 보정을 명하고 출원인이 그 기간에 보정하지 아니하면 출원을 무효로 할 수 있다(法 46, 16).

273) 실용신안등록출원의 경우에는 물품의 형상·구조 또는 조합의 고안을 보호대상으로 하므로 반드시 도면을 첨부하여야 한다. 따라서 실용신안등록출원의 출원서에 도면이 첨부되어 있지 않을 때는 이는 부적법한 출원서로 취급하여 불수리처분을 하여야 한다.

VI. 그 밖의 첨부서류

특허출원서 및 명세서, 도면 및 요약서 이외에도 대리인이 특허에 관한 절차를 밟을 경우에는 대리권을 증명할 수 있는 서류(위임장 등, 法 7), 법인이 출원한 경우에는 법인임을 증명하는 서류, 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 경우에는 출원인명의변경신고서, 상속인 경우에는 호적등본, 공동발명의 경우 지분을 이전한 경우에는 다른 공유자의 동의서, 유증을 받은 경우에는 유증증명서, 미생물에 관한 발명에 대한 특허출원인 경우 미생물을 기탁한 것을 증명하는 서면(令 2②) 등을 제출(단, 국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 증명서류 제출 생략 가능)하여야 한다.



【그림 2-23】 특허출원에 필요한 서류(法 42, 42의2)

VII. 외국어특허출원의 경우

1. 의 의

특허출원인이 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다. 이하 같은 조 제2항 및 제5항에서 같다)을 국어가 아닌 총리령으로 정하는 언어(영어)로 적겠다는 취지를 특허출원을 할 때 특허출원서에 적은 경우에는 그 언어로 적을 수 있다(法 42의3①, 施規 21의2). 미국, 유럽특허청(EPO) 및 일본 등은 이미 외국어로도 출원일 선점이 가능하나 우리나라는 이를 인정하고 있지 아니하여 국제 추세에 부응하지 못한다는 지적이 있었고, 국내에서도 영어 논문 등이 지속적으로 증가하고 있음을 고려할 때 이를 기초로 빠른 출원일을 확보할 수 있는 제도적 장치의 마련이 필요하여, 2015. 1. 1. 시행된 현행법(법률 제12753호, 2014. 6. 11. 개정)에서 이를 반영하였다. 다만 출원서와 요약서는 국어로 작성하여야 한다.

2. 국어번역문의 제출 및 교체

(1) 제 출

특허출원인이 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 제42조의3제1항에 따른 언어로 적은 특허출원(이하 “외국어특허출원”이라 한다)을 한 경우에는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출하여야 한다. 다만 본문에 따른 기한 이전에 제60조제3항에 따른 출원심사청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 제출하여야 한다(法 42의3②).

(2) 교 체

국어번역문을 제출한 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 기한 이전에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다(法 42의3③).

- i) 명세서 또는 도면을 보정(제42조의3제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우²⁷⁴⁾
- ii) 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우²⁷⁵⁾

274) 출원인이 보정한 경우 제47조제2항후단에 의하여 국어번역문이 신규사항인지 판단대상이 되는데, 국어번역문을 교체하게 되면 그 판단대상이 바뀌어 법적 안정성을 훼손하기 때문이다.

275) 출원인의 심사청구는 현재의 상태(국어번역문)에 의해 실제심사를 해 달라는 의사표시로 볼 수 있는데, 심사청구 후 국어번역문을 교체하는 것은 이러한 출원인의 심사청구와 모순되는 행위라 할 수 있기 때문이다.

(3) 예 외

분할출원, 변경출원이 외국어특허출원(실용신안등록출원)인 경우에 출원인은 국어번역문(法 42의3②) 또는 새로운 국어번역문(法 42의3③본문)을 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 분할출원, 변경출원일로부터 30일 이내에 국어번역문을 제출할 수 있다(法 52⑦, 53⑦). 다만 분리출원의 경우에는 외국어특허출원을 할 수 없으며(法 52의2③), 외국어특허출원을 한 경우 불수리된다.

3. 국어번역문을 제출하지 아니한 경우의 취급

(1) 명세서의 경우

특허출원인이 제42조의3제2항에 따른 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 제42조의3제2항에 따른 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(法 42의3④).

(2) 도면(설명부분에 한정)의 경우

도면(설명부분에 한정)에 대한 국어번역문을 제출하지 않은 경우는 명세서에 대한 국어번역문을 제출하지 않은 것과 달리 취하한 것으로 보지는 않지만, 도면의 기재요건 위반(法 42⑨) 등으로 보정 대상이 될 수 있다.²⁷⁶⁾

4. 국어번역문을 제출한 경우의 취급

1) 특허출원인이 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 제42조의3제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 외국어특허출원의 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다(法 42의3⑤본문). 따라서 심사관은 국어번역문을 기초로 심사를 진행하는 한편 국어번역문에 외국어 명세서 또는 도면에 없는 사항이 추가되면(法 47②전단 위반) 이를 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2) 및 특허무효사유(法 133①각호)로 하고 있다.

2) 다만 제42조의3제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막 국어번역문(이하 이 조 및 제47조제2항 후단에서 "최종 국어번역문"이라 한다) 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 42의3⑤단서).

3) 한편 외국어특허출원은 국어번역문을 제출하기 전까지 명세서 보정, 분할출원, 변경출원 및 출원인의 심사청구를 할 수 없고 출원공개되지 아니한다(法 47⑤, 52①단서, 53①II, 59②II, 64②II).

276) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5504면.

5. 오역(잘못된 번역)의 정정

(1) 요 건

특허출원인은 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 오역을 정정할 수 있다(法 42의3⑥전단). 다만 국어번역문에 오역이 있더라도 그 오역이 국어번역문에 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항은 오역정정할 필요가 없다.

(2) 절 차

① 오역 정정서의 제출

오역정정을 하기 위해서는 오역정정의 내용을 기재한 「국어번역문 오역 정정서」에 오역정정의 이유를 기재한 「설명서」를 첨부하여 제출하여야 한다(施規 21의3③).²⁷⁷⁾ 오역정정의 이유를 기재한 설명서를 첨부하는 이유는 i) 오역정정이 외국어 명세서 등의 기재에 따라 행해진 것임을 명확히 하고, ii) 제3자나 심사관이 출원서에 최초로 첨부된 외국어 명세서 등을 대조 확인하여 오역정정의 적정성 여부를 확인하는 부담을 낮추기 위한 것이다. 한편 오역정정에 관한 설명서의 내용이 불충분하여 오역정정의 타당성을 확인하기 어려운 경우에는 설명서에 대하여 보정명령을 한 후 오역정정을 무효처분할 수 있으나, 오역정정의 적합성 여부는 거절 이유 또는 보정명령의 대상이 되지 아니한다.²⁷⁸⁾

② 취하간주

최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①I) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①II)에 오역 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 42의3⑦).

(3) 효 과

① 국어번역문 신규사항의 판단대상

정정된 국어번역문이 제47조제2항후단에 따라 보정에 대한 신규사항의 판단대상이 된다(法 47②후단).

② 보정 효과의 미부여

정정된 국어번역문에 관하여는 보정의 효과(法 42의3⑤)를 부여하지 아니한다(法 42의3⑥후단). 즉 오역 정정은 명세서를 보정한 것이 아니라 국어번역문만을 정정한 것이기 때문에 국어번역

277) 설명서에는 i) 보정사항에 대응되는 출원서에 최초로 첨부된 외국어명세서 등의 기재사항과 그 기재 부분, ii) 오역정정 전 국어번역문의 번역이 부적절한 이유, iii) 오역정정 후 국어번역문의 번역이 적절한 이유(이하 “정정이유”라 한다)를 적어, 오역이 생긴 이유를 명백히 밝히는 동시에 통상의 기술자에게 있어서 오역의 정정 내용이 외국어명세서 등에 기재한 사항의 범위 내임을 확인할 수 있을 정도로 충분히 기재하여야 한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5512면).

278) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5518면.

문에 오역이 있는 경우에는 국어번역문에 대한 오역정정과 별도로 심사대상 명세서 등에 대하여 보정을 하여야 한다.

VIII. 국제출원의 경우

1. 국제출원서류의 제출

(1) 서

1) 국제출원을 하려는 자는 총리령으로 정하는 언어로 작성한 출원서와 발명의 설명, 청구 범위, 필요한 도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 193①). 여기서 「총리령으로 정하는 언어」란 국어, 영어 또는 일본어를 말한다(施規 91).

2) 국제출원에 관하여 지식재산처장에게 제출하는 서류는 국제출원의 발명의 설명 및 청구 범위를 적은 언어(이하 “국제출원의 언어”라 한다)로 작성하여야 한다. 다만 국적증명서, 법인 증명서, 그 밖에 지식재산처장이 지정하는 서류는 그러하지 아니하다(施規 75).

3) 국제출원은 서면 또는 전자문서로 할 수 있다. 국제출원의 서류를 서면으로 제출하는 경우에는 각 3통을 별개의 서류로 작성하여 제출하여야 한다(施規 92①).

(2) 국제출원서류의 작성

① 출원서

1) 국제출원서에는 다음의 사항을 적어야 한다(法 193①②). 한편 지식재산처장은 국제출원의 출원서에 기재사항 외의 사항이 기재되어 있는 경우에는 직권으로 그 사항의 기재를 말소하여야 한다(施規 95).

- i) 해당 출원이 특허협력조약에 따른 국제출원이라는 표시
- ii) 해당 출원된 발명의 보호가 필요한 「특허협력조약」 체약국의 지정
- iii) 지정된 체약국(이하 “지정국”이라 한다) 중 「특허협력조약」 제2조(iv)의 지역특허를 받으려는 경우에는 그 취지
- iv) 출원인의 성명이나 명칭, 주소나 영업소 및 국적
- v) 대리인이 있으면 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소
- vi) 발명의 명칭
- vii) 발명자의 성명 및 주소(지정국의 법령에서 발명자에 관한 사항을 적도록 규정되어 있는 경우만 해당한다)

2) 국제출원의 출원서 등이 제출된 경우에는 다음의 사항이 행하여진 것으로 본다(施規 93의2).

- i) 조약 제11조에 따른 국제출원일에 조약에 구속되는 모든 체약국의 지정(이를 자동지정 제도로 한다.) 다만 조약규칙 4.9(b)에 따른 우선권 주장의 기초가 되는 자국내 선출원에 대하여 취하되는 효과를 규정하고 있는 체약국에 대해서는 국제출원의 출원인은 해당 체약국의 지정을 제외할 수 있다.

- ii) 지정국 중 조약 제43조 또는 제44조가 적용되는 각 지정국에서 얻을 수 있는 모든 종류의 권리를 위한 것이라는 표시
- iii) 조약 제45조(1)이 적용되는 각 지역구의 지역특허[조약 제2조(iv)에 따른 특허를 말한다] 및 국내특허[조약 제45조(2)가 적용되는 경우를 제외한대]를 위한 것이라는 표시

② 발명의 설명

국제출원서에 첨부하여야 할 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다(法 193③).

③ 청구범위

국제출원서에 첨부될 청구범위는 보호를 받으려는 사항을 명확하고 간결하게 적어야 하며 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다(法 193④).

(3) 국제출원에 적어서는 아니 되는 표현 등

국제출원에는 다음의 사항이 포함되어서는 아니 된다(施規 77).

- i) 공공의 질서에 반하는 표현 또는 도면
- ii) 선량한 풍속에 반하는 표현 또는 도면
- iii) 출원인 외의 특정인의 생산물·방법 또는 출원이나 특허의 이점 또는 유효성을 비방하는 기술 (단, 선행기술과의 단순한 비교는 그 자체로는 비방으로 보지 아니한다.)
- iv) 국제출원에 기술된 사항과 관련성이 없거나 필요하지 아니한 기술

(4) 기재불비의 효과

① 국제출원일의 불인정

i) 발명의 설명 또는 청구범위를 제출하지 않거나, ii) 국제출원할 수 있는 언어로 작성하지 아니하여 보완명령을 받고 보완하지 아니하면 국제출원일이 인정되지 아니한다(法 194①).

② 취하간주

i) 발명의 명칭을 적지 아니한 경우, ii) 요약서를 첨부하지 아니한 경우, iii) 그 밖의 방식에 위반된 경우 중 어느 하나에 해당하여 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 흠결을 치유하지 아니하면 그 국제출원은 취하간주된다(法 196①).

2. 국제특허출원서 등의 취급

1) 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조제1항에 따라 제출된 특허출원서로 보고, 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면으로 본다(法 200의2①②). 2015. 1. 1. 시행된 현행법(법률 제12753호, 2014. 6. 11. 개정)은 국제출원일까지 제출한 원문(출원서, 발명의 설명, 청구범위 및 도면)을 국내법(法 42①②)에 따른 출원서, 명세서 및 도면으로 간주함으로써 국제특허출원과 관련된 심사에 있어서 기존의 번역문주의에서 원문주의로 전환하였다. 따라서

국제특허출원의 출원인은 원문에 기재된 발명의 범위에서 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 국내우선권주장출원을 할 수 있다.

2) 국제특허출원에 대해서는 다음의 요약서 또는 국어번역문을 제42조제2항에 따른 요약서로 본다(法 200의2③). 즉 요약서는 특허정보의 효율적 이용을 위한 것이기 때문에 국어로 기재될 것을 요구하고 있다.

- i) 국제특허출원의 요약서를 국어로 적은 경우에는 국제특허출원의 요약서
- ii) 국제특허출원의 요약서를 외국어로 적은 경우에는 제201조제1항에 따라 제출된 국제특허출원의 요약서의 국어번역문(제201조제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 말한다)

3. 국제특허출원의 국어번역문 제출

(1) 국어번역문의 제출

① 원 칙

1) 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 우선일부터 2년 7개월(이하 “국내서면제출기간”이라 한다) 이내에 다음의 국어번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 201①본문). 다만 출원서는 국어번역문을 제출하지 않고 후술하는 제203조의 국내 진입 의사 표시 서면을 제출하여야 한다.

- i) 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문
- ii) 국제특허출원의 요약서의 국어번역문

2) 여기서 「우선일」이란 i) 국제출원이 우선권주장을 수반하는 경우에는 동 우선권이 주장되는 출원의 선출원일, ii) 국제출원이 두 개 이상의 우선권주장을 수반하는 경우에는 우선권을 가장 먼저 주장한 출원의 출원일, iii) 국제출원이 우선권주장을 수반하지 아니하는 경우에는 동 국제출원의 출원일을 의미한다(PCT 2(xi)).

② 국어번역문 제출기간의 연장

국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 국내 진입 의사 표시 서면(法 203①)에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외한다)에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다(法 201①단서). 2015. 1. 1. 시행된 현행법(법률 제12753호, 2014. 6. 11. 개정)은 국어번역문 제출기간을 연장해 줌으로써 출원인의 편의를 증대시키고, 또한 국어번역문의 품질을 제고하여 출원공개된 명세서의 활용성을 높이고 있다.

(2) 국내 진입 의사 표시 서면의 제출

① 서면의 제출

1) 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간에 다음의 사항을 적은 서면을 지식재산청장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조제1항에 따른 국어번역문을 함께 제출하여야 한다(法 203①). 다만 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적어 서면을 제출하는 경우에는 국어번역문을 함께 제출하지 아니할 수 있다(法 203②).

- i) 출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- ii) 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
- iii) 발명의 명칭
- iv) 발명자의 성명 및 주소
- v) 국제출원일 및 국제출원번호

2) 이는 국내 진입 의사를 표시하는 서면으로서, 특허법은 출원인의 주체나 대상을 확정하는데 필요한 서지적 사항을 알기 위해서 출원서의 국어번역문에 갈음하는 서면을 강제적으로 제출하도록 하고 있다. 이 서면을 제출하여야 하는 자는 외국어뿐만 아니라 국어로 국제특허출원을 한 출원인도 포함된다.

② 부적법한 경우의 취급

지식재산청장은 i) 국제출원의 국내 진입 의사 표시 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우나, ii) 그 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반된 경우에 기간을 정하여 보정을 명하여야 하며, 보정명령을 받은 국제특허출원의 출원인이 지정된 기간에 보정하지 아니하면 지식재산청장은 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다(法 203②③).

(3) 국어번역문의 교체

1) 국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(같은 조 제1항 각호 외의 부분 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다(法 201③). 즉 출원인이 심사청구를 한 경우에는 그 날이 기준일이 되어 국내단계에서의 심사가 진행되게 되므로 더 이상 새로운 국어번역문을 갈음하여 제출할 수 없게 된다. 여기서 「기준일」이란 국제특허출원에 대한 국내법에 의한 처리기준 시점을 말하는 것으로서 국내서면제출기간의 만료일(2년 7개월)까지이며, 그 국내서면제출기간에 출원심사의 청구가 있으면 그 출원심사의 청구를 한 때까지이다.

2) 기준일이 지난 후에는 더 이상 새로운 국어번역문을 제출할 수 없으므로 국어번역문이 확정되며, 이를 「최종 국어번역문」이라고 한다(法 201⑤). 한편 제201조제3항의 법문의 문리적 해석에 의하면 국어번역문 교체시기는 역일주의(曆日主義)에 의하는 것이 아니라 시각주의(時刻

主義)에 의한다. 즉 출원심사의 청구가 있는 경우 심사청구일의 다음 날이 아니라 심사청구를 한 시점 이후부터 국어번역문이 확정된다.

(4) 국어번역문을 제출하지 아니한 경우의 취급

1) 출원인이 국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다(法 201④). 한편 우선일로부터 2년 7개월을 지나서 국어번역문을 제출한 경우 제출된 국어번역문은 불수리된다(施規 11).

2) 도면의 설명부분 또는 요약서의 국어번역문이 제출되지 아니하면 국제특허출원이 취하간 주되지 않고 도면의 설명부분 또는 요약서의 기재가 없었던 것으로 간주한다. 이 경우 방식위반에 해당하기 때문에 지식재산차장은 출원인에게 기간을 정하여 보정을 명하여야 하며(法 46), 출원인이 그 기간에 요약서의 국어번역문을 제출하지 아니하면 국제특허출원에 관한 절차를 무효로 할 수 있다.

(5) 국어번역문을 제출한 경우의 취급

1) 특허출원인이 기준일까지 제201조제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(같은 조 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 “최종 국어번역문”이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다(法 201⑤).

2) 특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제201조제5항을 적용하지 아니한다(法 201⑥). 즉 정정된 국어번역문에 관하여는 발명의 설명 및 청구범위의 보정 효과를 부여하지 아니한다.

(6) 오역(잘못된 번역)의 정정

1) 특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 보정의 효과(法 201⑤)를 부여하지 아니한다(法 201⑥). 한편 최초거절 이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① I) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① II)에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 201⑦).

2) 오역 정정은 발명의 설명, 청구범위를 보정한 것이 아니라 국어번역문만을 정정한 것이기 때문에 국어번역문에 오역이 있는 경우에는 국어번역문에 대한 오역정정과 별도로 심사대상 발명의 설명, 청구범위 등에 대하여 보정을 하여야 한다. 한편 오역의 정정이 있는 경우 정정된 국어번역문이 제47조제2항후단에 따라 보정에 대한 신규사항의 판단대상이 된다(法 208④).

(7) 청구범위제출유예(法 42의2)와 외국어특허출원(法 42의3) 규정의 부적용

국제특허출원에 관하여는 청구범위제출유예(法 42의2)와 외국어특허출원(法 42의3) 규정을 적용하지 아니한다(法 199②). 국제특허출원은 출원할 때 청구범위를 적지 아니하면 보완사유(法 194①각호)에 해당하여 출원일을 인정받을 수 없으므로 청구범위제출유예(法 42의2) 규정이 적용되지 아니한다. 또한 외국어국제특허출원은 국어번역문 제출과 관련하여 제201조에서 별도로 규정하기 때문에 외국어특허출원(法 42의3) 규정이 적용되지 아니한다.

제2절 명세서의 역할 및 기재방법

제42조 【특허출원】

- ① 특허를 받으려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허출원서를 지식재산청장에게 제출하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
1. 특허출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 3. 발명의 명칭
 4. 발명자의 성명 및 주소
- ② 제1항에 따른 특허출원서에는 발명의 설명·청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
- ③ 제2항에 따른 발명의 설명은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것
 2. 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것
- ④ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 “청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것
 2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것
- ⑤ 삭제 <2014.6.11.>
- ⑥ 제2항에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다. <개정 2014.6.11.>
- ⑦ 삭제 <2014.6.11.>
- ⑧ 제2항에 따른 청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2014.6.11.>
- ⑨ 제2항에 따른 발명의 설명, 도면 및 요약서의 기재방법 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다. <개정 2014.6.11.>
- [제목개정 2014.6.11.]

제1관 서 설

I. 명세서의 의의

「명세서」란 특허를 받으려는 발명의 기술적인 내용을 문장을 통해 명확하고 상세하게 적은 서면으로, 발명의 설명 및 청구범위를 기재하도록 법정되어 있다.

II. 명세서의 역할

1. 권리서 · 권리해설서의 역할

1) 출원인의 입장에서 청구범위는 등록 전에는 권리요구서, 등록 후에는 권리서의 역할을 한다. 따라서 청구범위의 청구항은 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 하며(法 42④Ⅱ), 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조 · 방법 · 기능 · 물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다(法 42⑥).

2) 발명의 설명은 청구범위를 해설하는 권리해설서의 역할을 한다. 따라서 청구범위의 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다(法 42④Ⅰ).

2. 기술문헌의 역할

1) 일반 공중의 입장에서 청구범위는 자유기술영역과 권리범위의 한계를 명확히 특정하여 침해가 발생하지 않도록 유도하고, 특허분쟁이 발생한 경우 특허침해 여부를 신속하게 판단할 수 있는 기준을 제시하는 역할을 한다.²⁷⁹⁾

2) 발명의 설명은 새로운 기술사상인 발명의 내용을 일반 공중에게 공개하는 기술문헌의 역할을 한다. 따라서 발명의 설명은 i) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것 및 ii) 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것의 요건을 충족하여야 한다(法 42③).²⁸⁰⁾

3. 심사 · 심판대상의 특징

지식재산청 등의 입장에서 명세서는 심사 · 심판대상을 특정하는 역할을 한다. 심사관 · 심판관은 명세서에 기재된 발명을 대상으로 심사, 심판을 진행한다.

279) 청구범위제도는 이른바 土地境界侵犯(trespass) 이론이 특허법에 적용됨에 따라 도입되었다고 보는 것이 일반적이다. 특허출원에 청구범위가 기재되지 않고 명세서에 의해서만 특허권이 부여되던 시절에는 제3자의 특허권 침해에 대하여 법원에서 침해 여부를 명확하게 확정하는 것이 곤란하였다. 마치 일정구역의 토지가 특정인의 소유에 속하고 있다 하더라도 현실적인 울타리가 세워져 있지 않으면 그 토지의 경계는 지적도상에만 나타날 뿐 제3자는 그 경계를 인식할 수 없고, 설사 인식하고 있는 상태에서 경계안으로 들어간 경우라 하여도 이를 무단침입으로 처벌할 수 없는 것과 마찬가지라고 할 수 있다. 그러므로 토지소유자는 자신의 토지영역을 확정하고 제3자의 무단침입을 배제하기 위하여 자신의 토지경계에 따라 울타리를 쌓아야 하고, 그 울타리로 경계지어진 영역 안으로 제3자가 무단침입하였을 경우에만 법으로 그 침해를 배제할 수 있는 것이다. 이러한 土地境界侵犯(trespass) 이론을 특허법에 적용하여 침해의 판정을 쉽게 하기 위한 제도로서 청구범위가 채택되었다(이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 359면).

280) 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조제3항은 발명의 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 “통상의 기술자”라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 · 구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있는데, 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이다(대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582; 2015. 9. 24. 선고 2013후525 등 참조).

【표 2-6】 명세서의 역할

구 분	발명의 설명	청구범위
출원인	권리해설서로서 역할(法 42④ I)	1. 등록 전에는 권리요구서로서 역할(法 42④Ⅱ, 42⑥) 2. 등록 후에는 권리서로서 역할(法 97)
제3자	기술문헌으로서 역할(法 42③)	자유기술영역(공공영역)과 권리범위의 한계 특정 (울타리 이론 → 토지경계침범 이론)
지식재산처	심사·심판 대상의 특정	

제2관 발명의 설명의 기재방법

I. 서 설

1) 「발명의 설명(description)」은 기술문헌의 역할과 아울러 청구범위를 해설하는 권리해설서의 역할을 담당한다. 따라서 발명의 설명의 기재는 i) 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것 및 ii) 그 발명의 배경이 되는 기술을 적을 것의 요건을 충족하여야 한다(法 42③). 즉 발명의 설명은 발명의 공개성, 재현성, 특정성을 달성하기 위한 수준으로 기재되어야 한다.²⁸¹⁾

2) 한편 발명의 설명의 기재방법에 관하여 필요한 기재사항은 총리령으로 정한다(法 42⑨). 제42조제3항은 발명의 설명 기재원칙(실시가능요건), 제42조제9항은 형식적인 기재방법(기재방법요건)이다.

II. 일반적인 기재방법(法 42③)(실시가능요건)

1. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것(法 42③ I)

(1) 의 의

발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(통상의 기술자)이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다(法 42③ I). 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 발명의 설명만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고 고서도 발명의 설명의 기재에 의하여 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다.²⁸²⁾

281) 이종완, 「특허법론」, 대한변리사회, 2004, 339면.

282) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072; 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 등 참조.

(2) 통상의 기술자

「통상의 기술자」란 그 출원이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 즉 평균적 기술자를 말한다.²⁸³⁾ 이러한 정의는 표현상으로는 진보성(法 29②)에서의 통상의 기술자와 동일하나, 발명의 설명은 기술문헌의 역할을 하므로 통상의 기술자의 수준을 낮게 보아야 하고 진보성은 비약적이고 누적적인 발명만 보호하기 위한 규정이라는 취지에 비추어 볼 때 통상의 기술자의 수준을 높게 보아야 한다.

(3) 과도한 실험이나 특수한 지식

「과도한 실험이나 특수한 지식」이라는 기준은 그 의미가 개념적으로는 이해가 가지만 어느 정도까지 통상의 기술자에게 기대할 수 있는 것인가에 대한 객관성을 담보하는 구체적인 기준이 필요하다고 할 것이다.²⁸⁴⁾

(4) 그 발명

실시의 대상이 되는 「그 발명」은 청구항에 기재된 발명으로 해석된다. 따라서 발명의 설명의 기재에 오류가 있다고 하더라도 i) 그러한 오류가 청구항에 기재되어 있지 아니한 발명에 관한 것이거나 ii) 청구항에 기재된 발명의 실시를 위하여 필요한 사항 이외의 부분에 관한 것이어서 그 오류에도 불구하고 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명을 정확하게 이해하고 재현하는 것이 용이한 경우라면 제42조제3항제1호 위반이 되지 아니한다.²⁸⁵⁾ 다만 청구범위에 기재된 발명과 직접적 관련은 없으나 발명을 이루는 구성요소 일부를 실시하는데 필요한 사항에 기재 불비가 있는 경우 제42조제3항제1호 위반으로 하여 거절이유를 통지한다.

(5) 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도²⁸⁶⁾

1) 「발명을 이해하고 재현할 수 있는 정도」인지 여부는 발명의 성격이나 기술내용, 발명의 설명의 기재 등 제반 사정을 참작하여 결정해야 한다. 예를 들어 일반적으로 기계장치 등에 관한 발명에 있어서는 특허출원의 명세서에 실시예가 기재되지 않더라도 통상의 기술자가 발명의 구성으로부터 그 작용과 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있는 경우가 많으나, 이와는 달리 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측 가능성 내지 실현 가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 기재되지 않으면 통상의 기술자가 그 발명의 효과를 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있다고 보기 어려워 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많다.²⁸⁷⁾

283) 대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95.

284) 미국에서는 ‘과도한 실험’인지 여부를 판단하기 위한 ‘완즈요건’이라는 8개의 요건이 있다. 즉 ① 청구항의 폭, ② 발명의 성질, ③ 선행기술의 상황, ④ 통상의 기술자의 기술수준, ⑤ 당해 분야의 예측성의 수준, ⑥ 발명자가 제공하는 지시의 양, ⑦ 실시예의 유무, ⑧ 개시내용에 기초하여 발명을 제작 또는 사용하는 데 필요한 실험의 양이 그것이라 한다(김용덕, “특허법 제42조 제3항(상세한 설명)의 기재요건”, 특허소송연구 6집, 특허법원, 2013, 262-263면).

285) 대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2586.

286) 구민승, “물건의 발명의 실시가능 요건에 있어서 발명의 효과의 재현 정도(대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061 판결)”, 대법원판례해설 제108호, 법원도서관, 2016, 357-366면.

한편 그 발명이 이용하고 있는 어떤 기술수단이 특허출원 당시의 기술수준에 속하는 범용성이 있는 것으로서 그 구성을 명시하지 아니하더라도 이해할 수 있는 것일 때는 구태여 그 기술수단의 내용을 적을 필요가 없다.²⁸⁷⁾

2) 「재현」이란 물건발명에서는 그 물건을 생산, 사용 등을 할 수 있고, 방법발명에 있어서는 그 방법을 사용할 수 있고, 물건을 생산하는 방법의 발명에 있어서는 그 방법에 의하여 그 물건을 생산할 수 있을 정도를 말한다.²⁸⁹⁾ 여기서 물건발명의 경우 「생산, 사용 등」의 의미에 관하여 i) 단순히 물건 자체의 생산, 사용 등을 의미한다는 형식적 재현설, ii) 발명의 설명에 기재된 효과를 가지는 물건의 생산, 사용 등을 의미한다는 실질적 재현설을 상정해 볼 수 있다. 이러한 견해의 차이는, 발명의 설명 또는 도면으로부터 물건을 생산하고 이를 사용할 수는 있으나, 그로부터 얻어지는 효과가 구체적 실험 등으로 증명이 되지 않고 통상의 기술자 입장에서 그러한 효과가 발생하리라고 충분히 예측할 수도 없는 경우, 제42조제3항제1호 위반으로 볼 수 있는지에 그 구별의 실익이 있다.²⁹⁰⁾ 이와 관련하여 대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후 2061 판결²⁹¹⁾에서는 “물건발명의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, i) 물건발명에서 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 물건 자체를 생산하고 이를 사용할 수 있고, ii) 구체적인 실험 등으로 증명이 되어 있지 않더라도 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 통상의 기술자가 발명의 효과 발생을 충분히 예측할 수 있다면, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 있다”라고 하여 실질적 재현설의 취지와 부합한다고 보인다.²⁹²⁾ 발명의 설명에 기재된 효과가 발명으로부터 도출될 수 없음이 명백한

287) 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없다면 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재 하여야만 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있다(대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후1854).

288) 대법원 1992. 7. 28. 선고 92후49.

289) 물건을 생산하는 방법의 발명이 새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 파라미터 발명에 해당하는 경우, 파라미터의 정의나 기술적 의미, 특성값이나 변수의 측정 방법측정 조건 등 파라미터의 확인 수단 등을 고려할 때 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 발명의 설명에 기재된 사항에 의하여 파라미터로 특정된 생산 방법을 사용할 수 없다면 특허법 제42조제3항제1호에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292).

290) 예를 들어 살충작용을 갖는 화합물의 발명의 경우, 청구항에 나타난 화학식의 물질을 생산할 수 있을 뿐만 아니라, 그 화합물이 실제로 살충작용을 나타내지 않으면 아니 될 것이다(사단법인 한국특허법학회 역, 특허판례백선(知財高裁 2010. 1. 28. 제10033호 판결의 해설 부분), 박영사, 2014, 136면).

291) 대법원 2018. 10. 25. 선고 2016후601 판결도 마찬가지이다.

292) ‘물건의 발명’의 경우 그 발명의 ‘실시’라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 그 발명의 청구범위에 특정된 물건 전체의 생산, 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 명세서 기재가 없는 경우에는 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다. 따라서 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 그 청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 위 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다(대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후518).

경우에 제42조제3항제1호 위반이라고 할 것이다.

3) 다만 실질적 재현설을 취하더라도, 문제가 되는 구성요소로 인한 효과가 실제로 발휘되는지를 파악하는 것으로 충분하다고 할 것이고, 효과의 정도가 미미하다고 하여 선불리 제42조제3항제1호 위반으로 판단해서는 안 될 것이며, 이는 진보성 판단의 영역에 관한 사항으로 보아야 한다. 즉 통상의 기술자가 발명의 설명의 기재로부터 효과가 우수하다는 것을 인식할 수 있는지 여부가 제42조제3항제1호의 기재요건이고, 발명의 설명에 기재된 효과가 특별하거나 현저한 가치를 가지는 진정한 것인지 여부는 진보성 판단에서 다루어져야 한다(진정성 여부에 다름이 있는 경우 추후 실험자료 등을 통해 증명하는 것이 가능하다).

2. 배경기술을 적을 것(法 42③II)

2011. 7. 1. 시행된 현행법(법률 제10716호, 2011. 5. 24. 개정)은 발명의 설명의 기재요건에서 배경기술을 적을 것을 의무화하고 있다. 발명의 배경기술은 그 발명의 기술적 특징을 쉽게 파악하는 데 도움이 되어 그 발명에 관한 특허출원의 심사에 유용할 뿐만 아니라 특허협력조약(PCT) 규칙에서도 필수 기재사항으로 규정하고 있음을 감안한 것이다.

III. 형식적인 기재방법(기재방법요건)(法 42⑨)

1. 서

1) 발명의 설명에는 i) 발명의 명칭, ii) 기술분야, iii) 발명의 배경이 되는 기술, iv) 발명의 내용, v) 도면의 간단한 설명, vi) 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용 및 vii) 그 밖에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항을 포함하여야 한다. 다만 ii), iv), v) 및 vii)의 사항은 해당하는 사항이 없는 경우에는 그 사항을 생략할 수 있다(法 42⑨, 施規 21③④). 이처럼 발명의 설명의 기재방법을 규정하여, i) 다양하고 편리하게 발명의 설명을 적을 수 있도록 함으로써 출원인의 편의를 도모함과 동시에²⁹³⁾ ii) 특허협력조약에서 규정한 기재형식과 일치시킴으로써 국내출원을 한 후 이를 바탕으로 쉽게 국제출원을 할 수 있게 하였다.

2) 2020년 3월 30일에 시행된 특허법 시행규칙(산업통상자원부령 제368호) 제21조 제5항과 제6항에서는 청구범위제출유예제도를 이용할 때, 출원서에 취지를 기재한다면 형식적 기재방

293) 이는 IT, BT, NT 등 새로운 기술분야가 등장하였고, 이러한 기술들이 기존의 기술들과 복합되어 발달되면서 발명의 내용을 종전의 출원서 형식에 맞출 수 없는 경우가 발생하고 있어 발명을 권리로 설정하는데 장애요인으로 작용하고 있음을 감안한 것이다. 예를 들어 종래기술과 전혀 다른 신규의 발상으로 개발된 개척발명의 경우에는 종래기술의 문제점을 해결(목적에 해당)하기 위해 개발된 것이 아니어서, 목적이나 종래기술에 비해 상승된 효과를 기재하기 곤란하였다. 또한 시행착오 결과에 의한 발견으로부터 얻어지는 발명(신규화합물질, 바이오기술의 성과물 등)의 경우에는 목적 및 효과의 관점보다는 발명의 구조, 용도, 유용성 등의 관점에서 기술하는 것이 그 발명을 이해하기에 더 쉬운 경우가 있다.

법을 따르지 않고 발명의 설명을 적은 명세서(임시 명세서)를 제출할 수 있도록 하고, 임시 명세서를 보정할 때 보정서에 형식적 기재방법을 따른 명세서, 요약서 및 필요한 도면을 첨부하여 지식재산처장에게 제출하도록 하였다. 이는 형식적 기재방법에 맞추어 명세서를 작성하는 데 상당한 시간이 소요됨에 따라 출원이 지연되는 문제점을 해결하기 위함이다.

【명세서】 【발명의 설명】 【발명의 명칭】 【기술분야】 【발명(고안)의 배경이 되는 기술】 (【선행기술문헌】) (【특허문헌】) (【비특허문헌】) 【발명의 내용】 【해결하고자 하는 과제】 【과제 해결 수단】 【발명의 효과】 【도면의 간단한 설명】 【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】 (【실시예】) (【산업상 이용가능성】) (【부호의 설명】) (【수탁번호】) (【서열목록 자유텍스트】) 【청구범위】 【청구항 1】 【청구항 2】
--

【그림 2-24】 명세서 기재 양식(별지 제15호 서식)

2. 구체적인 기재방법

(1) 서

발명의 설명은 원칙적으로**【발명의 명칭】**, **【기술분야】**, **【배경기술】**, **(【선행기술문헌】)****【발명의 내용】**, **【도면의 간단한 설명】**, **【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】**, **(【산업상 이용가능성】)**, **(【부호의 설명】)**, **(【수탁번호】)** 및 **(【서열목록 자유텍스트】)**란으로 구분하여 적으며, 그 내용은 통상의 기술자가 그 발명을 쉽게 이해하고 또한 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적

어야 한다. 다만 【발명의 명칭】, 【배경기술】, 【발명의 실시를 위한 구체적인 내용】을 제외한 위 식별항목에 해당 사항이 없는 경우에는 작성하지 않을 수 있다.

(2) 발명의 명칭

1) 【발명의 명칭】란에는 발명의 명칭이 발명의 표제일 뿐만 아니라 출원발명을 분류하여 기술분야를 특정하고 정리·검색을 쉽게 하려고 적는 것이기 때문에, 발명내용을 고려하여 카테고리 고리가 구분되도록 간단·명료하게 적는다. 발명의 기술분야는 발명의 명칭뿐만 아니라 발명의 구성 및 효과 등을 모두 감안하여 결정하게 되나 일반적으로 발명의 명칭을 주로 참조하여 결정하고 있다.

2) 심사 실무²⁹⁴⁾상 발명의 명칭의 기재방법은 다음과 같다.

- i) 발명의 명칭은 너무 막연한 기재나, 너무 장황한 기재를 피하여 발명의 내용에 따라 간명하게 적는다. 예를 들어 「원심탈수기 탈수통의 진동방지장치」라고 하여야 할 것을 단순히 「원심탈수기」 또는 「탈수통이 진동을 하지 않고 기동이 원활히 일어나게 한 원심탈수기」라고 하는 것 등은 부적당하다.
- ii) 개인명, 상표명, 상품의 별칭, 극히 추상적인 성능만을 나타내는 표현 또는 「특허」라는 용어를 발명의 명칭에 포함하여서는 아니 된다. 예를 들어 최신식, 문명식 이라는 말을 붙이거나 고안자나 출원인의 성명을 붙여서 [○○식 ○○], [○○안 ○○] 등으로 하거나, [발명특허 ○○○] 등과 같이 기재하는 것은 허용되지 아니한다.
- iii) 청구범위에 둘 이상의 카테고리의 청구항(물건, 제조방법, 제조장치, 사용방법 등)을 적는 경우에는 이들 복수의 카테고리를 모두 포함하는 간단·명료한 명칭으로 적어야 한다. 예를 들어 「종이, 그 제조방법 및 제조장치」 등으로 적을 수 있다.
- iv) 발명의 명칭은 그 발명이 무엇을 청구하는지 명확히 알 수 있도록 적어야 한다. 예를 들어 발명의 내용이 자동제어장치로서 다방면의 산업분야에 응용되는 경우에는 발명의 명칭을 「자동제어장치」로 적어도 무방하지만 온도제어에만 사용되는 경우에는 「자동온도 제어장치」라고 적는 것이 적절하다.
- v) 보정에 의하여 청구범위에 기재된 발명이 변경되는 경우에는 발명의 명칭도 이에 부합되도록 보정하여야 한다. 또한 발명의 명칭은 출원서에 적은 발명의 명칭과 동일하게 적어야 한다.

(3) 기술분야

【기술분야】란에는 특허를 받으려는 발명의 기술분야를 명확하고 간결하게 적어야 한다.²⁹⁵⁾ 기술분야를 적어도 1개 이상 적어야 하나, 명시적 기재가 없더라도 통상의 기술자가 기술상식으로 그 발명이 속하는 기술분야를 이해할 수 있을 때는 적지 아니하여도 된다. 출원인이 발명이 속하는 특허분류(IPC, CPC)를 알고 있는 경우에는 참조하여 적을 수 있다.

294) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2204-2205면.

295) 예를 들면 「본 발명은 하기 위한 에 관한 것이다.」와 같이 적어야 한다.

(4) 배경기술

1) 【배경기술】란에는 발명의 이해, 조사 및 심사에 유용하다고 생각되는 종래의 기술을 명시한다. 다만 종래기술과 전혀 다른 신규한 발상으로 개발된 발명으로 배경이 되는 기술을 알 수 없는 경우에는 그 취지를 기재함으로써 배경기술 기재를 대신할 수 있다.²⁹⁶⁾

2) 문제가 되는 것은 배경기술(종래기술)에 기재되었으면 이를 신규성, 진보성을 부정하는 공지기술로 볼 수 있느냐는 것이다.²⁹⁷⁾ 기존 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결 등은 특별한 사정이 없는 한 공지기술로 보아야 한다는 입장이었으나, 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결²⁹⁸⁾은 이러한 종래의 판결을 변경하면서 명세서에 배경기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수 없다고 판시하였다. 이는 출원 전 공지된 것 인지는 사실인정의 문제인데 배경기술이라는 항목(명세서의 기재형식)에 기재했다는 것에 근거하여 공지기술로 간주하는 태도는 객관적 진실에 반하는 결과를 낳을 수 있고, 더욱이 배경기술이란 공개 여부는 묻지 않고 출원 전 존재한 기술을 말하는 것이기 때문이다. 예를 들어 실제로는

296) 배경기술의 기재가 부적절한 예로는 i) 배경기술을 전혀 적지 않는 경우, ii) 특허를 받고자 하는 발명에 관한 배경기술이 아닌 경우, iii) 기초적인 기술에 불과하여 배경기술을 적은 것으로 볼 수 없는 경우 등이 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2314-2315면).

297) 「공지기술」이란 특허출원 전 공개된 기술을 의미하고, 「배경기술(종래기술)」이란 특허출원 전 공지 여부를 불문하고 존재한 기술을 의미한다. 한편 「선행기술」이란 해당 특허출원의 특허요건 심사를 위해 인용된 기술을 의미한다(박태일, “출원결과 중 출원인이 공지기술이라는 취지로 전제부에 기재한 구성요소의 평가”, 사법 40호, 사법발전재단, 2017 여름호, 350-351면).

298) 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다. 그리고 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다. 다만 특허심사는 지식재산처 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다. 그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원결과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 반복될 수 있다. 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 이와 달리 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다는 취지로 판시한 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37).

출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 배경기술에 기재할 수 있는데, 이를 공지기술이라고 단정할 수는 없는 것이다.

(5) 선행기술문헌

【선행기술문헌】란에는 특허를 받으려는 자가 알고 있는 종래기술의 문헌 정보를 다음과 같이 【특허문헌】과 【비특허문헌】란으로 구분하여 적되 그 문헌의 명칭, 발간일, 종래기술이 기재된 페이지 등의 정보를 구체적으로 적는다.

(6) 발명의 내용

① 기재항목

【발명의 내용】란은 원칙적으로 【해결하고자 하는 과제】, 【과제해결수단】 및 【효과】란으로 구분하여 적는다. 다만 구분하여 기재하기 어려운 경우에는 별도로 나누어 적지 아니하여도 된다.

② 해결하고자 하는 과제

【해결하고자 하는 과제】란에는 배경기술(종래기술)의 문제점을 분석하여 그 문제점으로부터 발명이 해결하려는 과제를 배경기술과 관련하여 적는다. 다만 동일 출원인의 제품 또는 선출원에 대한 문제점을 지적하는 경우 스스로 제품에 대한 문제를 자인하는 결과가 되어 제조물책임법에 의한 손해배상의 대상이 될 수도 있으므로 주의하여야 한다.

③ 과제 해결 수단

【과제 해결 수단】란에는 청구항에 기재된 발명에 의하여 어떻게 해당 과제가 해결되었는지를 적는다. 일반적으로는 청구항에 기재된 발명이 해결수단 그 자체가 되므로 청구항에 기재된 발명을 기재하면 된다.

④ 효과

1) 【효과】란에는 특허를 받으려는 발명이 배경기술과 관련하여 가지는 유리한 효과를 적는다. 발명의 설명에 기재된 효과는 그 발명의 신규성, 진보성의 존재를 추인하는 하나의 요소로 될 수 있으므로 출원인이 아는 한도 내에서 충분히 적을 필요가 있다.

2) 심사관은 발명의 효과가 기재되어 있으나 발명의 설명의 전체 기재로부터 그 효과를 예측할 수 없거나 그 효과 유무에 합리적인 의심이 드는 경우(기술상식에 어긋나는 의학적 효과나 비상식적인 효과 등), 그 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련된 효과라면 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지할 수 있다. 의견제출통지서를 통해 거절이유를 통지할 때 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다(法 222). 이는 특허 등록을 받은 제품을 판매하면서 검증되지 않은 효과를 홍보하는 문제점을 해소하기 위함이다. 이에 대하여 출원인은 의견서 또는 실험성적서 등의 자료를 제출하여 발명의 해당 효과를 증명하거나 발명의 설명에 기재된 검증되지 않은 해당 효과의 기재를 삭제하는 보정을 할 수 있다. 출원인이 발명의 효과를 증명할 수 있는 의견서나 자료를 제출하지 아니하여 해당 효과를 확인할 수 없을 때는 심사관은 기 통지한 거절이유에 의하여 거절결정하거나, 다른 거절이유가

없는 경우로서 쉽게 직권보정이 가능한 경우에는 명세서(발명의 설명, 청구범위 등)에서 해당 효과 기재를 직권보정에 의하여 삭제한 후 특허결정할 수 있다. 이때 출원인이 직권보정을 받아들이지 않을 경우 의견서를 제출하는 경우에는 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 보고 특허결정도 취소된 것으로 보므로, 기 통지한 거절이유에 의하여 거절결정할 수 있다.²⁹⁹⁾

3) 발명의 설명에 기재된 발명의 효과 중에 청구항에 기재된 발명과 관련되지 않은 효과에 대해서도 그대로 등록공보에 게재되면 허위·과대광고에 이용되거나 일반인에게 오인·혼동을 일으켜 피해를 줄 우려가 있다고 판단되는 경우(기술상식에 어긋나는 의학적 효과, 비상식적인 효과 등)에는 그 효과에 대한 증명을 요구할 수 있다. 이 경우에는 의견제출통지서의 ‘참고사항’에 기재하거나, ‘참고자료제출요청서’에 발명의 효과를 확인하기 어렵다는 취지를 기재하여 발명의 효과를 확인할 수 있는 실험성적서 등의 자료를 제출하도록 명할 수 있다(法 222). 출원인이 해당 효과 기재를 보정으로 삭제하지도 않고, 증명할 수 있는 의견서나 자료를 제출하지 아니하여 해당 효과를 확인할 수 없는 경우에는, 자료 등이 제출되어 증명될 때까지 심사를 보류하거나, 쉽게 직권보정할 수 있는 경우에는 해당 효과의 기재를 직권보정에 의하여 삭제하면서 특허결정할 수 있다. 이때 출원인이 직권보정을 받아들이지 않을 경우 의견서를 제출하면 직권보정 및 특허결정이 취소된 것으로 보므로, 증명될 때까지 심사를 보류할 수 있다.³⁰⁰⁾

4) 효과 증명을 요구하는 자료 제출을 명할 때에는 거짓자료를 제출하여 특허결정을 받은 경우 거짓행위의 죄(法 229)에 해당될 수 있음을 의견제출통지서나 참고자료제출요청서에 기재하여 고지할 수 있다.³⁰¹⁾

(7) 도면의 간단한 설명

【도면의 간단한 설명】란은 도면을 첨부하는 경우에만 기재하고, 도면이 구체적으로 나타내려는 것이 무엇인지를 쉽게 파악할 수 있을 정도로 첨부도면의 종류·도시상태 및 도시부분에 대한 설명을 간단히 적는다. 구체적으로 각각의 도면에 대한 설명을 【도 1】，【도 2】와 같이 구분하여 적되, 각 도면에 대한 설명은 줄을 바꾸어 적는다.³⁰²⁾

299) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2320-2321면. 예를 들어 청구항에 기재된 ‘로또번호를 생성하는 장치’에 관한 발명에 대하여 발명의 설명에 기재된 ‘당첨확률이 높은 로또번호의 생성’이라는 발명의 효과는 비상식적이므로 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지하면서 증명을 요구하고, 증명되지 않으면 거절결정할 수 있다.

300) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2321-2322면. 예를 들어 발명의 설명에는 ‘이 발명의 기능성 패치는 항균작용을 할 뿐만 아니라 수맥파도 차단하는 기능을 하는 것’으로 기재되어 있으나, 기능성 패치의 조성과 수맥파 차단 기능과는 관련성이 없어 그 효과에 대하여 합리적 의심이 드는 경우에, 해당 효과가 청구항에 기재된 발명과 관련이 없다고 하더라도 그대로 등록공보에 게재되면 과대광고에 이용될 우려가 있다고 판단되면 이러한 효과를 확인할 수 있도록 출원인에게 자료를 제출하도록 명할 수 있다. 출원인이 해당 효과를 증명할 수 있는 자료를 제출하지 않을 때는 자료가 제출될 때까지 심사를 보류할 수 있다. 만약 위 기재 외에는 다른 거절이유가 없다고 판단될 때는 위 기재를 명세서에서 삭제하도록 직권보정한 후 특허결정할 수 있다.

301) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2322면.

302) 구체적인 예는 다음과 같다.

(8) 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】란에는 통상의 기술자가 그 발명이 어떻게 실시되는지를 쉽게 알 수 있도록 그 발명의 실시를 위한 구체적인 내용을 적어도 하나 이상, 될 수 있으면 여러 형태로 적는다. 필요한 경우에는【실시예】란을 만들어 기재하고, 도면이 있으면 그 도면을 인용하여 적는다.

(9) 산업상 이용가능성

【산업상 이용가능성】란은 특허를 받으려는 발명이 산업상 이용가능한 것인지가 불분명할 때 그 발명의 산업상 이용방법, 생산방법 또는 사용방법 등을 적는다. 다만 산업상 이용가능성은 대부분 발명의 설명의 다른 기재로부터 충분히 유추 가능하므로 별도의 기재를 하지 아니하여도 된다.

(10) 부호의 설명

【부호의 설명】란에는 도면의 주요 부분을 나타내는 부호들에 대한 설명을 적는다. 해당 부호들은 발명의 설명 및 도면에 같이 기재하여야 하며, 청구범위를 적을 때도 해당 부호를 함께 적을 수 있다.

(11) 수탁번호

【수탁번호】란은 발명의 설명에 기재된 미생물들의 수탁번호들을 별도로 정리하려는 경우에 적는다.

(12) 서열목록 자유텍스트

【서열목록 자유텍스트】란에는 발명의 설명에 첨부된 서열목록에 기재된 자유텍스트를 필요에 따라 반복하여 적는다.

IV. 특수한 발명의 기재방법

i) 미생물 발명의 경우 통상의 기술자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 없는 경우에는 특허출원 전에 미생물의 기탁을 하여야 하고, 출원서에 그 취지를 적고 그 증명서류를 첨부하여야 하며(국내에 소재지가 있는 국내기탁기관 또는 국제기탁기관에 해당 미생물을 기탁한 경우에는 증명서류 제출 생략 가능), 명세서에 수탁번호를 적어야 하고, ii) 컴퓨터 프로그램 관련 발명의 경우 컴퓨터 프로그램 자체는 특허의 대상이 아니므로 컴퓨터 프로그램과 관련되는 장치나 관련물건과 결합하여 적어야 하고, iii) 식물발명의 경우 반복생산가능성이 있어야 하므로 발명의 특성을 재현할 수 있는 육종경과를 상세히 적어야 한다.

【도면의 간단한 설명】

도1은 전체를 조립한 평면도

도2는 어느 부분을 보인 정면도

도3은 어느 부분의 종단면도

제3관 청구범위의 기재방법

I. 서 설

1. 의 의

청구범위(claim)는 권리요구서와 권리서로서 역할을 하므로 기재요건 및 방법이 법정화되어 있다. 청구범위에는 청구항이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 i) 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것(이를 “뒷받침 요건”이라 함) 및 ii) 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것(이를 “명확성 요건”이라 함)을 모두 만족하여야 한다(法 42④). 또한 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다(法 42⑥). 그 밖의 청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다(法 42⑧). 제42조제4항은 청구항의 기재원칙, 제42조제6항은 청구항의 구성요소(elements of claim)의 기재방법, 제42조제8항은 다항제 기재방법이다.

2. 인정취지

청구범위는 특허제도의 연혁에 비추어 반드시 논리적으로 존재하여야 하는 것은 아니지만,³⁰³⁾ 발명자의 권리주장을 쉽게 하고 공공영역과 권리범위의 한계를 명확하게 하기 위한 현실적인 필요성에서 생겨난 제도이다.

303) 청구범위제도의 역사를 알기 위해서는 먼저 특허제도의 역사를 살펴볼 필요가 있다. 특허제도의 시초는 영국에서 국왕의 은혜로서 특허권이 부여되면서 시작되었는데, 최초로 법령화된 것은 1623년의 專賣條例(statute of monopolies)라고 할 수 있다. 동법 제6조는 독점금지에 대한 예외로서 특허권에 관하여 규정하고 있다. 초기에는 선서에 기하여 특허권이 부여되었고 그 증서로서 특허장이 발급되었다. 특허명세서에는 자기 발명이 타인의 발명과 다르고 우선한다는 점을 명백히 밝히기 위하여 1711년경부터 관행으로 시작되었는데 1852년 법으로 그 제출이 비로소 의무화되었다. 발명자에 특허권이 부여되는 대가로써 발명의 실시와 기술의 공개가 발명자의 의무로 되었다. 이때 명세서는 국민에 대하여 발명의 실시방법을 가르치고 발명이 어떤 것인가를 나타내는 기능을 하였고 발명의 실시에 대신하는 역할을 하였다. 그 후 발명자의 침해자에 대한 권리주장을 쉽게 하고 발명자의 이익을 지키기 위하여 청구범위를 기재하게 되었는바, 영국에서는 1883년 법에 의하여 비로소 명문화되었다. 청구범위제도는 미국에서 1799년에 최초로 시행되었는데 최초의 claim은 Dearborn Patent claim이었고, claim이라는 용어는 1807년 Jennings특허에서 처음 사용되었다. 그러나 진정한 의미에서의 claim은 1811년 Fulton의 증기선에 관한 특허에서였다고 한다. 청구범위의 해석과 판단은 침해사건에 있어서 처음에는 사실문제로서 재판소에서 배심원들에 의하여 이루어졌으나, 1875년 법에 따라 법률문제로서 형평법재판소에 의하여 배심원 없이 이루어지게 되었다(古川和夫, 「多項制の知識」, 통상산업조사회, 1975, 13-17면 참조).

II. 청구항의 기재원칙(法 42④)

1. 뒷받침 요건(法 42④ I)

(1) 의의 및 취지

청구범위에 기재된 청구항은 발명의 설명에 의하여 뒷받침되어야 한다(法 42④ I). 발명의 설명은 청구범위의 해설서적인 역할을 수행하므로 발명의 설명과 청구범위의 청구항 기재가 상호 모순되어서는 안 되기 때문이다. 또한 발명의 설명은 기술 공개서로서 역할을 하는바, 발명의 설명에 적지 아니함에 따라 공개하지 아니한 사항을 청구범위에 청구항으로 적어 특허권이 부여되면 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 결과가 되기 때문이다.³⁰⁴⁾

(2) 판 단

1) 뒷받침 요건은 특허출원 당시의 기술수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구항에 적혀 있는 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 적혀 있는지에 의하여 판단하여야 한다.³⁰⁵⁾ 따라서 출원 시의 기술상식에 비추어 보더라도 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 내지 일반화할 수 없는 경우에는 그 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침된다고 볼 수 없다.³⁰⁶⁾ 한편 도면은 특허출원서에 반드시 첨부하여야 하는 것은 아니고 도면만으로 명세서를 대체할 수는 없지만, 도면은 실시예 등을 구체적으로 보여줌으로써 발명의 구성을 더욱 쉽게 이해할 수 있도록 해 주는 것으로서 도면이 첨부되었으면 도면 및 도면의 간단한 설명을 종합적으로 참작하여 발명의 설명이 청구항을 뒷받침하고 있는지를 판단할 수 있다.³⁰⁷⁾

2) 청구범위는 발명의 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다.³⁰⁸⁾ 다만 청구범위의 청구항에는 기재되지 아니하고 발명의 설명에만 기재된 발명은 원칙적으로 보호받지 못한다. 이 경우 출원인은 발명의 설명에만 기재된 발명에 대하여 별도의 신규출원, 보정(法 47), 분할출원(法 52), 국내우선권주장출원(法 55) 등을 통해 보호받을 수 있다.

304) 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120; 2011. 10. 13. 선고 2010후2582.

305) 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582.

306) 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120; 2016. 5. 26. 선고 2015후2061 등.

307) 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776.

308) 대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184.

【표 2-7】 발명(A, B, C)과 발명의 구성요소(a, b, c, d)의 구별

유 형	기재불비 여부
청구범위: A, B 발명의 설명: A, B, C	-발명의 설명 또는 도면이 청구항을 뒷받침하기 때문에 제42조제4항제1호 위반이 아님 -통상의 기술자가 A, B 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적고 있지 않다면 제42조제3항제1호 위반으로 부적법
청구범위: A, B, C 발명의 설명: A, B	-발명의 설명 또는 도면에 기재되지 아니한 새로운 발명 C가 청구항에 기재되어 있기 때문에 발명의 설명 또는 도면이 청구항을 뒷받침한다고 할 수 없어 제42조제4항제1호 위반으로 부적법 -통상의 기술자가 A, B 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적고 있지 않다면 제42조제3항제1호 위반으로 부적법
청구범위: B(a, b, c, d) 발명의 설명: A(a, b, c)	-통상의 기술자가 발명의 설명에 기재된 A발명으로부터 청구항에 기재된 B발명까지 확장 내지 일반화할 수 없다면 제42조제4항제1호 위반으로 부적법 -통상의 기술자가 발명의 설명에 기재된 A발명으로부터 청구항에 기재된 B발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적고 있지 않다면 제42조제3항제1호 위반으로 부적법
청구범위: A(a, b, c) 발명의 설명: B(a, b, c, d)	-통상의 기술자가 발명의 설명에 기재된 B발명으로부터 청구항에 기재된 A발명까지 확장 내지 일반화할 수 없다면 제42조제4항제1호 위반으로 부적법 -통상의 기술자가 발명의 설명에 기재된 B발명으로부터 청구항에 기재된 A발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적고 있지 않다면 제42조제3항제1호 위반으로 부적법

(3) 뒷받침 요건 위반의 유형³⁰⁹⁾

- ① 청구항의 구성과 대응되는 사항이 발명의 설명에 직접적으로 기재되어 있지 않고, 암시도 되어 있지 아니한 경우³¹⁰⁾
- ② 발명의 설명과 청구항에 기재된 발명 상호 간에 용어가 통일되어 있지 아니하여서 양자의 대응관계가 불명료한 경우
- ③ 청구항의 구성이 특정기능을 수행하기 위한 「수단(means)」 또는 「공정(step)」으로 기재되어 있으나 이들 수단 또는 공정에 대응하는 구체적인 내용이 발명의 설명에 기재되어 있지 아니한 경우
- ④ 출원 시 그 기술분야의 통상의 지식에 비추어 보아 청구된 발명의 범위까지 발명의 설명에 기재된 내용을 확장하거나 일반화할 수 없는 경우³¹¹⁾

309) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2403-2405면.

310) 구체적인 【예】는 다음과 같다.

【예1】 청구항에는 구체적인 수치한정을 하고 있으나 발명의 설명에는 그 수치에 대하여 기재되어 있지 아니한 경우. 다만 이러한 수치한정이 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 시 해당 기술분야의 기술상식에 비추어 보아 발명의 설명으로부터 파악할 수 있는 범위 이내라고 판단할 경우에는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 인정할 수 있다.

【예2】 청구항에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서만 기재하고 있으나 발명의 설명에는 초음파모터를 이용한 발명에 대해서는 전혀 기재되어 있지 않고 직류모터를 이용한 발명만이 기재되어 있는 경우. 다만 발명의 설명에는 그 실시예로 직류모터에 대해서 기재하고 있으나 직류모터만이 아니라 다른 모터도 이용할 수 있다는 기재가 있고 출원당시의 기술상식에서 판단했을 때 초음파 모터를 이용한 실시도 가능한 경우에는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되는 것으로 인정할 수 있다.

- ⑤ 발명의 설명에 기재된 발명의 과제를 해결하기 위한 수단이 청구항에는 기재되어 있지 아니하여 통상의 기술자가 인식할 수 있는 범위를 벗어난 발명을 청구하는 것으로 인정되는 경우³¹²⁾

(4) 제42조제3항제1호와의 관계

청구항이 발명의 설명에 뒷받침되고 있지 아니하면 제42조제4항제1호 위반이나, 제42조제4항제1호 위반은 제42조제3항제1호 위반과 함께 되는 경우가 상당하다.³¹³⁾ 다만 제42조제4항제1호는 출원인이 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 막으려는 특

311) 구체적인 [예]는 다음과 같다.

【예1】 청구항에는 달성하려는 결과, 예를 들어 달성하려는 에너지 효율의 범위에 의하여 발명을 특정하려고 하고 있으나, 발명의 설명에는 특정 수단에 의한 실시예 밖에 기재되어 있지 않고 출원당시 기술분야의 통상의 지식으로도 그 제시된 실시예를 청구된 발명 전 범위로 확장하거나 일반화할 수 없다고 인정되는 경우

【예2】 청구항에는 원하는 성질에 의하여 정의된 화합물을 유효성분으로 하는 특정 용도의 치료제로서 청구되어 있지만, 발명의 설명에는 청구항에 포함된 일부의 구체적인 화합물에 대해서만 해당 치료제로서 유용성이 확인되어 있고, 이를 벗어나는 청구항에 포함된 화합물에 대해서는 그 유용성이 출원당시 기술분야의 통상의 지식으로도 인정될 수 없는 경우

【예3】 파라미터 발명에서 청구항에는 파라미터의 수치범위가 한정되어 있으나, 발명의 설명에는 그 수치범위 전체에 걸쳐 충분한 수의 구체적인 실시예가 기재되어 있지 않고, 실시예를 통해 더 나은 효과가 확인된 수치범위 이외의 범위에 대해서는 출원 시 그 기술분야의 기술상식으로도 그 효과가 인정되지 않는 경우

312) 구체적인 [예]는 다음과 같다.

【예1】 발명의 설명에는 「수분함량이 떡(생지)보다 낮아서 떡(생지)으로 수분 이행을 초래하지 아니하는 크립」만을 떡소로 할 수 있는 것으로 떡의 구성 및 효과를 설명하고 있으나, 청구항에는 수분 함량과 관계없이 유류에서 분리한 지방분의 의미를 갖는 「크립」으로 기재하고 있는 경우

【예2】 파라미터 발명에서 발명의 설명에는 파라미터의 특성값을 만족할 뿐만 아니라 특정 조성 및 공정을 통해 냉연강판을 구성하는 경우에 우수한 강도와 연신율을 확보하는 실시예만 기재되어 있으나, 청구항에는 특정 파라미터만을 만족하는 냉연강판으로 기재된 경우

313) 구체적인 [예]는 다음과 같다(지식재산채, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2307-2308면).

【예1】 청구항에는 가소성물(可塑性物)의 압출성형방법(壓出成形方法)에 관해서 기재되어 있으나, 발명의 설명에는 그 발명을 가소성물의 압출에 적용하는 방법에 대해서는 단순히 언급만 되어 있을 뿐, 탄수화물이나 단백질 등을 주성분으로 하는 농수산 가공품의 식용가소성물의 제조방법에 대해서만 세부적으로 기재되어 있고, 그 기재된 성형방법은 성형온도나 성형압력 등으로 보아서 세라믹스나 금속 등의 가소성물의 압출성형에는 부적절하다고 인정되는 경우에는 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다. 또한 발명의 설명에 발명을 농수산물의 압출 이외에 금속이나 세라믹 등 다른 가소성물의 압출방법에 적용한다는 기재가 없는 경우에는 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

【예2】 발명의 설명에는 「산소 흡수용 조성물에 관한 발명으로 보통의 전해 환원 철보다 빠른 속도로 산소를 흡수할 수 있는 어닐링한 전해 환원 철 미립자를 사용하는 것」으로 기재되어 있으나 청구항 1은 「중량 99.6%까지의 전해 환원 철 미립자, 전해질 생성을 위해 물과 결합하는 중량으로 약 3.5%까지의 염, -----성분을 포함하는 산소 흡수용 조성물」로 기재된 경우 전해 환원 철 미립자는 어닐링한 전해 환원 철 미립자의 상위개념으로 청구항이 발명의 설명에 기재된 내용보다 상위개념으로 기재되어 있고 이에 대한 기재가 발명의 설명에 기재되어 있지 아니한 경우 청구항이 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 아니한 것으로 보아 특허법 제42조제4항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

【예3】 청구항에는 치환기(X)로 CH₃, OH, COOH가 택일적으로 기재된 치환벤젠의 원료화합물을 니트로화하여 파라니트로치환벤젠을 제조하는 방법이 기재되어 있으나 발명의 설명에는 그 실시예로 원료화합물이 톨루엔(X가 CH₃)인 경우에 대해서만 기재되어 있고 그 방법은 CH₃와 COOH의 현저한 배향성의 상이(相異) 등으로 보아 원료가 안식향산(X가 COOH)인 경우에는 부적절하다고 인정되는 경우에는 특허법 제42조제3항제1호 위반으로 거절이유를 통지한다.

허요건이고 제42조제3항제1호는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 요건으로서 제42조제4항제1호와는 독립된 특허요건이므로 둘 중 어느 하나를 위반하였다고 반드시 다른 특허요건을 위반한 것은 아니다. 따라서 각각의 판단법리에 따라 개별적으로 위반 여부를 판단해야 한다.³¹⁴⁾ 예를 들어 발명의 설명에 청구범위에 기재되어 있는 구성이 가지는 발명의 작용 및 효과가 제대로 기재되어 있지 않고 그와 관련이 없는 발명의 작용 및 효과가 기재되어 있지만 발명의 설명에 청구범위에 기재되어 있는 구성이 나와 있고 그 구성이 쉽게 이해될 수 있다면, 제42조제3항제1호 위반이 문제 될 뿐 제42조제4항제1호 위반이라고 할 수 없다.³¹⁵⁾

2. 명확성 요건(法 42④II)

(1) 의의 및 취지

청구범위에 기재된 청구항은 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 한다(法 42④II). 청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 아니한 발명은 특허요건 판단 등이 불가능하며 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정할 수 없기 때문이다.³¹⁶⁾ 다만 발명이 간결하게 기재되어야 한다는 것은 청구항의 기재 그 자체가 간결하여야 한다는 것이며, 그 발명의 개념이 간결하여야 한다는 것은 아니다.

314) 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832. 제42조제4항제1호 규정의 취지에 대하여 종래의 대법원판결은, i) 공개하지 아니한 발명에 대하여 특허권이 부여되는 부당한 결과를 방지(위 판결, 대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 판결 등)하기 위한 것과, ii) 출원발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것(대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결, 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결 등)과 같이 2개의 유형으로 나뉘어 있었다. 이에 따라 그 판단 기준 역시, i) 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지 여부에 따라 판단(대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120 판결, 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결, 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011후2596 판결 등)한다는 것과, ii) 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 통상의 기술자의 입장에서 청구범위와 발명의 설명의 각 내용이 (청구항별로) 일치하여 그 명세서만으로 청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용 효과를 일목요연하게 이해할 수 있는지 여부에 따라 판단(대법원 1999. 12. 10. 선고 97후2675 판결, 대법원 2000. 10. 27. 선고 98후232 판결 등)한다는 것으로 나뉘어 있었다. ii) 유형의 판결은 '청구항별로' 기술구성 등을 '일목요연'하게 이해할 수 있어야 한다는 당초 판시에서 '청구항별로'라는 표현이 빠지고 '일목요연'하게 이해할 수 있어야 한다는 판시만이 남게 되어, 마치 특허법 제42조제3항제1호에서 요구하는 명세서 기재정도인 '통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 특수한 지식을 부가함이 없이 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있는 정도'와 같은 의미로 오해될 수 있었다.* 위 2012후832 판결에 의해 이러한 2가지 유형의 판단 기준이 i) 유형으로 정리되었는데, 이는 제42조 제4항 제1호의 규정 취지와 판단 기준에 관한 주류적 대법원판결(i) 유형)과 다소 상이한 표현의 대법원판결(ii) 유형)이 병존하여 오는 과정에서 발생한 실무상의 오해와 혼란을 없애기 위한 것으로 이해할 수 있다(정택수, "특허법 제42조제4항제1호 기재요건의 판단 기준(대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 판결)", 대법원판례해설 제102호, 2014. 391면-400면).

315) 대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588.

316) 권리범위확인 사건에서 발명의 설명의 다른 기재에 의한 보충을 하더라도 특허발명의 구성요소의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 특허 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없으면 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235).

(2) 판 단

발명이 명확하게 적혀 있는지는 통상의 기술자가 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 기재된 사항으로부터 특허를 받고자 하는 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하고, 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 하여 일률적으로 판단하여서는 안 된다.³¹⁷⁾

(3) 명확성 요건 위반의 유형³¹⁸⁾

- ① 청구항의 기재내용이 불명확한 경우(다만 불명확한 부분이 경미한 기재의 하자이며, 그 하자에 의해서는 통상의 기술자에게 발명이 불명확하지 않거나 또는 발명의 설명이나 도면, 출원 시의 기술상식 등에 의하여 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는 발명이 불명확한 것으로 취급하지 아니한다.)
- ② 발명을 이루는 각 구성요소가 단순히 나열되어 있을 뿐으로 그 결합관계가 기재되어 있지 아니하여서 발명이 불명확한 경우
- ③ 청구항에 기재된 발명의 카테고리가 불명확한 경우³¹⁹⁾
- ④ 동일한 내용이 중복으로 기재되어 있는 등 청구항의 기재가 너무 장황하여 보호를 받고자 하는 사항이 불명확하거나 간결하지 않은 경우
- ⑤ 청구항에 발명의 구성을 불명확하게 하는 표현이 기재되어 있는 경우³²⁰⁾(다만 이러한 표현을 사용하지 않고서는 해당 발명을 간단명료하게 나타낼 수 있는 적절한 표현이 없고

317) 대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563.

318) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2406-2417면.

319) 특허법에서는 물건의 발명과 방법의 발명에 따라 실시행위와 효력범위를 다르게 규정하고 있으므로, 발명의 카테고리는 청구항의 말미에 사용된 용어 또는 표현에 의하여 물건인지 방법인지 판단하되, 발명의 실체를 파악하여 카테고리의 구분이 어려운 경우 불명확한 것으로 판단한다. 「물건의 발명」의 경우 발명을 특정하기 위하여 물건의 구조, 기능 또는 결합을 표현할 수 있는 다양한 표현 방식을 사용할 수 있다. 마찬가지로 「방법의 발명」의 경우에도 발명을 특정하기 위하여 방법, 행위 또는 동작을 표현할 수 있는 다양한 표현 방식을 사용할 수 있다.

320) 구체적인 [예]는 다음과 같다.

【예1】「소망에 따라」, 「필요에 따라」, 「특히」, 「예를 들어」, 「및/또는」 등의 자구(字句)와 함께 임의의 부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 경우(‘A 및/또는 B’는 ‘A 및 B’인 경우와 ‘A 또는 B’인 경우를 함께 적은 것이므로, 발명이 ‘A 및 B’인 경우와 ‘A 또는 B’인 경우 모두에 대하여 각각 특허법 제42조 제4항제1호 및 제2호 위반 여부를 판단한다. 이때, 「및/또는」의 기재로 하나의 청구항에서 이질적인 복수의 발명을 청구하는 것은 아닌지 여부(청구항이 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재되었는지 여부)에 대해서도 판단한다.)

【예2】「주로」, 「주성분으로」, 「주공정으로」, 「적합한」, 「적량의」, 「많은」, 「높은」, 「대부분의」, 「거의」, 「대략」, 「약」 등 비교의 기준이나 정도가 불명확한 표현이 사용된 경우

【예3】「... 을 제외하고」, 「... 이 아닌」과 같은 부정적 표현이 사용된 경우

【예4】수치한정발명에서 「... 이상」, 「... 이하」, 「0~10」과 같이 상한이나 하한이 불명확한 수치한정이나 0을 포함하는 수치한정(0을 포함하는 성분이 필수성분이 아니라 임의성분인 경우에는 제외한다)을 한 경우(여기서 ‘임의성분’이란 출원인이 필요에 따라 선택적으로 첨가하거나 첨가하지 아니하여도 좋다고 인식하는 성분으로, 발명의 설명에 그 취지가 명확히 기재된 성분을 말한다.) 또는 「120~200℃, 바람직하게는 150~180℃」와 같이 하나의 청구항내에서 이중으로 수치한정을 한 경우

그 의미가 발명의 설명에 의하여 명확히 뒷받침되며 발명의 특정(特定)에 문제가 없다고 인정되는 경우에는 허용할 수 있다.³²¹⁾

- ⑥ 지시의 대상이 불명확하여 발명의 구성이 불명확한 경우³²²⁾(다만 지시의 대상이 문언상으로 일치하지 않더라도 그것이 명백한 오기에 불과하여 통상의 기술자가 발명의 구성을 정확하게 이해하여 재현할 수 있는 정도이면 적법한 기재로 본다.³²³⁾³²⁴⁾)
- ⑦ 청구항에 서로 다른 기능을 수행하는 복수의 동일한 표현의 기술용어가 있을 경우에 각각의 기능을 한정하여 기재하거나, 또는 도면에 사용된 부호에 의하여 명확하게 구별되도록 기재되어 있지 아니하여서 보호를 받으려는 발명의 구성이 불명확한 경우
- ⑧ 청구항에 상업상의 이점이나 판매지역, 판매처 등 발명의 기술적 구성과 관계가 없는 사항을 적어 발명이 명확하고 간결하지 아니한 경우
- ⑨ 발명의 구성을 적지 않고 발명의 설명 또는 도면의 기재에 대응하고 있는 경우(다만 발명의 설명 또는 도면의 기재에 대응하지 않으면 적절하게 적을 수 없는 경우에는 이들의 대응에 의한 기재를 인정한다.³²⁵⁾³²⁶⁾)
- ⑩ 발명의 설명 또는 도면 및 기술상식을 참작하여 i) 파라미터의 정의 또는 그 기술적 의미를 명확히 이해할 수 있고, ii) 파라미터의 측정방법, 측정조건, 측정장치 등을 파악하여 파라미터값을 명확히 확인할 수 있으며, iii) 해당 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유가 명확히 드러나고, iv) 또한 출원 시 기술수준과의 관계를 이해할 수 있는 경우 이외의 파라미터발명의 경우³²⁷⁾

321) 조성물 발명에 있어 그 구성으로 포함되어야 할 적극적 구성요소와 함께, 어떤 요소가 배제되어야 할 것을 내용으로 하는 소극적 구성요소(부정적 표현)가 기재된 경우, 소극적 구성요소 그 자체로는 독립된 기능을 발휘할 수 없을 것이므로, 소극적 구성요소에서 배제하고 있는 어떠한 요소가 없는 상황하에서만, 나머지 구성이 작동한다거나 현저한 효과가 증대된다는 특별한 사정이 인정되지 아니한 경우, 소극적 구성요소를 기술적으로 의미 있는 발명의 구성요소로 볼 수 없다(특허법원 2008. 4. 24. 선고 2007허5765). 한편 소극적 구성요소를 특허발명의 구성요소로 인정한 경우 확인대상발명이 그 구성요소를 명시적으로 채택하고 있다면, 그 확인대상발명은 특허발명의 위 구성을 갖추지 못한 것으로서 특허발명의 권리범위에 포함되지 않는다(대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후18).

322) 구체적인 예는 다음과 같다.

【예】 청구항에 여러 가지 종류의 기어가 기재되어 있고 그 중 어느 특정기어를 지시할 때 「상기 평기어」, 「전기 베벨기어」 등과 같이 지시의 대상을 명확히 적지 않고 「상기 기어」, 「전기 기어」 등과 같이 적은 결과 어느 기어를 지시하는지가 불명확한 경우

323) 특허법원 2003. 11. 21. 선고 2002허6251.

324) 구체적인 【예】는 다음과 같다. 심사단계에서 이러한 기재가 있는 경우 다른 거절이유가 없다면 특허결정하면서 직권보정을 하고, 다른 거절이유가 있다면 의견제출통지시에 '참고사항'으로 적어서 보정을 권고한다. 한편 다음의 【예】에 해당하는지가 불분명한 경우에는, 일단 출원인에 통지해 주어서 의견제출 및 보정의 기회를 부여하기 위하여 직권보정이나 '참고사항'보다는 거절이유로 통지하는 것이 바람직하다. 그러나 이러한 거절이유통지에 대하여 제출된 의견서/보정서를 고려하여 다시 심사하였을 때 그러한 기재가 다음의 【예】에 해당하는 것으로 판단되면 이를 이유로 거절결정을 해서는 안 되며 (다른 거절이유가 없다면) 직권보정으로 처리하도록 한다. 또한 제51조에 따른 보정각하 판단(새로운 거절이유 발생 여부의 판단)시에, 보정에 의하여 다음의 【예】에 해당하는 기재가 새로 생긴 경우에도 새로운 거절이유가 발생한 것으로 보지는 않으므로 이를 이유로 보정각하해서는 아니 된다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 2409-2411면).

예	내용	사례
1	청구항에 “상기 000”라고 기재되어 있고 해당 청구항의 선행부분이나 인용되는 청구항에 ‘000’가 전혀 기재되어 있지 않으나, 발명의 설명 및 도면을 참작하여 “상기”를 제외하고 해석하면 발명이 명확하게 파악되는 경우	청구항은 “상기 레귤레이터(10)의 입력단을 통해 인가되는 전원의 전압변동에도 기준전압이 흔들리지 않게 하기 위하여 상기 레귤레이터(10)와 상기 부가저항(R6)(90)을 직렬로 구성하고”라고 되어 있고 청구항의 “상기 부가저항(R6)(90)”의 선행부분에 “부가저항(R6)(90)”이 전혀 나타나 있지 않으나, 발명의 설명의 “기준전압이 흔들리지 않게 하기 위하여 상기 레귤레이터(10)와 부가저항(R6)(90)을 직렬로 구성하고”라는 기재를 참작하여 “상기”를 제외하고 해석하면 청구항의 발명이 명확하게 파악될 수 있는 경우에는, “상기”는 명백한 오기로 볼 수 있으므로 제42조 제4항제2호 위반이 아니다.
	다만 청구항에 “상기 000”라고 기재되어 있는데 해당 청구항의 선행부분이나 인용되는 청구항에 ‘000’가 전혀 기재되어 있지 않은 경우로서, ‘상기’를 잘못 적은 것인지 아니면 인용되는 청구항 번호를 잘못 적은 것인지가 불분명한 경우에는, 위의 유형에 해당되지 않고 제42조 제4항제2호에 위반으로 본다.	청구항 8에 “제1항에 있어서, ... 상기 더블링되지 않은 서브필드 ...”라고 기재되어 있으나, ‘더블링되지 않은 서브필드’는 청구항 8의 선행부분이나 청구항 1에는 나타나 있지 않고 청구항 6에만 기재되어 있고, 청구항 8에 있어서 인용하고 있는 항번호(제1항)가 오기인지 아니면 ‘더블링되지 않은 서브필드’ 앞에 ‘상기’라고 적은 것이 오기인지가 불분명한 경우에는 이는 제42조 제4항제2호 위반의 거절이유가 된다.
2	지시하는 문언과 그 지시대상의 문언이 완전히 일치하지는 않아도 그 의미상 서로 대응되는 표현으로 볼 수 있어서 지시대상임을 명확히 알 수 있는 경우	청구항은 “통신 시스템 내의 두 개의 노드들 중 제2 노드가 상기 두 개의 노드들 중 제1 노드에게 셀 부하를 포함하는 트래픽 상태와 관련된 정보를 제공하는 단계를 포함하고, ... 상기 하나의 값은 상기 전송된 정보와 매핑 정보에 기초하고”라고 되어 있을 때, “상기 전송된 정보” 중 ‘정보’는 “셀 부하를 포함하는 트래픽 상태와 관련된 정보”로 유일하게 결정되고 ‘전송된’이라는 문언은 그 선행부분에 나타나지 않으나 발명의 설명 등을 참작하면 청구항의 “제2 노드가 제1 노드에게 셀 부하를 포함하는 트래픽 상태와 관련된 정보를 제공하는” 것은 정보를 전송한다는 의미로 해석될 수 있음이 명확하므로, “상기 전송된 정보”는 제42조 제4항제2호 위반이 아니다.
	2 이상의 항을 인용하는 청구항으로서 그 인용되는 청구항들 중 일부가 삭제되어 있으나, 삭제된 항의 인용을 제외하고 해석하면 청구항의 발명이 명확하게 파악되는 경우	청구항 10이 “제1항 내지 제9항 중 어느 한 항에 있어서, ...”인데 제3항이 삭제되어 있더라도, 제3항을 제외하고 제1항, 제2항, 제4항 내지 제9항 중 어느 한 항을 인용하는 것으로 해석하면 청구항의 발명이 명확하게 파악될 수 있다면 청구항 10은 제42조 제4항제2호 위반이 아니다.
3	다만 1 이상의 항을 인용하는 청구항으로서 그 인용되는 청구항 전부가 삭제되어 있는 경우에는, 어느 항을 인용하고자 하는지 알 수 없고 발명을 명확하게 파악하기 곤란하므로 제42조 제4항제2호 위반으로 본다.	청구항 3이 “제1항에 있어서, ...”인데 제1항이 삭제되어 있으면 청구항 3은 제42조 제4항제2호 위반이며, 또 다른 예로, 청구항 5가 “제1항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, ...”인데 제1항 내지 제3항이 모두 삭제되어 있으면 청구항 5는 제42조 제4항제2호 위반에 해당한다.

325) 구체적인 【예】는 다음과 같다.

【예】 합금에 관한 발명에서 합금성분조성 상호간에 특정한 관계가 있어서 수치 또는 문장만으로는 명확하게 표현할 수 없는 경우에는 「첨부도면 제1도의 점 A(…), B(…), C(…), D(…)로 둘러싼 범위의 Fe·Cr·Al 및 2%이하의 불순물로 구성되는 내열전열합금」과 같이 도면을 대용하여 적을 수 있다.

326) 청구범위가 불명료한지 여부는 고안의 구성을 나타내는 청구범위에 사용된 용어 등이 불명료하게 표현되었는지 여부에 따라 결정될 것이고, 고안의 성격에 따라 고안의 보호범위와 기술구성을 적절히 나타내기 위해서는 불가피하게 청구범위에 도면을 인용하거나 직접 도면이나 그림으로 도시할 수밖에 없는 경우가 있을 수 있는 점, 추상적 기술사상을 설명하면서 구체적 형상을 한정할 필요가 있는 경우에 그

- ⑪ 아래의 i) 내지 iv)와 같이 조성비의 기술적인 결합이나 모순이 있는 조성비가 %로 기재된 조성물 발명의 경우(다만 청구범위가 “~를 포함하는”과 같이 특정 성분들로만 구성되어 있지 않고 다른 성분도 포함될 수 있는 개방형 청구항에서는 i)의 경우 명시된 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재이고, iv)의 경우 명시된 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재에 해당한다. 그러나 합금의 경우 청구항을 폐쇄형(‘이루어지는’의 형식) 또는 개방형(‘포함하는’의 형식)의 어느 형식으로 기재하더라도 조성범위의 총합이 100%를 초과하거나 미달해서는 안 된다. 합금은 첨가 성분의 종류 또는 양에 의하여 조직상태, 용도 또는 성질이 달라질 수 있으므로, 주성분의 한정만으로 청구범위가 특정될 수 없고, 나머지 첨가 성분이 조성범위를 명확히 하면서 모두 한정되어야 한다.³²⁸⁾)
- i) 모든 성분의 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우
 - ii) 모든 성분의 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우
 - iii) 하나의 최대성분량과 나머지 최소성분량의 합이 100%를 초과하는 경우³²⁹⁾
 - iv) 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 경우³³⁰⁾

형상을 글이 아닌 기호 등으로 표현하는 방식(X자형, L자형 등)이 일반적으로 이용되고 있는 점 등을 고려할 경우 청구범위에 그림이나 도면으로 고안의 구성을 표현하였다는 사유만으로 고안이 불명료하게 되었다고 할 수 없다(특허법원 2008. 4. 17. 선고 2007허7624). 이 판결은 청구항에 도면을 도시하여 구성으로 나타내더라도 발명의 구성을 명확하고 간결하게 적은 것으로 인정하여 명세서 기재요건을 충족하였다고 판단한 최초의 사례이다.

- 327) 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유가 명확히 드러나기 위해서는 파라미터를 만족하는 경우와 그렇지 않은 경우가 비교예로서 제시되어 파라미터와 효과와의 인과관계 및 기술적 과제와 해결수단으로서의 파라미터와의 연관관계가 명확하게 이해될 수 있어야 한다. 또한 출원 시 기술수준과의 관계가 이해될 수 있기 위해서는 발명의 설명에 유사한 구조 또는 효과를 갖는 공지물과의 비교 실험예가 나타나 있거나 논리적 설명이 제시되는 등, 공지물이 출원발명에 포함되지 않는다는 사실이 명확하게 이해될 수 있어야 한다. 파라미터의 기술적 의미, 측정방법, 해당 파라미터를 사용할 수밖에 없는 이유 및 기술수준과의 관계가 발명의 설명이나 도면에 명시적으로 기재되지 않는다면 출원 시 기술상식을 감안할 때 명확히 이해될 수 있는 경우에는 이를 이유로 발명이 불명확한 것으로 취급하지 않는다.
- 328) 아래의 【예】에서 성분 ①을 그 최소값인 40%로 선택할 경우 나머지 성분인 ② 내지 ⑤를 모두 최대값으로 해도 총합이 57%가 되어 100%에 미달하고, 합금의 경우 “~를 포함하는”과 같은 개방형 청구항으로 기재하더라도 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하는 것을 허용하지 않으므로 발명이 불명확하다.
- 【예】 【청구항 1】 ① 40~80%의 Cu, ② 10~45%의 Zn, ③ 1~5%의 Sn, ④ 0.6~3%의 Be, ⑤ 0.8~4%의 Si를 포함하는 것을 특징으로 하는 용접용 동합금
- 329) 아래의 【예】에서 세 성분 중 하나인 A의 최대치와 나머지 성분들 B, C의 최소치의 합이 100%를 넘으므로 발명이 불명확하다.
- 【예】 【청구항 1】 40~60질량%의 A성분과, 30~50질량%의 B성분과, 20~30질량%의 C 성분으로 이루어지는 조성물
- 330) 아래의 【예】에서 성분 c)를 그 최소값인 50중량%로 선택할 경우 나머지 성분인 a), b), d)를 모두 최대값으로 해도 총합이 91중량%가 되어 100중량%에 미달하므로 발명이 불명확하다. 이 경우 “~를 포함하는”과 같이 개방형 청구항으로 기재한다면 하나의 최소성분량과 나머지 최대성분량의 합이 100%에 미달하더라도 다른 성분을 포함하면 100%가 될 수 있으므로 명확한 기재에 해당한다.
- 【예】 a) 크레졸 노블락형 에폭시수지 5-20중량%

- ⑫ ⑪의 요건을 만족하지 않은 조성비가 중량비로 기재된 조성물 발명의 경우에는 만족하지 않아도 명확성 요건을 충족³³¹⁾

III. 청구항의 구성요소 기재방법(法 42⑥)

1) 청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다(法 42⑥). 즉 청구항에는 보호받으려는 발명의 필수구성요소를 적되, 청구항의 구성요소(elements of claim)는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등의 다양한 형태의 기재가 허용된다.³³²⁾³³³⁾

2) 출원인은 발명의 필수구성요소이기만 하면 스스로 발명을 보호할 수 있는 가장 적절한 구성요소를 선택하여 청구범위를 작성할 수 있다. 여기서 「필수구성요소」란 발명의 설명에 특정된 발명의 구성요소 중 출원인의 주관적 사고에 근거하여 추출한 후 청구항에 적은 구성요소를 말한다. 즉 발명을 정의하는데 필요한 모든 구성요소는 발명의 설명에 기재되면 되는 것이고, 이를 필수구성요소라고 하면서 청구항에 모두 기재해야 하는 것은 아니다. 발명의 설명에 특정된 발명의 구성요소 중 어떤 구성요소를 추출하여 청구항에 적을 것인지는 출원인의 의사에 의한 것으로서, 일부를 청구항에 적지 아니한 경우 특허발명의 권리범위를 넓힐 수는 있으나 신규성, 진보성의 심사에 있어서 다소 불리한 위치에 서게 된다.³³⁴⁾

b) 페놀 노블락형 경화제 5-20중량%

c) 실리카 및 알루미늄에서 선택된 무기 충전제 50-80중량% 및

d) 아민계 경화촉진제 0.5-1중량%

로 이루어지는 반도체 소자 밀봉용 에폭시 수지 조성물

331) 아래의 【예】에서 중량부는 일반적으로 하나의 기준 물질을 정하고 이에 따른 다른 성분의 함량을 표현하는 기재방식이나, 기준 물질이 특정되어 있지 않아도 한 성분을 기준으로 하여 다른 성분의 함량을 상대적인 비로 환산할 수 있으므로 조성물의 조성비가 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 있다.

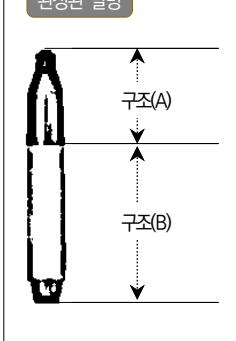
【예】【청구항 1】 A 성분 10-30 중량부, B 성분 20-30 중량부, C 성분 10-20 중량부, D 성분 20-30 중량부를 포함하는 수지 조성물

332) 기준에는 제42조제4항제3호에서 「발명의 구성에 없어서는 안 되는 사항만으로 기재될 것」을 요구하였다. 그런데 「구성」이 청구항을 이루는 구성요소(elements of claim) 또는 발명의 구조나 수단과 같은 구성(structural element)으로 중의적으로 해석될 수 있었다. 전자로 해석할 경우 발명을 이루는 필수구성요소를 전부 기재하여야 한다는 의미이고, 후자로 해석할 경우 발명을 특정하기 위해 물리적인 구조(structural element)만을 기재하여야 한다는 의미이다. 다만 후자로 해석할 경우 기술이 다양화됨에 따라 물건(장치)의 발명에 대해서 물리적인 구조(structural element)보다는 그 장치의 작용이나 동작방법 등에 의하여 발명을 기재하는 것이 바람직한 경우가 발생하고 있는데, 이를 제한하고 있어 문제가 되었다. 따라서 2007. 7. 1. 시행된 현행법(법률 제8197호, 2007. 1. 3. 개정)에서는 제42조제4항제3호를 삭제하고 제42조제6항을 신설하면서, 전자로 해석하여야 한다는 것을 명확히 하고 있다.

333) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486 판결에서도 “청구범위가 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하는 경우, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 발명의 설명이나 도면 등의 기재와 출원 당시의 기술상식을 고려하여 청구범위에 적혀 있는 사항으로부터 특허를 받으려는 발명을 명확하게 파악할 수 있다면 그 청구범위의 기재는 적법하다”라고 하여 기재의 다양성을 인정하고 있다.

3) 제42조제6항은 거절이유, 정보제공사유 또는 무효사유에 해당하지 아니한다. 청구범위는 출원인의 자유의사에 의하여 적는 것인데, 이를 거절이유 등으로 규정하는 것은 불합리하게 청구범위의 기재를 제약하기 때문이다.

완성된 발명



청구항 기재?

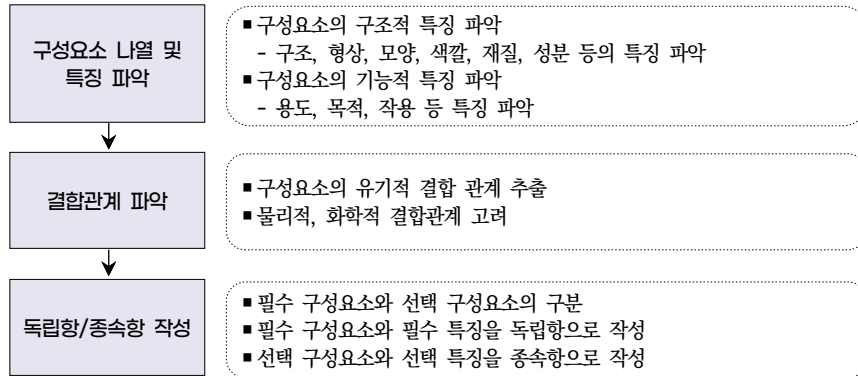
구성	구조	기능	방법
청구항	A의 일측에 B가 결합된 보드마카	필기수단의 일측에 지지수단이 결합된 보드마카	X공정 후 Y공정을 거치는 방법에 의하여 제조된 보드마카
비고		기능적 표현 청구항	PBP청구항

해설

보드마카를 발명한 경우 출원인은 다양한 방법에 의하여 보드마카를 특정하여 청구항에 적을 수 있다. 예를 들어 보드마카의 구조(structure) A, B를 알고 있는 경우에는 「A의 일측에 B가 결합된 보드마카」와 같이 청구항을 적을 수 있다. 구조를 알고 있지 아니한 경우에는 구조가 갖는 기능(function)(A는 필기하는 기능, B는 지지하는 기능)을 특정하여 「필기수단의 일측에 지지수단이 결합된 보드마카」와 같이 청구항을 적을 수 있다. 또한 구조(structure) 또는 기능(function)을 알지 못하더라도 제조방법을 알고 있는 경우에는 「X공정 후 Y공정을 거치는 방법에 의하여 제조된 보드마카」와 같이 청구항을 적을 수 있다. 출원인은 이와 같은 기재방법 중 발명을 보호할 수 있는 가장 적절한 수단을 선택하여 청구항을 작성할 수 있다.

【그림 2-25】 청구항의 구성요소 기재방법의 예시

334) 특허법 제42조제4항은 청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 청구항이 1 또는 2 이상 있어야 하며 그 청구항은 다음 각호에 해당하여야 함을 규정하고, 그 제2호는 “발명이 명확하고 간결하게 기재될 것”을 요구하고 있는바, 그 의미는 특허발명의 보호범위가 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 점(특허법 제97조)에 비추어 원칙적으로 청구항에는 명확한 기재만이 허용되는 것이고 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니한다는 취지이지(대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결 참조), 특허출원 명세서 전체의 기재로부터 발명의 필수 구성요소를 추출한 후 청구항에 기재된 발명에 그러한 구성요소가 누락되지 않도록 기재하여야 한다는 취지로는 보이지 않으며, 출원발명의 필수 구성요소를 출원 명세서의 다른 부분의 기재에 근거하여 파악하고 이를 청구항에 모두 기재할 것으로 요구하고 있는 것이라고는 볼 수 없다(특허법원 2004. 12. 17. 선고 2004허2314).



1) 청구항의 작성은 i) 구성요소의 나열 및 특징 파악, ii) 결합관계 파악, iii) 독립항/종속항의 작성 순서대로 이루어진다. 구성요소의 나열 및 특징 파악은 발명을 이루는 구성요소들을 추출하고, 각 구성요소의 구조, 형상, 모양, 색깔, 재질, 성분 등의 구조적 특징과 용도, 목적, 작용 등의 기능적 특징을 파악하는 과정을 말한다. 결합관계의 파악은 구성요소들의 유기적 결합관계, 즉 물리적, 화학적 결합관계를 파악하는 과정을 말한다. 독립항, 종속항의 작성은 발명을 이루는 필수적인 구성요소와 필수적인 특징으로 독립항을 작성하고, 선택적인 구성요소와 선택적인 특징으로 종속항을 작성하는 과정을 말한다.

2) 심사관은 청구범위에 기재된 발명을 중심으로 실제심사를 하여 특허 여부를 결정하게 된다. 즉 청구범위는 등록 전에 권리요구서로서 기능을 하므로 특허등록을 받을 수 있도록 적어야 한다. 특허출원인은 선행기술조사를 하여 신규성, 진보성에 위반되지 않도록 선행기술과 구별될 수 있게 청구범위의 청구항을 작성하여야 한다.

3) 또한 등록 후에는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지기 때문에 청구범위는 보호범위를 넓게 형성하는 한편 권리행사가 용이하도록 적어야 한다. 보호범위를 넓게 형성하도록 기재하기 위해서는 불필요한 한정어를 제거하고 청구항의 구성요소를 적게 적어야 하며, 여러 개의 청구항을 다양한 관점에서 적는 것이 바람직하다. 권리행사가 용이하도록 기재하기 위해서는 침해대상 대상을 가정하는 한편 침해증명을 고려하여 청구범위의 청구항을 작성하여야 한다.

IV. 다항제 기재방법(法 42⑧)

1. 서

1) 청구범위에는 청구항이 하나 이상 있어야 하는데(法 42④본문), 청구범위에 하나 이상의 청구항을 적는 것을 「다항제(多項制)」라 한다. 다항제는 청구범위에 하나의 청구항만을 적을 수 있는 단항제(單項制)와 반대되는 개념으로서 보호범위의 해석원리로서 주변한정주의의 입장을 취할 때 발명의 다면적 보호를 위한 청구범위의 기재방법이라는 점에 그 의미가 있다. 우리 특허법은 종래(1961년 제정 특허법)에는 하나의 청구항만을 기재하도록 하는 단항제를 채택하고 있었으나, 1980년 법률 제3325호부터 다항제를 도입하였다.

2) 한편 제42조제8항에서는 청구범위의 기재방법에 관하여 필요한 사항은 대통령령에 위임하고 있고, 특허법 시행령 제5조335)에서는 다항제에 의한 청구범위의 기재방법을 규정하고 있다.

2. 독립항과 종속항의 기재

1) 청구범위의 청구항(이하 "청구항"이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 "독립항"이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 "종속항"이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다(令 5①).³³⁶⁾ 청구항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다(令 5②).³³⁷⁾

335) 시행령 제5조 【청구범위의 기재방법】

- ① 법 제42조제8항에 따른 청구범위의 청구항(이하 "청구항"이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 "독립항"이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 "종속항"이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.
- ② 청구항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다.
- ③ <삭 제> (1999. 6. 30)
- ④ 다른 청구항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 적어야 한다.
- ⑤ 2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.
- ⑥ 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다.
- ⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다.
- ⑧ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

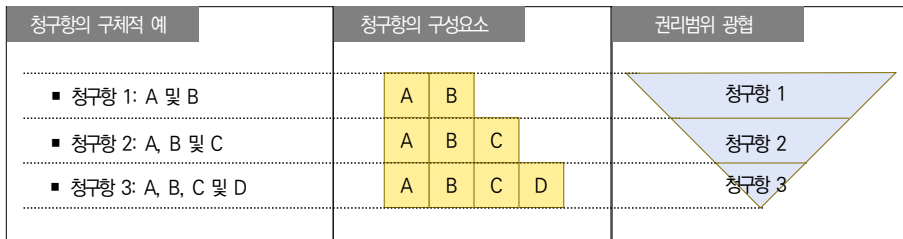
336) 시행령 제5조제1항은 임의사항으로 규정되어 있기 때문에, 심사 실무상 이 항을 이유로 거절이유를 통지하지는 아니한다(대법원 1992. 2. 25. 선고 91후578).

337) 이 규정은 특허법 제45조의 하나의 특허출원의 범위 규정과는 별개로 취급되어야 한다(대법원 1989. 6. 27. 선고 88후967). 다음의 【예】 등과 같이 청구항이 적정한 수로 기재되지 아니한 경우는 거절이유를 통지할 수 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2420면).

【예1】 하나의 청구항에 카테고리가 다른 2 이상의 발명이 기재된 경우

【예2】 하나의 청구항에 청구하는 대상이 2 이상인 경우: ... 고분자 화합물 및 그 고분자 화합물을 이용한 컨택트 렌즈

2) 독립항은 발명내용 중에서 발명의 본질적 특징과 관련된 필수구성요소를 기재하는 청구항을 말한다. 종속항은 발명의 내용이 다른 항에 종속된다는 의미로서 다른 항의 내용 변경에 따라 해당 청구항의 발명내용이 변경되는 청구항을 말한다. 독립항은 발명의 넓이를, 종속항은 발명의 깊이를 표현하는 것으로 구분될 수 있다. 독립항은 발명자의 아이디어로부터 얻어질 수 있는 모든 실시유형을 포섭할 수 있을 만큼 넓게 적어야 하며, 불필요한 한정어를 부가하여 발명의 범위를 좁게 해서는 아니 된다. 청구항에 기재하는 사항이 많으면 등록가능성은 상대적으로 높아지지만, 보호범위는 좁은 것(多記載 狹範圍의 原則, more means less)으로 해석되기 때문이다.³³⁸⁾



【그림 2-26】 다기재 협범위의 원칙

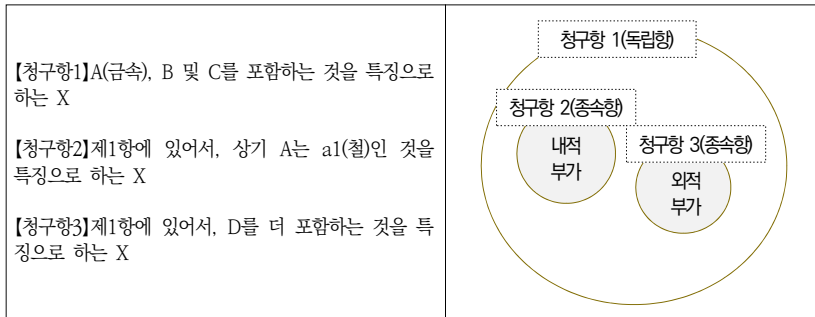
3) 독립항은 청구범위에 하나 이상을 기재하여야 한다. 발명이 선행기술과 다른 특징적인 면에서 복수의 실시예들을 포함하는데, 이들을 포괄하는 하나의 독립항을 작성하는 것이 불가능한 경우에는 복수의 독립항을 기재하는 것이 필요하다. 다만 이와 같은 기재를 하려면 복수의 독립항이 선행기술에 비해 개선된 기술적 특징이 동일하거나 상응하여 발명의 단일성(法 45)을 만족해야 한다.

4) 종속항을 적는 방법은 청구항을 한정하여 구체화(예를 들어 상위개념을 하위개념으로 한정)하는 「內的附加」 방법과 청구항을 부가하여 구체화(예를 들어 구성요소의 직렬적 부가)하는 「外的附加」 방법이 있다.

【예3】 동일한 청구항을 중복하여 기재(문언적으로 동일한 경우를 말하며 실질적으로 동일할 뿐 표현을 달리한 경우는 제외한다)하는 경우,

【예4】 하나의 청구항 내에서 다수의 청구항을 다중으로 인용하는 경우: 「청구항○ 또는 청구항○의 방법으로 제조되는 청구항○ 또는 청구항○의 물건」과 같은 것을 말하며, 이는 둘 이상의 항을 인용하는 종속항이 둘 이상의 항을 인용한 다른 청구항을 인용한 경우와 같은 혼란을 야기하므로 배제하는 것으로 한다.

338) 이 사건 등록발명의 독립항인 청구범위 제1항과 확인대상발명이 상이한 것이므로 종속항들인 이 사건 등록발명의 제2항이나 기타 제3항 내지 제6항과 확인대상발명은 상이한 발명이라 할 것이다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 등록발명의 출원 전에 공지되지 않았고, 이 사건 등록발명의 청구범위 제1항과 상이하여 이 사건 등록발명 청구범위 제1항의 권리범위에 속하지 아니한 것이며, 확인대상발명은 독립항인 이 사건 등록발명의 청구범위 제1항의 권리범위에 속하지 아니한 것이므로 이 사건 등록발명의 청구범위 제1항을 한정하거나 부가하여 구체화한 이 사건 등록발명의 청구범위 제2항 내지 제6항의 권리범위에도 속하지 아니한다(특허법원 2000. 10. 26. 선고 2000허273).



【그림 2-27】 종속항의 기재방법

5) 종속항은 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화해서 별개의 새로운 발명이라고 부를 수 있는 정도의 구성요소를 적어야 한다. 즉 심사관이 독립항의 구성요소와 결합하였을 때 신규성, 진보성 등의 특허요건 위반이 아니라고 판단할 만한 구성요소를 종속항에 적어야 한다. 그렇지 아니한 경우 독립항의 특허요건 위반이 있으면, 종속항도 같이 특허요건 위반이 된다.³³⁹⁾ 이와 같은 종속항을 적는 것은 출원인에게 심사청구료, 특허료 등 청구항 수에 따라 달라지는 비용 부담만 가중하는 결과를 초래한다.

3. 인용형식의 기재

1) 다른 청구항을 「인용하는 청구항」은 인용되는 「항의 번호」를 적어야 한다(令 5④). 한정하거나 부가하여 구체화한 발명을 인용형식이 없는 독립항으로 적을 수 있으나,³⁴⁰⁾ 인용형식이

339) 청구범위의 청구항은 상호 독립되어 있으므로 독립항, 종속항 상관없이 청구항별로 특허요건을 판단하고, 등록 후에는 청구항별로 침해 여부를 판단하는 것이 원칙이다. 그러나 종속항은 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화한 청구항이므로 그 보호범위가 독립항의 보호범위보다 상대적으로 좁다. 따라서 독립항이 특허요건판단에 있어서 신규성, 진보성 위반이 아니면, 종속항도 신규성, 진보성 위반이 아니다. 등록 후 침해 여부의 판단에 있어서도 독립항의 침해가 아니면 종속항의 침해도 되지 아니한다(물론 독립항의 보호범위가 인정되지 아니하고, 종속항의 보호범위만 인정되면 독립항의 침해가 아닐지라도 종속항의 침해가 될 수도 있다). 이와 같은 논리라면 표면적으로 살펴보면 종속항의 존재 의의가 없는 것으로 보일 수도 있다. 종속항의 가장 중요한 존재 의의는 등록 후 특허의 취소나 무효 가능성을 대비할 수 있다는 것이다. 제3자가 실시하는 발명이 독립항과 그 종속항의 침해인 경우 독립항이 특허취소 신청에 의하여 취소나 특허무효심판에 의하여 무효가 되더라도 종속항이 있다면 권리행사를 할 수 있게 된다. 또한 등록 후 정정심판 또는 정정을 청구할 때에도 종속항에 기재가 없었다면 발명의 설명에 적혀 있는 사항이라 하더라도 감축하는 것이 발명의 실질적 변경에 해당되어 원칙적으로 허용되지 않게 되기 때문에 종속항 기재의 의미가 있다.

340) 예를 들면 【예1】의 청구항 2에 기재된 발명과 【예2】의 청구항 2에 기재된 발명은 동일한 발명(A, B, C 및 D로 구성된 발명 X)이다. 다만 【예1】의 청구항 2는 종속항의 형식에 의하여, 【예2】의 청구항 2는 독립항의 형식에 의하여 동일한 발명을 표현하고 있을 뿐이다.

【예1】【청구항 1】 A, B 및 C를 포함하는 것을 특징으로 하는 발명 X.

【청구항 2】 제1항에 있어서, D를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 발명 X.

【예2】【청구항 1】 A, B 및 C를 포함하는 것을 특징으로 하는 발명 X.

【청구항 2】 A, B, C 및 D를 포함하는 것을 특징으로 하는 발명 X.

있는 청구항(독립항, 종속항)으로 적는 것은 불필요한 기재의 반복을 피하고 실질적으로 청구항을 구분될 수 있게 함으로써 심사나 심판 또는 특허침해문제를 다룸에 있어서 편의성을 제공하기 때문이다.³⁴¹⁾

2) 종속항의 경우에는 항상 다른 청구항을 인용하고 인용되는 항의 번호를 적는 데 반해, 독립항의 경우에는 원칙적으로 다른 청구항을 인용하지 아니한 독립형식으로 적지만, 중복기재를 피하려고 종속항과 비슷하게 다른 청구항을 인용하는 형식으로 적을 수 있다.³⁴²⁾³⁴³⁾ 청구항이 다른 청구항을 인용하고 있을 때, 독립항 또는 종속항인지에 관한 구별은 다른 청구항을 구체화하는지에 의한다. 구체적으로 청구항이 인용하고 있는 다른 청구항을 한정하거나 부가하여 구체화하고 있으면 종속항으로, 다른 청구항의 구성 일부를 생략하거나 치환하고 있다면 독립항으로 본다.³⁴⁴⁾³⁴⁵⁾

3) 한편 발명을 인용형식으로 적을 때 항의 번호를 구체적으로 적지 않고 “전술한, 상술한 항 중 어느 한 항”과 같이 표현하는 것은 시행령 제5조제4항 위반이다.³⁴⁶⁾

341) 예를 들어 청구항 간의 상호관계, 즉 넓고 좁은 관계를 알 수 있다면 심사관은 가장 넓은 청구항(독립항)에 대해서 서치(search) 및 실체심사를 하여 해당 청구항이 특허성이 있다고 인정될 때에는 나머지 좁은 청구항(종속항)들에 대해서는 실질적으로 심사를 할 필요 없이 특허성을 인정할 수 있게 되는 것이다(김원준, “청구범위의 다항제에 관한 올바른 이해를 위하여”, 한빛지적소유권센터 연구실 편, 「특허법의 제문제(上)」, 한빛지적소유권센터, 1993, 75면). 또한 출원인의 입장에서 심사관으로부터 독립항에 대해서는 특허성이 부족하여 특허를 허여할 수 없다는 통지를 받았으나, 이를 보다 구체화하였거나 한정하여 보호범위가 좁게 기재된 종속항에 대해서는 이와 같은 통지를 받지 아니한 경우 심사관이 이 종속항에 대해서는 특허성을 인정하고 있다고 해석할 수 있으며, 그 결과 출원인은 종속항에 적혀 있는 사항을 독립항에 한정함으로써 발명 전체가 특허거절결정되는 것을 방지할 수 있다. 즉 거절이유를 통지받았을 때 어느 수준까지 감축하여야 하는지를 종속항을 통해 살펴볼 수 있다(박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002, 234면).

342) 구체적인 [예]는 다음과 같다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2417-2418면).
 [예1] 청구항○의 방법으로 제조된물건
 [예2] 하여 청구항○의 물건을 제조하는..... 방법
 [예3] 청구항○의 방법으로 제조된 물건을 이용하여 하는 방법
 [예4] 청구항○의 장치로 제조된 물건

343) 아래의 [예]에서 청구항 1과 청구항 2는 독립항이며, 청구항 3은 종속항이다.

[예] 【청구항 1】 A, B 및 C로 구성된 것을 특징으로 하는 방법 X.
 【청구항 2】 제1항의 방법 X에 의하여 제조된 물건 Y.
 【청구항 3】 제1항에 있어서, D를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법 X.

344) [예]를 들어 청구항 2는 독립항으로 보고 심사를 진행한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2418면).

[예] 【청구항 1】 기어전동기구를 구비한구조의 동력전달장치
 【청구항 2】 제1항에 있어서, 기어전동기구 대신 벨트전동기구를 구비한 동력전달장치

345) 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546; 2006. 11. 24. 선고 2003후2072. 독립항과 종속항의 구별 기준을 표로 나타내면 다음과 같다.

구 분	독립항	종속항	판 단
인용형식 기재 有	○	○	구체화하면 종속항, 그렇지 아니하면 독립항
인용형식 기재 無	○	×	-

346) 아래의 [예]에서 청구항 3(종속항) 및 청구항 4(독립항)는 인용되는 항의 번호를 적지 않았기 때문에, 특허법 시행령 제5조제4항 위반이다.

4. 택일적 기재

2 이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다(승 5(5)).347)348)349)

5. 다중청구항을 다중청구항으로의 인용 不可

2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는

【예】 【청구항 1】 엔진

【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 알루미늄으로 만들어진 엔진

【청구항 3】 전술한 항 중 어느 한 항의 엔진 연료가 가솔린인 엔진

【청구항 4】 선루프, 미션 및 전술한 항 중 어느 한 항의 엔진을 갖는 자동차

347) 청구항이 2개일 때의 택일적 기재의 표현과 청구항이 3개일 때의 택일적 기재의 표현은 다음과 같다.

구 분	1	2	3	표 현
청구항이 2개인 경우	○	○	-	1 및 2
	×	○	-	1 또는 2 = 1 및 2 중 어느 하나(택일적 기재)
	○	×	-	1, 2 및 3 = 1 내지 3
청구항이 3개인 경우	○	○	○	1, 2 및 3 중 어느 둘 = 1 내지 3 중 어느 둘
	○	○	×	1, 2 및 3 중 어느 둘 = 1 내지 3 중 어느 둘
	×	○	○	1, 2 또는 3 = 1, 2 및 3 중 어느 하나 = 1 내지 3 중 어느 하나(택일적 기재)
	○	×	○	1, 2 또는 3 = 1, 2 및 3 중 어느 하나 = 1 내지 3 중 어느 하나(택일적 기재)
	×	×	×	1, 2 또는 3 = 1, 2 및 3 중 어느 하나 = 1 내지 3 중 어느 하나(택일적 기재)
	×	○	×	1, 2 또는 3 = 1, 2 및 3 중 어느 하나 = 1 내지 3 중 어느 하나(택일적 기재)
	×	×	○	1, 2 또는 3 = 1, 2 및 3 중 어느 하나 = 1 내지 3 중 어느 하나(택일적 기재)

348) 예를 들면 【예1】은 인용하는 청구항을 택일적으로 적은 청구항을 나타내고, 【예2】는 인용하는 청구항을 택일적으로 적지 아니한 청구항을 나타낸다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2421-2422면).

【예1】 ① 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, ... 장치

② 청구항 1 내지 청구항 3 중 어느 하나의 항에 있어서, ... 장치

③ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3 중 어느 한 항에 있어서, ... 장치

④ 청구항 1, 청구항 2 또는 청구항 3 에 있어서, ... 장치

⑤ 청구항 1 내지 청구항 7 및 청구항 9 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서, ... 장치

⑥ 청구항 1 내지 청구항 7 또는 청구항 9 내지 청구항 11 중 어느 한 항에 있어서, ... 장치

⑦ 청구항 1, 청구항 2 및 청구항 4 내지 청구항 7 중 어느 한 항에 있어서... 장치

【예2】 ① 청구항 1, 청구항 2에 있어서, ... 장치

② 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, ... 장치

③ 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 어느 한 항에 있어서, ... 장치

④ 청구항 1, 2에 있어서, ... 장치

349) 한편 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위하여 2이상의 항을 인용하는 경우에는 하나의 항이 선택되도록 항의 번호를 기재하지 않았다 하더라도 특허법 시행령 제5조 제5항의 위반으로 보지 아니한다. 예를 들어 아래의 【예】에서 청구항 3은 하나의 항이 선택되도록 항의 번호를 기재하지 않았지만 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위한 것으로 인정하여 특허법 시행령 제5조제5항의 위반으로 보지 않는다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2422면).

【예】 【청구항 1】 ...를 특징으로 하는 영상신호 압축기를 구비한 송신기

【청구항 2】 ...를 특징으로 하는 영상신호 신장기를 구비한 수신기

【청구항 3】 청구항 1의 송신기와 청구항 2의 수신기를 포함하는 영상신호 전송장치

방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다(令 5⑥). 그 이유는 심사관 또는 제3자가 하나의 청구항을 해석하기 위하여 너무 많은 수의 다른 청구항을 참조하여야 하는 어려움을 방지하기 위함이다.³⁵⁰⁾³⁵¹⁾

6. 기재의 순서

인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 적어야 한다(令 5⑦).³⁵²⁾ 이는 쉽게 청구항에

350) 예를 들면 【예1】의 청구항 4는 둘 이상의 항을 인용하는 종속항으로서 둘 이상의 항을 인용한 다른 청구항(청구항 3)을 인용하고 있으므로 청구범위 기재방법에 위배된다. 한편 【예2】의 청구항 5는 둘 이상의 항을 인용하는 종속항으로서, 둘 이상의 항을 인용하고 있는 제3항을 인용한 제4항을 인용하고 있어 청구범위 기재방법에 위배된다. 구체적으로 【예2】와 같은 경우 청구항 제4항은 청구항 제3항만 인용하고 있다고 하더라도 제3항이 둘 이상의 청구항을 인용하고 있어서, 실질적으로 둘 이상의 항을 인용하는 경우와 같으므로 제5항에 대하여 특허법 제42조제8항 위반으로 거절이유를 통지한다. 한편 특허법 시행령 제5조제6항은 「2 이상의 항을 인용하는 청구항」을 대상으로 하고 있어, 하나의 청구항만을 인용하는 청구항에는 적용할 수 없다(특허법원 2001. 9. 13. 선고 2001허1433). 아래의 【예2】에서 청구항 제6항은 특허법 시행령 제5조제6항을 위반하는 청구항 제5항을 인용하고 있어 실질적으로 다수의 다른 청구항을 참조하여 해석하여야 하는 어려움은 있으나 둘 이상의 항을 인용하는 청구항이 아니므로 특허법 시행령 제5조제6항의 위반으로 되지는 아니한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2423면). 이렇게 해석하더라도 어차피 청구항 제5항의 특허법 시행령 제5조제6항 위반이 해소되지 아니하면 특허출원 전체가 거절결정될 것이기 때문에 문제가 되지 아니한다.

【예1】 【청구항 1】 A 및 B를 포함하는 장치
 【청구항 2】 청구항 1 에 있어서, C를 더 포함하는 장치
 【청구항 3】 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, D를 더 포함하는 장치
 【청구항 4】 청구항 2 또는 청구항 3에 있어서, E를 더 포함하는 장치

【예2】 【청구항 1】 A 및 B를 포함하는 장치
 【청구항 2】 청구항 1에 있어서, C를 더 포함하는 장치
 【청구항 3】 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, D를 더 포함하는 장치
 【청구항 4】 청구항 3에 있어서, E를 더 포함하는 장치
 【청구항 5】 청구항 2 또는 청구항 4에 있어서, F를 더 포함하는 장치
 【청구항 6】 청구항 5에 있어서, G를 더 포함하는 장치

351) 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위하여 2이상의 항을 인용하는 청구항은, 2이상의 항을 인용하는 다른 청구항이 그 청구항을 인용하더라도, 특허법 시행령 제5조제6항의 「다시 2이상의 항을 인용하는 방식을 사용」하는 것으로 보지 않는다. 아래의 【예】에서 청구항 4는 2이상의 항을 인용하는 청구항으로서 2이상의 항을 인용하는 다른 청구항(청구항 3)을 인용하고 있지만, 청구항 3은 발명을 명확하고 간결하게 기재하기 위한 것으로 인정되므로, 청구항 4는 특허법 시행령 제5조제6항의 위반으로 취급하지 않는다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2423면).

【예】 【청구항 1】 ... 를 특징으로 하는 결합 디바이스
 【청구항 2】 ...를 특징으로 하는 방법
 【청구항 3】 청구항 2에 있어서, ... 상기 디바이스는 청구항 1의 결합 디바이스인 것을 특징으로 하는 방법

【청구항 4】 청구항 2 또는 청구항 3의 방법을 수행하는 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 매체

352) 【예】를 들어, 청구항 3은 인용되는 청구항이 인용하는 청구항보다 먼저 기재되지 않았기 때문에 청구항 2와 달리 청구범위 기재에 위배된다.

【예】 【청구항 1】 A 및 B를 포함하는 장치
 【청구항 2】 제1항에 있어서, C를 더 포함하는 장치
 【청구항 3】 제4항에 있어서, E를 더 포함하는 장치

기재된 발명을 파악하기 위한 것이다.³⁵³⁾ 한편 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다(승 5⑧). 발명의 이해에 도움이 되는 경우에는 청구항을 개조식(改造式)으로 기재할 수 있다.³⁵⁴⁾

7. 중복기재 가능 여부

기존에는 발명이 중복으로 기재되었을 때 시행령 제5조제3항의 “종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는데 필요한 수로 기재하여야 한다”에 의하여, 즉 「필요한 수」 이상으로 발명이 기재되어 다항제 기재방법 위반으로 거절이유를 통지하였다. 그러나 대법원 1995. 9. 26. 선고 94후1558 판결은 “동일한 발명사상의 내용이 청구항을 달리하여 중복 기재되어 있다고 하더라도 청구범위가 명확하고 간결하게 기재되어 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 그 내용을 명확하게 이해하고 인식하여 재현할 수 있다면 그 명세서의 기재는 적법하다”라고 하여, 시행령 제5조제3항과 상반된 판단을 하였고, 그 결과 시행령 제5조제3항이 삭제되었다. 따라서 발명이 중복으로 기재되었다고 하여 반드시 다항제 기재방법에 위반되는 것은 아니다. 다만 심사 실무³⁵⁵⁾는 현재 발명이 중복기재(문언적으로 동일한 경우를 말하며 실질적으로 동일할 뿐 표현을 달리한 경우는 제외한다)되어 있는 경우 “청구항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다”라는 특허법 시행령 제5조제2항 위반으로 처리하고 있다.

제4관 기재불비의 효과

I. 불수리

지식재산처장은 i) 명세서가 국어 또는 총리령이 정하는 언어(영어)로 기재되지 아니한 경우 또는 ii) 출원서에 명세서(명세서에 발명의 설명을 적지 아니한 경우 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우 등 출원이 시행규칙 제11조에 해당하는 경우 소명기회를 주고 소명하지 않거나 소명이 적법하지 아니하면 출원을 불수리한다(施規 11).

353) 청구범위에 기재된 청구항이 자신의 청구항과 같은 번호의 청구항을 인용하는 경우에는, 인용되는 청구항을 먼저 적지 아니한 것으로 특허법 제42조제8항 및 특허법 시행령 제5조제7항 위반의 거절이유를 통지하거나, 청구항의 기재가 명확하지 아니한 것으로 특허법 제42조제4항제2호 위반의 거절이유를 통지한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2424면).

354) 【예】를 들면 다음과 같다.

【예】 다음의 각 공정으로 이루어지는 금속재료 가공방법

(가) 금속재료를 800~850℃에서 가열하는 제1공정

(나) 가열된 재료를 단조하는 제2공정

(다) 단조된 재료를 600℃로 재가열하는 제3공정

(라) 재가열된 재료를 소입 처리하는 제4공정

355) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2420면.

II. 무 효

i) 출원서에 기재된 발명의 명칭과 발명의 설명에 기재된 발명의 명칭이 다른 경우, ii) 명세서에 기재된 발명의 명칭이나 도면의 간단한 설명이 부적합한 경우, iii) 발명의 명칭이 기재되지 아니한 경우 또는 iv) 도면을 제출하였음에도 불구하고 도면의 간단한 설명이 기재되지 아니한 경우 등 총리령으로 정하는 발명의 설명에 대한 형식적 기재 요건(法 42⑨)을 위반하여 제46조에 해당하는 경우 지식재산처장은 기간을 정하여 보정을 명하고, 출원인이 그 기간에 보정하지 아니하면 그 보정을 명한 출원 절차를 무효로 할 수 있다(法 16①본문).

III. 등록 전 · 후의 취급

1. 거절이유 등

일반적인 발명의 설명 기재방법(法 42③I), 청구범위 기재방법(法 42④) 위반이면 등록 전에는 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)이며, 등록 후에는 특허무효사유(法 133①)이다. 다만 발명의 설명 중 배경기술 기재(法 42③II),³⁵⁶⁾ 다항제 기재방법(法 42⑧) 위반이면 형식적인 요건으로서 실체파악 및 권리범위의 확정 여부와는 관계가 없는 사항이므로 거절이유(法 62)에만 해당하며, 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)에는 해당하지 아니한다.

2. 직권보정

1) 심사관은 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우이고 다른 거절이유가 없다면 직권보정하면서 특허결정할 수 있다. 이 경우 직권보정은 신규 사항이 추가되지 아니한 범위(法 47②)에서 하여야 한다(法 66의2①). 「명백히 잘못된 경우」란 사소한 오타자 이외에 명백히 잘못 기재된 기재불비가 있는 경우를 말하고, 여기서 명백히 잘못 기재된 기재불비란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세

356) 발명의 배경기술이 기재되지 않았다는 거절이유통지를 받은 경우 출원인은 발명의 설명의 【발명의 배경이 되는 기술】항목이나 그 【선행기술문헌】항목에 적절한 배경기술이 개시된 선행기술문헌의 정보를 추가하는 보정을 함으로써 대응할 수 있다. 이 경우에는 특허를 받으려는 발명의 배경기술이 그 선행기술문헌에 개시되어 있다는 점을 설명한 의견서를 함께 제출하는 것이 바람직하다. 한편 기존의 기술과 전혀 다른 신규한 발상에 의하여 개발된 발명이어서 적절한 배경기술을 알 수 없는 경우에는, 거절이유통지에 따른 의견서에 그러한 취지를 설명하여 대응할 수 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2317면). 한편 선행기술 문헌명을 명세서에 단순히 추가하는 보정과 선행기술 문헌명과 함께 그 문헌 내용의 간략한 요약만을 추가하는 보정은 신규사항 추가로 보지 않는다. 다만 미완성 발명이 완성되도록 하거나 발명의 실시 등에 관한 발명의 설명 기재요건 미비를 해소하기 위하여 선행기술문헌의 내용을 추가하는 보정, 또는 출원발명의 이점을 제시하기 위하여 출원발명과 선행기술을 비교하는 내용을 추가하는 보정은 일반적으로 신규사항 추가로 해당한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 4205-4206면).

서 등의 기재, 의견서 및 출원 시 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 경우를 말한다.

2) 한편 심사관은 다른 거절이유가 있다면 명백히 잘못된 경우 중 사소한 오타자인 것은「참고사항」으로 하여, 명백히 잘못된 기재불비에 해당하는 것은 「거절이유」에 포함하여 거절이유를 통지한다.

3) 또한 심사관은 제51조에 의한 보정각하 판단시에도 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 것인지와 관련하여, 기재불비가 명백히 잘못된 경우이어서 직권보정(法 66의2)을 할 수 있는 사항이라면, 보정을 승인하고 이후 절차를 진행할 수 있다. 명백히 잘못된 새로운 거절이유가 실수로 포함되었을 때 보정각하되고 거절결정되는 것은 출원인에게 너무 가혹하기 때문이다. 이 경우 심사관은 직권보정하면서 특허결정을 하게 된다.

3. 착오로 등록된 경우

기재불비로 기술적 범위를 특정할 수 없는데 착오로 등록된 경우와 관련하여, 판례³⁵⁷⁾는 “명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우에 있어서는 확인대상발명은 특허발명과과의 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다”라고 판시하고 특허발명의 권리범위를 부정하고 있다.

제5관 관련문제

I. 청구범위의 작성형태

1. 청구항의 구조

청구항은 일반적으로 「X와 Y를 포함하는 것을 특징으로 하는 Z」라는 형식으로 기재된다. 여기서 「X와 Y」는 특징부(body(elements), 본체부라고도 함), 「포함하는 것을 특징으로 하는」은 연결부(transition, 전환부라고도 함), 「Z」는 종결부(후단부라고도 함)에 해당한다. 특징부는 발명이 해결하려는 과제를 해결하기 위한 수단으로서 발명의 핵심적인 사항을 구성요소 간의 상호 유기적인 결합관계가 나타나도록 적는다. 연결부는 특징부와 종결부를 연결하는 표현으로서, 특징부가 종결부에서 갖는 기술적인 관계를 나타내는 것이 일반적이다. 종결부는 보호받으려는 발명의 분야를 개략적으로 설명하거나 발명의 목적 등을 포함할 수 있도록 적으며, 일반적으로 발명의 명칭과 일치한다. 종결부는 특허성 판단할 때 완전히 무시되는 것은 아니고 고려 대상이 될 수 있고,³⁵⁸⁾ 독립항과 그 종속항은 종결부가 서로 일치하여야 한다.

357) 대법원 1998. 10. 13. 선고 97후1344; 2001. 12. 27. 선고 99후1973; 2002. 6. 14. 선고 2000후235 등.

2. 연결부의 해석

(1) 문제의 제기

연결부는 통상적으로 「~을 특징으로 하는, ~을 포함하는, ~으로 이루어지는, ~로 구성되는, ~을 갖는」 등으로 표현되고 있다. 이와 같은 연결부의 표현에 따라 특허성 판단과 권리범위의 판단이 달라질 수 있는데 법 규정에서는 물론 판례에 의해서도 명확히 구체화되지 아니하여 문제가 되고 있다.

(2) 미국의 경우 해석

1) 미국의 경우 연결부는 일반적으로 개방형(open-ended) 연결부, 폐쇄형(close-end) 연결부, 반폐쇄형(semi close-ended) 연결부가 사용되고 있다. 개방형 연결부인 comprising은 「~을 포함하는」이라는 의미로서(characterized by, including도 거의 같은 의미임) 해당 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소들 이외에 다른 구성요소가 추가된 발명이라도 해당 특허발명의 권리범위에 속하는 것으로 해석되어 그 발명의 실시가 침해로 인정된다. 따라서 특징부에 열거된 구성요소만으로 제한하기를 원하지 아니한 출원인의 대부분은 통상적으로 개방형 연결부를 사용하고 있다.

2) 폐쇄형 연결부인 consisting of은 「~으로 구성된 또는 ~으로 이루어진」이라는 의미인데 원칙적으로 해당 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소들만으로 이루어진 발명만이 권리범위에 속하고 새로운 구성요소가 추가된 발명은 침해로 인정하기 어렵다.³⁵⁹⁾ 따라서 유사한 종래기술과 명확히 구별할 필요성이 있다거나 심사관으로부터 폐쇄형 연결부를 사용하도록 요구받지 아니한 이상 출원인은 자진해서 폐쇄형 연결부를 사용하지 아니한다.

3) 반폐쇄형 연결부인 consisting essentially of은 「실질적으로 ~로 구성된」이라는 의미인데 해당 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소들에 대한 구성요소가 추가된 발명은 추가된 구성요소가 해당 특허발명의 특성에 물질적 변화를 주지 아니하는 경우에만 해당 특허발명의 권리범위에 속한다.³⁶⁰⁾³⁶¹⁾

(3) 판례의 태도

1) 개방형 연결부와 관련하여 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결은 “특허발명의

358) 김종석, “청구항에서 연결부(전환부)에 대한 소고”, 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 2008, 2면.

359) 폐쇄형 연결부는 화학발명의 경우 미량의 언급되지 아니한 구성요소를 더 포함할 수도 있지만 추가적으로 포함될 수 있는 구성요소는 제한적이 될 수밖에 없으므로 그 범위가 가장 좁다고 할 수 있다.

360) 이창훈·김인순, 「미국청구범위 작성과 해석」, 한빛지적소유권센터, 2005, 83면.

361) 선행의 공지기술이 ‘A, B, C 및 D를 포함하는 조성물’이라고 할 때, 한 발명자가 성분 B를 제거한 새로운 발명을 했을 때 청구범위를, ‘A, C 및 D를 포함하는 조성물’이라고 기재하면 선행기술을 포함하고 있으므로 신규성 내지 진보성이 없고, ‘A, C 및 D로 이루어진 조성물’이라고 기재하면 특허를 받을 여지가 있으나 침해자가 단순한 부가성분 E를 첨가하여 발명을 실시한 경우 이를 배척하기 곤란한 경우가 있으며, ‘A, C 및 D로 필수적으로 이루어진 조성물’이라고 기재하면 특허를 받을 여지도 있고 단순한 부가성분 E를 첨가하여 발명을 실시한 경우 이를 배척할 수 있다(김종석, “청구항에서 연결부(전환부)에 대한 소고”, 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 2008, 6면).

청구항이 「어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)」이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이라고 볼 것이다」라고 판시하였다. 이는 「~을 포함하는」 형식의 개방형 연결부는 청구항에 기재된 구성요소 이외에 추가적인 구성요소를 갖는 발명도 권리범위에 포함되는 것으로 해석할 수 있다고 판단한 최초의 사례이다.

2) 반폐쇄형 연결부와 관련하여 대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442 판결은 “미국에서는 특허발명의 청구범위 해석시 청구항 중 전제부와 본체부 등을 연결하는 전환부 용어를 개방형인 「comprising」, 폐쇄형인 「consisting of」 및 중간단계인 「consisting essentially of」로 구분하고 있는바, 미국을 특허지정국으로 하여 PCT 국제출원을 한 다음 국내진입단계 절차를 위하여 명칭을 “암 관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산분자, 그 항원 및 이들의 용도”로 하여 국내에 그 발명의 설명, 청구범위 등에 관한 국어번역문을 제출한 사안에서, 그 청구항 중 「필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)」이라는 부분이 의미가 불명료하여 기재불비에 해당한다”라고 판시하였다.³⁶²⁾ 즉 미국에서는 「consisting essentially of(필수적으로 이루어지는)」의 용어를 사용하는 경우 권리범위 해석의 문제이나, 국내에서는 명확성 요건(法 42④Ⅱ) 위반의 기재불비로 취급하고 있다. 다만 명확성 요건에 위반되었는지는 단순히 청구범위에 사용된 용어만을 기준으로 일률적으로 판단하여서는 안 되고 청구범위로부터 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단하여야 하므로,³⁶³⁾ 다른 사안에서 반폐쇄형의 연결부를 기재할지라도 발명 파악이 명확히 된다면 명확성 요건을 충족할 수 있을 것이다.

【표 2-8】 미국과 한국에서 연결부의 취급

구 분	형 태	미 국	한 국
개방형	~을 포함하는	열거한 구성요소를 모두 포함하고 그 이외의 것을 더 포함하더라도 여전히 보호범위에 속함.	미국과 동일 (대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후 2072)
폐쇄형	~으로 이루어지는 (~로 구성된)	열거된 구성요소만 포함하는 경우에만 보호범위에 속하고 그 이외의 것을 포함하는 것은 보호범위에 속하지 아니함.	-

362) 구체적으로 판례는 원래 필수적 구성요소로만 기재하게 되어 있는 청구항에 위와 같이 「이루어지는」이라는 표현에다가 「필수적으로」라는 단어를 부가·유지함으로써, 「그 구성요소가 필수적으로 그 청구항에 기재된 염기서열로만 이루어진다.」는 의미인지, 아니면 「그 청구항에 기재된 구성요소는 필수적으로 포함되고 그 외 별도의 구성요소 추가를 허용한다.」는 의미인지부터가 불분명하다고 판시하고 있다.

363) 대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563.

반폐쇄형	~으로 필수적으로 이루어지는 (~로 필수적으로 구성된)	열거된 구성요소를 포함하는 경우에만 보호범위에 속하고 그 이외의 것을 포함하는 것은 보호범위에 속하지 아니함. 다만 주요하지 아니한 구성요소를 더 포함하는 경우에는 여전히 보호범위에 속함.	명확성 요건(法 42④II) 위반의 기재불비에 해당(대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442). 단, 용어만을 기준으로 일률적으로 판단하여서는 안 되고 청구범위로부터 발명을 명확하게 파악할 수 있는지에 따라 개별적으로 판단(대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563)
------	--------------------------------	---	--

3. 청구항의 작성형태

(1) 잼슨 청구항(jepson claim)

1) 통상의 발명은 종래의 기술을 기초로 하여 개량·진보함으로써 이루어진다. 「잼슨 청구항」이란 이러한 소위 개량발명에 있어서 종래의 기술, 즉 선행기술을 청구항의 전제부에 기재하고 그 선행기술에 대하여 그 발명이 특징으로 하는 개량부분을 특징부에 명확하게 지적하는 형식으로 기재하는 청구항³⁶⁴⁾을 의미한다. 잼슨 청구항은 구체적으로 「……에 있어서, ~를 특징으로 하는 ○○발명」의 형식을 취한다. 선행기술을 적지 않으면 그 발명의 기술내용을 명확하게 한정할 수 없는 경우에 잼슨 청구항이 이용되고 있다. 이러한 잼슨 청구항은 선행기술로부터 어떤 점이 개량되었는지를 나타냄으로써 독점권이 허여될 발명의 기술영역을 명백히 하는 데 공헌하였다.³⁶⁵⁾

2) 잼슨 청구항은 특허요건과 권리범위를 판단할 때, 전제부의 구성요소와 특징부의 구성요소 결합에 의한 전체에 의하여 발명을 특정하여야 한다. 더욱이, 단순히 잼슨 형식으로 기재되었다는 이유로, 전제부에 기재된 사항을 공지기술이라고 볼 근거는 없다.³⁶⁶⁾³⁶⁷⁾ 청구항에 기재된 구성

364) 미국의 Jepson이라는 발명자의 개량발명을 표현한 명세서에서 처음 인정된 형태이고, 미국을 비롯한 대개의 나라와 PCT 등도 이 유형의 청구범위를 많이 쓰고 있다.

365) 이종완, 「특허법론」, 대한변리사회, 2004, 354면.

366) ...까지는 전제부에 기재된 것으로서 그 기재 자체로서 공지기술을 나타내는 것으로 보아야 한다고 주장하나,에 있어서서는 전제부의 형식을 가진다고 하여 반드시 공지된 구성요소를 나열한 것으로 볼 이유는 없는 것이고, 오히려 이 사건 등록고안의 명세서 본문에 나타난 기술적 목적, 구성 및 효과를 참작하면 원고는 전제부에 기재된 구성요소들을 공지된 것으로 인정하고자 한 것이 아님을 알 수 있다(특허법원 2000. 11. 16. 선고 2000허2453; 2005. 3. 31. 선고 2004허4518 등 참조).

367) 고안의 청구범위를 전제부와 특징부로 나누어 기재하는 방식(통상적으로 잼슨 형식(jepson type)으로 부르는 방식)에 있어서 전제부의 의미는, i) 고안의 기술분야를 한정하는 경우, ii) 고안의 기술이 적용되는 대상물품을 한정하는 경우, iii) 공지의 기술로 생각하여 권리의 보호범위에서 제외하는 경우 등 여러 가지 형태가 있을 수 있다. 그중 출원인이 공지의 기술 부분을 전제부로 새로이 창안한 기술 부분을 특징부로 나누어 청구범위를 적은 경우에, 출원인이 출원과정에서 선행기술과의 관계에서 신규성 및 진보성 결여의 거절이유를 극복하기 위하여, 구성요소 중 일부를 전제부로 돌리는 방법에 의하여 전제부에 대해서는 권리의 보호범위로 주장하지 않겠다는 의사를 분명히 한 때에는, 특징부에는 해당하지 않고 전제부에만 해당하는 균등한 구성요소를 포함하는 기술의 실시에 대해서는 자신의 권리를 주장하지 않겠다는 의사로 볼 수 있을 것이다. 그러나 위와 같은 법리는 출원 또는 등록된 고안에 대한 권리의 보호범위에 관한 문제일 뿐이고, 출원된 고안이 선행기술과 비교하여 신규성 또는 진보성이 있는지를 판단하는 경우 어떠한 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지 여부는 사실관계의 문제로서 고안의 청구범위의 기재형식에 따라 역사적 사실관계가 확정되는 것은 아니며, 권리의 보호범위로부터 제외한다는 의사가 있다고 하여 반드시 이를 공지의 기술로 인정한다는 취지로 볼 수도 없다. 더욱이 공지된

요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실관계의 문제로서 청구범위의 기재 형식(위치)에 따라 역사적 사실관계가 확정되는 것은 아니기 때문이다.

3) 다만 특허요건을 판단할 때 명세서의 전체적인 기재와 출원 경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우(공지 자인)에는 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정할 수 있다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 반복될 수 있다.³⁶⁸⁾

4) 한편 등록 후 권리범위를 판단할 때 출원 경과 중에 특징부의 일부 구성요소가 공지기술이기 때문에 전제부에 옳기는 보정을 하면서 전제부에 대해서는 권리범위를 주장하지 않겠다는 의사를 분명히 한 후 등록된 경우, 특징부에는 해당하지 않고 전제부에만 해당하는 균등한 구성요소를 포함하는 기술의 실시에 대해서는 자신의 권리를 주장하지 않겠다는 의사로 볼 수 있을 것이다. 이처럼 출원 경과 중에 밝힌 출원인의 의견 표명에 대하여 일정한 요건 아래 의식적

구성요소가 포함되어 있다 하더라도, 고안의 신규성 또는 진보성을 판단함에 있어서는, 공지된 구성요소를 포함한 유기적 일체로서의 고안 전체의 기술사상이 비교 대상이 되는 선행기술과의 관계에서 신규성 내지 진보성이 인정될 수 있는지를 파악하여야 하는 것이어서, 그중 공지된 구성요소를 제외한 나머지 구성요소만으로 선행기술과 대비할 수는 없는 것이다(특허법원 2007. 10. 5. 선고 2007허2469).

368) 특허발명의 신규성 또는 진보성 판단과 관련하여 해당 특허발명의 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지는 사실인정의 문제이고, 그 공지사실에 관한 증명책임은 신규성 또는 진보성이 부정된다고 주장하는 당사자에게 있다. 따라서 권리자가 자백하거나 법원에 현저한 사실로서 증명을 필요로 하지 않는 경우가 아니라면, 그 공지사실은 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이다. 그리고 청구범위의 전제부 기재는 청구항의 문맥을 매끄럽게 하는 의미에서 발명을 요약하거나 기술분야를 기재하거나 발명이 적용되는 대상물품을 한정하는 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거는 되지 못한다. 또한 전제부 기재 구성요소가 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재될 수도 있는데, 출원인이 명세서에 기재하는 배경기술 또는 종래기술은 출원발명의 기술적 의의를 이해하는 데 도움이 되고 선행기술 조사 및 심사에 유용한 기존의 기술이기는 하나 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니다. 따라서 명세서에 배경기술 또는 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수도 없다. 다만 특허심사는 지식재산처 심사관에 의한 거절이유통지와 출원인의 대응에 의하여 서로 의견을 교환하는 과정을 통해 이루어지는 절차인 점에 비추어 보면, 출원과정에서 명세서나 보정서 또는 의견서 등에 의하여 출원된 발명의 일부 구성요소가 출원 전에 공지된 것이라는 취지가 드러나는 경우에는 이를 토대로 하여 이후의 심사절차가 진행될 수 있도록 할 필요가 있다. 그렇다면 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정할 수 있다. 그러나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 반복될 수 있다. 그리고 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 이와 달리 출원인이 청구범위의 전제부에 기재한 구성요소나 명세서에 종래기술로 기재한 사항은 출원 전에 공지된 것으로 본다는 취지로 판시한 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37).

제외로 인정하고 그 영역에 속하는 부분은 해당 특허발명의 침해 여부 판단 시 권리범위에서 배제된 것으로 보는 것을 출원경과참작의 원칙 또는 포대금반언의 원칙이라고 한다.³⁶⁹⁾ 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 특허요건을 판단할 때는 출원경과참작의 원칙이 적용되지 아니하고 출원경과 중의 공지 자인에 대해서는 추정의 복명을 허용하고 있다.³⁷⁰⁾

(2) product - by - process(PBP) 청구항

1) 「product - by - process 청구항」이란 어떤 물건이나 물질이 구조적 특성(structure)보다는 제조되는 방법에 의하여 한정되는 청구항으로서, 일반적으로 「X 단계와 Y 단계를 거쳐 제조되는 화합물 Z」와 같은 형태로 기재된다. 이러한 타입의 청구항은 화학관계의 발명에 있어서

369) 이 사건 등록고안의 출원인은 출원 시에는 등록청구범위 제1항을 「등반이시트의 첫힘동작으로 보조시트가 펼쳐져 침대로 변형되는 안락의자에 있어서, 바퀴를 구비한 한 쌍의 메인 후레임 뒤쪽에 회동가능하게 등반이 후레임을 설치하되, 위 등반이 후레임 하단에 상, 하 두개의 힌지부를 구성한 한 쌍의 힌지브라켓트를 착설하여 위 힌지브라켓트의 상부 힌지부에는 선단에 보조시트 후레임이 절첩가능하게 결합된 좌판 후레임을 결합하여 안내부의 안내로 별도의 지지 후레임없이 등반이시트와 보조시트가 연동되도록 구성함을 특징으로 안락의자」로 하고, 등록청구범위 제2항을 「제1항에 있어서, 위 등반이 후레임과 보조 후레임을 연결하는 연결레버를 “”형으로 일정 각도 정곡되어서 메인 후레임 앞측에 설치된 횡봉에 착설되어 한 쌍의 롤러로 된 안내부에 의하여 지지안내되도록 구성함을 특징으로 하는 안락의자」로 기재하였다가, 지식재산청 심사관으로부터 실용신안공고 제95-4971호 고안 등에 의하여 통상의 기술자가 극히 쉽게 고안할 수 있다는 이유로 거절이유통지를 받고, 1998. 7. 22. 의견서 및 보정서를 제출하면서 인용대상에 저촉되는 부분을 공지의 기술로 하여 청구범위를 대폭 축소 한정한다고 주장함과 아울러 청구항 제1항과 제2항을 결합하여 하나의 항으로 만들되 청구항 제1항에 있던 부분을 전제부로 기재하고 청구항 제2항에 있던 부분을 특징부에 기재하였는바, 그렇다면 출원인 스스로 전제부의 기재사항인 「등반이와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 안내부가 안내하도록 하는 구성」을 공지의 기술로 한정한 것이라 하겠고, 나아가 다시 특징부에서 위 안내부를 「한 쌍의 롤러」로 한정한 것은 출원인이 이와 균등관계에 있는 구성에 대해서는 그 권리범위를 주장하지 않겠다는 취지로 볼 것이므로, 결국 출원경과금반언의 원칙상 등반이와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 안내부가 안내하도록 함에 있어서, 그 안내부를 {확인대상 고안과 같은} 슬라이드관으로 구성하는 것은 이 사건 등록고안의 출원인이 의식적으로 그 보호범위로부터 제외한 것으로 봄이 상당하여, 확인대상 고안의 슬라이드관은 이 사건 등록고안 제1항의 롤러의 균등론이 될 수 없다(대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712).

370) 출원 경과 참작의 원칙을 공지성 인정 여부 판단에까지 확장하여 적용하면, 출원인이 출원경과 중 의식적으로 해당 기술이 공지된 것이라는 취지를 밝힌 이상은 객관적 진실에 부합하는지와는 무관하게 공지기술로 확정적으로 인정하여야 한다. 이러한 결과는 사실인정 문제에 관하여 행정기관에 의한 특허심사절차에 「민사소송에서의 자백」보다도 훨씬 더 강한 구속력을 부과하는 것이어서 매우 부당하다. 자신의 권리범위에서 해당 기술을 의식적으로 제외하겠다는 의사표시는 객관적인 권리범위 판단과 부합하는 것이 아니더라도 해당 부분에 대한 권리포기라는 별도의 법률효과에 의한 결과로 충분히 받아들일 수 있으나, 공지 여부라는 사실인정의 문제를 심사절차에서의 출원인의 의사표시에 의하여 확정적으로 좌우되도록 하는 것은 권리포기 의사표시와는 차원이 다른 문제이다. 즉 객관적 사실과 부합하여야 할 공지 여부 판단은 일정 범위에 대해서는 특허권 권리행사를 포기하는 의사를 표명하였음을 근거로 하는 의식적 제외 범리를 적용하기에 성질상 적절하지 않다. 또한 권리범위로부터 제외한다는 의사가 반드시 해당 부분을 확정적으로 공지기술로 인정하겠다는 취지라고 볼 수도 없다. 의식적 제외를 표명하는 출원인의 의사는 대체로 해당 부분을 권리범위에서 일단 배제시킴으로써 그 부분을 제외한 권리범위를 가지는 특허권을 우선적으로 취득하려는 데 있는 것이지(심사관이 문제 삼지 않는 부분에 대하여 빠른 시일 내에 특허권을 취득하는 이익을 추구하는 것 그 부분이 공지기술이라고 확정적으로 인정하겠다는 의사라고까지 볼 근거는 없기 때문이다(박태일, “출원경과 중 출원인이 공지기술이라는 취지로 전제부에 기재한 구성요소의 평가”, 사법 40호, 사법발전재단, 2017 여름호, 377-378면).

물건(product)과 제법(process)이 모두 신규한 경우에 사용되는 형식이다. 즉 물건(product)이 신규하여 특허받을 수 있으나 그 물건(product)의 구조적 특성을 규명하지 못하여 그것을 제조하는 제법(process)을 특정하지 않으면 그 물건도 한정할 수 없는 경우에 활용 가능한 형식이다.

2) product-by-process 청구항은 제법(process)을 고려하여 물건(product) 발명의 특허요건과 권리범위를 판단하여야 하는지 문제이다. 특허요건 판단과 관련하여 기존의 판례³⁷¹⁾는 제조방법이 기재된 물건발명을 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 있는지 여부로 나누어, i) 특별한 사정이 있는 경우에는 제조방법을 고려한 물건발명에 의하여 특허요건을 판단하고, ii) 특별한 사정이 없는 경우에만 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없이 물건발명에 의하여 특허요건을 판단한다는 입장이었다. 그러나 최근의 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결에서는 “물건의 발명에 관한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로, 물건의 발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이다. 따라서 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다”라고 판시하여 종래의 판례들을 변경하면서 특허요건을 판단할 때, 특별한 사정과 상관없이 물건(제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건)으로 출원발명을 파악해야 함을 명확히 하고 있다.³⁷²⁾ 즉 제조방법이 신규성, 진보성이 있다고 하여 제조방법에 의하여 제조된 물건이 반드시 신규성, 진보성이 있는 것은 아니고, 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 출원발명을 특정한 후 신규성, 진보성이 있는지 개별적으로 판단하여야 한다.³⁷³⁾

371) 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416; 2007. 5. 11. 선고 2007후449; 2007. 9. 20. 선고 2006후1100; 2008. 8. 21. 선고 2006후3472; 2009. 1. 15. 선고 2007후1053; 2009. 3. 26. 선고 2006후3250; 2009. 9. 24. 선고 2007후4328 등.

372) 이에 덧붙여 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 판결은 “한편 생명공학 분야나 고분자, 혼합물, 금속 등의 화학 분야 등에서의 물건의 발명 중에는 어떠한 제조방법에 의하여 얻어진 물건을 구조나 성질 등으로 직접적으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란하여 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 사정이 있을 수 있지만, 이러한 사정에 의하여 제조방법이 기재된 물건발명이라고 하더라도 그 본질이 ‘물건의 발명’이라는 점과 청구범위에 기재된 제조방법이 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 수단에 불과하다는 점은 마찬가지이므로, 이러한 발명과 그와 같은 사정은 없지만 제조방법이 기재된 물건발명을 구분하여 그 기재된 제조방법의 의미를 달리 해석할 것은 아니다”라고 하였다.

373) 제조방법이 제조 효율 또는 수율에만 영향을 미치는 경우 등과 같이 물건의 구조나 성질에 영향을 미치지 않는다면 제조방법을 제외하고 물건 자체로 출원발명을 파악해야 한다. 제조방법에 의한 물건을 특정함에 있어서 그 제조방법에 의해서 물건의 구조나 성질 등에 영향을 미쳤는지 여부를 결정하는 것이 어렵고, 해당 제조방법을 고려하지 않은 물건 자체와 동일한 인용대상으로 신규성, 진보성이 부정되는 합리적인 의심이 있다면 신규성, 진보성이 부정된다는 취지의 거절이유를 통지할 수 있다. 심사관은 의견서 등을 참작하여 심사를 진행한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 32 18, 3322면).

3) 한편 등록 후 특허침해소송이나 권리범위확인심판 등 특허침해단계에서 권리범위를 판단할 때도 특허요건을 판단할 때와 마찬가지로 물건(제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건)으로 특허발명을 파악한다. 다만 특허요건을 판단할 때와는 달리 이러한 해석방법에 의하여 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다.³⁷⁴⁾

(3) 마쿠쉬 請求項(markush claim)

1) 「마쿠쉬 청구항」이란 「A, B, C 또는 D」 혹은 「A, B, C 및 D로 구성된 군에서 선택한……」의 형태로 표현되는 청구항을 말한다. 일반적으로 발명의 보호범위를 모호하게 만드는 선택적 청구항은 인정되지 아니하지만, 발명이 둘 이상의 병렬적 개념이고 이들을 총괄하는 발명의 개념이 없을 때 마쿠쉬 청구항이 이용되고 있다. 즉 마쿠쉬 청구항은 발명의 각각의 구성요소에 대하여 개별적으로 청구항을 작성해야 하는 불합리를 방지하기 위해 인정된 것으로서 화학관련 발명에서 주로 사용된다.

2) 이러한 마쿠쉬 청구항은 극히 제한된 범위에서 운영되고 있다. 선택요소들이 「유사한 성질 또는 기능」을 갖는 경우에 한 해 하나의 청구항에 기재할 수 있다. 예를 들어 선택 형식에 의한 기재가 화학물질에 관한 것일 경우 i) 선택적으로 기재한 치환요소를 갖는 전체 화학물질이 공통되는 성질 또는 활성(活性)을 가질 것, ii) 선택적으로 기재한 치환요소를 갖는 전체 화학물질이 중요한 화학구조요소를 공유하고 있거나, 선택적으로 기재한 치환요소를 갖는 전체 화학물질이 그 발명이 속하는 기술분야에서 하나의 그룹으로 인식되는 화학물질군에 속할 것을 모두 만족하면 마쿠쉬 청구항으로 인정된다.³⁷⁵⁾

3) 청구항에 기재된 발명이 마쿠쉬(markush) 형식 등으로 기재되었을 때 그 선택요소 중 어느 하나를 선택하여 인용대상과 대비한 결과 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항 전체에 대하여 진보성이 없는 것으로 인정한다.³⁷⁶⁾

(4) 기능적 표현으로 기재된 청구항

1) 「기능적 표현으로 기재된 청구항」이란 발명 구성요소의 일부 또는 전부가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 기능적 표현으로 기재된 청구항을 말한다. 발명의 구성요소로 통상적인 구조, 방법, 물질 등을 명확하게 구체화하는 것은 불필요하거나 그에 대한 적합한 발명 명칭이 존재하지 않은 경우에 청구항의 구성요소를 기능적 표현으로 기재하게 된다.³⁷⁷⁾ 특허법은 제42조제6항에서 “청구범위에는 보호받으려는 사항을 명확히 할 수 있도록

374) 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726.

375) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2412-2413면.

376) 대법원 1998. 9. 18. 선고 96후2395 판결 등 참조.

377) BM발명이나 컴퓨터관련 발명 등 기술분야에 따라 발명의 특성상 청구항을 구체적인 구조의 기재만으로

발명을 특정하는 데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 적어야 한다”라고 하여 청구항에 자유롭게 발명의 구성요소를 기재할 수 있도록 함으로써 기능적 표현으로 청구항을 기재하는 것을 허용하고 있다.

2) 기능적 표현으로 청구항을 기재하는 경우 특허요건과 권리범위 판단 국면에서 발명의 특성을 달리하고 있다. 구체적으로 특허요건을 판단할 때 기능적 표현으로 기재된 청구항은 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석되고 발명의 설명에 기재된 실시예로 제한해석되지 않는다.³⁷⁸⁾ 따라서 포괄적인 기능적 표현의 하위개념에 해당하는 부분의 공지기술이 존재하면 그 구성요소는 공지기술과 동일하게 된다. 예를 들어 청구항이 필기하는 기능을 가지는 수단에 소거하는 기능을 가진 수단이 결합된 필기구일 때, 연필(필기하는 수단의 하위개념)에 결합된 지우개(소거하는 수단의 하위개념)가 공지기술이라면 청구항은 공지기술과 동일하여 신규성 위반이 된다. 또한 기능적 표현으로 기재된 청구항은 통상의 기술자가 발명의 설명에서 개시된 실시예에 근거하여 전체로서의 그 청구항에 기재된 발명을 쉽게 유추할 수 있는 경우에만 적절한 것으로 간주될 수 있으며 그렇지 아니한 경우 제42조제4항 제1호 위반이 되고, 발명을 불명료하게 표현하고 있는 경우에는 제42조제4항제2호 위반이다. 다만 발명의 기능을 적은 이른바 기능적 표현이라도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 설명을 참작한 결과 발명이 전체로서 명확하게 파악될 수 있다고 보이는 경우에는 허용될 수 있다.³⁷⁹⁾

3) 권리범위를 판단할 때 기능적 표현으로 기재된 청구항은 그 자체만으로 특허발명의 기술적 구성의 내용을 알 수 없는 경우에 해당하므로, 발명의 설명에 의하여 제한 해석되어야 한다.³⁸⁰⁾

표현하기 어려운 경우가 있다. 기존에는 기능에 초점을 맞춰 이를 기능식 청구항이라고 하였으나, 기능 이외에 효과, 성질 등의 특성을 포함할 수도 있으므로 조금 더 넓은 의미로 기능적 표현이 기재된 청구항이라고 부르게 한다.

378) 특허출원된 발명이 특허법 제29조제1항, 제2항에서 정한 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은 조 제1항 각호에서 정한 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야 하는바, 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받으려는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다. 따라서 특허출원된 발명의 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하여야 한다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977; 2007. 6. 14. 선고 2007후807; 2006. 10. 13. 선고 2004후776; 2010. 1. 28. 선고 2008후26 등). 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하려는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977).

379) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486; 1998. 10. 13. 선고 97후1344; 1985. 5. 28. 선고 84후43; 1987. 9. 29. 선고 84후54; 1998. 10. 2. 선고 97후1337 등

380) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의

발명의 설명 또는 도면에 개시되지 아니한 기술사상까지 기술적 범위를 확대하는 것은 출원인이 공중에 공개하지 아니한 부분까지 독점권을 부여하는 것으로서 특허법의 목적에 반하기 때문이다. 구체적으로 기능적 표현으로 기재된 청구항은 발명의 설명과 도면에 기재되어 뒷받침되는 범위내(기능적 표현으로 기재된 구성요소에 상응하는 실시예)에서 그 기술적 의미를 파악하여 특허발명을 특정하고, 확인대상발명과 대비하여 구성요소완비의 원칙과 균등론을 적용하여야 한다. 예를 들어 청구항이 필기하는 기능을 가지는 수단에 소거하는 기능을 가진 수단이 결합된 필기구이고, 발명의 설명에 그 실시예로 필기하는 기능을 가지는 수단으로서 볼펜, 소거하는 기능을 가진 수단으로서 볼펜 리무버(수정액)를 기재하고 있는 경우에 특허발명을 볼펜에 볼펜 리무버가 결합된 필기구로 특정한다. 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.³⁸¹⁾

【표 2-9】 제스 청구항, PBP 청구항 및 기능적 표현 청구항의 비교 분석

구 분	제스 청구항	PBP 청구항	기능적 표현 청구항
형태	……에 있어서, ~를 특징으로 하는 ○○ 발명	X 단계 후 Y 단계를 거치는 방법에 의해 제조되는 화합물 Z	구성요소의 일부 또는 전부가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 기능적 표현으로 기재된 청구항
필요성	소위 개량발명에 있어서 선행기술을 청구항의 전제부에 기재하고 그 선행기술에 대하여 그 발명이 특징으로 하는 개량부분을 특징부에 명확하게 지적하여 독점권이 허여될 발명의 기술영역을 명백히 하는데 공헌함	물건(product)의 구조적 특성을 규명하지 못하여 그것을 제조하는 제법(process)을 특정하지 않으면 그 물건도 한정할 수 없는 경우에 이용됨	발명의 구성요소로 통상적인 구조, 방법, 물질 등을 명확하게 구체화하는 것이 불필요하거나 그에 대한 적합한 발명 명칭이 존재하지 않은 경우에 이용됨
특허요건 판단	전제부의 구성요소와 특징부의 구성요소 결합에 의한 전체에 의하여 출원발명을 특정함(다만 명세서의 전체적인 기재와 출원 경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우(공지 자인)에는 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정함)	물건(제조방법의 기재가 물건의 구조나 성질에 영향을 준 경우 그 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건)으로 출원발명을 특정함 → 제조방법에 특허성이 있는지 여부와는 무관	기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명으로 출원발명을 특정함
침해 여부	특허요건 판단과 마찬가지로 전제부의 구성요소와 특징부의 구성요소 결합에 의한	특허요건 판단과 마찬가지로 물건(제조방법의 기재가 물	청구항 그 자체만으로 특허발명의 기술적 구성의 내용을 알

기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340).

381) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57.

판단	전체에 의하여 특허발명을 특정함. 다만 출원인이 출원과정에서 선행기술과의 관계에서 신규성 및 진보성 결여의 거절이유를 극복하기 위하여, 구성요소 중 일부를 전제부로 돌리면서 전제부에 대해서는 권리의 보호범위로 주장하지 않겠다는 의사를 분명히 한 때에는, 등록 후에 특징부에는 해당하지 않고 전제부에만 해당하는 균등한 구성요소를 포함하는 기술의 실시에 대해서는 자신의 권리를 주장하지 않겠다는 의사로 파악함	건의 구조나 성질에 영향을 준 경우 그 제조방법에 의하여 특정되는 구조나 성질을 가지는 물건)으로 특허발명을 특정함. 다만 권리범위가 명세서의 전체적인 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정해석함	수 없으므로 기능적 표현에 상응되는 발명의 설명과 도면에 기재된 실시예로 제한하여 특허발명을 특정함
----	--	--	---

II. 그 밖의 명세서의 기재불비

심사 실무³⁸²⁾상 다음과 같은 경우에는 명세서의 기재불비로 인정하고 있다.

① 외국어특허출원의 명세서를 제외하고 명세서에 기재된 용어가 국어로 기재되어 있지 아니한 경우

제42조의3제1항에 따른 외국어출원의 명세서를 제외하고 명세서에 기재된 용어가 국어로 기재되어 있지 않아서 그 기재사항이 불명확한 경우에는 소명기회를 부여한 후 반려한다. 다만 명세서 일부가 외국어로 기재되어 있고 이를 제외하고도 출원 내용을 이해하기에 어려움이 없는 경우에는 반려하지 않고 제46조 위반으로 보정을 요구한다.

② 외국의 선출원을 기초로 한 우리나라 출원이 번역이 잘못되어 기술내용이 불명료한 경우

외국어 출원을 국어로 출원하는 경우(파리조약에 의한 우선권주장 출원 등) 번역이 불비하여 제1국 출원의 내용과 다르거나 명세서의 기재내용이 불명확한 경우 번역이 잘못되었다는 이유로 거절이유를 통지하여서는 아니 된다. 이 경우 심사관은 우리나라에 출원된 출원서의 명세서만으로 기재불비 여부를 판단하여 기재불비가 있는 경우 제42조제3항제1호 또는 제4항을 적용하여 거절이유를 통지한다.

③ 명세서 전체를 통하여 용어가 통일되어 있지 아니한 경우

명세서 내의 용어가 통일되지 아니한 경우에는 제42조제3항제1호 위반이고, 발명의 설명과 청구범위에 기재된 기술용어가 다르거나 청구범위에 기재된 기술용어가 서로 다른 경우 제42조제4항 위반이다. 즉 명세서에 기재되는 용어는 철저히 일물일어주의(一物一語主義)가 적용되어야 한다.

④ 관용적으로 사용되고 있지 아니한 기술용어 등을 사용한 경우

특허의 명세서에 기재되는 용어는 그것이 가지고 있는 보통의 의미로 사용하고 동시에 명세서 전체를 통하여 통일되게 사용하여야 하나, 다만 어떠한 용어를 특정한 의미로 사용하려고 하는

382) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2317-2318면 참조.

경우에는 그 의미를 정의하여 사용하는 것이 허용되므로,³⁸³⁾ 용어의 의미가 발명의 설명에서 정의된 경우에는 그에 따라 해석하면 된다.³⁸⁴⁾ 다만 관용적으로 사용되고 있지 아니한 기술용어 또는 학술용어에 대하여 발명의 설명에서 정의하지 않고 사용하고 있어서 그 의미가 불명확한 경우 제42조제3항제1호 위반이다.

⑤ 명세서에 상표명을 적은 경우 취급

명세서에 상표명을 적는 것은 원칙적으로 허용하지 않으나 상표명을 기재하더라도 그 상표명의 물건을 쉽게 입수할 수 있고, 그 상표명의 품질이나 조성 등의 변화로 인해 발명의 내용이 변경될 가능성이 작으며, 그 상표명의 물건을 명확히 확정할 수 있는 경우에는 예외적으로 상표명을 적을 수 있다.

제3절 하나의 특허출원의 범위

제45조 【하나의 특허출원의 범위】

- ① 특허출원은 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.
- ② 제1항 단서에 따라 일 군의 발명에 대하여 하나의 특허출원으로 할 수 있는 요건은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「하나의 특허출원의 범위」란 하나의 특허출원으로 할 수 있는 발명의 범위를 말하는 것으로서, 하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 하는 것을 원칙으로 하나, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군의 발명에 대하여도 하나의 특허출원으로 할 수 있다.

2. 취 지

관련이 없는 복수의 발명을 청구범위에 기재하는 것을 허용한다면 심사시에는 심사관의 담당 기술분야에 관한 결정(출원의 분류)이 어려워져 심사의 적정성을 기대할 수 없고 등록 이후에는 특허권의 권리범위를 확정하기 곤란하다. 따라서 원칙적으로 이러한 행정절차의 간편 및 특허제도의 용이한 운영을 위해서 1발명 1출원주의를 채택하고 있다. 그러나 1발명 1출원주의만을 고수하게 되면 발명이 둘 이상이면 무조건 각각 출원하여야 하는데 밀접한 관련이 있는 발명이 둘 이상일 때 각각 출원하는 것은 출원인에게 비용적인 측면에서 부담이 되고, 심사관의 입장

383) 발명이 용어(단어)를 위해 만들어지는 것은 아니고, 용어가 그 발명을 위해 만들어져야 하는 것이기 때문에, 명세서에서 발명을 표현함에 있어서 용어의 정의가 허용될 수밖에 없다.

384) 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486; 2010. 12. 23. 선고 2009후436 등.

에서도 각각 심사하여야 하므로 심사업무의 부담 및 지연 등의 불편함이 생길 수 있다. 이러한 이유로 특허법은 1발명을 1특허출원으로 할 수 있음은 물론이고, 둘 이상의 발명이라 하더라도 단일성을 만족하는 일 군의 발명에 대해서는 1특허출원으로 할 수 있도록 하여 심사촉진에 기여하고, 관련기술을 하나의 출원에서 함께 공개하도록 함으로써 기술공개의 목적에도 부합하도록 하며, 출원인의 입장에서도 비용부담을 줄이고 특허관리를 쉽게 할 수 있도록 하고 있다.³⁸⁵⁾

II. 내 용

1. 원칙: 하나의 발명마다 하나의 특허출원

하나의 발명마다 하나의 특허출원으로 하는 것을 원칙으로 한다(法 45①본문). 「하나의 발명」이란 카테고리와는 관계없이 하나의 청구항을 의미한다. 다만 하나의 청구항이라도 마쿠쉬 타입(markush type)으로 기재된 청구항 또는 둘 이상의 항을 인용하는 청구항은 둘 이상의 발명을 포함할 수 있다.

2. 예외: 일 군의 발명에 대하여도 하나의 특허출원 가능

하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군(群)의 발명에 대하여도 하나의 특허출원으로 할 수 있다(法 45①단서). 「일 군의 발명」이란 카테고리의 동일성 여부를 불문하고 복수의 발명으로서 하나의 청구범위에 표현될 수 있는 기술적 상호관련성이 있는 발명을 말한다. 실무적으로는 일 군의 발명에 해당하면 「발명의 단일성(unity of invention)」을 만족한다고 표현한다.

III. 판 단

1. 판단대상: 독립항만을 기준으로 판단

단일성을 만족하는지는 독립항을 우선 고려하여 판단한다. 독립항이 단일성을 만족할 때는 이들 독립항에 종속된 종속항도 단일성을 만족한다.³⁸⁶⁾

385) 원래 특허법은 1발명 1출원주의(一發明一出願主義)를 채택하고 있으나 기술적으로 관련된 몇 가지 발명을 각 독립항으로 하여 한꺼번에 출원할 수 있도록 하는 것이 바람직한 면도 있기 때문에, 서로 기술적으로 밀접한 관계를 가지는 발명들에 대하여 그들을 하나의 출원으로 출원할 수 있도록 함으로써 출원인, 제3자 및 지식재산처의 편의를 도모하려는 것이 제45조 규정의 취지이다. 그러므로 위 규정을 해석하는 경우는 출원료나 특허관리면에서의 유리함 때문에 서로 관련성이 없는 복수의 발명을 하나의 출원서에 다수 포함하려는 출원인과 이것을 허용할 경우 타인의 권리에 대한 감지나 선행기술 자료로서의 이용 또는 심사에 대한 부담 때문에 불이익을 받게 되는 제3자 및 지식재산처와의 사이에 균형을 도모함이 필요하다. 이러한 관점에서 보면 "하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 일 군의 발명"에 해당하는가 여부는 각 청구항에 기재된 발명들 사이에 하나 또는 둘 이상의 동일하거나 또는 대응하는 특별한 기술적인 특징들이 관련된 기술관계가 존재하는가(즉 기술적으로 밀접한 관계가 존재하는가)에 달려있고, 특별한 기술적인 특징이란 각 발명에서 전체적으로 보아 선행기술과 구별되는 개량부분을 말한다 할 것이다(특허법원 1998. 7. 16. 선고 98허5145).

2. 판단방법: 시행령 제6조에 의한 판단

1) 일 군의 발명에 해당하여 단일성을 만족하는지와 관련하여, 특허법 시행령 제6조는 「법 제45조제1항 단서에 따른 일 군의 발명에 대하여 하나의 특허출원을 하기 위해서는 i) 청구된 발명 간에 기술적 상호관련성이 있을 것, ii) 청구된 발명들이 동일하거나 상응하는 기술적 특징을 가지고 있을 것(단, 이 경우 기술적 특징은 발명 전체로 보아 선행기술과 비교하여 개선된 것이어야 한다.)」고 규정되어 있다. 따라서 기술적 특징은 선행기술에 비해 개선된 부분을 의미하므로 발명의 단일성을 충족하는지의 판단은 때에 따라 선행기술을 검색하기 전에도 가능하지만, 선행기술을 고려한 후에 판단하는 것이 일반적이다.

2) 여기서 「개선」은 동일성 범주를 벗어나 신규성을 구비한 것으로 이해가 되며, 청구항에 기재된 발명이 진보성이 없는 경우에는 하나의 특허출원의 범위 위반으로 분할출원을 시사(示唆)하지 않고, 단지 진보성 위반으로 거절이유를 통지하는 것이 바람직할 것이다. 진보성을 기준으로 하면 많은 출원이 하나의 특허출원의 범위를 만족하지 아니하여 혼란이 있을 수 있기 때문이다. 다만 심사 실무³⁸⁷⁾는 「개선」의 의미를 신규성, 진보성을 구비한 것으로 파악하고 있다.

3) 각각의 독립항이 공통적인 「기술적 특징」을 공유(동일 또는 상응)하고 있으면 단일성을 만족하며, 그 대표적인 예로 i) 컴비네이션과 서브 컴비네이션³⁸⁸⁾의 관계에 있는 청구항, ii) 서브 컴비네이션과 서브 컴비네이션의 관계에 있는 청구항 또는 iii) 중간체와 최종생성물의 관계에 있는 청구항을 들 수 있다.

IV. 함결의 효과

1) 제45조의 하나의 특허출원의 범위 위반은 발명의 실체에 하자가 있는 것이 아니라 단지 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 절차상의 하자에 불과하므로 거절이유(法 62)에만 해당되고, 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133①)에는 해당되지 아니한다. 한편 심사관은 제45조에 따른 거절이유통지시에는 출원인이 거절이유에 대하여 보다 쉽게 대응할 수 있고 신속 정확한 심사에 도움이 된다고 인정될 때는 출원의 분할에 관한 시사(示唆)를 할 수 있다.³⁸⁹⁾

386) 다음과 같은 예에서 모든 청구항에 동일한 「기술적 특징」인 a 및 b가 존재하므로 청구항 1과 청구항1의 종속항인 청구항 2, 3은 단일성을 만족한다.

【예】 【청구항 1】 특징 a 및 b를 갖는 표시장치

【청구항 2】 제1항에 있어서, 특징 c를 부가한 표시장치

【청구항 3】 제1항에 있어서, 특징 d를 부가한 표시장치

387) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2502면.

388) 컴비네이션 청구항(combination claim)이란 청구항에서 복수개의 요소가 상호 공동으로 작용하는 것으로서, 구성요소가 상호 조합된 형태로 표현된 청구항을 말한다. 서브 컴비네이션 청구항(sub-combination claim)이란, 청구항의 구성요소가 서로 공동으로 작용하지 아니한 청구항을 말한다. 예를 들어 특정 구조의 볼트와 너트의 결합에 의한 체결장치는 컴비네이션에 해당하며, 특정 구조의 볼트와 너트 각각은 서브 컴비네이션에 해당한다.

389) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2515면.

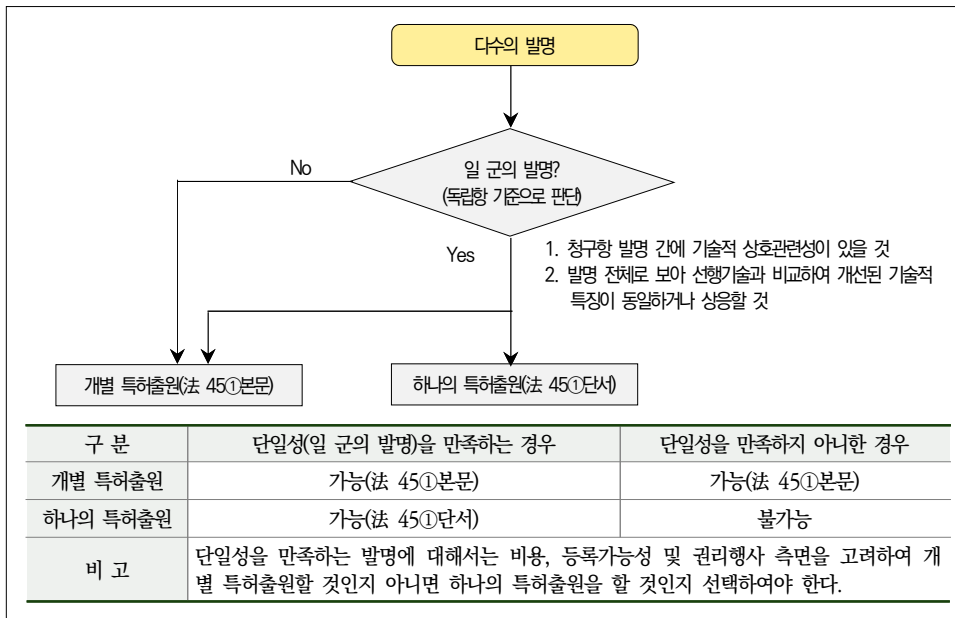
2) 한편 제45조에 따른 단일성에 대한 심사는 필요 이상으로 엄격하게 하지 아니한다. 이는 단일성을 만족하지 아니한 출원이 그대로 특허받아도 제3자의 이익을 직접적으로 해하는 것은 아니기 때문이다.

V. 관련문제

1. 개별 특허출원과 1특허출원의 비교

1) 개개의 발명을 하나의 특허출원으로 할 때는 개별 특허출원에 비해 출원 및 등록절차가 지의 제반비용이 절약되고 관련기술을 하나의 특허권으로 획득하여 출원인의 편익을 도모할 수 있으나, 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 한 전체가 거절되기 때문에 개별 특허출원 보다 등록받기가 어렵고, 등록 후에도 청구항별 특허권의 이전이 허용되지 아니하여 특허권의 행사에 제약이 따른다.

2) 기업의 입장에서 단일성을 만족하는 발명에 대하여 개별 특허출원을 할 것인지 아니면 하나의 특허출원으로 할 것인지는 「선택과 집중」의 문제라 할 수 있다. 제품에 구현되며 침해 여부의 판단이 쉬운 핵심 발명의 경우에는 개별 특허출원하여 많은 특허권을 확보함으로써 다수의 특허 장벽(patent wall)을 쌓아가는 것이 중요하지만, 비핵심 발명의 경우에는 비용 절감 차원에서 하나의 특허출원을 하는 것이 바람직할 것이다.



【그림 2-28】 개별 특허출원과 하나의 특허출원의 선택

2. 보정에 의한 독립항의 변경

어떤 특정한 독립항을 기준으로 하여 단일성을 판단한 결과 단일성을 만족하였을 때도, 보정에 의하여 그 기준이 되었던 특정한 독립항이 삭제되거나 발명의 내용이 변경된다면 단일성을 만족하지 아니할 수 있다. 따라서 이 같은 경우에는 단일성에 관한 판단을 다시 하여야 한다.³⁹⁰⁾

3. 다항제 기재방법과의 관계

「다항제 기재방법」이란 여러 발명을 독립항과 종속항이라는 형식으로 기재하는 방법을 말하고, 「하나의 특허출원의 범위」란 하나의 출원으로 할 수 있는 발명의 범위를 말하는 것으로서, 여러 발명이 다항제 기재방법을 만족하더라도 단일성이 없으면 하나의 특허출원의 범위를 만족하지 아니하기 때문에 하나의 특허출원을 할 수 없게 된다. 다항제 기재방법과 하나의 특허출원의 범위는 상호 독립적이지만 양 제도를 함께 운용하면 독립항만을 기준으로 단일성을 만족하는지 판단하면 되기 때문에 판단의 효율성을 높일 수 있다.

390) 다음의 【예1】에서 청구항 1이 신규성 위반으로 거절이유통지를 받고, 【예2】와 같이 청구항 1을 삭제한 경우에는 청구항 2와 청구항 3은 선행기술과 구별되는 기술적 특징을 공유하지 않기 때문에 단일성을 만족하지 아니하게 된다.

【예1】【청구항1】A로 구성된 것을 특징으로 하는 X.

【청구항2】제1항에 있어서, B를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 X.

【청구항3】A와 C로 구성된 것을 특징으로 하는 X.

【예2】【청구항1】(삭제)

【청구항2】A와 B로 구성된 것을 특징으로 하는 X.

【청구항3】A와 C로 구성된 것을 특징으로 하는 X.

【표 2-10】 하나의 특허출원의 범위 판단의 구체적 예³⁹¹⁾

구 분	구체적 예	설 명
만 족 하 는 예	【청구항 1】 램프용 필라멘트 A 【청구항 2】 필라멘트 A가 있는 램프 B 【청구항 3】 필라멘트 A가 있는 램프 B와 회전테 C로 구성되는 서치라이트(searchlight)	상기 모든 청구항에 공통되는 [특별한 기술적 특징]은 필라멘트 A이다. 청구항 1, 2 및 3 사이에는 단일성이 존재한다.
	【청구항 1】 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기 【청구항 2】 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기 【청구항 3】 영상신호의 시간축 신장기를 구비한 송신기와 수신한 영상신호의 시간축 압축기를 구비한 수신기로 이루어진 영상신호의 전송장치	청구항 1의 [특별한 기술적 특징]은 시간축 신장기에 있는 반면 청구항 2의 [특별한 기술적인 특징]은 시간축 압축기에 있으며, 이들은 서로 대응하는 기술적 특징이다(소위 서브컴비네이션과 서브컴비네이션). 따라서 청구항 1과 청구항 2사이에는 단일성이 존재한다. 청구항 3은 청구항 1 및 청구항 2의 [특별한 기술적 특징]들을 모두 포함하므로 청구항 1및 청구항 2와 단일성이 있다(소위 컴비네이션과 서브 컴비네이션).
만 족 하 지 않 는 예	【청구항 1】 직류모터용 제어회로 A 【청구항 2】 직류모터용 제어회로 B 【청구항 3】 제어회로 A가 있는 직류모터를 이용하는 장치 【청구항 4】 제어회로 B가 있는 직류모터를 이용하는 장치	제어회로 A는 하나의 [특별한 기술적 특징]이고, 제어회로 B는 제어회로 A와는 관련이 없는 또 다른 [특별한 기술적 특징]이다. 따라서 청구항 1과 청구항 3 사이 또는 청구항 2와 청구항 4 사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2 사이 또는 청구항 3과 청구항 4 사이에는 단일성이 없다.
	【청구항 1】 특징 A를 갖는 콘베이어벨트 【청구항 2】 특징 B를 갖는 콘베이어벨트 【청구항 3】 특징 A 및 특징 B를 갖는 콘베이어벨트	특징 A는 하나의 [특별한 기술적인 특징]이고, 특징 B는 또 다른 하나의 [특별한 기술적인 특징]이다. 따라서 청구항 1과 청구항 3사이 또는 청구항 2와 청구항 3사이에는 단일성이 있으나, 청구항 1과 청구항 2사이에는 단일성이 없다.

391) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 2506-2507면.

- 【예】【청구항 1】 a, b, c로 구성된 것을 특징으로 하는 X.
 【청구항 2】 제1항에 있어서, d를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 X.
 【청구항 3】 a, b, e로 구성된 것을 특징으로 하는 Y.
 【청구항 4】 제3항에 있어서, f를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 Y.

【해설】청구항 1 내지 4는 4개의 발명을 2개의 독립항과 2개의 종속항으로 표현함으로써 다항제 기재방법을 만족하고 있다. 그러나 다항제 기재방법을 만족한다고 하더라도 4개의 발명이 각각 단일성을 만족하지 않으면 하나의 특허출원으로 할 수 없다. 상기와 같이 청구항이 4개인 경우에는 원칙적으로 단일성을 만족하는지 6번($=4C_2$)을 판단하여야 한다. 이하 구체적으로 단일성을 만족하는지 판단하여 본다.

- 청구항 1과 청구항 2의 판단:** 청구항 2는 청구항 1의 종속항으로서 청구항 1과 기술적 특징(a, b, c)이 공통되므로 단일성을 만족한다. 청구항 3과 청구항 4도 마찬가지이다. 즉 독립항과 그 독립항의 종속항 사이에서는 단일성을 만족하는지를 판단할 필요가 없다.
- 청구항 1과 청구항 3의 판단:** 청구항 1과 청구항 3은 단일성을 만족하는지 판단하여야 한다. 구체적으로 a, b가 발명의 기술적 특징이라면 청구항 1과 청구항 3은 단일성을 만족하여 하나의 특허출원으로 할 수 있지만, c, e가 발명의 기술적 특징이라면 청구항 1과 청구항 3은 단일성을 만족하지 아니하여 하나의 특허출원으로 할 수 없다.
- 청구항 1과 청구항 4의 판단:** a, b가 발명의 기술적 특징이기 때문에 청구항 1과 청구항 3이 단일성을 만족한다면, 청구항 3의 종속항인 청구항 4는 청구항 1과 관련하여 판단할 필요가 없이 단일성을 만족한다. 한편 c, e가 발명의 기술적 특징이기 때문에 청구항 1과 청구항 3이 단일성을 만족하지 아니하면, 청구항 1과 청구항 4는 단일성을 만족하는지 판단할 필요가 없다. 각각 모두가 단일성을 만족하지 아니하면 1특허출원으로 할 수 없기 때문이다. 결국 청구항 1과 청구항 4는 단일성을 만족하는지 판단할 필요가 없다. 청구항 2와 청구항 3 또는 청구항 2와 청구항 4도 마찬가지이다.
- 결론:** 청구항 1과 청구항 3이 단일성을 만족하면 제45조제1항 본문과 단서가 모두 적용될 수 있으므로 하나 이상의 특허출원을 할 수 있고, 단일성을 만족하지 아니하면 제45조제1항 단서가 적용될 수 없으므로 최소한 둘 이상의 특허출원(예를 들어 둘의 특허출원을 하는 경우 청구항 1과 청구항 2를 하나의 특허출원, 청구항 3과 청구항 4를 다른 특허출원으로 할 수 있다.)을 해야 한다.

그 결과 단일성을 만족하는지는 독립항만을 기준으로 판단하면 된다. 즉 다항제 기재방법은 여러 발명을 독립항과 종속항이라는 형식으로 기재하는 방법을 말하며, 하나의 특허출원의 범위란 여러 발명을 하나의 특허출원으로 할 수 있는 발명의 범위를 말하는 것으로서, 서로 독립적인 제도이지만 양 제도를 함께 운용하면 독립항만을 기준으로 단일성을 만족하는지 판단하면 되기 때문에 판단의 효율성을 높일 수 있다.

PART 03

특허출원인의 이익을 위한 제도

제 1 장 서 론

제 2 장 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우

제 3 장 정당한 권리자의 보호

제 4 장 출원의 보정

제 5 장 분할출원

제 6 장 분리출원

제 7 장 변경출원

제 8 장 조약우선권주장출원

제 9 장 특허출원 등에 의한 우선권주장출원
(국내우선권주장출원)

제10장 발명의 동일성

제1장

서론

출원인은 발명을 특허출원하여 심사·특허결정·설정등록이라는 절차를 밟아야 비로소 특허권을 취득하게 된다. 이 과정에서 출원인의 권리취득에 있어 편의를 위해 특허법은 i) 일정한 사유로 출원 전에 신규성 또는 진보성을 상실한 발명을 보호하기 위한 규정(法 30)을 두고 있으며, 출원일의 소급제도로써 ii) 무권리자의 특허출원·특허에 대한 정당한 권리자의 주장출원(法 34, 35),¹⁾ iii) 보정(法 46, 47, 51), iv) 분할출원(法 52), v) 분리출원(法 52의2) 및 vi) 변경출원(法 53)에 관한 규정을 두고 있다. 또한 판단시점의 소급제도로써 vii) 조약우선권주장출원(法 54), viii) 국내우선권주장출원(法 55, 56)에 관한 규정을 두고 있다.

1) 정당한 권리자의 보호를 위해 출원일 소급제도 이외에 무권리자의 특허에 대한 이전청구(法 99의2)도 인정하고 있다.

제2장

공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우

제30조 【공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우】

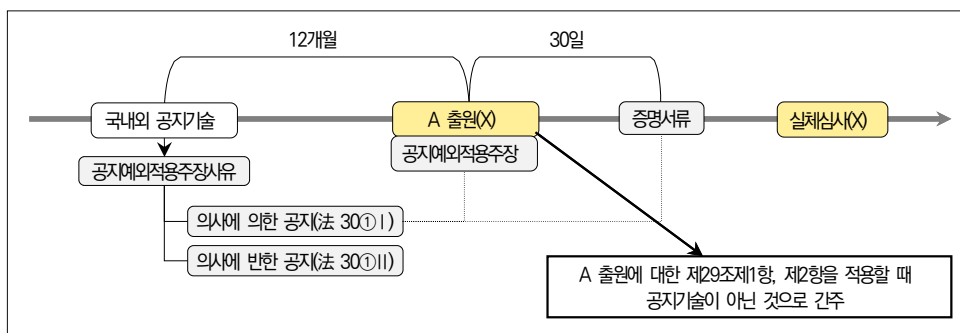
- ① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 같은 조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.
1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 제외한다.
 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우
- ② 제1항제1호를 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하여야 하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 총리령으로 정하는 방법에 따라 특허출원일부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
- ③ 제2항에도 불구하고 총리령으로 정하는 보원수수료를 납부한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 제1항제1호를 적용받으려는 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다. <산설 2015.1.28>
1. 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간
 2. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우」(이하에서는 “공지예외적용”이라 한다)란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 특허출원 전에 이미 공지 등이 된 것이라 하더라도 제30조제1항 각호의 법정사유에 해당하게 된 경우 그 날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여 신규성(法 29①) 또는 진보성(法 29②)을 적용할 때 그 발명은 공지 등이 되지 아니한 것으로 보는 경우를 말한다.



【그림 3-1】 공지예외적용주장출원 일반

2. 취 지

특허출원한 발명이 특허출원 전에 공지 등이 된 경우에는 신규성이나 진보성 상실로 특허를 받을 수 없음이 원칙이지만, 이러한 원칙을 기계적으로 적용하여 특허를 받을 수 없도록 하는 것은 i) 자기 발명의 공개로 인해 출원이 특허를 받지 못하게 되는 것은 너무 가혹하다는 측면과, ii) 그러한 예외를 인정하지 아니하면 연구결과를 신속히 공개하지 아니하여 결과적으로 국가산업발전을 저해한다는 측면을 고려하여 일정한 경우 공지예외적용을 인정하고 있다.²⁾ 한편 2012. 3. 15. 시행된 현행법(법률 제11117호, 2011. 12. 2. 개정)에서는 공지예외적용을 받기 위하여 출원하여야 하는 기간이 공지일로부터 6개월에서 공지일로부터 12개월로 변경되었다.

II. 공지예외적용사유

1. 자기 의사에 의하여 공지 등이 된 경우

1) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 공지 등이 된 경우를 말한다(法 30①Ⅰ 본문). 다만 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 직접 발명을 공개하거나 자신의 발명임을 밝혀야만 하는 것은 아니다.³⁾

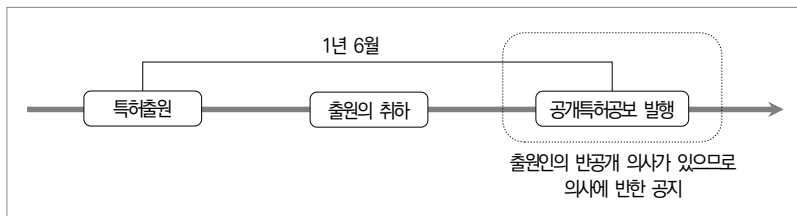
2) 구법에서는 자발적 의사에 의한 공지 등이 된 경우가 공지예외적용에 해당하는 경우를 제한열거적으로 나열하였으나, 이처럼 나열하는 것은 출원인에게는 제한열거적인 공지에 해당하는지에 대한 증명의 부담이, 그리고 심사관에게는 판단의 부담이 되었기 때문에 2006. 3. 3. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정)에서는 공지의 형태에 대한 제한을 없앴으로써 모든 형태의 자발적 공지 행위에 대하여 특허를 받을 수 있도록 하여 법규의 실질적 실효성을 확보하였다.

3) 특허법원 2016. 10. 20. 선고 2015허7308. 지식재산처 심사 실무(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 3236-3237면)에 의하더라도 특허법 제30조제1항제1호 규정에 의한 공지예외적용규정을 적용받기 위한 공개행위는 그 발명의 공개가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적 공개행위뿐만 아니라 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 의뢰하여 제3자가 공개하는 행위나 제3자가 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 허락(묵시적 허락을 포함한다)을 받아 인용하는 공개행위 등을 포함한다. 여기서 i)

2) 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우는 자기 의사에 의하여 공지 등이 된 경우에 해당하지 아니한다(法 30①Ⅰ단서). 이는 특허공보에 게재하는 것은 지식재산처장 등이 공중의 이용 도모를 위해 공개하는 것으로서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 적극적 의사가 포함되었다고 할 수 없기 때문이다.

2. 자기 의사에 반하여 공지 등이 된 경우

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이 제29조제1항 각호의 공지 등이 된 경우를 말한다(法 30①Ⅱ). 이는 공지시점을 기준으로 특허를 받을 수 있는 자가 공개 시키지 아니하여야겠다는 의사, 즉 「반공개 의사」를 가지고 있음에도 불구하고 이에 반해 발명이 공지 등이 된 경우로서, 협박·사기·강박 등에 의하여 공지 등이 된 경우를 말한다. 또한 출원인이 출원발명이 공개되기 직전에 자신의 발명이 공개되는 것을 원하지 아니하여서 자기의 출원에 대하여 취하서, 포기서를 제출하였으나 지식재산처장이 출원공개한 경우나 무권리자가 특허출원하였는데 출원공개된 경우도 의사에 반한 공지 등이 된 경우에 해당한다.⁴⁾ 이와 같은 공지는 발명자의 책임이 아니므로 발명자 보호의 필요가 있어 공지 등이 되지 아니한 것으로 보고 있다. 의사에 반한다는 증명은 의사에 의한 공지와 달리 공지되는 과정 등의 증명이 곤란한 경우가 많으므로 다양한 방법을 통하여 이루어지게 된다.⁵⁾



【그림 3-2】 지식재산처장이 착오로 공개특허공보를 발행한 경우

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 의뢰하여 공개한 경우란 권리자가 제3자에게 발명의 공개를 위탁(발명자 또는 권리자를 명기하는 경우 등)하거나, 신문에 보도자료 또는 원고를 전달하여 발명을 공개하는 경우(발명자나 권리자가 기사에 명확하게 나타나 있지 않더라도 보도자료 또는 원고의 기고자가 권리자임을 증명할 경우 가능) 등을 포함하며, ii) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명을 인용하는 공개란 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자의 논문이나 기사 등에서 발명자나 발명자가 속한 회사 등을 밝히고 그 발명을 인용하여 공개하는 경우나, 발명자가 속한 회사가 그 제품의 카탈로그 등을 통하여 발명을 공개하는 경우 등을 포함한다. 한편 발표자, 발명자 또는 출원인이 다수인 경우 발표자 중 1인이더라도 발명자 또는 출원인과 동일하면 이들 관계를 증명하지 않아도 본 규정을 적용받을 수 있으나 동일인이 없는 경우에는 i) 발표자가 발명의 발표시에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자임을 증명할 수 있는 서류, ii) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 공개를 의뢰하여 공개한 사실을 증명할 수 있는 서류, iii) 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명을 인용하는 공개사실을 증명할 수 있는 서류를 제출하여야 한다.

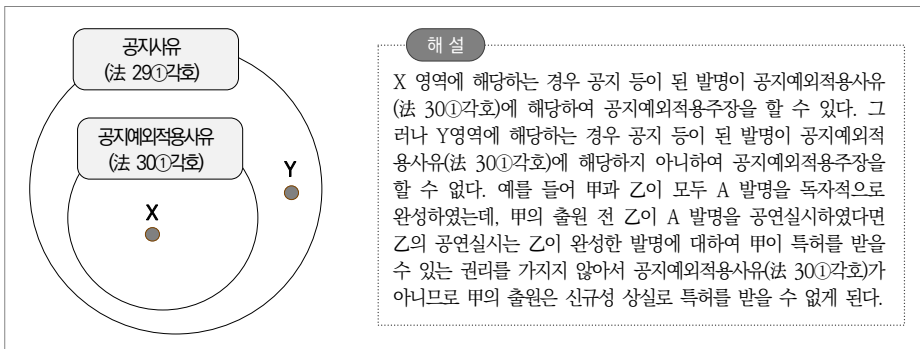
4) 즉 출원공개나 등록공고는 제30조제1항제1호의 자기 의사에 의하여 공지 등이 된 경우에 해당하지 않으나, 사안에 따라 제30조제1항제2호의 자기 의사에 반하여 공지 등이 된 경우에 해당할 수 있다.

5) 특허법원 1998. 11. 26. 선고 98허1747.

III. 공지의예외적용의 요건

1. 주체적 요건

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 제29조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 공지 등이 되어야 한다. 예를 들어 제3자가 독자적으로 발명을 완성하여 공지시킨 경우에는 그 공지된 발명에 대해 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 해당하지 않아서 공지의예외적용 주장을 할 수 없다.



【그림 3-3】 공지사유(法 29①각호)와 공지의예외적용사유(法 30①각호)의 관계

2. 객체적 요건

공지 등이 된 발명이 제30조제1항 각호의 공지의예외적용사유 중 어느 하나에 해당하여야 한다. 한편 출원된 발명(A+a)과 공지 등이 된 발명(A)이 같은 경우는 물론 다른 경우에도 공지 등이 된 발명은 그 출원된 발명의 특허성에 영향을 미치지 아니한다. 이는 공지의예외적용주장이 적법한 경우 심사관은 출원된 발명(A+a)과 공지 등이 된 발명(A)의 동일성·용이성 여부를 판단하지 않고 공지 등이 된 발명(A)을 선행기술에서 제외하고 심사하기 때문이다.⁶⁾

6) 특허법 제30조제1항제1호의 공지의예외규정은 특허출원된 발명에 대하여 신규성 요건인 특허법 제29조제1항뿐만 아니라 진보성 요건인 특허법 제29조제2항을 적용할 때에도 자기공지된 발명이 공지 등이 되지 않은 것으로 본다고 정하고 있다. 그리고 그 규정의 문언상 공지의예외의 효과가 미치는 '자기공지된 발명'과 출원의 대상인 '특허출원된 발명'을 분명하게 구별하고 있다. 이는 특허출원된 발명이 자기공지된 발명의 공지 이후 추가적인 연구개발이나 개량 등을 통하여 자기공지되었던 발명과 구성이나 효과에 차이가 생길 수 있음을 고려한 것이다. 따라서 공지의예외규정이 적용되기 위해서 반드시 자기공지된 발명이 특허출원된 발명과 동일해야 한다거나 자기공지된 발명 그 자체가 특허출원되어야만 한다고 볼 수는 없다(대법원 2025. 5. 29. 선고 2023후10712).

3. 시기적 요건

최선의 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 특허출원을 하여야 한다. 자기 의사에 의하여 공지 등이 된 경우는 물론 자기 의사에 반하여 공지 등이 된 경우에도 마찬가지이다. 이는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 발명을 빨리 특허출원하여 공개시킴으로써 일반 공중의 이용을 도모하는 것이 특허법의 목적에 부합하기 때문이다.

IV. 공지예외적용의 절차

1. 자기 의사에 의하여 공지 등이 된 경우(法 30① 1)

(1) 원 칙

의사에 의하여 공지 등이 된 경우에 본 규정을 적용받으려는 자는 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류⁷⁾를 총리령⁸⁾으로 정하는 방법에 의하여 특허출원일부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 30②).

(2) 예 외

총리령으로 정하는 보완수수료를 납부한 경우에는 다음의 어느 하나에 해당하는 기간에 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다(法 30③). 기존에는 출원과 동시에 그 취지를 적을 때에만 공지예외적용주장을 할 수 있었으나 2015. 7. 29. 시행된 현행법(법률 제13096호, 2015. 1. 28. 개정)은 출원 당시 단순한 실수 또는 제도에 대한 인식 부족으로 출원서에 공지예외주장의 취지를 기재하지 않아 특허를 받지 못하는 기존 제도의 문제점을 해결하고 있다.

i) 제47조제1항에 따라 보정할 수 있는 기간

ii) 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간⁹⁾

7) 증명서류에는 i) 공개일, ii) 공개자, iii) 공개형태, iv) 공개된 발명의 내용 등이 포함되어야 한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 3232면).

8) 제30조제2항의 규정에 의하여 공지 등이 되지 아니한 것으로 적용받으려는 자가 그 증명서류를 제출하는 때에는 별지 제13호서식의 서류제출서에 의한다. 다만 특허출원과 동시에 그 증명서류를 제출하는 때에는 출원서에 증명서류제출의 취지를 기재함으로써 그 제출서에 갈음할 수 있다(施規 20의2).

9) 특허결정등본이 송달되었다고 할지라도 추후 특허취소신청이나 특허무효심판에서 신규성, 진보성 위반 등의 인용대상으로 활용될 수 있으므로, 출원인의 입장에서는 공지예외적용주장을 할 필요가 있는 것이다.

2. 자기 의사에 반하여 공지 등이 된 경우(法 30①Ⅱ)

의사에 반하여 공지 등이 된 경우에 본 규정을 적용받으려는 자는 공지일부터 12개월 이내에는 특허출원을 하여야 하나, 취지기재 및 증명서류는 차후 심사관이 신규성 또는 진보성이 위반되었다고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주는 경우 그 공지가 의사에 반한다는 증명서류를 제출하면 된다. 이는 출원인이 특허출원할 때 의사에 반한 공지가 되었는지 모르는 경우가 대부분이기 때문이다.

V. 공지예외적용의 효과

1. 적법한 경우의 효과

(1) 신규성 또는 진보성의 판단 불가

1) 특허출원된 발명에 대하여 신규성(法 29①) 또는 진보성(法 29②)을 적용할 때 공지예외 적용사유에 해당하는 발명은 공지 등이 되지 아니한 것으로 본다. 즉 심사관은 공지예외적용 사유에 해당하는 공지기술로부터 특허출원된 발명의 신규성 또는 진보성을 판단하지 아니한다.

2) 또한 공지예외규정을 적용받아 특허를 받은 특허발명의 경우 확인대상발명이 그 특허권의 권리범위에 속하는지를 판단할 때에 자유실시기술의 주장 즉, 통상의 기술자가 공지예외규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 확인대상발명을 쉽게 실시할 수 있어 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 주장은 허용되지 아니한다.¹⁰⁾

(2) 다른 특허요건과의 관계

1) 공지예외적용주장출원의 경우 출원일이 소급되는 것은 아니므로 12개월의 유예기간이 있더라도 될 수 있으면 빨리 출원하여야 한다. 예를 들어 공지일과 공지예외적용을 주장한 특허출원(이하 “甲 출원”이라 한다)일 사이에 타인의 특허출원(이하 “乙 출원”이라 한다)이 있으면, 甲 출원은 乙 출원이 공개된다면 확대된 선출원 위반으로 특허를 받을 수 없게 될 수도 있다.¹¹⁾

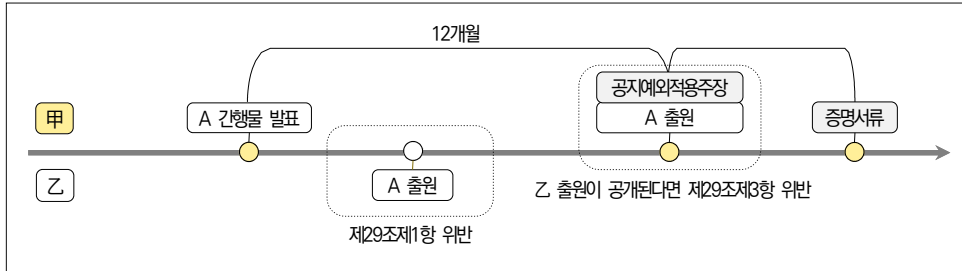
2) 한편 甲 출원과 같은 날에 乙 출원이 있는 경우 문제이다. 심사 실무¹²⁾의 태도는 “심사관은 乙 출원은 신규성이 없다는 이유로 거절이유를 통지함과 동시에 甲 출원과 乙 출원에 대하여 협의명령을 한다. 그 결과 협의명령에 따라 乙 출원의 취하 등의 적절한 조치가 있는 경우 甲 출원은 특허를 받을 수 있다”라는 입장이다. 그러나 선출원주의에서 협의제, 협의명령은 선출원의 지위가 있음을 전제로 하는데 乙 출원은 신규성 위반으로 특허거절결정이 확정될 것이고, 2006년 3월 3일 이후 출원에 대해서는 특허거절결정이 확정되었을 때 선출원의 지위를 인정

10) 대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562.

11) 다만 乙 출원이 공개 전에 무효, 취하, 포기 또는 특허거절결정이 확정된다면 甲 출원은 특허를 받을 수 있을 것이다. 한편 乙 출원은 신규성 위반으로 특허를 받을 수 없다.

12) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3234면.

하지 않기 때문에(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정), 협의명령을 함이 없이 甲 출원에 대하여 특허를 허여함이 타당할 것이다.¹³⁾



【그림 3-4】 공지예외적용주장과 특허요건의 관계

2. 부적법한 경우의 효과

(1) 공지예외적용주장의 무효

출원인이 공지예외적용주장을 하였으나 공지예외적용주장이 방식¹⁴⁾에 위반된 경우 지식재산처장은 그 흠결을 지적하여 보정명령을 하고 보정명령에도 불구하고 보정하지 않거나 보정에 의하여 흠결이 치유되지 아니하면 그 보정명령을 한 절차인 「공지예외적용주장」을 무효로 할 수 있다.

(2) 출원발명의 신규성, 진보성 판단

공지예외적용주장이 무효가 되면 출원은 공지예외적용주장을 수반하지 아니한 출원이 되므로 심사관은 공지예외적용을 주장한 공지기술에 의하여 출원된 발명의 신규성 또는 진보성을 판단하여야 한다.

13) 대법원 2000. 1. 21. 선고 97후2576 판결에서는 “동일한 발명에 대하여 같은 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 때에도 그 발명이 신규성이나 진보성의 결여로 여차피 특허거절결정되어야 하는 것인 이상 출원인 간의 협의절차 등을 거치지 않았다 하여 그 출원에 대한 신규성이나 진보성 결여를 원인으로 한 특허거절결정이 부적법하다고 할 수 없다”라고 판시하였다. 이는 심사관이 모든 거절이유에 대하여 거절이유통지를 한 후 특허거절결정하여야 하는 것은 아니기 때문이다. 대상판결에 의하면 乙 출원이 신규성 위반으로 거절결정이 확정된 경우 甲 출원은 특허를 받을 수 있으나, 乙 출원에 대하여 신규성을 적용하지 않고 심사 실무와 같이 협의제를 먼저 적용한다면 甲 출원은 특허를 받을 수 없게 될 수도 있어 심사 실무는 심사의 신뢰성을 저해시키게 된다고 할 수 있다.

14) i) 그 발명을 발표한 자와 출원인(발명자)이 다른 경우, ii) 발표를 한 날부터 12개월이 지난 후 공지 등이 된 발명을 출원한 경우(마지막 날이 공휴일이면 그 다음 날), iii) 출원서에 공지예외대상증명서류, 공개형태 또는 공개일자 등을 잘못 적은 경우, iv) 증명서류를 충분히 제출하지 못한 경우 등이 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3232면).

VI. 국제특허출원의 특례

국내출원의 경우 제30조제1항제1호를 적용받으려는 경우 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 특허출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다(法 30②). 한편 국제특허출원된 발명에 대하여 제30조제1항제1호를 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서류 및 증명서류를 기준일이 지난 후 30일 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다(法 200, 施規 111). PCT는 특허출원절차를 통일화하기 위한 조약으로서 지정국에서 출원 시 별도의 절차를 요구해서는 아니 되기 때문에 PCT 출원이 국내단계로 진입한 후에 절차적인 측면을 요구하도록 규정되어 있다.

VII. 관련문제

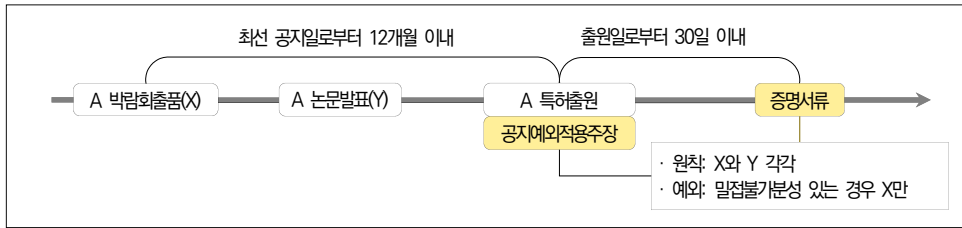
1. 복수 회에 걸친 공지가 있는 경우

(1) 공지가 모두 공지예외적용사유에 해당하는 경우

복수의 공지행위가 모두 공지예외적용사유(法 30①각호)에 해당하면 모든 공지행위에 대하여 각각 공지예외적용주장을 할 수 있다. 이 경우 출원인은 최선의 공지일로부터 12개월 이내 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 총리령으로 정하는 방법에 따라 출원일로부터 30일 이내 각각 제출하여야 한다. 다만 특정한 어느 하나의 공지와 밀접불가분의 관계¹⁵⁾에 있는 복수회에 걸친 공지일 경우에는 출원인의 편의를 위해 2번째 이후의 공지에 대해서는 취지기재 및 증명서류의 제출을 생략할 수 있다.¹⁶⁾

15) 밀접불가분의 관계에 있는 구체적인 예로는 i) 2일 이상 소요되는 시험, ii) 시험과 시험당일에 배포된 설명서, iii) 간행물의 초판과 중판, iv) 원고집과 그 원고의 학회(구두) 발표, v) 학회발표와 그 강연집, vi) 학회의 순회강연, vii) 박람회 출품과 그 출품물에 대한 카달로그, viii) 연구개발에 따른 발명에 관하여 하나의 학술적인 발표행위(학술지 게재, 학술단체 발표, 연구보고서 공표, 학위논문 공개 등) 등을 들 수 있다. 특정한 하나의 공개행위와 후속 공개행위가 밀접불가분의 관계에 있는지가 불명확한 경우에는 거절이유를 통지하여 출원인이 보완하거나 소명할 기회를 주는 것이 바람직하다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 3233-3234면).

16) 공지예외규정의 문언과 취지에 비추어 보면, 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허법 제30조제1항에서 정한 12개월의 기간 이내에 여러 번의 공개행위를 하고 그중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외주장을 하였더라도, 공지된 나머지 발명들이 가장 먼저 공지된 발명과 동일성이 인정되는 범위에 있다면 공지된 나머지 발명들까지 공지예외의 효과가 미친다고 보아야 한다(대법원 2025. 5. 29. 선고 2023후10712).



【그림 3-5】 공지예외적용사유에 해당하는 복수회의 걸친 공지가 있는 경우의 취급

(2) 공지 중 일부가 공지예외적용사유에 해당하지 아니한 경우

공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우는 공지예외적용사유에 해당하는 공지에 한한다. 따라서 공지예외적용사유(法 30①각호)가 아닌 다른 사유로 공지되었으면 그 공지에 의하여 특허출원된 발명의 신규성 또는 진보성을 판단하여야 한다. 예를 들어 공지예외적용사유에 해당하는 공지가 있는 날과 특허출원일 사이에 출원발명과 동일한 발명에 대하여 공지예외적용사유가 아닌 공지가 있는 경우 그 특허출원된 발명은 신규성이 없는 것으로 하여 특허거절결정된다.¹⁷⁾

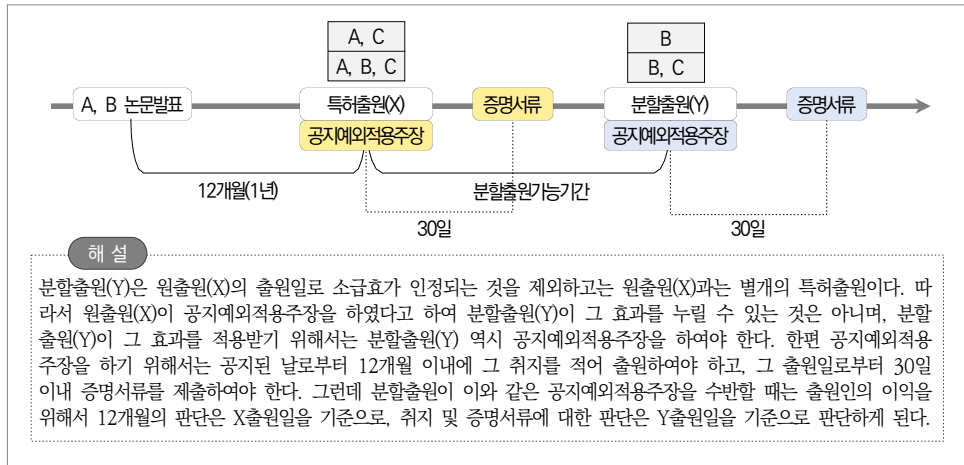
2. 각종 제도와와의 관계

(1) 분할·분리·변경출원의 경우

1) 분할출원, 분리출원 또는 변경출원의 경우에는 제30조제1항의 「12개월」은 원출원일을 기준으로 판단하기 때문에 공지예외적용사유에 해당하는 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 원출원이 있는 경우 각각 분할출원, 분리출원, 변경출원할 수 있는 시기에 분할출원, 분리출원 또는 변경출원을 하면 된다.

2) 한편 분할출원, 분리출원 또는 변경출원 모두 제30조제2항의 공지예외적용의 취지기재 및 증명서류제출기간은 원출원일을 기준으로 하지 않고 분할출원일, 분리출원일 또는 변경출원일을 기준으로 하므로, 분할출원서, 분리출원서 또는 변경출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 분할출원일, 분리출원일 또는 변경출원일로부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다(法 52②, 52의2②, 53②).

17) 특허법 제30조제1항제1호에 의한 공지가 있는 날과 특허출원일 사이에 제3자에 의하여 공지예외적용사유에 기재된 발명과 동일한 발명의 공개가 있는 경우 제3자에 의한 공지가 공지예외에 해당하는 공지에 의하여 지득(知得)한 발명의 공개라는 사실이 명백한 경우를 제외하고 그 공지예외적용사유는 신규성이 없는 것으로 하여 거절결정한다. 여기서 제3자에 의한 공지가 공지예외에 해당하는 공지에 의하여 지득(知得)한 발명의 공개란, 예를 들어 특허를 받을 수 있는 권리자가 한 시험 또는 간행물 발표, 학술단체가 개최하는 연구집회에서의 발표, 박람회에 출품 등에 의하여 공지된 발명을 제3자가 간행물에 전재(轉載)하는 경우 등이다. 또한 상기 이유에 의한 심사관의 거절이유통지에 대하여 출원인이 제3자에 의한 공지가 공지예외에 해당하는 공지에 의하여 알게 된 발명의 공개라는 사실이나, 출원인의 의사에 반하여 공지된 발명이라는 사실을 증명하지 못하는 경우 그 특허출원에 대하여 거절결정한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3302면).



【그림 3-6】 공지예외적용주장을 수반하는 분할출원

(2) 조약우선권주장출원의 경우

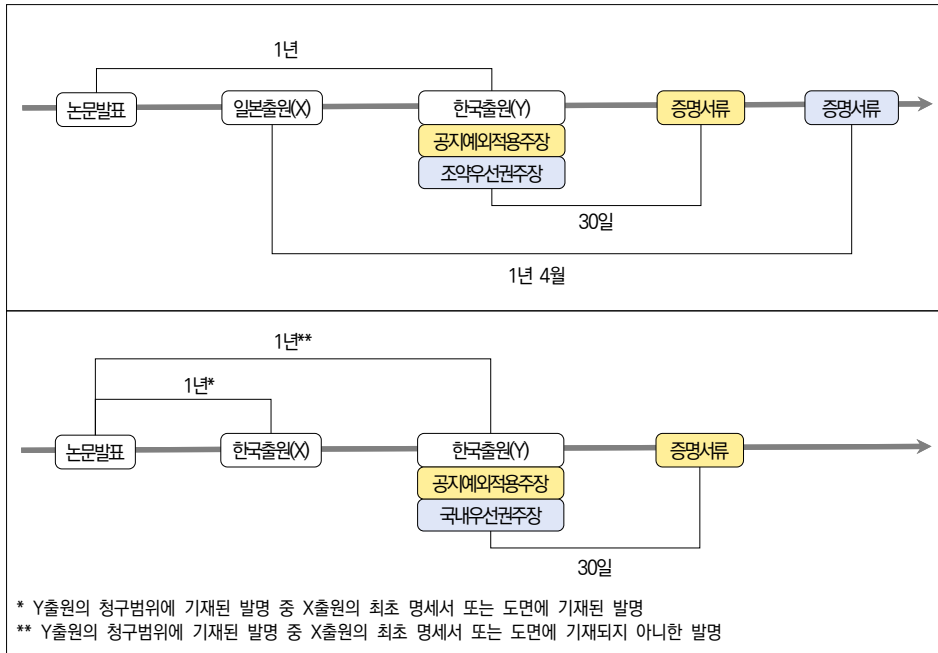
1) 조약우선권주장출원의 경우에는 제30조제1항 본문의 「특허출원」을 속지주의 원칙상 「국내의 특허출원」으로 해석하기 때문에 조약우선권주장출원 자체가 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 이루어져야 공지예외적용을 받을 수 있다. 즉 조약우선권주장출원은 제30조제1항의 「12개월」의 판단시점이 선출원일로 소급되지 아니한다. 그 결과 조약우선권주장출원이 공지예외적용주장을 수반하는 경우 우선기간이 12개월 이하로 단축될 수밖에 없다.

2) 한편 제30조제2항의 공지예외적용의 취지기재 및 증명서류제출기간은 우선권주장출원일을 기준으로 하므로, 우선권주장을 할 때 출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 우선권주장출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다(法 54①).

(3) 국내우선권주장출원의 경우

1) 국내우선권주장출원의 경우에는 국내우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명에 대해서는 제30조제1항의 「12개월」의 판단시점이 선출원일로 소급된다(法 55③). 따라서 이 발명은 공지예외적용사유에 해당하는 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 선출원이 있고 선출원일로부터 1년 이내에 국내우선권주장출원을 하였다면 공지예외규정의 적용을 받을 수 있다. 그러나 후출원의 청구범위에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일하지 않은 발명에 대해서는 제30조제1항의 「12개월」의 판단시점이 선출원일로 소급되지 않는다(法 55③ 반대해석). 따라서 이 발명은 공지예외적용사유에 해당하는 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 국내우선권주장출원을 하여야만 공지예외규정의 적용을 받을 수 있다.¹⁸⁾

2) 한편 제30조제2항의 공지예외적용의 취지기재 및 증명서류제출기간은 판단시점이 소급되지 않고 국내우선권주장출원일을 기준으로 하므로, 우선권주장을 할 때 출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 우선권주장출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다(法 55③).



【그림 3-7】 공지예외적용주장을 수반하는 우선권주장출원

18) 한편 국내우선권주장출원의 발명 중에서 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 개시되지 않은 발명은 국내우선권주장출원일에 출원된 것으로 보기 때문에 선출원보다 늦게 출원인에 의하여 공지된 발명에 대해서도 공지예외주장을 인정할 필요가 있다. 즉 선출원 시에는 공지예외주장을 하지 않았으나 선출원일과 국내우선권주장출원일 사이에 공지된 발명에 대하여 국내우선권주장출원에서 공지예외주장을 한 경우에는, 해당 공지된 발명이 선출원보다 늦게 공지되었다는 이유로 국내우선권주장출원의 공지예외주장을 부적법한 것으로 취급하지 아니한다(지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6405-6406면)

【표 3-1】 공지에의적용주장을 수반하는 분할출원, 분리출원, 변경출원 및 우선권주장출원의 관계

구 분	12개월(法 30①)	취지기재서면 및 증명서류(法 30②)
분할출원 (法 52②)	소급효 ○	소급효 ×
분리출원 (法 52의2②)	소급효 ○	소급효 ×
변경출원 (法 53②)	소급효 ○	소급효 ×
조약우선권주장출원 (法 54③)	소급효 ×*	소급효 ×
국내우선권주장출원 (法 55①)	소급효 ○**	소급효 ×

* 제30조제1항의 “특허출원”을 국내출원으로 제한해석하므로 소급효 불인정

** 단, 국내우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서만 인정

제3장

정당한 권리자의 보호

제34조 【무권리자의 특허출원과 정당한 권리자의 보호】

발명자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자(이하 “무권리자”라 한다)가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제62조제2호에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

제35조 【무권리자의 특허와 정당한 권리자의 보호】

제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 제133조제1항제2호에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무효로 된 그 특허의 출원 시에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제99조의2 【특허권의 이전청구】

- ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.
 1. 해당 특허권
 2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
 3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권
- ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

[본조신설 2016.2.29.]

제103조의2 【특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권】

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
 1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자
 2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.
- ② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

[본조신설 2016.2.29.]

제104조 【무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권】

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. <개정 2016.2.29.>
1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
 2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자
 3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
 4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자
 5. 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.
- ② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

「정당한 권리자」란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로서, 일반적으로 발명자 또는 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은 승계인을 말한다(法 33①본문). 「무권리자」란 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있지 아니한 자를 말한다. 특허법은 i) 무권리자의 출원이나 특허를 배척하는 한편(法 33①본문 위반) 일정요건 하에 정당한 권리자의 출원을 무권리자의 출원일로 소급시키거나(法 34, 35), ii) 특허권의 이전청구를 통해(法 99의2) 정당한 권리자를 보호해 주고 있다. 즉 정당한 권리자가 i)과 ii)의 방법 중에서 각각 드는 비용과 시간 등을 상호 비교하여 선택할 수 있도록 함으로써 편의를 제고하고 있다. 이는 선출원주의하에서 선발명주의적 요소의 가미라고 할 수 있다.¹⁹⁾

19) 무권리자 출원의 등록 전후로 구분하여 정당한 권리자의 보호방안에 대하여 살펴보면 다음과 같다.

정당한 권리자 보호	출원일의 소급효	특허권(특허출원)의 이전청구
무권리자의 출원	○ (法 34)	○ (해석상)
무권리자의 특허	○ (法 35)	○ (法 99의2)
비고	제35조에 의하여 정당한 권리자에게 특허가 인정되면 선의의 무권리자에게 중용권(法 104) 인정가능	제99조의2에 의하여 정당한 권리자에게 특허이전등록이 되면 선의의 무권리자에게 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권(法 103의2) 인정가능

II. 정당한 권리자 출원의 무권리자의 출원일로 소급에 의한 보호

1. 요건

(1) 주체적 요건

무권리자의 특허출원이 있거나 착오 등으로 인해 그에 대한 특허권의 설정등록이 있어야 한다. 무권리자가 선의·악의인지는 불문하나 선의의 무권리자는 일정요건을 갖추면 후술하는 바와 같이 중용권(法 104)에 의하여 보호된다. 「악의의 무권리자」란 진정한 발명자의 의사에 반하여 사기, 협박, 산업스파이 등을 통하여 해당 발명을 모인한 자(冒認者)를 말하며, 「선의의 무권리자」란 악의의 무권리자를 정당한 권리자로 믿고, 무권리자로부터 해당 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 양도받은 승계인을 말한다.

(2) 객체적 요건

1) 정당한 권리자 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 무권리자 출원의 발명 범위에 포함되어 있어야 한다.²⁰⁾ 「무권리자 출원의 발명 범위」란 무권리자의 보정 여부에 따라 범위가 달라지는 것은 타당하지 않으므로 무권리자가 출원할 때 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위로 해석함이 타당하다. 「최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항」은 최초 명세서 또는 도면에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재 없더라도 통상의 기술자가 무권리자의 출원일 당시의 기술상식에 비추어 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 말한다. 한편 정당한 권리자 출원의 명세서 또는 도면에 무권리자 출원의 발명 범위에 포함되지 아니한 발명이 포함되어 있다고 하더라도 보정에 의하여 그 발명이 삭제되었다면 출원일 소급요건을 충족한 것으로 본다.

2) 다만 무권리자 출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재되지 않았을지라도 무권리자가 도용한 정당한 권리자의 발명(모인대상발명)에 기재되었다는 정당한 권리자의 주장이 있었다면 출원일 소급효를 인정해 주는 것을 고려해 볼 수 있을 것이다. i) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결에서와 같이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 아니하였는지에 따라 무권리자인지를 판단하기 때문에 모인대상발명과 무권리자의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 반드시 동일성이 있지 않다는 점, ii) 모인대상발명 그 자체를 보호받고자 하는 정당한 권리자의 이익을 보호해 줄 필요가 있다는 점, iii) 제34조, 제35조에서는 분할출원(法 52), 분리출원(法 52의2), 변경출원(法 53), 우선권주장출원(法 54, 55)와 같이 소급효가 인정되는 객체적 범위를 명시하고 있지 않다는 점을 고려하여야 하기 때문이다.

20) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5312면.

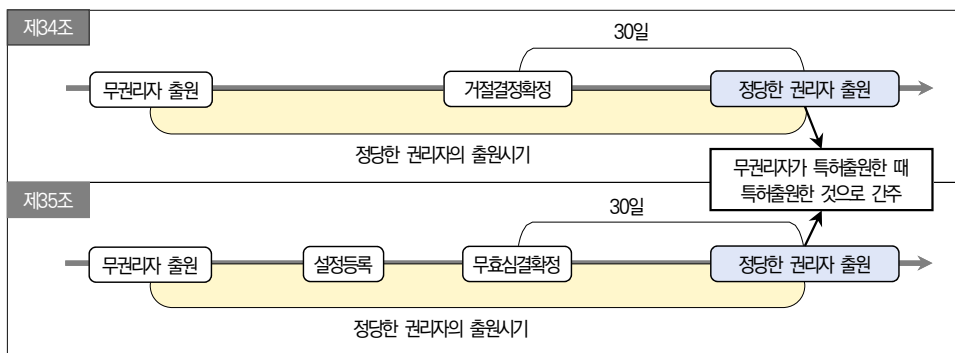
(3) 시기적 요건

① 특허를 받지 못하게 된 경우

무권리자가 한 특허출원이 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 거절이유(法 62Ⅱ)에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 정당한 권리자의 특허출원이 있어야 한다. 다만 무권리자가 특허를 받지 못하게 된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다(法 34). 「거절이유에 해당하여 특허를 받지 못하게 된 날」이란 특허거절결정의 확정일을 의미한다.²¹⁾

② 무효심결이 확정된 경우

무권리자의 특허가 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사유로 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 무권리자의 특허출원 후에 정당한 권리자의 특허출원이 있어야 한다. 다만 심결이 확정된 날부터 30일이 지난 후에 정당한 권리자가 특허출원을 한 경우에는 그러하지 아니하다(法 35).²²⁾



【그림 3-8】 정당한 권리자의 출원 일반

21) 심사 실무상 특허거절결정이 확정되거나 무효심결이 확정되기 전 정당한 권리자의 출원이 있는 경우 심사를 보류하고, 무권리자의 출원으로 주장된 출원의 특허여부결정 또는 무효심판의 심결이 확정된 이후에 심사를 재개한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5312면).

22) 기존에는 그 특허의 등록공고에 있는 날로부터 2년 이내와 심결이 확정된 날로부터 30일 중 빠른 날까지 정당한 권리자가 출원하면 무권리자의 출원일로 소급효를 인정하였으나, 정당한 권리자가 무권리자의 특허를 등록공고일로부터 2년이 지난 후에 알았거나, 그 전에 알았더라도 특허무효심결이 지연되어 등록공고일로부터 2년이 지난 후에 확정되면 정당한 권리자가 보호받을 수 없는 문제점이 있었고, 따라서 2017. 3. 1. 시행된 현행법(법률 제14035호, 2016. 2. 29. 개정)에서는 등록공고에 있는 날로부터 2년 이내라는 요건을 삭제하였다.

2. 절 차

정당한 권리자가 특허출원을 하려면 출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서와 함께 정당한 권리자임을 증명하는 서류를 첨부하여 제출하여야 한다(施規 31). 다만 정당한 권리자가 특허출원 전에 무권리자의 출원이 있는지 알 수 없는 경우가 상당할 것이므로 특허출원할 때 정당한 권리자임을 증명하는 서류를 첨부하지 않더라도 제46조의 절차보정사유로 보아 후에 보정할 수 있도록 함이 타당하다.

3. 효 과

(1) 적법한 경우의 효과

① 출원일의 소급효

1) 무권리자의 특허출원 후에 한 정당한 권리자의 특허출원은 무권리자가 특허출원한 때에 특허출원한 것으로 본다(法 34, 35).

2) 정당한 권리자의 특허출원에 대하여 제34조 및 제35조에 따라 특허된 경우에는 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산한다(法 88②). 즉 존속기간은 정당한 권리자 출원의 특허권을 설정등록한 날로부터 무권리자의 출원일 후 20년이 되는 날까지이다.

② 소급효의 예외

1) 특허출원에 대하여 특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간 만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다. 여기서 「특허출원일로부터 4년」과 관련하여, 정당한 권리자의 특허출원(法 34, 35)의 경우에는 정당한 권리자가 출원을 한 날을 특허출원일로 본다(法 92의2①④).

2) 한편 분할출원(法 52②각호), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②각호)과 달리, 정당한 권리자의 출원일이 무권리자의 출원일로 소급하는 경우 등록지연에 따른 존속기간연장등록출원(法 92의2①④) 이외에 출원일의 소급효에 대한 예외 규정을 두고 있지 아니한 것은 문제가 있다고 보인다. 구체적인 예로, 정당한 권리자의 특허출원이 확대된 선출원에 관한 규정(法 29③④)에서의 다른 출원에 해당할 때 무권리자 특허출원의 최초 명세서 또는 도면에는 포함되어 있지 아니하지만 정당한 권리자 특허출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함된 발명에 의하여 무권리자 특허출원과 정당한 권리자 특허출원 사이의 제3자의 출원을 거절하는 것은 먼저 출원하여 공개시킨 자에게 독점·배타적인 특허권을 부여한다는 특허법의 목적에 반하게 된다. 따라서 이와 같은 해석의 논란을 없애기 위해서는 분할출원, 분리출원, 변경출원과 같이 구체적 타당성 도모를 위해 일정한 경우 소급효의 예외를 명확히 규정하는 것이 필요하다고 할 것이다.

③ 심사청구기간의 특례

무권리자의 특허출원·특허에 대한 정당한 권리자의 특허출원의 경우 심사청구기간은 무권

리자의 출원일의 다음 날부터 기산한다(法 34, 35). 다만 정당한 권리자의 특허출원이 무권리자의 출원일로부터 3년의 기간이 지난 후라도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다(法 59③). 즉 정당한 권리자 특허출원의 심사청구기간은 무권리자 출원일로부터 3년과 정당한 권리자 출원일로부터 30일 중 늦은 날까지이다. 이 규정은 무권리자 출원의 출원일로부터 3년을 지난 후에 정당한 권리자 특허출원이 되었을 때 소급효로 인해 심사청구기간이 지났다고 하여 심사청구를 할 수 없다고 하는 것은 불합리하므로 정당한 권리자 특허출원에 대하여 심사청구를 할 수 있는 기회를 부여하기 위한 것이다.

④ 중용권의 발생

다음의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 유상의 통상실시권을 가진다(法 104). 이는 자신의 등록이 적법한 것으로 믿는 선의의 무권리자를 보호하는 한편 그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비가 산업발전에 이바지라는 법 목적에 비추어 보호해 줄 가치가 있기 때문이다.

- i) 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
- ii) 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자
- iii) 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자(다만 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다)

(2) 부적법한 경우의 효과

① 출원일의 불소급

1) 정당한 권리자 출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 무권리자 출원에 기재된 발명과 다른 발명이 있는 경우(정당한 권리자 출원에 다수의 발명이 포함되어 있고 그 발명 중 일부의 발명만이 무권리자에 의하여 출원된 발명에 해당하는 경우) 정당한 권리자 출원의 출원일은 소급되지 아니한다.²³⁾

2) 심사관은 출원일 소급을 인정할 수 없을 때 i) 다른 거절이유가 있는 경우에는 거절이유통지서에 출원일을 소급할 수 없다는 취지를 적어 함께 통지함으로써, 출원을 분할하거나 보정할 수 있도록 기회를 부여하고, ii) 다른 거절이유가 없는 경우에는 출원일을 소급할 수

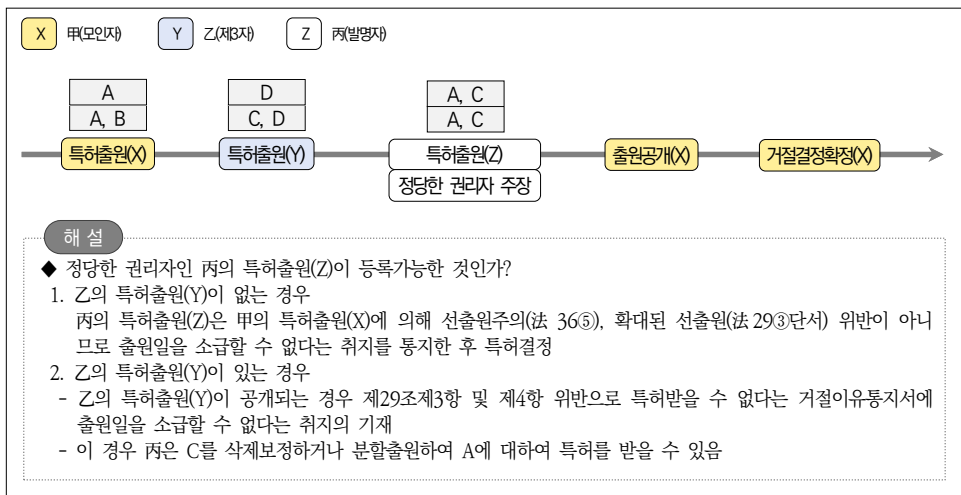
23) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5312면.

없는 취지만을 통지한 후 특허결정한다. 즉 정당한 권리자의 특허출원은 출원일이 소급되지 않더라도 무권리자의 선출원에 의하여 특허거절결정되지 아니한다. 무권리자의 선출원은 선출원의 지위가 없으며(法 36⑤), 발명자가 동일하여 정당한 권리자의 출원에 대하여 확대된 선출원을 적용하지 않기 때문이다(法 29③④단서).

3) 한편 무권리자 출원의 공개가 있는 후에 소급효가 인정되지 아니한 정당한 권리자의 출원이 있는 경우, 무권리자의 공개는 제30조제1항제2호의 의사에 반한 공지에 해당하기 때문에 공개된 날로부터 1년 이내 정당한 권리자가 출원했다면 공지가 되지 아니한 것으로 보아서 신규성, 진보성 위반을 판단하지 않게 된다. 그러나 공개된 날로부터 1년을 지나서 정당한 권리자가 출원했다면 정당한 권리자의 출원이 그 공개에 의하여 신규성, 진보성에 위반되었는지를 판단해야 한다.

② 불수리

청구범위를 적지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허출원한 정당한 권리자출원으로서 그 특허출원 당시에 이미 청구범위제출유예기간(法 42의2②)이 지났으면 불수리된다(施規 11).



【그림 3-9】 정당한 권리자의 출원에 새로운 발명이 기재된 경우의 취급

Ⅲ. 특허권의 이전청구에 의한 보호

1. 서

정당한 권리자가 무권리자의 특허출원이나 특허권의 이전을 법원에 청구하는 방법으로 무권리자의 특허를 반환받을 수 있는지와 관련하여, 대법원은 i) 정당한 권리자가 특허출원한 바

없고 무권리자만 특허출원한 경우(A 유형)²⁴⁾와 ii) 정당한 권리자가 특허출원한 이후 승계인과의 출원인변경 약정에 하자가 있어 결과적으로 승계인이 무권리자의 특허출원이 되는 경우(B 유형)²⁵⁾로 구분하여, B 유형의 경우에만 법원에 이전청구를 할 수 있다는 입장이었다.²⁶⁾ 다만 특허법에 근거를 두고 있지 않고 구체적인 사례별로 차이를 두는 것은 법적 안정성을 해하는 것이라 할 수 있으며, 일본, 독일 등 이전청구를 인정하고 있는 외국제도와와의 조화를 꾀할 필요가 있으므로 2017. 3. 1. 시행된 현행법(법률 제14035호, 2016. 2. 29. 개정)에서는 정당한 권리자의 이전청구에 관한 규정(法 99의2)을 신설하였다.

2. 특허권의 이전청구

(1) 정당한 권리자의 이전청구

① 등록 후의 이전청구

제33조제1항 본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하여 특허무효사유(法 133① II)에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전을 청구할 수 있다(法 99의2①). 특허권의 이전을 청구할지 아니면 정당한 권리자의 보호 규정(法 34, 35)에 따라 정당한 권리자가 별도의 특허출원을 할지는 정당한 권리자의 선택 문제로서 동일한 발명이라고 할지라도 발명의 설명이나 청구범위를 어떻게 기재하느냐에 따라 권리범위 자체가 달라지기 때문에 권리범위의 재설계의 필요성이 있다면 별도의 특허출원을 하고, 특허절차의 신속성이나 편의성을 고려한다면 특허권의 이전청구를 선택하면 된다.²⁷⁾

② 등록 전의 출원인변경신고

제99조의2에 명시되어 있지 않지만, 무권리자의 특허가 아닌 특허출원에 대하여도 정당한 권리자가 무권리자의 특허출원을 승계, 즉 출원인변경신고를 하였다면 제33조제1항 본문 위반이 해소된 것으로 보고 특허출원을 계속 진행하는 것을 인정하여 줄 필요가 있다.²⁸⁾ 무권리자의 특허출원에 대한 심사과정이 정당한 권리자가 특허를 받는데 유리한 상황이라면, 굳이 별도로 특허출원하여 출원일의 소급효를 인정받고 나서 심사과정을 반복할 필요가 없기 때문이다. 이 경우 정당한 권리자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다는 취지의 판결(출원인변경 절차의 이행을 구하는 소 또는 정당한 권리자에 관한 확인의 소에 의한 판결)을 출원인변경신고에 첨부하면 될 것이다.²⁹⁾

24) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310.

25) 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218.

26) 서울중앙지방법원 2010. 1. 20. 선고 2009가합97210.

27) 무권리자의 특허출원이나 특허가 배척되었을 때 정당한 권리자가 특허출원(法 34, 35)을 하여 심사를 받는 것은 권리회복에 장기간이 소요되는 불편함이 있다.

28) 강기중, “무권리자의 특허출원(모인출원)과 정당한 권리자의 보호”, 법조 53권 5호, 2004, 23면.

29) 中山信弘 編, 『註解特許法(上卷)』, 第3版, 青林書院, 2000, 322頁.

(2) 권리의 귀속시기

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 법원예의 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 해당 특허권과 보상금청구권(法 65②, 207④)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다(法 99의2②).³⁰⁾ 이는 처음부터 특허권을 취득할 수 있었던 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자이고, 해당 특허발명이 공개됨에 따라 산업발달에 이미 기여하였다는 점에서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 권리의 행사를 처음부터 인정함이 타당하기 때문이다. 그 결과 前 특허권자가 특허권, 보상금청구권의 행사를 통해 받은 이익은 부당이득으로 이전등록된 특허권자에게 반환해야 할 대상이 될 것이다. 또한 이전등록이 있기 전의 前 특허권자와 실시권자의 실시권 허락계약도 무효로 될 것이나 일정한 경우 후술하는 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권(法 103의2)에 의하여 실시권자의 보호가 가능하다.

3. 특허무효사유에서 제외

특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니함에도 불구하고 등록된 특허라 하더라도 특허권의 이전청구에 기초하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록(法 99의2)이 있으면 이전등록된 특허권은 특허무효심판을 청구할 수 있는 대상에서 제외된다(法 133①Ⅱ단서). 이는 이전청구에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록된 특허권이 애초에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 출원이 아니라는 점을 이유로 무효로 되는 것을 방지하기 위함이다.

4. 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권

1) 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 특허권의 이전청구에 기초하여 특허권의 이전등록이 있기 전에(法 99의2②) 해당 특허가 제33조제1항 본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하여 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 유상의 통상실시권을 가진다(法 103의2).

i) 이전등록된 특허의 원(原)특허권자

ii) 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자(다만 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다)

2) 이는 자신의 등록이 적법한 것으로 믿는 선의의 무권리자를 보호하는 한편 그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비가 산업발전에 이바지라는 법 목적에 비추어 보호해 줄 가치가 있으며, 또한 정당한 권리자가 별도의 특허출원(法 35)을 하여 특허권을 획득하였을 때 선의의 무권리자에게 인정되는 중용권(法 104)과의 형평성을 고려한 것이다.

30) 법 제99조의2제2항에 따라 특허권 이전등록을 받은 자가 발명자를 추가·삭제 또는 정정하려는 경우에는 특허권자 및 신청 전·후 발명자 전원이 서명 또는 날인한 확인서류를 첨부하지 않아도 된다(施規 28④)

제4장

출원의 보정

제1절 서설

I. 의의

「출원의 보정」이란 특허출원서의 방식이나 출원 명세서 또는 도면의 기재내용에 흠결이 있는 경우에 그 흠결을 치유하여 적법하게 하는 보충·정정을 말한다. 보정이 적법한 경우 명문의 규정은 없으나 소급효가 인정되어 보정된 내용대로 출원한 것으로 본다.³¹⁾

II. 취지

1) 특허법이 선출원주의를 채택한 결과 출원인이 출원을 서두르는 과정에서 출원서류가 미비하거나 예기치 못한 하자가 발생할 수 있는데 이 같은 경우에 보정을 허용하지 아니한 것은 선출원주의의 원칙에 충실히 따르고자 노력한 출원인에게 심히 가혹하다 할 것이다. 따라서 일정 범위에서 그 흠결을 치유할 기회를 부여하여 출원인의 권리를 보호하는 한편 불필요한 출원전수를 감소시켜 심사를 촉진하기 위해 보정을 인정하고 있다.

2) 다만 지식재산처의 심사지연이라는 폐해를 방지하기 위해 보정의 시기적 제한을 두고 있다. 또한 보정의 소급효가 인정되어 제3자에게 불측의 손해를 끼치는 것을 방지하는 한편 심사절차의 원활한 진행을 위하여 내용적 제한을 두고 있다.

III. 보정의 종류

출원의 보정은 특허에 관한 절차의 방식에 흠결 또는 불비한 사항이 있는 경우 이를 보충·정정하는 「절차보정(방식보정)」과 특허출원의 명세서 또는 도면의 내용에 흠결 또는 불비한 사항이 있는 경우 이를 보충·정정하는 「실체보정(명세서 또는 도면의 보정)」이 있다. 즉 발명의 내용을 보정하면 실체보정, 그 이외의 사항을 보정하면 절차보정이라고 할 수 있다. 한편 절차보정에는 절차의 계속 중 출원인의 의사에 의하여 스스로 자진하여 보정하는 「의사에 의한 보정」과 방식심사 결과 지식재산처장 등의 보정명령에 따라 행하는 「명령에 의한 보정」이 있다.

31) 특허등록 후 정정심결이 확정되면 정정된 내용대로 소급효가 인정(法 136⑩)됨에 비취보다라도 보정에 대하여 소급효를 인정하는 것은 당연하다고 할 것이다.

그에 반해 실제보정은 제47조제1항의 보정할 수 있는 시기에 출원인의 의사에 의하여 스스로 자진하여 보정하는 「의사에 의한 보정」만 가능할 뿐이다. 다만 심사관은 특허결정을 할 때 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 신규사항이 추가되지 아니한 범위(法 47②)에서 직권보정할 수 있다(法 66의2). 절차보정에 대해서는 「PART 1 제7장 제5절 방식심사」부분에서 설명하였으므로 이하에서는 실제보정을 구체적으로 살펴본다.

【표 3-2】 보정의 종류

대상 \ 방식	의사에 의한 보정	명령에 의한 보정
절차보정	○(절차 계속 중)	○(지식재산처장이 정한 기간 내)
실체보정	○(제47조제1항의 시기)	×

제2절 실제보정 (명세서 또는 도면의 보정)

제47조 【특허출원의 보정】

- ① 특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만, 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 “거절이유통지”라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간(제3호의 경우에는 그 때)에만 보정할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
 1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
 2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간
 3. 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우: 청구할 때
- ② 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3 제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다.
- ③ 제1항제2호 및 제3호에 따른 보정 중 청구범위에 대한 보정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당한는 경우에만 할 수 있다.
 1. 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우
 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
 4. 제2항에 따른 범위를 벗어난 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나 되돌아가면서 청구범위를 제1호부터 제3호까지의 규정에 따라 보정하는 경우
- ④ 제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다.
- ⑤ 외국어특허출원인 경우에는 제1항 본문에도 불구하고 제42조의3제2항에 따라 국어번역문을 제출한 경우에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제51조 【보정각하】

- ① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>
1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우: 그 직권보정 전에 한 보정
 2. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우: 취소된 특허결정 전에 한 보정
 3. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정
- ② 제1항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정(제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 제외한다)에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제1관 의 의

「실체보정」이란 명세서 또는 도면의 내용이 불명확하거나 미비한 점이 있는 경우에 그 흠결을 치유하기 위하여 출원인이 행하는 보충·정정을 말한다. 실체보정은 보정시기에 따라 보정범위와 위반시 취급을 달리하고 있다.

제2관 보정시기

I. 원 칙(자진보정)

특허출원인은 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 자진하여 보정할 수 있다(法 47①본문). 다만 제63조제1항에 따른 거절이유 통지를 받은 후에는 다음의 예외에서 정하는 기간(재심사 청구를 하는 경우에는 재심사 청구를 할 때)에만 보정할 수 있다.³²⁾

32) 다만 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 특허결정의 등본을 송달받은 날로부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간까지 재심사 청구를 할 수 있도록 하여 특허결정등본을 송달받은 후에 보정을 인정하고 있으므로, 제47조제1항 본문의 “특허결정의 등본을 송달하기 전까지”는 입법불비라고 여겨진다. 私見으로는 제47조제1항을 다음과 같이 개정하는 것이 적절해 보인다.

① 특허출원인은 제66조에 따른 특허여부결정의 등본을 송달하기 전과 제67조의2에 따른 재심사를 청구하는 경우 그 청구할 때까지 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다. 다만 특허여부결정의 등본을 송달하기 전까지라도 제63조제1항에 따른 거절이유통지(이하 “거절이유통지”라 한다)를 받은 후에는 다음 각 호의 구분에 따른 기간에만 보정할 수 있다.

1. 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 제2호의 거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간

II. 예 외

1. 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅰ)

특허출원인은 최초거절이유통지를 받은 경우에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 할 수 있다(法 47①Ⅰ).³³⁾ 「최초거절이유통지」란 거절이유통지(거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지는 제외한다)를 최초로 받거나 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 말한다. 「최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지」란 i) 특허출원한 발명에 원시적으로 거절이유가 존재하였는데 심사관이 간과한 후 나중에 이를 발견한 경우에 그 거절이유에 대한 거절이유통지, ii) 심사관이 직권 재심사를 하려고 특허출원인에게 특허결정을 취소한다는 사실을 통지한 경우에(法 66의3②) 그 통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지 또는 iii) 거절결정불복심판에서 취소환송되었는데 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지를 말한다.

2. 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ)

특허출원인은 최후거절이유통지를 받은 경우에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 할 수 있다(法 47①Ⅱ). 「최후거절이유통지」란 최초거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지를 말한다. 다만 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 보정은 후술하는 바와 같이 보정범위가 더욱 제한된다는 점에서 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간의 보정과 차이가 있다.

3. 재심사를 청구하는 경우 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ)

출원인은 재심사를 청구하는 경우 재심사를 청구할 때 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다(法 47①Ⅲ). 즉 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사를 청구할 수 있다(法 67의2①).

2. 거절이유통지(제66조의3제2항에 따른 통지를 한 경우에는 그 통지 전의 거절이유통지는 제외한다)에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 받은 경우: 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간

33) 의견서의 제출기간은 통상적으로 4개월 이내로 지정하되 제15조제2항에 따라 출원인의 지정기간연장신청이 있는 경우 연장이 가능하다. 다만 연장 기간이 4개월을 초과하는 경우에는 심사관의 기간연장승인여부에 따라 연장이 결정된다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 4105면).

제3관 보정범위

I. 자진 또는 최초거절이유통지에 대응(法 47①본문, I)한 보정

1. 의 의

제47조제1항의 실체보정을 할 수 있는 시기의 명세서 또는 도면의 보정은 신규사항이 추가되지 아니하는 범위에서만 가능하다. 즉 실체보정을 할 때는 언제나 신규사항(new matter)이 추가되지 아니하여야 한다. 「신규사항의 추가」란 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나서 보정하는 것을 말한다(法 47②전단).

2. 취 지

신규사항을 추가하는 보정을 인정하는 경우 완벽한 명세서 또는 도면을 작성하기 위해 노력한 결과 늦게 출원한 출원인이 명세서 또는 도면을 불충한 채로 적은 후에 신규사항을 추가하는 보정을 한 출원인보다 불리하게 되기 때문에 출원인 간의 형평성을 위하여 이를 금지하고 있다.

3. 판 단

(1) 판단대상

신규사항추가인지 여부는 보정된 명세서 또는 도면과 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면을 비교하여 판단한다. 요약서는 명세서 또는 도면에 해당하지 않으므로 신규사항 추가 여부를 판단하는 기준이 되는 최초 명세서 등에 포함되지 아니한다.

(2) 판단방법

명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다(法 47②전단). 여기서 「최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항」이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 출원 시의 기술상식에 비추어 보아 보정된 사항이 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 말한다.³⁴⁾³⁵⁾ 즉 통상의 기술자가 최초 명세서 또는 도면에

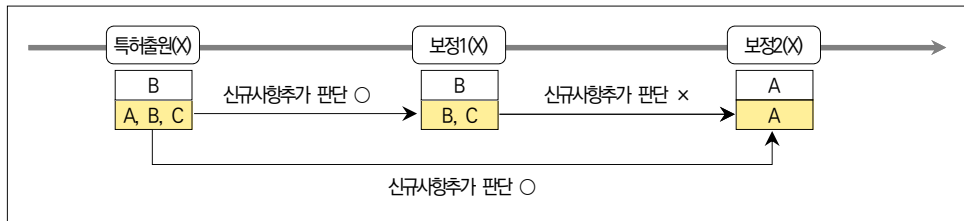
34) 유럽의 특허심사 실무는 “출원내용 전체에 걸쳐 변경이(추가, 정정, 혹은 삭제의 어느 것이라 하더라도) 통상의 지식을 가진 사람이 보아 명시되어 있는 것으로부터 넘지시 포함되어 있다고 해석되는 것을 감안하여도, 원출원의 내용으로부터 직접적 또한 일의적으로(directly and unambiguously) 도출되지 않을 때는, 보정은 원출원의 개시 내용을 초과하는 사항을 도입하는 것으로 허가되지 않아야 한다”라고 되어 있다. 나아가 PCT 가이드라인은 “당초의 출원에 명시적으로 존재(expressly present)하고 있지 않거나 당초에 본래적으로 존재하였다(inherent present)고 할 수 없는 정보를 도입하는 보정은 당초의 출원 내용을 넘는 사항을 추가하는 보정이라고 판단된다. 여기에서 ‘inherent present’란 명시적인 기재는 없지만 당초의 개시에 접한 통상의 기술자라면 빠진 사항이 의미하는 바가 필연적으로 명확하게 되는 경우를 의미한다”라고 하고 있다. 그리고 일본 東京高等裁判所 2003. 7. 1. 판결[平成 14년(行ケ)제3호]은 “출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는

도면에 기재된 사항이란 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 현실로 기재되어 있는 경우 또는 기재되어 있지 않더라도 현실로 기재되어 있는 것으로부터 자명한 경우에 한정된다. 따라서 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 현실로 기재된 것으로부터 자명한 사항이라고 하기 위해서는 현실로는 기재가 없더라도 현실로 기재된 것을 접한 통상의 기술자라면 그 사항이 거기에 기재된 것과 마찬가지로 이해하는 사항이라야 하고, 그 사항에 대하여 설명을 받으면 간단하게 이해할 수 있다고 하는 정도로는 자명이라고 할 수 없다"라고 판시하여 주지관용기술이라는 점만으로는 이를 추가하는 보정이 허용되지 않는다는 취지를 밝히고 있다(한규현, "명세서의 보정과 신규사항의 추가금지(대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130 판결)", 대법원판례해설 제70호, 법원도서관, 2008, 102-112면).

35) 심사 실무상 신규사항추가 판단의 구체적 예는 다음과 같이 취급한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사 기준(예규 제140호)」, 2025, 4202-4206면).

- ① 우선권주장의 기초가 된 제1국 출원 또는 선출원은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 해당되지 않으므로 신규사항의 추가 여부 판단의 기초로 사용할 수 없다.
- ② 요약서는 명세서 또는 도면에 해당하지 않으므로 신규사항 추가 여부를 판단하는 기준이 되는 최초 명세서 등에 포함되지 아니한다.
- ③ 미완성발명을 완성시키는 보정을 한 경우 그 보정은 신규사항을 추가한 것으로 된다.
- ④ 상위개념을 하위개념으로 보정하여 범위를 축소하였더라도(재질이나 용도한정의 경우 포함), 최초 명세서 등에 그 하위개념이 개시되어 있거나, 출원 시의 기술상식을 참작하여 통상의 기술자에게 그러한 상위개념이라고 하면 보정된 하위개념으로 바로 인식될 정도가 아니면 신규사항 추가에 해당한다.
- ⑤ 하위개념을 상위개념으로 보정하는 경우, 그 상위개념 중에 최초 명세서 등의 하위개념과 비교하여 발명의 효과 또는 과제해결 여부가 달라지는 부분이 포함되면 신규사항의 추가에 해당한다. 일부 구성을 삭제하는 경우에도 그 삭제되는 구성이 최초 명세서 등에서 과제해결을 위하여 필수적인 것으로 기재된 것이라면 신규사항추가에 해당한다. 다만 과제해결과 관계없이 임의로 부가된 사항을 삭제하여 상위개념이 되는 경우라면 최초 명세서 등 범위 내의 보정으로 볼 수 있다.
- ⑥ 수치범위를 추가하거나 변경 또는 감축하는 보정의 경우에, 새로운 수치범위가 최초 명세서 등에 기재되어 있지 않고, 최초 명세서 등의 기재로부터 자명하지 않은 경우에는 신규사항 추가에 해당한다.
- ⑦ 청구항에서 일정한 사항을 제외하는 보정(이른바 '제외 클레임' 보정)은, 그러한 제외하는 한정이 최초 명세서 등에 기재된 것으로 볼 수 없는 새로운 기술적 사항이 도입되는 것이 아니라면 허용된다. 특히 의료방법 관련 발명의 대상이 사람인지 동물인지가 명시되어 있지 아니한 경우, 그 발명이 특정 동물만을 대상으로 하는 것은 아닌 것이 자명할 때 사람에게 해당하는 부분을 삭제하기 위하여 한정하는 보정은 신규사항이 추가된 것으로 보지 않는다.
- ⑧ 최초 명세서 등에 독립적으로 기재된 개별구성이나 실시예들을 하나의 발명으로 결합하는 보정을 하는 경우, 그러한 결합이 최초 명세서 등에 언급되어 있거나 통상의 기술자가 출원 시의 기술상식에 비추어 당연히 상정할 수 있는 정도가 아니면 신규사항 추가에 해당한다.
- ⑨ 일반적으로 실시예 또는 시험예를 추가하는 보정은 신규사항 추가에 해당한다. 다만 최초 명세서 등의 기재 범위 내로 볼 수 있는 경우에는 신규사항 추가에 해당하지 않는다.
- ⑩ 일반적으로 발명의 새로운 효과를 추가하는 보정은 신규사항 추가에 해당한다. 다만 최초 명세서 등에 기재된 발명의 구성 등으로부터 통상의 기술자가 당연히 예측할 수 있는 정도이거나 최초 명세서 등에 기재된 발명의 구성이 그러한 효과를 나타낸다는 것이 해당 기술분야에서 잘 알려진 사실인 경우에는 신규사항 추가에 해당되지 않는다.
- ⑪ 선행기술 문헌명을 명세서에 단순히 추가하는 보정과 선행기술 문헌명과 함께 그 문헌 내용의 간략한 요약만을 추가하는 보정은 신규사항 추가로 보지 않는다. 다만 미완성 발명이 완성되도록 하거나 발명의 실시 등에 관한 발명의 설명 기재요건 미비를 해소하기 위하여 선행기술문헌의 내용을 추가하는 보정, 또는 출원발명의 이점을 제시하기 위하여 출원발명과 선행기술을 비교하는 내용을 추가하는 보정은 일반적으로 신규사항 추가에 해당한다.
- ⑫ 통상의 기술자가 최초 명세서 또는 도면에 오기가 있음을 인식할 수 있고, 그러한 오기가 무엇으로 정정되어야 하는지도 명확히 알 수 있다면, 그와 같은 오기의 정정은 신규사항 추가로 보지 않는다. 또한 명세서 또는 도면 중에 상충하는 2개 이상의 기재 중 어느 것이 올바른 지가 최초 명세서 등의 기재로부터 통상의 기술자에게 자명한 경우, 그 올바른 기재로 일치시키는 보정은 신규사항 추가가 아니다.

기재된 사항에 의하여 판단한 결과 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 기재되어 있다고 자명하게 이해할 수 있는 사항은 신규사항이 아니다. 한편 보정된 사항이 주지관용기술이더라도 그것이 통상의 기술자가 최초 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 아니라면, 이를 추가하는 보정은 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 것이어서 허용될 수 없다.³⁶⁾



【그림 3-10】 제47조제2항의 신규사항추가 판단

II. 최후거절이유통지에 대응하거나 재심사를 청구할 때(法 47①ⅡⅢ)(최후거절이유통지이후)의 보정

1. 의 의

최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 및 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ)(최후거절이유통지이후) 보정은 신규사항추가금지(法 47②)라는 보정범위를 만족하여야 함은 물론 청구범위 보정범위의 제한(法 47③)도 만족하여야 한다. 구체적으로 보정 중 청구범위에 대한 보정은 i) 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 및 iv) 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 보정(신규사항추가한 보정)에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나, 되돌아가면서 청구범위를 i) 내지 iii)에 따라 보정하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 할 수 있다.

2. 취 지

최후거절이유통지이후의 보정범위를 더 제한하는 이유는 이미 진행한 심사결과를 유효하게 활용하여 심사촉진을 도모하기 위함이다.

36) 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130.

3. 보정범위의 제한

(1) 청구범위를 감축하는 경우(法 47③Ⅰ)

청구범위의 감축이란 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하는 것을 말한다. 여기서 「청구항을 한정」하는 경우는 i) 택일적으로 기재된 요소의 삭제,³⁷⁾ ii) 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경,³⁸⁾ 또는 iii) 수치범위의 축소 등을 말한다. 「청구항을 삭제」하는 경우는 청구항을 직접 삭제³⁹⁾하는 경우뿐만 아니라 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항수를 감소⁴⁰⁾하는 것도 포함된다. 한편 「청구항에 부가」하는 경우는 청구항의 구성요소를 직렬적으로 부가하는 것⁴¹⁾을 의미한다.⁴²⁾

(2) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우(法 47③Ⅱ)

「잘못 기재된 사항을 정정하는 경우」란 정정 전의 기재내용과 정정 후의 기재내용이 동일함을 객관적으로 인정할 수 있는 경우로서, 명세서 또는 도면의 기재가 오기인 것이 명세서의 기재 내용으로 보아 자명한 것으로 인정되거나, 주지의 사항 또는 경험칙으로 보아 명확한 경우에

37) 예를 들면 「A 또는 B」라고 하는 택일적 기재 요소 중 A를 삭제하거나 B를 삭제하는 경우이다. 한편 아래의 【예】와 같이 택일적으로 기재된 구성요소의 추가하는 보정은 제47조제3항제1호의 요건을 만족하지 못한 것으로 하여 보정각하된다.

【예】 Fe 또는 Al로...→ Fe, Al 또는 Cu로....

38) 예를 들면 필기구를 만년필로 보정하는 경우이다.

39) 청구항을 신설하였다고 하더라도 항 정리에 따른 불가피한 경우에는 청구범위의 감축에 해당한다.

【예】 (보정 전)

【청구항 1】 구성요소 A, B, C 로 이루어진 물건

【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 구성요소 A 는 a1, a2, a3 중 하나로 이루어진 물건

(보정 후)

【청구항 1】 삭제

【청구항 2】 (정정) 구성요소 a1, B, C 로 이루어진 물건

【청구항 3】 (청구항 2 정정) 구성요소 a2, B, C 로 이루어진 물건

【청구항 4】 (청구항 2 정정) 구성요소 a3, B, C 로 이루어진 물건

40) 아래 【예】와 같이 인용항을 추가하는 보정은 특허법 제47조제3항제1호의 요건을 만족하지 못한 것으로 하여 보정각하된다.

【예】 청구항 1에 있어서...→ 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서....

41) 예를 들면 「A에 B를 부착시킨 병따개」라는 기재를 「A에 B를 부착시키고 다시 B에 C를 부착시킨 병따개」로 하는 경우이다. 이때 C의 부가가 신규사항 추가금지에 저촉되지 아니하여야 한다. 한편 병렬적 부가란 기재요소를 택일적으로 부가하는 것을 말하며(예컨대 「볼트」를 「볼트 또는 리벳」으로 하는 경우) 이러한 보정은 청구범위를 확장하는 것이기 때문에, 적법한 보정으로 인정되지 아니한다. 구성요소의 직렬적 또는 병렬적 부가/삭제에 따른 청구범위의 감축/확장을 표로 정리하면 다음과 같다.

보정 \ 구성요소	직렬적 요소(and)	병렬(택일)적 요소(or)
부가	청구범위의 감축	청구범위의 확장
삭제	청구범위의 확장	청구범위의 감축

42) 다음과 같은 경우에는 제47조제3항제1호에 해당하지 아니한 것으로 본다(지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 4208면).

그 오기를 정확한 내용의 자구나 어구로 고치는 것을 말한다.⁴³⁾ 예를 들어 청구항을 삭제한 후 삭제된 청구항을 인용하는 다른 청구항의 인용번호를 변경하거나 인용내용을 추가하는 보정은 잘못 기재된 사항을 정정하는 것으로 보아 이를 인정한다.⁴⁴⁾

(3) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우(法 47③Ⅲ)

「분명하지 아니하게 기재된 사항」이란 문리상 그 자체 의미가 분명하지 아니하게 기재된 사항으로 i) 청구항의 기재 그 자체의 문언상 의미가 불명료한 것, ii) 청구항 자체의 기재내용이 다른 기재와의 관계에 있어서 불합리한 것 또는 iii) 청구항 자체의 기재는 명료하지만 청구항에 적은 발명이 기술적으로 정확하게 특정되지 않고 불명료한 것 등을 말한다. 실체적으로는 달라지지 않으면서 청구항을 전반적으로 재기재하는 보정은 다른 사정이 없는 한 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우로 보아 제47조제3항제3호에 해당하는 보정으로 취급한다.⁴⁵⁾

구 분	구체적 예
하위개념의 기재로부터 상위개념의 기재로의 변경	당초: ...스프링으로 지지되는..... →탄성체로 지지되는...
직렬적 구성요소의 삭제	당초: A, B, C, D로 구성된 자동차 → A, B, C로 구성된 자동차
직렬적 구성요소의 가감	당초: A, B, C로 구성된 장치 → B, C, D, E로 구성된 장치
수치범위의 확장	당초: 10~50°C의 온도에서... → 10~70°C의 온도에서....
구성요소의 치환	당초: 볼트로 결합시킨... → 리벳으로 결합시킨....
수치범위의 변경	당초: 10~20°C의 온도에서... → 30~50°C의 온도에서....

43) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 4210면.

44) 아래 【예】와 같이 최초보정서에서 삭제된 청구항을 인용하는 청구항 4는 누가 보더라도 명백히 잘못된 기재임이 분명하므로, 이를 최후보정서에서 보정한 것은 항의 정리 차원에서 보정하는 것으로 본다.

【예】【최초출원서】

청구항 1 : A+B

청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C를 부가

청구항 3 : 청구항 2에 있어서, D를 부가

청구항 4 : 청구항 2에 있어서, E를 부가

【최초거절이유통지】청구항 1은 작동위주, 불명료

【최초보정 후의 명세서】

청구항 1 : A+B+C

청구항 2 : 청구항 2에 있어서, D를 부가

청구항 3 : 삭제

청구항 4 : 청구항 3에 있어서, E를 부가

【최후거절이유통지】청구항 4는 삭제된 제3항을 인용하고 있음

【최후보정 후의 명세서】

청구항 1 : A+B+C

청구항 2 : 청구항 1에 있어서, D를 부가

청구항 3 : 삭제

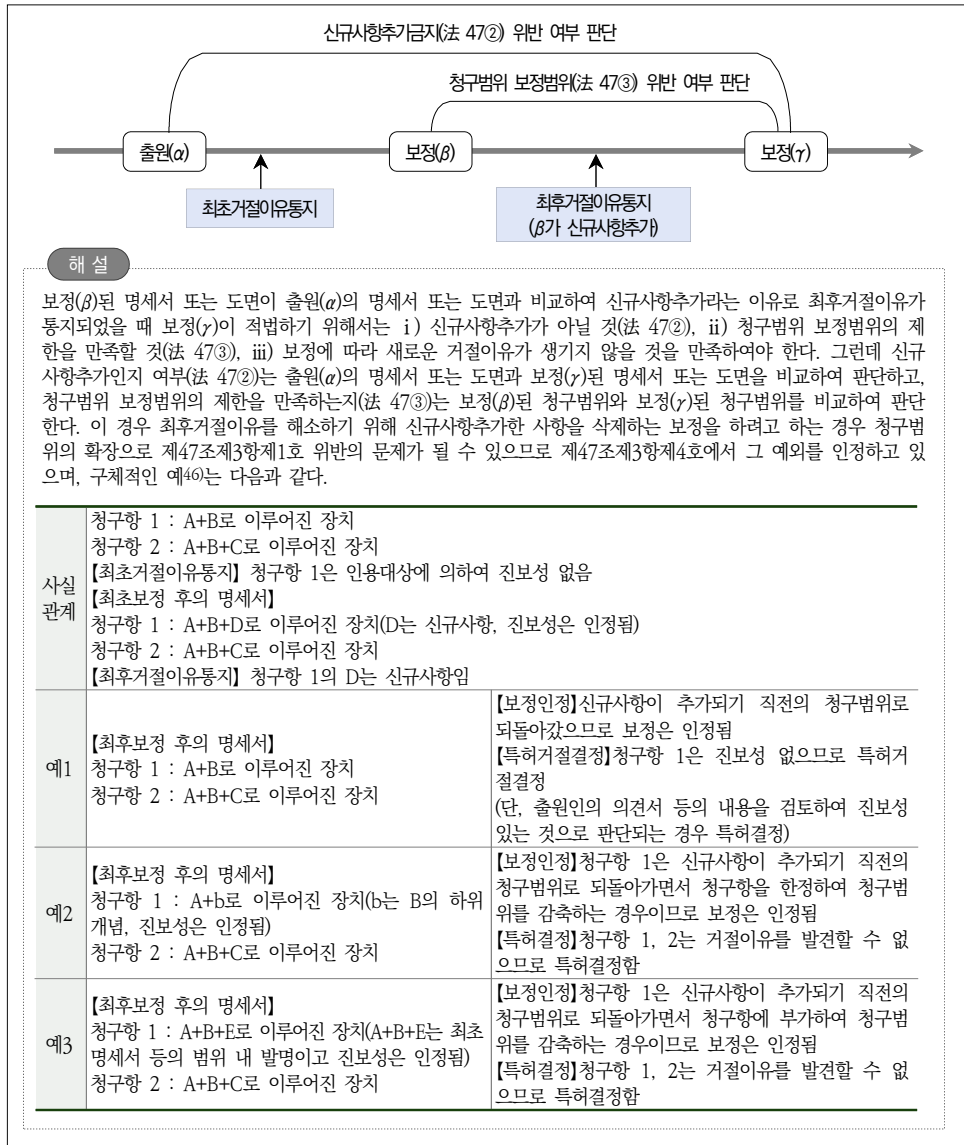
청구항 4 : 청구항 1에 있어서, E를 부가

45) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 4210-4211면.

(4) 신규사항추가한 보정에 대하여 보정 전 청구범위로 되돌아가거나, 되돌아가면서 청구범위를 제47조제3항제1호부터 제3호에 따라 보정하는 경우(法 47③Ⅳ)

1) 최초거절이유통지에 대응하는 보정이 신규사항추가금지 규정(法 47②)에 해당하여 최후 거절이유가 통지된 경우 해당 신규사항을 삭제하고 당초의 청구범위로 되돌아가는 보정을 청구범위의 확장임에도 불구하고 허용하도록 하고 있다. 이를 허용하지 아니하면 거절이유를 해소하기 위해 신규사항을 삭제하는 보정을 하더라도 제47조제3항제1호에 위반되어 보정각하될 수밖에 없고, 이는 출원인에게 너무 가혹하기 때문이다.

2) 다만 출원인이 최후거절이유통지를 극복하기 위해서 다시 보정할 때 청구범위에 대한 보정은 i) 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 및 iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하여야 한다.



【그림 3-11】 제47조제3항제4호의 구체적인 예

46) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 4211면.

제4관 보정의 절차

I. 보정서의 제출

출원인은 보정서를 제출하고 다음 날까지 보정료를 내야 한다(法 82①). 공동출원의 경우 대표자를 선정하여 신고한 경우를 제외하고는 각자가 보정을 할 수 있고(法 11), 임의대리인은 특별히 권한을 위임받지 않더라도 보정을 할 수 있다(法 6).

II. 보정의 취하간주

최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①I) 또는 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①II)에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다(法 47④). 다만 최초거절이유통지를 받기 전(法 47①본문)의 자진 보정의 경우는 이를 종합하여 보정 명세서를 인정한다.⁴⁷⁾⁴⁸⁾

제5관 보정의 효과

I. 적법한 경우의 효과

특허출원의 보정이 적법한 경우에 그 출원은 보정된 내용에 따라 소급하여 출원된 것으로 취급한다. 명문의 규정은 없으나 선출원의 지위를 인정하면서 하자를 치유할 기회를 준다는 보정제도의 취지에 비추어 볼 때 소급효가 인정됨이 타당하기 때문이다.

47) 하나의 특허출원보정단계에서 여러 차례 보정이 있는 경우에 기존의 심사 실무는 이를 종합하여 보정 명세서를 인정하여야 한다는 입장이었으나, 특허법원 2007. 7. 11. 선고 2006허9197 판결은 “뒤에 제출된 보정서가 앞에 제출된 보정서를 보충하는 것으로 보여지는 등의 특별한 사정이 없는 한, 보정기간 등의 절차적 요건을 준수한 보정서 중에서 최후의 것만을 심사하여 보정의 적법성을 판단하여야 한다”라고 하여 기존의 심사 실무와 상반된 입장을 취하였다. 이에 2013. 3. 22. 시행된 현행법(법률 제11654호, 2013. 3. 22. 개정)은 제47조제4항을 신설하여 판례의 입장을 반영하였다.

48) 최초거절이유통지를 받기 전 또는 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 제1차 내지 제4차 보정서를 제출하면 다음과 같이 심사대상 명세서 또는 도면을 인정한다.

보정대상항목	최초출원	최초거절이유통지전 (法 47①본문)		심사대상 명세서 또는 도면	최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①I)		심사대상 명세서 또는 도면
		제1차 보정서	제2차 보정서		제3차 보정서	제4차 보정서	
발명의 설명	◇	◇1	◇2	◇2			◇2
제1항	○		○2	○2	○3		○2
제2항	□	□1		□1	□3	□4	□4
제3항	△			△	△3		△
-							
제10항	☆			☆	☆3	☆4	☆4
도면	☞	☞1		☞1	☞3		☞1

II. 부적법한 경우의 효과

1. 기간을 지난 경우

지식재산청장은 실체보정을 할 수 있는 시기를 지나서 보정서를 제출한 경우 출원인에게 소명기회를 주고 소명하지 않거나 소명이 적법하지 아니하면 해당 보정서를 불수리하여야 한다(施規 11).

2. 보정범위가 부적법한 경우

(1) 자진 및 최초거절이유통지에 대응(法 47①본문, I)한 보정의 경우

신규사항추가금지(法 47②)는 거절이유 중 하나이다. 따라서 심사관은 제66조에 따른 특허 결정등본을 송달하기 전(法 47①본문)의 자진보정이 신규사항추가금지(法 47②) 위반이면 최초 거절이유통지를 하고, 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①I)에 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 위반이면 최후거절이유통지를 한다.

(2) 최후거절이유통지이후(法 47①II III) 보정의 경우

① 원 칙

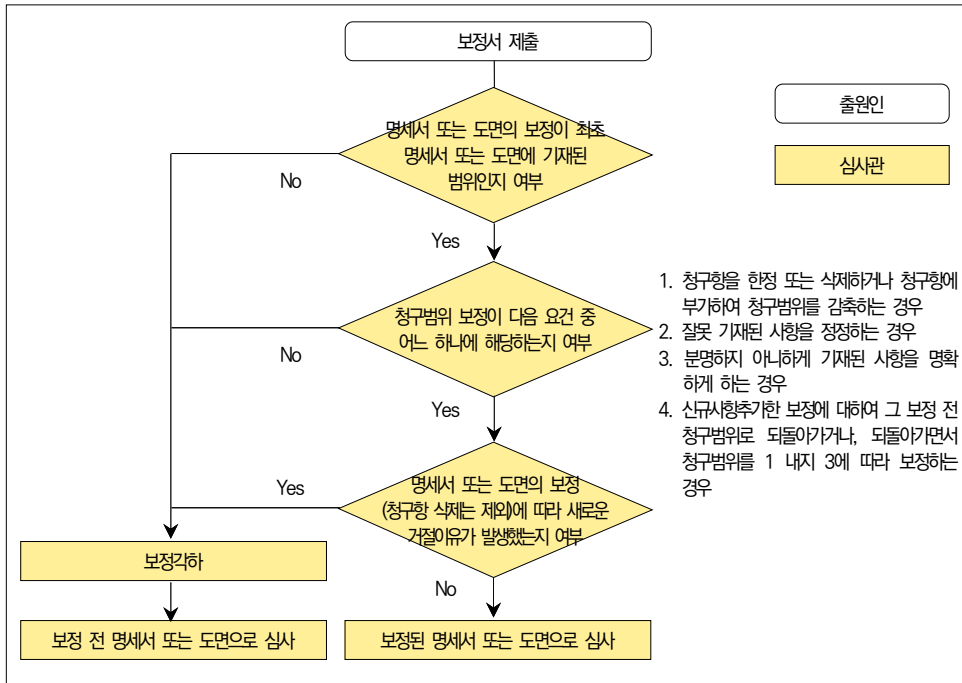
1) 심사단계에서 심사관은 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①II) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①III)(최후거절이유통지이후) 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정(제47조제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되면 서면으로 이유를 붙여서 보정에 대하여 직권으로 각하결정을 한다(法 51①본문, 51②). 이때에는 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니한다(法 63①단서, 法 170① 준용 51①).

2) 「보정각하」란 보정을 인정하지 아니한 행정처분으로서 보정각하결정을 한 경우 심사관은 보정 전의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원의 원거절이유가 해소되었는지를 심사한다. 그 결과 심사관은 원거절이유가 해소되지 못한 경우에는 거절이유가 동일하므로 2번의 거절이유통지를 하지 않고 특허출원을 특허거절결정한다.

3) 출원인은 보정각하결정에 대해서는 별도로 불복할 수 없으며, 이후 특허거절결정에 대한 불복심판의 심리 중에 보정각하결정이 부당함을 함께 다룰 수 있다. 다만 i) 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 ii) 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③).

② 예 외

i) 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우 그 직권보정 전에 한 보정, ii) 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 보정, iii) 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정은 보정각하결정을 하지 아니한다(法 51①단서). 또한 iv) 발생한 새로운 거절이유가 직권보정(法 66의2)을 할 수 있는 경우라면 심사관은 보정을 승인하고 이후 절차를 진행할 수 있다.

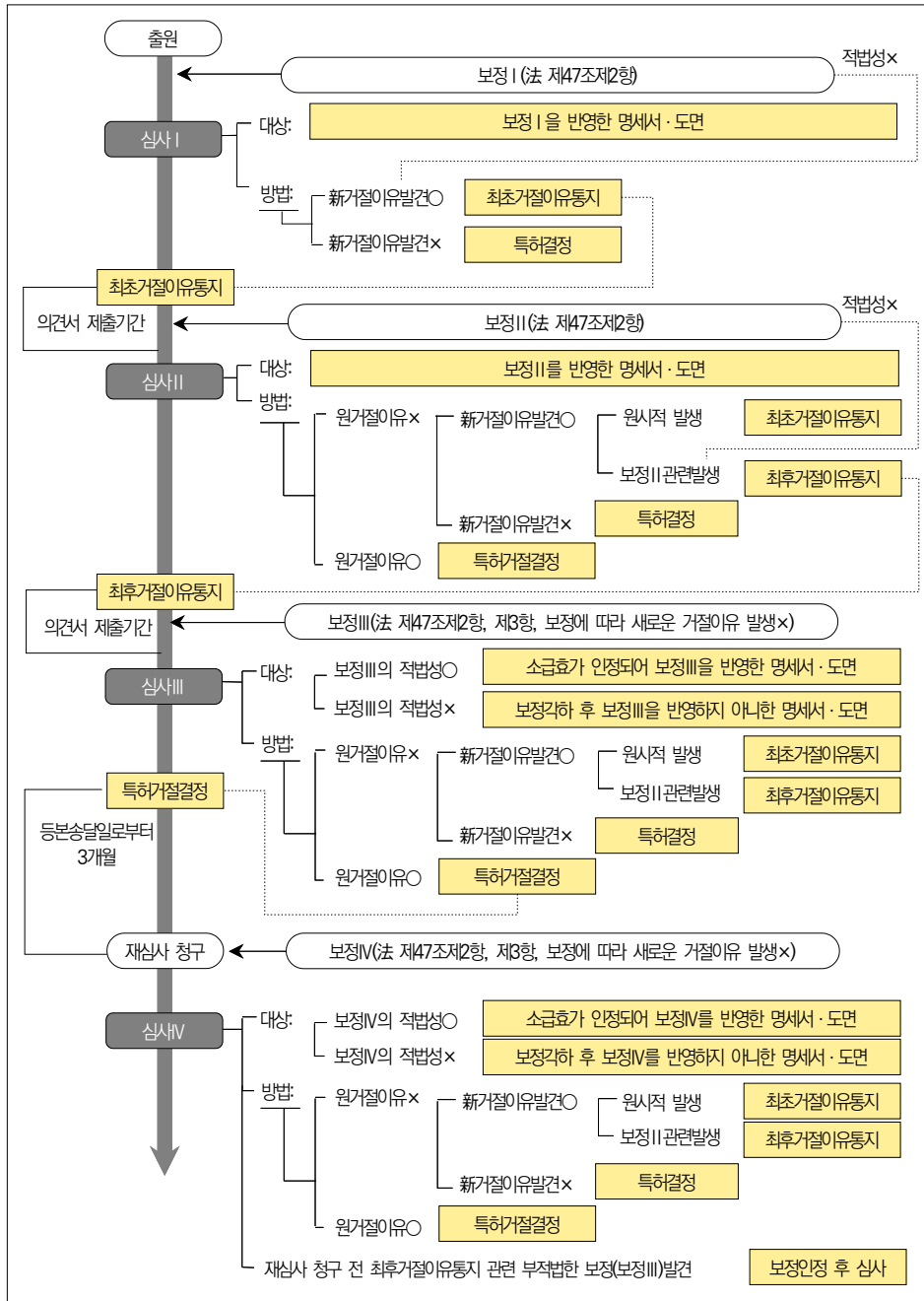


【그림 3-12】 최후거절이유통지이후 보정의 적법성에 대한 판단 흐름도

3. 착오로 등록된 경우

1) 최후거절이유통지이후(法 47①ⅡⅢ) 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정됨에도 불구하고 간과되어 보정이 적법함을 전제로 착오로 특허등록이 된 경우에 문제이다. 신규사항추가금지(法 47②전단)에 위반되면 특허무효사유(法 133①)이다. 그러나 청구범위 보정범위제한(法 47③)에 위반되면 제47조제3항이 심사의 신속성을 위해 둔 규정이기 때문에 형식적 하자에 불과하고, 신규사항추가금지(法 47②전단) 위반은 아닌데 제47조제3항만 위반이라는 것은 자신의 최초 명세서 또는 도면의 범위를 벗어난 것은 아니어서 일반인의 이익을 해하지 아니하므로 별도의 제재를 하지 아니함이 원칙이다.

2) 한편 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하면 새로운 거절이유를 이유로 특허무효사유(法 133①)이다. 예를 들면 최후거절이유통지에 대한 보정 결과 진보성 위반이라는 새로운 거절이유가 발생하여 보정이 인정되어서는 아니 됨에도 불구하고 그대로 특허된 경우 진보성 위반(法 29②)으로 특허무효사유(法 133①)가 된다. 다만 특허무효사유는 제한열거적이기 때문에 특허무효사유가 아닌 거절이유(제42조제3항제2호, 제42조제8항, 제45조 위반)는 별도의 제재를 할 수 없다.



【그림 3-13】 심사단계에서 보정의 처리절차

제6관 외국어특허출원의 실체보정

I. 보정시기의 제한

일반적으로 제66조에 따른 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 보정할 수 있음에도 불구하고 외국어특허출원인 경우에는 국어번역문을 제출한 경우(法 42의3②)에만 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다(法 47⑤). 한편 명세서 또는 도면을 보정한 경우에는 국어번역문을 교체할 수 없다(法 42의3③ I).

II. 보정범위의 제한

제47조제2항의 신규사항추가금지와 관련하여, 외국어특허출원에 대한 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다.⁴⁹⁾ 또한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분을 제외한다)⁵⁰⁾에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(法 47②).⁵¹⁾ 즉 명세서 또는 도면의 보정은 원문(외국어 명세서 또는 도면) 및 국어번역문 범위이어야 한다.⁵²⁾

49) 외국어 특허출원(외국어 국제특허출원도 포함)에 대해서는 출원인이 원문내용을 번역하여 제출한 국어번역문을 기준으로 보정의 신규사항 추가 여부를 심사하는 것을 원칙으로 하되, 외국어명세서 등과 심사대상 명세서 등의 일치성에 의의가 가는 경우 외국어명세서 등과 심사대상 명세서 등을 대조 확인한다. 외국어 명세서 등을 대조 확인해야 하는 사례 유형으로는, i) 심사대상 명세서 등에 원문 신규사항이 있다는 정보제공 등이 있고, 그 내용을 검토한 결과 심사대상 명세서 등에 원문 신규사항이 존재한다는 합리적 의문이 발생한 경우, ii) 국제특허출원의 국제예비심사 보고서에 신규사항에 대한 견해가 있거나 패밀리 출원의 심사결과를 확인하는 과정에서 상이한 내용의 발명이 패밀리 출원에 기재된 경우 등이 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5509-5510면).

50) 최종 국어번역문에서는 도면(설명부분 제외)가 포함되어 있지 않으므로(法 42의3①) 이를 다시 제47조제2항후단에서 기술하고 있는 것이다. 만일 이와 같이 규정되어 있지 않으면 도면(설명부분 제외) 범위에서 보정하는 것은 신규사항추가에 해당하게 된다.

51) 번역문의 신규사항이 추가되는 구체적인 사례로는, i) 오역 정정이 없는 경우에는 제42조의3제2항에 규정된 국어번역문에 기재된 사항의 범위가 아닌 사항이 심사대상 명세서 등에 추가된 보정인 경우, ii) 오역 정정이 있는 경우에는, 오역정정에 의하여 정정된 최종 국어번역문의 범위에 기재되지 않은 사항이 심사대상 명세서 등에 추가된 보정인 경우가 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5506-5507면).

52) 오역의 정정과 관련된 신규사항 추가금지 판단의 구체적인 예는 다음과 같다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5516-5517면 참조).

【표 3-3】 외국어특허출원에 대한 신규사항추가(法 47②) 판단방법의 예시

원 문 (Ca)(A)	국어번역문 (칼륨)(B)	오역정정 (칼슘)(C)	명세서보정 (칼슘)(D)	신규사항추가의 판단
○	○	-	-	B가 A(法 47②전단)와 B(法 47②후단)의 기재된 사항의 범위를 만족했는지 여부에 의하여 판단 → 제47조제2항 전단에 위반됨
○	○	○	-	B가 A(法 47②전단)와 C(法 47②후단)의 기재된 사항의 범위를 만족했는지 여부에 의하여 판단 → 제47조제2항 전단과 후단에 위반됨
○	○	-	○	D가 A(法 47②전단)와 B(法 47②후단)의 기재된 사항의 범위를 만족했는지 여부에 의하여 판단 → 제47조제2항 후단에 위반됨
○	○	○	○	D가 A(法 47②전단)와 C(法 47②후단)의 기재된 사항의 범위를 만족했는지 여부에 의하여 판단 → 제47조제2항 후단에 위반되지 아니함

Ⅲ. 신규사항추가금지(法 47②) 위반의 취급

1. 등록 전

1) 심사관은 제66조에 따른 특허결정등본을 송달하기 전(法 47①본문)의 자진보정이 원문 및 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어난 신규사항추가금지(法 47②) 위반이면 최초거절 이유통지를 하고, 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①I)에 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 위반일 때 최후거절이유통지를 한다.⁵³⁾

사례					해설
원문	국어 번역문	오역 정정	명세서 보정	심사 대상	
A	B	C	C	C	오역정정과 함께 명세서 보정을 B→C로 한 경우, 심사대상 명세서 등(C)은 원문(A)의 범위를 벗어났으므로 원문 신규사항 위반이 된다. 한편 오역정정이 적합하지 아니하더라도 별도의 보정명령을 하지 아니한다.
A	A	B	-	A	명세서의 보정없이 오역정정만 A→B로 한 경우, 심사대상 명세서 등(A)은 정정된 국어번역문(B)의 범위를 벗어났으므로 번역문 신규사항 위반이 된다.
A	B	C	D	D	오역정정을 B→C로 하고 명세서 보정을 B→D로 한 경우, 심사대상 명세서 등(D)은 원문(A) 및 정정된 국어번역문(C)의 범위를 벗어났으므로 원문 및 국어번역문 신규사항 위반이 된다. 출원인은 정정된 국어번역문을 다시 오역정정(C→A)하고, 명세서 등도 보정(D→A)하여 원문 및 국어번역문 신규사항 위반 거절이유를 해소해야 한다.

53) 번역문 신규사항을 지적받았을 때 출원인의 대응방안은 다음과 같다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5507면).

2) 또한 심사관은 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ)(최후거절이유통지이후) 보정이 원문 및 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어나 신규사항추가금지(法 47②) 위반이면 서면으로 이유를 붙여서 보정에 대하여 직권으로 각하결정을 한다(法 51①②). 출원인은 보정각하결정에 대해서는 별도로 불복할 수 없으며, 이후 특허거절결정에 대한 불복심판의 심리 중에 보정각하결정이 부당함을 함께 다룰 수 있다. 다만 i) 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 ii) 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③).

2. 등록 후

등록 후에는 원문의 범위를 벗어난 보정(法 47②전단)의 경우 특허무효사유(法 133①)에 해당한다. 국어번역문의 제출은 실제적인 문제라기보다는 심사관과 일반 공중이 정확한 내용을 알기 위한 철차적인 문제에 해당하므로 제47조제2항 후단의 국어번역문에 기재된 사항의 범위를 벗어난 보정은 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)에만 해당하고, 특허무효사유(法 133①)에는 해당하지 않는다.

제7관 국제출원의 실체보정

I. 국제단계에서의 실체보정

1. 국제조사보고서를 받은 후의 보정(PCT 제19조 보정)

(1) 보정의 시기 및 대상

출원인은 국제조사보고서를 받은 후, 즉 국제조사기관이 국제사무국 및 출원인에게 국제조사보고서를 송부한 날로부터 2개월의 기간 또는 우선일로부터 16개월 중 늦게 만료하는 기간에 국제사무국에 보정서를 제출함으로써 국제출원의 청구범위에 대하여 1회만 보정할 수 있다. 동시에 출원인은 보정의 내용 및 동 보정이 발명의 설명과 도면에 미칠 수 있는 영향에 대하여 PCT 규칙이 정하는 바에 따라 간단한 「설명서(statement)」를 제출할 수 있다. 이 경우 보정은 출원 시 국제출원의 개시된 범위를 넘어서는 아니되지만 지정국의 국내법령이 공개된 범위를 넘어서는 보정을 허용하고 있는 경우에는 해당 지정국에 있어서는 어떠한 영향도 미치지 아니한다(PCT 19).

-
- i) 국어번역문 신규사항에 해당되지 않는다고 의견서로 주장한다. 이 경우 의견서에 의하여 심사관이 국어번역문 신규사항이 아니라고 판단되면 거절이유가 해소된다.
 - ii) 일반출원에서의 신규사항의 경우와 마찬가지로, 지적받은 국어번역문 신규사항에 대한 사항을 명세서 등을 보정하여 삭제한다.
 - iii) 국어번역문에 오역이 있어 발생한 신규사항이면 설명서를 첨부한 오역정정서를 제출하고, 의견서에 지적받은 국어번역문 신규사항에 대한 기제가 국어번역문의 오역정정에 따라 해소되었음을 밝힌다.

(2) 보정서 및 설명서에 대한 국어번역문 또는 사본의 제출

① 청구범위가 원문에 대한 국어번역문 제출 전에 보정된 경우

1) 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다(法 201②).

2) 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 경우에는 제204조제1항과 제2항을 적용하지 아니한다(法 201⑧). 제204조제1항 및 제2항은 PCT 제19조(1)에 따른 보정서에 대한 국어번역문을 국제출원 시의 청구범위에 대한 국어번역문과 별도로 제출하는 것을 전제로 하고 있으므로 적용될 여지가 없다. 즉 절차의 간소화·비용절감 등을 위해서 국어번역문을 2번 제출할 필요가 없는 것이다.

② 청구범위가 원문에 대한 국어번역문 제출 후에 보정된 경우

1) 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허출원의 청구범위에 관하여 보정을 하거나 설명서를 국제사무국에 제출한 경우에는 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다. 이하 제204조 및 제205조에서 같다) 다음의 어느 하나에 해당하는 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 204①③). 여기서 「기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다」라고 함은 국내서면제출기간의 만료일 전에 심사청구를 한 경우에는 당일(當日)이라 하더라도 심사청구 이후에는 국어번역문을 제출할 수 없음을 의미한다.

i) 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 보정서 또는 설명서의 국어번역문

ii) 국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 보정서 또는 설명서의 사본

2) 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 청구범위가 보정된 것으로 본다. 즉 기준일이 지나기 전임에도 불구하고 국내법의 적용을 받는 보정(아직 국제특허출원의 심사가 진행되지 않았기 때문에 제47조제1항 본문 시기의 자진보정)으로 간주한다(法 204②본문).

3) 다만 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(法 204②단서). 즉 출원인이 제출한 보정서와 국제사무국으로부터 송달된 보정서가 모두 있는 경우 국제사무국으로부터 송달받은 보정서만을 적절한 보정으로 취급하며, 출원인이 보정서를 제출하지 않았더라도 기준일까지 국제사무국으로부터 보정서가 송달되었으면 보정이 있는 것으로 간주한다.

4) 그러나 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 국어번역문 또는 사본을 제출하지 아니하면 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만 국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다(法 204④). 한편 기준일이 지난 후에 제출된 국어번역문은 불수리된다(施規 11).

2. 국제예비심사보고서 작성 전의 보정(PCT 제34조 보정)

(1) 보정의 시기 및 대상

출원인은 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 청구범위, 발명의 설명 및 도면을 횡수에 무관하게 보정하여 그 보정서를 국제예비심사기관에 제출할 수 있으나, 그 보정의 범위는 국제출원에 기술된 범위를 넘어서는 아니 된다(PCT 34(2)(b)). 구체적으로 명백한 착오의 정정을 제외하고, 청구범위의 취하, 발명의 설명상의 일부 삭제 및 서면의 삭제를 포함한 청구범위, 발명의 설명 또는 도면에 대한 모든 변경은 보정으로 간주한다(PCT 규칙 66.5).

(2) 보정서에 대한 국어번역문 또는 사본의 제출

1) 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따라 국제특허출원의 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우 기준일까지 다음의 어느 하나에 해당하는 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 205①).

i) 외국어로 작성된 보정서인 경우 그 보정서의 국어번역문

ii) 국어로 작성된 보정서인 경우 그 보정서의 사본

2) 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다. 즉 기준일 이 지나기 전임에도 불구하고 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주한다. 다만 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(法 205②).

3) 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 국어번역문 또는 사본을 제출하지 아니하면 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따른 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다(法 205③). 한편 기준일이 지난 후에 제출된 국어번역문은 불수리된다(施規 11).

II. 국내단계에서의 실체보정(국제특허출원에 대한 보정의 특례)

1. 보정시기의 제한

1) 국제출원은 국제단계에서 국제사무국 또는 국제예비심사기관에 대하여 보정을 할 수 있으나 국내단계에 있어서는 일정한 제한이 있다. 즉 국제특허출원에 관하여는 다음의 요건을 모두 갖추지 아니하면 제47조제1항에도 불구하고 보정(제204조제2항 및 제205조제2항에 따른 보정은 제외한다)을 할 수 없다(法 208①).

i) 제82조제1항에 따른 수수료를 낼 것

ii) 제201조제1항에 따른 국어번역문을 제출할 것. 다만 국어로 출원된 국제특허출원인 경우는 그러하지 아니하다.

iii) 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사를 청구한 때를 말한다)이 지날 것

2) 이는 기준일이 지나기 전에는 국어번역문 교제에 의하여 동일한 목적을 달성할 수 있기에 국내법에 의한 보정은 최종 국어번역문이 확정된 이후에 허용코자 함이다. 특히 2006. 3. 3. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정)에서는 「기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사를 청구한 때를 말한다」라고 함으로써 심사청구와 동시에 보정할 수 있도록 하였다.

3) 그러나 국제사무국에 대한 보정 또는 국제예비심사기관에 대한 보정이 있는 후에 지식재산처에 제출된 국어번역문 또는 사본은 각각 제204조제2항 또는 제205조제2항에 따라 그 국어번역문 또는 사본에 의하여 보정된 것으로 간주되므로 이 조의 적용을 받지 아니한다. 즉 기준일이 지나기 전에 보정했음에도 불구하고 국어번역문 또는 사본을 제출하였으면 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주한다.

2. 보정범위의 제한

1) 제47조제2항의 신규사항추가금지와 관련하여, 통상의 국내출원의 명세서 또는 도면의 보정은 「특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 「외국어특허출원」에 대한 보정은 「최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(法 47②).

2) 그러나 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 전단을 적용할 때에는 「특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」은 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」으로 보고(法 208③), 제47조제2항 후단을 적용할 때에는 「외국어특허출원」은 「외국어로 출원된 국제특허출원」으로, 「최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」은 「법 제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」으로 본다(法 208④).

3) 즉 외국어로 출원된 국제특허출원의 경우 명세서 또는 도면의 보정은 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 사항의 범위에서 하여야 하고, 「법 제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다. 외국어 출원 제도(국제특허출원을 포함)를 운영하는 미국, 유럽특허청(EPO), 일본 및 중국 등은 출원 시 제출된 원문(외국어 발명의 설명, 청구범위 또는 도면) 기준으로 보정을 할 수 있으나, 우리나라만 국어번역문을 기준으로 하고 있어 번역상의 단순 오역이라도 이를 보정할 수 없어 출원인이 진정한 권리를 취득하지 못하는 문제점이 있었다. 따라서 2015. 1. 1. 시행된 현행법(법률 제12753호, 2014. 6. 11. 개정)에서는 외국어

출원인의 진정한 권리의 보호를 강화하고 국제 추세에 맞게 보정범위를 원문(法 208③)으로 전환하는 한편 보정범위를 원문으로 전환하게 되면 심사 및 제3자의 권리 감시에 어려움이 발생할 수 있으므로, 명세서 보정은 국어번역문의 범위(法 208④)에서도 보정하도록 하고, 심사관은 국어번역문 기준으로 보정의 적합성을 판단할 수 있도록 하였다. 다만 국어번역문의 잘못된 오역의 정정이 가능하므로(法 201⑥) 실질적인 보정 가능 범위는 원문이라고 할 수 있다.

3. 신규사항추가금지(法 47②) 위반의 취급

(1) 등록 전

1) 심사관은 제66조에 따른 특허결정등본을 송달하기 전(法 47①본문)의 자진보정이 원문 및 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어난 신규사항추가금지(法 47②) 위반이면 최초거절이유통지를 하고, 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①I)에 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 위반이면 최후거절이유통지를 한다.

2) 또한 심사관은 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①II) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①III)(최후거절이유통지이후) 보정이 원문 및 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어나 신규사항추가금지(法 47②) 위반이면 서면으로 이유를 붙여서 보정에 대하여 직권으로 각하결정을 한다(法 51①②). 출원인은 보정각하결정에 대해서는 별도로 불복할 수 없으며, 이후 특허거절결정에 대한 불복심판의 심리 중에 보정각하결정이 부당함을 함께 다룰 수 있다. 다만 i) 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 ii) 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③).

(2) 등록 후

등록 후에는 원문의 범위를 벗어난 보정(法 47②전단)의 경우에 특허무효사유(法 133①)이다. 국어번역문의 제출은 실제적인 문제라기보다는 심사관과 일반 공중에게 정확한 내용을 위한 절차적인 문제에 해당하기 때문에, 제47조제2항 후단의 국어번역문에 기재된 사항의 범위를 벗어난 보정은 거절이유(法 62)에만 해당하고, 특허무효사유(法 133①)에는 해당하지 않는다.

제3절 보정각하

제51조 【보정각하】

① 심사관은 제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정이 같은 조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(같은 조 제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 보정인 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>

1. 제66조의2에 따른 직권보정을 하는 경우: 그 직권보정 전에 한 보정
 2. 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우: 취소된 특허결정 전에 한 보정
 3. 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우: 그 청구 전에 한 보정
- ② 제1항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다. 다만, 제132조의17에 따른 특허거절결정에 대한 심판에서 그 각하결정(제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 제외한다)에 대하여 다투는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29>

[전문개정 2014.6.11.]

제170조 【심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용】

- ① 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조제1항제1호·제2호, 제51조, 제63조, 제63조의2 및 제66조를 준용한다. 이 경우 제51조제1항 본문 중 “제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정”은 “제47조제1항제2호에 따른 보정(제132조의17의 특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)”으로, 제63조의2 본문 중 “지식재산처장”은 “특허심판원장”으로 본다.
 - ② 제1항에 따라 준용되는 제63조는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다.
- [전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「보정각하」란 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ)의 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되는 경우 그 보정을 결정으로 각하하는 행정처분이다. 보정각하를 한 경우 심사관 또는 심판관은 보정 전의 명세서 또는 도면에 의하여 거절이유가 해소되었는지를 판단하게 된다.

2. 취 지

특허법은 심사대상을 변경하여 선의의 제3자에게 불측의 손해를 끼치며 법적 안정성을 해하는 것을 피하고 이미 진행한 심사결과와 활용을 통하여 심사촉진을 도모하기 위하여 최후거절이유통지이후(法 47①Ⅲ)의 보정범위(法 47②③)를 제한하고 있으며, 이러한 범위를 넘어선 보정에 대해서는 심사관 등이 직권으로 보정각하결정을 하여 보정을 인정하지 않고 있다.

II. 보정각하의 요건

1. 원 칙

1) 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ) 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정되어 부적법한 경우에 보정각하를 한다(法 51①).

2) 「그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우」란 그 보정서의 제출로 인해 전에 없던 거절이유가 발생한 것을 의미한다. 여기서 거절이유의 「발생」과 「발견」은 구분되어야 한다. 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ) 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우만 보정각하된다. 그러나 보정으로 원거절이유가 해소되지 못한 경우에는 새로운 거절이유가 발생한 경우가 아니므로 심사관은 보정을 인정한 후 거절이유가 동일하다는 것을 이유로 특허거절결정한다. 또한 보정으로 원거절이유가 해소되었으나 보정과 상관없는 거절이유가 발견된 경우에 그 거절이유가 원시적으로 발생하였으면 보정을 인정한 후 최초거절이유통지를, 최초거절이유통지에 대응한 보정에 의해 발생하였으면 보정을 인정한 후 최후거절이유통지를 하게 된다.⁵⁴⁾⁵⁵⁾

54) 제47조제2항의 신규사항추가금지에 위반되지 아니함을 전제로 구체적인 예를 살펴보면 다음과 같다.

구체적 예	설 명
청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치 【최후거절이유통지】청구항 1, 청구항 2는 인용대상에 의하여 진보성 없음. 【최후보정 후의 명세서】 청구항 1 : 삭제 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치	【보정인정】청구항 삭제로서 청구범위의 감축이고, 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하지 아니하여 보정 인정됨. 【특허거절결정】청구항 2는 진보성이 없으므로 특허거절결정함
청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : A+B+C로 이루어진 장치 【최후거절이유통지】청구항 1, 청구항 2는 인용대상에 의하여 진보성 없음. 【최후보정 후의 명세서】 청구항 1: 삭제 청구항 2: A+B+C+D로 이루어진 장치	【보정인정】청구항 1의 삭제와 청구항 2의 D 부가는 청구범위의 감축이고, 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하지 아니하여 보정 인정함. 【특허거절결정 또는 특허결정】청구항 2가 진보성이 없는 경우 특허거절결정하고, 청구항 2가 진보성이 있는 경우 특허결정함.
청구항 1: A+B로 이루어진 장치 청구항 2: A+B+C로 이루어진 장치 【최후거절이유통지】청구항 1, 청구항 2는 진보성 없음. 【최후보정 후의 명세서】 청구항 1: 삭제 청구항 2: A+B+C이고, A는 a로 이루어진 장치(A는 a로 내적한정하면서, 기재불비가 발생한 경우를 가정함)	【보정각하】청구항 2의 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하였기 때문에 보정이 부적법하여 보정각하함. 【특허거절결정】청구항 1, 청구항 2는 진보성이 없으므로 특허거절결정함.
청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 【최후거절이유통지】청구항 1이 인용대상 1에 의하여 진보성 없음. 【최후보정 후의 명세서】 청구항 1 : A+B+C로 이루어진 장치(인용대상 1에 대해서는 진보성이 인정되나 인용대상 1 및 인용대상 2에 의하여 진보성 없음. 인용대상 2는 C의 부가로 인해 추가로 필요)	【보정각하】청구항 1의 보정에 따라 보정 전에 없던 새로운 거절이유가 발생하였기 때문에 보정각하함. 【특허거절결정】청구항 1(A+B)은 인용대상 1에 의하여 진보성이 없으므로 특허거절결정함.
청구항 1 : A로 이루어진 장치 【최후거절이유통지】청구항 1이 인용대상 1에 의하여 진보성 없음. 【최후보정 후의 명세서】 청구항 1 : A+B로 이루어진 장치(인용대상 1에 B도 개시되어 있어 여전히 진보성이 부정됨)	【보정인정】청구항 1에 기재된 발명이 인용대상 1로부터 진보성이 부정된다는 거절이유는 기 통지되었던 거절이유이므로 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하지 아니하여 보정 인정함. 【특허거절결정】청구항 1(A+B)은 인용대상 1에 의하여 진보성이 없으므로 특허거절결정함.

55) 심사관이 「발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조제4항제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다」는 거절이유를 통지함에 따라 이를 해소하기 위한 보정이 이루어졌는데, 그 보정 이후 발명에 대한 심사 결과 신규성이나 진보성 부정의 거절이유가 발견된다고 하더라도, 그러한 거절이유는 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소

2. 예 외

(1) 청구항을 삭제하는 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우

1) 청구항을 한정 또는 삭제하거나 청구항에 부가하여 청구범위를 감축하는 경우(法 47③ I) 및 신규사항추가한 보정에 대하여 그 보정 전 청구범위로 되돌아가거나, 되돌아가면서 청구범위를 제47조제3항제1호 내지 제3호에 따라 보정하는 경우(法 47③ IV)에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하면 보정을 각하하지 아니하고 최후거절이유 통지를 한다. 「청구항을 삭제하는 보정」의 경우에는 청구항을 한정·부가하는 보정 등 다른 경우와 달리 그로 인하여 새로운 거절이유가 발생하더라도 위와 같은 보정의 반복에 의하여 심사관의 새로운 심사에 따른 업무량 가중 및 심사절차의 지연의 문제가 생기지 아니하므로 그에 대하여 거절이유를 통지하여 보정의 기회를 다시 부여함으로써 출원인을 보호하기 위함이다.⁵⁶⁾

2) 구체적인 예로는 i) 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둠으로써 제42조제3항제1호, 제4항에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 않은 기재불비가 발생한 경우, ii) 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제한 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항에서 그 인용번호를 잘못 변경한 경우, iii) 종속항이 2 이상의 항을 인용할 때 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재 누락하여 기재 불비가 발생한 경우 등이 있다.⁵⁷⁾ 다만 iv) 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청

발생한 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 보정으로 인하여 새롭게 발생한 것이라고 할 수 없으므로, 심사관으로서는 그 보정에 대한 각하결정을 하여서는 아니 되고, 위와 같은 신규성이나 진보성 부정의 거절이유를 출원인에게 통지하여 의견제출 및 보정의 기회를 부여하여야 한다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121). 구체적으로 심사관은 신규성, 진보성 부정의 거절이유가 거절이유통지 전부터 원시적으로 발생한 경우라면 최초거절이유통지를, 최초거절이유통지에 대응한 보정에 의해 발생한 경우라면 최후거절이유통지를 하게 된다.

56) 구체적인 예는 다음과 같다.

구체적 예	설 명
청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C를 부가한 장치 【최후거절이유통지】청구항 1은 진보성 없음. 【최후보정 후의 명세서】 청구항 1 : 삭제 청구항 2 : 청구항 1에 있어서, C를 부가한 장치	【보정인정】청구항 1을 삭제하는 보정은 청구범위의 감축에 해당함. 청구항 1의 삭제로 청구항 2에 기재 불비라는 새로운 거절이유가 발생하였으나 제51조제1항 발효 규정에 의하여 보정은 인정함 【최후거절이유통지】청구항을 삭제하면서 제42조제4항제2호 위반의 새로운 거절이유가 생긴 경우 다시 최후거절이유통지를 함.
청구항 1 : A+B로 이루어진 장치 청구항 2 : A+E로 이루어진 장치 청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, C를 부가한 장치 【최후거절이유통지】청구항 1은 진보성 없음. 【최후보정 후의 명세서】 청구항 1 : 삭제 청구항 2 : A+E로 이루어진 장치 청구항 3 : 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, C를 부가한 장치	【보정인정】청구항 1을 삭제하는 보정은 청구범위의 감축에 해당함. 한편 청구항 3은 삭제된 청구항 1을 인용하고 있지만 삭제된 청구항 1의 인용을 제외하고 해석하여 청구항의 발명이 A+E+C로 명확하게 파악되기 때문에 오기입이 명백한 경우로 취급하여 보정을 인정함 【특허결정】특허결정하면서 명백한 오기에 대해서는 직권보정함

57) 대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101; 2018. 6. 28. 선고 2014후553.

구함과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 이에 해당하지 아니한다.⁵⁸⁾

3) 물론 거절이유가 명백히 잘못된 경우라면 최후거절이유통지를 하는 것이 아니라 직권보정하면서 특허결정한다(法 66의2).

(2) 직권보정 전에 한 부적법한 보정이 특허결정이 취소된 후 발견된 경우

심사관의 직권보정에 대하여 출원인이 특허료를 낼 때까지 의견서를 제출한 경우 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 보고 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다(法 66의2). 특허결정이 취소된 것으로 보는 경우 심사관은 직권보정 전 명세서 또는 도면에 의하여 다시 심사를 진행한다. 한편 직권보정 전에 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ) 한 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했음에도 불구하고 보정각하결정을 하지 아니하고 이를 간과하여 특허결정을 취소한 후에 심사관이 이를 발견한 경우에는 보정을 인정하고 심사를 진행한다(法 51①Ⅰ). 이는 보정이 인정됨을 전제로 특허결정을 받았다는 것을 신뢰한 출원인의 이익을 보호하기 위함이다.

(3) 취소된 특허결정 전에 한 부적법한 보정이 직권 재심사 후 발견된 경우

심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유(단, 法 42③Ⅱ·42⑧·45 제외)를

58) 대법원 2018. 7. 12. 선고 2015후2259. 출원인인 원고가 심사전지절차로서 보정 전 청구항 제9항의 구성요소를 제1항에 포함시킴에 따라, 제9항을 인용하던 종속항인 제10항의 번호를 제2항으로 바꾸면서 제9항을 인용하던 부분을 제1항을 인용하는 것으로 바꾸었는데, 이러한 삭제된 청구항을 인용하는 부분의 변경과는 별개로 보정 전에 “적층된 소자들의 스택은 새로운 소자가 배치될 때마다 소자들을 위치시키는 수평력이 가해지는 것을 특징으로 하는 방법”으로 되어있던 부분을 “적층된 소자들의 스택은 새로운 소자가 배치될 때마다 소자들을 위치시키는 수평력이 가해지고,”라고만 기재하였다. 지식재산처 심사관은 위와 같은 심사전지보정은 보정에 의해 청구항 제2항의 끝부분에 “수평력이 가해지고,”라고만 기재하고 있어 발명이 불명확하여 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생하였다는 등의 이유로 이 사건 보정각하결정을 하였는데, 위 거절이유는 청구항 제9, 11항을 삭제하는 과정에서 발생하기는 하였으나, 청구항 제9, 11항의 삭제와 관련이 없는 부분에서 발생하였다고 봄이 타당하므로, 지식재산처 심사관이 원고에게 거절이유통지를 하는 등 이 사건 보정발명을 재보정할 기회를 부여하지 않은 것이 위법하다고 볼 수 없다고 보아 원심을 수긍한 사안이다.

	보정 전 청구범위	보정 후 청구범위
2	제1항에 있어서, 소자들의 스택은 소자들 사이에 연결을 형성하는 액체의 바스에서 제한된 깊이로 잠겨지는 것을 특징으로 하는 방법.	제1항에 있어서, <u>적층된 소자들의 스택은 새로운 소자가 배치될 때마다 소자들을 위치시키는 수평력이 가해지고,</u>
10	제9항에 있어서, <u>적층된 소자들의 스택은 새로운 소자가 배치될 때마다 소자들을 위치시키는 수평력이 가해지는 것을 특징으로 하는 방법.</u>	제8항 또는 제9항에 있어서, 소자들은 열 성형 공정에 의해 각각 제조되는 것을 특징으로 하는 방법.

발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다(法 66의3). 한편 심사관은 취소된 특허결정 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ) 한 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했음에도 불구하고 보정각하결정을 하지 아니하고 이를 간과하여 특허결정을 취소한 후에 직권 재심사단계에서 심사관이 이를 발견한 경우에는 보정을 인정하고 심사를 진행한다(法 51①Ⅱ). 이는 보정이 인정됨을 전제로 특허결정을 받았다는 것을 신뢰한 출원인의 이익을 보호하기 위함이다.

(4) 재심사의 청구 전에 한 부적법한 보정이 재심사 청구 후 발견된 경우

재심사의 청구 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ)에 한 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했음에도 불구하고 일반심사단계에서 보정각하결정을 하지 아니하고 이를 간과하여 추후 재심사단계에서 심사관이 이를 발견한 경우에는 보정을 인정하고 심사를 진행한다(法 51①Ⅲ). 이는 그 보정이 인정되었음을 전제하고 재심사를 청구한 출원인을 보호하기 위함이다.⁵⁹⁾

(5) 거절결정불복심판청구 전에 한 부적법한 보정이 심판청구 후 발견된 경우

심판청구 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ) 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했음에도 불구하고 심사단계에서 심사관이 보정각하결정을 하지 아니하고 이를 간과하여 추후 거절결정에 대한 불복심판단계에서 심판관 합의체가 이를 발견한 경우에는 보정을 인정하고 심리를 진행한다(170①괄호). 이는 그 보정이 인정되었음을 전제하고 심판절차를 밟은 청구인을 보호하기 위함이다.

(6) 발생한 새로운 거절이유가 직권보정(法 66의2)을 할 수 있는 경우

발생한 새로운 거절이유가 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우 직권보정(法 66의2)을 할 수 있는 사항이라면, 심사관은 보정을 승인하고 이후 절차를 진행할 수 있다. 명백히 잘못된 새로운 거절이유가 실수로 포함되었을 때 보정각하되고 거절결정되는 것은 출원인에게 너무 가혹하기 때문이다. 이 경우 심사관은 다른 거절이유가 없다면 특허결정하면서 직권보정을 하게 된다.

59) 즉 출원인은 원래 보정되지 아니한 명세서 또는 도면에 의하여 재심사 청구 여부를 결정하여야 하는데, 심사관이 보정각하를 하지 않아서 보정된 명세서 또는 도면을 가지고 재심사 청구 여부를 결정하게 된다. 이 경우 재심사단계에서 보정각하를 하는 것은 보정되지 아니한 명세서 또는 도면에 의하여 재심사 청구를 하는 것과 동일한 결과가 발생한다. 이는 심사관 행정처분에 대한 신뢰의 이익과 출원인의 절차적 이익을 보호 측면에서 바람직하지 않다.

【표 3-4】 거절이유통지 등의 개념정리

개 념	내 용
최초거절이유통지	■ 거절이유통지 전부터 원시적으로 존재하는 거절이유 ■ 직권 재심사를 하려고 특허출원인에게 특허결정을 취소한다는 사실을 통지한 경우에 그 통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유 ■ 거절결정불복심판에서 취소환송되었는데 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유
최후거절이유통지	■ 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 한 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우 - cf) 다만 일반적으로 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 한 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 제51조제1항에 위반되어 보정각하됨
특허거절결정	■ 거절이유가 동일한 경우(동일한 거절이유에 대해서는 2번의 거절이유통지를 하지 아니함) ■ 단, 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우에는 최초거절이유통지 ■ 거절이유의 동일성 판단 ① 세부적인 표현에 있어 차이가 있더라도 주된 취지에 있어서 동일하면, 동일한 거절이유 ② 구체적인 예를 들어 법조문을 달리하면 거절이유를 달리하며, 법조문을 같이 하더라도 사실을 달리하면 거절이유를 달리함. - cf) 심판단계에서 거절이유가 동일한 경우에는 기각심결을 하게 됨
보정각하	■ 원칙 - 최후거절이유통지이후(法 47①ⅡⅢ시기)의 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우 ■ 예외 ① 제47조제3항제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생한 경우 최후거절이유통지 ② 직권보정 전에 한 부적법한 보정이 특허결정이 취소된 후 발견된 경우(직권보정 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 또는 재심사 청구할 때 부적법한 보정이 특허결정이 취소된 후 발견된 경우) 보정인정 후 심사진행 ③ 취소된 특허결정 전에 한 부적법한 보정이 직권 재심사 후 발견된 경우(취소된 특허결정 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 또는 재심사 청구할 때 부적법한 보정이 직권 재심사 후 발견된 경우) 보정인정 후 심사진행 ④ 재심사의 청구 전에 한 부적법한 보정이 재심사 청구 후 발견된 경우(재심사 청구 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 부적법한 보정이 재심사 청구 후 발견된 경우) 보정인정 후 심사진행 ⑤ 거절결정불복심판청구 전에 한 부적법한 보정이 거절결정불복심판청구 후 발견된 경우(심판청구 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간 또는 재심사 청구할 때 부적법한 보정이 심판청구 후 발견된 경우) 보정인정 후 심리진행 ⑥ 발생한 새로운 거절이유가 직권보정(法 66의2)을 할 수 있는 경우 다른 거절이유가 없다면 특허결정하면서 직권보정

III. 보정각하의 절차

1. 방 식

1) 보정각하결정은 다음의 사항을 적은 서면으로 하여야 한다(施規 42). 즉 보정각하는 출원인에게는 불이익한 행위이므로 출원인이 이해할 수 있도록 그 이유를 구체적으로 명시한 서면으로 하여야 한다(法 51②).

i) 특허출원번호

ii) 발명의 명칭

iii) 특허출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소)

- iv) 특허출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소
- v) 각하결정의 주문 및 이유
- vi) 각하결정의 연월일

2) 심사관·심판관이 「직권」으로 보정각하를 하지만 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하더라도 절차적 위법은 아니다(法 63①단서). 따라서 심판단계나 소송단계에서 심사단계에서의 보정각하사유가 아닌 다른 보정각하사유로 보정이 부적법함, 즉 보정각하가 타당함을 주장할 수 있다. 예를 들어 심사단계에서 최후거절이유통지에 대응한 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 위반으로 보정각하되었으나 심판단계나 소송단계에서 청구범위 보정범위제한(法 47③) 위반이나 보정에 의해 새로운 거절이유가 발생하였음을 이유로 보정각하가 타당하다고 주장할 수 있다.⁶⁰⁾

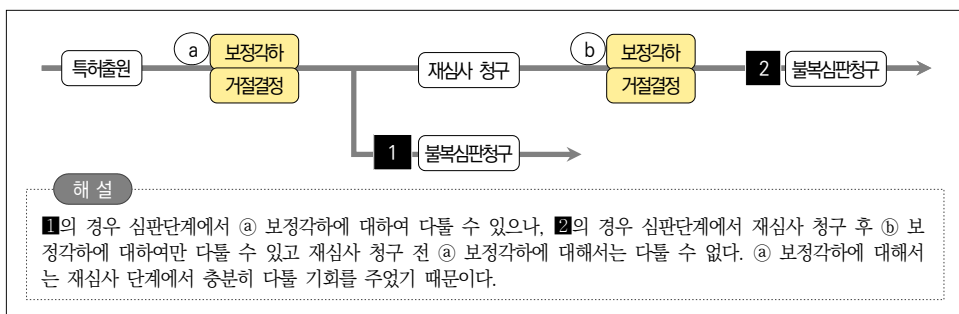
2. 불복 여부

(1) 원 칙

출원인은 보정각하결정에 대해서는 단독으로 불복할 수 없고 특허거절결정에 대한 심판을 청구하였을 때 그 보정각하결정을 함께 다룰 수 있다(法 51③). 종래 심사관, 심판관 합의체가 보정각하결정 시 법률에 따라 일정 기간 결정을 보류하거나 심결 등의 확정 전까지 심사를 중지함으로써 인하여 심사절차가 지연되는 문제점이 있었기 때문이다. 따라서 이를 방지하여 신속한 심사처리를 도모하고자 보정각하결정에 대해서는 단독으로 불복할 수 없도록 하고 거절결정불복심판에서 이를 다룰 수 있도록 하였다.

(2) 예 외

i) 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 보정각하결정과 ii) 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정각하결정은 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③괄호). 이는 직권 재심사 또는 재심사 청구가 있었다면 직권 재심사 또는 재심사단계에서 취소된 특허결정 전 또는 재심사의 청구 전 보정각하결정에 대하여 충분히 다룰 기회를 주었기 때문이다.



【그림 3-14】 재심사 청구 전의 보정각하에 대한 불복

60) 특허법원 2009. 7. 10. 선고 2008허10764.

IV. 보정각하의 효과

1. 보정의 불인정

보정각하를 한 경우 해당 보정은 없었던 상태로 되므로, 심사관 또는 심판관은 보정 전의 명세서 등을 기준으로 심사 또는 심판을 진행한다.

2. 보정각하 후 절차진행

(1) 일반심사단계 또는 재심사단계

심사관은 보정 전의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원의 원거절이유가 해소되었는지를 심사하여 원거절이유가 해소되지 못한 경우에는 거절이유가 동일하므로 2번의 거절이유통지를 하지 않고 특허출원을 특허거절결정한다.

(2) 거절결정불복심판단계

심판관 합의체는 보정 전의 명세서 또는 도면에 의하여 거절결정이유가 해소되었는지를 심리하여 원거절결정이유가 해소되지 아니한 경우 재차 거절결정을 하지 않고 기각심결을 하면 된다. 다만 거절결정에 대한 불복심판단계에서 보정각하결정에 대하여 함께 다투면 심판관 합의체는 보정각하결정의 당부를 심리하여 그 심리사항을 거절결정불복심판의 심결 이유에 적어야 한다.

【표 3-5】 보정범위가 부적합한 경우의 취급

보정시기	보정범위	위반시 취급			착오로 등록된 경우
		일반심사 단계	재심사단계	심판단계	
특허결정등본 송달 전	신규사항추가금지 (法 47②)	최초거절이유통지			제47조제2항전 단 위반의 경우, 보정에 의해 발생한 새로운 거절이유의 경우 (제한열거적인 특허무효사유에 해당함을 전제) 무효심판청구 가능
최초거절이유 통지에 따른 의견서 제출기간		최후거절이유통지			
최후거절이유 통지에 따른 의견서 제출기간	1. 신규사항추가금지 (法 47②) 2. 청구범위 보정범 위제한(法 47③) 3. 보정에 따라	보정각하	1. 재심사 청구 전 보정 - 보정인정 후 심사진행 2. 재심사 청구 후 보정 - 보정각하	1. 심판청구 전 보정 - 보정인정 후 심리진행 2. 심판청구 후 보정 - 보정각하	
재심사를 청구할 때	새로운 거절이유가 발생×	-	보정각하	보정인정 후 심리진 행(심판청구 전 보 정에 해당함)	

제5장

분할출원

제52조 【분할출원】

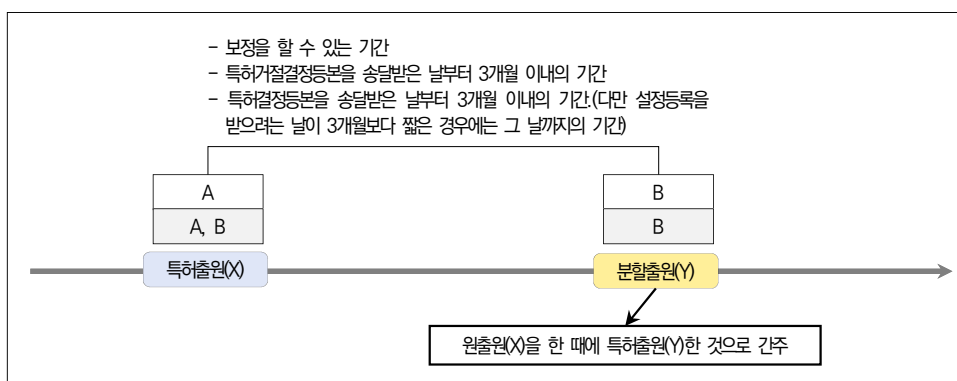
- ① 특허출원인은 둘 이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. 다만, 그 특허출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 제42조의3제2항에 따른 국어번역문이 제출된 경우에만 분할할 수 있다. <개정 2015. 1. 28., 2016. 2. 29., 2021. 10. 19.>
 1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간
 2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내의 기간
 3. 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만, 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간
- ② 제1항에 따라 분할된 특허출원(이하 “분할출원”이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용할 경우에는 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다.
 1. 분할출원이 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
 2. 제30조제2항을 적용하는 경우
 3. 제54조제3항을 적용하는 경우
 4. 제55조제2항을 적용하는 경우
- ③ 제1항에 따라 분할출원을 하려는 자는 분할출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다.
- ④ 분할의 기초가 된 특허출원이 제54조 또는 제55조에 따라 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 제1항에 따라 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권 주장을 한 것으로 보며, 분할의 기초가 된 특허출원에 대하여 제54조제4항에 따라 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다. <산설 2021. 10. 19.>
- ⑤ 제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 제54조제7항 또는 제55조제7항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권 주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다. <산설 2021. 10. 19.>
- ⑥ 분할출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산청장에게 제출할 수 있다. <개정 2013.3.22>
- ⑦ 분할출원이 외국어특허출원인 경우에는 특허출원인은 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다. <개정 2021. 10. 19.>
- ⑧ 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다. <개정 2021. 10. 19.>

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「분할출원」이란 하나의 특허출원(이하 “원출원”이라 한다)에 둘 이상의 발명이 포함된 경우 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 보정할 수 있는 기간, 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 말한다) 또는 특허결정등본을 송달받은 날로부터 3개월(다만 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간) 이내의 기간에 그 일부를 별개의 특허출원으로 분할하는 것을 말하며, 분할출원을 한 경우 그 분할출원은 원출원한 때에 출원한 것으로 본다.



【그림 3-15】 분할출원 일반

2. 취 지

(1) 출원일체의 원칙 회피

심사관은 출원한 발명의 청구범위에 기재된 청구항(발명)별로 특허요건에 위반되는지 여부, 즉 거절이유에 해당하는지 여부를 심사하지만 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우 출원전체를 거절결정하는데 이를 강학상 「출원일체의 원칙(all or nothing rule)」이라고 한다. 출원인은 일부의 청구항에 대해서만 거절이유가 있고, 나머지 청구항에 대해서는 거절이유가 없는 경우 거절이유가 없는 청구항에 기재된 발명에 대하여 분할출원하여 먼저 등록받는 한편 거절이유가 있는 청구항에 기재된 발명은 별도로 다툼으로써 출원일체의 원칙으로 인한 불이익을 회피하기 위한 수단의 하나로서 분할출원을 이용할 수 있다.⁶¹⁾ 특히 여러 개의 발명을

61) 물론 거절이유가 있는 청구항을 분할출원하여 별도로 다툼고, 원출원에서는 그 청구항을 삭제보정하여 원출원에 대하여 먼저 등록받을 수도 있다.

하나의 특허출원으로 하였는데 일 군의 발명에 해당하지 아니한 경우(단일성을 만족하지 아니한 경우) 분할출원이 많이 이용되고 있다.

(2) 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명의 보호

원출원의 출원 당시 청구범위에는 기재되어 있지 않으나 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 보호받고자 할 경우에도 분할출원의 의미가 있다.

(3) 권리범위 재설계 기회의 확보

특허결정등본이 송달된 후라도 특허가 활용되는 시장이 형성되는 방향에 대한 예측가능성이 떨어지거나 특허 장벽(Patent Wall)을 쌓는 데 필요한 경우 권리범위를 재설계할 기회를 확보하고자 분할출원을 할 수 있다.

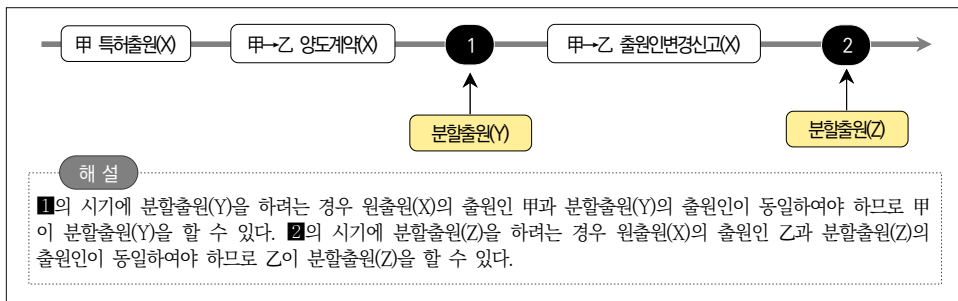
【표 3-6】 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명의 특허법상 보호방안

구분	내 용
적극적 보호	1. 보 정 출원서에 최초로 첨부한 명세서의 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 청구범위에 추가하는 보정이 가능하다. 다만 최후거절이유에 대한 의견서 제출기간(法 47①Ⅲ) 및 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅳ)는 청구범위를 확장하거나 변경하는 보정이 인정되지 않으므로 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 청구범위에 추가하는 보정을 할 수 없다. 이때 보정된 발명과 기 청구범위에 기재된 발명은 단일성(法 45)을 만족하여야 한다.
	2. 분할출원 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명은 보정을 할 수 있는 기간, 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 말한다) 또는 특허결정등본(특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다))을 송달받은 날로부터 3개월(다만 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간) 이내에 청구범위에 기재하여 분할출원할 수 있다. 이때 분할출원은 출원일의 소급효가 인정된다(法 52②). 원출원일로 출원일 소급효가 인정되면 특허요건 판단 시에 유리한 위치에 있게 되지만, 그만큼 존속기간이 짧아지게 된다.
	3. 우선권주장 발명의 설명 또는 도면에만 기재하고 청구범위로 기재하지 아니한 부분의 발명이라 하더라도 그 특허출원일로부터 1년 이내라면 그것을 조약우선권 또는 국내우선권주장출원할 때 청구범위에 포함시킴으로써 보호받을 수 있다. 우선권주장에 의하여 그 발명을 보호받는 경우 선출원일로 판단시점이 소급하게 된다(法 54①, 法 55③). 우선권주장출원은 1년이라는 우선기간의 제한이 있지만, 우선권주장할 때 발명의 설명 또는 도면에 기재되지 아니한 새로운 발명을 추가할 수 있다.
	4. 별도출원 출원인이 동일한 경우에는 확대된 선출원을 적용하지 않으므로 발명의 설명이나 도면에만 기재된 발명이라 하더라도 특허출원이 출원공개 전이라면 그 발명을 청구범위에 기재하고 별도의 새로운 출원을 하여 보호받을 수 있다. 별도출원은 분할출원에 비하여 특허요건 판단 시에 불리한 위치에 있지만, 등록된 후에는 존속기간을 더 길게 보호받을 수 있다.
소극적 보호	1. 확대된 선출원의 지위 비록 청구범위에 기재하지 아니하였다고 하더라도 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 발명의 설명이나 도면에 기재된 발명은 출원공개 또는 등록광고되었을 때 선출원의 범위가 확대되어 출원공개 또는 등록 공고 전 타인의 동일한 후출원을 거절시킬 수 있다. 이는 새로운 발명을 공개하지 아니한 자에게는 독점·배타적인 특허권을 부여할 이유가 없기 때문이다.
	2. 공지기술의 지위 출원서에 최초로 첨부된 명세서의 발명의 설명이나 도면에만 기재된 발명은 출원공개 또는 설정등록에 의하여 공지기술이 되므로, 출원공개 또는 설정등록 후에 출원한 타인의 후출원에 대하여 신규성 및 진보성의 판단시 인용대상이 된다.

II. 분할출원의 요건

1. 주체적 요건

원출원의 「특허출원인」이 분할출원을 할 수 있다. 즉 분할출원 당시 분할출원인은 원출원의 출원인 또는 그 승계인과 동일인이어야 한다. 예를 들어 승계인이 출원인변경신고를 통해 원출원을 승계하였으면 승계인이 분할출원을 할 수 있으며, 원출원이 공동출원이면 출원인변경신고가 없는 한 분할출원 역시 공동출원을 하여야 한다. 한편 「분할출원 당시」에만 동일인이면 되고 분할출원 이후에는 출원인이 달라지더라도 상관없다.



【그림 3-16】 분할출원 당시 출원인의 동일성

2. 객체적 요건

(1) 원출원의 요건

① 분할출원 당시 원출원이 적법하게 출원 계속 중일 것

1) 「분할출원 당시」 원출원이 적법하게 출원 계속 중이어야 한다. 여기서 「출원 계속 중」이란 출원에 대하여 지식재산청이 특허를 하여(제87조제2항에 따른 설정등록을 말한다)하는데 필요한 행정행위를 할 수 있는 상태를 말하는 것으로, 출원이 무효, 취하, 포기 또는 특허거절결정이 확정되기 전이나 설정등록되기 전을 말한다.⁶²⁾ 이미 출원절차가 종료된 출원에 관하여 분할출원을 인정해 준다면 행정절차가 복잡해지고 영속적으로 분할출원할 수 있는 권리를 인정하게 되어 절차의 안정성을 해치는 결과를 초래하기 때문이다. 따라서 분할출원 시에 원출원이 취하, 포기, 무효로 되거나 특허거절결정이 확정되어 원출원의 절차가 종료된 때에는 분할출원을 할 수 없다.

2) 다만 원출원이 취하 또는 포기된 날과 같은 날에 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 원출원이 지식재산청에 계속 중인 때에 출원한 것으로 취급한다. 이는 원출원의 취하 또는 포기 등 출원의 절차를 종료하는 절차와 분할출원 절차가 같은 날에 이루어질 때는 통상적으로 동시에 절차를 밟게 되므로 원출원의 취하 또는 포기와 분할출원 절차의 선후를 구분하기가 곤

62) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 4103면.

란하고, 분할출원 절차는 원출원이 계속되고 있음을 인식한 상태에서 이루어졌다고 봄이 타당하기 때문이다.⁶³⁾

② 분리출원이 아닐 것

원출원은 분리출원이 아니어야 한다(法 52의2④). 분리출원이 거절결정불복심판에서의 기각심결이 있는 후 제한된 범위인 특허가능한 청구항에 대해서 신속히 권리획득기회를 주는 제도임을 고려할 때 이를 기초로 다시 분할출원하여 권리범위를 재설계하는 것은 적절치 않기 때문이다.

③ 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 둘 이상의 발명이 포함되어 있을 것

원출원의 청구범위에 둘 이상의 발명이 기재되어 있는 경우뿐만 아니라 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서의 발명의 설명 또는 도면에 둘 이상의 발명이 포함된 경우에도 분할출원을 할 수 있다.⁶⁴⁾

(2) 분할출원의 요건

1) 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다. 「최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항」이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 원출원일 당시의 기술상식에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 말한다.

2) 분할출원에 포함된 발명 중 일부라도 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나면 거절이유에 해당한다(法 52①, 62). 다만 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에 있다면 삭제보정에 의하여 보정된 명세서 또는 도면에 포함되어 있지 않다고 하더라도 분할출원을 할 수 있다.

3. 시기적 요건

1) 출원인은 다음의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나 이상의 특허출원으로 분할할 수 있다(法 52①).

i) 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간

ii) 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 말한다) 이내의 기간

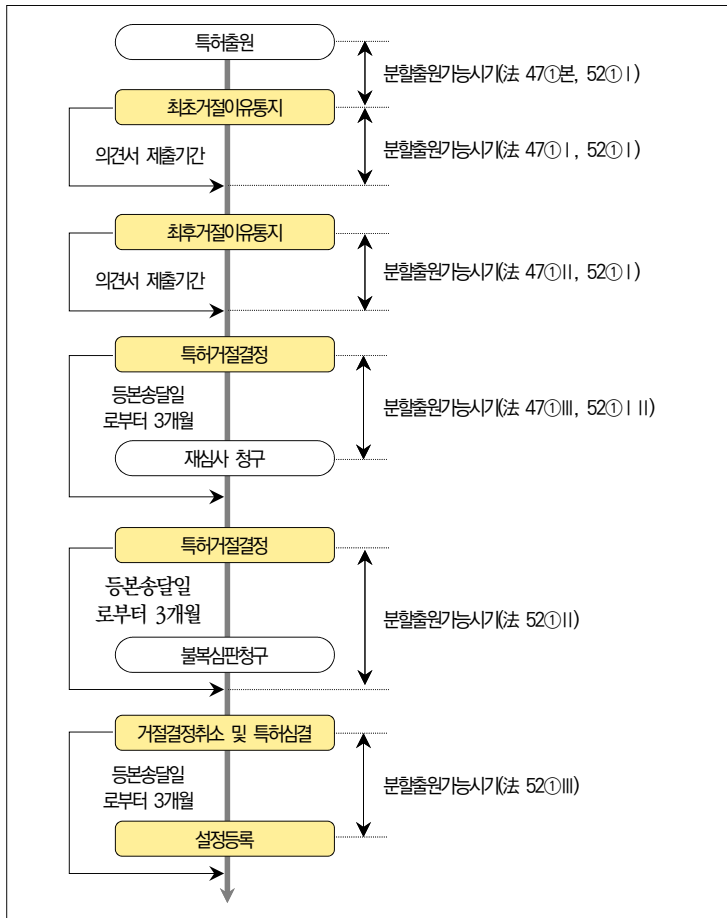
iii) 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등록을 결정한 심결에 한정되되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간. 다만 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간⁶⁵⁾

63) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6104면.

64) 대법원 1986. 9. 9. 선고 84후71.

65) 2015. 7. 29. 시행된 현행법(법률 제13096호, 2015. 1. 28. 개정)은 특허결정 후 해당 산업계의 기술 표준이 결정되거나 모방 제품이 출현하는 등 시장 환경의 변화에 따라 추가로 권리가 필요한 경우 분할출원을 통하여 출원인이 능동적으로 대응할 수 있도록 하고 있다.

2) ii)의 기간에 거절결정불복심판을 청구한 경우에는 그 기간 이내에 분할출원을 할 수 있다.⁶⁶⁾ 한편 ii), iii)의 기간에 재심사 청구를 한 경우에는 그 기간 이내라도 분할출원을 할 수 없는 것으로 실무상 운영하고 있다. 거절결정불복심판의 경우에는 심판을 청구하였다고 하여 거절결정이 취소되는 것이 아니라 인용심결이 내려졌을 때 비로서 거절결정이 취소되는데 반해(法 176①), 재심사 청구의 경우에는 재심사 청구를 하면 특허여부결정이 취소된 것으로 보기 때문이다(法 67의2③). 물론 재심사 청구와 동시에 분할출원을 하거나 재심사 단계에서 거절이 유통지에 따른 의견서 제출기간에 분할출원하는 것은 가능하다.⁶⁷⁾



【그림 3-17】 분할출원가능시기

66) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5310면.

67) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5406면.

III. 분할출원의 절차

1. 분할출원서 등의 제출

분할출원을 하려는 자는 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원(원출원)의 표시를 한 분할출원서와 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 52③). 한편 i) 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류, ii) 그 밖의 법령에 따른 증명서류 등을 첨부하여야 한다(施規 29①).

2. 우선권주장 및 증명서류 제출 간주

원출원이 조약 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권주장을 한 것으로 보며, 원출원에 대하여 제54조제4항의 조약우선권주장의 증명서류 제출기간 내 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(法 52④). 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 출원인의 실수 등으로 분할출원 시 우선권주장을 하지 않아서 등록이 거절되는 사례가 발생하는 문제점을 해소하기 위해 분할출원 시 우선권주장을 자동으로 인정하고, 증명서류 제출을 생략함으로써 출원인의 편의를 제고하고 있다.⁶⁸⁾

IV. 분할출원의 효과

1. 적법한 경우의 효과

(1) 출원일의 소급효

① 원 칙

적법하게 분할출원된 경우 그 분할출원은 원특허출원을 한 때에 출원한 것으로 본다(法 52②).

② 예 외

1) 분할출원이 다음에 해당하는 경우에는 출원일이 소급되지 않고 해당 분할출원을 한 때에 출원한 것으로 본다(法 52②단서, 92의2④).

- i) 확대된 선출원에 관한 규정(法 29③④)에서의 다른 출원에 해당하는 경우
- ii) 공지의예외적용의 취지기재 및 증명서류제출기간(法 30②)
- iii) 조약우선권주장출원의 취지 등의 기재(法 54③)
- iv) 국내우선권주장출원의 취지 등의 기재(法 55②)
- v) 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장시 특허출원일의 기산일(法 92의2④)

68) 채수근 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안, 디자인보호법 일부개정법률안, 상표법 일부개정법률안 검토보고(송갑석 의원 대표발의(의안번호 제2104891호, 제2104892호 및 제2104893호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2. 20면.

2) 구체적으로 분할출원이 확대된 선출원에 관한 규정(法 29③④)에서의 다른 출원에 해당하는 경우 원출원의 최초 명세서 또는 도면에는 포함되어 있지 아니하지만 분할출원의 최초 명세서 또는 도면에 포함된 발명에 의하여 원출원과 분할출원 사이의 제3자의 출원을 거절시키는 것은 먼저 출원하여 공개시킨 자에게 독점·배타적인 특허권을 부여한다는 특허법의 목적에 반하기 때문에 확대된 선출원을 적용할 때 소급효가 인정되지 않고 현실의 분할출원일을 기준으로 한다. 예를 들어 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 A, B 발명이 기재되고, 분할출원의 최초 명세서 또는 도면에 B, C 발명이 기재된 후 분할출원의 보정된 명세서 또는 도면에는 B 발명이 기재된 경우 원출원과 분할출원 사이에 C 발명을 출원한 제3자의 출원을 거절시키는 것은 적절치 않기 때문에 분할출원의 확대된 선출원을 적용함에 있어서는 출원일의 소급효를 인정하지 않는다.

3) 분할출원이 공지예외적용주장을 수반하는 경우 공지예외적용의 취지 기재 및 증명서류 제출기간(法 30②)이 원출원의 출원일로 소급효가 인정된다면 이론적으로 공지예외적용주장절차를 밟을 수 없으므로 현실의 분할출원일을 기준으로 한다. 즉 분할출원서에 공지예외적용의 취지를 적어 출원하고, 그 날로부터 30일 이내 증명서류를 제출하면 된다.⁶⁹⁾ 한편 공지예외적용주장이 적법하기 위해서는 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내 특허출원을 하여야 하는데 「12개월 이내 특허출원」은 출원일의 소급효가 인정되므로 원출원이 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내 이루어졌다면 분할출원은 분할출원할 수 있는 기간에 하면 된다.

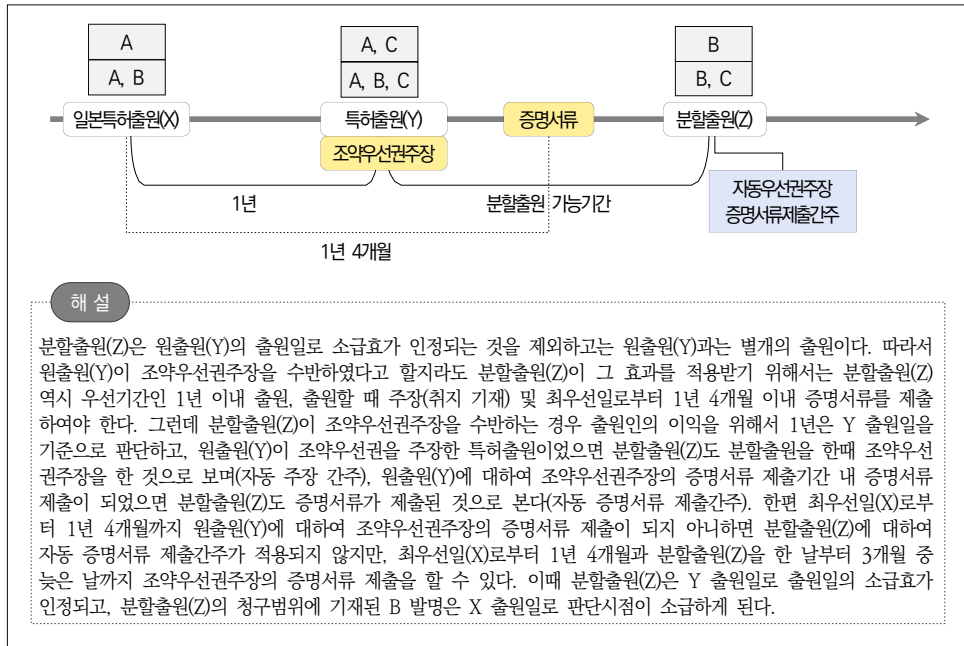
4) 분할출원이 우선권주장을 수반하는 경우 조약우선권주장출원의 취지(法 54③), 국내우선권주장출원의 취지(法 55②) 기재가 원출원일의 출원일로 소급효가 인정된다면 공지예외적용 주장과 마찬가지로 해당 절차를 밟을 수 없으므로 현실의 분할출원일을 기준으로 한다.⁷⁰⁾ 그리고 원출원이 조약 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분할출원을 한 때에 그 분할출원에 대해서도 우선권주장을 한 것으로 본다(法 52④). 한편 우선권주장출원이 적법하기 위해서는 선출원일로부터 1년 이내 특허출원을 하여야 하는데 「1년 이내 특허출원」은 출원일의 소급효가 인정되므로 우선권주장출원을 수반한 원출원이 우선권주장의 기초가 된 선출원일로부터 1년 이내에 이루어졌다면 분할출원은 분할출원할 수 있는 기간에 하면 된다.⁷¹⁾

5) 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다. 여기서 「특허출원일부터 4년」과 관련하여, 분할출원(法 52)의 경우에는 분할출원을 한 날을 특허출원일로 본다(法 92의2①④).

69) 다만, 특허법 제30조제3항에 따라 보완수수료를 납부하고 취지 기재서면 또는 증명서류를 추후 일정기간에 제출할 수 있다.

70) 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체.

71) 심사에 의하여 하나의 특허를 위한 우선권주장출원이 1이상의 발명을 포함하고 있음이 밝혀진 경우에 출원인은 그 출원을 수개의 출원으로 분할시킬 수 있으며 또한 당초 출원일을 그 각각의 출원일로 유지하고, 우선권의 혜택이 있는 경우에 이를 보유할 수 있다(파리條約 4G(1)). 즉 파리조약 제4조 G(1)은 특허출원의 심사를 행하여 출원이 둘 이상의 발명을 포함하는지를 확인하는 나라에만 적용되는 규정이다. 한편 출원인 또한 그 스스로 우선권주장출원을 분할시킬 수 있으며 당초의 출원일을 각 분할출원의 일부로 하여 우선권의 혜택이 있는 경우에 이를 보유할 수 있다. 각 동맹국은 그러한 분할이 인정될 수 있는 조건을 정한다. 이는 자발적 분할출원을 말하는 것으로 무심사주의 국가를 고려한 규정이다(條約 4G(2)).



【그림 3-18】 조약우선권주장을 수반하는 분할출원

(2) 원출원과의 관계

1) 분할출원은 원출원과는 전혀 별개의 새로운 출원이다. 따라서 분할출원은 원출원에 대하여 생긴 절차상의 효력을 그대로 승계할 수 없다. 즉 분할출원에 대한 심사청구, 출원공개, 특허여부결정도 원출원과 독립하여 행하여진다. 예를 들어 분할출원은 원출원일로부터 1년 6개월이 지나기 전에 분할되었으면 원출원일로부터 1년 6개월이 지난 후에, 원출원일로부터 1년 6개월이 지난 후에 분할되었으면 즉시 출원공개된다.

2) 다만 원출원이 우선권주장을 하지 아니한 경우 실무상 분할출원 역시 상기 주장을 할 수 없다. 이는 원출원과 동시에 우선권주장을 하지 아니하여 그 효과가 발생하지 아니한 경우 이를 회피하기 위한 수단으로서 분할출원을 이용하는 것을 방지하기 위해서이다.⁷²⁾⁷³⁾ 그러나 원출원이 공지에 외적용주장을 하지 않더라도 분할출원은 상기 주장을 할 수 있다. i) 제52조제2항제2호에서 원출원이 공지에외적용주장을 한 것을 전제로 분할출원이 그 주장을 할 수 있다고 규정되어 있지 않다는 점, ii) 원출원의 청구범위에 기재된 발명은 공지기술과 달라서 공지에외적용주장을 할 필

72) 다만 원출원에서 우선권주장의 취지만을 기재하고 그 증명서류를 법정기간에 제출하지 아니한 경우라도 분할출원서에 우선권주장의 취지를 기재하고 분할출원일로부터 규정된 날까지 그 증명서류를 제출한 경우에는 그 우선권주장은 적법한 것으로 본다(지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6106면).

73) 결국 원출원의 우선권주장 수반 여부에 따른 분할출원의 우선권주장 절차는 다음과 같다.

요가 없었지만 권리범위를 재설계하면서 분할출원한 청구범위에 기재된 발명은 공지기술과 동일하거나 용이할 수 있는데 공지예외적용주장을 통해 이를 보호해 줄 필요가 있다는 점, iii) 분할출원은 원출원과 별개의 독립된 제도라는 점, iv) 제30조의 공지예외적용주장은 출원인의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도라는 점 등을 고려한 것이다.⁷⁴⁾

3) 한편 분할출원의 심사는 지식재산청장이 정하는 순서에 따른다(施規 38②). 이는 심사순서를 탄력적으로 운영하여 변동하는 심사환경에 대응하기 위함이다.⁷⁵⁾

(3) 선출원주의의 회피

1) 분할출원을 한 경우 분할 후 청구범위에 기재된 발명은 원출원의 청구범위에 기재된 발명과 동일하지 아니하여야 하며, 동일한 경우에는 동일자에 동일발명에 관한 출원이 있으므로 협의제(法 36②)가 적용된다. 따라서 원출원의 청구범위에 기재된 발명을 분할할 때는 협의제(法 36②)를 회피하기 위하여 분할된 발명을 원출원의 청구범위에서 삭제하는 보정서를 제출하여야 한다(施規 29③). 다만 원출원의 발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명을 분할할 때는 원출원의 보정을 하지 아니하여도 된다.⁷⁶⁾

2) 원출원에 대한 거절결정불복심판청구와 원출원에서 특허가능한 청구항의 분할출원이 동시에 계속 중일 때 협의제의 적용이 문제이다. 이 경우 심사관은 협의제 적용 여부를 판단하기 위하여 심판결과가 확정된 후에 분할출원에 대한 특허여부결정을 하게 된다. 즉 심판결과 원출원에 대한 거절한다는 취지의 심결이 확정되면 선출원의 지위가 없어지기 때문에(法 36④) 협의제에 의하지 아니하지만, 원출원에 대한 인용심결이 확정되어 거절결정이 취소되면 협의제에 의한다.⁷⁷⁾

원출원		분할출원	
우선권주장	증명서류제출 (조약우선권주장)	우선권주장	증명서류제출 (조약우선권주장)
×		×(실무상 불인정)	
○	○	자동주장간주(제2항제3호, 제4항) 우선권주장의 취하(제5항)	자동제출간주(제4항)
○	×	자동주장간주(제2항제3호, 제4항) 우선권주장의 취하(제5항)	기간의 특례(제6항)

74) 대법원 2022. 08. 31. 선고 2020후11479. 한편 기존의 심사 실무는 원출원이 우선권주장, 공지예외적용주장을 하지 않은 경우 분할출원도 그 주장을 못한다는 입장이었으나, 제30조제3항이 신설(법률 제13096호)되면서 원출원이 공지예외적용주장을 하지 않더라도 분할출원이 그 주장을 할 수 있는 것으로 그 입장이 바뀌었다(지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 6106면). 이는 원출원이 출원과 동시에 공지예외적용주장을 하지 않더라도 추후 보완수수료를 내고 할 수 있기 때문에 굳이 이를 회피하기 위한 수단으로 분할출원을 이용할 필요가 없어졌기 때문이다. 그러나 대법판결은 분할출원은 원출원과 독립된 출원이기 때문에 원출원의 제30조제3항의 신설과 무관하게 제52조제2항제2호의 요건만 만족하면 공지예외적용주장을 수반한 적법한 분할출원이 될 수 있다고 판시하였다. 이러한 대법원의 판시이유에 따르면, 실무상 원출원이 우선권주장을 하지 아니한 경우 분할출원 역시 상기 주장을 할 수 없다는 것도 논란이 될 것으로 보인다.

75) 특허·실용신안 심사사무취급규정 제21조제1항에 의하면 분할출원은 분할출원의 심사청구순서에 따라 심사를 하고 있다.

76) 대법원 1985. 7. 23. 선고 83후26.

(4) 우선권주장취하기간의 특례

제52조제4항에 따라 우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한(法 54⑦, 55⑦)이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(法 52⑤). 이는 우선권주장의 자동간주(法 52④)를 원칙으로 하면서도 우선권주장을 원하지 않은 사항에 대해서는 의사에 따라 배제할 수 있도록 하려는 것이다.⁷⁸⁾

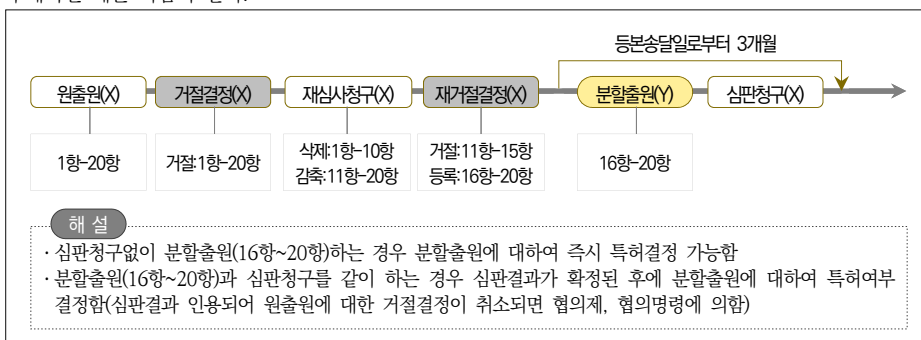
(5) 조약우선권주장의 증명서류 제출기간의 특례

조약우선권주장을 할 때 증명서류는 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 하나, 분할출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우에는, 즉 조약우선권주장의 취지를 기재하면서 분할출원하는 경우에는 최우선일로부터 1년 4개월의 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산청장에게 증명서류를 제출할 수 있다(法 52⑥). 이는 원출원에서 조약우선권주장을 하였으나 증명서류를 제출하지 않은 경우, 분할출원에서 조약우선권증명서류를 제출할 수 있는 기회를 주기 위한 규정이다.

(6) 청구범위제출유예기간의 특례

특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 분할출원에 관하여는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다(法 52⑧). 출원인의 출원 편의성을 제고하기 위해 분할출원 후 청구범위를 적는 보정을 할 수 있도록 허용하고, 청구범위를 적는 데 필요한 최소한의 기간을 보장하고 있다.

77) 구체적인 예는 다음과 같다.



78) 채수근 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안, 디자인보호법 일부개정법률안, 상표법 일부개정법률안 검토보고(송갑석 의원 대표발의(의안번호 제2104891호, 제2104892호 및 제2104893호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2, 20면.

(7) 심사청구기간의 특례

심사청구는 출원일로부터 3년 이내에 할 수 있다(法 59②). 그러나 분할출원의 경우에는 원출원일로부터 3년의 기간이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구를 할 수 있도록 하고 있다(法 59③).

(8) 국내우선권주장출원 불가

분할출원은 국내우선권주장출원의 기초가 되는 선출원이 될 수 없다(法 55①Ⅱ). 그러나 국내우선권주장출원을 기초로 분할출원할 수는 있다(法 52④⑤참조).

2. 부적법한 경우의 효과

(1) 불수리

지식재산처장은 i) 분할출원 당시 분할출원의 출원인이 원출원의 출원인 또는 승계인과 일치하지 아니한 경우(복수인 경우에는 모두 일치하여야 함), ii) 원출원이 무효·취하·포기 또는 특허거절결정 확정이 되어 원출원의 절차가 종료된 이후에 분할출원서가 제출된 경우, iii) 분리출원을 기초로 분할출원서가 제출된 경우 및 iv) 분할출원서가 기간을 지나서 제출된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우 소명기회를 주고 소명하지 않거나 소명이 적법하지 아니하면 분할출원서를 불수리하여야 한다(施規 11).

(2) 거절이유 등

심사관은 분할출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우 거절이유통지를 하며, 의견서 제출기간에 제출된 의견서 또는 보정서에 의해서도 지적한 거절이유가 해소되지 아니하면 특허거절결정을 한다(法 62). 다만 의견서 제출기간의 보정에 의하여 흠결이 치유되면 적법한 분할출원으로 보아 다시 출원일의 소급을 인정한다. 한편 이처럼 분할출원이 범위를 벗어난 것으로 인정되는 경우 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133)이다.

V. 외국어특허출원의 경우

1. 원출원이 외국어특허출원인 경우

원출원이 외국어특허출원인 경우에는 그 특허출원에 대한 국어번역문(法 42의3②)이 제출된 경우에만 분할출원할 수 있다(法 52①단서). 심사관과 일반 공중이 분할출원의 적합성 여부를 확인하기 위해서는 국어번역문이 필요하기 때문이다.

2. 분할출원이 외국어특허출원인 경우

1) 분할출원이 외국어특허출원인 경우에 특허출원인은 국어번역문(法 42의3②) 또는 새로운 국어번역문(法 42의3③본문)을 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는

날(다만 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 분할출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다(法 52⑦본문).

2) 다만 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다(法 52⑦단서).

- i) 명세서 또는 도면을 보정(제42조의3제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우
- ii) 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우

VI. 국제특허출원의 경우

특허법에서는 국제특허출원을 원출원으로 하여 분할출원을 할 수 있는 시기와 관련하여 별도의 규정을 두고 있지는 않다. 다만 분할출원은 보정할 수 있는 기간에 할 수 있으므로 국제특허출원의 보정의 기간을 적용하면, 국제특허출원에 관하여는 수수료의 납부, 국어번역문의 제출(국어로 출원된 국제특허출원의 경우를 제외한다) 및 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구 이후를 말한다)을 지난 후에 분할출원을 할 수 있을 것이다(法 208①).

VII. 관련문제

1. 분할출원의 보정

분할출원은 원출원과 별개의 출원이므로 분할출원을 통상의 출원으로 보고 보정의 적법성을 판단한다. 따라서 분할출원 이후에 보정에 의하여 분할출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나서 발명이 신규로 추가되었다면 신규사항추가금지(法 47②)에 위반된 것으로 보고 심사를 진행한다.

2. 분할출원을 기초로 한 분할출원

원출원(이하 “父출원”이라 한다)으로부터 분할출원(이하 “子출원”이라 한다)하고, 다시 子출원을 원출원으로 하여 분할출원(이하 “孫子출원”이라 한다)하였을 때 i) 孫子출원이 子출원에 대하여 분할출원의 요건을 충족할 것, ii) 子출원이 父출원에 대하여 분할출원의 요건을 충족할 것, iii) 孫子출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 父출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 범위 이내일 것을 만족하는 경우 孫子출원의 출원일은 父출원의 출원일로 소급한다.⁷⁹⁾ 이는 출원인이 父출원을 기초로 분할출원을 할 수 없는 경우(예컨대 분할출원의 시기적 제한 때문에 父출원으로부터 출원의 분할을 할 수는 없으나, 子출원으로부터 출원의 분할이 가능한 경우 등)에 실효성이 있다 할 것이다.

79) 변경출원도 이 기준을 적용한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5311면).

제6장

분리출원

제52조의2【분리출원】

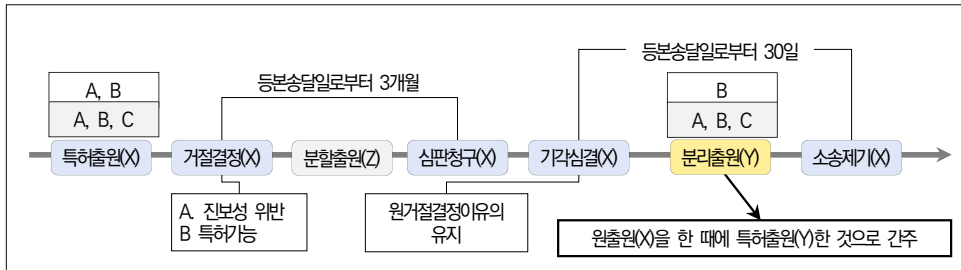
- ① 특허거절결정을 받은 자는 제132조의17에 따른 심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다.
 1. 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
 2. 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항
 3. 제1호 또는 제2호에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항
 4. 제1호부터 제3호까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항
- ② 제1항에 따라 분리된 특허출원(이하 “분리출원”이라 한다)에 관하여는 제52조제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 “분할”은 “분리”로, “분할출원”은 “분리출원”으로 본다.
- ③ 분리출원을 하는 경우에는 제42조의2제1항 후단 또는 제42조의3제1항에도 불구하고 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적을 수 없다.
- ④ 분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원의 기초가 될 수 없다.

[본조신설 2021. 10. 19.]

I. 서 설

1. 의 의

「분리출원」이란 특허거절결정을 받은 자가 거절결정불복심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리하는 것을 말하며, 분리출원을 한 경우 그 분리출원은 원특허출원(이하 “원출원”이라 한다)한 때에 출원한 것으로 본다.



【그림 3-19】 분리출원 일반

2. 취 지

특허거절결정불복심판에서 기각심결이 있는 후에는 분할출원을 할 수 없으므로 거절결정 대상이 되지 않은 청구항(즉 청구범위 중 특허가능한 청구항)을 포함하는 특허출원이 구제받지 못하는 경우가 발생하는 문제점이 있었다. 이에 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 심결취소의 소 제기 전까지 그 청구항을 새로운 특허출원으로 분리하여 신속하게 추가적인 권리획득할 수 있는 기회를 제공하고 있다.

II. 분리출원의 요건

1. 주체적 요건

원출원의 「원출원인(특허거절결정을 받은 자)」가 분리출원을 할 수 있다. 즉 분리출원 당시 분리출원인은 원출원의 출원인 또는 그 승계인과 동일인이어야 한다. 예를 들어 승계인이 출원인변경신고를 통해 원출원을 승계하였으면 승계인이 분리출원을 할 수 있으며, 원출원이 공동출원이면 출원인변경신고를 없는 한 분리출원 역시 공동출원을 하여야 한다. 한편 「분리출원 당시」에만 동일인이면 되고 분리출원 이후에는 출원인이 달라지더라도 상관없다.

2. 객체적 요건

(1) 원출원의 요건

① 분리출원 당시 원출원이 적법하게 출원 계속 중일 것

「분리출원 당시」 원출원이 적법하게 출원 계속 중이어야 한다. 따라서 분리출원 시에 원출원이 취하, 포기되거나 심판청구의 취하에 의한 거절결정의 확정 등이 되어 원출원의 절차가 종료된 때에는 분리출원을 할 수 없다. 다만 원출원이 취하, 포기되거나 심판청구의 취하에 의한 거절결정이 확정된 날과 같은 날에 분리출원이 있는 경우 그 분리출원은 원출원이 지식재산처에 계속 중인 때에 출원한 것으로 취급한다.

② 분리출원이 아닐 것

원출원은 분리출원이 아니어야 한다(法 52의2④). 분리출원이 분할출원을 할 수 없는 영역에서 추가적인 권리획득 기회를 부여하는 것임을 고려할 때 제한적으로 운영할 필요가 있기 때문이다.

(2) 분리출원의 요건

① 명세서 또는 도면의 요건

1) 분리출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다(法 52의2①각호 외의 부분 전단). 「최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항」이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사

항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 원출원일 당시의 기술상식에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 말한다.

2) 분리출원에 포함된 발명 중 일부라도 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에 있지 아니하면 거절이유에 해당한다(法 52의2①, 62). 다만 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에 있다면 삭제보정에 의하여 보정된 명세서 또는 도면에 포함되어 있지 않다고 하더라도 분리출원을 할 수 있다.

② 청구범위의 요건

1) 분리출원의 청구범위에는 다음의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다(法 52의2①후단).

- i) 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항⁸⁰⁾
- ii) 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항⁸¹⁾
- iii) i) 또는 ii)에 따른 청구항을 제47조제3항 각호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항⁸²⁾

80) 일부 청구항에 거절이유가 있을지라도 출원일체의 원칙(all or nothing rule)에 의하여 특허출원 전체가 특허거절결정되고 기각심결이 될 수 있다. 이 경우 거절이유가 없는 청구항(특허가능한 청구항)을 분리출원하여 특허등록받을 수 있도록 하고 있다. 한편 거절결정서나 의견제출통지서에 「참고사항」으로 기재된 사항은 거절이유에 해당된다고 하더라도 거절결정의 이유나 거절이유가 제시된 것이 아니므로, 「참고사항」에만 기재된 청구항은 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항에 해당한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6501면 이하 참조).

81) 하나의 청구항을 선택적으로 기재(예를 들어 2이상의 항을 인용하거나 마쿠쉬 형식으로 기재)하여 하나의 청구항에 여러 발명이 있는 경우 발명 단위로 거절이유를 판단하여, 하나의 발명이라도 거절이유가 있으면 청구항 전체에 거절이유가 있는 것으로 보기 때문에 이로 인해 특허출원 전체가 특허거절결정되고 기각심결이 될 수 있다. 이 경우 거절이유가 있는 발명을 삭제한 청구항을 분리출원하여 특허등록받을 수 있도록 하고 있다. 구체적인 【예】는 다음과 같다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6501면 이하 참조).

【예1】	거절결정 당시 청구항	[청구항 1] A를 포함하는 장치 [청구항 2] 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치 [청구항 3] 청구항 1 또는 2에 있어서, C를 더 포함하는 장치
	거절결정서의 [거절결정의 이유]	- 청구항 1은 D1에 의해 진보성 부정 - 청구항 3에서 청구항 1을 인용하는 발명(A+C)은 D1+D2에 의하여 진보성이 부정됨
	분리출원이 인정되는 청구항	[청구항 1] A, B를 포함하는 장치 → 특허거절결정에서 거절되지 않은 청구항 2에 해당 [청구항 2] A, B, C를 포함하는 장치 → 거절된 청구항 3에서 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항인 인용되는 항 '청구항 1'을 삭제한 청구항에 해당
【예2】	거절결정 당시 청구항	[청구항 1] A는 a, b, c 중 어느 하나로 구성된 장치
	거절결정서의 [거절결정의 이유]	- 청구항 1 발명 중에 'A는 a로 구성된 장치' 발명과 'A는 b로 구성된 장치' 발명은 D1에 의하여 진보성이 부정되므로, 청구항 1은 특허받을 수 없음
	분리출원이 인정되는 청구항	[청구항 1] A는 c로 구성된 장치 → 거절된 청구항 1에서 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항인 'a, b'를 삭제한 청구항에 해당

- iv) i)부터 iii)까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원(원출원)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항⁸³⁾
- 2) 청구항 중 일이라도 분리출원의 청구범위의 요건을 만족하지 아니하면 거절이유에 해당한다(法 52의2①, 62).⁸⁴⁾

3. 시기적 요건

특허출원에 대한 거절결정불복심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(심결취소의 소 제기기간에 대하여 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 분리출원할 수 있다(法 52의2①).

III. 분리출원의 절차

1. 분리출원서 등의 제출

분리출원을 하려는 자는 그 취지 및 분리출원의 기초가 된 특허출원(원출원)의 표시를 한 분리출원서와 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 52의2 ② 준용 52③). 한편 i) 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류, ii) 그 밖의 법령에 따른 증명서류 등을 첨부하여야 한다(施規 29의2①).

- 82) i) 또는 ii)에 따른 청구항(특허가능한 청구항)을 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 또는 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하도록 제한된 범위에서 보정한 청구항을 분리출원하여 특허등록받을 수 있도록 하고 있다.
- 83) i)부터 iii)까지 중 어느 하나의 청구항(특허가능한 청구항 또는 이를 제한된 범위에서 보정한 청구항) 중에서 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항에 대하여 분리출원하여 특허등록받을 수 있도록 하고 있다. 물론 이 경우에는 발명의 설명에서도 원출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제하여야 한다. 구체적인 【예】는 다음과 같다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6501면 이하 참조).

거절결정 당시 청구항	[청구항 1] A, B, C로 구성된 장치 [청구항 2] A, B, C, D, E로 구성된 장치
거절결정서 [거절결정의 이유]	- 청구항 1은 D1에 의하여 진보성 부정 (참고사항) 보정에 의하여 청구항 2는 기통지된 거절이유를 해소하여 거절결정 대상 청구항에 포함시키지 않았으나, E는 신규사항에 해당함
분리출원이 인정되는 청구항	[청구항 1] A, B, C, D로 구성된 장치 → 거절결정에서 거절되지 않은 청구항 2에서 신규사항을 삭제한 청구항에 해당

- 84) 원출원의 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항에 기초하므로, 거절결정서를 작성할 때에는 해당 거절결정의 이유가 적용되는 청구항이 어느 항인지를 객관적으로 알 수 있게 기재하도록 한다. 또한 거절이유 통지 후에 의견서나 보정서가 제출되지 않아 거절결정서에 [거절결정의 이유]를 기재하지 않은 경우에는 해당 거절결정의 기초가 되는 의견제출통지서에서 거절이유가 제시되지 않은 청구항을 거절되지 아니한 청구항으로 보고 분리출원의 청구항에 기재할 수 있으므로, 의견제출통지서를 작성할 때에도 해당 거절이유가 적용되는 청구항이 어느 항인지를 객관적으로 알 수 있게 기재하도록 한다. 특히 특허법 제42조 제3항 제1호에 의해 발명의 설명 기재불비로 거절결정된 출원에 대해서는 반드시 거절이유가 있는 청구항이 어느 항인지를 객관적으로 알 수 있어야 출원인이 분리출원의 기회를 가질 수 있다. 따라서 발명의 설명 기재불비로 의견제출통지서나 거절결정서를 작성할 때에는 거절이유가 있는 청구항을 명시적으로 표시하도록 한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6501면 이하 참조).

2. 우선권주장 및 증명서류 제출 간주

원출원이 조약 또는 국내우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 분리출원을 한 때에 그 분리출원에 대해서도 우선권주장을 한 것으로 보며, 원출원에 대하여 제54조제4항의 조약우선권주장의 증명서류 제출기간 내 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분리출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(法 52의2② 준용 52④). 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제 18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 출원인의 실수 등으로 분리출원 시 우선권주장을 하지 않아서 등록이 거절되는 사례가 발생하는 문제점을 해소하기 위해 분리출원 시 우선권주장을 자동으로 인정하고, 증명서류 제출을 생략함으로써 출원인의 편의를 제고하고 있다.⁸⁵⁾

IV. 분리출원의 효과

1. 적법한 경우의 효과

(1) 출원일의 소급효

① 원 칙

적법하게 분리출원된 경우 그 분리출원은 원출원을 한 때에 출원한 것으로 본다(法 52의2② 준용 52②).

② 예 외

1) 분리출원이 다음에 해당하는 경우에는 출원일이 소급되지 않고 해당 분리출원을 한 때에 출원한 것으로 본다(法 52의2② 준용 52②단서, 92의2④). 이에 대한 구체적인 예는 분할출원에서 상술한 바와 같다.

- i) 확대된 선출원에 관한 규정(法 29③④)에서의 다른 출원에 해당하는 경우
- ii) 공지예외적용의 취지기재 및 증명서류제출기간(法 30②)
- iii) 조약우선권주장출원의 취지 등의 기재(法 54③)
- iv) 국내우선권주장출원의 취지 등의 기재(法 55②)
- v) 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장시 특허출원일의 기산일(法 92의2④)

(2) 원출원과의 관계

분리출원은 원출원과는 전혀 별개의 새로운 출원이므로 심사청구, 출원공개 및 등록료 납부 등을 독립적으로 하여야 한다. 또한 원출원이 우선권주장을 하였다고 하더라도 분리출원이 이들 절차의 효력을 누리기 위해서는 다시 절차를 밟아야 한다. 다만 원출원이 우선권주장을 하지

85) 채수근 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안, 디자인보호법 일부개정법률안, 상표법 일부개정법률안 검토보고(송갑석 의원 대표발의(의안번호 제2104891호, 제2104892호 및 제2104893호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2. 20면.

아니한 경우 실무상 분리출원 역시 상기 주장을 할 수 없다. 그러나 원출원이 공지예외적용주장을 하지 않더라도 분리출원이 상기 주장을 할 수 있다. 한편 분리출원의 심사는 지식재산처장이 정하는 순서에 따른다(施規 38②).⁸⁶⁾

(3) 선출원주의의 회피

1) 분리출원을 한 경우 분리 후 청구범위에 기재된 발명은 원출원의 청구범위에 기재된 발명과 동일하지 아니하여야 하며, 동일한 경우에는 동일자에 동일발명에 관한 출원이 있으므로 협의제(法 36②)가 적용된다.

2) 원출원에 대한 심결취소소송과 원출원에서 특허가능한 청구항에 대한 분리출원이 동시에 계속 중인 경우 협의제의 적용이 문제이다. 심사 실무⁸⁷⁾는 분리출원은 원출원의 거절결정에서 거절되지 아니한 청구항만을 청구범위에 기재한 것이므로, 원출원의 거절결정불복심판의 심결취소소송이 제기되더라도 특별한 이유가 없는 한 심결취소소송의 결과를 기다릴 필요 없이 분리출원에 대해 심사보류하지 않고 심사를 진행하고 있다.⁸⁸⁾ 그 결과 원출원의 특허결정 전이고 원출원을 인용발명으로 하는 선출원주의 위반(法 36②)의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 분리출원에 대해 특허결정하고 있다.⁸⁹⁾

(4) 우선권주장취하기간의 특례

우선권을 주장한 것으로 보는 분리출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한(法 54⑦, 55⑦)이 지난 후에도 분리출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(法 52의2② 준용 52⑤). 이는 우선권주장의 자동간주를 원칙으로 하면서도 우선권주장을 원하지 않은 사항에 대해서는 의사에 따라 배제할 수 있도록 하려는 것이다.⁹⁰⁾

(5) 청구범위제출유예 및 외국어출원 불가

분리출원을 하는 경우에는 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니하여 청구범위제출을 유예하거나 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 국어가 아닌 언어로 적어 외국어출원을 할 수 없다(法 52의2③). 그러나 원출원이 청구범위제출유예한 출원이거나 외국어출원인 경우에는 이를 기초로 분리출원을 할 수 있다.

86) 특허·실용신안 심사사무규정 제21조제1항에 의하면 분리출원은 원출원의 심사청구순서에 따라 심사를 하고 있다.

87) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 6501면 이하 참조.

88) 분리출원의 청구항에 기재된 발명에 대해 원출원의 심사 시에 등록가능하다고 판단한 경우에도 분리출원의 심사 시에 다시 심사한 결과 신규성, 진보성, 기재불비 등의 거절이유를 통지할 수 있다. 이후의 심사절차는 통상적인 심사절차를 따른다.

89) 따라서 분리출원의 특허결정 후에 원출원의 기각심결이 취소되어 특허심판원으로 환송된다면, 특허심판원에서는 원거절결정의 이유와 다른 거절이유인 협의제(法 36②) 위반으로 원출원에 대하여 거절이유통지를 하게 될 것이다.

90) 채수근 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안, 디자인보호법 일부개정법률안, 상표법 일부개정법률안 검토보고(송갑석 의원 대표발의(의안번호 제2104891호, 제2104892호 및 제2104893호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2. 20면.

(6) 심사청구기간의 특례

심사청구는 출원일로부터 3년 이내에 할 수 있다(法 59②). 그러나 분리출원의 경우에는 원출원일로부터 3년의 기간이 지난 후에도 분리출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구를 할 수 있도록 하고 있다(法 59③).

(7) 새로운 분리출원, 분할출원, 변경출원, 국내우선권주장출원 및 재심사 청구 불가

1) 분리출원은 새로운 분리출원, 분할출원 또는 변경출원의 기초가 될 수 없다(法 52의2④). 또한 분리출원은 국내우선권주장출원의 기초가 되는 선출원이 될 수 없으며(法 55①Ⅱ), 분리출원인 경우에는 재심사를 청구할 수 없다(法 67의2①Ⅲ).

2) 그러나 분할출원, 변경출원 또는 국내우선권주장출원을 기초로 분리출원할 수는 있다(法 52의2② 준용 52④⑤참조).

2. 부적법한 경우의 효과

(1) 불수리

지식재산처장은 i) 분리출원 당시 분리출원의 출원인이 원출원의 출원인 또는 승계인과 일치하지 아니한 경우(복수인 경우에는 모두 일치하여야 함), ii) 원출원이 무효·취하·포기 또는 특허거절결정 확정이 되어 원출원의 절차가 종료된 이후에 분리출원서가 제출된 경우, iii) 분리출원을 기초로 분리출원서가 제출된 경우, iv) 분리출원서가 기간을 지나서 제출된 경우 및 v) 청구범위제출유예하거나 외국어로 된 분리출원서가 제출된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우 소명기회를 주고 소명하지 않거나 소명이 적법하지 아니하면 분리출원서를 불수리하여야 한다(施規 11).

(2) 거절이유 등

1) 심사관은 분리출원의 명세서 또는 도면의 요건을 만족하지 않거나(法 52의2①각호 외의 부분 전단 위반) 분리출원의 청구범위 요건을 만족하지 않은 경우(法 52의2①후단 위반) 거절이유통지를 하며, 의견서 제출기간에 제출된 의견서 또는 보정서에 의해서도 지적인 거절이유가 해소되지 아니하면 거절결정을 한다(法 62). 다만 의견서 제출기간의 보정에 의하여 흠결이 치유되면 적법한 분리출원으로 보아 다시 출원일의 소급을 인정한다.

2) 한편 분리출원의 명세서 또는 도면의 요건을 만족하지 않거나(法 52의2①각호 외의 부분 전단 위반) 분리출원의 청구범위 요건을 만족하지 않은 경우(法 52의2①후단 위반) 정보제공사유(法 63의2)이다. 다만 등록 후에는 분리출원의 명세서 또는 도면의 요건을 만족하지 않은 경우(法 52의2①각호 외의 부분 전단 위반)에만 특허무효사유(法 133)이다. 분리출원의 청구범위 요건(法 52의2①후단)은 심사의 신속성을 위해 필요한 규정이어서 등록 후에는 이를 다룰 필요가 없기 때문이다.

제7장

변경출원

제53조 【변경출원】

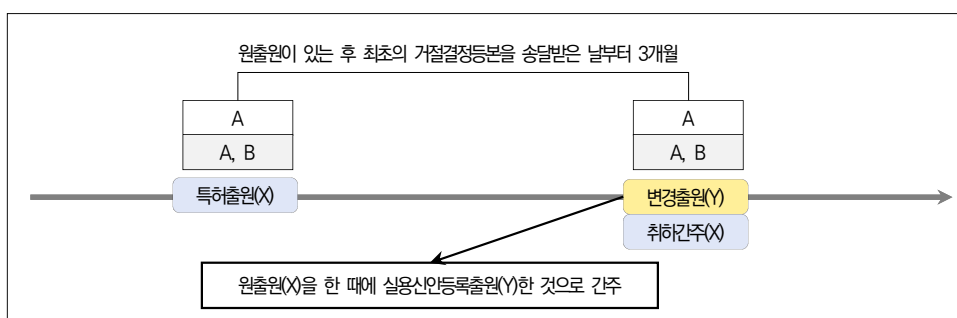
- ① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014. 6. 11., 2016. 2. 29., 2021. 10. 19.>
 1. 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(「실용신안법」 제3조에 따라 준용되는 이 법 제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간을 말한다)이 지난 경우
 2. 그 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제8조의3제2항에 따른 외국어실용신안등록출원인 경우로서 변경하여 출원할 때 같은 항에 따른 국어번역문이 제출되지 아니한 경우
- ② 제1항에 따라 변경된 특허출원(이하 “변경출원”이라 한다)이 있는 경우에 그 변경출원은 실용신안등록출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 변경출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2014.6.11.>
 1. 제29조제3항에 따른 다른 특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제4항에 따른 특허출원에 해당하여 이 법 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제4항을 적용하는 경우
 2. 제30조제2항을 적용하는 경우
 3. 제54조제3항을 적용하는 경우
 4. 제55조제2항을 적용하는 경우
- ③ 제1항에 따라 변경출원을 하려는 자는 변경출원을 할 때 특허출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
- ④ 변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다. <개정 2014.6.11.>
- ⑤ 삭제 <2014.6.11.>
- ⑥ 변경출원의 경우에 제54조에 따른 우선권을 주장하는 자는 같은 조 제4항에 따른 서류를 같은 조 제5항에 따른 기간이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다. <개정 2013.3.22.>
- ⑦ 특허출원인은 변경출원이 외국어특허출원인 경우에는 제42조의3제2항에 따른 국어번역문 또는 같은 조 제3항 본문에 따른 새로운 국어번역문을 같은 조 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다. 다만, 제42조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다. <신설 2014.6.11.>
- ⑧ 특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 변경출원의 경우 제42조의2제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다. <신설 2014.6.11.>

[전문개정 2006.3.3.]

I. 서 설

1. 의 의

「변경출원」이란 실용신안등록출원(이하 “원출원”이라 한다)을 한 자가 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 말한다)까지 특허출원으로 변경하는 것을 말하며, 변경출원을 한 경우 그 변경출원은 원출원을 한 때에 출원된 것으로 본다. 즉 변경출원이란 출원의 형식을 특허출원과 실용신안등록출원 상호 간에 변경하는 것을 말한다.



【그림 3-20】 변경출원 일반

2. 취 지

(1) 출원형식 선택의 과오를 치유할 기회 부여

특허로서 보호받기 위해서는 단순히 발명일 것을 필요로 하나 실용신안으로서 보호받기 위해서는 물품의 형상·구조·조합에 관한 고안이어야 한다. 그런데 출원인이 착오로 물질이나 방법발명을 실용신안등록출원으로 하는 경우가 있다. 이와 같은 단순한 출원형식 선택의 과오를 이유로 거절하고 재출원하게 한다면 우리 법제가 선출원주의를 채용하고 있음을 감안할 때 출원인에게 가혹하다 할 것이다. 따라서 특허법은 변경출원을 두어 이러한 폐해를 방지하고 있다.

(2) 진보성 위반을 극복하기 위한 방안

변경출원제도는 물품성이 있는 물건발명에 대한 특허출원이 진보성이 없다는 이유로 거절결정이 확정될 가능성이 있는 경우 이를 극복하는 방안으로서 의미가 있다고 할 것이다. 이는 진보성을 판단할 때 실용신안법은 특허법보다 낮은 수준인 「극히 용이성」을 요구하고 있기 때문이다.

3. 종 류

i) 실용신안등록출원을 기초로 특허출원하는 변경출원(法 53)과 ii) 특허출원을 기초로 실용신안등록출원하는 변경출원(實用 10)이 있다.

II. 변경출원의 요건

1. 주체적 요건

1) 「원출원」을 한 자가 변경출원을 할 수 있다. 즉 변경출원 당시 변경출원인은 원출원의 출원인 또는 그 승계인과 동일인이어야 한다. 예를 들어 원출원의 출원인이 출원단계에서 변경 되었으면 변경된 출원인이 변경출원을 할 수 있으며, 원출원이 공동출원이면 출원인변경신고가 없는 한 변경출원 역시 공동출원을 하여야 한다. 한편 「변경출원 당시」에만 동일인이면 되고 변경출원 이후에는 출원인이 달라지더라도 상관없다.

2) 임의대리인은 특별히 권한을 위임받지 않으면 변경출원을 할 수 없다(法 6). 이는 변경출원을 하는 경우 원출원이 취하간주되기 때문에 출원인에게 직접적인 이해관계가 있어 신중하게 처리하기 위함이다.

2. 객체적 요건

(1) 원출원의 요건

① 변경출원 당시 원출원이 적법하게 출원 계속 중일 것

「변경출원 당시」 원출원은 적법하게 「출원 계속 중」이어야 한다. 이미 출원절차가 종료된 출원에 관하여 변경출원을 인정해 준다면 행정절차가 복잡해지고 영속적으로 변경출원을 할 수 있는 권리를 인정하게 되어 절차의 안정성을 해치는 결과를 초래하기 때문이다. 따라서 변경출원 시에 원출원이 무효, 취하, 포기, 설정등록되거나 특허거절결정이 확정되어 원출원의 절차가 종료된 때에는 변경출원을 할 수 없다. 다만 원출원이 취하 또는 포기된 날과 같은 날에 변경출원이 있는 경우 그 변경출원은 원출원이 지식재산처에 계속 중인 때에 출원한 것으로 본다.

② 분리출원이 아닐 것

원출원은 분리출원이 아니어야 한다(法 52의2④). 분리출원이 거절결정불복심판에서의 기각 심결이 있는 후 제한된 범위인 특허가능한 청구항에 대해서 신속히 권리획득기회를 주는 제도를 고려했을 때 이를 기초로 다시 변경출원하여 권리범위를 재설정하는 것은 그 취지에 부합하지 않기 때문이다.

(2) 변경출원의 요건

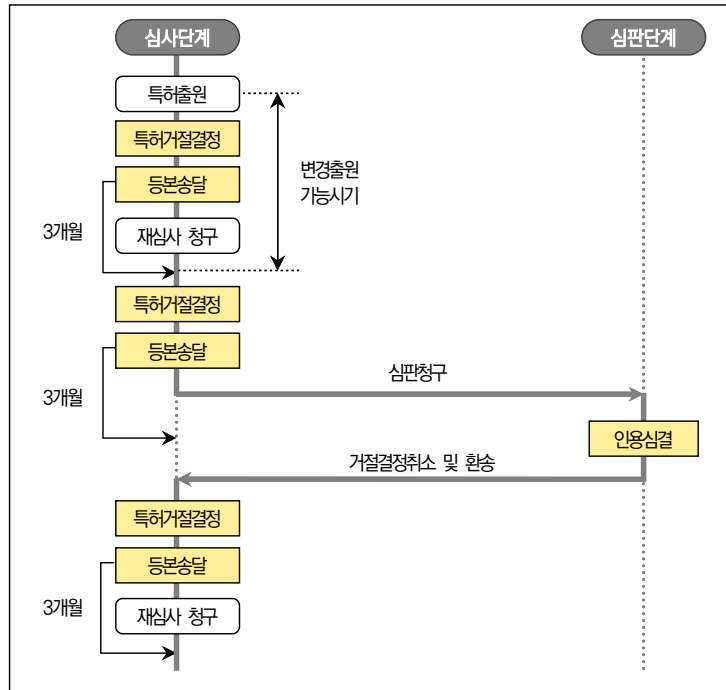
1) 변경출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다. 「최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항」이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 원출원일 당시의 기술상식에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 말한다.

2) 변경출원에 포함된 발명 중 일부라도 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나면 거절이유에 해당한다(法 53①, 62). 다만 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에 있다면 삭제보정에 의하여 보정된 명세서 또는 도면에 포함되어 있지 않다고 하더라도 변경출원을 할 수 있다.

3. 시기적 요건

원출원이 있는 후 변경출원을 할 수 있으나 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(거절결정불복심판청구를 할 수 있는 기간이 연장된 경우에는 그 기간을 말한다)이 지난 후에는 변경출원을 할 수 없다(法 53① I). 이는 변경출원이 특허거절결정에 대한 일방책(一方策)임을 감안하여 출원인에게 변경출원, 거절결정불복심판의 청구와 재심사 청구 중 택일적으로 조치를 취할 기회를 주기 위함이다.⁹¹⁾ 한편 「최초」 특허거절결정등본을 받은 경우에 한정되므로 거절결정불복심판 또는 재심사를 청구하여 원특허거절결정이 취소되었다거나 그에 따라 특허거절결정등본을 다시 송달받아 3개월 이내라고 하더라도 변경출원할 수 없다.

91) 특허거절결정에 대한 심판청구 또는 재심사 청구와 동시에 변경출원된 경우에는 그 절차가 형식적으로 적법한 때에는 수리하며, 그 변경출원이 심사청구된 경우에는 심사를 진행하고 심판청구 또는 재심사 청구에 대해서는 제53조제4항에 따라 원출원은 취하된 것으로 보고 각 절차에 따라 처리한다.



【그림 3-21】 변경출원 가능시기

III. 변경출원의 절차

실용신안등록출원을 특허출원으로 변경출원을 하려는 자는 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 원출원의 표시를 한 변경출원서와 명세서, 필요한 도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 53③).⁹²⁾ 한편 i) 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류, ii) 그 밖의 법령에 따른 증명서류 등을 첨부하여야 한다(施規 30①).

IV. 변경출원의 효과

1. 적법한 경우의 효과

(1) 출원일의 소급효

① 원 칙

적법하게 변경출원된 경우 그 변경출원은 원실용신안등록출원을 한 때에 출원한 것으로 본다

92) 특허출원을 실용신안등록출원으로 변경출원하는 경우에는 반드시 도면을 첨부하여야 하며, 그렇지 아니한 경우 불수리된다.

(法 53②).

② 예 외

변경출원이 다음에 해당하는 경우에는 출원일이 소급되지 않고 해당 변경출원을 한 때에 출원한 것으로 본다(法 53②단서, 99의2④). 이에 대한 구체적인 예는 분할출원에서 상술한 바와 같다.

- i) 확대된 선출원에 관한 규정(法 29③④)에서의 다른 출원에 해당하는 경우
- ii) 공지에외적용의 취지기재 및 증명서류제출기간(法 30②)
- iii) 조약우선권주장출원의 취지 등의 기재(法 54③)
- iv) 국내우선권주장출원의 취지 등의 기재(法 55②)
- v) 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장시 특허출원일의 기산일(法 92의2④)

(2) 원출원과 관계

변경출원은 원출원과는 별개의 새로운 출원이므로 심사청구, 출원공개 및 등록료 납부 등을 독립적으로 하여야 한다. 원출원이 우선권주장을 하였다고 하더라도 변경출원이 이들 절차의 효력을 누리기 위해서는 다시 절차를 밟아야 한다. 다만 원출원이 우선권주장을 하지 아니한 경우 실무상 변경출원 역시 상기 주장을 할 수 없다. 그러나 원출원이 공지에외적용주장을 하지 않더라도 변경출원 시 상기 주장을 할 수 있다. 한편 변경출원의 심사는 지식재산처장이 정하는 순서에 따른다(施規 38②).⁹³⁾

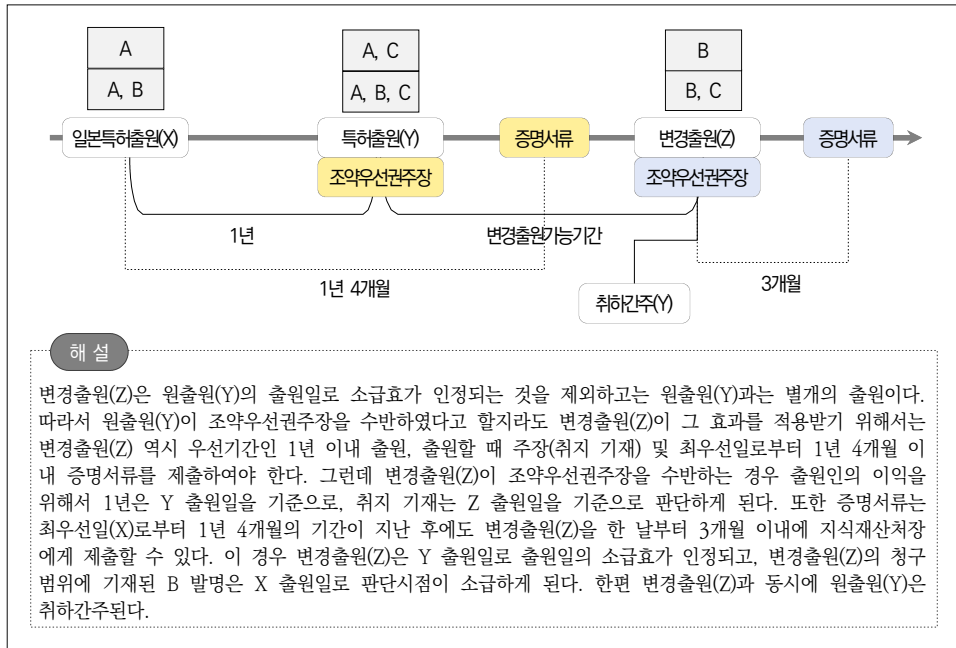
(3) 원출원의 취하간주

변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다(法 53④). 이것은 동일한 발명에 대한 중복 권리 허여를 배제하기 위함이다. 만일 원출원이 취하간주되지 아니한다면 원출원의 청구범위에 기재된 발명을 변경출원하는 경우 협의제에 의할 수밖에 없을 것이다. 한편 변경출원과 동시에 원출원이 취하된 것으로 보기 때문에 변경출원에 하자가 있어 특허거절결정되는 경우가 발생하더라도 원출원을 되살릴 방법이 없음에 유의하여야 한다.

(4) 조약우선권주장의 증명서류 제출기간의 특례

조약우선권주장을 할 때 증명서류는 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다(法 54⑤). 그러나 변경출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우에는, 즉 조약우선권주장의 취지를 기재하면서 변경출원하는 경우에는 최우선일로부터 1년 4개월의 기간이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 증명서류를 제출할 수 있다(法 53⑥).

93) 특허·실용신안 심사사무취급규정 제21조제1항에 의하면 변경출원은 원출원의 심사청구순서에 따라 심사를 하고 있다.



【그림 3-22】 조약우선권주장을 수반하는 변경출원

(5) 청구범위제출유예기간의 특례

특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 변경출원에 관하여는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 할 수 있다(法 53⑧).

(6) 심사청구기간의 특례

심사청구는 출원일로부터 3년 이내에 할 수 있다(法 59②). 그러나 변경출원(실용신안등록출원을 특허출원으로 변경출원)의 경우에는 원출원일로부터 3년의 기간이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 심사청구를 할 수 있도록 하고 있다(法 59③).

(7) 국내우선권주장출원 불가

변경출원은 국내우선권주장출원의 기초가 되는 선출원이 될 수 없다(法 55①Ⅱ). 그러나 국내우선권주장출원을 기초로 변경출원할 수는 있다(法 53②⑥참조).

2. 부적법한 경우의 효과

(1) 불수리

지식재산청장은 i) 변경출원 당시 변경출원의 출원인이 원출원의 출원인 또는 승계인과 일치하지 아니한 경우(복수인 경우에는 모두 일치하여야 함), ii) 원출원이 무효·취하·포기 또는 특허거절결정 확정이 되어 원출원의 절차가 종료된 이후에 변경출원서가 제출된 경우, iii) 분리출원을 기초로 변경출원서가 제출된 경우 및 iv) 변경출원서가 기간을 지나서 제출된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우 소명기회를 주고 소명하지 않거나 소명이 적법하지 아니하면 변경출원서를 불수리하여야 한다(施規 11).

(2) 거절이유 등

심사관은 변경출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우 거절이유통지를 하며, 의견서 제출기간에 제출된 의견서 또는 보정서에 의해서도 지적인 거절이유가 해소되지 아니하면 특허거절결정을 한다(法 62). 다만 의견서 제출기간 보정에 의하여 흠결이 치유되면 적법한 변경출원으로 보아 다시 출원일의 소급을 인정한다. 한편 이처럼 변경출원이 범위를 벗어난 것으로 인정되는 경우 정보제공사유(法 63의2), 특허무효사유(法 133)이다.

V. 외국어특허출원의 경우

1. 원출원이 외국어실용신안등록출원인 경우

원출원이 외국어실용신안등록출원인 경우에는 그 실용신안등록출원에 대한 국어번역문(法 42의3②)이 제출된 경우에만 변경출원할 수 있다(法 53①Ⅱ).

2. 변경출원이 외국어특허출원인 경우

1) 변경출원이 외국어특허출원인 경우에 특허출원인은 국어번역문(法 42의3②) 또는 새로운 국어번역문(法 42의3③본문)을 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(다만 기한 이전에 출원심사 청구의 취지를 통지(法 60③)받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)의 기한이 지난 후에도 변경출원을 한 날부터 30일이 되는 날까지는 제출할 수 있다(法 53⑦본문).

2) 다만 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다(法 53⑦단서).

- i) 명세서 또는 도면을 보정(제42조의3제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외한다)한 경우
- ii) 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우

VI. 국제특허출원의 경우

실용신안법 제34조제1항에 따라 국제출원일에 출원된 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우에는 이 제53조제1항에도 불구하고 실용신안법 제17조제1항에 따른 수수료를 내고 같은 법 제35조제1항에 따른 국어번역문(국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우는 제외한다)을 제출한 후(실용신안법 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 것으로 보는 국제출원을 기초로 하는 경우에는 같은 항에 따른 결정이 있는 후)에만 변경출원을 할 수 있다(法 209). 수수료 납부와 국어번역문 제출은 대한민국 지식재산처에서 최소한 심사를 받기 위한 요건이기 때문에 이를 만족한 후 변경출원할 수 있도록 시기적 제한을 두고 있다.

VII. 관련문제

1. 변경출원의 보정

변경출원은 원출원과 별개의 출원이므로 변경출원을 통상의 출원으로 보고 보정의 적합성을 판단한다. 따라서 변경출원 이후에 보정에 의하여 변경출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어나서 발명이 신규로 추가되었다면 신규사항추가금지(法 47②)에 위반된 것으로 보고 심사를 진행한다. 한편 변경출원의 보정이 변경출원의 최초 명세서 또는 도면과 비교하여 보정요건을 충족하였다 하더라도 변경출원의 요건을 충족하지 아니한 경우 거절이유(法 62)에 해당한다.

2. 분할출원과의 관계

분할출원을 한 후 그 분할출원을 원출원으로 하여 변경출원을 할 수 있다. 다만 분할출원과 변경출원이 하나의 절차에 의하여 이루어질 수는 없으므로 특허출원된 발명(A, B) 중 일부(A)를 특허로 보호받고, 일부(B)를 실용신안으로 보호받고자 할 때에는 일단 그 발명(B)을 동일한 출원형식으로 분할출원을 하고 그 분할출원을 다시 변경출원하여야 한다. 분할출원하지 않고 발명(A, B)에 대한 특허출원에서 발명(B)를 바로 변경출원하는 경우에는 특허출원이 취하간주되어(法 53④) 변경출원한 발명(B)에 대해서만 실용신안으로 보호를 받을 수 있게 된다.

【표 3-7】 분할출원, 분리출원 및 변경출원의 비교

제 도		분할출원(法 52)	분리출원(法 52의2)	변경출원(法 53)
서	의의	원출원에 둘 이상의 발명이 포함된 경우 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 보정할 수 있는 기간, 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 또는 특허결정등본을 송달받은 날부터 3개월 기간(다만 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간) 이내의 기간에 그 일부를 별개의 특허출원으로 분할하는 것을 말한다.	거절결정을 받은 자의 불복심판청구가 기각된 경우 심결 등본을 송달받은 날부터 30일(심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리하는 것을 말한다.	실용신안등록출원을 한 자가 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 최초의 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월까지 특허출원으로 변경하는 것을 말한다.
	취지	1. 출원일체의 원칙 회피 2. 발명의 설명/도면에만 기재된 발명의 보호 3. 권리범위 재설정 기회 확보	거절결정불복심판에 대한 기각 심결이 있는 후 소 제기 전까지 추가적인 권리획득할 수 있는 기회 제공	1. 출원형식선택의 과오 치유 (실→특) 2. 진보성 위반 거절이유 극복 (특→실)
요건	주체적	1. 분할·분리·변경출원 당시 원출원인 또는 그 승계인과 분할·분리·변경출원인이 동일인 2. 임의대리인이 변경출원하는 경우에는 특별히 권한을 위임받아야 함	1. 분할·분리·변경출원 당시 출원 계속 중이고, 분리출원이 아닐 것 2. 분할출원의 경우 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 둘 이상의 발명 포함	1. 분할·분리·변경출원 당시 출원 계속 중이고, 분리출원이 아닐 것 2. 분할출원의 경우 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 둘 이상의 발명 포함
	객체적	원출원 분할/분리/변경출원	1. 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항 범위 2. 분리출원의 경우 청구범위에 기재된 청구항이 일정요건을 만족할 것*	1. 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항 범위 2. 분리출원의 경우 청구범위에 기재된 청구항이 일정요건을 만족할 것*
	시기적	1. 보정을 할 수 있는 기간(法 47①), 2. 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(연장된 경우 그 기간) 3. 특허결정등본을 송달받은 날부터 3개월 기간(다만 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)	거절결정불복심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다)	원출원이 있는 후 최초의 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(연장된 경우에는 연장된 기간)
	절차	1. 그 취지 및 원출원 표시를 한 분할·분리·변경출원서와 명세서, 필요한 도면 및 요약서 제출 2. 분할·분리출원의 경우 원출원이 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 자동 주장 간주하며, 원출원에 대하여 조약우선권주장증명서류 제출기간 내 증명서류 제출이 있는 자동 제출간주. 이 경우 우선권주장의 보정 또는 추가기한이 지난 후에도 분할·분리출원을 한 날부터 30일 이내 우선권 주장의 전부 또는 일부 취하가능 / 단, 변경출원은 변경출원과 동시에 우선권주장을 하고 증명서류를 별도로 제출	1. 그 취지 및 원출원 표시를 한 분할·분리·변경출원서와 명세서, 필요한 도면 및 요약서 제출 2. 분할·분리출원의 경우 원출원이 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 자동 주장 간주하며, 원출원에 대하여 조약우선권주장증명서류 제출기간 내 증명서류 제출이 있는 자동 제출간주. 이 경우 우선권주장의 보정 또는 추가기한이 지난 후에도 분할·분리출원을 한 날부터 30일 이내 우선권 주장의 전부 또는 일부 취하가능 / 단, 변경출원은 변경출원과 동시에 우선권주장을 하고 증명서류를 별도로 제출	1. 그 취지 및 원출원 표시를 한 분할·분리·변경출원서와 명세서, 필요한 도면 및 요약서 제출 2. 분할·분리출원의 경우 원출원이 우선권을 주장한 특허출원인 경우에는 자동 주장 간주하며, 원출원에 대하여 조약우선권주장증명서류 제출기간 내 증명서류 제출이 있는 자동 제출간주. 이 경우 우선권주장의 보정 또는 추가기한이 지난 후에도 분할·분리출원을 한 날부터 30일 이내 우선권 주장의 전부 또는 일부 취하가능 / 단, 변경출원은 변경출원과 동시에 우선권주장을 하고 증명서류를 별도로 제출
효과	적법	1. 출원일의 소급효(예외 있음) 2. 원출원과의 독립성. 단 심사순서는 지식재산처장이 정하는 바에 의함 / 원출원이 우선권주장하지 않은 경우 분할·분리·변경출원도 불가 3. 협의제의 회피 - 분할·분리출원은 원출원과 청구범위가 동일한 경우 회피해야 하나, 변경출원은 변경출원과 동시에 원출원의 취하간주로 회피 불필요 4. 우선권주장취하시기의 특례 - 우선권 자동 주장 간주 분할·분리출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한이 지난 후에도 분할·분리출원을 한 날부터 30일 이내에 주장의 전부 또는 일부를 취하가능 5. 조약우선권주장의 증명서류 제출기간의 특례 - 최우선일로부터 1년 4개월 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 3개월 이내 6. 청구범위제출유예기간의 특례 - 청구범위제출유예기간(法 42의2②)이 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 30일 이내 / 단, 분리출원은 청구범위제출유예 불가 7. 심사청구기간의 특례 - 원출원일로부터 3년 지난 후라도 분할, 분리, 변경출원일로부터 30일 이내 8. 국내우선권주장출원과의 관계 - 분할·분리·변경출원은 국내우선권주장출원의 선출원 불가	1. 출원일의 소급효(예외 있음) 2. 원출원과의 독립성. 단 심사순서는 지식재산처장이 정하는 바에 의함 / 원출원이 우선권주장하지 않은 경우 분할·분리·변경출원도 불가 3. 협의제의 회피 - 분할·분리출원은 원출원과 청구범위가 동일한 경우 회피해야 하나, 변경출원은 변경출원과 동시에 원출원의 취하간주로 회피 불필요 4. 우선권주장취하시기의 특례 - 우선권 자동 주장 간주 분할·분리출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한이 지난 후에도 분할·분리출원을 한 날부터 30일 이내에 주장의 전부 또는 일부를 취하가능 5. 조약우선권주장의 증명서류 제출기간의 특례 - 최우선일로부터 1년 4개월 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 3개월 이내 6. 청구범위제출유예기간의 특례 - 청구범위제출유예기간(法 42의2②)이 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 30일 이내 / 단, 분리출원은 청구범위제출유예 불가 7. 심사청구기간의 특례 - 원출원일로부터 3년 지난 후라도 분할, 분리, 변경출원일로부터 30일 이내 8. 국내우선권주장출원과의 관계 - 분할·분리·변경출원은 국내우선권주장출원의 선출원 불가	1. 출원일의 소급효(예외 있음) 2. 원출원과의 독립성. 단 심사순서는 지식재산처장이 정하는 바에 의함 / 원출원이 우선권주장하지 않은 경우 분할·분리·변경출원도 불가 3. 협의제의 회피 - 분할·분리출원은 원출원과 청구범위가 동일한 경우 회피해야 하나, 변경출원은 변경출원과 동시에 원출원의 취하간주로 회피 불필요 4. 우선권주장취하시기의 특례 - 우선권 자동 주장 간주 분할·분리출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한이 지난 후에도 분할·분리출원을 한 날부터 30일 이내에 주장의 전부 또는 일부를 취하가능 5. 조약우선권주장의 증명서류 제출기간의 특례 - 최우선일로부터 1년 4개월 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 3개월 이내 6. 청구범위제출유예기간의 특례 - 청구범위제출유예기간(法 42의2②)이 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 30일 이내 / 단, 분리출원은 청구범위제출유예 불가 7. 심사청구기간의 특례 - 원출원일로부터 3년 지난 후라도 분할, 분리, 변경출원일로부터 30일 이내 8. 국내우선권주장출원과의 관계 - 분할·분리·변경출원은 국내우선권주장출원의 선출원 불가
	부적법	1. 불수리 → 주체적, 시기적 요건 위반 / 분할·분리·변경출원 당시 원출원에 관한 절차가 종료 / 분리출원서를 기초로 분할·분리·변경출원서 제출 / 청구범위제출유예하거나 외국어로 된 분리출원 2. 거절이유, 정보제공사유 및 특허무효사유 → 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위를 벗어난 경우 (분리출원은 청구범위의 요건 위반한 경우도 거절이유, 정보제공사유)	1. 불수리 → 주체적, 시기적 요건 위반 / 분할·분리·변경출원 당시 원출원에 관한 절차가 종료 / 분리출원서를 기초로 분할·분리·변경출원서 제출 / 청구범위제출유예하거나 외국어로 된 분리출원 2. 거절이유, 정보제공사유 및 특허무효사유 → 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위를 벗어난 경우 (분리출원은 청구범위의 요건 위반한 경우도 거절이유, 정보제공사유)	1. 불수리 → 주체적, 시기적 요건 위반 / 분할·분리·변경출원 당시 원출원에 관한 절차가 종료 / 분리출원서를 기초로 분할·분리·변경출원서 제출 / 청구범위제출유예하거나 외국어로 된 분리출원 2. 거절이유, 정보제공사유 및 특허무효사유 → 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위를 벗어난 경우 (분리출원은 청구범위의 요건 위반한 경우도 거절이유, 정보제공사유)
외국어	원출원	국어번역문이 제출된 경우에만 분할출원, 변경출원 가능(분리출원도 마찬가지)	국어번역문 제출기간이 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 30일(단 보정하거나, 출원인이 심사청구한 경우 새로운 국어번역문 제출 불가) / 분리출원은 외국어출원 불가	국어번역문 제출기간이 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 30일(단 보정하거나, 출원인이 심사청구한 경우 새로운 국어번역문 제출 불가) / 분리출원은 외국어출원 불가
	분할·변경출원	국어번역문 제출기간이 지난 후라도 분할출원, 변경출원 가능(분리출원도 마찬가지)	국어번역문 제출기간이 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 30일(단 보정하거나, 출원인이 심사청구한 경우 새로운 국어번역문 제출 불가) / 분리출원은 외국어출원 불가	국어번역문 제출기간이 지난 후라도 분할출원, 변경출원일로부터 30일(단 보정하거나, 출원인이 심사청구한 경우 새로운 국어번역문 제출 불가) / 분리출원은 외국어출원 불가
국제특허출원		1. 분할출원은 수수료 납부+번역문 제출(단, 국어출원 제외)+기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구 이후) 지난 후(法 208①) 2. 변경출원은 수수료 납부+번역문 제출 후(法 209)	1. 분할출원은 수수료 납부+번역문 제출(단, 국어출원 제외)+기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구 이후) 지난 후(法 208①) 2. 변경출원은 수수료 납부+번역문 제출 후(法 209)	1. 분할출원은 수수료 납부+번역문 제출(단, 국어출원 제외)+기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구 이후) 지난 후(法 208①) 2. 변경출원은 수수료 납부+번역문 제출 후(法 209)

* i) 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항, ii) 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항, iii) i) 또는 ii)에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항, iv) i)부터 iii)까지 중 어느 하나의 청구항에서 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항

제8장

조약우선권주장출원

제54조 【조약에 의한 우선권 주장】

- ① 조약에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다.
1. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국의 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우
 2. 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국에 대한민국 국민이 특허출원한 후 동일한 발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우
- ② 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 우선권 주장의 기초가 되는 최초의 출원일부터 1년 이내에 특허출원을 하지 아니하면 우선권을 주장할 수 없다.
- ③ 제1항에 따라 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국가명 및 출원의 연월일을 적어야 한다.
- ④ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자는 제1호의 서류 또는 제2호의 서면을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 다만, 제2호의 서면은 총리령으로 정하는 국가의 경우만 해당한다.
1. 최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본
 2. 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 그 밖에 출원을 확인할 수 있는 정보 등 총리령으로 정하는 사항을 적은 서면
- ⑤ 제4항에 따른 서류 또는 서면은 다음 각 호에 해당하는 날 중 최우선일(最優先日)부터 1년 4개월 이내에 제출하여야 한다.
1. 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일
 2. 그 특허출원이 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
 3. 그 특허출원이 제3항에 따른 다른 우선권 주장을 수반하는 경우에는 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 출원일
- ⑥ 제3항에 따라 우선권을 주장한 자가 제5항의 기간에 제4항에 따른 서류를 제출하지 아니한 경우에는 그 우선권 주장은 효력을 상실한다.
- ⑦ 제1항에 따라 우선권 주장을 한 자 중 제2항의 요건을 갖춘 자는 제5항에 따른 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

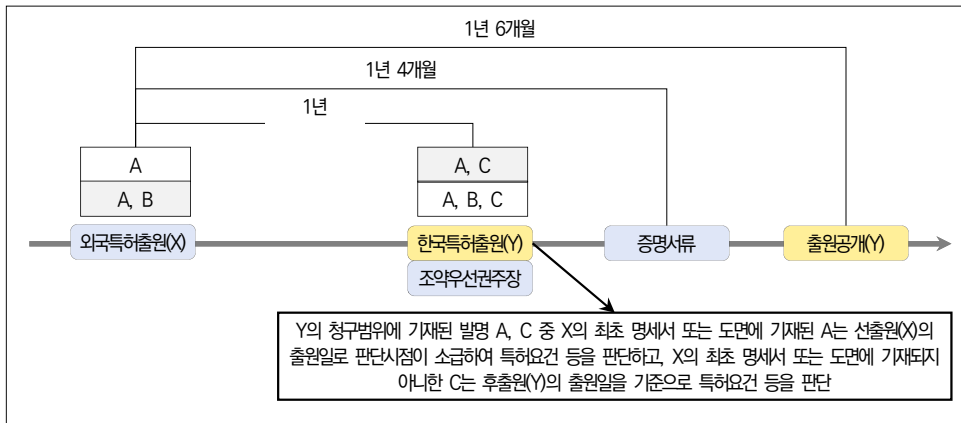
제63조의3 【외국의 심사결과 제출명령】

심사관은 제54조에 따른 우선권주장을 수반한 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 기간을 정하여 그 우선권주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(그 심사결과가 없는 경우에는 그 취지를 적은 의견서를 말한다)를 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다.

I. 서 설

1. 의 의

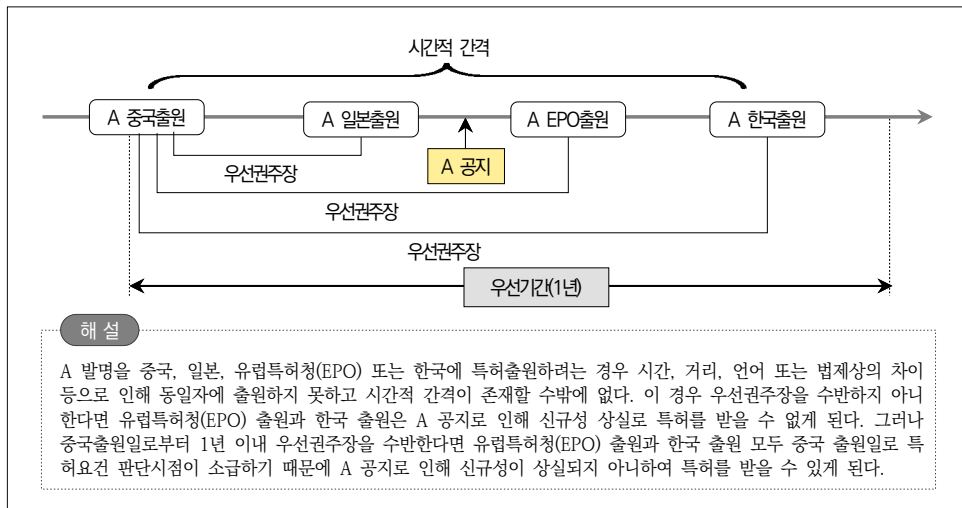
「조약우선권주장출원」이란 조약에 의하여 우리나라 국민에게 우선권을 인정하는 당사자 국민 또는 대한민국 국민이 조약 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원(이하 “선출원”이라 한다)한 후 1년 이내에 동일발명을 대한민국에 특허출원하여 우선권을 주장하는 경우에 제29조 및 제36조를 적용할 때에 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 보는 출원을 말한다(法 54①).



【그림 3-23】 조약우선권주장출원 일반

2. 취 지

출원인이 발명을 다수국에 출원하여 국제적으로 보호받기 위해서는 특허독립의 원칙에 의하여 국가마다 별개의 출원을 하여야 하는데 이 경우 시간·거리·비용 또는 법제상의 차이로 인하여 각국의 출원별로 시간적 간격(gap)이 존재하는 어려움이 따르는 것이 현실이다. 이에 특허법은 진정한 선출원자의 지위를 보장하고 발명의 국제적 보호를 위해 조약우선권제도를 두고 있다. 이러한 조약에 의한 우선권제도는 파리조약상의 우선권제도가 기본적으로 적용이 되고 그 밖에 파리조약의 비동맹국이라고 하더라도 우리나라와 조약에 따라 상호 우선권을 인정하기로 한 국가도 적용이 된다.



【그림 3-24】 조약우선권주장의 필요성

3. 우선권의 성질

(1) 복수성

동맹국에의 최초 정규출원으로 발생한 우선권은 하나의 불가분적인 것이 아니라 조약의 동맹국 수와 같은 복수의 집합($n-1$; 여기서 n 은 전체 조약 동맹국 수)을 내포하고 있다. 이를 우선권의 「복수성」이라 한다.

(2) 잠재성

우선권은 다수의 동맹국에 미치는 복수의 집합개념이나 모든 동맹국에 항상 행사되는 것은 아니고 전혀 행사되지 아니한 채 소멸하거나, 행사되더라도 일부 동맹국에 그치는 것이 일반적이다. 즉 우선권이란 현실화할 가능성이 있는 권리인 동시에 현실화하지 아니한 채 소멸할 가능성도 있는 잠재적인 것이다. 이를 우선권의 「잠재성」이라 한다.

(3) 독립성

우선권은 최초 출원행위로부터 발생하지만 그 발생과 함께 그 최초출원으로부터 분리되어 독립적이 된다. 이를 우선권의 「독립성」이라 하는데, 이러한 독립성 때문에 우선권만의 양도가 가능하므로 제1국 출원의 승계인은 우선권을 별도로 승계하여야 우선권주장출원을 할 수 있다. 또한 우선권의 독립성으로 말미암아 제1국 출원은 정규성만 인정되면 된다.

(4) 부속성

우선권은 동맹국의 최초 정규출원으로부터 독립된 것이라고 하더라도 그 독립성은 어디까지나 제2국 출원의 기초로써 사용될 때까지 성립되는 것이다. 따라서 제2국 출원의 기초로서 일단

행사된 때에는 독립성을 잃는 것이며, 그 후에는 제2국 출원의 부속물로서 제2국 출원국의 특허법에서의 출원과 그 운명을 함께 한다. 이를 우선권의 「부속성」이라고 한다.

4. 조약우선권의 유형

조약우선권의 유형에는 복합우선과 부분우선이 있다. i) 「복합우선」이란 하나의 출원에 관하여 복수의 우선권(둘 이상의 국가에서 한 출원에 기한 것을 포함한다)을 주장하는 것을 말하며, ii) 「부분우선」이란 1 또는 그 이상의 우선권을 주장하는 출원이 그 우선권이 주장되는 출원에 포함되지 아니한 일 또는 그 이상의 발명을 포함하는 것을 말한다. 어느 동맹국은 특허출원인이 복합우선 또는 부분우선을 주장한다고 하여, 그 우선권 또는 그 특허출원을 거절할 수 없다. 다만 이 두 경우에 그 동맹국의 법령상 발명의 단일성이 있는 경우에 한하며, 우리나라 특허법의 해석상 우선권주장출원이 발명의 단일성이 인정되지 아니할 때는 제45조 위반으로 거절이유통지를 할 수 있다. 우선권이 주장되는 선출원에 포함되지 않았던 구성요소에 대해서는 후출원일을 기준으로 특허요건 등을 판단하게 한다(파리조약 4F).

II. 우선권주장의 요건

1. 주체적 요건

(1) 우선권을 주장할 수 있는 자

우선권주장출원은 대한민국 국민, 조약 당사국 국민 또는 준당사국 국민⁹⁴⁾이 우선권주장을 할 수 있다(파리조약 2, 3, 4). 여기서 「조약」이란 파리조약을 포함한 다자 간 조약 또는 양자 간 조약⁹⁵⁾을 말하며 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권주장을 인정하는 조약이면 모두 포함되는 것으로 해석하여야 한다.

94) 현행 특허법 제54조 규정에 의하면 우선권주장을 할 수 있는 자는 조약 당사국 국민에 대하여만 규정되어 있다. 그러나 파리조약 제3조에 의하면 당사국에居所(domicile) 또는 진정하고 실효적인 산업상 또는 상업상 영업소를 가지는 비당사국 국민도 당사국 국민과 같이 취급하도록 규정되어 있고 헌법 제6조 제1항에서는 “헌법에 의하여 체결·공포된 조약과 일반적으로 승인된 국제법규는 국내법과 같은 효력을 가진다”라고 규정되어 있으므로 비동맹국 국민도 동맹국에居所나 영업소 등이 있는 경우 우리나라에 우선권주장을 할 수 있으며, 무국적자도 비당사국 국민으로 보아 우선권주장 출원을 할 수 있는 것으로 취급한다.

95) 양자 사이 조약으로서는 우리나라와 캐나다('79. 2. 13), 핀란드('79. 9. 13), 스페인('75. 8. 15), 스위스('77. 12. 12), 영국('78. 2. 19) 및 미국('78. 2. 30)간의 우선권주장을 상호 인정하는 조약이 있다. 그러나 이들 양자 사이 조약은 우리나라가 1980. 5. 4. 파리조약에 가입함에 따라 그 의미가 퇴색되었다. 한편 특허법조약(PLT)은 2000. 6. 타결되었으나 아직까지 발효되지는 않았고, 특허실체법조약(SPLT)은 현재 논의가 진행되고 있다.

- iv) 최선출원에 의하여 어떠한 권리도 존속되지 아니하였을 것
- v) 최선출원이 같은 국가 혹은 타국에서 아직 우선권주장의 기초로 되지 않았을 것

② 출원의 정규성

선출원은 정규의 출원이어야 한다. 「정규출원」이란 동맹 제1국에서 출원에 대한 방식심사를 한 결과 출원번호와 연월일이 부여된 출원을 의미한다. 일단 정규의 출원으로 인정되면 그 출원이 무효·취하·포기·거절된 경우에도 이를 기초로 우선권주장을 할 수 있다. 이는 상술한 바와 같이 우선권의 독립성에 기인한 것으로서 우선권주장출원 당시 선출원이 출원 계속 중이어야 한다는 국내우선권주장과 구별되는 점이다.

③ 형식의 무제한

제1국 출원은 특허출원, 실용신안등록출원뿐만 아니라 디자인등록출원도 가능하다(파리조약 4A(1)). 또한 출원인이 재량으로 특허 또는 발명자증⁹⁸⁾ 중 어느 하나를 신청할 수 있는 국가에서 행하여진 발명자증의 출원을 기초로도 우선권주장을 할 수 있다(파리조약 I(1)). 다만 상표출원을 기초로 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 우선권을 주장하는 것은 성격상 부합하지 아니한다.

(2) 우선권주장출원(후출원)의 요건

1) 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원의 출원할 때 최초로 첨부한 명세서 또는 도면이 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다. 여기서 「최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항」이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재 없더라도 통상의 기술자라면 선출원일(우선권주장일) 당시의 기술상식에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항을 말한다.⁹⁹⁾ 다만 우선권주장출원의 청구범위에 동일성이 없는 발명이 기재되어 있는 경우 이를 이유로 조약우선권주장출원 전체가 부적법하게 되는 것은 아니며 청구범위에 기재된 발명 중 동일성이 인정된 발명의 경

98) 「발명자증(inventor's certificate)」이란 발명과 관련된 권리를 국가에 귀속시키는 대신 발명자에게 일정한 보상을 주기 위한 제도를 말한다. 발명자증도 i) 발명의 보호를 내용으로 하며, ii) 출원일의 특징이 가능하며, iii) 사회주의 국가의 동맹가입 촉진과 동서 기술교류 확대에 이바지하기 위해 파리조약에 의하여 보호되고 있다. 발명자증이 보호되기 위해서는 자기의 선택에 의하여 특허 또는 발명자증 중의 어느 출원이라도 할 수 있는 동맹국(병유국)이어야 한다. 이는 발명자증은 특허보다 이용하기 어려운 경우가 많으므로 발명자증만을 인정하는 나라가 출원하는 것을 방지하기 위해 규정한 것이다.

99) 대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265. 구체적으로 살펴보면, 선출원의 최초 명세서 청구항에 기재된 균일용량 투여의 경우 항-CD20 항체의 투여량이 이 사건 특허발명의 청구항 3과 달리 기재(0.1~30mg/kg의 용량으로 투여하거나, 4주간 주당 375mg/m²의 용량으로 주입)되어 있고, 선출원의 최초 명세서의 실시예에 이 사건 특허발명의 청구항 3에서 청구하고 있는 항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/m²의 용량이 기재되어 있기는 하나 균일용량이 아니라 제1 투여(375mg/m²) 이후의 후속 투여량으로 기재되어 있는 사안이어서, 이 사건 특허발명의 청구항 3에 기재된 “항-CD20 항체의 500 내지 1500mg/m²의 용량”이라는 균일용량 투여가 선출원의 최초 명세서에 명시적으로 기재되어 있거나, 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 없다고 하여 후출원일로 기준으로 심사하여 후출원 이전에 반포된 선행발명 5에 의해 이 사건 특허발명 청구범위 제3, 5항의 진보성이 부정된다고 판단하였다.

우에는 우선권의 이익을 향유하고 그 이외의 발명은 우리나라 출원일(우선권주장을 수반하는 특허출원일)을 기준으로 특허요건 등을 심사하게 된다.

2) 선출원의 「최초」 명세서 또는 도면에는 기재되어 있었으나 보정에 의하여 삭제된 발명을 기초로도 우선권주장을 할 수 있다. 한편 우선권주장출원의 청구범위가 보정되면 보정 후에 최종적으로 확정된 청구범위를 기준으로 우선권주장의 적법성을 판단한다.

3. 시기적 요건

1) 우선권을 주장하기 위해서는 우선기간(period of priority) 내에 출원하여야 한다. 이러한 우선기간에 대해서는 출원인의 이익과 일반 제3자의 이익과의 조화라는 점에서 특허 및 실용신안에 대해서는 12개월, 디자인 및 상표에 대해서는 각각 6개월로 규정하고 있다(파리조약 4C(1), 法 54②).

2) 한편 실용신안등록출원을 기초로 디자인등록출원으로 우선권주장을 하는 경우 우선기간은 6개월이며, 특허출원을 기초로 실용신안등록출원으로 우선권주장을 하는 경우 우선기간은 12개월이다(파리조약 4E(1)(2)). 문제가 되는 경우는 디자인등록출원을 기초로 실용신안등록출원으로 우선권주장을 하는 경우인데 이 경우 파리조약에 직접적인 규정이 없어서 디자인등록출원을 기준으로 6개월로 하여야 한다는 제1국설과 실용신안등록출원을 기준으로 12개월로 하여야 한다는 제2국설이 있으나, 심사 실무¹⁰⁰⁾는 제1국설을 지지한다.

Ⅲ. 우선권주장의 절차

1. 출원과 동시에 우선권의 주장

(1) 원 칙

파리조약에서는 제2국에 출원할 수 있는 기간인 우선기간은 1년이라고 규정하고 있지만(파리조약 4C(1)), 제2국에 출원한 후 우선권주장을 할 수 있는 기간인 우선권주장기간은 동맹국의 자국 법에 일임하고 있다(파리조약 4D(1)). 그 결과 우선권주장기간은 각국에 따라 다르나, 우리나라 특허법은 예측가능성을 높이기 위해 제54조제3항에서 “우선권주장을 하려는 자는 특허출원을 할 때 출원서에 그 취지, 최초 출원국가명 및 출원연월일을 적어야 한다”라고 하여 출원을 할 때 우선권주장을 하도록 하고 있다. 한편 다른 동맹국에 비해 우선권주장출원을 하는 출원인에게 불이익한 점을 보완하여 우선기간은 만족하지만, 우선권주장기간은 만족하지 못한 출원인을 보호하기 위하여 제54조제7항에서 우선권주장의 보정 또는 추가를 인정하고 있다.

100) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6304면.

【표 3-8】 우선기간과 우선권주장기간의 비교

구 분	우선기간	우선권주장기간
의 의	제2국에 출원할 수 있는 기간	제2국에 출원한 후 우선권주장을 할 수 있는 기간
파리조약	1년	동맹국의 자국법에 일임
특허법의 태도	1. 출원과 동시에 우선권주장을 하도록 함(法 54③) 2. 단점(출원인에게 불이익)의 보완 ○ 우선권주장의 보정 또는 추가(法 54⑦)의 인정 ○ 요건 - 조약우선권주장을 한 자 & 우선기간 만족 ○ 효과 - 최우선일로부터 1년 4개월 이내 - 우선권주장의 보정 또는 추가 - 최우선일로부터 1년 4개월 이후 - 명백한 오기의 정정 또는 우선권주장의 취하	

(2) 예외: 분할출원, 분리출원, 변경출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우

분할출원, 분리출원, 변경출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우 조약우선권주장출원의 취지(法 54③) 기재가 원출원일의 출원일로 소급효가 인정된다면 해당 절차를 밟을 수 없으므로 현실의 분할출원일, 분리출원일, 변경출원일을 기준으로 한다(法 52②Ⅲ, 52의2② 준용 52②, 53②Ⅲ). 이에 더하여 분할출원, 분리출원의 경우 원출원이 조약우선권을 주장한 특허출원이면 분할출원, 분리출원을 한때에 그 분할출원, 분리출원에 대해서도 우선권주장을 한 것으로 본다(法 52④, 52의2② 준용 52④).¹⁰¹⁾

2. 우선권주장의 보정 또는 추가

(1) 요 건

1) 제54조제7항에 의한 우선권주장의 보정은 「제54조제1항에 따라 조약우선권주장을 한 자 중 제54조제2항의 요건을 갖춘 자」가 할 수 있도록 규정하고 있다. 「우선권주장을 한 자」인지 여부는 출원 시에 제출된 출원서의【우선권주장】란의 우선권주장 관련 기재사항으로 보아 우선권주장을 하나 이상 특정할 수 있는지에 의하여 판단한다. 「제54조제2항의 요건을 갖춘 자」란 「우선권주장의 기초가 되는 최초출원의 출원일로부터 1년 이내에 출원한 자」를 말한다. 따라서 우선권주장을 보정하거나 추가하기 위해서는 제54조제1항 및 제2항의 요건을 모두 갖추어야 하며 이들 요건을 갖추지 못하였다면 해당 우선권주장은 치유할 수 없는 흠결을 가진 것이므로, 이 경우 우선권주장의 보정이나 추가는 허용되지 아니한다.

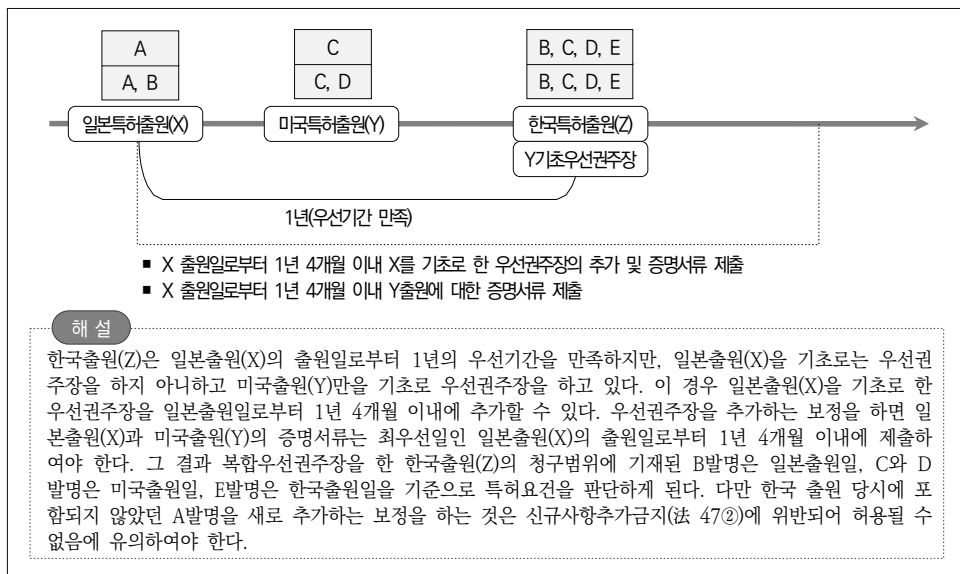
2) 또한 우선권주장이 취하 또는 무효로 되었거나 조약우선권주장출원이 무효, 취하, 포기되거나 심사관에 의하여 특허여부결정이 확정되면 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 없다.

101) 다만 변경출원은 분할출원, 분리출원과 달리 자동주장간주 규정(法 52④, 52의2② 준용 52④)이 없는데 굳이 차별을 둘 필요가 없으므로 이는 입법불비라고 생각된다.

(2) 효 과

① 일 반

우선권주장을 한 자는 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다. 다만 최우선일로부터 1년 4개월 이후라도 우선권주장에 관한 기재사항에 명백한 오기가 있는 경우 이와 같은 오기를 바로잡는 보정, 우선권주장의 취하와 같은 보정은 허용된다. 여기서 최우선일은 우선권주장의 추가 또는 취하를 반영하여 산정한다.



【그림 3-25】 우선권주장의 보정 또는 추가

② 분할출원, 분리출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우

우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원, 분리출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한(法 54⑦)이 지난 후에도 분할출원, 분리출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(法 52⑤, 52의2② 준용 52⑤). 이는 우선권주장의 자동간주를 원칙으로 하면서도 우선권주장을 원하지 않은 사항에 대해서는 의사에 따라 배제할 수 있도록 하려는 것이다.¹⁰²⁾

102) 다만 조약우선권주장의 취하는 실무상 제54조제7항의 기간인 최우선일로부터 1년 4월이 지나더라도 허용되고 있는데, 분할출원, 변경출원일로부터 30일 이내에만 취하할 수 있도록 하는 것은 출원인에게 오히려 불이익하다는 것을 고려할 때 제52조제5항과 제52조의2제2항에서 이 부분과 관련된 내용을 삭제하는 것이 적절하다고 여겨진다.

3. 우선권 증명서류의 제출

(1) 제출대상

① 원 칙

1) 조약우선권을 주장한 자는 최초로 출원한 국가의 정부가 인증하는 서류로서 특허출원의 연월일을 적은 서면, 발명의 명세서 및 도면의 등본(이하 “우선권증명서류”라 한다)을 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 54④ I).

2) 지식재산처장 또는 심판원장은 심사·심판을 위하여 필요한 경우 우선권증명서류에 대한 국어번역문을 제출하도록 명할 수 있다. 다만 우선권주장에 관한 서류 중 발명의 명세서 및 도면의 기재내용이 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면의 기재내용과 동일한 부분에 대해서는 그 취지를 기재하고 국어번역문의 제출을 생략할 수 있다(施規 25①③④).

② 예 외

제1국 출원이 총리령으로 정하는 국가인 경우에는 일반적인 증명서류에 갈음하여 최초로 출원한 국가의 특허출원의 출원번호 및 최초로 출원한 국가에서 부여한 접근코드를 제출할 수 있다(法 54④ II). 다만 출원번호 및 접근코드¹⁰³⁾를 특허출원서에 기재하면 별도의 증명서류 제출을 생략할 수 있다(施規 25①⑦). 여기서 「총리령으로 정하는 국가」는 지식재산처와 외국의 특허업무를 담당하는 행정기관 간에 우선권증명서류를 전자적 매체에 의하여 교환할 수 있는 체제가 구축된 국가로서 지식재산처장이 고시하는 국가를 말하며, 현재는 세계지식재산권기구(WIPO)의 전자적 접근 서비스(DAS, Digital Access Service)을 통하여 우선권 증명서류를 전자적으로 송달하기로 합의한 국가(지식재산처장이 우선권증명서류 제출기간내에 전자적 교환방법으로 해당 우선권증명서류를 세계지식재산권기구로부터 제공받을 수 있는 상태였음을 확인할 수 있는 경우에 한정한다)로서 지식재산처장이 지식재산처 홈페이지에 게시하는 국가와 대만 이 이에 해당한다(施規 25②, 특허·실용신안 우선권증명서류의 전자적 교환에 관한 고시(지식재산처고시 제2020-15호)). 다만 국어번역문의 제출이 필요한 경우에는 별도로 제출하여야 한다.

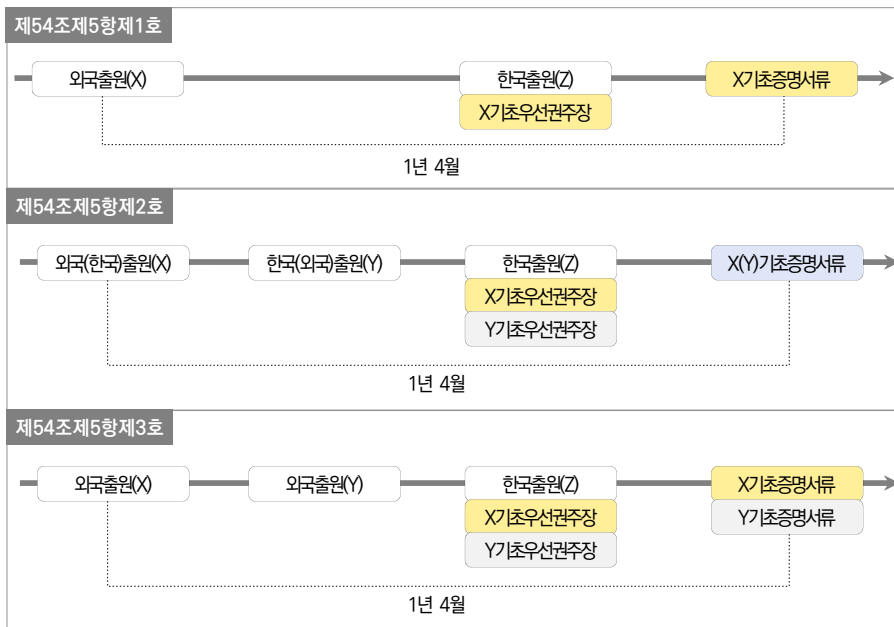
(2) 제출시기

① 원 칙

다음에 해당하는 출원일 중 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 우선권증명서류를 제출하여야 하며, 제출하지 아니하면 해당 우선권주장은 효력을 상실한다(法 54⑤⑥). 심사관은 우선권주장이 효력을 상실하는 경우 출원의 판단시점이 소급되지 않기 때문에 현실의 출원일을 기준으로 특허요건 등을 판단하게 된다.

103) 전자적 교환 시스템을 통한 우선권 증명서류 교환과 관련하여, 출원번호만의 확인을 통한 우선권 증명서류 교환이 보안성에 취약한 문제가 있어, 출원번호 외에 접근코드 등을 추가적으로 확인하도록 전자적 교환시스템이 개선됨에 따라 2015. 1. 1. 시행된 현행법(법률 제12753호, 2014. 6. 11. 개정)은 출원번호 외에 출원을 확인할 수 있는 정보 등을 추가적으로 서면에 기재하도록 하고 있다.

- i) 조약 당사국에 최초로 출원한 출원일
- ii) 그 특허출원이 국내우선권주장을 수반하는 경우에는 해당 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일
- iii) 그 특허출원이 다른 조약우선권주장을 수반하는 경우에는 해당 우선권주장의 기초가 되는 출원의 출원일



【그림 3-26】 조약우선권주장출원의 증명서류 제출기간

② 예외: 분할출원·분리출원·변경출원이 조약우선권주장을 수반하는 경우

1) 조약우선권주장의 취지를 기재하면서 분할출원, 변경출원하는 경우에는 최우선일로부터 1년 4개월의 기간이 지난 후에도 분할출원, 변경출원을 한 날부터 3개월 이내에 지식재산처장에게 증명서류를 제출할 수 있다(法 52⑥, 53⑥). 즉 출원인은 최우선일로부터 1년 4개월과 분할출원, 변경출원일로부터 3개월 중 늦은 날까지 지식재산처장에게 증명서류를 제출하면 된다.¹⁰⁴⁾

2) 한편 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에 의하면 원출원에 대하여 조약우선권주장의 증명서류 제출기간 내 제출된 서류 또는 서면이 있는 경우에는 분할출원, 분리출원에 대해서도 해당 서류 또는 서면이 제출된 것으로 본다(法 52②, 52의2② 준용 52④).¹⁰⁵⁾

104) 다만 분리출원은 분할출원, 변경출원과 달리 증명서류를 제출할 수 있는 기간의 특례(法 52⑥, 53⑥)에 관한 규정이 없는데 이는 입법불비라고 생각된다.

4. 외국의 심사결과 제출명령

심사관은 조약우선권주장을 수반한 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 기간을 정하여 그 우선권주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(그 심사결과가 없는 경우에는 그 취지를 적은 의견서를 말한다)를 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다(法 63의3). 이는 외국에의 심사결과에 대한 자료를 참조하여 심사의 효율성을 도모하기 위함이다. 한편 심사관이 거절이유를 통지할 때 외국에의 심사결과에 대한 자료를 참조하여 적은 선행기술에 대한 정보는 후에 특허등록되어 등록공고할 때 게재되고(法 87③Ⅶ), 이는 특허취소사유에서 제외된다(法 132의2②).

IV. 우선권주장의 효과

1. 적법한 경우의 효과

(1) 판단시점의 소급효

1) 조약우선권주장이 적법하면 조약우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 제29조 및 제36조를 적용할 때에 선출원일로 판단시점이 소급된다(法 54①).¹⁰⁶⁾ 또한 제29조 및 제36조 이외에도 파리조약 제4조 B에 의하여 판단시점이 선출원일로 소급한다. 파리조약 제4조 B는 “적법하게 된 우선권주장출원은 그사이에 이루어진 제3자의 행위(출원, 해당 발명의 공개, 실시 등) 등에 의하여 불리한 취급을 받지 아니하며, 이 경우에 제3자에게는 선출원권 또는 선사용권 등 어떠한 권리도 인정되지 아니한다”라고 규정되어 있다.¹⁰⁷⁾ 따라서 i) 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96), ii) 이용·저촉관계(法 98), iii) 선사용권(法 103), iv) 디자인권 존속기간 만료 후의 통상실시권(法 105), v) 생산방법의 추정(法 129), vi) 정정심판(法 136) 등을 판단할 때 판단시점이 소급된다. 다만 분할출원, 분리출원 또는 변경출원과 달리 조약우선권주장출원의 출원일은 우선권주장을 하는 실제의 제2국 출원일이며, 제1국 출원의 선출원일로 소급간주되는 것은 아님을 유의하여야 한다.¹⁰⁸⁾ 한편 청구범위에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재되지 아니한 발명은 우선권주장출원일을 기준으로 심사한다.¹⁰⁹⁾

105) 다만 변경출원은 분할출원, 분리출원과 달리 자동증명서류제출간주 규정(法 52②, 52의2② 준용 52④)이 없는데 굳이 차별을 둘 필요가 없으므로 이는 임법불비라고 생각된다.

106) 예를 들어 2024년 8월 3일에 출원된 제1국의 A발명을 기초로 2024년 12월 20일 우리나라에 조약우선권주장출원을 한 경우 특허요건의 판단시점은 2024년 8월 3일로 소급적용되므로 그 사이에 출원된 동일한 발명에 대한 타인의 출원은 후출원임을 이유로 거절된다.

107) 파리조약은 각국의 국내법이 상이하므로 추상적으로 판단시점의 소급효가 인정되는 것을 규정하고 있다. 따라서 이러한 파리조약에 기초한 제54조제1항의 소급효 인정 규정은 예시열거적이라고 할 수 있으며, 이는 국내우선권주장의 소급효 인정 규정인 제55조제3항이 제한열거적인 것과 구별된다.

108) 법 규정의 형태를 살펴볼 때 “B출원은 A출원한 때 출원한 것으로 본다”라고 규정되어 있는 것은 출원일의 소급효에 관한 규정이고, “B출원은 a 규정, b 규정, c 규정을 적용할 때 A 출원일에 출원한 것으로 본다”라고 규정되어 있는 것은 판단시점의 소급효에 관한 규정이다.

2) 판단시점의 소급효와 관련하여 확대된 선출원은 국내우선권제도와 형평성을 고려하는 한편 먼저 출원하여 공개시킨 자에게 독점·배타적인 특허권을 부여한다는 특허법의 목적에 부합하게 적용하여야 한다. 따라서 다른 출원이 조약우선권주장출원이면 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 판단시점이 소급하여 선출원일 후 조약우선권주장출원의 출원공개 또는 등록공고 전 사이에 출원된 제3자의 출원에 대하여 확대된 선출원이 적용된다. 한편 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되지 아니한 발명은 조약우선권주장출원일 후 조약우선권주장출원의 출원공개 또는 등록공고 전 사이에 출원된 제3자의 출원에 대하여 확대된 선출원이 적용된다. 다만 이에 대해서는 국내우선권제도(法 55④)와 같이 명문의 규정이 없으며 심사 실무¹¹⁰⁾상 인정되고 있을 뿐이다.

3) 출원공개와 관련하여서는 될 수 있으면 빨리 공개시켜 공중의 이용을 도모함으로써 중복투자 및 연구를 방지하는 것이 특허법의 목적에 부합하기 때문에 우선권주장출원일이 아니라 최우선일로부터 1년 6개월이 지난 후 출원공개된다(法 64①).

(2) 소급효의 예외

① 심사청구기간의 기산일

특허출원에 관한 출원심사청구기간의 기산일은 판단시점이 소급되는 경우 출원인에게 불이익하므로 실제 조약우선권주장출원일을 기준으로 한다.

② 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 출원기간, 취지기재 및 증명서류제출기간

조약우선권주장출원이 공지예외적용주장을 수반하는 경우 제30조제1항 본문의 「특허출원」을 우리나라의 특허출원으로 해석하기 때문에 그 조약우선권주장출원이 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 이루어져야 공지예외적용을 받을 수 있다. 즉 조약우선권주장출원은 제30조제

109) 구체적인 【예】를 들면 다음과 같다(지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6313면).

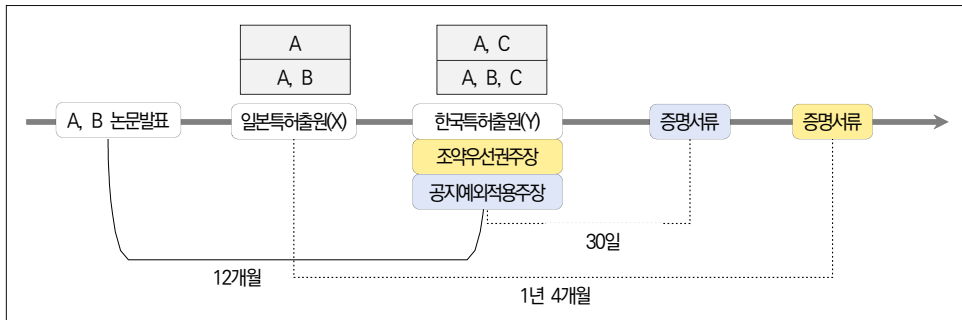
【예1】 우리나라에 특허출원된 발명이 「알콜의 탄소수가 1-10」인 것을 구성요소로 하는 것임에 대하여 우선권주장의 기초가 되는 제1국출원의 명세서에는 「알콜의 탄소수가 1-5」만이 기재되어 있는 경우에는 「알콜의 탄소수가 1-5」인 부분에 대해서는 우선권주장일을 기준으로 하고 「알콜의 탄소수가 6-10」인 부분에 대해서는 실제 우리나라 출원일을 기준으로 심사한다.

【예2】 제1국 출원의 명세서에는 「크롬을 구성요소로 하는 내식강」만 기재되어 있으나 우선권주장출원에는 ① 「크롬을 구성요소로 하는 내식강」과 ② 「크롬 및 알루미늄을 병용한 것을 특징으로 하는 내식강」을 요지로 하는 경우 ① 「크롬을 구성요소로 하는 내식강」에 대해서는 제1국출원일을 기준으로 심사하고 ② 「크롬 및 알루미늄을 병용한 것을 특징으로 하는 내식강」에 대해서는 실제 우리나라 출원일을 기준으로 심사한다.

【예3】 우선권주장출원은 「음극, 제어격자, 양극, 차폐격자와 양극과의 사이에 있고, 음극과 동전위로 유지되고 있는 제3의 격자를 갖고 있는 진공관」을 요지로 하는 것임에 대하여, 제1국출원의 출원 명세서 및 도면에는 「음극, 제어격자, 차폐격자, 양극을 갖고 있는 진공관」만이 기재되어 있는 경우에는 실제 우리나라 출원일을 기준으로 심사한다. 【예1】과는 달리 판단시점의 소급효가 인정되지 아니한 이유는 선출원의 출원서에 기재된 발명에 다른 구성요소를 결합시켰기 때문이다.

110) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3403-3404면.

1항의 「12개월」의 판단시점이 선출원일로 소급되지 아니한다. 그 결과 조약우선권주장출원이 공지의예외적용주장을 수반하는 경우 우선기간은 12개월 이하로 단축될 수밖에 없다. 한편 제 30조제2항의 취지 기재 및 증명서류제출기간은 출원인의 이익을 위하여 판단시점이 소급되지 않고 우선권주장출원일을 기준으로 하므로, 우선권주장을 할 때 출원서에 공지의예외적용의 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 우선권주장출원일로부터 30일 이내에 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 54①).¹¹¹⁾



【그림 3-27】 공지의예외적용주장을 수반하는 조약우선권주장출원

③ 존속기간 만료일의 기준일

우선권의 혜택으로 획득된 특허는 각 동맹국에서 우선권의 혜택없이 출원 또는 부여된 특허와 같은 존속기간을 갖는다(파리조약 4의2(5)). 즉 특허권 존속기간 만료일의 기준일은 판단시점이 소급되지 않고 우리나라 출원일을 기준으로 한다.

④ 재정에 있어서 출원일의 기산일

재정에 의한 강제실시권의 요건 중 특허발명의 불 실시 또는 불충분한 실시의 경우에서 「특허출원일로부터 4년」에 관하여도 출원인의 이익을 위하여 판단시점이 소급되지 않고 우리나라의 특허출원일을 기준으로 한다(파리조약 4의2(2)).

⑤ 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장시 특허출원일(法 92의2①)의 기산일(法 92의2④)

특허출원에 대하여 특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다. 여기서 「특허출원일로부터 4년」과 관련하여, 조약우선권주장출원(法 54)의 경우에는 조약우선권주장출원을 한 날을 특허출원일로 본다.

111) 다만, 특허법 제30조제3항에 따라 보완수수료를 납부하고 취지기재서면 또는 증명서류를 추후 일정기간에 제출할 수 있다.

2. 부적법한 경우의 효과

(1) 우선권주장절차의 무효

1) 출원인의 동일성, 출원의 정규성, 출원의 최선성, 우선권주장기간의 준수 또는 우선권 주장취지 기재 등의 요건을 충족하지 못한 경우 지식재산처장은 절차보정사유(法 46)에 해당함을 이유로 기간을 정하여 보정을 명하여야 하며, 그 기간에 보정하지 아니하면 그 「우선권주장절차」에 대하여 무효처분을 할 수 있다(法 16①). 우선권주장절차가 무효처분되면 당초 우선권주장을 수반한 출원은 우선권주장이 없는 통상의 출원이 된다.

2) 우선권주장이 복합우선권주장이고 해당 우선권주장의 일부에 흠결이 있는 경우 지식재산처장은 절차보정사유(法 46)에 해당함을 이유로 흠결이 있는 우선권주장에 대하여만 기간을 정하여 보정을 명하여야 하며, 그 기간에 보정하지 아니하면 우선권주장 전체를 무효처분하는 것이 아니고 그 보정을 명한 우선권주장만을 무효로 할 수 있다(法 16①). 이는 복합우선권주장의 절차는 여러 개의 우선권주장절차를 출원인의 편의상 한 건의 서류로 진행하도록 한 것이기 때문이다.

(2) 출원의 판단시점 소급효 불인정

심사관은 우선권주장 및 우선권주장의 보정을 심사한 결과 우선권주장이 부적합하여 우선권주장을 무효처분한 경우에 실제 출원한 후출원일을 기준으로 심사한다. 이는 우선권주장이 부적법한 경우의 효과는 우선권의 상실을 초과할 수 없기 때문이다(파리조약 4D(4)).

V. 국제특허출원의 특례

국제특허출원에 관하여는 제54조의 조약우선권에 관한 규정을 적용하지 아니한다(法 199②). 출원인이 PCT에 따라 조약우선권을 주장한 경우 절차는 PCT에 의하며(PCT 8(1)), 그 요건 및 효과는 파리조약의 스톡홀름의정서 제4조의 정하는 바에 의하기 때문이다(PCT 8(2)(a)). 한편 파리조약 제4조는 제54조의 요건 및 효과와 다를 바가 없으므로 결국 제54조를 적용하지 아니한다는 의미는 조약우선권주장의 절차를 제54조의 절차가 아니라 「PCT에 따른 절차」에 따른다는 의미이다.

제9장

— 특허출원 등에 의한 우선권주장출원 — (국내우선권주장출원)

제55조 【특허출원 등을 기초로 한 우선권 주장】

- ① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 “선출원”이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년이 지난 후에 출원된 경우
 2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원 또는 제52조의2제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분리출원이거나 제53조제2항 또는 「실용신안법」 제10조제2항에 따른 변경출원인 경우
 3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
 4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
- ② 제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.
- ③ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, 같은 조 제3항 본문, 같은 조 제4항 본문, 제30조제1항, 제36조제1항부터 제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항·제2항, 제129조 및 제136조제5항(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제95조 및 제103조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. <개정 2016.2.29.>
- ④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문, 같은 조 제4항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문·제4항 본문을 적용한다.
- ⑤ 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는 제3항과 제4항을 적용하지 아니한다.
1. 선출원이 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
 2. 선출원이 「공업소유권의 보호를 위한 파리 협약」 제4조D(1)에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우
- ⑥ 제4항을 적용할 때 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하더라도 제29조제7항을 적용하지 아니한다.
1. 선출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제특허출원인 경우
 2. 선출원이 「실용신안법」 제35조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 국제실용신안등록출원인 경우
- ⑦ 제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 자는 선출원일(선출원이 둘 이상인 경우에는 최선출

원일을 말한다)부터 1년 4개월 이내에 그 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

- ⑧ 제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 제79조에 따른 설정등록을 받을 수 없다. 다만, 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우에는 그러하지 아니하다. <신설 2021. 10. 19.>

[전문개정 2014.6.11.]

제56조 【선출원의 취하 등】

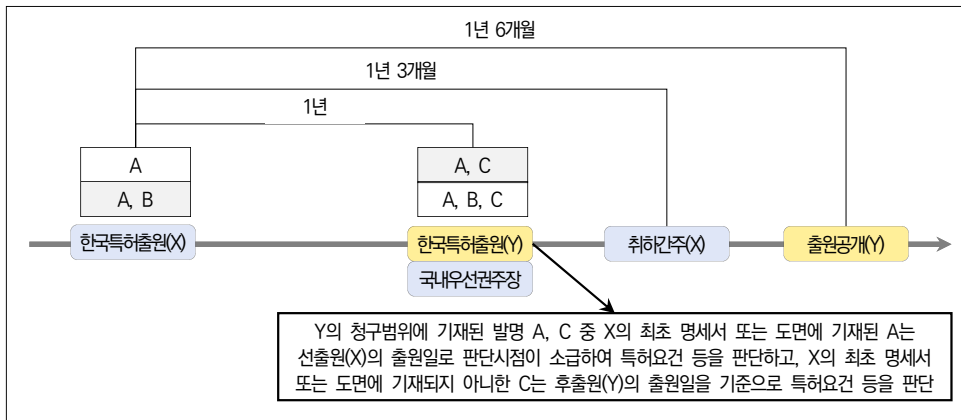
- ① 제55조제1항에 따른 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다. 다만, 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
 2. 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우
 3. 해당 선출원을 기초로 한 우선권 주장이 취하된 경우
- ② 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3개월이 지난 후에는 그 우선권 주장을 취하할 수 없다.
- ③ 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년 3개월 이내에 취하된 때에는 그 우선권 주장도 동시에 취하된 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「특허출원 등에 의한 우선권주장출원」(이하 “국내우선권주장출원”이라 한다)이란 특허를 받으려는 자가 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 “선출원”이라 한다)을 기초로 1년 이내 우선권주장의 출원을 한 경우에 우선권주장출원에 포함된 선출원 발명은 제55조제3항에 열거된 규정에 대하여 선출원을 한 때에 출원한 것으로 판단시점을 소급하여 주는 출원을 말한다. 특허출원 등에 의한 우선권은 강학상 국내우선권이라 하는데, 이는 조약우선권과 구별하기 위한 용어이다.



【그림 3-28】 국내우선권주장출원 일반

2. 취 지

(1) 기본발명과 개량발명을 하나의 출원으로 보호하여 출원인의 이익 극대화

국내우선권주장제도를 이용하는 경우 선출원에 포함된 기본발명을 보다 구체화하거나 개량·추가하는 발명을 하였을 때 기본발명과 개량발명을 하나의 출원으로 보호함으로써 기술개발의 진전이 현저한 현 실정에 비추어 포괄적이고 누락없이 발명을 보호할 수 있으며, 출원절차의 간편 및 출원비용의 절감을 통한 출원인의 발명의욕을 고취할 수 있다. 또한 기본발명의 출원 심사청구기간 또는 특허권의 존속기간을 우선기간만큼 연장할 수 있다.¹¹²⁾¹¹³⁾¹¹⁴⁾

(2) 내·외국인 간의 형평성 도모

국내우선권주장제도는 외국출원에 대해서만 인정되는 조약우선권주장과 달리 국내출원에 대해서 인정되므로 내·외국인의 불평등을 해소할 수 있다.

(3) PCT 이용의 활성화

PCT에 의한 국제출원에 있어서 대한민국을 지정하여 우선권주장, 즉 자기지정을 할 수 있으므로 국내법에 관련 규정을 두어 PCT 이용의 활성화에 기여할 수 있다.

112) 다만 국내우선권주장출원 시 새로 추가된 개량발명에 대해서는 판단시점의 소급효가 선출원일로 인정되지 않는다.

113) 선출원을 구체화 또는 개량·추가하는 발명에 대하여 통상의 출원절차로 출원할 경우에는 자신의 선출원과 동일발명으로 거절되게 될 수 있고, 선출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 이들 발명을 추가하는 경우에는 신규사항 추가 등에 의하여 특허거절결정될 수 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6403면).

114) 국내우선권주장의 이용형태를 다음과 같이 3가지로 구분해 볼 수 있다.

① 실시예 보충형

선출원주의하에서는 발명적 아이디어를 하루라도 빨리 출원할 필요가 있음에도 불구하고, 하나의 발명적 아이디어가 떠올랐을 때 그것을 충분하게 실증하기에는 상당한 시일이 요구된다. 이때 판명된 실시예를 우선적으로 기재하여 출원하고 그 후 실증을 통하여 또 다른 실시예가 갖추어지는 대로 실시예를 추가해 나가는 유형을 말한다. 「실시예 보충형」의 국내우선권주장은 이와 같은 실시예의 추가가 실무상, 특허화학발명의 경우 부적법한 보정으로 취급될 수도 있으므로, 이러한 위험성을 예방하기 위하여서도 자주 이용된다.

② 상위개념 추출형

「상위개념 추출형」이란 실증된 여러 개의 발명적 아이디어가 기초가 되어 별개의 발명적 아이디어가 탄생하였을 때 이러한 발명적 아이디어가 탄생한 순서대로 그때마다 개별출원을 하여 두었다가 이들을 기초로 한 새로운 발명적 아이디어, 즉 소위 상위개념이 얻어졌을 때 그들을 하나로 묶어 보다 넓은 범위의 권리를 취득해 나가는 유형을 말한다.

③ 출원의 단일성 이용형(일 군의 발명)

「출원의 단일성 이용형」이란 순차적으로 탄생한 발명적 아이디어가 그 기술적 사항이 비록 서로 상이한 것일지라도 산업상 이용분야가 극히 밀접한 것으로서 제45조에서 규정하는 하나의 특허출원의 범위, 즉 출원의 단일성 요건을 충족하는 경우라면 이들을 하나의 출원으로 하여 우선권주장을 하는 유형을 말한다. 예를 들어 「물건과 그 물건을 생산하는 방법」이나 「방법과 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기구·장치나 그 밖의 물건」 등과 같은 관계에 있는 발명에 적용된다.

II. 우선권주장의 요건

1. 주체적 요건

1) 「특허를 받으려는 자」가 우선권주장을 할 수 있다(法 55①). 즉 국내우선권주장을 할 수 있는 자는 선출원인 또는 선출원인의 정당한 승계인이다. 우선권주장출원 당시 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 일치해야 하는 것은 아니다. 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나, 선출원에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하여 양수인이 후출원을 한 경우 선출원과 후출원의 출원인이 달라질 수 있기 때문이다.¹¹⁵⁾ 이 경우 지식재산처장 등은 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있다(施規 7①).

2) 승계인은 조약에 의한 우선권주장과는 달리 우선권의 승계는 필요로 하지 아니한다. 이는 조약우선권은 제1국 출원을 기초로 제2국에 출원하는 것이므로 특허독립의 원칙에 따라 별도로

115) 국내우선권제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다. 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(특허법 제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(특허법 제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 '특허를 받을 수 있는 권리'를 승계하였다면 우선권주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받았다면 우선권주장을 할 수 있다고 보아야 한다.

① PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 선출원인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 실질적으로 승계받았는지 여부에 대한 실체심사는 PCT 제8조 (2)(b)에 따라 국내단계에 진입한 이후에 우리나라의 법령에 따라 해야 한다. 지식재산처장은 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허에 관한 절차를 밟고자 하는 경우에는 그 승계인임을 증명하는 서류를 제출하게 할 수 있으므로(특허법 시행규칙 제7조 제1항), 필요한 경우 보안을 요구함으로써 권리의 승계 여부를 심사할 수 있다. 그리고 특허법 제38조 제4항을 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 후출원인이 PCT 국제출원을 하기 전에 그 후출원인에게 국내에서 특허출원인변경신고를 마칠 것을 요구하는 것으로 해석한다면, 후출원인은 국내단계에서 절차상 하자를 보완할 기회를 상실하게 되므로 국내우선권제도의 취지에 부합된다고 볼 수 없다. 또한 선출원 발명을 개량하여 후출원 발명을 하는 과정에서 선출원의 출원인 중 일부만 후출원의 출원인에 포함되거나 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 달라질 수 있고, 후출원 시에 출원인명의변경 절차를 정당하게 마칠 수 없는 경우도 생기게 된다. 이러한 경우에도 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다는 이유로 우선권 주장의 효력을 부정하는 것은 우선권 주장 제도의 취지에 반하게 된다.

② 특허법 제55조 제1항은 우선권 주장을 할 수 있는 자는 '특허를 받으려는 자'라고 규정하고 있을 뿐이다. 이는 특허법이 분할출원(제52조)과 실용신안등록출원의 변경출원(제53조)을 할 수 있는 자는 '출원인'이라고 규정함으로써 분할출원인 또는 변경출원의 명의인이 일치할 것을 요구하는 것과 대비된다. 발명을 한 자의 승계인도 특허를 받을 수 있는 권리를 가지므로(특허법 제33조 제1항), 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 자는 특허법 제55조 제1항의 '특허를 받으려는 자' 및 '자신이 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자'에 해당한다고 봄이 문리해석에 부합한다. 특허출원인변경신고를 특허등록 전까지 하도록 규정한 특허법 시행규칙 제26조 제1항도 이러한 해석을 뒷받침한다(대법원 2019. 10. 17. 선고 2017후1274).

제2국에 우선권을 주장할 수 있는 권리가 필요하지만 국내우선권은 국내에서의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계만 있으면 충분하기 때문이다.

3) 임의대리인은 특별히 권한을 위임받아야 우선권주장출원을 할 수 있다(法 6).¹¹⁶⁾ 이는 국내우선권주장을 하는 경우 선출원이 취하간주되기 때문에 출원인에게 직접적인 이해관계가 있어 신중하게 처리하기 위함이다.

2. 객체적 요건

(1) 선출원의 요건

① 우선권주장출원을 할 때에 출원 계속 중일 것

i) 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우, ii) 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우¹¹⁷⁾가 아니어야 한다(法 55①ⅢⅣ). 즉 우선권주장출원을 할 때에 선출원이 출원 계속 중이어야 한다. 한편 「우선권주장출원을 할 때」를 기준으로 하므로 우선권 주장 이후에는 선출원이 출원 계속 중이지 않아도 된다.

② 분할출원·분리출원·변경출원이 아닐 것

국내우선권주장의 선출원은 분할출원, 분리출원 또는 변경출원이 아니어야 한다(法 55①Ⅱ). 선출원이 분할출원, 분리출원 또는 변경출원인 경우는 심사의 어려움을 줄이기 위해 우선권주장을 할 수 있는 출원에서 제외시키고 있다.

116) 국내우선권주장 및 취하의 특별히 권한을 위임받은 사항을 적은 위임장을 제출하는 방법은 다음과 같다 (지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 1208면).

구 분	선출원의 위임장	국내우선권주장 출원의 위임장
선출원 시 우선권주장에 대하여 특별히 권한을 위임하는 경우	본원 oo출원에 관한 일체의 건 (우선권주장에 관한 특별히 권한을 위임) 이 oo출원에 의거한 특허법 제55조제1항 또는 실용신안법 제18조제1항의 우선권주장 또는 그의 취하	본원 oo출원에 관한 일체의 건 ※ 특별히 권한을 위임하는 기재 불필요
국내우선권주장출원 시 우선권주장에 대하여 특별히 권한을 위임하는 경우	본원 oo출원에 관한 일체의 건 ※ 우선권주장에 관한 특별히 권한을 위임하는 기재가 없음	본원 oo출원에 관한 일체의 건 (우선권주장에 관한 특별히 권한을 위임) oo년 oo출원 제oooo호(선출원 표시)에 의거한 특허법 제55조제1항 또는 실용신안법 제18조제1항의 우선권주장 또는 그의 취하

117) 선출원과 후출원이 합해져서 하나의 특허가 되는 국내우선권제도에 있어서, 만일 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 선출원을 기초로 하여 우선권주장이 인정된다면 특허권이 바뀌게 되어 제3자에게 불측의 손해를 줄 수 있으며, 행정절차의 복잡을 초래할 것이기 때문이다. 한편 구법에서는 선출원에 대한 특허결정이 확정된 경우 국내우선권주장출원을 할 수 없었으나, 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 설정등록 전까지는 변경하였다. 선출원이 빠르게 특허결정확정된 경우에는 이를 개량하는 발명을 출원하더라도 우선권주장을 할 수 없는 문제점을 해소하기 위함이다. 따라서 현행법에 의하면 출원인은 다양한 특허관리 전략을 수립할 수 있고, 기술개발의 속도가 빠른 현 실정에서 발명의 노력을 방지할 수 있을 것이다.

③ 형식 제한

선출원은 특허출원 또는 실용신안등록출원이어야 한다(法 55①본문). 국내우선권주장출원의 취지인 개량발명 보호의 적정화에 비추어 볼 때 디자인등록출원, 상표출원은 선출원의 대상에 포함되지 아니한다.

(2) 우선권주장출원(후출원)의 요건

1) 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원의 출원할 때 최초로 첨부한 명세서 또는 도면이 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다. 여기서 「최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항」이란 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 통상의 기술자라면 선출원일(우선권주장일) 당시의 기술상식에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항을 말한다.¹¹⁸⁾ 우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명 중 선출원과 동일한 발명은 선출원일로 판단시점이 소급되고, 이용·개량발명은 현실의 국내우선권주장출원일을 기준으로 특허요건 등을 판단한다. 이처럼 국내우선권 주장출원은 선출원에 포함되어 있지 않았던 발명을 포함하여 우선권(부분우선권)을 주장할 수 있음은 물론 둘 이상의 선출원을 근거로 우선권(복합우선권)을 주장할 수도 있다. 또한 조약에 의한 우선권과의 복합우선권을 주장할 수도 있다.

2) 선출원의 「최초」 명세서 또는 도면에는 기재되어 있었으나 보정에 의하여 삭제된 발명을 기초로도 우선권주장을 할 수 있다. 한편 우선권주장출원의 청구범위가 보정되면 보정 후에 최종적으로 확정된 청구범위를 기준으로 우선권주장의 적법성을 판단한다.

3. 시기적 요건

우선권주장출원은 선출원의 출원일로부터 1년 이내에 할 수 있다(法 55①I). 조약우선권주장출원과 마찬가지로 출원인의 이익과 제3자의 이익의 조화를 위해서 우선기간을 1년으로 하고 있다.

Ⅲ. 우선권주장의 절차

1. 출원과 동시에 우선권의 주장

(1) 원 칙

국내우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하여야 한다(法 55②). 한편 선출원이 국내출원이기 때문에 우선권주장 증명서류는 제출할 필요가 없다.

118) 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999.

(2) 예외: 분할출원, 분리출원, 변경출원이 국내우선권주장을 수반하는 경우

분할출원, 분리출원, 변경출원이 국내우선권주장을 수반하는 경우 국내우선권주장출원의 취지(法 55②) 기재가 원출원일의 출원일로 소급효가 인정된다면 해당 절차를 밟을 수 없으므로 현실의 분할출원일, 분리출원일, 변경출원일을 기준으로 한다(法 52②Ⅳ, 52의2② 준용 52②, 53②Ⅳ). 이에 더하여 분할출원, 분리출원의 경우 원출원이 국내우선권을 주장한 특허출원이면 분할출원, 분리출원을 한때에 그 분할출원, 분리출원에 대해서도 우선권주장을 한 것으로 본다(法 52④, 52의2② 준용 52④).

2. 우선권주장의 보정 또는 추가

(1) 요건

1) 제55조제7항에 의한 우선권주장의 보정 또는 추가할 수 있는 자는 '제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권주장을 한 자'로 규정하고 있다. 따라서 국내우선권주장을 보정 또는 추가하기 위해서는 출원 당시에 국내우선권주장을 하고 있어야 하고, 출원 당시에 한 국내우선권주장 중 적어도 하나가 제55조제1항의 요건을 갖추어야 한다.

2) 또한 국내우선권주장으로 추가할 수 있는 출원도 제55조제1항의 요건을 갖추어야 한다. 제55조제1항의 요건이란 i) 선출원이 후출원의 출원일 이전 1년 이내에 출원된 것일 것, ii) 선출원이 분할출원, 분리출원 또는 변경출원이 아닐 것, iii) 우선권주장 출원할 때 선출원이 무효, 취하, 포기, 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정되지 아니하였을 것 등을 의미한다. 여기서 i) 요건은 후출원 시를 기준으로, iii) 요건은 국내우선권주장의 보정 또는 추가 시를 기준으로 판단한다¹¹⁹⁾

(2) 효과

① 일반

우선권주장을 한 자는 최선출원일로부터 1년 4개월 이내에 해당 우선권주장을 보정하거나 추가할 수 있다. 한편 최선출원일로부터 1년 4개월 이후라도 우선권주장에 관한 기재사항에 명백한 오기가 있는 경우 이와 같은 오기를 바로잡는 보정은 허용된다.¹²⁰⁾ 다만 제56조제2항에 따라 선출원일부터 1년 3개월이 지난 후에는 우선권주장을 취하할 수 없다.

119) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6408-6409면.

120) 외국에 출원한 제1국 출원과 국내에 출원한 선출원을 기초로 복합우선권주장을 한 경우, 다른 외국출원을 우선권주장에 추가하는 것은 제54조제7항에 따라 제1국 출원일과 국내 선출원의 출원일 중 최우선일로부터 1년 4개월 이내에 할 수 있는데 비하여, 다른 국내 출원을 우선권주장에 추가하는 것은 국내 선출원의 출원일들 중 최선출원일로부터 1년 4개월 이내에 할 수 있다. 이는 제55조제7항에서 규정하는 선출원이 같은 조 제1항에 의한 우선권주장, 즉 국내우선권주장의 기초가 된 먼저 한 출원을 의미하기 때문이다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 6408면).

② 분할출원, 분리출원이 국내우선권주장을 수반하는 경우

우선권을 주장한 것으로 보는 분할출원, 분리출원에 관하여는 우선권주장의 보정 또는 추가의 기한(法 55⑦)이 지난 후에도 분할출원, 분리출원을 한 날부터 30일 이내에 그 우선권주장의 전부 또는 일부를 취하할 수 있다(法 52⑤, 52의2② 준용 52⑤). 이는 우선권주장의 자동간주를 원칙으로 하면서도 우선권주장을 원하지 않은 사항에 대해서는 의사에 따라 배제할 수 있도록 하려는 것이다.

IV. 우선권주장의 효과

1. 적법한 경우의 효과

(1) 판단시점의 소급효

① 원 칙

1) 국내우선권주장을 수반하는 특허출원된 발명, 즉 청구범위에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 i) 산업상 이용가능성(法 29①본문), ii) 신규성(法 29①각호), iii) 진보성(法 29②), iv) 확대된 선출원 적용에 있어서 그 특허출원의 지위(法 29③④ 각호 외의 부분 본문), v) 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 출원기간(法 30①), vi) 선출원주의(法 36), vii) 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96①Ⅲ), viii) 이용·저축(法 98), ix) 선사용권(法 103), x) 디자인권 존속기간만료 후의 법정실시권(法 105), xi) 생산방법의 추정(法 129), xii) 정정심판청구 시 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있는 것의 요건(특허의 정정 포함)(法 136⑤)을 적용할 때에 그 특허출원은 선출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다(法 55③). 그러나 청구범위에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같지 아니한 발명은 우선권주장출원일을 기준으로 심사한다.

2) 출원공개와 관련하여서는 될 수 있으면 빨리 공개시켜 공중의 이용을 도모함으로써 중복 투자 및 연구를 방지하는 것이 특허법의 목적에 부합하기 때문에 우선권주장출원일이 아닌 최우선일로부터 1년 6개월이 지난 후 출원공개된다(法 64①).

② 예 외

1) 조약우선권주장과 마찬가지로 다음의 경우에는 출원인의 이익을 위하여 판단시점이 소급하지 않고 현실의 우선권주장출원일을 기준으로 한다.

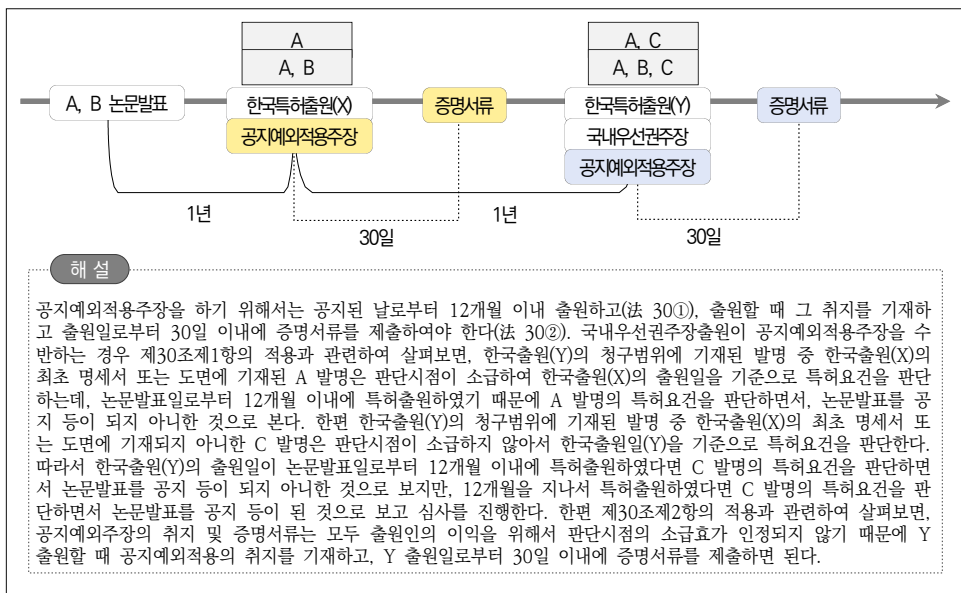
i) 심사청구기간의 기산일(法 59②)

ii) 존속기간의 만료일의 기준일(法 88①)

iii) 재정에 있어서 출원일의 기산일(法 107①)

iv) 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장시 특허출원일(法 92의2①)의 기산일(法 92의2④)

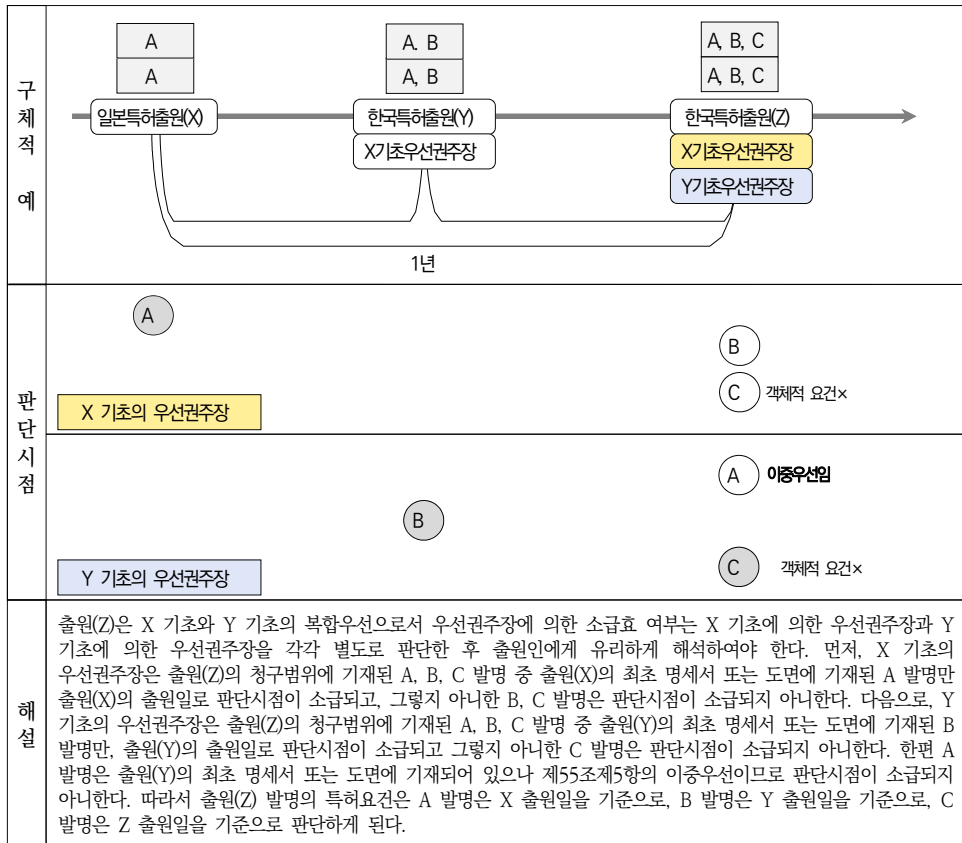
2) 국내우선권주장출원이 공지예외적용주장을 수반하는 경우 국내우선권주장출원의 청구범위에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명에 대해서는 제30조제1항의 「12개월」의 판단시점이 선출원일로 소급된다. 따라서 이 발명은 공지예외적용사유에 해당하는 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 선출원이 있고 선출원일로부터 1년 이내에 국내우선권주장출원을 하였다면 공지예외규정의 적용을 받을 수 있다. 그러나 후출원의 청구범위에 기재된 발명 중 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일하지 않은 발명에 대해서는 제30조제1항의 「12개월」의 판단시점이 선출원일로 소급되지 않는다. 따라서 이 발명은 공지예외적용사유에 해당하는 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 국내우선권주장출원을 하여야만 공지예외규정의 적용을 받을 수 있다.¹²¹⁾ 한편 제30조제2항의 공지예외적용의 취지기재 및 증명서류제출기간은 판단시점이 소급되지 않고 국내우선권주장출원일을 기준으로 하므로, 우선권주장을 할 때 출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 우선권주장출원일로부터 30일 이내에 제출하여야 한다(法 55③).¹²²⁾



【그림 3-29】 공지예외적용주장을 수반하는 국내우선권주장출원

- 121) 한편 국내우선권주장출원의 발명 중에서 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 개시되지 않은 발명은 국내우선권주장출원일에 출원된 것으로 보기 때문에 선출원보다 늦게 출원인에 의하여 공지된 발명에 대해서도 공지예외주장을 인정할 필요가 있다. 즉 선출원 시에는 공지예외주장을 하지 않았으나 선출원일과 국내우선권주장출원일 사이에 공지된 발명에 대하여 국내우선권주장출원에서 공지예외주장을 한 경우에는, 해당 공지된 발명이 선출원보다 늦게 공지되었다는 이유로 국내우선권주장출원의 공지예외주장을 부적법한 것으로 취급하지 아니한다(지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 6405-6406면)
- 122) 다만, 특허법 제30조제3항에 따라 보완수수료를 납부하고 취지기재서면 또는 증명서류를 후후 일정기간에 제출할 수 있다.

3) 또한 국내우선권주장의 선출원이 국내우선권주장 또는 조약우선권주장을 수반하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권주장의 기초가 된 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는, 즉 이중우선의 경우에는 우선권의 효과를 인정하지 않고 선출원에 대하여 새로 추가된 사항에 대해서만 우선권의 효과를 인정한다(法 55⑤).¹²³⁾ 따라서 이와 같은 발명에 대하여 우선권주장의 효과를 가지기 위해서는 선출원의 기초출원을 복합적으로 우선권주장을 하여야 한다.



【그림 3-30】 누적적 우선권주장출원의 판단시점

123) 예를 들어 발명 A에 대한 제1의 특허출원(X), 출원(X)을 기초출원으로 하고 발명을 B를 포함하여서 한 발명 A, B에 대한 국내(조약)우선권주장출원(Y) 및 출원(Y)를 기초출원으로 하여 발명 C를 포함하는 발명 A, B, C에 대하여 한 국내우선권주장출원(Z)이 있는 경우 발명 A는 이중 우선이므로 우선권주장의 효과가 인정되지 아니하지만, 발명 B는 우선권주장의 효과가 인정되어 출원(Y)의 출원일을 기준으로 특허요건 등을 판단하게 된다. 한편 발명 C는 출원(Y)에 기재된 발명과 실질적인 동일성이 없으므로 발명 A와 마찬가지로 출원(Z)의 출원일을 기준으로 특허요건 등을 판단하게 된다.

(2) 선출원의 출원공개 의제에 의한 확대된 선출원

① 일반적인 경우

1) 국내우선권주장을 수반하는 특허출원(후특허출원)의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 그 특허출원(후특허출원)이 출원공개되거나 등록공고된 때에 그 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 확대된 선출원(제29조제3항 본문, 같은 조 제4항 본문 또는 실용신안법 제4조제3항 본문, 같은 조 제4항본문)의 규정을 적용한다(法 55④). 한편 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되지 아니한 발명은 우선권주장출원일 후 우선권주장출원의 출원공개 또는 등록공고 전 사이에 출원된 제3자의 발명에 대하여 확대된 선출원을 적용한다(法 29③④).

2) 국내우선권주장출원의 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월을 지난 때에 일반적으로 출원공개되지 않고 취하간주되기 때문에 선출원의 지위, 확대된 선출원의 지위가 인정되지 아니한다. 이 경우 선출원과 우선권주장출원 사이에 제3자의 출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원의 최초 명세서·도면에 기재된 발명과 동일한 경우 제3자의 출원에 대하여 특허를 허여함은 공개와 독점의 조화라는 특허법의 목적에 반하기 때문에 일정 범위에 대하여 판단시점의 소급효를 인정해주고 있다. 다만 후출원이 출원공개 또는 설정등록된 때에는 국내우선권주장출원의 적법성을 판단하기 위해서 선출원의 열람을 허가하고 있으므로 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명의 공지기술의 지위가 인정된다(法 216).

3) 한편 선출원이 국내서면제출기간에 발명(고안)의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하된 것으로 보는 국제특허출원(실용신안등록출원)이더라도 제55조제4항에 따른 확대된 선출원을 적용한다(法 55⑥).

② 이중우선의 경우

국내우선권주장출원의 선출원이 국내우선권주장 또는 조약우선권주장을 수반하는 경우에는 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권주장의 기초가 된 출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대해서는, 즉 이중우선의 경우에는 제29조제3항, 제4항을 적용할 때에 판단시점의 소급효가 인정되지 아니한다(法 55⑤). 이러한 경우에도 확대된 선출원의 소급효를 인정하는 것은 국내 우선권주장을 2번 연속으로 주장한 것을 인정하는 것과 같기 때문이다. 따라서 선출원(선출원의 조약·국내우선권주장의 기초가 되는 특허출원을 말한다), 선출원 및 후출원 모두에 기재된 발명에 대해서는 후출원일 후 후출원의 출원공개 또는 등록공고 전 사이에 출원된 제3자의 발명에 대하여 확대된 선출원 규정을 적용하게 된다.

(3) 선출원의 취하간주 및 설정등록 불가

① 원 칙

1) 우선권주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다(法 56①본문). 따라서 국내우선권주장출원의 기초가 된 선출원에 대해서는 심사를 진행하지 않고 보류한다. 선출원에 대한 우선심사신청이 있는 경우도 또한 같다.¹²⁴⁾ 이는 선출원과 국내우선권주장출원을 한 출원의 상당부분의 내용이 중복될 것이기 때문에 이에 따른 중복심사를 없애고 자신의 선출원과의 관계에서 혐의제를 회피하기 위함이다. 한편 선출원이 「출원일로부터 1년 3개월」이 지난 때에 취하되는 것은 출원공개를 위한 준비에 소요되는 기간을 고려하여 중복적인 출원공개를 회피함과 아울러 출원인에게 다시 한번 검토할 기회를 부여하기 위해서이다.

2) 여러 개의 특허출원을 기초로 한 복합우선권주장출원에 있어서 최선출원일로부터 1년 3개월에 선출원들이 일괄적으로 취하되는 것으로 보는 것이 아니라 각각의 선출원의 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때에 취하되는 것으로 본다.

3) 한편 우선권주장의 기초가 된 선출원은 제79조에 따른 설정등록을 받을 수 없다. 다만 해당 선출원을 기초로 한 우선권주장이 취하된 경우에는 설정등록을 받을 수 있다(法 55⑧). 선출원의 특허결정이 확정된 후 설정등록 전에 국내우선권 주장을 한 경우에는 선출원에 대한 심사를 보류할 수 없으므로 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 선출원을 설정등록받을 수 없도록 규정하였다.

② 예 외

국내우선권주장출원 후 선출원의 출원일로부터 1년 3개월을 지나기 전에 i) 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우(法 56①I), ii) 선출원이 설정등록¹²⁵⁾되거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우(法 56①II), iii) 해당 선출원을 기초로 한 우선권주장이 취하(法 56①III)된 경우에는 선출원이 취하간주되지 아니한다(法 56①각호. i), ii)의 경우 출원 계속 중이지 않아서 취하간주할 대상이 없어졌기 때문이고, iii)의 경우 후출원의 판단시점이 소급하지 않아 혐의제를 회피할 필요성이 없어지고, 제56조제2항 및 제3항의 관계를 고려할 필요가 있기 때문이다.

124) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 5307면, 6412면. 다만 私見으로는 선출원이 취하간주될 것을 인지하면서도 우선심사신청을 하였다는 것은 선출원이 취하간주되기 전에 심사관의 심사를 받으려는 의사가 있는 것이고, 심사를 받을 실익(예를 들어 우선기간인 1년 이내 심사관에 의하여 발명의 등록가능성을 가늠해 보고, 개량발명의 추가적인 보호의 필요성이나 해외출원 여부를 결정하려는 경우)도 있으므로 출원인의 의사에 반하여 심사를 보류하는 것은 타당하지 않다고 판단된다.

125) 국내우선권주장의 선출원은 설정등록을 받을 수 없으므로 실효성이 없는 내용으로 이해된다.

(4) 우선권주장의 취하금지

① 취하시기

우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일로부터 1년 3개월을 지난 후에는 그 우선권주장을 취하할 수 없다(法 56②). 국내우선권주장에 따라 선출원이 이미 취하간주(法 56①)된 후에는 국내우선권주장의 취하를 인정할 실익이 없기 때문이다. 선출원일로부터 1년 3개월을 지난 후에 제출된 우선권주장 취하서는 불수리된다.

② 취하절차

국내우선권주장을 취하하려는 자는 지식재산처장에게 우선권주장 취하서를 제출하여야 한다. 공동출원인은 공동출원인 모두가 취하서를 제출하여야 하며(法 11), 임의대리인은 특별히 권한을 위임받아야 한다(法 6). 이는 국내우선권주장이 취하되면 후출원의 소급효 불인정 등 출원인인 본인에게 불리한 결과가 발생할 수 있기 때문이다.

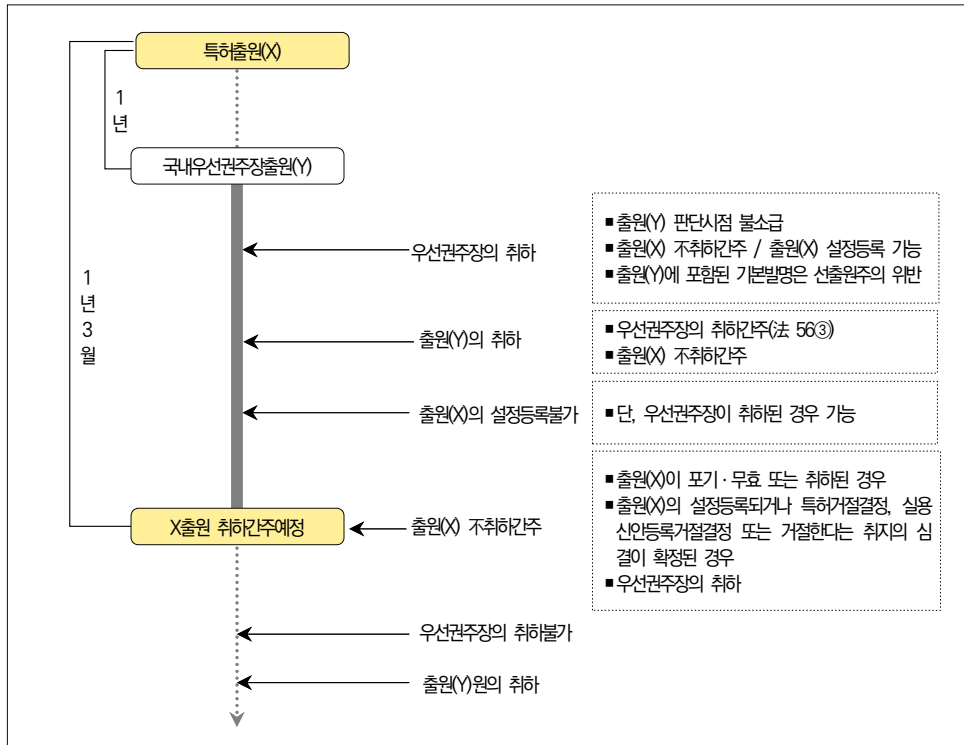
③ 취하효과

국내우선권의 주장이 취하된 때에는 그 국내우선권의 주장은 효력을 잃기 때문에 출원은 실제 출원일을 기준으로 특허요건 등을 판단한다. 또한 그 선출원은 취하간주되지 않으며 원출원 상태로 유효하게 존속한다(法 56①Ⅲ). 그 결과 후출원에 포함된 기본발명은 자신의 선출원과의 관계에서 선출원주의(法 36①)에 위반될 수 있다.

(5) 우선권주장의 취하간주

특허출원의 취하는 출원 계속 중이라면 언제든지 할 수 있다. 그런데 「국내우선권주장을 수반하는 특허출원」이 선출원의 출원일로부터 1년 3개월 이내에 취하된 때에는¹²⁶⁾ 그 「우선권주장」도 동시에 취하된 것으로 본다(法 56③). 우선권주장은 국내우선권주장출원과는 별개의 절차이므로 이 규정이 없으면 우선권주장출원이 취하되었다고 하더라도 우선권주장의 절차가 존속하여 선출원이 취하되기 때문에 출원인의 이익을 고려하여 이를 방지하기 위함이다. 따라서 우선권주장출원이 취하되면 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때에 취하간주되지 아니한다(法 56①Ⅲ). 한편 선출원의 출원일로부터 1년 3개월이 지난 후에는 이미 선출원이 취하간주되었기 때문에 우선권주장출원이 취하되었다고 하더라도 우선권주장 취하간주의 실익이 없다.

126) 私見으로는 제56조제3항에서는 우선권주장출원이 취하된 경우만을 언급하고 있으나, 우선권주장출원이 무효나 포기가 된 경우에도 선출원을 살리기 위해 우선권주장이 취하된 것으로 간주함이 타당할 것이다.



【그림 3-31】 국내우선권주장 및 국내우선권주장출원의 취하

2. 부적법한 경우의 효과

(1) 우선권주장절차의 무효

지식재산처장은 우선권주장의 방식이 부적법한 경우 조약우선권주장과 마찬가지로 제46조 규정에 따라 기간을 정하여 보정을 명하여야 하고 보정명령에도 불구하고 그 기간에 우선권주장의 함결을 보정하지 아니하면 우선권주장절차를 무효로 할 수 있다(法 16①).

(2) 출원의 판단시점 소급 불인정

심사관은 우선권주장 및 우선권주장의 보정에 대한 심사결과 우선권주장이 부적합하여 우선권주장을 무효처분한 경우 실제 출원한 후출원일을 기준으로 심사한다. 이때 우선권주장이 부적법하여 우선권주장이 무효처분된 경우 선출원은 취하되지 않으므로 제36조 선출원주의의 적용을 받을 수도 있을 것이다.

V. 국제특허출원의 특례

1. 국내우선권주장을 수반한 후출원이 국제특허출원인 경우

(1) 우선권을 주장한 국제특허출원의 제55조제2항 및 제56조제2항 부적용

통상적인 국내우선권주장출원의 경우 출원 시에 국내우선권을 주장하여야 하며(法 55②), 이는 선출원일로부터 1년 3개월이 지난 후에는 취하할 수 없다(法 56②). 그러나 국제특허출원이 우선권을 주장하는 경우에는 제55조제2항 및 제56조제2항을 적용하지 아니한다(法 202①). 이는 국제특허출원의 우선권주장은 PCT 제8조에 따라 수리관청에 하는 것이므로 지정국 국내법인 제55조제2항에 따른 우선권을 주장할 수는 없기 때문이다. 또한 국제출원 시에 한 우선권주장은 우선일로부터 2년 6개월을 지나기 전과 출원인이 출원심사청구를 하기 전 중 빠른 때까지는 우선권주장의 일부 또는 전부를 취하할 수 있기 때문에 역시 우선권주장 취하에 관한 국내법 제56조제2항은 적용되지 아니한다(施規 106의7).

(2) 우선권을 주장한 국제특허출원의 확대된 선출원

1) 우선권을 주장한 국제특허출원에 대하여 제55조제4항을 적용하는 경우 특례규정을 두고 있다. 제55조제4항을 적용할 때 우선권주장을 수반하는 특허출원이 국제특허출원인 경우에는 같은 항 중 「특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」은 「국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」으로, 「출원공개되거나」는 「출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나」로 본다(法 202②본문).

2) 즉 우선권주장을 수반하는 국제특허출원의 「국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 「특허출원이 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나」 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 확대된 선출원을 적용한다.

3) 다만 출원인이 국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 그 국제특허출원이 취하된 것으로 보는 경우에는 확대된 선출원(法 55④)을 적용하지 아니한다(法 202②단서).

2. 국내우선권주장출원의 선출원이 국제특허출원인 경우

(1) 우선권을 주장할 수 있는 범위 및 판단시점의 소급효 범위

통상적으로 국내우선권 주장의 기초가 된 선출원에서 우선권을 주장할 수 있는 발명으로서 일정한 판단시점이 선출원일로 소급되는 범위는 선출원의 「출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」에 기재된 발명이다(法 55①③⑤). 한편 선출원이 국제특허출원인 경우에 「출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」은 「국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」으로 본다(法 202③I).

(2) 확대된 선출원의 규정

1) 국내우선권주장의 선출원이 국제특허출원일 때 제55조제4항을 적용하는 경우 특례규정을 두고 있다. 제55조제4항 중 「선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」은 「선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 도는 도면」으로 보고, 「선출원에 관하여 출원공개」는 「선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개」로 본다(法 202③II).

2) 즉 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 「선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 도는 도면」에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권주장의 기초가 된 「선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개」가 된 것으로 보고 확대된 선출원을 적용한다.

3) 선출원이 국내서면제출기간에 발명(고안)의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하된 것으로 보는 국제특허출원(국제실용신안등록출원)인 경우에도 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위가 인정된다(法 55⑥).

(3) 선출원인 국제특허출원의 취하간주시기

국내우선권주장출원의 선출원은 원칙적으로 「그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때」에 취하된 것으로 본다(法 56①). 그러나 그 선출원이 국제특허출원인 경우에 「그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때」는 「국제출원일로부터 1년 3개월이 지난 때와 기준일 중 늦은 때」에 취하된 것으로 본다(法 202③III). 이처럼 기간을 정한 이유는 출원인의 「명시적 청구」가 없는 경우에는 조약 제23조 및 제24조에 따라 기준일 전에는 국제출원을 처리할 수 없기 때문이다.¹²⁷⁾ 물론 이 취하간주의 효과는 우리나라에서만 효력이 있으며, 다른 지정국에도 미치는 것은 아니다. 한편 국제특허출원이 국내우선권주장의 선출원인 경우에는 일반적으로 비용을 절감하기 위해 심사청구를 하지 않기 때문에 국제특허출원은 국내서면제출기간이 지난 후에 취하간주될 것이다.

3. 국내우선권주장출원의 선출원이 결정에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원인 경우

기본적으로 국내우선권주장출원의 선출원이 국제특허출원인 경우와 동일하다. 다만 취하간주시기는 「국제출원일로 인정할 수 있었던 날로부터 1년 3개월이 지난 때와 지식재산청장이 결정을 한 때 중 늦은 때」이다(法 202④).

127) 박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002, 596면.

【표 3-9】 조약우선권주장출원과 국내우선권주장출원의 비교

제 도		조약우선권주장출원(法 54)	국내우선권주장출원(法 55, 56)
서	의의	조약에 의하여 우리나라 국민에게 우선권을 인정하는 당사자 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일 발명에 대하여 우리나라에 출원하여 우선권을 주장하는 때에 일정요건에 대하여 선출원 시에 출원한 것으로 판단시점을 소급하여 주는 제도를 말한다.	특허를 받으려는 자가 국내의 선출원을 한 후 그 선출원의 출원일로부터 우선권주장의 출원을 한 경우에 후출원에 포함된 선출원 발명은 일정요건에 대하여 선출원 시에 출원한 것으로 판단시점을 소급하여 주는 특허법상의 제도를 말한다.
	취지	절차상 제약 극복하고 발명의 국제적 보호	1. 개량발명 보호의 적정화 2. 내·외국인 간 발명보호의 형평성 도모 3. 국제출원 이용의 활성화
요 건	주체적	1. 우선권주장을 할 수 있는 자 대한민국 국민, 조약당사국 국민, 준당사국 국민 2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있다면 출원인의 동일성 불필요(다만 승계인은 우선권 별도로 승계 → 우선권의 독립성)	1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있다면 출원인의 동일성 불필요 2. 임의대리인은 국내우선권 주장 또는 취하시 특별히 권한을 위임받아야 함
	객체적	1. 선출원의 요건 ① 최선성(예외있음) ② 정규성 ③ 형식제한 × → 디자인 ○ 2. 후출원의 요건 후출원의 청구범위에 기재된 발명이 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내	1. 선출원의 요건 ① 후출원 당시 선출원이 출원 계속 중일 것 ② 분할·분리·변경출원이 아닐 것 ③ 형식 제한 ○ → 디자인 ×
	시기적	1. 원칙(동종우선) → 제1국출원일로부터 1년 이내 출원 2. 이종우선시 우선기간은 6개월	선출원의 출원일로부터 1년 이내
	절 차	출원서 제출 1. 출원과 동시에 취지, 최초 출원국가명 및 출원연월일 기재(法 54③) - 단 분할·분리출원의 경우 원출원이 조약 우선권주장을 수반하는 경우 자동 주장 간주(法 52④, 52의2②) / 변경출원은 변경출원 시 별도 주장 필요(法 53②) 2. 우선권주장의 보정 또는 추가(法 54⑦) - 단, 분할출원, 분리출원의 경우 기간이 지난 후라도 그 날로부터 30일(法 52④, 52의2②) 이내 전부/일부 취하가능	출원서 제출 1. 출원과 동시에 취지, 선출원의 표시(法 55②) - 단 분할·분리출원의 경우 원출원이 국내우선권주장을 수반하는 경우 자동 주장 간주(法 52④, 52의2②) / 변경출원은 변경출원 시 별도 주장 필요(法 53②) 2. 우선권주장의 보정 또는 추가(法 55⑦) ① 단, 1년 3개월 지난 후에는 우선권주장 취하불가 ② 단, 분할출원, 분리출원의 경우 기간이 지난 후라도 그 날로부터 30일(法 52④, 52의2②) 이내 전부/일부 취하가능
효 과	증명 서류의 제출	1. 원칙 출원일 적은 서면 및 명세서 또는 도면(단, 일정한 경우 출원번호 및 총리령으로 정하는 사항)을 최우선일로부터 1년 4개월 이내 제출(法 54①⑤⑥) 2. 예외 ① 분할·변경출원의 경우 최우선일로부터 1년 4개월 지난 후라도 분할·변경출원일로부터 3개월 이내 지식재산청장에게 제출(法 52⑥·53⑥) ② 분할·분리출원의 경우 원출원이 증명서류 제출한 경우 자동 제출 간주(法 52④, 52의2②)	증명서류 제출 불요
	적법	1. 판단시점의 소급효(예외 있음)(法 54①) 2. 확대된 선출원의 적용은 해석상 국내우선권주장출원과 동일	1. 판단시점의 소급효(예외 있음)(法 55③⑤) 2. 확대된 선출원(法 55④⑤⑥) 3. 선출원의 취하간주(法 56①) 및 등록불가(法 55⑧) 4. 우선권의 취하 금지 및 취하간주(法 56②③)
부적법		우선권주장 → 무효 / 출원 → 소급효 ×, 실제출원일을 기준으로 판단	
국제특허출원의 특례		PCT 제8조 (1)과 (2)(a)를 적용(法 199②)	PCT 제8조 (1)과 (2)(b)를 적용(法 55, 56, 202)

제10장

발명의 동일성

I. 서 설

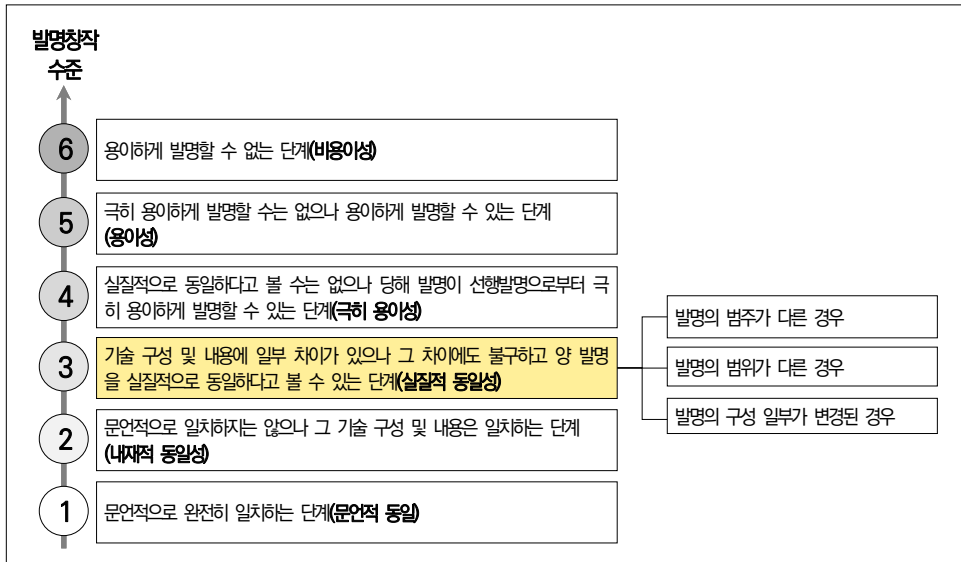
발명의 동일성이란 둘 이상의 발명을 상호 대비하여 그 대비되는 발명의 기술적 사상이 동일한 것을 말한다. 형식적으로 완전동일이란 거의 있을 수 없으므로 특허법은 발명의 동일성 개념을 도입하여 신규성(法 29①각호), 선출원주의(法 36), 확대된 선출원(法 29③④⑤⑥⑦) 등 특허요건과 무권리자의 특허출원·특허와 정당한 권리자의 보호(法 34, 35), 보정(法 47, 51), 분할출원(法 52), 분리출원(法 52의2), 변경출원(法 53), 조약우선권주장출원(法 54), 국내우선권주장출원(法 55, 56) 등 각종 제도를 이용할 때 소급효를 인정하기 위한 요건 등을 판단하고 있다. 그런데 이러한 발명의 동일성은 각 규정의 입법 취지와 목적에 따라 차이가 있으므로 이를 일반화하여 설명할 수는 없고 규정별로 달리 설명하여야 한다. 이하에서는 동일성의 유형 및 현재의 심사 실무와 판례의 판단방법을 살펴본다.

II. 동일성의 유형

1. 창작의 수준에 따른 구분

발명은 그 창작의 수준에 따라 인용대상과 비교하였을 때, ① 문언적으로 완전히 일치하는 단계, ② 문언적으로 일치하지는 않으나 그 기술 구성 및 내용은 일치하는 단계, ③ 기술 구성 및 내용에 일부 차이가 있으나 그 차이에도 불구하고 양 발명을 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 단계, ④ 실질적으로 동일하다고 볼 수는 없으나 당해 발명이 선행발명으로부터 극히 용이하게 발명할 수 있는 단계(실용신안의 진보성이 부정되는 영역), ⑤ 극히 용이하게 발명할 수는 없으나 용이하게 발명할 수 있는 단계(실용신안의 진보성은 인정되나 특허의 진보성이 부정되는 영역), ⑥ 용이하게 발명할 수 없는 단계(특허의 진보성이 인정되는 영역임)로 구분할 수 있다.¹²⁸⁾ 이 중 ① 단계는 문언적 동일, ② 단계는 내재적 동일성(이를 실질적 동일성의 한 유형으로 파악하기도 함), ③ 단계(경우에 따라 ④-⑤ 단계까지를 포함)는 실질적 동일성이라고 할 수 있다.

128) 유영선, “발명의 동일성에 대한 소고 -확대된 선출원을 중심으로-”, 대법원 제107차 특별소송실무연구회 발표 논문, 2011.2.7. 6면



【그림 3-32】 창작수준에 따른 발명 동일성의 유형

2. 문언적 동일과 내재적 동일성

문언적 동일이나 내재적 동일성은 인용대상에 본원발명의 구성이 개시(기재)되어 있는 것을 말한다. 여기서 「개시」란 인용대상에 문언적인 기재가 존재하는 경우(문언적 동일)와 통상의 기술자가 인용대상의 기재내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 인용대상으로부터 직접적으로 그 내용을 인식할 수 있는 경우(내재적 동일성)를 말한다.¹²⁹⁾

129) 내재적 동일성의 구체적인 사례로는 파라미터 발명이 있다. 파라미터 발명과 관련하여 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298 판결에서는 “새롭게 창출한 물리적, 화학적, 생물학적 특성값을 이용하거나 복수의 변수 사이의 상관관계를 이용하여 발명의 구성요소를 특정한 이른바 ‘파라미터 발명’과 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물건 또는 방법을 특정하고 있는 선행발명을 대비할 때, 특허발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성이 부정된다. 반면, 위와 같은 방법 등을 통하여 양 발명이 실질적으로 동일하다는 점이 증명되지 않으면, 신규성이 부정된다고 할 수 없다”라고 판시하여 문언적 동일하지는 않지만, 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 또는 시험·측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 선행발명의 대응되는 것과 동일하거나 또는 발명의 설명에 기재된 실시형태와 선행발명의 구체적 실시형태가 동일한 경우, 즉 내재적 동일성이 있는 경우 신규성이 부정된다고 하였다.

3. 실질적 동일성

(1) 유 형

실질적 동일성은 인용대상과 본원발명이 동일한 기술사상에 기반하고, 차이가 있더라도 미소한 차이에 불과한 것으로서, i) 물건발명과 방법발명과 같이 발명의 범주(카테고리)가 다른 경우, ii) 상·하위개념의 발명과 같이 발명의 범위가 다른 경우(부분적 일치에 있는 경우), iii) 발명의 구성 중 일부가 변경된 경우(단순한 구성의 변경이 있는 경우)의 유형으로 구분될 수 있다.

(2) 발명의 범주가 다른 경우

1) 제조방법발명이 인용대상이고, 물건발명이 본원발명인 경우를 예로 들 수 있다. 이때 본원발명은 인용대상과 동일성이 있다. 만일 동일성이 없다면 제조방법발명보다 특허권의 효력이 강한 물건발명이 등록되어 제조방법발명의 실시(물건생산을 청약하는 행위)에 대하여 침해를 주장할 수 있게 되어 부당하기 때문이다.¹³⁰⁾

2) 다만 물건발명이 인용대상이고, 본원발명이 제조방법발명인 경우에는 일반적으로 동일성이 없다고 할 것이다. 하나의 물건발명을 제조하는 방법은 수없이 많이 존재하는데 기존의 제조방법을 개량한다면 이에 대한 특허를 부정할 이유가 없기 때문이다. 또한 제조방법발명이 등록되더라도 그 제조방법의 사용에 의하여 생산된 물건에 대해서만 효력이 미치게 되고, 이미 공지된 기존의 제조방법에 사용에 의하여 생산된 물건에 대해서는 침해를 주장할 수 없어 기존의 제조방법을 실시하여 그 물건을 생산, 판매하고 있는 자를 제한하지도 않기 때문이다.

130) 이와 관련하여, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304 판결에서는 “물건의 발명에서 이와 동일한 발명이 그 출원 전에 공지되었거나 공연히 실시되었음이 인정되면 그 발명의 신규성은 부정된다. 특허발명에서 구성요소로 특정된 물건의 구성이나 속성이 선행발명에 명시적으로 개시되어 있지 않은 경우라도 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면, 이는 선행발명에 내재된 구성 또는 속성으로 볼 수 있다. 이와 같은 경우 특허발명이 해당 구성 또는 속성으로 인한 물질의 새로운 용도를 특허의 대상으로 한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 공지된 물건에 원래부터 존재하였던 내재된 구성 또는 속성을 발견한 것에 불과하므로 신규성이 부정된다. 이는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)이 출원 당시에 그 구성이나 속성을 인식할 수 없었던 경우에도 마찬가지이다. 또한 공지된 물건의 내재된 구성 또는 속성을 파악하기 위하여 출원일 이후 공지된 자료를 증거로 사용할 수 있다. 한편 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다. 즉 선행발명이 공지된 물건 그 자체일 경우에는 그 물건과 특허발명의 구성을 대비하여 양 발명이 동일한지 판단할 수 있으나, 선행발명이 특정 제조방법에 의해 제작된 물건에 관한 공지된 문헌인 경우, 선행발명에 개시된 물건은 선행발명에 개시된 제조방법에 따라 제조된 물건이므로, 선행발명에 개시된 제조방법에 따랐을 경우 우연한 결과일 수도 있는 한 실시례가 위와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점을 넘어 그 결과물이 필연적으로 해당 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 선행발명과 특허발명이 동일하다고 할 수 있다”라고 판시하여, 선행발명에 개시되어 있지 않더라도, 선행발명에 개시된 물건이 특허발명과 동일한 구성이나 속성을 갖는다는 점이 인정된다면(실질적 동일성 중 발명의 범주가 다른 경우의 동일성) 신규성이 부정된다고 하면서, 다만 동일한 구성 또는 속성을 가질 수도 있다는 가능성 또는 개연성만으로는 두 발명을 동일하다고 할 수 없고, 필연적으로 그와 같은 구성 또는 속성을 가진다는 점이 증명되어야 한다고 하였다.

(3) 발명의 범위가 다른 경우

1) 하위개념발명이 인용대상이고, 상위개념발명이 본원발명인 경우를 예로 들 수 있다. 발명에서 상위개념이란 더 넓은 포괄적인 기술을 의미하고 하위개념이란 상위개념에 포함되는 더 세분화된 특수 분야의 기술을 의미한다. 하위개념발명은 다시 한정하여 구체화한 발명과 부가하여 구체화한 발명으로 구분될 수 있다. 이때 본원발명은 인용대상과 동일성이 있다. 만일 동일성이 없다면 발명의 범주가 다른 경우에서 설명한 것과 같은 법리로 하위개념발명보다 특허권의 효력이 강한 상위개념발명이 등록되어 하위개념발명의 실시에 대하여 침해를 주장할 수 있게 되어 부당하기 때문이다.¹³¹⁾

2) 다만 상위개념발명이 인용대상이고, 하위개념발명인 본원발명인 경우에는 일반적으로 동일성이 없다고 할 것이다. 하위개념발명은 기존의 상위개념발명을 개량한 것으로 이에 대한 특허를 부정할 이유가 없기 때문이다. 또한 하위개념발명이 등록되더라도 이미 공지된 상위개념발명의 실시에 대해서는 침해를 주장할 수 없어 상위개념발명을 실시하고 있는 자를 제한하지도 않기 때문이다. 이때 하위개념발명이 한정하여 구체화한 발명이면 선택발명이라고 하고¹³²⁾, 부가하여 구체화한 발명이면 결합발명이라고 한다.

(4) 발명의 구성 중 일부가 변경된 경우

a+b1이 인용대상이고, a+b2가 본원발명인 경우를 예로 들 수 있다. 양 발명을 대비하였을 때 b1과 b2의 차이가 있지만 미세한 차이가 불과한 경우 동일성이 인정될 수 있다. 문제가 되는 것은 어느 정도의 창작 수준의 차이까지 동일성을 인정할 것인가라고 할 수 있다. 이에 대해서는 “과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 단순한 부가, 전환, 삭제 등에 불과하여 새로운 효과 발생이 없고, 발명 간의 차이가 발명의 사상에 실질적인 영향을 미치지 않는 비본질적 사항에 불과한 경우를 말한다(이를 “협의의 동일성”이라 한다)”라는 판단기준과 “어떤 발명에 대하여 그 구성을 변경함으로써 구성이 다른 발명이 되었을 때 그 변경이 목적 달성을 위한 구체화 수단으로서 통상의 기술자에 의하여 일반적으로 채용될 수 있는 정도의

131) 미국에서는 인용대상에 개시된 발명이 만일 본원발명의 특허 후에 존재하는 경우 특허침해를 구성하게 된다면, 인용대상의 발명이 본원발명의 특허발명일 이전에 존재하는 경우에는 본원발명의 동일성을 인정하는 방법이 사용되고 있는데, 이를 ‘후침해 선신규성 부정의 원칙’이라고 부른다(한국특허법학회 편(김판식 집필 부분), 「특허판례연구(개정판)」, 박영사, 2012, 117면).

132) 선택발명과 관련하여, 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3520 판결에서는 “선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하고 있어야 하고(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375 판결, 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338 판결 등 참조), 이에선 선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문헌적인 기재가 존재하는 경우 외에도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행문헌의 기재내용과 출원 시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우도 포함된다(대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 참조)”라고 판시하여 하위개념인 선택발명은 실질적 동일성의 범위를 벗어나 있어서 선행발명에 개시되지 있지 않은 경우, 즉 문헌적 동일과 내재적 동일성이 인정되지 않으면 신규성이 부정되지 않는다고 판시하였다.

기술수단의 단순한 치환, 부가 또는 삭제 등에 해당하는 것이고 그 변경에 의하여 발명의 목적 및 효과에 각별한 차이가 생기지 않는 경우를 말한다(이를 “광의의 동일성”이라 한다)라는 판단기준이 있다. 광의의 동일성 판단기준은 창작수준에서 살펴보면, ④-⑤ 단계의 진보성 판단에 준하는 판단기준이라고 할 수 있다.¹³³⁾

III. 심사 실무에 의한 동일성의 판단방법

1) 특허·실용신안 심사기준에 의하면, 확대된 선출원의 설명부분에서¹³⁴⁾ “발명의 동일성 문제는 발명의 신규성(法 29①) 문제뿐만 아니라 확대된 선출원(法 29③④), 정당한 권리자의 보호(法 33, 34, 35), 선출원주의(法 36), 특허를 받을 수 있는 권리의 승계(法 38), 분할출원(法 52), 분리출원(法 52의2), 변경출원(法 53) 및 우선권주장출원(法 54, 55) 등의 적합성을 판단하는 때에도 발생하는 문제로 본 장의 동일성 판단기준은 상기 각 부분에서 준용한다”라고 하고 있으며, 발명이 실질적으로 동일한 경우에 관하여 단순한 표현의 상위¹³⁵⁾, 단순한 효과의 인식 상위¹³⁶⁾, 단순한 목적의 상위¹³⁷⁾, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 차이¹³⁸⁾, 용도한정의 유무¹³⁹⁾ 등 다양한 세부 유형을 인정하고 있다. 이 중 단순한 효과의 인식 상위, 단순한 목적의 상위는 ② 단계의 내재적 동일성을, 단순한 표현의 상위는 ③ 단계의 실질적 동일성 중 발명의 범주가 다른 경우를, 단순한 구성의 변경, 단순한 용도의 차이, 용도한정의 유무는 ③ 단계의

133) 한편 방법발명에서는 구성요소 사이의 시간적 흐름이 존재하고, 구성요소의 배치 순서가 작용효과 등에 중대한 차이를 가져올 수 있기 때문에 구성요소의 배치 순서도 발명의 요소로 보아야 한다(특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874). 따라서 동일성 여부의 판단에 있어서는 원칙적으로 양 발명의 전체 공정을 확정된 후 대응하는 공정을 시계열적으로 구분 추출한 다음 비교하여 기술적 이동(異同)을 판별함과 아울러, 추가, 삭제 또는 변경된 공정이 있는 경우에는 그로 인하여 양 발명의 기술사상이 실질적으로 달라질 만큼 기술적 의의가 있는지 여부도 함께 검토하여야 한다(특허법원 2009. 1. 26. 선고 2008허12180).

134) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3410-3414면.

135) 단순한 표현의 상위란 청구범위의 표현은 다르지만, 실질적으로 동일한 내용인 것을 말하며, 단순한 카테고리 상위도 역시 단순한 표현의 상위에 속한다(예를 들어 해수 중에서 해수에 용해되지 않는 냉각제를 넣어놓아 해수 중의 수분을 분리함으로써「해수를 담수화하는 방법」과「해수를 농축화하는 방법」의 경우).

136) 단순한 효과의 인식 상위란 양 발명의 구성이 동일하므로 이로 인한 작용효과도 또한 동일하지만 단지 작용효과에 있어서 차이가 있는 정도에 불과한 것을 말한다(예를 들어 폴리에틸렌으로 피복한 전선을 요지로 하는 발명인면서, 선출원은 절연성에 뛰어난 효과가 있다고 하고 후출원은 고주파 특성이 좋다고 하여, 양자의 효과 인식에 차이가 있는 경우).

137) 단순한 목적의 상위란 양 발명의 구성은 동일하나 목적이라는 주관적인 의도는 다른 것을 말한다.

138) 단순한 용도의 차이란 구성의 차이가 있는 양 발명에 있어서 그 차이가 용도의 차이로서만 표시되어 있고, 그 용도의 차이가 타 구성으로부터 도출되는 용도 상호 간의 차이에 불과한 경우를 말한다(예를 들어 「화합물 B로 되는 염화비닐수지의 가소제」와「화합물 B로 되는 염화비닐수지의 변색방지제」).

139) 단순한 용도한정의 유무란 양 발명에 있어서 그 차이가 용도한정의 유무로서만 표시되어 있고 그 용도가 타 구성으로부터 당연히 도출되는 용도의 한정에 불과한 경우를 말한다(예를 들어 「단면이 평평한 실로 구성된 망」과「단면이 평평한 실로 구성된 어망」).

실질적 동일성 중 발명의 구성 일부가 변경된 경우를 설명하고 있는 것으로 보인다. 다만 발명의 구성 일부가 변경된 경우와 관련하여서는, 확대된 선출원을 설명부분에서¹⁴⁰⁾는 광의의 동일성 판단기준에 따라서 신규성을 설명하는 부분¹⁴¹⁾에서는 협의의 동일성 판단기준에 따라서 동일성을 판단한다고 기술하여 일관된 태도를 보이고 있지 않다.

2) 한편 ③ 단계의 실질적 동일성 중 발명의 범위가 다른 경우와 관련하여서는, 심사기준의 신규성의 동일성을 설명하는 부분¹⁴²⁾에서 “청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되어 있고 인용대상이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없고, 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고 인용대상이 상위개념으로 표현되어 있는 경우에는 통상 청구항에 기재된 발명은 신규성이 있다”라고 기재되어 있다.

IV. 판례에 의한 동일성 판단방법

1. 신규성, 확대된 선출원, 선출원주의에서 동일성 판단방법

(1) 서

신규성, 확대된 선출원, 선출원주의를 적용할 때 동일성 판단방법은 창작의 수준 중 일반적 으로 ①-③ 단계의 수준까지의 기준을 적용한다. 즉 문언적 동일, 내재적 동일성 및 실질적 동일성이라는 기준에 의하여 동일성의 판단을 하고 있다. 다만 신규성, 확대된 선출원을 적용 함에 있어서는 실질적 동일성 중 발명의 구성 일부가 변경된 경우, 그리고 선출원주의를 적용 함에 있어서는 실질적 동일성 중 발명의 구성 일부가 변경된 경우와 동일자 출원의 경우 동일 성 판단을 어떻게 할 것인가가 문제가 되고 있다.

(2) 신규성과 확대된 선출원에서 동일성 판단방법

확대된 선출원에서 발명의 구성 일부가 변경된 경우와 관련하여 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1181 판결¹⁴³⁾에서는 “구성요소에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지관용기술의 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이 에 불과하다면 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 두 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 해당 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가 진 사람이 쉽게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 두 발명을 동일하다고 할 수 없다”라고 하여 협의의 동일성 판단기준에 의하야만 하고, 광의의 동일성 판단기준까지 확대되는 것을 제한하고 있다.¹⁴⁴⁾ 신규성과 관련해서도 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결에서

140) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3411-3412면.

141) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3222면.

142) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 3224-3225면.

143) 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179도 동일한 취지로 판시하고 있다.

광의의 동일성 판단기준에 의해서 판단해서는 안된다고 명시하지는 않았으나, 확대된 선출원에서와 마찬가지로 협의의 동일성 판단기준에 따라 동일성을 판단해야 한다고 판시하고 있다.¹⁴⁵⁾

(3) 선출원주의에서 동일성 판단방법

① 발명의 구성 일부가 변경된 경우

1) 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827 판결에서는 “전후로 출원된 양 발명이 동일하다고 함은 그 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 동일하고, 비록 양 발명의 구성에 상이점이 있어도 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용 효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우에는 양 발명은 역시 동일한 발명이다”라고 판시하여 신규성, 확대된 선출원과는 달리 광의의 동일성 판단기준에 의하여 동일성을 판단하고 있다. 다만 이러한 실질적 동일성 판단기준은 i) 진보성 판단과의 경계가 모호해질 우려가 있다는 점, ii) 확대된 선출원 규정이 선출원주의를 보완하기 위해 제도인데 양자의 실질적 동일성을 달리 판단할 이유가 없다는 점을 고려할 때 그 운영을 신중히 할 필요가 있다.¹⁴⁶⁾ 한편 최근의 특허법원 2017. 10. 12. 선고 2017허1021 판결에서는 분할출원된 발명과 원출원 발명의 동일성이 있는지와 관련하여, “분할출원된 발명과 원출원 발명이 동일한지 여부는 청구범위에 기재된 양 발명의 기술적 구성이 실질적으로 동일한지 여부를 기준으로 하여야 하며, 청구범위의 기재가 문언적으로 일치하지 않더라도 그 차이가 동일한 기술적 구성에 대하여 기능·성질·효과 등으로 표현을 달리한 것에 불과하거나 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적 수단에서 주지관용기술을 부가·삭제·변경한 것 또는 단순히 수치 범위를

144) 대상판결은 특허법상 근거없이 동일성의 판단기준이 진보성과 유사한 정도로 확대되는 것을 일정하게 제한하는 점에서는 매우 바람직하다고 할 수 있으나, 선출원에 대한 지식재산권 심사 기간의 장단이라는 임의의 기간에 의하여 후출원의 특허여부 여부가 결정되는 점은 불합리하다고 볼 수 있고 이러한 불합리를 해소하기 위한 하나의 방법으로서 장기적으로 선출원과 확대된 선출원의 적용 시 진보성 판단에 상응하는 동일성의 판단기준의 도입도 고려할 만하나 이러한 기준은 대법원의 판례와 상응하지 않으므로 결국 새로운 기준의 도입은 입법에 의할 수밖에 없게 된다 (김관식, “발명의 동일성 판단 기준-선출원주의와 확대된 선출원주의 적용 시의 비교를 중심으로”, 창작과 권리 제69호, 세창출판사, 2012, 37-38면).

145) 구체적인 사례로는 수치한정발명이 있다. 선택발명과 관련하여, 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결에서는 “구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재내용과 출원 시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다”라고 판시하여 공지기술(선행발명)에 개시되어 있거나(문언적 동일, 내재적 동일성), 주지·관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면(실질적 동일성 중 구성이 변경된 경우 협의의 동일성) 신규성이 부정된다고 판시하였다.

146) 조영선, “발명(고안)의 동일성 판단”, 「특허판례연구」, 박영사, 2009, 97-98면 참조.

달리한 것에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 실질적으로 동일한 발명에 해당한다”라고 하여 협의의 동일성 판단기준에 따라 동일성을 판단하고 있다. 이에 따라 대법원의 입장 변화가 있을지 주목된다.

② 동일자 출원의 경우

1) 대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017 판결에서는 “두 발명이 서로 동일한 발명인지 여부는 대비되는 두 발명의 실체를 파악하여 따져 보아야 할 것이지 표현양식에 따른 차이에 따라 판단할 것은 아니므로, 대비되는 두 발명이 각각 물건의 발명과 방법의 발명으로 서로 발명의 범주가 다르다고 하여 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다. (중략) 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명 제1, 2항은 방법의 발명이고, 비교대상발명 제1, 2항은 물건의 발명(고안)이지만, 그 기술사상의 실체를 파악하여 이에 터잡아 대비하여 보면 위 각 대비되는 발명들은 동일한 기술사상에 대하여 단지 표현양식에 차이가 있는 것에 불과하다고 보일 뿐이므로, 두 발명은 동일한 발명으로 봄이 상당하다”라고 하여 방법발명과 물건발명의 동일성을 인정하였다.¹⁴⁷⁾

2) 다만 동일자 출원의 경우에는 실질적 동일성의 범위를 좁게 해석하여 양 발명 모두 등록을 시켜주고 등록 후 자유롭게 실시할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 판단된다. i) 동일자 출원이므로 특허권의 존속기간이 부당하게 연장되지 않는다는 점, ii) 발명의 범주가 다르다면 물건발명과 방법발명은 특허권자가 누릴 수 있는 권리의 내용에 큰 차이가 있는 점, iii) 특허 출원인이 동일하면 하나의 출원서에 복수의 청구항으로 기재하여 출원하는 경우라면 모두 유효하게 등록될 수 있었을 것이라는 점(대법원 1995. 9. 26. 선고 94후1558) 등을 고려해야 하기 때문이다.¹⁴⁸⁾

147) 이와 같이 출원인이 서로 상이하다고 판단하여 별개의 출원으로 출원한 복수의 발명을 그 구성의 차이에도 불구하고 ‘실질적으로 동일’하다고 판단하여 모두 무효로 하는 것은, i) 이와 같은 복수의 출원을 하나의 출원서에 복수의 청구항으로 기재하여 출원하는 경우라면 모두 유효하게 등록될 수 있었을 것이라는 점과(대법원 1995. 9. 26. 선고 94후1558 참조), ii) 유사한 복수의 발명을 출원일을 달리하여 출원하는 경우에는 독점권을 부당하게 연장시키는 효과가 발생할 수도 있으나, 출원일이 동일하므로 유사한 복수의 발명을 출원하여 독점권을 향유할 수 있는 기간을 부당하게 연장하는 점이 없다는 점, iii) 특허 발명의 범주의 차이에도 불구하고 동일하다고 판단한 경우에서 물건의 발명과 방법의 발명은 특허권자가 누릴 수 있는 권리의 내용에 있어 큰 차이가 있다는 점, iv) 선후출원 판단시의 실질적 동일성 개념의 적용은 미국에서 선출원에 비하여 진보성이 부정되는 후출원이 등록이 되지 아니하는 점과 일견 유사한 점이 있으나 미국에서도 이 경우 기간의 포기서(terminal disclaimer) 제출로 동일인의 경우 결합발명이 모두 등록이 가능하다는 점을 상기하면, 상기와 같은 결과는 매우 부당한 것이다. 상기의 점을 종합하여 볼 때 동일인의 결합발명 여부 판단시에는 발명의 동일성 판단을 엄격히 하여 결합출원 발명의 경우 일부 구성의 차이가 있어 양 발명의 구성이 전면적으로 일치하지 않는다면 그 발명의 동일성을 부정하는 편이 바람직할 것이다. 특별히 발명의 범주가 다른 경우에는 원칙적으로 상이한 발명으로 취급하는 것이 타당하다고 생각된다(김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 박사, 2013, 103-108면).

148) 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 박사, 2013, 103-108면 참조.

【표 3-10】 특허요건 판단에서 동일성 인정 여부

구 분			인용대상	본원발명	동일성 인정 여부	비고
문언적 동일			a+b(직접 기재)	a+b	인정	
내재적 동일성			a+b(직접 기재와 마찬가지)	a+b	인정	
실 질 적 동 일 성	범주 상이		물건발명	제법발명	일반적 불인정	
			제법발명	물건발명	일반적 인정	
	범위 상이	부가	a+b	a+b+c	일반적 불인정	결합 발명
			a+b+c	a+b	일반적 인정	
		한정	A+b (A는 a의 상위개념)	a+b	일반적 불인정	선택 발명
			a+b	A+b (A는 a의 상위개념)	일반적 인정	
	구성 변경		a+b1	a+b	일반적 불인정	

2. 보정, 우선권주장출원, 정정심판 등 소급효 인정과 관련된 규정에서 동일성 판단방법

판례는 보정(法 47②),¹⁴⁹⁾ 우선권주장출원(法 54①, 55③),¹⁵⁰⁾ 정정심판(法 136③)¹⁵¹⁾ 등에서 소급효를 인정받기 위한 동일성 판단과 관련하여, “명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 출원 시(우선권주장출원의 경우 우선권주장일 당시)의 기술상식에 비추어 보아 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다”라고 하여 ①-② 단계의 창작 수준에서의 동일성 판단을 하고 있다. 이는 소급효로 인해 제3자에게 불측의 손해를 끼치지 않기 위해서이다. 한편 구체적인 사례로는 i) 주지관용기술이더라도 통상의 기술자가 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니라면 보정이 인정되지 않는다는 사례,¹⁵²⁾ ii) 상위개념을 하위개념으로 정정하였다고 하더라도 통상의 기술자가 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이 아니라면 인정되지 않는다는 사례,¹⁵³⁾ iii) 하위개념을 상위개념으로 하여 우선권주장을 하였을 때 통상의

149) 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130.

150) 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999.

151) 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404.

152) 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130.

153) 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404.

기술자가 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 아니라면 인정되지 않는다는 사례¹⁵⁴⁾, iv) 최초 명세서 등의 기재 범위 내로 볼 수 없는 실시예를 추가하는 것이 통상의 기술자가 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 아니라면 인정되지 않는다는 사례¹⁵⁵⁾ 등이 있다.¹⁵⁶⁾

3. 무권리자 출원과 허위표시에서의 동일성 판단방법

(1) 무권리자 출원에서의 동일성 판단방법

발명자의 발명을 모인한 후 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경한 경우 무권리자에

154) 특허법 제55조의 우선권 주장을 수반한 후출원 발명 중 출원일의 소급 효과가 인정되는 것은 선출원의 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 발명에 한한다. 즉 선출원의 명세서와 도면에 기재된 발명과 동일하다고 인정되는 발명에 대하여는 우선권이 인정되어 선출원의 출원일에 출원한 것으로 보고, 요지가 변경되었거나 신규사항이 추가된 경우에는 우선권이 인정되지 아니한다. 그런데 교반기에는 패들타입 교반기 외에도 여러 가지 형상의 교반기가 존재함이 명백하고, 교반기는 패들타입 교반기의 상위개념에 해당하므로 양자를 동일하다고 할 수 없고, 결국 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원발명은 발명의 동일성이 인정되지 아니한다. 따라서 국내우선권에 관한 원고의 주장은 이유 없다. 이에 대하여 원고는, 지식재산처의 심사지침서에 의하면 발명의 신규성 판단 부분에서 청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 표현되어 있고 인용대상이 하위개념으로 표현되어 있는 경우에는 청구항에 기재된 발명은 신규성이 없는 발명이다 라고 정하고 있는바, 이는 하위개념으로 표현된 인용대상과 상위개념으로 표현된 청구항 기재 발명을 동일한 것으로 보는 것이며, 신규성에서의 동일성 판단의 기준은 국내우선권에서의 동일성 판단에도 그대로 준용되어야 하므로 이 사건 제1항 발명과 이 사건 선출원발명은 동일한 발명이므로 우선권이 인정되어야 한다고 주장한다. 살피건대, 지식재산처의 심사지침서의 내용은 발명의 동일성 판단을 위한 기본적인 과정을 제시하면서 이러한 내용이 발명의 동일성이 문제되는 여러 경우에도 준용될 수 있다는 것을 표현한 것에 불과하고, 구체적인 경우에 있어 발명의 동일성 판단기준을 완전히 동일하게 적용할 것을 제안하는 것도 아닌 것으로 보이며, 발명의 동일성이 문제되는 여러 경우에 있어서 동일성 여부의 판단 기준은 각 제도의 취지와 목적에 비추어 합리적으로 설정되는 것이 타당하다 할 것이므로, 심사지침서의 내용을 근거로 하는 원고의 위 주장은 이유 없다(특허법원 2009. 7. 1. 선고 2008허7706).“라고 하여 우선권주장일의 하위개념(패들타입 교반기)을 기초로 우선권주장출원일에 상위개념(교반기)을 주장하는 것은 동일성을 부정하였다. 상고심판결은 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371 판결이다. 위 대법원판결은 ‘출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정을 거절이유로 들어 특허거절결정을 하면서 우선권주장이 인정되지 않는다는 취지 및 그 이유가 포함된 거절이유를 통지하지 않는 것이 위법하다’는 점을 법리로 설시하면서, 지식재산처 심사 과정에서 우선권주장에 관한 거절이유가 통지되지 아니하였음에도, 원심은 이러한 점에 관하여 살피지 아니한 채, 거절결정이 적법하다고 판단하여 위법하다는 것이다.

155) 대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265).

156) 분할출원과 관련하여서는 기존에 ①-③ 단계의 창작 수준에서 동일성 판단을 하여 동일성을 불인정한 결과 소급효를 인정하지 않은 사례(대법원 2004. 3. 12. 선고 2002후2778)가 있으나 이는 i) 원출원의 청구범위와 분할출원의 청구범위를 비교하는 기준으로서 현재와 같이 원출원의 최초 명세서 또는 도면과 분할출원의 명세서 또는 도면을 비교하는 기준과 맞지 않는다는 점, ii) 동일성을 인정하여 출원일 소급을 인정한다면 제3자에게 불측의 손해를 줄 수 있기 때문에 ①-② 단계의 창작 수준까지에서 동일성 판단을 함이 적절하다는 점 등을 고려하였을 때 적절치 않다고 보여진다. 한편 그 후 특허법원 2012. 1. 13. 선고 2011허4110 판결에서는 분할출원으로서의 하위개념 발명이 원출원 명세서에 기재된 상위개념 발명에 개념적으로 포함된다는 점만으로는 분할출원된 발명이 원출원 명세서에 기재된 사항이라고 할 수는 없고, 원출원 명세서 전체의 기재와 최초 출원 당시의 기술상식을 종합적으로 고려하여 분할출원된 발명이 원출원 명세서에 기재된 것인지 또는 기재된 것과 동일하게 볼 수 있는 것인지 여부를 실질적으로 판단해야 한다”라고 하여 ①-② 단계의 창작 수준에서 동일성 판단을 하고 있다.

해당하는지와 관련하여, 기존의 대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결에서는 구성과 효과의 차이가 있다면 무권리자가 아니라고 판시하였으나, 최근 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결에서는 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 아니한 경우도 무권리자에 포함된다고 판시하였다. 즉 일반적인 판단기준은 “기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여했는지 여부”이고, “그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우”는 일반적인 판단기준을 구체화한 것에 불과하고, “등”을 부가하여 구체화된 기준과는 다른 기준이 적용될 수 있음을 판시하였다. 무권리자인지를 판단하면서 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여했는지를 가지고 판단한다는 발명자(무권리자)의 결정기준은 일응 이해가 되나,¹⁵⁷⁾¹⁵⁸⁾ 그 구체화된 기준으로서 진보성 판단에 준하는 광의의 동일성 판단기준을 적용하는 것은 i) 정당한 권리가 무권리자 특허출원으로 인정된 발명 전체에 대하여 별도 출원에 의한 출원일 소급을 인정받거나 특허권의 이전 청구를 통해 특허권을 획득할 수 있는데 지나치게 정당한 권리자를 두텁게 보호한다는 점, ii) 무권리자 출원 이후의 이와 동일한 개량발명을 한 제3자에게 불측의 손해를 끼칠 수 있다는 점에서 다시 한번 고려해 볼 필요가 있다고 여겨진다.¹⁵⁹⁾

(2) 허위표시에서의 동일성 판단방법

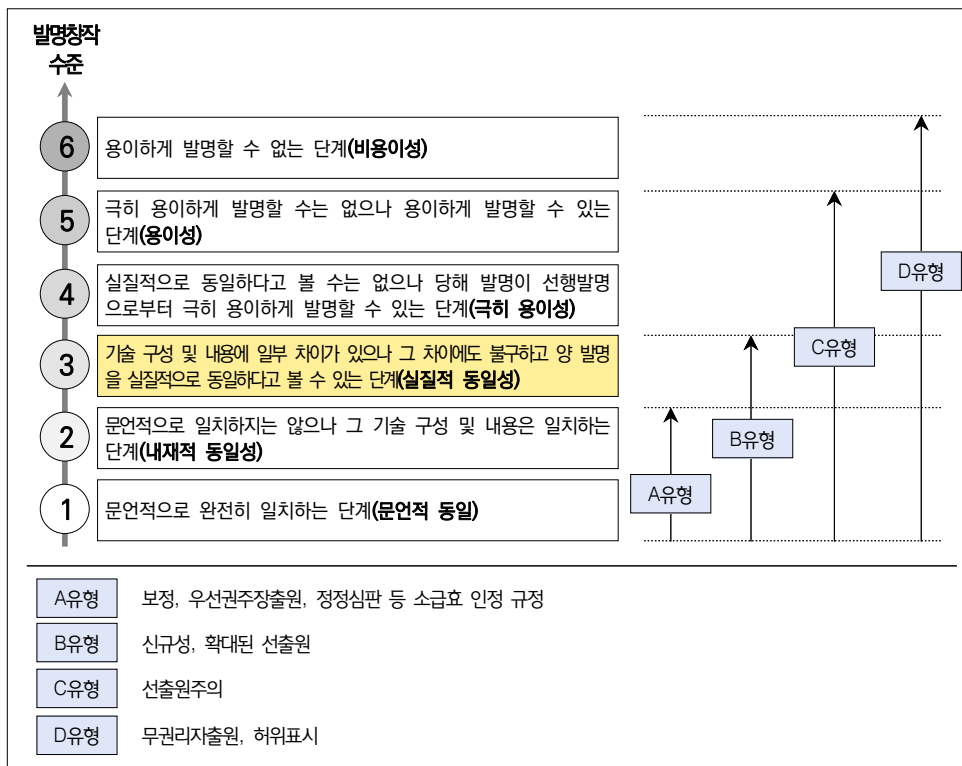
특허를 받은 구성 일부를 변경한 제품에 특허표시를 한 것과 관련하여 대법원 2015. 8. 13. 선고 2013도10265 판결에서는 “특허법 제224조 제3호는 같은 조 제1호의 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건을 생산사용양도하기 위하여 광고 등에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시(이하 ‘특허된 것 등으로 표시’라 한다)를 하는 행위를 금지하고 있다. 위 규정의 취지는 특허로 인한 거래상의 유리함과 특허에 관한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인시키는 행위를 처벌함으로써

157) 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178; 2012. 12. 27. 선고 2011다67705 판결에서도 공동발명자 결정기준으로서 기술적 사상의 창작에 실질적 기여를 했는지를 제시하고 있다.

158) 위 대법원판결은 정당한 권리자의 발명을 아무런 권리 없이 무단으로 출원한 종전의 강학상의 모인출원에 대한 판시기준을 정당한 권리자의 발명과 동일한지 아닌지를 바탕으로 등록된 특허의 무효를 판단하지 아니하고, 특허법의 원칙으로 돌아가서 발명자 내지 출원인이 해당 발명을 실제로 창작하였거나 그로부터 권리를 승계받은 자인지 여부에 따라 판단한 최초의 판결이라는 점에서 의의가 있다(박창수 강학상의 모인출원 - “기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우”, 한국특허법학회 42차 정기학회, 2012. 10. 20. 발표문, 7면). 종전 2003후2218 판결은 기본적으로 모인출원에 관하여 특허발명과 모인대상발명 사이의 동일성을 요구하는 종전의 실무예에서 벗어나지 못한 한계가 있고, 이러한 종전의 실무의 태도는 2009후2463 판결에서 제시된 ‘기술적 사상의 창작에 대한 실질적 기여’라는 탄력적인 기준에 따라 향후 바뀔 것으로 예상된다(성창익, “모인대상발명을 변형 또는 개량하여 특허등록한 경우 모인출원이 성립하는지 여부” 『특허판례연구』, 박영사, 2012, 332면).

159) 김관식, “발명의 동일성에 관한 연구”, 서울대학교 대학원, 박사, 2013, 166-169면 참고.

거래의 안전을 보호하는 데에 있다고 할 것이다. 이러한 취지에 비추어 볼 때, 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 통상의 기술자가 통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는, 위 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 위 규정에서 금지하는 표시행위에 해당한다고 볼 수 없다”라고 판시하였다. 즉 일반적인 판단기준은 “공중을 오인시킬 정도에 이르렀는지 여부”이고, “그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우”는 일반적인 판단기준을 구체화한 것에 불과하고, “등”을 부가하여 구체화된 기준과는 다른 기준이 적용될 수 있음을 판시하였다. 그 결과 광의의 동일성 판단기준보다 넓은 범위를 상정함으로써, 특허된 것으로 표시된 물건이 특허된 물건과 다소 다른 점이 있게 되었다고 하더라도 특허로 인한 재산상의 유리함 및 특허에 대한 공중의 신뢰를 악용하여 공중에게 오인될 정도가 아니라면 허용표시로 보지 않게 된다.



【그림 3-33】 판례에 의한 규정별 동일성의 인정범위

【표 3-11】규정별 판단대상의 비교

구 분	내 용	본원발명	비교대상	비 고
특허 요건 판단	신규성(法 29①각호)	청구범위	공지기술(1개)	동일성 판단
	진보성(法 29②)	청구범위	공지기술(1개 이상)	용이성 판단
	확대된 선출원 (法 29③④)	그 특허출원의 청구범위	다른 출원의 최초 명세서·도면	동일성 판단
	선출원주의(法 36)	청구범위	청구범위	동일성 판단
출원일 소급효	무권리자에 대한 정당한 권리자의 출원(法 34, 35)	정당한 권리자 출원의 명세서·도면	무권리자 출원의 최초 명세서·도면	1. 협의제 회피방안 → 무권리자 출원의 선출원지위 불인정 2. 객체적 요건: 동일성 판단 → 출원전체로서 판단 → 위반시 소급효 불인정
	신규사항추가금지 (法 47②전단)	명세서·도면	최초 명세서·도면	객체적 요건: 동일성 판단 → 출원전체로서 판단 → 위반시 거절이유 등
	분할출원(法 52)	명세서·도면	원출원의 최초 명세서·도면	1. 협의제 회피방안 → 청구범위가 동일 하지 않을 것을 요함 2. 객체적 요건: 동일성 판단 → 출원전체로서 판단 → 위반시 거절이유 등
	분리출원(法 52의2)	명세서·도면*	원출원의 최초 명세서·도면	1. 협의제 회피방안 → 청구범위가 동일 하지 않을 것을 요함 2. 객체적 요건: 동일성 판단 → 출원전체로서 판단 → 위반시 거절이유 등
	변경출원(法 53)	명세서·도면	원출원의 최초 명세서·도면	1. 협의제 회피방안 → 원출원의 취하간주 2. 객체적 요건: 동일성 판단 → 출원전체로서 판단 → 위반시 거절이유 등
판단 시점 소급효	조약우선권주장 출원(法 54)	청구범위	선출원의 최초 명세서·도면	1. 협의제 회피방안 → 외국의 선출원은 선출원의 지위, 확대된 선출원의 지위 불인정되어 회피 불필요 2. 객체적 요건: 동일성 판단 → 발명단위로 판단 → 발명단위로 소급효 결정
	국내우선권주장 출원(法 55)	청구범위	선출원의 최초 명세서·도면	1. 협의제 회피방안 → 선출원의 취하간주 2. 객체적 요건: 동일성 판단 → 발명단위로 판단 → 발명단위로 소급효 결정

* 단, 분리출원의 경우 청구범위에 기재된 청구항이 다음의 i) 내지 iv) 어느 하나에 해당할 것

i) 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항, ii) 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항, iii) i) 또는 ii)에 따른 청구항을 제47조제3항 각 호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항, iv) i)부터 iii)까지 중 어느 하나의 청구항에서 원출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항

PART 04

심사

제1장 심사절차 일반

제2장 심사의 주체

제3장 심사의 청구

제4장 심사의 진행

제5장 심사의 종료

제6장 심사와 관련된 제도

제1장

심사절차 일반

제1절 서 설

「특허출원의 심사」란 특허출원에 대하여 그 방식과 내용을 심리하여 특허를 부여할 것인지를 결정하는 과정을 말한다. 특허법은 심사주의를 채택하여 심사관에 의한 실체심사를 함으로써, 특허요건에 흠결이 없는, 즉 제62조의 거절이유에 해당하지 아니한 특허출원에 대해서만 특허결정하고 있다. 한편 제62조의 거절이유에 해당하는 특허출원에 대해서는 거절이유통지를 하여 의견서나 보정서를 제출할 수 있도록 함으로써 출원인이 거절이유를 극복할 기회를 제공하고, 그러함에도 불구하고 거절이유가 해소되지 아니한 경우에는 특허거절결정하고 있다.

제2절 심사주의와 무심사주의의 비교

I. 의 의

특허출원된 발명에 대하여 어떠한 방법으로 심사할지는 국가의 산업정책상의 문제라 할 수 있는데, 심사의 방법으로는 크게 심사주의와 무심사주의가 있다. 「심사주의」란 출원의 방식 사항 및 실체적인 사항 전부의 구비 여부를 심사한 뒤 특허 여부를 결정하는 심사방식을 말한다. 「무심사주의」란 특허를 받는데 필요한 요건 가운데 비교적 간단히 심사할 수 있는 특허출원서의 방식이나 절차 등의 적법 여부에 대해서만 심사하고 실질적인 사항을 심사하지 아니한 채 일단 특허를 부여하는 심사방식을 말한다.

II. 심사주의의 장단점

1) 심사주의는 i) 특허요건의 충족 여부를 사전에 심사함으로써 권리의 안정성 및 신뢰성을 도모하고 ii) 부실특허를 예방함으로써 특허분쟁을 사전에 방지하며, iii) 권리의 존재를 안정되게 함으로써 특허권의 재산적 가치를 높게 평가받을 수 있다는 장점이 있다.

2) 다만 최근 기술의 진보에 따라 출원건수가 급증한 결과 i) 심사인력이 부족하여 심사

적체에 따른 권리화 지연으로 인해 출원인의 불이익이 심화되었고, ii) 출원내용의 공개가 지연됨에 따라 동일기술에 대한 중복투자 및 연구와, iii) 그로 인한 동일발명에 대한 중복출원건수의 증가 등과 같은 단점이 있다.

Ⅲ. 무심사주의의 장단점

1) 무심사주의는 i) 단기간에 권리의 설정이 가능하며, ii) 심사에 필요한 인원이나 경비가 줄어든다는 장점이 있다.

2) 다만 무심사주의는 실제적 요건을 심사하지 않고 특허권을 부여하기 때문에 그 특허권에 하자나 흠결이 있는 경우 그 특허에 대한 법적 분쟁이 발생할 가능성이 커 권리의 법적 안정성이 보장되지 아니한다는 단점이 있다.

Ⅳ. 검 토

1. 심사주의의 채택

우리나라 특허법은 법적 안정성이 보장된 확실한 특허권을 설정하는 것이 유리하다는 판단 하에 기본적으로 심사주의를 채택하면서 그 단점을 보완하고 있다.

2. 심사주의의 보완

1) i) 출원발명의 조기공개를 통해 중복투자 및 연구를 방지하기 위한 출원공개제도, ii) 권리화 지연을 해결하기 위해 모든 출원이 아닌 심사청구가 있는 출원에 대해서만 심사를 함으로써 심사기간을 단축하는 심사청구제도를 도입하고 있다. 이러한 출원공개제도와 심사청구제도를 가미한 수정된 심사주의는 종래의 전통적인 심사주의의 단점을 개선한 것으로서, 무심사주의와 심사주의를 잘 조화시킨 제3의 제도라고 할 수 있다.

2) 한편 이러한 제도하에서도 최근 들어 발생하고 있는 특허출원의 양적, 질적 증가에 효율적으로 대처하는 데에는 많은 어려움이 있어 i) 출원공개제도를 보완하는 제도로서 신청에 의한 조기공개제도를, ii) 심사청구제도의 예외로서 출원인의 이익이나 공익상 필요한 경우로서 긴급한 처리가 필요한 출원에 대해서는 심사청구순서와 관계없이 먼저 심사를 할 수 있도록 하는 우선심사제도(法 61)를 도입하였다. 또한 심판사건의 적체를 해소하고 출원인의 입장에서 조속한 권리화를 도모하기 위해 iii) 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내 명세서 또는 도면을 보정하면서 재심사 청구를 한 사건에 대해서는 심판을 하기에 앞서 그 사건을 심사관에게 다시 심사토록 하는 제도인 재심사 청구제도(法 67의2)를, iv) 선출원의 심사결과 및 청구범위의 확정을 기다릴 필요 없이 선출원의 출원공개 또는 등록공고를 전제로 후출원을 심

사하여 심사청구제도의 실효성을 확보하기 위해 확대된 선출원(法 29③④⑤⑥⑦)을 도입하였으며, v) 출원공고제도와 이의신청제도를 폐지하고 등록공고제도(法 87)와 취소신청제도(法 132의 2-132의15)를 신설하였다.

3) 또한 심사관의 심사부담을 경감하기 위하여 i) 누구든지 그 발명이 거절이유(法 42③Ⅱ·42⑧·45 제외)에 의하여 특허될 수 없다는 정보를 증거와 함께 제공할 수 있도록 정보제공제도(法 63의2)를 도입하였고, ii) 심사에 있어서 필요하다고 인정되면 전문기관에 미생물의 기탁·분양, 선행기술의 조사, 특허분류의 부여, 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무를 의뢰할 수 있도록 하였다(法 58).

【표 4-1】 심사주의와 무심사주의의 비교

구 분	전통적 심사주의	무심사주의
의 의	등록 전 실체심사를 함	등록 전 실체심사를 하지 아니함
권리의 신뢰성(법적 안정성)	높음	낮음
권리화 기간(구체적 타당성)	장기	단기
발명의 조기공개유도	×	○
특허법의 태도	1. 심사주의의 채택 2. 심사주의의 단점 보완 - 심사청구제도(권리화 기간의 단점 보완) - 출원공고제도(발명의 조기공개유도의 단점 보완) - 확대된 선출원(심사청구제도의 실효성 확보) - 전문기관에 선행기술조사 의뢰(심사관의 부담 감소) - 정보제공(심사의 정확성 및 신속성 향상)	

제3절 심사의 분류

I. 절차에 따른 분류

1. 특허출원의 심사

「특허출원」이란 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 그 발명의 공개를 전제로 하여 지식 재산권에 대하여 특허를 받으려는 의사를 객관적으로 표시하는 행위를 말한다. 특허출원인이 특허를 받기 위하여 특허출원을 하면 심사관은 특허출원한 발명이 거절이유(法 62)에 해당하는지에 대하여 심사를 하게 된다.

2. 존속기간연장등록출원의 심사

「존속기간연장등록제도」란 i) 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가 등"이라 한다)을 위하여 필요한

유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 의한 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장하거나, ii) 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있는 제도를 말한다(法 89, 92의2). 특허권자가 존속기간연장등록을 하려면 특허법에서 정한 바에 따라 존속기간연장등록출원을 별도로 하여야 하며, 심사관은 존속기간연장등록출원이 거절이유(法 91, 92의4)에 해당하는지에 대하여 심사를 하게 된다.

II. 내용에 따른 분류

1. 방식심사

「방식심사」란 지식재산처장 등이 출원인이 제출한 특허출원서 등이 특허법령에서 정한 소정의 요건에 적합한지를 심사하는 것을 말한다. 이와 같은 방식심사는 특허요건 등을 심사하는 실체심사와는 구분되는 개념으로 특허에 관한 제반절차에서 행해지는데, 이처럼 출원인·청구인 등에게 일정한 방식에 의하여 절차를 밟을 것을 요구하는 것은 특허에 관한 방식과 절차를 통일함으로써 특허행정의 원활한 수행을 기하기 위해서이다. 이러한 방식심사는 특별한 청구가 없어도 진행되며 지식재산처장, 특허심판원장이 행한다.

2. 실체심사

「실체심사」란 심사관 등이 특허출원에 기재된 출원발명이 실제적인 특허요건을 구비하는 등 실질적으로 특허를 받을 수 있는지에 대하여 심사하는 것을 말한다. 특허출원에 대한 실체심사는 심사청구가 있는 때에만 심사관이 행한다.

제2장

심사의 주체

제57조 【심사관에 의한 심사】

- ① 지식재산처장은 심사관에게 특허출원을 심사하게 한다.
- ② 심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제58조 【전문기관의 등록 등】

- ① 지식재산처장은 출원인이 특허출원할 때 필요하거나 특허출원을 심사(국제출원에 대한 국제조사 및 국제예비심사를 포함한다)할 때에 필요하다고 인정하면 제2항에 따른 전문기관에 미생물의 기탁·분양, 선행기술의 조사, 특허분류의 부여, 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무를 의뢰할 수 있다. <개정 2016.12.2.>
- ② 제1항에 따라 지식재산처장이 의뢰하는 업무를 수행하려는 자는 지식재산처장에게 전문기관의 등록을 하여야 한다. <신설 2016.12.2.>
- ③ 지식재산처장은 제1항의 업무를 효과적으로 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 전담기관으로 하여금 전문기관 업무에 대한 관리 및 평가에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다. <신설 2018.4.17.>
- ④ 지식재산처장은 특허출원의 심사에 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 행정기관, 해당 기술분야의 전문기관 또는 특허에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다. 이 경우 지식재산처장은 예산의 범위에서 수당 또는 비용을 지급할 수 있다. <개정 2016.12.2., 2018.4.17.>
- ⑤ 제2항에 따른 전문기관의 등록기준, 선행기술의 조사 또는 특허분류의 부여 등의 의뢰에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2016.12.2., 2018.4.17.>

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.12.2.]

제58조의2 【전문기관 등록의 취소 등】

- ① 지식재산처장은 제58조제2항에 따른 전문기관이 제1호에 해당하는 경우에는 전문기관의 등록을 취소하여야 하며, 제2호 또는 제3호에 해당하는 경우에는 그 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 전부 또는 일부의 정지를 명할 수 있다. <개정 2016.2.29., 2016.12.2., 2018.4.17.>
 1. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우
 2. 제58조제5항에 따른 등록기준에 맞지 아니하게 된 경우
 3. 전문기관의 임직원인 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우
- ② 지식재산처장은 제1항에 따라 전문기관의 등록을 취소하거나 업무정지를 명하려면 청문을 하여야 한다. <개정 2016.12.2.>
- ③ 제1항에 따른 처분의 세부 기준과 절차 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.12.2.]

제68조 【심판규정의 심사예외 준용】

특허출원의 심사에 관하여는 제148조제1호부터 제5호까지 및 제7호를 준용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 심사관

1. 의 의

「심사관」이란 출원에 대한 심사를 담당하는 자를 말한다. 지식재산처장은 심사관에게 특허 출원을 심사하게 하고, 심사관의 자격에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다(法 57). 심사관은 지식재산처장과 분리된 별도의 기관으로서 존재하는 것이 아니라 지식재산처장의 지휘감독을 받는 지식재산처장의 하부구조라고 볼 수 있다. 그러나 심사관의 심사결과에 대하여 지식재산처장이 임의로 번복시킬 수 없으며, 심판 및 소송에 의해서만 변경될 수 있는 등 심사관의 심사는 지식재산처장과 독립되어 이루어진다.

2. 심사관의 제척

(1) 의의 및 취지

「심사관의 제척」이란 법정사유에 해당하면 법률상 당연히 심사관으로부터 배제되는 것을 말한다. 특허법은 심사의 공정성과 객관성을 담보하기 위해 특허출원의 심사에 관하여는 심판관의 제척사유를 준용한다(法 68 준용 法 148 I-V 및 VII). 다만 현행법은 심사관의 제척제도는 인정하나 심사관에 대한 기피제도(法 150)를 인정하고 있지 아니한데, 이는 기피제도로 인한 심사업무의 지연 등을 고려한 것이다.

(2) 제척사유

1) 심사관은 i) 심사관 또는 그 배우자이거나 배우자이었던 사람이 특허출원인인 경우, ii) 심사관이 특허출원인의 친족이거나 친족이었던 경우, iii) 심사관이 특허출원인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우, iv) 심사관이 특허출원에 대한 증인 또는 감정인이거나 감정인이었던 경우, v) 심사관이 특허출원인의 대리인이거나 대리인이었던 경우, 및 vi) 심사관이 특허출원에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대한 심사에서 제척된다.

2) 다만 심사관의 심사에 있어 전심판여라는 것은 있을 수 없으므로 제척사유에 관한 제 148조의 규정 중에 제6호의 전심판여에 관한 규정은 준용하지 않는다.

(3) 제척의 효과

심사관은 제척사유에 해당하면 당연히 그 출원에 대한 심사에서 제척된다. 그 결과 제척원인이 있는 심사관은 그 출원에 관하여 어떠한 직무집행도 할 수 없으며, 제척원인이 있는 심사관에 의한 심사는 위법한 것으로서 그러한 심사관이 한 특허거절결정에 대해서는 불복할 수 있다.

II. 전문기관

1. 전문기관의 등록 등

지식재산처장은 출원인이 특허출원할 때 필요하거나 특허출원을 심사(국제출원에 대한 국제 조사 및 국제예비심사를 포함한다)할 때에 필요하다고 인정하면 전문기관에 미생물의 기탁·분양, 선행기술의 조사, 특허분류의 부여, 그 밖에 대통령령으로 정하는 업무를 의뢰할 수 있으며, 업무를 효과적으로 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 대통령령으로 정하는 전담기관으로 하여금 전문기관 업무에 대한 관리 및 평가에 관한 업무를 대행하게 할 수 있다(法 58①③). 지식재산처장이 의뢰하는 업무를 수행하려는 자는 지식재산처장에게 전문기관의 등록을 하여야 한다(法 58②).¹⁾ 지식재산처장은 특허출원의 심사에 필요하다고 인정하는 경우에는 관계 행정기관, 해당 기술 분야의 전문기관 또는 특허에 관한 지식과 경험이 풍부한 사람에게 협조를 요청하거나 의견을 들을 수 있다. 이 경우 지식재산처장은 예산의 범위에서 수당 또는 비용을 지급할 수 있다(法 58④).

2. 전문기관 등록의 취소 등

지식재산처장은 전문기관이 i) 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우에는 전문기관의 등록을 취소하여야 하며, ii) 등록기준에 맞지 아니하게 되거나 iii) 전문기관의 임직원이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 그 등록을 취소하거나 6개월 이내의 기간을 정하여 업무의 정지를 명할 수 있다. 한편 지식재산처장은 전문기관의 등록을 취소하거나 업무정지를 명하려면 청문을 하여야 한다(法 58의2①②).

1) 기존에는 전문기관의 지정제(허가제)를 운영하였으나 이권 개입의 여지가 있어서 2017. 6. 3 시행된 현행법(법률 제14371호, 2016. 12. 2, 일부개정)에서는 등록제로 변경하였다.

제3장

심사의 청구

제1절 심사청구제도

제59조 【특허출원심사의 청구】

- ① 특허출원에 대하여 심사청구가 있을 때에만 이를 심사한다.
- ② 누구든지 특허출원에 대하여 특허출원일부터 3년 이내에 지식재산처장에게 출원심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 특허출원인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원심사의 청구를 할 수 없다.
〈개정 2016.2.29〉
 1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우
 2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)
- ③ 제34조 및 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관하여는 제2항에 따른 기간이 지난 후에도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날, 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 각각 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다. 〈개정 2021. 10. 19〉
- ④ 출원심사의 청구는 취하할 수 없다.
- ⑤ 제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간에 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

제60조 【출원심사의 청구절차】

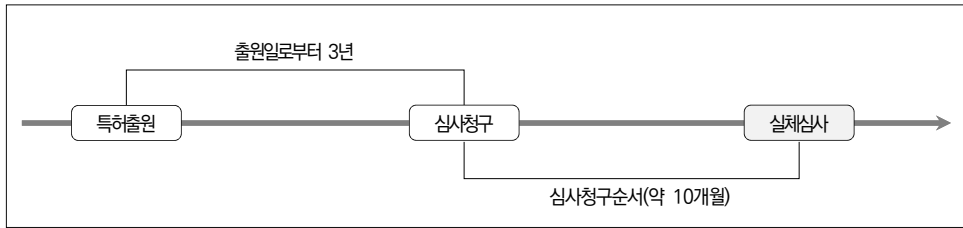
- ① 출원심사의 청구를 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 출원심사청구서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
 1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시
- ② 지식재산처장은 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있으면 출원공개 시에, 출원공개 후에 출원심사의 청구가 있으면 지체 없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다.
- ③ 지식재산처장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있으면 그 취지를 특허출원인에게 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

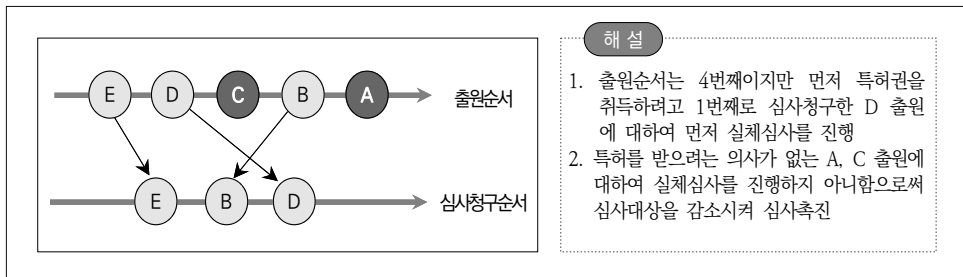
「심사청구제도」란 출원과 심사를 분리하여 출원일로부터 3년 이내에 심사청구가 있는 특허출원에 대하여만 심사청구의 순서에 따라 심사하는 제도를 말한다(法 59). 심사청구제도는 종래의 전통적 심사주의를 수정보완한 제도이다.



【그림 4-1】 심사청구제도 일반

2. 취 지

특허출원하는 목적과 발명의 경제적·기술적 가치가 동일하지 않다²⁾는 경험적 사실에 기초하여 특허권을 취득하려는 특허출원만을 선택적으로 심사함으로써 심사대상을 감소시켜 심사를 촉진하기 위해 심사청구제도를 두고 있다.



【그림 4-2】 심사청구제도의 취지

II. 심사청구의 요건

1. 심사청구인

(1) 원 칙

1) 누구든지 심사청구를 할 수 있다(法 59②본문). i) 특허출원에 관련된 기술을 실시하려는 자는 그 특허출원의 등록여부에 대하여 지대한 관심이 있는데 출원인이 심사청구할 때까지 기

2) 특허출원 중에는 i) 출원 당초에는 장래 활용되리라는 예상 하에 권리취득을 목적으로 출원하였으나 그 후 발명에 신규성이 없고 실시가치가 없다는 것이 판명된 것 등 출원인이 도중에 독점권을 취득하거나 출원을 지속시킬 자신과 열의를 상실한 것(오산적 출원), ii) 발명이 기본적으로 그 실시화에는 상당기간이 필요하므로 권리화를 서두를 필요가 없는 것(기본적 출원), iii) 발명이 극히 유행에 민감한 것이기 때문에 권리화를 서두를 필요가 있는 것(유행적 출원) 등이 혼재되어 있다.

다리게 하는 것은 불합리하고 ii) 심사청구는 단순한 실체심사의 개시요건에 지나지 않으므로 제3자에게 심사청구권을 인정하였다고 하여 당사자의 지위를 인정하는 것은 아니기 때문이다.

2) 공동출원인이 있는 경우에는 각자가 심사청구할 수 있으며(法 11), 임의대리인은 특별히 권한을 위임받지 않더라도 이를 행할 수 있다(法 6). 한편 법인 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 심사청구를 할 수 있다(法 4).

(2) 예 외

특허출원인은 i) 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우 또는 ii) 국어번역문(法 42의3②)을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)에 해당하는 경우에는 출원심사의 청구를 할 수 없다(法 59②단서). 출원인이 심사청구를 한다는 것은 현재까지의 청구범위에 의하여 실체심사를 해 달라는 취지인데, 청구범위를 적지 아니하거나 외국어특허출원의 번역문을 제출하지 않았다면 실체심사의 대상인 청구범위가 확정되지 않았기 때문에 심사청구를 제한하고 있다.

2. 심사청구대상

특허출원의 심사청구를 할 때 출원발명이 지식재산처에 적법하게 「출원 계속 중」이어야 한다(法 59②본문). 즉 출원이 취하·포기 또는 무효된 경우에는 심사청구의 대상이 될 수 없다. 한편 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 국내우선권주장출원은 원출원 또는 선출원과는 별개의 독립된 출원이므로 새로이 심사청구를 하여야 한다.

3. 심사청구기간

(1) 원 칙

특허출원에 관한 심사의 청구는 특허출원일로부터 3년 이내에 할 수 있다(法 59②본문). 출원인의 입장에서 보면 기술적·경제적으로 무가치한 출원에 대한 심사청구를 억제할 수 있는 충분한 고려기간이 필요하다. 그러나 그 심사청구기간을 너무 장기로 하게 되면 출원발명의 등록여부가 불확실해지게 되어 산업계의 불안정한 상태가 장기간 계속되는 문제점이 있으므로 출원일로부터 3년으로 규정하고 있다.³⁾⁴⁾ 따라서 출원인은 라이프 사이클이 짧은 기술과 관련된 발명에 대해서는 심사청구를 하여 조기에 특허권을 확보해야 하겠지만, 중장기적인 사업과 관련된 발명에 대해서는 심사청구시기를 늦출 필요가 있다. 시간의 경과에 따라 자사·타사의 연구개발 상황이나 그 기술 분야 전체의 장래성 등의 정보가 갱신되기 때문이다. 또한 심사청구를 하여 실체심사 결과 특허등록이 되면 청구범위가 확정되어 보정을 통한 권리범위를 재설계할 기회를 상실하게 되고, 특허료 등의 특허비용이 증가할 수 있다는 것을 고려해야 한다.

3) 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 536면.

4) 기존에는 특허출원일로부터 5년 이내 심사청구를 할 수 있었으나, 2017. 3. 1. 시행된 현행법(법률 제14035호, 2016. 2. 29. 개정)에서는 국제적 추세에 부응하기 위해 심사청구기간을 특허출원일로부터 3년으로 개정하였다.

(2) 예 외

① 정당한 권리자의 출원

무권리자의 특허출원·특허에 대한 정당한 권리자의 특허출원의 경우 심사청구기간은 무권리자의 출원일의 다음 날부터 기산한다(法 34, 35). 다만 정당한 권리자의 특허출원이 무권리자의 출원일로부터 3년의 기간이 지난 후라도 정당한 권리자가 특허출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다(法 59③). 즉 정당한 권리자 특허출원의 심사청구기간은 무권리자 출원일로부터 3년과 정당한 권리자 출원일로부터 30일 중 늦은 날까지이다. 이 규정은 무권리자 출원의 출원일로부터 3년을 지난 후에 정당한 권리자 특허출원이 된 경우 정당한 권리자 특허출원의 소급효로 인해 심사청구기간이 지났다고 하여 심사청구를 할 수 없다고 하는 것은 불합리하므로 정당한 권리자 특허출원에 대하여 심사청구를 할 수 있는 기회를 부여하기 위한 것이다.

② 분할출원·분리출원·변경출원의 경우

분할출원, 분리출원 또는 변경출원의 심사청구기간은 원출원일의 다음 날부터 기산한다(法 52②, 52의2②, 53②). 다만 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관하여는 원출원일로부터 3년의 기간이 지난 후라도 분할출원을 한 날, 분리출원을 한 날 또는 변경출원을 한 날부터 30일 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있다(法 59③). 즉 분할출원, 분리출원 또는 변경출원의 심사청구기간은 원출원일로부터 3년과 분할출원, 분리출원 또는 변경출원일로부터 30일 중 늦은 날까지이다. 입법취지는 앞서 설명한 정당한 권리자의 출원과 같다.

③ 조약우선권주장출원·국내우선권주장출원의 경우

조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원의 경우 출원인의 이익을 위해 심사청구기간의 판단시점이 선출원일로 소급되지 않기 때문에 심사청구기간은 우선권주장출원일의 다음 날부터 기산된다(法 54①, 55③).

Ⅲ. 심사청구의 절차

1. 심사청구서의 제출

출원심사의 청구를 하려는 자는 다음 사항을 적은 출원심사 청구서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 60①). 다만 특허출원과 동시에 출원심사청구를 하는 경우(청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 경우로 한정한다)에는 출원서에 그 취지를 기재함으로써 그 심사청구서에 갈음할 수 있다(施規 37①).

- i) 청구인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭·영업소의 소재지)
- ii) 출원심사의 청구대상이 되는 특허출원의 표시

2. 심사청구료의 납부

(1) 일반적인 경우

심사청구를 하는 자는 독립항과 종속항을 불문하고 청구항 수별로 심사청구료를 내야 한다. 이는 심사관이 출원발명의 청구항별로 거절이유에 해당하는지 심사하기 때문이다.

(2) 보정에 의한 청구항 수의 변화

출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구범위에 적은 청구항의 수가 증가한 때에는 그 증가한 청구항에 관하여 내야 할 심사청구료는 출원인이 내야 한다(法 82②).⁵⁾ 이때 지식재산처장은 심사청구료를 내지 아니하여 보정 명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 심사청구료를 내지 아니하면 특허출원서에 첨부한 명세서에 관한 보정을 무효로 할 수 있다(法 16①단서).

3. 심사청구사실의 게재

지식재산처장은 i) 출원공개 전에 출원심사의 청구가 있으면 출원공개 시에, ii) 출원공개 후에 출원심사의 청구가 있으면 지체없이 그 취지를 특허공보에 게재하여야 한다(法 60②). 이는 무용한 중복심사청구를 막기 위함이다.

4. 심사청구사실의 통지

(1) 취지 통지

지식재산처장은 특허출원인이 아닌 자로부터 출원심사의 청구가 있으면 그 취지를 특허출원인에게 통지하여야 한다(法 60③). 이는 출원인에게 그 심사절차에 관한 준비기간을 주기 위함이다.

(2) 청구범위의 보정

청구범위를 적지 아니하고 특허출원을 한 경우에 출원인은 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월 이전에 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 하며(法 42의2②단서), 출원인이 보정하지 아니하면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(法 42의2③).

(3) 국어번역문의 제출

외국어특허출원을 한 경우에 출원인은 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개

5) 심사청구 후 보정에 의하여 청구항이 증가된 경우(새로운 청구항이 신설되거나 삭제되었던 청구항에 '정정' 형식으로 발명을 적어 그 항에 대한 심사청구료가 추가된 경우를 말한다)에는 증가된 청구항에 대해서는 출원인이 심사청구료를 내야 하며, 청구항이 삭제된 경우에는 이미 납부된 심사청구료는 반환하지 아니한다.

월이 되는 날 이전에 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날
부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날
중 빠른 날까지 제출하여야 국어번역문을 제출하여야 하며(法 42의3②단서), 출원인이 국어번
역문을 제출하지 아니하면 그 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취한 것으로 본
다(法 42의3④).

IV. 심사청구의 효과

1. 심사청구가 있는 경우

(1) 심사의 진행

심사청구가 있으면 심사청구의 순서에 따라 특허출원에 대하여 실제심사가 이루어진다(法
59①, 施規 38①). 다만 i) 심사청구된 특허출원을 분할출원, 분리출원, 변경출원하여 심사청
구한 경우에는 지식재산처장이 정하는 바에 따라 심사하며(施規 38②)⑥, ii) 제61조에 의한
우선심사의 대상인 경우 그 예외를 인정하여 해당 심사청구순서보다 먼저 심사한다.

(2) 심사청구의 취하금지

출원심사의 청구는 취하할 수 없다(法 59④). i) 지식재산처의 입장에서 보면 출원심사청구의
취하를 인정하면 재청구를 인정할 것인가 여부, 그때까지 한 심사는 어떻게 취급할 것인가 등
심사절차나 그 절차의 결과가 복잡해지는 등의 문제가 생기기 때문이다. 또한 ii) 출원인의 입
장에서 보면 출원발명에 대하여 특허를 받을 수 없다고 판단되는 경우 굳이 출원심사의 청구를
취하할 것이 아니라 특허출원에 대한 특허여부결정의 확정 전까지 그 특허출원을 취하함으로써
출원심사청구의 취하와 같은 목적을 달성할 수 있기 때문이다.

2. 심사청구가 없는 경우

(1) 취하간주

출원심사의 청구를 할 수 있는 기간에 출원심사의 청구가 없으면 그 특허출원은 취하한 것
으로 본다(法 59⑤). 이는 심사청구를 할 수 있는 기간에 심사청구가 없는 출원에 대해서는
출원인이 더 이상 특허를 받으려고 하는 의사가 없는 것으로 인식하고 정리하고자 함이다. 특
허출원이 취하간주되는 경우 선출원의 지위가 없어지지만, 일반적으로 지식재산처장에 의하여

6) 구시행규칙(산업통상자원부령 제579호, 2024. 10. 31. 개정된 시행규칙 이전)에서는 원출원의 심사청구순
위에 따라 심사를 진행하였으나, 현행시행규칙에서는 심사순서를 탄력적으로 운영하여 변동하는 심사환경에
대응하기 위하여 지식재산처장이 정하는 순서에 따라 심사하도록 하고 있다. 현재 심사사무취급규정 제20
조에 따르면 분할출원은 분할출원의 심사청구순위에 따라, 분리출원, 변경출원은 원출원의 심사청구순위에
따라 심사를 하고 있다.

특허출원이 공개되므로 동일한 발명을 후출원할 때는 신규성(法 29①각호)이나 확대된 선출원(法 29③④) 위반으로 특허를 받지 못할 것이다.

(2) 불수리

지식재산처장은 i) 심사청구할 수 있는 기간을 지나서 심사청구한 경우, 출원인이 ii) 명세서에 청구범위를 적지 아니하고 심사청구하거나 iii) 외국어특허출원인데 국어번역문을 제출하지 아니하고 심사청구한 경우 소명기회를 주고 소명하지 않거나 소명이 적법하지 아니하면 심사청구서를 불수리하여야 한다(施規 11).

V. 관련문제

1. 심사청구와 관련제도

(1) 출원공개제도

심사청구와 관계없이 출원발명을 일정 기간이 지난 후에 출원공개하여 제3자의 중복투자 및 중복연구를 방지함으로써 심사주의의 단점을 보완해 주고 있다(法 64①).

(2) 확대된 선출원

선출원의 심사청구가 지연되어도 선출원의 공개를 요건으로 선출원의 지위를 청구범위로부터 최초 명세서 또는 도면의 범위로 확대하여 먼저 심사청구한 후출원의 심사를 신속히 진행함으로써 심사청구제도를 효율적으로 운용할 수 있도록 하고 있다(法 29③④).

2. 특허출원의 회복

특허출원인이 정당한 사유로 출원심사청구를 할 수 있는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구를 할 수 있고, 이 경우 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 본다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다(法 67의3). 2013. 3. 22. 시행된 현행법(법률 제 11654호, 2013. 3. 22. 개정)에서는 출원인의 권리보호를 강화하는 한편 향후 가입할 특허법 조약과의 합치를 도모하기 위해 이 규정을 신설하였다.

3. 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장

특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다(法 92의2).

4. 국제특허출원의 특례

(1) 출원심사청구시기의 제한

1) 국제특허출원의 출원인은 제201조제1항에 따라 국어번역문(국어로 출원된 국제특허출원의 경우는 제외한다) 및 제82조제1항에 따라 수수료를 낸 후라면 국내서면제출기간 만료일 전이라도 그 국제특허출원에 대하여 출원심사를 청구할 수 있다(法 210 I). 수수료 납부와 국어번역문 제출은 대한민국 지식재산처에서 최소한 심사를 받기 위한 요건이기 때문에 이를 만족한 후 출원인이 심사청구할 수 있도록 시기적 제한을 두고 있다.

2) 한편 국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 국내서면제출기간(제201조제1항 각호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다)이 지난 후에 그 국제특허출원에 대하여 출원심사를 청구할 수 있다(法 210 II). 즉 국제특허출원의 경우 출원인이 아닌 자가 심사청구할 수 있는 시기는 국내서면제출기간이 지난 후 「국제출원일」로부터 3년 이내이다. 국내서면제출기간에 심사청구를 하면 심사대상인 국어번역문이 확정되어 국어번역문을 교체할 수 없는데, 국제특허출원의 출원인 아닌 자가 심사청구를 하여 국어번역문을 교체할 수 없는 것은 출원인에게 불측의 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

(2) 출원심사청구의 효과

국내서면제출기간 전 출원심사청구를 한 경우에 국제특허출원의 발명의 설명·청구범위·도면 및 요약서의 최종 국어번역문은 확정된다. 국어번역문이 확정된 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다(法 201⑤). 즉 심사관은 최종 국어번역문에 의하여 국제특허출원을 심사하게 된다.

제2절 우선심사제도

제61조 【우선심사】

지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사하게 할 수 있다.

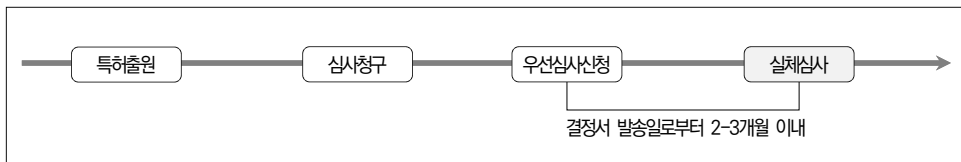
1. 제64조에 따른 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업(業)으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우
2. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우
3. 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「우선심사」란 심사청구된 특허출원 중에서 i) 출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우, ii) 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우 또는 iii) 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우에 해당되는 출원에 대해서 그 심사를 본래의 심사청구순위와 관계없이 우선하여 심사하는 것을 말한다(法 61).



【그림 4-3】 우선심사제도 일반

2. 취 지

심사청구순서에 따라 실체심사를 진행하는 심사청구제도(法 59①, 施規 38①)를 기계적으로 적용하면 심사의 진행이 늦어짐으로써 공공의 이익 및 출원인의 이익 보호⁷⁾가 미흡하게 되는 결과가 발생할 수 있으므로 우선적으로 심사하여 조기에 권리화가 가능하게 함에 우선심사제도의 의의가 있다. 다만 무분별한 우선심사신청을 막기 위해서 우선심사신청요건을 제한하고 있다.

II. 우선심사사유

1. 출원공개 후 제3자 무단실시의 경우(法 61 I)

출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우에는 우선심사를 신청할 수 있다. 여기서 「특허출원인이 아닌 자」는 특허출원인으로부터 출원발명에 관한 실시허락을 받지 아니한 자를 말하며, 「업」이란 개인적·가정적 실시를 제외한 실시를 말한다. 한편 「실시」란 제2조제3호의 실시로서 국내에서의 실시에 한정된다.

7) 출원발명에 대하여 제3자가 업으로서 실시하고 있는 경우에는 보상금청구권이 발생할 여지가 있지만 그 권리는 특허권 설정등록 후가 아니면 행사할 수 없으므로, 그 사이에 제3자의 모방에 따라 막대한 손해를 입게 되어 보상금청구권이 유명무실화되는 경우도 있다.

2. 대통령령(승 9①)으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우(法 61Ⅱ)⁸⁾

- ① 방위산업분야의 특허출원(「방위사업법」 제34조, 동법시행령 제39조, 동법시행규칙 제27조 및 동법시행규칙 제28조에서 규정하고 있는 방산물자 또는 그 제조방법에 관한 출원)
- ② 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 따른 녹색기술과 직접 관련된 특허출원
- ③ 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원
- ④ 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다)
- ⑤ 수출촉진에 직접 관련된 출원
- ⑥ 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원(고등교육법에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항에 따라 국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직에 의한 출원을 포함한다)
- ⑦ 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조에 따라 벤처기업의 확인을 받은 기업의 출원(출원된 발명이 벤처기업의 업종과 관련성이 있는 경우에 한정한다)

8) 한편 실용신안법의 경우에는 실용신안법 시행령 제5조에서 다음과 같이 특허법 시행령 제9조제1항에 대응하는 우선심사대상을 열거하고 있다. 특허법 시행령 제9조제1항과 비교하여 i) 특허법 시행령 제9조 제1항 제2호의 녹색기술[온실가스 감축기술, 에너지 이용 효율화 기술, 청정생산기술, 청정에너지 기술, 자원순환 및 친환경 기술(관련 융합기술을 포함한다) 등 사회·경제 활동의 전 과정에 걸쳐 에너지와 자원을 절약하고 효율적으로 사용하여 온실가스 및 오염물질의 배출을 최소화하는 기술을 말한다]와 직접 관련된 특허출원이 공해방지에 유용한 실용신안등록출원⁹⁾으로 바뀐 점, ii) 특허법 시행령 제9조제1항 제2호의2의 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원, 제2호의3의 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다), 제7호의2의 제198조의2에 따라 지식재산처가 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원, 제10호의 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원의 경우에는 실용신안법 시행령 제5조에 존재하지 않는 점에서 차이가 있다.

1. 방위산업분야의 실용신안등록출원
2. 공해방지에 유용한 실용신안등록출원
3. 수출촉진에 직접 관련된 실용신안등록출원
4. 국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 실용신안등록출원(「고등교육법」에 따른 국·공립학교의 직무에 관한 실용신안등록출원으로서 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조 1항에 따라 국·공립학교안에 설치된 기술이전 전담조직에 의한 실용신안등록출원을 포함한다)
5. 「벤처기업육성에 관한 특별법」 제25조에 따른 벤처기업의 확인을 받은 기업의 실용신안등록출원
6. 「중소기업기술혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 실용신안등록출원
- 6의2. 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 인증된 기업의 실용신안등록출원
- 6의3. 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 중소기업의 실용신안등록출원
7. 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 실용신안등록출원
8. 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 실용신안등록출원(그 실용신안등록출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 특허출원 또는 실용신안등록출원에 관한 절차가 진행중인 것에 한한다)
9. 실용신안등록출원인이 실용신안등록출원된 고안을 실시하고 있거나 실시준비중인 실용신안등록출원

- ⑧ 「중소기업 기술 혁신 촉진법」 제15조에 따라 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업의 특허출원(출원된 발명이 기술혁신형 중소기업의 업종과 관련성이 있는 경우에 한정한다)
- ⑨ 「발명진흥법」 제11조의2에 따라 직무발명보상 우수기업으로 인증된 기업(「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업 또는 「산업발전법」 제10조의2제1항에 따른 중견기업에 해당하는 경우에 한정한다)
- ⑩ 「발명진흥법」 제24조의2에 따라 지식재산 경영인증을 받은 기업의 특허출원
- ⑪ 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업의 결과물에 관한 특허출원
- ⑫ 조약에 의한 우선권주장의 기초가 되는 출원(당해 특허출원을 기초로 하는 우선권주장에 의하여 외국 특허담당 정부기관에서 특허에 관한 절차가 진행중인 것에 한정한다)
- ⑬ 제198조의2에 따라 지식재산처가 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원
- ⑭ 특허출원인이 업으로서 실시 중이거나 실시준비 중인 특허출원된 발명(다음 어느 하나에 해당하는 경우에도 출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 출원으로 본다.)
 - i) 「부품·소재전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법 시행규칙」 제6조의 규정에 의하여 부품·소재기술개발전문기업의 확인을 받은 기업의 출원(다만 출원된 발명이 부품·소재기술개발전문기업의 업종과 관련성이 있고, 최초 출원 시 출원인 중 적어도 1인이 부품·소재기술개발전문기업인 출원으로 한정한다.)
 - ii) 국가 또는 지방자치단체가 주최·주관한 공모전이나 경진대회에서 선정된 발명에 대한 출원(다만 국가 또는 지방자치단체로부터 출원이나 사업화 지원을 받은 출원으로 한정한다.)
- ⑮ 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원(다음의 어느 하나에 해당하는 특허출원)⁹⁾
 - i) 일본, 미국, 덴마크, 영국, 캐나다, 러시아, 핀란드, 독일, 스페인, 중국, 멕시코, 싱가포르, 헝가리 등의 대상국가(이하 “대상국가 등”이라 하고 정부 간 기구를 포함한다)에 출원한 특허출원의 출원일 또는 우선일 중 빠른 날(이하 “최우선일”이라 한다)과 대한민국 특허출원의 최우선일이 동일한 특허출원
 - ii) 대한민국, 미국, 중국, 일본, 오스트리아 등의 대상국가 등에서 국제조사나 국제예비심사가 수행된 국제출원의 국제출원일 또는 우선일 중 빠른 날과 대한민국 특허출원의 최우선일이 동일한 특허출원

3. 대통령령(승 9②)으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우(法 61Ⅲ)

9) 특허심사하이웨이(PPH)가 적용되는 경우는 다음과 같이 크게 8가지로 구분될 수 있다.

(1) 다음의 어느 하나에 해당하는 것으로서 지식재산처장이 정하여 고시하는 특허출원

- ① 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제21호에 따른 의료·방역 물품과 직접 관련된 특허출원
 - ② 「재난안전산업 진흥법」 제16조에 따라 인증을 받은 재난안전제품과 직접 관련된 특허출원
- (2) 재난으로 인한 긴급한 상황에 대응하기 위해 지식재산처장이 우선심사 신청 기간을 정해 공고한 대상에 해당하는 특허출원

1 특허받은 최초 특허출원을 기초로 대한민국에 조약에 의한 우선권을 주장한 특허출원	2 특허받은 상대국과 대한민국과의 국내단계에 모두 진입한 우선권 주장이 없는 국제출원
3 대한민국 선출원을 기초로 우선권을 주장하는 상대국 특허청에서 특허받은 경우 대한민국 특허청으로의 PPH 신청	4 제1국 선출원을 기초로 우선권을 주장하는 제2국 출원이 특허 받은 경우, 제1국 선출원을 기초로 우선권을 주장하는 대한민국 특허청에서 PPH 신청
5 대상국에서 국제조사나 국제예비심사가 수행되어 긍정적인 심사결과를 받고 대한민국의 국내단계에 진입한 국제출원	6 대상국에서 국제조사나 국제예비심사가 수행되어 긍정적인 심사결과를 받은 국제출원을 기초로 대한민국에 조약에 의한 우선권을 주장한 특허출원
7 대한민국 선출원을 기초로 우선권을 주장하는 대상국 특허청에서의 국제조사나 국제예비심사에서 긍정적인 심사결과를 받은 경우 대한민국 특허청으로의 PCT-PPH 신청	8 제1국 선출원을 기초로 우선권을 주장하는 제2국 특허청에서의 국제조사나 국제예비심사에서 긍정적인 심사결과를 받은 경우, 제1국 선출원을 기초로 우선권을 주장하는 대한민국 특허청에서 PCT-PPH 신청

4. 타법에서 규정하고 있는 경우

- ① 첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 내 의료연구개발과 관련한 특허출원
- ② 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 대한 규제특례법 제36조의8에 따라 규제특례가 적용된 특허사업과 직접 관련된 특허출원

Ⅲ. 우선심사신청요건

1. 신청인

누구든지 지식재산처장에게 특허출원에 관하여 우선심사를 신청할 수 있다. 다만 「국가 또는 지방자치단체의 직무에 관한 출원」에 대해서는 국가 또는 지방자치단체(국·공립학교 안에 설치된 기술이전·사업화 전담조직을 포함한다)만이 우선심사의 신청을 할 수 있다(특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시(지식재산처고시 제2023-29호) 3).

2. 신청대상

우선심사를 신청한 발명은 청구범위의 청구항에 기재되어 있어야 하며, 다수의 청구항이 있고 그 청구항 중의 하나가 우선심사대상으로 인정되면 출원 전체를 우선심사대상으로 인정한다. 우선심사 여부 결정은 우선심사결정 시까지 보정된 청구항을 기준으로 판단한다.

3. 신청시기

우선심사를 신청하기 위해서는 심사청구가 전제되어야 한다(法 59①). 또한 제61조제1호의 「출원공개 후 제3자 실시의 특허출원」은 다른 우선심사신청사유와는 달리 출원공개가 되어야만 우선심사를 신청할 수 있다. 한편 출원인은 심사청구를 하면서 동시에 우선심사신청을 할 수 있다. 다만 제61조제1호의 「출원공개 후 제3자 실시의 특허출원」은 우선심사신청일 전에 그 출원이 공개된 상태에서 제3자 실시가 있어야 하므로 조기공개신청과 동시에 우선심사를 신청할 수 없다.¹⁰⁾

10) 출원공개 전 제3자의 실시를 이유로 한 우선심사신청은 그 출원이 특허법 제64조 규정에 의한 공개가 되어 있지 않더라도 공개시기가 임박하거나(우선심사신청서를 이송 받은 날부터 15일 이내에 공개될 것으로 예상되는 출원), 출원인이 조기공개신청을 한 경우에는 우선심사신청을 각하하지 않고 우선심사 여부에 대한 결정을 보류한다. 우선심사 여부에 대한 결정을 보류한 후 조기공개신청을 취하는 등 조기에 공개되지 않기로 확정된 경우를 제외하고 그 출원이 공개되면 우선심사결정을 하고 심사를 진행한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 7408-7409면).

IV. 우선심사신청절차

1. 우선심사신청서의 제출

우선심사신청서에 우선심사신청설명서 및 증빙서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다(令 10①, 施規 39). 또한 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원을 제외하고는 출원된 발명에 관하여 직접 선행기술을 조사하고 그 결과를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.¹¹⁾ 한편 우선심사의 신청인은 지식재산처로부터 우선심사의 신청에 대한 접수번호를 부여받아 우선심사신청료를 국고수납은행에 내야 한다(특허·실용신안 우선심사의 신청에 관한 고시(지식재산처고시 제2023-29호) 5).

2. 우선심사 여부의 결정

(1) 방식심사 및 우선심사대상 적합 여부의 심사

우선심사신청서가 접수되면 지식재산처장은 방식심사를 하여 방식에 흠결이 없는 경우 우선심사대상 적합 여부를 심사한다(令 10②). 지식재산처장은 그 출원이 우선심사의 신청대상에 속하는지를 판단하기 어려운 경우에는 관계기관에 의견문의를 할 수 있으며 i) 우선심사의 신청대상이 아니라고 판단되거나, ii) 우선심사신청대상에 해당하는지가 제출된 서류만으로 불분명한 경우에는 1개월의 기간을 정하여 우선심사신청서를 보완할 것을 지시한다(특허·실용신안 심사사무취급규정 60, 61).

(2) 우선심사결정의 통보

1) 지식재산처장은 우선심사보완 지시기간이 지난 후 제출된 보완서류에 의해서도 보완사항을 해소하지 못한 경우에는 우선심사의 신청을 각하하고, 우선심사신청인 및 출원인(출원인이 우선심사신청인이 아닌 경우에 한한다)에게 이를 통보하여야 한다(특허·실용신안 심사사무취급규정 62). 이 경우 심사관은 특허출원의 심사청구순에 따라 그 특허출원을 심사하면 된다. 한편 우선심사신청이 거부된다고 하더라도 i) 행정처분이 아닌 내부적인 사무관리상의 문제이며, ii) 특허출원의 심사를 거부하는 것이 아니므로 이에 대한 출원인의 불복은 허용되지 아니한다고 해석하고 있다.¹²⁾

11) 자체 선행기술조사 결과의 작성방법은 다음과 같다.

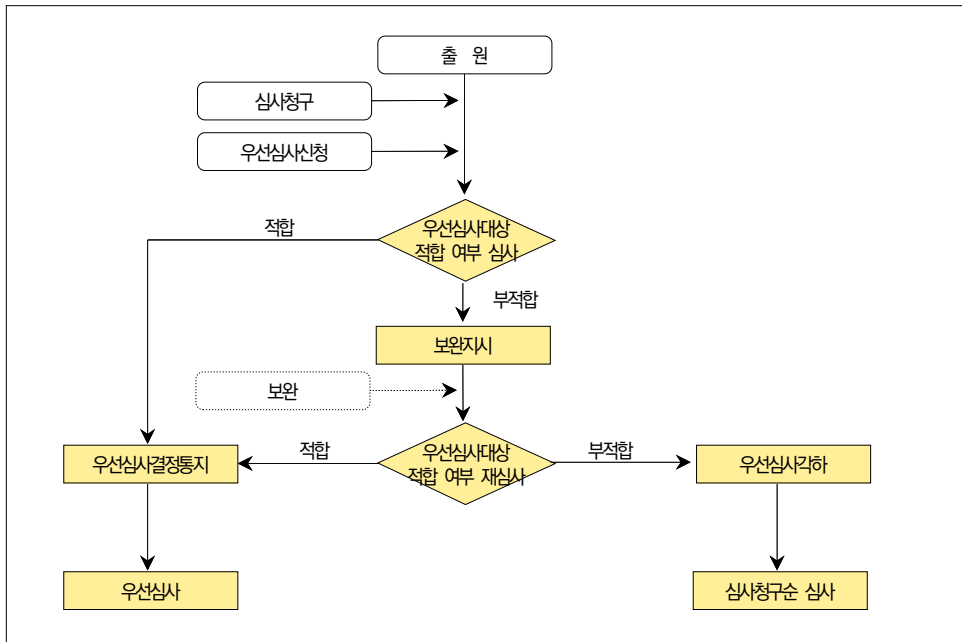
- ① 우선심사신청설명서에 선행기술의 검색방법, 검색결과 및 대비설명을 적는다.
- ② 선행기술의 검색방법에는 검색DB, 검색어, 검색IPC 등을 적는다.
- ③ 선행기술 검색결과에는 검색한 선행기술 문헌 중 출원 발명과 가장 근접한 선행기술문헌(4개 이상)을 순서대로 적는다.
- ④ 선행기술과의 대비설명에는 청구항별로 가장 근접한 선행기술문헌을 선정하여 유사점, 차이점 및 대비 판단을 구체적으로 적는다.

12) 제61조 및 동법 시행령 제9조에 의하면 지식재산처장은 출원공개 후 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 것으로서 대통령령으로 정하는 특허출원에 대해서는 심사관에게 다른 특허출원에 우선하여 심사

2) 지식재산처장은 그 특허출원이 우선심사의 대상에 해당하여 우선심사를 하기로 결정하였으면 즉시 우선심사신청인 및 출원인에게 그 사실을 통보하여야 한다.

(3) 수수료의 반환

우선심사신청의 각하 또는 우선심사신청이 방식심사 결과 무효처분되거나 불수리된 경우 우선심사신청료를 반환한다. 다만 무효처분되거나 불수리된 경우에는 우선심사신청료 전액을 반환하나 우선심사신청이 각하된 경우에는 우선심사신청료에서 우선심사 여부 결정비용을 제외한 금액을 반환한다.



【그림 4-4】 우선심사절차흐름도

하게 할 수 있다고 규정하고 있으며, 긴급하게 처리할 필요 여부에 관한 판단은 피청구인의 재량사항이라 할 것인바 이 건 발명보다 수년 전에 출원된 다수의 유사기술출원이 아직 심사를 기다리고 있는 점 등을 고려하여 피청구인의 이 건 처분이 재량을 일탈·남용하였거나 그 밖의 부당하게 처리하였다고 인정되지 아니하므로 이 건 처분이 위법·부당하다고 할 수 없다(통상산업부 재결 국행심 97-6054).

V. 우선심사결정의 효과

1. 우선심사

우선심사의 결정이 있으면, 그 출원에 대해서는 심사청구의 순위와 관계없이 우선적으로 심사에 착수한다. 이는 심사청구순서에 따라 실제심사를 진행하는 심사청구제도(法 59①, 施規 38①)에 대한 예외이다. 구체적으로 우선심사를 하기로 결정한 출원에 대한 심사는 일반적으로 우선심사결정서 발송일로부터 2개월(지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관의 장과 우선심사하기로 합의한 특허출원의 경우에는 3개월)까지 심사에 착수하여야 한다(특허·실용신안 심사사무취급규정 66①, 21①).

2. 신속한 권리구제 및 분쟁의 조속한 해결

우선심사로 인하여 조기에 권리가 부여되면 라이프 사이클이 짧고 기술발전이 빠른 발명에 대하여 신속한 권리구제를 할 수 있다. 또한 제3자가 출원발명을 무단실시하는 경우 조기에 등록 여부를 알 수 있어 출원인과 제3자 간의 분쟁을 조속히 해결할 수 있다.

제4장

심사의 진행

제1절 심사진행절차

제62조 【특허거절결정】

심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 “거절이유”라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다. <개정 2021. 10. 19.>

1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약을 위반한 경우
4. 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항에 따른 범위를 벗어나는 분리출원인 경우
7. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

[전문개정 2014.6.11.]

제63조 【거절이유통지】

① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>

1. 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우
2. 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우

② 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제63조의3【외국의 심사결과 제출명령】

심사관은 제54조에 따른 우선권 주장을 수반한 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 기간을 정하여 그 우선권 주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(그 심사결과가 없는 경우에는 그 취지를 적은 의견서를 말한다)를 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다.

[본조신설 2016.2.29.]

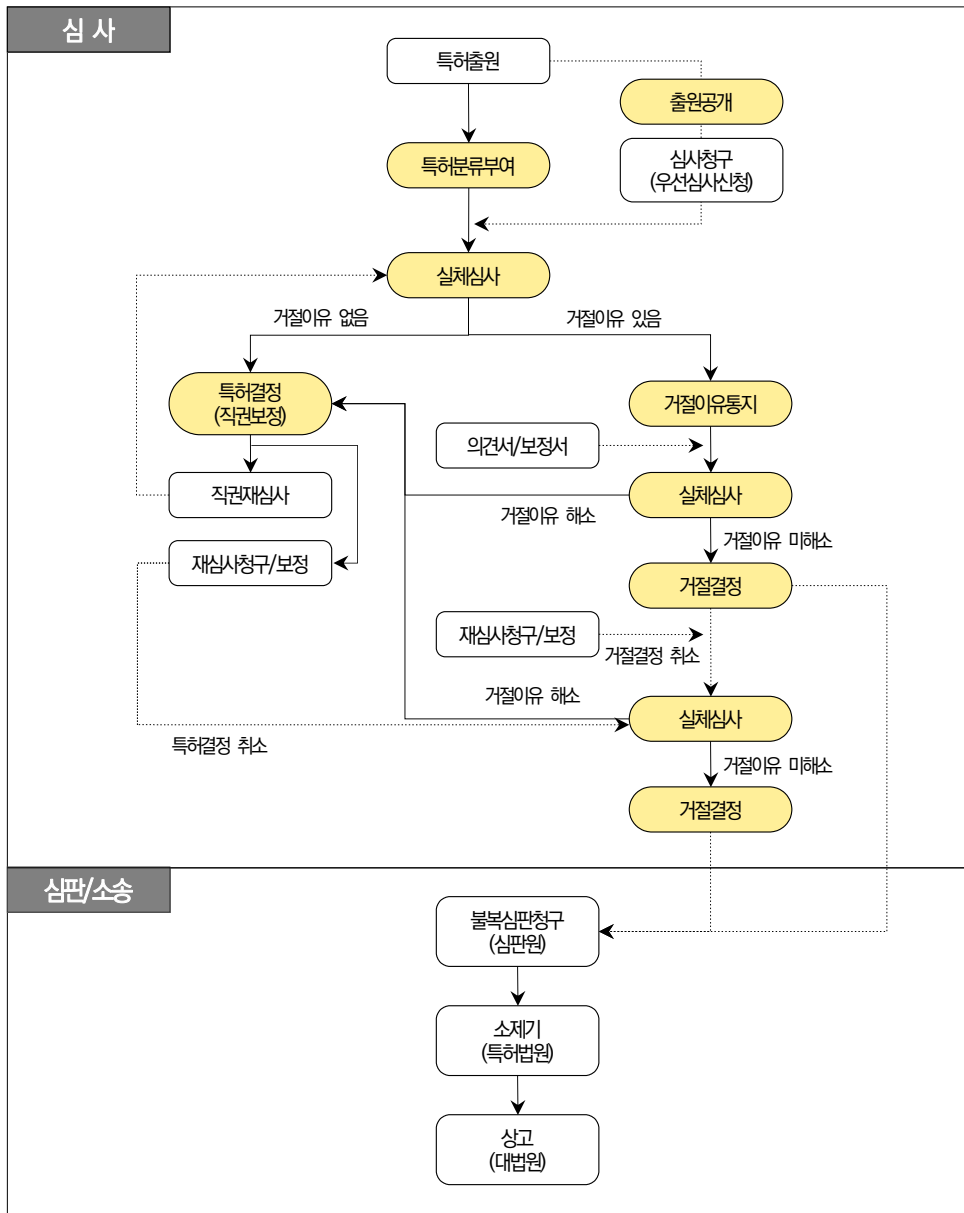
제78조 【심사 또는 소송절차의 중지】

① 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 특허취소신청에 대한 결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 심사절차를 중지할 수 있다. <개정 2016.2.29.>

② 법원은 소송에 필요한 경우에는 특허출원에 대한 특허여부결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 중지에는 불복할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]



【그림 4-5】 심사절차 일반

제1관 특허출원(출원서류의 접수 및 방식심사)

특허출원인이 특허출원서 등 출원에 관한 서류를 지식재산처에 제출하고 출원료를 납부하면, 지식재산처장은 출원된 서류에 대한 방식 및 절차가 적법한지를 판단하는 방식심사를 한다. 이러한 방식심사를 한 결과 i) 해당 출원의 방식이나 절차에 중대한 하자가 있거나 흠결이 있는 경우에는 지식재산처장은 해당 서류에 대하여 불수리처분을 하고(施規 11), 경미한 하자가 있어 보정이 가능한 경우에는 기간을 정하여 보정명령을 하게 된다(法 46). 반면 ii) 특허출원서 등 특허출원에 관한 서류가 적법하다고 판단되는 경우에는 그 출원에 대해서는 출원포대가 작성되고, 이후 해당 심사국으로 출원서류 및 출원포대를 목록과 함께 이송한다. 다만 출원인이 전자문서에 의하여 출원을 하는 경우에는 따로 출원포대를 작성하지는 않고 전자포대를 작성하게 되는데, 이 경우에는 컴퓨터에 의하여 자동으로 처리된다.

제2관 특허분류의 부여

I. 특허분류의 목적

지식재산처가 특허분류를 하는 목적은 i) 심사관의 심사담당분야를 정하는 기준을 제공함으로써 전문적인 심사를 가능하게 하고, ii) 특허문헌의 수집, 정리 및 검색의 수단으로 사용되어 특허문헌이 기술정보로 활용될 수 있게 하기 위함이다.

II. 특허분류의 종류

특허출원이 된 경우 지식재산처는 그 출원을 국제특허분류(International Patent Classification; IPC)¹³⁾와 선진특허분류(Cooperative Patent Classification; CPC)¹⁴⁾에 따라 분류한다.

13) 국제특허분류는 스트라스부르그 협정(strasbourg agreement concerning the international patent classification)에 따라 특허나 실용신안에 대한 통일된 분류체계의 채택을 통해 산업재산권 분야에서 더욱 긴밀한 국제적 협력을 확인하고 이 분야에서 각국의 법령을 조화시키는데 기여할 목적으로 채택되었다. 우리나라 지식재산처는 1948년부터 1979년까지는 일본특허분류를 참고한 한국특허분류(KPC:Korean Patent Classification)를 사용하여 오다가 1980년부터 국제특허분류(IPC: International Patent Classification) 제3판을 도입하여 사용하기 시작하여 현재 IPC 제7판을 사용하고 있는데 이러한 IPC 제7판은 우리나라뿐만 아니라 100여개국이 사용하고 있다.

14) 선진특허분류(CPC)는 국제특허분류(IPC)보다 세분화된 특허분류체계로서, 효율적인 선행기술조사를 위해 미국, 유럽특허청 주도로 2012년 개발되었고, 2015년 현재 전 세계 특허문헌의 약 71%가 선진특허분류(CPC)로 분류되고 있다. 우리나라는 2015년 1월 이후 신규출원에 대하여 국제특허분류(IPC), 선진특허분류(CPC)를 함께 하고 있다.

제3관 실체심사의 착수 및 진행

I. 심사관에 의한 심사

방식심사를 거치고 출원포대가 작성된 상태에서 출원인 또는 제3자의 심사청구가 있는 경우에는 지식재산처장은 그 출원의 실체심사를 담당할 심사관을 지정하고 이에 따라 실체심사가 시작되게 된다(法 57①). 한편 i) 일반 공중인 제3자는 정보제공을 통해 심사관을 보조하여 심사에 참여할 수 있으며, ii) 심판관은 거절결정불복심판의 경우 직접심사를 할 수 있는 경우¹⁵⁾가 있다.

II. 심사착수

1. 심사착수순서

특허출원에 대한 심사는 심사청구가 있는 출원에 대해서만 하며, 심사착수의 순서는 우선심사를 신청한 경우를 제외하고는 심사청구순서에 의한다. 다만 심사청구된 원출원을 분할출원, 분리출원, 변경출원하여 심사청구한 경우에는 지식재산처장이 정하는 순서에 따라 심사한다(施規 38).

2. 심사의 보류

(1) 동일발명에 대한 심사의 보류

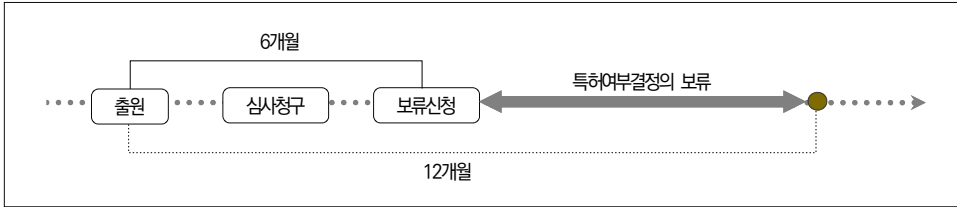
동일한 발명에 대하여 다른 날에 둘 이상의 특허출원이 있는 경우에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공개될 때까지 후출원의 심사를 보류하여야 한다(施規 40본문). 이는 후출원이 선출원에 의하여 확대된 선출원에 위반되기 위해서는 선출원이 출원공개 또는 등록공고됨을 요건으로 하고(法 29③④), 또한 심사관은 선출원이 출원공개 또는 설정등록될 때까지 비밀유지의무가 있기 때문이다(法 226). 다만 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 아니하다(施規 40단서).

(2) 특허여부결정의 보류

1) 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일로부터 6개월 이내에 결정 보류신청서를 지식재산처장에게 제출하는 경우에는 특허출원일로부터 12개월이 지나기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다(施規 40의2①본문). 이는 선출원 후 개량발명을 한 출원인에게 국내우선권주장출원을 할 수 있는 기회를 부여하기 위해서이다. 특허출원일로부터 12개월이 지나기 전에 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정되면 출원인이 조약우선권주장을 할 수는 있지만 국내우선권주장을 할 수 없다(法 55①Ⅳ).

15) 거절결정불복심판에서 심판관이 自判하는 경우에는 특허거절결정을 취소한 후에 특허심결을 할 수 있다.

2) 다만 i) 특허출원이 분리출원 또는 변경출원 및 우선심사의 결정이 있는 특허출원이거나, ii) 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서가 통지된 경우에는 특허여부결정을 보류할 수 없으며, 제출된 보류신청서는 불수리된다(施規 11, 40의2①단서).

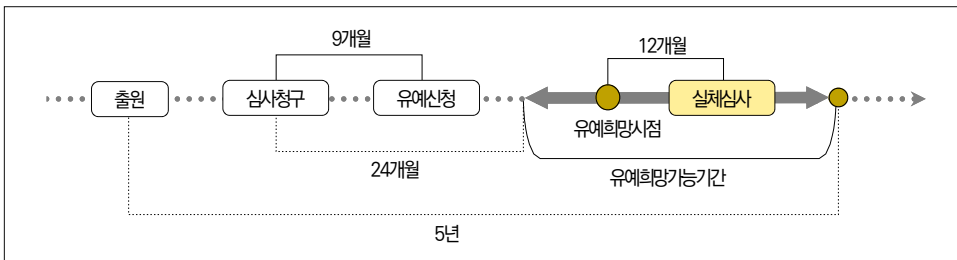


【그림 4-6】 특허여부결정의 보류

(3) 특허출원심사의 유예

① 심사유예신청

특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우로서 출원심사의 청구일부터 24개월이 지난 후에 특허출원에 대한 심사를 받으려면 출원심사의 청구일부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일부터 5년 이내에 한정하며, 이하 “유예희망시점”이라 한다)을 적은 심사유예신청서를 지식재산처장에게 제출할 수 있다. 다만 특허출원과 동시에 심사청구를 하면서 심사유예신청도 같이하는 경우에는 출원서에 그 취지 및 유예희망시점을 적음으로써 그 신청서를 갈음할 수 있으며, 심사청구와 동시에 심사유예신청을 하는 경우에는 심사청구서에 그 취지 및 유예희망시점을 적음으로써 그 신청서를 갈음할 수 있다(施規 40의3①).



【그림 4-7】 특허출원심사의 유예

② 변경 또는 취하

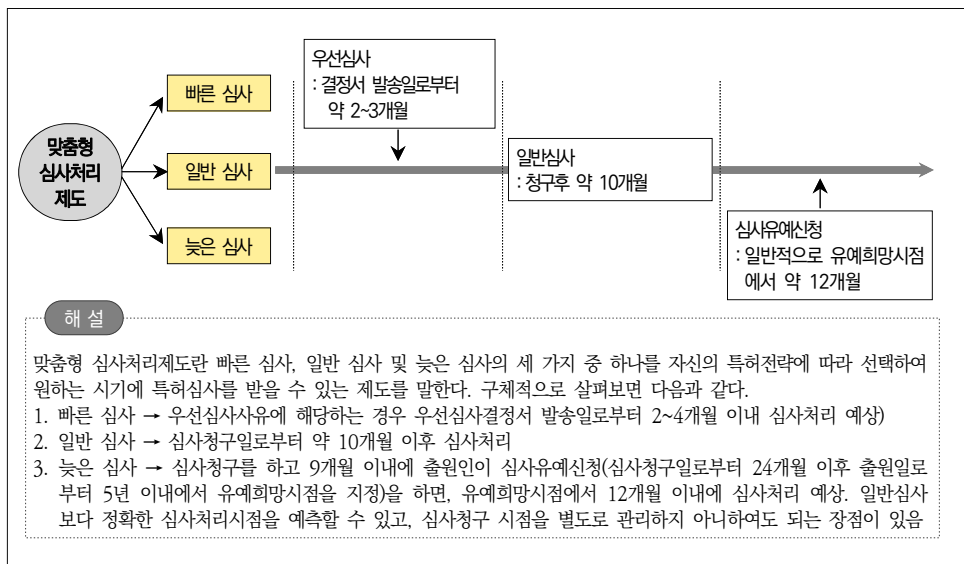
특허출원인이 심사유예신청을 취하하거나 유예희망시점을 변경하려면 심사유예신청서를 제출한 날부터 2개월 이내에 취하서 또는 보정서를 제출하여야 한다(施規 40의3②).

③ 결 정

심사관은 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다.¹⁶⁾ 다만 i) 특허출원이 분리출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우, ii) 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우 및 iii) 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하며, 제출된 유예신청서는 불수리된다(施規 11, 40의3③).

④ 심사청구료의 납부

심사청구와 동시에 특허출원심사 또는 실용신안등록출원심사의 유예를 신청한 경우에는 심사를 받으려는 시점으로부터 2개월 전까지 심사청구를 하였을 때의 심사청구료를 낼 수 있다(徵收規則 8④).

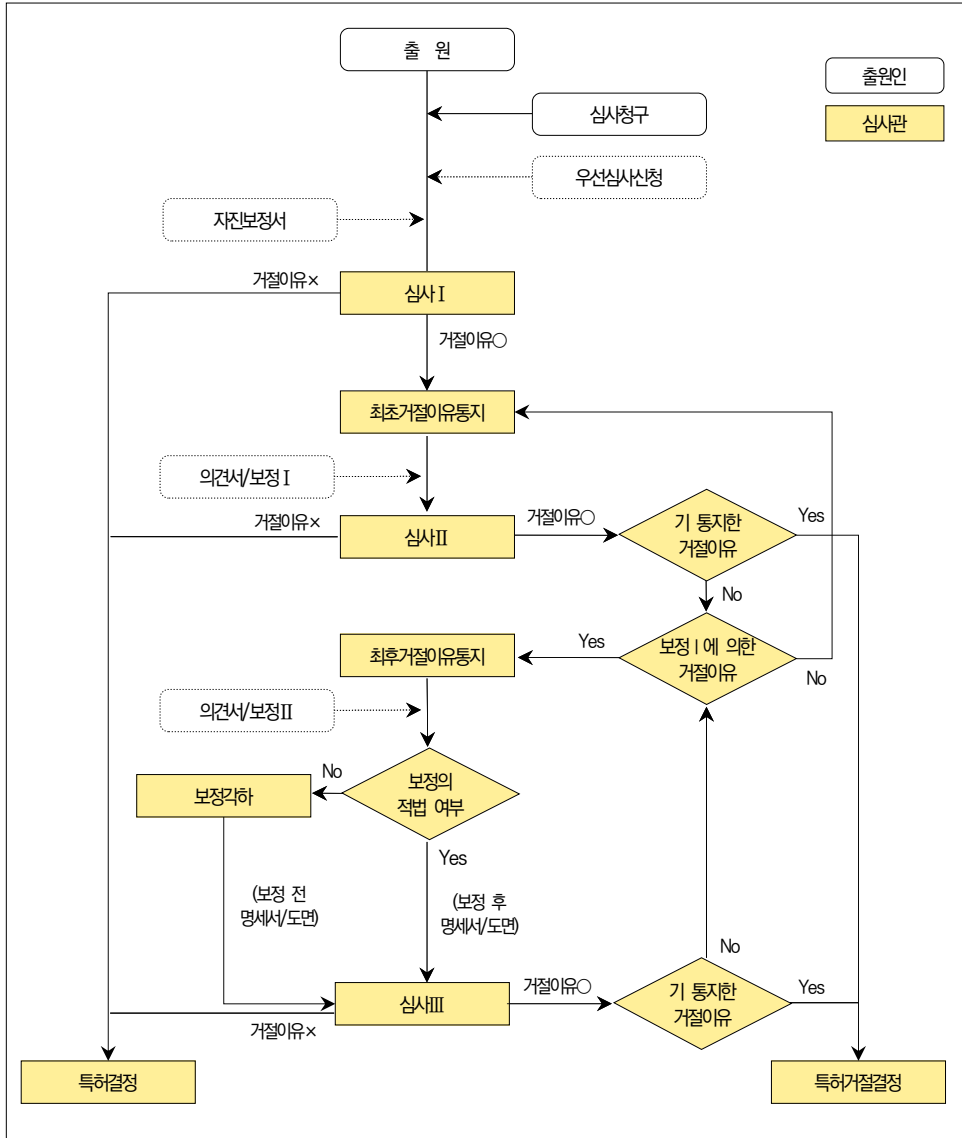


【그림 4-8】 맞춤형 심사처리제도

16) 심사유예신청이 있는 출원은 유예희망시점 또는 출원서류를 이송받은 날 중 늦은 날로부터 12개월이 되는 날이 속하는 달의 마지막 날(그 마지막 날이 특허법 제14조에 따른 공휴일이더라도 그 날)까지 심사에 착수하여야 한다(특허·실용신안 심사사무취급규정 21의2).

Ⅲ. 실체심사의 진행

1. 개략적인 흐름도



2. 흐름도의 설명

(1) 심사Ⅰ단계

출원인은 특허결정의 등본을 송달하기 전과 최초거절이유를 송달받기 전에 자진보정할 수 있다. 자진보정에 의하여 보정된 명세서 또는 도면을 심사하여 거절이유가 없는 경우 특허결정하고, 거절이유를 발견한 경우 최초거절이유를 통지한다.

(2) 심사Ⅱ단계

① 보정이 없는 경우

1) 보정이 없는 경우 의견서 등을 참조하여 최초거절이유통지서 발송시 심사한 명세서로 재심사한다. 그 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.

2) 거절이유가 있는 경우 i) 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지시 지적한 거절이유인 경우에는 거절이유를 해소하지 못하였으므로 특허거절결정하고, ii) 그 거절이유가 최초거절이유통지시 있었으나 지적하지 아니한 거절이유인 경우에는 최초거절이유를 다시 통지한다.

② 보정이 있는 경우

1) 보정이 있는 경우에는 의견서 등을 참조하여 보정내용을 반영한 보정 명세서로 재심사한다. 그 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.

2) 거절이유가 있는 경우 i) 그 거절이유 중 하나라도 최초거절이유통지시 지적한 거절이유인 경우에는 거절이유를 해소하지 못한 것으로 하여 특허거절결정하고, ii) 그 거절이유가 최초거절이유통지시 있었으나 지적하지 아니한 거절이유가 있는 경우 또는 보정 I에 따라 발생한 거절이유와 최초거절이유통지시 있었으나 지적하지 아니한 거절이유가 동시에 있는 경우에는 최초거절이유를 통지하며, iii) 그 거절이유가 보정 I에 따라 발생한 거절이유인 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

(3) 심사Ⅲ단계

① 보정이 없는 경우

1) 최후거절이유에 대응한 보정이 없는 경우에는 의견서 등을 참조하여 최후거절이유통지서 발송시 심사한 명세서로 재심사한다. 그 결과 거절이유가 없는 경우에는 특허결정한다.

2) 거절이유가 있는 경우에는 i) 그 거절이유 중 하나라도 최초 또는 최후거절이유통지시 지적한 거절이유인 경우에는 거절이유를 해소하지 못하였으므로 특허거절결정하고, ii) 그 거절이유가 최초거절이유통지시 있었으나 지적하지 아니한 거절이유이거나, 보정 I에 따라 발생한 거절이유나 최후거절이유통지시 지적하지 아니한 거절이유와 최초거절이유통지시 있었으나 지적하지 아니한 거절이유가 동시에 있는 경우에는 최초거절이유를 통지하며, iii) 그 거절이유가 보정 I에 따라 발생한 거절이유나 최후거절이유통지시 지적하지 아니한 거절이유인 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

② 보정이 있는 경우

1) 최후거절이유통지에 대한 보정이 있는 경우에는 보정요건을 판단하여 보정요건을 충족한 경우 보정II를 반영한 보정서로 재심사하며, 심사절차는 보정이 없는 경우의 심사와 같다.

2) 보정요건을 만족하지 못한 경우에는 보정서를 보정각하한다. 보정각하 후 심사는 최후거절이유통지 시 심사한 명세서로 심사하며, 심사절차는 보정이 없는 경우의 심사와 같다.

IV. 심사 또는 소송절차의 중지

특허출원의 심사에 있어서 필요한 경우에는 특허취소신청에 대한 결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 그 심사절차를 중지할 수 있다. 법원은 소송에 필요한 경우에는 특허출원에 대한 특허여부결정이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다. 심사절차나 소송절차의 중지에 대해서는 불복할 수 없다(法 78①②③).

제2절 거절이유 및 거절이유통지

I. 거절이유

1. 주체적 사유

- ① 외국인으로서 특허에 관한 권리를 누릴 수 없는 자가 특허출원한 경우(法 25)
- ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원한 경우(法 33①본문)
- ③ 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원이 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고 재직 중 특허출원한 경우(法 33①단서)
- ④ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공유자 모두가 공동으로 출원하지 아니한 경우(法 44)

2. 실체적 사유

- ① 특허요건(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성, 소위 확대된 선출원)에 위반된 경우(法 29)
- ② 특허를 받을 수 없는 발명에 해당하는 경우(法 32)
- ③ 선출원 규정(法 36①-③)을 위반한 경우
- ④ 일반적인 발명의 설명의 기재불비의 경우(法 42③1)
- ⑤ 청구범위 기재불비의 경우(法 42④)
- ⑥ 신규사항추가인 보정의 경우(法 47②)

1) 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(法 47②).

2) 외국어특허출원(외국어국제특허출원 포함)은 원문(외국어 명세서 또는 도면)과 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어난 보정을 하면 거절이유(法 62Ⅴ), 정보제공사유(法 63의2)이다. 다만 특허등록 후에는 제47조제2항전단의 원문의 범위를 벗어난 보정만 특허무효사유이다(法 133①Ⅵ). 국어번역문의 제출은 실제적인 문제라기보다는 심사관과 일반 공중이 정확한 내용을 알기 위한 절차적인 문제에 해당하기 때문에 원문 기준의 보정을 하였다면 국어번역문을 벗어났다고 할지라도 이를 굳이 무효로 시킬 이유가 없기 때문이다.

⑦ 분할출원의 범위를 벗어난 경우(法 52①)

⑧ 분리출원의 범위를 벗어난 경우(法 52의2①)

1) 분리출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다(法 52의2①각호 외의 부분 전단). 또한 분리출원의 청구범위에는 제52조의제1항 각호에 해당하는 특허가능한 청구항만을 적을 수 있다(法 52의2①후단).

2) 분리출원의 명세서 또는 도면의 요건을 만족하지 않거나(法 52의2①각호 외의 부분 전단 위반) 분리출원의 청구범위 요건을 만족하지 않은 경우(法 52의2①후단 위반) 거절이유(法 62Ⅵ), 정보제공사유(法 63의2)이다. 다만 등록 후에는 분리출원의 명세서 또는 도면의 요건을 만족하지 않은 경우(法 52의2①각호 외의 부분 전단 위반)에만 특허무효사유(法 133)이다. 분리출원의 청구범위 요건(法 52의2①후단)은 심사의 신속성을 위해 필요한 규정이어서 등록 후에는 이를 다룰 필요가 없기 때문이다.

⑨ 변경출원의 범위를 벗어난 경우(法 53①)

3. 조약 위반

특허제도의 국제화 경향에 따라 조약, 협정, 약정 등은 특허 실체법의 중요한 부분을 구성하고 있으므로 조약 등에 위반되는 경우를 거절이유로 하고 있다.

4. 절차적 사유

① 발명의 설명 중 배경기술의 기재 위반된 경우(法 42③Ⅱ)

② 청구범위 기재방법에 위반된 경우(法 42⑧)

③ 하나의 특허출원의 범위(法 45)에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우

【표 4-2】 거절이유, 정보제공사유, 특허무효사유 및 특허취소사유의 비교

요 건	내 용	거절이유	정보제공 사유	특허무효 사유	특허취소 사유
주체적	■ 외국인의 권리능력(法 25) ■ 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자(法 33①본문) ■ 특허를 받을 수 없는 자(法 33①단서) ■ 공동출원(法 44)	○	○	○*	
실체적	■ 산업상 이용가능성(法 29①본문) ■ 신규성(法 29①각호) ■ 진보성(法 29②) ■ 확대된 선출원(法 29③④⑤⑥⑦) ■ 선출원주의(法 36①②③)				○***
	■ 불특허발명(法 32) ■ 일반적 발명의 설명 기재(法 42③ I) ■ 청구범위 기재(法 42④) ■ 신규사항추가금지(法 47②) ■ 분할출원의 범위를 벗어난 경우(法 52①) ■ 분리출원의 범위를 벗어난 경우(法 52의2①) ■ 변경출원의 범위를 벗어난 경우(法 53①)	○	○	○**	
조약	■ 조약을 위반한 경우	○	○	○	
절차적	■ 발명의 설명 중 배경기술 기재(法 42③ II) ■ 다항제(法 42⑧) ■ 하나의 특허출원의 범위(法 45)	○			
후발적 무효사유	■ 특허 후 특허권자가 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반된 경우			○	

* 단, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자(法 33①본문) 위반과 공동출원(法 44) 위반은 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에 제외

** 단, 신규사항추가금지(法 47②)는 원문의 범위(法 47②전단)를 벗어난 경우, 분리출원(法 52의2)은 원출원의 최초 명세서 또는 도면의 범위를 벗어난 경우(法 52의2①각호 외의 부분 전단)에만 특허무효사유에 해당

*** 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)와 제36조 제1항 내지 제3항에 한하되, 등록특허공보에 게재된 선행기술을 기초로 하는 불가/심판 실무상 제29조제1항본문위반도 제외

II. 거절이유통지

1. 의 의

1) 심사관은 출원을 심사한 결과 그 출원이 거절이유(法 62각호)에 해당되어 특허를 허여할 수 없어 특허거절결정을 하려면 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 63① I). 이는 출원발명에 대하여 등록을 허용할 것인가에 대한 판단에는 고도의 전문지식을 요하고, 심사관이라 하여 그와 같은 지식을 두루 갖출 수는 없으므로 이로 인한 과오를 예방하기 위함이며, 또한 선출원주의 제도에서 야기되기 쉬운

과오를 보정할 기회도 주지 않고 곧바로 특허거절결정함은 출원인에게 지나치게 가혹하기 때문이다.¹⁷⁾

2) 또한 심사관은 직권 재심사(法 66의3①)를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절 이유로 특허거절결정을 하려는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 63①Ⅱ). 이는 심사관이 특허출원에 관하여 명백한 거절이유가 있음에도 불구하고 특허결정을 한 후 이를 취소하여 다시 심사를 진행할 때, 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유를 이유로 곧바로 거절결정하는 것은 출원인에게 가혹하기 때문이다.

3) 특허거절결정을 하기 전에 이러한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주는 것은 강행규정¹⁸⁾이며 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 된 특허거절결정에 대해서 출원인은 이를 이유로 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있다. 다만 보정각하결정(法 51①)을 하려는 경우에는 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하여도 된다(法 63①단서).

2. 거절이유의 종류

(1) 최초거절이유통지

1) 「최초거절이유통지」란 제63조에 따라 거절이유통지를 최초로 받거나 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 말한다. 「최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지」란 i) 특허출원한 발명에 원시적으로 거절이유가 존재하였는데 심사관이 간과한 후 나중에 이를 발견한 경우에 그 거절이유에 대한 거절이유통지, ii) 심사관이 직권 재심사를 하려고 특허출원인에게 특허결정을 취소한다는 사실을 통지한 경우에(法 66의3②) 그 통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지(法 47①Ⅱ괄호) 또는 iii) 거절결정불복심판에서 취소환송되었는데 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대한 거절이유통지를 말한다.

2) 심사 실무¹⁹⁾상 최초거절이유통지를 하는 구체적인 예는 다음과 같다

- i) 자진보정이 있었는지와 관계없이 심사가 착수된 이후 첫 번째의 거절이유통지인 경우
- ii) 보정되지 아니한 보정식별항목(특허법 시행규칙 별지 제9호서식 기재요령의 식별항목으로서 식별번호 등을 말한다. 이하 같다)에 거절이유가 있는 경우
- iii) 거절이유통지 후 보정된 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하는 거절이유라고 하더라도 그 거절이유가 보정에 의하여 발생한 것이 아니라 최초거절이유통지시에도 발명의 설명 또는 청구범위에 존재하던 거절이유인 경우²⁰⁾

17) 대법원 1997. 4. 11. 선고 96후1217.

18) 대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300; 1996. 11. 22. 선고 96후177 등

19) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 5333-5334면.

20) 구체적인 【예】는 다음과 같다.

- iv) 보정 외적인 요인에 의하여 거절이유가 발생한 경우²¹⁾
- v) 직권 재심사를 하려고 특허출원인에게 특허결정을 취소한다는 사실을 통지한 후 그 통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유를 발견한 경우
- vi) 거절결정불복심판에서 취소환송되었는데 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유를 발견한 경우

(2) 최후거절이유통지

1) 「최후거절이유통지」란 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 대한 거절이유통지를 말한다. 즉 거절이유통지에 대한 보정 전에는 존재하지 않았거나 심사할 필요가 없는 거절이유였으나 보정에 의해 새롭게 발생하였거나 심사할 필요가 생긴 거절이유에 대해서는 최후거절이유통지를 한다.²²⁾

2) 심사 실무²³⁾상 최후거절이유통지를 하는 구체적인 예는 다음과 같다.

- i) 명세서 또는 도면을 보정하여 신규사항이 추가된 경우, 기재불비가 새롭게 발생한 경우, 분할출원, 분리출원 또는 변경출원의 범위를 벗어나게 된 경우
- ii) 심사가 이루어진 청구항을 보정하여 새롭게 신규성, 진보성 등에 관한 거절이유를 통지하게 된 경우(다만 보정된 청구항의 발명이 그 청구항 외의 다른 청구항에 원래부터 기재되어 있던 발명이었음에도 해당 거절이유를 통지하지 않았던 경우에는 최초거절이유를 통지한다.²⁴⁾)
- iii) 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 바뀐 청구항에 신규성, 진보성의 거절이유

【예1】아래의 사례에서 심사관이 최초거절이유를 통지한 후 경미한 기재불비(명세서 등을 참고할 때 A'는 A가 되어야 할 것으로 인정)를 보정한 청구항에 대하여 다시 심사한 결과 구성요소 A+C로 된 장치에 관한 선행기술을 발견하여 거절이유를 통지하려는 경우, 이는 보정 전 청구항에 기재된 발명에도 존재했던 신규성 또는 진보성의 거절이유이므로 최초거절이유를 통지한다.

보정 전	보정 후
청구항 1: 구성요소 A' 또는 B에 C를 부가한 장치	청구항 1: 구성요소 A 또는 B에 C를 부가한 장치

【예2】하나의 청구항에 기재된 둘 이상의 발명 중 일부에 대하여만 거절이유를 통지하였다가 나머지 발명에 대하여 거절이유를 통지하는 경우 그 청구항이 거절이유통지에 따라 보정되었더라도 최초거절이유를 통지하여야 한다.

- 21) 예를 들어 심사에 착수하여 최초거절이유를 통지할 때에는 외국인으로서 권리능력에 관한 홈결이 없었으나 보정 이후 제25조에 따라 특허에 관한 권리를 누릴 수 없게 된 경우, 해당 거절이유는 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유가 아니므로 최초거절이유를 통지한다.
- 22) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5335면.
- 23) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5335-5336면.
- 24) 구체적인 【예】는 다음과 같다.

【예1】아래 사례에서 신규성 또는 진보성을 위반으로 거절이유를 통지한 청구항 1을 보정하여 종전의 신규성이나 진보성 거절이유를 해소하였으나, 구성 D를 부가함으로써 D를 포함하는 선행기술을 추가로 인용할 필요가 생겼다면 이는 보정에 의하여 발생한 거절이유이므로 최후거절이유를 통지한다. 만일 'A 및 B'라는 표현이 구성요소를 선택적으로 지칭 아니하여 발명의 구성이 불분명하다는 거절이유가 있었다면, 이는 구성 D를 부가한 것과 관계없이 보정 전 청구항에 존재하던 거절이유로서 보정에 의하여 발생한 거절이유가 아니므로 최후거절이유통지 대상이 아니다.

가 있는 경우(다만 그 청구항이 거절이유를 통지받지 아니한 청구항의 발명으로 보정된 경우에는 최초거절이유를 통지한다.)

- iv) 청구항 기재의 현저한 기재불비 또는 신규사항의 추가 등으로 신규성 또는 진보성 등과 관련된 심사가 불가능했던 청구항을 보정한 후 다시 심사한 결과 신규성이나 진보성에 관한 거절이유를 발견한 경우

3. 거절이유 종류의 선택

심사한 결과 발견한 거절이유 모두가 최후거절이유통지 대상인 경우만 최후거절이유를 통지하고, 그 외에는 최초거절이유를 통지한다. 한편 거절이유의 종류가 불분명한 경우에는 출원인의 보정 기회를 보장하기 위해 최초거절이유를 통지한다.²⁵⁾

4. 청구항별 통지

1) 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 거절이유를 통지할 때에는, 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고²⁶⁾ 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다(法 63②). 특허거절결정은 지식재산처의 처분으로서 이는 행정절차법 제23조에 따라 처분의 이유 및 근거를 제시하도록 규정되어 있으므로, 특허 심사에서도 구체적으로 거절이유 및 근거를 제시하여야 하나 심사 실무상 일부 그렇지 아니한 면이 있어 2007. 7. 1. 시행된 현행법(법률 제8197호, 2007. 1. 3. 개정)은 이를 구체적으로 명시하도록 하고 있다. 그 결과, 특허출원에 대한 심사품질을 개선하고, 출원인의 일부 청구항에 대한 권리 포기·보완 등 대응능력을 제고할 수 있게 되었다.

2) 거절이유를 통지할 때 인용대상의 경우 i) 우리나라의 특허공보나 실용신안등록공보, ii) 외국의 특허 명세서나 초록, iii) 국제특허출원에 대한 국제사무국이 발행한 공보, iv) 정기간행물, v) 부정기간행물 및 카탈로그, vi) 단행본 등을 간행물로 적을 수 있으며, 일부를 인용하는 경우에는 인용하는 면을 정확히 적는다.

보정 전	보정 후
청구항 1: 구성요소 A 및 B에 C를 부가한 장치	청구항 1: 구성요소 A 및 B에 D를 부가한 장치

【예2】 기재불비만으로 통지한 거절이유에 대한 보정으로 청구항이 확장됨으로써 신규성 또는 진보성의 거절이유가 발생한 경우 보정에 의하여 선행기술을 다시 찾아 심사하여야 하므로 그 거절이유가 같은 청구항 번호에 존재하는 거절이유라도 최후거절이유를 통지하여야 한다.

25) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5336면.

26) 청구범위는 발명의 설명에 적혀 있는 사항 중 보호를 받으려는 사항을 하나 이상의 항으로 명확하고 간결하게 적어야 한다'라고 규정하고 있는바, 이러한 다항제를 채택한 취지는 발명을 여러 각도에서 다면적으로 적어 발명을 충실히 보호할 수 있도록 하고, 발명자의 권리범위와 일반인의 자유기술영역과의 한계를 명확하게 구별하여 특허분쟁의 경우 특허침해 여부를 명확하고 신속하게 판단할 수 있도록 하기 위한 것으로서, 청구항은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 있어 각 청구항마다 특허요건을 구비하여야 하고, 심사도 청구항별로 행해지는 것이므로 거절이유를 통지하는 경우는 거절의 대상으로 되는 청구항을 구체적으로 특정하여야 한다(대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515).

5. 거절이유통지의 적법성

1) 거절이유통지서에 기재된 거절이유와 거절결정서에 기재된 거절결정의 이유는 주지가 부합하여야 한다. 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되지 아니하고, 출원인에게 그 거절이유에 대한 실질적인 의견서 제출 및 보정의 기회가 부여되었다고 볼 수 있을 정도로 그 취지와 이유가 명시되었는지 관점에서 판단하여야 한다. 구체적인 사례들을 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 다른 거절이유를 통지하고 거절결정해서는 안 된다. 일반적으로 법조문과 이를 뒷받침하는 사실이 중 하나라도 다르다면 다른 거절이유로 취급한다.

2) 거절이유통지가 어느 정도 추상적이나 개괄적으로 기재되어 있다고 하더라도 통상의 기술자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재되어 있으면 충분하다.²⁷⁾

3) 출원발명에 대하여 우선권주장의 불인정으로 거절이유가 생긴 경우에는 우선권주장의 불인정은 거절이유 일부를 구성하는 것이므로, 우선권주장이 인정되지 아니한다는 취지 및 그 이유를 거절이유통지서에 포함하여야 한다.²⁸⁾

4) 기통지한 거절이유에서 선행기술로 인용된 자료가 특허공보와 같이 하나의 기술에 관한 것이거나 여러 실시태양을 개시하고 있지만 동일 또는 밀접한 기술사상에 대한 문헌인 경우에는 그 문헌 전체에 대하여 거절이유통지가 있었다고 봄이 상당하므로, 추가적인 거절이유통지 없이 기통지한 거절이유에서 위 문헌 중 직접 인용하지 않았던 부분을 들어 바로 거절결정할 수 있다. 다만 그 인용된 자료가 서적 등과 같이 방대하거나 여러 개의 기술에 관한 기재가 있는 것인데, 거절이유통지에서는 그 중 일부 기술만을 사본하여 첨부하거나 적시한 경우라면 인용되지 않은 부분을 새로운 거절이유로 볼 여지가 있으므로, 가급적 다시 거절이유를 통지하여 출원인에게 의견제출할 기회를 부여하도록 한다.²⁹⁾

5) 진보성 위반을 이유로 한 거절이유에 기재된 주선행발명을 다른 선행발명으로 변경하는 경우에는, 일반적으로 출원발명과 공통점 및 차이점의 인정과 그러한 차이점을 극복하여 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지에 대한 판단 내용이 달라지므로, 출원인에게 이에 대하여 실질적으로 의견제출의 기회가 주어졌다고 볼 수 있는 등의 특별한 사정이 없는 한 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유에 해당한다.³⁰⁾

27) 대법원 1997. 4. 11. 선고 96후1217; 2008. 12. 24. 선고 2007후265 등.

28) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371. 대법판결은 우선권주장의 불인정으로 판단시점의 소급효가 인정되지 않아 선출원과 후출원 사이의 공지기술에 의하여 출원발명의 진보성 결여가 발생한 사안으로, 우선권주장의 불인정을 거절이유통지서에 명기하지 않았다면 출원인에게 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하였다고 할 수 없으므로 타당하지 않다고 판시하였다.

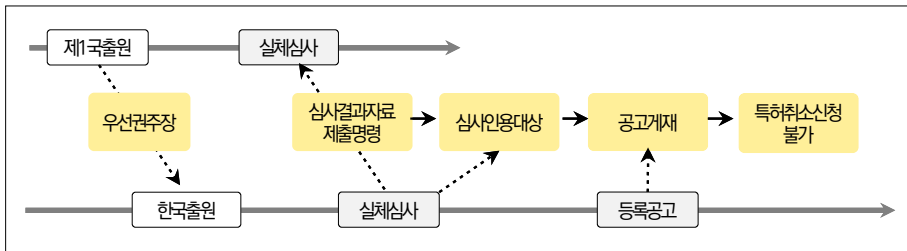
29) 특허법원 2011. 4. 27. 선고 2010허2612; 2012. 6. 20. 선고 2011허10306 참조.

30) 대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341. 이와 관련하여 개정된 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호), 5312면」에는 “출원발명의 각 구성요소가 공지된 근거로 제시되고 있는 선행기술문헌이 동일하고, 선행기술문헌으로부터 출원발명의 진보성을 판단하는 과정에서 필요한 전체사실(출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제 등), 판단의 중심이 되는 구성요소, 판단 내용(해결하여야 하는 기술적

6. 기 타

(1) 외국의 심사결과 제출명령

심사관은 조약우선권주장을 수반한 특허출원의 심사에 필요한 경우에는 기간을 정하여 그 우선권주장의 기초가 되는 출원을 한 국가의 심사결과에 대한 자료(그 심사결과가 없는 경우에는 그 취지를 적은 의견서를 말한다)를 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출할 것을 특허출원인에게 명할 수 있다(法 63의3). 이는 외국에의 심사결과에 대한 자료를 참조하여 심사의 효율성을 도모하기 위함이다. 한편 심사관이 거절이유를 통지할 때 외국에의 심사결과에 대한 자료를 참조하여 적은 선행기술에 대한 정보는 후에 특허등록되어 등록공고할 때 게재되고(法 87③Ⅶ), 이는 특허취소사유에서 제외된다(法 132의2②).



【그림 4-9】 외국의 심사결과 제출명령(法 63의3)

(2) 보정 또는 분할 등에 대한 시사

심사관은 거절이유통지시 출원인의 편의를 도모하고 신속·정확한 심사에 도움이 된다고 인정되는 경우에는 보정 또는 분할 등에 대한 시사(示唆)를 할 수 있다. 다만 이와 같은 시사가 법률적인 효과를 발생시키는 것은 아니며, 보정 또는 분할의 여부는 출원인의 의사에 의하여 결정되는 것이다.³¹⁾

(3) 거절이유통지서에 오기(誤記)가 있는 경우의 취급

거절이유통지서 중에 오기를 발견한 때에는 i) 출원인이 그 오기에 대하여 오기임을 판단하고 올바르게 해석하여 의견서를 제출한 경우, ii) 출원인으로부터 그 오기에 대하여 아무런 의견의 제시가 없거나 의견서가 제출된 경우, 또 그 오기가 심사관이 의도한 거절이유에 아무런 영향을 미치지 아니한 단순한 오·탈자 등 경미한 오기인 경우를 제외하고는 의견서 제출의 여부에 상관없이 다시 정당한 거절이유통지서를 하여야 한다.³²⁾

과제, 해결에 필요한 기술수단, 결합의 동기·암시 또는 장애요소 등)이 중요한 부분에 있어서 일치”하는 지에 따라 주지가 부합하는지 판단하고 있다.

31) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5320면.

(4) 명세서 또는 도면에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우의 취급

다른 거절이유를 통지할 때 명세서 또는 도면에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우이어서 직권보정(法 66의2)할 수 있는 사항이 포함되어 있다면, 명백히 잘못된 경우 중 사소한 오탃자인 것은「참고사항」으로 하여, 명백히 잘못된 기재불비에 해당하는 것은 「거절이유」에 포함하여 통지하되, 다른 거절이유가 없다면 전화 등 통신수단을 이용하여 자진보정을 유도하거나 직권보정을 할 수 있다.³³⁾

(5) 거절이유의 재통지

거절이유를 통지한 후 보정서 등을 반영하여 출원을 다시 심사한 결과 거절이유가 있고 그 거절이유가 이미 통지한 거절이유이면 다시 거절이유를 통지하지 않고 거절결정하는 것이 원칙이나, 출원인이 거절이유를 해소하기 위한 보정 의사 등을 명확히 표시하였는데 단지 그러한 보정이 보정서에서 누락된 것으로 보이면 일정요건하에서 동일한 거절이유를 다시 통지할 수 있다.³⁴⁾

제3절 거절이유통지를 받은 출원인의 대응방안

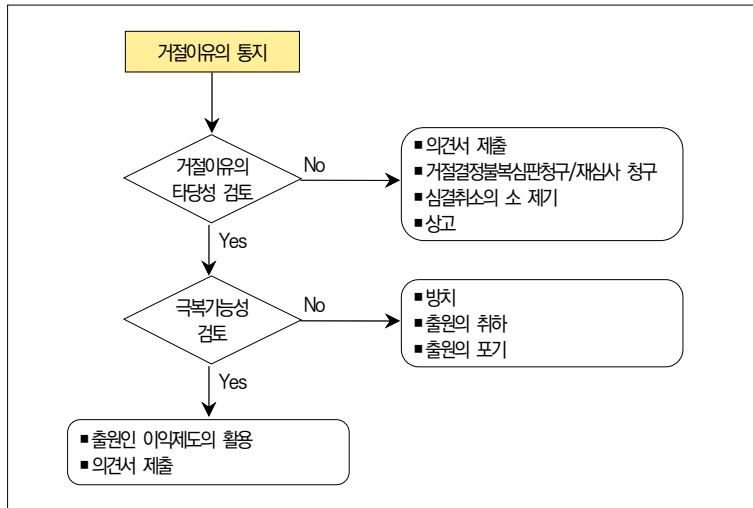
I. 서 설

거절이유는 제62조에 제한열거적으로 규정된 것으로서 특허출원한 발명이 특허를 받을 수 없는 이유이다. 심사관은 특허출원한 발명의 청구범위의 청구항별로 거절이유를 검토하지만, 일부 청구항의 거절이유가 극복되지 아니하면 특허출원한 발명 전체에 대하여 특허거절결정을 한다. 다만 심사관은 특허출원한 발명이 거절이유에 해당하면 특허거절결정을 하기 전에 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 이때 출원인은 거절이유의 타당성을 검토하고, 그 검토 결과에 따라 적절한 대응조치를 취할 수 있다.

32) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5320면.

33) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5320면.

34) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 8301면.



【그림 4-10】 거절이유통지를 받은 출원인의 대응방안

II. 거절이유의 타당성 검토

출원인은 거절이유통지에 대하여 구체적인 조치를 마련하기 전에 거절이유가 타당한지를 먼저 파악하여야 한다. 구체적으로 i) 출원발명에 거절이유가 존재하는지 여부, ii) 거절이유와 함께 제시된 인용대상이 적법하게 존재하는지 여부 또는 iii) 심사관의 법 적용에 착오가 없었는지 여부 등을 검토하여야 한다.

III. 거절이유가 타당하지 아니한 경우

1. 의견서 또는 보정서 제출

출원인은 거절이유가 타당하지 아니하면 타당하지 아니한 이유를 구체적으로 적은 의견서를 제출할 수 있다. 이때 필요한 경우 보정서를 함께 제출할 수도 있다. 거절이유가 타당하지 아니한데 보정서를 제출하는 것이 논리적으로 맞지 않다고 생각될 수 있으나 권리범위를 재설계 하거나 거절이유로 지적한 부분 이외의 부분에서 발명의 내용을 명확히 할 필요가 있는 경우 의견서와 함께 보정서를 제출하고 있다.

2. 특허거절결정에 대한 불복

특허거절결정을 받은 자가 이에 대하여 불복할 때는, 특허거절결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내 재심사 청구와 거절결정불복심판의 청구 중 어느 하나를 할 수 있으며(法 67의2, 132의17), 필요한 경우 분할출원, 변경출원을 할 수 있다. 한편 재심사단계에서 특허거절결정등본을 송달받으면 그 날로부터 3개월 이내 분할출원이나 거절결정불복심판을 청구할 수 있다.

3. 불복의 소 제기

출원인은 거절결정불복심판에서 기각심결을 받으면 심결등본송달일로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내 분리출원을 하거나 심결취소의 소를 특허법원에 제기할 수 있으며, 심결취소의 소에서 기각판결을 받으면 기각판결 송달일로부터 2주일 이내에 대법원에 상고할 수 있다.

IV. 거절이유가 타당한 경우

1. 극복가능한 경우

(1) 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 주장

출원인은 신규성(法 29①) 또는 진보성(法 29②) 위반으로 거절이유통지를 받았을 때 취지 및 증명서류를 제출하면서 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 주장을 할 수 있다. 다만 공지 등이 된 날로부터 12개월 이내에 출원한 경우에 한하고, 제30조제1항제1호의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 의한 공지는 제30조제1항제2호의 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반한 공지와 달리 보완수수료를 납부하여야 한다(法 30①③). 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 주장이 타당한 경우 심사관은 그 공지기술과 관련하여 신규성(法 29①) 또는 진보성(法 29②)을 판단해서는 아니 된다.

(2) 무권리자의 특허출원·특허에 대한 정당한 권리자의 주장

1) 출원인은 무권리자의 특허출원이나 특허로 인해 거절이유통지를 받았을 때 정당한 권리자의 주장을 하여 무권리자 출원의 출원일로 소급효를 인정받을 수 있다(法. 34, 35). 다만 정당한 권리자 출원이 무권리자 출원의 출원일로 소급되기 위해서는 정당한 권리자의 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 무권리자의 최초 명세서 또는 도면에 포함되어 있어야 하므로 동일성 판단을 전제로 하는 거절이유에 한한다. 즉 정당한 권리자의 주장은 특허출원이 무권리자의 출원 또는 공개로 인해 신규성(法 29①), 확대된 선출원(法 29③④), 선출원주의(法 36)에 위반되었다는 이유로 심사관으로부터 거절이유통지를 받았을 때 가능하다.

2) 정당한 권리자가 별도 출원을 하였지만, 무권리자의 특허출원을 승계하였다면 제33조제1항본문 위반이 해소된 것으로 보고 무권리자의 특허출원을 계속 진행하는 것을 인정하여 줄

필요가 있다. 무권리자의 특허출원에 대한 심사과정이 정당한 권리자가 특허를 받는데 유리한 상황이라면, 굳이 무권리자 출원을 거절시키고 정당한 권리자의 출원에 대한 심사과정을 반복할 필요가 없기 때문이다. 한편 제99조의2에 따른 이전청구에 의하여 정당한 권리자가 무권리자의 특허를 승계하였다면 무권리자의 특허는 특허무효사유에서 제외된다(法 133①Ⅱ단서). 이 경우 정당한 권리자는 그 출원을 취하, 포기하면 될 것이다.

(3) 보 정

출원인은 심사관이 지적한 거절이유를 극복하기 위해 보정할 수 있다. 예를 들어 신규성(法 29①) 또는 진보성(法 29②) 위반으로 거절이유통지를 받았을 때 청구범위를 삭제하거나 감축하는 보정 등을 통해 거절이유를 극복할 수 있을 것이다. 다만 최초거절이유통지를 받은 경우에는 의견서 제출기간에 신규사항추가금지(法 47②)에 위반되지 아니하는 범위에서 보정할 수 있으나, 최후거절이유통지를 받은 경우에는 의견서 제출기간에 신규사항추가금지(法 47②)에 위반되지 아니하는 물론이거니와 청구범위 보정범위제한(法 47③)도 만족하여야 하고, 보정에 의하여 새로운 거절이유가 발생하지 아니하여야 한다.

(4) 분할출원

심사관은 청구범위의 청구항별로 특허요건을 검토하지만 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 특허출원 전체를 특허거절결정한다. 따라서 출원인은 청구범위에 기재된 청구항 중 일부 청구항에 대해서만 거절이유통지를 받거나 하나의 특허출원범위(法 45)에 위반됨을 이유로 거절이유통지를 받은 경우 분할출원을 하여 특허출원 전체가 거절결정되는 것을 회피할 수 있다. 다만 청구범위에 기재된 청구항을 분할할 때는 분할출원이 원출원의 출원일로 소급효가 인정되기 때문에 협의제를 회피하기 위해서 원출원의 청구범위에 기재된 청구항 중 분할출원된 청구항을 삭제보정하여야 한다.

(5) 변경출원

출원인은 심사관으로부터 진보성(法 29②)에 위반되었다는 이유로 거절이유통지 또는 특허거절결정을 받았을 때 최초 특허거절결정등본의 송달일로부터 3개월까지 변경출원을 고려해볼 수 있다. 실용신안법은 특허법보다 창작수준이 낮은 정도의 진보성인 「극히 용이성」을 요구하므로 특허출원이 진보성(法 29②)에 위반되었다고 할지라도 실용신안등록출원은 진보성에 위반되지 않을 수 있기 때문이다. 다만 실용신안법은 보호대상이 물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안이어야 하므로 물질발명이나 방법발명은 진보성(法 29②)에 위반되었다고 할지라도 변경출원을 할 수 없다.

(6) 조약우선권주장출원 또는 국내우선권주장출원

출원인은 심사관이 기재불비(法 42③④⑧) 등으로 거절이유통지를 하였을 때 출원일로부터 1년이 지나지 않았다면 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원 등을 고려해 볼 수 있을 것이다. 물론 통상적으로 기재불비의 경우 보정으로 하자가 치유될 수 있으나 신규사항추가금지

(法 47②) 범위를 벗어난 경우에는 조약우선권주장출원 또는 국내우선권주장출원이 거절이유를 극복하기 위한 적절한 수단이 될 수 있다.

(7) 의견서 제출

출원인은 거절이유가 타당하더라도 보정, 공지예외적용주장 등을 통해 거절이유를 극복하였기 때문에 다시 한번 심사하여 특허결정을 해 달라는 의견서를 심사관에게 제출할 수 있다.

2. 극복불가능한 경우

출원인은 심사관의 거절이유가 타당하고 극복할 수 없다고 여겨질 때 일반적으로 거절이유 통지에 대하여 아무런 대응을 하지 않고 그대로 방치하여 거절결정을 유도한다. 다만 출원인은 아직 특허출원이 공개되기 전이고 노하우로서 발명을 보호할 가치가 있다고 판단되는 경우 출원의 취하·포기를 고려해 볼 수 있다. 출원의 취하 또는 포기는 출원의 취하서 또는 포기서를 지식재산처장에게 제출하여야 하며, 제출된 취하서 또는 포기서가 적법하게 수리되면 그때부터 해당 출원은 취하 또는 포기된 것으로 취급된다.

제5장

심사의 종료

제1절 서 설

「심사의 종료」란 해당 심사절차에 있어서 심사의 계속을 소멸시키는 것을 말한다. 특허출원인의 특허를 받을 수 있는 권리에 의한 출원에 의하여 개시된 심사절차는 일반적으로 특허여부결정에 의하여 종료되지만, 출원의 무효, 취하 및 포기에 의하여 종료되기도 한다. 출원의 무효에 대해서는 앞서 살펴보았기 때문에 이하에서는 특허여부결정에 의한 종료와 특허출원의 취하 및 포기에 의한 종료에 대하여 후술한다.

제2절 특허여부결정에 의한 종료

제62조 【특허거절결정】

심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나의 거절이유(이하 “거절이유”라 한다)에 해당하는 경우에는 특허거절결정을 하여야 한다. <개정 2021. 10. 19.>

1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항부터 제3항까지 또는 제44조에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 같은 항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약을 위반한 경우
4. 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항에 따른 범위를 벗어나는 분리출원인 경우
7. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우

[전문개정 2014.6.11.]

제63조 【거절이유통지】

① 심사관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 특허출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 다만, 제51조제1항에 따라 각하결정을 하려는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>

1. 제62조에 따라 특허거절결정을 하려는 경우
 2. 제66조의3제1항에 따른 직권 재심사를 하여 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우
- ② 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 제1항 본문에 따라 거절이유를 통지할 때에는 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고, 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제66조 【특허결정】

심사관은 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 한다. [전문개정 2014.6.11.]

제66조의2 【직권보정 등】

- ① 심사관은 제66조에 따른 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에는 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다. 이 경우 직권보정은 제47조제2항에 따른 범위에서 하여야 한다. <개정 2016. 2. 29., 2021. 8. 17.>
- ② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.
- ③ 특허출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
- ④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다. 다만, 특허출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>
- ⑤ 삭제 <2016.2.29.>
- ⑥ 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2021. 8. 17.>

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.2.29.]

제66조의3 【특허결정 이후 직권 재심사】

- ① 심사관은 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에는 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사(이하 “직권 재심사”라 한다)할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 거절이유가 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건에 관한 것인 경우
 2. 그 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우
 3. 그 특허출원이 취하되거나 포기된 경우
- ② 제1항에 따라 심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다.
- ③ 특허출원인이 제2항에 따른 통지를 받기 전에 그 특허출원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하게 된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다.

[본조신설 2016.2.29.]

제67조 【특허여부결정의 방식】

- ① 특허결정 및 특허거절결정(이하 “특허여부결정”이라 한다)은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ② 지식재산처장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제67조의2 【재심사의 청구】

- ① 특허출원인은 그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사(이하 “재심사”라 한다)를 청구할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016. 2. 29., 2021. 10. 19.>
 1. 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우
 2. 제132조의17에 따른 심판청구가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다)

3. 그 특허출원이 분리출원인 경우
 - ② 특허출원인은 제1항에 따른 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다.
 - ③ 제1항에 따라 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정 또는 특허거절결정은 취소된 것으로 본다. 다만, 재심사의 청구절차가 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
 - ④ 제1항에 따른 재심사의 청구는 취하할 수 없다.
- [전문개정 2014.6.11.]

제67조의3 【특허출원의 회복】

- ① 특허출원인이 정당한 사유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간을 지키지 못하여 특허출원이 취하되거나 특허거절결정이 확정된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구를 할 수 있다. 다만, 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
 1. 제59조제2항 또는 제3항에 따라 출원심사의 청구를 할 수 있는 기간
 2. 제67조의2제1항에 따라 재심사의 청구를 할 수 있는 기간
- ② 제1항에 따른 출원심사의 청구 또는 재심사의 청구가 있는 경우에는 제59조제5항에도 불구하고 그 특허출원은 취하되지 아니한 것으로 보거나 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다.

[본조신설 2013.3.22.]

I. 서 설

1. 의의 및 취지

「특허출원의 특허여부결정」이란 특허출원의 심사 결과 특허 적격 여부에 관하여 심사관이 행하는 최종적 판단으로서의 행정처분을 말한다. 심사관에 의한 행정처분인 특허여부결정은 공정성과 객관성이 담보되어야 하므로 특허법은 이러한 특허여부결정 절차 및 방법 등에 관한 규정을 두고 있다.

2. 종 류

(1) 특허거절결정

「특허거절결정」이란 심사관이 출원발명에 대하여 실체심사를 한 결과 거절이유를 발견하였을 때 그 거절이유의 존재로 인하여 해당 출원발명은 특허를 받을 수 없다는 것을 확인하는 행정처분을 말한다. 여기서 거절이유는 제한열거적이기 때문에 심사관은 제62조 각호의 거절이유에 명시되지 아니한 사항을 이유로 특허거절결정을 할 수 없고, 특허출원이 거절이유에 해당될 때는 반드시 특허거절결정을 하여야 하며, 심사관의 재량은 인정되지 아니한다. 그 결과 심사관은 발명의 성립성이 없는 경우 발명의 정의 규정(法 2 I)이 제62조의 거절이유에 명시되어 있지 않기 때문에 우회적으로 제29조제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명 또는 제42조 제3항제1호의 발명의 설명 기재요건 위반으로 특허거절결정하고 있다.

(2) 특허결정

「특허결정」이란 심사관이 출원발명에 대하여 실체심사를 한 결과 거절이유를 발견할 수 없을 때 해당 출원발명은 특허를 받을 수 있다는 취지의 행정처분을 말한다(法 66).

II. 특허여부결정의 요건

1. 주 체

특허거절결정 또는 특허결정은 원칙적으로 심사관이 행한다(法 57①). 특허출원의 특허여부 결정에 관하여는 그 공정을 확보하기 위하여 심판관의 제척제도(단, 전심판관 제외)를 준용한다(法 68).

2. 대 상

(1) 심사청구된 특허출원

특허여부결정의 대상은 지식재산처에 출원 계속 중인 특허출원 중 심사청구가 된 특허출원이다. 심사청구를 하지 아니한 출원은 실체심사를 할 수 없으며, 출원의 취하·포기·무효 등으로 출원 계속 중이 아닌 출원은 그 대상이 없어졌기 때문에 특허여부결정을 할 수 없다.

(2) 보정한 경우의 대상

1) 실체심사에 착수하기 이전(法 47①본문)에 제출된 자진보정과 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①I)에 제출된 보정은 제출된 대로 인정한다. 즉 보정된 내용을 반영한 명세서 또는 도면을 그 심사대상으로 한다.

2) 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①II)에 제출된 보정 또는 재심사를 청구할 때(法 47①III) 보정은 특허여부결정을 하기에 앞서 보정각하 여부를 먼저 판단하여 심사대상 명세서 또는 도면을 확정한다. 구체적으로 심사관은 보정의 적법성을 판단하여 보정이 적법하면 보정의 소급효가 인정되기 때문에 보정 후 명세서 또는 도면에 의하여, 보정이 부적법하면 보정은 보정각하하고 보정 전 명세서 또는 도면에 의하여 심사를 진행한다.

(3) 외국어특허출원(외국어국제특허출원 포함)의 경우의 대상

외국어특허출원(외국어국제특허출원 포함)의 경우 국어번역문에 따라 실체보정한 것으로 간주하기 때문에(法 42의3⑤, 201⑤), 국어번역문을 그 심사대상으로 한다. 다만 원문과 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어난 보정을 하면 거절이유(法 62), 정보제공사유(法 63의2)로 규정하고 있다.³⁵⁾

35) 외국어 특허출원(외국어 국제특허출원도 포함)에 대해서는 출원인이 원문내용을 번역하여 제출한 국어번역문을 기준으로 보정의 신규사항 추가 여부를 심사하는 것을 원칙으로 하되, 외국어명세서 등과 심사대상 명세서 등의 일치성에 의문이 가는 경우 외국어명세서 등과 심사대상 명세서 등을 대조 확인한다. 외국어 명세서

3. 시 기

(1) 특허거절결정의 경우

① 거절이유의 통지(의견제출기회의 부여)

1) 심사관은 특허출원이 거절이유를 포함하고 있어 특허거절결정을 하여야 하는 경우에는 특허거절결정을 하기 전에 일단 그 특허출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 63①I). 이는 출원인에게 거절이유에 대하여 아무런 해명할 기회를 주지 않고 그대로 특허거절결정을 하는 것은 출원인에게 가혹할 뿐 아니라, 심사관의 잘못으로 특허거절결정을 하는 경우도 있으므로 출원인에게 충분한 의견제시의 기회를 주어 심사관이 재심사할 기회를 갖도록 하기 위한 것이다. 특허거절결정을 하기 전에 이러한 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주는 것은 강행규정³⁶⁾이며 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 된 특허거절결정에 대해서 출원인은 이를 이유로 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구할 수 있다.

2) 심사관은 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대하여 거절이유를 통지할 때에는, 그 통지서에 거절되는 청구항을 명확히 밝히고 그 청구항에 관한 거절이유를 구체적으로 적어야 한다(法 63②).

② 출원인의 의견서·보정서의 제출

출원인은 거절이유통지를 받은 경우에는 의견서 제출기간에 의견서 또는 보정서를 제출할 수 있다. 한편 의견서 제출기간이 지나서 제출된 보정서는 불수리 사항이지만, 의견서는 불수리 사항(施規 11)이 아니므로 수리하여 참조한다. 즉 의견서는 심사 계속 중에는 언제든지 제출할 수 있다.

③ 특허거절결정을 하여야 하는 경우

1) 심사관은 거절이유통지에 따라 제출된 의견서·보정서에 의해서도 이미 통지한 거절이유가 해소되지 아니하고 동일한 경우에는 다른 거절이유가 있더라도 다시 거절이유를 통지하지 아니하고 특허거절결정을 한다. 심사관이 모든 거절이유에 대하여 거절이유통지를 한 후 거절결정을 하여야 하는 것은 아니기 때문이다. 한편 거절결정서에 기재된 거절결정의 이유는 거절이유통지서에 기재한 거절이유와 동일하여야 한다. 거절결정의 이유가 거절이유와 동일한 경우란 주지(主旨)에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애되어서는 아니 되고 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가되어야 한다.³⁷⁾³⁸⁾

등을 대조 확인해야 하는 사례 유형으로는, i) 심사대상 명세서 등에 원문 신규사항이 있다는 정보제공 등이 있고, 그 내용을 검토한 결과 심사대상 명세서 등에 원문 신규사항이 존재한다는 합리적 의문이 발생한 경우, ii) 국제특허출원의 국제예비심사 보고서에 신규사항에 대한 견해가 있거나 패밀리 출원의 심사결과를 확인하는 과정에서 상이한 내용의 발명이 패밀리 출원에 기재된 경우 등이 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 5509-5510면).

36) 대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300; 1996. 11. 22. 선고 96후177 등

37) 대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950; 1994. 6. 28. 선고 92후1066; 2000. 1. 14. 선고 97후3494 등

2) 심사관은 특허출원에 있어서 청구범위에 둘 이상의 청구항이 있고, 하나의 청구항이라도 거절이유가 해소되지 못한 경우에는 출원 전체를 특허거절결정하여야 한다.³⁹⁾

(2) 특허결정의 경우

심사관은 i) 특허출원을 심사한 결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우, ii) 거절이유통지를 하고 그에 의하여 제출된 의견서 및 보정서에 따라 심사한 결과 거절이유통지서에 지적한 거절이유가 해소되고 그 이외의 새로운 거절이유를 발견할 수 없는 경우 또는 iii) 거절결정불복 심판청구에 의한 환송심결에 따라 심사국으로 이송된 출원을 심사한 결과 거절이유를 발견할 수 없는 경우, iv) 출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적합한 사항이 명백히 잘못되어 직권보정한 경우에는 특허결정을 한다.

III. 특허여부결정의 절차

1. 방 식

특허여부결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다(法 67①). 구체적으로 특허여부 결정서에는 다음의 사항을 기재하고 심사관은 이에 기명날인하여야 한다(施規 48②).

- i) 특허출원번호
- ii) 발명의 명칭
- iii) 출원인의 성명 및 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소)
- iv) 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허 법안·특허법안(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
- v) 거절이유통지연월일(특허거절결정의 경우에 한한다)
- vi) 결정의 주문 및 그 이유(특허거절결정의 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 때에는 해당 청구항 및 그 특허거절결정의 이유를 적어야 한다)
- vii) 결정연월일
- viii) 직권보정 사항이 있는 경우에는 그 직권보정 사항(특허결정의 경우에 한정한다)

2. 송 달

지식재산처장은 특허여부결정이 있는 경우에는 그 결정의 등본을 특허출원인에게 송달하여야 한다(法 67②).

38) 심사단계에서 출원발명 전체가 인용대상과 비교하여 진보성이 없다고 하는 거절이유에는 심판단계의 출원발명의 일부 청구항이 진보성이 없어서 거절되어야 한다는 심결이유에서의 거절이유가 당연히 포함되는 것으로서, 심사절차에서의 거절이유통지하면서 출원발명의 일부 청구항에 대한 의견제출이나 보정의 기회가 충분히 부여되었다 할 것이므로 위 심결에서의 거절이유가 구 특허법 제170조제2항 소정의 '특허거절결정의 거절이유와 다른 거절이유'라고 할 수 없다(특허법원 2001. 9. 13. 선고 2001허89).

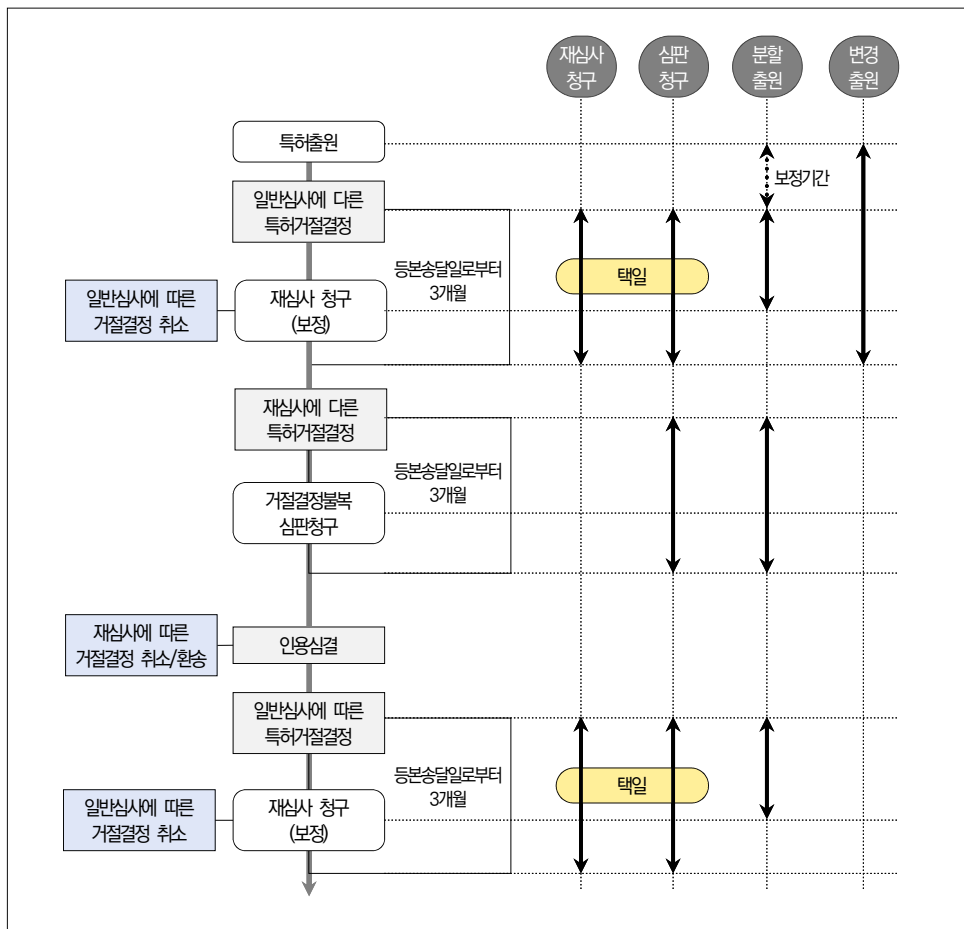
39) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820; 2024. 12. 22. 선고 2024후10825. 특허법은 제215조에서 둘 이상의 청구항이 있는 특허에 관하여 청구항마다 특허가 되거나 특허권이 있는 것으로 보는 경우를 열거하고 있고, 제215조의2에서 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다고 규정하고 있으나, 특허거절결정 등에 관하여는 이러한 규정을 두고 있지 않다.

IV. 특허여부결정의 효과

1. 특허거절결정의 효과

(1) 특허거절결정에 대한 불복

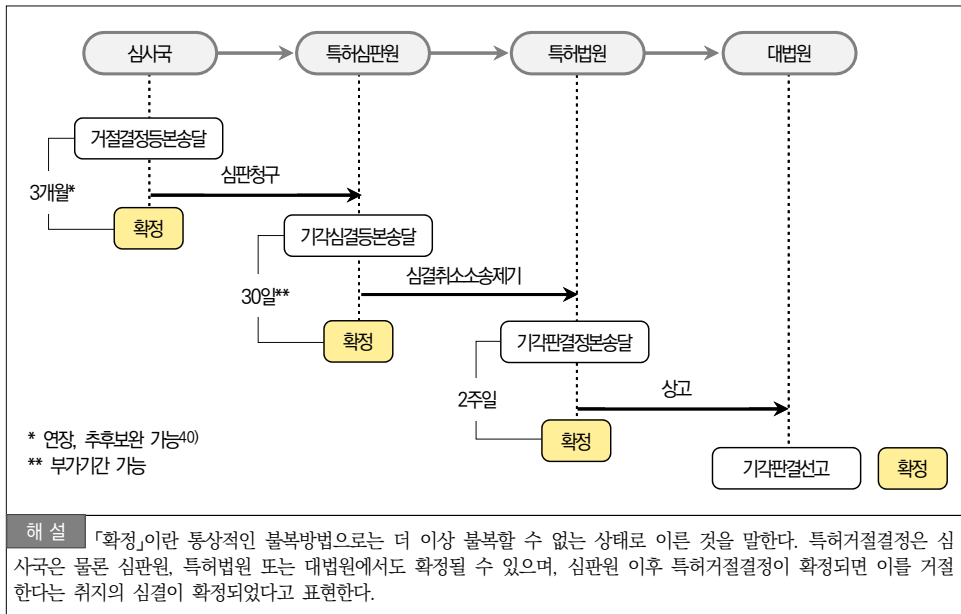
특허거절결정을 받은 자가 이에 대하여 불복할 때는 특허거절결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내 재심사 청구와 거절결정불복심판의 청구 중 어느 하나를 할 수 있으며(法 67의2 ①Ⅱ, 132의17), 필요한 경우 분할출원, 변경출원을 할 수 있다. 한편 재심사에 따른 특허거절결정등본을 송달받으면 그 날로부터 3개월 이내 분할출원이나 거절결정불복심판을 청구할 수 있으나, 재심사 청구는 할 수 없다(法 67의2①Ⅰ).



【그림 4-11】 특허거절결정등본을 송달받은 출원인의 대응방안

(2) 특허거절결정의 확정

특허거절결정에 대한 심판청구를 할 수 있는 기간이 지났거나 특허거절결정에 대하여 심판을 청구했다 하더라도 나중에 심판청구를 취하하거나 심판청구에 대하여 기각(각하)심결이 확정되면 특허거절결정에 대하여 더 이상 불복할 수 없으므로 특허거절결정이 확정된다.



【그림 4-12】 특허거절결정의 확정시기

2. 특허결정의 효과

(1) 특허료 납부 및 설정등록

특허거절결정과는 달리 특허결정에 대해서 출원인은 불복할 수 없으므로⁴¹⁾ 지식재산처장이 특허결정등본을 출원인에게 송달한 때 해당 특허결정은 확정된다. 지식재산처장은 출원인이 특허결정등본송달일로부터 3개월 이내에 최초 3년분의 특허료를 내면 직권으로 특허등록을 하게 된다(法 87①).

40) 재심사를 청구할 수 있는 기간이면 제67조의3에 의하여 특허출원의 회복이 가능하다.

41) 대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274.

(2) 직권보정

심사관은 특허결정을 할 때 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에 직권으로 보정할 수 있다(法 66의2).

(3) 직권재심사

심사관이 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사할 수 있다(法 66의3).

(4) 분할출원, 변경출원, 국내우선권주장출원 또는 재심사의 청구

1) 출원인은 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등락을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내(다만 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)에 분할출원을 할 수 있고(法 52①Ⅲ), 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간에 재심사를 청구할 수 있다(法 67의2①본문). 다만 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허결정이 있는 경우 또는 그 특허출원이 분리출원인 경우에는 재심사를 청구할 수 없다(法 67의2①Ⅰ,Ⅲ).

2) 또한 출원인은 특허출원에 대하여 최초 특허거절결정이 되지 않고 특허결정등본이 송달되었으면 특허료를 내서 설정등록 전에는 출원 계속 중이기 때문에 변경출원을 할 수 있고(法 53①), 출원일로부터 1년 이내라면 특허결정등본을 송달된 경우라도 설정등록 전에 국내우선권주장출원을 할 수 있다(法 55①Ⅳ).⁴²⁾ 이처럼 분할출원, 변경출원, 국내우선권주장출원 또는 재심사 청구를 허용하는 것은 권리범위를 재설계할 수 있는 기회를 주기 위함이다. 특히 국내우선권주장출원은 새로운 개량발명을 추가적으로 포함하는 것이 가능하며, 국내우선권주장출원을 한 경우 선출원은 우선권주장이 취하된 경우를 제외하고는 설정등록을 받을 수 없다(法 55⑧).

(5) 공지에외적용주장

출원인은 제66조에 따른 특허결정 또는 제176조제1항에 따른 특허거절결정 취소심결(특허등락을 결정한 심결에 한정하되, 재심심결을 포함한다)의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내(다만 제79조에 따른 설정등록을 받으려는 날이 3개월보다 짧은 경우에는 그 날까지의 기간)에 제30조제1항제1호의 의사에 의한 공지에 대한 공지에외적용취지를 적은 서면 및 증명서류를 할 수 있다(法 30③). 이는 심사관이 미처 발견하지 못한 공지기술에 의하여 설정등록 이후에 취소신청이나 특허무효심판이 청구되는 것을 방지하기 위함이다.

42) 조약우선권주장출원의 경우 출원일로부터 1년 이내라면 선출원이 설정등록되더라도 그 출원을 할 수 있다. 조약우선권주장출원의 선출원은 출원 계속 중일 필요가 없고, 정규성만 만족하면 되기 때문이다.

V. 관련제도

1. 직권보정

(1) 의의 및 취지

「직권보정」이란 심사관이 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우에 직권으로 보정하는 것을 말한다(法 66의2①). 적힌 사항이 명백히 잘못되었는데 불필요한 의견제출통지로 인한 심사절차의 지연이 되는 것을 방지하고 명세서 또는 도면의 하자를 치유하여 명세서 또는 도면의 완벽성을 높이기 위하여 이를 인정하고 있다.⁴³⁾

(2) 요 건

1) 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 적힌 사항이 명백히 잘못된 경우이어야 한다(法 66의2①본문). 「명백히 잘못된 경우」란 사소한 오타자 이외에 명백히 잘못 기재된 기재불비가 있는 경우를 말하고, 여기서 명백히 잘못 기재된 기재불비란 통상의 기술자가 그 기재가 잘못되었다는 사실을 쉽게 인식할 수 있고, 명세서 등의 기재, 의견서 및 출원 시 기술상식을 참작하여 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있어서 해당 보정이 어떻게 이루어질 것인지 쉽게 예측할 수 있는 경우를 말한다.⁴⁴⁾ 적힌 사항이 잘못되었다는 것이 명백하더라도 명세서와 의견서 등으로부터 출원인의 당초 의도가 명확히 파악되지 않는다면 직권보정하지 않는다.⁴⁵⁾

2) 직권보정은 신규사항이 추가되지 아니한 범위(法 47②)에서 하여야 한다(法 66의2①단서).

(3) 절 차

심사관이 직권보정을 하려면 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 하며, 특허출원인은 직권보정 사항의 일부 또는 전부를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를 낼 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 66의2②③).

(4) 효과: 의견서를 제출하지 아니한 경우

특허출원인이 의견서를 제출하지 아니한 경우 이를 수용한다는 의사가 있는 것이기 때문에

43) 명세서 등을 명확하게 기재할 책임은 원칙적으로 출원인에게 있고 제47조에서 보정할 수 있는 자, 보정이 가능한 기간 및 범위를 엄격하게 정하고 있는 점을 고려할 때, 심사관에 의한 직권보정제도는 출원인에 의한 보정의 예외로서 제한된 범위 내에서 보충적으로 운영될 필요가 있다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 8201-8202면).

44) 직권보정의 대상은 국어표준 용어 또는 맞춤법상의 단순한 오자, 탈자 또는 도면부호의 불일치, 출원인의 당초 의도를 명확히 알 수 있는 기재불비 등으로 구체적인 예는 다음과 같다. 다만 아래의 경우라 하더라도 출원인의 의도가 명확하게 파악되지 않는다면 직권보정하지 않는다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 8203-8204면).

구 분			예시 및 설명
사 소 한 오 탈 자	국문법에 어긋난 오자		(a) 반도테 → 반도체 (b) 기판는 → 기판은
	국문법상 해석이 분명한 탈자		(a) 라인에 전달하○신호 → 라인에 전달하는 신호 (b) 리니어 터 → 리니어 모터
	참조부호의 붙임치		명세서 중 [도2] 버퍼부(115) vs. 도면 [도2] 버퍼부(15)
	반복된 기재		지식재산처 지식재산처는 → 지식재산처는
	도면의 간단한 설명 의 오류	도면번호오기	도 1은 재생기기의 단면도 도 1은 재생기기의 측면도 → 도 2는 재생기기의 측면도 도 3은 재생기기의 사시도
		도면부호오기	3…치차 3…모터 → 3…치차 4…모터
대표도의 오기		명세서로 파악해 본바 명백히 잘못 기재된 대표도	
명 백 하 잘 못 기 재 된 기 재 불 비	명세서상의 발명의 명칭이 출원서와 일치하지 아니한 경우		명세서의 발명의 명칭을 출원서에 기재된 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다. 만약, 출원서에 기재된 발명의 명칭이 명세서의 발명의 명칭 기재요건을 충족하지 못하는 경우에는 출원서와 명세서 모두를 적절하다고 인정되는 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다.
	삭제된 청구항을 인용하는 경우	삭제된 청구항만을 인용하며, 선행 청구항이 1개인 경우	청구항 1. A와 B를 포함하는 장치 청구항 2. 삭제 청구항 3. 청구항 2에 있어서, C를 더 포함하는 장치 → 청구항 1에 있어서, C를 더 포함하는 장치
		삭제되지 않은 청구항도 인용하는 경우	청구항 1. A와 B를 포함하는 장치 청구항 2. 삭제 청구항 3. 청구항 1 또는 2에 있어서, C를 더 포함하는 장치 → 청구항 1에 있어서, C를 더 포함하는 장치
	종속항임에도 인용하는 청구항과 말미가 다른 경우		청구항 1. A를 포함하는 장치 청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 방법 → 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치
기 재 된 기 재 불 비	보정으로 종속항이 인용하는 청구항에 병합되었음에도 종속항을 삭제하지 않은 경우		[보정 전] 청구항 1. A를 포함하는 장치 청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치 [보정 후] 청구항 1. A와 B를 포함하는 장치 청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치 → 삭제
	동일한 구성을 두 개 이상의 용어를 사용하여 지칭하는 경우		청구항 1. 핵 형성층을 형성하는 단계와 상기 핵 생성층 위에 실리콘 층을 형성하는 단계를 포함하는 반도체층 형성 방법 → 청구항 1. 핵 형성층을 형성하는 단계와 상기 핵 생성층 위에 실리콘 층을 형성하는 단계를 포함하는 반도체층 형성 방법
	청구항을 잘못 인용한 것이 명백한 경우		청구항 1. A를 포함하는 장치 청구항 2. 청구항 1에 있어서, B를 더 포함하는 장치 청구항 3. 청구항 1에 있어서, 상기 B는 C인 장치→ 청구항 2에 있어서, 상기 B는 C인 장치
	문언적으로 동일한 청구항을 중복하여 기재하는 경우		청구항 1. A와 B를 포함하는 장치 청구항 2. A와 B를 포함하는 장치 → 삭제
인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하지 않은 경우		(a) 청구항 1 및 2에 있어서, → 청구항 1 또는 2에 있어서, (b) 청구항 1 및 청구항 2 또는 청구항 3 중 적어도 어느 한 항에 있어서, → 청구항 1 내지 3 중 어느 한 항에 있어서,	

출원인의 의사에 의한 보정과 같이 취급한다. 다만 직권보정이 신규사항을 추가하거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 66의2⑥). 심사관이 잘못된 방향으로 직권보정을 한 경우에 출원인이 의견서를 제출하지 않으면 그 직권보정 사항이 그대로 인정되어 취소할 수 없게 되는데, 이 경우 처음부터 없던 권리가 만들어지거나 의도하지 않은 권리가 되어도 정정이 불가하거나 권리가 무효화될 가능성도 있는 문제점이 있어서, 2021. 11. 18. 시행되는 현행법(법률 제18409호, 2021. 8. 17. 일부개정)에서는 신규사항을 추가하지 않는 범위내에서 직권보정할 수 있는 제한을 추가하되, 신규사항을 추가하거나 명백히 잘못되지 않은 사항을 직권보정한 경우 해당 직권보정은 없었던 것으로 간주하도록 하였다.⁴⁶⁾

(5) 효과: 의견서를 제출한 경우

1) 특허출원인이 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 일부 또는 전부는 처음부터 없었던 것으로 본다. 이 경우 그 특허결정도 함께 취소된 것으로 본다. 다만 특허출원서에 첨부된 요약서에 관한 직권보정 사항의 전부 또는 일부만 처음부터 없었던 것으로 보는 경우에는 그러하지 아니하다(法 66의2④). 요약서에 관한 기재는 거절이유가 아니기 때문에 굳이 특허결정이 취소된 것으로 볼 이유가 없다.

2) 특허결정이 취소된 것으로 보는 경우 심사관은 직권보정 전 명세서 또는 도면에 의하여 다시 심사를 진행한다. 이때 심사관이 직권보정 전에 이미 통지된 거절이유가 발견되더라도 다시 거절이유를 통지하여야 한다. 다만 그 거절이유가 출원인이 받아들이지 아니한 직권보정 사항에 해당하고, 이미 통지된 거절이유라면 바로 거절결정할 수 있다.⁴⁷⁾

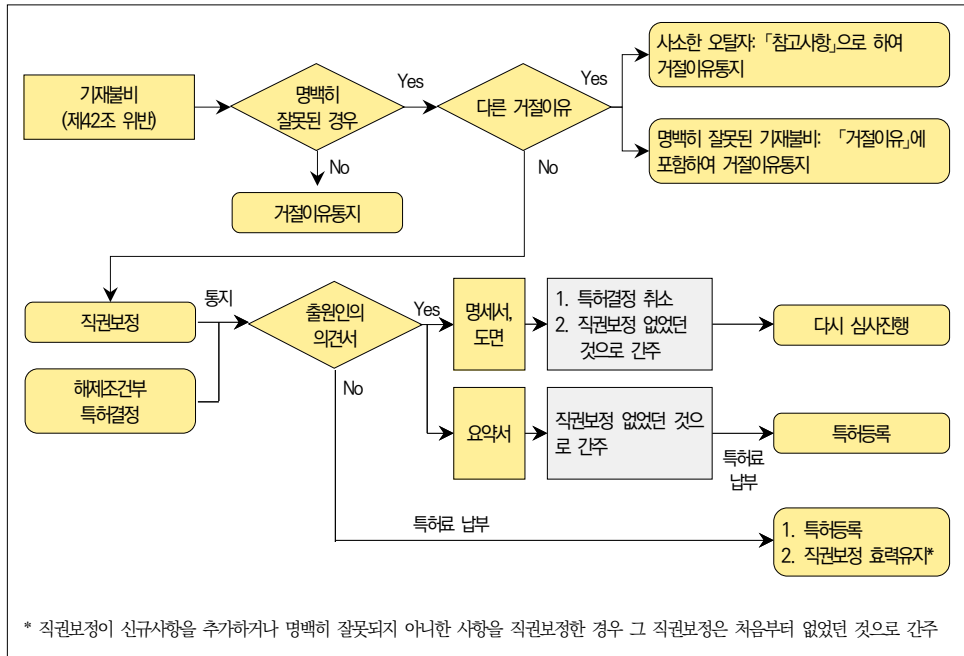
3) 심사관은 직권보정 전에 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①Ⅲ) 한 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했음에도 불구하고 보정각하결정을 하지 아니하고 이를 간과하여 특허결정을 취소한 후에 발견한 경우에는 보정을 인정하고 심사를 진행한다(法 51①Ⅰ). 이는 보정이 인정됨을 전제로 특허결정을 받았다는 것을 신뢰한 출원인의 이익을 보호하기 위함이다.

45) 예를 들어 삭제된 청구항만을 인용하고 있고 선행 청구항이 2 이상인 경우, 삭제된 청구항 대신에 선행 청구항 중 어느 항을 인용하고자 했던 것인지 출원인의 당초 의도가 명확하지 않은 경우에는 직권보정하지 않는다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 8204번).

46) 채수근 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안 검토보고(이철규 의원 대표발의(의안번호 제2105036호 및 제2105093호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2. 10-11면 참조.

47) 예를 들면 다음과 같다.

거절이유통지	보정	특허결정	의견서	재심사
A B	A' B'	A' B'(직권보정)	불수용	A'에 대해서는 이미 통지한 거절이유가 발견되더라도 바로 거절결정불가능하지만, B'에 대해서는 이미 통지한 거절이유가 발견된 경우 바로 거절결정가능함



【그림 4-13】 직권보정제도

2. 직권 재심사

(1) 의의 및 취지

「직권 재심사」란 심사관이 특허결정된 특허출원에 관하여 명백한 거절이유를 발견한 경우에 직권으로 특허결정을 취소하고, 그 특허출원을 다시 심사하는 것을 말한다(法 66의3①본문). 기존에는 심사관이 특허결정을 한 후 하자를 발견하더라도 이를 취소하고 다시 심사할 수 있는 명문 규정이 없어 무효 가능성이 있는 특허가 그대로 등록되는 문제점이 있었기 때문에 2017. 3. 1. 시행된 현행법(법률 제14035호, 2016. 2. 29. 개정)에서는 직권으로 특허결정을 취소할 수 있는 규정을 신설하였다. 본 제도는 주로 특허결정 후 제3자의 정보제공에 의하여 명백한 거절이유를 발견하였을 때 이용될 수 있을 것이다.

(2) 요건

1) 특허결정된 특허출원에 관하여 배경기술 기재(法 42③II), 다항제 기재방법(法 42⑧) 및 하나의 특허출원의 범위(法 45) 위반을 제외한 명백한 거절이유를 발견한 경우이어야 한다. 여기서 「명백한 거절이유」란 특허결정된 특허출원이 등록되었을 때 무효로 될 가능성이 있다는 정도로는 부족하고, 무효로 될 것임이 명백한 경우를 의미한다고 할 것이다.

2) 다만 i) 그 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우나 ii) 그 특허출원이 취하되거나

포기된 경우에는 직권 재심사를 할 수 없다. i)의 경우 이미 등록된 상태에서 특허결정을 취소하고 그 출원을 다시 심사하는 것은 권리의 안정성을 해하기 때문에 특허취소신청이나 특허 무효심판으로 다투도록 하는 것이 바람직하고, ii)의 경우 출원절차가 종료되어 취소할 특허결정이 없기 때문이다.

(3) 절 차

심사관이 직권 재심사를 하려면 특허결정을 취소한다는 사실을 특허출원인에게 통지하여야 한다(法 66의3②). 특허출원인이 통지를 받기 전에 그 특허출원이 i) 특허결정에 따라 특허권이 설정등록된 경우나 ii) 취하되거나 포기된 경우에는 특허결정의 취소는 처음부터 없었던 것으로 본다(法 66의3③).

(4) 효 과

1) 심사관은 특허결정을 취소하면 처음부터 다시 심사를 진행한다. 심사관은 직권 재심사에 이르게 된 명백한 거절이유에 대해서는 특허출원인에게 최초거절이유를 통지하여 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 47①II괄호). 즉 심사관이 특허결정을 취소하면 다시 최초거절이유통지를 하여, 출원인에게 청구범위를 확장, 변경할 수 있는 보정기회를 주고 있다(法 47②).

2) 심사관은 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유로 특허거절결정을 하려는 경우에도 특허출원인에게 최초거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 63①II). 이는 심사관이 특허출원에 관하여 명백한 거절이유가 있음에도 불구하고 특허결정을 한 후 이를 취소하여 다시 심사를 진행할 때 취소된 특허결정 전에 이미 통지한 거절이유를 이유로 곧바로 거절결정하는 것은 출원인에게 가혹하기 때문이다.

3) 심사관은 취소된 특허결정 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①II) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①III) 한 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 또는 청구범위 보정범위 제한(法 47③)을 위반하거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했음에도 불구하고 보정 각하결정을 하지 아니하고 이를 간과하여 특허결정을 취소한 후에 직권 재심사단계에서 발견한 경우에는 보정을 인정하고 심사를 진행한다(法 51①II). 이는 보정이 인정됨을 전제로 특허결정을 받았다는 것을 신뢰한 출원인의 이익을 보호하기 위함이다.

4) 특허결정을 취소하기 전에 한 보정각하결정은 추후 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③괄호). 이는 직권 재심사단계에서 직권 재심사의 전 보정각하결정에 대하여 충분히 다룰 기회를 주었기 때문이다.

3. 재심사 청구

(1) 의의 및 취지

「재심사 청구」란 특허출원인이 그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3

개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여 해당 특허출원에 관한 재심사를 청구하는 경우 심사관에게 보정된 출원을 다시 심사하게 하는 것을 말한다(法 67의2). 기존의 거절결정 불복심판청구일로부터 30일 이내 실제보정을 한 경우 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있는 심사전치제도(法 172-175)를 삭제하고 재심사 청구제도(法 67의2)를 도입하였다. 그 결과 특허거절결정등본송달일로부터 3개월 이내 거절결정불복심판청구와 재심사 청구 중에서 출원인이 원하는 수단을 선택하게 함으로써, 출원인이 재심사 청구를 하는 경우 심판청구를 하지 않더라도 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있도록 하여, 특허절차를 간소화하고 불필요한 심판청구 수수료를 낼 필요를 없게 하였다. 또한 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 특허결정의 등본을 송달받은 날로부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간까지 재심사 청구를 할 수 있도록 하여, 특허결정등본을 송달받았을지라도 제한된 보정범위 내에서 권리범위를 재설계할 기회를 주고 있다.

(2) 요 건

① 원 칙

그 특허출원에 관하여 특허결정의 등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록을 받기 전까지의 기간 또는 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 명세서 또는 도면을 보정하여야만 재심사를 청구할 수 있다(法 67의2①본문).

② 예 외

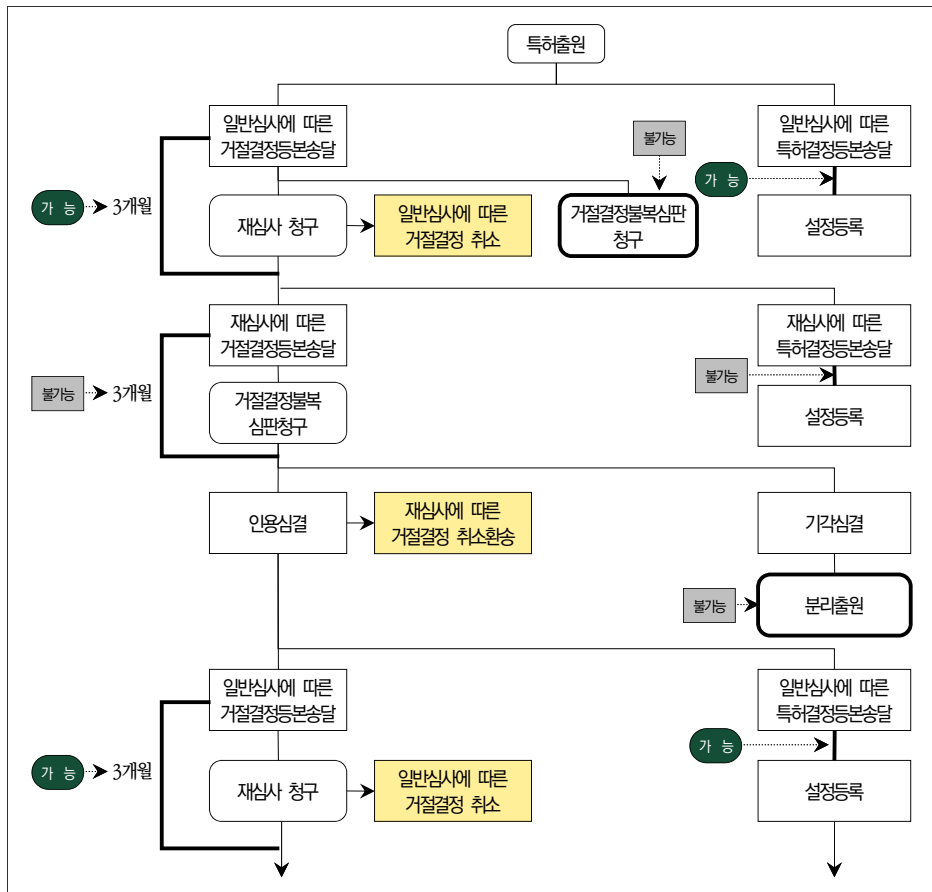
1) 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 재심사를 청구할 수 없다(法 67의2①단서).

- i) 재심사를 청구할 때에 이미 재심사에 따른 특허여부의 결정이 있는 경우
- ii) 거절결정불복심판청구(法 132의17)가 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다)
- iii) 그 특허출원이 분리출원인 경우

2) i)의 경우 이미 재심사 청구를 하여 특허여부결정이 된 경우에는 재심사 절차의 반복으로 인해 심사가 지연되는 것을 방지하기 위해 다시 재심사 청구를 할 수 없도록 제한하고 있다. ii)의 경우 거절결정불복심판청구와 재심사 청구는 선택적 사항으로서 출원인은 특허거절결정 등본송달일로부터 3개월(연장된 경우에는 그 연장된 기간) 이내 둘 중에 하나를 선택하여 특허거절결정에 대하여 다툴 수 있다.⁴⁸⁾ 다만 거절결정불복심판에서 재심사에 따른 특허거절결

48) 재심사가 청구된 경우 특허거절결정은 취소된 것으로 보므로 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 할 수 있는 행위, 즉 특허거절결정에 대한 불복심판청구 및 분할출원은 할 수 없다. 다만 재심사 청구와 동시에 분할출원을 하거나 재심사 과정에서 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에 분할출원을 하는 것은 가능하다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5406면).

정이 취소되고, 심사국으로 환송된 이후 특허여부결정이 된 경우에는 재심사에 따른 특허여부 결정이 아닌 일반심사에 따른 특허여부결정이기 때문에 다시 재심사 청구를 할 수 있다(法 67 의2①Ⅱ팔호). iii)의 경우 분리출원은 거절결정불복심판에서의 기각심결이 있는 후 제한된 범위인 특허가능한 청구항에 대해서 신속히 권리획득기회를 주는 제도이기 때문에, 이를 재심사로 다루는 것을 제한하고 있다.



【그림 4-14】 재심사 청구의 시기

(3) 절 차

재심사를 청구하려는 자는 보정서에 그 취지를 적어 지식재산처장에게 제출하여야 한다(施規 37의2①). 이때 출원인은 재심사의 청구와 함께 의견서를 제출할 수 있다(法 67의2②).

(4) 적법한 경우의 효과: 특허여부결정의 취소 간주 및 재심사

1) 심사관은 재심사가 청구된 경우 그 특허출원에 대하여 종전에 이루어진 특허결정 또는 특허거절결정은 취소된 것으로 보고 출원에 대한 재심사를 진행한다(法 67의2③본문). 구체적으로 심사관은 제51조제1항에 의하여 보정의 적법성을 판단하여⁴⁹⁾ 보정이 적법하면 보정의 소급효가 인정되기 때문에 보정 후 명세서 또는 도면에 의하여, 보정이 부적법하면 보정은 보정각하하고 보정 전 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원의 거절이유(法 62)가 있는지 판단하여 다시 특허여부결정을 하게 된다.⁵⁰⁾

2) 한편 심사관은 재심사의 청구 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①Ⅱ)에 한 보정이 보정의 범위를 벗어나거나(法 47②③) 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생했음에도 불구하고 일반심사단계에서 보정각하결정을 하지 아니하고 이를 간과하여 추후 재심사단계에서 발견한 경우에는 보정을 인정하고 심사를 진행한다(法 51①Ⅲ).

(5) 적법한 경우의 효과: 취하금지

재심사의 청구는 취하할 수 없다(法 67의2④). 이는 재심사 청구가 있는 경우 특허결정 또는 특허거절결정은 취소된 것으로 간주되므로 재심사 청구의 취하에 따라 절차상 혼란이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 재심사 청구에 대한 취하서가 제출되는 경우 서류의 종류가 불명확한 것으로 보아 반려된다.

(6) 부적법한 경우의 효과

1) 재심사의 청구절차가 절차보정사유(法 46)에 해당하여 제16조제1항에 따라 무효로 된 경우에는 특허결정 또는 특허거절결정은 취소되지 아니한 것으로 본다(法 67의2③단서).

2) 출원인이 i) 명세서 또는 도면의 보정없이 재심사 청구한 경우, ii) 재심사를 청구할 때 이미 재심사에 따른 특허여부결정이 있는 경우, iii) 재심사를 청구할 때 거절결정불복심판이 있는 경우(제176조제1항에 따라 특허거절결정이 취소된 경우는 제외한다) 또는 iv) 재심사 청구한 출원이 분리출원인 경우에는 재심사 청구서는 반려된다.⁵¹⁾

49) 보정각하 후 거절결정이 되었는데 재심사 청구를 하였으면 심사관은 제47조제3항 위반 여부를 판단할 때 보정각하 전 청구범위와 비교하여 판단한다. 한편 심사관이 직권보정을 한 출원에 대한 재심사의 경우, 재심사 청구에 의하여 특허결정이 취소되더라도 직권보정은 취소되지 아니한다. 따라서 직권보정이 반영된 명세서 및 도면과 재심사 보정 사항을 비교하여 보정각하 여부를 판단한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 5402. 5404면).

50) 이미 통지된 거절이유라도 거절결정이유가 아닌 경우에는 재심사 청구할 때 한 보정이 해당 거절이유를 해소하지 못하였더라도 바로 거절결정하지 않고 의견제출의 기회를 부여한다. 다만 이미 통지된 거절이유가 명세서 등 보정에 의하여 거절결정 당시에는 해소되었으나, 재심사 청구 보정에 의하여 다시 발생한 경우에는 해당 거절이유는 이미 출원인에게 의견제출의 기회 및 실질적인 보정의 기회를 부여한 것으로 간주하여 거절결정한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025. 5407면).

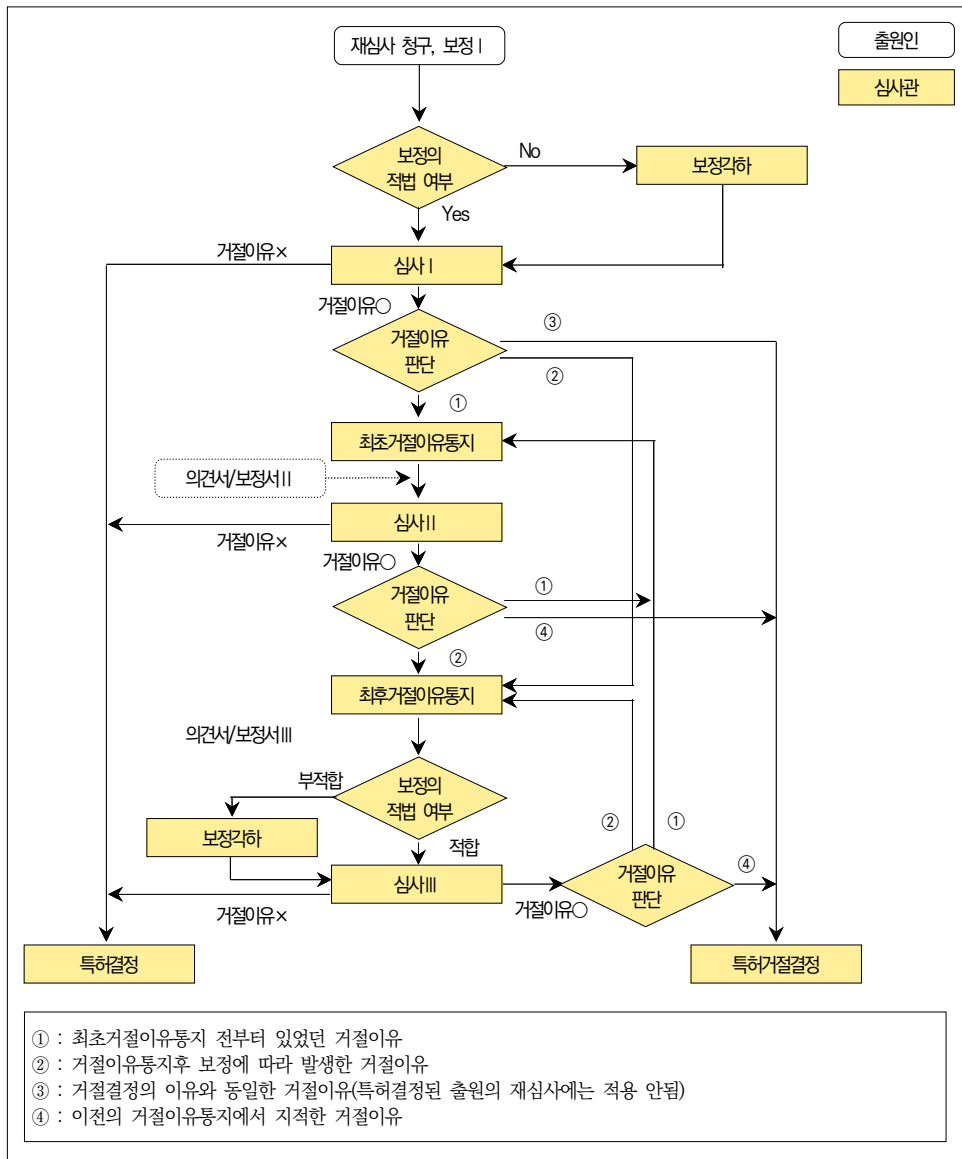
(7) 특허출원의 회복

특허출원인이 정당한 사유로 재심사의 청구를 할 수 있는 기간을 지키지 못하여 특허거절결정이 확정⁵²⁾된 것으로 인정되는 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 재심사의 청구를 할 수 있고, 이 경우 특허거절결정이 확정되지 아니한 것으로 본다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다(法 67의3). 2013. 7. 1. 시행된 현행법(법률 제11654호, 2013. 3. 22. 개정)에서는 출원인의 권리보호를 강화하는 한편 향후 가입할 특허법조약과의 합치를 도모하기 위해 이 규정을 신설하였다.

- 51) 재심사 청구와 거절결정불복심판이 같이 청구된 때에는 다음과 같이 취급한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5402-5403면).

구 분	취급
심판청구서를 제출한 후 재심사 청구 취지를 적은 보정서를 제출한 경우	제67조의2제1항제2호에서 재심사를 청구할 때에 이미 거절결정불복심판이 청구된 경우에는 재심사를 청구할 수 없다고 규정하고 있는바, 보정서 제출 시점을 기준으로 심판청구가 계속 중인 경우에는 특허법 시행규칙 제11조제1항제19호를 이유로 소명 기회를 부여하고 보정서를 반려한다. 이때 보정서를 반려 받은 출원인은 제67조의2제1항의 기간이 지나지 않았다면 심판청구를 취하고 보정하면서 재심사를 다시 청구할 수 있다.
재심사 청구 취지를 적은 보정서를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우	보정서 제출에 따른 보정 및 재심사 청구 절차는 적법하므로 특허거절결정이 취소된 것으로 보고 재심사절차를 진행한다. 이 경우 심판절차는 심결각하된다.
심판청구서와 재심사 청구 취지를 적은 보정서가 동일자로 제출된 경우	심판청구서와 보정서의 제출 시점을 확정할 수 없는바, 출원인의 선택을 유도하기 위해 보정서가 늦게 제출된 것으로 보고 보정서에 대하여 반려이유를 즉시 통지한다. 반려이유통지서에서는 출원인이 거절결정불복심판이나 재심사 중 어느 하나를 선택할 수 있음을 상세히 설명하여야 한다. 출원인이 심판청구를 취할 때는 재심사 청구가 유효한 것으로 보고 재심사절차를 진행하고, 반려 요청할 때는 보정서를 즉시 반려하고, 심판절차를 진행한다.
심판청구서와 재심사 청구 취지가 기재되지 아니한 보정서를 동일자에 제출한 경우	보정서에 재심사 청구의 취지가 기재되지 않는바, 보정서는 보정이 가능한 기간에 제출된 것으로 볼 수 없으므로 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간에 제출되지 아니한 서류로 취급하여 소명 기회를 부여한 후 보정서를 반려한다.

- 52) 거절결정이 확정되기 위해서는 재심사청구기간 중 제67조의2제1항제2호의 특허거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월(제15조제1항에 따라 제132조의17에 따른 기간이 연장된 경우 그 연장된 기간을 말한다)에 한한다.



【그림 4-15】 특허거절결정에 대한 재심사 청구의 심사절차도⁵³⁾

53) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5402면

제3절 특허출원의 취하와 포기에 의한 종료

I. 서 설

1. 의 의

「특허출원의 취하 또는 포기」란 출원인의 의사 또는 법률에 의하여 출원 계속의 효과를 소멸시키는 것을 말한다.

2. 취 지

출원인 스스로 출원 계속을 소멸시키고 싶거나 심사의 원활화를 위해 출원 계속을 소멸시킬 필요가 있는 경우에 출원의 취하나 포기를 할 수 있도록 하여 출원인의 의사를 존중하고 심사의 편의를 도모하고 있다.

II. 의사에 의한 특허출원의 취하·포기

1. 특허출원의 취하·포기를 할 수 있는 자

(1) 출원인

특허출원인 스스로 특허출원을 취하·포기할 수 있다. 공동출원의 경우에는 공유자 모두가 특허출원을 취하·포기하여야 한다. 2명 이상이 공동으로 특허출원을 하고 대표자를 선정하여 지식재산처에 신고하였으면 견해의 대립은 있으나, 심사 실무⁵⁴⁾는 이는 불이익행위로서 다른 공동출원인의 명시적 동의가 있어야 해당 절차를 밟을 수 있도록 하고 있다(法 11). 한편 이와는 별도로 공동출원인 중 1명이 특허를 받을 수 있는 권리를 포기할 때는 출원의 포기와는 달리 자기의 지분을 포기하는 것이므로 다른 공동출원자의 동의가 없어도 마음대로 자기의 지분을 포기할 수 있다.

(2) 대리인

법정대리인의 경우 친권자는 언제나 절차를 밟을 수 있으나, 후견인은 후견감독인의 동의가 필요하다. 한편 임의대리인의 경우는 특별히 권한을 위임받아야 한다(法 6).

2. 특허출원의 취하·포기의 대상

(1) 원 칙

원칙적으로 특허출원발명 전체에 대하여 취하·포기를 할 수 있을 뿐 청구항별 취하·포기는

54) 지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 1216면.

인정되지 아니한다. 다만 둘 이상의 청구항이 있는 특허출원에 대한 특허결정을 받은 자가 특허료를 낼 때에는 청구항별로 이를 포기할 수 있다(法 215의2①).

(2) 청구항별 일부취하의 허용 여부

청구항별 일부 취하가 허용되는지에 대하여 판례⁵⁵⁾는 “출원서에 첨부된 명세서와 도면의 보정이라는 제도 및 그 보정의 시기와 범위를 제한하는 규정을 두고 있을 뿐 특허결정이 되기 전에 특허출원의 일부를 취하할 수 있다고 규정해 놓은 바 없으며, 특허법에 정해진 보정기간이 지난 후에도 특허출원의 일부 취하를 허용하는 것은 특허출원의 보정에 엄격한 시기적 제한을 두고 있는 특허법의 취지에도 반하므로 원칙적으로 청구항별 일부 취하는 허용되지 아니한다”라고 하여 일부 취하서를 삭제보정서와 동일시하고 있다. 즉 청구항별 일부 취하를 하는 경우 보정기간의 제한을 가하여, 보정기간을 지난 일부 취하서를 불수리하는 한편 특허출원을 거절 결정하였다.⁵⁶⁾

3. 특허출원의 취하·포기의 시기

특허출원이 출원 계속 중이라면 언제든지 특허출원의 취하·포기를 할 수 있다. 즉 출원인은 특허출원이 설정등록되거나 무효 또는 특허거절결정이 확정되기 전까지 자유로이 해당 특허출원을 취하·포기할 수 있다.

4. 특허출원의 취하·포기의 절차

특허에 관한 절차를 밟는 자가 그 절차를 취하·포기하려면 취하서 또는 포기서를 지식재산 처장에게 제출하여야 한다(施規 19①). 한편 출원인이 전자문서이용신고를 한 경우에는 취하서 또는 포기서를 전자문서로도 제출할 수 있다(施規 9의2①). 제출된 취하서 또는 포기서가 적법하게 수리된 경우 그 때부터 해당 특허출원은 취하 또는 포기된 것으로 취급된다.⁵⁷⁾

55) 대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044.

56) 다만 i) 특허를 받을 수 있는 권리의 포기는 법률에 의하지 아니하면 제한할 수 없는 국민의 자유인데 심사나 심판의 편의를 위해 법률에 특별한 규정없이 보정기간에 제한을 두는 것은 타당하지 아니한다는 점, ii) 둘 이상의 청구항을 가지게 된 출원은 애초에 발명별로 출원이 가능하고, 이 경우에 각 출원별로 자유롭게 출원을 취하할 수 있었는데 단순히 출원 또는 심사상의 편의를 도모하고자 둘 이상의 발명을 1출원으로 하게 된 경우에 일부 취하가 허용되지 아니한 것은 다항제 및 1특허출원범위의 취지에 반한다는 점을 감안할 때 청구항별 일부 취하를 허용하여야 한다는 비판이 있다(박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002, 304-305면).

57) 출원인이 출원의 취하를 위해 취하서를 제출한 이후 이를 다시 취소할 수 있는지가 문제이다. 이에 대하여 출원의 취하의 취소를 인정할 수 없다는 부정설과 출원의 취하가 출원인이나 대리인의 중대한 착오에 의한 경우에는 그 취소를 인정할 수 있다는 긍정설로 견해가 대립되는데, 심사 실무는 절차의 명확성과 안정성을 위하여 표시주의를 원칙으로 하는 민사소송에서와 같이 출원의 취하의 취소는 원칙적으로 인정할 수 없다는 부정설을 취하고 있다.

III. 법률에 의한 특허출원의 취하·포기

1. 법률에 의한 취하

(1) 국내출원의 경우

다음 중 어느 하나의 경우에 특허출원은 취하된 것으로 본다.

- i) 특허출원인이 명세서에 청구범위를 적지 아니하고 특허출원하였는데 i) 출원일(우선권 주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월 또는 ii) 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하지 아니한 경우(法 42의2②)
- ii) 특허출원인이 외국어특허출원하였는데 i) 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월 또는 ii) 제3자의 출원심사 청구의 취지를 통지받은 날부터 3개월이 되는 날 중 빠른 날까지 그 명세서의 국어번역문을 총리령으로 정하는 방법에 따라 제출하지 아니한 경우(法 42의3②)
- iii) 변경출원의 기초가 되는 원특허출원의 경우(法 53④)
- iv) 출원일로부터 3년 이내에 심사청구하지 아니한 특허출원의 경우(法 59⑤)
- v) 국내우선권주장의 기초가 된 선출원이 그 출원일로부터 1년 3개월을 지난 경우(다만 그 선출원이 i) 포기, 무효 또는 취하된 경우, ii) 설정등록되었거나 특허거절결정, 실용신안등록거절결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우, iii) 선출원을 기초로 한 우선권주장이 취하된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다)(法 56①)

(2) 국제출원의 경우

다음 중 어느 하나의 경우에 국제출원 또는 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

- i) 국제출원에 대하여 제195조의 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정하지 아니한 경우(法 196①I)
- ii) 국제출원에 관한 수수료 미납부에 대한 보정명령을 받은 날로부터 1개월(施規 106) 이내에 내지 아니한 경우(法 196①II)
- iii) 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 국제출원일로부터 4개월 이내에 그 국제출원이 보완사유(法 194①각호)에 해당하는 경우(法 196①III)
- iv) 국제특허출원의 경우 국내서면제출기간(국어번역문 제출기간이 연장된 경우 연장된 기간)에 발명의 설명, 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(法 201④)
- v) 국제특허출원이 국내우선권주장의 선출원인 경우 국제출원일로부터 1년 3개월이 지난 때와 기준일 중 늦은 때인 경우(法 202③III)
- vi) 국제특허출원의 출원인인 재외자가 기준일이 지난 후 2개월(施規 116) 이내에 특허관리인을 선임·신고하지 아니한 경우(法 206③)
- vii) 국제조사기관이 인정하지 아니하는 언어로 국제출원이 되었는데 출원인이 국제조사를 위하여 국제조사기관이 인정하는 언어로 된 번역문을 지식재산청장에게 제출하지 아니한 경우(施規 95의2).

2. 법률에 의한 포기

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 본다(法 81③).

IV. 특허출원의 취하·포기의 효과

1. 절차의 종료

특허출원이 취하·포기된 경우 i) 심사계속 중이면 심사가 종료되고, ii) 거절결정불복의 심판계속 중이면 흠결을 보정할 수 없는 부적법한 심판으로서 심결각하의 대상이 된다. 그 결과 특허출원 절차가 취하·포기에 의하여 종료된 이후에는 분할출원(法 52), 분리출원(法 52의2), 변경출원(法 53) 및 국내우선권주장출원(法 55)의 기초가 될 수 없다. 다만 조약우선권주장출원은 우선권의 독립성으로 인하여 제1국 출원에서 출원일자가 일단 부여되면, 즉 제1국 출원의 정규성이 인정된다면 특허출원이 취하·포기되어도 그 출원을 기초로 제2국에 조약우선권주장출원을 할 수 있다(法 54).

2. 등록금지적 효력

출원공개 후에 특허출원이 취하·포기되면 출원공개된 발명의 내용에 의하여 출원공개 전 후출원에 대해서는 확대된 선출원의 지위(法 29③)에 의하여, 출원공개 후 후출원에 대해서는 공지기술의 지위(法 29①각호, 29②)에 의하여 후출원의 등록을 금지시킬 수 있다. 한편 취하·포기된 특허출원은 선출원의 지위가 인정되지 아니한다(法 36④).⁵⁸⁾

3. 보상금청구권의 소멸

보상금청구권은 특허출원이 취하·포기되면 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다(法 65⑥).

58) 구법에서는 취하된 출원에는 선출원의 지위를 인정하지 않고, 포기된 출원에는 선출원의 지위를 인정하였으나, 2006. 3. 3. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정)에서는 양자 모두 선출원의 지위를 인정하지 않고 있으므로(法 36④) 양자의 구별 실익이 크지 않다고 할 것이다.

제6장

심사와 관련된 제도

제1절 정보제공제도

제63조의2 【특허출원에 대한 정보제공】

특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 지식재산처장에게 제공할 수 있다. 다만, 제42조제3항제2호, 같은 조 제8항 및 제45조에 따른 요건을 갖추지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「정보제공제도」란 특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 제62조 각호의 거절이유(단, 法 42③Ⅱ·42⑧·45 제외) 규정에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 지식재산처장(거절결정불복심판단계에서는 심판원장)에게 제공할 수 있는 제도를 말한다.

2. 취 지

특허출원에 관하여 누구든지 그 출원이 특허되어서는 아니 된다는 정보를 증거와 함께 제공함에 함으로써 심사관에 의한 심사의 신속성 및 정확성을 높여 심사의 질적 향상에 기여하도록 함에 정보제공제도의 취지가 있다.

II. 정보제공사유

1. 주체적 사유

- ① 외국인으로서 특허에 관한 권리를 누릴 수 없는 자가 특허출원한 경우(法 25)
- ② 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 자가 출원한 경우(法 33①본문)

- ③ 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원이 상속이나 유증의 경우를 제외하고 재직 중 특허출원한 경우(法 33①단서)
- ④ 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공유자 모두가 공동으로 출원하지 아니한 경우(法 44)

2. 실체적 사유

- ① 특허요건(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성, 소위 확대된 선출원)에 위반된 경우(法 29)
- ② 특허를 받을 수 없는 발명에 해당하는 경우(法 32)
- ③ 선출원 규정(法 36①-③)을 위반한 경우
- ④ 일반적인 발명의 설명의 기재불비의 경우(法 42③ 1)
- ⑤ 청구범위 기재불비의 경우(法 42④)
- ⑥ 신규사항추가인 보정의 경우(法 47②)
- ⑦ 분할출원의 범위를 벗어난 경우(法 52①)
- ⑧ 분리출원의 범위를 벗어난 경우(法 52의2①)
- ⑨ 변경출원의 범위를 벗어난 경우(法 53①)

3. 조약 위반

특허제도의 국제화 경향에 따라 조약, 협정, 약정 등은 특허 실체법의 중요한 부분을 구성하고 있으므로 조약에 위반되는 경우를 정보제공사유로 하고 있다.

4. 거절이유와 비교

발명의 설명 중 배경기술 기재(法 42③II), 다항제 기재방법(法 42⑧) 및 하나의 특허출원의 범위(法 45)는 정보제공의 사유에 해당하지 아니한다. 이는 출원발명에 대한 실체적인 특허요건이 아니라 절차적인 요건으로서 일반 공중보다 심사관이 더욱 잘 파악할 수 있기 때문이다.

III. 정보제공의 요건

1. 정보제공자

누구든지 정보제공을 할 수 있다. 일반 공중을 심사에 참여시켜 심사의 정확성 및 신속성을 향상시킨다는 정보제공의 취지에 비춰 볼 때 누구든지 정보제공을 할 수 있도록 함이 타당하다.

2. 정보제공시기

1) 지식재산처에 출원 계속 중이면 언제든지 정보제공을 할 수 있다. 따라서 출원이 무효, 취하, 포기, 설정등록되기 전이나 출원의 특허거절결정이 확정되기 전까지 정보제공을 할 수 있다. 구체적으로 정보제공은 특허출원이 심사국에 계속 중인 경우뿐만 아니라 특허심판원에 계속 중인 경우, 즉 거절결정불복심판이 청구된 경우에도 할 수 있다(法 170① 준용 63의2).⁵⁹⁾ 한편 특허결정된 특허출원에 대하여 설정등록 전에 정보제공된 경우, 심사관은 제출된 증거자료를 살펴서 특허결정된 특허출원에 명백한 거절이유가 있다면 직권 재심사를 하게 된다(法 66의3).

2) 구법에서는 출원공개 후에만 정보제공할 수 있도록 하였으나 심사처리기간이 단축되어 공개 전 심사가 일반화되면 정보제공이 이루어지기 전에 심사가 완료되어 정보제공제도의 취지를 살릴 수 없으므로 2006. 10. 1. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정)에서는 출원공개 전이라도 출원 계속 중이면 언제든지 정보제공을 할 수 있도록 하고 있다. 다만 특허출원이 출원공개되기 전에는 제3자가 출원된 발명의 내용을 파악하기 힘들어서 출원공개 전 정보제공을 하는 경우는 출원인이 자발적으로 발명을 공개하기 전에는 극히 드물 것으로 보인다.

3) 취소신청과 비교하여 실무적인 관점에서 살펴보면, 상대적으로 저렴한 비용으로 설정등록 전에 권리범위의 감축, 변경의 필요성이나 설정등록되는 것을 저지해야 할 필요성의 측면에서는 정보제공이 적절하다. 그러나 정보제공을 하는 경우 출원인에게 보정, 분할출원 등을 통해 폭넓게 권리범위의 재설계 기회가 제공되는데 반해, 설정등록 후 취소신청을 하는 경우 취소신청이 특허심판원에 계속 중인 동안 특허권자에게 제한적인 정정만 허용되기 때문에 출원인(특허권자)의 대응기회를 줄이겠다는 측면에서는 정보제공보다는 취소신청이 더 적절하다고 여겨진다.

IV. 정보제공의 절차

정보제공자는 제62조 각호(단, 法 42③Ⅱ·42⑧·45 제외) 규정에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 지식재산처장(거절결정불복심판단계에서는 심판원장)에게 제출할 수 있다(施規 45). 일반적으로 정보제공시 제출되는 증거로는 간행물이나 그 사본 또는 출원 명세서나 도면의 사본이 제출되나, 그 이외의 것을 증거로 제출할 수도 있다.

59) 정정심판에서는 제3자가 정보제공을 할 수 있다는 근거 규정이 명확하지 아니하나, 정정불인정이유가 있는 증거가 제출되어 직권심리가 가능한데도 이를 살피지 아니한다면 공익에 반하는 결과를 초래하므로, 정정심판에 있어서도 정보제공을 할 수 있다. 예를 들어 정정심판의 대상이 되는 권리에 대하여 무효심판의 심결취소소송이 계속되고 있는 경우 무효심판청구인에게 정정심판 사실을 통지하여, 무효심판청구인이 소송단계에서 새로 제출된 무효 증거를 기초로 정정심판에 대한 정보제공할 수 있는 기회를 부여한다(특허심판원, 「심판판람」, 제14판, 2024, 179면).

V. 정보제공의 효과

1. 심사의 참고

1) 심사관은 제출된 정보를 근거로 특허거절결정을 하여야 하는 의무는 없다. 즉 제출된 증거를 채택할지는 심사관의 재량사항이다. 또한 정보제공자는 특허법상 그 특허출원에 관한 절차에서의 당사자가 아니기 때문에 심사관은 제출된 정보의 채택 여부에 관해 정보제공자에게 통지할 의무는 없다. 그러나 심사 실무⁶⁰⁾상 정보제공이 있는 특허출원이 특허거절결정, 특허결정이나 그 밖의 사유로 심사가 종결되는 때에는 심사관이 그 결과 및 제출정보의 활용 여부를 정보제공자에게 통보하도록 하고 있다.

2) 한편 심사 실무⁶¹⁾상 정보제공이 있는 출원에 대하여 정보제공이 있다는 사실을 출원인에게 통지하고 있다.

2. 심사의 신속성 및 정확성 향상

심사관은 심사에 있어 필요한 자료 및 증거 등을 쉽게 수집할 수 있어, 그 출원에 대한 심사를 신속하고 정확하게 할 수 있다. 아울러 일반 공중에 의한 심사 협조를 통해 완전한 심사가 이루어지면 하자 있는 권리의 발생가능성이 그만큼 줄어들게 되므로 특허권의 법적 안정성이 확보된다.

제2절 출원공개제도

제64조 【출원공개】

- ① 지식재산청장은 다음 각 호의 구분에 따른 날부터 1년 6개월이 지난 후 또는 그 전이라도 특허출원인이 신청한 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 출원공개를 하여야 한다.
 1. 제54조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 그 우선권 주장의 기초가 된 출원일
 2. 제55조제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 선출원의 출원일
 3. 제54조제1항 또는 제55조제1항에 따른 둘 이상의 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 경우: 해당 우선권 주장의 기초가 된 출원일 중 최우선일
 4. 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하지 아니하는 특허출원의 경우: 그 특허출원일
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.
 1. 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우
 2. 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)
 3. 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허의 경우
- ③ 제41조제1항에 따라 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허출원의 출원공개를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 제1항에 따라 출원공개를 하여야 한다. 다만, 그 특허출원이 설정등록된 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.

60) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5371면.

61) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5356면

- ④ 제1항의 출원공개에 관하여 출원인의 성명·주소 및 출원번호 등 특허공보에 게재할 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제65조 【출원공개의 효과】

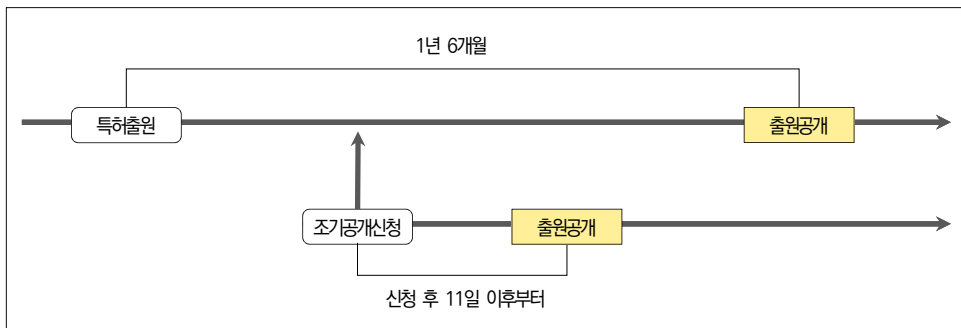
- ① 특허출원인은 출원공개가 있는 후 그 특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 특허출원된 발명임을 서면으로 경고할 수 있다.
- ② 특허출원인은 제1항에 따른 경고를 받거나 제64조에 따라 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. <개정 2019. 1. 8.>
- ③ 제2항에 따른 청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다.
- ④ 제2항에 따른 청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다.
- ⑤ 제2항에 따른 청구권을 행사하는 경우에는 제127조·제129조·제132조 및 「민법」 제760조·제766조를 준용한다. 이 경우 「민법」 제766조제1항 중 “피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날”은 “해당 특허권의 설정등록일”로 본다.
- ⑥ 제64조에 따른 출원공개 후 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제2항에 따른 청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다. <개정 2016.2.29.>
 1. 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우
 2. 특허출원에 대하여 제62조에 따른 특허거절결정이 확정된 경우
 3. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이 확정된 경우
 4. 제133조에 따른 특허를 무효로 한다는 심결(같은 조 제1항제4호에 따른 경우는 제외한다)이 확정된 경우

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「출원공개제도」란 특허출원된 내용에 대하여 심사청구의 유무와 관계없이 출원일로부터 1년 6개월이 지난 후 또는 특허출원일부터 1년 6개월이 지나기 전이라도 출원인의 신청이 있으면 그 특허출원에 관하여 특허공보에 게재하여 사회일반에 공표하는 제도를 말한다.



【그림 4-16】 출원공개제도 일반

2. 취 지

특허출원 후 오랫동안 출원발명이 일반 공중에게 공표되지 아니한 경우 특허공보의 기술문헌으로서의 가치가 현저히 떨어질 뿐만 아니라 출원된 발명과 동일한 발명에 대하여 제3자가 중복투자 또는 중복연구를 하게 되는 폐해가 발생하게 된다. 따라서 이러한 폐해를 줄이고 출원발명을 조기에 공개시켜 기술문헌으로서 제3자가 이용하게 함으로써 산업발전에 이바지하기 위해 전통적 심사주의에 대한 수정방안 중 하나로서 출원공개제도를 도입하게 되었다.

II. 출원공개의 요건

1. 출원공개의 신청인

출원공개를 신청하지 않더라도 지식재산처장에 의하여 강제공개되나, 출원인의 신청에 의하여 조기공개가 가능하다. 조기공개신청의 경우 공동출원을 한 경우에는 공동출원인 각자가 할 수 있으며(法 11), 임의대리인의 경우에는 특별히 권한을 위임받지 아니하여도 된다(法 6).

2. 출원공개의 대상

(1) 원 칙

출원공개를 할 당시에 지식재산처에 출원 계속 중인 출원이어야 한다. 따라서 출원공개 전에 그 특허출원이 취하·포기·무효로 되거나 특허거절결정이 확정되면 출원공개 대상이 되지 아니한다.

(2) 예 외

① 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우(法 64②Ⅰ)

특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우에는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권 주장출원의 경우 최우선일로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)까지 명세서에 청구범위를 적는 보정을 하여야 하고(法 42의2②), 보정하지 아니한 경우에는 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하된 것으로 보기 때문에(法 42의2③) 출원공개되지 아니한다.

② 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다)(法 64②Ⅱ)

특허출원인이 외국어특허출원을 한 경우에는 출원일(우선권주장의 경우 최우선일)로부터 1년 2개월이 되는 날(제60조제3항에 따른 출원심사 청구의 취지를 통지받은 경우에는 그 통지를 받은 날부터 3개월이 되는 날 또는 출원일(우선권 주장출원의 경우 최우선일로부터 1년 2개월이 되는 날 중 빠른 날)까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 총리령으로 정하는 방법에 따라

제출하여야 하고(法 42의3②), 명세서의 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 기한이 되는 날의 다음 날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 보기 때문에(法 42의3④) 출원공개되지 아니한다.

③ 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허의 경우(法 64②Ⅲ)

출원일로부터 1년 6개월이 지나기 전에 특허결정이 되고 특허료가 납부되어 설정등록이 되면 등록공고가 출원공개보다 선행될 수 있다. 이 경우 등록공고는 특허가 확정된 발명의 내용을 일반에게 공표하여 침해하지 않도록 유도하는 기능과 아울러 출원공개의 발명 공표적 기능까지를 대행한다. 따라서 출원공개 전 등록공고가 된 경우에는 출원공개를 다시 할 필요가 없다.

④ 국방상 필요한 발명으로서 비밀취급이 필요한 경우(法 64③)

국방상 필요한 발명으로서 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허출원의 출원공개를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 출원공개를 하여야 한다. 다만 그 특허출원이 설정등록된 경우에는 출원공개를 하지 아니한다.

⑤ 공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 경우(令 19③)

3. 출원공개의 시기

1) 특허출원일로부터 1년 6개월이 지난 후 강제공개된다.⁶²⁾ 여기서 「특허출원일」은 i) 무권리자에 대한 정당한 권리자 출원의 경우 무권리자의 출원일(法 34, 35), ii) 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일,⁶³⁾ iii) 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 최우선일을 기준으로 한다.

2) 한편 특허출원일로부터 「1년 6개월」 전이라도 출원인의 신청에 의하여 조기공개가 가능하며 조기공개신청이 있는 경우 신청이 있는 날로부터 11일 이후부터 공개될 수 있다. 이와 같은 조기공개제도는 출원일로부터 1년 6개월이 지나기 전이라도 제3자가 출원발명을 무단 실시하는 경우 보상금청구권의 발생이 가능하게 하고, 출원인이 우선심사신청을 할 수 있도록 하여 출원인을 보호하려는 데에 그 취지가 있다.

62) 특허출원의 공개시기와 관련하여 현행 특허법에서는 확립적으로 「출원일로부터 1년 6개월」로 규정되어 있다. 즉 출원 후 1년 6개월의 기간을 지연시킨 후에 공개한다는 규정이다. 여기에서 「1년 6개월」의 기간은 나름대로의 의미가 있는 기간이다. 출원공개는 그 시기가 빠를수록 그 제도의 취지에 어울리는 것이지만 특허제도가 재내자만을 위한 것이 아니고, 재외자의 출원도 고려하여야 하는 국제성이 강한 제도라는 점을 감안하여 그 출원의 공개시기도 고려하여야 한다. 즉 우선권주장을 수반하는 외국인의 출원은 출원공개 시점에 대한 시기의 기준은 최우선일로 하고 있다. 그러므로 우선권주장을 수반하는 출원에 대한 국내 출원일(최우선일로부터 1년 이내)과 출원 후 우선권증명서류의 제출기간(최우선일로부터 1년 4개월) 및 출원공개를 위한 특허공보의 제작에 소요되는 기간 등을 감안하여 출원공개시기를 「출원일(최우선일)로부터 1년 6개월」로 정한 것이다(이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 517면).

63) 분할출원, 분리출원 또는 변경출원이 i) 원출원일로부터 1년 6개월 이내에 출원된 경우에는 원출원일로부터 1년 6개월이 된 시점에 공개하여야 하며, ii) 원출원일로부터 1년 6개월이 지난 후에 출원된 경우에는 그 후 지체없이 출원을 공개하여야 한다.

Ⅲ. 조기공개신청의 절차 및 출원공개의 방법

1. 특허출원의 조기공개 신청

(1) 조기공개신청서의 제출

1) 「출원인」은 자신의 출원발명이 출원일로부터 1년 6개월이 지나기 전에 출원공개될 필요가 있을 때는 지식재산처장에게 그 취지를 적은 신청서를 제출하여야 한다. 다만 특허출원과 동시에 신청하는 경우(청구범위가 기재된 명세서가 첨부된 경우만 한한다) 출원서에 그 취지를 기재함으로써 신청서의 제출에 갈음할 수 있다(施規 44①). 한편 출원의 조기공개신청제도는 출원인의 이익을 위한 제도이므로 출원인을 제외한 제3자는 조기공개신청을 할 수 없다.

2) 출원의 조기공개를 신청할 때는 별도로 수수료를 내지 아니한다. 특허출원일로부터 1년 6개월이 지난 후에 의무적으로 공개하는 대신에 출원인의 신청에 의하여 출원공개를 하는 시기를 앞당기는 것일 뿐이기 때문이다. 이는 출원공개를 신청할 때 수수료를 별도로 내야 하는 디자인보호법상의 출원공개제도와 국제출원의 조기공개제도와 다른 점이다.

3) 한편 i) 명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우, ii) 제42조의3제2항에 따른 국어번역문을 제출하지 아니한 경우(외국어특허출원의 경우로 한정한다) 및 iii) 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허 중 어느 하나에 해당하는 경우는 출원공개의 대상이 아닌데 이에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우 지식재산처장은 조기공개신청서를 불수리하여야 한다(施規 11).

(2) 조기공개신청의 취하

조기공개신청 후 출원인이 조기공개신청을 취하할 수도 있다. 이때 출원인이 조기공개신청을 취하하려는 경우에는 조기공개신청서를 제출한 날로부터 10일 이내에 취하서를 제출하여야 한다(施規 44③). 출원발명을 조기공개하면 제3자에게 정보제공할 수 있는 기회를 제공할 뿐만 아니라 모방품의 출현으로 인해 출원발명의 가치가 현저히 훼손될 가능성이 있고, 나중에 개량발명을 하여 특허출원하려는 출원인에게 불이익이 될 우려도 있으므로 출원인의 의사에 의하여 신청 후 10일 이내 취하할 수 있도록 하고 있다.

2. 출원공개의 방법

(1) 전문공개

출원공개의 방법에는 i) 출원의 중요한 부분만을 공개하는 방법(要部공개)과 ii) 출원내용의 전문을 공개하는 방법(全文공개)이 있는데, 현행 특허법은 특허출원의 서지적 사항과 명세서 또는 도면 전부를 특허공보에 게재하여 공개하는 전문공개방식을 취하고 있다.

(2) 공개특허공보의 발행

출원공개는 공개특허공보에 다음의 사항을 게재함으로써 행해진다(令 19③). 이러한 공개특허공보는 전자적 매체(CD-ROM)로도 발행할 수 있다.

- i) 다음의 구분에 따른 사항
 - 가. 출원인이 자연인인 경우: 성명 및 주소
 - 나. 출원인이 법인인 경우: 법인의 명칭 및 영업소의 소재지
- ii) 출원번호·분류기호 및 출원연월일
- iii) 발명자의 성명 및 주소⁶⁴⁾
- iv) 출원공개번호 및 공개연월일
- v) 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 및 도면. 다만 제42조의3제1항에 따라 명세서 및 도면을 국어가 아닌 언어로 적은 특허출원(이하 "외국어특허출원"이라 한다)과 제199조 제1항에 따른 국제특허출원 중 국어가 아닌 언어로 적은 국제특허출원(이하 "외국어국제특허출원"이라 한다)의 경우에는 다음의 구분에 따른 명세서(외국어국제특허출원의 경우에는 발명의 설명 및 청구범위를 말한다.) 및 도면으로 한다.
 - 가. 외국어특허출원의 경우: 제42조의3제5항에 따라 보정한 것으로 보는 명세서 및 도면
 - 나. 외국어국제특허출원의 경우: 제201조제5항에 따라 보정한 것으로 보는 명세서 및 도면
- vi) 특허출원서에 첨부된 요약서
- vii) 제42조의2제2항에 따른 명세서 보정에 관한 사항
- viii) 우선권주장에 관한 사항
- ix) 분할출원, 분리출원 또는 변경출원에 관한 사항
- x) 제60조제2항에 따른 출원심사의 청구사실. 다만 출원공개시에 그 사실이 게재되지 아니한 경우에는 해당 출원의 공개번호·분류기호 및 출원번호를 그 심사청구사실과 함께 추후 발행되는 공개특허공보에 게재하여야 한다.
- xi) 제63조의2의 규정에 의하여 누구든지 그 특허출원이 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 지식재산처장에게 제공할 수 있다는 취지
- xii) 기타 특허출원의 공개에 관계되는 사항

IV. 출원공개의 효과

1. 보상금청구권의 발생

(1) 의의 및 취지

1) 「보상금청구권」이란 특허출원인이 출원공개가 있는 후 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고 그 특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있는 권리를 말한다(法 65①②).

64) 지식재산처장은 자연인인 출원인 또는 발명자의 주소를 게재하는 경우 그 특허권자, 출원인 또는 발명자의 신청이 있으면 그 주소의 일부만을 게재할 수 있다(施規 19④).

2) 특허법은 특허출원된 발명의 내용을 공개시켜 일반 공중에게 중복투자·중복연구를 방지하도록 하는 대신 공개된 발명에 대하여 제3자의 모방이나 도용에 의하여 출원인의 이익이 훼손되므로 그 상실된 이익을 보전하기 위해 보상금청구권을 인정하고 있다.

(2) 법적성질

보상금청구권은 i) 출원 계속 상태의 종료 또는 특허권의 소멸시 소급하여 소멸하는 해제조건부 권리이고, ii) 제3자가 출원발명을 무단실시한 경우 독점·배타적 권리인 특허권과는 달리 제3자의 실시를 배제할 수는 없으며 단지 제3자의 실시가 없었다면 출원인이 더 많이 이익을 얻을 수 있었던 이익의 상실을 보상하기 위해 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 인정하는 채권적 권리이며, iii) 보상금청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한 독립적인 권리이다.

(3) 성립요건

① 특허출원이 「출원공개」 될 것

보상금청구권이 발생하기 위해서는 일단 출원공개가 되어야 한다. 여기서 「출원공개일」이 인정되기 위해서 그 특허출원이 공개된 취지를 제제한 공개특허공보가 발행되어야 한다(施規 43).

② 출원인이 서면으로 경고하거나 공개된 발명을 알고 있을 것

1) 출원인은 출원발명을 업으로 실시한 자에게 서면으로 경고하여야 한다(法 65①). 여기에서 「경고」는 특허권 침해 등을 중지하도록 하는 「경고」와는 다른 의미로서 실시자에게 출원발명의 실시의 중지를 요구하는 것이 아니라 특허출원인이 자신의 특허출원이 출원공개되었다는 사실 및 후에 보상금청구권의 대상이 됨을 실시자에게 알리는 사실의 통지이다. 「경고」는 구체적으로 하여야 하고 추후 증명을 위해 통상적으로 내용증명우편으로 행하며, 출원공개 후는 물론 출원공개 전에도 경고를 할 수 있다. 다만 출원공개 전 경고를 한 경우에는 출원공개된 때부터 공개된 발명임을 알고 실시하여 보상금청구권이 발생한 것으로 해석된다.

2) 제3자가 공개된 사실을 알고 실시할 때는 경고하지 아니하여도 된다. 다만 이러한 악의의 증명은 출원인이 하여야 하므로 대개는 서면으로 경고를 하게 된다.

3) 보상금청구권이 인정되는 출원발명은 청구범위에 기재된 발명이다. 여기서 출원인이 출원발명임을 경고한 후 청구범위 보정을 한 경우에 재경고를 하여야 하는지가 문제 된다. 보정에 의하여 청구범위가 확장 또는 변경되었으면 그 확장 또는 변경된 내용에 대하여 보상금청구권을 행사하기 위해서는 다시 경고를 하여야 하나 보정에 의하여 청구범위가 감축 또는 삭제되었으면 재경고를 할 필요가 없다.

③ 「정당한 권원」없는 제3자가 「업」으로서 「출원발명」을 「실시」할 것

출원공개가 있는 후 경고받거나 알았을 때부터 정당한 권원 없는 제3자가 업으로서 그 출원발명을 실시한 경우이어야 한다. 여기서 i) 「정당한 권원」이란 출원공개된 발명이 특허되어도 그 특허권에 구속되지 아니한 사유⁶⁵⁾를, ii) 「업」으로의 실시란 개인적·가정적 실시를 제외

한 실시를, iii) 「출원발명」이란 특허출원 후 등록되기 전의 발명을, iv) 「실시」란 제2조제3호에서 규정한 실시를 말한다.

(4) 보상금청구권의 효력

① 보상금액

제3자가 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(法 65②). 「실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액」으로 산정한 이유는 등록되지 않았다는 이유로 보상금액이 부당히 낮게 책정되는 것을 방지하기 위함이다.

② 행사시기

보상금청구권은 그 특허출원된 발명에 대한 특허권이 설정등록된 후에만 행사할 수 있다(法 65③). 특허법이 보상금청구권의 발생과는 별도로 보상금청구권을 행사할 수 있는 시기를 따로 규정한 것은 보상금청구권은 제3자가 출원공개 후 경고받거나 알았을 때부터 발생하지만 특허권의 설정등록이 되지 않으면 소멸하기 때문(法 65⑥), 보상금청구권은 특허권 설정등록 전의 단계에서는 불확정상태라 할 수 있는데 특허권의 설정등록 전에 보상금청구권의 행사를 인정하면 산업계의 혼란 및 불필요한 분쟁의 발생으로 인한 법원의 업무부담 가중 등 폐해가 예상되기 때문이다.⁶⁵⁾

③ 특허권과의 독립성

보상금청구권의 행사는 특허권의 행사에 영향을 미치지 아니한다(法 65④). 즉 시기를 기준으로 출원공개 후 경고받거나 알았을 때부터 특허권 설정등록할 때까지의 기간 동안 실시에 대해서는 보상금청구권의 행사가 가능하고, 특허권 설정등록 후의 실시에 대해서는 특허권에 기한 민·형사상 제재가 가능하다. 이에 대하여 보상금청구권을 행사하였으면 특허권을 행사할 수 없다고 보는 견해⁶⁷⁾가 있으나, 보상금청구권과 특허권은 전혀 다른 성질의 권리이며, 양 권리는 시기를 기준으로 구분되어 있으므로 타당하지 아니한 것으로 여겨진다. 따라서 등록 이후에 계속적으로 발명을 실시하려는 제3자는 이에 대하여 명확히 해 둘 필요가 있다.

④ 준용규정

보상금청구권 행사와 관련하여서는 특허법상 간접침해(法 127), 생산방법의 추정(法 129), 자료의 제출(法 132)에 관한 규정을, 민법상 공동불법행위자의 책임(民法 760),⁶⁸⁾ 손해배상청

65) 예를 들어 직무발명에 의한 통상실시권, 추가납부기간이 지난 후에 회복한 특허출원에 대한 통상실시권, 선사용에 의한 통상실시권 등이 있다.

66) 그러나 보상금청구권의 행사를 위하여 등록까지 기다려야 하는 제한조건으로 인해, 출원인은 경고를 받은 실시자로부터 정보제공 등에 의한 특허등록의 방해를 받게 되는 문제점이 있어 보상금청구권이 출원인에게 실질적인 도움이 되지 못하고 있는 것이 현실이다.

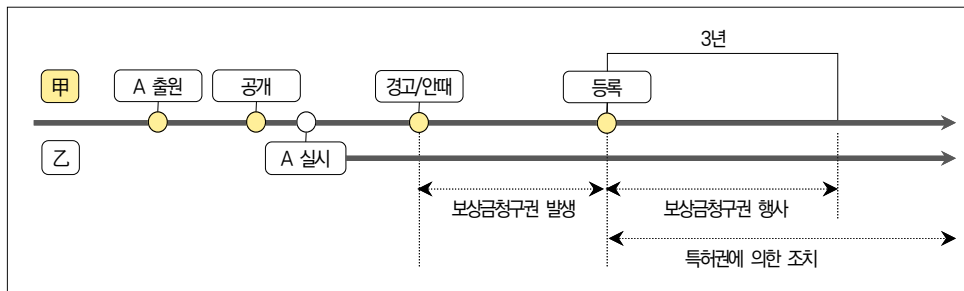
67) 박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002, 315면.

68) 제760조[공동불법행위자의 책임]① 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.

② 공동 아닌 수인의 행위 중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도 전항과 같다.

③ 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다.

구권의 소멸시효(民法 766)⁶⁹⁾에 관한 규정이 준용된다(法 65⑤). 다만 손해배상청구권의 소멸시효는 「피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 않거나 불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에는 시효로 인하여 소멸한다」고한 것에 비해, 특허법은 보상금청구권의 소멸시효에 관해서는 민법 제766조의 규정을 준용하되 3년이라는 단기소멸시효의 기산점을 피해자 또는 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날이 아니라 실제로 보상금청구권을 행사할 수 있는 시기인 해당 특허권의 「설정등록일」을 기준으로 하도록 규정하고 있다. 따라서 특허출원인이 보상금청구권을 행사하려면 해당 특허권의 설정등록일로부터 3년 이내에 하여야 하고, 그 기간이 지나면 단기소멸시효의 완성으로 인해 보상금청구권은 소멸하게 된다. 한편 불법행위를 한 날로부터 10년은 제3자가 출원공개 후 경고를 받거나 안 날로부터 10년으로 해석되는데 특허권 설정등록 후 3년이라는 단기소멸시효기간 때문에 적용될 여지가 거의 없다고 할 것이다.



【그림 4-17】 보상금청구권의 발생 및 행사

(5) 보상금청구권의 소멸

① 소멸원인

「특허권의 설정등록이 되지 않거나」 「설정등록이 된 경우라도 특허권이 소급하여 소멸한 경우」에 보상금청구권은 소멸한다. 구체적으로 출원공개 후 i) 특허출원이 포기·무효 또는 취하된 경우, ii) 특허출원의 특허거절결정이 확정된 경우, iii) 특허취소신청에 의한 특허취소결정이 확정된 경우 및 iv) 특허무효심판에 의한 특허를 무효로 한다는 심결(후발적 무효사유 제외)이 확정된 경우⁷⁰⁾ 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보상금청구권은 처음부터 발생하지 아니한 것으로 본다(法 65⑥).

69) 제766조【손해배상청구권의 소멸시효】① 불법행위로 인한 손해배상의 청구권은 피해자나 그 법정대리인이 그 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 인하여 소멸한다.

② 불법행위를 한 날로부터 10년을 경과한 때에도 전항과 같다.

70) 특허취소신청에 의한 취소결정이나 특허무효심판에 의한 특허를 무효로 한다는 심결이 청구항별로 확정되어 소급하여 소멸한 경우에는 해당 청구항별로 보상금청구권이 소멸한다(法 215).

② 배상책임

특허권자가 보상금청구권을 행사한 후 특허권에 대한 취소결정, 무효심결이 확정되거나 특허의 정정청구 또는 정정심판청구에 따라 그 청구항이 삭제된 경우에 그 보상금청구권은 처음부터 없었던 것으로 되는데 이 경우 특허권자의 배상책임이 문제 될 수 있다. 이는 민법상의 일반적인 배상책임에 따라 고의·과실이 있는 경우에는 손해배상책임을 진다고 할 것이다. 그러나 고의·과실이 없는 경우에는 부당이득만 반환하면 족할 것이다.

2. 우선심사의 신청

출원공개 후 특허출원인이 아닌 자가 업으로서 특허출원된 발명을 실시하고 있다고 인정되는 경우에는 우선심사를 신청할 수 있다(法 61Ⅰ). 한편 「대통령령으로 정하는 특허출원으로서 긴급하게 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우(法 61Ⅱ) 또는 대통령령으로 정하는 특허출원으로서 재난의 예방·대응·복구 등에 필요하다고 인정되는 경우(法 61Ⅲ)」는 출원공개가 없다고 하더라도 우선심사를 신청할 수 있다.

3. 특허출원에 관한 서류의 열람 등의 신청

특허출원, 특허취소신청, 심판 등에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급,⁷¹⁾ 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 지식재산처장 또는 특허심판원장에게 서류의 열람 등의 허가를 신청할 수 있다(法 216①). 지식재산처장 또는 특허심판원장은 신청이 있더라도 다음의 어느 하나에 해당하는 서류를 비밀로 유지할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 서류의 열람 또는 복사를 허가하지 아니할 수 있다(法 216②).

- i) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원(국내우선권 주장을 수반하는 특허출원이 출원공개 또는 설정등록된 경우에는 그 선출원은 제외한다⁷²⁾)에 관한 서류
- ii) 출원공개 또는 설정등록되지 아니한 특허출원의 특허거절결정에 대한 심판(法 132의17)에 관한 서류
- iii) 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 서류

4. 기탁된 미생물의 분양

기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 i) 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우 또는 ii) 제63조제1항(제170

71) 「등본」이란 서류의 원본 그대로를 사기(寫記)한 것을 말하며, 「초본」이란 원본 중 관계부분을 사기(寫記)한 것을 말한다. 또한 「원본(原本)」이란 일정한 사실관계 또는 법률관계를 기술한 원문서를 말한다.

72) 국내우선권주장을 수반하는 출원의 발명에 대하여 무효 여부를 다투기 위해서는 선출원의 발명과 동일성 여부 및 출원시기 소급적용의 적법성 여부에 관해 확인을 하여야 한다는 점에서, 2017. 3. 1. 시행된 현행법(법률 제14035호, 2016. 2. 29. 개정)에서는 국내우선권주장을 수반하는 출원이 출원공개 또는 설정등록되면 그 선출원의 열람을 허가하고 있다.

조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 의견서를 작성하기 위하여 필요한 경우 총리령으로 정하는 바에 따라 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다(令 4①). 한편 미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자도 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다(令 4②).

5. 공지기술로서의 활용

제3자는 출원공개된 발명을 기술정보로써 이용하여 중복투자 및 중복연구를 방지할 수 있으며, 심사관은 출원공개 전 후출원에 대해서는 확대된 선출원의 지위(法 29③④)에 의하여, 출원공개 후 후출원에 대해서는 공지기술의 지위(法 29①②)에 의하여 후출원의 등록을 금지시킬 수 있다.

V. 국제출원의 국제공개 및 국제특허출원의 국내공개

1. 국제공개

(1) 의 의

국제사무국은 수리관청으로부터 국제출원에 관한 서류를 송부받아 국제공개를 행한다(PCT 21(1)). 「국제공개」는 출원공개에 대한 국내법상의 요청을 국제출원에서도 만족시키고자 한 것으로서 새로운 기술정보의 확산을 조기에 달성하고자 한 것이다.

(2) 시 기

국제공개는 원칙적으로 우선일로부터 18개월이 지난 후에 국제사무국에 의하여 행해진다. 그러나 국제사무국은 우선일로부터 18개월이 지나기 전이라도 출원인이 조기공개신청을 하면 즉시 공개하여야 한다(PCT 21(2)(3)).⁷³⁾

(3) 대 상

원칙적으로 모든 국제출원이 국제공개된다. 다만 국제사무국은 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 국제공개를 하지 않을 수 있다.

- i) 국제공개 기술적 준비가 완료되기 전에 국제출원이 취하되거나 취하된 것으로 보이는 경우(PCT 21(5))
- ii) 국제출원이 선량한 풍속이나 공공의 질서에 반하는 표현이나 도면을 포함하고 있거나 PCT 규칙에 규정된 비방하는 기재사항을 포함하고 있다고 인정하는 경우(PCT 21(6))
- iii) 국제출원이 어느 국가도 자국에 관한 한 국제출원을 공개할 필요가 없다고 선언한 국가만을 지정하고 있는 경우(다만 이 경우라도 국제사무국은 i) 출원인으로부터 청구가 있을

73) 출원인이 조기공개신청을 할 때는 국내공개와 달리 특별공개수수료를 주어야 한다(PCT 규칙 48.4).

때, ii) 국제출원에 기초한 특허 또는 국내출원이 어느 지정국의 국내관청에 의하여 또는 동 국내관청을 대신하여 공표된 때에는 그 공표 후 우선일로부터 18개월이 지났다면 신속히 해당 국제출원을 국제공개한다(PCT 64(3)).

(4) 내 용

국제공개는 전자적 형태로 웹사이트(patentscope.wipo.int)를 통해 공개되며, 출원서 자체를 제외한 출원인이 제출한 국제출원 전문이 공개되는데, 출원서의 서지적 사항과 요약서가 기재된 표지, 발명의 설명, 청구범위 및 도면, 제19조 보정서가 있는 경우에는 보정된 사항 및 설명서, 국제조사보고서 등을 포함한다. 국제조사기관의 견해서는 국제공개 대상이 아니었으나, PCT 규칙 개정으로 2014년 7월 1일부터 출원된 국제출원에 대해서는 국제공개 시점에 견해서가 공개된다(PCT 규칙 48.1, 48.2).

(5) 언 어

국제공개언어로 출원되었으면 각각 이들 언어로 공개가 되는데, 국제공개언어는 영어, 일본어, 불어, 독어, 러시아어, 스페인어, 중국어, 아랍어 등 8개국 언어가 지정되어 있었으나 2007년 10월 한국어 및 포르투갈어가 추가로 채택되었다.

(6) 효 과

국제공개는 원칙적으로 지정국의 국내공개에 관한 국내법상의 요건을 갖추고 있다는 면도 있으므로 각국의 국내공개와 같은 효과가 있다. 그러한 이유에서 PCT는 국제공개에 대하여 가보호(假保護)의 규정을 두고 있다. 따라서 국제공개의 지정국에서의 효과는 그 지정국의 국내법령이 정하는 효과와 동일하지만(PCT 29(1)), 그 효과가 발생하는 시점에 대해서는 각 지정국의 선택으로서 정해진다(PCT 29(2)(3)(4)).

2. 국제특허출원의 국내공개

(1) 국내공개시기

① 일반적인 경우

일반 국내특허출원의 공개시기는 조기공개 신청이 없는 경우 출원일로부터 1년 6개월이 지난 후이다(法 64①). 그러나 국제특허출원은 원칙적으로 국내서면제출기간(제201조제1항 각호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장해 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 항에서 같다)이 지난 후에 국내공개가 이루어진다. 다만 국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제특허출원으로서 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개된 경우에는 우선일로부터 1년 6개월이 되는 날과 출원심사의 청구일 중 늦은 날이 지난 후 국내공개가 이루어지며(法 207①), 우선일로부터 1년 6개월이 지나기 전이라도 출원인이 국어번역문을 제출한 후라면 조기공개의 신청을 할 수 있다(施規 44②).

② 국어로 국제특허출원한 경우

국어로 출원한 국제특허출원에 관하여 국내에서의 출원공개 전에 이미 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개가 된 경우에는 그 국제공개 시에 출원공개가 된 것으로 본다(法 207②). 이는 국어가 PCT 국제출원의 국제공개어로 채택(2009. 1. 1. 이후 국제출원부터 적용)됨에 따라 국내출원의 공개시점과 국제출원의 공개시점을 동일하게 적용토록 하여 동일한 효과를 발생토록 하려는 조치이다.

(2) 보상금청구권의 발생

국제특허출원의 출원인은 국제특허출원에 관하여 출원공개(국어로 출원한 국제특허출원인 경우 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 있는 후 국제특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을 서면으로 경고할 수 있다(法 207③). 국제특허출원의 출원인은 제3항에 따른 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고도 그 국제특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만 그 청구권은 해당 특허출원이 특허권의 설정등록된 후에만 행사할 수 있다(法 207④). 그 밖의 보상금 청구권에 관한 내용은 통상의 국내출원과 동일하다.

PART 05

특허협력조약(PCT)에 의한 국제출원

제1장 서론

제2장 국제출원절차

제3장 국제특허출원에 관한 특례

제1장

서론

I. 특허협력조약(PCT)의 설립배경

특허협력조약(Patent Cooperation Treaty; PCT)은 파리조약 제19조에 따른 특별협정의 하나로서 1970년 워싱턴에서 개최된 외교회의에서 채택되어 1978년 1월 24일부터 효력이 발생하였다. PCT의 당사국은 발명의 보호를 위한 출원의 제출, 조사 및 심사에서의 협력 및 특별한 기술용역의 제공을 위한 동맹을 구성하는데 이를 국제특허협력동맹이라고 한다. 우리나라는 1984년 5월 10일에 36번째로 PCT의 가입국이 되었으며 1997년 9월에 개최된 PCT 동맹 총회에서 세계적으로 10번째의 국제조사기관(International Searching Authority; ISA) 및 9번째의 국제예비심사기관(International Preliminary Examining Authority; IPEA)으로 지정되어 1999년 12월부터 업무를 수행하고 있다.¹⁾ 또한 2007년 10월 제43차 WIPO 총회에서 한국어가 PCT 국제공개어로 채택되었다.

1) 특허협력조약의 연혁은 다음과 같다.

일시	내용	비고
1970.06.19.	Washington 외교회의에서 조약체결	일명 워싱턴 조약이라 함
1977.10.24.	조약발효요건 충족	8개국이 비준서 또는 가입서 기탁
1978.01.24.	조약발효	18개국이 비준서 기탁
1978.06.01.	국제출원업무 개시(18개국)	EPC와 동시 개시
1979.03.01.	세계지적소유권기구(WIPO) 가입	한국
1980.05.04.	파리조약 가입	한국
1984.05.10.	PCT 가입서 WIPO 기탁(PCT 제2장 유보)	한국(제36번째 가입국)
1984.08.10.	조약발효 및 국제출원업무 개시	한국
1990.09.04.	PCT 제2장 유보철회	한국
1997.09.16.	국제조사 및 국제예비심사기관으로 지정	한국(WIPO 총회)
1999.12.01.	국제조사 및 국제예비심사기관 업무개시	한국
2009.01.01	한국어의 PCT 국제공개어 업무 개시	한국

II. PCT의 목적

1. 특허출원절차의 협력

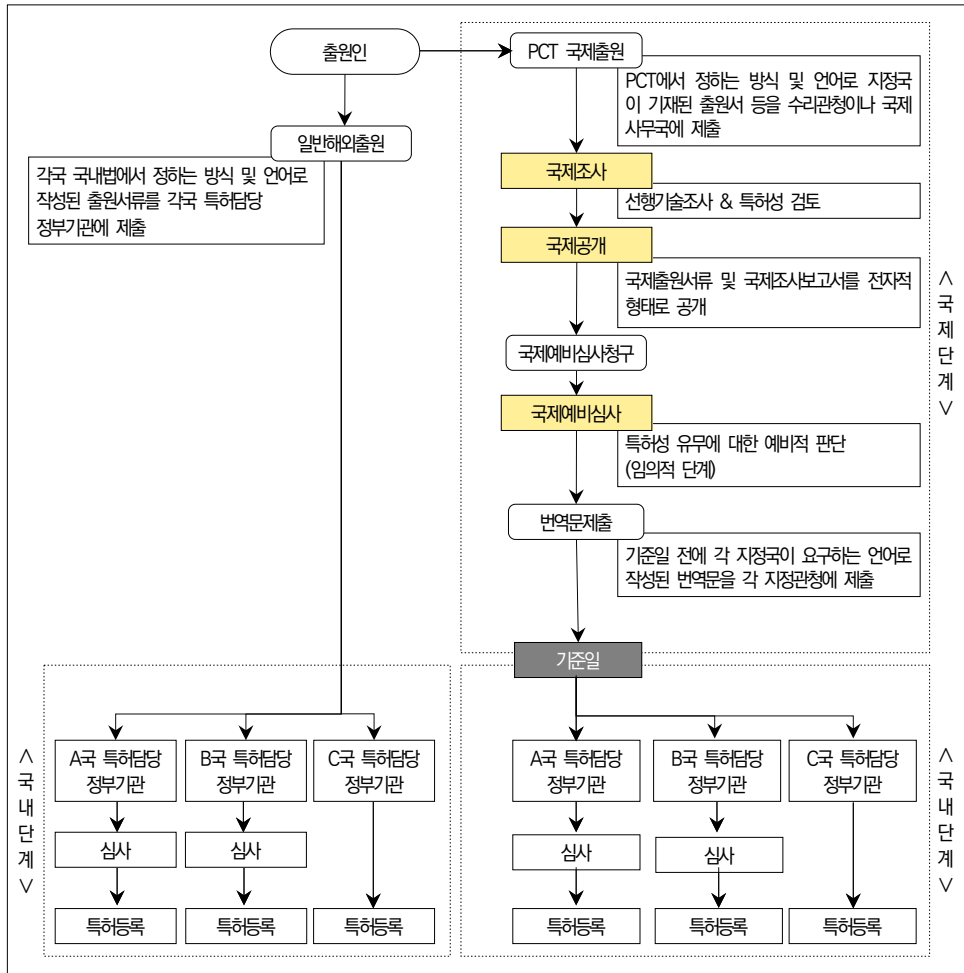
해외출원절차면에서의 협력은 처음부터 PCT의 목적으로 추진됐다. 즉 해외출원을 하려는 출원인은 속지주의의 원칙에 따라 국가마다 각각 상이한 특허법이 존재하기 때문에 각국의 방식에 따른 출원서류를 각국의 언어로 작성하여 제출하여야 하는 문제점이 있었다. PCT는 이러한 문제점을 해결하고 특허출원절차를 국제적으로 통일화하고 간편화함으로써 발명을 국제적으로 보호함에 그 목적이 있다.

2. 특허정보의 제공

각국 특허담당 정부기관에서 행하는 작업 중 선행기술의 조사 및 기술정보의 수집은 각국에서 동일하게 이루어지는 작업임에도 불구하고 종래에는 각국 특허담당 정부기관에서 개별적으로 이를 행하였기 때문에 동일한 대상을 중복으로 심사하는 것이 되어 인적 자원의 낭비가 되고, 심사가 지체되는 문제점이 있었다. PCT의 다른 목적은 국제단계에서 국제조사, 국제예비심사를 통해 선행기술의 조사 및 기술정보의 수집을 공통으로 하여 상술한 문제점을 해결함에 있다.

3. 개발도상국의 원조

PCT의 또 다른 목적은 개발도상국이 국제사무국으로부터 제공되는 새로운 발명에 대한 선진기술정보를 활용함으로써 기술 및 경제발전의 기틀을 삼을 수 있도록 함에 있다.



【그림 5-1】 PCT에 의한 해외출원절차와 일반해외출원절차의 비교

III. PCT의 장단점

1. 장 점

(1) 출원인의 입장

해외출원을 하려는 출원인의 입장에서 보면 국제출원절차의 통일성으로 말미암아 수리관청 또는 국제사무국에 1회 출원한 것만으로 각 지정국에서 직접 출원한 것과 동일한 효과를 누릴 수 있어서 PCT를 이용하지 않을 때 다수국에 출원하여야 하는 시간적 노력을 줄일 수 있고, 비용을 절약할 수 있다. 또한 국제출원을 한 이후에 국제단계에서 국제조사기관의 조사보고서, 국제예비심사기관의 국제예비심사보고서를 활용하여 불필요한 절차의 진행과 비용의 낭비를 줄일 수 있다. 그뿐만 아니라 파리조약에 의한 출원루트의 우선기간(1년)보다 그 기간(31개월)이 연장되므로 시간적 여유를 갖게 된다는 장점이 있다.

(2) 각국 특허담당 정부기관의 입장

각국 특허담당 정부기관의 입장에서 볼 때도 국제조사보고서·국제예비심사보고서에 의하여 심사관의 심사부담을 크게 경감할 수 있을 뿐만 아니라 충분한 심사 자료와 조사관에 의하여 작성된 국제조사보고서를 활용함으로써 개별국가의 심사수준 차이에도 불구하고 심사결과의 객관성을 높이고 특허제도의 신뢰를 높일 수 있으며, 각국 특허담당 정부기관의 현대화를 촉진하는 데 기여할 수 있다.

(3) 기업의 입장

개발도상국 기업의 입장에서 보면 선진국과의 특허정보교류의 기회가 확대되어 산업재산권 분야의 국제적 협력이나 국제적 지위의 향상에도 기여할 수 있을 뿐만 아니라 국제출원내용의 국제공개를 통하여 선진외국의 기술정보를 활용할 수 있는 장점이 있다.

2. 단 점

1) PCT의 문제점으로는 여러 가지가 제기되고 있으나 크게 i) 국제출원의 국내단계 진입할 때 비용이 과다하다는 점과, ii) 그 내용이 난해한 점, iii) 국내단계의 절차지연에 따라 존속기간이 단축된다는 점, iv) 유보조항이 과도한 점 등이 있다.

2) 특히 국내단계에 진입한 국제출원의 절차 및 각국 특허담당 정부기관 내에서의 특허행정 절차는 국가마다 속지주의의 원칙에 기초하여 각국 국내법에 따라 수행되도록 하는 문제점이 있다. 따라서 1985년에 들어서서 WIPO(World Intellectual Property Organization)를 중심으로 파리조약을 보충하는 조약을 체결하는 방법에 의한 체약국 간의 특허법 통일화 작업(Patent Harmonization Treaty; PHT)을 시도하였고, 1995년 12월부터 약 5년간 5회의 전문가 회의 및 3회의 특허법상설위원회(Standing Committee on the law of Patents, SCP)에서 각국 특허법의 절차적 내용에 한정하여 통일화를 기하려는 구체적인 검토가 되어, 전문

27개 조문의 특허법조약(Patent Law Treaty; PLT)이 2000년 6월 외교회의에서 채택되었다. 한편 현재는 특허법조약(PLT)에의 가입·시행이 확산될 것을 대비하여 PCT 제도의 국제실무의 효율화 및 단순화뿐만 아니라 PLT와의 조화를 위한 PCT 개혁에 대한 논의가 활발히 진행되고 있다.

【표 5-1】 PCT에 의한 해외출원과 일반해외출원의 비교

구 분		PCT 해외출원	일반 해외출원
출원 단계	출원	■ 하나의 방식으로 PCT 출원을 하면 세계 여러 국가에 출원되는 효과 발생	■ 각 국가의 국내법에서 정하는 방식 및 언어로 각 국가에 개별 출원
	우선기간 이용	■ 우선일로부터 1년 이내 PCT 출원	■ 우선일로부터 1년 이내 각 국가에 모두 출원
국제 단계	국내단계 진입 기간확보	■ 국내단계진입기간(30/31개월)의 확보로 무분별한 해외출원 방지: 사업화 및 시장국가 예측이 곤란한 경우 최종적인 결정의 연기 가능	-
	비용	■ 국내단계 진입 시기를 달리하여 소요되는 비용의 분산 ■ 국제출원료, 국제조사료 등이 추가로 소요	■ 소요비용의 분산이 되지 아니함
	보고서 활용	■ 국제단계에서 국제조사보고서, 국제예비심사보고서를 활용하여 국내단계진입 여부 결정가능 ■ 등록 가능성이 없는 경우 국내단계진입을 포기하여 불필요한 비용의 절감가능	■ 국내 단계 진입 전에 특허성과 관련하여 참고할 수 있는 공적 보고서 없음
	보정	■ 국제단계에서 PCT 제19조 보정, PCT 제34조 보정을 통해 등록 가능성 향상 가능	-
국내 단계	조기 권리화	■ 국내단계절차진행이 지연되어 등록까지 오랜 시간 소요	-
기타	PCT 가입	-	■ 대만 등과 같이 PCT 가입국이 아닌 경우 일반 해외출원만 가능

IV. PCT의 구성

PCT는 전문과 총 69개 조문으로 이루어져 있으며 조약에 부속되어 조약과 함께 채택된 규칙을 기본적 구성으로 하고 있다. PCT의 규정은 i) 총강(PCT 1, 2), ii) 제1장 국제출원과 국제조사(PCT 3-30), iii) 제2장 국제예비심사(PCT 31-42), iv) 제3장 공동규정(PCT 43-49), v) 제4장 기술적 용역(PCT 50-52), vi) 제5장 행정규정(PCT 53-58), vii) 제6장 분쟁(PCT 59), viii) 제7장 개정 및 수정(PCT 60, 61), ix) 제8장 최종규정(PCT 62-69)으로 나눌 수 있다.

V. PCT 출원절차

1. 국제단계

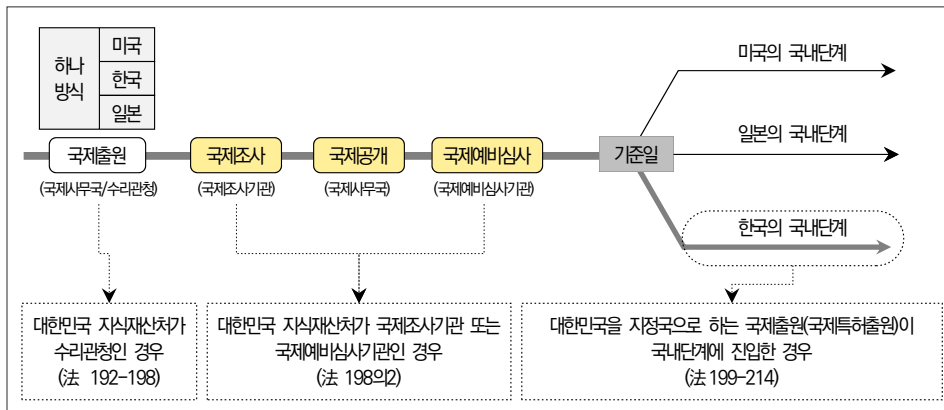
국제출원에서 지정관청에 대한 국내절차 진행 전까지의 전과정을 말한다. 여기에는 i) 수리관청 혹은 WIPO 국제사무국에서 하는 국제출원절차와 ii) 모든 국제출원에 대하여 국제조사기관이 행하는 국제조사, iii) 국제사무국이 행하는 국제출원에 대한 국제공개, iv) 출원인이 필요에 의하여 선택 시 국제예비심사기관이 행하는 국제예비심사의 4개의 절차로 다시 세분된다.

2. 국내단계

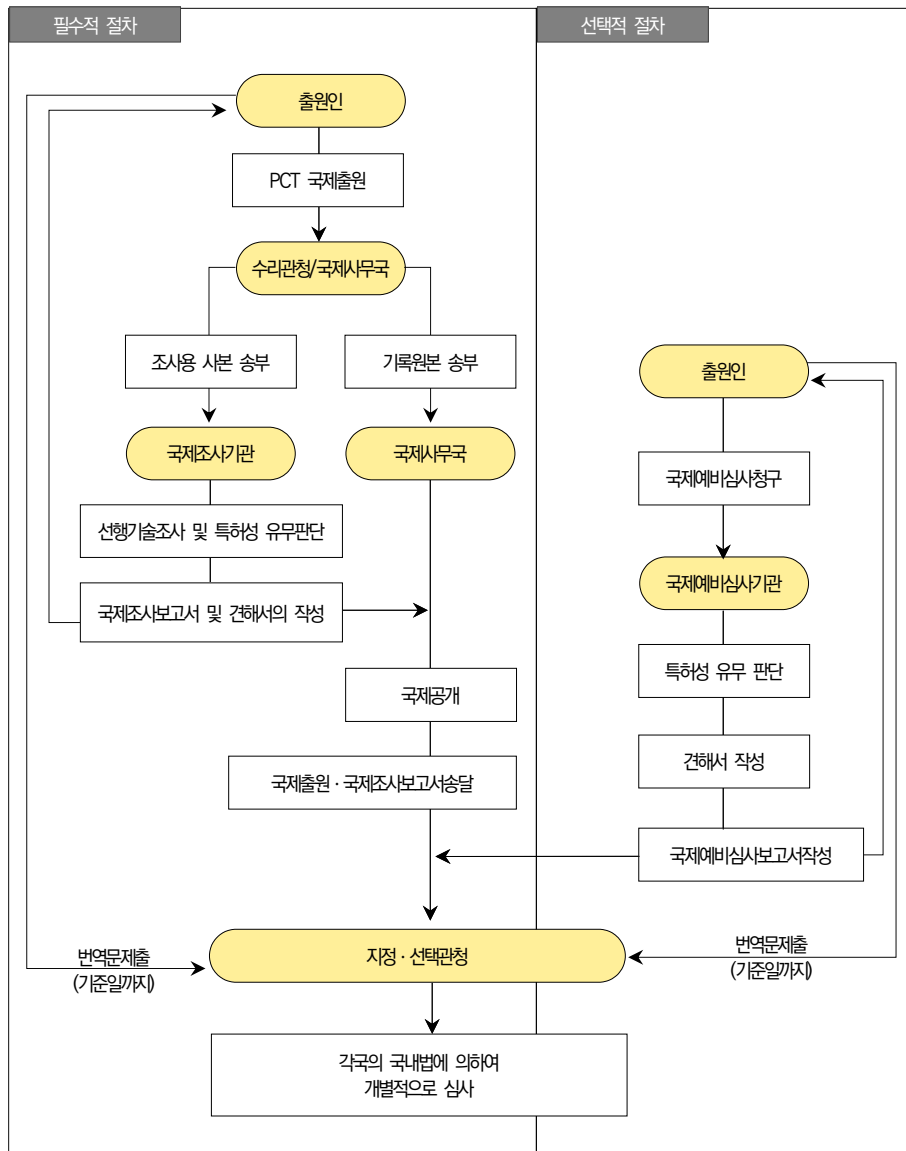
지정국에서 국내절차의 개시에서부터 심사완료까지의 전 과정을 말한다. 여기에는 번역문 제출, 국내수수료 납부, 대리인 선임, 지정관청의 실체심사 및 특허여부결정 등이 있다.

VI. 특허법 규정에 반영된 PCT

우리나라 특허법상 특허협력조약에 의한 국제출원(제10장)은 i) 제1절 국제출원절차(法 192-198의2)와 ii) 제2절 국제특허출원에 관한 특례(法 199-214)로 구분되어 있다. 여기서 제1절 국제출원절차는 어느 나라를 지정국으로 했는지와 관계없이 우리나라를 수리관청으로 하여 국제출원할 때 적용되는 규정(法 192-198)과 우리나라가 국제조사 및 국제예비심사기관인 경우에 적용되는 규정(法 198의2)이고, 제2절 국제특허출원에 관한 특례(法 199-214)는 어느 나라를 수리관청으로 했는지와 관계없이 우리나라를 지정국으로 한 국제출원(이를 “국제특허출원”이라 한다)이 국내단계로 진입할 때 적용되는 규정이다.



【그림 5-2】 우리나라 특허법 규정(法 199-214)에 반영된 PCT



【그림 5-3】 국제출원의 개략적인 절차도

제2장

국제출원절차

제192조 【국제출원을 할 수 있는 자】

지식재산처장에게 국제출원을 할 수 있는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자로 한다.

1. 대한민국 국민
2. 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인
3. 제1호 또는 제2호에 해당하는 자가 아닌 자로서 제1호 또는 제2호에 해당하는 자를 대표자로 하여 국제출원을 하는 자
4. 총리령으로 정하는 요건에 해당하는 자

[전문개정 2014.6.11.]

제193조 【국제출원】

- ① 국제출원을 하려는 자는 총리령으로 정하는 언어로 작성한 출원서와 발명의 설명·청구범위·필요한 도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
- ② 제1항의 출원서에는 다음 각 호의 사항을 적어야 한다.
 1. 해당 출원이 「특허협력조약」에 따른 국제출원이라는 표시
 2. 해당 출원된 발명의 보호가 필요한 「특허협력조약」 제약국(締約國)의 지정
 3. 제2호에 따라 지정된 제약국(이하 “지정국”이라 한다) 중 「특허협력조약」 제2조(iv)의 지역특허를 받으려는 경우에는 그 취지
 4. 출원인의 성명이나 명칭·주소나 영업소 및 국적
 5. 대리인이 있으면 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소
 6. 발명의 명칭
 7. 발명자의 성명 및 주소(지정국의 법령에서 발명자에 관한 사항을 적도록 규정되어 있는 경우만 해당한다)
- ③ 제1항의 발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다.
- ④ 제1항의 청구범위는 보호를 받으려는 사항을 명확하고 간결하게 적어야 하며, 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다.
- ⑤ 제1항부터 제4항까지에서 규정한 사항 외에 국제출원에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제194조 【국제출원일의 인정 등】

- ① 지식재산처장은 국제출원이 지식재산처에 도달한 날을 「특허협력조약」 제11조의 국제출원일(이하 “국제출원일”이라 한다)로 인정하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 1. 출원인이 제192조 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 경우
 2. 제193조제1항에 따른 언어로 작성되지 아니한 경우
 3. 제193조제1항에 따른 발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우
 4. 제193조제2항제1호·제2호에 따른 사항 및 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우
- ② 지식재산처장은 국제출원이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명하여야 한다.

- ③ 지식재산처장은 국제출원이 도면에 관하여 적고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니하면 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다.
- ④ 지식재산처장은 제2항에 따른 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완을 한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을, 제3항에 따른 통지를 받은 자가 총리령으로 정하는 기간에 도면을 제출한 경우에는 그 도면의 도달일을 국제출원일로 인정하여야 한다. 다만, 제3항에 따른 통지를 받은 자가 총리령으로 정하는 기간에 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

제195조 【보정명령】

지식재산처장은 국제출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.

1. 발명의 명칭이 적혀 있지 아니한 경우
2. 요약서가 제출되지 아니한 경우
3. 제3조 또는 제197조제3항을 위반한 경우
4. 총리령으로 정하는 방식을 위반한 경우

[전문개정 2014.6.11.]

제196조 【취하된 것으로 보는 국제출원 등】

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 국제출원은 취하된 것으로 본다.
 1. 제195조에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니한 경우
 2. 국제출원에 관한 수수료를 총리령으로 정하는 기간에 내지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(a)에 해당하게 된 경우
 3. 제194조에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 총리령으로 정하는 기간에 그 국제출원이 제194조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 것이 발견된 경우
- ② 국제출원에 관하여 내야 할 수수료의 일부를 총리령으로 정하는 기간에 내지 아니하여 「특허협력조약」 제14조(3)(b)에 해당하게 된 경우에는 수수료를 내지 아니한 지정국의 지정은 취하된 것으로 본다.
- ③ 지식재산처장은 제1항 및 제2항에 따라 국제출원 또는 지정국의 일부가 취하된 것으로 보는 경우에는 그 사실을 출원인에게 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제197조 【대표자 등】

- ① 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 제192조부터 제196조까지 및 제198조에 따른 절차는 출원인의 대표자가 밟을 수 있다.
- ② 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 경우에는 총리령으로 정하는 방법에 따라 대표자를 정할 수 있다.
- ③ 제1항의 절차를 대리인에 의하여 밟으려는 자는 제3조에 따른 법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제198조 【수수료】

- ① 국제출원을 하려는 자는 수수료를 내야 한다.
- ② 제1항에 따른 수수료, 그 납부방법 및 납부기간 등에 관하여 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제198조의2 【국제조사 및 국제예비심사】

- ① 지식재산처는 「특허협력조약」 제2조(xix)의 국제사무국(이하 “국제사무국”이라 한다)과 체결하는 협정에 따라 국제출원에 대한 국제조사기관 및 국제예비심사기관으로서의 업무를 수행한다.
- ② 제1항에 따른 업무수행에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제1절 대한민국 지식재산처를 수리관청으로 하는 국제출원절차

I. 서 설

PCT에 의한 국제출원은 수리관청 또는 WIPO 국제사무국에 할 수 있다. 대한민국 지식재산처를 수리관청으로 하여 PCT에 의한 국제출원을 할 때는 특허법 제192조 내지 제198조 및 시행규칙 제74조 내지 제106조의9에서 규정한 절차에 따라야 한다.

II. 국제출원을 할 수 있는 자

1. 출원인

지식재산처장에게 국제출원을 할 수 있는 자는 i) 대한민국 국민, ii) 대한민국에 주소 또는 영업소를 가진 외국인, iii) 대한민국에 주소 또는营业소를 가지지 아니한 외국인으로서 대한민국 국민이나 대한민국에 주소 또는 영업소를 가지는 외국인을 대표자로 하여 공동으로 국제출원을 하는 자,²⁾ iv) i) 내지 iii)에 해당하지 아니하는 자로서 1명 이상의 대한민국 국민 또는 국내에 주소 또는 영업소를 가진 외국인과 공동으로 국제출원을 하는 자이다(法 192, 施規 90).³⁾

2. 대표자

2명 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에는 대표자가 제192조부터 제196조까지 및 제198조⁴⁾에 따른 절차를 밟을 수 있는데(法 197①), 2명 이상이 공동으로 국제출원을 하는 경우에 출원인이 대표자를 정하지 아니한 때에는 지식재산처에 국제출원할 자격을 가지는 대한민국 국민 또는 국내에 주소나 영업소를 갖는 외국인 중 출원서에 최초로 기재되어 있는 출원인을 대표자로 정할 수 있다(法 197②, 施規 106의4).

3. 대리인

1) 국제출원에 관한 절차를 대리인이 밟는 경우 법정대리인을 제외하고는 변리사를 대리인으로 하여야 한다(法 197③). 국제출원에 관한 절차를 밟는 자가 그 대리인 또는 대표자의 선임을 신고한 후에 새로운 대리인 또는 대표자의 선임을 신고하는 경우에는 먼저 선임된 대리인 또는 대표자는 해임된 것으로 본다. 다만 신고서에 먼저 선임된 대리인 또는 대표자를 계속하여 대리인 또는 대표자로 한다는 취지가 기재된 경우에는 그러하지 아니하다(施規 78④).

2) 제192조제4호와 같이 대한민국 국민 또는 재내자와 공동출원만 하면 대한민국 국민 또는 재내자를 대표자로 정하지 않더라도 국제출원할 수 있으므로 제192조제3호는 실효성이 없다고 여겨진다.

3) 한편 총회는 PCT의 당사국은 아니나 파리조약의 당사국인 어느 국가의 거주자(재내자)와 국민이 국제출원을 하는 것을 인정하도록 결정할 수 있다(PCT 9(2)).

4) 국제출원에 관한 국제단계에서의 절차를 의미하며, 해당 규정이 있는 절차에 한하는 것은 아니다.

2) 국제출원에 관한 절차를 밟는 자는 자신의 모든 국제출원에 관한 절차에 대하여 자신을 대리할 대리인을 선임하는 경우 포괄위임장을 지식재산처장에게 제출할 수 있다(施規 80①). 포괄위임장이 수리관청에 제출된 경우에는 출원인은 그 사본을 출원서에 첨부하여 대리권의 증명에 갈음할 수 있다(施規 80②).

III. 국제출원서류의 제출 등

1. 서

1) 국제출원을 하려는 자는 총리령으로 정하는 언어로 작성한 출원서와 발명의 설명, 청구 범위, 필요한 도면 및 요약서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 193①). 여기서 「총리령으로 정하는 언어」란 국어, 영어 또는 일본어를 말한다(施規 91).⁵⁾

2) 국제출원에 관하여 지식재산처장에게 제출하는 서류는 국제출원의 발명의 설명 및 청구 범위를 적은 언어(이하 “국제출원의 언어”라 한다)로 작성하여야 한다. 다만 국적증명서, 법인 증명서, 그 밖에 지식재산처장이 지정하는 서류는 그러하지 아니하다(施規 75).

3) 국제출원은 서면 또는 전자문서로 할 수 있다. 국제출원의 서류를 서면으로 제출하는 경우에는 각 3통을 별개의 서류로 작성하여 제출하여야 한다(施規 92①).

2. 국제출원서류의 작성

(1) 출원서

1) 국제출원서에는 다음의 사항을 적어야 한다(法 193①②). 한편 지식재산처장은 국제출원의 출원서에 기재사항 외의 사항이 기재되어 있는 경우에는 직권으로 그 사항의 기재를 말소하여야 한다(施規 95).

- i) 해당 출원이 특허협력조약에 따른 국제출원이라는 표시
- ii) 해당 출원된 발명의 보호가 필요한 「특허협력조약」 체약국의 지정⁶⁾
- iii) 지정된 체약국(이하 “지정국”이라 한다) 중 「특허협력조약」 제2조(iv)의 지역특허⁷⁾를 받으려는 경우에는 그 취지

5) 국제출원은 수리관청이 인정하는 언어로 제출하여야 하는데, 각 수리관청은 국제조사기관이 인정한 언어 또는 국제공개 언어 중 적어도 하나를 국제출원언어로 인정하여야 한다(PCT 규칙 12.1(a)(b)). 현재 각 체약국에 인정되고 있는 국제출원의 언어로는 영어, 불어, 독어, 스페인어, 러시아어, 네덜란드어, 덴마크어, 핀란드어, 스웨덴어, 노르웨이어, 일본어, 중국어, 한국어 등이 있다. 한편 출원서는 수리관청이 인정하는 국제공개언어로 제출되어야 한다(PCT 규칙 12.1(c)).

6) 시행규칙 제93조의2에 따라 국제출원할 때 모든 체약국이 지정된 것으로 보며, 실제로 출원서에도 체약국을 지정하는 란이 삭제되었기 때문에 의미가 없는 규정이라 여겨진다.

7) 지역특허는 하나의 특허담당 기관에서 특허를 받아서 복수의 국가에 대하여 효력을 발생시키는 것을 말한다. 이에는 유럽특허와 아프리카지식재산권기구(OAPI) 특허가 있다.

- iv) 출원인의 성명이나 명칭, 주소나 영업소 및 국적
 - v) 대리인이 있으면 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소
 - vi) 발명의 명칭
 - vii) 발명자의 성명 및 주소(지정국의 법령에서 발명자에 관한 사항을 적도록 규정되어 있는 경우만 해당한다)
- 2) 국제출원의 출원서 등이 제출된 경우에는 다음의 사항이 행하여진 것으로 본다(施規 93의2).
- i) 조약 제11조에 따른 국제출원일에 조약에 구속되는 모든 체약국의 지정(이를 자동지정 제도로 한다.) 다만 조약규칙 4.9(b)에 따른 우선권주장의 기초가 되는 자국 내 선출원에 대하여 취하되는 효과를 규정하고 있는 체약국에 대해서는 국제출원의 출원인은 해당 체약국의 지정을 제외할 수 있다.⁸⁾
 - ii) 지정국 중 조약 제43조 또는 제44조⁹⁾가 적용되는 각 지정국에서 얻을 수 있는 모든 종류의 권리를 위한 것이라는 표시
 - iii) 조약 제45조(1)이 적용되는 각 지역구의 지역특허[조약 제2조(iv)에 따른 특허를 말한다] 및 국내특허[조약 제45조(2)가 적용되는 경우를 제외한다]를 위한 것이라는 표시

(2) 발명의 설명

발명의 설명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적어야 한다(法 193③).

(3) 청구범위

청구범위는 보호를 받으려는 사항을 명확하고 간결하게 적어야 하며 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어야 한다(法 193④).

8) 자기지정(self-designation) 제도를 운용하고 있는 국가의 경우, 자동 지정에 의하여 자국이 지정될 경우 국내우선권주장 제도에 의하여 선출원이 취하되어 출원인이 피해를 받을 수 있으므로, 이를 방지하기 위하여 국제출원서 양식에 특정 국가의 지정을 배제할 수 있는 표시 박스(box)를 신설하여 출원인이 자동지정을 배제할 수 있도록 하였다. 다만 이 규정을 적용받기 위해서는 해당 관청이 2003년 1월 1일까지 국제사무국에 본 조항이 그 국가의 지정과 관련하여 적용된다는 통보를 하여야 한다.

9) 제43조【특정한 종류의 보호를 요구하는 출원】

지정국 또는 선택국이 발명자증, 실용증, 실용신안, 추가특허, 추가발명자증 또는 추가실용증을 부여하는 것을 국내법령에 정하고 있는 경우에는, 출원인은 해당 지정국 또는 해당 선택국에 관한 한 국제출원이 특허가 아니고 발명자증, 실용증 및 실용신안을 요구하는 출원이라는 것, 또는 국제출원이 추가특허, 추가 발명자증 및 추가실용증을 요구하는 출원이라는 것을 규칙에 따라 표시할 수 있다. 이러한 국제출원의 효과는 출원인의 이와 같은 선택에 따라 처리된다. 제2조(ii)의 규정은 본조 및 본조에 관한 규칙 규정에 대해서는 적용하지 아니한다.

제44조【두 가지 종류의 보호를 요구하는 출원】

지정국 또는 선택국이 특허 또는 제43조에 규정하는 다른 종류의 보호중 하나를 요구하는 출원으로써 다른 종류의 보호도 요구할 수 있다는 것을 국내법령으로 인정하는 경우에는 출원인은 그가 요구하는 두가지 종류의 보호를 규칙에 따라 표시할 수 있으며 이러한 국제출원의 효과는 출원인의 이와 같은 의사에 따라 처리된다. 제2조(ii)의 규정은 본조의 규정에 대해서는 적용하지 아니한다.

(4) 국제출원에 적어서는 아니 되는 표현 등

국제출원에는 다음의 사항이 포함되어서는 아니 된다(施規 77).

- i) 공공의 질서에 반하는 표현 또는 도면
- ii) 선량한 풍속에 반하는 표현 또는 도면
- iii) 출원인 외의 특정인의 생산물·방법 또는 출원이나 특허의 이점 또는 유효성을 비방하는 기술(단, 선행기술과의 단순한 비교는 그 자체로는 비방으로 보지 아니한다.)
- iv) 국제출원에 기술된 사항과 관련성이 없거나 필요하지 아니한 기술

3. 수수료의 납부

국제출원을 하려는 자는 수수료를 내야 한다(法 198①). 국제출원에 관한 수수료에는 i) 송달료, ii) 국제출원료, iii) 국제조사에 관한 조사료, vi) 가산료(별 것을 명한 금액의 50%)가 있다. 이 중 송달료, 국제출원료, 조사료의 경우에는 국제출원이 지식재산처에 접수된 날로부터 1개월 이내에 내야 한다(徵收規則 10①②). 기존에는 국제출원할 때 모든 계약국이 지정된 것으로 되는 것이 아니라 계약국을 직접 지정할 수 있었기 때문에 지정료를 별도로 내야 했으나 현재는 국제출원할 때 모든 계약국이 지정된 것으로 됨으로써(자동지정제도의 도입으로) 지정료는 국제출원료에 포함되었다.

IV. 국제출원일의 인정

1. 서

1) 지식재산처장은 국제출원으로 제출된 서류를 접수한 때에는 국제출원일 인정과는 무관하게 그 국제출원번호 및 그 국제출원의 접수일을 출원인에게 통지하고(施規 94), 국제출원일 인정 요건(보완사유)을 검토하여 흠결이 없는 경우에는 별도로 해당 국제출원일을 출원인에게 통지하여야 한다(施規 100). 여기서 「해당 국제출원일」이란 국제출원이 지식재산처에 도달한 날¹⁰⁾을 의미한다.

2) 국제출원일이 인정된 국제출원은 출원서에 기재된 각 지정국에서 정규의 국내출원으로서의 효과가 있고, 국제출원일은 각 지정국의 실제의 출원일로 간주된다.¹¹⁾ 그 결과 국제출원일이 인정되면 출원의 정규성이 인정되어 조약에 의한 우선권이 발생하고, 특허출원이 계속 중이면 이를 기초로 국내우선권주장출원을 할 수 있다. 국제출원일이 인정된 국제출원은 국제단계에서 국제조사 및 국제공개의 대상이 되며, 출원인의 선택에 의하여 국제예비심사의 대상이 되기도 한다.

3) 국제출원을 서면으로 각 3통 제출한 경우 수리관청은 수리관청용 사본(home copy)은 보유 하고, 기록원본(record copy)은 우선일로부터 13개월을 만료하기 전까지 국제사무국에 도달하도록

10) 국내출원과는 달리 우편의 경우에도 도달주의이다.

11) 다만 국제출원이 우선권주장을 수반하는 출원의 경우에는 우선일로 국제출원의 판단시점이 소급된다.

송부하고, 조사용 사본(search copy)은 관할국제조사기관에 송부하여야 한다. 이 경우 기록원본이 국제출원의 정보가 된다(PCT 12(1)(2), PCT 규칙 23). 한편 국제사무국은 기록원본을 접수한 경우 출원인, 수리관청 그리고 국제조사기관에 기록원본의 접수사실 및 접수일자를 신속히 통지한다. 국제사무국은 우선일로부터 13개월 만료시까지도 기록원본을 수리하지 아니하였을 때는 그 취지를 수리관청에 통지하여 송달을 촉구하여야 하는데, 재촉일부터 1개월이 지나도록 기록원본이 도달하지 않으면 그 사실을 출원인에게 통지한다. 이러한 취지를 출원인에게 통지한 날로부터 3개월 이내에 국제사무국이 기록원본을 수리하지 아니하면 그 국제출원은 취하된 것으로 간주된다(PCT 12(3), PCT 규칙 22).

2. 국제출원의 보완

(1) 국제출원일의 인정요건(국제출원의 보완사유) 및 보완명령

지식재산처장은 다음의 국제출원일을 인정할 수 없는 요건, 즉 보완사유 중 어느 하나에 해당함을 발견한 경우 국제출원일을 인정하지 않고 기간을 정하여 서면으로 절차의 보완을 명하여야 한다(法 194①②).

- i) 국제출원서에 발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우
- ii) 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우
- iii) 대한민국에 국제출원할 수 있는 자격(法 192)을 갖추지 아니한 자가 출원한 경우
- iv) 국제출원서에 특허협력조약에 따른 국제출원이라는 표시가 되어 있지 아니한 경우
- v) 국제출원이 총리령으로 정하는 언어(국어, 영어 또는 일본어)로 작성되지 아니한 경우
- vi) 해당 출원된 발명의 보호가 필요한 특허협력조약 체약국의 지정을 하지 아니한 경우(즉 지정국이 1개도 없는 경우)¹²⁾

(2) 보완유무에 따른 효과

지식재산처장은 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완한 경우에는 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정한다(法 194④전단부). 그러나 지식재산처장은 절차의 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완하지 아니한 경우에는 국제출원일을 인정하지 않으며, PCT 규칙 20.4(i)에 따라 그 출원은 국제출원으로 취급하지 아니한다는 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다(法 194①단서, 施規 98).

3. 국제출원의 보정

(1) 보정사유 및 보정명령

1) 지식재산처장은 국제출원일의 인정요건은 충족하였으나 다음의 보정사유 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 보정을 명하여야 한다(法 195).

12) 자동지정제도가 도입됨에 따라 실효성이 없는 규정이라 할 것이다.

- i) 발명의 명칭이 적혀 있지 아니한 경우
 - ii) 요약서가 제출되지 아니한 경우
 - iii) 특허법상 행위능력이 없는 자가 법정대리인에 의하지 않고 절차를 밟거나 선임된 임의 대리인이 변리사가 아닌 경우
 - iv) 총리령으로 정하는 방식에 위반된 경우
- 2) 여기서 「총리령으로 정하는 방식에 위반된 경우」란 다음에 위반된 것을 의미한다(施規 101).
- i) 출원인(출원인이 2명 이상인 경우 제192조제1호 또는 제2호에 해당하는 최소 1명의 출원인)의 주소(법인의 경우에는 그 영업소의 소재지) 및 국적에 관한 기재가 있을 것
 - ii) 출원인 또는 대리인(출원인이 2명 이상이거나 대리인이 2명 이상인 경우에는 그들 중 최소 1명의 출원인 또는 대리인)이 기명을 한 후 서명 또는 날인할 것(다만 대리인이 기명을 한 후 서명 또는 날인한 경우에는 출원인(출원인이 2명 이상인 경우에는 모든 출원인)이 기명을 한 후 서명 또는 날인한 위임장이 첨부되어야 한다)
 - iii) 국제출원의 출원서, 발명의 설명, 청구범위, 도면 및 요약서가 각각 서식에 따라 작성되어 있을 것
- 3) 또한 지식재산처장은 국제출원을 한 자가 수수료를 그 기간에 내지 아니하면 1개월의 기간을 정하여 해당 수수료 및 가산료를 낼 것을 명하여야 한다(施規 104).

(2) 보정유무에 따른 효과

보정이 적법하게 이루어지면 보정된 내용대로 출원된 것으로 본다. 즉 보완의 효과와는 달리 국제출원일은 변동이 없게 된다. 그러나 보정명령에 대한 기간에 보정이 이루어지지 아니하면 그 국제출원은 취하한 것으로 간주된다(法 196① I II).

4. 누락 부분 등에 대한 보완¹³⁾

(1) 누락 부분 등에 대한 보완사유

지식재산처장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 2개월 이내에 그 누락된 부분 또는 잘못 제출된 부분을 정정하는 부분(이하 “정정 부분”이라 한다)을 제출하도록 출원인에게 보완을 명하여야 한다(法 194③④, 施規 99의2①).

- i) 발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락(발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우는 제외한다)되어 있거나 잘못 제출된 경우
- ii) 도면의 전부 또는 일부가 누락되어 있거나 잘못 제출된 경우¹⁴⁾

13) 특허법 시행규칙 제99조의2에는 발명의 설명 또는 청구범위의 일부 누락과 도면의 전부 또는 일부의 누락에 대한 보완에 대하여 규정되어 있으며, 이 규정은 PCT 규칙 20.5에 상응한다. 특허법조약(Patent Law Treaty)에 제5조에 맞추어 현행처럼 개정된 PCT 규칙 20.5가 2007년 4월 1일부터 시행되면서 PCT 제14조(2)에 규정된 도면의 전부 누락에 해당하는 경우의 취급까지 포함하게 됨에 따라, PCT 제14조(2) 및 그에 따른 특허법 제194조제3항의 규정은 실질적으로 사문화되었다(권종남, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 932면 참조).

14) 도면은 국제출원일 인정요건에 포함되지 아니하므로, 즉 도면이 없더라도 국제출원일이 인정되므로 도면의 일부 누락뿐만 아니라 전부 누락까지 포함하여 규정되어 있다.

(2) 명령 또는 의사에 의한 보완

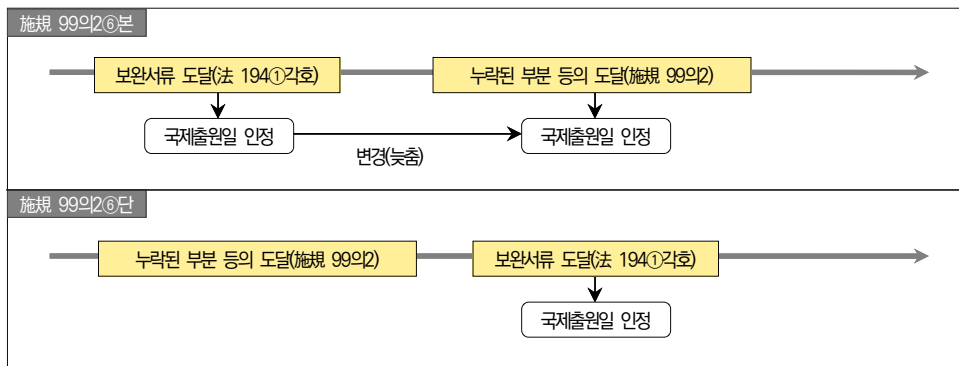
1) 지식재산처장은 국제출원일을 인정할 때 누락된 부분 등에 대한 보완사유에 해당하는 경우에는 2개월 이내에 그 누락된 부분 또는 정정 부분을 제출하도록 출원인에게 보완을 명하여야 한다(法 194③④, 施規 99의2①). 출원인은 보완명령을 받은 경우 그 기간 내에 보완서나 의견서를 지식재산처장에게 제출할 수 있다(施規 99의2③④).

2) 지식재산처장의 보완명령과 상관없이 출원인은 국제출원의 접수일부터 2개월 이내 누락된 부분 또는 정정 부분을 지식재산처장에게 제출할 수 있다(施規 99의2②③).

(3) 보완유무에 따른 효과

1) 지식재산처장은 보완서류제출서가 접수된 경우에는 해당 서류의 접수일을 국제출원일로 인정하여야 한다(法 194④중단부, 施規 99의2⑥본문). 다만 해당 접수일이 제194조제4항에 따라 국제출원일로 인정되는 날보다 앞서는 경우에는 그러하지 아니하다(施規 99의2⑥단서). 즉 출원인이 국제출원의 누락 부분을 제출하면, 국제출원이 특허법 제194조제1항의 요건을 모두 충족한 날과 국제출원의 누락 부분이 도달된 날 중 늦은 날이 국제출원일이 된다(PCT 규칙 20.5(b)).

2) 지식재산처장은 국제출원이 도면에 관하여 기재하고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니함에도 불구하고, 출원인이 기간에 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 본다(法 194④후단부).



【그림 5-4】 누락 부분 등에 대한 보완 효과

(4) 보완의 취하

시행규칙 제99조의2 제6항 본문에 따라 누락된 부분 등의 보완서류 접수일이 국제출원일로 인정된 경우에는 국제출원을 한 출원인은 국제출원일의 통지일로부터 1개월 이내에 누락된 부분 등의 보완서류의 제출을 취하할 수 있다. 서류의 제출이 취하된 경우에는 누락된 부분 등의 보완서류 접수일을 국제출원일로 인정한 것은 없었던 것으로 본다(施規 100의2). 이는 국제출원일이 정정된 경우 출원인이 누락된 부분 등을 무시할 것을 신청할 수 있음을 규정한 것이다. 이 경우 누락된 부분 등은 제출되지 아니한 것으로 간주되고 해당 규정에 의한 국제출원일의 정정은 행해지지 아니한 것으로 본다.

【표 5-2】 국제출원의 방식심사

제 도		보완	보정	누락된 부분 등의 보완
사유		1. 국제출원서에 발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우 2. 출원인의 성명이나 명칭을 적지 아니한 경우 3. 대한민국에 국제출원할 수 있는 자격(法 192)을 갖추지 아니한 자가 출원한 경우 4. 국제출원서에 특허협력조약에 따른 국제출원이라는 표시가 되어 있지 아니한 경우 5. 국제출원이 총리령으로 정하는 언어(국어, 영어 또는 일어)로 작성되지 아니한 경우 6. 해당 출원된 발명의 보호가 필요한 특허협력조약 계약국의 지정을 하지 아니한 경우	1. 발명의 명칭이 적혀 있지 아니한 경우 2. 요약서가 제출되지 아니한 경우 3. 행위제한능력이 법정대리인에 의하지 않고 절차를 밟거나 선임된 임의대리인이 변리사가 아닌 경우 4. 총리령으로 정하는 방식에 위반된 경우 5. 국제출원을 한 자가 수수료를 해당 기간에 내지 아니한 경우	1. 발명의 설명 또는 청구범위의 일부가 누락(발명의 설명 또는 청구범위가 제출되지 아니한 경우는 제외한다)되어 있거나 잘못 제출된 경우 2. 도면의 전부 또는 일부가 누락되어 있거나 잘못 제출된 경우
	의사	-	국제출원 계속 중	국제출원의 접수일로부터 2개월 이내 보완(施規 99의2②③)
절차	명령	지식재산처장은 기간을 정하여 보완명령(法 194②)	지식재산처장은 기간을 정하여 보정명령(法 195)	지식재산처장은 통지일로부터 2개월 이내 보완명령(施規 99의2③④)
효과	적법	보완서 도달일을 국제출원일로 인정(法 194④전단부)	보정된 내용대로 출원한 것으로 간주	1. 접수일(도달일)을 국제출원일로 인정(단, 국제출원일 통지일로부터 1개월 이내 보완 취하지 국제출원일 정정 없었던 것으로 간주)(施規 99의2⑥본문) 2. 제194조제4항에 따라 국제출원일로 인정되는 날보다 앞서는 경우는 그러하지 아니함(施規 99의2⑥단서)
	부적법	국제출원일 불인정(法 194①단서)	국제출원의 취하간주(法 196①Ⅱ)	1. 국제출원절차 진행하고 나중에 기재불비 등의 거절이유가 발생한 가능성 존재 2. 도면에 관하여 기재하고 있으나 그 출원에 도면이 포함되어 있지 아니함에도 불구하고, 출원인이 기간에 도면을 제출하지 아니한 경우에는 그 도면에 관한 기재는 없는 것으로 간주(法 194④)

V. 그 밖의 국제출원에 관한 절차

1. 국제출원의 취하

(1) 국제출원인의 의사에 의한 취하

국제출원인은 지식재산처장에 대하여 우선일로부터 2년 6개월을 지나기 전과 출원인이 출원 심사청구를 하기 전 중 빠른 때까지 국제출원, 지정국의 지정 또는 우선권주장을 취하할 수 있다. 이 경우 국제출원인은 취하서를 지식재산처장에게 제출하여야 하며, 이러한 국제출원의 취하는 모든 출원인을 대리하는 대리인 또는 대표자(제197조제2항에 따른 대표자는 제외)가 없는 경우에는 모든 출원인이 기명을 한 후 서명 또는 날인한 서면으로 하여야 한다(施規 106의7).

(2) 법률에 의한 국제출원 등의 취하간주

① 국제출원의 취하간주

1) 국제출원이 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 해당 국제출원은 취하된 것으로 간주한다(法 196①).

- i) 제195조에 따른 지식재산처장의 보정명령을 받은 자가 지정기간에 보정을 하지 아니한 경우
- ii) 국제출원에 관한 수수료를 수수료 납부의 보정을 명한 날부터 1개월 이내에 내지 아니하여 특허협력조약 제14조(3)(a)에 해당되게 된 경우
- iii) 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 국제출원일로부터 4개월 이내에 그 국제출원이 국제출원의 보완명령사유에 해당되는 것이 발견된 경우

2) 지식재산처장은 국제출원일이 인정된 국제출원에 관하여 국제출원일로부터 4개월 이내에 그 국제출원이 국제출원의 보완명령사유에 해당되는 것이 발견되어 국제출원이 취하된 것으로 보게 되는 경우에는 미리 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다. 이 경우 출원인은 통지를 받은 경우에는 통지일로부터 2개월 이내에 의견서를 지식재산처장에게 제출할 수 있다(施規 106의2).

② 지정국의 지정의 취하간주

국제출원에 관하여 내야 할 수수료의 일부를 내지 아니하여 특허협력조약 제14조(3)(b)에 해당하게 된 경우에는 수수료를 내지 아니한 지정국의 지정은 취하된 것으로 본다(法 196②). 다만 국제출원할 때 모든 지정국이 지정된 것으로 보며 지정료가 국제출원료에 포함되었기 때문에 수수료 일부를 내지 아니한 경우 국제출원 전체가 취하간주되는 것이지, 지정국 일부가 취하간주되는 경우는 없을 것이다.

③ 취하간주의 통지

지식재산처장은 국제출원 또는 지정국의 일부가 취하된 것으로 보는 경우에는 그 사실을 출원인에게 알려야 한다(法 196③).

2. 국제조사용 번역문의 제출

(1) 제출시기 및 보정명령

국제조사가기관이 인정하지 아니하는 언어로 국제출원이 출원된 경우¹⁵⁾ 출원인은 국제조사를 위하여 국제출원의 접수일로부터 1개월 이내에 조약규칙 12.3(a)에 따라 국제조사가기관이 인정하는 언어로 된 번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 지식재산처장은 출원인이 국제출원의 접수일로부터 1개월 이내에 번역문을 제출하지 아니하면 보정을 명한 날로부터 1개월 이내에 그 번역문을 제출하도록 출원인에게 보정을 명하여야 한다(施規 95의2①②).

(2) 취하간주

출원인이 보정기간에 번역문을 제출하지 아니하거나 가산료를 내지 아니하면 조약규칙 12.3(d)에 따라 그 출원은 취하된 것으로 본다. 이 경우 지식재산처장은 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다(施規 95의2③).

3. 우선권주장 및 우선권서류의 제출 등

(1) 우선권주장

국제출원은 규칙에 정하는 바에 따라 파리조약의 당사국에서 또는 파리조약의 비당사국인 세계무역기구회원국에 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하는 선언을 수반할 수 있다(PCT 8(1), PCT 규칙 4.10(a)). 이 경우 자기지정이 되는 경우를 제외하고는 신청된 우선권 주장의 조건과 효과는 파리조약의 스톡홀름의정서 제4조의 정하는 바에 의한다(PCT 8(2)(a)). 「자기지정」이란 어느 계약국에서 또는 어느 계약국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권 주장을 수반하는 국제출원에는 해당 계약국의 지정을 포함하는 것을 말한다. 국제출원이 어느 지정국에서 또는 어느 지정국에 대하여 행하여진 국내출원에 의한 우선권주장을 수반하는 경우 또는 하나의 국가만의 지정을 포함한 국제출원에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에는 해당 지정국에서의 조건 및 효과는 해당 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다(PCT 8(2)(b)). 구체적인 내용은 「제3장 국제특허출원에 관한 특례」부분에서 후술한다.

(2) 우선권주장의 보정 또는 추가

1) 출원인이 우선권주장을 보정 또는 추가하려는 경우에는 우선일로부터 1년 4개월(우선권 주장의 보정 또는 추가로 인하여 우선일이 변경되는 경우에는 변경된 우선일로부터 1년 4개월과 우선일로부터 1년 4개월 중 먼저 끝나는 날)과 국제출원일부 4개월 중 늦게 끝나는 날 이내에 보정 또는 추가하여야 한다. 그리고 출원인이 조기국제공개를 신청한 후에 지식재산처장이 상기 보정(추가)서류를 수령한 경우에는 해당 서류는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다

15) 예를 들면 대한민국 지식재산처를 수리관청으로 하여 국어로 국제출원하면서 국제조사가기관은 일본을 지정하는 경우를 말한다.

만 조기국제공개를 위한 기본적 준비가 완료되기 전에 해당 조기국제공개를 취하한 경우에는 해당 제출서류는 유효한 것으로 본다.

2) 이 경우 우선권주장의 보정 또는 추가로 인하여 우선일이 변경된 경우에는 변경 전 우선일로부터 기산하여 만료되지 아니한 기간은 변경된 우선일로부터 그 기간을 기산하여야 한다(施規 102).

(3) 우선권주장에 대한 보정명령

1) 지식재산처장은 i) 국제출원일이 우선일부터 1년 이내에 해당하지 아니하는 경우, ii) 우선권주장이 조약규칙 4.10에서 정한 방식요건을 만족하지 못한 경우나 iii) 우선권주장에 관한 기재내용이 해당 우선권서류상의 기재내용과 일치하지 아니한 경우에는 출원인에게 우선권 주장에 대한 보정을 명하여야 한다. 이러한 우선권주장에 대한 보정명령을 받은 자가 우선권 주장을 보정할 수 있는 기간에 보정하지 아니한 경우에는 해당 우선권주장은 없는 것으로 보고 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다(施規 103①②③).

2) 다만 i) 조약규칙 4.10(a)(ii)에 따른 선출원번호를 적지 아니한 경우, ii) 우선권주장에 관한 기재내용이 제106조의6 제1항에 따른 우선권서류의 기재와 일치하지 아니하는 경우, iii) 국제출원일이 우선일부터 1년이 지났으나 그 지난 날부터 2개월 이내인 경우에 중 어느 하나에 해당된다는 이유만으로는 해당 우선권주장이 없는 것으로 보지 아니한다(施規 103④).

3) 한편 다음의 요건을 모두 충족하는 우선권주장의 보정이 있는 경우에는 해당 보정은 제 102조제1항에 따른 기간에 한 것으로 본다(施規 103⑤).

i) 제102조제1항에 따른 기간의 만료일로부터 1개월 이내일 것

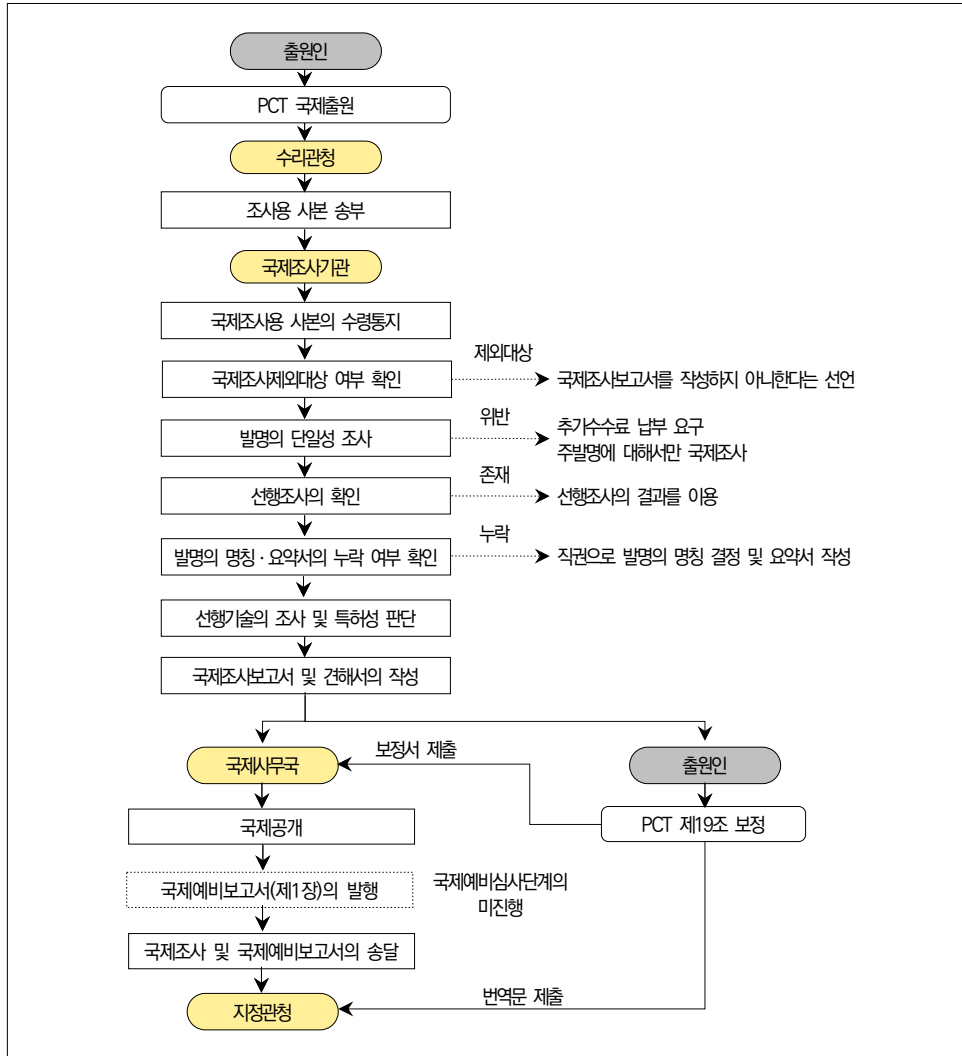
ii) 제4항 각호 외의 부분 본문에 따른 통지가 있기 전일 것

(4) 우선권서류의 제출

1) 조약 제2조(vi)에 따른 국제출원 또는 국내출원을 기초로 하여 우선권을 주장하려는 자는 우선일로부터 1년 4개월 이내에 우선권서류제출서에 그 국내출원 또는 국제출원을 수리한 관청이 인정하는 해당 국내출원 또는 국제출원의 등본을 첨부하여 지식재산처장에게 제출할 수 있다(施規 106의6). 제출된 우선권서류는 국제사무국으로 송부된다. 다만 제출하지 아니한 경우 이를 이유로 지식재산처장이 우선권을 부인하는 것은 아니며, 각 지정국 법령이 따르는 바에 따라 우선권서류 및 그 번역문을 제출하면 된다(施規 106의6①).

2) 한편 대한민국에 제출한 특허출원·실용신안등록출원 또는 국제출원을 기초로 하여 우선권을 주장하려는 자는 국제출원의 출원서에 우선권서류의 송달신청의 취지를 적거나 우선일로부터 1년 4개월 이내에 우선권서류송달신청서를 지식재산처장에게 제출하여 우선권서류를 국제사무국에 송달할 것을 지식재산처장에게 요청할 수 있다(施規 106의6②).

제2절 대한민국 지식재산처의 국제조사 및 국제사무국의 국제공개



【그림 5-5】 국제조사 및 국제공개 절차

I. 서 설

모든 국제출원은 국제조사의 대상이 되며, 「국제조사」는 관련이 있는 선행기술 발견과 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 등의 특허성을 판단하는 것을 목적으로 한다(PCT 15(1)(2)). 국제 조사 결과는 국제조사보고서 및 견해서로 작성되어 출원인과 국제사무국에 송부된다. 이 국제조사보고서 및 견해서는 출원인이나 지정관청을 구속하는 효과는 없으나 각 지정국에 대한 본격적인 출원절차를 개시하기 전에 출원인에게 자신의 출원과 관련된 관련선행기술의 존재 또는 특허성에 대한 정보를 미리 알려주어, 출원인이 절차진행의 계속 여부를 결정하는데 참고자료로 활용할 수 있도록 한다.

II. 국제조사기관

1. 국제조사의 관할

1) 국제조사는 국제조사기관이 행하며 총회는 국내관청 또는 출원대상인 발명에 관한 선행 기술에 대하여 자료조사보고를 작성하는 임무를 가지는 정부 간 기구(예를 들면 국제특허협회)를 국제조사기관으로 할 수 있다. 단일의 국제조사기관이 설립되기 전에 둘 이상의 국제조사기관이 존재하는 경우에 각 수리관청은 PCT 제16조(3)(b)에서 규정하는 적용가능한 협정조항에 따라 국제출원의 국제조사를 행할 권능이 있는 하나 또는 둘 이상의 국제조사기관을 지정한다(PCT 16(1)(2)).

2) 현재 국제조사기관으로는 미국·일본·러시아·스웨덴·스페인·오스트리아·호주·중국·한국의 각 특허담당 정부기관(특허청, 지식재산처 등) 및 유럽특허청 등이 있다. 한편 출원인은 대한민국 지식재산처가 수리관청이면 국제조사기관으로서 대한민국, 오스트리아, 호주 및 일본 특허담당 정부기관 중 선택할 수 있으며,¹⁶⁾ 상술한 바와 같이 국제조사기관이 인정하지 아니한 언어로 국제출원하였으면 출원인은 국제조사를 위하여 국제출원의 접수일로부터 1개월 이내에 PCT 규칙 12.3(a)에 따라 국제조사기관이 인정하는 언어로 된 번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다.¹⁷⁾

16) 출원인의 국제출원 언어에 따라 국제조사기관 및 국제예비심사관은 다음과 같이 차이가 있다(지식재산처, 「PCT 국제조사/국제예비심사 매뉴얼」, 2015, 15면).

언어	관할 국제조사기관	관할 국제예비심사기관	비고
국어	대한민국 특허담당 정부기관	대한민국 특허담당 정부기관	
영어	대한민국 특허담당 정부기관 오스트리아 특허담당 정부기관 호주 특허담당 정부기관	대한민국 특허담당 정부기관 오스트리아 특허담당 정부기관 호주 특허담당 정부기관	출원인 선택
일어	일본 특허담당 정부기관	일본 특허담당 정부기관	

17) 국제조사기관의 현황은 다음과 같다(천효남, 「특허법」, 제9판, 법경사, 2003, 459면).

2. 최소한의 요건

국내관청 또는 정부 간 기구가 국제조사기관으로 선정되고 또는 국제조사기관으로 활약하기 위해서는 다음의 요건을 만족하여야 한다(PCT 16(3)(c), PCT 규칙 36).

- i) 국내관청 또는 정부 간 기구는 적어도 조사를 수행하기 위한 충분한 기술적 자격이 있는 상근 직원 100명을 보유하고 있을 것
- ii) 국내관청 또는 정부 간 기구는 조사를 위하여 적절히 정비된 PCT 규칙 제34조의 최소한의 자료(종이, 마이크로폼 또는 전자매체로 된)를 보유 또는 이용할 수 있을 것
- iii) 국내관청 또는 정부 간 기구는 소정의 기술분야를 조사할 능력이 있고, 적어도 PCT 규칙 제34조의 최소한 자료에 사용된 또는 번역된 언어를 이해할 수 있는 언어능력을 구비한 직원을 보유하고 있을 것
- iv) 그 국내관청 또는 정부간기구가 국제예비심사기관으로 선정될 것

III. 국제조사기관(대한민국 지식재산청)의 절차

1. 조사용 사본 수령의 통지

지식재산청장은 조사용 사본을 수령한 때에는 국제사무국, 출원인 그리고 수리관청(국제조사기관이 수리관청과 동일하지 아니한 때)에 조사용 사본의 접수사실 및 일자를 신속히 통지하여야 한다(PCT 규칙 25, 施規 106의10).

2. 국제조사대상 여부의 확인

(1) 원 칙

모든 국제출원은 국제조사의 대상이다(PCT 15(1)). 지식재산청장은 제194조에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원에 대하여 심사관에게 PCT 제18조(1)에 따른 국제조사보고서(이하

조사기관	조사언어
유럽특허청(EP)	영어, 불어, 독어, 네덜란드어, 스페인어
미국(US)	영어
스웨덴(SE)	스웨덴어, 영어, 불어, 덴마크어, 핀란드어, 노르웨이어, 스페인어
일본(JP)	일본어
호주(AU)	영어
러시아(RU)	러시아어, 영어, 불어, 독어, 스페인어
오스트리아(AT)	영어, 불어, 독어
중국(CN)	중국어, 영어
스페인(ES)	스페인어
한국(KR)	한국어, 영어, 일본어

“국제조사보고서”라 한다) 및 PCT 규칙 43.1에 따른 견해서(이하 “국제조사기관의 견해서”라 한다)를 작성하게 하여야 한다. 다만 출원인이 지식재산처 외의 기관을 국제조사기관으로 지정 한 경우에는 그러하지 아니하다(施規 106의11①).¹⁸⁾

(2) 예 외

① 청구범위 전부가 국제조사대상이 아닌 경우

국제출원의 청구범위 전부가 다음 중 어느 하나에 해당하여 유효한 국제조사를 할 수 없는 경우에는 심사관은 국제조사보고서를 작성하지 아니한다(施規 106의11⑤).

- i) 과학 또는 수학의 이론
- ii) 단순히 발견한 동물·식물의 변종
- iii) 사업활동, 순수한 정신적 행위의 수행 또는 유희에 관한 계획, 법칙 또는 방법
- iv) 수술 또는 치료에 의한 사람의 처치방법 및 진단방법
- v) 정보의 단순한 제시
- vi) 심사관이 선행기술을 조사할 수 없는 컴퓨터 프로그램
- vii) 발명의 설명·청구범위 또는 도면에 필요한 사항이 기재되어 있지 아니하거나 기재된 사항이 현저히 불명료하여 유효한 국제조사를 할 수 없는 경우

② 청구범위 일부가 국제조사대상이 아닌 경우

국제출원이 그 청구범위 일부에 관하여 위의 국제조사보고서의 불작성 사유에 해당하는 경우 또는 그에 기재된 종속항이 PCT 규칙 6.4(a)의 규정(종속항 기재방법)에 위반되는 경우에는 심사관은 국제조사보고서에 그 취지를 기재하고 그 청구범위에 대해서는 국제조사를 하지 아니한다(施規 106의11⑥). 이 경우 심사관은 국제조사를 하지 아니한 청구범위에 대해서는 국제조사기관의 견해서에 그 취지를 기재하고 그 청구범위에 대한 견해를 제시하지 아니한다(施規 106의11⑥).

3. 발명의 단일성 조사

(1) 단일성 조사 및 추가수수료 납부의 요구

1) 심사관은 국제출원이 조약 제17조(3)(a)에 따른 발명의 단일성 요건을 충족하지 아니하는 경우에는 기간을 정하여 추가수수료의 납부를 명하여야 한다. 이 경우 추가수수료의 납부명령을 받은 자가 지정된 기간에 추가수수료를 낸 경우에는 그 발명에 대하여 국제조사를 수행하여야 한다.

18) 지식재산처장은 우선권주장의 기초가 되는 선출원이 국어 또는 영어 외의 언어로 기재되어 있는 경우에는 기간을 정하여 번역문을 제출할 것을 출원인에게 명할 수 있다. 이 경우 번역문을 제출하려는 자는 선출원 번역문 제출서에 i) 번역문, ii) 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 한편 번역문의 제출명령을 받은 자가 지정된 기간에 번역문을 제출하지 아니하면 그 국제출원에 대하여 우선권주장이 없는 것으로 보고 국제조사기관의 견해서를 작성할 수 있다(施規 106의11②③④).

2) 그러나 심사관은 추가수수료 납부명령을 받은 자가 지정된 기간에 추가수수료를 내지 아니하면 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명 또는 1군의 발명과 관련되는 국제출원부분(이하 “주발명”이라 한다)만 국제조사보고서를 작성하여야 하며, 청구범위의 일부만 국제조사보고서를 작성하는 경우에는 국제조사기관의 견해에 그 취지를 기재하고 그 청구범위의 일부에만 견해를 제시하여야 한다. 한편 심사관은 국제출원에 대하여 국제조사보고서의 작성이 시작된 이후에 조약규칙 20.5 또는 20.5bis에 따라 명세서, 도면 등의 누락 부분 또는 정정 부분이 제출된 경우에는 조약규칙 40bis.1에 따라 기간을 정하여 추가수수료의 납부를 명할 수 있고, 추가수수료의 납부명령을 받은 자가 지정된 기간 내에 추가수수료를 납부한 경우에는 제출된 누락 부분 또는 정정 부분을 포함한 국제출원에 대하여 국제조사보고서를 작성해야 한다(施規 106의14).

(2) 추가수수료에 대한 이의신청

추가수수료의 납부명령을 받은 자는 i) 국제출원이 조약 제17조(3)(a)에 따른 발명의 단일성 요건을 충족하고 있는 경우, ii) 추가수수료의 납부명령을 받은 추가수수료 금액이 과다한 경우에는 그 이유를 적은 진술서를 첨부하여 지식재산처장에게 추가수수료의 납부명령에 대한 이의신청(이하 “추가수수료 이의신청”이라 한다)을 할 수 있다(施規 106의15①). 지식재산처장은 각 추가수수료 이의신청에 대하여 심사 결정할 3인의 심사관합의체를 구성할 심사관을 지정하여야 한다. 또한 지식재산처장은 지정된 심사관 중 1명을 심사장으로 지정하여야 한다(施規 106의16①③). 지식재산처장은 납부된 추가수수료의 전부 또는 일부를 출원인에게 반환하여야 한다는 결정이 있으면 그 결정에 의한 금액을 출원인에게 반환하여야 한다. 이 경우 추가수수료의 전부를 반환하는 때에는 추가수수료 이의신청료도 함께 반환하여야 한다. 심사장은 추가수수료 이의신청에 대한 결정이 있으면 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다(施規 106의16⑤⑥).

4. 선행조사의 확인

다른 국제출원을 기초로 하여 우선권을 주장한 국제출원에 대하여 심사관이 국제조사보고서를 작성하는 경우 해당 우선권주장의 기초가 되는 국제출원(이하 “선행국제출원”이라 한다)에 대한 국제조사보고서를 이용하는 경우 그 취지를 출원인에게 통지하고 지식재산처장은 출원인의 청구에 따라 납부된 조사료 일부를 반환하여야 한다. 다만 선행국제출원의 국제조사보고서가 지식재산처에서 작성되지 아니하면 그러하지 아니하다(施規 106의22①). 또한 국제출원에 대하여 심사관이 국제조사보고서를 작성할 때 해당 국제출원과 관련된 국내출원의 심사의 결과를 이용하는 경우 그 취지를 출원인에게 통지하고 지식재산처장은 출원인의 청구에 따라 납부된 조사료 일부를 반환하여야 한다(施規 106의22②).

5. 발명의 명칭 및 요약서의 누락 여부의 확인

(1) 심사관에 의한 발명의 명칭 결정

심사관은 국제출원의 발명의 명칭이 i) 국제출원에 발명의 명칭이 기재되어 있지 아니하고 발명의 명칭에 관하여 PCT 규칙 37.2에 따른 통지를 받지 못한 경우, ii) 국제출원에 기재된 발명의 명칭이 PCT 규칙 4.3에 따른 요건을 충족하지 못하는 경우에는 발명의 명칭을 정하여야 한다. 심사관은 정한 발명의 명칭을 국제조사보고서에 적어야 한다(施規 106의17).

(2) 심사관에 의한 요약서의 작성

심사관은 국제출원의 요약서가 i) 국제출원에 요약서가 포함되어 있지 아니하고 요약서에 관하여 PCT 규칙 38.2에 따른 통지를 받지 못한 경우, ii) 국제출원에 포함된 요약서가 PCT 규칙 8에 따른 요건을 충족하지 못하는 경우에는 요약서를 작성하여야 한다. 이 경우 지식재산처장은 심사관이 작성한 요약서를 국제조사보고서에 첨부하여 출원인에게 송부하여야 하며, 요약서가 국제조사보고서에 첨부되어 송부된 경우에는 출원인은 국제조사보고서 송부일부터 1개월 이내에 요약서에 대하여 보정신청 또는 의견진술을 하거나, 심사관이 요약서를 새로 작성하지 아니하면 출원인이 작성한 요약서에 대하여 보정신청을 할 수 있다. 한편 심사관은 보정신청 또는 의견진술이 있으면 요약서의 보정 여부를 결정하여야 하며, 요약서를 보정한 때에는 국제사무국에 그 보정사실을 통지하여야 한다(施規 106의18).

6. 선행기술의 조사 및 국제조사보고서의 작성

1) 심사관은 국제출원의 언어로 국제조사보고서와 견해서를 작성한다(施規 106의19①③). 국제조사는 관련이 있는 선행기술을 발견하여 국제조사보고서를 작성한다(PCT 18(1)). 여기서 「선행기술」이란 세계의 어느 장소에서나 서면에 의한 공개(도면, 그 밖의 예시를 포함한다)에 의하여 공중이 이용할 수 있게 되어 있으며 또한 청구범위에 기재되어 있는 발명의 신규성 및 진보성을 판단하는 데 도움이 될 수 있는 모든 것으로서 국제출원의 출원일보다 앞서 서면에 의한 개시를 통하여 공개된 기술을 의미한다. 다만 공중의 이용가능성이 국제출원일 전에 발생하였어야 한다(PCT 규칙 33.1(a)(b)).

2) 국제조사는 발명의 설명과 도면을 적당히 고려하여 청구범위에 기준을 두고 행한다(PCT 15(3), PCT 규칙 33.3(a)). 한편 국제조사는 가능하고 합리적인 범위에서 청구범위에 포함된 사항의 전체 또는 보정 후의 청구범위에 포함될 것이라고 합리적으로 예측되는 사항 전체에 대하여 수행한다(PCT 규칙 33.3(b)).

7. 특허성 여부의 판단 및 견해서의 작성

2004년도부터는 선행기술조사가 주기능이었던 국제조사기관의 기능이 대폭 확장되어 i) 산업상 이용가능성·신규성·진보성이 있는 것으로 보이는지 여부, ii) 그 국제출원이 국제조

사기관의 판단에 따라 PCT와 PCT 규칙의 요건들을 충족하는지 여부에 대한 견해를 국제 조사보고서와 함께 작성하여야 한다(PCT 규칙 43의2, 施規 106의19②).¹⁹⁾ 국제조사기관의 견해서는 국제예비심사기관의 견해와 유사하나 국제예비심사기관의 견해서는 국제예비심사 보고서 작성 전단계로서 특허성에 의문이 있는 경우 출원인에게 통보하여 출원인과 의견을 교환할 수 있는 수단으로 활용되고 있으나 국제조사기관의 견해서는 출원인과의 의견교환 없이 모든 국제출원 건에 대해서 작성된다는 차이점이 있다.

8. 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서의 송부

국제조사보고서, 국제조사를 하지 아니한다는 선언통지서 또는 국제조사기관의 견해서는 국제조사기관이 조사용 사본을 수령한 날로부터 3개월 또는 우선일로부터 9개월 중 늦게 만료하는 기간에 작성하여야 한다(PCT 규칙 42). 국제조사기관은 해당 서류를 작성 후 신속히 출원인과 국제사무국에 송부한다(PCT 18(2), 施規 106의20).

IV. 출원인의 절차

1. 국제조사보고서와 견해서의 활용

1) 국제출원인은 국제조사보고서에 기재된 관련 선행기술과 국제조사 견해서에 기재된 특허요건의 판단 결과 출원발명을 권리화하기 어렵다고 생각될 때는, 국제출원을 취하하거나 지정국의 국내단계절차를 밟지 아니함으로써 출원비용을 절감할 수 있다.²⁰⁾ 반면, 보정에 따라 문제를 해소할 수 있다고 판단할 때는, 출원인은 국제사무국에 대하여 PCT 제19조에 따른 보정을 할 수 있다.

19) 국제조사기관이 작성한 견해서에 출원된 발명이 특허를 받을 수 있는 것으로 나타날 경우 출원인은 특허를 받으려는 국가에 조기에 국내단계진입을 함으로써 보다 빠른 시간 내에 특허를 받을 수 있게 되고, 출원발명의 이전을 위한 협상에서도 유리한 입장에 설 수 있게 된다. 반면에, 출원발명이 특허를 받을 수 없는 것으로 나타날 경우 출원인은 출원내용이 공개되기 전에 국제출원을 취하함으로써 출원공개에 따른 불이익을 방지할 수 있으며, 무모하게 각국의 국내단계에 진입을 하지 아니함으로써 비용을 절약할 수 있다.

20) 국제조사보고서에서 선행기술은 관련정도에 따라 다음과 같이 나뉘어진다.

「X」: 해당 문헌 하나만을 고려할 때 신규성 또는 진보성이 결여되는 것으로 판단되는 경우

「Y」: 해당 문헌이 하나 또는 그 이상의 다른 문헌과 결합되었을 때 진보성이 결여된 것으로 판단되는 경우

「A」: 「X」 또는 「Y」에는 해당되지 않으나, 출원발명과 관련이 있는 경우

「O」: 구두에 의한 개시, 사용, 전시 등에 대하여 언급하고 있는 문헌

「P」: 우선일 후 국제출원일 전에 공개된 특허문헌

「E」: 국제출원일 전에 출원되고 국제출원일 후에 공개된 특허문헌

「T」: 국제출원일 또는 우선일보다 늦게 공개되나, 발명의 원리나 이론을 이해하기 위하여 인용된 문헌

「L」: 우선권주장에 의문을 제기하거나 해당 출원의 주요 청구내용을 부정하거나 그 밖의 내용을 확정하기 위하여 언급하고 있는 문헌

2) 한편 이에 대한 특별한 규정은 없으나 국제출원인은 국제조사기관이 작성한 견해서에 대해서 비공식적으로 의견서를 국제사무국에 제출할 수 있도록 하여 출원인이 국제예비심사를 청구하지 아니한 경우 국제조사기관이 작성한 견해서에 대하여 출원인에게 반박할 기회를 부여하고 있다. 이는 국제예비심사를 청구하지 아니한 경우 국제조사기관의 견해서의 내용이 국제사무국에 의하여 「국제예비보고서(특허협력조약 제1장)」로 발간되어 출원인에게 불이익을 줄 수 있기 때문이다.

2. 국제조사보고서 받은 후 보정(PCT 제19조 보정)

(1) 보정의 시기 및 대상

출원인은 국제조사보고서를 받은 후, 즉 국제조사기관이 국제사무국과 출원인에게 국제조사보고서를 송부한 날로부터 2개월의 기간 또는 우선일로부터 16개월 중 늦게 만료하는 기간에 국제사무국에 보정서를 제출함으로써 국제출원의 청구범위에 대하여 1회만 보정할 수 있다. 동시에 출원인은 보정의 내용 및 동 보정이 발명의 설명과 도면에 미칠 수 있는 영향에 대하여 PCT 규칙이 정하는 바에 따라 간단한 「설명서(statement)」를 제출할 수 있다. 이 경우 보정은 출원 시 국제출원의 개시된 범위를 넘어서는 아니되지만 지정국의 국내법령이 공개된 범위를 넘어서는 보정을 허용하고 있는 경우에는 해당 지정국에 있어서는 어떠한 영향도 미치지 아니한다(PCT 19).

(2) 보정서 및 설명서에 대한 번역문 또는 사본의 제출

각 지정국 법령에 따라 지정국에 보정서 및 설명서의 번역문 또는 사본을 제출하여야 국제사무국에 대하여 한 청구범위에 대한 보정서와 설명서의 제출이 각 지정국에서 인정받게 된다. 예를 들어 우리나라를 지정국으로 할 때는 번역문 또는 사본 제출과 관련하여 제201조제2항 및 제7항과 제204조가 적용된다.

V. 국제사무국의 절차

1. 국제공개

(1) 의 의

국제사무국은 수리관청으로부터 국제출원에 관한 서류를 송부받아 국제공개를 행한다(PCT 21(1)). 「국제공개」는 출원공개에 대한 국내법상의 요청을 국제출원에서도 만족시키고자 한 것으로서 새로운 기술정보의 확산을 조기에 달성하고자 한 것이다.

(2) 시 기

국제공개는 원칙적으로 우선일로부터 18개월이 지난 후에 국제사무국에 의하여 행해진다. 그러나 국제사무국은 우선일로부터 18개월이 지나기 전이라도 출원인이 조기공개신청을 하면 즉시 공개를 행하여야 한다(PCT 21(2)(3)).²¹⁾

(3) 대 상

원칙적으로 모든 국제출원이 국제공개된다. 다만 국제사무국은 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 국제공개를 하지 않을 수 있다.

- i) 국제공개 기술적 준비가 완료되기 전에 국제출원이 취하되거나 또는 취하된 것으로 보이는 경우(PCT 21(5))
- ii) 국제출원이 선량한 풍속이나 공공의 질서에 반하는 표현이나 도면을 포함하고 있거나 PCT 규칙에 규정된 비방하는 기재사항을 포함하고 있다고 인정하는 경우(PCT 21(6))
- iii) 국제출원이 어느 국가도 자국에 관한 한 국제출원을 공개할 필요가 없다고 선언한 국가만을 지정하고 있는 경우²¹⁾(다만 이 경우라도 국제사무국은 i) 출원인으로부터 청구가 있을 때, ii) 국제출원에 기초한 특허 또는 국내출원이 어느 지정국의 국내관청에 의하여 또는 동 국내관청을 대신하여 공표된 때에는 그 공표 후 우선일로부터 18개월이 지났다면 신속히 해당 국제출원을 국제공개한다)(PCT 64(3)).

(4) 내 용

국제공개는 전자적 형태로 웹사이트(patentscope.wipo.int)를 통해 공개되며, 출원서 자체를 제외한 출원인이 제출한 국제출원 전문이 공개되는데, 출원서의 서지적 사항과 요약서가 기재된 표지, 발명의 설명, 청구범위 및 도면, 제19조 보정서가 있는 경우에는 보정된 사항 및 설명서, 국제조사보고서 등을 포함한다. 국제조사기관의 견해서는 국제공개 대상이 아니었으나, PCT 규칙 개정으로 2014년 7월 1일부터 출원된 국제출원에 대해서는 국제공개 시점에 견해서가 공개된다(PCT 규칙 48.1, 48.2).

(5) 언 어

국제공개언어로 출원된 경우에는 각각 이들 언어로 공개가 되는데, 국제공개언어는 영어, 일본어, 불어, 독어, 러시아어, 스페인어, 중국어, 아랍어 등 8개국 언어가 지정되어 있었으나 2007년 10월 한국어 및 포르투갈어가 추가로 채택되었다.²³⁾

(6) 효 과

국제공개는 원칙적으로 지정국의 국내공개에 관한 국내법상의 요건을 갖추고 있다는 면도 있으므로 각국의 국내공개와 같은 효과가 주어진다. 그러한 이유에서 PCT는 국제공개에 대하여 가보호(假保護)의 규정을 두고 있다. 따라서 국제공개의 지정국에서의 효과는 그 지정국의 국내법령이 정하는 효과와 동일하지만(PCT 29(1)), 그 효과가 발생하는 시점에 대해서는 각 지정국의 선택으로서 정해진다(PCT 29(2)(3)(4)).

21) 출원인이 조기공개신청을 하는 경우에는 국내공개와 달리 특별공개수수료를 주어야 한다(PCT 규칙 48.4).

22) 현재 국제공개를 행할 필요가 없다고 선언한 국가는 미국뿐이고, 따라서 미국만을 지정국으로 하여 국제출원한 경우(예를 들면 국제출원하여 미국을 제외한 모든 계약국의 지정을 취하한 경우)에 국제공개되지 아니한다.

23) 국어가 국제공개어로 채택됨에 따라 출원인의 국제출원, 국제조사기관의 절차(국제조사보고서와 견해서, PCT 19 보정서), 국제예비심사기관의 절차(견해서, PCT 34 보정서, 국제예비심사보고서) 등을 국어로 진행할 수 있게 되었다.

2. 국제예비보고서(IPRP(chapter 1)²⁴⁾)의 발행

(1) 보고서의 발행 및 송달

국제예비심사보고서가 작성되지 않았거나 예정이 없는 경우 국제사무국은 국제조사기관의 견해서와 동일한 내용의 보고서를 국제조사기관을 대신하여 발행하여야 한다. 그 보고서에는 국제조사기관을 대신하여 국제사무국이 발행한다는 표시와 함께 「특허성에 관한 국제예비보고서(특허협력조약 제1장)」라는 명칭을 붙여야 한다. 그 후 국제사무국은 출원인과 지정관청에 국제예비보고서를 송달하여야 한다(PCT 규칙 44의2.2).

(2) 지정관청을 위한 번역문

국제예비보고서가 국내관청의 공식언어 또는 국제공개언어 중의 하나와 다른 언어로 발행된 경우 지정관청은 해당 보고서의 영어번역문을 요구할 수 있으며, 번역문은 국제사무국에 의하여 또는 국제사무국의 책임하에 준비되어야 한다(PCT 규칙 44의2.3).

3. 지정관청으로의 송달

1) 국제사무국은 국제조사보고서, 국제조사보고서를 작성하지 아니한다는 취지의 선언서, 국제예비보고서를 작성한 경우에는 국제예비보고서를 번역문과 함께 각 지정관청에 송달한다. 다만 해당 지정관청이 송달의무의 전부 또는 일부를 면제하는 경우에는 그러하지 아니한다(PCT 20(1)). 한편 청구범위가 PCT 제19조(1)에 따라 보정된 경우에 송달되는 문서는 출원 시에 있어서의 청구범위의 전문과 보정 후에 청구범위의 전문을 포함하거나 출원 시에 있어서의 청구범위의 전문과 보정을 명기하는 기재를 포함하며 PCT 제19조(1)에 규정하는 설명서가 있는 경우에는 동 설명서를 포함한다(PCT 20(2)).

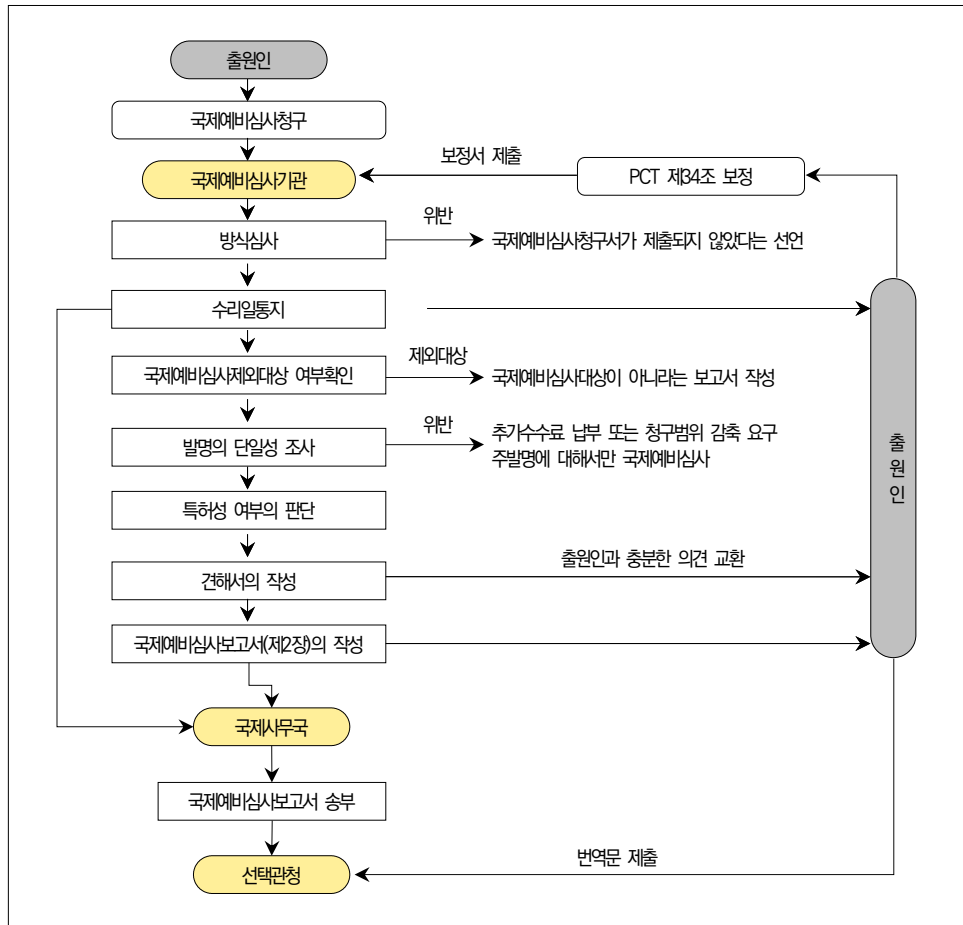
2) 국제조사기관은 지정관청 또는 출원인의 청구에 응하여 지정관청 또는 출원인에게 국제조사보고서에 기재된 문헌의 사본을 송부한다(PCT 20(3)).

4. 비밀유지

국제사무국 및 국제조사기관은 국제출원의 국제공개가 행하여지기 전에 어떠한 자 또는 당국에 대하여서도 국제출원을 공개하여서는 아니 된다. 다만 출원인의 청구에 의한 경우 또는 그의 승낙을 얻은 경우는 예외로 한다(PCT 30(1)). 국내관청은 i) 국제출원의 국제공개일, ii) PCT 제20조 규정에 의한 지정관청에서 국제출원의 수리일, iii) PCT 제22조에 따른 지정관청에서 국제출원의 사본의 수리일 중 가장 빠른 날 이전에 제3자에게 국제출원이 공개되도록 허용하여서는 아니 된다. 다만 출원인의 청구에 의한 경우 또는 그의 승낙을 얻은 경우는 예외로 한다(PCT 30(2)).

24) International Preliminary Report on Patentability.

제3절 대한민국 지식재산처의 국제예비심사



【그림 5-6】 국제예비심사 절차

I. 서 설

1) 「국제예비심사」란 출원인의 선택에 의하여 청구범위에 기재되어 있는 발명이 신규성(novelty), 진보성(inventive Step) 및 산업상 이용가능성(industrial applicability)을 가지는 지에 대한 견해를 표시하는 것을 목적으로 하는 국제단계의 절차를 말한다(PCT 33(1)). 국제 조사가 모든 국제출원에 적용되는 필요적 과정이라면 국제예비심사는 출원인의 선택에 따라 행해지는 임의적 과정이다. 국제예비심사 결과는 국제예비심사보고서로 작성되어 출원인과 국제사무국에 송부된다.

2) 국제예비심사보고서에 나타난 견해는 예비적이며, 계약국의 지식재산처를 구속하는 것은 아니기 때문에 계약국은 청구범위에 기재되어 있는 발명이 자국에서 특허를 받을 수 있는 발명인지 여부를 결정하는 경우는 추가 또는 다른 기준을 적용할 수 있다(PCT 33(5)).

II. 국제예비심사기관

1. 국제예비심사의 관할

국제예비심사는 국제예비심사기관이 행하며, 총회는 관계국제예비심사기관과 국제사무국의 적용협정에 따라 국제예비심사를 관할하게 될 하나 또는 둘 이상의 국제예비심사기관을 지정한다(PCT 32(2)(3)). 국제예비심사기관으로는 중국·일본·러시아·스웨덴·오스트리아·호주·한국·미국의 각 특허담당 정부기관 및 유럽특허청 등이 있다. 한편 출원인은 대한민국 지식재산처가 수리관청인 경우에는 국제예비심사기관으로서 대한민국, 오스트리아, 호주 및 일본 특허담당 정부기관 중 선택할 수 있다.

2. 최소한의 요건

국제예비심사기관으로 선정되어 활약하기 위해서는 다음의 요건을 만족하여야 한다(PCT 규칙 63).

- i) 국내관청 또는 정부 간 기구는 심사를 수행하기 위한 충분한 기술적 자격을 갖춘 상근 직원 100인 이상을 보유하고 있을 것
- ii) 국내관청 또는 정부 간 기구는 적어도 심사를 위하여 적절히 정비된 PCT 규칙 제34조에 정하는 최소한의 자료를 쉽게 이용할 수 있도록 정리해 놓을 것
- iii) 국내관청 또는 정부 간 기구는 필요한 기술분야를 심사할 수 있으며 적어도 PCT 규칙 제34조에 정하는 최소한의 자료에 사용된 언어 또는 번역된 언어를 이해할 수 있는 어학능력을 지닌 직원을 보유하고 있을 것
- iv) 국내관청 또는 정부 간 기구는 국제조사기관으로서 지명될 것

III. 대한민국 지식재산처에 국제예비심사의 청구

1. 국제예비심사의 청구를 할 수 있는 자

PCT 제31조(2)의 규정(PCT 제2장에 구속되는 계약국의 거주자 또는 국민 등)에 해당하는 출원인은 국제예비심사기관(지식재산처장)에게 국제출원에 대하여 국제예비심사를 청구할 수 있다(施規 106의23①).²⁵⁾ 한편 지식재산처장은 조약규칙 54.4에 따라 국제예비심사를 청구할 수 없는 출원인이 국제예비심사를 청구한 경우에는 해당 국제예비심사청구서는 제출되지 아니한 것으로 본다(施規 106의26).

2. 국제예비심사의 청구기간

1) 국제예비심사를 청구하려는 자는 i) 국제조사보고서 및 국제조사기관의 견해서 또는 PCT 제17조(2)(a)에 따라 국제조사보고서를 작성하지 아니한다는 취지의 통지서를 출원인에게 송부한 날부터 3개월과 ii) 우선일로부터 22개월의 기간 중 늦게 끝나는 날 이내에 국제예비심사청구서 2통을 지식재산처장에게 제출하여야 한다(施規 106의23②). 기간의 만료 후에 국제예비심사청구서가 제출된 경우에는 해당 국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 것으로 본다. 이 경우 지식재산처장은 그 취지를 출원인에게 통지하여야 한다(施規 106의23⑤).

2) 출원인은 국제예비심사청구서를 제출하는 경우 국제예비심사청구를 할 수 있는 기간에 국제출원에 관한 의견서 또는 보정서를 지식재산처장에게 제출할 수 있다(施規 106의23③).

3. 국제예비심사청구서의 제출

1) 국제예비심사를 청구하려는 자는 다음의 사항을 적은 국제예비심사청구서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 국제예비심사청구서는 국제출원의 언어로 작성하여야 한다. 한편 출원인·대리인 또는 대표자는 PCT 규칙 53.8에 따라 국제예비심사청구서에 기명을 한 후 서명 또는 날인하여야 한다(施規 106의24).

i) 국제예비심사청구라는 표시

ii) 출원인에 관한 사항

iii) 대리인 또는 대표자가 있는 경우에는 그 대리인 또는 대표자에 관한 사항

iv) 국제예비심사청구에 관련된 국제출원에 관한 사항

v) 보정에 관한 사항(PCT 규칙 53.9에 따른 기재사항이 있는 경우에 한한다)

25) 출원인(출원인이 둘 이상인 경우에는 최소한 1명의 출원인)이 PCT 제2장의 규정(국제예비심사)에 구속되는 계약국의 거주자 또는 국민인 경우에 그와 같은 계약국의 수리관청 또는 그와 같은 계약국을 위하여 행동하는 수리관청에 국제출원을 하였을 때는 동 출원인은 국제예비심사의 청구를 할 수 있다. 한편 총회는 국제출원을 할 자격을 가지는 자에 대하여 동인(同人)이 본 조약의 비당사국 또는 PCT 제2장의 규정(국제예비심사)에 구속되지 아니한 당사국의 거주자나 국민인 경우에 있어서도 국제예비심사의 청구를 허용하도록 결정할 수 있다(PCT 31, PCT 규칙 54.2).

2) 국제예비심사의 청구서에는 국제예비심사의 결과를 이용하는 것을 출원인이 의도하는 하나 또는 둘 이상의 계약국(선택국)을 표시한다. 다만 국제예비심사청구서가 제출되는 경우 PCT 제2장에 구속되고 지정이 이루어진 모든 계약국이 선택된 것으로 본다(施規 106의23④). 이를 「자동선택제도」라 한다.²⁶⁾

4. 수수료의 납부

국제예비심사를 청구하려는 자는 수수료를 내야 한다(施規 106의25).

5. 국제예비심사청구 또는 선택국의 취하

국제출원인은 지식재산처장에 대하여 우선일로부터 2년 6개월을 지나기 전과 출원인이 출원심사청구를 하기 전 중 빠른 때까지 국제예비심사청구 또는 선택국의 선택을 취하할 수 있다(施規 106의7, 106의46).

IV. 국제예비심사기관(대한민국 지식재산처)에서의 절차

1. 방식심사

(1) 절차의 보완

지식재산처장은 국제예비심사청구서에 국제예비심사청구의 대상인 국제출원이 특정되지 아니하면 기간을 정하여 보완을 명하여야 한다. 지식재산처장은 보완명령을 받은 자가 지정된 기간에 보완한 경우에는 그 보완서의 도달일에 국제예비심사청구서가 수리된 것으로 보며, 지정된 기간에 보완하지 아니한 경우에는 그 국제예비심사청구서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 한편 지식재산처장에 의하여 국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 것으로 보기 전까지는 출원인의 신청에 따라 보완할 수 있는 기간을 연장할 수 있다(施規 106의27).

26) 자동지정제도와 자동선택제도를 비교하면 다음과 같다.

구 분	내 용
자동지정제도	■ 국제출원할 때 모든 PCT 계약국이 자동적으로 지정된 것으로 보는 제도 - 지정국을 1개도 지정하지 아니한 경우 보완사유에 해당한다는 규정(法 194①각호)은 무의미 ■ 자동지정의 도입으로 PCT 출원할 때 지정료가 출원료에 포함됨. - 지정료를 내지 아니한 지정국은 취하간주(法 196②)는 무의미 ■ 단, 자기지정에 의하여 선출원이 취하됨으로써 출원인에게 불이익이 되는 것을 방지하기 위해 자동지정 배제 가능
자동선택제도	■ 국제예비심사를 청구할 때 PCT 제2장에 구속되고 지정이 이루어진 모든 PCT 계약국이 자동적으로 선택된 것으로 보는 제도 ■ PCT 제2장에 구속되는 PCT 계약국 : 국제예비심사를 허용하는 PCT 계약국을 의미.

(2) 절차의 보정

1) 지식재산처장은 국제예비심사청구서가 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 보정을 명하여야 한다(施規 106의29①).

i) 국제예비심사청구서 2통을 제출하지 아니한 경우

ii) 국제예비심사청구라는 표시, 출원인에 관한 사항, 대리인 또는 대표자가 있는 경우에는 그 대리인 또는 대표자에 관한 사항, 국제예비심사청구에 관련된 국제출원에 관한 사항을 표시하지 아니한 경우(다만 출원인이 2명 이상인 경우 출원인에 관한 표시는 국제예비심사를 청구할 수 있는 출원인 중 최소 1명에 관하여 기재된 경우를 제외한다.)

iii) 국제예비심사청구서를 국제출원의 언어로 작성하지 않거나 출원인·대리인 또는 대표자는 PCT 규칙 53.8에 따라 국제예비심사청구서에 기명을 한 후 서명 또는 날인하지 아니한 경우(다만 같은 조 제3항에 관한 사항은 출원인이 2명 이상이거나 대리인이 2명 이상인 경우 그들 중 최소 1명이 기명을 한 후 서명 또는 날인한 경우는 제외하고, 대리인이 기명한 후 서명 또는 날인한 경우에는 출원인(출원인이 2명 이상인 경우에는 모든 출원인)이 기명을 한 후 서명 또는 날인한 위임장이 첨부되어야 한다)

2) 지식재산처장은 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정한 경우에는 국제예비심사청구서의 도달일에 국제예비심사청구서가 수리된 것으로 보며, 지정된 기간에 보정하지 아니하면 그 국제예비심사청구서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 한편 지식재산처장은 국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 것으로 보기 전까지는 출원인의 신청에 따라 보정기간을 연장할 수 있다(施規 106의29③④⑤).

(3) 수수료 미납부에 대한 보정

1) 지식재산처장은 국제예비심사를 청구한 자가 국제예비심사 수수료를 i) 국제예비심사청구서 제출일부터 1개월과 ii) 우선일로부터 22개월 중 늦게 끝나는 날 이내(다만 국제예비심사청구서가 관할 국제예비심사기관에 제출되지 아니한 경우 또는 iii) 국제조사와 국제예비심사를 동시에 수행하는 경우에는 PCT 규칙 57.3(b) 또는 (c)에 따른다.)에 내지 아니하면 PCT 규칙 제58.1조(a)에 따라 1개월 이내에 그 수수료 및 가산료를 낼 것을 명하여야 한다(施規 106의30①).

2) 지식재산처장은 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 수수료 및 가산료를 내지 아니하면 해당 국제예비심사청구서는 제출되지 아니한 것으로 본다(施規 106의30③).

2. 수리일의 통지

지식재산처장은 국제예비심사청구서를 수리한 때에는 그 수리일을 출원인에게 즉시 통지하여야 한다(施規 106의28). 한편 지식재산처장은 국제예비심사청구서가 제출되지 아니한 것으로 보는 경우에는 그 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다(施規 106의31).

3. 국제예비심사제외대상 여부의 확인

(1) 원 칙

지식재산처장은 제106조의23에 따라 국제예비심사가 청구된 국제출원에 대하여 심사관에게 국제예비심사를 하게 한다(施規 106의37①).

(2) 예 외

① 청구범위 전부가 국제예비심사대상이 아닌 경우

국제출원의 청구범위의 전부가 다음 중 어느 하나의 사항에 해당하는 경우에는 심사관은 국제예비심사를 하지 아니한다는 취지를 PCT 제34조(2)(c)에 따른 견해서(이하 “국제예비심사기관의 견해서”라 한다) 또는 국제예비심사보고서에 기재하여야 한다(施規 106의37②).

- i) 특허법 시행규칙 제106조의11제2항제1호에 규정된 국제조사보고서를 작성하지 아니한 대상에 해당하는 경우
- ii) 발명의 설명·청구범위 또는 도면에 기재된 사항이 현저히 불명료하거나 청구범위가 발명의 설명에 의하여 충분히 뒷받침되어 있지 아니하여 PCT 제33조에 따른 신규성·진보성 또는 산업상 이용가능성에 대하여 유효한 견해를 제시할 수 없는 경우
- iii) 국제조사보고서가 작성되지 아니하여 심사관이 국제예비심사를 하지 아니한다고 결정한 경우

② 청구범위 일부가 국제예비심사대상이 아닌 경우

국제출원의 청구범위의 일부가 상기 사유에 해당하는 경우 또는 청구범위에 기재된 종속항이 PCT 규칙 66.2(a)의 규정에 위반되는 경우에는 심사관은 견해서 또는 국제예비심사보고서에 그 취지를 기재하고 그 청구범위에 대해서는 국제예비심사를 하지 아니한다(施規 106의37③).

4. 발명의 단일성 조사

1) 심사관은 국제출원이 PCT 제34조(3)(a)에 따른 발명의 단일성 요건을 충족하지 아니하는 경우에는 기간을 정하여 청구범위의 감축 또는 추가수수료의 납부를 명할 수 있다. 심사관은 위의 명령을 받은 자가 지정된 기간에 청구범위를 감축함이 없이 추가수수료를 내지 않거나 적게 낸 경우에는 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명 또는 일 군의 발명과 관련되는 국제출원 부분에만 국제예비심사를 하고 그 취지를 국제예비심사보고서에 적는다. 또한 위의 명령을 받은 자가 지정된 기간에 청구범위를 감축하였으나 발명의 단일성 요건을 충족하지 아니하는 경우에 관하여도 같은 취급을 한다(施規 106의39①②③).

2) 국제조사의 추가수수료 이의신청(施規 106의15), 추가수수료 이의신청에 대한 결정(施規 106의16)은 국제예비심사에 관한 발명의 단일성에 관하여 이를 준용한다(施規 106의39④).

5. 특허성 여부의 판단

1) 심사관은 출원 시의 국제출원에 기초를 두고 PCT 제19조 보정서, 제34조 보정서 및 국제조사보고서에 인용된 문헌을 참고하여 청구범위에 기재된 발명이 신규성, 진보성 및 산업상의 이용가능성을 가진지에 대하여 판단한다.

2) 한편 이러한 특허요건을 판단하기 위해서는 우선권주장의 적법성을 검토하여야 하므로 지식재산처장은 우선권주장의 기초가 되는 선출원이 국어 또는 영어 외의 언어로 기재되어 있는 경우에는 기간을 정하여 국어에 의한 번역문을 제출할 것을 출원인에게 명할 수 있다. 위의 번역문의 제출명령을 받은 자가 기간에 번역문을 제출하지 아니하면 그 국제출원에 대하여 우선권주장은 없는 것으로 보고 국제예비심사보고서를 작성할 수 있다(施規 106의35).

6. 견해서의 작성

(1) 국제조사기관의 견해서를 1차 견해서로 간주

국제예비심사가 청구된 경우 국제조사기관의 견해서는 그 국제출원에 대한 국제예비심사기관의 견해서로 본다(施規 106의40①).

(2) 출원인과 의견교환 및 국제예비심사기관의 견해서 작성

1) 국제조사기관의 견해서를 국제예비심사기관의 1차 견해서로 봄에도 불구하고 국제출원이 다음에 해당하는 경우에는 심사관은 국제예비심사보고서의 작성 전에 국제예비심사기관의 견해서를 추가로 작성하여 송부하고 기간을 정하여 출원인에게 의견서 및 보정서를 제출할 수 있는 기회를 줄 수 있다(施規 106의40②).

- i) 특허법 시행령 제106조의36 제2항의 규정의 국제예비심사보고서 작성개시 전까지의 보정의 범위에 위반되는 경우
- ii) 특허법 시행령 제106조의37 제2항의 국제예비심사를 하지 아니한 경우 또는 동조 제3항의 규정에 해당하는 경우
- iii) 특허법 시행령 제106조의38에 따른 제출명령을 받은 자가 서열목록 등을 제출하지 아니하여 유효한 국제예비심사를 할 수 없는 경우
- iv) 청구범위에 기재되어 있는 발명이 PCT 제33조에 따른 신규성·진보성 또는 산업상 이용가능성의 요건을 충족하지 아니하는 경우
- v) 국제출원의 형식 또는 내용이 PCT 및 PCT 규칙에서 정하고 있는 요건을 충족하지 아니하는 경우
- vi) 그 밖에 PCT 및 PCT 규칙에 따라 국제예비심사기관의 견해서 작성이 필요한 경우

2) 국제조사기관의 견해서와 다른 점은 출원인은 국제예비심사기관과 구두와 서면으로 연락할 권리를 가진다(PCT 34(2)(a)) 즉 국제예비심사기관은 전화, 서면 또는 면담에 의하여 수시로 출원인과 자유로이 의견을 교환할 수 있으며 재량으로 출원인이 요구하는 경우에 2회 이상의

면담을 인정할 것인지의 여부 또는 출원인으로부터의 서면에 의한 비공식 의견에 대하여 회답할 것인지의 여부를 결정할 수 있다(PCT 규칙 66.6). 이 경우 심사관은 정하여진 기간에 출원인의 신청이 있는 경우에는 그 기간을 연장할 수 있으며, 출원인의 신청이 있는 경우 기간을 정하여 출원인에게 국제출원에 관한 의견서 및 보정서를 제출할 수 있는 기회를 추가로 줄 수 있다(施規 106의40③④). 만약 출원인이 견해서에 대하여 아무런 조치를 취하지 아니한 경우 국제예비심사보고서는 부정적으로 작성된다.

【표 5-3】 국제조사기관의 견해서와 국제예비심사기관의 견해서의 비교

구 분	국제조사기관의 견해서	국제예비심사기관의 견해서
대 상	모든 PCT 출원 건 → 필수절차	국제예비심사청구가 있는 건 → 임의절차
출원인과의 의견교환기회	없음	특허성 여부에 대한 판단이 부정적일 경우 최소한 1회 견해서를 작성하여 출원인에게 통보하고 출원인의 의견 제출 또는 보정의 기회를 주어야 함
견해서 수령 후 출원인의 대응방안	국제예비심사를 청구하지 아니한 경우에는 출원인의 대응방법에 대한 명문의 규정은 없으나 비공식적으로 국제사무국에 대하여 의견 제출할 수 있으며, 국제조사보고서를 받은 후 PCT 제19조 보정 가능	최초 출원의 범위에서 발명의 설명, 청구범위, 도면의 PCT 제34조 보정이 가능하고 견해서 내용에 대한 의견 제출도 가능

7. 국제예비심사보고서(IPRP(chapter II))의 작성

심사관은 국제예비심사보고서를 국제출원 언어로 작성하여야 한다(施規 106의41). 한편 보고서에는 국제예비심사기관에 의하여 작성된 국제예비심사보고서라는 표시와 함께 「특허성에 관한 국제예비보고서(특허협력조약 제2장)」와 같이 명칭을 붙인다(PCT 규칙 70.15(b)).

8. 국제예비심사보고서의 송부

지식재산처장은 심사관이 국제예비심사보고서를 작성한 때에는 그 국제예비심사보고서 및 그 부속서류를 출원인과 국제사무국에게 송부하여야 한다(施規 106의42).

9. 비밀유지

국제사무국 및 국제예비심사기관은 어떠한 때에도 어떠한 자 또는 당국(국제예비심사보고서의 작성 후에는 선택관청은 제외)에도 국제예비심사의 일건 서류, 국제예비심사보고서의 작성 유무 및 국제예비심사의 청구 또는 선택국의 취하 여부에 대하여 정보를 공개하여서는 아니 된다. 다만 출원인의 청구에 의하는 경우 또는 그의 승낙을 얻을 경우는 예외로 한다(PCT 38).

V. 출원인의 절차

1. 국제예비심사보고서 작성 전의 보정(PCT 제34조 보정)

(1) 보정의 시기 및 대상

출원인은 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 청구범위, 발명의 설명 및 도면을 횡수에 무관하게 보정하여 그 보정서를 국제예비심사기관에 제출할 수 있으나, 그 보정의 범위는 국제출원에 기술된 범위를 넘어서는 아니 된다(PCT 34(2)(b)). 구체적으로 명백한 착오의 정정을 제외하고, 청구범위의 취하, 발명의 설명상의 일부삭제 및 서면의 삭제를 포함한 청구범위, 발명의 설명 또는 도면에 대한 모든 변경은 보정으로 간주한다(PCT 규칙 66.5).

(2) 보정서에 대한 번역문 또는 사본의 제출

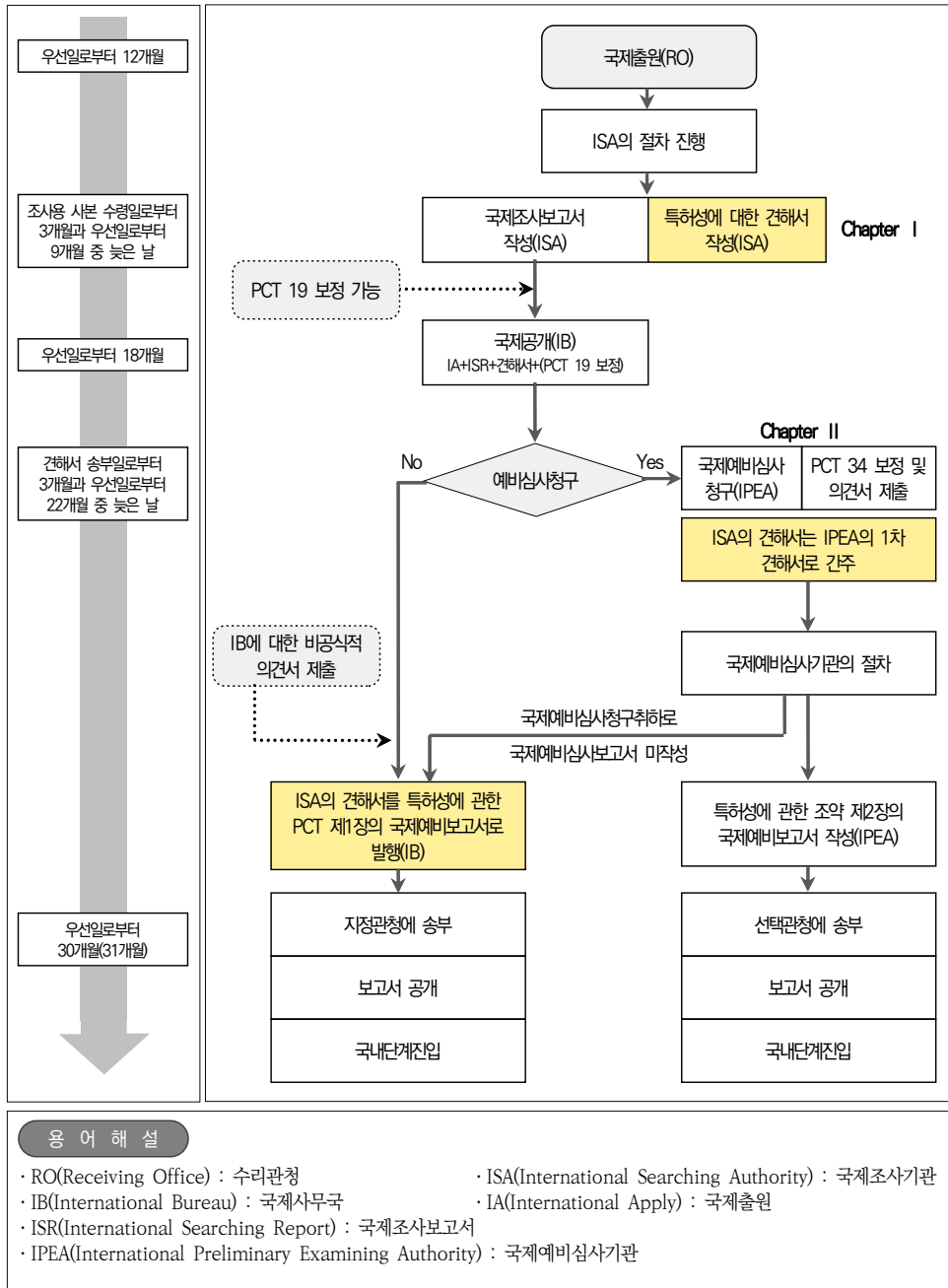
각 선택국 법령에 따라 선택국에 보정서의 번역문 또는 사본을 제출하여야 국제예비심사에 대하여 한 보정이 각 선택국에서 인정받게 된다. 예를 들어 우리나라를 선택국으로 하면 번역문 또는 사본 제출과 관련하여 제205조가 적용된다.

2. 국제예비심사보고서의 활용

출원인은 국제예비심사보고서를 토대로 출원발명에 대하여 검토한 결과 특허성이 없는 것으로 판단되면 이후의 국내단계절차를 밟지 아니함으로써 출원비용을 절감할 수 있다.

【표 5-4】 국제조사와 국제예비심사의 비교

구 분	국제조사	국제예비심사
목 적	■ 국제조사기관이 국제출원과 관련된 선행기술의 존재 여부의 발견 ■ 국제조사기관이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 인정 여부에 대하여 예비적이고 구속력이 없는 견해를 표시	■ 국제예비심사기관이 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성 인정 여부에 대하여 예비적이며 구속력이 없는 견해를 표시
대 상	■ 모든 국제출원이 국제조사의 대상	■ 국제조사와는 달리 출원인의 선택에 의한 임의적 절차로 국제출원의 청구범위에 기재되어 있는 발명
범 위	■ 발명의 설명, 도면에 타당한 고려를 하여 청구범위를 기초	■ 청구범위와 발명의 설명, 도면을 기초
이용할 수 있는 자	■ 국제출원을 할 수 있는 자	■ PCT 제2장 규정에 구속된 계약국의 거주자 또는 국민으로서 그러한 계약국을 위해 행동하는 수리관청에 출원한 경우
지정/선택	■ 출원서 제출로 출원일의 모든 계약국의 지정을 구성	■ 청구서 제출로 조약 제2장에 구속되는 모든 지정국의 선택을 구성
의견교환	■ 불리한 보고서 작성 전에 예고받을 권리가 없으며 원칙적으로 국제조사기관과 출원인간의 의견교환 불허용	■ 불리한 보고서 작성 전에 예고받을 권리(견해서 송부)있으며 국제예비심사기관과 출원인간의 구두 또는 서면에 의한 의견교환 허용
보정의 범위	■ 국제조사 보고서를 송달받은 후 국제사무국에 대하여 1회에 한해 청구범위에 대하여 보정(PCT 19) ■ 동시에 설명서 제출 가능	■ 국제예비심사 보고서가 작성 전까지 국제예비심사기관에 대하여 청구범위, 발명의 설명 및 도면에 대하여 횡수의 제한없이 보정(PCT 34)
발명의 단일성	■ 추가수수료의 납부를 요구 ■ 주발명에 관계되는 국제출원 부분과 추가수수료가 소정의 기간에 지불된 발명에 관계되는 국제출원 부분에 관하여 국제조사보고서를 작성	■ 출원인에게 그의 선택에 따라 요건을 충족하도록 청구범위를 제한하거나 추가수수료를 낼 것을 요구 ■ 주발명에 관계되는 국제출원 부분과 추가수수료가 소정의 기간에 지불된 발명에 관계되는 국제출원 부분에 관하여 국제예비심사보고서를 작성
공개 여부	■ 국제조사보고서와 견해서는 국제출원의 공개시에 전자적 형태로 공개	■ 국제예비심사보고서는 비공개(선택관청은 제외)
종료형식	■ 국제조사보고서의 작성 또는 국제조사보고서를 작성하지 아니한다는 선언 / 견해서의 작성	■ 국제예비심사보고서의 작성



【그림 5-7】 국제조사와 국제예비심사의 비교

제3장

국제특허출원에 관한 특례

제199조 【국제출원에 의한 특허출원】

- ① 「특허협력조약」에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정 국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다.
- ② 제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(이하 “국제특허출원”이라 한다)에 관하여는 제42조의2, 제42조의3 및 제54조를 적용하지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제200조 【공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 특례】

국제특허출원된 발명에 관하여 제30조제1항제1호를 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서면 및 이를 증명할 수 있는 서류를 같은 조 제2항에도 불구하고 총리령으로 정하는 기간에 지식재산청장에게 제출할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제200조의2 【국제특허출원의 출원서 등】

- ① 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조제1항에 따라 제출된 특허출원서로 본다.
- ② 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면으로 본다.
- ③ 국제특허출원에 대해서는 다음 각 호의 구분에 따른 요약서 또는 국어번역문을 제42조제2항에 따른 요약서로 본다.
 1. 국제특허출원의 요약서를 국어로 적은 경우: 국제특허출원의 요약서
 2. 국제특허출원의 요약서를 외국어로 적은 경우: 제201조제1항에 따라 제출된 국제특허출원의 요약서의 국어번역문(제201조제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 말한다)

[본조신설 2014.6.11.]

제201조 【국제특허출원의 국어번역문】

- ① 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 「특허협력조약」 제2조(xi)의 우선일(이하 “우선일”이라 한다)부터 2년 7개월(이하 “국내서면제출기간”이라 한다) 이내에 다음 각 호의 국어번역문을 지식재산청장에게 제출하여야 한다. 다만, 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 제203조제1항에 따른 서면에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외한다)에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다.
 1. 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문
 2. 국제특허출원의 요약서의 국어번역문
- ② 제1항에도 불구하고 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다.

- ③ 제1항에 따라 국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(제1항 단서에 따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만, 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다.
- ④ 제1항에 따른 출원인이 국내서면제출기간에 제1항에 따른 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다.
- ⑤ 특허출원인이 국내서면제출기간의 만료일(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 경우에는 그 청구일을 말하며, 이하 “기준일”이라 한다)까지 제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 “최종 국어번역문”이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다.
- ⑥ 특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 제5항을 적용하지 아니한다.
- ⑦ 제6항 전단에 따라 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 기간에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2016.2.29.>
- ⑧ 제2항에 따라 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 경우에는 제204조제1항 및 제2항을 적용하지 아니한다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제202조 【특허출원 등에 의한 우선권 주장의 특례】

- ① 국제특허출원에 관하여는 제55조제2항 및 제56조제2항을 적용하지 아니한다.
- ② 제55조제4항을 적용할 때 우선권 주장을 수반하는 특허출원이 국제특허출원인 경우에는 같은 항 중 “특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”으로, “출원공개되거나”는 “출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나”로 본다. 다만, 그 국제특허출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 경우에는 제55조제4항을 적용하지 아니한다.
- ③ 제55조제1항, 같은 조 제3항부터 제5항까지 및 제56조제1항을 적용할 때 선출원이 국제특허출원 또는 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우에는 다음 각 호에 따른다.
 1. 제55조제1항 각 호 외의 부분 본문, 같은 조 제3항 및 제5항 각 호 외의 부분 중 “출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.
 - 가. 선출원이 국제특허출원인 경우: “국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”
 - 나. 선출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우: “국제출원일까지 제출된 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”
 2. 제55조제4항 중 “선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 보고, “선출원에 관하여 출원공개”는 “선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개”로 본다.
 - 가. 선출원이 국제특허출원인 경우: “선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”
 - 나. 선출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원인 경우: “선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”
 3. 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때”는 “국제출원일부터 1년 3개월이 지난 때 또는 제201조제5항이나 「실용신안법」 제35조제5항에 따른 기준일 중 늦은 때”로 본다.

④ 제55조제1항, 같은 조 제3항부터 제5항까지 및 제56조제1항을 적용할 때 제55조제1항에 따른 선출원이 제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우에는 다음 각 호에 따른다.

1. 제55조제1항 각 호 외의 부분 본문, 같은 조 제3항 및 제5항 각 호 외의 부분 중 “출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.
 - 가. 선출원이 제214조제4항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원인 경우: “제214조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”
 - 나. 선출원이 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우: “「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”
2. 제55조제4항 중 “선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 다음 각 목의 구분에 따른 것으로 본다.
 - 가. 선출원이 제214조제4항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원인 경우: “제214조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 선출원의 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면”
 - 나. 선출원이 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원인 경우: “「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날의 선출원의 국제출원의 고안의 설명, 청구범위 또는 도면”
3. 제56조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “그 출원일부터 1년 3개월이 지난 때”는 “제214조제4항 또는 「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날부터 1년 3개월이 지난 때 또는 제214조제4항이나 「실용신안법」 제40조제4항에 따른 결정을 한 때 중 늦은 때”로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

제203조 【서면의 제출】

- ① 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간에 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조제1항에 따른 국어번역문을 함께 제출하여야 한다.
 1. 출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 3. 발명의 명칭
 4. 발명자의 성명 및 주소
 5. 국제출원일 및 국제출원번호
- ② 제1항 후단에도 불구하고 제201조제1항 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적어 제1항 전단에 따른 서면을 제출하는 경우에는 국어번역문을 함께 제출하지 아니할 수 있다.
- ③ 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 보정기간을 정하여 보정을 명하여야 한다.
 1. 제1항 전단에 따른 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우
 2. 제1항 전단에 따라 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반되는 경우
- ④ 제3항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하면 지식재산처장은 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제204조 【국제조사보고서를 받은 후의 보정】

- ① 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허

출원의 청구범위에 관하여 보정을 한 경우 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다. 이하 이 조 및 제205조에서 같다) 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 보정서의 국어번역문
2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 보정서의 사본
- ② 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 청구범위가 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다.
- ③ 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 설명서를 국제사무국에 제출한 경우 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 기준일까지 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
 1. 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 설명서의 국어번역문
 2. 국어로 출원한 국제특허출원인 경우: 그 설명서의 사본
- ④ 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항 또는 제3항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

제205조 【국제예비심사보고서 작성 전의 보정】

- ① 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따라 국제특허출원의 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우 기준일까지 다음 각 호의 구분에 따른 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
 1. 외국어로 작성된 보정서인 경우: 그 보정서의 국어번역문
 2. 국어로 작성된 보정서인 경우: 그 보정서의 사본
- ② 제1항에 따라 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다.
- ③ 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 제1항에 따른 절차를 밟지 아니하면 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따른 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만, 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

제206조 【재외자의 특허관리인의 특례】

- ① 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 제5조제1항에도 불구하고 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다.
- ② 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출한 재외자는 총리령으로 정하는 기간에 특허관리인을 선임하여 지식재산처장에게 신고하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

제207조 【출원공개시기 및 효과의 특례】730

- ① 국제특허출원의 출원공개에 관하여 제64조제1항을 적용하는 경우에는 “다음 각 호의 구분에 따른

날부터 1년 6개월이 지난 후”는 “국내서면제출기간(제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장해 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출기간을 말한다. 이하 이 항에서 같다)이 지난 후(국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제특허출원으로서 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개된 경우에는 우선일부터 1년 6개월이 되는 날 또는 출원심사의 청구일 중 늦은 날이 지난 후)”로 본다.

- ② 제1항에도 불구하고 국어로 출원한 국제특허출원에 관하여 제1항에 따른 출원공개 전에 이미 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개가 된 경우에는 그 국제공개가 된 때에 출원공개가 된 것으로 본다.
- ③ 국제특허출원의 출원인은 국제특허출원에 관하여 출원공개(국어로 출원한 국제특허출원인 경우 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 있는 후 국제특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을 서면으로 경고할 수 있다.
- ④ 국제특허출원의 출원인은 제3항에 따른 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고도 그 국제특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록 시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만, 그 청구권은 해당 특허출원이 특허권의 설정등록된 후에만 행사할 수 있다. <개정 2019. 1. 8>

[전문개정 2014.6.11.]

제208조 【보정의 특례 등】

- ① 국제특허출원에 관하여는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추지 아니하면 제47조제1항에도 불구하고 보정(제204조제2항 및 제205조제2항에 따른 보정은 제외한다)을 할 수 없다. <개정 2014.6.11.>
 1. 제82조제1항에 따른 수수료를 낼 것
 2. 제201조제1항에 따른 국어번역문을 제출할 것. 다만, 국어로 출원된 국제특허출원인 경우는 그러하지 아니하다.
 3. 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사를 청구한 때를 말한다)이 지날 것
- ② 삭제 <2001.2.3.>
- ③ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 전단을 적용할 때에는 “특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면”은 “국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구 범위 또는 도면”으로 본다. <개정 2014.6.11.>
- ④ 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 후단을 적용할 때에는 “외국어특허출원”은 “외국어로 출원된 국제특허출원”으로, “최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)”은 “제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)”으로 본다. <신설 2014.6.11.>

- ⑤ 삭제 <2001.2.3.>

[제목개정 2014.6.11.]

제209조 【변경출원시기의 제한】

「실용신안법」 제34조제1항에 따라 국제출원일에 출원된 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우에는 이 법 제53조제1항에도 불구하고 「실용신안법」 제17조제1항에 따른 수수료를 내고 같은 법 제35조제1항에 따른 국어번역문(국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우는 제외한다)을 제출한 후(「실용신안법」 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 것으로 보는 국제출원을 기초로 하는 경우에는 같은 항에 따른 결정이 있는 후)에만 변경출원을 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제210조 【출원심사청구시기의 제한】

국제특허출원에 관하여는 제59조제2항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에만 출원 심사의 청구를 할 수 있다.

1. 국제특허출원의 출원인은 제201조제1항에 따라 국어번역문을 제출하고(국어로 출원된 국제특허출원의 경우는 제외한다) 제82조제1항에 따른 수수료를 낸 후
2. 국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 국내서면제출기간(제201조제1항 각 호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다)이 지난 후

[전문개정 2014.6.11.]

제211조 【국제조사보고서 등에 기재된 문헌의 제출명령】

지식재산처장은 국제특허출원의 출원인에 대하여 기간을 정하여 「특허협력조약」 제18조의 국제조사보고서 또는 같은 조약 제35조의 국제예비심사보고서에 적혀 있는 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제212조 삭제 <2006.3.3.>

제213조 삭제 <2014.6.11.>

제214조 【결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원】

- ① 국제출원의 출원인은 「특허협력조약」 제4조(1)(ii)의 지정국에 대한민국을 포함하는 국제출원(특허출원만 해당한다)이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 총리령으로 정하는 기간에 총리령으로 정하는 바에 따라 지식재산처장에게 같은 조약 제25조(2)(a)에 따른 결정을 하여줄 것을 신청할 수 있다.
 1. 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a)에 따른 거부를 한 경우
 2. 「특허협력조약」 제2조(xv)의 수리관청이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a) 또는 (b)에 따른 선언을 한 경우
 3. 국제사무국이 그 국제출원에 대하여 같은 조약 제25조(1)(a)에 따른 인정을 한 경우
- ② 제1항의 신청을 하려는 자는 그 신청 시 발명의 설명, 청구범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한정한다), 그 밖에 총리령으로 정하는 국제출원에 관한 서류의 국어번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다.
- ③ 지식재산처장은 제1항의 신청이 있으면 그 신청에 관한 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 같은 조약규칙에 따라 정당하게 된 것인지에 관하여 결정을 하여야 한다.
- ④ 지식재산처장은 제3항에 따라 그 거부·선언 또는 인정이 「특허협력조약」 및 같은 조약규칙에 따라 정당하게 된 것이 아니라고 결정을 한 경우에는 그 결정에 관한 국제출원은 그 국제출원에 대하여 거부·선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 본다.
- ⑤ 지식재산처장은 제3항에 따른 정당성 여부의 결정을 하는 경우에는 그 결정의 등본을 국제출원의 출원인에게 송달하여야 한다.
- ⑥ 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 관하여는 제199조제2항, 제200조, 제200조의2, 제201조제5항부터 제8항까지, 제202조제1항·제2항, 제208조 및 제210조를 준용한다. <개정 2016.2.29.>
- ⑦ 제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원에 관한 출원공개에 관하여는 제64조제1항 중 “다음 각 호의 구분에 따른 날”을 “제201조제1항의 우선일”로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

제1절 서 설

I. 의 의

「국제특허출원」이란 특허협력조약에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원을 말하며, 「특례」는 국내단계의 진입할 때 취급을 말한다. 즉 「국제특허출원에 관한 특례」란 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원이 국내단계로 진입 때 국내법과의 관계에서 어떤 취급을 받는지에 대한 것이다.

II. 특례 규정을 둔 취지

국제출원의 국제단계까지는 PCT의 적용을 받으며, 국내단계부터는 국내법의 적용을 받는다. 그러나 국제출원에 대해서 통상의 국내 특허출원과 같이 국내 규정을 그대로 적용하는 것이 불합리한 경우가 발생할 수 있으므로, 특허법은 국제특허출원에 관한 특례 규정을 제199조 내지 제214조 및 시행규칙 제107조 내지 제129조에 걸쳐서 규정하고 있다.

제2절 국제특허출원의 출원일의 인정과 출원서 등의 취급

I. 국제특허출원일의 인정

「특허협력조약」에 따라 국제출원일이 인정된 국제출원으로서 특허를 받기 위하여 대한민국을 지정국으로 지정한 국제출원은 그 국제출원일에 출원된 특허출원으로 본다(法 199①). 즉 수리관청에 국제출원이 수리된 날을 우리나라에 특허출원한 날로 간주한다.

II. 국제특허출원의 출원서 등의 취급

1) 국제특허출원의 국제출원일까지 제출된 출원서는 제42조제1항에 따라 제출된 특허출원서로 보고, 국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 및 도면은 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면으로 본다(法 200의2①②). 2015. 1. 1. 시행된 현행법(法律 제12753호, 2014. 6. 11. 개정)은 국제출원일까지 제출한 원문(출원서, 발명의 설명, 청구범위 및 도면)을 국내법(法 42①②)에 따른 출원서, 명세서 및 도면으로 간주함으로써 국제특허출원과 관련된 심사에 있어서 기존의 번역문주의에서 원문주의로 전환하였다.²⁷⁾ 따라서 국제특허출원의 출원인은 원문에 기재된 발명의 범위에서 분할출원, 분리출원, 변경출원 또는 국내우선권주장출원을 할 수 있다.

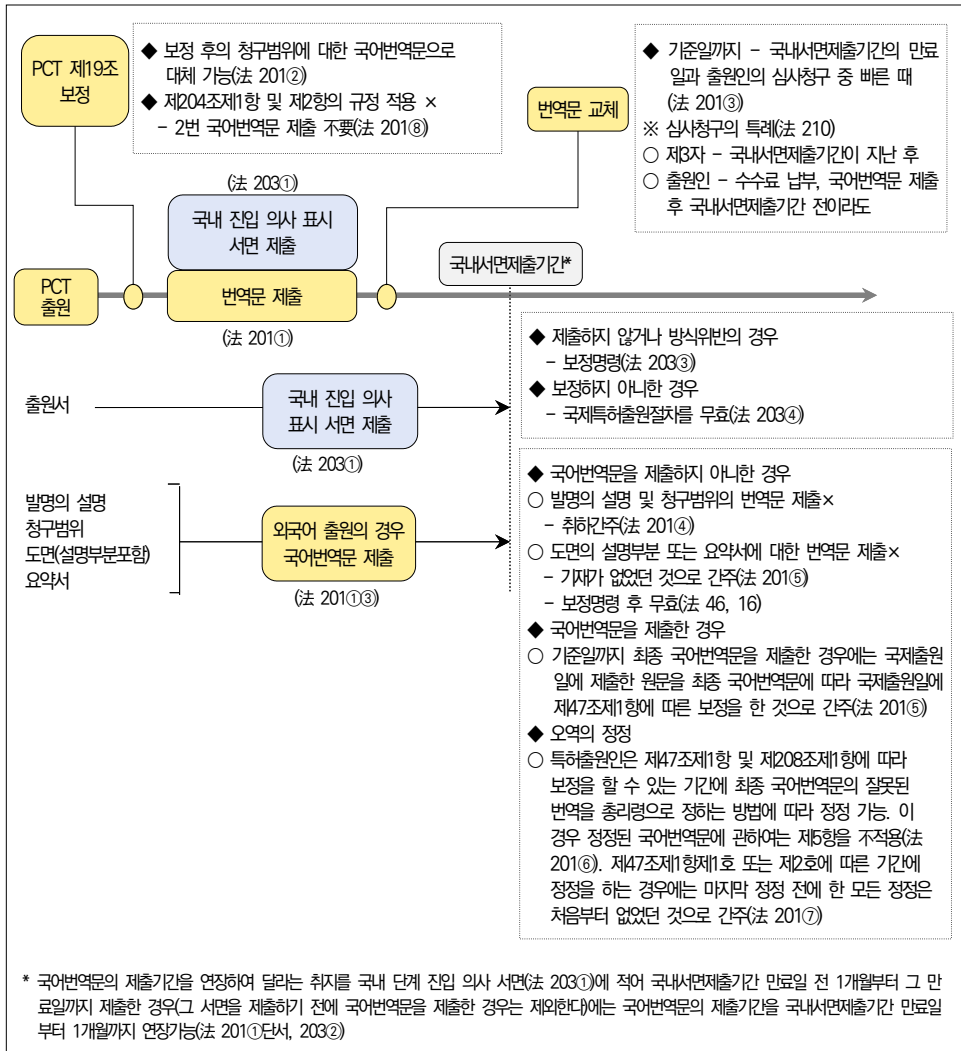
27) 번역문주의와 원문주의의 차이는 다음과 같다.

2) 국제특허출원에 대해서는 다음의 요약서 또는 국어번역문을 제42조제2항에 따른 요약서로 본다(法 200의2③). 즉 요약서는 특허정보의 효율적 이용을 위한 것이기 때문에 국어로 기재 될 것을 요구하고 있다.

- i) 국제특허출원의 요약서를 국어로 적은 경우에는 국제특허출원의 요약서
- ii) 국제특허출원의 요약서를 외국어로 적은 경우에는 제201조제1항에 따라 제출된 국제특허출원의 요약서의 국어번역문(제201조제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국제특허출원의 요약서의 국어번역문을 말한다)

구 분		번역문주의(기존)	원문주의(현행)
국어번역문 보정 가능 여부		불가	잘못된 번역 정정 가능
보정범위 위반	등록 전	국어번역문	원문 및 국어번역문 공통
	등록 후	원문 및 국어번역문 공통	원문
특허 후 정정범위		국어번역문	원문
분할출원, 분리출원, 변경출원, 국내우선권주장출원 범위		국어번역문	원문
확대된 선출원 대상 발명		원문 및 국어번역문 공통	원문

제3절 국어번역문의 제출



【그림 5-8】 국어번역문 제출 절차도

I. 국제특허출원의 국어번역문 제출

1. 국어번역문의 제출

(1) 원 칙

1) 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 우선일부터 2년 7개월²⁸⁾(이하 “국내서면제출기간”이라 한다) 이내에 다음의 국어번역문을 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 201①본문). 다만 출원서는 국어번역문을 제출하지 않고 후술하는 제203조의 국내 진입 의사 표시 서면을 제출하여야 한다.

i) 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문

ii) 국제특허출원의 요약서의 국어번역문

2) 여기서 「우선일」이란 i) 국제출원이 우선권주장을 수반하는 경우에는 동 우선권이 주장되는 출원의 선출원일, ii) 국제출원이 두 개 이상의 우선권주장을 수반하는 경우에는 우선권을 가장 먼저 주장한 출원의 출원일, iii) 국제출원이 우선권의 주장을 수반하지 아니하는 경우에는 동 국제출원의 출원일을 의미한다(PCT 2(xi)). 이러한 우선일은 일률적으로 정할 필요가 있으므로, 국제특허출원인의 우선권주장에 명백한 오류가 없다면 그 주장하는 날을 우선일로 보아 이를 기준으로 특허협력조약 및 특허법에서 정한 절차를 진행하여야 하며, 그 우선권주장의 실제 효력 유무에 따라 달리 볼 것은 아니다.²⁹⁾

(2) 국어번역문 제출기간의 연장

국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 국내 진입 의사 표시 서면(法 203①)에 적어 국내서면제출기간 만료일 전 1개월부터 그 만료일까지 제출한 경우(그 서면을 제출하기 전에 국어번역문을 제출한 경우는 제외한다)에는 국내서면제출기간 만료일부터 1개월이 되는 날까지 국어번역문을 제출할 수 있다(法 201①단서). 2015. 1. 1. 시행된 현행법(法律 제

28) 국내법령은 우선일로부터 30개월보다 나중에 만료되는 기간을 정할 수 있다(PCT 39(1)(b)). 이 경우 선택국은 그 기간을 국제사무국에 통지하여야 하며, 국제사무국은 접수한 통지서의 내용을 신속히 공보에 게재하여야 한다(PCT 규칙 70.1(a)(b)). 대한민국의 경우에는 국제예비심사보고서가 작성·송부되는 기간인 우선일로부터 28개월 이후 2개월만에 국내단계 진입절차를 밟는 데 시간적 무리가 있으므로 우선일로부터 31개월로 연장하고 있다. 참고로, 우리나라와 유럽특허청(EPO)은 국내단계진입기간이 31개월이지만, 일본, 미국 등 대부분 국가는 30개월이다.

29) 이러한 구 특허법과 특허협력조약의 규정들에 의하면, 출원인이 국제특허출원을 하면서 파리협약의 당사국에서 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하였다면 구 특허법 제201조 제1항 본문의 우선일은 국제특허출원의 제출일이 아니라 우선권을 주장한 선출원의 제출일이 된다. 그리고 우선일은 특허협력조약과 그 규칙에서 국제특허출원의 국제공개, 국제조사, 국제예비심사 청구 등 국제단계를 구성하는 각종 절차들의 기한을 정하는 기준으로 되어 있고, 구 특허법에서도 명세서 및 청구의 범위 등에 관한 번역문의 제출기한의 기준으로 되어 있는 등, 출원 관계 기관의 업무와 관련자들의 이해관계에 중대한 영향을 미치게 되므로, 우선일은 일률적으로 정하여질 필요가 있다(대법원 2017. 4. 28. 선고 2014두42490).

12753호, 2014. 6. 11. 개정)은 국어번역문 제출기간을 연장해줌으로써 출원인의 편의를 증대시키고, 또한 국어번역문의 품질을 제고하여 출원공개된 명세서의 활용성을 높이고 있다.³⁰⁾

2. 국내 진입 의사 표시 서면의 제출

(1) 서면의 제출

1) 국제특허출원의 출원인은 국내서면제출기간에 다음의 사항을 적은 서면을 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 이 경우 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은 제201조제1항에 따른 국어번역문을 함께 제출하여야 한다(法 203①). 다만 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적어 서면을 제출하는 경우에는 국어번역문을 함께 제출하지 아니할 수 있다(法 203②).

- i) 출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- ii) 출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
- iii) 발명의 명칭
- iv) 발명자의 성명 및 주소
- v) 국제출원일 및 국제출원번호

2) 이는 국내 진입 의사를 표시하는 서면으로서, 특허법은 출원인의 주체나 대상을 확정하는데 필요한 서지적 사항을 알기 위해서 출원서의 국어번역문에 갈음하는 서면을 강제적으로 제출하도록 하고 있다. 이 서면을 제출하여야 하는 자는 외국어뿐만 아니라 국어로 국제특허출원을 한 출원인도 포함된다.

(2) 부적법한 경우의 취급

지식재산처장은 i) 국제출원의 국내 진입 의사 표시 서면을 국내서면제출기간에 제출하지 아니한 경우나, ii) 그 제출된 서면이 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반된 경우에 기간을 정하여 보정을 명하여야 하며, 보정명령을 받은 국제특허출원의 출원인이 지정된 기간에 보정하지 아니하면 지식재산처장은 해당 국제특허출원을 무효로 할 수 있다(法 203③④).

3. 국어번역문의 교체

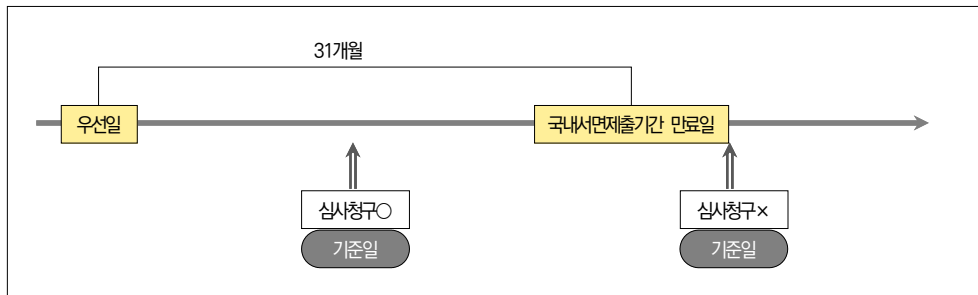
1) 국어번역문을 제출한 출원인은 국내서면제출기간(같은 조 제1항 각호 외의 부분 단서에

30) 2015년 1월 1일부터 시행된 법률은 다음과 같이 기존과 차이가 있다.

구 분	기 준	현 행
의사표시	국내 진입 의사 표시를 위한 서면 제출	좌동
번역문 제출	서면과 함께 제출	서면과 함께 또는 서면에 취지 기재시 1개월 연장 가능
서면제출기간	우선일로부터 2년 7개월	좌동

따라 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 조에서 같다)에 그 국어번역문을 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다. 다만 출원인이 출원심사의 청구를 한 후에는 그러하지 아니하다(法 201③). 즉 출원인이 심사청구를 한 경우에는 그 날이 기준일이 되어 국내단계에서의 심사가 진행되게 되므로 더 이상 새로운 국어번역문을 갈음하여 제출할 수 없게 된다.³¹⁾ 여기서 「기준일」이란 국제특허출원에 대한 국내법에 의한 처리기준 시점을 말하는 것으로서 국내서면제출기간의 만료일(2년 7개월)까지이며, 그 국내서면제출기간에 출원심사의 청구가 있으면 그 출원심사의 청구를 한 때까지이다.

2) 기준일이 지난 후에는 더 이상 새로운 국어번역문을 제출할 수 없으므로 국어번역문이 확정되며, 이를 「최종 국어번역문」이라고 한다(法 201⑤). 한편 제201조제3항의 법문의 문리적 해석에 의하면 국어번역문 교체시기는 역일주의(曆日主義)에 의하는 것이 아니라 시각주의(時刻主義)에 의한다. 즉 출원심사의 청구가 있는 경우 심사청구일의 다음 날이 아니라 심사청구를 한 시점 이후부터 국어번역문이 확정된다.



【그림 5-9】 기준일의 정의

4. 국어번역문을 제출하지 아니한 경우의 취급

1) 출원인이 국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원을 취하한 것으로 본다(法 201④). 한편 우선일로부터 2년 7개월을 지나서 국어번역문을 제출한 경우 제출된 국어번역문은 불수리된다(施規 11).

2) 도면의 설명부분 또는 요약서의 국어번역문이 제출되지 아니하면 국제특허출원이 취하간주되지 않고 도면의 설명부분 또는 요약서의 기재가 없었던 것으로 간주한다. 이 경우 방식위

31) PCT 제23조에 의하여 국내서면제출기간 내(심사청구를 한 후에는 예외)에는 심사를 할 수 없기 때문에 번역문의 교체를 인정해도 심사상의 지장이 없고, 또 출원인 스스로 정해진 기간에 번역문 오류를 발견하여 이를 새로 교체하여 장래 발생할지도 모르는 불이익을 예방하려는 것을 막을 이유가 없기 때문이다. 이 경우 번역문의 교체는 「번역문 전체」를 교체하는 것으로 그 일부만의 교체는 인정되지 아니한다. 다만 출원인이 국내서면제출기간에 심사청구를 한 경우에는 그 날이 기준일이 되기 때문에 심사청구 한 후에는 새로운 번역문을 제출할 수 없다.

반에 해당하기 때문에 지식재산처장은 출원인에게 기간을 정하여 보정을 명하여야 하며(法 46), 출원인이 그 기간에 요약서의 국어번역문을 제출하지 아니하면 국제특허출원에 관한 절차를 무효로 할 수 있다.

5. 국어번역문을 제출한 경우의 취급

특허출원인이 기준일까지 제201조제1항에 따라 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)의 국어번역문(같은 조 제3항 본문에 따라 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 마지막에 제출한 국어번역문을 말한다. 이하 이 조에서 “최종 국어번역문”이라 한다)을 제출한 경우에는 국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 최종 국어번역문에 따라 국제출원일에 제47조제1항에 따른 보정을 한 것으로 본다(法 201⑤).

6. 오역(잘못된 번역)의 정정

1) 특허출원인은 제47조제1항 및 제208조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간에 최종 국어번역문의 잘못된 번역을 총리령으로 정하는 방법에 따라 정정할 수 있다. 이 경우 정정된 국어번역문에 관하여는 보정의 효과(法 201⑤)를 부여하지 아니한다(法 201⑥). 한편 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①I) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①II)에 정정을 하는 경우에는 마지막 정정 전에 한 모든 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 201⑦)

2) 오역 정정은 발명의 설명, 청구범위를 보정한 것이 아니라 국어번역문만을 정정한 것이기 때문에 국어번역문에 오역이 있는 경우에는 국어번역문에 대한 오역정정과 별도로 심사대상 발명의 설명, 청구범위 등에 대하여 보정을 하여야 한다. 한편 오역의 정정이 있는 경우 정정된 국어번역문이 제47조제2항후단에 따라 보정에 대한 신규사항의 판단대상이 된다(法 208④).

7. 청구범위제출유예(法 42의2)와 외국어특허출원(法 42의3) 규정의 부적용

국제특허출원에 관하여는 청구범위제출유예(法 42의2)와 외국어특허출원(法 42의3) 규정을 적용하지 아니한다(法 199②). 국제특허출원은 출원할 때 청구범위를 적지 아니하면 보완사유(法 194①각호)에 해당하여 출원일을 인정받을 수 없으므로 청구범위제출유예(法 42의2) 규정이 적용되지 아니한다. 또한 외국어국제특허출원은 국어번역문 제출과 관련하여 제201조에서 별도로 규정하고 있으므로 외국어특허출원(法 42의3) 규정이 적용되지 아니한다.

II. 국제단계에서의 보정에 대한 국어번역문 또는 사본의 제출

1. 국제조사보고서 받은 후의 보정에 대한 국어번역문 또는 사본의 제출

(1) 청구범위가 원문에 대한 국어번역문 제출 전에 보정된 경우

1) 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인이 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 청구범위에 관한 보정을 한 경우에는 국제출원일까지 제출한 청구범위에 대한 국어번역문을 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체하여 제출할 수 있다(法 201②).

2) 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문을 제출하는 경우에는 제204조제1항과 제2항을 적용하지 아니한다(法 201⑧). 제204조제1항 및 제2항은 PCT 제19조(1)에 따른 보정서에 대한 국어번역문을 국제출원 시의 청구범위에 대한 국어번역문과 별도로 제출하는 것을 전제로 하고 있으므로 적용될 여지가 없다. 즉 절차의 간소화·비용절감 등을 위해서 국어번역문을 2번 제출할 필요가 없는 것이다.

(2) 청구범위가 원문에 대한 국어번역문 제출 후에 보정된 경우

1) 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제19조(1)에 따라 국제조사보고서를 받은 후에 국제특허출원의 청구범위에 관하여 보정을 하거나 설명서를 국제사무국에 제출한 경우에는 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다. 이하 제204조 및 제205조에서 같다) 다음의 어느 하나에 해당하는 서류를 지식재산청장에게 제출하여야 한다(法 204①③). 여기서 「기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다.」라고 함은 국내서면제출기간의 만료일 전에 심사청구를 한 경우에는 당일(當日)이라 하더라도 심사청구 이후에는 국어번역문을 제출할 수 없음을 의미한다.

i) 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 보정서 또는 설명서의 국어번역문

ii) 국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 보정서 또는 설명서의 사본

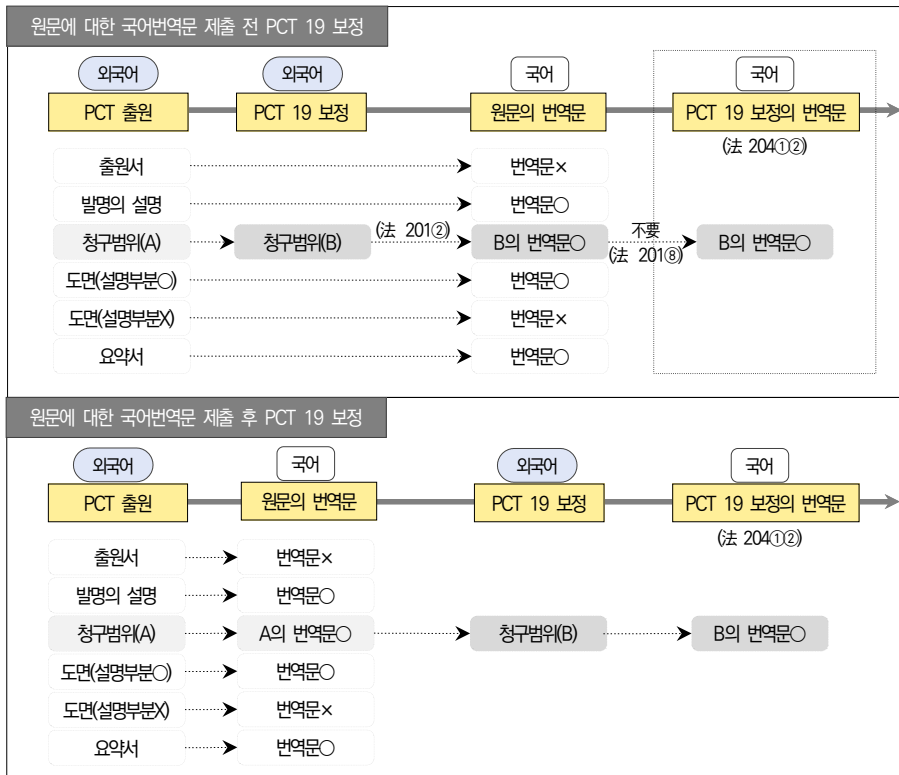
2) 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 청구범위가 보정된 것으로 본다. 즉 기준일이 지나기 전임에도 불구하고 국내법의 적용을 받는 보정(아직 국제특허출원의 심사가 진행되지 않았기 때문에 제47조제1항 본문 시기의 자진보정)으로 간주한다(法 204②본문).

3) 다만 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 지식재산청에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(法 204②단서). 즉 출원인이 제출한 보정서와 국제사무국으로부터 송달된 보정서가 모두 있는 경우 국제사무국으로부터 송달받은 보정서만을 적법한 보정으로 취급하며, 출원인이 보정서를 제출하지 않았더라도 기준일까지 국제사무국으로부터 보정서가 송달된 경우에는 보정이 있는 것으로 간주한다.³²⁾³³⁾

32) 황은택, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 1007면.

33) 다만 기준일 이후에 국제사무국으로부터 보정서를 송달받은 경우에는 그 보정서는 지식재산청에 제출되지 아니한 것으로 간주한다. 이는 기준일 이후에는 이미 그 국제특허출원의 국내 절차의 개시가 확정되었기 때문에 출원인도 모르는 사이에 갑자기 보정이 이루어지는 것을 방지하기 위해서이다(황은택, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 1008면).

4) 그러나 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 국어번역문 또는 사본을 제출하지 아니하면 「특허협력조약」 제19조(1)에 따른 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만 국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 「특허협력조약」 제20조34)에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다(法 204④). 한편 기준일이 지난 후에 제출된 국어번역문은 불수리된다(施規 11).



【그림 5-10】 외국어로 국제특허출원한 경우 PCT 제19조 보정의 국어번역문 제출

- 34) 【제20조】(1) (a) 국제출원은 국제조사보고서(제17조제2항(b)에 언급된 표시를 포함한다) 또는 제17조제2항(a)에 언급된 선언과 함께 이 규칙이 정하는 바에 따라 각 지정관청에 송달된다. 다만 그 지정관청이 송달의무의 전부 또는 일부를 면제하는 경우에는 그러하지 아니한다.
- (b) 송달되는 문서는 (a)의 국제조사보고서 또는 선언의 소정의 번역문을 포함한다.
- (2) 청구범위가 제19조제1항에 따라 보정된 경우에 송달되는 문서는 출원 시에 있어서의 청구범위의 전문과 보정 후에 청구범위의 전문을 포함하거나 출원 시에 있어서의 청구범위의 전문과 보정을 명기하는 기재를 포함하며 또 제19조제1항에 규정하는 설명서가 있는 경우에는 동 설명서를 포함한다.
- (3) 국제조사기관은 지정관청 또는 출원인의 청구에 응하여 규칙이 정하는 바에 따라 동 지정관청 또는 출원인에게 국제조사보고서에 기재된 문헌의 사본을 송부한다.

2. 국제예비심사보고서 작성 전의 보정에 대한 국어번역문 또는 사본의 제출

1) 국제특허출원의 출원인은 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따라 국제특허출원의 발명의 설명, 청구범위 및 도면에 대하여 보정을 한 경우 기준일까지 다음의 어느 하나에 해당하는 서류를 지식재산청에게 제출하여야 한다(法 205①).

i) 외국어로 작성된 보정서인 경우³⁵⁾ 그 보정서의 국어번역문

ii) 국어로 작성된 보정서인 경우 그 보정서의 사본

2) 보정서의 국어번역문 또는 사본이 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 제47조제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 본다. 즉 기준일 이 지나기 전 임에도 불구하고 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주한다. 다만 「특허협력조약」 제36조(3)(a)³⁶⁾에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산청에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(法 205②).

3) 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 국어번역문 또는 사본을 제출하지 아니하면 「특허협력조약」 제34조(2)(b)에 따른 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산청에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다(法 205③). 한편 기준일이 지난 후에 제출된 국어번역문은 불수리된다(施規 11).

35) 국제예비심사단계에서는 국제특허출원 당시 언어와 다른 국제예비심사기관이 지정하는 언어로 PCT 제34조 보정을 할 수 있다.

36) 국제예비심사보고서는 소정의 번역문 및 원어로 된 부속서류와 함께 국제사무국이 각 선택관청에 송달한다.

【표 5-5】 PCT 제19조 보정과 PCT 제34조 보정의 비교

제 도		PCT 제19조	PCT 제34조
요 건	주체적	제외자의 경우라도 가능(法 206①)	
	객체적	청구범위를 기준으로 1회 보정가능	청구범위·발명의 설명·도면을 기준으로 횟수에 제한없이 보정가능
	시기적	국제조사보고서를 송부한 날로부터 2개월 이내 또는 우선일로부터 16개월 중 늦은 때	국제예비심사보고서 작성되기 전
절 차		- 국제사무국에 보정서 제출(설명서 제출가능) - 국제사무국은 보정서를 첨부하여 국제공개하고 지정(선택)관청에 송부	- 국제예비심사기관에 보정서 제출 - 국제예비심사기관은 국제예비심사보고서에 보정사항을 기록하고, 보정서를 첨부하여 출원인, 국제사무국에 송부하며, 국제사무국은 선택관청에 송부
효 과 (번역문 또는 사본의 제출)		1. 원문의 국어번역문 제출 전 보정한 경우(외국어로 국제특허출원한 경우에 한함) ① 원문에 대한 국어번역문을 제출할 때 보정 후의 청구범위에 대한 국어번역문으로 대체 제출가능(法 201②) ② 제204조제1항 및 제2항 부적용(번역문 두 번 제출 불요)(法 201⑧) 2. 원문의 국어번역문 제출 후 보정한 경우 1) 기준일까지(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구를 한 때까지를 말한다) i) 외국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 보정서의 국어번역문 또는 ii) 국어로 출원한 국제특허출원인 경우 그 보정서의 사본 이 지식재산처장에게 제출되었을 때에는 그 보정서의 국어번역문 또는 사본에 따라 法 제47조제1항에 따른 청구범위가 보정된 것으로 본다. 다만 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 출원한 국제특허출원인 경우에 한정한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(法 204①②). 2) 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 국어번역문 또는 사본을 제출하지 아니하면 보정서 또는 설명서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만 국어로 출원한 국제특허출원에 「특허협력조약」 제20조에 따라 기준일까지 그 보정서 또는 그 설명서가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다(法 204④).	1. 기준일까지 i) 외국어로 작성된 보정서의 경우 그 보정서의 국어번역문, ii) 국어로 작성된 보정서의 경우 그 보정서의 사본이 지식재산처장에게 제출되었을 때에는 제 47조제1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 한다. 다만 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그 보정서에 따라 보정된 것으로 본다(法 205①②). 2. 국제특허출원의 출원인이 기준일까지 국어번역문 또는 사본을 제출하지 아니하면 보정서는 제출되지 아니한 것으로 본다. 다만 「특허협력조약」 제36조(3)(a)에 따라 기준일까지 그 보정서(국어로 작성된 보정서의 경우만 해당한다)가 지식재산처에 송달된 경우에는 그러하지 아니하다(法 205③).

Ⅲ. 우선권증명서류에 대한 국어번역문의 제출

1. 국제출원 시 우선권증명서류를 제출한 경우

1) 국제출원 시 우선권을 주장하고 우선권서류를 제출한 경우 그 우선권서류의 사본은 국제사무국을 통해 지정국에게 송부된다. 한편 지식재산처장 또는 특허심판원장은 심사·심판을 위하여 필요한 경우 우선권주장을 한 자에 대하여 기간을 정하여 우선권증명서류에 대한 국어번역문을 제출하도록 명할 수 있으며, 제출명령을 받은 자가 지정된 기간에 국어번역문을 제출하지 아니하면 해당 우선권주장을 무효로 할 수 있다. 다만 우선권주장에 관한 서류 중 명세서 및 도면의 기재내용이 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면의 기재내용과 동일한 부분에 대해서는 그 취지를 기재하고 국어번역문의 제출을 생략할 수 있다(施規 113).

2. 국제출원 시 우선권증명서류를 제출하지 아니한 경우

국제출원 시 우선권주장을 선언하였음에도 불구하고 수리관청에 우선권서류를 제출하지 아니한 경우 지식재산처장은 기간을 정하여 우선권서류를 제출할 것을 명하여야 하며, 제출명령을 받은 자가 그 기간에 우선권서류를 제출하지 아니하면 우선권주장은 효력을 상실한다(施規 113의2). 한편 지식재산처장 또는 특허심판원장은 심사·심판을 위하여 필요한 경우 우선권주장을 한 자에 대하여 기간을 정하여 우선권증명서류에 대한 국어번역문을 제출하도록 명할 수 있으며, 제출명령을 받은 자가 지정된 기간에 국어번역문을 제출하지 아니하면 해당 우선권주장을 무효로 할 수 있다. 다만 우선권주장에 관한 서류 중 발명의 명세서 및 도면의 기재내용이 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면의 기재내용과 동일한 부분에 대해서는 그 취지를 기재하고 국어번역문의 제출을 생략할 수 있다(施規 113).

제4절 국제특허출원의 특례 규정

Ⅰ. 다른 출원이 국제특허출원(국제실용신안등록출원)인 경우 확대된 선출원 적용

1) 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 확대된 선출원 규정(法 29③④) 중 「출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」은 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」으로, 같은 항 제2호 중 「출원공개」는 「출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개」로 본다(法 29⑤⑥).

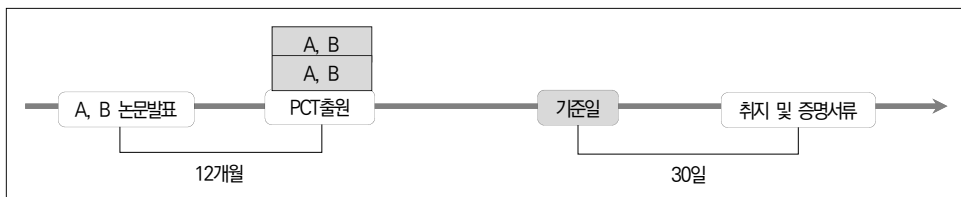
- i) 다른 특허출원이 제199조제2항에 따른 국제특허출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우
- ii) 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제2항에 따른 국제실용신안등록출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 포함한다)인 경우

2) 즉 특허출원한 발명이 그 특허출원일 전에 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원을 하여 그 특허출원 후에 「출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개」되거나 등록 공고된 다른 국제특허출원 또는 국제실용신안등록출원의 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에는 그 발명에 대해서는 확대된 선출원 위반으로 특허를 받을 수 없다. 외국어 국제특허출원의 원문(국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 및 도면)이 제42조제2항에 따른 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면으로 간주되기 때문에(法 200의2①②) 확대된 선출원을 적용할 때 원문 기준으로 다른 출원의 지위를 인정하고 있다.

3) 다만 출원인이 국내서면제출기간에 발명(고안)의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하된 것으로 보는 국제특허출원(국제실용신안등록출원)은 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위를 갖지 아니한다(法 29⑦). 따라서 외국어 국제특허출원(국제실용신안등록출원)은 최종 국어번역문이 확정되기 전까지는 확대된 선출원 적용을 보류하여야 한다. 물론, 국어로 국제특허출원한 경우에는 국제특허출원이 우리나라의 특허출원(法 199①)이고, 국제공개가 국내공개로 간주(法 207②)되기 때문에 국내단계로 진입 여부와 상관없이 확대된 선출원이 인정된다.

II. 공지예외적용의 특례

국내출원의 경우 제30조제1항제1호를 적용받으려는 경우 특허출원서에 그 취지를 적어 출원하고, 특허출원일부터 30일 이내에 증명서류를 제출하여야 한다(法 30②). 한편 국제특허출원된 발명에 대하여 제30조제1항제1호를 적용받으려는 자는 그 취지를 적은 서류 및 증명서류를 기준일이 지난 후 30일 이내에 지식재산처장에게 제출할 수 있다(法 200, 施規 111). PCT는 특허출원절차를 통일화하기 위한 조약으로서 지정국에서 출원 시 별도의 절차를 요구해서는 아니 되기 때문에 PCT 출원이 국내단계로 진입한 후에 절차적인 측면을 요구하도록 규정되어 있다.³⁷⁾



【그림 5-11】 공지예외적용주장을 수반하는 국제특허출원

37) 한편 국제출원의 경우 출원인은 국제출원일 당시에 국제출원서(box No. VIII(v))에서 '신규성 상실의 예외에 관한 선언'을 할 수 있고 제200조의2제1항에 따라 국제출원서는 우리나라 특허출원의 출원서로 간주되는데, 국제출원서에 위 선언이 포함된 것이 확인된 경우에는 제30조제2항에 따른 취지 기재가 올바르게 된 것으로 취급하여야 한다(PCT 규칙 4.17 참조).

III. 우선권주장의 특례

1. PCT 제8조

국제출원은 규칙에 정하는 바에 따라 파리조약의 당사국에서 또는 동 조약의 당사국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권을 주장하는 선언을 수반할 수 있다(PCT 8(1)). 국제출원이 우선권을 주장하는 경우 자기지정이 되는 경우를 제외하고는 우선권주장의 요건과 효과는 파리조약의 스톡홀름의정서 제4조의 정하는 바에 의한다(PCT 8(2)(a)). 자기지정에 의한 경우에는 해당 지정국에서의 요건 및 효과는 해당 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다(PCT 8(2)(b)).

2. 자기지정

(1) 의 의

1) 「자기지정」이란 어느 체약국에서 또는 어느 체약국에 대하여 행하여진 선출원에 의한 우선권주장을 수반하는 국제출원에는 해당 체약국의 지정을 포함하는 것을 말한다. 국제출원이 어느 지정국에서 또는 어느 지정국에 대하여 행하여진 국내출원에 의한 우선권주장을 수반하는 경우 또는 하나의 국가만의 지정을 포함한 국제출원에 의한 우선권주장을 수반하는 경우에는 해당 지정국에서의 요건 및 효과는 해당 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다(PCT 8(2)(b)).

2) 이 경우 국내법에 국내우선권제도가 없다면 우리나라 국민은 우리나라에의 출원발명에 대하여 자기지정제도를 이용할 방법이 없게 되는데 우리 특허법은 국내우선권제도에 관한 규정(法 55, 56)을 두어 자기지정제도 이용의 활성화를 도모하고 있다. 한편 외국어로 된 국제특허출원의 경우 국어번역문이 존재하는 관계로 특별히 따로 규정(法 202)을 두고 있다.

(2) 유 형

① 자기지정으로 인정되는 유형

자기지정의 유형으로는 i) 국내의 선출원을 기초로 국제출원에 의한 우선권주장을 하면서 지정국에 한국, 일본, 미국 등을 포함한 경우와 ii) 한국만을 지정국으로 하는 국제특허출원을 기초로 국제출원에 의한 우선권주장을 하면서 지정국에 한국, 일본, 미국 등을 포함한 경우가 있다.

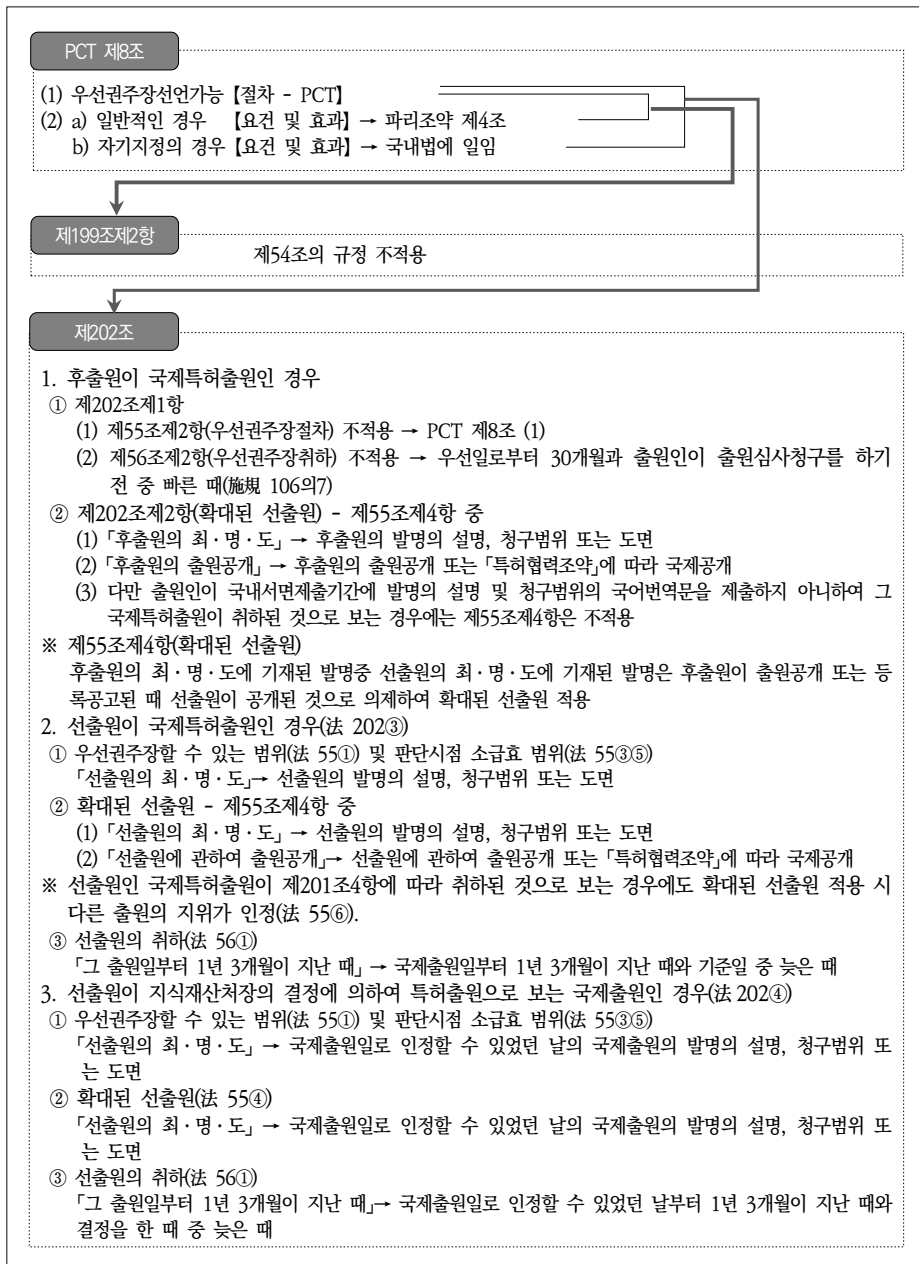
② 자기지정으로 인정되지 아니한 유형

1) 상술한 자기지정으로 취급되는 경우를 제외하고는 자기지정에 의한 우선권주장출원이 아니라 조약에 의한 우선권주장출원이다. 예를 들어 i) 지정국에 한국, 일본, 미국 등을 포함한 국제출원을 기초로 국제출원에 의한 우선권주장을 하면서 지정국에 한국, 일본, 미국 등을 포함한 경우에는 조약우선권의 요건 및 효과가 적용되는 것이지 자기지정에 의한 국내우선권의 요건 및 효과가 적용되는 것은 아니다.

2) 또한 ii) 지정국에 한국, 일본, 미국 등을 포함한 국제출원을 기초로 국내출원에 의한 우선권주장을 하는 경우에는 「출원인의 의사」에 의하여 조약우선권주장(法 54) 또는 국내우선권주장(法 55) 중 어느 하나를 선택할 수 있다. 이 경우 국내우선권주장을 선택하면 선출원은 국제출원일로부터 1년 3개월이 지난 때와 기준일 중 늦은 때에 취하간주된다.

구 분	선출원	후출원(우선권주장출원)	비 고
자기지정○	한국	PCT(한국, 미국, 일본 등)	지정국 한국에 대해서는 PCT 8(1),(2)b가 적용이 되며, 한국이 아닌 지정국에 대해서는 PCT 8(1),(2)a가 적용
	PCT(한국)	PCT(한국, 미국, 일본 등)	
자기지정×	PCT(한국, 미국, 일본 등)	PCT(한국, 미국, 일본 등)	PCT 8(1),(2)a에 의한 조약우선권주장의 요건 및 효과 적용
	PCT(한국, 미국, 일본 등)	한국	출원인의 의사에 의하여 조약우선권주장(法 54) 또는 국내우선권주장(法 55) 중 선택가능
해 설	PCT 출원서에서는 우선권주장을 체크하는 란은 있지만 국내우선권과 조약우선권을 구별하는 란이 존재하지 아니한다. 따라서 우선권주장을 체크하였을 때, 원칙은 PCT 8(1),(2)a가 적용이 되며, 이를 적용할 수 없는 경우에만 예외적으로 PCT 8(1),(2)b가 적용되는 것이다. 한편 국내출원서에는 출원 시 조약우선권주장(法 54) 또는 국내우선권주장(法 55)을 선택하여 적을 수 있다.		

【그림 5-12】 자기지정의 유형

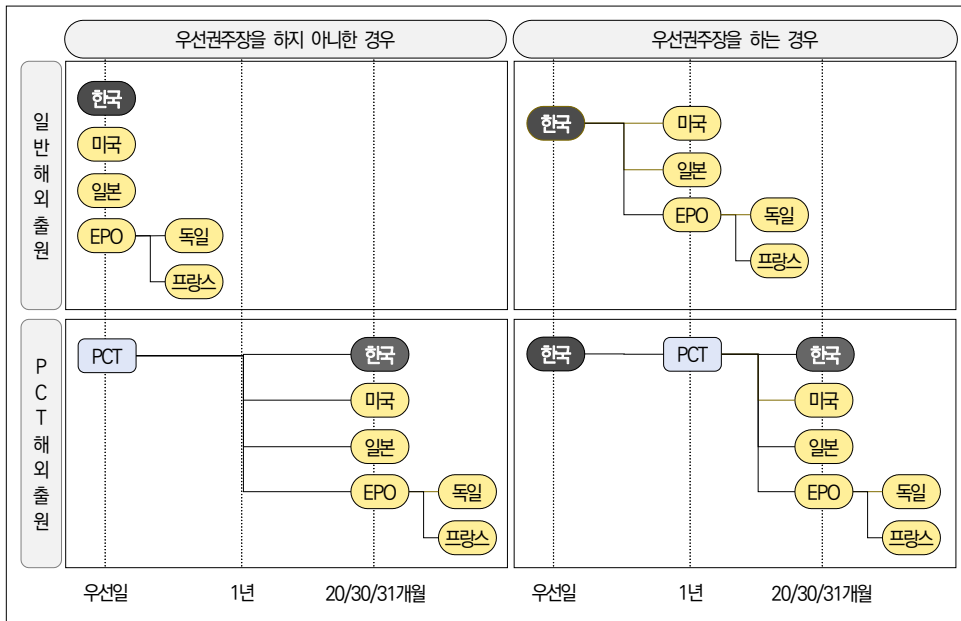


【그림 5-13】 PCT 제8조의 해석

3. 조약우선권주장규정(法 54)의 부적용

1) 국제특허출원에 관하여는 제54조의 조약우선권에 관한 규정을 적용하지 아니한다(法 199②). 출원인이 PCT에 따라 조약우선권을 주장한 경우 절차는 PCT에 의하며(PCT 8(1)), 그 요건 및 효과는 파리조약의 스톡홀름의정서 제4조의 정하는 바에 의하기 때문이다(PCT 8(2)(a)). 한편 파리조약 제4조는 제54조의 요건 및 효과와 다를 바가 없기 때문에 결국 제54조를 적용하지 아니한다는 의미는 조약우선권주장의 절차를 제54조의 절차가 아니라 「PCT에 따른 절차」에 따른다는 의미이다.

2) 파리조약에 의한 우선권제도(法 54)는 출원인을 불리하게 취급하지 아니하지만, 다수국에 일일이 모두 출원하여야 하는 불편이 있다. 한편 PCT는 출원과 심사에 있어 출원인 및 각 국가 특허담당 정부기관(특허청, 지식재산처 등)이 부담하는 중복노력을 국제협력하여 제거하려는 목적으로 체결된 것으로서 하나의 국제출원을 수리관청에 함으로써 각 지정국에서 출원한 것과 동일한 효과를 가지므로 파리조약상 우선권제도를 어느 정도 개선하고 있다.



【그림 5-14】 해외출원의 방법

4. 특허출원 등에 의한 우선권주장의 특례

(1) 국내우선권주장을 수반한 후출원이 국제특허출원인 경우

① 우선권을 주장한 국제특허출원의 제55조제2항 및 제56조제2항 부적용

통상적인 국내우선권주장출원의 경우 출원 시에 국내우선권을 주장하여야 하며(法 55②), 이는 선출원일로부터 1년 3개월이 지난 후에는 취하할 수 없다(法 56②). 그러나 국제특허출원이 우선권을 주장하는 경우에는 제55조제2항 및 제56조제2항을 적용하지 아니한다(法 202①). 이는 국제특허출원의 우선권주장은 PCT 제8조에 따라 수리관청에 하는 것이므로 지정국 국내법인 제55조제2항에 따른 우선권을 주장할 수는 없기 때문이다.³⁸⁾ 또한 국제출원 시에 한 우선권주장은 우선일로부터 2년 6개월을 지나기 전과 출원인이 출원심사청구를 하기 전 중 빠른 때까지는 우선권주장의 일부 또는 전부를 취하할 수 있기 때문에 역시 우선권주장 취하에 관한 국내법 제56조제2항은 적용되지 아니한다(施規 106의7).

② 우선권을 주장한 국제특허출원의 확대된 선출원

1) 우선권을 주장한 국제특허출원에 대하여 제55조제4항을 적용하는 경우 특례 규정을 두고 있다. 제55조제4항을 적용할 때 우선권주장을 수반하는 특허출원이 국제특허출원인 경우에는 같은 항 중 「특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」은 「국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」으로, 「출원공개되거나」는 「출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나」로 본다(法 202②본문).

2) 즉 우선권주장을 수반하는 국제특허출원의 「국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 「특허출원이 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나」 특허가 등록공고되었을 때 해당 우선권주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 확대된 선출원을 적용한다.

3) 다만 출원인이 국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 그 국제특허출원이 취하된 것으로 보는 경우에는 확대된 선출원(法 55④)을 적용하지 아니한다(法 202②단서).

(2) 국내우선권주장출원의 선출원이 국제특허출원인 경우

① 우선권을 주장할 수 있는 범위 및 판단시점의 소급효 범위

통상적으로 국내우선권 주장의 기초가 된 선출원에서 우선권을 주장할 수 있는 발명으로서 일정한 판단시점이 선출원일로 소급되는 범위는 선출원의 「출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」에 기재된 발명이다(法 55①③⑤). 한편 선출원이 국제특허출원인 경우에 「출원서에 최초로

38) PCT 제8조(1), PCT 규칙 4.1(b)(i) 및 동 규칙 4.10 등의 규정이 적용된다(특허법원 2005. 7. 15. 선고 2004허8671 참조).

첨부한 명세서 또는 도면」은 「국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」으로 본다(法 202③I).

② 확대된 선출원의 규정

1) 국내우선권주장의 선출원이 국제특허출원일 때 제55조제4항을 적용하는 경우 특례 규정을 두고 있다. 제55조제4항 중 「선출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」은 「선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」으로 보고, 「선출원에 관하여 출원공개」는 「선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개」로 본다(法 202③II).

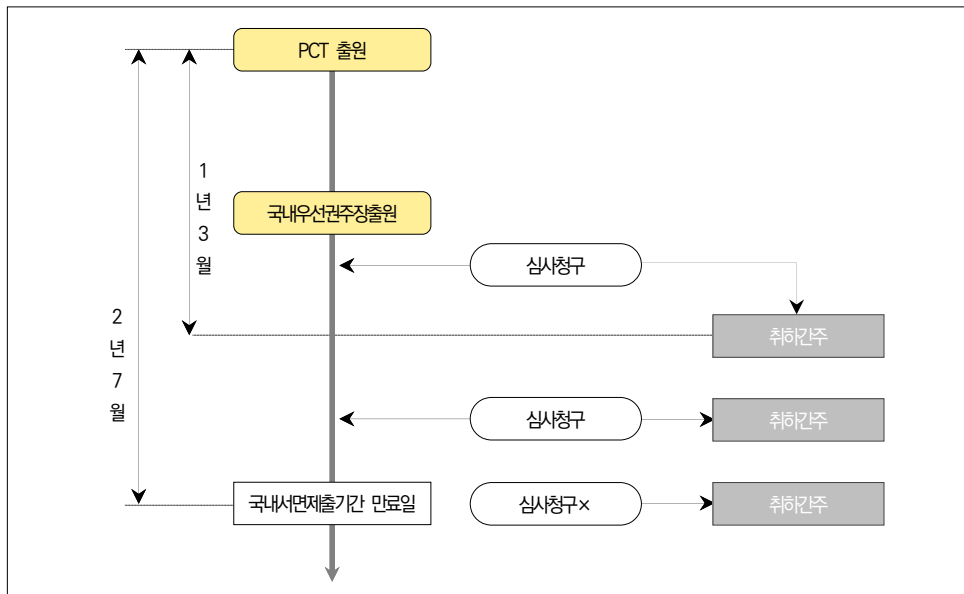
2) 즉 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권주장의 기초가 된 「선출원의 국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때 해당 우선권주장의 기초가 된 「선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개」가 된 것으로 보고 확대된 선출원을 적용한다.

3) 선출원이 국내서면제출기간에 발명(고안)의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하여 취하된 것으로 보는 국제특허출원(국제실용신안등록출원)인 경우에도 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위가 인정된다(法 55⑥).

③ 선출원인 국제특허출원의 취하간주시기

국내우선권주장출원의 선출원은 원칙적으로 「그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때」에 취하된 것으로 본다(法 56①). 그러나 선출원이 국제특허출원인 경우에 「그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때」는 「국제출원일로부터 1년 3개월이 지난 때와 기준일 중 늦은 때」에 취하된 것으로 본다(法 202③III). 이처럼 기간을 정한 이유는 출원인의 「명시적 청구」가 없는 경우에는 조약 제23조 및 제24조에 따라 기준일 전에는 국제출원을 처리할 수 없기 때문이다.³⁹⁾ 물론 이 취하간주의 효과는 우리나라에서만 효력이 있으며, 다른 지정국에도 미치는 것은 아니다. 한편 국제특허출원이 국내우선권주장의 선출원인 경우에는 일반적으로 비용을 절감하기 위해 심사청구를 하지 않기 때문에 국제특허출원은 국내서면제출기간이 지난 후에 취하간주될 것이다.

39) 박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002, 596면.



【그림 5-15】 PCT 선출원의 취하간주시기

(3) 국내우선권주장출원의 선출원이 결정에 의하여 특허출원으로 보는 국제출원인 경우

기본적으로 국내우선권주장출원의 선출원이 국제특허출원인 경우와 동일하다. 다만 취하간주시기는 「국제출원일로 인정할 수 있었던 날로부터 1년 3개월이 지난 때와 지식재산처장이 결정을 한 때 중 늦은 때」이다(法 202④).

【표 5-6】 국내우선권주장과 국제특허출원의 특례

구 분	유 형		국내우선권 주장절차	선출원의 취하	국내우선권 주장의 취하	확대된 선출원
	선출원	후출원				
자 기 지 정 ×	국내	국내	특허출원 시 특허출원서에 그 취지 및 선출원의 표시 (法 55②)	선출원일 로부터 1 년 3개월 이 지난 후 취하 간주(法 56①)	선출원의 출원일로부터 1년 3 개월을 지 나기 전까 지 취하 가능(法 56②)	후출원의 최·명·도에 기재된 발명 중 선출원의 최·명·도에 기재된 발명과 같은 발명은 후출원이 출원공개 또는 등록공고되었을 때에 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 간주
	PCT (지정국 : 한국, 일본 등)	국내 (국내 우선권 선택)		국제출원 일 부 터 1년 3개 월이 지 난 때와 기 준 일 중 늦은 때 취하 간주 (法 202 ③)	우 선 일 로 부 터 2년 6 개 월 을 지 나 기 전 과 출원인 이 출원심 사 청구 를 하 기 전 중 빠 른 때 까 지 우 선 권 주 장 의 일 부 또 는 전 부 취 하 가 능 (施規 의7)	1. 후출원의 최·명·도에 기재된 발명 중 선출원의 「국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면에 기재된 발명」과 같은 발명은 후출원이 출원공개 또는 등록공고되었을 때에 「선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개」된 것으로 간주 2. 선출원인 국제특허출원이 제201조4항에 따라 취하된 것으로 보는 경우에도 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위가 인정된다(法 55⑥).
자 기 지 정 ○	PCT (지정국 : 한국)	PCT (지정국 : 한국, 일본 등)	PCT 제8조에 의하여 국제 출원서에 우 선 권 주 장 의 취지 및 선출 원의 표시 (法 202①)	우 선 일 로 부 터 2년 6 개 월 을 지 나 기 전 과 출원인 이 출원심 사 청구 를 하 기 전 중 빠 른 때 까 지 우 선 권 주 장 의 일 부 또 는 전 부 취 하 가 능 (施規 의7)	1. 후출원의 「국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명 중 선출원의 「국제출원일까지 제출된 국제출원의 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명과 같은 발명은 후출원이 「출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나」 또는 등록공고되었을 때에 「선출원에 관하여 출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개」된 것으로 간주 2. 선출원인 국제특허출원이 제201조4항에 따라 취하된 것으로 보는 경우에도 확대된 선출원 적용 시 다른 출원의 지위가 인정된다(法 55⑥). 3. 후출원인 국제특허출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 경우에는 확대된 선출원(法 55④) 부적용(法 202②단서).	1. 후출원의 「국제출원일까지 제출된 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 발명 중 선출원의 최·명·도에 기재된 발명과 같은 발명은 후출원이 「출원공개 또는 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개되거나」 또는 등록공고되었을 때에 선출원에 관하여 출원공개된 것으로 간주 2. 후출원인 국제특허출원이 제201조제4항에 따라 취하한 것으로 보는 경우에는 확대된 선출원(法 55④) 부적용(法 202②단서).
비 고(판단방법)			※ 국내우선권주장의 절차, 국내우선권주장의 취하 → 후출원을 기준으로 판단 ※ 선출원의 취하간주시기 → 선출원을 기준으로 판단			

IV. 재외자의 특허관리인의 특례

1) 재외자는 재외자(법인의 경우에는 그 대표자)가 국내에 체류하는 경우를 제외하고는 그 재외자의 특허에 관한 대리인으로서 국내에 주소 또는 영업소가 있는 자(이하 "특허관리인"이라 한다)에 의해서만 특허에 관한 절차를 밟거나 이 법 또는 이 법에 따른 명령에 따라 행정청이 한 처분에 대하여 소(訴)를 제기할 수 있다는 제5조제1항의 규정에 불구하고, 재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지는 특허관리인에 의하지 아니하고도 국어번역문의 제출 등 특허에 관한 절차를 밟을 수 있다(法 206①). 즉 국제특허출원의 경우에는 기준일 전까지 재외자가 특허관리인에 의하지 아니하고 절차를 밟더라도 불수리되지 아니한다.

2) 그러나 특허관리인에 의하지 아니하고 국어번역문을 제출한 재외자는 기준일로부터 2개월 이내에 특허관리인을 선임하여 지식재산처장에게 신고하여야 한다. 특허관리인의 선임신고가 없으면 그 국제특허출원은 취하된 것으로 본다(法 206②③, 施規 116).

V. 출원공개시기 및 효과의 특례

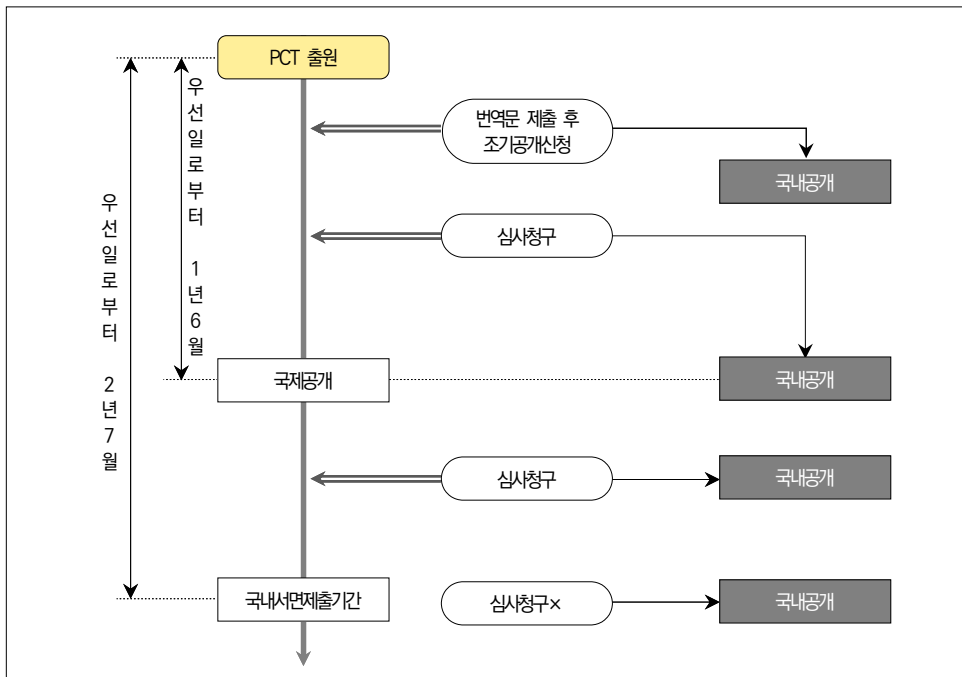
1. 국내공개시기

(1) 일반적인 경우

일반 국내특허출원의 공개시기는 조기공개 신청이 없는 경우 출원일로부터 1년 6개월이 지난 후이다(法 64①). 그러나 국제특허출원은 원칙적으로 국내서면제출기간(제201조제1항 각호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장해 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다. 이하 이 항에서 같다)이 지난 후에 국내공개가 이루어진다. 다만 국내서면제출기간에 출원인이 출원심사의 청구를 한 국제특허출원으로서 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개된 경우에는 우선일로부터 1년 6개월이 되는 날과 출원심사의 청구일 중 늦은 날이 지난 후 국내공개가 이루어지며(法 207①), 우선일로부터 1년 6개월이 지나기 전이라도 출원인이 국어번역문을 제출한 후라면 조기공개의 신청을 할 수 있다(施規 44②).

(2) 국어로 국제특허출원한 경우

국어로 출원한 국제특허출원에 관하여 국내에서의 출원공개 전에 이미 「특허협력조약」 제21조에 따라 국제공개가 된 경우에는 그 국제공개 시에 출원공개가 된 것으로 본다(法 207②). 이는 국어가 PCT 국제출원의 국제공개어로 채택(2009. 1. 1. 이후 국제출원부터 적용)됨에 따라 국내출원의 공개시점과 국제출원의 공개시점을 동일하게 적용토록 하여 동일한 효과를 발생토록 하는 조치이다.



【그림 5-16】 외국어로 국제특허출원한 경우의 국내공개

2. 보상금청구권의 발생

국제특허출원의 출원인은 국제특허출원에 관하여 출원공개(국어로 출원한 국제특허출원인 경우 「특허협력조약」 제21조에 따른 국제공개를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 있는 후 국제특허출원된 발명을 업으로 실시한 자에게 국제특허출원된 발명인 것을 서면으로 경고할 수 있다(法 207③). 국제특허출원의 출원인은 제3항에 따른 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고도 그 국제특허출원된 발명을 업으로서 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 특허권의 설정등록시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 다만 그 청구권은 해당 특허출원이 특허권의 설정등록된 후에만 행사할 수 있다(法 207④).⁴⁰⁾ 그 밖의 보상금 청구권에 관한 내용은 통상의 국내출원과 동일하다.⁴¹⁾

40) PCT에 의하면, 국제공개의 효과는 지정국의 국내법에 따른 출원공개의 효과와 동일하여야 하며(PCT 제 29조(1)), 국제공개언어가 지정국의 국내법에 따른 공개의 언어와 동일하지 아니하면 국제공개의 효과가 번역문의 국내법에 따른 공개 시 등에 발생하도록 효과발생시기를 특별히 규정할 수 있다(PCT 제29조(2)).

41) 국어로 된 국제특허출원이 국내단계에 진입한 경우 2009년 1월 1일 이후 출원에 대하여 변경된 점은 다음과 같다.

구 분		기 준	현 행
국제단계에서 이루어진 보정서 또는 설명서 제출	외국어로 된 국제출원	국어로 된 번역문	기존과 동일
	국어로 된 국제출원		보정서(또는 설명서)의 사본
출원공개시기	외국어로 된 국제출원	법 제201조제1항에 따른 기간	기존과 동일
	국어로 된 국제출원		국제공개를 국내공개로 간주
출원공개의 효과 발생시기	외국어로 된 국제출원	국제출원이 국내공개된 이후	기존과 동일
	국어로 된 국제출원		국제공개된 이후

【표 5-7】 국제공개와 국내공개의 비교

제 도	국제출원의 국제공개	국내공개	
		국제특허출원의 국내공개	통상의 국내출원의 국내공개
요건	주체적	국제사무국	지식재산처장
	객체적	1. 원칙 - 출원 계속 중인 모든 국제출원 2. 예외 ① 국제공개의 기술적 준비가 완료되기 전 국제출원절차가 종료된 경우 ② 공서양속에 위반 ③ 국제출원이 국제공개를 행할 필요가 없다고 선언한 국가만을 지정국으로 하는 경우	대한민국을 지정국으로 하는 국제출원으로서 국내단계에 진입한 경우
	시기적	1. 국제출원의 우선일로부터 18개월을 지난 후 국제공개 2. 이 기간 이내라도 출원인의 신청에 의하여 조기공개가능	1. 원칙적으로 국내서면 제출기간을 지난 후 지체없이 공개 2. 이 기간에 심사청구한 국제특허출원으로서 국제공개된 경우에는 우선일로부터 1년 6개월이 되는 날과 심사청구일 중 늦은 날이 지난 후 국내공개 3. 1년 6개월이 지나기 전이라도 번역문을 제출하면 출원인의 신청에 의하여 조기공개가능 4. 단, 국어로 국제특허출원한 경우에는 국제공개된 때 국내공개된 것으로 간주
	형식	전자적 형태로 공개	CD-ROM에 의한 공개특허공보 발행
절차	언어	영어, 불어, 독어, 일본어, 중국어, 스페인어, 러시아어, 아랍어, 한국어 또는 포르투갈어로 된 경우에는 그 언어로 그대로 국제공개되나 그 이외의 언어로 된 경우에는 영어에 의한 번역문	국어
	내용	1. 서지적 사항, 발명의 설명, 청구범위, 도면 및 원칙적으로 국제조사보고서가 기재된다. 또한 PCT 19에 의한 보정이 있는 경우 보정사항, 국제조사결해서도 공개 2. 국제예비보고서는 국제공개되지 아니함.	국제공개를 보완할 목적으로 이루어지는 것임과 동시에 국내출원에 대한 출원공개와 같은 목적으로 이루어지는 것이므로 공개공보에 기재될 사항도 국제공개 사항에 준함
효과	보상금 청구권	국어로 국제특허출원한 경우에만 보상금청구권 인정	○
	확대된 선출원의 지위		○

VI. 보정의 특례

1. 보정시기의 제한

1) 국제출원은 국제단계에서 국제사무국 또는 국제예비심사기관에 대하여 보정을 할 수 있으나 국내단계에 있어서는 일정한 제한이 있다. 즉 국제특허출원에 관하여는 다음의 요건을 모두 갖추지 아니하면 제47조제1항에도 불구하고 보정(제204조제2항 및 제205조제2항에 따른 보정은 제외한다)을 할 수 없다(法 208①).

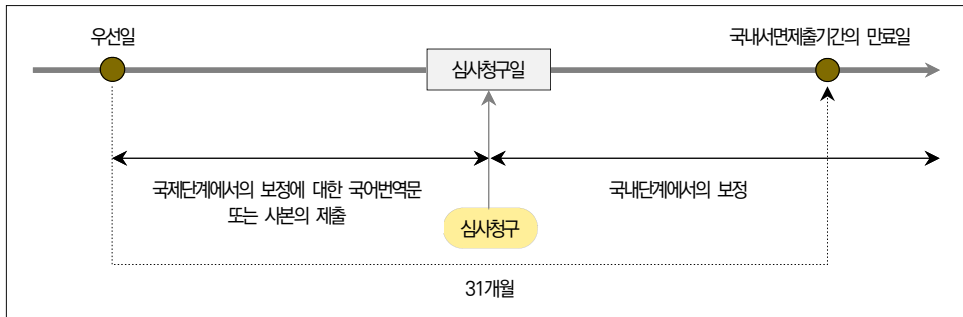
i) 제82조제1항에 따른 수수료를 낼 것

ii) 제201조제1항에 따른 국어번역문을 제출할 것. 다만 국어로 출원된 국제특허출원인 경우는 그러하지 아니하다.

iii) 기준일(기준일이 출원심사의 청구일인 경우 출원심사를 청구한 때를 말한다)이 지날 것

2) 이는 기준일이 지나기 전에는 국어번역문 교체로 동일한 목적을 달성할 수 있으므로 국내법에 의한 보정은 최종 국어번역문이 확정된 이후에 허용코자 함이다. 특히 2006. 3. 3. 시행된 현행법(法律 제7871호, 2006. 3. 3 개정)에서는 「기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사를 청구한 때를 말한다」라고 함으로써 심사청구와 동시에 보정할 수 있도록 하였다.⁴²⁾

3) 그러나 국제사무국에 대한 보정 또는 국제예비심사기관에 대한 보정이 있는 후에 지식재산처에 제출된 국어번역문 또는 사본은 각각 제204조제2항 또는 제205조제2항에 따라 그 번역문 또는 사본에 의하여 보정된 것으로 간주되므로 이 조의 적용을 받지 아니한다. 즉 기준일이 지나기 전에 보정했음에도 불구하고 국어번역문 또는 사본을 제출한 경우 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주한다.



【그림 5-17】 국제단계에서의 보정에 대한 국어번역문 제출시기와 국내단계에서의 보정시기

42) 기존에는 국내서면제출기간이 지난 후 심사청구하는 경우에는 제47조의 보정에 의하여 필요한 청구항에 대해서만 심사청구료를 지불하면 되지만, 국내서면제출기간 전 심사청구하는 경우에는 심사청구 시 보정이 불가능하여 모든 청구항에 대하여 심사청구료를 지불하여야 하는 불합리한 점이 있었기 때문에, 현행법은 심사청구와 동시에 보정을 허용함으로써 이를 개선하고 있다.

2. 보정범위의 제한

1) 제47조제2항의 신규사항추가금지와 관련하여, 통상의 국내출원의 명세서 또는 도면의 보정은 「특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 「외국어특허출원」에 대한 보정은 「최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(法 47②).

2) 그러나 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정할 수 있는 범위에 관하여 제47조제2항 전단을 적용할 때에는 「특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면」은 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」으로 보고(法 208③), 제47조제2항 후단을 적용할 때에는 「외국어특허출원」은 「외국어로 출원된 국제특허출원」으로, 「최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」은 「제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」으로 본다(法 208④).

3) 즉 외국어로 출원된 국제특허출원의 경우 명세서 또는 도면의 보정은 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 사항의 범위에서 하여야 하고, 「제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다. 외국어 출원 제도(국제특허출원을 포함)를 운영하고 있는 미국, 유럽특허청(EPO), 일본 및 중국 등은 출원 시 제출된 원문(외국어 발명의 설명, 청구범위 또는 도면) 기준으로 보정을 할 수 있으나, 우리나라만 국어번역문을 기준으로 하고 있어 번역상의 단순 오역이라도 이를 보정할 수 없어 출원인이 진정한 권리를 취득하지 못하는 문제점이 있었다. 따라서 2015. 1. 1. 시행된 현행법(法律 제12753호, 2014. 6. 11. 개정)에서는 외국어 출원인의 진정한 권리의 보호를 강화하고 국제 추세에 맞게 보정범위를 원문(法 208③)으로 전환하는 한편 보정범위를 원문으로 전환하게 되면 심사 및 제3자의 권리 감시에 어려움이 발생할 수 있으므로, 명세서 보정은 국어번역문의 범위(法 208④)에서도 보정하도록 하고, 심사관은 국어번역문 기준으로 보정의 적합성을 판단할 수 있도록 하였다. 다만 국어번역문의 잘못된 오역의 정정이 가능하므로(法 201⑥) 실질적인 보정 가능 범위는 원문이라고 할 수 있다.⁴³⁾

43) 기존과 개정 후의 보정범위의 비교 사례는 다음과 같다.

구 분	원 문	번역문	보정범위
기존(번역문주의)	Ca	칼륨	칼슘으로 보정불가
개정(원문주의)	Ca	칼륨	칼슘으로 보정가능

3. 신규사항추가금지(法 47②) 위반의 취급

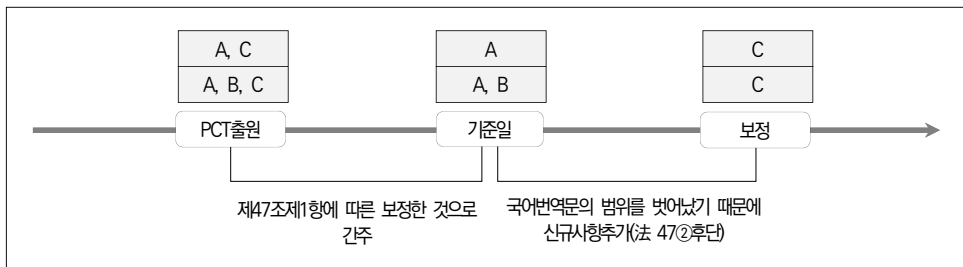
(1) 등록 전

1) 심사관은 제66조에 따른 특허결정등본을 송달하기 전(法 47①본문)의 자진보정이 원문 및 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어난 신규사항추가금지(法 47②) 위반인 경우에는 최초거절이유통지를 하고, 최초거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①I)에 보정이 신규사항추가금지(法 47②) 위반인 경우에는 최후거절이유통지를 한다.

2) 또한 심사관은 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47①II) 또는 재심사를 청구할 때(法 47①III)(최후거절이유통지이후) 보정이 원문 및 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어나 신규사항추가금지(法 47②) 위반인 경우에는 서면으로 이유를 붙여서 보정에 대하여 직권으로 각하결정을 한다(法 51①②). 출원인은 보정각하결정에 대해서는 별도로 불복할 수 없으며, 이후 특허거절결정에 대한 불복심판의 심리 중에 보정각하결정이 부당함을 함께 다룰 수 있다. 다만 i) 제66조의3에 따른 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 각하결정과 ii) 제67조의2에 따른 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 각하결정은 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③).

(2) 등록 후

등록 후에는 원문의 범위를 벗어난 보정(法 47②전단)의 경우에 특허무효사유(法 133①)이다. 국어번역문의 제출은 실체적인 문제라기보다는 심사관과 일반 공중에게 정확한 내용을 위한 절차적인 문제에 해당하기 때문에, 제47조제2항 후단의 국어번역문에 기재된 사항의 범위를 벗어난 보정은 거절이유(法 62)에만 해당하고, 특허무효사유(法 133①)에는 해당하지 않는다.



【그림 5-18】 국제특허출원의 보정범위 제한

【표 5-8】 국제출원의 보정

구 분	내 용
국제출원절차에서의 보정(절차보정)	1. 보완(法 194①②④) 2. 보정(法 195, 196①) 3. 누락 부분의 보완(法 194③④, 施規 99의2)
국제단계에서의 보정 (실체보정)	1. PCT 제19조 보정 2. PCT 제34조 보정 3. 국내단계진입시 국어번역문 또는 사본의 제출(法 201②⑧, 204, 205)
국내단계에서의 보정 (실체보정)	1. 보정시기(法 208①) ① 수수료 납부 + 국어번역문 제출 + 기준일 지난 후(기준일이 출원심사의 청구일인 경우에는 출원심사의 청구 이후를 말한다) 국내법의 적용을 받는 보정가능 ② 단, PCT 제19조, 제34조 보정 후 국어번역문 또는 사본을 제출한 경우 기준일이 지나 기 전임에도 불구하고 국내법의 적용을 받는 보정으로 간주(法 204②, 205② 제외) 2. 보정범위(法 208③④): 「국제출원일까지 제출한 발명의 설명, 청구범위 또는 도면」에 기재된 사항의 범위와 「제201조제5항에 따른 최종 국어번역문(제201조제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 국제출원일까지 제출한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)」에 기재된 범위

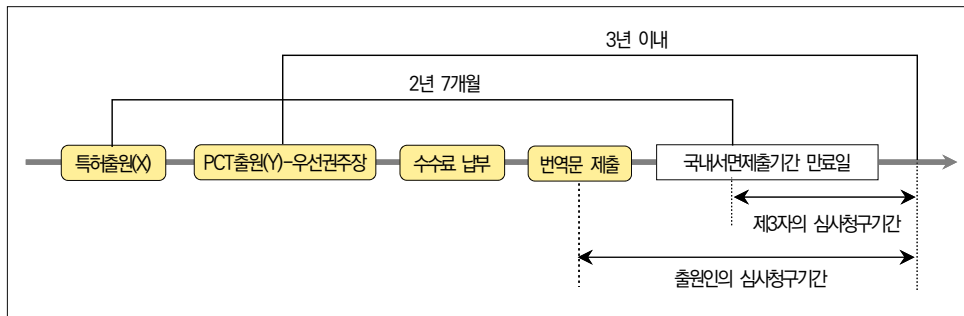
VII. 변경출원시기의 제한

실용신안법 제34조제1항에 따라 국제출원일에 출원된 실용신안등록출원으로 보는 국제출원을 기초로 하여 특허출원으로 변경출원을 하는 경우에는 이 법 제53조제1항에도 불구하고 실용신안법 제17조제1항에 따른 수수료를 내고 같은 법 제35조제1항에 따른 국어번역문(국어로 출원된 국제실용신안등록출원의 경우는 제외한다)을 제출한 후(실용신안법 제40조제4항에 따라 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 것으로 보는 국제출원을 기초로 하는 경우에는 같은 항에 따른 결정이 있는 후)에만 변경출원을 할 수 있다(法 209). 수수료 납부와 국어번역문 제출은 대한민국 지식재산처에서 최소한 심사를 받기 위한 요건이기 때문에 이를 만족한 후 변경출원할 수 있도록 시기적 제한을 두고 있다.

VIII. 출원심사청구시기의 제한

1) 국제특허출원의 출원인은 제201조제1항에 따라 국어번역문(국어로 출원된 국제특허출원의 경우는 제외한다) 및 제82조제1항에 따라 수수료를 낸 후라면 국내서면제출기간 만료일 전이라도 그 국제특허출원에 대하여 출원심사를 청구할 수 있다(法 210 I). 수수료 납부와 국어번역문 제출은 대한민국 지식재산처에서 최소한 심사를 받기 위한 요건이기 때문에 이를 만족한 후 출원인의 심사청구할 수 있도록 시기적 제한을 두고 있다.

2) 한편 국제특허출원의 출원인이 아닌 자는 국내서면제출기간(제201조제1항 각호 외의 부분 단서에 따라 국어번역문의 제출기간을 연장하여 달라는 취지를 적은 서면이 제출된 경우에는 연장된 국어번역문 제출 기간을 말한다)이 지난 후에 그 국제특허출원에 대하여 출원심사를 청구할 수 있다(法 210Ⅱ). 즉 국제특허출원의 경우 출원인이 아닌 자가 심사청구할 수 있는 시기는 국내서면제출기간이 지난 후 「국제출원일」로부터 3년 이내이다. 국내서면제출기간에 심사청구를 하면 심사대상인 국어번역문이 확정되어 국어번역문을 교체할 수 없는데, 국제특허출원의 출원인 아닌 자가 심사청구를 하여 국어번역문을 교체할 수 없는 것은 출원인에게 불측의 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

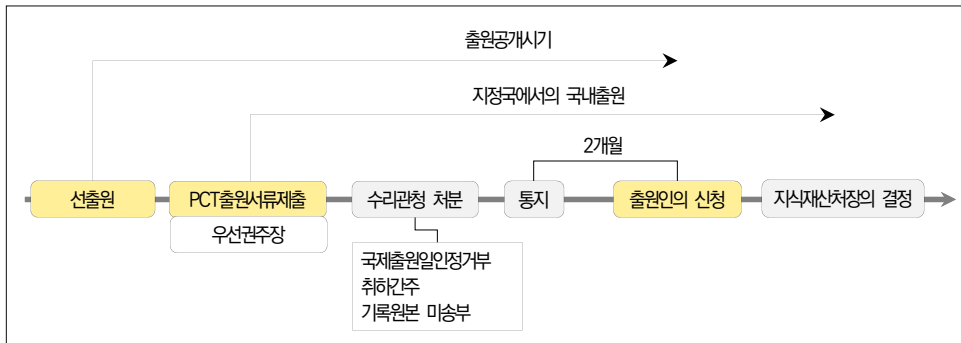


【그림 5-19】 국제특허출원에 대한 심사청구시기

IX. 국제조사보고서 등에 기재된 문헌의 제출명령

「지식재산차장」은 국제특허출원의 출원인에 대하여 기간을 정하여 PCT 제18조의 국제조사 보고서 또는 같은 조약 제35조의 국제예비심사보고서에 적혀 있는 문헌의 사본을 제출하게 할 수 있다(法 211). PCT에 의하면 지정관청 또는 출원인은 국제조사기관에 대하여 국제조사 보고서에서 인용된 문헌의 사본을 제출토록 요구할 수 있으며(PCT 제20조(3)), 국제예비심사기관에 대하여 국제예비심사보고서에 인용되었으나 국제조사보고서에는 인용되지 아니한 문헌의 사본을 제출토록 요구할 수 있다(PCT 제36조(4)). 이에 따라, 특허법은 출원인을 통하여 문헌의 사본을 제출받도록 규정하고 있다. 물론 지식재산처는 국제조사기관이나 국제예비심사기관에 대하여 직접 문헌 사본의 제출을 요구할 수도 있다. 실무적으로는 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 기재된 문헌을 지식재산처가 보유하고 있지 않거나 입수하기 곤란한 경우 출원인, 국제조사기관 또는 국제예비심사기관에 사본 제출을 요구하고 있다.

X. 결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원



【그림 5-20】 결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원

1. 의 의

제214조에서는 수리관청에서 국제출원일을 인정하지 아니하여 국제조사나 국제공개가 이루어지지 아니한 국제출원이라 할지라도 그 수리관청의 국제출원일 인정 거부 등에 잘못이 있는 경우 대한민국에서 일정한 절차 및 지식재산처장의 결정을 거쳐 국내법상의 특허출원으로 구제할 수 있도록 규정하고 있다. 이러한 지식재산처장의 결정에 의하여 구제된 국제출원은 더 이상 통상의 국제출원이 아니며, 단지 그러한 거부 등이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 대한민국에 출원한 특허출원으로 간주한다.

2. 대 상

대한민국을 지정국에 포함한 국제출원(특허출원만 해당한다)이 다음의 어느 하나에 해당되는 것을 대상으로 한다(法 214①).

- i) 수리관청에 의하여 국제출원일 인정이 거부된 경우
- ii) 수리관청에 의하여 국제출원 취하간주 선언된 경우
- iii) 국제사무국에 의하여 소정기간 내 기록원본의 불수리가 인정된 경우

3. 신청 및 결정

1) 국제출원인은 상기의 거부·선언·인정이 출원인에게 통지된 날부터 2개월 이내에 지식재산처장에게 신청서를 제출하여야 하며(施規 117①), 발명의 설명, 청구범위 또는 도면(도면 중 설명부분에 한정한다), 그 밖에 총리령⁴⁴⁾으로 정하는 국제출원에 관한 서류의 국어번역문을

44) 「총리령으로 정하는 국제출원에 관한 서류」란 해당 국제출원에 관하여 출원인이 조약 제2조(xv)에 따른

지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 214②).

2) 지식재산처장은 출원인의 신청이 있으면 그 신청에 관한 거부·선언 또는 인정이 PCT 및 같은 조약의 규칙에 따라 정당하게 된 것인지에 관해 결정하여야 한다(法 214③).

4. 결정의 효과

1) 지식재산처장은 그 거부·선언 또는 인정이 특허협력조약 및 동 규칙에 따라 정당하게 된 것이 아니라는 결정을 한 경우에는 그 결정에 관한 국제출원은 그 국제출원에 대하여 거부·선언 또는 인정이 없었다면 국제출원일로 인정할 수 있었던 날에 출원된 특허출원으로 보며(法 214④), 정당성 여부의 결정을 하는 때에는 그 결정의 등본을 국제출원의 출원인에게 송달하여야 한다(法 214⑤).

2) 국제특허출원에 관한 규정 중 일부(제199조제2항, 제200조, 제200조의2, 제201조제5항부터 제7항까지, 제202조제1항·제2항, 제208조 및 제210조를 준용)를 결정에 의하여 특허출원으로 인정되는 국제출원에 준용(法 214⑥)하며, 출원공개시기에 관해서는 「우선일(法 201①)」을 기준으로 기산한다(法 214⑦). 그 밖의 공지예외규정 적용이나 보정·변경출원·심사청구 가능시기 등은 지식재산처장이 거부·선언 또는 인정이 PCT 및 같은 규칙에 비추어 부당하다는 취지의 결정을 한 후로 제한되고,⁴⁵⁾ 등록지연에 따른 존속기간연장등록출원에 있어서 출원일로부터 4년의 기산은 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날을 기준으로 한다(法 92의2④).

XI. 국제특허출원의 심사에 관한 특례

국제특허출원에 관한 심사에 있어 해당 국제특허출원이 국제공개되지 아니하여 지식재산처장이 조약 제2조(xv)에 따른 수리관청 또는 국제사무국에 제출된 서류(지식재산처장에게 제출된 서류는 제외한다)의 확인이 곤란한 경우에는 해당 서류의 사본을 제출하게 할 수 있으며, 해당 서류의 사본을 지식재산처장에게 제출하지 아니하면 그 국제특허출원의 「국제공개일까지 그 국제특허출원에 대한 심사를 보류할 수 있다(施規 116의2). 이는 국제특허출원에 대한 방식심사시 국제공개가 이루어지지 아니한 경우 국제사무국에 제출한 출원서류를 전산상으로 열람할 수 없어 해당 출원서류와 국내 진입할 때 제출한 서면·번역문 간의 대비판단이 곤란한 문제가 발생함을 방지하기 위함이다.

수리관청 또는 동조(xix)에 따른 국제사무국에 제출한 서류 및 수리관청 또는 국제사무국이 해당 국제출원에 관하여 행한 처분에 관한 서류를 말한다(施規 118).

45) 국제특허출원에 관한 특례 규정이 대부분 적용되지만, 국어번역문의 제출기한과 관련된 규정 등은 준용되지 아니한다.

PART 06

특허권

제1장 서 론

제2장 특허권의 발생

제3장 특허권의 효력

제4장 특허권의 변동 등

제5장 특허권의 소멸 등

제1장

서론

I. 특허권의 의의

「특허권」이란 발명이라는 객체에 대해 법률에 의하여 부여된 권리를 말한다. 이러한 특허권은 특허결정을 받고 특허료를 내어 특허등록원부에 기재됨과 동시에 그 효력이 발생한다. 특허권자는 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하며, 제3자가 정당한 권원 없이 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 경우 특허권의 침해로 이유로 민·형사상 제재를 할 수 있다. 특허권은 개인의 재산권적인 성질을 가진 사권이므로 특허권자는 특허권을 이전할 수 있으며, 특허권에 대한 실시권이나 질권을 설정하여 이익을 얻을 수 있다. 다만 특허권의 존재 역시 궁극적으로 산업발전의 이바지에 그 의의가 있으므로 특허권에는 시간적·내용적·지역적 제한이 따른다.

II. 특허권의 본질

1) 특허권의 본질에 대해서는 예전부터 i) 인격과 분리하여 존재할 수 없는 인격권이라는 「인격권설」, ii) 발명자의 정신적 노력의 결과 산출된 발명에 대하여 발명자에게 인정되는 소유권이라는 「소유권설」, iii) 권리가 유한하고 국가마다 별도의 권리를 획득하여야 하며 점유할 수 없으므로 소유권과는 다른 무체재산권이라는 「무체재산권설」 등의 견해가 있다.

2) 인격권설은 특허권이 일신전속적인 권리가 아니며 타인에게 승계될 수 있는 재산권적인 성질을 가지고 있어서 한계가 있고, 소유권설은 i) 특허권이 시간상 유한하다는 것, ii) 각국에서 별개의 권리가 부여된다는 것(1국 1특허주의), iii) 외형상의 소재지를 갖지 아니한다는 것, iv) 형체상의 존재가 없어서 점유할 수 없다는 것을 설명하지 못하고 있다. 따라서 무체재산권설이 가장 타당하며 이 설이 독일, 일본 및 우리나라의 통설이다.

Ⅲ. 특허권의 특성

1. 독점·배타성

특허권은 무체재산권으로서 물권에 준하는 권리이므로 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 한편 타인의 무단실시를 배타적으로 배제할 수 있다. 그러나 특허권의 독점성은 상당 부분 제한되고 있음을 고려할 때(法 94①, 98 참조), 특허권 효력의 본질은 배타성에 있다고 봄이 타당하다.

2. 무체성

특허권의 객체인 발명은 형체를 가진 것이 아니라 청구범위에 기재된 무형의 기술사상이다. 이러한 이유로 특허권은 유체물을 대상으로 하는 소유권 등과 달리 i) 타인의 모방과 도용이 쉽지만, ii) 침해사실의 발견이나 침해 여부의 증명이 어렵고, iii) 손해액의 증명이 곤란하며, iv) 특허권 침해의 예방이 매우 어렵다.

3. 총괄적·전면적 지배성

특허권은 총괄적·전면적으로 객체인 발명을 지배하고, 그 지배가 일정한 방향 또는 목적에 한정되지 않는다. 이 점에서 일정한 범위에서만 일면적·부분적으로 객체를 지배하는 실시권과는 다르다.

4. 탄력성

특허권자는 특허권의 객체인 발명을 자신이 실시할 수 있을 뿐만 아니라 타인에게 실시하게 할 수도 있다. 특허권자가 타인에게 특허발명을 실시하게 하는 경우 특허권은 그만큼 제한을 받지만 이러한 제한이 소멸하면 당연히 원권리상태로 복귀하므로 이를 특허권의 탄력성이라 한다.

5. 유한성

특허권은 발명의 공개에 대한 보상을 위하여 주어지는 권리로서 일정 기간 유한적으로 존속 기간이 인정된다. 그리고 그 기간이 지난 후에는 소멸되므로 누구나 자유롭게 그 객체인 발명을 실시할 수 있게 된다. 이 점에서 항구성이 있는 소유권과 구별된다.

6. 제한성·공익성

특허권은 그 권리의 이용과 행사 등에 있어 일정한 제한과 의무가 부가되는데, 이는 특허권이 사권이지만 민법상의 일반사권과는 달리 공익성이 강하기 때문이다.

제2장

특허권의 발생

제1절 특허료의 납부

제79조 【특허료】

- ① 제87조제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날(이하 “설정등록일”이라 한다)부터 3년분의 특허료를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다.
- ② 제1항에도 불구하고 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료는 그 납부연도 순서에 따라 수년분 또는 모든 연도분을 함께 낼 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 특허료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제80조 【이해관계인에 의한 특허료의 납부】

- ① 이해관계인은 특허료를 내야 할 자의 의사와 관계없이 특허료를 낼 수 있다.
- ② 이해관계인은 제1항에 따라 특허료를 낸 경우에는 내야 할 자가 현재 이익을 얻는 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제81조 【특허료의 추가납부 등】

- ① 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자는 제79조제3항에 따른 납부기간이 지난 후에도 6개월 이내(이하 “추가납부기간”이라 한다)에 특허료를 추가로 낼 수 있다.
- ② 제1항에 따라 특허료를 추가로 낼 때에는 내야 할 특허료의 2배의 범위에서 총리령으로 정하는 금액을 납부하여야 한다.
- ③ 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 제79조제1항 또는 제2항에 따라 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

제81조의2 【특허료의 보전】

- ① 지식재산처장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조제3항 또는 제81조제1항에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전(補填)을 명하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내(이하 “보전기간”이라 한다)에 특허료를 보전할 수 있다.
- ③ 제2항에 따라 특허료를 보전하는 자는 내지 아니한 금액의 2배의 범위에서 총리령으로 정한 금액을 내야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제81조의3 【특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등】

- ① 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
- ② 제1항에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조제3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.
- ③ 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.
- ④ 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원 또는 특허권의 효력은 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 이 조에서 “효력제한기간”이라 한다) 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다.
- ⑤ 효력제한기간 중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ⑥ 제5항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
- ⑦ 제1항 본문에 따른 납부나 보전 또는 제3항 전단에 따른 신청에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

[시행일:2014.6.11.] 제81조의3제3항

[시행일:2015.1.1.] 제81조의3

제82조 【수수료】

- ① 특허에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 내야 한다.
- ② 특허출원인이 아닌 자가 출원심사의 청구를 한 후 그 특허출원서에 첨부한 명세서를 보정하여 청구범위에 적은 청구항의 수가 증가한 경우에는 그 증가한 청구항에 관하여 내야 할 심사청구료는 특허출원인이 내야 한다.
- ③ 제1항에 따른 수수료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제83조 【특허료 또는 수수료의 감면】

- ① 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 특허료 및 수수료는 제79조 및 제82조에도 불구하고 면제한다.
 1. 국가에 속하는 특허출원 또는 특허권에 관한 수수료 또는 특허료
 2. 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항에 따른 심사관의 무효심판청구에 대한 수수료
- ② 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 제79조 및 제82조에도 불구하고 총리령으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다. <개정 총리016. 3. 29., 2021. 8. 17.>
 1. 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자
 2. 「재난 및 안전관리 기본법」 제36조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제60조에 따른 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중 총리령으로 정하는 요건을 갖춘 자
 3. 그 밖에 총리령으로 정하는 자
- ③ 제2항에 따라 특허료 및 수수료를 감면받으려는 자는 총리령으로 정하는 서류를 지식재산처장에게 제출하여야 한다.

- ④ 지식재산차장은 제2항에 따른 특허료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 자에 대하여는 총리령으로 정하는 바에 따라 감면받은 특허료 및 수수료의 2배액을 징수할 수 있다. 이 경우 그 출원인 또는 특허권자가 하는 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 총리령으로 정하는 기간 동안 제2항을 적용하지 아니한다. <신설 2021. 8. 17>

[전문개정 2014.6.11.]

제84조 【특허료 등의 반환】

- ① 납부된 특허료 및 수수료는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 의하여 반환한다. <개정 2015. 5. 18., 2016. 2. 29., 2016. 3. 29., 2021. 8. 17., 2021. 10. 19.>
1. 잘못 납부된 특허료 및 수수료
 2. 제132조의13제1항에 따른 특허취소결정이나 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
 3. 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
 4. 특허출원(분할출원, 분리출원, 변경출원 및 제61조에 따른 우선심사의 신청을 한 특허출원은 제외한다) 후 1개월 이내에 그 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 낸 수수료 중 특허출원료 및 특허출원의 우선권 주장 신청료
 5. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목 중 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료
 - 가. 제36조제6항에 따른 협의 결과 신고 명령(동일인에 의한 특허출원에 한정한다)
 - 나. 삭제 <2021. 8. 17.>
 - 다. 제63조에 따른 거절이유통지
 - 라. 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달
 - 5의2. 출원심사의 청구를 한 이후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액
 - 가. 제5호가목에 따른 신고 명령 후 신고기간 만료 전까지
 - 나. 제5호다목에 따른 거절이유통지(제47조제1항제1호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의견서 제출기간 만료 전까지
 6. 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
 7. 제176조제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 심판 또는 재심 중 제170조제1항에 따라 준용되는 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 보정이 있는 경우는 제외한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료(재심의 경우에는 재심청구료를 말한다. 이하 이 조에서 같다)
 8. 심판청구가 제141조제2항에 따라 결정으로 각하되고 그 결정이 확정된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액
 9. 심리의 종결을 통지받기 전까지 제155조제1항에 따른 참가신청을 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
 10. 제155조제1항에 따른 참가신청이 결정으로 거부된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
 11. 심리의 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액
- ② 지식재산차장 또는 심판원장은 납부된 특허료 및 수수료가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 한다. <개정 2016.3.29.>
- ③ 제1항에 따른 특허료 및 수수료의 반환청구는 제2항에 따른 통지를 받은 날부터 5년이 지나면 할 수 없다. <개정 2022. 10. 18.>

[전문개정 2014.6.11.]

제85조 【특허원부】

- ① 지식재산처장은 지식재산처에 특허원부를 갖추어 두고 다음 각 호의 사항을 등록한다.
 1. 특허권의 설정·이전·소멸·회복·처분의 제한 또는 존속기간의 연장
 2. 전용실시권 또는 통상실시권의 설정·보존·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한
 3. 특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한
- ② 제1항에 따른 특허원부는 그 전부 또는 일부를 전자적 기록매체 등으로 작성할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에서 규정한 사항 외에 등록사항 및 등록절차 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ④ 특허발명의 명세서 및 도면, 그 밖에 대통령령으로 정하는 서류는 특허원부의 일부로 본다.

I. 서 설

1. 특허료의 의의

「특허료」란 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 국가에 내야 하는 일정한 금액을 말한다(法 79①).

2. 특허료의 성질

특허료의 성질에 대해서는 i) 행정상 수수료라는 「수수료설」, ii) 재산에 대한 징수라는 「조세설」, iii) 특허료가 해가 지날수록 점차 고액화하고 있는 것은 특허권에 의한 독점의 대가라는 「독점대가설」, iv) 공공영역으로 편입되지 않으려고 특허료를 내므로 공공의 이익을 위해야 한다는 「공공이익설」 등이 있다. 현행 실무상 특허료를 내지 아니한 경우 보정명령을 하지 않으므로 수수료설은 타당하지 않으며 조세설, 독점대가설 및 공공이익설을 종합한 성질을 가진다고 볼 수 있다.

II. 납부의 주체

1. 납부 의무자

1) 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날(이하 “설정등록일”이라 한다)부터 3년분의 특허료(이를 「등록료」라 함)를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료(이를 「유지료(연차료)」라 함)를 그 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다(法 79①).

2) 다만 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료는 그 납부연도 순서에 따라 수년분 또는 모든 연도분을 함께 낼 수 있다. 이 경우 납부된 특허료는 그 후 특허료의 변경이 있는 때에도 이에 따라 납부된 것으로 본다(法 79②).¹⁾

1) 라이프사이클(lifecycle)이 짧은 특허발명에 대한 특허권의 경우 유지료를 포괄납부할 경우 일정 기간 사

2. 이해관계인에 의한 특허료의 납부

(1) 이해관계인의 대납

이해관계인은 특허료를 내야 할 자의 의사와 관계없이 특허료를 낼 수 있다(法 80①). 「이해관계인」이란 특허권의 부등록 및 소멸에 관하여 법률상 이해관계를 가진 자로서 실시권자, 질권자 등을 예로 들 수 있다. 특허권의 발생이나 존속의 이익이 특허료보다 낮다면 특허권자는 특허료를 내지 않을 수 있는데 이해관계인은 반대의 경우가 있을 수 있다. 이때 이해관계인은 특허권에 부수적인 자기 권리의 유지를 위하여 특허권자의 의사와 관계없이 특허료를 낼 수 있다. 다만 이해관계인의 특허료 납부는 권리이지 법률상 의무는 아니다.²⁾

(2) 비용상환청구

이해관계인이 의사와 관계없이 특허료를 낸 경우에는 내야 할 자가 현재 이익을 얻은 한도에서 그 비용의 상환을 청구할 수 있다(法 80②). 특허권자(출원인)의 입장에서 발생 또는 존속의 이익은 이해관계인과 다를 수 있기 때문에 현재 이익을 얻은 한도 내에서만 비용상환청구를 할 수 있도록 하고 있다. 그러나 특허권자의 의사에 의하여 이해관계인이 특허료를 대납한 경우라면 특허료 전액의 비용상환을 청구할 수 있다.

Ⅲ. 납부의 방법

1. 납부기간 및 방법

(1) 등록료

특허결정 또는 특허할 것이라는 등록심결의 등본을 받은 날로부터 3개월 이내에 최초 3년분의 특허료를 일시에 내야 한다(徵收規則 8⑤). 다만 등록료의 납부가 특허결정을 받은 자에게 부담이 될 수 있으므로 청구항별 포기를 인정하여 보호받으려는 청구항에 대해서만 등록료를 낼 수 있도록 하고 있다(法 215의2). 청구항별로 포기하려는 자는 설정특허료납부서에 그 취지를 적어 지식재산처장에게 제출하여야 한다(施規 19의2).

(2) 유지료

특허권자는 제4년분부터의 특허료를 그 권리의 설정등록일을 기준으로 하여 매년 1년분씩

용되지 아니한 특허권을 유지할 수밖에 없으므로 신중히 처리하여야 한다. 더욱이 특허료는 다음과 같이 3년마다 계단식으로 증가하는 누진세로서 연차가 지날수록 기존보다 많은 금액을 내야 한다.

구 분	등록료	유지료(연차료)			
	1-3년	4-6년	7-9년	10-12년	13-25년
기본료	13,000원/년	36,000원/년	90,000원/년	216,000원/년	324,000원/년
가산료 (청구항별)	12,000원/년	20,000원/년	34,000원/년	49,000원/년	49,000원/년

2) 서울고등법원 1990. 9. 5. 선고 90나3166.

그 전년도에 내야 한다(徵收規則 8⑧). 유지료를 낼 때도 등록료와 마찬가지로 특허권의 청구 항별 포기를 할 수 있다(法 215).

2. 추가납부기간 및 방법

특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자는 납부기간(法 79③)이 지난 후에도 6개월 이내(이하 “추가납부기간”이라 한다)에 특허료를 추가로 낼 수 있다. 다만 특허료를 추가로 낼 때에는 내야 할 특허료의 2배의 범위에서 총리령³⁾으로 정하는 금액을 내야 한다(法 81①②).⁴⁾

3. 보전(補填)기간 및 방법

(1) 보전명령 및 보전기간

지식재산처장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 납부기간(法 79③) 또는 추가납부기간(法 81①)에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에 특허료의 보전을 명하여야 하며, 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날로부터 1개월 이내(이하 “보전기간”이라 한다)에 특허료를 보전할 수 있다(法 81의2①②).

(2) 보전금액

특허료를 보전하는 자는 내지 아니한 금액의 2배의 범위에서 총리령⁵⁾으로 정한 금액을 내야 한다(法 81의2③).

IV. 불납의 효과

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다(法 81③). 이는 특허료를 전부 내었을 때 특허권을 발생시키고, 특허료를 낸 만큼만 특허권을 유지·존속시켜 주는 것이 타당하기 때문이다.

3) 1개월이 지날 때마다 내야 할 특허료의 3%의 가산(최대 18%의 가산)을 누적하고 있다(徵收規則 8⑥⑧).

4) 특허료 납부의 추가납부기간 또는 회복기간은 파리조약 제5조의2를 반영한 결과이다. 파리조약에서는 “산업재산권의 유지를 위하여 정하여진 요금의 납부에 대해서는 적어도 6개월의 유예기간이 인정된다. 다만 국내법령에 할증요금의 납부를 정하고 있는 경우는 그 납부를 요건으로 한다(조약 5의2(1)). 동맹국은 요금의 불납으로 인하여 효력이 상실된 특허의 회복에 관하여 정할 수 있다(조약 5의2(2))”라고 규정하고 있다.

5) 부족하게 납부한 금액에 3%를 가산하여 내야 한다((徵收規則 8⑥⑨))

V. 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등

1. 서

i) 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허출원이 포기간주되거나 특허권이 소멸간주되는 경우 또는 ii) 정당한 사유가 아니더라도 특허권자의 부지(不知)나 실수로 인해 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허권이 소멸되는 경우 너무 가혹하므로 일정요건하에서 회복할 기회를 주고 있다.

2. 요 건

(1) 정당한 사유로 납부 또는 보전하지 못한 경우

특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하면 i) 그 사유가 소멸한 날로부터 2개월 및 ii) 추가납부기간의 만료일과 보전기간의 만료일 중 늦은 날로부터 1년 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다(法 81의3①).

(2) 특허권자의 부지(不知) 등으로 납부 또는 보전하지 못한 경우

추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일로부터 3개월 이내에 제 79조에 따른 특허료의 2배를 내고 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다(法 81의3③). 특허권자 등의 사업 연속성을 지원하여 경쟁력 향상에 기여하기 위함이다.

3. 절 차

특허료를 추가납부하거나 보전하려는 자는 납부서에 그 취지를 기재하고 증명서류(정당한 사유가 있는 경우로 한정한다)를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 81의3⑦, 施規 55의2①②).

4. 효 과

(1) 특허출원 또는 특허권의 회복

특허료를 내거나 보전한 자는 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다(法 81의3②③). 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보는 경우 지식재산처장은 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하며, 설정등록에 의하여 특허권이 발생한다(法 87①②).

(2) 효력의 제한

회복된 특허출원 또는 특허권의 효력은 특허료 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 “효력제한기간”이라 한다) 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다(法 81의3④). 특허료 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 후 특허권 회복등록 전에 특허권 등이 소멸된 것으로 신뢰하고 그 특허발명을 실시한 제3자를 보호하기 위한 취지이다.

(3) 법정실시권의 발생

효력제한기간 중 국내에서 선의로 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 81의3⑤⑥).⁶⁾

VI. 면제 및 감면

1. 특허료의 면제

국가에 속하는 특허권에 대한 특허료는 면제이다(法 83① I). 다만 국가와 국가 이외의 자가 공동으로 특허권의 설정등록을 받고자 하거나 이들이 공유특허권자인 경우에는 면제되지 아니한다.⁷⁾

2. 특허료의 감면

1) 지식재산처장은 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 한 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대하여 총리령으로 정하는 특허료 및 수수료를 감면할 수 있다(法 83②).

- i) 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자
- ii) 「재난 및 안전관리 기본법」 제36조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제60조에 따른 특별재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중 총리령으로 정하는 요건을 갖춘 자
- iii) 그 밖에 총리령으로 정하는 자

2) 지식재산처장은 특허료 및 수수료 감면을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 받은 자에 대하여는 총리령으로 정하는 바에 따라 감면받은 특허료 및 수수료의 2배액을 징수할 수 있다. 이 경우 그 출원인 또는 특허권자가 하는 특허출원 또는 그 특허출원하여 받은 특허권에 대해서는 총리령⁸⁾으로 정하는 기간 동안 특허료 및 수수료를 감면하지 아니한다(法 83④).

6) 효력제한기간 중 유지료(연차료)를 납부 또는 보전하여 회복한 경우 전용실시권이 존재할 수 있기 때문에 제81조의3제5항을 “특허권 또는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다”라고 개정함이 적절해 보인다.

7) 지식재산처, 「등록업무편람」, 2022, 126면.

- i) 「국민기초생활 보장법」에 따른 의료급여 수급자
- ii) 「재난 및 안전관리 기본법」 제36조에 따른 재난사태 또는 같은 법 제60조에 따른 특별 재난지역으로 선포된 지역에 거주하거나 주된 사무소를 두고 있는 자 중 총리령으로 정하는 요건을 갖춘 자
- iii) 그 밖에 총리령으로 정하는 자

VII. 특허료 등의 반환

1. 반환대상

납부된 특허료 및 수수료는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에만 납부한 자의 청구에 따라 반환한다(法 84①).

- ① 잘못 납부된 수수료 및 특허료
- ② 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분⁸⁾
- ③ 특허권의 존속기간의 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
- ④ 특허출원(분할출원, 분리출원, 변경출원 및 우선심사의 신청이 있는 특허출원을 제외한다) 후 1개월 이내에 그 특허출원을 취하하거나 포기한 경우에 이미 납부된 수수료 중 특허출원료 및 특허출원의 우선권주장 신청료
- ⑤ 출원심사청구를 한 이후 다음의 어느 하나가 있기 전까지 특허출원을 취하(제53조제4항 또는 제56조제1항 본문에 따라 취하된 것으로 보는 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다)하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료
 - i) 동일인의 동일출원(同日出願)에 따른 지식재산처장의 협의 결과 신고 명령(法 36⑥)
 - ii) 거절이유통지(法 63)
 - iii) 특허결정등본의 송달(法 67②)
- ⑥ 출원심사의 청구를 한 이후 다음의 어느 하나에 해당하는 기간 내에 특허출원을 취하하거나 포기한 경우 이미 낸 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액
 - i) 동일인의 동일출원(同日出願)에 따른 지식재산처장의 협의 결과 신고 명령 후 신고기간 만료 전까지
 - ii) 거절이유통지(제47조제1항제1호에 해당하는 경우로 한정한다) 후 의견서 제출기간 만료 전까지

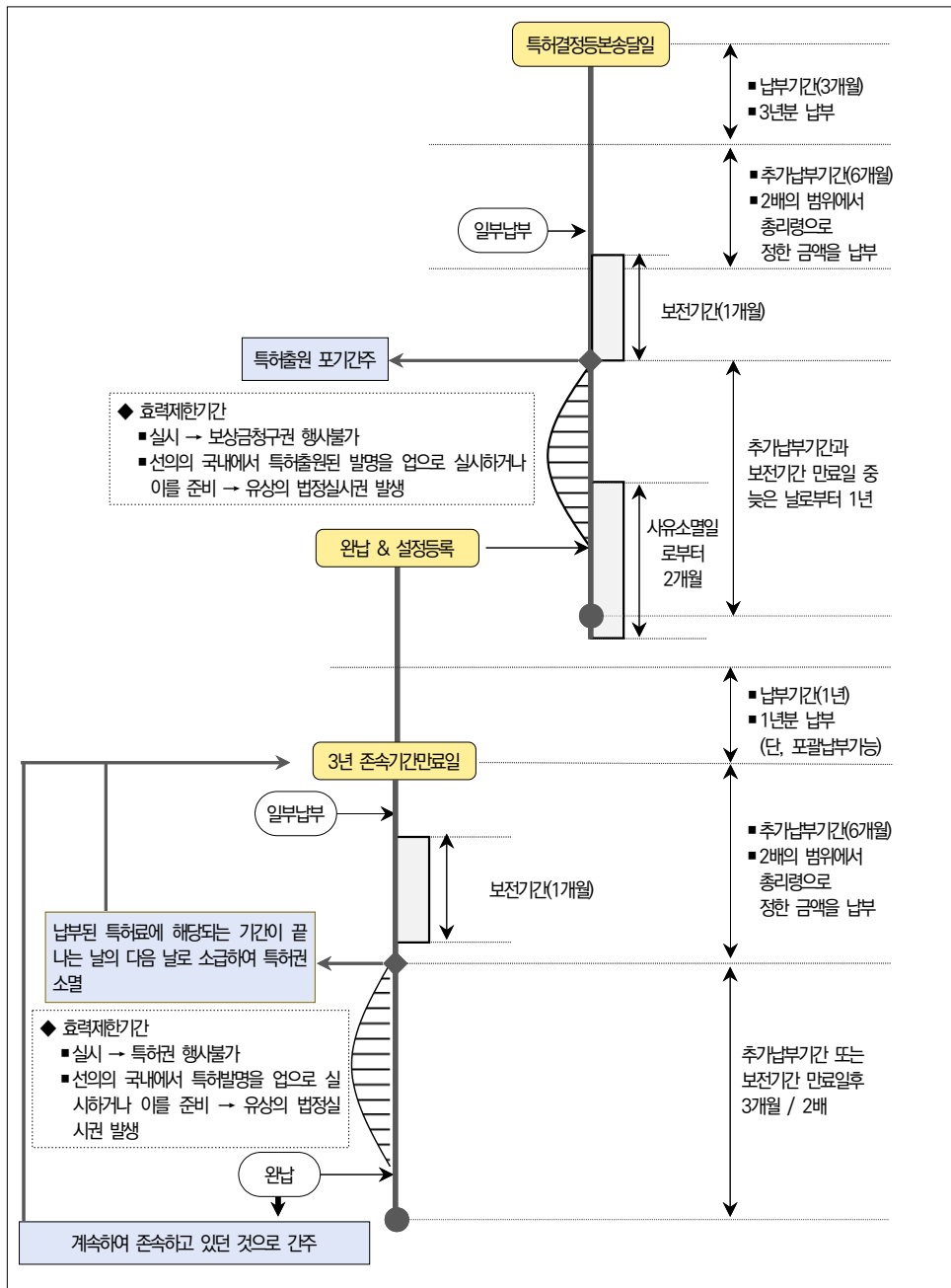
8) 징수금액 고지를 송달받은 날로부터 1년을 의미한다(徵收規則 13의2②③).

9) 청구항별로 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되거나 특허권을 포기한 경우에는 해당 해의 다음해부터의 특허료 해당분을 해당 청구항별로 반환한다(法 215).

- ⑦ 특허권을 포기한 해의 다음 해부터의 특허료 해당분
- ⑧ 제176조제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정이 취소된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함하되, 심판 또는 재심 중 제170조제1항에 따라 준용되는 제47조제1항제1호 또는 제2호에 따른 보정이 있는 경우는 제외한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료(재심의 경우에는 재심청구료를 말한다. 이하 이 조에서 같다)
- ⑨ 심판청구가 제141조제2항에 따라 결정으로 각하되고 그 결정이 확정된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액
- ⑩ 심리의 종결을 통지받기 전까지 제155조제1항에 따른 참가신청을 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
- ⑪ 제155조제1항에 따른 참가신청이 결정으로 거부된 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 참가신청료의 2분의 1에 해당하는 금액
- ⑫ 심리의 종결을 통지받기 전까지 심판청구를 취하한 경우(제184조에 따라 재심의 절차에서 준용되는 경우를 포함한다)에 이미 낸 수수료 중 심판청구료의 2분의 1에 해당하는 금액

2. 통지 및 반환청구

지식재산처장 또는 심판원장은 특허료 및 수수료가 반환대상에 해당하는 경우 그 사실을 납부한 자에게 통지하여야 하며, 그 통지를 받은 자는 통지를 받은 날로부터 5년이 되는 날까지 납부된 특허료 및 수수료의 반환을 청구할 수 있다(法 84②③).



【그림 6-1】 특허료 납부 절차

VIII. 특허등록

1. 특허등록의 의의 및 취지

「특허등록」이란 특허에 관한 권리의 발생·변경·소멸이나 그 밖에 특허권에 관한 소정사항을 지식재산처에 비치된 특허원부에 기재하는 절차를 총칭하는 것을 말한다. 특허권의 발생은 물론 권리의 존속·소멸이나 그 밖에 권리의 변동사항 등을 일반 공중에게 공표함으로써 거래의 안전을 도모하고 선의의 제3자에 대한 불측의 손해를 미리 방지하기 위해 특허법은 등록주의를 채택하고 있다.

2. 특허등록의 효력

(1) 특허권 및 전용실시권 등록의 효력

1) i) 특허권의 발생·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·포기에 의한 소멸¹⁰⁾ 또는 처분의 제한, ii) 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한, iii) 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 효력이 발생한다(法 87①, 101①). 이는 특허권·전용실시권이 독점·배타적인 물권적 권리이므로 권리의 변동을 공시하여야 할 필요가 있기 때문이다.

2) 다만 특허권, 전용실시권 또는 그 질권이 상속이나 그 밖의 일반승계에 의하여 이전되는 경우에는 등록을 하지 않더라도 권리변동의 효력이 발생하며, 그 취지를 지체없이 지식재산처장에게 신고하면 된다(法 101②). 이는 상속의 경우 사망과 상속인의 등록 사이에 권리의 공백상태의 발생을 방지하기 위함이고, 승계 전후의 사이에 권리내용의 변동이 없이 권리·의무가 포괄적으로 이전되는 것이므로 등록이 없어도 제3자에게 영향을 미치지 않기 때문이다.

3) 한편 전용실시권 또는 질권이 혼동에 의한 소멸한 경우에는 지식재산처장이 직권으로 소멸등록을 한다(登錄令 14).

(2) 통상실시권 등록의 효력

1) 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다(法 118①). 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다(法 118③). 즉 통상실시권은 등록이 없어도 효력이 발생하나¹¹⁾ 제3자에 대하여 대항하려면 등록을 하여야 한다.

10) 특허권의 소멸은 포기에 의한 경우 이외에는 사유가 발생하였을 때 소멸하며, 지식재산처장은 이를 직권으로 당연히 등록한다. 한편 청구항별로 포기한 경우에는 청구항별로 소멸등록을 한다(法 215).

2) 다만 법정실시권은 설정등록이 없이도 대항가능하며(法 118②), 강제실시권은 등록이 대항요건이나 강제실시권의 등록은 지식재산처장의 직권등록사항이다(登錄令 14).

【표 6-1】 등록의 효력

권 리		특허권	전용실시권	통상실시권
등록 사항	설정	○	○	○ (법정실시권 제외)
	이전	○ (상속 그 밖의 일반승계 제외)	○ (상속 그 밖의 일반승계 제외)	○
	변경	- (∴전면적 지배성)	○ (∴일면적 지배성)	○
	소멸	○ (포기에 한함)	○ (혼동 제외)	○
	처분 제한	○	○	○
효 력		효력발생요건		대항요건

11) 채권적 권리인 통상실시권의 경우 통상실시권의 효력은 그 원인의 성립과 동시에 발생한다. 즉 당사자 간의 설정행위에 의한 통상실시권은 설정계약이 성립되었을 때, 법정실시권은 법정요건이 성립되었을 때, 심판에 의하거나 지식재산처장의 행정처분에 의한 강제실시권은 심판의 확정 또는 지식재산처장의 처분이 있을 때 그 효력이 발생한 것으로 본다.

제2절 설정등록 및 등록공고

제86조 【특허증의 발급】

- ① 지식재산처장은 특허권의 설정등록을 한 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 특허권자에게 특허증을 발급하여야 한다.
- ② 지식재산처장은 특허증이 특허원부나 그 밖의 서류와 맞지 아니하면 신청에 따라 또는 직권으로 특허증을 회수하여 정정발급하거나 새로운 특허증을 발급하여야 한다.
- ③ 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 결정, 심결 또는 이전등록에 따른 새로운 특허증을 발급하여야 한다. <개정 2016.2.29.>
 1. 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우
 2. 제99조의2제2항에 따라 특허권이 이전등록된 경우

[전문개정 2014.6.11.]

제87조 【특허권의 설정등록 및 등록공고】

- ① 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.
- ② 지식재산처장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.
 1. 제79조제1항에 따라 특허료를 냈을 때
 2. 제81조제1항에 따라 특허료를 추가로 냈을 때
 3. 제81조의2제2항에 따라 특허료를 보전하였을 때
 4. 제81조의3제1항에 따라 특허료를 내거나 보전하였을 때
 5. 제83조제1항제1호 및 같은 조 제2항에 따라 그 특허료가 면제되었을 때
- ③ 지식재산처장은 제2항에 따라 등록한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다. <개정 2016.2.29.>
 1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
 2. 특허출원번호 및 출원연월일
 3. 발명자의 성명 및 주소
 4. 특허출원서에 첨부된 요약서
 5. 특허번호 및 설정등록연월일
 6. 등록공고연월일
 7. 제63조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따라 통지한 거절이유에 선행기술에 관한 정보(선행기술이 적혀 있는 간행물의 명칭과 그 밖에 선행기술에 관한 정보의 소재지를 말한다)가 포함된 경우 그 정보
 8. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항
- ④ 비밀취급이 필요한 특허발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허의 등록공고를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 제3항에 따라 등록공고를 하여야 한다.
- ⑤ 삭제 <2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

특허권은 설정등록에 의하여 발생한다. 지식재산처장은 특허료를 내거나 특허료가 면제된 경우 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하며 등록한 경우에는 일정 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다(法 87).

II. 설정등록

1. 의의 및 취지

「설정등록」이란 지식재산처장이 특허출원에 대한 심사관의 특허결정 후에 특허권이 발생하였음을 직권으로 특허원부에 기재하는 절차를 말한다. 특허법은 특허권을 설정등록에 의하여 발생하게 함으로써 i) 권리의 안전성을 도모하고 ii) 권리의 분쟁을 미리 방지하고 있다.

2. 요건

(1) 특허결정

심사관은 거절이유를 발견할 수 없으면 특허결정을 하여야 하며(法 66), 유효한 특허결정은 설정등록의 전제가 된다.

(2) 특허료의 납부 또는 면제

지식재산처장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직권으로 특허권의 설정등록을 하여야 한다(法 87②).

- i) 납부기간에 특허료를 냈을 때(法 79①)
- ii) 추납기간에 특허료를 추가로 냈을 때(法 81①)
- iii) 보전기간에 특허료를 보전하였을 때(法 81의2②)
- iv) 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 후에 특허료를 내거나 보전한 때(法 81의3①)
- v) 특허료가 면제되었을 때 (法 83① I, 83②)

3. 절차

지식재산처장은 특허료의 납부 또는 면제시에는 지식재산처에 비치된 특허원부에 특허권의 설정등록을 하여야 한다(法 85①, 87②). 특허권의 설정등록은 지식재산처장의 직권사항이며 이해관계인의 별도 신청절차가 필요하지 않다.

4. 효과

(1) 특허권의 발생

특허권은 설정등록에 의하여 발생한다(法 87①). 그러므로 특허권의 설정등록이 있으면 특허출원인은 특허권자가 되고 출원발명은 특허발명(法 2II)이 된다.

(2) 보상금청구권의 행사

특허권자는 특허권이 설정등록된 후에는 출원중인 발명을 업으로 실시한 제3자에 대하여 특허권과는 별개로 보상금청구권을 행사할 수 있다(法 65③④). 다만 설정등록이 있는 날로부터 3년을 지난 후에는 보상금청구권을 행사할 수 없다(法 65⑤).

(3) 등록의 추정적 효력

특허원부에 등록된 사항은 진정한 것으로 보아 원부상의 권리가 실제 존재하는 것으로 추정되며, 다만 이것은 반증으로 번복될 수 있지만 이때의 증명책임은 이를 주장하는 자가 진다. 한편 특허권의 설정등록은 공시의 효과만 있을 뿐 공신력이 있는 것은 아니다. 이것은 거래의 안전보다는 진정한 권리자를 보호하기 위함이다.

(4) 공지기술로서의 이용

설정등록된 후에는 신청에 의하여 서류를 열람할 수 있다(法 216①). 그 결과 제3자는 공개된 발명을 기술정보로써 이용하여 중복투자 및 중복연구를 방지할 수 있으며, 심사관은 후출원 발명에 대하여 신규성(法 29①각호), 진보성(法 29②) 등의 거절이유의 인용대상으로 활용할 수 있다.

(5) 특허증의 발급

1) 지식재산처장은 특허권의 설정등록을 한 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 특허권자에게 특허증을 발급하여야 한다. 지식재산처장은 특허증이 특허원부나 그 밖의 서류와 맞지 아니하면 신청에 따라 또는 직권으로 특허증을 회수하여 정정발급하거나 새로운 특허증을 발급하여야 하고, 정정을 인정한다는 취지의 결정 또는 심결이 확정된 경우나 특허권이 이전등록(法 99의2②)된 경우에는 그 결정, 심결 또는 이전등록에 따른 새로운 특허증을 발급하여야 한다(法 86).

2) 「특허증」이란 특허권이 설정등록되었다는 하나의 증표로서 지식재산처장이 특허원부에 등록된 사항을 특허증 서식에 적어 특허권자에게 발급하는 공적증서를 말한다. 파리조약 제4조의3에서는 “발명자는 특허에 발명자로서 명시될 권리를 갖는다”라고 규정함으로써 발명자의 보호에 앞장서고 있다. 결국, 특허증의 발급은 역사적·전통적 산물임과 동시에 발명자의 명예를 표시하기 위한 것이라고 할 수 있다. 이러한 특허증의 이전이나 분실 여부가 특허권에 영향을 미치는 것은 아니다.

(6) 기탁된 미생물의 분양

기탁된 미생물에 관계되는 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 i) 그 미생물에 관계되는 발명에 대한 특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우 또는 ii) 제63조제1항(제170조제2항에서 준용하는 경우를 포함한다)에 따른 의견서를 작성하기 위하여 필요한 경우 총리령으로 정하는 바에 따라 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관으로부터 그 미생물을 분양받을 수 있다(令 4①). 한편 미생물을 기탁한 자로부터 미생물 분양에 대한 허락을 받은 자도 국내기탁기관, 국제기탁기관 또는 지정기탁기관에 신청하여 해당 미생물을 분양받을 수 있다(令 4②).

III. 등록공고

1. 의의 및 취지

「등록공고」란 특허권이 발생하였을 때 발명의 내용을 일반에게 공표하여 침해하지 않도록 유도함으로써 특허분쟁을 미리 방지하기 위한 절차를 말한다. 이런 점에서 등록공고는 출원발명의 조기공표를 목적으로 행하는 출원공개와는 그 제도적 취지를 달리한다. 그러나 출원공개 전에 등록공고되면 등록공고는 출원공개의 발명 공표적 기능까지를 대행하기 때문에 출원공개를 다시 할 필요가 없다.

2. 요건

지식재산처장은 특허권 설정등록이 있으면 그 특허에 관하여 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다. 다만 지식재산처장은 국방상 필요한 발명으로서 비밀취급이 필요한 특허발명에 대해서는 그 발명의 비밀취급이 해제될 때까지 그 특허의 등록공고를 보류하여야 하며, 그 발명의 비밀취급이 해제된 경우에는 지체 없이 등록공고를 하여야 한다(法 87③④).

3. 절차

등록특허공보에는 다음의 사항을 게재함으로써 행해진다(法 87③, 令19②). 한편 이러한 등록특허공보는 전자적 매체(CD-ROM)로도 발행할 수 있다.

- i) 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)
- ii) 특허출원번호 및 출원연월일
- iii) 발명자의 성명 및 주소¹²⁾
- iv) 특허출원서에 첨부된 요약서
- v) 특허번호 및 설정등록연월일
- vi) 등록공고연월일
- vii) 제63조제1항 각호 외의 부분 본문에 따라 통지한 거절이유에 선행기술에 관한 정보(선행기술이 적혀 있는 간행물의 명칭과 그 밖에 선행기술에 관한 정보의 소재지를 말한다)가 포함된 경우 그 정보
- viii) 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

12) 지식재산처장은 자연인인 특허권자 또는 발명자의 주소를 게재하는 경우 그 특허권자, 출원인 또는 발명자의 신청이 있으면 그 주소의 일부만을 게재할 수 있다(施規 19④).

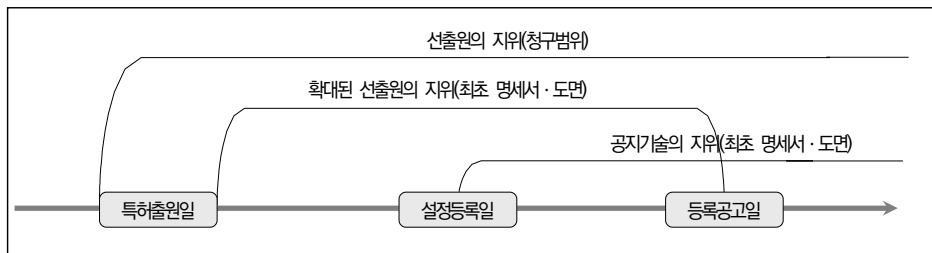
4. 효 과

(1) 특허취소사유의 제한

특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다(法 132의2②). 심판관 합의체는 특허취소신청이 이를 이유로 한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다(法 132의13④). 특허취소신청제도가 심사관이 특허등록 전 검토하지 못한 선행기술로 인해 부실특허가 발생하는 것을 방지하기 위함이기 때문에 특허등록 전 검토한 선행기술을 근거로는 취소신청을 하지 못하도록 제한을 두고 있다.

(2) 확대된 선출원의 적용

특허출원이 출원공개되지 않고 설정등록되어 등록공고된 경우 특허출원일의 다음 날부터 등록공고 전 다른 특허(실용신안등록)출원에 대하여 확대된 선출원이 적용된다(法 29③④). 다만 특허출원이 출원공개된 후 설정등록되어 등록공고된 경우라면 특허출원일의 다음 날로부터 출원공개 전 다른 특허(실용신안등록)출원에 대하여 확대된 선출원이 적용된다.



【그림 6-2】 출원공개되지 않고 등록공고된 특허의 등록금지적 효력

【표 6-2】출원공개제도와 등록공고제도의 비교

제 도		출원공개제도		등록공고제도		
서	의 의	특허출원된 내용에 대하여 심사청구의 유무와 관계없이 일정 기간이 지나면 그 출원내용을 공보에 게재하여 사회일반에 공표하는 것을 말한다.		특허권이 발생하였을 때 발명의 내용을 일반에게 공표하는 제도를 말한다.		
	취 지	■출원인 → 보상금청구권 발생 ■제3자 → 중복투자 및 중복연구 방지 ■지식재산처 → 심사청구제도를 효율적 운영		특허권을 침해하지 않도록 유도하여 특허분쟁을 미리 방지		
요 건	주체적		출원인의 신청 여부와 관계없이 지식재산처장이 출원공개. 단 신청에 의한 조기공개 가능		출원인의 신청 여부와 관계없이 지식재산처장이 등록공고	
	객 체 적	원 칙	출원 계속 중인 특허출원		설정등록이 된 발명	
		예 외	■명세서에 청구범위를 적지 아니한 경우 ■외국어특허출원인데 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 ■등록공고를 한 특허의 경우 ■국방상 필요한 발명으로서 비밀취급이 필요한 경우 ■공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 경우		국방상 필요한 발명으로서 비밀취급이 필요한 경우	
		시 기 적	원 칙	■일반 출원일로부터 1년 6개월이 지난 후 ■조기공개 1년 6개월이 지나기 전이라도 가능		특허권의 설정등록이 있는 경우
	예 외	■정당한 권리자 출원(法 34, 35) → 무권리자 출원일 ■분할출원·분리출원·변경출원(法 52②·52의 2·53②) → 원출원일 ■조약·국내우선권주장출원(法 54①·55③) → 최우선일				
절 차		공개특허공보에 전문공개, CD-ROM 배포		등록특허공보에 전문공개, CD-ROM 배포		
효 과		■보상금청구권의 발생(法 65) ■우선심사(法 61 I) ■특허출원에 관한 서류의 열람 등의 신청(法 216) ■기탁된 미생물의 분양(令 4①) ■공지기술로서 이용(法 29①각호·29②) ■확대된 선출원(法 29③④)		■특허공보에 게재된 선행기술을 기초로 한 이 유로는 특허취소신청 不可(法 132의2②) ■확대된 선출원(法 29③④)		

제3장

특허권의 효력

제1절 특허권의 존속기간과 존속기간연장등록제도

제1관 특허권의 존속기간

제88조 【특허권의 존속기간】

- ① 특허권의 존속기간은 제87조제1항에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.
- ② 정당한 권리자의 특허출원이 제34조 또는 제35조에 따라 특허된 경우에는 제1항의 특허권의 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「특허권의 존속기간(term of patent right)」이란 특허권자가 특허발명을 독점배타적으로 실시할 수 있는 기간을 말한다. 특허권은 발명에 대한 공개의 대가로서 일정 기간의 독점배타적 이익을 보장하기 위하여 부여되는 권리이므로 유체물에 대한 소유권과 달리 존속기간을 두어 유한적이다.

2. 취 지

i) 특허권을 일정 기간 특허권자에게 독점배타적으로 실시할 수 있도록 하는 한편 ii) 일정 기간이 지난 후에는 소멸시켜 누구라도 자유롭게 이용할 수 있는 공공영역으로 만드는 것이 기술발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하려는 법 목적에 부합되기 때문에 존속기간을 두고 있다.

II. 존속기간

1. 원 칙

특허권의 존속기간은 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다(法 88①).¹³⁾ 즉 특허권의 발생일은 설정등록을 한 날이지만, 그 존속기간 만료일의 계산은 특허출원일을 기준으로 한다.

2. 예 외

(1) 무권리자에 대한 정당한 권리자의 특허출원

무권리자의 특허출원이 거절이유에 해당되어 특허를 받지 못하게 되거나 무권리자의 특허가 특허무효사유에 해당되어 무효심결이 확정되었는데, 정당한 권리자가 일정 기간 내에 특허출원하면 무권리자의 출원 시에 특허출원한 것으로 보는데(法 34, 35), 이때 정당한 권리자의 특허권 존속기간은 무권리자의 특허출원일의 다음 날부터 기산한다(法 88②). 제88조제2항은 정당한 권리자의 출원일이 제34조, 제35조에 따라 무권리자의 출원일까지 소급되는 경우 존속기간의 기산일도 소급됨을 명확히 하는 확인적 성격을 가진 규정이다.

(2) 기 타

i) 분할출원, 분리출원 또는 변경출원의 존속기간은 원출원의 다음 날부터 기산하며(法 52②, 52의2②, 53②), ii) 조약우선권주장출원, 국내우선권주장출원의 존속기간은 우선권주장출원(후출원)의 다음 날부터 기산하며(法 54①, 55③), iii) 국제특허출원의 존속기간은 국제출원일의 다음 날부터 기산한다.

3. 만료일이 공휴일인 경우

특허에 관한 절차에서 기간의 마지막 날이 공휴일(「노동절 제정에 관한 법률」에 따른 노동절 및 토요일을 포함한다)에 해당하면 기간은 그 다음 날로 만료한다(法 14Ⅳ). 그러나 존속기간은 절차적 기간이 아닌 실체적 기간이므로 만료일이 공휴일인 경우라도 그 다음 날로 만료되지 않고 그 날로 만료된다.

13) 특허권의 존속기간은 국가마다 기술수준, 산업정책적 측면, 발명자와 사회일반의 이익의 조화 측면에서 상이하나 최근 WTO/TRIPs에서는 특허권의 최소보호기간을 특허출원일로부터 20년으로 규정하고 있다(WTO/TRIPs협정 제33조).

Ⅲ. 존속기간 만료의 효과

1. 특허권 및 부수적인 권리의 소멸

존속기간이 만료되는 경우 특허권 및 특허권에 부수적인 실시권·질권 등은 장래를 향하여 소멸한다. 존속기간의 만료는 소멸등록하지 않더라도 그 효력이 발생하나 지식재산처장은 존속기간이 만료되면 직권으로 소멸등록을 한다. 한편 특허권 등록은 특허권 발생의 요건이지만 존속요건은 아니다. 따라서 특허권이 부적법하게 소멸등록되었다 하더라도 특허권의 효력에는 아무런 영향이 없고, 특허권의 존속기간도 그대로 진행한다.¹⁴⁾

2. 특허권 존속기간 만료 후의 디자인보호법상 법정실시권

디자인등록출원일 전 또는 같은 날에 출원되어 등록된 특허권이 디자인권과 저촉되는 경우 특허권의 존속기간이 만료되는 경우에 원특허권자는 원특허권의 범위에서, 전용실시권자나 등록된 실시권자(단, 법정실시권자는 등록 不要)는 원권리의 범위내에서 그 디자인권에 대하여 통상실시권을 가진다(디자인 103③). 이때 특허권자는 무상으로 실시할 수 있으나 실시권자는 디자인권자 등에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(디자인 103④).

3. 특허권 존속기간 만료 후의 상표법상 법정사용권

상표등록출원일 전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 그 원특허권자는 원특허권의 범위에서, 전용실시권자나 등록된 실시권자(단, 법정실시권자는 등록 不要)는 원권리의 범위내에서 그 등록상표의 지정상품과 동일·유사한 상품에 대하여 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 사용할 권리를 가진다. 다만 부정경쟁의 목적으로 그 상표를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다(商標 98①②). 이때 특허권자는 무상으로 실시할 수 있으나 사용권자는 상표권자 등에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(商標 98③).

14) 특허권이 부적법하게 소멸등록된 때에는 특허권자는 그 회복을 신청할 수 있고, 회복등록은 부적법하게 말소된 등록을 회복하여 처음부터 그러한 말소가 없었던 것과 같은 효력을 보유하게 하는 등록에 불과하므로, 회복등록이 되었다고 해도 특허권의 존속기간에 영향이 있다고 볼 수 없다(대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000 참조).

제2관 존속기간연장등록제도

제89조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장】

- ① 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 “허가 등”이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장할 수 있다. 다만, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다. <개정 2025. 1. 21.>
- ② 제1항을 적용할 때 허가 등을 받은 자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간은 제1항의 “실시할 수 없었던 기간”에 포함되지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제90조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원】

- ① 제89조제1항에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제91조에서 “연장등록출원인”이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 지식재산청장에게 제출하여야 한다.
 1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 3. 연장대상특허권의 특허번호 및 연장대상청구범위의 표시
 4. 연장신청의 기간
 5. 제89조제1항에 따른 허가 등의 내용
 6. 총리령으로 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)
- ② 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 제89조제1항에 따른 허가 등을 받은 날부터 3개월 이내에 출원하여야 한다. 다만, 제88조에 따른 특허권의 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 할 수 없다.
- ③ 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만, 그 출원에 관하여 제91조의 연장등록거절결정이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 지식재산청장은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 제1항 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.
- ⑥ 연장등록출원인은 지식재산청장이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 제1항제3호부터 제6호까지의 사항(제3호 중 연장대상특허권의 특허번호는 제외한다)에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.
- ⑦ 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우에는 연장등록출원인은 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 하고, 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우에는 어느 특허권의 존속기간도 연장할 수 없다. <신설 2025. 1. 21.>
- ⑧ 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 그 출원은 제7항을 적용할 때는 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2025. 1. 21.>
 1. 포기, 무효 또는 취하된 경우
 2. 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

[전문개정 2014.6.11.]

제91조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정】

심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다. <개정 2025. 1. 21.>

1. 그 특허발명의 실사가 제89조제1항에 따른 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우
2. 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조제1항에 따른 허가 등을 받지 아니한 경우
3. 연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하는 경우
4. 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
5. 제90조제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우
6. 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우

[전문개정 2014.6.11.]

제92조 【허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등】

- ① 심사관은 제90조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제91조 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 한다.
- ② 지식재산처장은 제1항에 따른 연장등록결정을 한 경우에는 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.
- ③ 지식재산처장은 제2항에 따른 등록을 한 경우에는 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.
 1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 특허번호
 3. 연장등록의 연월일
 4. 연장기간
 5. 제89조제1항에 따른 허가 등의 내용

[전문개정 2014.6.11.]

제92조의2 【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장】

- ① 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다.
- ② 제1항의 규정을 적용함에 있어서 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장에서 제외된다. 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니 된다.
- ③ 제2항에서 “출원인으로 인하여 지연된 기간”에 관한 사항은 대통령령으로 정한다.
- ④ 제1항에 따라 특허출원일로부터 4년을 기산할 때에는 제34조, 제35조, 제52조제2항, 제52조의2제2항, 제53조제2항, 제199조제1항 및 제214조제4항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 날을 특허출원일로 본다. <개정 2021. 10. 19.>
 1. 제34조 또는 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원의 경우에는 정당한 권리자가 출원을 한 날
 2. 제52조에 따른 분할출원의 경우에는 분할출원을 한 날
 - 2의2. 제52조의2에 따른 분리출원의 경우에는 분리출원을 한 날
 3. 제53조에 따른 변경출원의 경우에는 변경출원을 한 날
 4. 제199조제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 제203조제1항 각 호의 사항을 기재한 서면을 제출한 날
 5. 제214조에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날
 6. 제1호부터 제5호까지의 규정 중 어느 하나에 해당되지 아니하는 특허출원에 대하여는 그 특허출원일

[본조신설 2011.12.2.]

제92조의3【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원】

- ① 제92조의2에 따라 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하려는 자(이하 이 조 및 제92조의4에서 “연장등록출원인”이라 한다)는 다음 각 호의 사항을 적은 특허권의 존속기간의 연장등록출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2013.7.30.>
1. 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
 3. 연장 대상 특허권의 특허번호
 4. 연장신청의 기간
 5. 총리령이 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)
- ② 제1항에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 설정등록일부터 3개월 이내에 출원하여야 한다.
- ③ 특허권이 공유인 경우에는 공유자 전원이 공동으로 특허권의 존속기간의 연장등록출원을 하여야 한다.
- ④ 연장등록출원인은 심사관이 특허권의 존속기간의 연장등록 여부결정 전까지 연장등록출원서에 기재된 사항 중 제1항제4호 및 제5호의 사항에 대하여 보정할 수 있다. 다만, 제93조에 따라 준용되는 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다.

[본조신설 2011.12.2.]

제92조의4【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정】

심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다.

1. 연장신청의 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우
2. 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
3. 제92조의3제3항을 위반하여 연장등록출원을 한 경우

[본조신설 2011.12.2.]

제92조의5【등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록결정 등】

- ① 심사관은 제92조의3에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 제92조의4 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유를 발견할 수 없는 경우에는 연장등록결정을 하여야 한다.
- ② 지식재산처장은 제1항의 연장등록결정이 있으면 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 등록이 있으면 다음 각 호의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다.
1. 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 특허번호
 3. 연장등록 연월일
 4. 연장 기간

[본조신설 2011.12.2.]

제93조 【준용규정】

특허권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여는 제57조제1항, 제63조, 제67조, 제78조제1항·제3항, 제148조제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제7호를 준용한다. 이 경우 제78조제1항 중 “특허취소신청에 대한 결정”은 “제92조의4 및 제92조의5에 따른 연장등록거절결정 또는 연장등록결정”으로, “그 심사절차”는 “허가등에 따른 연장등록출원 심사 절차”로 본다. <개정 2025. 1. 21.>

[전문개정 2011.12.2.]

제94조 【특허권의 효력】

- ① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조제2항에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다. <개정 2019. 12. 10.>
- ② 특허발명의 실시가 제2조제3호나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다. <신설 2019. 12. 10.>

[전문개정 2014.6.11.]

제95조 【허가 등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력】

제90조제4항에 따라 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

「존속기간연장등록제도」란 i) 허가 등으로 인해 특허발명을 실시할 수 없었던 경우, ii) 심사 등이 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우 특허권의 존속기간을 연장할 수 있는 제도를 말한다. 특허권자는 존속기간 동안 충분하게 특허권의 효력을 누릴 수 있어야 하지만 실제로는 특허권이 발생하였지만 허가 등으로 인해 특허발명을 실시할 수 없거나, 설정등록에 의한 특허권의 발생이 늦어져 존속기간이 짧아지게 되는 문제점이 발생할 수 있으므로 특허법은 이를 보완하기 위해서 존속기간연장등록제도를 두고 있다.¹⁵⁾ 이하 허가 등에 따른 특허권의 존속기간연장등록제도와 등록지연에 따른 특허권의 존속기간연장등록제도로 구분하여 설명한다.

II. 허가 등에 따른 특허권의 존속기간연장등록제도

1. 의의 및 취지

(1) 의 의

「허가 등에 따른 특허권의 존속기간연장등록제도」란 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등(이하 "허가 등"이라 한다)을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는

15) 허가 등에 따른 존속기간연장등록출원은 1999년부터 2023년까지 총 980건으로, 이 중 외국인(글로벌 제약사) 출원이 92.0%(888건)로 대부분을 차지하고 있고, 내국인 출원은 8.0%(77건)에 불과하다. 한편 등록지연에 따른 존속기간연장등록출원은 2013년 도입 이후 2023년까지 총 19건이 발생하였다(박희석 수석전문위원, “특허법 일부개정법률안 심사보고서(고등진 의원 대표 발의(의안번호 2204182))”, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2024.12. 11면),

발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 의한 등록지연에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장(단, 허가 등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장 불가)할 수 있는 제도를 말한다(法 89).

(2) 취 지

다른 법률의 허가 등을 받지 못하여 발명을 실시하지 못하더라도 특허권의 설정등록은 가능하다. 다만 설정등록 후에도 실시할 수 없었던 특허권자의 불이익을 해소하고 다른 특허권자와의 형평성을 위해 허가 등에 따른 특허권의 존속기간연장등록제도를 규정하고 있다. 즉 특허권의 존속기간을 보장하여 특허권자가 기술개발 투자액을 회수할 수 있도록 함으로써 궁극적으로 산업발전에 이바지하고자 함에 그 의의가 있다. 이와 같은 제도를 채택한 것은 1987년 7월 1일 이후 물질특허의 도입 이후부터이다. 한편 2025. 7. 22. 시행되는 개정법(법률 제20700호, 2025. 1. 21. 일부개정)에서는 i) 허가 등이 있는 후 특허권 존속기간의 상한을 ‘허가 등을 받은 날로부터 14년’으로 정하고, ii) 하나의 허가 등에 대하여 하나의 연장등록출원만 가능함을 정하면서, iii) 이와 관련된 규정을 정비하였다.¹⁶⁾

2. 요 건

(1) 주체적 요건

존속기간연장등록출원은 특허권자만이 할 수 있으며(法 91Ⅳ), 특허권이 공유인 경우에는 모두가 공동으로 출원하여야 한다(法 90③, 91Ⅴ). 한편 임의대리인은 연장등록출원의 취하와 달리 특별히 권한을 위임받지 않더라도 존속기간 연장등록출원을 할 수 있다(法 6).

(2) 객체적 요건

① 허가 등의 필요성

1) 그 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 의하여 허가 등을 받을 필요가 있어야 한다(法 91Ⅰ), 여기서 허가 등을 받을 필요가 있는 발명은 그 허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명을 말한다(法 89①). 「대통령령으로 정하는 발명」이란 i) 특허발명을 실시하기 위하여 약사법 제31조제2항·제3항 또는 제42조제1항에 따라 품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 유효성분부의 화학구조가 새로운 물질을 말한다. 이하 같다)을 유효성분으로 하여 제조한 의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 한정한다]의 발명 또는 「마약류 관리에 관한 법률」 제18조제2항 또는 제21조제2항에 따라 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 마약 또는 향정신성의약품으로서 최초로 품목허가를 받은 마약 또는 향정신성의약품으로

16) 개정법(법률 제20700호)의 주요내용은 다음과 같다(박희석 수석전문위원, “특허법 일부개정법률안 심사보고서(고동진 의원 대표 발의(의안번호 2204182))”, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2024.12, 1-2면).

한정한다)의 발명¹⁷⁾, ii) 특허발명을 실시하기 위하여 「농약관리법」 제8조제1항, 제16조제1항 또는 제17조제1항에 따라 등록한 농약 또는 원제(신물질을 유효성분으로 하여 제조한 농약 또는 원제로서 최초로 등록한 농약 또는 원제로 한정한다)의 발명을 말한다(令 7①). 허가 등이 된 의약품(농약)에 의하여 확인된 신물질을 유효성분으로 하여 제조된 의약품(농약)이면서 용도, 제형 등만을 변경한 경우에는 이미 허가 등이 된 의약품(농약)과 동일한 물질로 볼 수 있기 때문에 존속기간 연장 대상이 될 수 없다. 그러나 이미 허가 등이 된 의약품(농약)의 염, 에스테르, 구조 이성질체, 광학이성질체 등이 달라 새로운 신물질을 유효성분으로 한 것이라면 존속기간 연장의 대상이 될 수 있다.¹⁸⁾ 여기서 신물질이란 약효를 나타내는 유효성분부의 화학구조가 새로운

구 분		주요내용
i) 허가 등이 있는 후 특허권 존속기간 상한 설정		
	허가 등이 있는 후 특허권 존속기간 상한 신설 (제89조제1항 단서 신설)	-허가 등이 있는 후 특허권 존속기간은 허가 등을 받은 날부터 14년 초과 금지
	등록지연에 따른 특허권의 존속기간 연장기간 적용 명확화 (제89조제1항)	-허가 등에 따른 특허권 존속기간 연장과 등록지연에 따른 연장이 모두 발생하는 경우에 허가 등이 있는 후 특허권 존속기간 상한 적용
ii) 연장가능한 특허권의 수 제한		
연장 등록 출원	하나의 허가 하나의 연장등록출원 신설 (제90조제7항 신설)	-하나의 허가등에 대하여 하나의 특허권에 대하여만 연장등록출원을 하고, 둘 이상의 연장등록출원이 있는 경우 모든 특허권 존속기간 연장 불가
	착오로 인한 복수 연장등록출원에 대한 보완조치 마련 (제90조제8항 신설)	-연장등록출원이 포기, 무효 또는 취하 또는 거절결정 확정된 경우 신설되는 하나의 허가에 대한 하나의 연장등록출원 규정(제90조제7항) 적용 시 처음부터 없었던 것으로 간주
iii) 관련 규정의 정비		
연장 등록 거절 결정	거절이유 (제91조제3호)	-허가 등이 있는 후 특허권 존속기간 상한 설정에 따른 용어 정비
	거절이유 신설 (제91조제6호 신설)	-거절이유에 '하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우' 추가
연장 등록 무효 심판	무효사유 신설 (제134조제1항제6호)	-무효사유에 '하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록된 경우' 추가
	무효 후 연장등록출원에 대한 보완조치 마련 (제134조제5항)	-신설되는 1허가 1연장등록을 위반하여 무효(제134조제1항제6호) 확정 시 해당 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 간주
심사 절차 정비	허가등에 따른 연장등록출원 심사 절차 정비(준용규정) (제93조)	-등록지연에 따른 존속기간 연장등록결정 및 거절결정에 대한 심결 등 확정시까지 연장등록출원 심사절차 중지

- 17) 특허법원 2019. 7. 5. 선고 2018허2250, 2018허2267 판결에서 마약류 관리법에 의한 품목허가가 존속기간 연장에서 제외된 것은 입법불비라고 판시하였고, 2020. 7. 14. 시행(대통령령 제30844호, 2020. 7. 14. 일부개정)된 시행령에서 이를 반영하였다.
- 18) 손천우, 특허권의 존속기간 연장등록의 요건과 연장된 특허권의 효력범위 -대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결을 중심으로-, 사법 47호, 2019 봄호, 사법발전재단, 373면. 최근 특허법원도 2017. 12. 21. 선고 2016허9035 판결에서 “이 사건 의약품의 유효성분인 9-시스 레티노산(9-cis retinoic acid)은 기존에 품목허가를 받은 의약품의 유효성분인 트레티노인, 이소트레티노인과 기하이성질체(幾何異

물질을 말하는 것으로서, '약효를 나타내는 유효성부분'은 의약품(농약)의 유효성분 중 유효성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 의약품(농약) 품목허가(등록)상의 효능·효과를 나타내는 부분을 의미한다. 한편 그 자체로는 유효성을 가지지 않는 부분이 기존에 품목허가(등록)된 의약품(농약)의 '약효를 나타내는 유효성부분'에 결합되어 의약품(농약)의 효능·효과 정도에 영향을 미치더라도 이는 의약품(농약)의 효능·효과로서의 '약효'를 나타내는 부분이 아니므로, 이러한 부분이 '약효를 나타내는 유효성부분'에 결합되어 있다는 사정만으로 그 결합물 전체를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 '약효를 나타내는 유효성부분'이라고 볼 수는 없다.¹⁹⁾

2) 연장등록의 대상이 되는 특허는 물질특허, 제법특허, 용도특허 및 조성물 특허이며 중간체, 촉매 및 제조장치에 관한 특허는 성격상 제외된다. 한편 약사법 및 농약관리법에 따라 최초의 허가 또는 등록을 받은 유효성분이 청구범위에 기재되어 있어야 한다.

性質體, geometrical isomer, 시스-트랜스 이성질체)의 관계에 있다. 이 사건 의약품의 유효성분은 기존에 품목허가를 받은 의약품의 유효성분들과 입체구조가 달라 화학구조가 다르다고 평가할 수 있다. 한편 기하이성질체는 입체구조가 서로 달라 일반적으로 이온화 등의 물리화학적 성질이나 생물학적 활성(유효성)에 있어 상당한 차이가 있다. 더욱이 9-시스 레티노산(9-cis retinoic acid)은 트레티노이드 레티노이드 수용체 중 RAR에만 결합하는 것과 달리, RAR 뿐만 아니라 RXR에도 결합한다. 또한 레티노산(9-cis retinoic acid)은 트레티노이드가 갖지 못한 만성 손 습진 치료효과를 갖고 있는데, 이러한 치료효과의 차이는 위와 같은 작용기전의 차이에서 기인한 것으로 보인다. 따라서 비록 9-시스 레티노산과 트레티노이드가 RAR에 결합하는 공통적인 성질을 갖고 있고, 이 사건 의약품이 인체에 투여되는 경우 트레티노이드 등의 기하이성질체로 이성질체화될 수 있는 점을 감안하더라도, 앞서 살펴 본 기하이성질체의 일반적인 성질, 각 유효성분의 작용 및 효과의 차이에 비추어 보면, 이 사건 의약품은 기존에 품목허가를 받은 의약품들과 상이한 만성 손 습진 치료효과를 갖는 동시에 '기존에 허가된 의약품들과 비교하여 위와 같은 치료효과를 나타내는 부분의 화학구조가 새로운 물질'을 유효성분으로 하여 제조한 것으로서 최초로 품목허가를 받은 의약품으로 볼 수 있다. 그렇다면 이 사건 연장대상 특허발명은 이를 실시하기 위하여 구 약사법에 따른 품목허가를 받아야 하고 그 허가를 받는 데 필요한 활성(유효성)·안전성 등의 시험에 장기간이 소요되는 '이 사건 시행령이 정하는 발명'에 해당함에도, 피고가 이 사건 의약품이 신약에 해당하지 않는다는 이유로 이 사건 연장출원을 거절한 것은 위법하다"라고 하여 같은 취지로 판결하였다.

- 19) 대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070. 구체적으로 살펴보면, 이 사건 청구항은 페그인터페론베타-1a(이하 '이 사건 의약품')를 유효성분으로 하는 의약품 발명이다. 원고는 이 사건 청구항에 관한 존속기간 연장등록출원을 하였는데, 지식재산청 심사관은 인터페론베타-1a를 유효성분으로 하는 기허가 의약품이 있고, 이 사건 의약품은 치료효과를 나타내는 유효성부분이 인터페론베타-1a로 기허가 의약품과 동일하여 신물질에 해당하지 않는다는 이유로 거절결정을 하였고 특허심판원도 같은 취지에서 원고의 거절결정취소 심판청구를 기각하였으나, 원심은 약효를 나타내는 유효성부분은 페그인터페론베타-1a이고 신물질에 해당한다고 보아 이 심판원의 심결을 취소하였다. 이에 대법원은 의약품의 유효성분 중 체내 유효성을 가지면서 내재된 약리작용에 의하여 재발성 다발성 경화증의 치료효과를 나타내는 부분은 인터페론베타-1a이고, 인터페론베타-1a에 결합된 폴리에틸렌글리콜 부분은 체내 유효성이나 위와 같은 치료효과를 가지지 않으면서 인터페론베타-1a 부분이 혈액 중에 오래 체류하도록 하거나 인터페론베타-1a의 단백질 수용체에 대한 결합력을 낮추는 등으로 인터페론베타-1a의 유효성 정도에 영향을 미치는 부분에 불과하므로, 이 사건 의약품의 유효성분 중 '약효를 나타내는 유효성부분'은 인터페론베타-1a이고, 폴리에틸렌글리콜 부분이 '약효를 나타내는 유효성부분'인 인터페론베타-1a에 결합되어 페그인터페론베타-1a를 구성하고 있다고 하더라도 그 결합물 전체인 페그인터페론베타-1a를 이 사건 시행령 조항에서 말하는 '약효를 나타내는 유효성부분'이라고 볼 수는 없고, 이 사건 의약품에서 '약효를 나타내는 유효성부분'인 인터페론베타-1a 부분은 기허가 의약품에서 '약효를 나타내는 유효성부분'인 인터페론베타-1a와 입체적 화학구조가 동일하다고 보아, 이와 달리 판단한 원심을 파기·환송하였다.

② 허가 등의 취득

특허권자, 전용실시권자 또는 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받아야 한다(法 89①, 91Ⅱ). 「등록된 통상실시권자」로 한정된 것은 제134조의 존속기간 연장등록무효심판에서 연장등록의 유효성이 다투어지는 경우에 허가 등을 받은 자의 행위내용이 쟁점이 될 가능성이 있는데, 만약 등록하지 않으면 허가 등을 받은 자에게 지식재산처가 통지할 수 없게 되고, 이 경우 허가 등을 받은 자가 알지 못하는 사이에 자신의 행위 내용에 관하여 심판절차가 이루어지는 미묘한 사태가 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 허가 등의 신청 당시부터 통상실시권의 등록이 되어야 하는 것은 아니고,²⁰⁾ 출원서의 보정기간인 연장등록여부의 결정 등본 송달 전까지만 등록되면 될 것이다.

③ 연장기간

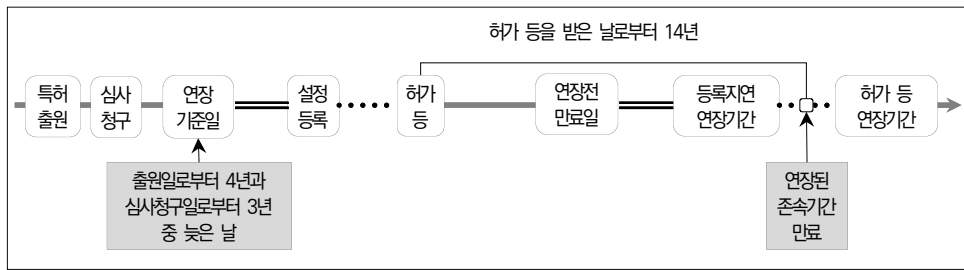
1) 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간으로서 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 연장할 수 있다(法 89①, 91Ⅲ). 연장기간을 5년 이내로 하는 것은 특정발명을 지나치게 장기간 보호함으로써 산업발전에 방해가 되지 않도록 하기 위함이다. 「그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간」은 특허권 설정등록일 이후의 기간으로서 시험기간과 관할관청의 허가신청 관련서류의 검토기간을 합산한 기간이다. 다만 허가 등을 받은 자에게 책임 있는 사유로 인해 소요된 기간은 그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간에 포함되지 아니한다(法 89②).²¹⁾²²⁾ 「특허발명」이란 특허를 받은 발명을 말하는 것이기 때문에(法 2Ⅱ) 특허를 받기 이전부터 허가 등으로 인해 실시하지 못하였더라도 그 부분은 「그 특허발명을 실시할 수 없었던 기간」에 포함되지 아니하고, 설정등록일 이후의 기간만을 고려한다.

2) 다만, 허가 등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장할 수 없다(法 89①단서, 91Ⅲ). 개정법(법률 제20700호)에서는 i) 일부 의약품 등의 경우 특허권 존속기간이 상대적으로 길어서 제네릭 의약품 등의 출시가 지연됨에 따라 국민들의 입장에서 저렴한 의약품 등의 조기 이용에 차질이 발생할 수 있고, 영세한 국내 후발 의약품 등의 제조기업의 성장을 저해할 수 있다는 점, ii) 미국, 유럽 등에서도 허가 등을 받은 날로부터 14년 또는 15년의 상한을 두고 있다는 점을 고려하여 허가 등을 받은 날부터 14년의 상한 설정에 관한 내용을 신설하였다. 한편 허가 등에 따른 존속기간의 연장과 등록지연에 따른 존속기간의 연장(法 92의5②)이 모두 있는 경우 14년의 상한 설정을 함에 있어서 등록지연에 따라 연장된 존속기간이 포함된다(法 89①괄호).

20) 대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후844, 851, 868, 875.

21) 특허권의 존속기간의 연장제도 운용에 관한 규정(지식재산보호법 제2019-3호) 제4조.

22) 식품의약품안전처 내 어느 심사부서에서 보완요구가 이루어지고 그 결과 보완자료를 제출할 때까지 그 보완요구 사항에 대한 심사가 진행되지 못하였다 하더라도, 그 동안 식품의약품안전처의 다른 심사부서에서 그 의약품의 제조판매·수입품목 허가를 위한 심사 등의 절차가 계속 진행되고 있었던 경우에는 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위하여 소요된 기간으로 볼 수 있으므로, 이를 가지고 허가 등을 받은 자의 귀책사유로 인하여 허가 등의 절차가 지연된 기간이라고 단정할 수 없다(대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후844, 851, 868, 875).



【그림 6-3】 허가 등을 받은 날로부터 14년의 상한 설정의 예시

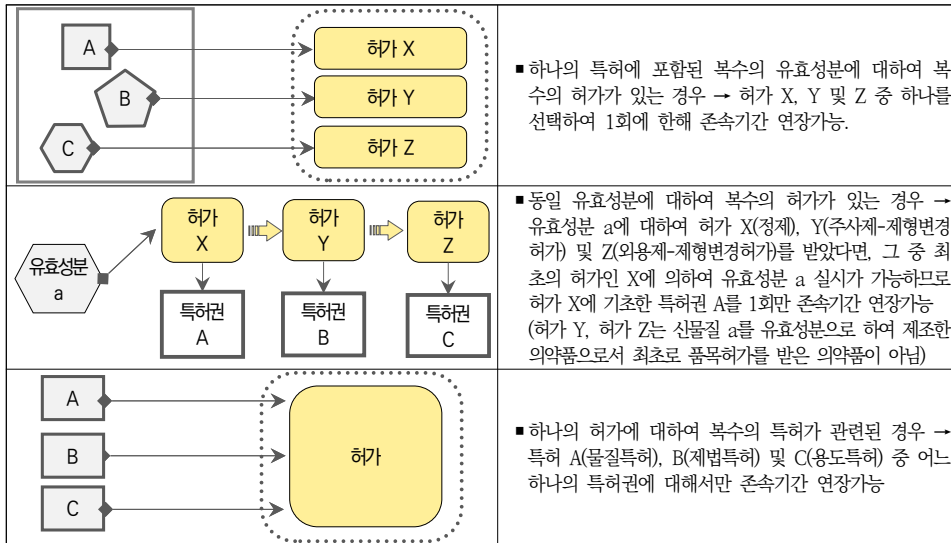
④ 연장횟수

1) 존속기간 연장은 한 차례만 할 수 있다(法 89①). 구체적으로 i) 하나의 특허에 대한 허가 등에 따른 존속기간연장은 1회에 한하고, ii) 복수의 허가 등이 있는 경우에는 그 중 최초의 허가 등에 의한 것만 연장등록이 인정된다.²³⁾

2) 특허 기종에는 하나의 허가 등에 둘 이상의 특허권이 있는 경우에 특허권 모두 그 존속기간의 연장등록을 개별적으로 할 수 있는 것으로 운영하였으나²⁴⁾, 개정법(법률 제20700호)에서는 하나의 허가 하나의 연장등록출원에 관한 규정(法 90⑦⑧)을 신설함으로써 과도한 존속기간 연장을 방지하고 있다. 구체적으로 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권이 있는 경우에는 연장등록출원인은 그 중 하나의 특허권에 대해서만 존속기간의 연장등록출원을 하여야 하고, 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원이 있는 경우에는 어느 특허권의 존속기간도 연장할 수 없다(法 90⑦, 91Ⅵ). 다만 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 i) 포기, 무효 또는 취하된 경우, ii) 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우 그 출원은 제7항을 적용할 때는 처음부터 없었던 것으로 본다(法 90⑧). 즉 이와 같은 사유가 발생한 경우 연장등록출원의 지위를 상실하기 때문에 다른 연장등록출원에 의한 존속기간의 연장이 인정될 수 있다.

23) 특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정(지식재산처고시 제2019-3호) 제3조제1항, 제3항.

24) 특허권의존속기간의연장제도운용에관한규정(지식재산처고시 제2019-3호) 제3조제2항.



【그림 6-4】 허가 등과 연장횟수

(3) 시기적 요건

① 연장등록 당시 특허권이 유효할 것

특허권은 연장등록 당시 유효한 것이어야 하며, 그 특허권이 취소, 무효로 되거나 특허료의 불납으로 인해 소멸된 경우에는 존속기간연장등록출원이 인정되지 아니한다. 지식재산처장은 존속기간연장등록출원 당시 또는 출원 이후 특허권이 소멸되었다면 소명기회를 부여한 후 그 연장등록출원서를 반려한다.

② 허가 등을 받은 날로부터 3개월 이내 및 존속기간만료 6개월 이전에 출원할 것

허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 허가 등을 받은 날로부터 3개월 이내 및 존속기간의 만료 6개월 이전에 출원하여야 한다(法 90②). 기간을 지나서 존속기간의 연장등록출원을 하면 부적법한 출원에 해당하여 출원서류가 반려된다(施規 11). 존속기간의 만료 직전 돌연 존속기간이 연장된다면 만료를 예상하고 특허발명의 실시를 준비하고 있던 제3자에게 불측의 손해를 입힐 수 있으므로, 적어도 특허권 존속기간의 만료 전 6개월 이후에는 존속기간연장등록출원을 할 수 없도록 하고 있다.

3. 절 차

(1) 연장등록출원서의 제출

연장등록출원인은 다음의 사항을 적은 출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 90①).

- i) 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

- ii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
- iii) 연장등록 특허권의 특허번호 및 연장대상청구범위의 표시
- iv) 연장신청의 기간
- v) 제89조제1항에 따른 허가 등의 내용
- vi) 총리령으로 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)

(2) 연장등록출원의 효과

① 존속기간의 연장 간주

허가 등에 따른 존속기간의 연장등록출원이 있으면 그 존속기간은 연장된 것으로 본다. 다만 그 출원에 대하여 제91조의 연장등록거절결정이 확정된 경우에는 그러하지 아니하다(法 90④). 존속기간의 남은 기간이 근소한 경우 연장등록출원 계속 중 연장등록 전에 존속기간이 만료되는 불합리한 사태가 생길 수 있으므로 연장등록출원이 되면 일단 그 존속기간은 연장된 것으로 간주한다.

② 특허공보에 게재

지식재산처장은 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 있으면 연장등록 출원서에 적혀 있는 사항을 특허공보에 게재하여야 한다(法 90⑤).

(3) 연장등록출원서의 보정

① 시 기

연장등록출원인은 지식재산처장이 연장등록여부결정등본을 송달하기 전까지 보정할 수 있다. 다만 심사관으로부터 거절이유(法 91)에 해당한다는 이유로 거절이유통지를 받은 후에는 해당 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다(法 90⑥단서). 이는 심사관이 출원서에 의해 실체심사를 진행하는데, 출원서의 보정으로 인해 심사 대상이 변경되어 심사가 지연되는 것을 방지하기 위함이다.

② 대 상

연장등록출원인은 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 i) 연장대상 청구범위의 표시, ii) 연장신청의 기간, iii) 제89조의 허가 등의 내용, iv) 총리령으로 정하는 연장이유 등 절차적 사항에 대하여 보정할 수 있다(法 90⑥본문). 다만 절차보정이라도 i) 연장등록출원인의 보정, ii) 연장대상 특허권의 특허번호 변경 등은 오기를 바로잡는 보정과 같이 자명한 사항이 아닌 경우 요지를 변경하는 보정이므로 허용되지 아니한다.

(4) 연장등록출원의 심사

① 연장등록거절결정 및 불복

1) 심사관은 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다(法 91).

- i) 그 특허발명의 실시가 제89조제1항에 따른 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 아니하는 경우

- ii) 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권이나 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조 제1항에 따른 허가 등을 받지 아니한 경우
 - iii) 연장신청의 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하는 경우
 - iv) 연장등록출원인이 해당 특허권자가 아닌 경우
 - v) 특허권이 공유인데 공유자 모두가 연장등록출원을 하지 아니한 경우
 - vi) 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 존속기간의 연장등록출원을 한 경우
- 2) 연장등록거절결정을 받은 자는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 불복심판을 청구할 수 있다(法 132의17).

② 등록결정 및 특허공보게재

심사관은 허가 등에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없을 때에는 연장등록결정을 하여야 한다. 지식재산처장은 연장등록결정을 한 경우에는 특허권 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하고 다음의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다(法 92).

- i) 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- ii) 특허번호
- iii) 연장등록의 연월일
- iv) 연장기간
- v) 제89조제1항에 따른 허가 등의 내용

③ 심사·심판 절차의 준용

1) 연장등록출원이 있는 경우 지식재산처장은 심사관에게 연장등록출원을 심사하게 한다(法 93 준용 57①). 이때 심사관은 심판관의 제척·기피 사유 중 전심판여를 제외하고 제척사유를 준용한다(法 93 준용 148 I-V, VII). 한편 심사관은 연장등록출원의 거절이유가 발견된 경우 거절결정하기 전에 출원인에게 거절이유통지를 하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 93 준용 63). 연장등록출원에 대한 등록결정 및 거절결정은 서면으로 이유를 붙여서 하여야 하며, 지식재산처장은 등록결정 또는 거절결정이 있는 경우 그 결정의 등본을 존속기간연장등록출원인에게 송달하여야 한다(法 93 준용 67). 허가 등에 따른 연장등록출원의 심사에 필요한 경우에는 제92조의4 및 제92조의5에 의한 등록지연에 따른 연장등록거절결정 또는 연장등록결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 허가 등에 따른 연장등록출원 심사 절차를 중지할 수 있다.²⁵⁾ 허가 등에 따른 연장등록출원의 심사절차의 중지에 대해서는 불복할 수 없다(法 93 준용 78①③).

2) 다만 존속기간연장등록출원절차에는 성격상 심사청구제도, 출원공개제도 및 정보제공제도는 준용되지 아니한다.

25) 이는 허가 등에 따른 존속기간의 연장등록출원에 대한 심사 시 허가 등을 받은 날로부터 14년을 초과하였는지 판단할 때 등록지연에 따른 존속기간의 연장이 있으면 그 기간도 포함하여 계산하여야 하기 때문이다.

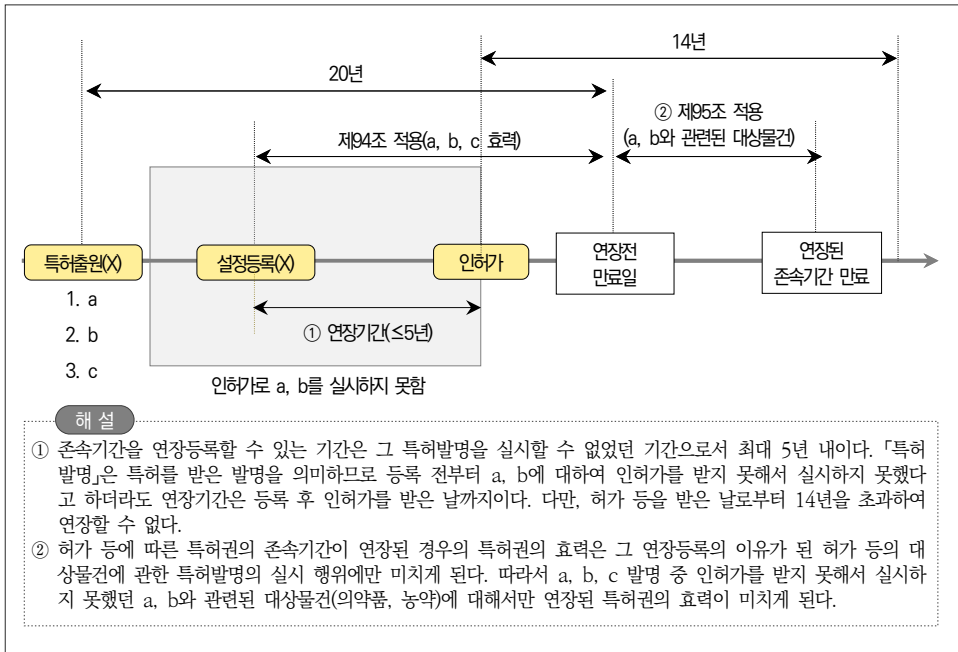
4. 연장된 특허권의 효력

1) 제90조제4항에 따른 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정해져 있는 경우에는 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다(法 95). 즉 특허발명을 실시하기 위하여 허가 등을 받을 필요가 없었다면 존속기간 동안 충분히 실시할 수 있었기 때문에 허가 등의 대상물건에 대한 특허발명의 실시에 대해서만 특허권의 효력이 연장된 것으로 본다.

2) 여기서 문제가 되는 것은 “대상물건”의 해석이다. 이와 관련하여서는 i) 품목허가를 받은 의약품 그 자체에만 효력이 미친다는 제품설, ii) 품목허가를 받은 의약품 주성분의 실시에만 효력이 미친다는 주성분설, iii) 품목허가를 받은 의약품의 유효성분의 유리형태 및 그 유효성분의 염과 에스테르의 실시에도 효력이 미친다는 유효성분설 등이 있다. i) 유효성분은 명세서와 허가 또는 등록정보에 모두 개시되지만 의약품이나 농약, 원제는 허가 또는 등록정보에만 개시되는 것이고, 명세서에는 개시되지 않는다는 점(제품설의 문제점), ii) 대상물건이 유효성분 외의 다른 보조성분도 모두 포함하는 의약품, 농약, 원제 그 자체라면 제3자가 유효성분의 함량, 제형 등만을 변경하여 제조, 판매하더라도 존속기간이 연장된 특허권을 침해하지 않게 된다는 점(주성분설의 문제점) 등을 고려하였을 때 대상물건은 유효성분으로 해석해야 한다.²⁶⁾ 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245789 판결에서도 “특허법은 이와 같이 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았다. 이러한 법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다. 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품(이하 ‘침해제품’이라 한다)이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 i) 통상의 기술자라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, ii) 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다”라고 하여 ‘품목’이 아닌 ‘유효성분, 치료효과, 용도’가 동일한지 여부를 그 기준으로 제시하였다.²⁷⁾ 다만 대상판결은 효력범위가 과도하게 확대되지 않도록 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 i) 통상의 기술자가 쉽게 선택할 수 있는 정도인지 여부, ii) 유효성분의 약리작용에 나타난 효과가 실질적으로 동일한지 여부를 통해 효력범위를 제한할 여지를 남겨 두고 있다.²⁸⁾²⁹⁾

26) 강춘원, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 1067-1071면 참조.

27) 이에 대한 하급심 판결(특허법원 2017. 6. 30. 선고 2016나1929)에서는 “존속기간이 연장된 특허권의 효력은 위 제조·수입품목 허가사항에 의하여 특정된 의약품뿐만 아니라 실질적으로 동일한 품목으로 취급되어 하나의 제조·수입품목 허가를 받을 수 있도록 규정된 의약품 또는 이미 의약품 제조·수입품목 허가를 받은 의약품과 실질적으로 동일하여 별도로 의약품 제조·수입품목 허가를 받을 필요가 없는 의약품 등에도 미친다고 보아야 할 것이다”라고 하여 제품설을 지지하였다.



【그림 6-5】 허가 등에 따른 특허권의 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력

Ⅲ. 등록지연에 따른 특허권의 존속기간연장등록제도

1. 의의 및 취지

(1) 의의

「등록지연에 따른 특허권의 존속기간연장등록제도」란 특허출원에 대하여 특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있는 제도를 말한다(法 92의2①).

(2) 취지

기존에는 심사처리기간 지연 등으로 특허권 설정등록이 늦어지면 특허권의 존속기간이 짧아지게 되는 불합리한 점이 있었다. 따라서 2012. 3. 15. 시행된 현행법(법률 제11117호,

- 28) 손천우, 특허권의 존속기간 연장등록의 요건과 연장된 특허권의 효력범위 -대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245798 판결을 중심으로-, 사법 47호, 2019 봄호, 사법발전재단, 395면
29) 한편 강춘원, “존속기간이 연장된 특허권의 효력범위 -특허법 제95조의 새로운 해석론-”, 지식재산연구 제14권 제4호, 2019년 12월, 한국지식재산연구원, 1-40면에서는 존속기간이 연장되기 전 특허발명의 권리범위도 함께 고려하여 해석하여야 한다는 해석론을 제시하고 있다.

2011. 12. 2. 개정)에서는 i) 심사처리기간 등에 따라 달라지는 존속기간을 합리적으로 조정해 줌으로써 특허권자의 권리행사 기간을 충실히 보장하는 한편 ii) 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환」을 국내법에 반영하기 위해서 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장에 관한 규정(法 92의2-92의5)을 신설하였다.³⁰⁾

2. 요건

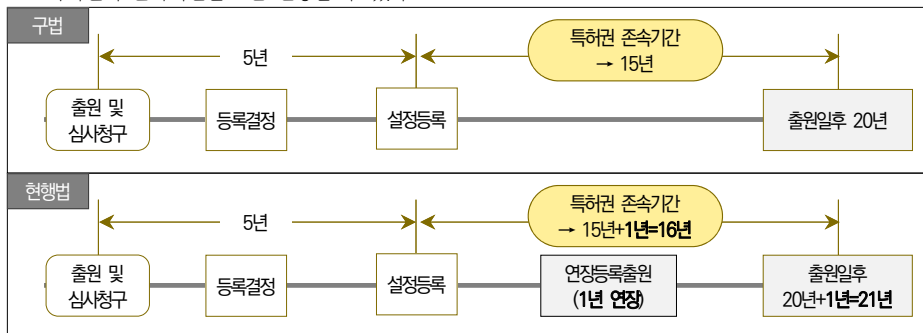
(1) 주체적 요건

존속기간연장등록출원은 특허권자만이 할 수 있으며(法 92의4Ⅱ), 특허권이 공유인 경우에는 모두가 공동으로 출원하여야 한다(法 92의3③, 92의4Ⅲ). 한편 임의대리인은 연장등록출원의 취하와 달리 특별히 권한을 위임받지 않더라도 존속기간 연장등록출원을 할 수 있다(法 6).

(2) 객체적 요건

1) 특허출원에 대하여 특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날(이하 “연장기준일”이라 한다)보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에 그 지연된 기간(연장기준일로부터 설정등록일까지의 기간)이어야 한다(法 92의2①, 92의4Ⅰ). 여기서 특허출원일로부터 4년을 기산할 때에는 i) 제34조 또는 제35조에 따른 정당한 권리자의 특허출원의 경우에는 정당한 권리자가 출원을 한 날, ii) 제52조에 따른 분할출원의 경우에는 분할출원을 한 날, iii) 제52조의2에 따른 분리출원의 경우에는 분리출원을 한 날, iv) 제53조에 따른 변경출원의 경우에는 변경출원을 한 날, v) 제199조제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 제203조제1항 각호의 사항을 적은 서면을 제출한 날, vi) 제214조에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 국제출원의 출원인이 제214조제1항에 따라 결정을 신청한 날, vii) 제1호부터 제5호까지의 규정 중 어느 하나에 해당되지 아니하는 특허출원에 대해서는 그 특허출원일에 해당하는 날을 특허출원일로 본다(法 92의2④). 출원인의 늑장으로 인한 등록지연을 보상해 주는 것은 부당하기 때문이다.

30) 예를 들어 아래의 그림의 경우 출원일로부터 4년보다 설정등록이 1년 지연되었으므로 현행법에 의하면 특허권의 존속기간을 1년 연장할 수 있다.



2) 다만, 대통령령으로 정하는 출원인으로 인하여 지연된 기간³¹⁾은 특허권의 존속기간의 연장에서 제외된다. 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 특허권의 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과하여서는 아니 된다(法 92의2②③). 결국 연장기간은 [연장기준일로부터 설정등록일까지의 기간 - 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간]이다.

(3) 시기적 요건

등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 특허권의 설정등록일로부터 3개월 이내에 출원하여야 한다(法 92의3②). 한편 기간을 지나서 존속기간 연장등록출원을 하면 부법칙출원에 해당하여 출원서류가 반려된다(施規 11).

3. 절 차

(1) 연장등록출원서의 제출

연장등록출원인은 다음의 사항을 적은 출원서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 92의3①).

- i) 연장등록출원인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- ii) 연장등록출원인의 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
- iii) 연장대상 특허권의 특허번호
- iv) 연장신청의 기간
- v) 총리령으로 정하는 연장이유(이를 증명할 수 있는 자료를 첨부하여야 한다)

(2) 연장등록출원서의 보정

① 시 기

연장등록출원인은 심사관이 특허권 존속기간의 연장등록 여부결정 전까지 보정할 수 있다.³²⁾ 다만 심사관으로부터 거절이유(法 92의4)에 해당한다는 이유로 거절이유통지를 받은 후에는 그 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간에만 보정할 수 있다(法 92의3④단서).

② 대 상

연장등록출원인은 연장등록출원서에 적혀 있는 사항 중 i) 연장신청의 기간, ii) 총리령으로 정하는 연장이유 등 절차적 사항에 대하여 보정할 수 있다(法 92의3④본문). 다만 절차보정이

31) 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도(法 89②)와 달리 출원인의 귀책사유 여부를 묻지 않고 출원인으로 인하여 발생한 모든 지연기간에 대해 연장기간이 감축되도록 하고 있다. 한편 논란의 여지를 없애기 위해 시행령 제7조의2, 시행규칙 제54조의5에서 출원인으로 인하여 지연된 기간을 제한없이 규정하고 있다.

32) 私見으로는, 출원인이 연장등록 여부결정이 있는지를 알 수 없으므로 출원인의 대응기회부여를 고려하면 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도(法 90⑥)와 같이 연장등록결정등본을 송달하기 전까지 보정할 수 있도록 함이 적절하다고 생각된다.

라도 i) 연장등록출원인의 보정, ii) 연장대상 특허권의 특허번호 변경 등은 오기를 바로잡는 보정과 같이 자명한 사항이 아닌 경우 요지를 변경하는 보정이므로 허용되지 아니한다.

(3) 연장등록출원의 심사

① 연장등록거절결정 및 불복

1) 심사관은 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 다음에 해당하는 경우에는 그 출원에 대하여 연장등록거절결정을 하여야 한다(法 92의4).

i) 연장신청의 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우

ii) 연장등록출원인이 그 특허권자가 아닌 경우

iii) 특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 연장등록출원을 하지 아니한 경우

2) 연장등록거절결정을 받은 자는 그 결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 불복심판을 청구할 수 있다(法 132의17).

② 등록결정 및 특허공보게재

심사관은 등록지연에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 연장등록결정을 하여야 한다. 지식재산처장은 연장등록결정이 있으면 특허권의 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하고 다음의 사항을 특허공보에 게재하여야 한다(法 92의5).

i) 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

ii) 특허번호

iii) 연장등록 연월일

iv) 연장 기간

③ 심사·심판 절차의 준용

1) 연장등록출원이 있는 경우 지식재산처장은 심사관에게 연장등록출원을 심사하게 한다(法 93 준용 57①). 이때 심사관은 심판관의 제척·기피 사유 중 전심관여를 제외하고 제척사유를 준용한다(法 93 준용 148 I-V, VII). 한편 심사관은 연장등록출원의 거절이유가 발견된 경우 거절결정하기 전에 출원인에게 거절이유통지를 하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 93 준용 63). 연장등록출원에 대한 등록결정 및 거절결정은 서면으로 이유를 붙여서 하여야 하며, 지식재산처장은 등록결정 또는 거절결정이 있는 경우 그 결정의 등본을 존속기간연장등록출원인에게 송달하여야 한다(法 93 준용 67). 허가 등에 따른 연장등록출원의 심사에 필요한 경우에는 제92조의4 및 제92조의5에 의한 등록지연에 따른 연장등록거절결정 또는 연장등록결정이나 심결이 확정될 때까지 또는 소송절차가 완결될 때까지 허가 등에 따른 연장등록출원 심사 절차를 중지할 수 있다. 허가 등에 따른 연장등록출원의 심사절차의 중지에 대해서는 불복할 수 없다(法 93 준용 78①③).³³⁾

2) 다만 존속기간연장등록출원절차에는 성격상 심사청구제도, 출원공개제도 및 정보제공제도는 준용되지 아니한다.

33) 특허출원과 존속기간연장등록출원의 주요 차이점을 살펴보면 다음과 같다.

4. 연장된 특허권의 효력

등록지연에 따른 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 제94조제1항의 적용을 받는다. 즉 특허권자는 연장된 존속기간 동안 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(法 94①).

제 도		특허출원	존속기간연장등록출원
의의		지식재산체에 대하여 특허를 하여해 달라는 의사표시	지식재산체에 대하여 특허권의 존속기간을 연장해 달라는 의사표시
요건		제62조의 거절이유에 해당하지 아니하여야 함	제91조, 제92조의4의 거절이유에 해당하지 아니하여야 함
절차	제출서류	특허출원서, 명세서, 필요한 도면 및 요약서	연장등록출원서
	출원서의 보정	1. 원칙: 특허출원 계속 중 2. 예외: 지식재산처장이 보정명령을 한 경우 그 보정기간 내	1. 원칙: - 허가 등에 따른 존속기간의 연장: 지식재산처장이 연장등록여부결정등본송달전 - 등록지연에 따른 존속기간의 연장: 심사관이 연장등록여부결정전 2. 예외: 지식재산처장이 보정명령을 한 경우 그 보정기간 내 또는 심사관이 거절이유 통지하는 경우 의견서 제출기간
	명세서 또는 도면의 보정	제47조제1항의 시기에 가능	불가능(정정청구 또는 정정심판청구에 의함)
	실체심사의 대상	청구범위를 기준으로 명세서 또는 도면을 참작하여 심사	연장등록출원서에 적혀 있는 사항을 기준으로 심사
	심사청구, 출원공개, 정보제공	존재	부존재
	효과	특허권의 존속기간만큼 효력이 발생하며, 제94조제1항에 의하여 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점함	1. 허가 등에 따른 존속기간의 연장: 특허권의 존속기간 이외에 최대 5년 이내(허가 등을 받은 날부터 14년 초과금지)에서 효력이 연장되며, 제95조에 의하여 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건이 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시외의 행위에는 미치지 아니함 2. 등록지연에 따른 존속기간의 연장: 좌동

【표 6-3】 허가 등과 등록지연에 따른 존속기간연장등록제도의 비교

제 도		허가 등에 따른 존속기간연장등록제도	등록지연에 따른 존속기간연장등록제도
서	의 의	특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 의한 등록지연에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한 다)을 한 차례만 연장(단, 허가등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장 불가)할 수 있는 제도를 말한다(法 89).	특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있는 제도를 말한다(法 92의2①).
	취 지	설정등록 후에도 실시할 수 없었던 특허권자의 불이익을 해소	심사처리기간 등에 따라 달라지는 존속기간을 합리적으로 조정
요 건	주체적	특허권자, 공유인 경우에는 전원	
	객체적	1. 허가 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 장기간이 소요되는 대통령령이 정하는 발명일 것(약사법에 의하여 허가를 받아야 하는 의약품, 마약류 관리에 관한 법률에 따라 품목허가를 받은 마약/향정신성의약품, 농약관리법에 의하여 등록을 받아야 하는 농약/원제) 2. 실시를 위하여 허가 등을 받을 것 3. 특허발명을 실시할 수 없었던 기간(단, 허가 등을 받은 자의 책임있는 사유로 소요된 기간은 제외)으로서 5년까지 존속기간(등록지연에 따라 연장등록된 경우 그 날까지) 연장 가능. 단, 허가 등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장 불가 4. 1차례만 연장가능(하나의 허가 등에 둘 이상의 특허권이 있는 경우 하나의 특허권만 연장등록출원 가능)	특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에 그 지연된 기간일 것(단, 출원인으로 인해 실제 지연된 기간은 제외)
	시기적	1. 연장등록 당시 특허권이 유효할 것 2. 허가 등을 받은 날로부터 3개월 이내 및 존속기간만료 6개월 이전에 출원할 것(위반시 불수리)	특허권의 설정등록일부터 3개월 이내 출원할 것(위반시 불수리)
절 차		1. 연장등록출원서의 제출(연장대상청구범위의 표시) 2. 연장등록출원서의 보정 - (시기) 연장등록여부결정의 등본송달전(단, 심사관이 거절이유통지한 경우 의견서제출기간) - (대상) 출원인, 특허번호 변경 보정 불가 3. 연장등록출원의 효과 - 존속기간연장간(단, 거절결정이 확정된 경우 제외) - 특허공보에 게재 4. 거절결정 - (주체) 특허권자가 출원하지 않은 경우 - (주체) 공유인대 모두가 출원하지 않은 경우 - (객체) 허가 등을 받을 필요성이 없는 경우 - (객체) 특허권자, 전용실시권, 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받지 않은 경우 - (객체) 연장기간을 초과한 경우 - (객체) 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권에 대한 연장등록출원을 한 경우 5. 등록결정 및 특허공보게재	1. 연장등록출원서의 제출 2. 연장등록출원서의 보정 - (시기) 연장등록여부결정전(단, 심사관이 거절이유통지한 경우 의견서제출기간) - (대상) 출원인, 특허번호 변경 보정 불가 3. 거절결정 - (주체) 특허권자가 출원하지 않은 경우 - (주체) 공유인대 모두가 출원하지 않은 경우 - (객체) 연장기간을 초과한 경우 4. 등록결정 및 특허공보게재
		심사·심판절차의 준용 - 제57조제1항, 제63조, 제67조, 제78조제1항, 제3항 및 제148조제1호부터 제5호 및 제7호 준용	
효 과		그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정해져 있는 경우에는 있어서는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다(法 95).	특허권자는 연장된 존속기간 동안 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(法 94①).

제2절 효력이 미치는 범위 및 효력의 구체적인 내용

제1관 효력이 미치는 범위

I. 시간적 범위

특허권의 존속기간은 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다(法 88①). 한편 i) 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 의한 등록지연에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장(단, 허가 등을 받은 날부터 14년을 초과하여 연장 불가)하거나, ii) 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다. 이에 대한 구체적인 내용은 「제6편 제3항 제1절 특허권의 존속기간과 존속기간연장등록제도」에서 설명한 바와 같다. 그러나 존속기간 내라도 특허료의 불납, 특허권의 포기, 무효심결의 확정 등으로 특허권이 소멸할 수 있다.

II. 내용적 범위

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(法 97). 즉 등록 후에는 청구범위가 권리서로서 역할을 한다. 구체적인 내용은 「제6편 제3장 제3절 특허발명의 보호범위」에서 후술한다.

III. 지역적 범위

1. 속지주의의 원칙

특허권의 효력은 속지주의 원칙에 따라 우리나라에만 미친다. 우리나라 내에 있는 자에 대해서는 내·외국인을 불문하고 특허권의 효력이 미친다. 파리조약 제4조의2에서는 “동맹국의 국민이 각 동맹국에서 출원한 특허는 동맹국 또는 비동맹국과 관계없이 동일한 발명에 대하여 타국에서 취득한 특허로부터 독립한다”라고 규정하여 특허독립의 원칙을 천명하고 있고, 이에 따라 독립적으로 취득한 특허권은 그 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 있는 것으로 인정되는데 이를 속지주의라고 한다.

2. 역외적용의 원칙 적용 여부

1) 특정국가의 법이 자국의 영토 밖에서 발생한 행위에 대하여 효력을 갖는다는 것을 역외적용의 원칙(principle of extraterritoriality)이라고 하는데, 이는 자국 영토 밖의 영토를 보유하는 타국의 자주권과 특허법을 무시할 수 있다는 우려가 있다. 따라서 자국법과 타국법이 충돌할 때 발생할 수 있는 국제적 불화를 피하고, 타국의 영토에서 자주권 행사를 존중한다는 국제적 신의는 지켜져야 하므로, 역외적용의 원칙은 일반적으로 배제되어야 함이 타당하다. 그러나 다국적 기업의 영업행위가 국제적으로 이루어지면서 우리나라의 영토 밖에서 이루어진 행위가 우리나라의 시장에 영향을 미치는 경우에 이를 규제할 필요성이 대두되고 있으며, 최근 대법원은 특허법상 특허침해의 역외적용과 관련하여 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결과 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 222799(병합) 판결을 선고하였다.

2) 2014다42110 판결에서 대법원은 “간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다”라는 법리를 실시하였다. 2014다42110 판결은 당해 특허발명의 주요 구성을 갖춘 반제품이 국내에서 생산되어 수출된 후 외국에서 완성품으로 생산된 사건에서, 완성품이 국내에서 생산되지 않았다는 이유로 제127조가 규정하는 「간접침해」를 인정하지 않았다.³⁴⁾ 2014다42110 판결은 국내에서 등록된 특허권의 간접침해가 인정되려면 반제품에 대한 완성품이 반드시 국내에서 생산되어야 한다고 판단함으로써, 속지주의 원칙을 엄격하게 적용한 판결이라고 평가할 수 있다.³⁵⁾ 그러나 다국적 기업과 국제거래가 점차적으로 증가하고 있는 현대 세계경제를 고려하면, 이 판결과 같이 특허침해를 판단하면서 속지주의 원칙을 지나치게 고수하는 것은 특허권자의 보호에 미흡할 수 있다는 비판이 제기되었다.³⁶⁾

3) 2014다42110 판결이 선고되고 약 4년 후, 2019다222782 판결에서 대법원은 “특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산, 사용, 양도, 대여, 수출 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 것이 원칙이다. 그러나 i) 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고,

34) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970에서도 동일한 취지로 판결하였다.

35) 문선영, “특허권 공동침해 관련 최근 법적 쟁점에 대한 연구”, 『아주법학』제10권 제2호, 2016, 아주대학교 법학연구소, 139면.

36) 신혜은, “특허권의 간접침해와 국제거래에서의 시사점”, 『과학기술과 법』제7권 제1호, 2016, 충북대학교 법학연구소, 62면.

ii) 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공 조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, iii) 그와 같은 가공 조립이 극히 사소하거나 간단하여 iv) 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다”라고 하여 반제품의 생산이라고 할지라도 완제품인 특허발명이 생산된 것과 같이 볼 수 있다면 반제품을 생산 및 수출하는 행위에 대해 구성요소완비의 원칙을 적용할 수 있으므로 직접침해라고 판시하면서 속지주의 원칙의 예외를 인정하여 특허권자의 실질적인 보호를 추구하고 있다. 나아가 2019다222782 판결은 제한적인 요건 하에 우리 특허법상 직접침해 법리와 간접침해 규정이 역외적인 효력을 가질 수 있다는 법리를 채택함으로써, 속지주의 원칙에 내재되어 있는 「타국의 자주권과 특허법의 존중」과 「국제적인 신의의 존중」이라는 가치를 준수하려고 하였다는 점에서 의의가 있다.³⁷⁾ 물론 이러한 경우에 해당하는지는 속지주의 원칙과 구성요소 완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.³⁸⁾

제2관 효력의 구체적인 내용

제2조 [정의]

이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. <개정 2019. 12. 10., 2025. 1. 21.>

1. “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.
2. “특허발명”이란 특허를 받은 발명을 말한다.
3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.
 - 가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위
 - 나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위
 - 다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

제94조 [특허권의 효력]

- ① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다. 다만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 제100조제2항에 따라 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다. <개정 2019. 12. 10.>
- ② 특허발명의 실시가 제2조제3호나목에 따른 방법의 사용을 청약하는 행위인 경우 특허권의 효력은 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 미친다. <신설 2019. 12. 10.>

[전문개정 2014.6.11.]

37) 이주환, “특허침해의 역외적용에 대한 우리 대법원의 태도 - 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782 판결을 중심으로 -”, 「선진상사법률연구」 통권 제94호, 2021.4, 특허법원 국제 지식재산권법 연구센터, 192-194, 218면 참조.

38) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970.

제95조 【허가 등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력】

제90조제4항에 따라 특허권의 존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다.

[전문개정 2014.6.11.]

제96조 【특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위】

- ① 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항에는 미치지 아니한다.
 1. 연구 또는 시험(「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시
 2. 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치, 그 밖의 물건
 3. 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건
- ② 둘 이상의 의약(사람의 질병의 진단·경감·치료·처치(處置) 또는 예방을 위하여 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다)이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 「약사법」에 따른 조제행위와 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 의 의

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(法 94①). 또한 허가 등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건(그 허가 등에 있어 물건에 대하여 특정의 용도가 정하여져 있는 경우에는 그 용도에 사용되는 물건)에 관한 그 특허발명의 실시 행위에만 미친다(法 95). 허가 등에 따른 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력(法 95)은 상술하였으므로 이하에서는 제94조제1항의 특허권의 효력에 대하여 구체적으로 살펴본다.

II. 「업」으로서 「특허발명」의 「독점적」 실시

1. 「업」으로서 실시

1) 업으로서의 의미에 대해서 여러 가지 학설³⁹⁾이 있지만, 산업발전의 이바지라는 특허법의 목적에 비추어 단순히 개인적 또는 가정적인 실시를 제외하는 의미로만 해석하는 것이 다수설이다. 정당한 권원 없는 자의 실시라 할지라도 그것이 업으로서 실시가 아닌 개인적·가정적

39) i) 가정적, 개인적인 실시 이외의 것을 가리킨다는 설, ii) 널리 사업으로서 반복, 계속적인 실시를 말한다는 설, iii) 직·간접적으로 불특정인의 수요 또는 편의 제공을 목적으로 실시함을 의미한다는 설, iv) 계속적인 의사로 행하는 경제활동을 가리킨다는 설 등이 있다(中山信弘, 「註解 特許法」, 제2판, 青林書院, 1994, 312면).

실시일 경우에는 공정한 경쟁실시를 저해하지 않기 때문에 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 한편 「업」으로서의 실시에는 그 실시의 빈도와 규모, 영리·비영리 등은 문제가 되지 아니한다. 예컨대 특허발명인 세탁기를 세탁업자가 1회 사용하는 것은 업으로서의 실시이지만 가정주부가 가정에서 장기간 사용하더라도 업으로서의 실시가 아니다.

2) 다만 컴퓨터의 보급이 일반화되고 컴퓨터 관련 발명이 등장하면서 이러한 가정적, 개인적인 복제, 유포행위가 특허권자의 경제적 이익에 큰 영향을 끼치는 것이 가능하게 되었기 때문에 업으로서의 의미에 대한 검토가 필요할 것으로 여겨진다. 예를 들어 컴퓨터 관련 발명이나, 의약의 용도발명, 특허받은 전화기의 사용방법 등은 사실상 최종 수요자에 의하여 실시되는데 업으로서 실시가 아니기 때문에 직접적인 권리행사를 할 수 없다는 문제점이 있다.

2. 「특허발명」의 실시

「특허발명」이란 특허를 받은 발명을 말한다(法 2Ⅱ). 그러므로 설정등록된 이후 발명은 특허발명이다.

3. 「독점적」 실시

1) 특허권의 효력은 적극적 효력과 소극적 효력으로 구분된다. 적극적 효력이란 독점성에 기인한 효력으로서 특허권자만이 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리(專用權, 獨占權)를 말한다. 제94조제1항에서는 “특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다”라고 하여 적극적 효력의 근거가 되고 있다. 소극적 효력이란 배타성에 기인한 효력으로서 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로서 실시하면 이를 침해라고 하여 배제할 수 있는 권리(禁止權, 排他權)를 말한다. 특허권자는 침해자에 대하여 그 실시를 중지할 것을 청구할 수 있으며, 침해행위로 인하여 손해를 입었으면 손해배상청구 등의 각종 민·형사상의 제재를 할 수 있다. 특허법에서는 소극적 효력에 대하여 직접적으로 규정하고 있지 않으나, 적극적 효력인 독점성을 보장하기 위해서는 독점성을 침해하는 행위에 대해서 그 행위를 배제할 수 있는 배타성이 있어야 한다고 하여, 소극적 효력을 간접적으로 파악하고 있는 것이 일반적이다. 이러한 독점성과 배타성은 동전의 양면과 같다고 할 것이다.

2) 그러나 소극적 효력을 독점성의 반대급부로서 간접적으로 규정된 것으로 이해하는 경우 i) 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때 전용실시권자의 범위에서는 특허권자의 독점적 실시가 유보되어 있어(法 94①단서) 제3자가 무단으로 실시하더라도 특허권의 침해가 되지 않기 때문에 특허권자에게는 침해에 대한 소권이 인정되지 아니한다고 해석되는데, 이는 현재 실무상 인정되고 있는 특허권자의 침해금지청구권 및 손해배상청구권 등에 관한 소권⁴⁰⁾을 설명할 수 없고, ii) 소극적 효력이 적극적 효력에서 비롯되는데 소극적 효력의 범위가 적극적 효력의 범위와 상이하다는 문제점이 있다.⁴¹⁾ 또한 iii) 제94조제1항에 근거를 두고 있는

40) 서울민사지방법원 1991. 5. 8. 선고 90가합92251.

적극적 효력은 이용·저촉 관계에 있는 선출원 권리자의 허락을 받지 않고는 실시할 수 없다는 제98조의 규정에 의하여 상당히 제한되고 있음을 고려할 때 특허권 효력의 본질은 타인의 무단실시를 금지시킬 수 있는 소극적 효력에 있다고 보는 것이 타당하다.⁴²⁾ 따라서 특허권 효력의 본질에 대한 오해를 차단하기 위하여 특허권의 소극적 효력, 즉 침해에 대한 규정을 명시적으로 두는 것이 바람직할 것이다.⁴³⁾

III. 실 시

1. 의의 및 취지

「실시」란 발명을 그 발명의 내용에 따라 사용하는 것을 말하며, 특허법은 제2조제3호에서 특허법상 실시를 물건의 발명, 방법의 발명 및 물건을 생산하는 방법의 발명으로 분류하여 규정하고 있다. 무체재산권인 특허권은 사실상 점유가 불가능하고 침해의 형태가 다양하므로, 특허권에 의하여 독점이 되는 대상을 명확히 하기 위하여 특허법은 실시의 개념을 직접 규정하고 있다.⁴⁴⁾

2. 실시의 종류

(1) 물건발명

「물건발명」의 경우에는 그 물건을 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위를 말한다(法 2Ⅲ가).

(2) 방법발명

「방법발명」인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 말한다(法 2Ⅲ나).

(3) 물건을 생산하는 방법발명

「물건을 생산하는 방법발명」인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청

41) 간접침해의 경우에 특허권자는 간접침해의 대상이 되는 물건을 독점적으로 실시할 수는 없으나, 타인의 실시를 배제시킬 수는 있다(法 127).

42) 이용·저촉관계의 경우에 후출원 특허권자는 선출원 권리자의 동의를 받지 아니하고 자기의 특허발명을 실시할 수 없으나(法 98), 선출원 권리자 또는 제3자가 무단으로 자기의 특허발명을 실시하는 것은 금지시킬 수 있다(法 138③).

43) 참고로 미국특허법은 다음과 같이 명시적으로 특허침해를 정의하고 있다.

35 U.S.C 271 Infringement of patent: (a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent thereof, infringes the patent.

44) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 4면.

약하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다(法 2Ⅲ다).

3. 구체적인 내용

(1) 생 산

「생산」이란 특허발명의 구성요소를 충족하지 아니한 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 모든 구성요소를 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미하고, 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 포함된다.⁴⁵⁾ 생산행위는 반드시 완성행위일 것을 요구하는 것은 아니며 착수행위도 포함한다. 그러나 무형의 제작, 설계도의 작성과 같은 생산의 준비행위는 착수행위라고 할 수 없으므로 생산행위에 포함되지 아니한다. 한편 i) 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ii) 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, iii) 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 iv) 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 이 역시 생산된 것과 같이 보고 있다.⁴⁶⁾

(2) 사 용

「사용」이란 발명이 추구하는 본래의 목적을 달성하거나 작용·효과를 나타내도록 그 발명을 이용하는 것을 말한다. 그러나 특허된 내용과 목적, 효과가 다르게 사용되는 것은 특허법상 사용이라고 할 수 없다. 예컨대 특허제품인 경주용 오토바이를 실내장식용으로 사용한 경우는 특허법상 사용이라 할 수 없다.

(3) 양 도

「양도」란 생산된 특허제품의 소유권을 의사표시에 의하여 타인에게 유상 또는 무상으로 이전하는 것을 말한다. 이때 유상의 경우에는 판매가 되며, 무상의 경우에는 증여가 된다.

(4) 대 여

「대여」란 특허권자가 특허제품을 유상 또는 무상으로 일정한 시기에 반환할 것을 조건으로 타인에게 빌려주는 것을 말한다. 제3자가 특허제품을 구입 후 타인에게 대여하는 경우는 포함되지 않으며 유상의 경우에는 임대차, 무상인 경우에는 사용대차가 된다.

(5) 수 출

「수출」이란 국내에서 외국에 물건 등을 내보내는 것을 말한다. 기존에는 수출을 특허발명의 실시행위로 보지 않았으나⁴⁷⁾, 2025. 7. 22. 시행되는 개정법(법률 제20700호, 2025. 1. 21.

45) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356; 2015. 7. 23., 선고 2014다42110.

46) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합).

일부개정)에서는 i) 특허 침해 물품이 국경을 통해 확산하는 것을 방지하고 특허권자의 권리 보호를 강화할 필요가 있다는 점⁴⁸⁾, ii) 디자인보호법, 상표법에서 수출을 실시(사용)행위로 보고 있을 뿐만 아니라 독일, 일본 등에서도 수출을 실시행위로 보고 있어서 관련 법률, 외국 입법례와의 조화가 필요하다는 점을 고려하여 수출을 물건발명, 물건을 생산하는 방법발명의 실시행위에 포함하였다.⁴⁹⁾

(6) 수 입

「수입」이란 외국에서 국내에 물건 등을 들여오는 것을 말한다. 그러나 보세구역 내에 있는 동안은 아직 수입된 것으로 보지 아니한다.

(7) 양도·대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)

「양도·대여의 청약」이란 특허제품을 양도 또는 대여하기 위하여 계약을 성립시킬 것을 목적으로 하는 의사표시를 말한다. 이는 WTO/TRIPs 제28조에서 「offering for sale」도 특허의 실시행위로 규정하였기 때문에 이를 반영하기 위한 것이다. 구체적인 예로 카탈로그에 의한 권유, 팜플렛의 배포, 상품판매의 광고, 상품의 진열 등에 의해서 특허제품의 판매를 유도하는 행위를 말한다. 「전시」는 발명을 양도하거나 대여할 목적으로 불특정다수인이 인식할 수 있는 상태에 두는 것을 말하며, 양도나 대여의 목적이 아닌 단순한 전시는 특허법상 실시에 해당하지 아니한다.

(8) 방법 사용의 청약

기존에는 컴퓨터 프로그램을 기록매체(USB, CD 등)에 저장한 후 이를 복제하여 실시하였으나 현재는 대부분 온라인 전송을 통하여 복제한 후 실시하고 있는데, 기록매체에 저장된 컴퓨터 프로그램만을 특허법에서 보호함으로써 온라인 전송행위에 대해서는 권리행사를 할 수 없다는 문제점이 있었다. 이에 2020. 3. 11. 시행된 현행법(법률 제16804호, 2019. 12. 10. 개정)에서는 방법발명 실시의 정의에 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 추가하여, 온라인 전송행위를 방법발명 실시의 일 유형으로 포섭함으로써 특허권의 침해가 될 수 있도록 하였다(法 2Ⅲ나). 다만 소프트웨어 산업의 위축을 방지하기 위하여 그 방법의 사용이 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 그 방법의 사용을 청약하는 행위에만 특허권의 효력이 미치도록 제한하고 있다(法 94②). 따라서 방법의 사용을 청약하는 행위에는 제130조의 과실추정 규정이 적용되지 않으며, 특허권자로부터 침해 경고를 받은 이후에 실시를 중단하면 특허권의 침해가 되지 않는다.

4. 문제가 되는 행위

특허제품의 단순한 소지행위·단순구입·보관행위는 특허법상 실시에 해당하지 않으므로 그 자체가 특허권의 침해라고 볼 수 없다. 그러나 소지자 또는 보관자가 물건을 양도 또는 대여할

47) 서울고등법원 2017. 8. 21.자 2015라20296 결정에서는 양도에 수출이 포함되지 않는다고 하였다.

48) 기존에는 특허법상 실시행위에 수출이 규정되어 있지 않아서 수출로 인한 문제가 발생한 경우 불공정무역조사법 및 관세법에 따라 침해 물품의 수출(수입) 행위를 금지할 수 있었으나 특허법상 침해금지청구, 손해배상청구를 할 수 없었다.

49) 박희석 수석전문위원, 「특허법 일부개정법률안 심사보고서(이철규 의원 대표 발의(의안번호 2204271))」, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2024.12. 6-8면.

목적으로 소지하는 것은 특허권을 침해할 개연성이 있으므로 특허권자는 침해예방에 필요한 조치를 취할 수 있다(法 126).

5. 실시행위의 독립성

1) 「실시행위의 독립성」이란 각각의 실시행위는 서로 독립적이므로 침해 여부 역시 각각 독립적으로 판단하여야 한다는 것을 말한다. 즉 제2조제3호에서 규정한 각각의 실시행위는 특허권의 효력상 독립적이며 어느 하나의 실시행위는 다른 실시행위에 영향을 미치지 아니하기 때문에 한 단계의 실시행위가 적법하다고 하여 다른 단계의 행위까지도 적법하게 되는 것은 아니다.

2) 예컨대 甲이 위법하게 특허발명을 생산한 경우에는 그것을 판매하지 않더라도 특허권의 침해가 되며, 乙이 침해자인 甲으로부터 특허발명을 선의로 적법하게 구입하였다고 하더라도 乙이 특허발명을 사용 또는 판매하는 경우에는 독립적인 별개의 실시행위에 해당되므로 특허권의 효력은 여전히 거기에까지 미치게 되어 별개의 특허권 침해가 된다. 이 경우 특허권자가 甲과 乙 모두에 대하여 중복하여 손해배상을 청구할 수 있는지가 문제이다. 이에 대해서는 공동불법행위 이론을 인용하여 부진정연대채무가 되어 그중 1명으로부터 손해가 배상이 되면 다른 일련의 실시행위에 대한 손해배상청구권은 소멸하고 이중으로 손해배상이 이루어진 경우라면 부당이익의 문제가 된다고 보아야 한다.⁵⁰⁾

A(물건)발명의 특허권자				
甲	A생산			
	A판매	丁	A사용	
		A판매	戊	A사용 A생산
정당한 권원이 없는 자				
乙	A생산			
	A판매	丙	집에서 A 사용	
		己	A생산에만 사용하는 b생산	

주체	행위	실시 여부	침해 여부
乙	A 생산 A 판매	실시 실시	침해 침해
丙	A 구입 A 사용	비실시 실시	비침해 비침해(∴업이 아님)
丁	A 구입 A 사용 A 판매	비실시 실시 실시	비침해 비침해(∴권리소진) 비침해(∴권리소진)
戊	A 구입 A 사용 A 생산	비실시 실시 실시	비침해 비침해(∴권리소진) 침해
己	b 생산	비실시	침해(∴간접침해)
비고	각각의 실시행위별로 침해인지 여부를 판단 (실시행위의 독립성)		

해설 특허발명의 실시와 침해는 구별되어야 한다. 특허권의 침해가 되기 위해서는 특허권의 존속 중 정당한 권원 없는 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 업으로서 실시하여야 한다. 따라서 특허발명의 실시라고 할지라도 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한 경우, 정당한 권원이 있는 경우 또는 업으로서 실시가 아닌 경우에는 침해가 아니다. 또한 특허발명의 실시가 아닐지라도 특허발명의 보호범위에 속하는 간접침해일 수 있다.

【그림 6-6】 실시와 침해의 구별

50) 서울중앙지방법원 2009. 1. 8. 선고 2008가합1588 참조.

제3관 효력의 제한

I. 서

특허권 효력의 제한은 적극적 효력의 제한과 소극적 효력의 제한으로 구분될 수 있다. 적극적 효력의 제한이란 특허권자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 없는 것을 말하며, 소극적 효력의 제한이란 제3자의 실시를 금지시킬 수 없는 것을 말한다. 특히 소극적 효력의 제한은 침해가 성립하지 않은 경우와 침해에 대한 권리 행사가 제한되는 경우로 구분될 수 있다.

II. 적극적 효력의 제한

1. 타법에 의한 제한

의약품 발명은 약사법에 의하여 품목허가를 받아야 하고, 농약 또는 농약원제의 발명은 농약관리법에 의하여 등록을 받아야 실시할 수 있으므로 특허권의 적극적 효력이 제한된다. 다만 특허발명을 실시하지 못하는 특허권자의 불이익을 해소하고 다른 특허권자와의 형평성을 유지하기 위해 허가 등에 따른 존속기간연장등록제도(法 89)를 두어 보완하고 있다.

2. 이용·저촉관계에 의한 제한

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하거나 통상실시권허락심판에 의하지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다(法 98, 138). 즉 이용·저촉관계의 경우에는 후출원 특허발명에 관한 특허권의 적극적 효력이 제한된다.

3. 특허권 공유에 의한 제한

특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다(法 99③). 그러나 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있고, 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(法 99②④).

4. 특허권 포기 등의 제한

실시권이나 질권 등은 특허권이 소멸하면 같이 소멸되는 부수성을 가지고 있으므로 실시권자 또는 질권자는 특허권의 소멸이나 변경에 이해관계가 있다고 할 수 있다. 따라서 특허권자가 특허권을 포기하거나, 그 특허발명의 명세서·도면에 대한 특허의 정정 또는 정정심판을 청구할 때 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 질권자 및 직무발명에 대한 통상실시권자(사용자)의 동의(다만 특허권자가 특허의 정정, 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)를 받아야 한다(法 119①, 132의3③, 133의2④, 136⑧)

Ⅲ. 소극적 효력의 제한

1. 실시권의 존재에 의한 제한

실시권은 특허권의 침해가 되지 아니한 정당한 권원 중 하나이므로 특허권자는 특허권 침해를 이유로 실시권자의 실시를 배제할 수 없다. 한편 특허권자는 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점하지만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정한 때에는 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다(法 94①). 즉 특허권자는 전용실시권자의 실시를 배제할 수 없음은 물론이거나 특허권자라도 설정행위로 정한 범위에서는 특약이 없는 한 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다. 이처럼 전용실시권, 통상실시권의 존재는 특허권의 소극적 효력의 제한이고, 이에 대하여 전용실시권의 존재는 특허권의 적극적 효력의 제한이기도 한 것이다.

2. 권리소진에 의한 제한

(1) 의 의

1) 「권리소진」이란 특허권자 또는 제조·판매권을 가진 실시권자(이하 “특허권자 등”이라 한다)가 특허발명을 실질적으로 구현한 제품(이하 “특허제품”이라 한다)을 적법하게 판매한 경우 권리가 소진되어 동일물에 대해서는 특허권의 침해를 주장할 수 없게 되는 것을 말한다.⁵¹⁾⁵²⁾

51) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 참조.

52) 한국에서는 특허법에 이와 관련된 명시적인 규정을 두고 있지 않다. 이는 “저작자는 저작물의 원본이나 그 복제물을 배포할 권리를 가진다. 다만 저작물의 원본이나 그 복제물이 해당 저작재산권자의 허락을 받아 판매 등의 방법으로 거래에 제공된 경우에는 그러하지 아니하다”라고 규정한 저작권법 제20조, “배치설계권의 효력은 적법하게 제조된 반도체집적회로등을 인도받은 자가 그 반도체집적회로등에 대하여 영리를 목적으로 반도체집적회로등을 양도·대여하거나 전시(양도·대여를 위한 경우로 한정한다) 또는 수입하는 행위를 하는 경우에는 미치지 아니한다”라고 규정한 반도체집적회로의 배치설계에 관한 법률 제9조 제2항, “품종보호권·전용실시권 또는 통상실시권을 가진 자에 의하여 국내에서 판매되거나 유통된 보호품종의 종자, 그 수확물 및 그 수확물로부터 직접 제조된 산물에 대하여는 품종보호권의 효력이 미치지 아니한다”라고 규정한 식물신품종보호법 제58조 본문에서 권리소진에 관한 명시적인 규정을 두고 있는 것과 대비된다.

권리소진은 특허권이 특허제품에 구현될 때 특허권자가 여전히 보유하고 있는 특허권과 특허제품을 구입하여 소유권을 취득한 양수자가 누리는 특허에 대한 사용권의 충돌에 대한 이해관계를 조절하기 위한 법리이다. 권리소진이 필요한 이유는 i) 양수인이나 전득자로서는 그 특허제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한없이 그 특허제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고(양수인 또는 전득자의 보호), ii) 특허제품을 유통할 때 양도할 때마다 특허권자의 동의를 얻어야 한다면 특허제품의 유통이 현저히 방해될 수 있고(유통 과정의 보호), iii) 특허권자가 특허제품을 판매할 때 이미 특허권자에게 특허발명의 대가를 배타적으로 취득할 기회가 주어지는 것이어서 이중 이득의 기회를 줄 필요가 없기 때문이다(권리자의 이중 이득 금지).⁵³⁾⁵⁴⁾

2) 이하에서는 권리소진이 적용되기 위한 요건을 살펴보고, 권리소진과 관련된 문제로서 i) 방법발명의 특허에 대해서도 권리소진이 적용되는지 여부, ii) 조건부 판매로 권리소진을 제한할 수 있는지 여부, iii) 외국에서의 판매에 대하여 권리소진이 적용될 것인지 여부, iv) 수리나 부품 교환을 하는 행위가 특허권을 침해하는 것으로 볼 것인지 여부를 검토해 본다.

(2) 적용요건

① 특허권자 또는 제조판매권을 가진 실시권자일 것

특허권자 또는 제조판매권을 가진 실시권자가 판매하여야 한다. 따라서 실시권자가 실시권의 제한조건을 벗어나서 판매한 경우에는 실시권의 제한조건이 위법하다거나 무효인 경우를 제외하고는, 권리소진의 효과가 발생하지 않아서 특허권의 침해가 된다. 다만 계약상 부수적인 제한조건을 위반하여 판매한 경우에는 일률적으로 특허권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, i) 계약의 구체적인 내용, ii) 특허권자가 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 iii) 특허제품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 권리소진 여부를 판단하여야 한다.⁵⁵⁾

② 특허발명을 실질적으로 구현한 제품(특허제품)일 것

특허발명을 실질적으로 구현한 제품을 판매하여야 한다. 즉 특허발명 청구항의 모든 구성요소를 포함하여 문언적으로 포함한 경우나 일부가 변경되었다고 하더라도 균등의 범위내에서 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타낼 정도로 구현된 제품을 판매하여야 한다. 한편 특허발명 중 일부만이 구현되어 있거나 다른 부품과 결합할 때 비로소 특허발명이 완성되어 실시되는 제품이라고 할지라도 해당 제품이 특허발명의 핵심적 특징을 모두 가지고 있다면 특허발명을

53) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 참조.

54) 한편 특허제품의 구입 후 행위의 적법성에 대한 논의를 실시행위독립의 원칙의 예외라고 하는 것은 타당하지 않다. 이 경우에도 여전히 실시행위독립의 원칙이 적용되는 것이다. 실시행위독립의 원칙이란 각각의 실시행위는 서로 독립적이므로 침해 여부 역시 각각 독립적으로 판단하여야 하는 원칙일 뿐이기 때문이다.

55) 대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 참고.

실질적으로 구현한 제품으로 볼 수 있다. 여기서 「핵심적 특징」이라 함은 결국 대상 특허발명을 다른 특허발명과 구별할 수 있도록 만드는 발명적 요소를 말한다. 예를 들어 일상적으로 다른 용도로도 사용되는 메모리 칩을 별다른 과정을 거치지 아니하고 문제된 칩에 부착하여 대상 특허발명이 구현되거나 미완성의 렌즈를 일상적 연마방식으로 연마함으로써 대상 특허의 효과를 달성할 수 있는 경우처럼 새로운 발명적 요소로 볼 수 없는 일상적 행위의 추가 또는 일반 부품의 결합으로 대상 특허발명이 실시된다면 대상 특허발명은 그 제품에 실질적으로 구현되어 있다고 보아야 한다.⁵⁶⁾

③ 적법하게 판매할 것

판매란 그 형식을 가리지 아니하고 제품의 소유권이 적절한 대가관계를 통해 이전되는 모든 거래행위를 가리킨다.⁵⁷⁾ 따라서 판매나 증여 등 일반적인 양도와 같은 자발적인 처분행위는 물론 경매와 같은 비자발적 처분행위도 모두 포함한다.⁵⁸⁾

(3) 방법발명의 특허에 대해서도 권리소진이 적용되는지 여부

1) 특허권이 소진된다는 것은 적법하게 판매된 특허제품(특정한 물건)에 대하여 소진된다는 의미이므로 물건발명의 특허에 대하여 권리소진이 발생함에는 의문이 없으나 방법발명의 특허에 대해서도 권리소진이 발생하는지 논란이 되어 왔다.

2) 일본에서는 방법발명에 대하여는 원칙적으로 소진의 문제가 발생하지 않지만, 물건을 생산하는 방법발명에 대하여는 물건발명의 경우와 다르게 취급하여야 할 이유가 없으므로 그 방법에 의하여 생산된 물건이 권리자에 의하여 적법하게 배포된 경우 권리가 소진된다고 해석하고 있다.⁵⁹⁾ 미국에서는 QUANTA COMPUTER 사건⁶⁰⁾에서 방법특허의 실시행위에 대하여 소진을 적용하지 않으면 특허권자는 특허명세서 중에 방법발명을 삽입함으로써 소진 이론을 회피할 수 있게 되어 부당하고, 방법특허는 제품이나 장치와 같이 판매되지는 않지만 그 방법발명이 제품에 실질적으로 구현됐다면 특허권은 소진된다고 하면서, 실질적으로 구현되기 위한 요건으로, i) 제품이 타용도의 사용이 없을 것과 ii) 제품이 특허의 핵심적 특징을 구현하는 요소로 되어야 한다는 2가지 판단기준을 제시하고 있다.⁶¹⁾

3) 우리나라는 서울고등법원 2000. 5. 2. 선고 99나59391 판결(대법원 2000. 7. 21. 2000다27718호 심리불속행 상고가각)⁶²⁾과 서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합

56) 설민수, “특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”, 사법논집 제55집, 법원도서관, 2012, 35-36면.

57) 설민수, “특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”, 사법논집 제55집, 법원도서관, 2012, 39면.

58) 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299.

59) 中山信弘 著, 한일지재권연구회 역, 「공업소유권(상) 특허법」, 법문사, 2001, 362면 참조.

60) QUANTA COMPUTER, INC., et al., v. LG ELECTRONICS, INC., 128 S.Ct. 2109(U.S. 2008).

61) 황성필, “Quanta v. LG 판결을 반영하는 특허 라이선싱 전략”, 지식재산연구 제4권 제1호, 2009년 3월, 한국지식재산연구원, 121-126면 참조.

62) 피고들이 주장하는 소진이론이란 “물건의 특허” 또는 “제조방법의 특허”에 있어서 특허대상이 된 물건 또는 특허방법에 의하여 생산된 물건이 “특허권자”에 의하여 적법하게 판매·배포되었을 경우 그 권리가 소진

58313 판결⁶³⁾에서는 물건발명, 제조방법발명의 특허에서 권리소진이 발생하고, 단순 방법발명의 특허에서는 권리소진이 발생하지 않는다는 입장이었다. 그러나 최근 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결에서는 “방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, i) 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다. 그리고 ii) 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다. 또한 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 iii) 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다”라고 하여 방법발명에 대한 권리소진의 근거를 명확히 하였다.⁶⁴⁾ 또한 “어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 i) 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, ii) 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, iii) 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 한다”라고 하여 방법발명의 경우에도 권리소진이 된다고 하면서 그 요건을 제시하였다.⁶⁵⁾

내지 소모되어 당해 물건에 특허권의 효력이 미치지 않는다는 이론으로서, 이 사건과 같이 “단순 방법의 특허”에 있어서 특허의 사용을 위하여 필요한 물건이 “특허권자 이외의 자”에 의하여 확보된 경우에는 적용될 여지가 없다 할 것이다(서울고등법원 2000. 5. 2. 선고 99나59391).

63) 법원은 방법발명의 특허소진에 관하여, 방법의 발명의 경우에는 물건의 발명과 달리 일반적으로 그 발명의 특허권은 소진되지 않지만 특허권자가 방법의 특허권과 동시에 그 방법을 실시하기 위한 장치에 관해서도 특허권을 가지고, 그 방법은 다른 장치에 의해서도 사용할 수 있는 경우에는 특허권자가 그 특허장치를 양도한 이상 그 방법의 특허권도 소진한다고 봄이 상당하다(서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합58313).

64) QUANTA 판결 이후 나온 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299 판결에서도 물건을 생산하는 방법발명 이외에도 그 방법발명에만 사용되는 물건을 양도한 경우에 양도받은 제3자가 해당 물건을 양도·대여·수입 또는 대여의 청약뿐만 아니라 사용하는 행위를 하더라도 특허권이 소진되어 침해가 성립하지 아니한다고 하여 방법발명에 대해서도 권리소진을 인정하였다.

65) 대상판결은 ㉠ 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, ㉡ 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, ㉢ 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중을 실질적 구현 여부의 판단 요소로 제시하고 있다. 또한 이 부분 판시는 위 각 판단 요소(㉠, ㉡, ㉢)를 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 실질적 구현 여부를 판단하여야 한다고 실시하고 있는데, 위 각 판단 요소는 엄밀한 의미에서 ‘and’ 조건으로 연결된 것은 아니고, 이들을 종합적

4) 그러나 방법발명의 특허가 공유일 때 그 방법의 실시에만 사용되는 물건(전용품)이 양도되었다고 할 지라도 그 전용품이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 양수인 또는 전득자가 그 물건을 이용하여 해당 방법발명을 실시하는 것과 관련하여서 권리소진이 되지 아니한다고 할 것이다.⁶⁶⁾ 이는 i) 전용품의 제조 및 양도행위는 방법발명의 실시가 아니므로 제99조제3항이 적용될 수 없고, ii) 이에 대해 특허권이 소진된다고 한다면 다른 공유자의 동의 없이도 그 양수한 물건을 이용하는 한 물건이 소멸할 때까지 계속하여 방법발명의 특허를 실시할 수 있는 결과가 되어 각 공유자가 다른 공유자의 동의를 받지 않고도 통상실시권을 허락할 수 있는 것과 같은 결과가 초래되게 되는데 이는 제99조제4항에 반하기 때문이다.

(4) 조건부 판매로 권리소진을 제한할 수 있는지 여부

1) 권리소진은 특허권자 등이 특허제품의 판매를 적법하게 한 경우에 적용되기 때문에 특허제품을 판매할 때 조건을 부과하여 권리소진을 배제할 수 있는지 문제이다. 일본에서는 특허권자가 특허제품을 판매할 때 특허제품의 사용에 제한을 두더라도 그 제한에 반하는 이용이 계약위반이 되는 것을 별도로 하고, 특허권 침해를 구성하는 것은 아니라고 하고 있다.⁶⁷⁾ 미국에서도 일본과 마찬가지로 최근의 LEXMARK 사건⁶⁸⁾에서 특허권자가 스스로 또는 실시권

으로 고려한다는 점에서 볼 때 ‘or’ 조건에 가깝다고 할 수 있다. 만일 엄밀한 의미에서 ‘and’ 조건으로 설정할 경우 실질적으로 구현된 물건이라고 인정될 수 있는 범위가 지나치게 좁아질 우려가 있고, 아직 국내에서 특허권 소진에 관한 분쟁이 많지 않은 상황인 데다가, 처음부터 기준을 경직되게 설정할 경우 다양한 사례를 포섭하는 데 한계가 있을 수 있다는 고려도 반영된 것으로 보인다. 더욱이 위 각 판단 요소는 실제 사례에서 서로 밀접하게 연관된 경우가 많을 것으로 보여 ‘and’ 조건과 ‘or’ 조건 간에 결론에 있어서의 차이도 그다지 커 보이지 않는다. 물론 이렇게 할 경우 반대 측면에서 특허권 소진이 너무 쉽게 인정되어 특허권자에게 불리할 수 있다는 견해도 있을 수 있지만, 실시된 각 판단 요소 중 어느 하나만 충족될 경우 곧바로 실질적 구현을 인정하자는 취지는 아니고, 실시된 판단 요소들을 두루 고려하여 실질적 구현 여부를 판단하자는 것이므로, 개별 사안에서 구체적 타당성 있는 결론을 충분히 도출할 수 있을 것으로 사료된다(이헌, “방법의 발명과 특허권 소진”, 사법, 48호 2019년 여름, 160-161면)

66) 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299.

67) 中山信弘, 「공업소유권법(상)」, 제2판·증보판, 홍문당, 2000, 362項; 瀧谷達紀, 「지적재산법 I」, 제2판, 有斐閣, 2006, 335項 등 참조.

68) IMPRESSION PRODUCTS, INC. v. LEXMARK INTERNATIONAL, INC., U.S. Supreme Court. No 15-1189(U.S. Mar. 30. 2017). 사실관계를 살펴보면, Lexmark는 프린터와 카트리지를 판매하는 전략에 있어서 프린터를 낮은 가격으로 판매하고, 프린터의 수명이 다할 때까지 자신의 프린터에만 사용되는 소모품인 카트리지를 미국 内外에서 판매함으로써 수익을 얻는 비즈니스 모델을 가지고 있었고, 구매 후 재사용 및 재판매에 아무런 제한을 두지 않는 정가 카트리지(regular price cartridge)와 이를 제한하는 할인된 카트리지(special price cartridge)로 구분하여 판매하였다. 할인된 카트리지는 토너를 다시 채워 사용할 수 없도록 이를 감지하는 마이크로칩이 설치되어 있었다. 그런데 카트리지를 재사용하는 회사들이 정가 카트리지의 경우 카트리지의 토너를 다시 채우고, 할인된 카트리지의 경우 마이크로칩을 교체한 후 토너를 다시 채워서 Impression Products Inc.(이하 “Impression”라 한다)에게 판매하였으며, Impression은 이를 다시 미국 内에서 판매하였다. Lexmark는 Impression 등 63개 회사들이 미국 内에서 할인 판매된 카트리지와 미국 外에서 정가 판매 및 할인 판매된 카트리지를 구입 후 재사용한 것과 관련하여, U.S. Patent No. 6,078,771 등 카트리지 관련 특허 21개를 침해하였다고 소를 제기하였다. 이에 대하여 Impression은 해당 카트리지에 대한 특허권이 소진되었다고 주장하였다.

자를 통하여 물품을 판매함으로써 적법한 판매가 발생하면, 판매 당시 어떠한 제한을 부가하였는지 또한 판매가 특허가 등록된 국가에서 이루어졌는지 상관없이 해당 물품에 대해서는 더 이상 미국 특허권의 침해를 주장할 수 없다고 판시하였다. 이는 권리소진(미국에서는 이를 최초 판매 원칙(first sale doctrine)이 함)이 특허권자가 특허제품을 판매할 때 특허권자의 권한 양도(특허권자가 구매자에게 특허제품을 정당하게 사용하거나 재판매할 수 있는 권리를 제품의 판매와 동시에 부여)를 추정하는 것이 아니라 특허권자의 권리범위를 제한하는 원칙이기 때문이라는 것이다. 물론 이 경우 당초 부가한 제한조건을 위반하였다는 주장은 계약법에 의하여 가능하나 이는 계약 당사자에게만 효력이 있다고 판시하였다. 미국 연방대법원의 이러한 판결에 의하면, 특허권자가 최초의 판매에서 적절한 이익을 회수하지 못하면 그 판매 후에는 확실히 이고 자동적으로 특허권이 소진되어 특허권으로 이익을 거두기가 어렵게 되었다고 할 수 있다.

2) 우리나라는 이에 관한 사례가 아직 존재하지 않으나 만약 조건부 판매에 의하여 권리소진을 제한할 수 있다면 i) 조건부 판매가 계약법적으로 유효한지 여부, ii) 계약법적으로 유효하더라도 특허권의 남용이나 공정거래법 등에 위반되는지 여부와 함께 검토되어야 할 것이다. 구체적으로 살펴보면, 공정거래법 제59조에 의하면 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”라고 규정되어 있고, 공정거래위원회는 공정거래법 제59조와 관련하여 지식재산권의 행사가 정당한 것인지를 판단하는 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(개정 2016. 3. 23. 공정거래위원회 예규 제247호)」을 마련하고 부당한 행사에 해당하는 유형을 예시하고 있는데, “일반적으로 특허권자 또는 특허권자로부터 정당한 권한을 부여받은 자가 계약상품을 판매하면, 일단 판매된 계약상품에 대한 특허권자의 권리는 소진된다고 볼 수 있다. 만약 특허권자가 판매한 상품의 재판매와 관련된 조건을 부과하는 등 특허권이 소진된 영역에서 사업활동을 제한하는 조건을 부과한다면 이는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 행위로 판단할 수 있다”라고 하여 조건부 판매가 지식재산권의 부당한 행사임을 명시하고 있다.

(5) 외국에서의 판매에 대하여 권리소진이 적용될 것인지 여부

① 문제의 소재

외국에서 특허제품의 판매가 권리소진과 관련하여 문제되는 경우는 i) 국내와 외국 특허권의 특허권자가 각기 다른데 외국의 특허권자가 판매한 특허제품(진정상품)을 제3자가 구매하여 국내에 병행수입(parallel import)하는 경우,⁶⁹⁾ ii) 국내와 외국 특허권의 특허권자가 동일한데 특허권자가 외국에서 판매한 특허제품을 제3자가 구매한 후 국내에 병행수입하는 경우,⁷⁰⁾ iii)

69) 「진정상품(genuine goods)」이란 외국에서 적법하게 발명을 실시할 수 있는 자(예를 들어 외국의 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자)에 의하여 생산되어 유통된 상품을 말한다. 「병행수입(parallel import)」이란 상품을 국내로 수입할 수 있는 정당한 권원을 가진 자(예를 들어 국내의 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자) 이외의 제3자가 진정상품을 수입하는 것을 말한다(병행수입에 있어서의 불공정거래 행위의 유형고시(공정거래위원회고시 제2012-17호) 제2조 참조).

국내 특허권자가 특허권이 없는 외국에서 특허제품을 판매하거나 국내에서 판매하여 외국에 수출하였는데 제3자가 이를 그대로 또는 가공하여 국내에 수입할 경우로 구분될 수 있다. 각각의 경우 국내의 특허권을 침해하는지가 문제이다.

② 국내의 사례

1) WTO/TRIPS협정 제6조는 “이 협정에 따른 분쟁해결의 목적을 위하여 제3조(내국민 대우의 원칙)와 제4조(최혜국대우의 원칙)의 규정을 조건으로 이 협정의 어떠한 규정도 지식재산권이 소진문제를 다루기 위하여 사용되지 아니한다”라고 규정하고 있다. 이에 특허권의 국제소진 인정에 관한 각국의 입장은 자국의 경제 상황 등에 따라 개별적으로 판단되고 있어 통일되지 않은 상태이다.⁷¹⁾⁷²⁾ 구체적으로 일본에서는 BBS 사건⁷³⁾에서 일본의 특허권자와 외국의 특허권자가 일치하더라도 외국에서의 특허권이 일본의 특허권과 동일하다고 할 수 없고, 동일한 발명에 대한 대응 특허권을 가지고 있다고 할지라도 별개의 권리이기 때문에 특허권자가 이중이득을 취하였다고 볼 수 없다고 하여 국제소진을 부정하였다. 다만 최종적으로 국제거래에서 광범위하고 진전된 상품유통과 특허권자의 권리조정이라는 측면을 고려하면 일본 특허권자 또는 이와 같다고 인정되는 자가 국외에서 특허제품을 양도하는 경우 양수인과 사이에 일본을 제외한다는 의사가 합의된 경우, 그리고 양수인으로부터 특허제품을 양수한 제3자 또는 그 후의 전득자에 대하여는 양도인과 양수인 사이에 위와 같은 뜻의 합의가 있었다는 사실이 특허제품에 명기된 경우를 제외하고는 특허권을 행사할 수 없다는 일종의 묵시적 실시허락에 기한 특허권의 소멸을 인정하여 침해를 부정하였다. 즉 일본은 외면적으로는 국내소진만을 채택하고 있으나, 실질적으로는 국제소진을 인정하고 있다. 미국은 앞서 살펴본 LEXMARK 사건에서 특허권의 소진은 저작권의 국제소진을 인정한 Kirtsaeng 사건⁷⁴⁾의 연장선에 있다고 하면서, 특허소진은

70) 국내와 외국의 특허권자가 동일한 경우 특허권자는 각국에서 판매조건이나 실시료를 달리하는 방식으로 시장을 분할하여 차별적 가격이나 판매조건을 통해 그 수익을 극대화하게 된다. 그런데 제3자가 가격이나 판매조건이 다른 국가의 진정상품을 구매한 후 병행수입하면 특허권자의 이러한 시장분할 노력을 흔들게 된다.

71) 박태일, “특허소진에 관한 연구 -국내외 사례의 유형별 검토를 중심으로-”, 정보법학 제13권 제3호, 36면.

72) 병행수입의 자유를 주장하는 개발도상국과 이에 반대하는 선진국 사이의 의견차이로 인해 병행수입 허용 여부와 그 기준에 관한 합의를 할 수 없었기 때문에, 결국 병행수입 문제는 WTO분쟁절차에 의하여 해결될 수 없는 것으로 규정한 것이다(WTO사무국/김의수, 「우루과이라운드 협정의 이해」, 대외경제정책연구원(2000), 274면 참조.).

73) 일본최고재판소 판결 1997. 7. 1. 판례시보 1612호.

74) Kirtsaeng 사건(Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., U.S. Supreme Court, No. 11-697 (U.S. Mar. 19, 2013))을 요약하면, 학습 교재 출판사인 원고 John Wiley & Sons, Inc.는 해외 자회사인 Wiley Asia를 통해 해외판 영어 교재를 출판 및 판매해 왔는데, 그 교재에는 (허락 없이) 미국으로 반입되어서는 안 된다는 문구가 기재되어 있었다. 그러나 태국계 유학생인 피고 Kirtsaeng은 지인들을 통해 태국 서점에서 낮은 가격에 구입해 전달받은 Wiley의 해외판 교재들을 미국에서 재판매하여 차액을 남겼다. 이에 대하여 Wiley사는 Kirtsaeng의 허가받지 않은 해외판 교재 수입과 미국 내에서의 재판매는 17 미국저작권법 제106조(3) 배포권과 제602조(a)(1) 허락받지 않은 저작물 수입에 대한 규정을 위반한 것이라고 주장하며 소를 제기하였고, Kirtsaeng은 미국저작권법 제109조(a) 최초판매원칙에 기한 항변을 하였다. 이에 연방대법원은 1) 미국 저작권법 제109조(a)가 지역적 제한에 관한 규정을 두고 있지 않다는 점, 2) 개정 경과 등을 보더라도 미국 의회가 미국 저작권법 제109조(a)를 입법화할 때 지역을 의식하지 않았다는 점, 3) 보통법상 연혁(the first sale doctrine's common-law history)에 비추어 보면 법원이 처음으로

특허권자가 대가를 받고 특허제품에 대한 소유권을 포기함으로써 발생하는 것이고 얼마만큼의 대가를 받을 수 있는지와는 무관하므로 특허제품의 판매가 특허가 등록된 미국에서 이루어지지 않았더라도 해당 특허제품에 대해서는 더 이상 미국 특허권의 침해를 주장할 수 없다고 판시하였다.

2) 우리나라는 서울지방법원 동부지원 1981. 7. 30. 선고 81가합466(특허권침해금지) 판결에서 “원고 주장과 같이, 각국에서의 특허권은 서로 독립적이고, 또 개개의 특허 실시행위는 서로 독립된 것이라 할지라도, 원고의 이 사건 특허권은 원고가 위 약품을 독점적으로 제조하여 적법하게 스위스에 수출함으로써 이미 행사되어 소진된 것이고, 그 후에 위 약품이 어떻게 유통·소비되는가 하는 점은 원고의 제조, 판매행위에 기초를 두고 그 제품이 실수요자에게 분배되는 과정에 불과하여 원고가 관여할 사정이 아니며, 피고(병행수입업자)가 위 약품을 적법하게 수입한 제3국에서 다시 수입하는 경우에게까지 추급권을 행사하여 특허권자로서의 권리를 주장할 수는 없는 법리라고 하면서, 특허권자의 승낙없이 제3국으로부터 위 특허제품을 수입하였다 하여 특허권이 침해되었다고는 볼 수 없다. 또한 제3국에 특허권자의 특허등록이 되어 있지 아니하여 위 제품을 수출함에 있어 특허실시료를 징수하는 등 특허권을 행사할 기회가 없었다 하더라도 적어도 특허권자의 손을 떠나버린 당해 제품에 관한 한 특허권 행사 없이 유통·소비되리라는 것을 특허권자도 용인하였다고 볼 것이다”라고 판시하여, 국내 특허권자가 국내에서 판매하여 외국에 수출하였는데 제3자가 이를 그대로 국내에 수입할 경우에 소진을 인정하면서 특허권 침해를 부정하였다.⁷⁵⁾

③ 소 결

1) 특허권자 등이 국내외에서 특허제품을 판매한 경우 특허권이 부여된 국가의 특허권이 소진되었다고 보아야 한다. 권리자의 이중 이득 금지라는 권리소진의 근거에 비추어 볼 때 특허제품이 국내나 국외에서 판매되었는가의 문제는 중요하지 않으며, 특허제품이 국경을 넘는다는 사실 때문에 이를 달리 볼 필요가 없기 때문이다.⁷⁶⁾ 다만 각국의 특허는 서로 독립적이고(특허권 독립의 원칙) 특허권의 효력이 국내에서만 미치기 때문에(속지주의), 권리소진이 적용되는 범위는 특허권의 부여된 국가의 범위에 한정함이 타당할 것이다. 즉 권리소진의 요건으로서 판매지역은 국내외를 불문하나, 그 효력이 발생하는 지역은 특허권이 부여된 국가로 한정된다고 해석해야 한다.

최초판매원칙을 인정했던 Bobbs-Merrill 판결(Bobbs-Merrill Co. v. Straus, 210 U.S. 339, 28 S.Ct. 722, 52 L.Ed. 1086 (1908).)이나 입법 조항에도 지역적 차별이 존재하지 않았다는 점, 4) 지역적 해석을 택하면 도서관의 경우 해외에서 출판된 많은 소장서들을 유통하기 전에 매번 저작권자의 허가를 받아야 하는데 이는 현법상 “과학과 유용한 예술의 진흥(promot[ing] the progress of science and useful arts)”이라는 저작권법의 목적 달성을 불가능하게 한다는 점 등을 미국 저작권법 제109조(a)는 외국에서 제작된 저작물에도 적용된다고 판단하였다(맹정환, 저작권의 국제적 소진 이론에 대한 미연방대법원 Kirtsaeng 판결의 시사점, 법률신문뉴스(2013-08-26)).

75) 위 판결은 우리나라에서 특허제품의 병행수입이 특허권 침해로 되는지에 관한 최초이자 유일한 사례이나 항소취하되어 상급심의 판단이 내려지지 않았다.

76) 박태일, “특허소진에 관한 연구 -국내외 사례의 유형별 검토를 중심으로-”, 정보법학 제13권 제3호, 40-41면.

2) 이에 따르면, i)의 경우 외국에서 특허권의 경우 권리소진이 발생하지만, 국내에서 특허권의 경우 특허권자가 달라 국내의 특허권자가 특허제품의 판매를 통해 이득을 취한 것도 아니고 특허독립의 원칙 및 속지주의에 의하여 국내에서 권리소진이 발생하지 않아서 국내 특허권의 침해라고 볼 것이다. ii)의 경우 외국에서 특허제품의 판매를 통해 외국과 국내에서 특허권의 권리소진이 발생하였고, 특허권자가 이득을 취하였기 때문에 국내 특허권의 침해가 아니라고 볼 것이다. iii)의 경우 국내의 특허제품의 판매를 통해 국내 특허권의 권리소진이 발생하였고, 특허권자가 이득을 취하였기 때문에 국내 특허권의 침해가 아니라고 볼 것이다.

(6) 수리나 부품 교환을 하는 행위가 특허권을 침해하는 것으로 볼 것인지 여부

1) 특허권자 등이 판매한 특허제품을 제3자가 입수한 후 그 부품을 교체하여 사용하거나 재판매하는 경우 이를 특허권의 침해라고 할 수 있는지가 문제이다. 특허제품 가운데는 부품을 지속적으로 교체해 줄 필요가 발생하는 제품이 상당하고, 특허권자의 실제 수익도 완제품 판매보다는 부품의 판매에서 얻어지는 경우가 많기 때문이다. 그 결과 더 저렴한 가격에 부품을 구입해 특허제품의 유지비용을 낮추려고 하는 구매자의 이해관계와 실제적 수익이 발생하는 부품을 통해 수익을 극대화하고자 하는 특허권자의 이해관계가 충돌하게 된다.⁷⁷⁾

2) 이와 관련하여, 미국에서는 판례이론으로 발전된 수리와 재생산의 법리에 의하여 특허제품에 가한 변형행위를 특허법상 허용되는 「수리」로 볼 것인지 아니면 특허권 침해로 되는 「재생산」으로 평가할 것인지를 판단하는 방법으로 이 문제를 해결하고 있다. 즉 권리소진이 발생한 경우 구매자의 특허제품의 사용권에 특허권자의 권리가 소멸되는 것이고 특허제품의 재생산에 해당하지 않는 한 구매자의 수리행위가 허용된다는 것이다. 수리와 재생산의 문제를 다른 연방항소법원(CAFC) 판결들은 대체로 미국에서는 수리의 범위를 넓게 인정하고 있다. 구체적으로 i) 특허제품을 전체로 보았을 때 사용이 끝난 후에 그것을 사용할 수 있도록 하는 행위는 재생산에 해당하고, ii) 특허를 받지 않은 부분의 사용이 다 하였을 때 전체를 사용할 수 있는 상태로 유지할 목적으로 사용이 끝난 부분이 교환되는 경우에는 수리에 해당하며, iii) 의도된 것과 다른 용도를 수행할 수 있도록 하는 것을 목적으로 특허 장치 중의 부품을 개조 또는 교환하는 경우에는 수리 또는 수리에 가깝다고 정리할 수 있다.⁷⁸⁾ 일본에서는 특허제품을 시장에서 입수한 자가 그 부품을 가공 내지 교환하는 행위가 특허제품의 생산행위에 해당하지에 따라서 특허권 침해 여부를 결정하는 「생산 어프로치」⁷⁹⁾, 특허발명의 보호와 거래 안정의 조

77) 설민수, “특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”, 사법논집 제55집, 법원도서관, 2012, 55면.

78) 표호건, “소모이론에 관한 고찰”, 법학연구 제15권 제4호, 연세대학교, 2005, 88면. 미국에서 이렇게 수리행위가 광범위하게 인정되는 근본적 원인은 특허소진의 역사에도 보이듯이 미국의 제조업자들이 제조된 제품의 유통망까지는 장악하지 못했고, 수리업이나 재활용산업이 원래 제품의 제조업과는 별개 산업으로 발전했으며, 그 과정에서 소비자의 소모품이나 부품에 대한 저가 대체품 활용요구가 작용하는 것이 가장 큰 원인이라고 볼 수 있다(설민수, “특허권 소진 법리의 역사적 전개와 한국에서의 적용”, 사법논집 제55집, 법원도서관, 2012, 60면).

79) 생산 어프로치에 따른 대표적 재판례로서 리사이클 잉크 카트리지 사건에 관한 最高裁 平成 19년(2007) 1 1. 8. 선고 平成 18(受) 826호 판결이 있다. 이에 의하면, 잉크 카트리지에 대한 특허권자인 캐논 또는 캐

화를 도모하는 권리소진의 목적론적 해석으로부터 소진의 적용범위를 확정해야 한다는, 즉 특허제품 구매자의 사용행위를 시장에서 허용될 수 있는 범위에 한정할 필요가 있다는 「소진 어프로치」⁸⁰⁾가 있다.⁸¹⁾ 생산 어프로치는 소진의 효과를 당해 부품 교환 행위가 특허법상 허용되는 수리인가 또는 허용되지 않는 재생산인가에 의하여 판단하는 것이나, 소진 어프로치는 특허제품의 효용이 사회통념상 상실된 후에 그 특허제품을 가공하여 효용을 재차 발휘할 수 있는 상태로 만들었는지 여부라는 판단기준을 이용하는 것이라고 할 수 있다.⁸²⁾

3) 우리나라는 수리와 재생산의 관점에서 부품의 교체가 특허권의 침해인지 여부를 판단하고 있는 것으로 보인다. 다만 판례는 부품이 비소모품인 경우와 소모품인 경우를 달리 보고 있다. 부품이 비소모품인 경우에는 발명의 기술적 사상과 관련된 본질적인 구성요소라면 부품의 교체가 생산에 해당하고,⁸³⁾ 특허발명의 대상 또는 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모품인 경우에는 i) 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 ii) 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 iii) 해당 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, iv) 특허권자 측에 의하여 그러한 부품을 따로

논으로부터 허락을 받은 자가 일본 또는 국외에서 판매한 잉크 카트리지 중 잉크가 소비된 것에 잉크를 재충전하여 제품화한 사안인데, 특허권자 등이 일본국에서 양도한 특허제품에 대하여 가공이나 부재의 교환이 이루어져 이것에 의하여 당해 특허제품과 동일성을 잃은 특허제품이 새롭게 생산된 것이라고 인정되는 때에는 특허권자는 그 특허제품에 대해서 특허권을 행사하는 것이 허용된다 하면서, 피고의 제품은 동일성을 결한 특허제품이 새롭게 생산된 경우라고 인정하는 것이 상당하다고 하면서 침해를 인정하였다. 그리고 특허제품의 새로운 생산에 해당하는지 여부에 관하여는 i) 당해 특허제품의 속성, ii) 특허발명의 내용, iii) 가공 및 부재의 교환의 태양 외, iv) 거래의 실정 등도 종합하여 고려하여 판단하는 것이 타당하며, i) 당해 특허제품의 속성으로서의 제품의 기능, 구조 및 재질, 용도, 내구사용기간, 사용 태양이, iii) 가공 및 부재의 교환의 태양으로서의 가공 등이 된 때의 당해 특허제품의 상태, 가공의 내용 및 정도, 교환된 부재의 내구사용기간, 당해 부재의 특허제품 중에 있어 기술적 기능 및 경제적 가치가 고려의 대상이 되어야 한다고 판시하였다(박태일, 「특허소진에 관한 연구-국내의 사례의 유형별 검토를 중심으로-」, 정보법학 제13권 제3호, 62-64면 참조).

80) 소진 어프로치에 따른 대표적 재판례로서 1회용 카메라에 관한 東京地裁 平成 12년(2000.) 6. 6. 자 平成 11(コ) 22179호 결정 및 東京地裁 平成 12년(2000.) 8. 31. 선고 平成 21(ワ) 16782호 판결이 있다. 東京地裁 平成 12년(2000.) 6. 6. 자 결정은, 신청인이 코니카 필름 일체형 카메라를 제조 판매하는 회사로서 위 카메라에 대한 실용신안권자이고, 피신청인은 사용 후의 위 카메라의 본체 부분을 이용하여 필름과 전지를 재장전한 제품을 판매한 사안인데, 법원은 실용신안권자가 실시품을 양도한 경우에는 당해 실시품에 대해서는 실용신안권은 목적을 달성한 것으로 보아 소진하지만, 위 카메라는 소위 필름 일체형 카메라로서 소비자는 본체에 미리 필름이 내장된 상품을 구입하여 그대로 촬영하고 촬영이 종료되면 필름이 본체에 내장된 채로 현상을 맡기게 되므로 소비자에게는 본체가 반환되지 않는 제품이라 할 수 있고, 또한 당해 실시품은 내장된 필름을 꺼내기 위해 본체의 일부를 파괴하지 않으면 안 되는 구조로 이루어져 있으며 소비자 스스로가 필름을 교환하고 재이용하는 것은 매우 곤란하도록 설계되어 있으므로, 위와 같은 실시품의 객관적인 성질, 거래의 양태, 통상의 이용형태 등에 비추어 보면, 당해 실시품은 판매시에 미리 내장된 필름의 사용만이 예정된 상품임이 분명하므로, 피신청인의 행위는 신청인이 당해 실시품을 시장에 두었을 때 예상한 범위를 초월하는 실시형태라 할 수 있다고 하여 신청인의 실용신안권 침해를 인정하였다(김민재, 「부품교환의 특허법상 해석에 관한 비교법적 고찰 - 프린터카트리지 사례를 통하여 본 재제조 산업의 전망 -」, 「지식재산 21」(제102호), 지식재산처(2008), 173-174면 참조).

81) 박태일, 「특허소진에 관한 연구-국내의 사례의 유형별 검토를 중심으로-」, 정보법학 제13권 제3호, 65면.

82) 표호건, 「소모이론에 관한 고찰」, 법학연구 제15권 제4호, 연세대학교, 2005, 91면.

83) 서울중앙지방법원 2006. 8. 23. 선고 2005가합48548.

제조·판매하고 있다면 생산에 해당한다⁸⁴⁾는 것이다. 이는 완제품에 대한 특허권자가 소모품이 유통되는 부품시장(after market)에서 과도한 독점권을 갖는 것은 타당하지 않기 때문에 부품이 소모품인 경우에는 생산에 해당하기 위한 요건을 엄격히 규정하고 있는 것으로 보인다. 다만 특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1001 판결⁸⁵⁾에서는 부품을 교체하는 것이 원래 특허제품과의 동일성을 해할 정도에 이르게 된 경우에는 재생산으로 특허권을 침해하는 것으로, 동일성을 유지되는 경우에는 수리로서 특허권을 침해하지 않은 것으로 판단하고 있다. 또한 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단하여야 한다고 하여 상표법에서의 판단기준⁸⁶⁾과 동일한 판단기준을 제시하였다. 이는 본질적 부분의 교체라면 생산이 된다는 기존의 판례보다 수리의 범위를 조금 더 넓게 인정해 주려는 경향으로 파악된다.

3. 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위

(1) 연구 또는 시험(「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)을 하기 위한 특허발명의 실시

1) 연구 또는 시험을 위한 특허발명의 실시(「약사법」에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다)는 특허권의 효력이 미치지 않는다(法 96Ⅰ). 누구든지 특허발명을 연구 또는 시험하여 그 내용을 확인·검증하고 더욱 개량된 발명을 이어나갈 수 있도록 특허권의 효력을 제한함으로써 특허법이 추구하는 발명의 보호와 발명의 이용 도모를 통한 기술발전 촉진 사이에 조화와 균형을 이루기 위한 규정이다. 따라서 특허권자 등의 독점적·배타적 이익을 불합리하게 훼손하지 않으면서 특허발명을

84) 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580.

85) 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등이 이를 수리하거나 소모품 내지 부품을 교체하는 경우에 그로 인하여 원래 제품과의 동일성을 해할 정도에 이르는 때에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 특허권을 침해하는 것으로 보아야 할 것이나, 그러한 수리 또는 소모품 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 수리 또는 소모품 내지 부품의 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되고, 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한, 그러한 수리행위나 부품 교체행위는 방법발명 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리에 해당하므로, 제3자가 업으로서 그러한 소모품 내지 부품을 생산·양도·대여 또는 수입하는 등의 경우에 특허법 제127조제2항 소정의 간접침해가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 양수인 등의 그러한 수리행위나 부품 교체행위가 방법발명의 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다. 이는 그러한 소모품 내지 부품이 그 특허발명의 실시에만 사용되는 것인 경우에도 마찬가지이다. 한편 수리행위 내지 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단하여야 한다.

86) 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권을 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 아니한다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이고, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 해당 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445).

연구 또는 시험하기 위해 그 특허발명을 실시하는 행위에는 특허권의 효력이 미치지 않는다.⁸⁷⁾ 구체적으로 특허발명의 실시자가 연구·시험의 주체와 일치하지 않은 경우, 특허발명의 실시자가 연구·시험의 결과에 대한 직접적 이익을 향유하지 않은 경우라도 기술발전에 기여하는 정도가 다르다고 볼 수 없으므로 본 규정이 적용될 수 있고,⁸⁸⁾ 국제적 교류가 일상화된 현실에서 시험결과의 공유 등을 통해 해외에서의 시험이 국내에 영향을 미쳐 개량발명을 촉진하고 기술적 진보에 기여하는 계기가 될 수도 있으므로 본 규정은 연구·시험의 장소가 국내일 것으로 제한되지 않는다. 또한 연구·시험은 다양한 형태로 기술발전에 기여할 수 있으므로, 반드시 특허성의 확인, 기능 조사나 개량발명 등을 통해서만 기술발전이 도모된다고 할 수 없다. 즉, 발명의 개량을 목적으로 하지 않은 연구나 시험에서도 발명의 내용을 이해하고 기술정보를 축적하는 과정 등을 통해 얼마든지 기술발전에 기여할 수 있다. 따라서 연구·시험의 목적이 무엇인지, 즉 특허성 실증⁸⁹⁾이나 기술 개량을 목적으로 하는지 또는 상업적 이익을 목적으로 하는지 등에 따라 본 규정의 적용을 달리하지 않는다.⁹⁰⁾

2) 다만 특허발명 자체의 연구 또는 시험(research on)이어야 하며 다른 연구 또는 시험의 목적을 위하여 특허발명을 이용하는 실시(research with)는 특허권의 효력이 제한되지 아니한다.⁹¹⁾ 예를 들어 환경단체가 한강의 수질오염정도를 연구하기 위해 특허발명인 수질오염측정방법을 사용한다면 특허권의 효력이 제한되지 아니한다.

3) 한편 각각의 실시행위별로 특허권의 침해인지를 판단하므로, 연구 또는 시험을 위한 실시는 침해가 아니나 그 결과 제작된 것을 업으로서 연구 또는 시험 이외의 것에 실시했을 때는 특허권의 침해가 된다. 예를 들면 물건을 생산하는 방법에 관한 특허발명을 시험하여 생산된 물건을 타인에게 양도하는 것은 특허권의 침해가 된다. 그러나 물건제조장치에 관한 특허발명을 시험하여 생산된 물건을 타인에게 양도하는 것은 물건의 양도가 물건제조장치의 실시(法 2Ⅲ가)가 아니므로 특허권의 침해가 되지 아니한다.⁹²⁾

87) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970.

88) 특히 제약 산업분야에서는 보통 의약품 개발부터 품목허가를 거쳐 시판에 이르기까지 실험실 단계의 실험, 임상시험, GMP(Good Manufacturing Practice) 규정을 준수하는 제조시설에서의 의약품 생산 등 복잡한 절차를 거치야 하므로 그 과정에 막대한 예산과 대규모 생산설비가 필요하기 마련인데, 현실적으로 제약회사의 생산역량이 이에 미치지 못하는 경우가 있다. 실제로 많은 바이오/제약 기업들이 생산 역량이 부족하거나 경영 효율화를 꾀하기 위하여 생산대행기업[바이오CMO(Bio-Contract Manufacturing Organization)]에게 의약품의 생산을 위탁하고 있음을 알 수 있다. 이 경우 연구·시험의 주체(제약회사)와 특허발명의 실시 주체(바이오CMO)가 일치하지 않고 그 연구·시험 결과의 이익도 대개는 연구·시험의 주체인 제약회사가 향유하게 되는데, 그렇다고 하여 시험적 실시의 예외를 인정하지 않는 것은 부당하다.

89) 특허발명의 실시가 특허발명에 대한 신규성·진보성 유무를 조사하기 위한 것인지, 특허발명이 실시가능한지를 연구·시험하기 위한 것인지, 특허발명이 명세서에 기재된 효과를 갖고 있는지를 확인하기 위한 것인 등을 확인하기 위해 특허발명을 실시하는 경우를 말한다(특허법원 2017. 11. 16. 선고 2016나1455).

90) 특허법원 2024. 12. 3. 선고 2023나10914. 대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970 판결의 하급심 판결이다.

91) 특허법원 2017. 11. 16. 선고 2016나1455.

92) 이를 표로 정리하면 다음과 같다.

4) 기존에 논란이 되었던 부분은 특허발명인 의약품의 존속기간이 만료된 후 상업화할 목적으로 특허권의 존속기간 중 약사법의 허가를 얻기 위한 시험을 한 경우(통상적으로 시험결과를 얻어내기 위해서는 2~3년의 기간이 소요됨) 특허권의 침해가 되는지 여부이다. 이에 대하여 판례⁹³⁾는 허가를 얻기 위한 시험이 침해가 된다면 의약품의 존속기간이 만료된 후에도 시험 결과를 얻어내기까지 특허권자를 부당하게 보호하는 결과가 되므로 제96조제1항제1호에 해당하여 침해가 아니라고 하였다. 2010년 1월 27일 개정(법률 제9985호, 2010. 7. 28. 시행)된 특허법에서는 제96조제1항제1호의 연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시에 “약사법”에 따른 의약품의 품목허가·품목신고 및 「농약관리법」에 따른 농약의 등록을 위한 연구 또는 시험을 포함한다”라고 하여 이를 명확히 하고 있다.⁹⁴⁾

(2) 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기·차량 또는 이에 사용되는 기계·기구·장치, 그 밖의 물건

1) 단순히 국내를 통과하는데 불과한 선박·항공기 또는 이에 사용되는 장치 등은 그 용도가 국내통과라는 목적에 한정되므로 특허권자에게 주는 손해가 없을 뿐만 아니라, 이에 대하여 특허권의 효력이 미친다고 하면 교통을 방해하는 결과가 되어 국제교통상 장애가 있으므로 특허권의 효력이 미치지 않도록 하고 있다(法 96Ⅱ).

2) 「국내」란 영토뿐만 아니라 영해 및 영공 등을 포함하며, 「국내를 통과하는데 불과한」이란 주유를 하거나 하역을 위하여 일시 정박하거나 착륙한 교통기관을 말한다. 한편 「기계·기구·장치, 그 밖의 물건」은 직접 항공기 등의 운행에 필요한 것뿐만 아니라 여객의 생활에 필요한 일체의 설비물도 포함하는 것으로 넓게 해석하는 것이 타당하다고 본다. 다만 물건 이외의 「방법」은 포함되지 아니한다. 또한 일시적 또는 우발적으로 선박·항공기·차량 또는 이들에게서 사용하는 기계·기구 등을 육상에서 수리 등을 하는 경우에 수리장치 또는 방법이 특허에 해당되거나 선박 또는 항공기에 적재된 특허물이 수입을 목적으로 하는 경우에 이들에 대하여 특허권의 효력이 미친다는 것은 당연하다.⁹⁵⁾

특허발명	제3자의 실시	침해 여부	비 고
A 제조방법 (方1)	方1 사용(∴ 시험을 위해)	×	제96조제1항제1호 해당
	方1의 사용에 의하여 생산된 A 판매	○	제2조제3호(다)목의 실시예 해당
A 제조장치 (裝1)	裝1의 사용(∴ 시험을 위해)	×	제96조제1항제1호 해당
	裝1의 사용에 의하여 생산된 A 판매	×	제2조제3호(가)목의 실시예 해당하지 아니함

93) 특허법원 2008. 12. 30. 선고 2008허4936, 서울남부지방법원 2001. 6. 15. 선고 2001카합1074.

94) 입법취지상 국외에서 품목허가를 받기 위한 목적의 연구·시험도 이에 해당한다(특허법원 2024. 12. 3. 선고 2023나10914).

95) 파리조약은 제5조의3에서 특허권의 효력이 제한되는 경우를 동맹국의 선박·항공기 등에 한정하고 있으나 특허법은 동맹국의 선박·항공기 등에 한정하지 않고 국내를 통과하는 모든 선박·항공기 등으로 규정하고 있어 파리조약 제5조의3보다 넓게 적용되므로, 동맹국 이외의 선박·항공기·차량도 본 규정의 적용을 받는다고 해석할 수 있다.

(3) 특허출원을 한 때부터 국내에 있는 물건

1) 특허출원을 한 때 이미 국내에 존재하고 있는 물건에까지 특허권의 효력이 미친다는 것은 법적 안정성을 현저하게 해칠 뿐만 아니라 그로 인하여 특허권자의 이익을 특별히 해친다고 보기 어려우므로 기존상태를 보호하려는 이 규정의 의의가 있다(法 96①Ⅲ).

2) 이 규정은 국내에 있는 물건이 특허출원을 한 때까지 비밀리에 존재하고 있는 경우뿐만 아니라 공연히 존재했을 때도 적용된다. 그러나 특허출원 전에 그 특허발명과 동일물이 국내에 공연히 존재했을 때는 신규성을 상실한 것이 되어 특허무효심판청구의 이유가 되며, 특허권이 무효가 되지 않더라도 물건의 소유자는 선사용권자로 되는 경우가 많으므로 실제 본 규정이 적용되는 경우는 해당 물건이 비밀상태에 있어서 신규성을 이유로 특허무효심판청구를 할 수 없거나 선사용권(法 103)의 요건에 해당되지 아니한 경우이다.

(4) 약사법에 의한 조제행위와 그 조제에 의한 의약

1) 둘 이상의 의약(사람의 병의 진단·치료·처치 또는 예방을 위해 사용되는 물건을 말한다. 이하 같다.)이 혼합되어 제조되는 의약의 발명 또는 둘 이상의 의약을 혼합하여 의약을 제조하는 방법의 발명에 관한 특허권의 효력은 약사법에 따른 조제⁹⁶⁾하는 행위 및 그 조제에 의한 의약에는 미치지 아니하도록 하고 있다(法 96②). 이 규정은 1987년 물질특허도입에 따른 보완으로서 사람의 보건위생은 모든 것에 우선하여 보호되어야 한다는 사고에 근거를 둔 규정이다.⁹⁷⁾

2) 「의약」은 반드시 사회적으로 의약으로서 인식될 것을 필요로 하지 않으며, 신규물질이라고 하더라도 약효가 있고 동시에 그 의약이 둘 이상의 의약을 혼합함으로써 조제된 것이면 의약에 해당한다. 다만 둘 이상의 화학물질 또는 의약을 화학반응시켜 얻어지는 의약이나 단일화학물질로서 되는 의약은 여기에서 말하는 둘 이상의 의약을 혼합함으로써 제조되어야 할 의약에는 해당하지 아니한다. 한편 약국이나 병원 등에서 제96조제2항에 해당하지 않은 의약, 예를 들어 단일화학물질로 된 의약을 환자에게 판매한 경우 특허권자 등으로부터 그 의약을 구매한 것이 일반적이므로 권리소진이 되어 특허권의 침해 문제가 발생하지 않는다.

4. 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권의 효력 제한

효력제한기간 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다(法 81의3④). 특허료 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 후 특허권 회복 전에 특허출원과 특허권이 소멸된 것으로 신뢰하고, 그 출원발명 또는 특허발명을 실시한 제3자를 보호하기 위한 취지이다.

96) 「조제」란 일정한 처방에 따라서 두 가지 이상의 의약품을 배합하거나 한 가지 의약품을 그대로 일정한 분량으로 나누어서 특정한 용법에 따라 특정인의 특정된 질병을 치료하거나 예방하는 등의 목적으로 사용하여도록 약제를 만드는 것을 말한다(약사법 제2조제11호).

97) 둘 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 조제하는 것은 의료인의 진료행위에 속하는 것이므로 국민 복지를 위하여 위와 같은 의료인의 조제행위에 대해서는 누구도 그 권리를 독점하지 않게 함으로써 결과적으로 의사 등이 환자의 상태에 따라 행하는 치료행위 또는 의사나 치과의사의 처방에 의한 약사의 조제행위의 자유를 해치지 않기 위한 것이다(특허법원 2004. 5. 21. 선고 2002허3962).

5. 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한

i) 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우, ii) 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우, iii) 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권 존속기간의 연장등록이 된 경우 및 iv) 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 i) 선의로 수출 또는 수입하거나 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건, ii) 선의의 실시행위 및 iii) 선의의 간접침해행위 중 어느 하나에 대해서는 미치지 아니한다(法 181). 이는 특허심판원의 확정된 특허취소결정 또는 심결을 신뢰한 자를 보호하기 위함이다.

6. 특허권의 하자에 의한 제한

(1) 문제의 소재

특허요건 흠결에도 불구하고 착오로 등록되었을 때 특허권의 하자를 이유로 i) 권리범위확인심판이나 특허침해소송에서 특허취소신청이나 특허무효심판을 거치지 않고 그 부분이 당연무효라고 할 수 있는지 여부, ii) 권리범위를 부정할 수 있는지 여부 및 iii) 권리행사를 제한할 수 있는지 여부가 문제이다.

(2) 당연무효인지 여부

특허권은 하자가 있더라도 특허취소신청의 취소결정이나 특허무효심판의 무효심결 확정에 의하여 소멸하기 전까지는 일용 유효한 권리로 보아 법적 안정성을 도모하여야 한다. 따라서 특허가 무효심결확정 등에 의하지 않고도 다른 절차에서 당연무효라고 할 수는 없다.⁹⁸⁾ 특허결정, 설정등록이라는 행정처분에 의해 발생한 특허권은 공정력(公定力)이 있기 때문이다. 일반적으로 하자있는 행정처분이 당연무효가 되기 위해서는 그 하자가 법규의 중요한 부분을 위반한 중대한 것으로서 객관적으로 명백한 것이어야 하는데, 지식재산처 심사관이 특허결정을 할 때에는 엄격한 선행기술의 조사, 거절이유의 통지 등의 절차를 거쳐 특허출원에 대하여 거절이유를 발견할 수 없는 때에 한하여 이루어지는 점, 특허요건 흠결 중에는 신규성 또는 진보성 결여와 같이 단순한 사실확정의 문제에서 나아가 법적 평가의 성격을 지니는 것들이 적지 않은데다가 대체로 그 판단이 반드시 자명하지는 아니한 점 등에 비추어 보면, 특허요건 흠결에 의한 특허권의 하자는 중대명백하다고 할 수 없는 것이다.⁹⁹⁾

98) 실용신안법은 실용신안등록이 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 실용신안등록의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 등록실용신안은 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 실용신안등록을 무효로 한다는 심결이 확정되지 아니하면 유효하며, 위와 같은 실용신안등록을 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 다른 절차에서 그 전체로서 실용신안등록이 당연무효라고 판단할 수 없다(대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095; 2000. 11. 10. 선고 2000후1283 등).

(3) 권리범위의 인정 여부

① 원 칙

하자가 있는 특허권이라도 원칙적으로 권리가 유효하면 권리범위가 인정된다. 다만 특허가 취소, 무효로 될 것이 명백함에도 불구하고 다른 절차에서 그 특허의 권리행사를 인정하여야만 한다면 오로지 침해 여부에만 관심을 가지는 당사자에게 공익의 대표자로서 특허취소신청이나 특허무효심판청구를 강요하는 결과가 될 뿐만 아니라 절차가 부당하게 지연되는 등의 문제점이 있어 학설과 판례는 일정한 경우에 특허권의 권리범위나 그 행사를 제한하는 방법 등으로 합리적인 해결을 모색하고 있다.¹⁰⁰⁾

② 특허발명의 신규성 위반의 경우

1) 특허법은 공개의 대가로서 특허권이라는 독점·배타권을 부여하기 때문에 새로운 발명을 공개시키지 않았음에도 불구하고 착오로 등록된 경우로서 특허발명이 공지기술과 문언적 동일하거나 내재적 동일성이 있는 경우 특허취소신청에 의한 취소결정이나 특허무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허권의 권리범위를 인정하지 않고 있다.¹⁰¹⁾ 또한, 특허발명이 공지기술과 실질적 동일성이 있는 경우에도 권리범위를 인정하지 않아야 한다. 예를 들어 공지기술이 하위개념발명이고 특허발명이 상위개념발명인 경우 특허발명은 신규성이 없어 특허를 받을 수 없지만, 착오로 등록되었으면 공지된 하위개념발명을 권리범위에서 제외함이 타당하다. 또한 공지기술이 제조방법발명이고 특허발명이 물건발명인 경우 특허발명은 신규성이 없어 특허를 받을 수 없지만, 착오로 등록되었으면 공지된 제조방법발명을 권리범위에서 제외함이 타당하다.

2) 문제가 되는 것은 청구항의 구성요소 중 일부가 공지기술일 때 권리범위의 해석이다. 대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45 전원합의체 판결은 “청구범위 일부에 공지사유가 있는 경우 그 공지기술이 신규의 발명과 유기적으로 결합되어 있으면 그 공지부분에까지 권리범위가 미치고, 신규의 발명에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대해서는 그 권리범위를 확장할 수 없다”라고 판시하여 신규의 발명과 유기적 결합 여부에 따라 보호범위의 확장 여부를 구별하는 입장을 취하고 있다. 대법판결은 보호범위의 해석원리 중 중심한정주의의 관점에 의한 판결로서 유기적 결합은 발명사상의 핵심을 추출하는 기준이라고 할 수 있다. 그러나 지금은 중심한정주의가 아닌 주변한정주의의 관점에서 보호범위를 해석하고 있기 때문에 판례의 논리가 타당하지 않다.

3) 주변한정주의의 관점에서 살펴보면, 복수의 구성요소로 이루어진 특허발명에 있어서 그 중 일부 구성요소가 공지된 경우, 각 구성요소가 독립하여 별개의 발명이 되는 것이 아니라 그 구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이고, 또한 여기에서 이들 구성요소를 분리하게 되면 그 발명의 목적달성은 불가능하게 되고, 이러한 공지의 구성요소가 나머지

99) 특허법원 2009. 2. 18. 선고 2007허12961 참조.

100) 최정열, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 405면.

101) 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체.

신규의 구성요소들과 유기적 결합관계를 이루고 있다고 하지 않을 수 없으므로, 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하는 데에도 공지된 부분을 제외하여서는 아니 된다.¹⁰²⁾ 따라서 유기적 결합 여부에 따라 보호범위의 확장 여부를 나누는 것은 잘못된 것이라고 할 수 있다.

4) 또한 주변한정주의의 발현이라고 할 수 있는 구성요소완비의 원칙에 의하면 대상판결과 같이 유기적으로 결합되지 않은 공지된 구성요소를 제외하고 신규의 구성요소에 의해서만 권리범위를 결정하는 경우 공지기술을 포함하여 권리범위를 결정하는 경우보다 권리범위가 오히려 넓어지는 기이한 결과가 발생한다.¹⁰³⁾

5) 결국 “일부 공지된 기술을 보호범위에서 제외한다”는 법리는 구성요소가 공지일 때 구성요소 자체를 권리범위에서 제외한다는 것이 아니라 그 기술적 사상을 구체화한 다수의 실시유형 중 공지된 실시유형을 그 권리범위에서 제외한다는 것으로 해석하여야 하는 것이 타당할 것이다.¹⁰⁴⁾

유형	특허요건 판단	침해 판단
(유형1) 특허발명이 공지기술과 문언적 동일/내재적 동일성 	공지 A+B와 출원된 발명 A+B는 동일하므로 신규성 위반임에도 불구하고 착오로 등록	취소신청이나 무효심판과 관계없이 제3자의 A+B 실시에 대해서 권리범위를 불인정
(유형2) 특허발명이 공지기술과 실질적 동일성 * A는 a1과 a2를 포괄하는 개념임	공지 a1+B와 출원된 발명 A+B는 동일하므로 신규성 위반임에도 불구하고 착오로 등록	취소신청이나 무효심판과 관계없이 제3자의 a1+B 실시에 대해서 권리범위를 불인정. 다만 a2+B 실시에 대해서는 권리범위를 불인정하되, 특허권자가 정정(심판)청구를 통해 취소사유, 무효사유를 극복하였을 때 권리범위를 인정하는 것이 타당
(유형3) 특허발명의 구성요소 일부가 공지기술 	공지 A와 출원된 발명 A+B는 동일하지 않기 때문에 신규성 위반이 아니고, 만약 A+B가 A로부터 용이하지 않다면 등록가능함	구성요소완비의 원칙에 따라 제3자의 B 실시는 권리범위에 속하지 않으나, A+B 실시는 권리범위에 속함

【그림 6-7】 특허발명이 공지기술과 동일한 경우 침해 판단의 예시

② 특허발명의 선출원주의, 확대된 선출원 위반의 경우

등록된 특허발명이 신규성이 없는 경우에는 그에 대한 등록무효심판 등이 없어도 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 특허무효사유에 있어서 신규성 결여와 선출원주의, 확대된 선출원 위반은 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 위 법리는 후출원발명에 선출원주의 위반¹⁰⁵⁾, 확대된 선출원 위반¹⁰⁶⁾의 무효사유가 있는 경우에도 그대로 적용된다.

102) 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617.

103) 특허 주변한정주의적 입장에서는 청구범위에 기재된 구성요소 전체에 의하여 보호범위를 정하며 구성요소가 공지이나 아니냐에 따라 해석에 강약은 둘 수 있으나 공지된 구성요소를 제외하는 것은 허용되지 아니한다.

104) 竹田和彦, 「特許の知識 理論と實際」, 제6판, 다이아몬드社, 1999, 381-383면 참조.

③ 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없거나 특허발명의 실시가 불가능한 경우

발명을 제대로 공개시키지 아니하여 공중의 이용 도모에 기여하지 않았음에도 불구하고 착오로 등록된 특허발명, 즉 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없거나¹⁰⁷⁾ 특허발명의 실시가 불가능한 경우¹⁰⁸⁾에는 특허무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전이라도 특허권의 권리범위를 부정함이 타당하다. 다만 청구범위 일부가 불명료하게 표현되어 있거나 그 기재에 오기가 있다 하더라도, 발명의 설명과 도면 등을 참작하여 볼 때 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 명확하게 이해할 수 있고 오기임이 명백하여 그 발명 자체의 보호범위를 특정할 수 있는 경우에는 특허의 권리범위를 부정할 수 없다.¹⁰⁹⁾

(4) 권리행사의 제한 여부

① 원 칙

특허권의 권리범위가 인정되면 정당한 권원 없이 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 제3자에 대해서는 특허권의 침해를 이유로 권리행사를 할 수 있다. 다만 권리행사 후 무효심결의 확정에 의하여 특허권이 소급하여 소멸한 경우 권리침해소송 등 민사소송의 확정 판결 혹은 침해죄의 확정판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다(民訴法 451①, 刑訴法 420⑥). 또한 특허권자가 무효심결의 확정 전에 특허권을 행사하여 고의 또는 과실로 타인에게 손해를 입혔으면 그 손해를 배상하여야 하며,¹¹⁰⁾ 고의 또는 과실에 의하지 아니한 경우에도 부당이득은 반환하여야 한다.

105) 대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827.

106) 특허법원 2009. 9. 18 선고 2009허2432.

107) 특허발명의 청구범위 기재나 발명의 설명, 그 밖의 도면의 설명에 의하더라도 특허출원 당시 발명의 구성요소 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다(대법원 1998. 10. 13. 선고 97후1344; 2002. 6. 14. 선고 2000후235).

108) 이 사건 등록고안은 실시가 불가능한 고안에 해당하여 그 권리범위를 인정할 수 없으므로, 확인대상고안은 이 사건 등록고안의 권리범위에 속할 여지가 없다(대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973 등).

109) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64.

110) 법적 분쟁의 당사자가 법원에 대하여 해당 분쟁의 종국적인 해결을 구하는 것은 법치국가의 근간에 관계되는 중요한 일이므로 재판을 받을 권리는 최대한 존중되어야 하고, 제소행위나 응소행위가 불법행위가 되는가를 판단할 때에는 적어도 재판제도의 이용을 부당하게 제한하는 결과가 되지 아니하도록 신중하게 배려하여야 할 것이고, 따라서 법적 분쟁의 해결을 구하기 위하여 소를 제기하는 것을 원칙적으로 정당한 행위이고, 단지 제소자가 패소의 판결을 받아 확정되었다는 것만으로 바로 그 소의 제기가 불법행위였다고 단정할 수 없으나, 반면 소를 제기당한 사람 쪽에서 보면, 응소를 강요당하고 어쩔 수 없이 그를 위하여 변호사 비용을 지출하는 등의 경제적·정신적 부담을 지게 되는 까닭에 응소자에게 부당한 부담을 강요하는 결과를 가져오는 소의 제기는 위법하게 되는 경우가 있을 수 있으므로, 민사소송을 제기한 사람이 패소판결을 받아 확정된 경우에 그와 같은 소의 제기가 상대방에 대하여 위법한 행위가 되는 것은 해당 소송에 있어서 제소자가 주장한 권리 또는 법률관계가 사실적·법률적 근거가 없고, 제소자가 그와 같은 점을 알면서 혹은 통상인이라면 그 점을 용이하게 알 수 있음에도 불구하고 소를 제기하는 등 소의 제기가 재판제도의 취지와 목적에 비추어 현저하게 상당성을 잃었다고 인정되는 경우에 한한다(대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513 등). 특히 이러한 행위가 부당하게 경쟁자를 배제하기 위한 것으로 인정되고, 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 경우에는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제23조제1항제2호(부당하게 경쟁자를 배제하는 행위) 위반으로서 같은 법에 의한 규제의 대상이 될 수도 있을 것이다(곽민섭, 「특허법 주해Ⅱ」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 59면).

② 예 외

1) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결은 “특허법은 제1조에서 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하여 발명자뿐만 아니라 그 이용자의 이익도 아울러 보호하여 궁극적으로 산업발전에 기여함을 입법목적으로 하고 있는 한편 제29조제2항에서 통상의 기술자가 특허출원 전에 공지된 선행기술에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것에 대해서는 특허를 받을 수 없다고 규정함으로써 사회의 기술발전에 기여하지 못하는 진보성 없는 발명은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역에 두고 있다. 따라서 진보성이 없어 본래 공중에게 개방되어야 하는 기술에 대하여 잘못하여 특허등록이 이루어져 있음에도 별다른 제한 없이 그 기술을 해당 특허권자에게 독점시킨다면 공공의 이익을 부당하게 훼손할 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같은 특허법의 입법목적에도 정면으로 배치된다. 또한 특허권도 사적 재산권의 하나인 이상 그 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 정의와 공평의 이념에 맞게 행사되어야 할 것인데, 진보성이 없어 보호할 가치가 없는 발명에 대하여 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 실질적 정의와 당사자들 사이의 형평에도 어긋난다.¹¹¹⁾ 이러한 점들에 비추어 보면, 특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다. 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다고 할 것이다”라고 판시하였다. 2010다95390 전원합의체 판결은 진보성이 부정되어 무효될 것이 명백한 경우라도 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 아니하면 특허발명의 보호범위는 부정되지 아니한다는 종래 대법원의 태도를 유지하면서도,¹¹²⁾ 종래 판결과 달리 i) 특별한 사정이 없는 한 그 권리행사를 제한하고 있다는 점, ii) 특허권침해소송을 담당하는 법원이 특허발명의 진보성 위반 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다는 점에 특색이 있다.¹¹³⁾

2) 「특별한 사정」이란 무효사유가 존재하더라도 정정심판, 정정청구에 의하여 그 무효사유를 극복할 수 있는 사정을 말한다. 다만 민사소송의 판결이 확정되거나 민사소송의 사실심 변론종결

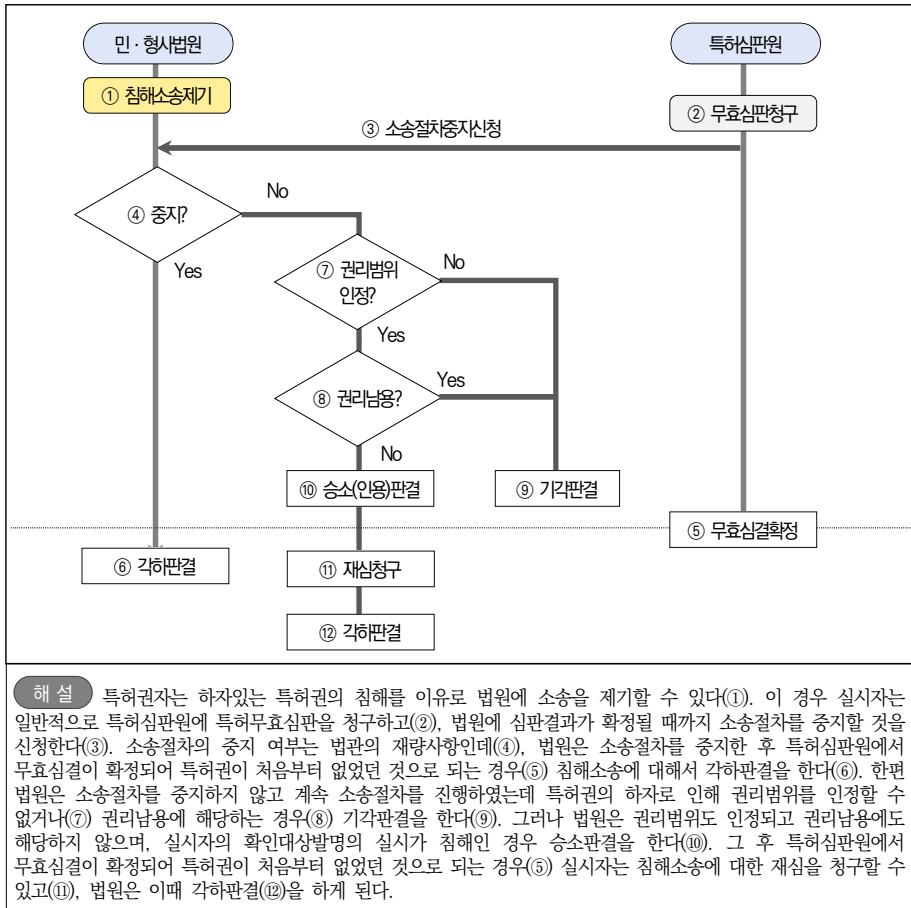
111) 예를 들어 진보성이 없음에도 불구하고 권리행사를 인정하면 특허침해소송에서도 무효심결이 확정될 때까지 소송절차를 중지하지 아니하면 특허발명을 유효한 것으로 취급하여 청구를 인용하여야 하는 경우가 생길 수 있는데, 이런 혼란은 소송 경제상 바람직하지 않다.

112) 특허침해소송 등을 담당하는 법원이 진보성 결여라는 무효사유에 대하여 심리판단 할 수 있는지에 관하여는 당초 이를 부정하는 대법원판결(대법원 1992. 6. 2. 선고 91마540 등)과 이를 긍정하는 대법원판결(대법원 1991. 10. 25. 선고 90후2225; 1997. 7. 22. 선고 96후1699; 1997. 8. 22. 선고 97후68 등)이 나뉘어져 있었으나, 대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095 판결 이래로는 진보성 결여에 대해서는 심리판단할 수 없고, 그 결과 진보성 결여라는 이유로 보호범위를 부정할 수 없다는 입장을 유지하여 오고 있었다.

113) 한규현, 「특허법 주해 I」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 1125면. 종래의 대법원 판례와 차이점을 비교하면 다음과 같다.

후에 확정된 정정심결을 토대로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용할 수 없다.¹¹⁴⁾

3) 한편 i) 특허무효사유 중 어느 범위까지 판단할 수 있는지, ii) 어떠한 경우에 특허무효사유가 명백하다고 할 수 있는지 등에 대해서는 세부적인 기준이 제시되어야 할 것이다.



【그림 6-8】 하자있는 특허권에 의한 권리행사

진보성 위반	종전 판례 (대법원 97후2095 등)	최근 판례 (대법원 2010다95390)
권리범위 부정 여부	×	×
침해소송에서 진보성 심리가능 여부	×	○
권리행사 가능 여부	○	△ (무효로 될 것이 명백하고 특별한 사정이 없는 경우 권리남용으로 불가능)

114) 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체.

7. 자유기술에 의한 제한

(1) 의 의

1) 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하는 경우 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않게 된다.¹¹⁵⁾ 침해소송이나 권리범위확인심판에서 실시자가 이를 이유로 항변하는 것을 「자유기술의 항변」이라 한다. 자유기술의 항변은 특허권의 권리범위 자체를 부정하는 것이 아니라 특허권과의 대비 이전에 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 자유기술의 영역까지 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것이므로, 확인대상발명이 특허권의 독점·배타적인 효력이 미칠 수 없는 자유기술의 영역(public domain, 이를 “공공영역”이라고도 함)에 속함을 이유로 항변하는 것이다.

2) 침해소송이나 권리범위확인심판에서 특허발명의 진보성이 없더라도 권리범위를 부정할 수 없는데,¹¹⁶⁾ 자유기술의 항변에 의하면 비교대상을 공지기술과 특허발명이 아닌 공지기술과 확인대상발명으로 비함으로써 특허발명의 권리범위를 부정하지 않고서도 신속하고 합리적인 분쟁해결을 꾀할 수 있다. 특허심판원, 법원에서는 자유기술의 항변이 있는 경우 특허발명과 대비 이전에 확인대상발명이 자유기술인지 여부를 먼저 판단하여야 한다.

(2) 자유기술의 항변에서의 확인대상발명

자유기술에서 확인대상발명을 파악할 때 확인대상발명을 특허발명과 대응되는 구성만으로 이루어진 발명으로 파악되어야 하는지(대응 구성설)¹¹⁷⁾ 아니면 특허권자가 특정한 대응제품의 구성 전체로 파악되어야 하는지(전체 구성설)¹¹⁸⁾ 문제가 되어 왔다. 이에 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64 판결에서는 “확인대상고안을 등록실용신안의 청구범위에 기재된 구성과 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판청구인이 특정한 확인대상고안의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다”라고 판시하여 전체 구성설을 지지하였다.¹¹⁹⁾ 이는 확인대상발명의 진보성을 판단할 때도 특허발명의 진보성 판단과 마찬가지로 각 구성요소가 결합된 전체로서의 기술사상이 그 대상이 되는 것이고 각 구성요소가 독립하여 그 대상이 되는 것은 아니므로, 확인대상발명의 구성요소를 인위적으로 분리해서는 안 되기 때문이다.¹²⁰⁾ 전

115) 대법원 2001. 12. 11. 선고 99후62; 2001. 10. 30. 선고 99후710 등

116) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체; 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 등 참조.

117) 특허법원 1998. 9. 4. 선고 98허4722; 2004. 11. 25. 선고 2004허2239.

118) 특허법원 2007. 4. 20. 선고 2006허510; 2007. 8. 24. 선고 2007허1541.

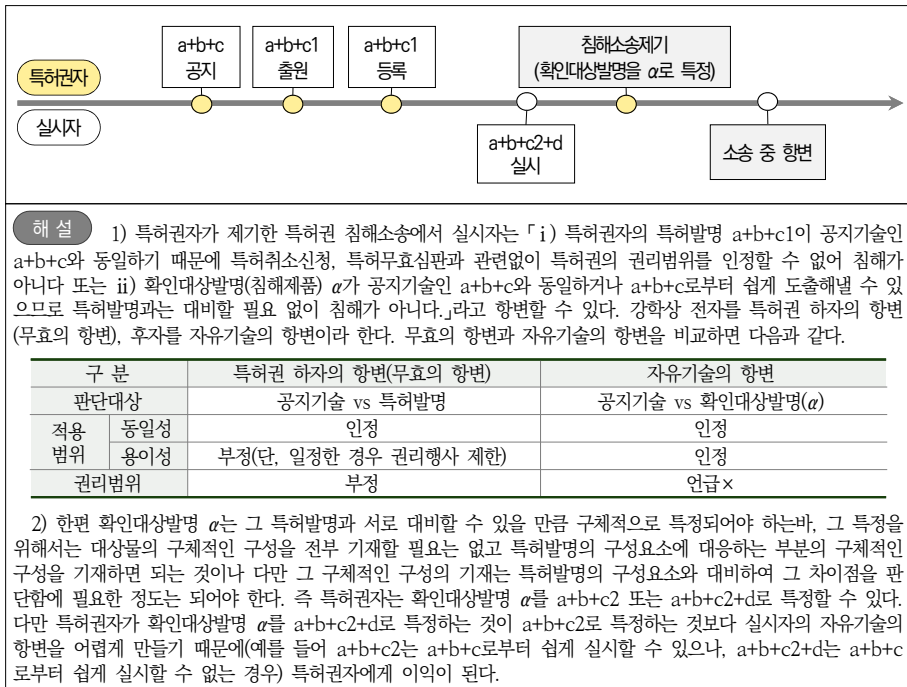
119) 특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허4523 판결에서도 간접침해에 있어서 자유기술의 항변의 대상이 되는 확인대상발명을 직접침해와 마찬가지로 특허권자가 특정한 대응제품의 구성 전체로 봐야 한다는 전체 구성설을 지지하고 있다.

120) 다만 대응구성설의 입장에서 보면, i) 확인대상발명은 제140조제3항에 규정된 “특허발명과 대비될 수 있는 설명서 및 필요한 도면”이 아닌 그 설명서 및 필요한 도면에 기재된 발명 중 “특허발명과 대비되는 구성들로 이루어진 발명”이라는 점, ii) 제3자가 자유기술임을 증명하는 경우 특허발명과 대응되는 구성으로 이루어진 발명에 대해서만 그 발명이 공지이거나 진보성이 없어 누구나 사용할 수 있는 자유기술이라는 것을 증명하면 되는 것이지, 특허발명과 직접 대응되지도 아니하고, 특허발명과 대응되는 발명의 작용, 효과 등을 설명하기 위해 추가적으로 적은 나머지 구성들을 포함한 발명, 또는 실시물 전체에 대해서까지 신규성, 진보성 여부를 증명하여야 하는 것은 제3자에게 가혹하다는 점(권리자가 확인

체 구성설에 의하면, 특허권자는 확인대상발명을 특허발명과 대응되는 구성 이상으로 구체적으로 특정함으로써 항변의 남용을 자제시킬 수 있게 된다.

(3) 자유기술 항변의 적용범위

자유기술의 항변은 특허발명과 대비 이전에 확인대상발명의 실시가 자유기술의 영역에 속함을 이유로 항변하는 것이기 때문에 확인대상발명을 특허발명과 대비하여 구성요소완비의 원칙에 의한 문언침해, 균등론에 의한 균등침해이든 상관없이 적용된다.¹²¹⁾ 예를 들어 공지기술이 $A+B+C1$ 이고, 특허발명이 $A+B+C2$ 인데, 제3자가 $A+B+C2$ 인 확인대상발명을 실시하고 있는 경우에 권리범위확인심판에서 제3자는 특허발명($A+B+C2$)이 공지기술($A+B+C1$)로부터 용이하기 때문에 권리범위에 속하지 않는다고 할 수는 없으나, 제3자가 실시하고 있는 확인대상발명($A+B+C2$)이 공지기술($A+B+C1$)로부터 용이하기 때문에 공공영역에 속하여 권리범위에 속하지 않는다는 항변을 할 수 있다.



【그림 6-9】 공지기술과 관련된 무효의 항변과 자유기술의 항변의 비교

대상발명을 어떻게 특정하느냐에 따라 자유기술의 증명 정도가 달라지게 됨) 등에 대한 비판이 있을 수 있다(이영창, “자유실시기술이 되어야 하는 확인대상발명”, 지식재산21, 2009년 7월, 97-106면 참조).

121) 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366).

(4) 공지예외적용주장과 자유기술의 항변

출원 전 공지가 되었는데 공지예외적용주장을 하여 등록된 특허발명에 대하여 제3자가 그 공지를 근거로 자유기술의 항변을 할 수 있는지 문제가 될 수 있다. 이는 공지예외적용주장이 적법하였을 때 공지가 안 된 것으로 간주한다는 그 효과를 특허된 발명뿐만 아니라 제3자가 실시하고 있는 확인대상발명에도 적용할 수 있느냐의 문제로 귀착된다. 비록 제30조 규정이 형식적으로는 제29조제1항의 신규성 또는 제2항의 진보성 판단을 하는 특허발명을 적용대상으로 하고 있으나, i) 자유기술의 항변을 인정한다면 공지예외적용주장을 하여 등록된 특허는 실질적으로 권리행사를 할 수 없게 되어 공지예외적용주장제도의 취지를 몰각시키고 제도를 형해화한다는 점, ii) 자유기술의 항변은 애당초 특허를 받을 수 없는 공공영역에 대해서 권리범위를 인정하지 않겠다는 것인데, 시기적, 절차적 요건 등을 지키면서 공지예외적용주장을 하였다면 입법적 결단을 통해 공공영역이 독점배타적인 특허를 받을 수 있는 영역에 편입되어 더 이상 공공영역이 아니라는 점, iii) 공지된 발명에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 특허권자와의 형평을 도모하기 위하여 인정되는 선사용에 의한 통상실시권(法 103)을 넘어서는 무상의 실시권한을 부여하는 것은 온당치 않다는 점 등 공지예외적용규정의 문언내용과 입법취지, 자유기술 법리의 본질 및 기능, 다른 규정(선사용권)과의 형평성 등을 종합하여 보면, 확인대상발명에 대해서도 그 효과가 적용된다고 봄이 타당하다.¹²²⁾ 즉 공지예외적용주장을 하여 특허를 받은 경우 공지예외적용주장의 대상이 된 공지에 대해서는 자유기술의 항변을 부정하여야 한다.¹²³⁾

8. 권리남용에 의한 제한

(1) 의 의

민법 제2조에는 “권리는 남용하지 못한다”라고 규정되어 있다. 권리남용이란 권리 자체는 유효한 것을 전제로 그 권리의 행사가 외관상으로 적법한 것으로 보이지만 권리의 사회적경제적 목적 또는 사회적으로 허용되는 한계를 일탈한 것일 때 이에 대한 법적 보호를 부정하는 것을 말한다.¹²⁴⁾ 특허권도 남용하였을 때 그 법적 보호를 부정하면서 소극적 효력을 제한하고 있는데 구체적으로 i) 특허법 규정에 의한 제한, ii) 판례의 의한 제한, iii) 타법에 의한 제한으로 구분될 수 있다.

(2) 특허법 규정에 의한 제한

① 실시의무에 의한 제한

1) 특허권자가 스스로 특허발명을 실시할 의무를 말한다. 특허발명의 실시의무는 권리남용 금지의 특허법상 표현으로서, 특허법은 발명공개의 대가로 특허권을 부여하고 그 공개된 발명의

122) 대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012.

123) 대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562.

124) 박윤직, 「민법주해(I)-총칙(1)」, 박영사, 2000, 183면.

적절한 실시를 통하여 산업발전에 기여하려는 특허법의 목적을 달성하기 위해 실시하지 아니한 경우 제재조치를 두고 있다. 즉 특허법은 「권리 위에서 잠자는 것」을 묵인하지 아니한다.

2) 파리조약에 의하면 특허발명의 실시를 확보하는 방법은 특허발명의 불실시 또는 불충분한 실시에 대하여 강제실시권(compulsory License)을 허락하는 방법과 특허권을 취소(revocation)하는 방법이 있다. 특허법은 이를 반영하여 불실시에 대한 제재인 재정에 의한 강제실시권(法 107)와 특허권의 취소(法 116)¹²⁵⁾를 인정하고 있었다.¹²⁶⁾ 그러나 특허권의 취소(法 116)에 관한 규정은 2012. 3. 15. 시행된 현행법(법률 제11117호, 2011. 12. 2. 개정)에서 삭제하였다. 이는 i) 개인의 재산권을 침해한다는 비판이 있었고, ii) 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환」을 국내법에 반영하기 위해서이다.

② 실시협조의무에 의한 제한

1) 특허제도는 발명의 보호와 함께 발명의 이용을 통한 산업발전의 이바지를 목적으로 하고 있으므로 특허권자는 그 특허발명을 실시하려는 자에게 정당한 이유가 없는 한 실시협조를 하여야 할 의무가 있다. 실시협조의무 역시 권리남용금지의 특허법상 표현이다.

2) 특허발명이 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인과 이용관계에 있거나 타인의 디자인권과 저촉관계에 있을 때 후출원 권리자가 실시권의 허락을 청구할 경우에 선출원 권리자는 정당한 이유가 없는 한 후출원 권리자에게 실시권을 허락하여 실시에 협조를 하여야 한다. 만약 이용·저촉관계에 있는 선출원 권리자가 정당한 이유없이 실시허락을 하지 않을 경우 후출원 권리자는 특허권자의 실시협조의무 위반을 이유로 통상실시권허락심판을 청구하여 강제적으로 실시권을 허락받을 수 있다(法 138).

3) 재정제도(法 107)와 관련하여서도 특허권자의 실시협조의무가 요구된다. 즉 국내에 특허발명을 실시하려는 자가 있는데도 불구하고 정당한 이유없이 실시협조를 하지 아니함으로써 국내산업에 불이익을 끼칠 때는 특허권자의 권리남용 법리를 원용하여 그 특허권을 재정실시권의 대상으로 하고 있다.

(3) 판례에 의한 제한

① 일 반

1) 우선 민법상 권리남용에 해당하기 위한 요건을 살펴보면, i) 행사할 권리가 존재하여야 하고, ii) 권리행사라고 할 수 있는 행위가 있어야 하며, iii) 권리행사 자의 이익과 그로 인해 침해되는 상대방의 이익 사이에 현저한 불균형이 있어야 한다. 「현저한 불균형」이 있는지는

125) 특허청장(현재 지식재산청장)은 불실시를 이유로 재정이 있는 날부터 계속하여 2년 이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있다.

126) 파리조약 제5조A(2)(3)에서는 “각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타권 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있으며, 강제실시권의 부여가 그러한 남용을 방지하기에 충분하지 아니하면 특허의 몰수 또는 철회를 규정할 수 있다”라고 규정하고 있는데, 이를 반영한 규정이 제107조제1항제1호, 제2호 및 제116조이다.

양자의 이익을 단순히 양적으로 비교하는 것으로 그치는 것이 아니고 각개 권리의 보호이익과 구체적 사건에서의 여러 사정을 종합적으로 고려하여 비교형량할 것이 요구되며, 신의성실의 원칙, 공공복리, 공평의 이념, 사회의 윤리관념, 공서양속과 도의, 사회질서, 정의, 권리의식, 권리의 경제적·사회적 목적 등을 기준으로 판단하여야 한다.¹²⁷⁾ 이와 관련하여 대법원¹²⁸⁾은 “주관적으로 그 권리행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는 데 있을 뿐 행사하는 사람에게 아무런 이익이 없는 경우이어야 하고, 객관적으로는 그 권리행사가 사회질서에 위반된다고 볼 수 있어야 한다”라고 하여 주관적 요건과 객관적 요건을 만족해야 한다는 입장이다.

2) 그러나 특허권의 행사에 있어서 권리남용은 민법과 달리 가해의사(加害意思)와 같은 주관적 요건은 필요하지 않다는 입장이다.¹²⁹⁾ 즉 특허권은 사권임과 동시에 공권임을 고려할 때 민법상 권리남용의 법리를 벗어나 특허권 고유의 남용 논리를 바탕으로 공공의 이익을 고려한 법리상 제한이 폭넓게 인정되고 있다.¹³⁰⁾

② 하지있는 특허권에 의한 권리행사의 제한

앞서 살펴본 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결은 “특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 한다”라고 판시하였다. 대법판결은 사안마다 제각각인 사실들을 법관이 신중적으로 평가한 뒤 권리자에게 통상 기대되었던 법적효과를 이례적으로 부정함으로써 당해 사안에서 구체적인 형평을 꾀하고자 하는 민법상 권리남용 이론의 일반적인 모습과는 완전히 대조적인 것으로서, 특허의 진보성 위반이 명백하고 특별한 사정이 없다면 확일적으로 권리남용에 해당한다는 것이다.¹³¹⁾

③ 장기간 행사하지 않았던 특허권에 의한 권리행사의 제한

특허권자가 상당한 기간 권리를 행사하지 아니하여 침해의 대항을 받는 자에 대하여 앞으로도 그 권리를 행사하지 않겠다는 확신을 주고 침해의 대항을 받는 자도 이에 따라 행동한 경우,

127) 관윤직, 「민법주해(I)-총칙(1)」, 박영사, 2000, 191-192면.

128) 대법원 1998. 6. 26. 선고 97다42823; 2003. 2. 14. 선고 2002다62319, 62326 등.

129) 상표권의 행사가 권리남용에 해당하는지와 관련하여서는 대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223 판결에서는 “상표권자가 그 상표를 출원·등록하게 된 목적과 경위, 상표권을 행사하기에 이른 구체적·개별적 사정 등에 비추어, 상대방에 대한 상표권의 행사가 상표사용자의 업무상의 신용유지와 수요자의 이익보호를 목적으로 하는 상표제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 상거래질서를 어지럽히고 수요자 사이에 혼동을 초래하거나 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 상표권의 행사는 가사 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 상표권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 상표권 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다”라고 판시하였다.

130) 차상욱, “특허 침해소송과 권리남용항변”, 정보법학 제11권 제2호, 한국정보법학회, 2007, 169-170면 참조.

131) 박준석, “무효사유 있는 특허권에 기한 권리행사와 권리남용”, (사)한국지식재산학회, 「특허 침해소송의 이론과 실무」, 법문사, 2016, 395면.

특허권자가 이 확신에 반하여 새삼스럽게 권리를 행사하는 것은 신의성실의 원칙에 반하여 허용되지 아니한다는 실효의 항변이 인정되는지 문제이다. 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다 48272 판결에서는 “등록고안이 등록된 지 6년가량 지나서야 실용신안권을 행사하였다 하여 권리자가 고의로 그 권리행사를 게을리하였다고 단정하기도 어렵거니와, 가사 권리자가 권리행사를 게을리함으로써 실용신안권의 침해행위가 그 기간만큼 가능하게 되었다고 하더라도, 위 침해행위가 권리자가 권리행사를 게을리한 것에 의하여 유발된 것이 아니어서 그 권리행사를 게을리한 것이 침해행위로 인한 손해의 발생 또는 그 확대의 한 원인이 되었다고 볼 수는 없을 것이고, 권리자가 권리행사를 게을리하였다는 사유를 들어 침해행위로 인한 손해배상책임을 제한하는 것이 공평 또는 신의칙의 견지에서 타당하다고 할 것도 아니다”라고 하여 특허권에 대하여 실효의 항변을 인정하는 범위를 좁게 보고 있다.¹³²⁾ 한편 대법원 2005. 10. 28. 선고 2005다 45827 판결은 “일반적으로 권리의 행사는 신의에 좇아 성실히 하여야 하고 권리는 남용하지 못하는 것이므로 i) 권리자가 실제로 권리를 행사할 수 있는 기회가 있었음에도 불구하고 상당한 기간이 경과하도록 권리를 행사하지 아니하여 ii) 의무자인 상대방으로서도 이제는 권리자가 권리를 행사하지 아니할 것으로 신뢰할 만한 정당한 기대를 가지게 된 다음에 iii) 새삼스럽게 그 권리를 행사하는 것이 법질서 전체를 지배하는 신의성실의 원칙에 위반하는 것으로 인정되는 결과가 될 때에는 이른바 실효의 원칙에 따라 그 권리의 행사가 허용되지 아니한다고 보아야 할 것이고, 또한 실효의 원칙이 적용되기 위하여 필요한 요건으로서의 실효기간(권리를 행사하지 아니한 기간)의 길이와 의무자인 상대방이 권리가 행사되지 아니하리라고 신뢰할 만한 정당한 사유가 있었는지의 여부는 일률적으로 판단할 수 있는 것이 아니라 구체적인 경우마다 권리를 행사하지 아니한 기간의 장단과 함께 권리자측과 상대방측 쌍방의 사정 및 객관적으로 존재한 사정 등을 모두 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단하여야 할 것이다”라고 하여 실효의 항변을 적용하기 위한 요건을 제시하고 있다.

④ 표준필수특허에 대하여 FRAND 선언한 특허권자의 권리행사 제한

표준필수특허¹³³⁾의 특허권자가 FRAND(Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)

132) 김기영, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 40-44면 참조.

133) 표준필수특허는 표준기술을 구현하기 위하여 반드시 실시되어야 하는 특허를 말한다. 표준기술은 기술간 호환성을 높여 경제적 효율성을 창출하고, 관련 기술의 이용과 개발을 촉진한다는 점에서 산업 정책적으로 그 필요성이 강조된다. 그러나 표준기술은 관련 시장에서 막대한 영향력을 행사할 수 있게 되고, 일단 표준으로 선정된 기술을 다른 기술로 대체하는 데는 상당한 전환비용이 소요되어 이러한 영향력은 장기간 지속될 수 있다. 특히 표준기술이 배타적·독점적 특성을 갖는 특허권으로 보호받을 때는 관련 시장에 심각한 경쟁제한 효과를 초래할 수도 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 많은 표준화 기구들은 표준기술 선정에 앞서 관련된 특허 정보를 미리 공개하도록 하고(적시 공개 의무), 표준기술로 선정될 기술이 특허권으로 보호받을 때는 공정하고, 합리적이며, 비차별적인(FRAND: Fair Reasonable And Non-Discriminatory) 조건으로 실시허락할 것을 사전에 협의(FRAND 선언 의무)하도록 하고 있다. 이와 같은 특허 정보 공개와 실시조건 협의 절차는 표준필수특허권의 남용을 방지한다는 측면에서 그 필요성이 강조되며, 해당 절차의 이행 여부는 표준필수특허권 행사의 부당성을 판단할 때 중요한 고려 사항이 된다. 일반적으로 표준기술 선정을 위한 협의와 표준필수특허권의 행사는 관련 기술의 이용을

선언을 위반한 것인지가 문제된 사안으로, 특허권의 행사 자체에 대하여 권리남용의 항변을 인정할 것인지와 관련하여 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552 판결에서는 “특허권은 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 배타적인 권리로서, 특허발명의 실시에 대한 독점적 권리를 부여함으로써 발명을 보호·권장하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지하려는 것인데, 특허권도 기본적으로는 사적 재산권의 성질을 가지지만 그 보호범위는 필연적으로는 사회적 제약을 받는다고 할 것인바, 상대방에 대한 특허권의 행사가 특허제도의 목적이나 기능을 일탈하여 공정한 경쟁질서와 거래질서를 어지럽히고 수요자 또는 상대방에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위배되는 등 법적으로 보호받을 만한 가치가 없다고 인정되는 경우에는, 그 특허권의 행사는 설령 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록특허에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없고, 특허권의 행사를 제한하는 위와 같은 근거에 비추어 볼 때 특허권의 행사의 목적이 오직 상대방에게 고통을 주고 손해를 입히려는데 있을 뿐 이를 행사하는 사람에게는 아무런 이익이 없어야 한다는 주관적 요건을 반드시 필요로 하는 것은 아니다”라고 하면서, i) FRAND 선언은 특허권자에게 실시허락계약의 체결과 관련하여 FRAND 조건으로 성실하게 협상할 의무 등을 부담시키는 일반 원칙을 선언하는 것이므로, FRAND 선언이 곧바로 불특정의 제3자에게 해당특허에 대하여 자동적으로 실시권을 부여하기로 하는 것 또는 구속력 있는 취소불가능한 실시권 허락을 확약한 것에 해당한다거나, 해당 특허를 사용한 자 또는 사용하려는 자가 FRAND 선언에 의하여 당연히 실시권을 취득한 것으로 볼 수는 없고, 특허권자는 FRAND 선언을 통해 곧바로 제3자에게 실시권을 허락하는 것이 아니라 ‘FRAND 조건에 의한 실시권 허락’이라는 제한을 수용하는 의사표시를 한 것에 불과하며, ii) FRAND 선언이 있었다는 사정만으로 실시권을 허락받지 않은 채 임의로 표준필수특허를 실시하는 제3자에게 침해금지청구권을 행사하는 것까지 포기한 것이라고 해석할 수 없으므로, 표준필수특허에 대하여 실시권 허락 요청 없이 무단으로 실시하고 있거나 표준필수특허의 유효 여부나 침해 여부를 부인하면서 표준필수특허를 실시하고 있는 제3자에게 특허권에 기하여 침해금지 등을 구한다고

촉진하고, 효율성 창출을 통해 소비자 후생 증대에 기여할 수 있다는 점에서 친경쟁적인 효과를 발생시킬 수 있다. 그러나 다음과 같이 표준화 절차를 악용하거나, 표준기술로 채택된 이후 부당한 조건을 제시하는 등의 행위는 특허권의 정당한 권리범위를 벗어난 것으로 판단할 수 있다(공정거래위원회, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(공정거래위원회예규 제333호) III.5. 참조).

- i) 표준기술 선정을 위한 협의과정에서 이와 관련된 거래가격·수량, 거래지역, 거래상대방, 기술개량의 제한 등의 조건에 부당하게 합의하는 행위
- ii) 표준기술로 선정될 가능성을 높이거나 실시조건의 사전 협상을 회피할 목적 등으로 부당하게 자신이 출원 또는 등록한 관련 특허 정보를 공개하지 않는 행위
- iii) 관련 시장에서의 독점력을 강화하거나 경쟁사업자를 배제하기 위하여 FRAND 조건으로의 실시허락을 부당하게 회피, 우회하는 행위
- iv) 부당하게 표준필수특허의 실시허락을 거절하는 행위
- v) 부당하게 표준필수특허의 실시조건을 차별하거나, 비합리적인 수준의 실시료를 부과하는 행위
- vi) 표준필수특허의 실시허락을 하면서 실시권자가 보유한 관련 특허권의 행사를 부당하게 제한하는 조건을 부과하거나 부당하게 실시권자가 보유한 비표준필수특허에 대한 상호실시허락의 조건을 부과하는 행위

하더라도 금반언의 원칙에 반한다거나 권리남용에 해당한다고 할 수 없다고 하였다.¹³⁴⁾ 현재 공정거래위원회에서는 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」에서 대상판결을 더욱 구체화하여 표준필수특허에 대하여 FRAND 선언한 특허권자의 권리행사가 그 남용에 해당하여 공정거래법에 적용을 받는지에 대한 지침을 제공하고 있다.¹³⁵⁾

(4) 타법에 의한 제한

① 공정거래법 제59조

공정거래법 제59조에 의하면 “이 법의 규정은 저작권법, 특허법, 실용신안법, 디자인보호법 또는 상표법에 의한 권리의 정당한 행사라고 인정되는 행위에 대하여는 적용하지 아니한다”라고 규정되어 있다. 다만 이 규정이 경쟁질서의 유지라는 공정거래법의 법 목적달성을 불가능하게 할 정도로 특허권을 남용하는 행위(지식재산권의 부당한 행사)까지 배제하는 것은 아니다. 「특허권을 남용하는 행위」란 행위의 외형상 특허권의 행사로 보이더라도 그 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 경우를 의미하고, 여기에 해당하는지는 특허법의 목적과 취지, 해당 특허권의 내용과 아울러 해당 행위가 공정하고 자유로운 경쟁에 미치는 영향 등 제반 사정을 함께 고려하여 판단하여야 한다.¹³⁶⁾ 공정거래위원회는 공정거래법 제59조와 관련하여 지식재산권의 행사가 정당한 것인지를 판단하는 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침」을 마련하고 부당한 행사에 해당하는 유형을 예시하고 있다.

② 특허권 남용과의 관계

특허권 남용은 공정거래법 위반보다 광범위한 불법행위이기 때문에 공정거래법 위반이 아니어도 특허권 남용이 될 수 있다.¹³⁷⁾ 특허권 남용에 해당하는지는 특허법 내에서 판단하게 되고, 특허권 남용이 인정되면 그로 인해 관련 시장에서의 독점적 시장지배력 확보나 공정한 경쟁질서

134) 송재섭, “표준필수특허에 근거한 권리행사의 한계 - 침해금지청구권과 손해배상청구권을 중심으로 -”, 저스티스, 통권 제140호, 2014, 223-226면 참조.

135) 공정거래위원회, 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(공정거래위원회예규 제333호) III.5. 참조. 예를 들어 다음과 같이 규정되어 있다.

“표준특허권자가 성실하게 협상의무를 이행하지 않고 침해금지청구를 하는 행위는 부당한 행위로 판단될 가능성이 크다. 표준필수특허권자가 성실하게 협상의무를 이행했는지를 판단함에 있어서는 i) 잠재적 실시권자에게 공식적으로 협상을 제안했는지 여부, ii) 잠재적 실시권자와의 협상기간이 적절했는지 여부, iii) 잠재적 실시권자에게 제시한 실시허락 조건이 합리적, 비차별적인지 여부, iv) 실시허락 조건에 합의하지 못하는 경우 법원이나 중재기관에 회부하기로 했는지 여부 등을 고려할 수 있다. 그러나 실시허락을 받을 의사가 없는 잠재적 실시권자(unwilling licensee)에 대한 표준필수특허권자의 침해금지청구가 허용되지 않는 경우 잠재적 실시권자가 성실하게 협상하지 않거나 실시로 지급을 지연 또는 회피하는 역 특허억류(reverse hold-up)가 발생할 수 있다. 또한 특정한 경우에는 침해금지청구만이 표준필수특허권자의 유일한 권리구제 수단이 될 수도 있다. 따라서 i) 잠재적 실시권자가 법원이나 중재기관의 결정에 따르기는 거절하거나, FRAND 조건에 관한 구체적인 내용이 법원이나 중재기관의 사건처리 과정에서 확인되는 등 객관적으로 드러난 상황에서 FRAND 조건으로의 실시계약 체결을 거부하는 경우, ii) 잠재적 실시권자가 파산이 임박하는 등의 사유로 인하여 손해배상을 기대하기 어려워 침해금지청구만이 유일한 구제수단으로 인정되는 경우에는 표준필수특허권자의 침해금지청구가 부당한 행위로 판단될 가능성이 적다.”

136) 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498.

137) 정승복, 「해의특허분쟁 가이드북(제2판)」, 세창출판사, 2010, 243면.

훼손 등 경쟁법적 효과까지 발생하였는지를 고려하여 공정거래법 위반 여부를 판단하게 된다. 특허권의 행사가 특허권 남용으로 인정되면 권리행사의 효과가 부정되는 것에 그침에 반해, 공정거래법 위반에 해당하면 특허권자는 시정조치, 과징금 및 민형사상 책임을 지게 된다.¹³⁸⁾

제4관 효력의 확장

특허법은 특허권의 침해가 쉬운 반면 침해사실의 발견이 어려운 점을 고려하여 특허권의 효력이 실질적으로 감소하는 것을 방지하고 특허권자를 보호하기 위해 소극적 효력을 확장하여 특허발명의 실시가 아닐지라도 침해로 보는 행위로 간주하면서 특허발명의 보호범위에 속함을 인정하고 있다. 구체적으로 i) 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, ii) 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권을 침해한 것으로 본다(法 127). 이에 대해서는 「제6편 제3장 제5절 제5관 간접침해」에서 후술한다.

제3절 특허발명의 보호범위

제97조 【특허발명의 보호범위】

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다.
[전문개정 2014.6.11.]

제1관 서 설

1) 「특허발명의 보호범위」란 제3자의 침해로부터 보호하기 위해 특허권의 소극적 효력이 미치는 영역을 말한다. 특허권은 특허권자가 독점적으로 실시할 수 있는 적극적 효력과 타인의 실시를 배제할 수 있는 소극적 효력이 병존하는데, 이 중 소극적 효력이 미치는 범위를 특허발명의 보호범위라고 한다.¹³⁹⁾ 특허발명의 보호범위는 제97조에서 해석의 기준을 제시하고

138) 강명수, “특허권 남용에 대한 고찰”, (사)한국지식재산학회, 「특허 침해소송의 이론과 실무」, 법문사, 2016, 366-367면.

139) 보호범위는 권리범위라는 용어와 일반적으로 혼용되어 사용되고 있다. 권리범위의 정의가 명확하지는 않으나, 「권리범위」란 권리가 인정되는 범위로서 특허권의 효력이 미치는 범위를 말하는 것으로서, 특허권자가 실시할 수 있는 전용권의 범위와 타인의 실시를 배제할 수 있는 배타권의 범위를 총칭하는 개념이라고 할 것이다. 이에 반하여 특허발명의 보호범위는 발명이 보호되는 범위를 말하는 것으로서 배타권의 범위만을 의미한다고 할 것이다. 양자가 혼용되어 사용되는 것은 구별의 실익이 그리 크지 않기 때문인 것으로 보이며, 본 서에서도 혼용해서 사용하기로 한다.

있을 뿐이므로 그 판단은 학설, 판례 및 경험칙 등에 맡기고 있다. 구체적으로 제97조에서는 “특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다”라고 규정되어 있다. 이 규정은 특허발명의 보호범위를 정할 때 청구범위를 기준으로 한다는 원칙을 제시하는데 그 의의가 있다. 그러나 무형의 기술적 사상의 창작인 발명에 대하여 보호받으려는 범위를 청구 범위의 문구로 명료하게 표현하는 것에는 발명의 추상성으로 인해 한계가 있다. 그러므로 보호범위를 판단하기 위해서는 청구범위 표현의 한계성을 감안하여 법률적 가치판단이 가미된 해석이 필요하다.

2) 과대하게 넓은 보호범위의 인정은 오히려 산업발전을 저해하여 특허법의 목적에 반하는 결과를 초래할 수 있지만, 지나치게 좁은 보호범위의 인정도 오히려 발명자의 발명의욕을 상 실시켜 기술발전의 촉진을 저해하게 된다. 그러므로 첨예하게 대립하는 특허권자와 제3자의 이익을 적절히 조정하고, 궁극적으로는 산업발전 이바지라는 특허법 목적을 달성하기 위해서 특허발명의 보호범위를 어느 정도까지 인정할지 검토하는 것은 특허권자와 제3자 모두에게 있어서 중대한 사항이라고 할 수 있다.

제2관 해석에 관한 학설

I. 문제의 소재

제97조에서는 “특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다”라고 기재되어 있다. 여기서 「적혀 있는 사항에 의하여」를 어떻게 해석하느냐에 따라 보호범위는 달라질 수밖에 없는데, 해석원리로서는 주변한정주의와 중심한정주의가 있다.

II. 학설의 대립

1. 주변한정주의

(1) 의 의

「주변한정주의(peripheral limitation)」란 특허발명의 보호범위는 「청구범위에 적혀 있는 사항」의 문언적 의미로만 해석하여야 하고, 그 이외의 기재사항, 즉 발명의 설명에 의한 확장 해석은 인정되지 아니한다는 해석방법을 말한다. 주변한정주의는 계약법적 성격이 강한 영미법 계통에서 발달한 해석방법으로, 계약법 정신에 비추어 볼 때 특허권이란 발명자가 자신의 발명을 영업비밀로 숨겨놓지 않고 공중에게 공개한 것에 대한 반대급부로서 주어지는 것이기 때문에 공중에게 일정한 기여를 한 범위에서만 보호를 받게 된다. 그러므로 청구범위의 기재를 조금이라도 벗어나는 것은 보호범위에 속하지 아니한다고 본다.

(2) 장단점

주변한정주의는 특허발명의 보호범위가 명확하고 그 이해가 쉬운 장점이 있으나 청구범위의 문언 외의 균등범위에서 해당 특허권을 주로 침해하는 대부분 침해자로부터 특허권자가 보호되지 못하는 단점이 있다. 또한 주변한정주의하에서 출원인은 자기의 발명이라고 생각하는 사항을 청구범위에 적을 때 그와 균등한 것으로 생각하는 모든 실시예를 빠짐없이 포함하도록 청구범위를 작성하여야 하는 부담을 갖게 된다. 그러나 청구범위를 모두 넓게 기재하는 경우 청구범위의 불명료 또는 불특정으로 인정될 위험이 있을 뿐만 아니라 종래의 기술 내지는 공지기술을 포함하는 발명으로 인정되어 특허거절결정 또는 특허무효의 판단을 받게 될 위험도 안게 된다.¹⁴⁰⁾

2. 중심한정주의

(1) 의 의

「중심한정주의(central limitation)」란 특허발명의 보호범위를 해석할 때 청구범위의 적혀 있는 사항에 구애받지 않고 그곳에 표현된 「실질적인 발명사상」을 보호하려는 것으로서, 청구범위와 발명의 설명을 일체로 하여 발명사상의 핵심을 파악한 후 이에 상응하는 범위까지 보호범위를 인정하는 해석방법을 말한다. 중심한정주의는 대륙법 계통의 직권주의적 성격이 강조된 해석방법으로서, 법원이 일반적 발명사상의 추출 등의 방식을 통하여 청구범위에 기재된 구체적인 문언뿐만 아니라 이 문언과 일반적으로 또는 실질적으로 발명사상을 같이 하는 범위에까지 발명의 보호범위를 인정하게 된다. 이는 보호범위를 확장 해석하는 입장이며 균등물은 모두 특허발명의 보호범위에 속한다고 본다.

(2) 장단점

중심한정주의에서는 실시예를 청구범위에 일일이 적지 아니하여도 보호되며 출원자의 과오로 발명의 내용을 협소하게 적은 경우에도 보호되므로 발명 보호에 충실하다는 장점이 있다. 그러나 일반 제3자가 명세서의 문언을 통하여 특허발명의 보호범위를 정확하게 판단하기 곤란하여 특허권자와 일반 공중 사이에 보호범위에 대한 다툼이 끊이지 않게 되는 단점이 있다. 따라서 최근 독일은 미국의 태도와 유사하게 명세서 중의 청구범위의 각 항이 가진 의미를 강조하고 있고, 유럽특허조약의 규정(제69조) 역시 그러하다.¹⁴¹⁾

140) 이수완, “청구범위의 해석에 관한 소고”, 한빛지적소유권센터 연구실 편저, 「특허법의 제문제(上)」, 한빛지적소유권센터, 1993, 20면.

141) 유럽특허조약 제69조 : 유럽특허의 보호범위는 청구범위의 청구항의 내용에 의하여 정한다. 그러나 발명의 설명 및 도면은 청구범위의 청구항의 해석에 참작되어야 한다.

III. 판례의 태도

1) 우리나라의 이전 판례¹⁴²⁾의 대체적 경향은 “특허발명의 범위는 청구범위 기재된 구체적인 문언의 범위뿐만 아니라 발명의 설명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을 밝히고 이를 참작하여 그 발명의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이요 청구범위에 관한 기재에만 구애될 수 없다”라고 하여 중심한정주의적 입장을 취하고 있었다.

2) 그러나 최근에는 중심한정주의적 판례는 살펴볼 수 없고, “특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 설명의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 발명의 설명의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 발명의 설명의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다”¹⁴³⁾라고 하여, 대부분 판례가 주변한정주의적 입장¹⁴⁴⁾으로 돌아섰다.

IV. 검토

특허발명의 보호범위에 관한 해석에 대해서는 종래에 특허발명의 보호범위를 널리 해석하려는 독일을 중심으로 한 대륙법계의 국가가 채용해 왔던 중심한정주의적 해석방법과 자유경쟁의 입장에서 특허발명의 보호범위를 좁게 해석하려는 미국을 중심으로 한 영미법계의 국가가 채용해 왔던 주변한정주의적 해석방법으로 나뉘어져 있었다. 그러나 특허제도의 국제화 경향에 맞추어, 주변한정주의의 해석방법을 취하던 미국은 최근 균등론을 도입하여 중심한정주의적 요소를 대폭 취하였으며(확대해석 인정), 중심한정주의의 해석방법을 취하던 독일도 최근 청구범위에 대한 금반언의 원칙을 도입하여 주변한정주의적 요소를 취하고 있다(확대해석 제한). 그 결과 현재는 대륙법계, 영미법계 모두 비슷하게 청구범위를 해석하고 있으며, 주변한정주의와 중심한정주의는 전통적인 해석방법으로서의 연혁상의 구별의 의의가 있을 뿐이다.

142) 대법원 1972. 5. 23. 선고 72후4; 1973. 7. 10. 선고 72후42; 1973. 8. 31. 선고 72후43 등.

143) 대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 등.

144) 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라고 할 것이므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다(대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513; 2001. 8. 21. 선고 99후2372 등).

【표 6-4】 주변한정주의와 중심한정주의의 비교

구 분	주변한정주의	중심한정주의
의 의	청구범위의 기재에 의해서 문언 그대로 해석	청구범위의 기재에서 발명의 핵심사상을 추출하여 확장 해석
판단의 용이성	○	×
특허권자의 보호	×	○
판례 및 특허법의 태도	1. 판례의 태도 - 90년대 초반까지 중심한정주의 입장에 있었으나 90년대 후반 이후 주변한정주의 입장으로 변화 2. 주변한정주의의 보완(특허권자의 보호) ① 다항제(法 42④) ② 간접침해(法 127) ③ 균등론(判例가 인정) ④ 생략침해, 불완전이용침해 이론(判例는 불인정)	

제3관 보호범위의 판단

I. 서 설

보호범위의 판단은 단순히 특허발명의 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라 확인대상발명과 관계에서 특허발명의 권리가 미치는 범위를 객관적으로 확정하는 것이다.¹⁴⁵⁾ 보호범위의 판단은 i) 특허발명의 특정, ii) 확인대상발명의 특정을 한 후, iii) 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 구성요소완비의 원칙과 균등론을 적용함으로써 특허발명의 실시인지 판단하고 iv) 법률의 제한 및 확장을 고려하여 이루어진다.

II. 특허발명의 특정

1. 특정기준

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여진다(法 97). 이는 특허발명의 보호범위가 청구범위에 기재된 그대로 정해진다는 의미는 아니며, 발명의 설명·도면의 참작과 함께 출원 당시의 기술수준, 출원의 경과 및 특허권의 하자 등을 참작하여 해석된 청구범위가 특허발명의 보호범위결정의 기준이 된다는 의미이다. 즉 특허발명을 특정할 때는 청구범위 기준의 원칙, 발명의 설명 참작의 원칙, 공지기술 참작의 원칙, 출원 경과 참작의 원칙 및 특허권 하자 참작의 원칙 등이 고려된다.

145) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 등.

2. 청구범위 기준의 원칙

1) 「청구범위 기준의 원칙」이란 특허발명의 보호범위는 원칙적으로 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 결정됨을 의미한다. 발명의 설명에 적혀 있는 발명일지라도 청구범위에 포함되지 아니한 것은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 된다. 이처럼 보호범위 해석에 있어 무엇보다도 청구범위에 문언 내용을 중심으로 하여야 한다는 입장을 문언 중심의 원칙 또는 「용어책임설(patentee as lexicographer)」이라고 부르기도 한다. 즉 출원인은 청구범위를 작성할 때 사전편집자와 같이 용어의 선택을 신중히 하여야 할 책임이 있으며, 부적절하거나 명료하지 아니한 용어의 선택으로 발생한 불이익은 출원인이 감내하여야 한다.

2) 한편 청구범위의 청구항별로 개별적으로 보호범위를 판단하여야 한다. 이때 독립항과 이를 한정하는 종속항 등 여러 항으로 이루어진 청구항의 기술내용을 파악하는 경우에 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을, 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항으로 제한하여 해석할 수는 없다.¹⁴⁶⁾¹⁴⁷⁾ 다만, 특별한 사정이 있는 경우에는 제한해석할 수 있다.¹⁴⁸⁾

3. 발명의 설명 참작의 원칙

(1) 의 의

「발명의 설명 참작의 원칙」이란 청구범위는 발명의 설명에 적혀 있는 사항 중 보호받으려는 사항을 적은 것이므로(法 42④) 보호범위 해석에 있어서 청구범위의 기재사항 외에 발명의 설명을 참작하여야 한다는 것을 의미한다. 즉 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고, 특별한 사정이 없는 한 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 아니하지만, 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하려는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.¹⁴⁹⁾ 청구범위는 발명의 설명에 적혀 있는 사항 중 발명을 특정하는데 필요한 구성요소를 무색투명하게 기재되어야 하므로 청구범위의 기재만으로는 발명의 해결 과제·해결 수단 및 효과를 충분히 파악하기 어렵기 때문이다.

146) 대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후934.

147) 즉 청구항별로 침해 여부를 판단하지만 하나의 청구항이라도 침해라면 그 특허를 침해했다고 할 수 있다.

148) 실용신안등록청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 고안의 상세한 설명과 도면 등을 보충하여 그 문언이 표현하고 있는 기술적 구성을 확정하여 등록실용신안의 권리범위를 정하여야 하고, 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57).

149) 대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240; 2020. 1. 30. 선고 2017다227516 등.

(2) 발명의 설명 또는 도면에 의하여 제한 해석되는 경우

1) 제3자의 입장을 고려하여 청구범위 문언 그대로 해석하는 것이 명백히 불합리하다는 특별한 사정이 있다면 발명의 설명 또는 도면에 의하여 제한 해석될 수 있다. 진실로 발명하지 않은 부분까지 특허권의 보호범위를 인정하는 것은 제3자에게 불측의 손해를 줄 수 있기 때문이다. 예를 들어 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다.¹⁵⁰⁾ 발명의 설명에 의하여 보충을 하더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 발명의 설명 또는 도면에 의하여 뒷받침되는 범위에서 권리범위를 제한 해석할 수 있다. 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.¹⁵¹⁾ 더 나아가 청구범위의 기재가 발명의 설명에 의하더라도 출원 당시 발명의 구성요소 일부가 추상적이거나 불분명하여 도저히 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없으면 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다.¹⁵²⁾

2) 한편, 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 청구범위가 확장해석되는 사례는 아직까지 찾아보기 어렵다.

4. 공지기술참작의 원칙

1) 「공지기술참작의 원칙」이란 출원 시의 기술수준인 공지기술보다 개량·진보의 정도를 고려하여 특허발명의 보호범위를 결정하여야 한다는 것이다.¹⁵³⁾ 발명의 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술까지 참작하는 것은 전체 공지기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 공지기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 균등범위를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지를 결정하게 된다.¹⁵⁴⁾ 이처럼 공지기술 참작의 원칙에 의하면 개량 진보의 정도가 큰 발명의 보호범위는 넓게 해석되고, 반대로 개량 진보의 정도가 작은 발명의 보호범위는 좁게 해석된다.

2) 한편 특허발명이 공지기술과 비교하여 개량·진보되지 아니한 경우, 즉 특허발명이 공지기술과 동일한 경우에는 보호범위를 인정할 수 없는데, 이를 특히 「공지기술제외의 원칙」이라 한다.

150) 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761; 2025. 7. 17. 선고 2023후11340.

151) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57.

152) 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235; 1989. 3. 28. 선고 85후109 등.

153) 특허권의 권리범위를 정하는 경우는 출원 당시의 기술수준을 고려하고 그 작용, 효과도 살펴보아야 한다(대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1857).

154) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424.

5. 출원경과참작의 원칙

(1) 의의 및 취지

「출원경과참작의 원칙(prosecution history estoppel)」이란 특허권자가 자기의 발명에 대한 출원 계속 중에 감축 등을 통해 어떤 구성을 보호범위에서 제외하려는 의사가 존재하는 경우 등록 이후 균등범위임을 이유로 자기의 보호범위에 속한다고 주장하는 것을 금한다는 것으로서, 「포대금반언의 원칙(file wrapper estoppel)」¹⁵⁵⁾이라고도 한다. 예를 들어 청구항에 「A+B1+C」를 구성요소로 하여 출원하였다가 「A+B2+C」로 보정하면서 특허된 경우 최초의 「A+B1+C」에 대해서는 균등물임을 이유로 권리를 주장할 수 없다. 출원경과참작의 원칙은 균 등론의 적용에 따른 청구범위의 확장해석을 억제하기 위한 이론으로서 발전되어 왔다. 특허권 자는 심사관의 거절이유통지가 타당하지 않다고 판단되었을 때 청구범위를 감축 또는 변경하 는 주장(이하 “감축 등”이라 한다)을 하지 아니하고 심판이나 소송 등의 절차를 밟아 다룰 수 있는데, 이러한 방식을 취하지 아니하고 스스로 감축 등을 하여 특허를 받은 이상 후에 감축 등의 부당성을 다룰 수 있는 절차적 권리는 이미 소멸하고, 감축 등을 한 청구항 부분에게지 보호범위의 확장해석을 주장할 수 없다. 이는 보호범위(특허침해)의 회피를 위해 대외적으로 공시가 되는 심사과정이나 정정절차 등을 신뢰한 제3자를 보호하여야 하기 때문이다.¹⁵⁶⁾

(2) 적용대상

① 보 정

선행기술과의 관계에서 특허성을 확보하기 위한 보정, 예를 들어 신규성 등을 상실하는 것을 회피하기 위하여 청구범위를 제한적으로 보정을 한 경우 출원경과참작의 원칙이 적용된다.¹⁵⁷⁾

155) 「포대(file wrapper)」란 출원과 관련된 출원서, 명세서, 의견서 등 일체의 서류를 정리해 놓은 파일을 말하며, 「금반언(estoppel)」이란 권리를 갖는 자가 자기의 이익을 위한 행위를 신뢰하여 행동한 제3자에 대하여 그 행위와 모순되는 주장을 하는 것이 금지된다는 의미이다. 즉 「포대금반언의 원칙」이란 「포대는 거짓말을 하지 아니한다」는 의미이다. 이는 포대를 보면 출원인이 출원과정에서 의식적으로 제외한 사항을 알 수 있기 때문이다.

156) 특허법원 2023. 11. 30. 선고 2023허11593.

157) 포대금반언의 원칙을 적용한 최초의 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결에서는 “이 사건 등록고안의 출원인은 출원 시에는 등록청구범위 제1항을 「등반이시트의 젖힘동작으로 보조시트가 펼쳐져 침대로 변형되는 안락의자에 있어서, 바퀴를 구비한 한 쌍의 메인 후레임 뒤측에 회동가능하게 등받이 후레임을 설치하되, 위 등받이 후레임 하단에 상, 하 두개의 힌지부를 구성한 한 쌍의 힌지브라켓트를 착설하여 위 힌지브라켓트의 상부 힌지부에는 선단에 보조시트 후레임이 절첩가능하게 결합된 좌판 후레임을 결합하여 안내부의 안내로 별도의 지지 후레임없이 등받이시트와 보조시트가 연동되도록 구성함을 특징으로 안락의자」로 하고, 등록청구범위 제2항을 「제1항에 있어서, 위 등받이 후레임과 보조 후레임을 연결하는 연결레버를 “”형으로 일정 각도 정곡되어서 메인 후레임 앞측에 설치된 링봉에 착설되어 한 쌍의 롤러로 된 안내부에 의하여 지지안내되도록 구성함을 특징으로 하는 안락의자」로 기재하였다가, 지식재산청 심사관으로부터 실용신안공고 제95-4971호 고안 등에 의하여 통상의 기술자가 극히 쉽게 고안할 수 있다는 이유로 거절이유통지를 받고, 1998. 7. 22. 의견서 및 보정서를 제출하면서 인용대상에 저촉되는 부분을 공지의 기술로 하여 청구범위를 대폭 축소 한정한다고 주장함과 아울러 청구항 제1항과 제2항을 결합하여 하나의 항으로 만들되 청구항 제1항에 있던 부분을 전제

또한 기재불비 등 특허법이 정하는 다른 거절이유를 회피하기 위한 목적으로 보정이 이루어진 경우에도 적용된다. 출원된 발명이 선행기술과 저촉되는 경우뿐만 아니라 명세서가 기재불비된 경우도 특허법에서 규정한 거절이유와 무효사유가 되는 것이고, 명세서를 보정하는 목적이나 동기 또한 양자 모두 출원된 발명의 특허를 받기 위한 것이라는 점에서 차이가 없기 때문이다. 나아가 기재불비 등의 거절이유를 극복하기 위해 출원인이 의식적으로 청구범위를 삭제 내지는 감축하였다고 하여도 제외된 부분에 대해서 출원인이 특허받을 의사를 포기한 점이 그 출원과 정의 흐름에 비추어 분명하다고 하면,¹⁵⁸⁾ 출원경과를 본 제3자가 출원인에 의하여 의식적으로 제외된 부분을 자유롭게 사용할 수 있는 공공영역으로 인식하리라는 점이 명백하기 때문이다.¹⁵⁹⁾

② 그 밖의 대상

i) 등록 후 청구범위의 정정,¹⁶⁰⁾ ii) 보정없이 의견서만 제출한 경우(한정적 주장),¹⁶¹⁾ iii) 분할출원한 경우¹⁶²⁾에도 출원경과참작의 원칙을 적용하고 있다.

-
- 부로 기재하고 청구항 제2항에 있던 부분을 특징부에 기재하였는바, 그렇다면 출원인 스스로 전체부의 기재사항인 「등반기와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 안내부가 안내하도록 하는 구성」을 공지의 기술로 한정한 것이라 하겠고, 나아가 다시 특징부에서 위 안내부를 「한 쌍의 롤러」로 한정한 것은 출원인이 이와 균등관계에 있는 구성에 대해서는 그 권리범위를 주장하지 않았다는 취지로 볼 것이므로, 결국 출원경과금반언의 원칙상 등반기와 보조받침을 직접 연결하여 연계동작을 하는 연결레버를 안내부가 안내하도록 함에 있어서, 그 안내부를 {확인대상 고안과 같은 슬라이드관으로 구성하는 것은 이 사건 등록고안의 출원인이 의식적으로 그 보호범위로부터 제외한 것으로 봄이 상당하여, 확인대상 고안의 슬라이드관은 이 사건 등록고안 제1항의 롤러의 균등론이 될 수 없다}라고 판시한 바 있다.
- 158) 이를 포기하지 않았다면 상급심으로 다투거나 아니면 삭제 내지는 감축이 아니라 기재불비를 해소할 수 있는 명확한 표현 등으로 대체하여야 할 것이다.
- 159) 대법원 2007. 2. 23. 선고 2005도4210.
- 160) 대법원 2004. 11. 26. 선고 2002후2105; 2018. 8.1. 선고 2015다244517.
- 161) 특허법원 2002. 8. 30. 선고 2002허635.
- 162) 구체적인 예로는 원출원에 대한 금반언이 적용되는 경우와 분할출원에 대한 금반언이 적용되는 경우가 있다. 원출원에 대한 금반언이 적용되는 경우를 살펴보면 대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결에서 “이 사건 특허발명에 대한 출원과정에서 지식재산처 심사관의 거절이유통지의 내용, 원고의 이에 대응한 보정서와 의견서의 내용, 원고가 이 사건 출원발명(C3, C5)으로부터 이 사건 화합물(C3)을 제외한 나머지 화합물에 대한 부분(C5)을 분할출원을 한 경위 등을 참작하면, 원고는 심사관으로부터 거절이유통지를 받고서 선행기술을 회피하고 명세서 기재요건을 충족시키기 위하여 이 사건 출원발명의 화합물을 이 사건 화합물로 감축보정하면서(C3)을 제외한 나머지 화합물(C5)들을 별개의 발명으로 분할출원함으로써 이들을 이 사건 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 봄이 상당하므로, 위 분할출원된 화합물에 속하는 피고의 오르토-크레졸프탈레인헥사노일에스테르(C5)는 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다”라고 하여 원출원에서 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외한 것이라고 하였다. 분할출원에 대한 금반언이 적용되는 경우를 살펴보면 대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340 판결에서 “원고는 원출원발명의 출원 과정에서 거절이유를 극복하기 위해, 원출원 제1항 발명의 ‘세정수단’에는 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출하였다. 원출원발명과 이 사건 특허발명의 출원인은 모두 원고로 동일하다. 이 사건 특허발명은 원출원발명을 기초로 하는 1세대 분할출원 발명으로부터 분할출원된 발명으로서 원출원발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 있는 발명이다. 원고는 원출원발명에 관한 위와 같은 의견제출 이후에 이 사건 특허발명을 출원하였다. 이러한 사정을 고려하면, 원출원발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있다. 이를 참작하면, 원고는 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’ 중 ‘전기분해 방식으로

(3) 적용범위

1) 특허권자의 의사에 의하여 보호범위에서 의식적으로 제외된 사항이 무엇인지에 대한 판단은 무척 어려운 문제이다. 이와 같은 문제에 대해, 청구범위의 감축 등이 출원경과참작 원칙의 적용을 받을 때 감축 등이 된 청구범위의 구성요소에 일절의 균등범위를 인정하지 아니한다는 「엄격한 기준의 입장(absolute bar approach)」과 일정 범위에서 균등범위를 인정하는 「유연한 기준의 입장(flexible bar approach)」이 있을 수 있다. 여기서 「엄격한 기준의 입장(absolute bar approach)」은 청구범위의 직접주의에 의거하는 것인데, 감축 등이 이루어진 사실에 의하여 자동적으로 출원경과참작의 원칙을 적용하는 자동적용의 접근법이다. 이 접근법에 의하면 청구범위의 확실성 내지 명료성이 향상되고 합법적인 기술혁신을 촉진하는 것과 함께, 청구범위의 해석에 있어서 법원의 부담이 경감된다. 이에 대하여 「유연한 기준의 입장(flexible bar approach)」은 감축 등에 의하여 포기된 범위의 광범에 따라서 출원경과참작 원칙의 적용범위를 탄력적으로 신축시키는 접근법이다. i) 모순행위에 의하여 특허부여와 침해금지이라는 2개의 결과를 방지하고자 함이 출원경과참작 원칙의 근거 중 하나인데, 보정 이 유가 명확하지 않다면 모순행위라고 단정하기 어려운 점, ii) 엄격한 기준의 입장에 의하면 특허발명의 보정된 내용을 확인한 후 사소하게 변경하면 침해를 회피할 수 있게 되어 균등론의 적용을 무력화시키는 점, iii) 보정된 청구항과 보정되지 않은 청구항 사이에 불균형이 지나치게 크다는 점, iv) 균등론의 적용범위가 지나치게 넓어지는 폐해는 균등론의 다른 적용요건에 의해서도 어느 정도 해결이 가능하다는 점 등을 고려하면 유연한 기준의 입장을 적용하는 것이 타당하다.¹⁶³⁾

2) 미국에서는 Festo 사건¹⁶⁴⁾에서 유연한 기준의 입장을 취하되 보정이 합리적으로 보아 특정한 균등물을 포기하려고 한 것이라고 볼 수 없는 경우, 예를 들어 i) 출원 시에 그러한 균등물이 예측할 수 없는 것이었다던가, ii) 보정한 이유가 균등물과 아주 미미한 관련성만을 갖는 경우, iii) 보정된 청구항에 상대방의 구성을 포함시키는 것을 기재할 수 없었던 다른 이유가 있는 경우 등에 해당한다면 특허권자는 보정시에 그 분야에 통상의 지식을 가진 사람에게 합리적으로 기대할 수 없는 것이었음을 증명하여 출원경과참작의 원칙이 적용된다는 추정(presumption)을 반복시킬 수 있다고 판시하였다.

살균물질을 생성하여 세정하는 수단'을 의식적으로 제외하였다고 보인다'라고 하여 원출원발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원권이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있다고 하였다.

163) 구민승, “출원경과 금반언에 의한 균등의 배제 범위”, 사법 41호, 사법발전재단, 2017년 가을호, 254-259면.

164) Festo corporation vs. Sho-ketsu kinzoku kogyo kabushiki co., ltd. 이 사건에서 미국 연방대법원은 “i) 언어에 의하여 발명의 본질을 정확하게 표현하는 것에 한계가 있다는 점, ii) 금반언에 대해서 기성개념 및 현존하는 특허권자의 기대를 존중하여야 한다는 점, iii) 특허권자가 보정을 행하는 때에 보정 후의 청구범위에 관하여 갖는 의도가 그것의 균등범위를 일절 포기하는 것에 반드시 일치하지 아니한다는 점 등에 주목하여, 감축 보정으로 인해 엄격한 기준의 입장을 유지하여야 할 이유가 없으며, 문제는 권리자의 축소보정이 문제의 특정 균등물을 포기하지 않았다는 것을 증명할 수 있는지에 달려 있다”라고 하는 취지로 CAFC에서 제시한 “엄격한 기준의 입장”을 파기하였는데, 이는 금반언의 적용범위에 대하여 참고할만한 사항이라고 사료된다.

3) 우리나라는 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결¹⁶⁵⁾에서는 “특허발명의 출원과 정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 지식재산처 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조). 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사실만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정 이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다”라고 판시하여 유연한 기준의 입장을 취하고 있다. 미국의 Festo 사건은 보정한 경우 일단 균등범위에서 제외되는 것으로 추정하되, 특허권자의 증명에 의하여 추정을 복멸시킬 수 있다는 것인데 반해, 우리나라의 대법원은 보정했다고 하더라도 출원인이 이를 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재하지 않는다면 균등범위에서 제외할 수 없다는 것이다.¹⁶⁶⁾ 「의식적 제외」의 개념을 엄격히 적용하게 되면 대개 균등론을 적용할 여지가 없어져 버리게 되어 부당한 결과가 초래되므로 의식적 제외는 그 취지가 명확한 경우에만 이루어져야 한다는 것이다.

6. 특허권 하자 참작의 원칙

특허법은 공개의 대가로서 특허권이라는 독점·배타권을 부여하기 때문에 새로운 발명을 제대로 공개시키지 않았음에도 불구하고 착오로 등록된 경우에는 보호범위를 인정할 수 없다. 구체적으로 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지 등이 되어서 신규성이 없는 경우, 특허발명이 선행특허와 동일하여 선출원주의 또는 확대된 선출원에 위반된 경우, 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우 확인대상발명은 특허발명과의 구체적 기술 대비를 할 필요도 없이 그 보호범위에 속하지 아니한다.

165) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210에서도 동일한 취지로 판결하였다.

166) 예를 들어 상위개념 A와 그 하위개념으로 a1, a2, a3가 있는 상황에서, 당초 A라는 구성요소였으나 선행기술에 a1이 개시되어 a3로 보정하였고 상대방 구성은 a2인 경우, 엄격한 기준의 입장에서는 의식적으로 제외된 것으로 보고, 유연한 기준의 입장(미국)에서는 일단 의식적으로 제외된 것으로 추정하되, 특허권자가 그 추정을 복멸시킬 수 있고, 유연한 기준의 입장(한국)에서는 이를 의식적 제외로 보지 않게 된다(구 민승, “출원경과 금반언에 의한 균등의 배제 범위”, 사법 41호, 사법발전재단, 2017년 가을호, 254면)

III. 확인대상발명의 특징

1) 확인대상발명이란 권리범위확인심판에서 특허발명의 권리범위에 속하는지의 판단대상이 되는 구체적인 실시형태를 말하며, 침해소송에서는 대상 제품, 피고 제품, 피고 실시제품 등으로 표시된다. 확인대상발명은 대상물을 주관적으로 가공하여 설명서 또는 도면에 의하여 기재하는데, 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어야 한다. 그리고 해당 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 특정되어야 하는바, 그 특징을 위해서는 대상물의 구체적인 구성을 전부 적을 필요는 없고 특허발명의 구성요소에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하면 되는 것이나 다만 그 구체적인 구성의 기재는 특허발명의 구성요소와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요한 정도는 되어야 한다.¹⁶⁷⁾ 확인대상발명의 구성요소 중 특허발명의 구성요소에 대응하지 아니한 구성요소는 자유기술의 항변의 경우를 제외하고 특허발명과 대비하여 구성요소완비의 원칙, 균등론 등에 의한 특허발명의 실시인지 판단할 때 영향을 미치지 아니한다.¹⁶⁸⁾ 이에 대한 구체적인 내용은 「제7편 제2장 제4절 권리범위확인심판」에서 살펴본다.

IV. 구성요소완비의 원칙

1. 서

1) 「구성요소완비의 원칙(All Elements Rule; AER)」이란 청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우에만 보호범위에 속한다는 원칙이다. 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.¹⁶⁹⁾ 즉 특허발명의 청구범위의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수적 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 특허발명의 비교적 중요하지 아니한 사항이라 하여 무시하는 것은 사실상 청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.¹⁷⁰⁾ 이는 청구범위를 해석할 때 출원경과에 나타난 출원인의 의사를 참작한다고 하더라도 마찬가지이다.¹⁷¹⁾

167) 대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381.

168) 실무상 특허발명의 실시인지 여부는 청구항의 대비표에 의하여 판단한다. 구체적으로 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 특허발명에 대응되는 구성이 모두 동일하면 구성요소완비의 원칙을 적용하고, 대응되는 구성 일부에 차이가 있다면 균등론의 적용 여부를 검토한다.

169) 대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513; 2000. 11. 14. 선고 98후2351 등.

170) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123; 2005. 9. 30. 선고 2004후3553.

171) 대법원 2001. 12. 24. 선고 99후2181.

2) 구성요소완비의 원칙은 청구범위의 해석원리로서 주변한정주의의 입장에서의 해석방법이다. 주변한정주의하에서는 특허권의 권리범위를 특허권자가 알아서 특정하여야 할 뿐만 아니라, 그 구성요소의 선정까지도 특허권자가 책임져야 한다. 따라서 특허권자는 스스로 책임하에 선택한 구성요소가 혐의대상물 중에 존재하지 아니한 이상 그 혐의물을 실시한 제3자에게 침해의 책임을 지을 수 없다고 하는 것이 주변한정주의의 근본사상이다. 이 점에서 주변한정주의는 구성요소가 결여되지만 하면 그 결여된 구성요소의 범위를 정할 필요도 없이 침해를 구성하지 아니한다는 구성요소완비의 원칙과 잘 어울리게 되는 것이다.

2. 구체적인 내용

(1) 부가의 원칙

「부가의 원칙」이란 청구범위의 청구항에 기재된 구성요소를 모두 포함하고 있는 한 다른 구성요소를 더 포함하고 있다 하더라도 여전히 해당 청구항에 기재된 특허발명의 보호범위에 속한다고 할 수 있는 것을 말한다. 예를 들어 특허발명의 구성요소가 「A+B+C」인데, 제3자가 「A+B+C+D」를 실시하고 있다면 보호범위에 속하게 된다.

(2) 생략의 원칙

「생략의 원칙」이란 청구범위의 청구항의 구성요소 중 적어도 어느 하나가 생략되거나 다른 것으로 대체되어 있다면 해당 청구항에 기재된 특허발명의 보호범위에 속한다고 할 수 없는 것을 말한다. 예를 들어 특허발명의 구성요소가 「A+B+C」인데, 제3자가 「A+B」를 실시하고 있다면 보호범위에 속하지 않게 된다.

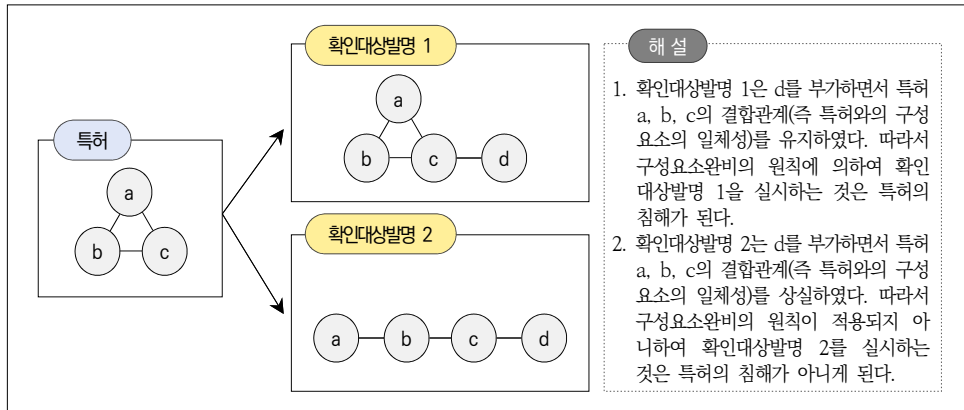
3. 전제조건으로서 일체성 유지

구성요소완비의 원칙이 적용되기 위해서는 특허발명의 구성요소가 일체성을 유지하면서 확인대상발명에 포함되어 있어야 한다. 여기서 「일체성이 유지된다」라는 것은 특허발명의 구성요소의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 유지되고 있고, 특허발명의 작용효과도 확인대상발명에 나타나고 있는 것을 말한다.¹⁷²⁾¹⁷³⁾ 따라서 확인대상발명의 부가된 요소에 의하여 특허발명의 유기적 결합관계가 바뀌거나 특허발명의 작용효과가 사라지고 다른 것으로 전환될 때는 일체성이 유지된다고 볼 수 없다.¹⁷⁴⁾

172) 안원모, “특허의 이용침해와 이용관계”, 산업재산권 제51호, 2016.12, 29면.

173) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결에서도 “특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다”라고 하여 일체성이 유지되어야 함을 나타내고 있다. 또한 구성요소완비의 원칙에서 더 나아가 균등론 적용 시에서 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 등에서 “변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내어야 한다”라고 판시하고 있는데, 이도 일체성이 유지되어야 함을 나타내는 표현이라고 할 수 있다.

174) 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결에서 특허등록된 확인대상발명이 선 특허발명인 제30항 발



【그림 6-10】 일체성 유지

4. 구성요소의 특징

1) 청구항의 구성요소(elements of claim)는 청구항을 복수의 구성요소(element)로 나누어 청구항을 해석하기 위한 기술적 용어(technical term)이다. 구성요소 단위를 작게 보는 경우 구성요소의 생략이지만 구성요소 단위를 크게 보는 경우 구성요소의 생략이 아닌 변경으로 평가할 수 있는 경우도 있으므로 어느 정도를 구성요소로 볼 것인지는 중요한 문제이다. 예를 들어 “a, b, c로 된 X와 d, e, f로 된 Y를 포함하는 자전거”가 특허발명이고, 확인대상발명이 “a, b, c, d, e로 된 자전거”라고 했을 때, a, b, c, d, e, f를 구성요소로 본다면 확인대상발명은 특허발명의 구성요소인 f를 생략했기 때문에 구성요소완비의 원칙에 따라 특허발명의 실시가 아니지만, X, Y를 구성요소로 본다면 확인대상발명은 Y를 Y1(d, e)으로 변경했기 때문에 Y와 Y1의 균등론 적용 여부에 따라 특허발명의 실시가 될 개연성을 가지고 있게 된다.

2) 보통 실무적으로는 청구항의 문구를 임의로 한 단위씩 끊어 하나의 구성요소로 보고 있으나 각 구성요소의 단위는 발명 전체의 작용효과에 기여하기 위해 독자적인 기능을 보유할 정도는 되어야 할 것이다.¹⁷⁵⁾

명과 이용관계에 있는가가 문제되었다. 위 판결의 사안에서 제30항 발명은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대 등의 효과를 위하여 선재를 한 방향으로만 형성한 것인 데 비하여, 확인대상발명은 하나의 석쇠틀에서 가로, 세로 방향으로 선재가 교차되는 양방향 구성을 채택하고 있었다. 심결과 원심은 이용관계에 있다고 판단하여 일단 본안판단으로 나아간 후 막상 권리범위 속부 실체 판단에서는 확인대상발명의 구성이 제30항 발명의 권리범위에서 의식적 제외된 구성이라고 보아 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 그러나 대법원은, 이용관계 해당 여부에 관한 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결의 판단기준을 인용한 다음, 하나의 석쇠틀에서 가로, 세로 방향으로 선재가 교차되는 확인대상발명의 양방향 구성은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대와 같은 한 방향 구성의 효과를 나타낼 수 없어 제30항 발명과 상이한 구성이라고 할 것이고, 확인대상발명 내에서 제30항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 볼 수도 없어 두 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 권리범위확인심판 청구는 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 전 출원에 의한 등록 발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다고 판단하였다.

5. 구성요소완비의 원칙의 한계

구성요소완비의 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 i) 미세한 설계변경, ii) 중요도가 매우 낮거나 본질적 기능과는 무관한 요소(非要部)만이 결여되고 다른 모든 요소가 실시되고 있는 경우에 특허발명의 보호범위에 포함되지 아니한 문제가 발생된다. 이 경우 특허권의 효력이 유명무실하게 될 수 있으므로, 청구항에 기재된 구성요소와 실질적으로 동일한 것의 실시도 침해로 보아야 하는 필요성에서 균등론이 발전되었으며, 생략의 원칙의 예외로서 간접침해에 관한 규정을 두고 있다. 또한 확인대상발명이 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요성이 낮은 비요부를 생략한 생략발명 또는 생략발명에 구성요소를 부가한 불완전이용발명을 특허권의 침해로 보아야 한다는 논의가 있다.

V. 균등론

1. 서

1) 「균등론(doctrine of equivalents)」이란 확인대상발명과 청구항에 기재된 발명의 구성요소가 완전히 일치하지는 아니하지만, 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명의 구성요소로부터 확인대상발명의 구성요소를 용이하게(쉽게) 변경하여 실질적으로 동일한 효과를 얻을 수 있는 것일 때에는 확인대상발명이 특허발명의 기술사상과 균등한 것으로서 특허발명의 보호범위에 포함된다고 보는 이론이다.

2) 발명은 기술적 사상이어서 청구범위에 표현의 한계를 가지고 있는 문언 형식으로 기재하는 것이 출원인에게 매우 어렵고, 침해자가 청구범위의 구성요소를 그대로 모방하여 침해하는 때도 있지만, i) 많은 경우에 발명의 구성 중 비교적 경미한 부분에 변환을 가하여 그 것로부터 일탈을 시도하고자 하는데 출원인이 이처럼 변환을 가하는 모든 경우를 예측하여 이를 포괄할 수 있도록 청구범위의 문언을 기재하는 것은 어렵거나 불가능한 일이라는 점, ii) 타인의 발명에 대하여 아무런 지적 창작을 가하지 아니한 모방자가 방치되는 것은 정의와 공평의 관념에 반한

175) 서울고등법원 2012. 4. 19. 선고 2011나45820 판결에서는 이 사건에서 문제로 된 특허발명의 ‘풋 스위치’는 그 자체만으로 쓰레기 투입구 발명에 있어서 독자적인 기능을 수행할 수 없고, ‘투입구 문’ 및 ‘안전커버’와 결합하여 ‘투입구 문과 안전커버의 개폐’라는 기능을 수행할 수 있으므로, 피고들 실시제품에 위와 같은 기능상 단위구성이 구비되어 있는지를 살펴야 한다고 판시하고 있다. 그런데 피고들 실시제품은 ‘투입구 문’과 ‘안전커버’에 대응되는 ‘투입구 도어’와 ‘용적제한밸브’ 및 이를 개폐하는 기능을 수행하는 구성을 갖추고 있으므로, ‘풋 스위치’의 결여만으로 피고들 실시제품이 이 사건 특허발명의 구성요소 중 일부를 결여하여 그 권리범위에 속하지 않는다고 볼 수 없다고 판시하고 있다. 만일 이 사건에서 한정 단위로 구성요소를 분해하였다면, ‘풋스위치’도 하나의 한정으로서 구성요소로 파악되었을 것이지만, 이 사건에서는 ‘풋 스위치’를 ‘투입구 문과 안전커버의 개폐’라는 기능단위에 포함되는 것으로 이해하여 별도의 구성요소로 파악하지 않고, 이를 보다 큰 하나의 기능단위에 포함시켜 기능단위별로 구성요소를 분해하고 있다(강경태, “균등침해 판단에서 구성의 구분과 과제의 해결원리-서울고등법원 2011나45820 판결에 대한 판례평석-” LAW & TE CHNOLOGY(제9권 제1호, 통권 제44호), 서울대학교 기술과법센터, 2013, 114면 이하의 판례평석).

다는 점에 비추어 균등론을 도입하여 특허권자를 보호하고 있다. 즉 균등론은 특허권자를 보호하고 구체적인 타당성을 기하기 위하여 경험적으로 발전되어 온 이론이다.

3) 다만 균등론은 그 자체의 불안정성을 해소하고 최소한의 법적 안정성을 유지하기 위해 기본적인 적용기준이 필요하며, 이 기준은 판례에 의하여 제시되고 있다. 구체적으로 판례에 의한 적용기준을 살펴보면, “특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 그리고 i) 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경¹⁷⁶⁾된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고(제1요건), ii) 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며(제2요건), iii) 그와 같은 변경이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우에는(제3요건), iv) 특별한 사정이 없는 한(제4요건) 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다”¹⁷⁷⁾고 하여 특허권자가 주장하여야 하는 적극적 요건 i) 내지 iii)과 제3자가 항변하는 소극적 요건 iv)를 실시하고 있다.

2. 제1요건: 과제의 해결원리가 동일할 것

(1) 의 의

확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일해야 한다. 「과제의 해결원리가 동일」한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 「기술사상의 핵심」이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.¹⁷⁸⁾ 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술 과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제해결원리를 파악할 때 발명의 설명의 기

176) 대상판결은 기존의 구성의 ‘치환 내지 변경’을 ‘변경’으로 표현하였다. 대상판결은 변경을 치환과 동의어 또는 치환을 포괄하는 상위개념으로 보고 변경이라는 단일 용어를 사용한 것으로 보인다. 균등침해 판단 시 청구항에 기재된 구성과 침해제품의 구성은 반드시 일 대 일 대응을 요구하지 않고 일정한 분해와 결합을 통하여 일 대 다 또는 다 대 일의 대응도 충분히 가능한 것이므로, 치환보다는 변경이라는 탄력적이고 유연한 개념을 사용하는 것이 바람직한 것으로 보인다. 언뜻 사소한 용어변경처럼 보이나, 향후 구성요소의 파악 방법이나 생략침해의 영역을 포괄하는 균등침해의 법리 발전 등에 긍정적인 역할을 할 것으로 기대된다(한동수, 판례평석: 균등침해에서 과제해결원리의 의미, 법률신문, 2014.10.31).

177) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361; 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 등.

178) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361; 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 등.

재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다.¹⁷⁹⁾

(2) 구체적인 판단방법

과제해결원리는 우선 내적 증거인 발명의 설명에 기재된 종래기술의 문제점, 해결과제, 과제해결수단, 발명의 효과 기재에 기초하여 판단하되, 필요한 경우 출원경과나 다른 공지의 증거 등 외적 증거에 대한 추가심리를 통하여 기술적 사상의 핵심을 객관적으로 추출한다.¹⁸⁰⁾ 이를 토대로 파악된 과제해결원리가 확인대상발명까지 포섭할 수 있을 정도로 상위개념화가 가능한지 파악한다. 다만 명세서에 기재 또는 시사된 범위 내에서만 상위개념화를 할 수 있고, 특허발명의 구성과 관련된 공지기술이 다수 존재하는 경우¹⁸¹⁾나 출원과정에서 의식적으로 제외된 범위가 있는 경우에는 상위개념화되는 범위가 좁아질 수밖에 없을 것이다.¹⁸²⁾ 한편 발명의 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.¹⁸³⁾ 예를 들어 발명의 설명에 기술사상의 핵심을 A로 해 두었는데, 침해제품은 이를 포함하지 않는 경우 특허권자가 다른 기술사상 B를 핵심으로 주장하여 침해제품에 B가 있다는 이유로 균등을 주장할 수는 없을 것이다.¹⁸⁴⁾

(3) 발명 전체 vs. 구성별 판단

제1요건을 발명 전체(invention as a whole)가 아닌 구성(요소)별(individual elements of the claim)로 판단해야 한다는 견해¹⁸⁵⁾가 있으나, i) 발명 전체로 판단할 때 명세서 기재를 중심으로 과제해결원리를 객관적으로 파악할 수 있다는 점, ii) 발명 전체로 판단한다고

179) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424.

180) 한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것’의 의미와 판단방법”, 대법원 판례해설(제80호), 법원도서관, 2009, 647-649면.

181) 어떠한 기술적 과제의 해결수단이 다수 밀집되어 있는 기술분야일수록 과제의 해결원리의 동일성의 폭은 좁아질 수밖에 없다(특허법원 2007. 6. 22. 선고 2007허1008). 따라서 기본발명의 균등범위가 개량발명의 균등범위보다 더 넓다고 할 수 있다.

182) 출원경과를 참작하여 과제해결원리를 추가하는 것도 가능할 것이다. 발명의 과제해결원리의 수를 많이 잡을수록 균등이 되기 위해서는 침해제품이 모든 과제해결원리를 만족시켜야 할 것이므로 균등의 범위가 좁아지고, 제3자에게 불측의 손해를 주지 않기 때문이다(구민승, “특허 균등침해의 제1, 2요건”, 사법 48호, 사법발전재단, 2019 여름호, 94-95면).

183) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424.

184) 田村善之, “特許法における發明の本(質的部分という發想の意義)”, 日本(工業)所有權法學(會年報 32号, 200 8, 52-53.

185) 김동준, “균등침해 요건 중 과제해결원리 동일성 판단방법”, (사)한국지식재산학회, 「특허 침해소송의 이론과 실무」, 법문사, 2016, 221-222면 참조.

할지라도 구성요소완비의 원칙이나 제3요건 판단을 통해서 구성별 판단을 할 수 있으므로 균등론이 너무 확대되는 것을 충분히 예방할 수 있다는 점 등을 고려할 때 발명 전체로 판단함이 적절한 것으로 여겨진다. 제1요건을 발명 전체로서 판단하느냐 아니면 구성별로 판단하느냐는 발명의 구성을 본질적 구성(요부)과 비본질적 구성(비요부)으로 구분하였을 때 본질적 구성이 변경되었으면 결론이 다르지 않으나, 비본질적 구성이 변경되면 결론이 달라진다. 비본질적 구성이 변경되면 발명 전체로서 판단할 때는 과제의 해결원리가 동일하나, 구성별로 판단할 때는 과제의 해결원리가 달라지기 때문이다.¹⁸⁶⁾ 구성별로 제1요건을 판단하는 경우 비본질적 부분이 다소 많이 바뀌게 되면 제1요건을 만족하지 못하게 되는데, 이는 균등론 도입 취지에 반하는 결과를 낳게 된다. 즉 균등 여부를 발명 전체(invention as a whole)가 아니라 문제가 되는 변경된 구성별(individual elements of the claim)로 판단하여야 함은 당연하나, 그렇다고 하여 제1요건을 구성별로 판단하여야 하는 것은 아니다.¹⁸⁷⁾ 대법원 2019. 1. 31.자 2016마 5698 결정에서도 “발명의 설명에 구성 6 가이드케이스가 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내한다고 기재되어 있으나, 이러한 기능은 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내하는 것을 통해 앞서 본 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하는 데 기여하는 정도에 그칠 뿐 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심으로 파악할 수는 없다”라고 판시하여 구성별이 아닌 발명 전체로서 과제의 해결원리를 파악하고 있다.¹⁸⁸⁾

3. 제2요건: 변경가능성이 있을 것(작용효과가 실질적으로 동일할 것)

(1) 의 의

변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내어야 한다. 구체적으로 작용효과가 실질적으로 동일한지는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 확인대상발명도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 작용효과는 완전히 동일할 것까지는 필요 없고, 확인대상발명의 효과가 더욱 크거나 넓어도 좋고 더욱 작거나 좁아도 좋으며, 실질적으로 동일한 작용효과라면 충분하다.¹⁸⁹⁾ 즉 ① 부가적인 작용효과나 실시예에 특유한 작용효과까지 본 요건에서 말하는 특허발명의 작용효과로 보아 이 요건의 충족 여부를 판단하는 것은 타당하지 않다(확인대상발명이 특허발명의 부가적 작용효과까지 실현할 것을 요구하면, 균등이 성립할 여지가 거의 없게 된다). ② 그리고 확인대상발명이 특허발명의 작용효과 외에 별도의 부수적인 효과를 나타내는 것은 작용효과의 동일성을 부정하는 근거로 되지 않는다(확인대상발명이 개량 등으로 별개의 작용효과를 부가함으로써 침해를 면하는 것이 가능하다고 한다면, 균등을 인정하는 취지를 몰각하는 결과가 된다).¹⁹⁰⁾¹⁹¹⁾

186) 구민승, “특허 균등침해의 제1, 2요건”, 사법 48호, 사법발전재단, 2019 여름호, 79면 참조.

187) 구민승, “특허 균등침해의 제1, 2요건”, 사법 48호, 사법발전재단, 2019 여름호, 83면 참조.

188) 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결도 동일한 취지로 판결하였다.

189) 中山信弘 외 3인 편저, 사단법인 한국특허법학회 역, 「특허판례백선」, 박영사, 2014, 439면, 451-452면.

190) 정택수, “균등침해의 적극적 요건과 이용침해의 성립요건(대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788)”, 대법원 판례해설 제104호, 법원도서관, 2015, 347-348면.

(2) 발명 전체 vs. 구성별 판단

대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결에서는 “발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다”라고 판시하였다. 제2요건을 판단할 때 특허발명의 기술사상의 핵심이 확인대상발명에 구현되어 있다면(제1요건을 만족한다면) 작용효과가 동일하다(제2요건을 만족한다)고 볼 수 있으나, 특허발명의 기술사상의 핵심이 공지된 경우에 문제이다. 제1요건을 적용할 때 해결원리를 상위개념화하지 않고 청구범위에 근접해서 파악하여 균등범위를 줄여야 하나, 그렇다고 하여 기술사상의 핵심이 없다고 단정할 수는 없고, 확인대상발명에 기술사상의 핵심이 포함된 경우를 가정할 수 있을 것이다. 대상판결은 이 경우 제2요건을 적용할 때 개별 구성의 기능이나 효과 등을 비교하여야 한다는 것이다.¹⁹²⁾¹⁹³⁾

4. 제3요건: 변경용이성이 있을 것(구성변경이 자명할 것)

(1) 판단시점

그와 같이 변경하는 것 자체가 통상의 기술자라면 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도이어야 한다. 한편 변경용이성의 판단시점이 문제인데 미국, 일본,¹⁹⁴⁾ 유럽과 마찬가지로 대법원은 균등

191) 확인대상발명이 기술사상의 핵심과 관련이 없는 관용적 기술수단을 채택하고 있고 이로 인해 효과의 차이가 있다고 할지라도 이는 부수적인 효과의 차이에 불과하므로 실질적인 작용효과에 차이가 있다고 할 수 없다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361).

192) 특허 균등침해의 제1요건인 ‘과제해결원리의 동일’과 관련하여 대법원은 발명 전체의 관점에서 전체 발명의 과제해결원리가 같은지를 판단(제1설)해 왔다고 볼 수 있다. 제2요건인 ‘작용효과’의 동일과 관련하여도 발명 전체의 효과를 염두에 두고 비교해야 한다는 입장을 취하여 왔다. 이에 대하여 균등판단은 발명 전체가 아닌 구성요소별로 이루어지므로 제1요건 판단도 역시 구성요소별로 이루어져야 한다는 입장(제2설)이 형성되어 있다. 최근에 선고된 두 대법원판결(대법원 2019. 1. 31.자 2016마5698 결정, 같은 날 선고 2018다267252 판결)은 이러한 논란에 대하여 종전 대법원 입장인 발명 전체의 관점에서 과제해결원리를 판단하는 것이 원칙임을 선언하면서 이에 의할 때 균등 범위가 지나치게 넓어질 수 있다는 단점을 보완하는 법리를 제시하였다. 두 입장의 장점을 살려 핵심적 구성이나 기술사상이 공지되지 않았을 때는 제1설을 통해 균등을 넓히고, 공지되거나 그와 다른 것을 없앨 때에는 제2설적 요소를 가미해 균등을 좁혀야 함을 나타냄으로써 제1설을 중심으로 제2설을 통합하였고, 공지기술의 참작이 그 통합의 연결고리가 되었다. 특히 ‘선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데’에서 특허발명의 실질적 가치를 찾을 수 있고, 그 실질적 가치에 따라 특허발명의 보호범위가 결정되어야 하며, 명세서와 공지기술을 통해 그 실질적 가치 파악이 객관화될 수 있고, 과제해결원리의 파악은 이러한 특허발명의 실질적 가치를 명시적으로 고려하는 요건으로 기능한다는 취지의 판시는 실무적으로 큰 의미를 가질 것으로 본다(구민승, “특허 균등침해의 제1, 2요건”, 사법 48호, 사법발전재단, 2019 여름호, 요지).

193) 결국 제1요건과 제2요건의 구체적인 적용형태는 다음과 같이 유형화될 수 있을 것이다(구민승, “특허 균등침해의 제1, 2요건”, 사법 48호, 사법발전재단, 2019 여름호, 97면).

론에 의한 발명 보호의 실효성을 높이기 위해 침해 시(제조시점)를 기준으로 판단하고 있다.¹⁹⁵⁾ 즉 특허발명의 출원 이후 침해 시(권리범위확인심판에서는 심결 시)까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다.

(2) 진보성과의 관계

① 문제의 소재

제29조제2항은 특허출원 전에 통상의 기술자가 제29조제1항 각호의 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 특허를 받을 수 없다고 하여 진보성에 관한 규정을 두고 있는데, 진보성에서 발명의 용이성과 균등론에서의 변경용이성의 수준의 차이가 있는지가 문제이다.

② 학설의 대립

1) 제1설은 진보성의 용이성이 균등론의 변경용이성보다 더 높은 수준이라는 설이다.¹⁹⁶⁾ 즉 균등의 용이성이 진보성에서의 용이성보다 더 용이한 것, 즉 기술적으로 더 낮은 수준이라는 것이다. 이 설에 의하면 공지기술로부터 용이한 발명은 다시 변경용이성이 있는 발명과 없는 발명으로 구분되는데, 변경용이성이 있는 발명이 균등물이라고 보는 입장이다.

구 분	기술사상의 핵심이 공지되지 아니한 경우	기술사상의 핵심이 공지된 경우
본질적 구성의 차이가 있는 경우	-선행기술과 비교하여 정해지는 발명의 실질적 가치를 기준으로 구성에서 과제해결원리가 어느 정도 상위개념화가 가능함 (균등범위가 넓어짐). -과제해결원리가 동일하다면, 이러한 해결원리를 구현하는지의 관점에서 효과가 동일한지를 판단하므로 제2요건도 만족되기 쉬움	-과제해결원리가 청구범위의 구성에 근접한 것으로 파악되어야 함 (균등범위가 좁아짐)
비본질적 구성의 차이가 있는 경우	-본질적 구성이 공통되므로 과제해결원리가 같음 -해결원리를 구현하는지의 관점에서 효과가 동일한지를 판단하므로 제2요건도 만족되기 쉬움	-본질적 구성이 공통되므로 과제해결원리가 같음 -그러나 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술 과제를 해결하였다고 할 수 없으므로 차이나는 구성의 기능이나 역할을 비교하여 양자의 작용효과가 동일하지 않다고 볼 수 있음

194) 일본의 최고재판소의 판시사항(最判 평성 10년 2. 24. 판시1630호, 32면, 最判 평10년 2. 24. 판시1630호, 32면)을 예로 들면 다음과 같다. “청구범위의 구성요소 중에 대상 제품과 다른 부분이 존재하여도 그것이 ① 특허발명의 본질적인 부분이 아니고, ② 치환하여도 특허발명의 목적을 달성할 수 있고, ③ 그 치환은 통상의 기술자가 제조시점에 있어서 용이하게 생각이 미칠 수 있는 것이며, ④ 대상 제품이 출원 시에 있어서의 공지기술과 동일 또는 통상의 기술자가 출원 시에 용이하게 생각할 수 있었던 것은 아니며, ⑤ 대상 제품이 출원원질차에 있어서 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특단의 사정이 없을 때에는 균등으로서 특허발명의 기술적 범위에 속한다.”

195) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210. 이와 같이 침해시점을 기준으로 삼는 일본, 미국의 주된 논리적 근거는 특허권자가 출원 시점에 향후 통상의 기술자가 용이하게 치환할 수 있는 것 모두를 예상하여 청구범위에 적을 수 없고, 이를 특허권자에게 책임을 지우는 것은 부당하다는 것이다. 다만 특허권자가 출원 시에는 인식(예상)할 수 없었던 치환요소까지 권리범위에 포함시키는 것으로서 권리자를 과도하게 보호하는 것이라는 비판이 있다(남석우, “균등침해시 치환의 용이성 판단시점”, 지식재산21, 2010년 1월, 132면)

196) 中山信弘, 「註解 特許法」, 제2판, 青林書院, 1994, 568면.

2) 제2설은 진보성의 용이성과 균등론의 용이성이 같은 수준이라는 설이다.¹⁹⁷⁾ 특허성에 대한 심사에서 심사관이 인정한 범위를 넘어서 청구범위의 한정사항을 확장해석하는 것을 제한할 필요가 있다는 점, 특허심사와 특허침해소송이 일관성을 갖게 되며 아울러 균등론 판단에 진보성에 대한 심결취소소송의 판결 및 각종 자료 등을 이용할 수 있게 되어 객관적인 판단을 기대할 수 있고 나아가서는 법적 안정성에도 기여할 수 있다는 점을 그 근거로 하고 있다.

③ 소 결

1) 제2설에서는 제1설과 같이 균등론에서 말하는 변경의 용이성이 진보성에서 말하는 발명의 용이성보다 기술적으로 낮은 수준의 것이라고 한다면, 변경의 용이성은 벗어났으나 발명의 용이성은 벗어나지 못한, 즉 진보성이 없어 특허로 보호될 정도의 것은 아니나 그렇다고 균등영역에서의 침해도 아닌 그야말로 특허법이 제대로 기능할 수 없는 「회색의 기술영역(gray arts zone)」이 존재하게 된다는 것이라고 비판한다. 다시 말해서 특허권으로는 보호되지 아니하나, 그렇다고 특허발명에 대한 침해는 구성하지 아니한 기술영역이 존재하게 되는데, 이는 특허소송에서 검토하여야 할 확인대상발명의 대다수가 위 영역에 포함되게 되기 때문에 제1설은 타당하지 아니한다고 비판을 하고 있다.

2) 그러나 제2설에서는 이 영역을 이른바 「회색의 기술영역」이라고 비판을 하지만, 이 영역은 이른바 「공공영역(public domain)」에 속하면서 제3자의 독점이 허용되지 아니한, 즉 후출원 배제의 효과가 나타나는 영역으로서 발명자와 공중의 이익 사이의 균형점을 추구하는 특허법 으로서는 이를 당연히 예정하고 있는 것이므로, 이 영역에서 특허법이 제대로 기능하지 못한다고 볼 것이 아니므로 제1설이 타당하다고 여겨진다. 따라서 기본발명의 특허권자는 이 영역에서 제3자의 실시행위가 있다 하더라도 침해를 주장할 수는 없지만, 그 제3자가 후출원을 하게 되면 진보성이 없어 특허거절결정을 받게 된다.

3) 다만 이와 같은 논의는 구성요소를 변경한 경우에만 적용되는 것이며, 구성요소를 부가한 경우는 적용되지 않는다. 구성요소를 부가한 발명이 진보성이 있어 등록되었다 하더라도 구성요소완비의 원칙에 의하여 선출원 권리의 침해가 될 수 있다.¹⁹⁸⁾ 즉 특허요건으로서의 진보성의 판단과 보호범위의 판단은 전혀 별개의 개념으로 파악하여야 한다.¹⁹⁹⁾

197) 민병호, “일본의 균등론 성립요건에 관한 고찰”, 제간 창작과 권리 제2호, 1996, 34면.

198) 예를 들어 선출원 권리의 구성요소가 a+b+c이고 후출원 권리의 구성요소가 a+b+c+d인 이용관계가 이에 해당한다.

199) 균등침해와 진보성의 판단방법은 구성요소의 치환이 통상의 기술자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 것인지가 쟁점이 되므로(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 참조) 진보성의 판단 방법과 매우 유사한 점이 있으나, 균등침해는 제3자가 실시하고 있는 기술내용이 특허발명의 구성요소를 전부 포함하고 있는 것을 전제로 하는 데 비해 진보성의 판단은 특허발명과 대비되는 선행발명 하나에 특허발명의 기술내용과 대비할 만한 기술내용이 전부 개시되어 있을 것을 요하지 아니한 점에서(여러 선행기술의 결합에 따라 진보성 구비 여부를 판단할 수 있다) 원칙적으로 차이가 있다(특허법원, 「특허재판실무편람」, 2002, 98면).

5. 제4요건: 특별한 사정이 없을 것

(1) 의 의

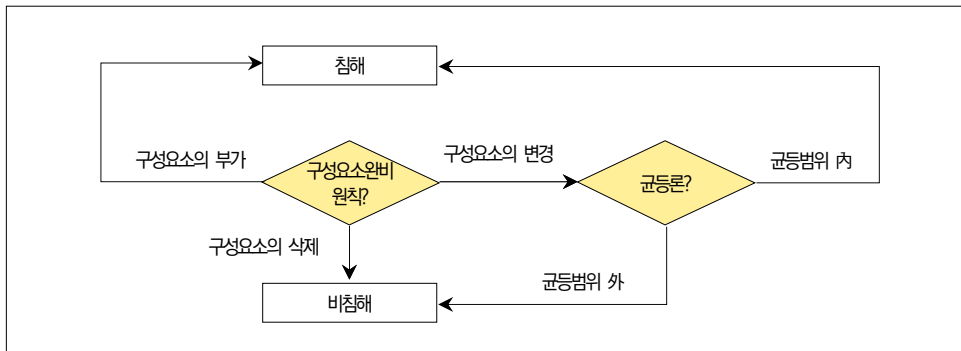
「특별한 사정」이란 i) 확인대상발명이 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 공지 기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 ii) 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 변경(치환)된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 사정을 말한다.²⁰⁰⁾ 즉 자유기술의 영역에 속하는 부분이나 출원절차에서 의식적으로 제외된 부분 등까지 보호범위를 인정하는 것은 제3자에게 불측의 손해를 끼칠 수 있으므로 특허권자와 제3자와의 형평성을 고려하여 균등범위의 제한을 두고 있다.

(2) 확인대상발명이 공지기술이 아닐 것

확인대상발명이 해당 특허발명의 출원 시점에 있어서 공지된 기술과 동일하거나 그로부터 그 출원 시에 통상의 기술자가 쉽게 창작해낼 수 있었던 것이라면 균등물이라 할 수 없다. 이는 특허발명이 애당초 특허를 받을 수 없었던 공공영역까지 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것으로서, 이를 이유로 항변하는 것을 자유기술의 항변이라고 한다.

(3) 의식적으로 제외된 것이 아닐 것

해당 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 변경된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것이 아니어야 한다. 이처럼 출원절차에서 의식적으로 제외된 것에 대한 균등범위를 인정하지 않는 것을 출원경과참작의 원칙이라고 한다.



【그림 6-11】 구성요소완비의 원칙과 균등론의 적용

200) 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806.

VI. 법률에 의한 제한·확장의 고려

1. 법률에 의한 제한

1) 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 구성요소완비의 원칙, 균등론에 의한 결과 확인대상발명이 특허발명의 실시라고 하더라도 법률의 제한에 해당하면 확인대상발명은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 된다. 법률에 의한 제한으로는 i) 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96)²⁰¹⁾, ii) 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한(法 181), iii) 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권의 효력 제한(法 81의3④) 등을 들 수 있다. 이와 같은 사유는 특정물건이나 행위에 대하여 특허권의 효력이 제한되는 것으로서 행위주체를 묻지 아니한다. 이러한 의미에서 권리범위의 한계를 나타내는 것이라 할 수 있다.

2) 다만 실시권의 존재,²⁰²⁾ 권리소진의 적용을 받는 물건²⁰³⁾ 등은 실시가 침해로 인정되지 아니한 주관적인 측면, 즉 정당한 권원에 관한 것으로서 침해의 객관적인 측면에 관한 보호범위의 확정 시 문제되는 법률에 의한 제한에는 해당하지 아니한다.²⁰⁴⁾

-
- 201) 특허심판원 2008.3.24 심결 2007당2503 적극적 권리범위확인심판 사건 심결에서는 “특허권 존속기간 중에 제너릭 의약품의 허가를 위하여 행한 생물학적 동등성 시험에 대해 특허심판원은 “피청구인이 확인대상 발명을 제조한 것은 생동시험을 실시하기 위한 것이고 이러한 생동시험은 제너릭 의약품이 기존 신약을 대체할 수 있는 정도로 생물학적으로 동등한지 여부를 확인하는 시험으로서 특허법 제96조 제1항 제1호의 시험에 해당하는 것으로 인정되므로 이를 위한 확인대상발명의 생산, 즉 제조 행위는 특허법 제96조제1항제1호에서 규정하는 ‘연구 또는 시험을 하기 위한 특허발명의 실시’라고 봄이 타당하다”라고 판시하였다.
- 202) 디자인권의 권리범위확인심판에서 대법원 1974. 8. 30. 선고 73후8 판결은 “피청구인의 확인대상 디자인이 청구인의 본건 디자인에 유사하다면 피청구인의 확인대상 디자인은 청구인의 본건 등록디자인의 권리범위에 속한다고 할 것이며 피청구인의 주장대로 본건 디자인등록의 출원 전부터 확인대상 디자인의 실시사업을 하였다면 선사용권이 있는지 여부는 권리범위를 확인하는데 아무 관련이 없다”라고 판시하고 있다. 특허권에 관한 권리범위확인심판사건에서 특허법원 2005. 6. 24. 선고 2004허3478 판결은 “한국전력공사가 선사용권을 가지는지 여부는 이 사건 특허발명 자체의 권리범위를 확정하는데 아무런 관련이 없고, 위와 같은 사유는 구체적인 실시사업에 관한 침해소송에서 항변으로서 주장되거나, 별도의 확인소송에서 주장되어야 할 것이므로, 원고의 위 선사용권 주장은 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다”라고 판시하여 같은 입장을 취하고 있다. 또한 상표권에 관한 권리범위확인심판사건에서 대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24 판결도 “상표권의 권리범위확인청구는 단순히 그 상표자체의 기술적 범위를 확인하는 사실확정을 목적으로 한 것이 아니라 그 기술적 범위를 기초로 하여 구체적으로 문제가 된 상대방의 사용상표와의 관계에 있어서 그 상표에 대하여 등록상표권의 효력이 미치는 여부를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이다. 그러므로 상대방의 사용상표가 상표법 제26조 각 호에 규정된 자기의 성명·명칭·상호등 상표권의 효력이 미치지 아니하는 상표에 해당하는 경우에는 이는 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 볼 수밖에 없으며, 상표권의 효력은 미치나 별도로 설정된 사용권에 의하여 상표권자에게 그 상표의 사용을 주장할 수 있는 경우와 같이 볼 수는 없는 것이다”라고 판시하여 같은 입장을 취하고 있다.
- 203) 특허권의 적극적 권리범위확인심판은 특허발명의 보호범위를 기초로 하여 심판청구인이 확인대상발명에 대하여 특허권의 효력이 미치는가를 확인하는 권리확정을 목적으로 한 것이므로, 설령 확인대상발명의 실시와 관련된 특정한 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 하더라도 그와 같은 사정은 특허권 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론으로 하고 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다. 구체적으로 명칭을 ‘유기성 폐기물을 순간 고온처리하여 사료를 제조하는 방법’으로 하는 특허발명 청구범위 제1, 2항에 대한 특허권의 공유자 중 1명의 소유였던 사료제조 설비가 무에게 양도된 사안에서, 무이 위 설비를 이용하여 확인대상발명을 실시하는 것과 관련하여 확인대상발명이 그 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과 위 특허권이 소진되었는지 여부는 아무런 관련이 없다고 판시하였다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289).

2. 법률에 의한 확장

확인대상발명의 실시가 특허발명의 실시가 아니라고 하더라도 법률의 확장인 간접침해(法 127)에 해당하면 특허발명의 보호범위에 속하게 된다.

제4관 관련문제

I. 역균등론

「역균등론」이란 문언상으로는 청구범위에 기재된 구성요소가 모두 포함되어 있으나 실질적으로는 상이한 방법으로 기능을 수행할 정도로 변경이 크게 이루어졌을 때 균등론의 적용을 역으로 하여 해당 특허권의 범위를 제한하는 이론이다. 예를 들어 청구범위에는 금속으로 기재되어 있고 발명의 설명에는 구리(Cu)만 기재되고 있는데, 제3자의 실시가 철(Fe)인 경우 문언적으로는 특허발명의 침해가 되나, 실질적으로는 기술적 원리를 달리한다면 침해가 되지 아니한다고 할 수 있다. 역균등론은 균등론이 항상 특허권자에게만 유리하게 적용되는 것이 아니며 때로는 특허권자에게 불리하게 작용할 수 있는 것을 의미하는 것으로서, 균등론과 함께 형평의 원칙에 의하여 인정되는 원칙이다.²⁰⁵⁾ 다만 역균등론은 특허권을 유명무실하게 할 수 있으므로 그 적용에 있어서 신중을 기하여야 할 것이다.

II. 특허요건과 보호범위 판단 시 발명의 특정

1. 청구범위 중심과 발명의 설명 참조

1) 특허요건과 보호범위를 판단할 때 발명의 특정은 청구범위를 중심으로 한다. 따라서 청구범위에 기재된 청구항은 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있어야 한다(法 42④II). 청구항의 기재가 불명확하거나 그 기재내용이 간결하지 아니한 발명은 특허요건 판단 등이 불가능하며 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확하여 특허발명의 보호범위를 결정할 수 없기 때문이다.

2) 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하려는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다.²⁰⁶⁾ 문제가 되는 것은 청구범위에 기재된 발명을 여러 가지 사정을 고려하여 제한 해석을 할 수 있는지는 것이다.

204) 따라서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는데 이와 같은 항변을 하는 경우에는 그 항변을 배척하여야 하고, 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 이러한 것을 이유로 한 경우에는 확인의 이익이 없어서 각하되어야 한다.

205) C. Bruce Hamburg 著, 이선희 譯, 「미국에 있어서의 균등론」, 대한변리사회, 1998, 178-191면.

206) 대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011; 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 등.

2. 제반 사정에 의한 제한 해석이 인정되는지 여부

(1) 특허요건 판단

1) 특허요건 판단을 위해 발명을 특정할 때는 제반 사항에 의하여 청구범위에 기재된 발명을 제한 해석해서는 안 된다. 만약 이를 인정하게 된다면 출원인이 표시한 의사를 심사하는 측에서 임의로 변경하는 것을 허용하는 결과가 되고, 기재불비가 있거나 특허요건을 구비하지 못한 발명이 등록될 수 있는 불합리가 발생하기 때문이다.

2) 예를 들어 특허요건을 판단할 때는 발명의 설명이나 도면에 의하여 청구범위에 적혀 있는 사항을 통상의 의미 이상으로 확장하거나 제한하여 해석하는 것은 허용되지 아니한다.²⁰⁷⁾²⁰⁸⁾ 또한 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 또는 종래기술인 정도를 넘어서 공지기술이라는 취지로 청구범위의 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에 별도의 증거 없이도 전제부 기재 구성요소를 출원 전 공지된 것이라고 사실상 추정할 수 있으나 이러한 추정이 절대적인 것은 아니므로 출원인이 실제로는 출원 당시 아직 공개되지 아니한 선출원발명이나 출원인의 회사 내부에만 알려져 있었던 기술을 착오로 공지된 것으로 잘못 기재하였음이 밝혀지는 경우와 같이 특별한 사정이 있는 때에는 추정이 반복될 수 있다.²⁰⁹⁾

(2) 보호범위 판단

1) 보호범위 판단을 위해 발명을 특정할 때는 특별한 사정에 의하여 청구범위에 기재된 발명을 제한 해석할 수 있다. 특별한 사정이란 제3자의 입장을 고려한 사정으로, 청구범위에 적혀 있는 사항이라는 사정만으로 보호할 가치가 없는 사항이나 진실로 발명하지 아니한 부분까지 그 권리를 인정하는 것은 제3자에게 불측의 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

207) 특허출원된 발명이 특허법 제29조제1항, 제2항에서 정한 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원된 발명을 같은 조 제1항 각호에서 정한 발명과 대비하는 전제로서 그 발명의 내용이 확정되어야 하는바, 청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받으려는 사항이 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여야 하고 발명의 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 따라 청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다. 따라서 특허출원된 발명의 청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하여야 한다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977; 2007. 6. 14. 선고 2007후807; 2006. 10. 13. 선고 2004후776; 2010. 1. 28. 선고 2008후26 등).

208) 청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허등록의 유·무효 판단을 위한 특허발명의 요지를 인정하는 경우에 청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수는 없다(대법원 2005. 11. 24. 선고 2003후2515; 2001. 9. 7. 선고 99후734 등).

209) 대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37. 판결은 더 나아가 “대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결 등이 인정하고 있는 출원경과금반언의 원칙은 출원경과 중에 밝힌 출원인의 의견 표명에 대하여 일정한 요건 아래 ‘의식적 제외’로 인정하고 그 영역에 속하는 부분은 해당 특허발명의 침해 여부 판단 시 권리범위에서 배제된 것으로 보는 법리인데, 일단 의식적 제외로 인정하는 이상은 그 효과를 반복시킬 수 있는 구조가 아니다. 만일 이러한 강력한 효과를 공지 자인에 대해서도 확장하여 적용하면, 출원인이 출원경과 중 의식적으로 해당 기술이 공지된 것이라는 취지를 밝힌 이상은 객관적 진실에 부합하는지와 무관하게 공지기술로 확정하여야 하므로 매우 부당한 결과를 초래한다. 이러한 점에서 볼 때에도 사실상의 추정 및 복명의 허용이라는 구도가 타당하다”라고 하여 그 이유를 제시하고 있다.

2) 예를 들어 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 특별한 사정이 있다면 발명의 설명의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 보호범위를 정할 수 있다.²¹⁰⁾ 또한 출원과정 중에 출원인의 의견 표명에 대하여 일정한 요건 아래 「의식적 제외」로 인정하고 그 영역에 속하는 부분은 보호범위 판단시 배제시킬 수 있고(출원경과참작의 원칙),²¹¹⁾ 공지기술을 참작하여 공공영역에 속하는 발명을 보호범위에서 제외시킬 수 있으며(공지기술참작의 원칙). 신규성, 선출원주의, 확대된 선출원 위반이나 착오로 등록된 경우, 실시불가능한 경우, 발명의 설명을 참작하더라도 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우에는 보호범위를 인정하지 않을 수 있다(특허권 하자 참작의 원칙).

3) 이처럼 특허요건과 특허발명의 보호범위를 판단할 때 발명의 특정하기 위한 청구범위의 해석은 차이가 있으며, 대개 특허발명의 보호범위를 판단할 때의 외연이 특허요건 판단보다 상대적으로 좁게 된다.

【표 6-5】 특허요건과 보호범위 판단 시 청구범위에 기재된 발명 특정의 비교

발명의 특정	특허요건 판단	보호범위 판단
청구범위 중심의 원칙	적용	적용
발명의 설명 참작의 원칙	적용	적용 (제한 해석 가능)
공지기술 참작의 원칙	부적용 (발명의 특정 후 신규성, 진보성 판단으로 갈음)	적용 (제한 해석)
출원경과 참작의 원칙	부적용 (다만 출원인이 공지되었음을 자인하는 경우 공지된 것으로 추정).	적용 (제한 해석)
특허권하자 참작의 원칙	부적용 (발명의 특정 후 신규성, 진보성 등의 판단으로 갈음)	적용 (제한 해석)
비 고	출원인이 표시한 의사를 심사하는 측에서 임의로 변경하는 것을 허용하는 결과가 되고, 기재불비가 있거나 특허요건을 구비하지 못한 발명이 등록될 수 있는 불합리가 발생하기 때문에 제한 해석 불가	청구범위에 적혀 있는 사항이라는 사정만으로 보호할 가치가 없는 사항이나 진실로 발명하지 아니한 부분까지 그 권리를 인정하는 것은 제3자에게 불측의 손해를 줄 수 있기 때문에 제한 해석 가능

210) 대법원 2019. 7. 10. 선고 2017다209761 등.

211) 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다. 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다(대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340).

1. 구별의 필요성

발명을 완성한 후 특허출원하였을 때 특허를 받을 수 있는 것인지의 판단인 특허요건 판단과 발명을 실시하는 것이 타인의 특허를 침해하는 것인지의 판단인 침해 성립요건 판단은 전혀 별개의 문제라고 할 수 있다. 특허요건 판단은 선행기술과의 관계에서 특허출원한 발명이 동일성, 용이성이 있는지를 판단하는 것이지만, 침해 성립요건 판단은 선행특허와의 관계에서 특허를 받은 발명의 실시가 구성요소완비의 원칙과 균등론의 적용에 의하여 선행특허의 보호범위에 속하는지를 판단하는 것이기 때문이다. 이것은 디자인이나 상표가 등록요건 판단과 침해 성립요건 판단이 대체로 비슷한 점에 비추어 봤을 때 특허의 가장 큰 차이점이라 할 수 있다.

2. 구체적 예

(1) 서

「a+b+c」가 출원되어 출원공개 또는 등록공고된 특허발명이라는 가정하에 「a+b」, 「a+b'+c」, 「a+b+c+d」 발명을 출원하였을 때 특허를 받을 수 있는지와 실시가 「a+b+c」의 특허발명을 침해하는지에 대하여 구체적으로 검토해 본다.

(2) 「a+b」와 관련하여

① 특허를 받을 수 있는지 여부

소기재 광범위의 원칙에 따라 「a+b」는 「a+b+c」보다 상위개념발명이기 때문에 「a+b+c」의 공개시 또는 출원일보다 후출원한 경우 동일성과 관련된 특허요건인 신규성(法 29①각호), 확대된 선출원(法 29③④) 또는 선출원주의(法 36)의 위반으로 특허를 받을 수 없다.

② 침해인지 여부

「a+b」를 실시하더라도 구성요소의 생략이므로 구성요소완비의 원칙에 의하면 「a+b+c」의 보호범위에 속하지 아니하여 「a+b+c」의 침해가 아니다. 다만 「a+b」가 「a+b+c」의 생산에만 사용되는 물건에 해당한다면 간접침해일 수 있다.

(3) 「a+b+c+d」와 관련하여

① 특허를 받을 수 있는지 여부

다기재 협범위의 원칙에 따라 「a+b+c+d」는 「a+b+c」보다 하위개념발명이기 때문에 「a+b+c」와 관련하여 동일성이 없다. 다만 「a+b+c」의 공개시 이후에 출원한 경우 진보성이 있는지 문제가 될 수 있다. 출원발명은 구성요소 「d」의 결합에 곤란성, 효과의 현저성이 있다면 진보성이 있으므로 다른 거절이유가 없는 한 특허를 받을 수 있다.

② 침해인지 여부

「a+b+c+d」를 실시하는 경우 구성요소의 부가이므로 구성요소완비의 원칙에 의하면 「a+b+c」의 보호범위에 속하게 되고, 「a+b+c+d」의 실시자에게 정당한 권원이 없다면 「a+b+c」의 침해가 된다. 한편 만약 「a+b+c+d」가 등록이 되었다면 이를 이용관계라 한다.

(4) 「a+b'+c」와 관련하여

① 특허를 받을 수 있는지 여부

1) 「b」와 「b'」의 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주자관용기술의 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면(선출원주의에서는 그 차이가 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용 효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우라면) 서로 실질적으로 동일성이 있어서 신규성(法 29①각호), 확대된 선출원(法 29③④) 또는 선출원주의(法 36)의 위반으로 특허를 받을 수 없다.

2) 한편 「a+b'+c」가 실질적 동일성이 없더라도 「a+b+c」의 공개시 이후에 출원되었다면 진보성이 있어야 특허를 받을 수 있다.

② 침해인지 여부

「a+b'+c」가 「a+b+c」와 관련하여, i) b와 b'의 변경이 있는 경우에도 과제의 해결원리가 동일할 것, ii) b를 b'로의 변경에 의하더라도 a+b+c와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낼 것, iii) b를 b'로의 변경이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도일 것이어야 하고, iv) a+b'+c가 특허발명인 a+b+c의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 v) a+b+c의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 변경된 구성요소 b'가 청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특별한 사정이 없는 경우 「a+b+c」의 균등물이 되어 「a+b+c」의 보호범위에 속하게 되고 「a+b'+c」의 실시자에게 정당한 권원이 없다면 「a+b+c」의 침해가 된다.

[특허요건 판단과 침해 성립요건 판단의 구별]

구 분		특허발명	확인대상발명	침해 성립요건 판단	특허요건 판단
AER	부가 법칙	a+b+c	a+b+c	침해	동일성이 있어 등록불가(法 29①·29③④·36 위반)
			a+b+c+d	침해	공개 전 출원은 등록가능하고, 공개 후 출원이라면 진보성이 있는 경우 등록가능(등록된 경우 이를 이용관계라 함)
	생략 법칙	a+b+c	a+b	1. 원칙 → 비침해 2. 예외 → 간접침해	동일성이 있어 등록불가(法 29①·29③④·36 위반)
균 등 론		a+b+c	a+b+c'	1. 침해 (1) 과제해결원리○ (2) 변경가능성○ (3) 변경용이성○ (4) 특별사정 × 2. 그렇지 아니하면 비침해	1. 구성의 차이가 주자관용기술의 부가, 삭제, 변경에 불과하고 새로운 효과도 발생하지 아니한 경우라면(선출원주의에서는 그 차이가 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경에 지나지 아니하고 발명의 목적과 작용 효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 경우라면) 실질적 동일성이 있어 등록불가(法 29①·29③④·36 위반) 2. 구성의 곤란성이 없고 효과의 현저성이 없어서 용이하다면, 공개 전 출원은 등록가능하고 공개 후 출원이라면 진보성 위반으로 등록불가 3. 그렇지 아니하면 등록가능

제4절 이용·저촉발명

제98조 【타인의 특허발명 등과의 관계】

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

제1관 서 설

I. 의 의

1. 이 용

(1) 문제의 소재

「이용」이란 후출원 권리자가 자기의 특허발명 등을 실시하면 선출원인 타인의 특허발명 등을 실시하게 되지만, 선출원 권리자가 자기의 특허발명 등을 실시하면 후출원 특허발명 등의 실시로는 되지 아니한 일방적 충돌관계를 말한다. 한편 이용발명이 구체적으로 무엇인지에 대해서는 다음의 몇 가지 학설이 있다.

(2) 학 설

i) 선출원 특허발명의 구성요소 전부 또는 주요부분을 발명의 구성요소의 주요부분으로 하는 발명이라고 보는 주요부설, ii) 타인의 선출원 특허발명을 기초로 하여 이를 개량·확장한 발명이라고 보는 개량확장설, iii) 선행발명의 구성요소에 새로운 기술적 요소를 부가한 것으로서 그 실시가 당연히 선행발명의 실시를 수반하는 것이므로 선행발명의 특허요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용한 것이어야 한다는 요지공통설(그대로설), iv) 선출원의 특허발명을 실시하지 아니하면 자기의 특허발명을 실시할 수 없는 관계에 있는 것이라는 실시불가피설이 있다.

(3) 검 토

1) i) 주요부설은 주요부를 어떻게 해석하느냐에 따라 그 범위가 지나치게 확장될 우려가 있다는 문제점이 있으며, ii) 개량확장설은 개량확장의 개념이 명확하지 않고 개량 또는 확장에 의하여 별개의 발명이 될 수 있으므로 타당하지 않다. 우리나라 및 일본의 통설적 지위를 차지하고 있는 학설은 그대로설이며, 다만 선출원 발명이 물건발명이고 후출원 발명이 물건의 제조방법발명인 경우를 고려하여 실시불가피설도 포함하는 것이 타당하다고 여겨진다.

2) 대법원²¹²⁾은 “선행특허발명과 후발명이 이용관계에 있는 경우에는 후발명은 선행특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후발명이 선행특허발명의 기술적 구성요소에 새로운

기술적 요소를 부가하는 것으로서 후발명이 선평발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후발명 내에 선평발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 선평발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다”라고 함으로써 그대로설의 입장에서 판시하되, 균등물을 이용하는 경우에도 이용관계를 긍정함으로써 그대로설을 확장해석하고 있다. 균등물에 어떠한 요소가 부가되어 진보성(法 29②)이 있는 경우 등록될 수 있으나, 등록 후의 실시는 선출원 권리의 침해가 되기 때문에 후출원 권리자에게 실시권능을 확보해 줄 필요성의 입장에서 대법원의 태도가 타당한 것으로 여겨진다.

3) 다만 이용발명의 범위가 모호해지고 지나치게 확장되는 것을 제한하기 위해 선행발명의 기술적 요지를 보완·개량한 이용발명은 「구성요소의 일체성」 측면이 요구된다. 즉 부가된 구성요소에 의하여 기본발명이 목적으로 하는 작용효과가 상실되고 다른 것으로 전환되는 경우에는 구성요소의 일체성이 유지된다고 볼 수 없으므로 이용관계가 부정될 것이다.²¹³⁾²¹⁴⁾

2. 저 축

「저축」이란 후출원인 특허권이 선출원인 타인의 디자인권 또는 상표권과 완전히 동일한 것으로서, 두 개의 권리가 중복되어 그 어느 쪽을 실시해도 타방의 권리를 실시하게 되는 쌍방향 충돌관계를 말한다. 저축발명이란 이러한 저축관계가 성립되는 발명을 말한다.

II. 법 규정

제98조에서 “특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한

212) 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393; 2001. 8. 21. 선고 98후522 등.

213) 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결에서 특허등록된 확인대상발명이 선 특허발명인 제30항 발명과 이용관계에 있는가가 문제되었다. 위 판결의 사안에서 제30항 발명은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대 등의 효과를 위하여 선재를 한 방향으로만 형성한 것인 데 비하여, 확인대상발명은 하나의 석쇠틀에서 가로, 세로 방향으로 선재가 교차되는 양방향 구성을 채택하고 있었다. 심결과 원심은 이용관계에 있다고 판단하여 일단 본안판단으로 나아간 후 막상 권리범위 속부 실제 판단에서는 확인대상발명의 구성이 제30항 발명의 권리범위에서 의식적 제외된 구성이라고 보아 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 그러나 대법원은, 이용관계 해당 여부에 관한 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결의 판단기준을 인용한 다음, 하나의 석쇠틀에서 가로, 세로 방향으로 선재가 교차되는 확인대상발명의 양방향 구성은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대와 같은 한 방향 구성의 효과를 나타낼 수 없어 제30항 발명과 상이한 구성이라고 할 것이고, 확인대상발명 내에서 제30항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 볼 수도 없어 두 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 권리범위확인심판 청구는 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적인 권리범위확인심판으로서 부적법하다고 판단하였다.

214) ‘A에 B를 반응시켜 물질 X를 제조하는 방법’이라는 선행발명에 대하여 ‘A에 B와 C를 반응시켜 물질 Y를 제조하는 방법’이라는 발명은 A가 B에 반응하여 X가 제조되고 다시 이것에 C가 반응하여 Y가 제조되는 경우가 아니라면 이용관계에 있다고 보기 어려울 것이다(조영선, 특허법, 박영사, 2015, 416면).

디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다”라고 규정하고 있다. 제98조는 제94조제1항에서 “특허권자는 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다”라고 규정하고 있는 특허권의 적극적 효력을 제한하고 있다.²¹⁵⁾

Ⅲ. 취 지

발명은 기술적 사상의 창작이므로 개량·진보의 과정에서 선후출원 권리의 경합이 발생하게 된다. 이 경우 i) 선출원우위의 원칙에 의하여 선출원 권리자를 보호하고 ii) 후출원 권리자의 실시 방안을 마련할 필요성이 있으므로, 이 양자의 권리를 조정하는 데에 이용·저촉관계의 취지가 있다.

제2관 이용·저촉관계의 유형

I. 이용관계의 유형

1. 내용에 따른 구별²¹⁶⁾

(1) 사상상의 이용

① 유형

「사상상의 이용」이란 그대로설의 입장에 의한 이용관계로서 동일 카테고리 내에서 이용관계가 성립하는 것을 말한다. 사상상의 이용관계가 성립하는 유형으로는 선행발명에 다른 구성요소를

215) 특허권의 본질을 전용권, 즉 적극적 효력이 미치는 권리라고 이해하면 자기발명을 실시하는 것은 특허권자의 권리로서 타인의 특허권을 침해할 수 없으므로, 제98조는 예외적으로 인정되는 침해의 성립요건일뿐만 아니라 제138조의 통상실시권의 설정요건이 된다. 그러나 특허권의 본질을 배타권, 즉 소극적 효력이 미치는 권리라고 이해하면, 이용발명의 실시는 필연적으로 선행 특허권에 대한 침해를 구성하기 때문에 오직 제138조와의 관계에서만 통상실시권의 설정요건을 규정하는데 의의가 있는 것으로 본다. 다만 배타권으로 본다고 할지라도 동일자 출원의 경우에는 제98조의 적용이 되지 않으므로 양자 모두 자유롭게 실시할 수 있음을 나타내고 있는 것으로 해석된다.

216) 이용관계의 유형은 내용에 따라 다음과 같이 구별될 수 있다.

카테고리	학설	이용관계		인정 여부	
				통설	판례
동일 카테고리	그대로설	사상상의 이용	외적부가 (결합발명)	○	90'초: × 2000'초: ○
			내적부가 (선택발명)	○	90'초: × 최근: -
다른 카테고리	실시불가피설	실시상의 이용		○	-

부가하여 선행발명의 이용분야를 외연적으로 확장하는(외적부가하는) 「결합발명」과 선행발명을 상위개념으로 하여 그 하위개념적인 범위에서 선행발명의 인식 이외의 새로운 작용효과를 알아내거나 기술문제를 독립적으로 해결한(내적부가하는) 「선택발명」이 있다.

② 결합발명

선출원 발명이 「A+B+C」로 구성된 발명인데 선출원의 기술사상에 「D」라는 구성요소를 추가하여 전체적인 기술사상을 「A+B+C+D」로 하는 발명을 말한다. 구체적인 사례로는 촉매부가발명이 있다. 종래의 대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660 판결²¹⁷⁾에서는 촉매의 부가로 인해 작용효과상의 우월성이 있다면 후출원특허발명이 선행발명을 이용하지 아니한다고 판시하였다. 그러나 이는 특허요건의 판단과 침해 성립요건 판단을 혼동하는 것으로서 현저한 효과로 인해 진보성(法 29②)에 위반되지 아니하여 등록되더라도 일체성을 상실하지 않았다면 침해, 즉 이용발명으로 봄이 타당하다. 이와 관련하여 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결에서 “화학반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학물질 제조방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조방법 발명의 기술적 구성요소의 일체성, 즉 출발물질에 반응물질을 가하여 특정한 목적물질을 생성하는 일련의 유기적 결합관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용발명에 해당한다고 봄이 상당하다”라고 판시하여 종래의 대법원판결의 잘못된 점을 바로 잡고 있다.

【표 6-6】 甲이 A+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중이고, 乙이 A+B+C+D로 구성된 발명을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부

선출원 여부	후출원의 등록가능성	후출원의 실시가 선출원의 침해인지 여부
甲 > 乙	1. 甲의 공개 전 → 등록가능 2. 甲의 공개 후 → A+B+C로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우 제29조제2항 위반	1. 乙의 실시는 甲의 특허권의 침해 2. 정당한 권원획득 후 실시 ① 허락 ② 통상실시권허락심판(乙이 등록된 경우) (甲으로부터 A+B+C를 구매한 후 D를 부가하여 실시하는 것도 가능)
甲 < 乙	1. 乙의 공개 전 → 제29조제3항, 제36조 위반 2. 乙의 공개 후 → 제29조제1항, 제36조 위반	1. 甲의 실시는 AER에 의하여 乙의 특허권의 직접침해 × 2. 단, 乙의 특허권의 간접침해일 수는 있음
甲 = 乙	실질적 동일성이 없는 경우 양자 모두 등록가능	양자 모두 등록된 경우 자유롭게 실시(·제98조의 “특허출원일 전”의 해석결과 동일자 출원의 부적용)

217) 화학물질의 제조과정(수단)에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 아니한 것은 그 기술사상을 현저히 달리 하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 반응물질, 생성물질이 같다고 하더라도 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우월성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 아니한다고 인정되는 경우를 제외하고는 후발명이 선행발명을 이용하고 있다고 볼 수 없고, 따라서 후발명은 선행발명의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이다(대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660).

③ 선택발명

선행발명 A의 명세서 본문에는 a1, a2에 대하여만 개시되어 있었는데, 후에 A의 개념에 포함되는 발명 중 선택한 a3을 말한다. 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960 판결에서는 선택발명이 특허발명과 비교하여 현저히 향상된 작용효과 있는 경우 확인대상발명은 특허발명과 다른 발명으로서 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다. 다만 특허발명의 보호범위는 그 배타적 효력이 미치는 범위를 어떻게 설정하느냐의 문제이고, 침해 대상으로 거론되는 선택발명이 특허요건을 갖추어 선행발명인 특허발명과 별개의 권리로서 성립할 수 있느냐의 문제와는 무관한 것으로서, 선택발명이 그 기본이 되는 선행발명의 기술적 사상을 그대로 이용하고 있으며 일체성이 상실되지 않았다면 특허발명의 침해로 보아야 할 것이다.²¹⁸⁾ 그리고 선택발명이 등록되었다면 이용관계를 긍정함이 타당하다.

【표 6-7】 甲이 A+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중이고, 乙이 a1(A의 하위구성요소)+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부

선출원 여부	후출원의 등록가능성	후출원의 실시가 선출원의 침해인지 여부
甲 > 乙	1. 甲의 공개 전 → 등록가능 2. 甲의 공개 후 → A+B+C로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우 제29조제2항 위반	1. 乙의 실시는 甲의 특허권의 침해로 보는 것이 타당 2. 단, 판례는 현저한 효과가 있어 등록된 경우 침해가 아니라고 판시.
甲 < 乙	1. 乙의 공개 전 → 제29조제3항, 제36조 위반 2. 乙의 공개 후 → 제29조제1항, 제36조 위반	1. 甲이 a1+b+c를 실시하는 경우 침해 2. 그렇지 않으면 비침해
甲 = 乙	실질적 동일성이 없는 경우 양자 모두 등록가능	양자 모두 등록된 경우 자유롭게 실시(·제98조의 “특허출원일 전”의 해석결과 동일자 출원 부적용)

(2) 실시상의 이용

「실시상의 이용」이란 실시불가피설의 입장에 의한 이용관계로서 다른 카테고리내에서 후출원 발명을 실시하는 경우 선출원 발명의 실시가 되는 것을 말하며, 선출원이 물건발명이고 후출원이 제법발명인 경우 이에 해당한다. 다만 선출원이 제법발명이고 후출원이 물건발명인 경우에는 후출원이 등록될 가능성이 없으므로 논의의 실익이 없다. 한편 異法간의 이용관계, 즉 특허발명과 등록디자인 또는 유사디자인과의 이용관계 역시 「실시상의 이용」에 해당한다.

218) 선택발명의 향상된 효과는 동질의 우수한 효과나 이질적인 효과를 말한다. 이중 선택발명이 동질의 효과를 잃으면서 이질적인 효과만을 나타낸다면 구성요소의 일체성을 상실한 것으로 볼 수 있을 것이다.

【표 6-8】 甲이 물건발명(物)을 출원 후 실시중이고, 乙이 물건을 제조하는 방법(方1)을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부

선출원 여부	후출원의 등록가능성	후출원의 실시가 선출원의 침해인지 여부
甲 > 乙	1. 物의 최초 명세서 또는 도면(최·명·도)에 기재된 方이 方1인 경우 ① 物의 공개 전 출원 → 제29조제3항 위반 ② 物의 공개 후 출원 → 제29조제1항 위반 2. 物의 최·명·도에 기재된 方이 方1이 아닌 경우 ① 物의 공개 전 출원 → 등록가능 ② 物의 공개 후 출원 → 物의 최·명·도에 기재된 方으로부터 쉽게 발명할 수 있는 경우 제29조제2항 위반	1. 方1의 실시는 物의 침해 ○(∴ 法 제2조제3호(가) 목의 실시의 유형-물건생산을 청약하는 행위는 제외) 2. 정당한 권원획득 후 실시 ① 허락 ② 통상실시권허락심판(乙이 등록된 경우)
甲 < 乙	1. 方1의 공개 전 출원 → 제29조제3항, 제36조 위반 2. 方1의 공개 후 출원 → 제29조제1항, 제36조 위반	1. 物의 실시가 方1의 실시에 의한 경우 - 方1의 침해 ○ 2. 物의 실시가 方1의 실시가 아닌 경우 ① 方1의 침해 × ② 단, 方1의 출원 전 物이 공지되지 않았다면 方1의 실시에 의하여 物을 생산한 것으로 추정(法 129)
甲 = 乙	실질적 동일성이 없는 경우 양자 모두 등록가능	양자 모두 등록된 경우 자유롭게 실시(∴ 제98조의 "특허출원일 전"의 해석결과 동일자 출원의 부적용)

2. 대상에 따른 구별

이용관계는 i) 특허발명 상호 간은 물론 ii) 특허발명과 등록실용신안, iii) 특허발명과 등록디자인 또는 그 디자인과 유사한 디자인 간에도 발생한다.

II. 저촉의 유형

1. 특허권과 디자인권

특허권과 디자인권은 보호의 객체가 상이하므로 상호 권리 간에 저촉관계가 발생할 수 있다. 예를 들어 선출원 디자인권의 창작대상이 일정한 형상·모양을 갖는 장난감인데, 후출원된 발명이 동일한 구성요소를 갖는 장난감이면 양자는 상호 저촉관계에 해당한다.

2. 특허권과 상표권

물품 자체의 형상을 표시하는 입체상표가 상표법의 보호대상이 됨과 동시에 물품의 형상에 관한 기술적 사상인 발명이 특허법의 보호대상이 될 수도 있다. 이 경우에 특허권과 상표권의 저촉관계가 발생하게 된다.

3. 특허권과 특허권(실용신안권)

특허권 상호 간 또는 특허권과 실용신안권이 저촉되면 부적법한 저촉관계로서 이를 이중특

허(double patent) 또는 오인특허(fehlerpatent)라고 한다. 이 경우 선출원주의가 적용되기 때문에 후출원 권리가 특허무효사유(法 133①)에 해당한다. 문제가 되는 것은 후출원 권리가 무효로 되기 전의 실시가 저촉관계에 있는 선출원 권리의 침해가 되는지이다. i) 선출원 특허를 개량하여 적법하게 등록된 이용발명의 실시도 선출원 특허의 침해인데, 선출원 특허발명과 동일하지만 착오로 등록되었다는 것만으로 그 발명을 실시하는 것이 선출원 특허의 침해가 아니라는 것은 납득할 수 없다는 점, ii) 일정한 경우 중용권(法 104)을 인정하여 충분히 보호하고 있는데 이는 침해가 성립됨을 전제로 한 항변에 해당한다는 점을 고려할 때, 후출원 발명의 실시를 선출원 특허의 침해로 보아야 한다.²¹⁹⁾

제3관 이용·저촉관계의 판단

I. 판단기관

이용·저촉관계는 주로 침해소송에서 법원이 판단한다. 권리범위확인심판에서도 이용·저촉 관계를 판단할 수 있는지가 문제인데, 인용심결을 하였을 때 타방의 권리를 부정하는지 여부에 따라 허용 여부를 달리한다. 권리범위확인심판은 확인적 성격을 가지는 심판이고 타방의 권리 부정은 특허무효심판의 전권사항이므로 권리범위확인심판에서 타방의 권리를 부정하는 심결을 할 수 없기 때문이다. 따라서 소극적 권리범위확인심판의 경우 권리범위에 속하지 아니한다는 인용심결이 타방의 권리를 부정하지 아니하기 때문에 허용되고,²²⁰⁾ 적극적 권리범위확인심판의

219) 대법원 2021. 3. 18 선고 2018다253444 전원합의체 참조. 보충의견에서 “종래 구 특허법(1986. 12. 31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제45조 제3항은 ‘특허권자, 전용실시권자 또는 동상실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)는 특허발명이 그 출원한 날 이전에 출원된 타인의 특허발명 등록실용신안 또는 등록의장을 이용하거나 이들과 저촉되는 경우 그 특허권자·실용신안권자·의장권자의 동의를 얻거나 제59조 제1항의 규정에 의하지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다”라고 하여 특허권과 특허권 또는 이와 동종의 권리인 실용신안권의 저촉관계에 관하여도 선출원 권리자의 동의가 없으면 침해가 성립함을 규정하고 있었다. 그런데 1986. 12. 31. 개정에서 후출원 특허권과 선출원 특허권 또는 실용신안권 상호 간의 저촉관계는 무효심판에 의하여 해결하는 것이 타당하다는 비판 등을 수용하여 이 부분이 삭제되었다. 이후 조문 번호가 변경되고, 선출원 권리로 상표권이 추가되는 등의 개정과정을 거쳐 현행 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정된 것) 제98조는 “특허권자 등은 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다”라고 규정하고 있다. 위와 같은 개정을 통해 후출원 특허와 선출원 특허 또는 실용신안의 저촉관계에 관한 규정이 삭제되긴 하였으나, 특허법은 후출원 특허권이 타인의 동종 또는 이종의 선출원 등록권리와 이용관계에 있거나 타인의 이종의 선출원 등록권리와 저촉관계에 있는 경우에 선출원 권리가 우선하고 후출원 특허권자 등의 권리가 제한될 수 있음을 여전히 명확히 규정하고 있다. 위와 같은 특허법 개정을 후출원 특허와 선출원 특허 또는 실용신안의 저촉관계의 경우에는 선출원 권리자의 동의를 받지 않더라도 정당한 권리의 실시에 해당하는 것으로 보겠다는 반성적 고려에 의한 것으로는 볼 수 없다. 오히려 다른 이용·저촉관계와의 형평상 선출원 특허권자 또는 실용신안권자의 동의를 받지 않은 후출원 특허권자의 권리 행사 역시 침해로 보는 것이 타당하고, 이는 특허법 제98조에 대응되는 규정을 가지고 있는 실용신안법(실용신안법 제25조)에도 그대로 적용된다.”라고 하여 그 이유를 설시하고 있다.

경우 권리범위에 속한다는 인용심결이 타방의 권리를 부정하지 아니하는 이용관계의 확인을 구하는 것만 허용된다.²²¹⁾²²²⁾

II. 판단대상 및 시기

1. 판단대상

(1) 타인의 권리일 것

1) 선출원된 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등이 타인의 권리이어야 한다. 선출원인 자기의 권리라면 권리주체가 동일하여 권리조정의 필요성이 없으므로 동일인 간에는 제98조의 이용, 저촉관계가 성립되지 아니한다.

2) 한편 공유자 일부가 이용발명을 하여 특허권을 획득하였으면 이용발명을 한 공유자는 특허가 없는 한 다른 공유자의 허락없이 이용발명을 실시할 수 있다. 예를 들어 甲과 乙이 자전거에 대한 특허권자인데 乙이 자전거를 개량한 라이트를 결합한 자전거를 발명하여 특허를 받았다면 乙은 甲의 동의없이도 라이트 결합한 자전거를 실시할 수 있다. 이는 공유자 일부가 이용발명을 한 경우에는 제98조의 「타인」이 아니기 때문이다.

(2) 상호 등록되었을 것

이용저촉관계는 상호 등록된 권리간의 관계를 전제로 한다. 일방이 등록되지 아니하였다면 단순한 권리침해의 문제가 되고 독점권 상호 간의 중복은 발생하지 않기 때문이다.

2. 판단시기

출원일을 기준으로 한다. 구체적으로 출원일이 다른 경우 선출원우위의 원칙에 의하여 선출원 권리자를 보호하되 후출원 권리자의 실시 방안을 마련하고 있다. 다만 출원일이 같은 경우 각 권리자가 자기의 권리에 따라 자유롭게 실시할 수 있다. 이는 제98조에서 특허발명이 그 특허발명의 「특허출원일 전」에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 그 특허발명의 「특허출원일 전」에 출원된 타인

220) 대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19; 1996. 12. 20. 선고 95후1920 등.

221) 후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상 고안으로 하여 선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고, 다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률) 제11조제3항에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433).

222) 저촉관계를 확인하는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 경우 특허권(실용신안권) 상호 간에는 인용심결을 하였을 때 선출원주의 위반으로 타방의 권리가 무효라는 의미가 있어 타방의 권리를 부정하기 때문에 허용되지 않으나, 특허권과 디자인권(상표권) 간에는 선출원주의가 적용되지 않아 인용심결을 하더라도 타방의 권리를 부정하지 않기 때문에 허용될 수 있다.

의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우만을 규정하고 있고, 출원일이 같은 경우에 대해서는 아무런 언급이 없기 때문이다.

제4관 이용·저촉관계의 효력 및 조정

I. 선출원 권리자 보호방법

1. 특허권의 행사

이용·저촉관계에 있는 후출원 발명의 권리자가 선출원 권리자의 허락을 받지 않거나 통상 실시권허락심판에 의하지 않고 자기의 특허발명을 업으로 실시하면 선출원 권리의 침해를 구성하기 때문에 선출원 권리자는 민·형사상 제재를 할 수 있다.

2. 크로스 라이선스(cross license)의 청구

통상실시권허락심판에 따라 통상실시권을 허락한 선출원 권리자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 후출원 권리자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(法 138③).

3. 디자인권의 존속기간 만료 후의 법정실시권

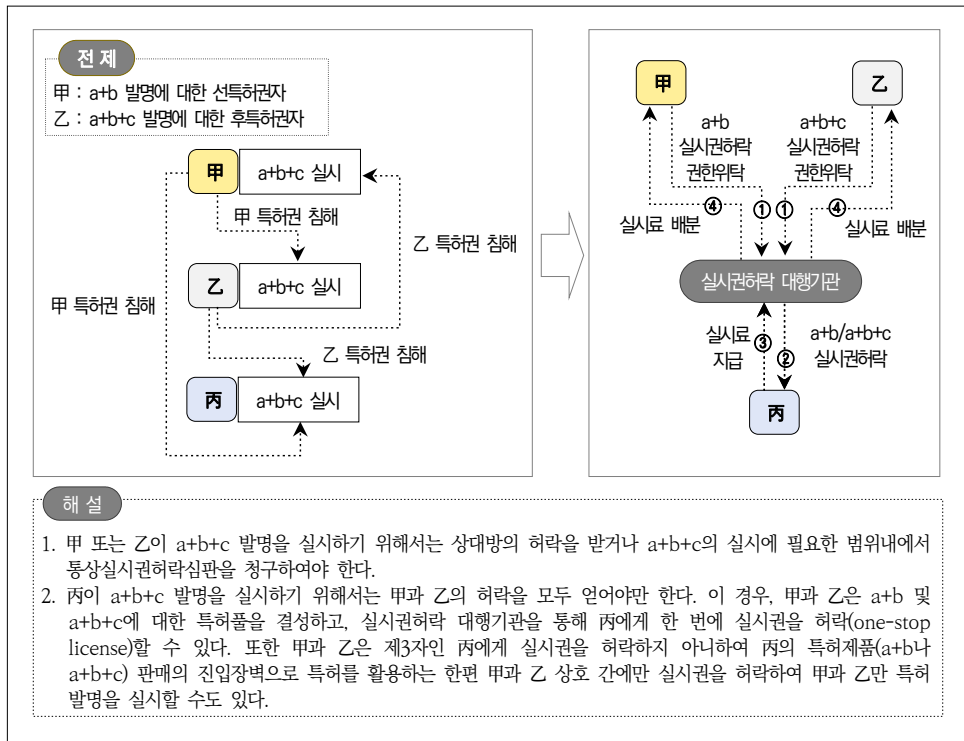
특허출원일 전 또는 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 특허권과 저촉되는 경우 디자인권의 존속기간이 만료될 때에는 그 디자인권자 및 실시권자는 그 디자인권의 범위 또는 원권리의 범위에서 법정의 통상실시권을 갖는다(法 105①②). 이때 디자인권자는 무상으로 실시할 수 있으나 실시권자는 특허권자 등에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 105③).

II. 후출원 권리자 보호방법

1. 선출원 권리자의 실시허락

1) 이용·저촉관계에 있는 후출원 권리자는 선출원 권리자의 허락을 얻어야, 즉 허락에 의한 실시권을 획득한 후에야 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다(法 98). 다만 후출원 권리의 적극적 효력이 제한되는 것이며 소극적 효력이 제한되는 것은 아니다. 즉 후출원 권리자는 선출원 권리자의 허락을 받지 않고는 후출원 발명을 실시할 수 없지만 타인이 후출원 발명을 실시할 때는 후출원 권리의 침해를 이유로 민형사상 제재를 할 수 있으며, 이는 타인이 선출원 권리자라고 하더라도 마찬가지이다.²²³⁾

2) 한편 후출원 권리자가 선출원 권리자가 판매한 물건을 구입하여 이용발명을 생산하였으면 권리소진이 되어 선출원 권리의 침해가 아니다. 따라서 이 경우에는 선출원 권리자의 허락을 받을 필요가 없다.



【그림 6-12】 선·후출원 권리의 침해

2. 통상실시권허락심판의 청구

후출원 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당되어 실시의 허락을 받으려는 경우에 선출원 권리자가 정당한 이유없이 실시허락을 하지 않거나 실시허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권허락심판을 청구할 수 있다. 다만 후출원특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 이용관계에 있는 경우에는 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이어야 한다(法 138①②).

223) 대법원 2006. 9. 11. 자 2006마232 결정 참조.

제5절 특허권의 침해

제1관 서 설

「특허권의 침해」란 특허권의 존속 중 정당한 권원이 없는 자가 업으로서 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 것을 말한다. 특허법은 특허발명을 실시하는 직접침해뿐만 아니라 특허발명의 실시가 아니어도 침해의 개연성이 높은 경우 제127조에 의하여 침해로 보는 행위, 즉 간접침해를 인정하고 있다. 특허권의 침해가 있으면 특허권자는 특허권의 소극적 효력, 즉 대외적(對外的) 효력에 의하여 민사 및 형사적 구제조치를 취할 수 있다. 그러나 특허법에 있는 몇 개의 특별규정으로는 그 구제가 충분하다고 할 수 없으므로 민법 및 형법의 일반원칙이 보충적으로 적용된다.

제2관 침해의 성립요건

I. 특허권의 존속 중 실시일 것

1) 특허권의 침해가 성립하기 위해서는 특허권의 존속 중 실시이어야 한다. 그러므로 특허료의 불납, 존속기간의 만료, 특허권의 포기, 상속인 부존재 등으로 인해 특허권의 소멸된 후의 실시나 특허출원 중의 실시는 특허권의 침해가 아니다. 한편 등록주의를 관철시켜 법적 안정성을 도모하기 위하여 일단 설정등록에 의하여 특허권이 발생한 이상 특허요건의 흠결이 있다고 할지라도 특허취소신청에 의한 취소결정이나 특허무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전까지 특허권이 존속 중인 것으로 본다. 다만 취소결정이나 무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지 등이 되어서 신규성이 없는 경우, 특허발명이 선행특허와 동일하여 선출원주의 또는 확대된 선출원에 위반된 경우, 명세서의 기재불비 등으로 인하여 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명의 실시가 불가능한 경우에는 특허권의 보호범위를 인정할 수 없으므로 특허권의 침해가 아니다.

2) 한편 특허권의 존속 중 제3자의 실시이면 침해의 성립요건으로 족하고, 특허권의 권리행사 당시 특허권이 존속 중이어야 하는 것은 아니다. 예를 들어 특허권이 포기되어 소멸하더라도 포기되기 전의 제3자가 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시하는 경우 특허권자는 특허권이 포기된 후 손해배상청구 등 권리행사를 할 수 있다.

II. 정당한 권원 없는 자의 실시일 것

1) 정당한 권원 없는 자가 특허발명을 실시하여야 한다. 예를 들어 실시권이란 정당한 권원을 가진 자의 실시는 특허발명의 보호범위에 속하더라도 특허권의 침해가 아니다. 또한 특허권자 또는 제조·판매권을 가진 실시권자가 특허발명을 실질적으로 구현한 특허제품을 적법하게 판매하였을 때, 그로부터 특허제품을 구입한 제3자가 실시하더라도 침해가 아니다(권리소진).

2) 「실시」란 제2조제3호의 행위를 말한다. 예를 들면 물건을 생산하는 방법발명의 실시는 그 방법의 사용을 청약하는 행위를 제외하고는 전부 물건발명의 실시가 된다. 한편 실시의 각 행위는 독립되어 있으므로 하나의 행위가 적법해도 다른 행위까지 적법한 것은 아니며 각각의 실시행위별로 침해인지 여부를 판단하여야 한다(실시행위의 독립성).

III. 업으로서 실시일 것

「업」으로서의 의미는 산업발전 이바지라는 특허법의 목적에 비추어 단순히 개인적 또는 가정적인 실시를 제외하는 의미로 해석된다. 정당한 권원 없는 자의 실시라 할지라도 그것이 개인적·가정적 실시일 경우에는 공정한 경쟁 질서를 저해하지 않기 때문에 특허권의 효력이 미치지 아니한다. 한편 개인적·가정적 실시가 아닌 이상 그 목적의 영리·비영리를 불문하며 1회의 실시라도 업으로서 실시에 해당한다.

IV. 특허발명의 보호범위에 속하는 발명을 실시할 것

1) 특허발명의 보호범위에 속하는 확인대상발명을 실시하여야 한다. 보호범위에 속하는지는 특허발명의 청구범위를 중심으로 하고, 발명의 설명의 참작, 공지기술의 참작, 출원경과의 참작 및 특허권 하자의 참작 등을 하여 특허발명을 특정한 후 확인대상발명과 비교하여 구성요소완비의 원칙, 균등론 등에 의하여 특허발명의 실시인지 판단에 의한다. 다만 구성요소완비의 원칙, 균등론 등에 의하여 특허발명의 실시라고 할지라도 i) 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96), ii) 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한(法 181), iii) 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권의 효력 제한(法 81의3④) 등의 법률의 제한에 해당한다면 보호범위에 속하지 않게 된다.

2) 한편 확인대상발명의 실시가 특허발명의 실시가 아니더라도 법률의 확장인 간접침해행위(法 127)에 해당하면 보호범위에 속하게 된다.

V. 관련문제

1. 고의 또는 과실의 不要

일반적으로 특허권 침해의 성립요건에는 침해자의 고의나 과실을 요구하지 아니한다. 고의 또는 과실의 유무는 침해가 성립된 이후 특허권자가 취할 수 있는 조치에 영향을 미친다. 구체적으로 특허권자는 고의나 과실이 있는 경우에는 민사상 손해배상이나 신용회복청구를 할 수 있고, 형사상 고의가 있는 경우에는 침해죄를 물을 수 있다. 다만 방법의 사용을 청약하는 행위의 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 한 경우에만 침해가 성립한다(法 94②).

2. 복수 주체에 의한 특허발명의 분산 실시

(1) 문제의 소재

최근 전자상거래 관련발명(BM 발명) 특허와 관련되어 복수 주체에 의한 청구범위 구성요소의 분산 실시가 증가되고 있다. 이런 경우 복수 주체에게 특허권 침해에 대한 책임을 물을 수 있는지 문제이다. 예컨대 방법발명의 청구항이 제1단계 내지 제5단계로 구성되어 있는데, 甲이 제1단계 내지 제3단계를 실시하고, 乙이 제4단계 및 제5단계를 실시하는 경우가 있다. 이처럼 복수 주체(甲과 乙)가 하는 실시행위가 합해질 때 청구항에 기재된 모든 구성요소를 실시하게 된 경우 甲 또는 乙에게 책임을 물을 수 있는지가 문제이다.

(2) 직접침해인지 여부²²⁴⁾

① 원 칙

직접침해가 성립하기 위해서는 청구항의 모든 구성요소를 단일 주체가 실시할 것을 필요로 한다. 따라서 복수 주체에 의한 분산 실시는 원칙적으로 직접침해가 아니다. 다만 사법상의 법인격 부인의 법리나 형법상의 정범으로서의 실시행위성을 규범적으로 파악하는 간접정범이론²²⁵⁾ 등과 마찬가지로²²⁶⁾, 침해에 관여하는 복수 주체 중 규범적, 실질적으로 볼 때 타인의 행위가 자기의 자유의사에 기한 결과로 평가할 수 있는 경우에는 해당 타인의 행위를 자기의 행위로 간주하여 그 법적 책임을 물을 수 있다고 보아야 한다.²²⁷⁾

② 단독 직접침해로 인정되는 경우

1) 甲과 乙이 특허발명의 구성요소를 일부씩 분담하여 실시하는 경우에 있어서, 甲이 乙을 도구나 수족으로 이용하여 구성요소 전체 실시에 의한 권리침해를 지배관리하고 있고 그로 인해 영업상의 이익을 얻었다면(이를 “도구이론” 또는 “지배관리론”이라 함) 乙의 행위를 甲의 행위와 법적으로 동일시하여 甲이 단독으로 특허권을 직접침해한다고 볼 수 있다.²²⁸⁾ 이는 마치 그

224) 권택수, “복수주체에 의한 실시와 특허권 침해”, 법학평론 제6권, 2016.04, 134-140면 참조.

225) 정범에는 이론상 보통 단독(직접)정범 · 간접정범 · 공동정범이 포함한다. 단독정범은 자기의 범죄를 스스로 행하는 자이고, 간접정범은 타인을 이용하여 자기의 범죄를 행하는 자이며, 공동정범은 수인이 공동하여 죄를 범하는 경우라고 할 수 있다.

226) 이처럼 행위자의 책임 유무를 규범적인 관점에서 파악하는 것은, 가령 민상법에서는 법인의 형식적 독립성을 인정하는 것이 정의 형평에 위배되는 결과가 되는 경우에 법인과 그 배후에 있는 자(지배주주 등)를 동일시하는 법인격 부인의 법리를 통해 인정되고 있는 바이고, 또 죄형법정주의의 요청상 엄격해석이 요구되는 형법에서도 정범으로서의 실시행위성을 규범적으로 파악하는 간접정범의 개념이 인정되고 있다. 어느 것이나 모두 정의·형평의 이념이나 처벌의 당위성이라는 규범적인 요청에서 법 주체성, 실행행위성을 규범적으로 파악하고 일정한 요건 하에 타인의 행위에 의한 결과에 대하여 스스로 직접 행위를 하지 않은 자의 책임을 인정하는 것이다(권택수, “복수주체에 의한 실시와 특허권 침해”, 법학평론 제6권, 2016.04, 130면).

227) 服部誠, “支配管理型の特許侵害について”, 「知的財産法の新しい流れ」, 青林書院, 2010, 463頁 이하.

228) 복수 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배, 관리하고, 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이

사정을 알지 못하는 제3자를 이용하여 범죄를 실행하게 한 자는 스스로 범죄를 실행한 것과 다르지 않다는 형법상 간접정범(형법 제34조제1항²²⁹⁾)과 유사하다. 예컨대 전자상거래 관련발명과 관련하여, 업으로 실시하고 있지 않은 개인 사용자(user) 乙의 행위를 포함하여 복수 주체가 특허권 침해에 관여하는 경우가 있다. 이 경우 업으로 실시하고 있는 사업자 甲이 개인 사용자 乙의 행위를 도구로 이용(지배 관리성과 이익성을 충족한다면)하려는 의사가 있다면, 개인 사용자 乙의 행위를 포함하여 사업자 甲의 업으로서의 행위와 법적으로 동일시할 수 있는 경우도 있을 것이다. 다만 사업자 甲이 개인 사용자 乙을 “도구로 이용”한다는 특별한 관계가 없다면 甲에게 직접침해를 묻기는 어려우므로 그 적용범위는 그다지 넓지 않을 것이다.²³⁰⁾

-
- 익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배, 관리하면서 영업상의 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다(서울고등법원 2017년 8월 21일 선고 2015라20296),
- 229) 어느 행위로 인하여 처벌되지 아니하는 자 또는 과실범으로 처벌되는 자를 교사 또는 방조하여 범죄행위의 결과를 발생하게 한 자는 교사 또는 방조의 예에 의하여 처벌한다.
- 230) 이와 관련된 사례로는 컴팩트 디스크 제조 기술에 관한 특허침해(서울고등법원 2003. 2. 10. 선고 2001나42518 판결)를 들 수 있다. 이 사건의 제조방법 특허는 마스터 테이프(원본 테이프)를 제작하는 단계(1단계), CD테이프마스터를 제작하는 단계(2단계), 글래스마스터를 제작하는 단계(3단계), 스템퍼(stamper)를 제작하는 단계(4단계), 그리고 마지막으로 오디오 CD를 제작하는 단계(5단계)로 구성된 발명이었다. 피고는 음반 제작업체들과의 제조위탁계약에 따라 마스터테이프를 음반 제작업체들에 인도하면 음반 제작업체들이 스템퍼를 제작하여 피고에게 공급해 주고, 피고는 위 공급받은 스템퍼를 사용하여 오디오 CD를 제조, 판매한 것으로, 특허발명의 모든 단계를 피고가 직접 실시하는 것은 아니었다. 이러한 사안에 대하여 재판부는 “음반 제작업체들에 특허발명의 실시를 포함하는 2단계 내지 4단계 과정의 작업을 하게 하고 그들로부터 위 과정을 거친 스템퍼를 공급받는 점, 피고가 공급받은 스템퍼는 피고의 의뢰에 따라 피고가 원하는 데이터를 담은 CD를 생산하기 위하여 피고가 원하는 수량만큼만 제작되고 오로지 피고에게만 인도되는 것인 점에 비추어 보면, 음반 제작업체들이 피고의 의뢰에 따라 스템퍼를 제작하기 위하여 특허발명을 실시하는 것이므로 이는 피고가 특허발명을 실시하는 것으로 평가하여야 할 것이다”라고 판시하였다. 또 다른 사례로는 단문 메시지 서비스를 이용한 통합메일 서비스 방법 및 장치에 관한 특허침해(서울고등법원 2006. 7. 10.자 2005라726 결정)를 들 수 있다. 이 사건의 특허발명은 무선통신망의 상대자 또는 유선상의 통신 상대자에게 무선통신망에서 사용되는 가상적 인식자(ID)를 부여하는 단계(1단계), 무선통신단말기를 통하여 타 무선통신망의 상대자 또는 유선상의 통신 상대자와 SMS 메시지를 송수신하는 경우 이전 단계에서 부여되었던 가상 ID와 각 상대자의 고유 ID를 변환하는 단계(2단계), SMS를 유선망에서 사용되는 전자우편 형태의 데이터로 변환하는 등의 데이터 변환 단계(3단계)로 이루어져 있다. 피고는 그 목적하는 사업의 SMS 서비스에서 피고 자신 및 이동통신사가 이 사건 특허의 각 단계를 나누어 실시하고 있었다. 이에 대하여 재판부는 “피고인 SMS Mobile Origination 서비스 운영자가 그 서비스를 주도적으로 기획, 구성하여 이동통신사, 방송사 등의 협력 하에서 서비스를 제공하면서 그에 따른 경제적 이익을 향유하고 위 서비스 사업의 성패에 따른 위험부담을 지고 있다면, 피고인 SMS Mobile Origination 서비스 운영자가 특허발명을 실시하고 있는 주체로 인정할 수 있다”라고 하여 이동통신사의 행위를 피고인 서비스운영자의 행위로 간주하여 직접침해를 인정하였다. 또한 카테터, 스타터, 허브, 봉합사를 구성요소로 하는 안면 리프팅 시술(늘어나거나 주름진 피부를 당겨주어 탄력 있는 피부를 만들고 주름을 제거하기 위한 목적의 시술)에 사용되는 키트에 대한 특허침해사건(서울고등법원 2017. 8. 21. 선고 2015라20296 결정)에서, 수출업체(C)는 제조업자 1, 2, 3의 카테터, 스타터, 허브, 봉합사의 제작을 지배, 관리하고, 이를 수출함으로써 영업상의 이익을 얻었으므로, 수출업체(C)가 이 사건 카테터, 스타터, 허브, 봉합사를 생산한 것으로 봄이 타당하다고 하여 공동 직접침해가 아닌 수출업체(C)의 단독 직접침해를 인정하였다.

③ 공동 직접침해로 인정되는 경우

甲과 乙이 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고,²³¹⁾ 특허발명의 전체 구성요소를 나누어 실시하는 경우에는 이들 甲과 乙이 공동으로 직접침해를 한 것으로 볼 수 있다.²³²⁾ 이는 2인 이상이 공동하여 범죄를 실행한 형법상 공동정범(형법 제30조²³³⁾)과 유사하다. 특허발명의 구성요소 실시 일부만을 타인에게 하게 하여 직접침해를 회피하려는 시도가 있다는 점, 특허발명의 실시에 있어서 복수 주체가 관여할 수밖에 없는 새로운 형태의 발명이 출현하고 있다는 점 등을 고려할 때 복수 주체가 관여하는 공동 직접침해의 성립을 인정할 필요가 있기 때문이다. 만일 공동 직접침해의 성립을 인정하지 않으면, 실시행위의 일부만을 타인에게 하게 함으로써 특허침해를 회피하는 것이 가능하게 되어 명백히 균형을 잃게 된다. 다만 산업발전 이바지라는 법 목적을 달성하기 위해 발명의 보호와 제3자의 이용도모는 균형을 이루어야 한다는 점에 비춰 봤을 때 특허법에 근거를 두고 있지 않은 공동 직접침해의 인정범위를 제한적으로 해석하여 지나친 특허권자의 보호를 경계하여야 하고, 인정범위를 명확히 하여 제3자의 예측가능성을 높여야 한다.

(3) 그 밖의 검토

① 간접침해인지 여부

개별적인 행위가 특허법상의 간접침해(法 127)에 해당한다면 그에 따라 해결하면 되나, 일정한 행위 유형(이른바 전용성 및 공용성의 요건을 충족하는 행위 유형)을 한정하여 침해로 보는 행위로 간주하는 간접침해의 규정에 의해서는 복수 주체가 관여하는 사안을 모두 해결할 수 없다. 구체적으로 간접침해가 성립하기 위해서는 특허발명인 물건발명의 생산에만 사용하거나 방법발명의 실시에만 사용하는 물건, 즉 전용품이어야 한다. 그러나 전자상거래 관련발명은 그 특성상 범용성이 있는 서버 또는 컴퓨터상에서 구현되는 경우가 대부분이기 때문에 전용품의 조건을 만족하기는 현실적으로 어려움이 있다.²³⁴⁾

231) 예를 들어 i) 甲과 乙이 계속적인 거래관계가 있는 경우, 조인트 벤처 등을 형성하여 실시하는 경우와 같이 일체가 되어 결과를 발생시키려는 의사로 각자 구성요소의 일부를 실시하고 이들 행위를 합하면 구성요소 전부를 충족하는 경우, 또는 ii) 甲이 자신의 행위와 乙의 행위가 결합하여 특허권 침해하는 결과가 발생할 것을 예상하고 乙도 역시 그러한 경우 등이 있을 수 있다. 궁극적으로는 甲과 乙의 각 행위 상호 간이나 행위와 특허발명 사이의 구체적인 관계, 甲과 乙의 전체 실시에 대한 기여율, 실시에 의한 경제적 이익의 귀속 등을 종합적으로 고려하여 공동직접침해의 성립 여부를 판단하여야 할 것이다(高部眞規子, “複数主体の関与と特許權侵害”, 知的財産訴訟実務大系(1), 青林書院, 2014, 416頁).

232) 서울고등법원 2017년 8월 21일 선고 2015라20296.

233) 2인 이상이 공동하여 죄를 범한 때에는 각자를 그 죄의 정범으로 처벌한다.

234) 김원준, “특허침해소송에 있어서 Business Model 특허보호 방안에 관한 연구”, 법학논총 31(2), 2011, 466면.

② 민법상 공동불법행위가 성립하는지 여부

민법상 공동불법행위에 의한 손해배상책임(민법 제760조²³⁵⁾)이 성립되기 위해서는 각 행위가 독립하여 불법행위의 요건을 갖추고 있으면서 객관적으로 관련되고 공동하여 위법하게 피해자에게 손해를 가한 것으로 인정되어야 한다고 한다.²³⁶⁾ 그러나 복수 주체에 의한 분산 실시의 경우 각자의 행위 자체가 특허권 침해에 해당한다고 보기 어려우므로 복수 주체에게 민법상의 공동불법행위책임을 물을 수 없을 것이다.

제3관 침해의 종류

I. 직접침해

1. 의 의

「직접침해」란 특허권 침해의 전형적인 모습으로서 특허권의 존속기간 중 정당한 권원 없는 자가 업으로서 특허발명을 실시하는 것을 말한다.

2. 유 형

(1) 문언침해

「문언침해」란 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 구성요소 전부를 실시하는 경우를 말한다. 문언침해인지는 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule : AER)에 따라 판단한다.²³⁷⁾ 즉 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.²³⁸⁾ 예를 들어 특허발명의 구성요소가 「A+B+C」인데, 제3자가 「A+B+C+D」를 실시하고 있다면 침해이지만 제3자가 「A+B」를 실시하고 있다면 침해가 아니다.

235) 민법 제760조(공동불법행위자의 책임) ① 수인이 공동의 불법행위로 타인에게 손해를 가한 때에는 연대하여 그 손해를 배상할 책임이 있다.

② 공동 아닌 수인의 행위중 어느 자의 행위가 그 손해를 가한 것인지를 알 수 없는 때에도 전항과 같다.

③ 교사자나 방조자는 공동행위자로 본다.

236) 대법원 2008. 4. 24. 선고 2007다44744.

237) 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836; 2001. 8. 21. 선고 98후522 등.

238) 대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513; 2000. 11. 14. 선고 98후2351; 2001. 8. 21. 선고 99후2372등.

(2) 균등침해

「균등침해」란 확인대상발명과 특허발명의 청구항에 기재된 발명의 구성요소가 완전히 일치하지는 아니하지만, 통상의 기술자가 청구항에 기재된 발명의 구성요소로부터 확인대상발명의 구성요소를 용이하게(쉽게) 변경하여 실질적으로 동일한 효과를 얻을 수 있는 것일 때에는 확인대상발명이 특허발명의 기술사상과 균등한 것으로서 특허발명의 침해에 해당한다는 것을 말한다. 예를 들어 특허발명의 구성요소가 「A+B+C」인데 제3자가 「A+B'+C」를 실시하는 경우 균등침해가 성립하기 위해서는 i) B와 B'의 변경이 있는 경우에도 과제의 해결원리가 동일하고, ii) B를 B'로의 변경에 의하더라도 A+B+C와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, iii) B를 B'로의 변경이 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도인 경우이고, iv) 특별한 사정이 없어야 한다. 여기서 특별한 사정이란 i) A+B'+C가 특허발명인 A+B+C의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나 ii) A+B+C의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 변경된 구성요소 B'가 청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 사정을 말한다.

(3) 이용·저촉침해

1) 「이용」이란 후출원 권리자가 자기의 특허발명 등을 실시하면 선출원인 타인의 특허발명 등을 실시하게 되지만, 선출원 권리자가 자기의 특허발명 등을 실시하면 후출원 특허발명 등의 실시로는 되지 아니한 일방적 충돌관계를 말한다. 「이용발명」이란 통설인 그대로설에 의하면, 기본발명의 구성요소에 새로운 기술적 요소를 부가하여 특허성을 취득한 것으로서 그 실시가 당연히 선행발명의 실시를 수반하는 것을 말한다. 이 설에 의하면 이용발명의 요건으로서는 i) 선행발명의 구성요소 또는 그 균등물을 그대로 포함할 것, ii) 선행발명에 별도의 기술적 요소의 부가가 있을 것, iii) 이용발명에 있어서 선행발명이 그 일체성을 가진 형태로 존재할 것을 만족하여야 한다. 한편 선출원되어 등록된 물건발명과 후출원되어 등록된 그 물건의 제법발명은 실시불가피설에 의한 이용관계가 성립한다.

2) 「저촉」이란 후출원인 특허권이 선출원인 타인의 디자인권 또는 상표권과 완전히 동일한 것으로서, 두 개의 권리가 중복되어 그 어느 쪽을 실시해도 타방의 권리를 실시하게 되는 쌍방적 충돌관계를 말한다. 「저촉발명」이란 이러한 저촉관계가 성립되는 발명을 말한다. 저촉관계는 특허권과 디자인권, 특허권과 상표권 간에 발생한다. 한편 특허권 상호 간 또는 특허권과 실용신안권이 동일한 발명임에도 불구하고 양자 모두 등록되었으면 부적법한 저촉관계로서 선출원주의가 적용되어 특허무효사유(法 133①)에 해당한다.

3) 이러한 이용, 저촉에 의한 침해는 문언침해, 균등침해에 해당하는 확인대상발명이 등록된 것을 말한다. 문언침해, 균등침해에 해당하지만 이용·저촉침해에 관한 규정을 따로 두고 있는 이유는 제98조에 따라 선출원 권리자가 권리행사를 할 수 있도록 함으로써 선출원 권리자를 보호하고, 제138조에 따라 후출원 권리자의 실시방안을 확보하여 권리 간의 이해관계를 조정하기 위해서이다.

(4) 생략침해 및 불완전이용침해

1) 「생략발명」이란 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요성이 낮은 구성요소를 생략하여 특허발명의 작용효과보다 열악하거나 동일한 효과를 가져오는 발명을 말하고, 「불완전이용발명」이란 생략발명에 일정한 구성요소를 부가한 발명을 말한다. 특허발명의 모방을 시도하는 자는 특허발명을 그대로 실시하거나 일부 구성요소의 단순한 치환을 시도하는 것보다는 구성요소 일부를 생략하여 특허침해를 회피하려는 경향이 자주 있어서, 생략발명이나 불완전이용발명이 특허권을 침해하는지가 문제이다.

2) 생략침해 또는 불완전이용 침해의 인정 여부에 대해서는 긍정설²³⁹⁾과 부정설²⁴⁰⁾이 있으며, 특허법원²⁴¹⁾은 i) 구성요소의 생략이 통상의 기술자에게 용이하게 생각할 수 있을 것, ii) 그러한 생략에도 불구하고 작용·효과에 별다른 차이가 없을 것을 만족하는 경우 생략침해가 될 수 있다는 법리를 인정하기는 하였으나, 실제로 확인대상발명이 생략침해나 불완전이용침해에 해당한다는 결론에 이른 사례는 하나도 없다.

3) 대법원²⁴²⁾은 특허발명의 모든 구성요소는 필수적이며, 따라서 침해가 성립하려면 특허발명의 모든 구성요소가 갖추어져야 한다는 구성요소완비의 원칙(All Elements Rule)에 의한 입장에 있으며, 이러한 대법원의 입장에 따르면 불완전이용발명 또는 생략발명의 침해는 인정될 수 없다. 확인대상발명이 특허발명의 구성요소 전부를 실시하는 경우에만 문언침해로 보는 이유는 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 청구범위에는 특허로 보호받으려는 사항을 명확하고 간결하게 그리고 발명을 특정하는데 필요한 구성요소를 적어야 하므로 청구범위에 기재된 구성요소는 모두 필수적이고 중요한 구성요소로 보아야 하기 때문이다. 만약 특허출원인이 무용하고 불필요한 구성요소를 청구범위에 포함시켰다면 이는 원칙적으로 출원인의 책임으로 돌려야 할 문제이지 청구범위를 임의로 해석하여 불완전이용발명 또는

239) 청구항에 기재되어 있는 요소 중 발명의 기능과 관계가 없는 비요부 요소를 제외한 다른 모든 구성요소를 실시한 자는 발명의 원리를 이용하여 발명의 기능에 따른 이익을 얻었다 할 것이고 이를 침해로 인정하지 아니한 것은 공평의 원칙에 반하며 나아가 특허권 자체를 형해화(形骸化)할 우려가 있다는 것으로, 민법상 부당이득의 법리를 바탕으로 하고 있다(MINORU TAKEDA, “知識財産權侵害要論”, 發明協會, 1997, 113면).

240) i) 특허권은 발명자가 자신의 발명을 공개하는 대신 국가가 그 반대급부로서 일정 기간의 독점권을 인정하는 일종의 계약이고 청구범위는 그 계약을 명문화한 계약서라고 할 것인데, 계약조항에 해당하는 청구범위에 기재된 구성요소를 임의로 배제하고 침해 판단을 할 수는 없다는 계약설, ii) 특허출원인은 출원서류를 작성할 때 사전편집자와 같이 용어의 선택을 신중히 하여야 할 책임을 부담하며, 부적절하거나 명료하지 아니한 용어의 선택으로 말미암은 불이익은 원칙적으로 출원인에게 지워져야 한다는 입장, 즉 불필요한 요소를 청구범위에 적은 후 뒤에 가서 그것이 구성요소가 아니라고 주장하게 되면 청구범위 기재를 신뢰한 제3자에게 불측의 손해를 입힐 염려가 있으므로 그러한 주장은 허용되어서는 아니 된다는 用語責任論(patentee as lexicographer), iii) 출원과정에서 보정 등을 통하여 불필요한 구성요소를 삭제할 기회를 주었기 때문에 구성요소를 결여한 실시는 침해로 보지 아니하여야 한다는 절차의 이익 보장설 등이 있다.

241) 특허법원 1999. 4. 16. 선고 98허8014; 2000. 9. 7. 선고 99허9755; 1999. 8. 26. 선고 99허2389; 1998. 10. 29. 선고 98허5312; 1998. 11. 26. 선고 98허1747 등

242) 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617; 2000. 11. 14. 선고 98후2351.

생략발명을 침해로 인정하여서는 아니 된다. 특히 시행령 제5조에서 규정하고 있는 다항제하에서는 청구범위를 독립항, 종속항으로 기재하는 것뿐만 아니라, 발명을 여러 가지 각도에서 정의하여 기재하는 방법도 가능하며, 이 경우 각 청구항을 독립된 발명으로 본다. 따라서 출원인으로서의 자신의 발명이 주요부 A, B, C와 비요부 D로 구성되어 있다면 A+B+C를 독립항으로, A+B+C+D를 종속항으로 하여 청구범위를 작성하면, 제3자가 비요부 요소인 D가 결여된 실시를 하더라도 독립항의 침해를 주장할 수 있다. 이처럼 다항제하에서는 비요부 요소가 결여된 실시를 침해로 보지 아니한다고 하더라도 특허권자에게 큰 불이익이 없으므로 구성요소가 결여된 실시를 침해로 보지 아니하여야 한다는 견해가 타당하다.²⁴³⁾ 다만 최근 대법원²⁴⁴⁾에서는 균등론의 적용요건 중 “구성요소의 치환”을 이 보다 더 포괄적인 상위개념인 “구성요소의 변경”이라고 표현함으로써 균등침해 판단 시 청구항에 기재된 구성과 침해제품의 구성은 반드시 일(一) 대 일(一) 대응을 요구하지 않고 일정한 분해와 결합을 통하여 일(一) 대 다(多) 또는 다(多) 대 일(一)의 대응도 충분히 가능할 것으로 보인다. 이는 생략침해이나 불완전이용침해를 균등침해의 법리 안에서 포괄하기 위한 포섭으로 이해된다.²⁴⁵⁾²⁴⁶⁾

4) 또한 최근의 대법원²⁴⁷⁾은 “i) 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ii) 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공 조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, iii) 그와 같은 가공 조립이 극히 사소하거나 간단하여 iv) 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다”라고 하면서 당해 특허발명을 이루는 구성부품들이 우리나라에서 생산되어 수출된 후 외국에서 특허발명인 완제품이 생산된 경우에 있어서 앞에서 언급한 요건들을 만족시킨다는 이유로, 특허권의 「직접침해」를 인정하였다. 이는 확인대상발명이 특허발명의 부품으로서 생략발명일지라도 구성요소완비의 원칙을 적용할 수 있는 상태에 이르렀다면 직접침해가 된다는 것이다. 이와 같은 법리를 외국에서의 완제품의 생산이 아니라 국내에서의 완제품의 생산된 경우에도 적용할 수 있을지 귀추가 주목된다.

(5) 선택침해

1) 「선택발명」이란 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위

243) 특허법원, 「특허재판실무편람」, 2002, 192면-193면.

244) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361; 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 등.

245) 한동수, 판례평석: 균등침해에서 과제해결원리의 의미, 법률신문, 2014.10.31.

246) 균등한지 문제되는 구성이 특허발명의 과제 해결에 아무런 역할을 하지 않는 경우도 상정할 수 있다. 이러한 경우에는 그 구성을 생략한 기술(소위 ‘생략발명’으로 불린다)에서도 발명의 과제해결원리는 동일하게 유지될 것이므로, 그 구성의 생략에 의하더라도 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고, 그 구성의 생략이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있다는 나머지 요건들을 충족한다면, 균등한 구성으로 봄이 논리적이라고 할 것이다(서울고등법원 2016. 3. 24., 선고 2015라20318 결정).

247) 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합).

상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명으로서, 선행 또는 공지의 발명에는 직접적으로 개시되어 있지 아니한 사항을 선택한 발명을 의미한다. 예를 들어 선행발명 A의 명세서 본문에는 a1, a2에 대하여만 개시되어 있었는데, 후에 A의 개념에 포함되는 a3을 선택하였을 때 a3의 발명을 선택발명이라 한다.

2) 대법원²⁴⁸⁾은 선택발명이 특허발명과 비교하여 현저히 향상된 작용효과 있는 경우 확인대상발명은 특허발명과 다른 발명으로서 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다. 다만 특허발명의 보호범위는 그 배타적 효력이 미치는 범위를 어떻게 설정하느냐의 문제이고, 침해 대상으로 거론되는 선택발명이 특허요건을 갖추어 선행발명인 특허발명과 별개의 권리로서 성립할 수 있느냐의 문제와는 무관한 것으로서,²⁴⁹⁾ 선택발명이 그 기본이 되는 선행발명의 기술적 사상을 그대로 이용하고 있으며 일체성이 상실되지 않았다면 특허발명의 침해로 보아야 할 것이다. 그리고 선택발명이 등록되었다면 이용관계를 긍정함이 타당하다.

(6) 우회침해

1) 「우회방법발명」이란 선행의 특허발명과 기술사상을 같이 하지만 그 보호범위를 벗어나기 위하여 무용의 물질이나 공정을 부가하여 일부러 우회의 길을 가는 발명을 말한다. 예를 들어 청구범위에 기재된 구성요소 중 최초의 요소와 최종의 요소를 동일하게 하고 그 중간에 객관적으로 보아 무용하거나 용이한 요소를 덧붙인 것으로서 특허발명이 물질 A에 반응수단 X를 행해서 물질 B를 제조하는 방법인데, A를 A와 균등하지 아니한 유사물질 A'로 바꾼(예컨대 산화한) 후 X와 동일 또는 유사한 반응수단을 행해서 물질 B'로 하고 최후에 B'를 B로 바꾸는(환원하는) 방법의 경우이다.²⁵⁰⁾

2) 선행발명의 공정에 부가가 있는 경우로서 공정의 부가가 선행발명의 공정 전 또는 완료 후에 있으면 침해라고 볼 여지가 있으나, 선행발명의 공정의 중간단계에 새로운 공정이 삽입 되면 선행발명의 공정이 도중에서 중단되어 발명의 일체성이 상실되므로 원칙적으로 침해라고 단정하기 어려우며, 일체성이 상실되지 아니하는 범위에서만 침해라고 할 수 있을 것이다. 이와 관련하여, 대법원²⁵¹⁾은 새로운 공정이 i) 주지관용기술에 의하여 부가할 수 있는 공정에 불과하고, ii) 그 공정의 부가로 인하여 우월하거나 현저하게 향상된 효과가 발생하지 않는다면 권리범위에 속한다고 판시하면서 우회침해를 긍정하고 있다.

248) 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960 판결.

249) 특허법원 1998. 12. 10. 선고 98허676 참조.

250) 吉藤幸朔 著, 유미특허법률사무소 譯, 「특허법개설」, 제13판, 대광서림, 2000, 607면.

251) 확인대상발명은 그 출발물질, 반응물질(피페라진) 및 목적물질이 이 사건 특허발명과 동일하고 그 제조 방법도 반응물질인 피페라진을 출발물질의 C-7 위치에 결합시켜 목적물질을 만드는 이 사건 특허발명의 주반응의 반응기전(reaction mechanism)을 그대로 이용한다는 점에서 그 기술적 사상과 핵심적인 구성이 동일하며, 다만 확인대상발명이 출발물질에 알루미눔클로라이드를 반응시켜 중간체를 거치는 구성을 부가한 차이가 있기는 하지만, 이 부가공정은 이 사건 양 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 주지된 관용기술(보호기의 사용)에 의하여 용이하게 부가시킬 수 있는 공정에 불과하다고 보여지고, 그 작용효과 역시 주지된 관용기술을 부가함으로 인한 효과 이상으로 우월하거나 현저하게 향상되었다고 보기 어려우므로, 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없어 이 사건 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다(대법원 2000. 7. 4. 선고 97후2194 판결).

구 분	특허발명	확인대상발명	대법원 판례	비 고
문언 침해	$A + B + C$	$A + B + C$	침해 ²⁵²⁾	최근 판례는 개별 구성요소의 중요성을 강화하는 방향으로 나아감(생략침해나 불완전이용 침해의 인정여부와 상관관계 있음)
	$A + B + C$	$A + B + C + D$	침해 ²⁵³⁾	촉매를 이용한 화학발명의 이용침해의 해당 여부에 대한 중요한 판례의 변화가 있음
균등 침해	$A + B + C$	$A + B + C'$	침해 ²⁵⁴⁾	과제의 해결원리의 동일성, 출원경과참작의 원칙 등 적용범위의 해석 확립 필요
	$A + B + C$	$A + B + C' + D$	침해 ²⁵⁵⁾	균등물을 기초로 한 이용발명을 침해로 인정함
생략 침해	$A + B + C$	$A + B$	최근 대법원 판례는 침해 부정 ²⁵⁶⁾	침해를 문언침해와 균등론적 침해로 나누고 개별적 구성요소의 존재를 중요시하는 최근 판례의 동향과 관련하여 그 존재의 의의 및 별도의 침해이론으로서의 인정 여부를 심도있게 논의하여 나가야 함. 최근에는 균등침해의 하나의 유형으로 파악하려는 경향이 있음
불완전 이용 침해	$A + B + C$	$A + B + \text{□} + D$	대법원 판례 없음	
선택 침해	$A + B + C$	$a + B + C$	침해를 부정한 과거의 판례 ²⁵⁷⁾ 는 존재 ²⁵⁸⁾ 나 논란 있음	최근 판례의 경향에 따라 이용 침해의 한 유형으로서 파악하여야 한다는 주장이 강하게 제기되고 있음
우회 침해	$A + B + C$	$A + B1 + B + C$	침해 ²⁵⁸⁾	균등침해와의 관계 정립 필요

【그림 6-13】 직접침해의 유형별 검토²⁵⁹⁾

252) 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584; 2001. 8. 21. 선고 99후2372 등

253) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522.

254) 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836 등

255) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522; 2001. 9. 7. 선고 2001후393

256) 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617; 2000. 11. 14. 선고 98후2351 등

257) 대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960.

258) 대법원 1997. 11. 14. 선고 96후2135; 2000. 7. 4. 선고 97후2194 등

259) 특허법원, 「특허재판실무편람」, 2002, 218면 참조.

II. 간접침해

확인대상발명의 실시가 특허발명의 실시가 아니라고 하더라도 법률의 확장에 해당하는 간접침해인 경우에는 특허발명의 보호범위에 속하게 된다. 「간접침해」란 직접침해의 전단계로서 그대로 방지할 경우 침해의 개연성이 높은 일정한 행위에 대하여 특허권을 침해하는 것으로 의제하는 것을 말한다. 간접침해가 성립하기 위해서는 특허권의 존속기간 중 정당한 권원 없는 자가 업으로서 간접침해행위를 하여야 한다. 간접침해행위는 i) 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, ii) 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이에 대해서는 「제6편 제3장 제5절 제5관 간접침해」에서 후술한다.

제4관 침해에 대한 조치

I. 민사적 조치

제126조 【권리침해에 대한 금지청구권 등】

- ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.
- ② 특허권자 또는 전용실시권자가 제1항에 따른 청구를 할 때에는 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다)의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제128조 【손해배상청구권 등】

- ① 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다. <신설 2016.3.29.>
- ② 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하गे 한 물건을 양도하였을 때에는 다음 각 호에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다. <개정 2020. 6. 9.>
 1. 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액
 2. 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액

③ 삭제 <2020. 6. 9.>

④ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다. <개정 2016.3.29.>

⑤ 제1항에 따라 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다. <개정 2016. 3. 29., 2019. 1. 8.>

⑥ 제5항에도 불구하고 손해액이 같은 항에 따른 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때에는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다. <개정 2016.3.29.>

⑦ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제2항부터 제6항까지의 규정에도 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. <개정 2016.3.29.>

⑧ 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다. <신설 2019. 1. 8., 2024. 2. 20.>

⑨ 제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다. <신설 2019. 1. 8.>

1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
5. 침해행위의 기간·횟수 등
6. 침해행위에 따른 벌금
7. 침해행위를 한 자의 재산상태
8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.3.29.]

제131조 【특허권자 등의 신용회복】

법원은 고의나 과실로 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해서는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

1. 침해금지 및 예방청구권

(1) 의 의

1) 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 및 예방을 청구할 수 있다(法 126①). 특허권 또는 전용실시권은 물권에 준하는 권리이므로, 특허권자 또는 전용실시권자는 특허발명을 독점·배타적으로 지배할 수 있다. 따라서 그 원활한 지배 상태가 침해당할 때에는 침해행위를 금지하기 위하여 물권적 청구권(소유물 방해제거 및 방해예방청구권과 유사)과 같은 권리가 인정된다. 한편 특허권 또는 전용실시권이 공유인 경우에는 각 공유자는 자기의 지분에 기하여 단독으로 침해금지청구권을 행사할 수 있다. 이는 침해금지 및 예방청구권의 행사가 보존행위이기 때문이다.

2) 이러한 침해금지 및 예방청구권은 현재 또는 장래의 침해에 대하여 행사하는 점에서, 과거의 침해에 대하여 행사하는 손해배상, 부당이득반환 등의 청구권과 다르고 특허권 침해에 대한 구제수단으로서 가장 유효하고 직접적이다.²⁶⁰⁾²⁶¹⁾ 다만 특허권의 존속기간이 만료된 후에는 침해금지청구권을 행사할 수 없다.²⁶²⁾

(2) 요건

1) 특허권 또는 전용실시권이 현재 침해되고 있거나 적어도 침해될 우려가 있어야 한다. 여기서, 「침해할 우려가 있는 경우」는 침해자의 주관적인 침해의 의도에서 더 나아가 객관적인 침해의 준비행위가 완성된 경우를 말한다고 할 것이다.²⁶³⁾²⁶⁴⁾

2) 침해자의 고의·과실·책임능력은 요구되지 않으며 객관적인 위법요소만 있으면 된다. 이 점에서 고의·과실이 필요한 손해배상청구의 요건과 다르다.

(3) 폐기·제거청구

특허권자 또는 전용실시권자는 금지청구에 수반하여 i) 침해행위를 조성한 물건(물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 침해행위로 생긴 물건을 포함한다.)의 폐기, ii) 침해행위에 제공된 설비의 제거, iii) 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있다(法 126②). 침해가 있을 때 예견되는 장래의 손해를 예방하기 위해서는 침해품의 폐기 등이 뒷받침되어야 하기 때문이다. 다만 폐기·제거 청구권은 단독으로 행사할 수 없으며 반드시 침해금지소송과 함께 행사할 수 있는 「부대청구」이다.

(4) 침해금지가처분 신청

① 의의

침해금지청구의 본안소송 확정 전 현저한 손해를 받거나 급박한 방해를 방지할 수 없는 등 긴급한 행위가 필요한 경우에 침해금지를 위한 임시적 지위설정을 위해 침해금지청구권을 피보전권리로 하여 침해금지가처분 신청을 할 수 있다.²⁶⁵⁾ 일반적으로는 가처분 신청 후 본안소

260) 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 819면.

261) 특허권자의 입장에서 그 권리를 행사할 때 가장 중요하게 생각하는 것은 침해금지청구권 및 그 보전을 위한 가처분신청이라고 할 수 있는데, 이는 일단 법원의 가처분 또는 침해금지명령이 내려지면 특허권자는 손해배상액을 정하기 위한 협상에서 압도적인 협상력(excessive bargaining power)을 가지고 되어 일반적인 손해배상액과는 비교가 되지 아니한 막대한 금액을 침해자에게 요구할 수 있게 되기 때문이다(김주형, “특허권 등 침해에 대한 금지청구권”, 재판자료 56집, 법원도서관, 1992, 335면).

262) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876.

263) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 297면.

264) 원고가 그 제조방법에 관하여 특허권을 보유한 농약원제 메타실에 대하여 피고명의로 농수산부에 메타실수입원제등록 및 메타실수화제 제조 품목등록이 되어 있고 피고가 발행 배포한 농약안내서에 메타실수화제에 관한 소개가 되어있다 하더라도 피고가 실제로 메타실원제를 수입한 일도 없고 또 수입절차를 취한 일도 없다면 위와 같은 사유만으로 피고가 원고들의 특허권리를 침해하고 있다거나 침해할 우려가 있다고 단정할 수 없다(서울고등법원 1988. 7. 4. 선고 88나7745).

265) 대법원 2007. 7. 2. 자 2005마944.

송이 진행되는 것이 원칙이나, 함께 진행되는 때도 있으며 이 경우 관련 사건으로 동일법원에서 심리하게 된다.²⁶⁶⁾

② 처분의 긴급성

가처분이 인정되기 위해서는 침해 사실 외에 처분의 긴급성(보전의 필요성)이 필요하다. 더구나 가처분 채무자에 대하여 본안판결에서 명하는 것과 같은 내용의 특허권침해금지라는 부작위 의무를 부담시키는 이른바 만족적 가처분일 경우에 있어서는 처분의 긴급성에 대한 고도의 소명이 필요하다.²⁶⁷⁾ 처분의 긴급성은 당사자 쌍방의 이해득실관계, 본안소송에 있어서의 장래의 승패의 예상, 그 밖의 제반 사정을 고려하여 법원의 재량에 따라 합목적적으로 결정하여야 한다. 예를 들어 채무자가 지식재산처에 별도로 제기한 심판절차에 의하여 그 특허권이 무효라고 하는 취지의 심결이 있는 경우나, 무효심판이 청구되고 그 청구의 이유나 증거관계로부터 장래 그 특허가 무효로 될 개연성이 높다고 인정되는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 형평을 고려하여 처분의 긴급성을 결한 것으로 보는 것이 합리적이다.²⁶⁸⁾

③ 본안소송에서 패소한 경우

가처분결정이 있고 난 뒤 가처분 집행권자가 본안소송에서 패소확정되었다면 그 가처분으로 인하여 채무자가 입은 손해에 대해서는 채권자에게 고의 또는 과실이 없다는 반증이 없는 한 배상할 책임이 있다.²⁶⁹⁾²⁷⁰⁾

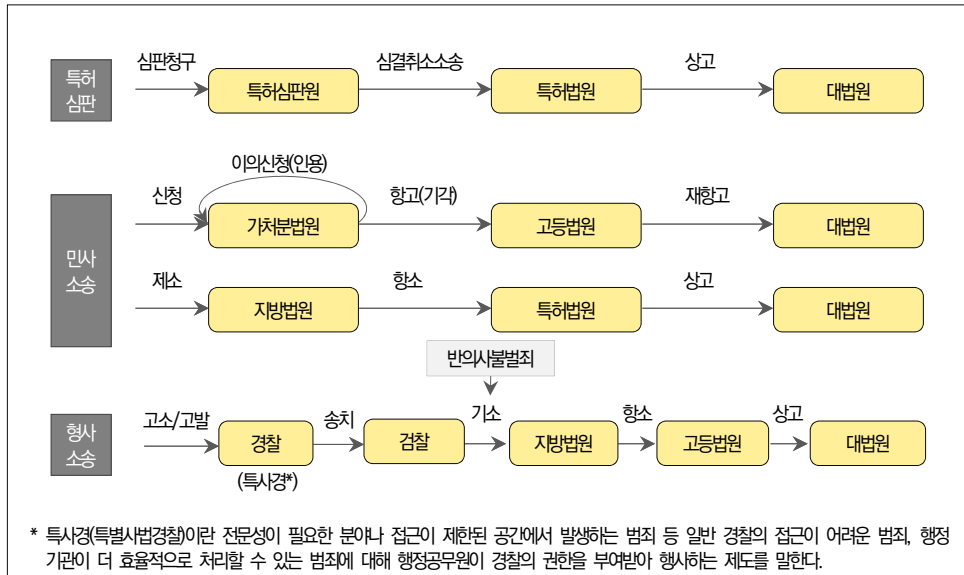
266) 가처분결정 이후에도 위반행위가 계속되는 경우 가처분집행으로 그 목적을 달성하여야 하므로, 채권자는 금지청구의 대상인 채무자의 물건 또는 방법을 집행이 가능할 정도로 구체적으로 특정하여야 한다. 특히 물건의 발명의 경우 채무자가 생산, 판매하고 있는 상품명, 제품형식번호 등을 기재하고 설명을 첨가하거나 도면이나 사진을 첨부하는 등의 방법으로 채무자가 실제 실시하고 있는 물건과 다른 물건을 식별 가능할 정도로 특정하여야 하고, 집행관이 특허권침해금지가처분결정에 따른 집행을 실시함에 있어서도 그 집행대상을 특정하기 위한 집행권원상의 내용을 확인하여야 할 것이다. 한편 집행에 관한 이의신청은 집행 또는 집행행위에 형식적, 절차상의 하자가 있는 경우에 할 수 있고 집행권원 자체에 대한 실체권리관계에 관한 사유는 집행에 관한 이유사유로 삼을 수 없으므로(대법원 1987. 3. 24. 자 86마카51 결정 참조), 집행권원의 피보전권리인 침해금지청구권의 부존재 내지 소멸을 주장하는 것에 해당하는 사유는 가처분이의(민사집행법 제301조, 283조)나 사정변경 등에 따른 가처분취소(민사집행법 제301조, 제288조)로 다루어야 할 것이고, 집행에 관한 이의신청으로 다룰 수는 없다(대법원 2025. 9. 29. 자 2025마6304).

267) 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563; 2003. 11. 28. 선고 2003다30265.

268) 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563; 2007. 6. 4. 선고 2006마907.

269) 대법원 1980. 2. 26. 선고 79다2139; 2002. 9. 24. 선고 2000다46184.

270) 다만 가처분소송이 아닌 침해금지본안소송에서 승소후 무효심결이 확정된 경우에는 특허권자에게 고의, 과실이 있는 경우에만 손해배상책임이 있다(대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513 참조).



【그림 6-14】 특허에 관한 분쟁 진행의 관할²⁷¹⁾

2. 손해배상청구권

(1) 의 의

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(法 128①). 특허침해로 인해 손해배상청구의 경우 그 침해사실 및 손해액의 증명이 일반 재산권의 침해에 비해 훨씬 곤란하므로 특허법은 증명책임의 완화 내지 전환을 위해 손해액의 추정 등(法 128②-128⑦)의 특별규정을 두어 이를 보완하고 있다.

(2) 요 건

i) 침해자에게 고의·과실이 있을 것, ii) 침해행위가 있을 것, iii) 침해행위로 인해 손해가 발생하였을 것, iv) 침해행위와 손해발생 사이에 인과관계가 있을 것이 요구된다.

271) 2016년 1월 1일부터는 지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권) 침해 민사본안 소송의 관할을 1심은 고등법원 소재지가 있는 6개 지방법원(서울중앙지방법원, 대구지방법원, 대전지방법원, 광주지방법원, 부산지방법원, 수원지방법원)이 전속적으로 맡고, 2심은 특허법원으로 집중하게 되도록 민사소송법(제24조, 제36조) 및 법원조직법(제28조, 제28조의4, 제32조)이 개정되었다. 기존에는 침해소송의 1심을 58개 지방법원과 지원에서, 2심을 고등법원과 지방법원 항소부에서 맡는 한편 심결 취소소송을 특허법원에서 맡고 있어서 관할이 분산되어 있었다. 이번 개정은 특허소송의 관할을 특허법원으로 집중해 특허권 등의 분쟁 해결에 있어 법원의 전문성, 효율성 및 신속성을 제고하는 한편 소송 당사자에게 보다 신속하고 전문적인 재판을 보장함으로써 지식재산권 보호의 실효성을 높이고자 하는 취지를 담고 있다. 다만 민사 가처분 사건이나 형사사건 등의 관할은 종전과 변동이 없다.

(3) 손해액의 범위

침해행위와 상당인과관계에 있는 모든 손해로서 i) 침해행위로 인하여 특허권자 등이 이미 가지고 있던 이익이 손실되는 적극적 손해,²⁷²⁾ ii) 침해행위가 없었더라면 특허권자가 얻을 수 있었던 이익의 손실인 소극적 손해 및 iii) 정신적 손해²⁷³⁾를 모두 포함한다. 한편 손해배상의 방법으로서 금전배상이 원칙이지만 정신적 손해의 경우에는 금전배상 외에 신용회복조치를 청구할 수 있다.²⁷⁴⁾

(4) 손해액의 추정 등

① 손해액의 산정

1) 손해배상을 청구하는 경우 그 권리를 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 물건을 양도하였을 때에는²⁷⁵⁾ 다음에 해당하는 금액의 합계액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 할 수 있다(法 128②).²⁷⁶⁾

272) 적극적인 손해의 구체적인 예로는 i) 침해의 제거 또는 방지를 위해 지출한 상당인과관계가 있는 비용, ii) 변호사 비용 등이 있을 수 있다.

273) 원고는 위에서 본 바와 같이 피고의 특허권 침해행위로 인하여 자신이 오랜 기간 동안 특허권의 취득을 위하여 들인 노력, 비용에 대한 보상을 제대로 받지 못하게 되는 손해를 입게 되었고, 나아가 이러한 위법행위를 바로잡기 위하여 자신의 비용을 들여 피고를 상대로 수사기관에 고소하고 그에 따른 조사를 위하여 수사기관에 출석하고 관련 자료를 확보하는데 노력을 기울여야 한 점, 그리고 고소사건의 종결 이후에도 피고가 계속 위 특허방법에 의한 포장지의 제조를 위하여 들여놓은 기계를 그대로 작업장에 보유하고 있어 언제든지 특허권 침해행위가 이루어질 수 있었고, 이러한 사정으로 인하여 특허권 침해금지가처분신청을 하는 등 끊임없이 피고의 동태를 주시할 수밖에 없었던 점 등 여러 사정에 비추어 볼 때, 원고는 피고의 위와 같은 위법행위로 인하여 재산상 손해의 전보로 충족될 수 없는 정신적 고통을 겪었고, 이를 금전으로 위자하기 위한 적절한 배상액은 약 200만원 정도로 봄이 상당하다(서울중앙지방법원 2003. 12. 2. 선고 2002가단109162).

274) 예를 들면 소극적 손해로는 i) 특허권자의 매상감소, ii) 특허제품의 가격하락 또는 iii) 실시료 수입의 감소가 있을 수 있는데, 침해행위에 의해서만 발생한 것이라는 인과관계의 증명은 통상적으로 다음과 같이 상당히 어렵다. 따라서 손해배상청구의 실효성 확보를 위해 인과관계를 증명하지 않더라도, 매상감소에 의한 일시이익에 관해서는 제128조제2항제1호 및 제4항에서, 실시료 수입의 감소에 대해서는 제128조제2항제2호 및 제5항에서 별도의 규정에 의하고 있다. 한편 그 외의 적극적 손해, 정신적 손해, 소극적 손해 중 제품가격 인하로 인한 손해 등에 대한 손해배상청구는 제128조제1항의 일반적인 손해배상의 법리에 의한다.

소극적 손해	계산식	비고
매상감소	감소된 판매수량×특허권자 제품 의 단위수량당 이익액	감소된 판매수량이 침해자 때문이라는 것을 증명하여야 함(침해외의 사유로 감소된 판매수량의 경우 손해액에서 제외)
제품가격 인하	(원가격-인하된 가격)×판매수량	가격 인하가 영업상의 문제가 아니라 침해자 때문이라는 것을 증명하여야 함(침해외의 사유로 가격 인하된 경우 손해액에서 제외)
실시료 수입의 감소	침해품 판매수량×실시권자 판매 가격×약정실시료율	침해자 때문에 침해품 판매수량만큼 실시권자가 판매하지 못하였음을 증명하여야 함(침해외의 사유로 실시권자가 판매하지 못한 경우 손해액에서 제외)

275) 특허권자의 보호를 강화한다는 입법취지에 비추어볼 때 반드시 양도에 한정되는 것은 아니고 대여나 청약 등도 포함된다고 해석함이 타당하다.

i) 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액²⁷⁷⁾을 곱한 금액(法 128②I)

ii) 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액(法 128②II)

2) 제128조제2항제1호는 i) 특허권자의 생산능력 범위내에서 침해자의 양도수량을 특허권자의 판매 감소량으로 간주할 수 있게 되었다는 점,²⁷⁸⁾ ii) 특허권자 등이 침해자의 양도수량만 확인하면²⁷⁹⁾ 침해자의 단위수량당 이익액을 알 수 없다고 하더라도 특허권자 등의 단위수량당 이익액을 이용할 수 있으므로 계산이 용이하다는 점에서 특허권자 등을 충분히 보호할 수 있다는 데 그 의의가 있다 할 것이다. 다만 특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있다는 것을 침해자가 증명하면 양도수량 중 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량은 빼야 한다. 「침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사

276) 특허권 침해를 이유로 손해액을 산정한 일례로는, 소위 “기저귀 사건”이 있었다. 전용실시권자인 유한킴벌리가 쌍용과 열지를 상대로 기저귀 특허침해를 이유로 손해배상청구를 하였고, 서울지방법원 남부지원 제3민사부 2003. 2. 13. 선고 96가합6616판결(쌍용), 서울지방법원 남부지원 제4민사부 2003. 2. 7. 선고 2001가합8692, 2001가합11162(열지)에서 구체적인 손해액 산정 기준이 제시되었다. 판결을 요약하면, 1995. 2. 22.부터 1997. 10. 31.까지의 기간 동안 전용실시권자인 원고(유한킴벌리 주식회사)의 손해액을 계산함에 있어 먼저, 위 기간 동안 원고가 자체 생산라인으로 추가생산 내지는 수입할 수 있었던 수량범위내에 드는 피고들의 판매수량을 확정된 다음, 원고의 연도별 단위당 이익액을 확정하고, 이를 피고의 위 침해수량에 곱하여 산정된 연도별 손해액의 합계액을 전용실시권자인 원고의 손해액으로 하고 있다. 한편 전용실시권자인 원고가 자체 생산라인으로 추가생산할 수 있었던 범위를 초과하는 수량에 대하여는 특허권자인 공동원고(킴벌리 클라크 코퍼레이션)가 특허법 제128조제5항에 의하여 위 공동원고가 통상받을 수 있었던 실시료의 합계액을 산정한 후, 이를 공동원고의 손해액으로 인정하고 있다(안원모, 특허권의 침해와 손해배상, 세창출판사(2005), 162면, 163면 참조). 다만 위 사건들은 모두 항소심에서 특허침해가 부정되었고 대법원에서 그대로 확정되었기 때문에, 손해액 산정에 관해 상급심에서는 따로 판단하지 않았다.

277) 단위수량당 이익액과 관련하여 대법원 2006. 10. 30. 선고 2005다36830 판결은 ‘단위수량당 이익액’이라 함은 등록디자인 제품을 판매할 경우 그 판매가격에서 재료비 및 노무비, 관리비 등 제경비를 공제한 금액을 뜻한다고 할 것이다’라고 하여 매출액에서 변동경비를 제외하는 한계이익설을 지지하고 있다.

278) 침해자의 침해와 특허권자의 판매 감소량의 인과관계를 증명하는 것은 일반적으로 쉽지 않다. 특허권자의 판매 감소에 침해자의 침해품뿐만 아니라 제3자의 대체품이 기여할 수도 있고, 침해자의 노력이나 역량이 기여한 부분도 있을 수 있기 때문이다.

279) 침해자의 판매수량에 대한 관련 자료는 모두 침해자 측에서 가지고 있을 것이기 때문에, 이를 확인할 때 제132조의 자료의 제출에 관한 규정이 유용하게 활용될 수 있다.

정」이란 i) 판매된 침해품이 침해자의 시장개발노력, 침해품의 품질의 우수성, 가격경쟁력 등의 요인에 의하여 판매된 경우, ii) 경쟁제품이 있어서 침해자의 매출액 전부가 권리자의 판매 제품이 될 수 없는 경우, iii) 침해행위 후 획기적인 신기술이 개발되어 특허 실시품의 매출이 떨어진 경우 등의 사정을 의미한다.²⁸⁰⁾

3) 제128조제2항제2호는 침해자의 양도수량 중 특허권자의 생산능력 범위를 초과한 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(이하 “초과수량”²⁸¹⁾이라 함)에 대하여 특허법 제128조제5항의 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 인정한다는 것이다. 이는 2020. 12. 10. 시행된 현행법(법률 제 17422호, 2020. 6. 9. 일부개정)에서 반영된 것으로서, i) 오늘날 특허권을 활용한 제품의 제조방식이 OEM 등 다양한 방식으로 이루어지는 점, ii) 설령 생산하지 않더라도 특허권자는 수많은 제조업자에게 실시계약을 체결하여 실시할 가능성이 열려 있는 점 등 특허권의 특성을 고려하였을 때, 침해자가 특허권자의 생산능력을 초과하여 취득한 이익을 응당 특허권자가 얻을 수 있었던 이익으로 볼 필요가 있기 때문이다.²⁸²⁾ 다만 특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 것을 침해자가 증명하면 해당 수량은 초과수량에서 빼야 한다.

② 손해액의 추정

1) 손해배상을 청구하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자가 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정한다(法 128④). 제128조

280) 침해자의 시장개발 노력, 판매망, 침해자의 상표, 광고·선전, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 디자인권의 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 말하는 것으로서, 디자인권을 침해하지 않으면서 디자인권자의 제품과 시장에서 경쟁하는 경쟁제품이 있다는 사정이나 침해제품에 실용신안권이 실시되고 있다는 사정 등이 그러한 사유에 포함될 수 있다(대법원 2006. 10. 13. 선고2005다36830).

281) 초과수량은 양도수량 중 제1호의 수량과 실시권 설정(허락) 불가 수량을 뺀 수량으로서 다음과 같이 결정된다.

조건	제1호의 수량	제2호의 수량
$A > B$	B	양도수량 - B - C
$A < B$	A	양도수량 - A - C = 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량 - C

A: 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량)

B: 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량

C: 특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량

282) 송대호, 특허법 일부개정법률안 검토보고서(박법계 의원 대표발의(의안번호 17894)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2019.3, 2면 참고.

제2항은 특허권자 등의 단위수량당 이익액이 높으면 더 많은 손해배상을 청구할 수 있지만, 제128조제4항은 침해자의 단위수량당 이익액이 높으면 더 많은 손해배상을 청구할 수 있다는 점에서 대조된다. 즉 이 규정은 특허권의 생산능력의 범위 내에서 침해자의 단위수량당 이익액이 특허권자 등의 단위수량당 이익액보다 더 높을 때 원용할 수 있는 규정이다.²⁸³⁾ 이 경우, 침해자는 특허권자 등의 실손해액이 자신의 이익액보다 적음을 증명하면 본 조항의 추정효과를 벗어날 수 있다.²⁸⁴⁾

2) 그러나 이는 손해의 발생을 전제로 하여 침해자의 이익을 손해액으로 추정하는 규정으로서 침해자의 이익액으로부터 손해의 발생까지 추정하는 규정은 아니다. 특히 이 규정에서의 손해는 일반적으로 “매상감소에 의한 일실이익(逸失利益)”이고 특허권자의 생산능력 범위 내에서 손해의 한도를 제한하는 것으로 해석되므로 특허권자 또는 전용실시권자가 스스로 실시하고 있지 아니한 경우와 같이 특허권자의 생산능력이 없는 경우에는 추정의 전제인 손해의 발생 자체를 관념할 수 없어서 이 추정 규정은 적용되지 아니한다.²⁸⁵⁾²⁸⁶⁾²⁸⁷⁾ 한편 손해의 발생에 관한 주장·

283) 조영선, 「특허법」, 박영사, 2009, 412면 참조.

284) 침해자의 이익과 관련해서는 도표와 같이 총이익설, 순이익설, 한계이익설 등의 학설이 있다(사법연수원, 「특허법」, 2009, 493면). 이와 관련하여 서울중앙지방법원 2004. 2. 13. 선고 2002가합30683 판결은 구체적인 계산방식으로 침해자의 총매출액에서 침해된 특허를 이용한 사료나 그 관련제품의 매출액이 차지하는 비율에 따른 매출총이익액에서 같은 비율에 따른 판매 및 일반관리비(다만 그 특허를 이용한 매출과 관계없이 고정적으로 지출되리라고 보이는 임원급여와 감가상각비는 제외한다)를 공제하는 방식을 제시하여, 특허법 제128조제4항에 기하여 손해배상을 청구한 사안에 대하여 한계이익설을 채택하였다. 최근의 특허법원 판결(2018. 11. 8. 선고 2018나1275, 1282 드)에서도 “침해자가 그 침해행위로 얻은 이익액’은 특별한 사정이 없는 한 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 생산·판매를 위하여 추가로 들어가는 비용(변동비용)을 공제한 한계이익으로 산정될 수 있다”라고 하여 제128조 제2항과 마찬가지로 단위수량당 이익액에 대한 한계이익설을 지지하고 있다.

학설	침해자의 이익	근거
총이익설	매출액 - 제조원가(판매원가)	권리자의 이익을 보호하는 규정이므로 권리자의 증명책임을 경감하여야 함(매출액의 증명책임은 권리자, 제조원가에 대한 증명책임은 침해자에 있음)
순이익설	매출액 - 변동경비(재료비, 운송비, 보관비) - 고정경비(설비비, 임차료, 인건비)	민법 제750조의 일반 불법행위책임 원리상 일실이익은 필요경비를 공제한 순이익액임(권리자가 침해자의 순이익이 얼마인지를 증명하여야 함)
한계이익설	매출액 - 변동경비	순이익을 산정하는 경우 기초가 되는 판매비, 일반관리비는 기업에 따라 다르고, 침해행위 초기단계에서는 거의 이익이 생기기 아니한 경우도 있는데 고정비용까지 공제한다면, 권리자의 손해전보를 용이하게 하지 못함(매출액의 증명책임은 권리자, 변동경비에 대한 증명책임은 침해자에 있음)

285) 상표법 제67조제1항의 규정은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 증명하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 따라 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 등이 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고, 상표권 등의 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 상표권자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 스스로 업으로 등록상표를 사용하고 있고 또한 그 상표권에 대한 침해행위에 따라 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장·증명할 필요가 있으나, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 따라 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 볼 수 있다(대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119).

증명의 정도에 있어서는 위 규정의 취지에 비추어 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·증명하는 것으로 족하다고 보아야 할 것이다.²⁸⁸⁾

3) 침해품 일부가 특허의 침해일 때 손해액의 산정이 문제이다. 예컨대 甲이 특정 물건을 제조할 때 그 물건에 사용되는 일부 부품에 관하여 乙이 특허권을 가지고 있는 경우, 甲의 실시행위로 인하여 乙이 배상받을 수 있는 손해액을 어떻게 산정할 것인지 문제가 된다. 이 경우에는 그 물건에서 침해된 특허가 차지하는 비중, 즉 그 특허가 유발되는 구매동기의 정도를 기여율로 평가하여 물건 전체가 특허의 대상이 될 때 산정되는 손해액에 위 기여율²⁸⁹⁾을 곱하여 계산되는 금액을 손해액으로 하여야 한다는 견해가 다수설이다.²⁹⁰⁾ 대법원은 실용신안

286) 일본 역시 소위 표찰사건(標札事件)의 판결(大阪地判 昭55.06.17.)에서 “손해액 추정 규정은 스스로 실용신안권을 실시하고 있는 해당 권리자가 침해자의 침해에 의하여 입은 소극적 손해(침해에 따라 잃어버린 정도의 본래 스스로 실시에 의하여 얻어야 할 이익상당의 손해)의 액과 인과관계를 증명하는 것이 극히 곤란하다는 것을 감안하여 권리자 보호를 위하여 갖추어진 규정이지, 단지 권리를 보유하기만 하고 이를 실시하고 있지 아니한 자에게 적용하여야 하는 규정은 아니라고 해석된다”라고 판시하여 실시하고 있지 아니한 권리자의 손해배상을 부정하고 있다.

287) 특허법 제128조제2항, 제4항은 침해품이 판매된 경우에 그 판매수량분 만큼 특허권자의 특허제품의 판매가 감소하였을 것이라는 개연성에 기초해서 그 감소분에 의하여 특허권자가 당연히 얻었을 이익액을 원고의 손해액으로 하거나 침해품의 판매에 의하여 침해자가 얻은 이익을 특허제품의 판매감소분에 의하여 특허권자가 얻었을 이익으로 추정할 수 있다는 전제에서 규정된 것이다. 특허권자가 방법의 발명에 관해서 특허권을 가지고 있고, 침해자가 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산하여 양도하는 특허권의 간접 침해행위를 한 경우에는 방법발명의 실시는 그 방법의 사용에 불과하고, 그 실시로 인해 특허제품이 생산·판매되는 것이 아니어서 침해품의 판매로 인해 특허제품의 판매가 감소된다는 개연성을 인정하기 어려우므로 특허권의 간접침해자가 얻은 이익인 침해품의 판매수익을 방법발명에 관한 특허권자의 일실이익이라고 볼 수는 없다. 따라서 원고는 피고 (○)○, 김○○에 대하여 피고 (○)○, 김○○가 얻은 이 사건 액커제품의 판매이익을 손해액으로 구할 수는 없다(서울중앙지방법원 2009. 1. 8. 선고 2008가합1588).

288) 특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조제4항에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·증명하는 것으로 충분하다(대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831).

289) 특허발명의 실시 부분이 제품의 전부가 아니라 일부에 그치는 경우이거나 침해자가 침해한 특허기술 외에도 침해자의 자본, 영업능력, 상표, 기업신용, 제품의 품질, 디자인 등의 요소가 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 것으로 인정되는 경우, 침해자가 그 물건을 생산·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 당해 특허권의 침해행위에 관계된 부분의 기여율을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이다. 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 특허권의 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다(대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244 판결 등 참조). 기여율을 산정함에 있어 특허발명의 실시 외에 침해자의 판매이익의 발생 및 증가에 기여한 요소 및 그와 같은 요소가 기여한 정도에 관한 증명책임은 침해자에게 있다(대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830 판결, 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 등 참조)(특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893). 한편 특허발명의 기여 부분 및 정도에 관한 사실인정이나 비율을 정하는 것은 행평의 원칙에 비추어 현저히 불합리하다고 인정되지 아니하는 한 사실심의 전권사항에 속한다(대법원 2019. 9. 10. 선고 2017 다 34981 판결 참조).

290) 박성수, 「특허침해로 인해 손해배상액의 산정」, 경인문화사, 2007, 347 - 349면 참조.

침해 사건에서 명시적이지는 아니하나 같은 취지를 전제로 한 것이 있고,²⁹¹⁾ 저작권 침해 사건에서는 명시적으로 기여율 참작설에 의하고 있다.²⁹²⁾²⁹³⁾

③ 손해액의 의제

1) 손해배상을 청구하는 경우 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다(法 128⑤). 이 규정은 특허권의 침해가 있는 경우 그로 인해 특허권자가 별도로 실시계약을 체결할 기회를 상실하게 되어 손해를 입게 되기 때문에, 그에 대한 보상으로 합리적으로 받을 수 있는 금액을 손해액으로 인정한 것으로서, 「손해의 하한액」을 정한 것이다. 특허권자는 제3자가 특허권을 침해하더라도 항상 이익을 보는 것은 아니기 때문에 제3자가 얻은 이익액이 미비하거나 침해로 인해 손해가 발생하였다고 하더라도 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 최소한의 손해액으로 하여 손해배상을 청구할 수 있다.

2) 이 규정은 손해액의 추정 규정(法 128④)과는 달리 특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 아니하여 매상감소에 의한 일실이익(逸失利益)이 없는 경우에도 적용된다는 점에 그 의의가 있다. 특허권자는 손해발생에 관하여 주장·증명을 할 필요가 없고, 권리침해사실과 합리적으로 받을 수 있는 금액을 주장·증명하면 된다.²⁹⁴⁾

3) 한편 2019. 7. 9. 시행된 현행법(법률 제16208호, 2019. 1. 8. 일부개정)에서는 기존의 “통상적”으로 받을 수 있는 금액에서, 손해액이 낮게 책정되는 문제를 해결하고 그 특허침해 등의 개별적·구체적인 정황을 고려하여 손해액을 산정할 수 있게 하려고 “합리적”으로 받을 수 있는 금액으로 개정하였다. 기존의 “통상적”으로 받을 수 있는 금액은 통상실시권의 실시료에 준하여 판단되었는데,²⁹⁵⁾ 이처럼 판단하는 것은 i) 해당 특허발명에 대한 통상실시권 계약을 체결하지 않았으면 적용이 곤란하다는 점, ii) 기술거래시장의 가격변동을 충실히 반영하기 어려운 점, iii) 무단으로 특허발명을 실시하였을 때 발생하는 손해배상액이 침해자가 특허권자로부터 처음부터

291) 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272.

292) 대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244. 최근 특허법원 2018. 11. 8. 선고 2018나1275, 1282 판결에서도 특허권 침해 사건에서 2002다18244 판결을 인용하면서 기여율 참작설에 의하고 있다.

293) 조영선, 「특허법」, 박영사, 2009, 424면.

294) 대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다33175 판결은 “구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제67조제2항은 같은 조 제1항과 마찬가지로 불법행위에 기한 손해배상청구에 있어서 손해에 관한 피해자의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정이고 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상무의무를 인정하는 취지는 아니라 할 것이므로, 같은 법 제67조제2항에 의하여 상표권자 등이 상표권 등을 침해한 자에 대하여 침해에 의하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 상표권자 등은 손해의 발생사실에 관하여 구체적으로 주장·증명할 필요는 없고, 권리침해의 사실과 통상적으로 받을 수 있는 금액을 주장·증명하면 족하다고 할 것이지만, 침해자도 손해의 발생이 있을 수 없다는 것을 주장·증명하여 손해배상책임을 면할 수 있는 것이라고 해석하는 것이 상당하다”라고 하였다. 그러나 특허의 경우 상표와는 달리 선택이 아닌 창작을 보호객체로 하는 것인 만큼 특허권자가 특허를 전혀 실시하지 않고 있는 경우에도 이 규정에 기하여 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액의 손해배상을 청구할 수 있다고 해석함이 타당하다.

295) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 참조.

실시권 허락을 받은 경우와 사실상 동일하게 되어 특허권 침해를 유인할 가능성이 있다는 점 등의 문제가 있었기 때문이다.²⁹⁶⁾

④ 손해액의 참작

1) 손해의 액이 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 초과하는 경우에는 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있다. 이 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에게 고의 또는 중대한 과실이 없을 때는 법원은 손해배상액을 산정할 때 그 사실을 고려할 수 있다(法 128⑥). 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액은 손해액의 하한선을 규정한 것에 불과하므로 실제 손해가 이를 초과하는 것을 증명하면 그 초과액에 대해서도 손해배상을 청구할 수 있음을 명확히 한 확인적 의미의 규정이다.

2) 다만 제130조에 따라 침해자에게 과실이 추정되는데 합리적으로 받을 수 있는 금액을 초과하는 손해액에 대한 손해배상을 청구할 때 경과실의 침해자에 대하여 이를 모두 배상하게 하는 것은 너무 가혹하다는 취지에서 법원이 재량에 의하여 증명된 실제 손해액보다 경감하여 손해배상액을 정할 수 있음을 규정하고 있다.²⁹⁷⁾ 이는 민법 제765조²⁹⁸⁾에 규정된 배상액의 경감청구 규정에 대한 특별법이라고 할 수 있다. 그러나 이 경우에도 합리적으로 받을 수 있는 금액보다 적은 금액까지 경감할 수는 없을 것이다.

⑤ 손해액의 인정

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소송에서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우(예를 들면 침해자가 매입·매출관계서류를 전혀 작성하지 않거나 폐기한 경우 등)에는 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(法 128⑦). 다만 이는 자유심증주의하에서 손해가 발생된 것은 인정되나 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 증명도·심증도를 경감함으로써 손해의 공평·타당한 분담을 지도 원리로 하는 손해배상제도의 이상과 기능을 실현하려는 데 취지가 있는 것이지, 법관에게 손해액 산정에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원이 위와 같은 방법으로 구체적 손해액을 판단할 때에는 손해액 산정 근거가 되는 간접사실들의 탐색에 최선의 노력을 다하여야 하고, 그와 같이 탐색해 낸 간접사실들을 합리적으로 평가하여 객관적으로 수긍할 수 있는 손해액을 산정하여야 한다.²⁹⁹⁾³⁰⁰⁾

296) 법원에서 “통상적”으로 받을 수 있는 금액을 통상실시권의 실시료에 준하여 판단함에 따라 해당 특허발명의 매출액 대비 2%~5%에 불과하여 미국의 13.1%와 비교할 때 상당히 낮게 나타나고 있으며, 개정법은 이를 확대함으로써 특허권의 경제적 가치를 제고하고자 하는 것이다(송대호, 특허법 일부개정법률안 검토보고서(원혜영 의원(의안번호 8842)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2017.11., 4면).

297) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 305면.

298) 제765조【배상액의 경감청구】 ① 본장의 규정에 의한 배상의무자는 그 손해가 고의 또는 중대한 과실에 의한 것이 아니고 그 배상으로 인하여 배상자의 생계에 중대한 영향을 미치게 될 경우에는 법원에 그 배상액의 경감을 청구할 수 있다.

② 법원은 전항의 청구가 있는 때에는 채권자 및 채무자의 경제상태와 손해의 원인 등을 참작하여 배상액을 경감할 수 있다.

⑥ 징벌적 손해배상

1) 법원은 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제1항에도 불구하고 제2항부터 제7항까지의 규정에 따라 손해로 인정된 금액의 5배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 정할 수 있다(法 128⑧). 법원은 배상액을 판단할 때에는 다음의 사항을 고려하여야 한다(法 128⑨).

- i) 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부
- ii) 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도
- iii) 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모
- iv) 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익
- v) 침해행위의 기간·횟수 등
- vi) 침해행위에 따른 벌금
- vii) 침해행위를 한 자의 재산상태
- viii) 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도

2) 기존에는 손해액을 산정함에 있어서 그 침해행위로 인하여 얻은 이익액 또는 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액을 근거로 하는 등 실손배상 원칙을 따르고 있었으나, 고의적인 침해행위를 한 자에 대한 제재수단으로서의 실효성이 낮아서 침해행위를 예방하기에 부족하여, 2019. 7. 9. 시행된 구법(법률 제16208호, 2019. 1. 8. 일부개정)에서는 손해액의 3배를 넘지 아니하는 범위 내에서 배상액을 결정하는 징벌적 손해배상제도³⁰¹⁾를 도입하여 특허권자 보호를 강화하였고,³⁰²⁾ 2024. 8. 21. 시행된 현행법(법률 제20322호, 2024. 2. 20. 일부개정)에서는 3배에서 5배로 그 범위를 확대하였다.³⁰³⁾

299) 대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728.

300) 특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제128조제6항을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고, 이 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 증명하기 어려운 경우 반드시 손해액을 증명할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정 방법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여야만 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다(대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006).

301) 징벌적 손해배상제도란 가해행위로 피해를 입은 당사자가 실제로 입은 손해의 단순한 전보를 넘어서는 금전적 불이익을 가해자에게 부담시키는 제도를 말한다. 우리나라는 현재 하도급 거래 공정화에 관한 법률, 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률, 파견근로자보호 등에 관한 법률, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 개인정보 보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률, 대리점거래의 공정화에 관한 법률, 제조물책임법에 징벌적 손해배상제도를 도입하고 있다.

302) 송대호 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안 검토보고서(원혜영 의원(의안번호 8842)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2017.11. 9-10면.

303) 최근 특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276 판결에서 고의적인 특허침해를 이유로 징벌적 손해배상(2배 증액)을 인정하였다. 또한 특허법원 2024. 9. 26. 선고 2023나11399 판결에서는 고의적인 상표침해를 이유로 징벌적 손해배상(2배 증액)을 인정하였다.

3. 신용회복청구권

(1) 의 의

법원은 고의나 과실로 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해서는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다(法 131).

(2) 요 건

i) 고의나 과실이 있을 것, ii) 특허권 또는 전용실시권을 침해할 것, iii) 업무상의 신용을 떨어뜨릴 것을 요건으로 한다. 예를 들어 침해품의 품질이 조악하여 소비자가 특허권자가 생산한 특허제품에 대해서도 품질이 조악한 것으로 믿게 된 경우가 이에 해당한다.

(3) 신용회복방법

법원은 특허권자 또는 전용권자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하여 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다. 이와 관련하여 헌법재판소는 법원이 신용회복을 위하여 재판으로 사죄광고명령을 내리는 것이 헌법이 규정하는 양심의 자유에 반한다는 위헌 결정을 내린 바 있다.³⁰⁴⁾ 그러나 침해자의 비용으로 패소한 민사손해배상판결, 형사명예훼손죄의 유죄판결 등을 신문·잡지 등에 게재하게 하거나, 명예훼손 기사의 취소광고 등의 조치를 하게 하는 것은 가능하다.

4. 부당이득반환청구권

(1) 의 의

특허권자 또는 전용실시권자는 법률상 원인없이 특허권을 침해하여 이익을 얻고 그로 인하여 손해를 끼친 자에 대하여 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다(民法 741). 특허법에는 부당이득반환청구권에 대한 특별한 규정을 두고 있지 않으나 민법의 부당이득반환청구제도가 그대로 준용된다. 반환할 이득의 범위는 현실로 발생한 침해자의 이익과 특허권자의 손실을 각각 증명하면 그중 적은 쪽의 금액이 인정됨이 타당하다.³⁰⁵⁾

(2) 실효성

손해배상청구권과 비교하여 침해자의 고의·과실과 관계없이 행사할 수 있는 효용성이 있으며, 3년의 단기 소멸시효³⁰⁶⁾가 지나서 손해배상청구권을 행사할 수 없는 경우에도 부당이득반환청구권의 소멸시효는 10년이므로 본 청구권을 행사하여 특허권자 등이 실효적으로 보호될 수 있다.

304) 헌법재판소 1991. 4. 1. 결정

305) 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 835면.

306) 손해배상청구권의 소멸시효는 가해자를 안 날로부터 3년, 불법행위를 한 날로부터 10년이다.

5. 기 타

(1) 경 고

1) 「경고」는 특허권자 또는 전용실시권자가 특허발명을 무단실시하고 있는 자에게 특허권이 있음을 인식시켜 침해행위를 중지할 것을 알리는 행위이다. 이러한 경고는 고의를 증명하는데 유력한 증거가 될 수 있다. 구체적으로 방법의 사용을 청약하는 행위의 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한다는 것을 알면서 한 경우에만 침해가 성립하기 때문에(法 94②), 경고를 받은 후 실시를 중단하면 침해가 성립하지 않는다. 또한 권리행사측면에서 살펴보면, 경고는 민사적으로는 고의 침해에 대한 징벌적 손해배상을 인정하고 있는 손해배상청구권을 행사할 때 의미가 있고, 형사적으로는 과실범은 처벌하지 않고 고의범만을 처벌하기 때문에 실효성이 있다고 할 수 있다. 다만 경고를 받은 이후의 침해행위에는 특별한 사정이 없는 한 고의가 있다고 보아야 하겠지만, 경고를 받은 후 신중하게 전문가의 자문을 구하고 그 의견에 따라 정직하게 행동하였으면 범의(犯意)가 조각될 수도 있다.³⁰⁷⁾

2) 경고는 본안소송으로 진행하기 전 상대방의 대응전략을 살펴볼 수 있다는 점에 또 다른 의미가 있다. 상대방이 경고장을 받은 후 확인대상발명의 실시가 특허권의 침해됨을 인정하고 확인대상발명의 불실시에 대한 합의, 특허권에 대한 실시권 설정이나 특허권 매입 등과 같이 원만한 분쟁의 해결을 원한다면 굳이 시간과 비용이 상당하게 소요되는 본안소송을 진행할 필요가 없기 때문이다.

3) 한편 실시자 이외에 실시자의 거래처까지 경고장을 남발하는 것은 민사상 불법행위에 해당함은 물론 형사소송법 제314조의 “신용훼손의 방법 또는 위력으로서 사람의 업무를 방해한 자”에 해당하여 업무방해죄가 성립될 수도 있으므로 주의하여야 한다.³⁰⁸⁾³⁰⁹⁾

307) 다만 전문가에게 자문을 구함에 있어 중요한 사항을 감추거나 자기에게 일방적으로 유리한 자료만을 제출한 경우, 화학분야의 전문가에게 그와 다른 기계분야의 자문을 구한 경우, 전문가가 확정적인 회답을 하지 아니하고 불명확하게 회답한 경우와 같이, 조력을 구하는 태도와 전문가의 전문분야 및 전문 정도, 회신내용 등에 따라서는 비록 전문가의 의견에 기하여 행동한 경우라고 하더라도 침해의 고의가 인정될 수도 있다(곽민섭, “지적재산권 침해소송 실무와 최근의 판례동향”, 특허심판원, 2009년 5월, 58-59면).

308) 특허권의 침해 여부는 고도의 전문적인 식견을 가지고 판단하여야 하고 전문가에 따라 견해의 차이가 있을 수 있으므로 특허심판원의 심결 또는 특허법원의 판결 등에 의하여 비로소 객관적으로 확정될 수 있으며, 특히 피고가 특허를 가지고 있다고 주장하는 마사이위킹용 전문슈즈의 경우 다수의 업체에서 생산되고 있고, 피고 스스로 인정한 바와 같이 피고도 다른 업체로부터 특허 침해를 원인으로 한 판매금지 경고장을 받는 등 각각의 업체마다 특허의 권리범위에 관하여 주장하는 바가 다르고 분쟁이 많아 특허의 권리범위를 쉽게 판단할 수 없다고 할 것인데, 피고가 특허심판원에 권리범위 확인의 청구를 하거나, 법원에 특허권 침해를 원인으로 한 가처분신청을 하지도 아니한 채 단지 의뢰하였던 변리사의 판단에 근거하여 원고의 이 사건 제품이 피고의 특허권을 침해한다고 단정한 뒤, 피고의 특허를 침해하는 이 사건 제품들을 폐기하고 더 나아가 주요 일간지에 사과문을 게재하라는 강력한 내용의 경고장을 원고의 거래처에 발송한 행위는 고의 내지는 적어도 과실에 의하여 원고의 영업활동을 방해한 것으로 봄이 상당하다(대전지방법원 2009. 12. 4. 선고 2008가합7844).

309) 甲 회사와 乙의 공유인 특허발명이 그 진보성이 부정된다는 이유로 특허심판원의 무효심결이 내려진 후

(2) 증거보전

특허권의 침해에 대한 소제기의 전후를 불문하고 미리 증거조사를 하지 아니하면 증거가 인멸되거나 훼손될 염려가 있는 경우에는 소송 전에 법원에 증거보전신청을 하여 증거조사의 결과를 보전할 수 있다(民訴法 375).

II. 형사적 조치

제225조 【침해죄】

- ① 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
 - ② 제1항의 죄는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소(公訴)를 제기할 수 없다. <개정 2020. 10. 20.>
- [전문개정 2014.6.11.]

제230조 【양벌규정】

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조제1항, 제228조, 제229조 또는 제229조의3의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2025. 1. 21.>

1. 제225조제1항의 경우: 3억원 이하의 벌금
2. 제228조 또는 제229조의 경우: 6천만원 이하의 벌금
3. 제229조의3의 경우: 1억원 이하의 벌금

[전문개정 2014.6.11.]

제231조 【몰수 등】

- ① 제225조제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다.
- ② 피해자는 제1항에 따른 물건을 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 배상을 청구할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

확정되기 전에 甲 회사의 대표인 피고인이 '丙이 생산·판매한 제품은 위 특허권을 침해한 제품이다'라는 사실을 인터넷을 통하여 적시하고, 또한 丙의 거래처들에 같은 내용의 내용증명을 발송하였다는 내용으로 기소된 사안에서, 범행 당시 이미 위 특허발명에 대한 무효심결이 있었다는 사유만으로 위 심결이 확정되지도 아니한 상태에서 그 무효사유가 있음을 알고 있었다고 단정하기는 어렵고, 더욱이 丙의 제품이 위 특허발명의 특징적 구성을 가지고 있어 특허권을 침해하는 것이라고 판단할 여지가 없지 아니한 사정들에 비추어, 위 각 범행일시에 피고인에게 위와 같이 적시된 사실이 허위라는 인식이 있었다고 보기 어려운데도, 이와 달리 본 원심판단에 허위사실 적시 명예훼손죄와 허위사실 유포 그 밖의 위계에 의한 업무방해죄의 '범의'에 관한 법리오해의 위법이 있다(대법원 2010. 10. 28. 선고 2009도4949).

1. 침해죄

(1) 의 의

특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다(法 225①). 특허법에 특별히 규정된 것을 제외하고는 형법이 적용된다(刑法 8). 특허권 침해죄와 관련하여서는 특별히 과실범 처벌규정을 두고 있지 아니하기 때문에 고의범(故意犯)만 처벌한다. 따라서 타인의 특허권을 침해한다는 인식이 전혀 없었던 경우에는 침해죄를 인정할 수 없다.³¹⁰⁾ 한편 특허권 침해죄는 침해행위가 다수에 걸쳐 행하여지더라도 이는 포괄일죄를 구성함에 지나지 아니한다.³¹¹⁾

(2) 반의사불벌죄

본 죄는 피해자의 명시적인 의사에 반하여 공소(公訴)를 제기할 수 없는 반의사불벌죄이다(法 225②). 기존에는 친고죄로 규정하였으나, 친고죄는 i) 고소하여야만 기소할 수 있어서 고소하지 않으면 수사개시와 진행을 할 수 없다는 점, ii) 내용이 복잡하고 특허권 침해 여부를 판단하기까지 상당한 시간이 소요되어 침해가 불분명한 경우에도 고소기간이 범인을 알게 된 날로부터 6월 이내로 짧아서 일단 미리 고소해야 하는 등 침해죄를 다루는 데 한계가 있다는 점 등을 고려하여 2020. 10. 20. 시행된 현행법(법률 제17536호, 2020. 10. 20. 일부개정)에서 반의사불벌죄(反意思不罰罪)로 개정하였다. 반의사불벌죄에 의하면, 고소가 없더라도 수사개시와 진행을 할 수 있으나 특허권자 또는 전용실시권자가 기소를 원하지 않는다는 의사를 확실히 표명할 때 한하여 기소하지 않게 된다.³¹²⁾³¹³⁾

2. 몰 수

(1) 의 의

침해죄에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(法 231①). 「몰수」란 형법상 형의 일종으로서 범죄행위와 관련된 재산의 박탈을 내용으로 하는 재산형을 말한다. 또한 본조에서 몰수는 특허권 침해자의 침해행위에 의한 이득을 금지함이 그 목적이다. 형법상 몰수는 부가형으로 되어 있어 다른 형벌을 선고하는 때에만 이와 함께 과할 수 있다. 다만

310) 대법원 1984. 5. 29. 선고 82도2834; 1984. 12. 26. 선고 82도1799; 2010. 1. 14. 선고 2008도639 등.

311) 대법원 1960. 10. 26. 선고 4293형상326.

312) 송대호, 특허법 일부개정법률안 검토보고서(이장섭의원 대표발의(의안번호 1476)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2020.7. 2-3면.

313) 피해자가 처벌을 희망하지 않는 의사표시나 처벌을 희망하는 의사표시의 철회를 하였다고 인정하기 위해서는 피해자의 진실한 의사가 명백하고 믿을 수 있는 방법으로 표현되어야 한다(대법원 2021. 10. 28. 선고 2021도10010).

행위자에게 유죄의 재판을 아니할 때에도 몰수의 요건이 있을 때에는 몰수만을 선고할 수 있다(刑法 49).

(2) 초과손해액 청구

피해자는 물건을 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 대해서만 배상을 청구할 수 있다(法 231②).

3. 양벌규정

특허권 침해죄의 주체는 자연인이다. 따라서 개인의 종업원 또는 법인의 종업원이 특허권을 침해한 때에도 침해죄의 주체는 종업원이다. 다만 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 「업무에 관하여」 침해죄의 행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 3억원 이하의 벌금형을, 그 개인에게는 1억원 이하의 벌금형을 과한다. 다만 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위해 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다(法 230).

【표 6-9】 특허권의 침해에 대한 특허권자의 구체적인 조치

구 분		내 용
민사상 조치	침해금지 및 예방 청구권	1. 의 의 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 및 예방을 청구할 수 있다. 고의·과실 유무를 불문한다(法 126①). 2. 폐기·제거청구(法 126②) → 반드시 침해금지소송과 함께 행사가능 ① 침해행위를 조성한 물건의 폐기 ② 침해행위에 제공된 설비의 제거 ③ 그 밖에 침해 예방에 필요한 행위 3. 침해금지가처분 신청 → 본안소송확정 전 긴급한 행위가 필요한 경우
	손해배상 청구권	1. 의 의 특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(法 128①). 2. 손해액의 산정(法 128②): ①과 ②의 금액의 합계액 ① 그 물건의 양도수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 경우에는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘지 않는 수량에 특허권자 또는 전용실시권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액 ② 그 물건의 양도수량 중 특허권자 또는 전용실시권자가 생산할 수 있었던 물건의 수량에서 실제 판매한 물건의 수량을 뺀 수량을 넘는 수량 또는 그 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량이 있는 경우 이들 수량(특허권자 또는 전용실시권자가 그 특허권자의 특허권에 대한 전용실시권의 설정, 통상실시권의 허락 또는 그 전용실시권자의 전용실시권에 대한 통상실시권의 허락을 할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량)에 대해서는 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액 3. 손해액의 추정(法 128④) → 침해행위로 인한 이익액 4. 손해액의 의제(法 128⑤) → 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 액 5. 손해액의 참작(法 128⑥) → 손해액 의제 초과액에 대해서도 청구가능, 고의·중과실이 없으면 참작 6. 손해액의 인정(法 128⑦) → 변론 전체의 취지 및 증거조사의 결과 7. 징벌적 손해배상(法 128⑧⑨) → 고의 침해인 경우 손해액의 5배를 넘지 아니하는 범위 내에서 배상액을 결정
	신용회복 청구권	1. 의 의 법원은 고의나 과실로 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 떨어뜨린 자에 대해서는 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있다(法 131). 2. 법원의 조치 → 손해배상을 갈음하여 또는 손해배상과 함께 신용회복에 필요한 조치(사죄광고명령 ×)
	부당이득 반환 청구권	1. 의 의 특허권자 또는 전용실시권자는 법률상 원인없이 특허권을 침해하여 이익을 얻고 그로 인하여 손해를 끼친 자에 대하여 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다(民法 741준용). 2. 선의·악의 불문 3. 실효성 ① 고의·과실과 관계없이 행사가능 ② 단기소멸시효의 적용 ×
형사상 조치	침해죄	1. 의 의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다(法 225①). 2. 반의사불벌죄(法 225②)
	몰 수	1. 의 의 제225조제1항에 해당하는 침해행위를 조성한 물건 또는 그 침해행위로부터 생긴 물건은 몰수하거나 피해자의 청구에 따라 그 물건을 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(法 231①). 2. 초과손해액청구(法 231②) → 물건을 받은 후 물건의 가액을 초과하는 손해액
	양벌규정	법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 침해죄의 행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 3억원 이하의 벌금에 해당하는 벌금형을, 그 개인에게는 1억원 이하의 벌금형을 과한다. 다만 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위해 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다(法 230).

제5관 특허권자의 보호 강화를 위한 특별규정

I. 서 설

특허권은 점유할 수 없는 무체물을 그 보호객체로 하는 무체재산권이므로 유체물을 대상으로 하는 소유권 등과 달리 i) 타인의 모방과 도용이 쉽지만, ii) 침해사실의 발견이나 침해 여부의 증명이 어렵고, iii) 손해액의 증명이 곤란하며, iv) 특허권 침해의 예방이 매우 어렵다는 점을 고려하여 특허권의 침해를 직접침해뿐만 아니라 간접침해(法 127)까지 확장하여 인정하고 있으며, 구체적 행위의 내용·방식·형태 제시 의무(法 126의2), 감정사항 설명의무(法 128의2), 생산방법의 추정(法 129), 과실의 추정(法 130), 자료의 제출(法 132) 등과 같은 특별규정을 마련하여 특허권자의 보호를 강화하고 있다.

II. 간접침해

제127조 【침해로 보는 행위】

다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다. <개정 2025. 1. 21.>

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입 하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입 하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

1. 서

(1) 의 의

「간접침해」란 특허발명 그 자체의 실시가 아니므로 직접침해는 아니지만, 직접침해의 전 단계로서 그대로 방치하면 침해의 개연성이 높은 일정한 행위에 대하여 특허권을 침해하는 것으로 간주하는 것을 말한다.

(2) 취 지

현재 특허권을 침해하고 있지는 않으나 그대로 방치하면 침해로 이어질 개연성이 높은 예비적 행위나, 특허발명의 구성부품만을 업으로서 판매하여 최종조립에 의한 특허발명의 실시를 개인적·가정적으로 유도하는 행위 등에 대해서는 실질적으로 특허발명이 실현하고 있는 기술적 사상을 이용하여 이익을 얻고 특허권자에게 손해를 미칠 우려가 존재하지만 구성요소완비의 원칙에 의한 직접침해만을 고수한다면 이자에게 책임을 물을 수 없는 문제점이 생긴다. 이는 특허권의 효력을 현저히 감소시켜 특허제도의 목적에 반하게 된다.³¹⁴⁾ 따라서 특허법은 특허

발명의 실시가 아닐지라도 특허권의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 경우 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 장래의 특허권의 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 침해로 보는 행위로 간주하여 특허발명의 보호범위에 속함을 인정하고 있다.³¹⁵⁾

2. 성립요건

(1) 서

간접침해가 성립하기 위해서는 특허권의 존속 중 정당한 권원 없는 자가 업으로서 간접침해 행위를 하여야 한다. 간접침해행위란 i) 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, ii) 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이하에서는 간접침해행위에 대하여 상세히 살펴본다.

(2) 특허가 물건발명인 경우

① 의 의

특허가 물건발명인 경우 「그 물건의 생산에만」 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(法 127 I)이어야 한다.³¹⁶⁾ 예를 들어 텔레비전의 완성품에 대하여 특허가 있는데 그 텔레비전의 조립에만 필요한 일정한 부품을 세트로 판매하는 경우가 있다. 텔레비전의 조립세트는 텔레비전 그 자체는 아니므로 특허발명이라고 하기는 곤란하며 그것을 판매하여도 바로 직접침해라고는 할 수 없다. 그러나 그 텔레비전의 조립세트가 해당 텔레비전의 조립 이외의 용도에 사용되지는 않고, 언젠가는 그 텔레비전 조립세트에 의하여 해당 텔레비전의 완성품을 조립하여 특허권을 직접침해할 것으로 예상할 수 있으므로, 침해행위의 전 단계에 있는 조립세트의 판매행위를 침해행위로 보아서 사전에 침해행위의 금지를 도모하는 것이다.³¹⁷⁾

② 생 산

1) 「생산」이란 특허발명의 구성요소를 충족하지 아니한 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 구성요소를 충족하는 물건을 만들어 내는 모든 의식적 행위를 의미하고, 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 포함될 수 있다.³¹⁸⁾ 여기서 문제가

314) 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 808면.

315) 특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496 참조.

316) 특허발명인 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 사용하는 것은 특허발명인 물건의 생산에 해당하기 때문에 직접침해이다.

317) 다만 실무상 완구용 세트와 같은 경우에는 유의할 점이 있다. 업계에서 완구의 완성품 형태의 유통과 완구용 세트형태의 유통을 동일하게 보므로, 완구용 세트형태의 실시행위는 간접침해가 아닌 직접침해행위로 취급하고 있는 것이 일본과 우리나라의 입장이다.

되는 것은 부품의 교체가 특허발명인 물건의 「사용」이 아닌 「생산」에 해당하는지이다. 부품이 비소모품이면 발명의 기술적 사상과 관련된 본질적인 구성요소라면 부품의 교체가 생산에 해당하고,³¹⁹⁾ 특허발명의 대상 또는 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모품이면 i) 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 ii) 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 iii) 해당 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, iv) 특허권자 측에 의하여 그러한 부품을 따로 제조·판매하고 있다면 생산에 해당한다³²⁰⁾는 것이 판례의 태도이다. 완제품에 대한 특허권자가 소모품이 유통되는 부품시장(after market)에서 과도한 독점권을 갖는 것은 타당하지 않기 때문에 부품이 소모품 이면 생산에 해당하기 위한 요건을 엄격히 규정하고 있다. 다만 특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1001 판결³²¹⁾에서는 부품을 교체하는 것이 원래 특허제품과의 동일성을 해할 정도에 이르게 된 경우에는 재생산으로 특허권을 침해하는 것으로, 동일성을 유지되는 경우에는 수리로서 특허권을 침해하지 않은 것으로 판단하고 있다. 또한 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단하여야 한다고 하여 상표법에서의 판단기준³²²⁾과 동일한 판단기준을 제시하였다. 이는 본질적 부분의 교체라면 생산이 된다는 기존의 판례보다 수리의 범위를 조금 더 넓게 인정해 주려는 경향으로 파악된다.

2) 한편 「생산」이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.³²³⁾

318) 대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602; 2009. 9. 10. 선고 2007후3356.

319) 서울중앙지방법원 2006. 8. 23. 선고 2005가합48548.

320) 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 참조.

321) 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등이 이를 수리하거나 소모품 내지 부품을 교체하는 경우에 그로 인하여 원래 제품과의 동일성을 해할 정도에 이르는 때에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지로 특허권을 침해하는 것으로 보아야 할 것이나, 그러한 수리 또는 소모품 내지 부품이 제품의 일부에 관한 것이어서 수리 또는 소모품 내지 부품의 교체 이후에도 원래 제품과의 동일성이 유지되고, 그 소모품 내지 부품 자체가 별도의 특허 대상이 아닌 한, 그러한 수리행위나 부품 교체행위는 방법발명 제품 사용의 일환으로 허용되는 수리에 해당하므로, 제3자가 업으로서 그러한 소모품 내지 부품을 생산·양도·대여 또는 수입하는 등의 경우에 특허법 제127조 제2항 소정의 간접침해가 성립하는지는 별론으로 하고, 특별한 사정이 없는 한 양수인 등의 그러한 수리행위나 부품 교체행위가 방법발명의 특허권을 직접 또는 간접적으로 침해한다고 볼 수는 없다. 이는 그러한 소모품 내지 부품이 그 특허발명의 실시에만 사용되는 것인 경우에도 마찬가지이다. 한편 수리행위 내지 부품 교체행위가 제품의 동일성을 해할 정도에 이르러 생산행위에 해당하는지 여부는 당해 제품의 객관적 성질, 이용형태 및 특허법의 규정취지 등을 종합하여 판단하여야 한다.

322) 특별한 사정이 없는 한 상표권자 등이 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 아니한다고 할 것이나, 원래의 상품과의 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선을 하는 경우에는 실질적으로 생산행위를 하는 것과 마찬가지이므로 이러한 경우에는 상표권자의 권리를 침해하는 것으로 보아야 할 것이고, 동일성을 해할 정도의 가공이나 수선으로서 생산행위에 해당하는가의 여부는 해당 상품의 객관적인 성질, 이용형태 및 상표법의 규정취지와 상표의 기능 등을 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445).

(3) 특허가 방법의 발명인 경우

특허가 방법발명인 경우 「그 방법의 실시에만」 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(法 127Ⅱ)이어야 한다. 예를 들어 특정의 농약(DDT)을 살충제로 사용하는 방법발명이 특허발명이고 그 농약이 살충제로만 사용되는 경우 그 농약을 살충제로 사용하면 당연히 직접침해가 되지만 그 농약을 생산·양도하는 행위는 방법발명의 실시가 아니므로 직접침해가 아니다. 그러나 특허권의 보호를 위하여 농약을 살충제로 사용하기 전 단계인 그 농약의 생산·양도행위를 특허권의 침해로 간주한다.

(4) 「특허발명인 물건발명의 생산, 방법발명의 실시」에 사용되는 물건인지 여부(供用性)

물건의 사용이 구성요소완비의 원칙에 의한 특허발명인 물건발명의 생산, 방법발명의 실시에 해당하는 경우³²⁴⁾뿐만 아니라 균등론에 의한 물건발명의 생산, 방법발명의 실시인 경우에도 실질적으로 특허발명을 생산, 실시한 것으로 볼 수 있으므로 간접침해를 긍정한다.

(5) 「에만」에 사용되는지 여부(專用性)

1) 「...에만」이란 「해당 발명 A에 있어서 사용하는 물건 B가 해당 발명 이외의 타용도를 갖고 있지 않다는 것」을 의미한다.³²⁵⁾ 「타용도」가 무엇인가에 대해서는 기존에 경제적·상업적·실용적 사용가능성³²⁶⁾과 경제적·상업적·실용적 사용사실³²⁷⁾이 있었으나, 우리나라 대법원³²⁸⁾은 경제적·상업적·실용적 사용사실을 지지하고 있다. 한편 특허권자가 타용도가 없음을 주장·증명하여야 한다. 그러나 타용도가 존재하지 않는다는 사실을 증명하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란하지만, 타용도가 존재한다는 사실을 주장·증명하는 것이 보다 쉬운 법

323) 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110, 다만 2025. 7. 22. 시행되는 개정법(법률 제20700호, 2025. 1. 21. 일부개정)에서는 수출을 제2조제3호의 발명의 실시행위에 추가하면서 제127조의 간접침해행위에도 포함시켰는데, 대법원과 같이 제127조제1호에서 특허발명인 물건의 생산을 국내로 제한해석한다면, 수출에 대해서는 간접침해를 물을 수 없게 되는 문제점이 있다.

324) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356.

325) 다양한 용도에 널리 사용될 수 있는 기초상품(staple commercial product)이나 시장에서 쉽게 취득할 수 있는 범용품(汎用品) 등 이른바 중성적 물건에 관해서는 그것이 특허발명의 구성요소에 속한다 하더라도 간접침해가 성립할 여지가 없다(서울고등법원 1999. 9. 21. 선고 98나41072).

326) 東京地判 昭和 56. 2. 25의 교환렌즈사건에 대한 판례의 입장이다.

327) 大阪地判 昭和 54. 2. 16의 장식화장판의 벽면접착시공법사건에 대한 판례의 입장이다.

328) 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결에서는 “상업적 또는 경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한하여 인정되어야 하고, 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 타용도가 있다고 할 수 없다”라고 판시하고 있고, 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결에서는 “확인대상발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 확인대상발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허발명의 실시 물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는, 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다”라고 판시하고 있다. 또한, 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903 판결에서도 “사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다. 이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다”라고 판시하고 있다.

이고, 더욱이 실시자가 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 크다. 따라서 그 자체로 범용성(汎用性)이 있는 물건이 아닌 한 특허발명인 물건발명의 생산이나 방법발명의 실시에 사용하는 물건이라는 점(供用性)이 증명된 후 실시자가 그 물건에 타용도가 있음에 관하여 구체적이고 합리성이 있는 주장을 하는 때에만 타용도가 없다(專用性)는 것에 대한 증명책임이 현실화된다고 보는 것이 타당하다. 이 경우 특허권자는 실시자가 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다.³²⁹⁾

2) 물건의 용도는 시간의 경과에 따라 변할 수 있으므로 타용도의 유무 판단은 해당 행위로 해석하는 것이 타당하다. 즉 등록 후 일정 기간이 지난 후 타용도가 발견되면 타용도가 발견되기 전까지의 행위는 간접침해일지라도 타용도가 발견된 이후의 행위는 간접침해가 아니다.

(6) 「물건」에 해당하는지 여부

1) 「물건」이란 특허발명인 물건의 생산, 방법의 실시에 사용되는 수단으로서 기계, 장치 등과 같은 도구뿐만 아니라 특허발명인 물건의 구성요소로서 다른 구성요소와 결합하여 특허발명을 생산하게 되는 부품도 포함된다. 예를 들어, 특허발명이 A+B+C로 구성된 연필인 경우 연필의 생산에만 사용되는 생산장치 X, 연필의 구성요소인 A가 물건이 될 수 있다.

2) 「물건」이 특허발명의 출원 시점에서 공지되었으면 간접침해가 아니다. 특허발명의 출원 전에 공지되었으면 이미 공공영역(자유기술의 영역)이라고 할 수 있고, 또한 타용도가 있다고 볼 수도 있기 때문이다.³³⁰⁾

3) 타용도가 없는 물건인 이상 기술구성 일부가 종래의 기술을 개량한 것으로서 그 자체에 특허성이 있는 것이라고 하더라도 간접침해이다(이 경우에는 선·후 특허권자 사이에 실시권 허락의 문제가 나타나게 된다).³³¹⁾ 이는 특허요건 판단과 침해의 성립요건 판단은 별개의 것이기 때문이다. 또한 타용도가 없는 물건에 다른 구성요소를 부가하여 그 다른 구성요소로 인해 타용도를 창출해 낸 경우라고 하더라도 타용도가 없는 물건이 특허권의 간접침해임에는 변함이 없다. 이렇게 해석하지 않는다면 다른 구성요소를 임의로 부가하는 것만으로 언제나 간

329) 특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305.

330) 일면에 접착제가 도포되어 롤에 감겨 있는 합성수지필름이 이 사건 특허발명에 있어 증명서의 피복재로 없어서는 안될 소모품으로서 열용착시 증명서와 접합되는 물건이라는 점만 알 수 있을 뿐, 나아가 위 합성수지 접착필름이 오로지 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 인정할 만한 자료를 찾아볼 수 없고, 오히려 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포된 일본국 실용신안공보 소(昭)61-26036호(을 제18호증)를 보면 위 합성수지 접착필름은 이미 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것임을 알 수 있는바, 사정이 이와 같다면 위 합성수지 접착필름은 이 사건 특허발명의 증명서 자동피복장치의 생산에만 사용되는 물건이라고 보기 어렵다 할 것이므로, 피고가 이를 제작·판매하는 행위가 이 사건 특허발명의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없을 것이다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602).

331) 확인대상발명의 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상, 확인대상발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선했던 페토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도, 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580).

접침해를 회피할 수 있게 되어 부당한 결과를 초래하게 되기 때문이다.³³²⁾ 한편 특허받은 물건의 생산에만 사용하거나 방법의 실시에만 사용하는 물건과 동일한 물건뿐만 아니라 균등한 물건인 경우에도 간접침해가 성립된다.³³³⁾

(7) 그 밖의 요건

① 주관적 요건의 유무

직접침해와 마찬가지로 간접침해에 대해서도 침해자의 고의·과실을 불문한다는 것이 통설이다.

② 직접침해와의 관계

1) 직접침해가 있어야 간접침해가 인정된다는 종속설과 직접침해와 별도로 간접침해의 요건만 갖추면 된다는 독립설이 있다. 이에 대한 구별이 문제가 된 유형으로는 i) 실시권, 권리소진이 적용되는 물건 등과 같이 정당한 권원을 가진 자가 특허발명을 실시하거나 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96) 등에서 특허발명을 실시하여 직접침해가 아닌데 그 자에게 간접침해행위에 해당하는 물건을 생산하여 양도 등을 하는 행위, ii) 특허발명의 실시를 국외에서 하여 직접침해가 아닌데 그 자에게 국내에서 간접침해행위에 해당하는 물건을 생산하여 양도 등을 하는 행위, iii) 최종 특허발명의 실시를 업이 아닌 개인적, 가정적으로 유도하여 직접침해가 아닌데 그 자에게 간접침해행위에 해당하는 물건을 생산하여 양도 등을 하는 행위가 있을 수 있다. 독립설에 의하면, i) 내지 iii)이 모두 간접침해일 수 있으나, 종속설에 의하며 직접침해가 성립하지 않으므로 간접침해도 성립되지 않게 된다. i) 및 ii)의 행위에 대해서는 이를 특허권의 침해라고 보는 것은 불법에 가공하지 않은 행위에 대해서 책임을 묻는 것이기 때문에 특허권의 부당한 확장이고 특허발명의 실시를 교사하거나 방조하더라도 위법성이 있다고 할 수 없다는 입장, iii)에 대해서는 이를 간접침해라고 하지 않는다면 간접침해 규정의 실질적인 실효성이 없어진다는 입장이 다소 우위에 있는 견해로 보인다.³³⁴⁾

2) 대법원도 독립설과 종속설 중 어느 한 가지 설만을 지지하는 것이 아니라 사안별로 달리 판단하고 있다. i)와 관련하여, 대법원 2019. 2. 28. 선고 2017다290095 판결은 “방법의 발명(이하 ‘방법발명’이라고 한다)에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건(이하 ‘전용품’이라고 한다)의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래한다. 또한 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의

332) 서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합39552.

333) 특허법원 2007. 5. 23. 선고 2006허6679.

334) 광민집, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 106-07면; 문선영, “특허권 간접침해 규정의 문제점과 개선방안”, 경북대학교 법학연구원, 법학논고 제45집, 2014년 2월, 581-582면.

가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다. 따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다”라고 하여 실시권자에게 전용품을 납품하는 행위는 간접침해가 아니라고 판시하였다.

3) ii)와 관련하여, 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결은 “간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 발명에 관한 특허권자가 그 물건에 대하여 가지는 독점적인 생산·사용·양도·대여·수출 또는 수입 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미치는 점을 고려하면, 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다”라고 하여 완제품인 특허발명을 외국에서 생산한다면 반제품을 생산 및 수출하는 행위가 간접침해가 아니라고 하였다.³³⁵⁾ 다만 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2019다222799(병합) 판결에서는 “국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, 이것이 하나의 주체에 수출되어 마지막 단계의 가공 조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, 그와 같은 가공 조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다”라고 하여 반제품의 생산이라고 할지라도 일정요건 하에서 완제품인 특허발명이 생산된 것과 같이 볼 수 있다면 반제품을 생산 및 수출하는 행위에 대해 구성요소완비의 원칙을 적용할 수 있으므로 직접침해라고 판시하면서 속지주의 원칙의 예외를 인정하고 있다. 2019다222782 판결은 속지주의 원칙을 엄격하게 적용하였던 2014다42110 판결이 채택한 법리에서 탈피하여, 완제품이 외국에서 생산되었다고 할지라도 일정요건 하에서 우리나라에서 완제품이 생산된 것으로 간주할 수 있다는 태도를 보임으로써, 특허권의 실질적인 보호를 추구한다는 점에서 의의가 있다. 나아가 2019다222782 판결은 제한적인 요건 하에 우리 특허법상 직접침해 법리와 간접침해 규정이 역외적인 효력을 가질 수 있다는 법리를 채택함으로써, 속지주의 원칙에 내재되어 있는 「타국의 자주권과 특허법의 존중」과 「국제적인 신의의 존중」이라는 가치를 준수하려고 하였다는 점에서도 의의가 있다.³³⁶⁾ 물론 이러한 경우에 해당하는지는 속지주의 원칙과 구성요소

335) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970에서도 동일한 취지로 판결하였다.

336) 이주환, “특허침해의 역외적용에 대한 우리 대법원의 태도 - 대법원 2019.10.17. 선고 2019다222782 판결을 중심으로 -”, 「선진상사법률연구」 통권 제94호, 2021.4, 특허법원 국제 지식재산권법 연구센터, 192-194, 218면 참조.

완비의 원칙을 고려하여 엄격하게 판단하여야 한다.³³⁷⁾ 결국 두 판결을 정리하면, ① 국내에서의 행위를 특허발명의 실시행위로 평가할 수 있는 경우에는 특허권에 대한 직접침해가 성립하고(2019다222782 판결), ② 국내에서의 행위를 특허발명의 실시행위라고 평가할 수 없는 경우에는 특허권에 대한 직접침해는 물론 간접침해도 성립할 수 없다(2014다42110 판결)고 할 수 있다.

4) iii)과 관련하여, 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결은 “특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 확인대상발명의 감광드럼카트리지가 특허발명의 본질적 구성요소이고 타용도로는 사용되지도 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라 레이저 프린터 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고 특허권자가 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위를 벗어날 수 없다”라고 하여 일반적인 특허발명의 실시가 개인적, 가정적으로 되는 특허발명인 레이저 프린터에 사용되는 감광드럼카트리지를 생산하여 판매하는 행위를 간접침해라고 하였다.

3. 특허권자의 조치

(1) 민사적 조치

민사적으로는 직접침해의 경우와 마찬가지로 침해금지청구나 손해배상청구³³⁸⁾ 등으로 구제될 수 있다. 다만 간접침해에 대한 침해금지청구권은 손해배상청구와는 달리 현재 또는 장래의 침해행위를 금지하는 것이므로 침해금지청구권을 소송상 행사할 때 타용도 존재의 기준시점은 간접침해 시가 아니라 사실심 변론종결 시를 기준으로 하여야 한다. 변론 종결 시에 타용도가 있음에도 불구하고 침해금지청구권의 행사를 인정하면 특허발명과 무관한 타용도로 이용할 수 있는 물건에까지 특허권의 효력이 미치게 되기 때문이다.

337) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970.

338) 특허법 제128조제2항, 제4항은 침해품이 판매된 경우에 그 판매수량분 만큼 특허권자의 특허제품의 판매가 감소하였을 것이라는 개연성에 기초해서 그 감소분에 의하여 특허권자가 당연히 얻었을 이익액을 원고의 손해액으로 하거나 침해품의 판매에 의하여 침해자가 얻은 이익을 특허제품의 판매감소분에 의하여 특허권자가 얻었을 이익으로 추정할 수 있다는 전제에서 규정된 것이다. 특허권자가 방법의 발명에 관해서 특허권을 가지고 있고, 침해자가 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산하여 양도하는 특허권의 간접침해행위를 한 경우에는 방법발명의 실시는 그 방법의 사용에 불과하고, 그 실시로 인해 특허제품이 생산·판매되는 것이 아니어서 침해품의 판매로 인해 특허제품의 판매가 감소된다는 개연성을 인정하기 어려우므로 특허권의 간접침해자가 얻은 이익인 침해품의 판매수익을 방법발명에 관한 특허권자의 일실이익이라고 볼 수는 없다. 원고의 특허발명이 방법발명이므로 특허법 제128조제4항에 따라 피고들이 원고의 특허권을 침해하여 얻은 이익을 산정하기 곤란하고, 이를 인정할 자료가 없으며, 원고가 특허발명의 실시를 허락하고 실시료를 받은 적이 있는지, 그 실시료가 얼마인지 등을 인정할 자료도 없으므로 피고들의 손해배상액에 관하여 특허법 제128조제7항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과를 참작하여 상당한 손해액을 인정함이 상당하다(서울중앙지방법원 2009. 1. 8. 선고 2008가합1588).

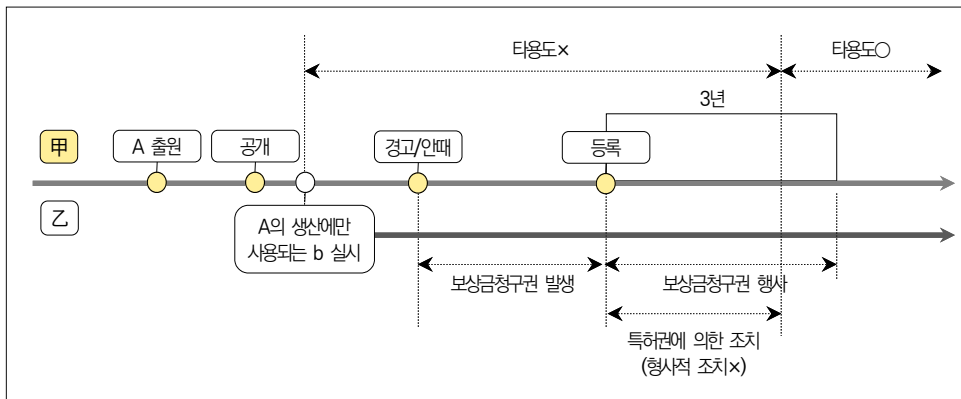
(2) 형사적 조치

간접침해에 대해서는 침해죄를 물을 수 없다. i) 확장해석을 금하는 죄형법정주의의 원칙이나, ii) 특허권 침해의 미수범에 대한 처벌 규정이 없어 특허권 직접침해의 미수범은 처벌되지 아니함에도 특허권 직접침해의 예비단계행위에 불과한 간접침해행위를 특허권 직접침해의 기수범과 같은 벌칙에 의하여 처벌할 때 초래되는 형벌의 불균형성 등에 비추어 볼 때, 간접침해는 특허권자 등을 보호하기 위하여 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 이를 특허권 침해행위를 처벌하는 형벌법규의 구성요건으로서 규정한 취지는 아니기 때문이다.³³⁹⁾³⁴⁰⁾

4. 관련문제

(1) 간접침해와 보상금청구권

특허출원된 발명의 간접침해에 해당하는 물건을 출원공개 후 제3자가 정당한 권원 없이 업으로 실시하고 있는 자에게 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 설정등록할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다(法 65⑤).



【그림 6-15】 간접침해에 대한 특허권자의 조치

339) 대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350.

340) 법 규정상의 위치를 볼 때도, 간접침해에 관한 규정(제127조)이 특허권자의 민사적 구제조치와 관련된 제6장 특허권자의 보호(제126조-제132조) 아래에 규정된 점을 고려하면, 간접침해는 민사책임에 관한 것에 한정된다고 보는 것이 입법자의 의도라고 해석될 수 있다.

(2) 간접침해와 권리소진

특허발명의 특허권자로부터 특허발명의 간접침해에 해당하는 물건을 적법하게 양도받은 제3자가 해당 물건을 양도·대여·수출·수입 또는 대여의 청약뿐만 아니라 사용하는 행위를 하더라도 권리소진에 의하여 침해가 성립하지 아니한다. 물건의 양도가 계약에 의한 경우뿐만 아니라 경매절차에 의한 경우에도 특별한 사정이 없는 한 특허권 소진의 법리는 적용된다. 다만 방법발명에 대한 특허권이 공유인 경우에 있어서 간접침해에 해당하는 물건을 양도하는 경우에는 그 물건이 공유자 중 일부의 소유이고 그 소유자가 아닌 다른 공유자가 그 물건의 양도에 대해서 동의를 한 바가 없다면, 다른 공유자의 동의없이 통실풍속권을 허락하는 것과 같게 되어 제99조제4항에 위반되기 때문에 권리소진이 되지 아니한다.³⁴¹⁾

(3) 간접침해와 자유기술의 항변

특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허4523 판결은 “간접침해를 전제로 한 적극적 권리범의 확인심판절차에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유실시 기술에 해당하는지 여부를 판단하는 경우는, 피심판청구인이 실시하는 부분이 특허발명에 대응하는 제품의 일부 구성에 불과하여 그 자체만으로는 침해가 성립되지 아니한 경우에도 그 실시 부분이 그 대응제품의 생산에만 사용되는 경우에는 침해로 의제되는 간접침해의 특성상, 확인대상발명을 위 실시 부분의 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 위 실시 부분의 구성과 함께 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성 전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 할 것이다”라고 하여 간접침해에서도 자유기술의 항변을 인정하되, 확인대상발명은 간접침해 대상 물건인 부품이 아닌 권리가 특정된 부품이 결합된 전체라는 판단기준을 제시하고 있다. 이는 간접침해 대상인 부품 자체만으로 자유기술인지 여부를 살펴보면 대부분 자유기술에 해당되어 간접침해에 해당되는 건들이 존재하지 않게 되기 때문에 결과적으로 간접침해 조문이 사문화되는 불합리함을 방지하기 위함이다.³⁴²⁾ 결국 자유기술의 항변에서 확인대상발명은 직접 침해, 간접침체에 상관없이 대응 구성이 아니라 전체 구성이라는 것이다.

341) 특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299.

342) 이금옥, “간접침해관련 사건에서 자유실시기술 여부의 판단을 위한 확인대상발명의 특정”, 지식재산21, 2009년 10월, 83-97면.

【표 6-10】 A, A의 제조장치 및 A의 제조방법과의 관계

특허발명 실시중	A	A의 제조방법(方1)	A의 제조장치(裝1)
A	■ 직접침해	■ 方1의 실시 : 직접침해 ■ 다른 方의 실시 : 비침해	■ A의 생산 - 裝1의 사용 : 직접침해 - 다른 裝의 사용 : 비침해 ■ A의 사용·양도·대여·수출·수입·청약 : 비침해
A의 제조방법(方1)	■ 직접침해(∵ A의 제조방법의 실시는 물건생산의 청약을 제외하고는 모두 A의 실시에 해당함)	■ 직접침해	■ A의 제조방법의 사용 - 裝1의 사용 : 직접침해 - 다른 裝의 사용 : 비침해 ■ A의 제조방법의 사용에 의 한 A의 사용·양도·대여·수출·수입·청약 : 비침해
A의 제조장치(裝1)	■ A의 제조장치의 사용 - 직접침해(∵ A의 생산에 해당) ■ A의 제조장치의 생산·양도·대여·수출·수입·청약 - 타용도가 있는 경우 : 비침해 - 타용도가 없는 경우 : 간접침해	■ A의 제조장치의 사용 - 方1의 사용 : 직접침해 - 다른 方의 사용 : 비침해 ■ A의 제조장치의 생산·양도·대여·수출·수입·청약 - 타용도가 있는 경우 : 비침해 - 타용도가 없는 경우 : 간접침해	■ 직접침해

Ⅲ. 그 밖의 특별규정

제126조의2 【구체적 행위의 내용·방식·형태 제시 의무】

- ① 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하여야 한다.
- ② 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다.
- ③ 제2항에 따른 자료제출명령에 관하여는 제132조제2항 및 제3항을 준용한다. 이 경우 제132조제3항 중 “침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때”를 “구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때”로 한다.
- ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 진실한 것으로 인정할 수 있다.

[본조신설 2019. 1. 8.]

제128조의2 【감정사항 설명의무】

특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다. [본조신설 2016.3.29.]

제129조 【생산방법의 추정】

물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허된 방법에

의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만, 그 물건이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공언히 실시된 물건
2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건

[전문개정 2014.6.11.]

제130조 【과실의 추정】

타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제132조 【자료의 제출】

- ① 법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. <개정 2016.3.29.>
- ② 법원은 자료의 소지자가 제1항에 따른 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다. <신설 2016.3.29.>
- ③ 제1항에 따라 제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 제1항 단서에 따른 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다. <신설 2016.3.29.>
- ④ 당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. <신설 2016.3.29.>
- ⑤ 제4항에 해당하는 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. <신설 2016.3.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.3.29.]

1. 구체적 행위의 내용·방식·형태 제시 의무

(1) 의 의

특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하여야 한다(法 126의2①). 즉 특허권자 등이 주장하는 침해행위를 부인하는 피고에게 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하라는 것으로서, i) 침해행위는 침해자의 영역에서 주로 발생하므로 특허권자 등이 침해사실을 증명하기는 매우 어렵다는 점, ii) 특허권자 등이 침해행위의 구체적인 태양을 제시하며 침해사실을 증명하고자 할 때 피고가 단순히 부인만으로도 방어할 수 없도록 하고 자기의 구체적인 행위의 내용·방식·형태를 제시하도록 하는 것은 해당 소송의 적정성과 신속성을 제고하는 데 기여할 수 있다는 점 등을 고려하여 2019. 7. 9. 시행된 현행법(법률 제16208호, 2019. 1. 8. 일부개정)에서 도입되었다.

(2) 자료제출명령 및 자료제출을 거부할 정당한 이유가 있는 경우

1) 법원은 당사자가 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다(法 126의2②본). 이는 특허권자 등이 특허권 등의 침해와는 관계없이 상대방의 미공개 기술 또는 영업비밀 등을 확보할 목적으로 소송을 남용할 수 있다는 점을 고려할 필요가 있기 때문이다.

2) 다만 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다(法 126의2②단서). 법원은 자료의 소지자가 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다(法 126의2③ 준용 132②).

(3) 영업비밀이 포함된 경우

제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무 판단에 반드시 필요한 때에는 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다(法 126의2③ 준용 132③). 단순히 영업비밀에 속한다는 것을 정당한 이유로 본다면 이 규정의 실효성이 크게 감소하기 때문에 반드시 필요한 때에는 정당한 이유에 해당하지 아니한다. 한편 자료를 제출하는 당사자는 그 자료에 영업비밀이 포함되었으면 열람범위와 열람자의 제한 또는 비밀유지명령제도(法 224의3)를 통해 보호받을 수 있다.

(4) 제 재

당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 진실한 것으로 인정할 수 있다(法 126의2④).

2. 감정사항 설명의무

특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 법원이 침해로 인한 손해액의 산정을 위하여 감정을 명한 때에는 당사자는 감정인에게 감정에 필요한 사항을 설명하여야 한다(法 128의2). 이는 감정 대상 자료의 경우 당사자 외에 알기 어려운 특별한 사정이 있을 수 있기 때문에 민사소송법상의 감정제도에 추가하여 감정인에 대한 당사자의 설명의무를 도입함으로써 감정의 충실도를 높이고 소송이 장기화될 우려를 막기 위함이다.

3. 생산방법의 추정

물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건은 그 특허

된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다. 다만 그 물건이 i) 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 물건 또는 ii) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 물건인 경우에는 그러하지 아니하다(法 129).³⁴³⁾ 신규의 동일한 제품은 동일방법에 의하여 제조되는 경우가 많고, 더욱이 방법발명의 경우 어떤 행위가 그 방법을 침해한 것인지에 대하여 증명하기가 쉽지 아니한바 생산방법의 추정(法 129) 규정을 두어 증명책임의 전환을 도모하였다. 이 경우 실시자는 특허권자의 특허발명과 다른 방법에 의하여 생산한 것이라는 점 또는 물건이 출원 전 공지되었음을 주장·증명하여 침해주장에서 벗어날 수 있다.³⁴⁴⁾

4. 과실의 추정

1) 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다(法 130). 이는 무체재산권인 특허권의 특성상 고의나 과실의 증명이 어렵고 특허발명의 내용이 공개특허공보, 등록특허공보, 특허등록원부 등에 공시되었음에도 이를 간과하고 특허발명을 실시하는 것은 침해자의 과실로 여겨질 수 있기 때문이다. 또한 업으로서 발명을 하는 자에게 해당 기술분야에서 특허권 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하기 때문이다.³⁴⁵⁾

2) 권리자가 침해사실을 알면서도 그 침해에 대하여 어느 정도 방관한 경우나 침해품이라고 지목된 제품이 별도의 산업재산권을 등록받은 사정이 있다는 것만으로는 과실의 추정을 복명시킬 수 없다. 과실의 추정을 복명시키는 위해서는 i) 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있거나 ii) 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·증명하여야 한다.³⁴⁶⁾

3) 특허권을 침해하는 제품을 생산·판매한 후에 정정하는 심결이 확정된 경우에도 정정으로 인해 청구범위의 실질적 변경이 있다고 할 수 없으므로 제130조에 의하여 특허권 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전후하여 그대로 유지된다.³⁴⁷⁾

343) 제129조제1호에서 공지, 공연실시의 지역적 기준을 국내로 한정하고 있는 것은 신규성 상실사유인 제29조 제1항제1호의 공지, 공연실시를 기준에 국내로 한정한 것과 그 궤를 같이 하는 것이라고 할 수 있다. 다만 私見으로는 외국에서 공지, 공연실시된 물건의 제조방법에 대하여 특허를 받았을 때 증명책임의 전환을 통해 특허권자를 보호해 주는 것은 특허권자를 너무 과도하게 보호하는 한편 국내산업의 기술경쟁력을 저해하는 요인이 되기 때문에 제129조제1호의 공지, 공연실시를 현재(2006. 10. 1. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정))의 제29조제1항제1호와 같이 국내외를 기준으로 함이 타당하다고 여겨진다.

344) 원고가 신규개발, 그 제조방법에 관하여 특허등록을 마친 「케토코나졸」로 불리는 화합물을 피고가 원료로 수입, 케토코나졸 제품을 제조·판매하였다면, 위 물질이 원고의 특허출원 당시 국내에서 공지된 물건이라는 점에 대한 주장 증명이 없는 한, 피고가 수입 사용한 위 케토코나졸 원료는 특허법 제129조에 의하여 원고의 위 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정되고, 나아가 피고가 위 원료를 사용한 제품을 제조·판매하는 행위는 원고의 특허권을 침해하는 것으로 추정된다(서울고등법원 1992. 7. 29. 선고 91나53298).

345) 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272; 2006. 4. 27. 선고 2003다15006.

346) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006. 이후 구체적인 사례로 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007다65245 판결은 “피고들 자신이 위 침해 당시 이 사건 실시고안을 등록한 자신의 실용신안권에 기해 제작한 것이라고 믿었다더라도 그러한 점만으로는 이 사건 실시고안이 이 사건 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정 등에 해당한다고 할 수 없다”라고 하였다.

5. 자료의 제출

(1) 의 의

법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다(法 132①본문). 2016. 6. 30. 시행된 현행법(법률 제14112호, 2016. 3. 29. 개정)은 제출명령대상을 시대적 환경 및 기술의 발달 등을 고려하여 서류에서 자료로 변경하였고, 제출명령범위를 손해액 산정 이외에 침해의 증명에 필요한 자료까지 확대하였다. 특히 제출명령범위를 침해의 증명에 필요한 자료까지 확대한 것은 침해자인 피고에게 증명책임을 전환하는 것으로서, 신속하고 실체적 진실에 부합하는 재판을 진행하고자 하는 공익적 목적으로, 기존의 민사소송법의 일반적 문서제출의무³⁴⁷⁾를 침해사실의 증명에 적용한 규정이라고 할 수 있다. 이처럼 손해액 산정이 아닌 침해사실의 증명에 필요한 자료까지 제출하도록 하고, 그렇지 않으면 제재를 가하는 것은 실질적으로 실시자인 피고에게 증명책임을 전환한 것이라고 할 수 있다.³⁴⁹⁾³⁵⁰⁾

(2) 자료제출을 거부할 정당한 이유가 있는 경우

그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그 자료를 제출하지 아니할 수 있다(法 132①단서). 법원은 자료의 소지자가 제출을 거부할 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 자료의 제시를 명할 수 있다. 이 경우 법원은 그 자료를 다른 사람이 보게 하여서는 아니 된다(法 132②).

347) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다19925.

348) 민사소송법 제344조(문서의 제출의무) ① 다음 각 호의 경우에 문서를 가지고 있는 사람은 그 제출을 거부하지 못한다.

1. 당사자가 소송에서 인용한 문서를 가지고 있는 때
2. 신청자가 문서를 가지고 있는 사람에게 그것을 넘겨 달라고 하거나 보겠다고 요구할 수 있는 사법상의 권리를 가지고 있는 때
3. 문서가 신청자의 이익을 위하여 작성되었거나, 신청자와 문서를 가지고 있는 사람 사이의 법률관계에 관하여 작성된 것인 때. 다만 다음 각목의 사유 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

가. 제304조 내지 제306조에 규정된 사항이 적혀있는 문서로서 같은 조문들에 규정된 동의를 받지 아니한 문서

나. 문서를 가진 사람 또는 그와 제314조 각호 가운데 어느 하나의 관계에 있는 사람에 관하여 같은 조에서 규정된 사항이 적혀 있는 문서

다. 제315조제1항 각호에 규정된 사항중 어느 하나에 규정된 사항이 적혀 있고 비밀을 지킬 의무가 면제되지 아니한 문서

제347조(제출신청의 허가여부에 대한 재판) ① 법원은 문서제출신청에 정당한 이유가 있다고 인정할 때에는 결정으로 문서를 가진 사람에게 그 제출을 명할 수 있다.

제349조(당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효과) 당사자가 제347조제1항·제2항 및 제4항의 규정에 의한 명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 문서의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

349) 송대호, 특허법 일부개정법률안 검토보고서(원혜영의원 대표발의), 산업통상자원위원회, 2015.4. 14-16면.

350) 침해의 증명에 필요한 자료는 상대방의 실시 제품이나 실시 방법에 관하여 다툼이 있는 경우 실제 실시 제품이나 실시 방법에 관한 자료를 말하는 것이다. 또한 침해 주장 제품의 제조에 필요한 원료의 성분, 제조설비, 제조공정, 제조 완료된 제품에 관한 실험결과 등에 대한 자료도 포함될 수 있다(장현진, “자료 제출명령의 실무적 운영 방안”, 「특허소송연구」 제7집, 특허법원, 2017, 702면).

(3) 영업비밀이 포함된 경우

제출되어야 할 자료가 영업비밀(「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 영업비밀을 말한다. 이하 같다)에 해당하나 침해의 증명 또는 손해액의 산정에 반드시 필요한 때에는 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유로 보지 아니한다. 이 경우 법원은 제출 명령의 목적 내에서 열람할 수 있는 범위 또는 열람할 수 있는 사람을 지정하여야 한다(法 132③). 단순히 영업비밀에 속한다는 것을 정당한 이유로 본다면 이 규정의 실효성이 크게 감소되기 때문에 반드시 필요한 때에는 정당한 이유에 해당하지 아니한다. 한편 자료를 제출하는 당사자는 그 자료에 영업비밀이 포함되어있으면 열람범위와 열람자의 제한 또는 비밀유지명령제도(法 224의3)를 통해 보호받을 수 있다.

(4) 제 재

당사자가 정당한 이유 없이 자료제출명령에 따르지 아니한 때에는 법원은 자료의 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다. 이 경우 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(法 132④⑤).

참고자료 무역위원회의 불공정무역행위 조사를 통한 침해의 구제

1. 개요

불공정무역행위는 수출입거래 등에 있어서 일반적으로 요구되는 경쟁원리와 거래질서를 침해하여 경쟁상 대방 또는 소비자에게 불이익을 초래하는 무역행위를 의미한다. 우리나라는 “불공정무역행위 조사 및 산업 피해구제에 관한 법률”에 의하여 불공정무역행위를 금지(제4조 제1항)하고 있으며, 불공정무역행위로 인한 피해를 구제하기 위하여 산업통상자원부에 준사법적인 행정기관인 무역위원회를 설치하고 불공정무역행위 조사제도를 운영하고 있다.

2. 불공정무역행위의 유형

(1) 지식재산권 침해물품의 수출입 행위 등(제4조 제1항 제1호)

지식재산권을 침해하는 물품 등을 해외에서 국내에 공급하는 행위 또는 수입하거나 수입된 지식재산권 침해 물품 등을 국내에서 판매하는 행위, 지식재산권을 침해하는 물품 등을 수출하거나 수출을 목적으로 국내에서 제조하는 행위를 말한다. 지식재산권은 특허권·실용신안권·디자인권·상표권·저작권·저작인접권·프로그램저작권·반도체집적회로의 배치설계권이나 지리적 표시 또는 영업비밀을 모두 포함한다.

(2) 원산지표시 위반물품의 수출입 행위(제4조 제1항 2호)

원산지를 거짓으로 표시하거나 오인토록 표시한 물품, 원산지표시를 손상하거나 변경한 물품, 원산지 표시대상 물품인데 원산지표시를 하지 않은 물품 등을 수출하거나 수입하는 행위를 말한다.

(3) 허위·과장 표시물품의 수출입 행위(제4조 제1항 제3호)

품질 등을 거짓으로 표시하거나 과장하여 표시한 물품 등을 수출하거나 수입하는 행위를 말한다. 품질 등은 가격, 원재료·성분, 품질·성능·효능, 규격·용량·수량, 제조일자·유효기간, 제조방법, 제품의 특징, 제조자, 보증·품질사후관리, 용기·포장, 용도·사용방법·주의사항, 기타 거래내용·거래조건 등을 포함한다.

(4) 수출입질서 저해 행위(제4조 제1항 제4호)

수출입계약의 이행과 관련하여 계약내용과 현저하게 다른 물품 등의 수출입 또는 분쟁의 발생 등을 통하여 대한민국의 대외신용을 손상시켜 해당 지역에 대한 수출입에 지장을 주는 행위를 말한다.

3. 불공정무역행위 조사절차

(1) 조사신청

불공정무역행위 조사는 지식재산권 권리자, 원산지표시 위반물품 경쟁사업자 등 이해관계인이 아니라도 '누구든지' 신청할 수 있다. 다만 조사신청은 불공정무역행위가 있었던 날부터 1년 이내에 하여야 한다. 무역위원회는 불공정무역행위의 혐의가 있어 이를 조사할 필요가 있으면 직권으로 조사할 수도 있다.

(2) 조사개시 결정

무역위원회는 불공정무역행위의 혐의가 있다고 인정되는 경우에는 조사신청 후 20일 이내에 조사개시 여부를 결정하여야 한다.

(3) 잠정조치

회복할 수 없는 피해를 입고 있거나 입을 우려가 있는 자는 조사신청 후 판정 전이라도 무역위원회에 일정 금액의 담보를 제공하고 수출입 및 판매, 제조 등 불공정무역행위의 중지나 그 밖에 피해 예방조치를 하여 줄 것을 신청할 수 있다.

(4) 사건조사

불공정무역행위에 대한 조사는 서면조사를 원칙으로 하되, 필요한 경우에는 현지조사를 할 수 있다. 조사에 필요한 경우 조사단 구성, 질의서 송부, 외부전문가 감정, 자료제출명령, 기술설명회 개최 등도 가능하다. 또한 당사자 및 이해관계인이 조사의 원활한 진행에 협조하지 않는 경우에는 이용 가능한 자료에만 근거하여 조사판정할 수 있다. 피신청인의 영업중단, 소재불명 등으로 조사를 진행하기 어렵거나 관련 소송, 특허심판 등이 진행 중일 때는 조사를 중지할 수 있으며, 신청인이 조사신청을 철회하거나 조사중지 후 상당기간이 지났음에도 중지 사유가 해소되지 않으면 조사를 종결할 수 있다.

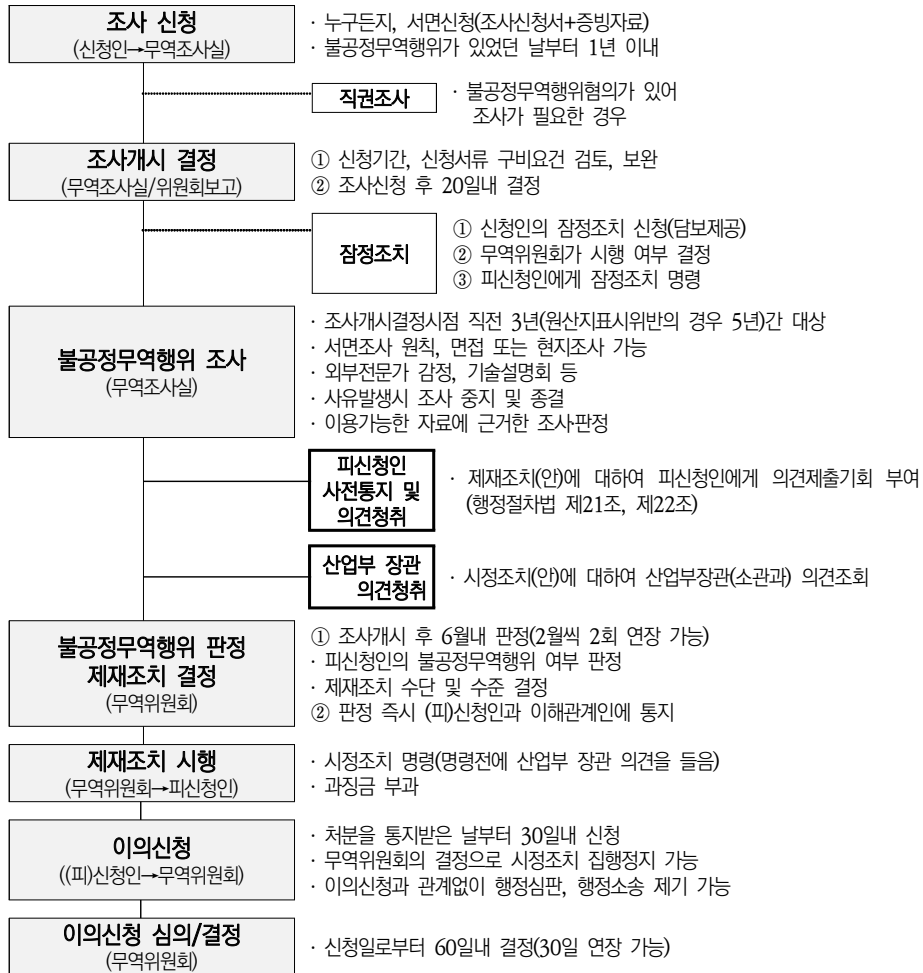
(5) 판정 및 처분

무역위원회는 조사개시 결정일부터 6개월 이내에 조사를 끝내고 판정하여야 한다. 다만 소송, 특허심판 등 관련 분쟁조정 절차가 진행 중이거나 신청인 또는 피신청인이 정당한 사유로 기간연장을 신청한 경우에는 2회 연장이 가능(각 회당 2개월 이내)하다. 무역위원회는 불공정무역행위로 판정한 경우에는 수출·수입·판매·제조행위의 중지, 반입배제 또는 폐기처분, 정정광고, 시정명령 받은 사실 공표 등의 시정조치 명령과 조사대상 기간 연평균 거래금액의 30%까지 과징금을 부과할 수 있다. 원산지표시 위반 불공정무역행위로 판정한 경우에는 3억원의 범위에서 조사대상 기간 5년간 수출입신고금액의 10%까지 과징금을 부과할 수 있다.

(6) 이의신청

무역위원회의 처분에 불복하는 경우에는 처분의 통지를 받은 날부터 30일 이내에 이의신청을 할 수 있으며, 무역위원회는 이의신청에 대하여 60일 이내에 결정한다. 다만 추가 조사가 필요한 경우 30일 연장할 수 있다. 이의신청을 한 자는 이의신청과 관계없이 행정심판법에 따른 행정심판이나 행정소송법에 따른 행정소송을 제기할 수 있다.

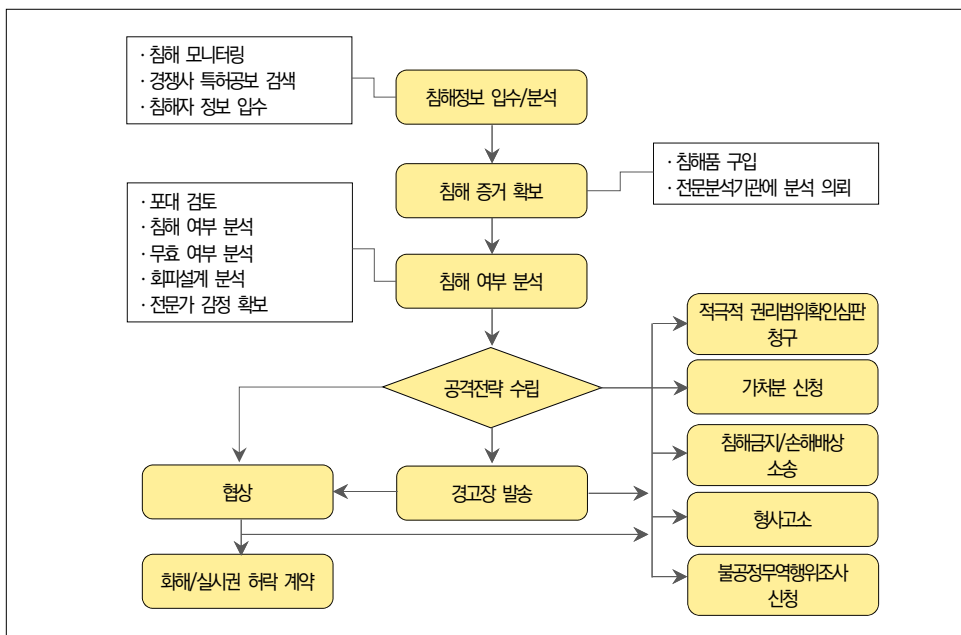
불공정무역행위 조사절차



제6절 침해주장에 대한 대응방안

I. 서 설

특허권의 존속 중 정당한 권원 없는 자가 업으로서 특허발명의 보호범위에 속하는 확인대상 발명을 실시하면 특허권의 침해가 되며, 특허권자는 민·형사상 제재를 할 수 있다. 그러나 특허권자 등의 권리행사가 항상 적법한 것은 아니기 때문에 특허권자로부터 권리의 대항을 받은 제3자(실시자)는 특허권자의 권리행사가 적법한지 판단을 한 후 이에 상응하는 대응방안을 마련하여야 한다.



【그림 6-16】 특허침해시 대응절차

II. 침해 여부 및 특허 유효성의 검토

침해의 대항을 받는 자는 구체적 방어수단을 마련하기 이전에 침해주장 사실의 진위를 먼저 파악하여야 한다. 구체적으로 특허권이 유효한지, 확인대상발명의 실시가 침해의 성립요건을 만족하는지, 특허권자의 권리행사가 남용에 해당하는지 여부 등을 검토하여 그에 상응하는 대응을 하여야 한다.

III. 특허권의 흠결 유무에 따른 조치

1. 특허취소신청, 특허무효심판청구

제3자는 먼저 등록공고 및 등록원부 등을 찾아 진정한 권리자에 의하여 현재 특허권이 유효하게 존속하고 있는지 검토하여야 한다. 검토 결과 특허권에 흠결이 있으면 특허취소신청이나 특허무효심판을 청구할 수 있다. 그러나 등록주의를 관철시켜 법적 안정성을 도모하기 위하여 일단 설정등록에 의하여 특허권이 발생한 이상 특허요건의 흠결이 있다고 할지라도 특허취소신청에 의한 취소결정이나 특허무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전까지는 특허권은 존속 중인 것으로 본다.

2. 소송절차의 중지 신청

특허취소신청이나 특허무효심판청구를 한 경우 결정이나 심결이 확정될 때까지 침해소송절차를 중지해 줄 것을 법원에 신청할 수 있다. 다만 소송절차중지 여부는 법관의 재량사항이다.

IV. 특허권의 침해 여부에 따른 조치

1. 침해주장이 부당한 경우의 조치

(1) 소송에서 의견서 제출 및 상대방에 대한 답변서 회신

제3자는 i) 특허발명의 실시 또는 간접침해행위가 아니거나, ii) 정당한 권원(실시권, 권리소진)이 있거나, iii) 업으로서의 실시가 아니거나, iv) 법률의 제한(法 81의3④, 96, 181), v) 자유기술, vi) 특허권의 하자로 인한 권리범위 불인정 등에 해당하므로 침해가 아니라는 의견을 소송 중인 법원에 제출할 수 있다. 이때 필요하다면 감정서를 첨부할 수 있으며 해당 의견서와 같은 취지의 답변서를 상대방인 특허권자에게 회신할 수 있다. 또한 진보성 위반이 명백하고 특별한 사정이 없다면 권리남용에 해당하므로 권리행사가 인정되어서는 아니 된다는 항변을 할 수도 있다.³⁵¹⁾

(2) 소극적 권리범위확인심판 청구

제3자는 특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 특허심판원에 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.³⁵²⁾ 다만 권리범위확인심판의 심결은 법원에 유력한 증거로써 활용될 수 있으나 법원을 기속하지 못한다.

(3) 확인의 소 제기

제3자는 특허권자가 제기한 침해소송과는 별도로 선사용권존재 확인의 소, 침해금지청구권 부존재 확인의 소, 손해배상채무부존재 확인의 소 등을 법원에 제기할 수 있다.

351) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390.

352) 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328.

2. 침해주장이 정당한 경우의 조치

(1) 실시의 중지

제3자는 자기의 실시가 특허권의 침해라고 판단되면 그 물품의 제조·판매나 사용 등을 즉시 중지하고 선의·무과실을 주장하는 것이 현명하다.

(2) 정당한 권원의 획득 후 실시

특허권의 침해가 됨에도 불구하고 계속 실시를 원할 때는 특허권자로부터 정당한 권원을 획득하여야 한다. 따라서 제3자는 특허권자로부터 특허제품을 구매하여 실시하거나 전용실시권을 설정 또는 통상실시권을 허락받아서 실시하여야 한다. 한편 제3자가 이용·저촉발명을 실시하고 있는 경우 선출원권리자가 실시 허락을 하지 않으면 통상실시권허락심판의 청구를 고려해볼 수 있다.

(3) 화해·중재

제3자는 침해소송이 계속 중이면 원고인 특허권자와 화해³⁵³⁾·중재³⁵⁴⁾ 등을 통해 원만한 해결을 보는 것이 바람직할 수 있다. 한편 특허권의 침해로 인하여 발생된 분쟁 등이 있는 경우에 산업재산권분쟁조정위원회에 조정신청을 할 수 있으며, 여기에서 조정이 성립되어 조정조서가 작성되는 경우에도 재판상 화해와 동일한 효력을 갖는다(發振法 46). 조정은 소송과 비교하여 비용이 저렴하고 간이, 신속하게 처리될 수 있는 이점이 있으며 일도양단적인 분쟁해결이 아니라 당사자의 양보와 합의를 필요로 한다는 점에서 소송과 다른 특성이 있다.

(4) 회피설계

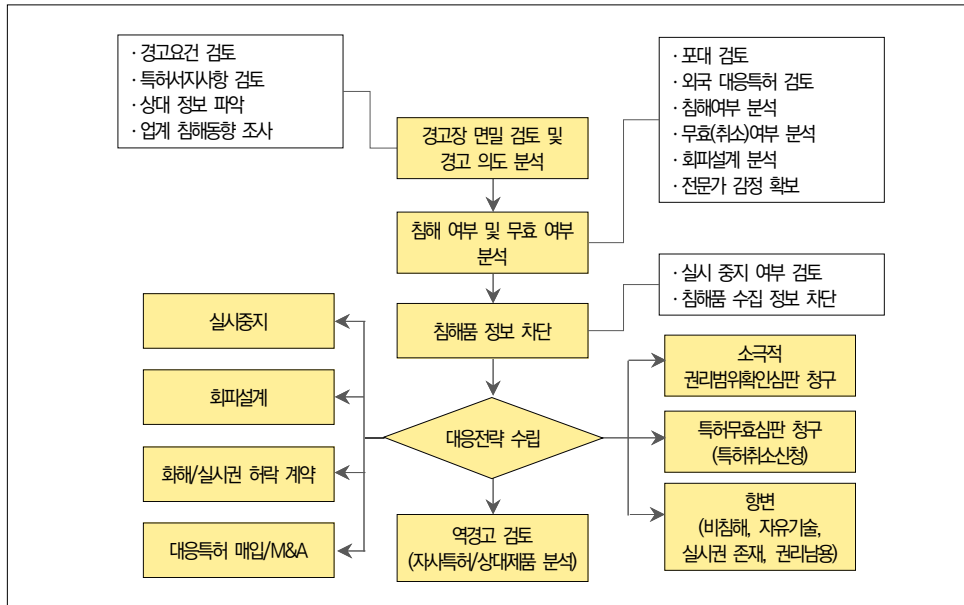
제3자는 특허권의 침해라고 판단되면 회피설계(design-around)를 고려해 볼 수 있다. 회피설계할 때는 특허발명의 균등범위를 벗어날 수 있도록 주의하여야 한다. 다만 회피설계에 필요한 시간, 생산설비의 교체, 연구원의 노력 등에 대한 비용 등과 특허권자로부터 실시권을 허락받을 때 소요되는 비용 등을 비교하여 회피설계하는데 비용이 더 많이 든다고 판단되면 실시권을 허락받는 것이 타당하다.

(5) 대응특허 매입 등

대응특허를 매입하거나 대응특허를 소유한 회사를 M&A하는 것을 고려해 볼 수 있다. 대응특허를 매입하여 특허권자가 생산, 판매하고 있는 제품에 대한 침해를 주장함으로써 침해에 대한 분쟁에서 상호 간의 화해를 끌어낼 수 있다.

353) 「화해」는 제소 전 화해와 소송상 화해가 있는데, 화해조서가 작성되면 그 조서는 확정판결과 동일한 효력을 갖는다(民訴法 220).

354) 「중재」란 분쟁해결을 법원의 판결에 의하지 아니하고 제3자인 중재인의 판정에 의하는 것으로서, 그 사건에 대한 중재인의 판정은 법원의 확정판결과 동일한 효력을 갖는다. 지식재산처에서는 분쟁의 조정을 위하여 산업재산권분쟁조정위원회를 운영하고 있다.



【그림 6-17】 경고장 수령시 제3자의 대응방안

제7절 그 밖의 벌칙

제226조 【비밀누설죄 등】

- ① 지식재산처 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원이었던 사람이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2021. 4. 20.>
- ② 전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2021. 4. 20.>

[전문개정 2014. 6. 11.]

제226조의2 【전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제】

- ① 제58조제2항에 따른 전문기관 또는 제58조제3항에 따른 전담기관의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 제226조 제1항을 적용하는 경우에는 지식재산처 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다. <개정 2016. 12. 2., 2018. 4. 17., 2021. 4. 20., 2024. 2. 6.>
- ② 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다. <신설 2021. 4. 20.>

[전문개정 2014. 6. 11.]

제227조 【위증죄】

- ① 이 법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓으로 진술·감정 또는 통역을 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2017.3.21.>
- ② 제1항에 따른 죄를 범한 자가 그 사건의 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결이 확정되기 전에 자수한 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제228조 【허위표시의 죄】

제224조를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2017.3.21.>

[전문개정 2014.6.11.]

제229조 【거짓행위의 죄】

거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권의 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2017.3.21.>

[전문개정 2014.6.11.]

제229조의2 【비밀유지명령 위반죄】

- ① 국내외에서 정당한 사유 없이 제224조의3제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 제1항의 죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다.

[본조신설 2011.12.2.]

제229조의3 【외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령 위반죄】

제41조제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다.

[본조신설 2025. 1. 21.]

제230조 【양벌규정】

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 제225조제1항, 제228조, 제229조 또는 제229조의3의 어느 하나에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을, 그 개인에게는 해당 조문의 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2025. 1. 21.>

1. 제225조제1항의 경우: 3억원 이하의 벌금
2. 제228조 또는 제229조의 경우: 6천만원 이하의 벌금
3. 제229조의3의 경우: 1억원 이하의 벌금

[전문개정 2014.6.11.]

제232조 【과태료】

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 50만원 이하의 과태료를 부과한다.
 1. 「민사소송법」 제299조제2항 및 같은 법 제367조에 따라 선서를 한 자로서 특허심판원에 대하여 거짓 진술을 한 자
 2. 특허심판원으로부터 증거조사 또는 증거보전에 관하여 서류나 그 밖의 물건 제출 또는 제시의 명령을 받은 자로서 정당한 이유 없이 그 명령에 따르지 아니한 자
 3. 특허심판원으로부터 증인·감정인 또는 통역인으로 소환된 자로서 정당한 이유 없이 소환에 따르지 아니하거나 선서·진술·증언·감정 또는 통역을 거부한 자
- ② 제1항에 따른 과태료는 대통령령으로 정하는 바에 따라 지식재산처장이 부과·징수한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

특허제도의 효율적인 운영을 위해서는 특허권자의 보호를 위한 형사적인 제재방법 외에도 특허권 전반에 걸쳐 발생할 수 있는 불합리에 대한 방지책이 마련되어야 한다. 이러한 이유로

특허법 내에 소위 질서벌의 성격으로서의 특허침해죄(法 225), 비밀누설죄(法 226, 226의2), 위증죄(法 227), 허위표시의 죄(法 228), 거짓행위의 죄(法 229), 양벌규정(法 230) 및 몰수(法 231) 규정을 두고 있으며, 행정벌의 성격으로서 과태료(法 232)에 관한 규정을 두고 있다. 특허침해죄(法 225) 및 몰수(法 231) 규정에 대해서는 상술하였으므로 이하에서는 나머지 부분에 대해서 살펴보도록 한다.

II. 비밀누설죄

1. 지식재산처 직원 등

지식재산처 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원이었던 사람이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(法 226①). 제58조제2항에 따른 전문기관 또는 제58조제3항에 따른 전담기관의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 제226조제1항을 적용하는 경우에는 지식재산처 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다(法 226의2①). 미공개 출원의 경우 공개 전까지는 출원인의 영업비밀에 속하는 것으로 볼 수 있고, 산업기술의 유출에 따른 경제적 파급효과 및 국익보호의 측면이 강조될 필요가 있다는 점에서 비밀유지의무 위반자에 대하여 엄중한 처벌을 규정하고 있다.³⁵⁵⁾ 본 죄는 비친고죄이며, 양벌규정이 적용되지 아니한다.

2. 전문심리위원

전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다(法 226②). 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정³⁵⁶⁾을 적용할 때에는 공무원으로 본다(法 226의2②). 본 죄는 비친고죄이며, 양벌규정이 적용되지 아니한다.³⁵⁷⁾

355) 산업기술과 관련하여 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」상 비밀누설죄의 경우 5년 이하의 징역 또는 재산상 이익액의 2배 이상 10배 이하에 상당하는 벌금에 처하도록 하고 있고, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」상 비밀누설죄의 경우 5년 이하의 징역이나 10년 이하의 자격정지 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하도록 하여 엄중한 처벌을 가하도록 하고 있다.

356) 제129조(수뢰, 사전수뢰) ①공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.

②공무원 또는 중재인이 될 자가 그 담당할 직무에 관하여 청탁을 받고 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 후 공무원 또는 중재인이 된 때에는 3년 이하의 징역 또는 7년 이하의 자격정지에 처한다.

제130조(제삼자뇌물제공) 공무원 또는 중재인이 그 직무에 관하여 부정한 청탁을 받고 제3자에게 뇌물을 공여하게 하거나 공여를 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.

제131조(수뢰후부정청사, 사후수뢰) ①공무원 또는 중재인이 전2조의 죄를 범하여 부정한 행위를 한 때에는 1년 이상의 유기징역에 처한다.

②공무원 또는 중재인이 그 직무상 부정한 행위를 한 후 뇌물을 수수, 요구 또는 약속하거나 제삼자에게 이를 공여하게 하거나 공여를 요구 또는 약속한 때에도 전항의 형과 같다.

③공무원 또는 중재인이었던 자가 그 재직 중에 청탁을 받고 직무상 부정한 행위를 한 후 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 5년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지에 처한다.

④전3항의 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다.

제132조(알선수뢰) 공무원이 그 지위를 이용하여 다른 공무원의 직무에 속한 사항의 알선에 관하여 뇌물을 수수, 요구 또는 약속한 때에는 3년 이하의 징역 또는 7년 이하의 자격정지에 처한다.

III. 위증죄

이 법에 따라 선서한 증인, 감정인 또는 통역인이 특허심판원에 대하여 거짓으로 진술·감정 또는 통역을 한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(法 227①). 다만 위증죄를 범한 자가 그 사건의 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결이 확정되기 전에 자수한 경우에는 그 형을 감경 또는 면제할 수 있다(法 227②). 위증죄의 주체는 「선서」한 증인·감정인 또는 통역인으로서, 범죄행위는 특허심판에 대하여 허위의 진술·감정 또는 통역을 하는 것이다. 한편 본 죄는 비친고죄이며, 양벌규정이 적용되지 아니한다.

IV. 허위표시죄

1. 의 의

허위표시의 금지(法 224)에 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(法 228). 본 죄는 특허제품 또는 특허방법이 아닌 것에 특허표시, 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 함으로써 특허에 대한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인케 하는 행위를 처벌하려는 규정으로써 그 보호법익은 사회의 거래안전이라고 할 수 있다. 본 죄는 비친고죄이며, 양벌규정이 적용된다.

2. 허위표시의 유형

1) 「허위표시」란 특허된 것이 아닌 물건이나 특허출원 중이 아닌 물건 등에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 것을 말하는 것으로서 특허법에 규정된 허위표시의 유형은 다음과 같은 행위를 말한다(法 224).

- i) 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
- ii) i)의 표시를 한 것을 양도·대여 또는 전시하는 행위
- iii) i)의 물건을 생산·사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
- iv) 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법을 사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위

2) 다만 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 통상의 기술자가 보통 채용하는 정도로 기술적

357) 실용신안법은 전문심리위원과 관련된 벌칙 규정을 두고 있지 않고, 입법불비라고 여겨진다.

구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 허위표시행위에 해당한다고 볼 수 없다.³⁵⁸⁾

V. 거짓행위죄

1. 의 의

거짓이나 그 밖의 부정한 행위로 특허, 특허권 존속기간의 연장등록, 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(法 229). 본 죄는 특허출원심사 또는 심판의 과정에서 기만적 방법을 사용하여 특허 또는 심결이나 판결을 받는 것과 같은 국가적 법익을 침해하는 행위를 처벌하려는 규정이다. 따라서 본 죄는 비친고죄이며 양벌규정이 적용된다.

2. 거짓행위의 의미

1) 「거짓행위」란 심사, 취소신청 또는 심판의 과정에서 허위의 자료나 위조된 자료를 제출하여 심사관 또는 심판관을 착오에 빠뜨려 특허요건을 결한 발명에 대하여 특허권을 받거나 자기에 유리한 결정, 심결을 받는 행위를 말한다.³⁵⁹⁾ 사기에 한하지 않고 부정행위 일체를 포함한다. 거짓의 방법은 허위자료의 제출 등 적극적인 행위가 있어야 한다는 견해도 있으나 부작위의 경우까지를 포함한다고 봄이 일반적 견해이다.

2) 거짓의 방법에 의하여 자기에 유리한 심결을 받지 못하고 불리한 심결을 받은 경우도 본 죄를 구성한다는 견해가 있으나, 심사단계에서 거짓의 행위에 의하더라도 특허권을 받지 못한 경우(특허거절결정)는 처벌하지 아니하는 것에 비추어 생각하면 자기에 불리한 심결을 받는 경우는 본 죄를 구성하지 아니한다고 본다.

VI. 비밀유지명령 위반죄

국내외에서 정당한 사유 없이 제224조의3 제1항에 따른 비밀유지명령을 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. 비밀유지명령 위반죄는 비밀유지명령을 신청한 자의 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없다(法 229의2). 이는 민사소송 절차에서 생산되거나 교환된 비밀정보의 보호에 관한 사법명령의 위반에 대하여 사법당국이 제재를 부과할 수

358) 대법원 2015. 8. 13. 선고 2013도10265.

359) 소외인 명의의 시험성적서를 마치 피고인의 것인 양 지식재산처에 제출하는 등의 행위를 하여 위 소외인이 특허를 받을 수 있는 권리를 피고인 자신이 발명한 것처럼 모인하여 특허를 받았다면 피고인의 행위는 거짓의 행위로서 특허권을 받은 경우에 해당한다(대법원 1983. 12. 27. 선고 82도3238).

있는 권한을 규정한 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환」을 반영한 것이다.

VII. 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀유지명령 위반죄

외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령을 위반한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다(法 229의3). 본 죄는 비친고죄이며, 양벌규정이 적용된다. 2025. 7. 22. 시행되는 개정법(법률 제20700호, 2025. 1. 21. 일부개정)에서는 i) 국방상 중요한 기술 등이 해외유출되는 것을 방지하기 위한 실효적인 조치로서 처벌 규정을 도입할 필요가 있다는 점, ii) 미국, 일본, 독일 등 주요국가에서는 위와 같은 비밀취급명령 등을 위반한 자를 형사처벌하고 있어 이를 참고할 필요가 있다는 점을 고려하여 형사처벌에 대한 규정을 신설하였다.

VIII. 양벌규정

1) 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인, 그 밖의 종업원³⁶⁰⁾이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 침해죄(法 225①), 허위표시죄(法 228), 거짓행위죄(法 229) 또는 외국에의 특허출원 금지/비밀유지명령 위반죄(法 229의3)에 위반행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인에는 다음에 해당하는 벌금형을, 그 개인에게는 각 해당 조문의 벌금형을 과한다. 다만 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위해 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다(法 230).

i) 침해죄에 해당하는 경우에는 3억원 이하의 벌금형

ii) 허위표시죄(法 228), 거짓행위죄(法 229)에 해당하는 경우에는 6천만원 이하의 벌금형

iii) 외국에의 특허출원 금지/비밀유지명령 위반죄(法 229의3)에 해당하는 경우에는 1억원 이하의 벌금형

2) 양벌규정은 기업체의 종업원이 그 기업체의 업무와 관련하여 특허권의 침해행위 등을 범하는 경우가 적지 아니함을 고려하여 실효성 있는 범죄행위의 방지를 위해 규정된 것이다. 양벌규정이 적용되기 위해서는 종업원 등이 업무에 관하여 위반행위를 하여야 하는데, 여기서 「업무」는 본래의 업무를 수행하기 위하여 행하여진 행위일 필요는 없고, 업무와 관련하여 행하여진 행위이면 충분하다. 예컨대 법인 또는 개인의 대리인의 경우, 그 범죄행위가 대리의 목적을 달성하기 위한 행위로써 본인의 업무에 관한 것이면 충분하고, 대리권의 범위일 필요는 없다.

3) 한편 2008. 12. 26. 시행된 현행법(법률 제9249호, 2008. 12. 26. 개정)에서는 법인 또는 개인이 그 위반행위를 방지하기 위해 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리

360) 사용인 그 밖의 종업원이란 업무주체인 법인 또는 자연인과의 고용계약에 의하여 노무를 제공하는 자를 말한다.

하지 아니한 경우에는 양벌규정의 적용을 배제함으로써 사용자 면책 조항을 합리적으로 조정하고 있다. 이는 헌법재판소³⁶¹⁾에서 종업원 등의 범죄행위에 대한 법인 등의 선임감독상의 과실 유무와 무관하게 법인 등을 처벌하는 것은 다른 사람의 범죄에 대해 그 책임 유무를 묻지 않고 형벌을 부과하는 결과가 되어 형사법의 기본원리인 「책임 없는 자에게 형벌을 부과할 수 없다」라는 책임주의에 반한다는 결정을 하였기 때문이다.

IX. 과태료

1. 의 의

「과태료」는 행정상의 질서위반자에 대하여 과하는 행정벌(行政罰)이며 형법상의 형벌이 아니다.³⁶²⁾ 특허법은 일정한 행위를 한 자에게 과태료에 처하고, 대통령령으로 정하는 바에 따라 지식재산처장이 과태료를 부과·징수하고 있다(法 232).

2. 대 상

다음에 해당하는 자는 50만원 이하의 과태료에 처한다(法 232①).

- i) 「민사소송법」 제299조제2항 및 같은 제367조에 따라 선서를 한 자로서 특허심판원에 대하여 거짓 진술을 한 자
- ii) 특허심판원으로부터 증거조사 또는 증거보전에 관하여 서류나 그 밖의 물건 제출 또는 제시의 명령을 받은 자로서 정당한 이유 없이 그 명령에 따르지 아니한 자
- iii) 특허심판원으로부터 증인·감정인 또는 통역인으로 소환된 자로서 정당한 이유 없이 소환에 따르지 아니하거나 선서·진술·증언·감정 또는 통역을 거부한 자

361) 헌법재판소 2007. 11. 29. 선고 2005헌가10.

362) 행정법상의 의무위반행위에 대하여 일반공권력에 근거하여 일반사인에 대한 제재로서 과해진 벌을 「행정벌」이라고 하고, 그중 형법에 정해진 형벌을 과하는 경우를 「행정형벌」이라고 하며, 형벌이 아닌 제재로서 과태료라고 하는 금전벌을 과하는 경우를 행정상의 「질서벌」이라고 하는데, 과태료는 질서벌의 일종이고 형벌은 아니다.

【표 6-11】 벌칙의 구별

죄 명	구성요건	처 벌		반의사 불벌죄	친고죄	양벌 규정	비 고
		징역/금고	벌금				
침해죄 (法 225)	특허권 또는 전용실시권을 침해 한자	7년이하 징역	1억원 이하	○	×	○	몰수* · 교부
비밀누설죄 (法 226, 226의2)	지식재산처 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원(전문기관 또는 전담기관의 임직원이거나 임직 원이었던 사람 포함)이었던 사 람이 특허출원 중인 발명(국제 출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우	5년이하 징역	5천만원 이하	×	×	×	
	전문심리위원 또는 전문심리위 원이었던 자가 그 직무수행 중 에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우	2년이하 징역/ 금고	1천만원 이하	×	×	×	
위증죄 (法 227)	이 법에 따라 선서한 증인·감 정인 또는 통역인이 특허심판원 에 대하여 허위의 진술·감정 또는 통역을 한 경우	5년이하 징역	5천만원 이하	×	×	×	특허취소신청 에 대한 결정 또는 심결 확정전 자수시 감정·면제
허위표시죄 (法 228)	허위표시의 금지(法 224)에 위 반한 자	3년이하 징역	3천만원 이하	×	×	○	
거짓행위죄 (法 229)	거짓이나 그 밖의 부정한 행위 로써 특허, 특허권 존속기간의 연장등록 특허취소신청에 대한 결정 또는 심결을 받은 자	3년이하 징역	3천만원 이하	×	×	○	
비밀유지명령 위반죄 (法 229의2)	국내외에서 정당한 사유 없이 제224조의3제1항에 따른 비밀 유지명령을 위반한 자	5년이하 징역	5천만원 이하	×	○	×	
외국에의 특허출원 금지/ 비밀취급명령 위반죄 (法 229의3)	제41조제1항에 따른 외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명 령을 위반한 자	5년이하 징역	5천만원 이하	×	×	○	×

* 특허법은 필요적 몰수, 실용신안법은 임의적 몰수

제4장

특허권의 변동 등

제1절 특허권의 이전 및 공유

제1관 특허권의 이전

제99조 【특허권의 이전 및 공유 등】

- ① 특허권은 이전할 수 있다.
- ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.
- ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.
- ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제99조의2 【특허권의 이전청구】

- ① 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다.
- ② 제1항의 청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 다음 각 호의 권리는 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다.
 1. 해당 특허권
 2. 제65조제2항에 따른 보상금 지급 청구권
 3. 제207조제4항에 따른 보상금 지급 청구권
- ③ 제1항의 청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다.

[본조신설 2016.2.29.]

I. 서 설

1. 의 의

「특허권의 이전」이란 특허권의 주체인 특허권자를 변경하는 것을 말한다. 특허권의 이전은 주체의 변경으로서 상대적 소멸이라는 점에서 특허권이 절대적으로 소멸하는 무효심결의 확정 또는 특허권의 포기 등과 구별된다.

2. 취 지

특허법은 특허권의 재산권적 성질을 인정하여 특허권의 이전을 허용하고 있다. 따라서 특허권자는 특허권을 실시할 수 없거나 특허권을 통해 이익을 얻고자 하는 경우 특허권을 이전할 수 있다.

II. 이전의 유형

1. 특정승계와 일반승계

특허권의 이전, 즉 이전적 승계는 매매·증여 등과 같이 개개의 권리가 개개의 취득원인에 의하여 취득되는 「특정승계」와 상속·포괄유증·회사의 합병 등과 같이 하나의 취득원인에 의하여 다수의 권리가 일괄해서 취득되는 「일반승계」로 나뉜다. 특정승계와 일반승계는 후술하는 바와 같이 이전의 효력발생시기에 차이가 있다.

2. 전부이전과 일부이전

특허권자는 특허권 전부를 이전할 수 있을 뿐만 아니라 특허권의 지분 일부를 이전할 수 있다. 다만 청구범위가 다항으로 되어 있는 경우에 그중 일부인 어느 하나의 청구항만을 이전할 수 있는지 문제이다. i) 특허법상 특허권은 복수의 청구항 모두를 일체로 하여 부여되는 것이고 ii) 청구항마다 특허권이 있는 것으로 본다고 규정하고 있는 제215조의 대상에서 제99조제1항이 제외되어 있고 iii) 일부 청구항의 이전을 허용한다면 실시상의 권리충돌로 인하여 법적 안정성을 해치게 되며, iv) 실무상으로도 특허권의 설정등록 후에는 특허의 정정의 대상이 될 뿐이고 분할 및 보정이 인정되지 않으므로, 일부 청구항의 이전은 인정되지 아니한다고 함이 타당하다.

III. 이전의 절차

1. 신청에 의한 이전

특허권을 이전하려는 자는 이전등록신청서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(登錄令 20 ①). 이전등록 신청은 등록권리자와 등록의무자가 공동으로 신청함을 원칙으로 한다. 다만 등록의무자의 승낙서를 첨부하거나 판결 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 등록권리자 단독으로 이전등록신청을 할 수 있다(登錄令 15).

2. 직권 또는 촉탁에 의한 이전

지식재산처장은 특허권 수용의 경우 직권으로 등록하며, 일정한 경우 법원 등의 촉탁에 의하여 등록한다(登錄令 13).

IV. 이전의 효과

1. 이전의 효력발생

(1) 특정승계의 경우

특허권의 이전은 특허등록원부에 등록하여야만 효력이 발생한다(法 101①I). 즉 이전등록은 특허권 이전의 효력발생요건이다. 공시의 원칙에 기한 결과이지만 공신(公信)의 원칙은 성립하지 아니한다. 다만 공시의 원칙에 의하여 등록사항이 진실한 권리관계와 일치한다는 추정이 될 뿐이다.

(2) 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우

상속 또는 회사의 합병 등의 경우에 사망 또는 합병 등의 사실이 있으면 권리는 당연히 상속인 또는 흡수법인에 포괄적으로 이전되어 버리므로 그것만으로 권리이전의 효력이 발생한다. 이는 특정승계와 같이 등록이 있어야 권리변동이 생긴다면 상속이나 그 밖의 일반승계부터 등록이 될 때까지 권리자가 없는 공백상태로 되는 것을 방지하기 위함이다. 다만 상속인이나 그 밖의 일반승계인은 지체없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다(法 101②).

2. 절차의 효력 승계 및 절차의 속행

특허권 또는 특허에 관한 권리에 관하여 밟는 절차의 효력은 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에게 미치며(法 18), 지식재산처장 또는 심판장은 특허에 관한 절차가 지식재산처 또는 특허심판원에 계속 중일 때 특허권 또는 특허에 관한 권리가 이전되면 그 특허권 또는 특허에 관한 권리의 승계인에 대하여 그 절차를 속행하게 할 수 있다(法 19).

V. 관련문제

1. 특허권의 이전과 실시권, 질권의 부속성

특허권의 이전은 주체의 변경이기 때문에 특허권이 이전되더라도 그에 존재하는 부수적인 권리인 실시권, 질권 등은 소멸하지 아니한다. 오히려 실시권자 또는 질권자가 먼저 등록한 경우에는 새로운 특허권자에 대해서도 실시권 또는 질권의 효력을 주장할 수 있다(法 101, 118). 그러나 특허권이 수용된 경우에는 그에 부수적인 권리는 모두 소멸한다(法 106②).

【표 6-12】 특허권의 이전에 따른 부수적 권리(실시권, 질권)의 취급

구 분	내 용	비 고
원 칙	■ 부수적인 권리는 소멸하지 아니함 ■ 특허권의 이전등록 전에 미리 등록을 하였다면 새로운 특허권자에게 효력 주장 가능	■ 제122조의 법정실시권자는 전 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)에 한하며 부수적인 권리자는 법정실시권을 갖지 아니하여도 됨
예 외	■ 특허권이 수용된 경우 부수적인 권리의 소멸(法 106②)	■ 실시권자는 보상받을 수 있으나(法 106③), 질권자는 물상대위(法 123) 가능하므로 보상받지 못함

2. 특허권의 이전청구와 법정실시권

(1) 이전청구

i) 제33조제1항 본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 ii) 제44조의 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있다(法 99의2①).

(2) 권리의 귀속시기

특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 법원에의 이전청구(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전청구)에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 해당 특허권과 보상금청구권(法 65②, 207④)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 본다(法 99의2②).³⁶³⁾ 이는 특허권을 취득할 수 있었던 자는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자이고, 해당 특허발명이 공개됨에 따라 산업발달에 이미 기여하였다는 점에서 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 권리의 행사를 처음부터 인정함이 타당하기 때문이다. 따라서 前 특허권자가 특허권, 보상금청구권의 행사를 통해 받은 이익은 부당이득으로 이전등록된 특허권자에게 반환해야 할 대상이 될 것이다. 또한 이전등록이 있기 전의 前 특허권자가 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락한 것도 무효로 될 것이나 일정한 경우 후술하는 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권(法 103의2)에 의하여 실시권자의 보호가 가능하다.

(3) 권리가 공유인 경우

이전청구에 따라 공유인 특허권의 지분을 이전하는 경우에 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받아야만 지분을 양도할 수 있다는 제99조제2항에도 불구하고 다른 공유자의 동의를 받지 아니하더라도 그 지분을 이전할 수 있다(法 99의2③).

(4) 무효사유에서 제외

이전청구에 기초하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록(法 99의2)이 있으면 이전등록된 특허권(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)은 특허무효심판을 청구할 수 있는 대상에서 제외된다(法 133①Ⅱ단서). 이는 이전청구에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록된 특허권이 애초에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 출원이 아니라는 점을 이유로 무효로 되는 것을 방지하기 위함이다.

(5) 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권

1) 다음의 어느 하나에 해당하는 자가 특허권의 이전청구에 기초하여 특허권의 이전등록이

363) 한편 지식재산청장은 이전청구에 따라 특허권이 이전등록된 경우에는 새로운 특허증을 발급하여야 한다(法 86③).

있기 전에(法 99의2②) 해당 특허가 i) 제33조제1항 본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 ii) 제44조의 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인때 공동출원하지 아니하여 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 유상의 통상실시권을 가진다(法 103의2).

i) 이전등록된 특허의 원(原)특허권자

ii) 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자(다만 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다)

2) 이는 자신의 등록이 적법한 것으로 믿는 선의의 무권리자를 보호하는 한편 그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비가 산업발전에 이바지라는 법 목적에 비추어 보호해 줄 가치가 있으며, 또한 정당한 권리자가 별도의 특허출원(法 35)을 하여 특허권을 획득하였을 때 선의의 무권리자에게 인정되는 중용권(法 104)과의 형평성을 고려한 것이다.

3. 질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권

특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 122).

제2관 특허권의 공유

제99조 【특허권의 이전 및 공유 등】

- ① 특허권은 이전할 수 있다.
- ② 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.
- ③ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 그 특허발명을 자신이 실시할 수 있다.
- ④ 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의의 및 취지

「특허권의 공유」란 하나의 특허권을 2명 이상이 지분에 의하여 공동으로 소유하는 것을 말한다. 특허권의 객체인 발명은 무형인 기술적 사상의 창작으로서 점유를 수반하지 않으므로 특허발명을 수인이 동시에 실시할 수 있는 등 유체재산권과는 다른 특수성을 지니고 있다. 특허권의 공유에 관하여는 민법의 공유규정이 준용되지만, 이러한 특허권의 특수성을 고려하여 민법의 규정과는 다른 특별한 규정(法 99②③④)을 두어 공유 특허권자의 보호에 적정을 도모하고 있다.

2. 법적성질

특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있고 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락하는 등 일정한 제약을 받아 그 범위에서 합유와 유사한 성질을 가지지만, 이러한 제약은 특허권이 무체재산권인 특수성에서 유래한 것으로 보일 뿐이고, 특허권의 공유자들이 반드시 공동목적이나 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 특허권을 소유한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 특허법에 특허권의 공유를 합유관계로 본다는 명문의 규정도 없는 이상, 특허권의 공유에도 특허법의 다른 규정이나 그 본질에 반하지 아니하는 범위에서는 민법상의 공유 규정이 적용될 수 있다고 할 것이다.³⁶⁴⁾³⁶⁵⁾

II. 공유관계의 생성

공동발명이라는 하나의 객체에 대하여 등록 전에는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유로서, 등록 후에는 특허권의 공유로서 보호를 하고 있다. 특허권의 공유관계는 i) 공동발명하여 공동출원에 의한 경우, 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 이전 등과 같이 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 그대로 등록된 경우와 ii) 질권에 의한 특허권 지분의 경락, 특허권의 일부 이전 등과 같이 등록 후 특허권의 공유가 된 경우가 있다.

364) 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567. 기존의 대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111, 97다41298에서는 “특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 타 공유자의 동의없이 그 지분을 양도 또는 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없으며 그 특허권에 대하여 전용실시권 또는 통상실시권을 허락할 수 없다고 규정하고 있으므로 특허의 공유관계는 민법 제293조에 규정된 합유에 준하는 것이라 할 것이다”라고 판시하고 있다. 다만 이는 특허권의 공유관계 전체를 민법상 합유에 준하는 것으로 보는 것이 아니라, 제99조제2항 및 제4항의 내용만이 민법상 합유에 준한다고 보는 것으로 해석된다.

365) 민법상 공유·합유와 특허법상 공동발명자간의 권리관계를 비교하면 다음과 같다(정차호·이문옥, “공동발명자 결정방법 및 관련 권리의 연구”, 지적재산21, 2005년 1월, 52면).

Ⅲ. 공유 특허권의 내용

1. 특허발명의 실시

(1) 공유발명 전체에 대하여 실시

특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 지분비율과 관계없이 그 특허발명 전체를 자신이 실시할 수 있다(法 99③). 이는 특허발명이 무체물이므로 유체물과 달리 여러 사람이 특허발명을 사용·수익하더라도 다른 공유자의 사용·수익을 제한하는 것이 아니기 때문이다.³⁶⁶⁾ 한편 공유자 중 일부가 특허발명을 실시하여 이익을 얻었으면 이익에 대한 배분문제가 발생한다. 특허권 자체를 처분하는 경우에 그것으로부터 발생하는 이익을 지분의 비율로 분배할 때 공유 특허권의 지분의 효과가 발생하는 것이지 공유자 각자에게 자유롭게 허용되는 특허발명의 실시에 의한 이익에 대해서는 지분의 효과가 발생하지 않기 때문에 특약이 없는 한 실시자의 전속적인 재산으로 귀속된다고 할 것이다.³⁶⁷⁾

(2) 공유자의 이용발명

공유자 일부가 이용발명을 하여 특허권을 획득하였으면 이용발명을 한 공유자는 특약이 없는 한 다른 공유자의 허락없이 이용발명을 실시할 수 있다. 이는 공유자 일부가 이용발명을 한 경우에는 제98조의 「타인」이 아니기 때문이다.

구 분	민법상 공유	민법상 합유	공동발명자의 권리
인적 결합 형태	공유자간 특별한 인적결합관계 필요치 아니함	조합체 (民法 271)	공동발명자간 계약에 의함
지분의 처분	지분 처분의 자유	지분의 처분 제한 (民法 273①)	다른 공동발명자 모두의 동의를 받지 아니하고는 지분처분 금지 (法 37③, 99②)
분할청구	분할 청구를 통한 공유관계의 청산 가능	분할청구 불가능 (民法 273②)	분할청구 가능 (登錄領 29②)
공유물의 처분·변경	공유자 모두의 동의 필요 (民法 264)	합유자 모두의 동의 필요 (民法 272)	공동발명자 모두의 동의 필요 (法 44, 99②④, 139③)
사용	지분비율로 사용	조합계약 그 밖의 규정의 정함에 따름	공동발명자는 다른 발명자의 동의를 받지 아니하고 발명의 실시가능(法 99③)
등기방식	공유자 모두의 명의로 등기하되 그 지분을 기재	합유자 모두의 명의로 등기하되 합유의 취지를 기재	공동발명자 모두의 명의로 등록하되 그 지분을 기재(登錄領 29①)

366) 이는 민법상의 공유자가 그 지분에 따라 공유물을 사용·수익할 수 있는 경우와 다르다.

367) 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 667면.

(3) 1기관의 범위(공유자의 자기실시범위)

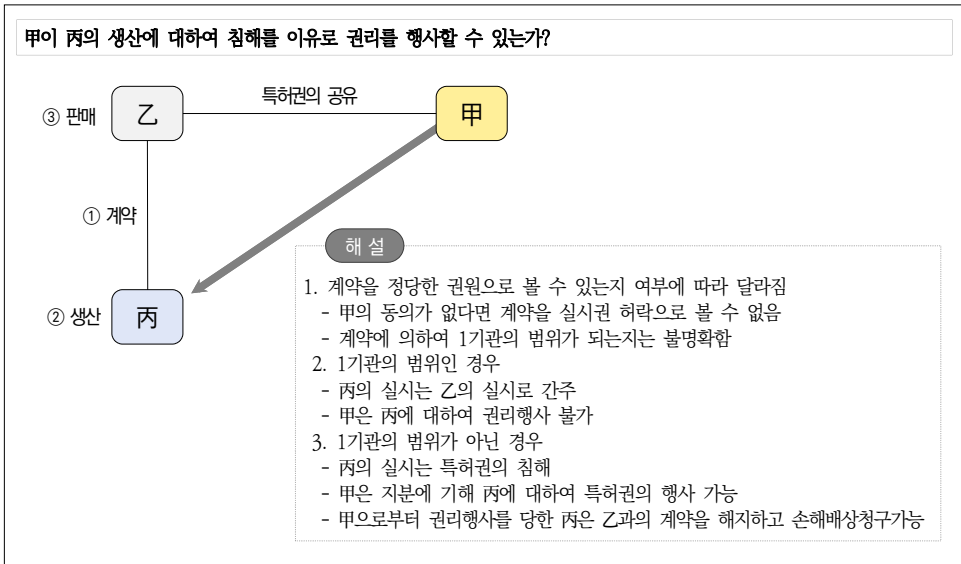
1) 공유자 1명이 특허발명을 스스로 실시하지 않고 타인에게 하청을 주거나 외주를 의뢰한 경우, 하청 등을 받은 자의 실시행위를 하청 등을 준 공유자 중 1명의 실시행위로 간주할 수 있는지가 문제이다. 공유자의 1기관의 범위(자기실시범위)를 너무 넓게 인정하게 되면 특허법 제99조제3항과 제4항의 구별이 없어지게 되고 다른 공유자의 권리를 해칠 우려가 있고, 너무 좁게 인정하게 되면 특허발명의 활용을 저하시키는 문제점이 있다.³⁶⁸⁾ 이와 같은 공유자간의 이해관계를 고려하여 하청 등을 받은 자의 실시행위가 하청을 준 공유자의 1기관에 해당한다면 하청을 준 공유자의 실시행위로 간주할 수 있을 것이다. 일본에서는 하청 제조업자에 대한 사례³⁶⁹⁾가 있다. i) 공유자와 하청 제조업자 사이에 계약관계가 존재하고, ii) 실질적으로 그 공유자가 하청업자를 감독·지휘(지배관리)하여야 하고, iii) 생산된 물품이 전부 공유자에게 인도되었다면, 하청 제조업자의 실시를 독립된 실시로 인정할 수 없어서 침해주장을 하지 못한다는 것이다. 이는 공유자는 다른 공유자의 동의를 받지 않고 특허발명을 실시할 수 있는데, 하청 제조업자가 그 실시를 지원하였다고 하여 책임을 묻는 것이 적절하다고 할 수 없기 때문이다. 다만, 다른 공유자의 이익을 훼손하지 않아야 하므로 일본 사례와 같이 제한된 범위(i) 내지 iii) 충족) 내에서 인정하여야 한다.

2) 국내에서는 1기관의 범위(공유자의 자기실시범위)를 인정하지는 않았으나 그 요건을 판시한 최근의 사례가 있다. 구체적으로 특허법원 2025. 5. 28. 선고 2023나11078 판결에서 “특허권 공유자가 특허발명을 직접 실시하지 않고 타인에게 실시하게 하는 경우에 그 실시행위의 전 과정이 공유자의 계산 아래 그의 지휘·감독 하에 이루어진 것이라면 공유자에 의한 자기실시로 볼 수 있다”라고 하여 일본과 비슷한 요건을 실시하였다.³⁷⁰⁾

368) 고영수, “공유특허권의 실시와 실시허락”, 지식재산연구 제1권 제1호, 2006, 23면 참조.

369) 소위 하청 제조업자에 관한 판례로 등록실용신안권의 권리 공유자의 한명이었던 A로부터의 의뢰로 제조를 하고 있던 자 C에 대해, C가 제조를 위한 기계 설비 등을 소유하고 자기 부담으로 재료를 조달하고 있었다고 해도 원료의 구입, 제품 판매, 품질 등에 대하여 권리 공유자 A의 면밀한 지휘 감독을 받고 실시품은 모두 권리공유자 A의 지시에 따라 납입되고, 다른 사람에게는 전혀 판매되지 아니한 경우에는, C는 권리 공유자 A의 하나의 기관으로 제조하였던 것이고, 권리공유자 A의 계산과 지배 관리 하에 등록실용신안권의 실시를 하였다고 보아야 하며, C는 실용신안권을 독립된 사업으로 실시한 것으로는 볼 수 없다고 하여 권리 공유자 B의 차압 및 손해배상 청구를 기각한 일이 있다(샌다이코제아키타 지부 소회48, 12, 19. 판결).

370) 이 사례에서는 하청을 받은 자가 하청을 준 공유자에게 특허발명에 해당하는 제품을 생산하여 납품할 뿐만 아니라 이를 직접 판매하기로 하였는데, 이는 공유자의 계산 아래 그의 지휘·감독 하에서 이루어진 것이 아니고 하청을 받은 자가 주도적으로 한 것이므로 공유자의 자기실시범위를 벗어났다는 것이다.



【그림 6-18】 1기관의 범위인지에 따른 법률관계

2. 특허권의 지분 양도 또는 지분에 대한 질권설정의 제한

1) 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 지분을 양도하거나 그 지분을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다(法 99②). 이는 상술한 것과 같이 공유자는 자신의 지분비율과 관계없이 특허발명 전체를 실시할 수 있어 새로운 공유자로 된 자의 자본력·기술력·신용력 여하에 따라 다른 공유자의 이해관계에 영향을 미치기 때문이다.³⁷¹⁾

2) 다만 공유자 사이의 지분양도는 단지 공유자간의 지분변동에 불과하고, 다른 공유자의 이익을 해하는 것이 아니기 때문에 다른 공유자의 동의를 얻을 필요가 없다. 또한 상속에 의한 특허권의 지분 이전은 다른 공유자에게 불측의 손해를 끼칠 염려가 없으므로 다른 공유자의 동의를 받지 아니하여도 된다. 특허법이 이처럼 공유지분의 자유로운 양도 등을 금지하는 것은 다른 공유자의 이익을 보호하는 데 그 목적이 있으므로, 각 공유자의 공유지분은 다른 공유자의 동의를 얻지 않는 한 압류의 대상이 될 수 없다.³⁷²⁾ 한편 공유자 1명이 사망하였는데 상속인이 없거나 공유자 1명이 지분을 포기하면 그 지분은 다른 공유자의 각 지분 비율에 따라 다른 공유자에게 귀속된다.

371) 예를 들면 자본력·경영능력 등에서 별반 차이가 나지 아니한 A, B, C 3인이 특허권을 공유하고 있을 경우에 공유자 중 A는 자기의 특허권에 대한 지분을 D라는 자에게 양도를 했는데 D는 자본력·경영능력에서 상기의 A, B, C 3인과 비교해서 월등하게 우세한 자로 가정하면 기존의 공유자 B, C의 특허권에 대한 여러가지 영향력은 변모될 수밖에 없다(이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 666면).

372) 대법원 2012. 4. 16. 선고 2011마2412 결정.

3. 특허권에 대한 실시권 설정의 제한

1) 특허권이 공유인 경우에는 각 공유자는 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 그 특허권에 대하여 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(法 99④).³⁷³⁾ 이는 특허권의 지분 양도 또는 특허권의 지분에 대한 질권의 설정과 같이 새로운 실시권자의 자본력·기술력·신용력 여하에 따라 다른 공유자의 이해관계에 영향을 미치기 때문이다. 이러한 제한에 위반된 실시권은 무효이므로 무효인 실시권에 기한 실시는 정당한 권원이 없는 자의 실시가 되고, 따라서 특허권의 침해를 구성한다.

2) 다만 특허권의 일부 지분에 대한 실시권의 설정은 상정할 수 없다.³⁷⁴⁾ 이는 공유자의 한 사람이 다른 공유자의 동의를 얻어 전용실시권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 때도 그 전용실시권의 설정 또는 통상실시권의 허락은 특허권의 일부 지분에 국한된 처분이 아니라 특허권 자체에 대한 처분행위에 해당하는 것이며, 특허발명은 무체물이므로 실시권자가 특허발명 전체를 실시할 수 있는데 특허권자가 그 실시권자의 실시를 배제할 수 없기 때문이다.

4. 특허권의 존속기간연장등록출원

특허권이 공유인 경우에는 모두가 존속기간연장등록출원을 하여야 하며 그렇지 아니한 경우 거절이유(法 91, 92의4), 무효사유(法 134①②)이다.

5. 심판청구

공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여 청구하여야 하며, 특허권의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法 139②③). 이에 위반되면 부적법한 심판청구로서 심결각하된다(法 142).

6. 심결취소의 소 제기

심판청구는 제139조제2항, 제3항에 따라 공유자 모두를 청구인, 피청구인으로 하여야 하는 고유필수적 공동심판이나, 심결취소의 소의 제기에 관련하여서는 아무런 규정을 두고 있지 않

373) 특허권의 일부 공유지분의 이전청구권을 보전하기 위한 처분금지가처분결정에 기하여 가처분등록이 경료된 후 특허권이 전부 제3자에게 이전된 상태에서 가처분권자인 그 지분의 양수인이 본안소송에서 승소하여 그 지분에 대한 이전등록이 이루어졌다면, 위 가처분등록 이후의 특허권 이전은 양수인 앞으로 이전등록된 지분의 범위에서만 무효가 된다. 이는 특허권의 일부 지분을 양수하기로 한 자는 그 지분의 이전등록이 있기까지는 특허권의 공유자로서 양수의 목적이 되지 아니한 다른 지분의 양도에 대하여 동의권을 행사할 수 없는 것이므로, 다른 지분의 처분을 저지할 수 있는 특약이 존재하는 등의 특별한 사정이 있는 경우가 아니라면 양수의 목적이 된 지분의 이전등록 이전에 그러한 동의권의 보전을 위한 가처분이나 다른 지분에 대한 처분금지의 가처분을 구하는 것은 허용되지 않기 때문이다(대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295).

374) 대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295.

다. 원고와 관련하여서는, i) 공유자 중 1인이 단독으로 심결의 취소를 구하는 소를 제기하더라도 그 소송에서 심결을 취소하는 판결이 확정되면 취소의 효력이 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개되고(행정소송법 제29조 제1항) 심결취소청구를 기각한 판결이 확정되어 심결이 유지된 경우에는 심결에 불복하지 않은 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 않아서, 결국 합일합정의 요청에 반하지 않는다는 점, ii) 공유자 모두가 공동으로 심결의 취소를 구하는 소를 제기하여야 한다고 볼 경우 공유자 중 1인이 라도 소의 제기에 협력할 수 없는 경우 나머지 공유자가 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸되어 버리는 부당한 결과에 이르게 된다는 점을 고려하여 1인의 소 제기를 허용하고 있다.³⁷⁵⁾ 한편 피고와 관련하여서는, 심결취소소송도 심판과 마찬가지로 공유자 모두를 피고로 하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 해석한 것에 별 이론이 없다.³⁷⁶⁾ 이렇게 해석하더라도 공유자가 원고로 되는 경우와 달리 특별히 부당한 결과가 발생하는 것이 아니기 때문이다.

IV. 공유관계의 소멸

특허권 자체가 소멸, 수용된 경우나 지분의 포기로 공유자 1명만이 남는 경우 또는 공유자 중 1명이 다른 공유자의 지분을 모두 양수한 경우 등에 의해 공유관계는 소멸한다.

V. 공유 특허권의 諸문제

1. 침해에 대한 조치

공유인 특허권이 침해된 경우 공유자 모두가 아닌 각자가 그 침해에 대하여 특허권에 의한 조치를 취할 수 있는지 문제이다. 침해금지청구는 일종의 보존행위이기 때문에 특허권의 침해가 있을 때는 각 공유자는 자기 지분에 기하여 단독으로 특허권 전체에 대하여 침해금지청구권(法 126)을 행사할 수 있다고 하여야 할 것이다.³⁷⁷⁾ 한편 손해배상청구권은 가분채권이므로 각 공유자는 자기의 지분비율에 따른 손해액의 청구를 하는 손해배상청구를 할 수 있다고 보는 것이 타당하다.

2. 공유특허권의 분할청구

(1) 분할청구

등록령 제26조제2항에서는 “등록권리자가 2명 이상인 경우 민법 제268조제1항 단서에 따

375) 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567; 2024. 12. 22. 선고 2024후10825.

376) 특허법원 2005. 4. 22. 선고 2004허4693.

377) 대법원 1999. 5. 25. 선고 98다41216.

른 약정이 있을 때에는 등록신청서에 이를 적을 수 있다”라고 규정하고 있으며, 민법 제268조 제1항에서는 “공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다”라고 규정하고 있다. 특허권이 공유인 경우 민법의 공유물분할청구권에 관한 규정이 유추적용되어 공유물 분할금지 특약이 없는 한 공유특허권의 분할청구가 가능하다고 해석된다.³⁷⁸⁾ 이는 i) 공유 특허권자 간에 신뢰관계를 상실하였으면 그 계속관계에서 벗어날 수 있도록 해 주는 것이 타당하다는 점, ii) 분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 변동이 발생한다고 보기 어려워 제99조제2항 및 제4항에 반하지 않는다는 점, iii) 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없는 점 등을 고려한 것이다. 다만 특허권은 무체재산권이기 때문에 분할방식은 현물분할은 인정될 수 없고 경매에 의한 대금분할이나 공유자의 1인이 다른 공유자의 지분을 취득하고 그 대가를 지급하는 가격배상에 의한 분할이 인정될 수 있을 것이다.³⁷⁹⁾³⁸⁰⁾

(2) 공유특허권의 분할청구로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권

공유인 특허권의 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자가 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 나머지 공유특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 122). 공유특허권의 공유자가 공유특허권의 관리나 활용에 이권이 있는 경우 공유자는 공유특허권의 분할청구를 할 수 있다. 그 결과 공유자 중 일부가 공유특허권을 경매에 부치게 되면 그 권리 전체가 타인에게

378) 등록령 제29조제2항 후단 참조.

379) 특허법 제99조제2항 및 제4항의 규정 취지는, 공유자 외의 제3자가 특허권 지분을 양도받거나 그에 관한 실시권을 설정받을 경우 그 제3자가 투입하는 자본의 규모·기술 및 능력 등에 따라 그 경제적 효과가 현저하게 달라지게 되어 다른 공유자 지분의 경제적 가치에도 상당한 변동을 가져올 수 있는 특허권의 공유관계의 특수성을 고려하여, 다른 공유자의 동의 없는 지분의 양도 및 실시권 설정 등을 금지한다는 데에 있다. 그렇다면 특허권의 공유자 상호 간에 이해관계가 대립되는 경우 등에 그 공유관계를 해소하기 위한 수단으로서 각 공유자에게 민법상의 공유물분할청구권을 인정하더라도 공유자 이외의 제3자에 의하여 다른 공유자 지분의 경제적 가치에 위와 같은 변동이 발생한다고 보기 어려워서 위 특허법 제99조제2항 및 제4항에 반하지 아니하고, 달리 분할청구를 금지하는 특허법 규정도 없으므로, 특허권의 공유관계에 민법상 공유물분할청구에 관한 규정이 적용될 수 있다. 다만 특허권은 발명실시에 대한 독점권으로서 그 대상은 형체가 없을 뿐만 아니라 각 공유자에게 특허권을 부여하는 방식의 현물분할을 인정하면 하나의 특허권이 사실상 내용이 동일한 복수의 특허권으로 증가하는 부당한 결과를 초래하게 되므로, 특허권의 성질상 그러한 현물분할은 허용되지 아니한다고 봄이 상당하다(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578).

380) 공유자에게 분할청구권을 인정할 수 없다는 부정설은 i) 동일한 발명에 대하여 복수의 특허권이 발생하게 된다는 점, ii) 일부 공유자의 일방적인 청구에 의하여 다른 공유자가 사실상 특허권의 처분을 강요당하게 된다는 점 등을 들고 있으나, 앞서 본 것과 같이 분할청구권을 인정한다고 하더라도 특허권의 본질상 복수의 특허권을 발생시키는 현물분할은 인정되지 아니하고, 분할방법으로는 경매에 의한 대금분할 이외에 가격배상에 의한 분할이 가능할 뿐만 아니라, 경매에 의한 대금분할도 공유자 상호 간의 이해관계가 대립될 경우 그 공유관계를 조기에 해소할 필요에서 부득이하게 인정되는 것이므로, 부정설의 위 논거들이 타당하다고 보기 어렵다. 따라서 특허권 등의 공유자에 의한 현물분할 외의 공유물분할청구가 가능한 것으로 봄이 타당하다(장락원, “특허권 등의 공유자에게 분할청구권이 인정되는지 여부(대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578)”, 대법원판례해설 제102호, 법원도서관, 2014, 412-414면).

이전되며, 다른 공유자는 자신의 의사와 상관없이 지분비율에 따라 대금을 배당받고 특허권을 상실하게 된다. 이 경우 특허권을 상실한 공유자는 본인의 의사와 상관없이 실시사업을 중단해야 하는 문제가 있으므로, 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 법정실시권을 인정하여 산업설비를 보호해 주고 있다.³⁸¹⁾

3. 제99조제2항 또는 제4항을 위반한 공유자의 취급

특허권이 공유인 경우에는 지분비율과 상관없이 공유자 모두가 특허발명 전체를 실시할 수 있으므로 공유자 각자의 자본력·기술력 여하에 따라 다른 공유자에게 미치는 영향이 지대하고, 이로 인해 수익·처분의 측면에서 제한이 따른다. 그런데 공유자 중 일부가 이러한 제한을 위반하여 제3자에게 실시권을 허락하는 계약 등의 행위를 한 경우 다른 공유자는 제3자에 대해서는 특허권의 침해에 대한 조치를 취할 수 있지만 계약 등을 한 공유자에 대해서는 특허법상 아무런 조치도 취할 수 없다. 즉 특허권이 공유인 경우 공유의 특수성으로 인해 수익·처분의 측면에서 제한(法 99②④)을 두고 있지만, 이를 위반한 공유자에 대해서는 직접적인 제재 조치를 취할 수 없다는 문제점이 있다.

제2절 실시권

제1관 서 설

I. 의 의

「실시권」이란 특허권자 이외의 자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 말한다. 실시권은 특허권의 침해가 되지 아니한 정당한 권원 중 하나로서 특허권에 부수적인 권리이기 때문에 특허권이 존재하여야만 발생할 수 있고, 특허권이 소멸하면 실시권도 소멸한다.

II. 취 지

특허권자가 특허발명을 실시할 의사가 없거나 특허발명을 실시할 자본 등 여력이 부족한 경우 제3자에게 특허발명의 실시 기회를 부여하는 것이 실시 장려라는 특허법의 목적에 부합하며, 특허권의 재산적 가치를 존중하는 것이기 때문에 실시권 제도를 마련하고 있다.

381) 채수근 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안, 디자인보호법 일부개정법률안, 상표법 일부개정법률안 검토보고(송갑석 의원 대표발의(의안번호 제2104891호, 제2104892호 및 제2104893호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2. 30면 참조.

Ⅲ. 종 류

1. 전용실시권과 통상실시권

전용실시권과 통상실시권은 효력, 구체적으로 독점·배타성 여부에 따라 구분된다. 「전용실시권」은 특허발명을 업으로서 독점·배타적으로 실시할 수 있는 물권적 권리이고 「통상실시권」은 독점·배타성 없이 단순히 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 채권적 권리이다. 즉 통상실시권의 본질은 부작위청구권(不作爲請求權)이라고 봄이 통설적 견해이다.³⁸²⁾

2. 허락실시권, 법정실시권 및 강제실시권

허락실시권, 법정실시권 및 강제실시권은 발생원인에 따라 구분된다. 「허락실시권」은 당사자의 의사에 의하여 발생하며, 「법정실시권」은 의사에 무관하게 법률규정에 의하여 발생하고, 「강제실시권」은 의사에 불구하고 법률 규정의 만족과 특허심판원의 심판 또는 지식재산처장의 결정에 의하여 발생한다. 한편 허락실시권은 효력범위에 따라 전용실시권과 통상실시권이 존재하나, 법정실시권과 강제실시권은 통상실시권만이 존재한다. 법률 규정 또는 행정처분에 의해서도 전용실시권이 발생된다면 특허권자의 권리가 지나치게 제한되기 때문이다.

【표 6-13】 실시권의 종류

효력 \ 발생원인	허락실시권	법정실시권	강제실시권
전용실시권	○	×	×
통상실시권	○	○	○

제2관 전용실시권

제100조 【전용실시권】

- ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.
- ② 전용실시권을 설정받은 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다.
- ③ 전용실시권자는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다.
 1. 전용실시권을 실시사업(實施事業)과 함께 이전하는 경우

382) 통상실시권의 허락자는 통상실시권에 대하여 특허발명을 업으로서 실시하는 것을 용인할 의무, 즉 실시권자에 대하여 실시에 대한 금지, 손해배상청구권을 행사하지 아니한다는 부작위 의무를 지는데 그치는 것이고, 실시권 허락자는 실시권자에 대하여 권원 없는 제3자의 업으로서의 실시를 배제하여 통상실시권자의 손해를 막을 작위의무까지 당연히 지는 것은 아니다(日本 大阪地判 昭和 59. 4. 26).

2. 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우
- ④ 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다.
- ⑤ 전용실시권에 관하여는 제99조제2항부터 제4항까지의 규정을 준용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제101조 【특허권 및 전용실시권의 등록의 효력】

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사항은 등록하여야만 효력이 발생한다.
 1. 특허권의 이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다), 포기(소멸 또는 처분의 제한)
 2. 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한
 3. 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한
- ② 제1항 각 호에 따른 특허권·전용실시권 및 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체 없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「전용실시권(exclusive license)」이란 특허권자 이외의 자가 설정행위로 정한 범위에서 독점·배타적으로 그 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다(法 100②).

2. 성 질

전용실시권은 특허권에 부수적인 권리이고 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 허락에 의하여 발생하는 물권적인 권리이므로 시기·지역·실시내용이 중복되는 둘 이상의 전용실시권은 병존할 수 없다.

II. 발 생

1) 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다(法 100①). 전용실시권은 특허권자의 「의사에 의한」 설정계약에 의해서만 성립하고 이를 등록하여야만 효력이 발생한다(法 101①). 전용실시권의 설정등록은 전용실시권자와 특허권자가 공동으로 신청을 하여야 하고 신청서에는 등록원인을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다(登錄令 22).

2) 등록이 되지 아니한 전용실시권의 법적 성질은 특허권자와의 관계에 있어서 독점적 통상실시권과 유사하다고 할 것이다. 「독점적 통상실시권」이란 타인에게는 실시권을 허락하지 아니할 것을 조건으로 하여 특허권자와 통상실시권자만 해당 특허발명을 실시할 수 있도록 하는 통상실시권을 말한다. 특허법상의 실시권은 아니지만 당사자 간의 필요에 따라 약정에 의하여

행해지고 있는 실정이다. 실시권자는 다소 사용료의 지급이 과하더라도 경쟁업자를 배제하기 위한 수단으로서 독점적 통상실시권을 체결하게 되며, 또한 특허권자는 특히 외국인이면 개별적으로 여러 사람에게 통상실시권 설정계약을 하는 것이 번거로우므로 특정인(독점적 통상실시권자)을 중심으로 하여 쉽게 특허관리를 하기 위하여 독점적 통상실시권을 활용하기도 한다.

3) 독점적 통상실시권을 허락하는 계약이 성립하기 위해서는 특허권자가 실시권자 외의 제3자에게 통상실시권을 부여하지 아니할 의무를 부담하여야 하고, 단지 특허권자가 어느 한 실시권자에게만 실시권을 부여함에 따라 그 실시권자가 사실상 독점적인 지위를 향유하고 있다는 사정만으로 그러한 계약이 있었다고 보기 어렵다.³⁸³⁾ 그러나 등록하여야만 그 효력이 발생하는 전용실시권 설정과 달리, 독점적 통상실시권의 허락은 당사자 간 의사의 합치만 있으면 성립되고 이러한 의사의 합치는 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다.³⁸⁴⁾

4) 독점적 통상실시권도 통상실시권의 일종이며 전용실시권처럼 대세효를 가지지 아니한다. 그러므로 특허권자가 계약에 위반하여 제3자에게 특허발명의 실시를 허락하였더라도 독점적 통상실시권자는 제3자의 실시를 금지할 수 없고, 다만 특허권자에게 채무불이행의 책임을 물을 수밖에 없다. 그러나 독점적 통상실시권자는 계약에서 정한 바에 따라 특허발명을 독점적으로 실시할 권리를 가지고 그로 인한 경제적 이익을 향유하는 점에서는 전용실시권자와 다르지 않다. 독점적 통상실시권자가 특허권자로부터 부여받은 권리에 의하여 누리는 이러한 경제적 이익은 결국 특허법에 의하여 보호되는 특허권자의 독점적·배타적 실시권에 기인하는 것으로서 법적으로 보호할 가치가 있는 이익에 해당하고, i) 제3자가 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서 ii) 법규를 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서를 위반하는 등 위법한 행위를 함으로써 이러한 이익을 침해하였다면 이로써 불법행위가 성립하기 때문에 이에 대해서는 민법상 손해배상을 청구할 수 있다.³⁸⁵⁾

III. 효 령

1. 범 위

전용실시권의 구체적인 효력은 「사적자치의 원칙」에 따라 당사자 간의 계약에 의하여 정해진다. 당사자 간의 계약은 사회질서에 반하지 아니하면 실시료액, 실시료의 지급방법, 지급시기, 실시권의 범위나 그 밖의 권리·의무사항 등을 포함할 수 있다. 특허권자는 특허권의 전 범위에 대하여 전용실시권을 설정할 수도 있고, 범위를 한정하여 그 일부에 대하여 설정할 수도 있다.

383) 독점적 통상실시권의 부여는 특허권자가 제3자에게는 통상실시권을 부여하지 않을 부작위 의무를 부담하는 불리한 내용이기 때문에, 명시적인 계약이 없는 상황에서 묵시적으로 일방 당사자에게 불리한 계약의 내용을 인정하기 위해서는 엄격한 증거가 필요한 것이다(박성민, “약가인하에 의한 손해배상 여부 —대법원 2016다260707 판결, 대법원 2018다221676 판결—”, 지식재산연구 제16권 제2호, 2021. 6, 39면).

384) 특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332.

385) 특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332.

또한 특허권자는 특허발명의 사용분야 또는 제품의 생산수량을 제한하여 전용실시권을 설정할 수도 있다.

2. 내 용

1) 전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다(法 100②). 따라서 전용실시권자는 설정된 범위에서 정당한 권원 없이 자기의 권리를 침해한 자에 대하여 민·형사상 제재를 할 수 있다. 특허권자라고 하더라도 전용실시권을 설정한 범위에서는 전용실시권자의 허락없이 특허발명을 실시하는 경우 전용실시권의 침해가 된다(法 94①단서).

2) 전용실시권은 특허권에 부수적인 권리이므로 특허권의 효력이 제한되는 일정한 경우에는 전용실시권의 효력도 제한된다. 또한 전용실시권이 공유인 경우에는 공유자간에 특허발명의 실시에 대하여 약정한 경우가 아니라면 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 각 공유자는 스스로 특허발명을 실시할 수 있음은 특허권의 공유의 경우와 같다(法 100⑤).

IV. 변동 등

1. 이 전

(1) 원 칙

전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다(法 100③). 특허발명에 대해서 어느 정도 자본을 가지고 어떠한 기술에 의하여 실시하는가 하는 것이 특허권자에게 있어서도 중대한 이해관계가 있으므로 원칙적으로 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다. 전용실시권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(法 100⑤).

(2) 예 외

① 실시사업과 함께 이전하는 경우

실시사업을 이전하여도 실시권을 이전할 수 없게 된다면 실시사업의 설비가 가동될 수 없는 경우가 발생하여 실시 장려를 통한 산업발전에 이바지라는 특허법의 목적에 부합하지 않기 때문에 실시사업과 함께라면 특허권자의 동의를 받지 않더라도 전용실시권을 이전할 수 있다.

② 상속이나 그 밖의 일반승계에 의하여 이전하는 경우

상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 승계인의 범위가 한정되고 특허권자가 불측의 손해를 입을 우려도 적고 피승계인의 권리·의무가 포괄적으로 이전되기 때문에 특허권자의 동의를 받지 않더라도 전용실시권을 이전할 수 있다.³⁸⁶⁾

2. 실시권 및 질권 설정

전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(法 100④).³⁸⁷⁾ 전용실시권이 공유인 경우에는 다른 공유자의 동의를 받아야만 그 지분에 대한 질권을 설정하거나 전용실시권에 대한 통상실시권을 허락할 수 있다(法 100⑤). 그러나 전용실시권자가 설정범위에서 다시 전용실시권을 설정할 수는 없는 것으로 해석된다.³⁸⁸⁾

3. 특허권의 포기에 대한 동의 및 실시권 포기의 제한

1) 특허권자는 전용실시권자의 동의를 받아야만 특허권을 포기하거나 특허의 정정청구·정심판청구(다만 전용실시권자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)를 할 수 있다(法 119①, 132의3③, 133의2④, 136⑧, 137④ 준용 136⑧).

2) 전용실시권자는 전용실시권을 목적으로 하는 허락에 의한 통상실시권 및 질권이 설정된 경우 허락에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 포기할 수 있다(法 119②).

V. 소 멸

전용실시권은 특허권에 부수적인 권리이므로 특허권이 소멸되는 경우에 당연히 소멸하며 특허권이 수용되는 경우에도 소멸한다(法 106②). 한편 이외에도 전용실시권의 포기, 혼동,³⁸⁹⁾ 설정계약의 해제, 무효, 취소, 설정기간의 만료 등으로 전용실시권은 소멸한다.

VI. 관련문제

1. 등록의 효과

1) i) 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한, ii) 전용실시권을 목적으로 하는 질

386) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2002, 248면.

387) 전용실시권자가 실용신안권자의 동의 없이 타인에게 실용신안의 사용을 허락하여 그것을 사용한 제품을 생산하게 한 것은 실용신안법의 규정을 위반하여 실용신안권을 침해한 행위라 할 것이므로 실용신안권자는 계약을 해지할 수 있다(수원지방법원 2002. 3. 15. 선고 2001가합3821).

388) 이는 제100조제4항에서 전용실시권자가 특허권자의 동의를 받아 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있으나, 다시 전용실시권자를 설정하는 것이 제외되어 있는 것으로부터 간접적으로 파악할 수 있다.

389) 「혼동」이란 서로 대립하는 두 개의 법률상의 지위 또는 자격이 동일인에게 귀속되는 경우 한쪽의 권리가 다른 쪽 권리에 흡수되는 것을 말한다. 그러나 흡수 소멸될 권리가 제3자의 권리의 목적물일 때에는 혼동사유가 발생하였다고 하더라도 그 사유가 해소될 때까지는 그 전용실시권은 소멸하지 아니한다(民法 191). 예를 들어 전용실시권자가 특허권을 양수하여 이전등록을 한 경우 원칙적으로 전용실시권은 혼동에 의하여 소멸하지만, 전용실시권에 질권이 설정된 경우에는 질권자의 이익을 위하여 그 한도 내에서 전용실시권은 소멸하지 아니한다(천효남, 「특허법」, 제9판, 법경사, 2003, 581면).

권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경³⁹⁰⁾·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다. 예를 들어 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 설정 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 아니한 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 아니한 계약상 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 된 것은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다.³⁹¹⁾

2) 전용실시권 또는 그 질권이 상속이나 그 밖의 일반승계에 의하여 이전되는 경우에는 등록하지 않더라도 권리변동의 효력이 발생하며, 그 취지를 지체없이 지식재산처장에게 신고하면 된다(法 101②). 이는 상속의 경우 사망과 상속인의 등록 사이에 권리의 공백 상태의 발생을 방지하기 위함이고, 승계 전후의 사이에 권리내용의 변동이 없이 권리·의무가 포괄적으로 이전되는 것이므로 등록이 없어도 제3자에게 영향을 미치지 않기 때문이다.

3) 전용실시권 또는 질권이 혼동에 의한 소멸한 경우에는 소멸등록을 하지 아니하여도 전용실시권이 소멸하지만 권리소멸관계의 명확성을 기하기 위하여 지식재산처장이 직권으로 소멸등록을 한다(登錄令 14).

2. 전용실시권을 설정한 특허권자의 지위

(1) 문제의 소재

전용실시권자는 그 설정행위로 정한 범위에서 그 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다(法 100②). 한편 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하지만, 그 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때에는 전용실시권자가 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하는 범위에서는 그러하지 아니하다(法 94①). 이 경우 전용실시권의 범위에서 제3자가 특허발명을 침해하고 있을 때 전용실시권자 이외에 특허권자에게 손해배상청구 또는 침해금지청구 등의 소권이 인정되는지 문제이다.

(2) 검토

1) 특허권의 소극적 효력을 제94조제1항의 “특허권자는 특허발명을 업으로서 실시할 권리를 독점한다”에서 규정하고 있는 독점성의 반대급부로서 간접적으로 규정된 것으로 이해하는 경우 특허권에 관하여 전용실시권을 설정하였을 때 특허권자는 실시할 권리를 독점하지 않으므로(法 94①단서), 제3자의 침해에 대하여 특허권자의 소권이 인정되지 않을 것이다. 그러나 제100조제4항의 “전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다”에서 규정하고 있는 특허권자의 동의권을 고

390) 전용실시권은 특허권과 달리 부분적, 일면적 지배성을 가지므로 효력에 변경이 있는 경우, 즉 기간·지역·실시내용 등의 변경이 있는 경우 변경등록을 하게 된다.

391) 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645.

려해 봤을 때 동의를 얻지 않고 전용실시권자가 통상실시권을 허락한 경우 특허권자는 그 무효인 통상실시권을 포함한 제3자에 대하여 특허권의 침해에 대한 소권이 있다고 해석되어야 한다.³⁹²⁾

2) 특허권의 소극적 효력은 적극적 효력과는 별개의 권리이며, 전용실시권의 설정은 특허권의 소극적 효력이 미치지 아니하는 계약으로 이해할 수 있으며, 전용실시권이 존재하더라도 타인의 실사를 배제할 수 있는 특허권자의 권한은 전용실시권자 이외의 자에게는 여전히 행사할 수 있으므로 특허권자에게는 침해에 대한 소권이 인정된다고 볼 것이다. 즉 특허권자가 전용실시권을 설정하는 것은 흡사 소유권자가 소유물을 제3자에게 사용·수익하게 하는 것과 다를 바가 없으므로 이 경우 소유자가 물상청구권을 상실하지 아니하는 것과 같이 해석하여야 한다는 점³⁹³⁾에서 특허권자의 권리 행사를 긍정함이 타당하다. 따라서 전용실시권이 침해되었을 때 전용실시권자는 물론이고 특허권자도 그 침해를 금지한다거나 손해배상청구를 할 수 있다.

3) 손해배상청구와 관련하여, 특허권자가 전용실시권자로부터 판매량에 따른 실시료(running royalty)를 받는다면 판매량 감소에 따른 손해액에 대하여 전용실시권자와 별도로 침해자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있으나, 판매량과 상관없이 실시료(fixed royalty)를 받는다면 특허권자에게 침해자의 실시가 있더라도 손해가 있다고 말할 수 없으므로, 이 경우에는 별도로 손해배상을 청구할 수 없다.³⁹⁴⁾ 한편 특허권자 또는 전용실시권자가 고의나 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위로 이익을 얻었을 때는 그 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자가 입은 손해액으로 추정하는 것이고(法 128①④), 따라서 특허권자 및 전용실시권자가 입은 손해의 총액은 침해행위자가 얻은 이익의 액에 한정되므로, 전용실시권자의 손해는 특허권자가 피고에게 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액을 공제한 잔액이라 할 것이고,³⁹⁵⁾ 전용실시권자가 특허권자로부터 전용실시권을 일정액에 매수하여 전용실시권자만이 특허권을 실시하고 있는 경우에는 침해행위자가 얻은 이익의 액이 모두 전용실시권자의 손해라 할 것이다.

4) 즉 특허권자가 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액은 원래 피고의 이익산출에 있어서 경비로서 공제되어야 할 성질의 것이다. 이익액으로부터 이를 공제한 액을 손해액으로 하지 않으면 특허권자에 대한 그 금액이 이중지급이 되므로 전용실시권자의 손해배상분에는 특허권자에게 지급하여야 할 그 금액을 제외하는 것이 타당하다.

392) 제100조제3항에서 원칙적으로 특허권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 이전할 수 있다는 규정에 비취했을 때도, 특허권자에게 동의를 받지 않고 이전받은 자의 특허발명 실시의 침해에 대한 소권을 인정하여야 한다.

393) 박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002, 391면.

394) 서울중앙지방법원 2009. 10. 7. 선고 2007가합33960.

395) 서울민사지방법원 1991. 5. 8. 선고 90가합92251.

3. 등록청구권

전용실시권은 등록이 효력발생요건이므로 특허권자가 전용실시권의 등록에 협조하지 아니한 경우에 계약서상에 명시되어 있지 아니하여도 전용실시권자는 특허권자에게 등록청구권을 행사할 수 있다고 해석된다. 그러나 통상실시권은 등록이 대항요건이기 때문에 계약상의 특약이 없는 한 통상실시권자에게 등록청구권이 인정되지 아니한다고 할 것이다.³⁹⁶⁾

4. 특허권자의 변동에 의한 계약승계문제

특허권자가 전용실시권을 설정한 후에 제3자에게 권리를 이전한 경우 권리취득자(새로운 특허권자)에게 전용실시권설정계약에서 정한 계약 내용이 그대로 이전되는지 문제이다. 이때 지식재산처에 등록된 조건은 그대로 승계된다고 해석하여야 하나, 등록되지 아니한 조건은 승계된다고 볼 수 없고 기존 특허권자와의 채무불이행문제만 남는다고 볼 것이다.³⁹⁷⁾

제3관 통상실시권

제102조 【통상실시권】

- ① 특허권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상실시권을 허락할 수 있다.
- ② 통상실시권자는 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다.
- ③ 제107조에 따른 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다.
- ④ 제138조, 「실용신안법」 제32조 또는 「디자인보호법」 제123조에 따른 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권과 함께 이전되고, 해당 특허권·실용신안권 또는 디자인권이 소멸되면 함께 소멸된다.
- ⑤ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 이전할 수 있다.
- ⑥ 제3항 및 제4항에 따른 통상실시권 외의 통상실시권은 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다.

396) 설정등록을 한 통상실시권은 그 특허권·전용실시권 또는 설정등록 후에 설정된 전용실시권자에 대해서 그 효력을 주장할 수 있는데 불과한 것이다. 이것을 실시권자의 측면에서 보면 허락에 의한 통상실시권의 설정을 받은 자는 실시계약에 의하여 정해진 범위에서 해당 발명을 실시할 수 있지만 그 실시권을 독점할 수 있는 것은 아니고 단순히 특허권자 또는 실시권자에 대해서 특허발명을 업으로 실시할 수 있는 권리를 청구할 수 있는데 지나지 아니한다고 볼 수 있다. 허락에 의한 통상실시권이 이와 같은 권리이므로 실시계약에 있어서 통상실시권에 대하여 등록을 하는지의 여부는 당사자 간의 계약에 의해서 자유로이 정할 수 있다고 본다(사적 계약자유의원칙). 그러므로 실시권자는 당연히 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 통상실시권에 관한 등록절차를 수행하여야 한다는 것을 요구할 수는 없고, 실시계약에 의해서 등록에 관한 특약이 있는 경우에만 그 수행을 요구할 수 있다고 본다(日本 最高裁判 昭和 48. 4. 20).

397) 사법연수원, 「특허법」, 2009, 157면.

⑦ 통상실시권에 관하여는 제99조제2항 및 제3항을 준용한다.
[전문개정 2014.6.11.]

제118조 【통상실시권의 등록의 효력】

- ① 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다.
 - ② 제81조의3제5항, 제103조부터 제105조까지, 제122조, 제182조, 제183조 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권은 등록이 없더라도 제1항에 따른 효력이 발생한다.
 - ③ 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다.
- [전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「통상실시권(non-exclusive license)」이란 특허권자 이외의 자가 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 말한다(法 102②).

2. 성 질

통상실시권은 특허권에 부수적인 권리이고 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 없는 채권적 권리이다. 따라서 통상실시권을 허락한 후에도 중복되는 범위에서 i) 특허권자가 스스로 실시할 수 있고, ii) 같은 내용의 복수의 통상실시권이 동시에 존재할 수 있으며, iii) 특허권자가 다시 전용실시권을 설정할 수도 있다.

3. 종 류

통상실시권은 발생원인에 따라 i) 특허권자(또는 전용실시권자)와 특허발명을 실시하려는 자와의 계약에 의하여 발생하는 허락에 의한 통상실시권, ii) 특허권자(또는 전용실시권자)의 의사와 관계없이 법률 규정에 의하여 발생하는 법정실시권, iii) 특허권자(또는 전용실시권자)의 의사에 불구하고 법률 규정의 만족과 지식재산처장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의하여 발생하는 강제실시권으로 구분된다.

II. 허락에 의한 통상실시권

1. 의 의

「허락에 의한 통상실시권」이란 특허권자 또는 전용실시권자와 특허발명을 실시하려는 자와의 계약에 의하여 발생하는 통상실시권을 말한다(法 102①, 100④).

2. 발 생

특허권자 또는 특허권자의 동의를 받은 전용실시권자는 그 특허권에 대하여 타인에게 통상 실시권을 허락할 수 있다(法 102①, 100④). 허락에 의한 통상실시권은 특허권자(또는 전용실시권자)와의 계약에 의하여 발생하며 통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다(法 118①). 즉 허락에 의한 통상 실시권의 등록은 제3자 대항요건이다.

3. 효 력

(1) 범 위

허락에 의한 통상실시권의 효력범위는 상술한 전용실시권과 같이 「사적자치의 원칙」에 따라 당사자 간의 계약에 의하여 정해진다.

(2) 내 용

1) 통상실시권자는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다(法 102②). 허락에 의한 통상실시권은 독점·배타성이 없고 단지 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 실시할 수 있는 채권적 권리이므로 일반적으로 타인의 침해에 대하여 직접적으로 침해를 배제할 민·형사상 권리를 가지지 아니한다.³⁹⁸⁾³⁹⁹⁾ 다만 상술한 것과 같이 특허권자가 독점적 통상실시권을 허락하였는데 제3자가 독점적 통상실시권을 해한다는 사정을 알면서 법규를 위반하거나 선량한 풍속 또는 사회질서를 위반하는 등 위법한 행위를 한 경우에는 불법행위가 성립한다.⁴⁰⁰⁾ 따라서 이 경우에는 불법행위에 대한 손해배상청구권을 행사할 수 있다.

2) 통상실시권은 특허권 또는 전용실시권에 부수적인 권리이므로 특허권 또는 전용실시권의 효력이 제한되는 일정한 경우에는 허락에 의한 실시권의 효력도 제한된다.

398) 부산지방법원 2001. 11. 16. 선고 2000가합19444; 수원지방법원 성남지원 2006. 11. 24. 선고 2005가합5573; 서울중앙지방법원 2007. 6. 14. 선고 2006가합34553.

399) 통상실시권자가 제3자의 침해에 대해 특허권자의 금지청구권을 대위행사할 수 있는지 문제가 될 수 있다. 제3자의 침해가 있는 경우 배상감소 등의 불이익은 예상되지만, 통상실시권자의 특허발명 실시 자체가 불가능한 것은 아니므로 통상실시권자에게 금지청구권을 대위행사할 요건이나 필요성을 갖추었다고 할 수 없어(대위행사를 위해서는 대위의 근거가 되는 피보전 권리가 존재하여야 하나, 통상실시권자는 특허권자에게 제3자의 침해를 배제하여 달라고 요구하는 채권이 없다) 대위청구권(民法 404)을 인정할 수 없다고 봄이 타당하다(사법연수원, 「특허법」, 2009, 162면). 만약, 채권자 대위가 인정된다면 제3자에게 새롭게 실시권을 허락하거나 제3자의 실시를 묵인할 수 있는 특허권자의 자유를 박탈하는 결과를 초래하게 될 것이다. 다만 계약상 특허권자에게 제3자의 침해를 배제할 의무가 있는 경우에는 특허권자의 자유를 부당하게 침해하는 것은 아니므로 이를 인정해도 좋다고 본다(이회기, 「특허법 주해Ⅱ」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 1253-1254면).

400) 특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332.

4. 변동 등

(1) 이 전

허락에 의한 통상실시권자는 i) 실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 ii) 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 iii) 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 허락에 의한 통상실시권을 이전할 수 있다(法 102⑤). 허락에 의한 통상실시권이 공유인 경우에는 다른 공유자의 동의를 받아야만 그 지분을 양도할 수 있다(法 102⑦).

(2) 질권 설정

허락에 의한 통상실시권자는 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 그 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다(法 102⑥). 허락에 의한 통상실시권이 공유인 경우에는 다른 공유자의 동의를 받아야만 그 지분에 대한 질권을 설정할 수 있다(法 102⑦).⁴⁰¹⁾

(3) 특허권의 포기에 대한 동의 및 실시권 포기의 제한

1) 특허권자는 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 허락에 의한 통상실시권자의 동의를 받아야만 특허권을 포기하거나 특허의 정정청구·정정심판청구(다만 허락에 의한 통상실시권자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)를 할 수 있다(法 119①, 132의3③, 133의2④, 136⑧, 137④).

2) 허락에 의한 통상실시권자는 통상실시권을 목적으로 하는 질권이 설정된 경우 질권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 포기할 수 있다(法 119③).

5. 소멸

허락에 의한 통상실시권은 특허권(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 전용실시권)에 부수적인 권리이므로 특허권(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권 또는 전용실시권)이 소멸되는 경우에 당연히 소멸하며, 특허권이 수용되는 경우에도 소멸한다(法 106②). 한편 이외에도 통상실시권의 포기, 혼동, 설정계약의 해제, 무효, 취소, 설정기간의 만료 등으로 허락에 의한 통상실시권은 소멸한다.

401) 통상실시권자가 제3자에게 다시 통상실시권을 허락(sublicense 가능 여부)할 수 있는지 문제이다. 제100조제4항에서 전용실시권은 특허권자의 동의를 받아서 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다고 규정하고 있는데 반해, 제102조제6항에서 통상실시권자는 특허권자의 동의를 받아서 질권을 설정할 수 있다고 규정하고 있을뿐 통상실시권을 허락할 수 있다는 것을 제외하고 있다. 따라서 통상실시권자는 다시 통상실시권을 허락할 수 없다는 것으로 해석된다. 다만 특허권자와 통상실시권와의 계약에서 제3자에 대한 통상실시권을 허락할 수 있는 조건이 명시된 경우가 있는데, 이는 특허권자가 특허권에 대한 통상실시권 허락 권한을 위탁한 것으로 이해하는 것이 바람직하다 할 것이다.

III. 법정실시권

1. 의의 및 취지

「법정실시권」이란 특허권자 또는 전용실시권자의 의사와 관계없이 법률 규정에 의하여 발생하는 통상실시권을 말한다. 특허법은 기존의 산업시설을 보호하고 특허권자와 일정한 관계에 있는 자 사이의 형평을 도모하여 산업발전에 이바지하기 위해 법정실시권에 관한 규정을 두고 있다.

2. 종 류

법정실시권은 다음과 같이 9 종류가 있다.

- i) 직무발명에 의한 통상실시권(發振法 10①)
- ii) 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권(法 81의3)
- iii) 선사용에 의한 통상실시권(法 103)
- iv) 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권(法 103의2)
- v) 무효심판청구 등록 전에 실시에 의한 통상실시권(法 104)
- vi) 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권(法 105)
- vii) 질권 행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권(法 122)
- viii) 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권(法 182)
- ix) 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(法 183)

3. 발 생

법정실시권은 법률에서 규정하는 실시권의 성립요건을 만족한 때 효력이 발생한다. 실시권의 성립요건을 만족했음은 실시권자가 증명하여야 한다. 법정실시권은 설정등록을 하지 않더라도 제3자 대항요건을 구비한다(法 118②).

4. 효 력

(1) 범 위

법정실시권자는 법률의 규정에 정해진 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다(法 102②). 구체적으로 대부분의 법정실시권(法 81의3⑤, 103, 103의2, 104, 182)은 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 효력을 갖는다. 다만 i) 직무발명에 대한 사용자 등의 통상 실시권(發振法 10①)은 특허발명 전체에 대해서, ii) 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권(法 105)의 경우 디자인권자는 그 디자인권 범위에서, 디자인권에 대한 실시권자는 원실시권의 범위에서, iii) 질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권(法 122)은 특허발명의 전 범위에서, iv) 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(法 183)은 원통상 실시권의 발명의 범위 및 사업목적의 범위에서 효력을 갖는다.

(2) 내 용

법정실시권자는 이 법에 따라 정해진 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다(法 102②). 이에 대한 구체적인 내용은 허락에 의한 통상실시권에서 상술한 바와 같다.

5. 변동 등

(1) 이전 및 질권설정

법정실시권의 이전 및 질권설정은 허락에 의한 통상실시권에서 상술한 바와 같다(法 102⑤⑥⑦).

(2) 특허권의 포기에 대한 동의 및 실시권 포기의 제한

1) 특허권자는 법정실시권자 중 직무발명에 대한 통상실시권자의 동의를 받아야만 특허권을 포기하거나 특허의 정정청구·정정심판청구(다만 직무발명에 대한 통상실시권자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)를 할 수 있다(法 119①, 132의3③, 133의2④, 136⑧, 137④).

2) 법정실시권자는 법정실시권을 목적으로 하는 질권이 설정된 경우 질권자의 동의를 받아야만 법정실시권을 포기할 수 있다(法 119③).

6. 소 멸

법정실시권은 특허권의 소멸, 특허권의 수용, 법정실시권의 포기, 혼동 등으로 소멸한다. 한편 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 실시가능한 법정실시권은 실시사업이 폐지된 경우 소멸하는 것으로 해석된다.

7. 대 가

실시권의 인정취지가 기존의 산업시설을 보호하는 측면에 있다면, 즉 산업정책적인 목적이 라면 법정실시권자는 그 실시의 대가를 특허권자에게 지급하여야 하고, 실시권의 인정취지가 특허권자와 일정한 관계에 있는 자 사이의 형평을 도모하는 측면에 있다면, 즉 공평의 목적이 라면 법정실시권자는 특허권자에게 대가를 지급할 필요가 없다. 구체적으로 직무발명에 의한 통상실시권(發振法 10①), 선사용에 의한 통상실시권(法 103), 디자인권의 존속기간 만료 후의 그 디자인권자의 통상실시권(法 105), 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상 실시권(法 182)을 제외하고는 법정실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에 대하여 대가를 지불하여야 한다.

IV. 강제실시권

1. 의의 및 취지

「강제실시권(compulsory license)」이란 특허권자의 의사에 불구하고 법률 규정의 만족과 지식재산처장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의하여 발생하는 통상실시권을 말한다. 특허

법은 i) 국방상·공익상 필요에 의한 경우, ii) 특허발명의 실시를 유도하고 특허권의 남용을 방지하기 위한 경우 제3자에게 그 특허발명을 실시하게 하려고 강제실시권에 관한 규정을 두고 있다. 이는 특허권이 사권임과 동시에 공권이기 때문에 일정한 제한을 두고 있는 것이다.

2. 종 류

강제실시권은 다음과 같이 3 종류가 있다.

- i) 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권(法 106의2)
- ii) 재정에 의한 통상실시권(法 107-115)
- iii) 통상실시권허락심판에 의한 통상실시권(法 138)

3. 발 생

강제실시권은 법률 규정의 만족과 지식재산처장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의하여 발생한다. 구체적으로 국가 비상사태 등에 의한 실시권(法 106의2) 및 재정에 의한 실시권(法 107)은 결정서 또는 재정서의 등본이 송달된 때, 통상실시권허락심판에 의한 실시권(法 138)은 심결이 확정된 때 그 효력이 발생한다. 지식재산처장은 강제실시권의 효력이 발생하면 직권등록을 하여야 한다(登録令 14).

4. 효 력

(1) 범 위

강제실시권의 경우 지식재산처장의 결정이나 재정 또는 심판관 합의체의 심결에 의하여 정해진 범위에서 효력이 있다.

(2) 내 용

강제실시권자는 지식재산처장의 결정이나 재정 또는 심판관 합의체의 심결에 의하여 정해진 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리를 가진다(法 102②). 이에 대한 구체적인 내용은 허락에 의한 통상실시권에서 상술한 바와 같다.

5. 변동 등

(1) 이 전

재정에 의한 통상실시권(法 107)의 경우 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있다(法 102③). 이는 재정에 의한 통상실시권의 설정원인과 그 취지에서 볼 때 통상실시권이 실시사업과 분리되어 이전되는 것은 불합리하기 때문이다. 통상실시권허락심판에 의한 통상실시권(法 138)의 경우 실시권의 허락원인이 된 원 권리와 함께 이전할 수 있다(法 102④). 이 실시권은 이용·저촉관계의 조정을 위하여 설정된 실시권이므로 해당 특허권에 종속되어야 하

기 때문이다. 한편 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권(法 106의2)의 경우 제102조제3항 및 제4항의 반대해석상 특허권자의 동의, 상속이나 그 밖의 일반승계 또는 실시사업과 함께라면 이전할 수 있으나, 공익을 위하여 인정되는 강제실시권의 취지를 고려해 볼 때 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있도록 제한하여야 한다.

(2) 질권 설정 不可

재정에 의한 통상실시권(法 107), 통상실시권허락심판에 의한 통상실시권(法 138)은 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 없다(法 102⑥). 한편 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권(法 106의2)은 제102조제6항의 반대해석상 질권을 설정할 수 있으나 공익을 위하여 인정되는 강제실시권의 취지를 고려해 볼 때 수익행위를 하는 것은 타당하지 않으므로 질권을 설정할 수 없는 것으로 제한하여야 한다.

6. 소멸

강제실시권은 일반적으로 특허권의 소멸, 특허권의 수용, 강제실시권의 포기, 혼동 등으로 소멸한다. 그 밖에 i) 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권(法 106의2)은 결정의 취소에 의하여, ii) 재정에 의한 통상실시권(法 107)은 재정의 실효(法 113)나 재정의 취소(法 114)에 의하여, iii) 통상실시권허락심판에 의한 통상실시권(法 138)은 원권리의 소멸에 의하여 소멸한다.

7. 보상금 또는 대가

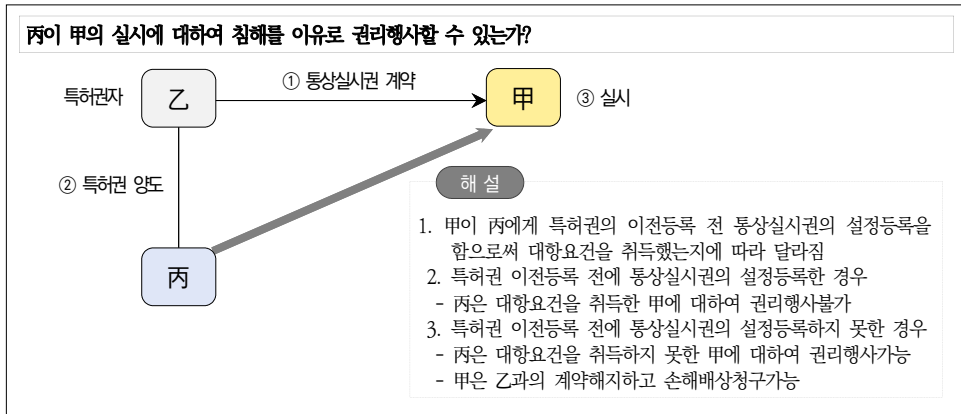
강제실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 보상금 또는 대가를 지급하여야 하며 이와 같은 보상금이나 대가는 지식재산처장의 결정이나 재정 또는 심판에 의하여 정하여진다.

V. 관련문제

1. 등록의 효과

통상실시권을 등록한 경우에는 그 등록 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대해서도 그 효력이 발생한다. 다만 법정실시권은 등록이 없더라도 발생 후에 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여 효력이 발생한다(法 118①②). i) 통상실시권의 이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, ii) 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자⁴⁰²⁾에게 대항할 수 있다. 강제실시권의 설정등록은 지식재산처장의 직권등록사항이다(法 118③, 登錄令 14).

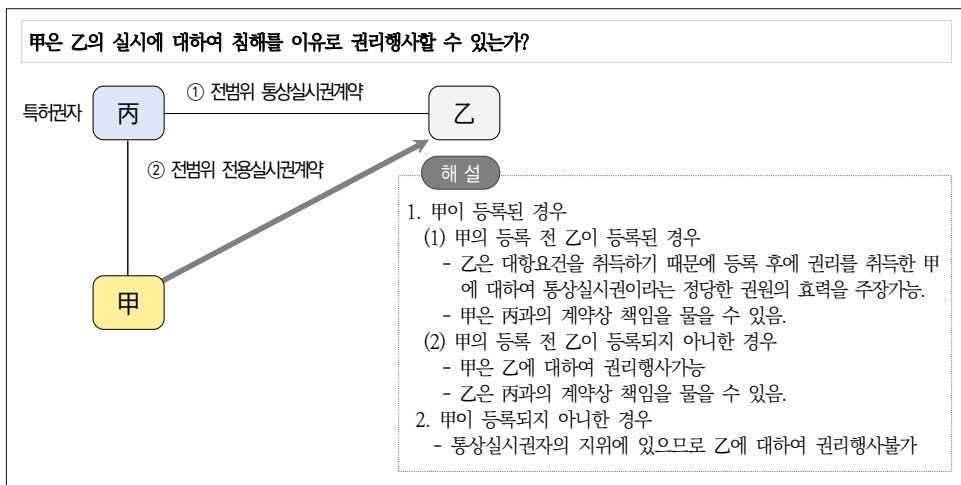
402) 여기서 제3자란 통상실시권자의 지위와 양립할 수 없는 법률상의 지위를 취득한 사람을 말한다(대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691 참조).



【그림 6-19】 통상실시권의 대항요건취득 여부에 따른 법률관계

2. 등록의 선후에 따른 전용실시권과 통상실시권의 관계

특허권자가 중복되는 범위에 甲과 전용실시권 계약을 체결하고 乙과 통상실시권 계약을 체결한 경우 甲과 乙의 지위는 등록의 선후에 따라 달라진다. 甲이 먼저 등록한 경우 乙은 아직 통상실시권을 등록하기 전이므로 乙은 甲에게 자신의 통상실시권의 효력을 주장할 수 없으며, 甲의 동의 없이 乙이 실시하는 경우 乙의 실시는 甲의 전용실시권을 침해하게 된다. 乙이 먼저 등록된 경우에는 乙은 甲에 대하여 대항요건을 취득하기 때문에 甲은 乙에 대하여 침해를 이유로 권리행사를 할 수 없다. 한편 甲의 등록일과 乙의 등록일이 같은 경우에는 접수된 순서에 의한다(登録令 28①).



【그림 6-20】 등록의 선·후에 따른 전용실시권과 통상실시권의 관계

【표 6-14】 실시권의 비교

권 리		전용실시권	통상실시권		
			허락실시권	법정실시권	강제실시권
의 의	특허권자 이외의 자가 설정행위로 정한 범위에서 독점·배타적으로 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리		특허권자 이외의 자가 이 법에 따라 또는 설정행위로 정한 범위에서 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 권리		
성 질	부수적, 물권적		부수적, 채권적		
발 생	계약 + 등록		계약	법률 규정 만족	법률 규정 만족 + 행정처분
효 력	효력범위	설정행위로 정한 범위		법률 규정에 의하여 정한 범위	행정처분에 의하여 정한 범위
	효력내용	1. 특허발명을 실시 가능 2. 타인의 실시 금지 가능	1. 특허발명을 실시 가능 2. 타인의 실시 금지 불가능		
변 동	이 전	사업과 함께, 상속이나 그 밖의 일반승계, 특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의			1. 제106조의2 → 학설 대립 2. 제107조 → 실시사업과 함께만 3. 제138조 → 실시권의 허락원인이 된 원권리와 함께
	실시권허락	특허권자의 동의	불가		
	질권설정	특허권자의 동의	특허권자(전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의		1. 제106조의2 → 학설 대립 2. 제107조, 제138조 → 불가
	특허권포기	동의권 ○		직무발명에 대한 통상실시권자만 동의권 ○	동의권 ×
	실시권포기	통상실시권자, 질권자의 동의	질권자의 동의		
소 멸	일반	특허권의 소멸(전용실시권에 대한 특허권의 수용, 혼동)		통상실시권의 경우에는 전용실시권 또는 특허권의 소멸, 실시권의 포기,	
	특수	설정기간 만료, 설정계약의 해지	제105조, 제122조, 발명진흥법 제10조제1항을 제외하고는 실시사업의 폐지		1. 제106조의2 → 지식재산처장 결정취소 2. 제107조 → 재정의 취소나 실효 3. 제138조 → 원권리 소멸
대 가	약정시 정한 대가		제103조, 제105조(디자인권자), 제182조, 발명진흥법 제10조제1항을 제외하고는 대가 지급		행정처분시 정한 대가
등록효과	전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한, 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록이 효력발생요건		1. 통상실시권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한, 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 등록이 대항요건 2. 법정실시권은 설정등록없이도 대항가능 3. 강제실시권의 설정등록은 지식재산처장의 직권등록사항		

제4관 법정실시권의 구체적 내용

I. 직무발명에 대한 통상실시권

발명진흥법 제10조 【직무발명】

- ① 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안등록, 디자인등록(이하 “특허등”이라 한다)을 받았거나 특허등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권(이하 “특허권등”이라 한다)에 대하여 통상실시권(通常實施權)을 가진다. 다만, 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2013.7.30>
1. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등에게 특허등을 받을 수 있는 권리나 특허권등을 승계시키는 계약 또는 근무규정
 2. 종업원 등의 직무발명에 대하여 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약 또는 근무규정
- ② 제1항에도 불구하고 공무원 또는 국가나 지방자치단체에 소속되어 있으나 공무원이 아닌 자(이하 “공무원등”이라 한다)의 직무발명에 대한 권리는 국가나 지방자치단체가 승계할 수 있으며, 국가나 지방자치단체가 승계한 공무원등의 직무발명에 대한 특허권등은 국유나 공유로 한다. 다만, 「고등교육법」 제3조에 따른 국·공립학교(이하 “국·공립학교”라 한다) 교직원의 직무발명에 대한 권리는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」 제11조제1항 후단에 따른 전담조직(이하 “전담조직”이라 한다)이 승계할 수 있으며, 전담조직이 승계한 국·공립학교 교직원의 직무발명에 대한 특허권등은 그 전담조직의 소유로 한다. <개정 2021. 4. 20>
- ③ 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효로 한다.
- ④ 제2항에 따라 국유로 된 특허권 등의 처분과 관리(특허권 등의 포기를 포함한다)는 「국유재산법」 제8조에도 불구하고 지식재산처장이 이를 관장하며, 그 처분과 관리에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009.1.30, 2010.1.27>

1. 의 의

「직무발명에 대한 통상실시권」이란 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때 사용자 등에게 그 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다(發振法 10①).

2. 취 지

발명진흥법은 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 원시적으로 발명자인 종업원 등에게 귀속한다고 하는 한편 사용자 등에게는 그 직무발명의 탄생에 기여한 점을 인정하여 법정실시권을 인정하고 있다.

3. 성립요건

(1) 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고, 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명일 것

이에 대한 구체적인 내용은 「제2편 제4장 제3절 직무발명」에서 살펴본 바와 같다.

(2) 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 것
실시권의 부수성으로 인해 종업원 등 또는 그 승계인이 특허를 받은 경우에만 실시권이 발생한다.

(3) 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 예약승계에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하였을 것

1) 예약승계계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니하였는데 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 법정실시권이 발생하지 않는다. 이는 대기업의 직무발명보상제도 도입을 적극적으로 유도함으로써 기업 전반에 상당한 보상문화를 정착시키기 위함이다. 중소기업의 경우 예약승계계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하지 아니하여도 법정실시권이 인정되지만 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 미승계통지를 하거나, 승계통지를 하였으나 종업원 등의 의사와 달라서 직무발명에 대한 권리의 승계가 되지 않아야 한다. 즉 사용자 등이 승계 여부를 통지하지 아니한 경우에는 법정실시권이 발생하지 아니한다(發振法 13③).

2) 한편 예약승계계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하여 이를 정한 경우에는 그 권리는 발명을 완성한 때부터 사용자 등에게 승계되기 때문에 법정실시권은 혼동에 의해 소멸하나, 사용자 등이 대통령령으로 정하는 기간에 종업원 등에게 미승계통지를 한 경우에는 법정실시권이 인정된다(發振法 13①).

4. 범 위

사용자의 이익 보호를 위하여 특허발명 전체에 대하여 통상실시권을 인정한다.

5. 대 가

산업정책적인 측면보다 직무발명의 탄생에 기여한 사용자 등의 이익형량을 고려한 공평의 견지에서 인정되는 실시권이므로 사용자 등은 무상으로 특허발명을 실시할 수 있다.

II. 디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권

제105조 【디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권】

- ① 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료될 때에는 그 디자인권자는 그 디자인권의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 그 디자인권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

- ② 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료될 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 권리를 가진 자는 원(原)권리의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 그 디자인권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.
1. 그 디자인권의 존속기간 만료 당시 존재하는 그 디자인권에 대한 전용실시권
 2. 그 디자인권이나 그 디자인권에 대한 전용실시권에 대하여 「디자인보호법」 제104조제1항에 따라 효력이 발생한 통상실시권
- ③ 제2항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
[전문개정 2014.6.11.]

1. 의 의

「디자인권 존속기간 만료 후의 통상실시권」이란 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료될 때에는 그 디자인권자에게 그 디자인권의 범위에서, 디자인권에 대한 전용실시권자 또는 그 디자인권이나 전용실시권에 관한 등록된 통상실시권을 가진 자에게 원(原)권리의 범위에서 그 특허권 또는 그 디자인권의 존속기간이 만료 당시 존재하는 그 특허권의 전용실시권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다(法 105).

2. 취 지

1) 디자인보호법과 특허법은 선출원주의가 적용되지 아니하므로 디자인과 발명이 동일하더라도 각각 디자인권과 특허권이 발생할 수 있는데, 이를 저촉관계라 한다. 이처럼 디자인권과 특허권이 저촉되는 경우에 제98조에 의하면 선출원우위의 원칙에 따라 해결한다. 즉 특허출원일 전에 출원되어 등록된 디자인권이 특허권과 저촉되는 경우 디자인권자는 특허권에 구속되지 않고 자유로이 등록디자인을 실시할 수 있고, 특허권자는 특허발명을 실시하려면 디자인권자의 허락을 받거나 통상실시권허락심판을 청구하여야 한다. 한편 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 특허권과 저촉되는 경우 제98조가 적용되지 않으므로 양자 모두 자유롭게 등록디자인과 특허발명을 실시할 수 있다.

2) 특허법은 이처럼 양 권리가 병존하는 경우뿐만 아니라 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간 만료(403)로 먼저 소멸하더라도 법정실시권을 인정하여 계속 등록디자인을 실시할 수 있도록 함으로써 선출원 권리자인 디자인권자를 보호하는 한편 그 디자인권자가 갖추어놓은 산업설비를 보호해주고 있다.

3. 성립요건

(1) 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 디자인권이 등록될 것

403) 디자인권은 설정등록한 날부터 발생하며 디자인등록출원일 후 20년이 되는 날까지 존속한다(디자인 91①).

디자인등록출원이 특허출원일 전이거나 최소한 특허출원일과 같은 날의 출원이어야 한다. 디자인등록출원이 저촉되는 특허권의 특허출원일보다 후출원이면 디자인권자는 디자인권의 존속기간 중에는 물론 존속기간 만료로 소멸한 후에도 선출원 특허권자의 동의 등이 있어야만 등록디자인을 실시할 수 있다.

(2) 등록된 디자인권이 특허권과 저촉될 것

디자인권이 특허권과 저촉관계에 있어야 한다. 저촉이란 특허권이 타인의 디자인권과 완전히 동일한 것으로서, 두 개의 권리가 중복되어 그 어느 쪽을 실시해도 타방의 권리를 실시하게 되는 쌍방적 충돌관계를 말한다. 특허발명이 등록디자인을 이용하는 경우에는 구성요소완비의 원칙에 따라 등록디자인을 실시하는 것이 특허권의 침해가 되지 않으므로 법정실시권을 인정할 필요가 없다.

(3) 디자인권이 존속기간 만료로 소멸할 것

디자인권이 존속기간의 만료로 소멸한 경우에 한한다. 따라서 등록료의 불납, 디자인권의 포기 또는 무효심판 등의 사유로 소멸하면 법정실시권이 인정되지 아니한다.

4. 주체 및 범위

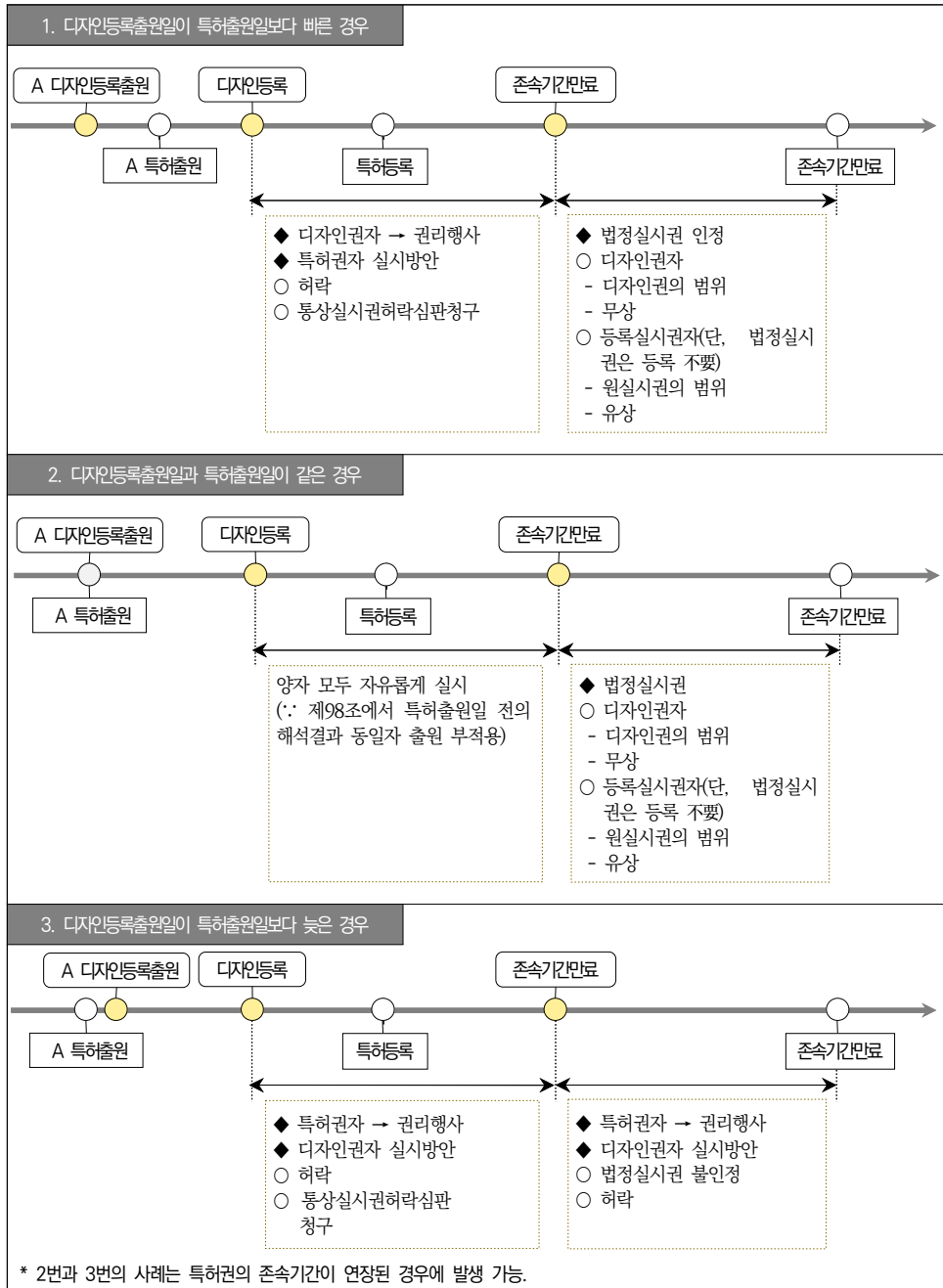
i) 존속기간의 만료로 소멸한 디자인권의 디자인권자는 그 디자인권의 범위에서, ii) 디자인보호법 제104조제1항의 효력을 가지는 통상실시권을 가진 자, 즉 존속기간의 만료로 인하여 소멸한 디자인권의 소멸시에 존재하는 등록된 실시권자(전용실시권자, 등록된 통상실시권자) 및 등록하지 아니하여도 동일한 효력을 가지는 법정실시권자는 원권리의 범위에서 법정실시권을 갖는다.

5. 대 가

디자인권자에게 법정실시권을 인정하는 이유는 공평의 견지에서 특허출원보다 선출원 또는 특허출원과 동일(同日)출원인 디자인권자를 보호하기 위해서이기 때문에 디자인권자는 대가를 지급하지 아니하여도 된다. 다만 존속기간 만료 당시 그 디자인권에 존재하는 등록된 실시권자(전용실시권자, 등록된 통상실시권자) 및 등록하지 아니하여도 동일한 효력을 가지는 법정실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 105③). 실시권자에게는 공평의 견지보다는 산업설비의 보호라는 경제적인 측면에서 법정실시권을 인정하기 때문이다.

【표 6-15】 저촉관계에 있는 경우 존속기간 만료에 의한 법정실시권의 발생 여부

유 형	출원일	존속기간만료일	법정실시권인정 여부
특허권과 상표권	특허권 ≥ 상표권	특허권 > 상표권	○(商標 제98조)
	상표권 ≥ 특허권	상표권의 존속기간은 무한	×
특허권과 디자인권	특허권 ≥ 디자인권	특허권 > 디자인권	○(디자인 제103조)
	디자인권 ≥ 특허권	디자인권 > 특허권	○(法 제105조)



【그림 6-21】 저촉된 디자인권과 특허권의 취급

Ⅲ. 질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권

제122조 【질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권】

특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. <개정 2021. 10. 19.>[전문개정 2014.6.11.]

1. 의 의

「질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권」이란 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)가 그 특허발명을 실시하고 있는데 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전된 경우 그 특허발명에 대하여 해당 특허권자에게 인정되는 통상실시권을 말한다(法 122).

2. 취 지

(1) 질권행사로 인한 경우

특허권자가 채무를 이행하지 아니한 경우 질권자는 특허권을 경매하여 그 가액으로 우선변제를 받고 특허권은 경락자에게 이전된다. 이 경우 특허권자가 질권설정 이전부터 특허발명을 실시하고 있었는데 특허권의 이전에 의하여 특허발명을 실시하지 못한다면 이미 실시를 위해 갖추어놓은 산업설비를 폐기하여야 하므로 특허법은 법정실시권을 인정하여 그 산업설비를 보호해 주고 있다.

(2) 공유특허권의 분할청구로 인한 경우

공유특허권의 공유자가 공유특허권의 관리나 활용에 이견이 있는 경우 공유자 중 일부는 공유특허권의 분할청구를 할 수 있다.⁴⁰⁴⁾ 그 결과 공유자 중 일부가 공유특허권을 경매에 부치게 되면 그 권리 전체가 타인에게 이전되고 다른 공유자는 자신의 의사와 상관없이 지분비율에 따라 대금을 배당받고 특허권을 상실하게 된다. 이 경우 특허권을 상실한 공유자는 본인의 의사와 상관없이 실시사업을 중단하여야 하므로, 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 법정실시권을 인정하여 산업설비를 보호해 주고 있다.⁴⁰⁵⁾

404) 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578.

405) 채수근 수석전문위원, 특허법 일부개정법률안, 디자인보호법 일부개정법률안, 상표법 일부개정법률안 검토보고(송갑석 의원 대표발의(의안번호 제2104891호, 제2104892호 및 제2104893호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2. 30면 참조.

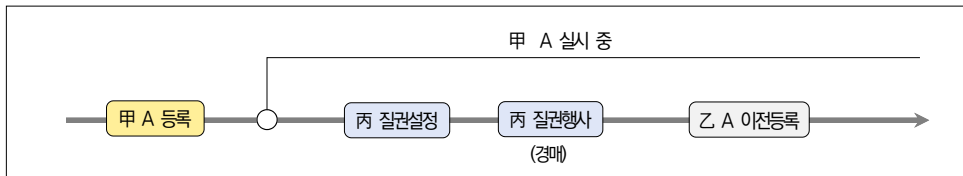
3. 성립요건

(1) 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 특허발명을 실시 중일 것

특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 특허발명을 실시 중이어야 한다. 따라서 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이후에 특허발명을 실시 중인 경우, 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 단지 실시사업을 준비하고 있던 경우에는 법정실시권이 발생하지 아니한다.

(2) 특허권이 경매 등에 의하여 이전되었을 것

특허권이 경매 등에 의하여 타인에게 이전되어야 한다.



【그림 6-22】 질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권의 예

4. 주체 및 범위

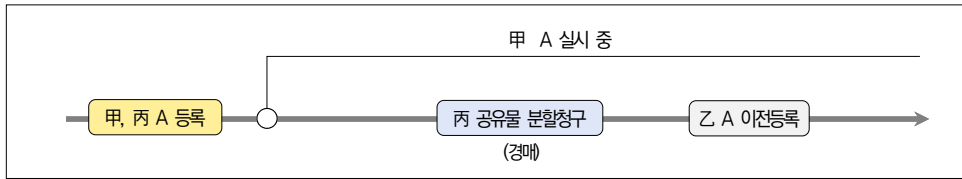
(1) 주 체

1) 질권행사로 이전된 경우에는 질권이 설정된 前 특허권자가, 공유인 특허권의 분할청구로 이전된 경우에는 분할청구를 한 공유특허권자를 제외한 나머지 공유특허권자가 법정실시권을 가진다.

2) 한편 그 특허권에 존재하는 전용실시권자, 등록된 실시권자 또는 법정실시권자는 법정실시권을 가지지 못한다. 특허권의 이전은 주체의 변경이므로 부수적인 권리인 실시권의 소멸이 아니고 오히려 등록된 실시권자는 법정실시권이 인정되지 아니한다고 하더라도 새로운 특허권자에게 효력을 주장할 수 있기 때문이다.

(2) 범 위

통상실시권의 범위에 대하여 법에서 특별히 규정하고 있지 않기 때문에 i) 특허권자가 질권설정 이전에 현실로 실시하고 있던 특허발명의 범위로 한정하여야 한다는 견해(제한설)와 ii) 제한이 없이 특허발명 전범위에 대하여 실시할 수 있다는 견해(무제한설)가 있다. 이에 대하여 원래 특허권자였고 통상실시권에 대하여 상당한 대가를 지급한다는 점에 비추어 무제한설이 타당하다고 여겨진다.



【그림 6-23】 공유특허권의 분할청구로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권의 예

5. 대가

경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 122). 이는 산업설비 보호 측면이 강하기 때문이다.

IV. 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권

제81조의3 【특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등】

- ① 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 그 특허료를 내거나 보전할 수 있다. 다만, 추가납부기간의 만료일 또는 보전기간의 만료일 중 늦은 날부터 1년이 지난 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2021. 10. 19.>
- ② 제1항에 따라 특허료를 내거나 보전한 자는 제81조제3항에도 불구하고 그 특허출원을 포기하지 아니한 것으로 보며, 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.
- ③ 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸한 경우 그 특허권자는 추가납부기간 또는 보전기간 만료일부터 3개월 이내에 제79조에 따른 특허료의 2배를 내고, 그 소멸한 권리의 회복을 신청할 수 있다. 이 경우 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.
- ④ 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원 또는 특허권의 효력은 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간(이하 이 조에서 “효력제한기간”이라 한다) 중에 타인이 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 행위에 대해서는 그 효력이 미치지 아니한다.
- ⑤ 효력제한기간 중 국내에서 선의로 제2항 또는 제3항에 따른 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ⑥ 제5항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.
- ⑦ 제1항 본문에 따른 납부나 보전 또는 제3항 전단에 따른 신청에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

[시행일:2014.6.11.] 제81조의3제3항

[시행일:2015.1.1.] 제81조의3

1. 의 의

「특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권」이란 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원 또는 특허권의 효력제한기간 중 국내에서 선의로 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다(法 81의3⑤).

2. 취 지

1) 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다(法 81③).

2) 특허법은 이 경우 특허료 불납 또는 미납에 의한 특허출원의 포기 또는 특허권의 소멸상태를 신뢰한 선의의 실시자를 보호하고 그 실시로 인하여 갖추어진 산업시설을 보호함으로써 산업발전 이바지라는 법 목적을 달성하기 위해 회복한 특허출원과 특허권에 대하여 법정실시권을 인정하고 있다.

3. 성립요건

(1) 회복한 특허출원 또는 특허권의 효력제한기간 중의 실시일 것

1) 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원 또는 특허권의 효력제한기간 중이어야 한다. 「회복한 특허출원 또는 특허권」이란 i) 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 정당한 사유로 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하였는데 그 사유가 소멸한 날로부터 2개월 및 추가납부기간의 만료일과 보전기간의 만료일 중 늦은 날로부터 1년 이내에 그 특허료를 내거나 보전하여 특허출원이 설정등록되거나 또는 특허권이 회복된 경우(法 81의3①)와 ii) 추가납부기간에 특허료를 내지 아니하였거나 보전기간에 보전하지 아니하여 특허발명의 특허권이 소멸하였는데 추가납부기간 또는 보전기간 만료일로부터 3개월 이내에 특허료의 2배를 납부하여 특허권이 회복된 경우를 의미한다(法 81의3③).

2) 「효력제한기간」이란 특허료 추가납부기간 또는 보전기간이 지난 날부터 특허료를 내거나 보전한 날까지의 기간을 말한다.

(2) 선의일 것

「선의」란 특허출원 또는 특허권이 소멸되었음을 신뢰하고 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 자를 말한다.

(3) 국내일 것

특허출원된 발명 또는 특허발명의 업으로 실시하거나 이를 준비하는 것은 국내에서 이루어져야 한다. 이는 특허권의 효력이 국내에만 미치며, 가급적 국내투자를 장려하기 위함이다.

(4) 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있을 것

특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있어야 한다. 즉 그 발명의 실시사업을 하거나 사업준비를 하고 있어야 한다. 「실시사업」이란 사용자가 계속의 의사를 가지고 발명을 실시하는 것을 의미하고, 「사업준비」란 사업을 개시하기 위한 예비행위로서 즉시 실시할 의도가 있고 객관적으로 인정되는 것이어야 한다. 예를 들어 단지 머릿속에서 발명의 실시를 하려고 생각하였든가, 실시에 필요한 기계구입을 위하여 은행에 자금대출의 신청을 하였다고 하는 정도로는 사업의 준비라고 할 수 없을 것이다. 그렇지만 그 사업에 필요한 기계를 발주하여 이미 설비를 갖추었다든가 고용계약을 체결하여 상당한 선전활동을 하고 있었으면 사업준비에 포함될 것이다.⁴⁰⁶⁾

4. 범 위

1) 「그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위」에서 통상실시권을 갖는다. 「발명의 범위」와 관련해서는 발명의 형태 또는 형식을 변경하는 것이 인정되는지가 문제이다. 이에 대해서는 i) 외관을 중시하여 실시형태가 변경되면 법정실시권이 인정되지 아니한다는 「실시형태설」과, ii) 발명의 핵심적 사상을 중시하여 실시형태가 변경되더라도 발명의 사상이 변경되지 않았다면 법정실시권이 인정된다는 「사상설」이 있다. 제81조의3제5항에서는 「발명의 범위」라고 규정하고 있을 뿐이고 「형태 또는 형식의 범위」라고는 하지 아니함에 비추어 볼 때 그 형태나 형식의 변경이 이른바 균등의 범위에 속한 경우에는 발명의 범위에 속하는 것으로 해석하여 실시권의 범위에 속한다고 보며 그렇지 않으면 실시권의 범위에서 제외되는 것으로 보는 것이 일반적이다.⁴⁰⁷⁾

406) 지식재산청, 「조문별 특허법 해설」, 2002, 255면.

407) 서울중앙지방법원 2009. 2. 18. 선고 2007가합77557 판결은 “선사용에 의한 통상실시권의 효력은 이 사건 특허발명 출원 당시 피고가 실시하고 있던 실시형태뿐만 아니라 이것에 구현된 발명과 동일성의 범위에서 변형 가능한 실시형태에도 미치는 것으로 봄이 상당하다”라고 판시하여 이를 긍정하고 있다. 이와 관련되어 일본 최고재판소도 “실시하거나 준비하고 있는 발명의 범위란, 특허발명의 특허출원 시 선사용권자가 실제로 일본 국내에 있어서 실시하거나 준비하고 있었던 실시형태에 한정되는 것이 아니라, 그 실시형식으로 구현되어 있는 기술적 사상, 즉 발명의 범위를 말하는 것이고, 따라서 선사용권의 효력은 특허출원 시 선사용권이 실제로 실시하거나 준비하고 있었던 실시형식뿐만 아니라 이것에 구현된 발명과 동일성을 잃지 아니하는 범위에 있어서 변경한 실시형식에도 미치는 것으로, 선사용권 제도의 취지가 주로 특허권자와 선사용권자간의 공평을 꾀하는 것에 있는 것에 비추어보면, 특허출원 시 선사용권자가 실제로 실시하거나 준비하고 있는 실시형식 이외로 변경하는 것을 일체 인정하지 아니한 것은 선사용권자에게 있어서 가혹하고 상당하지도 아니하다”라고 하여 동일한 취지로 판시하였다(日最高裁判 1986(昭和61).10.3 1986(昭和61)(才) 454号, 519면).

2) 「사업목적의 범위」와 관련해서는 효력제한기간 중의 사업목적의 범위에 한정되며 동일한 사업목적의 범위에서라면 양적 확장(예컨대 공장부지의 확장, 종업원의 증원, 영업소의 확장 등)은 인정된다. 다만 효력제한기간 중의 사업목적의 범위를 벗어난 질적 확장은 인정되지 아니한다(예컨대 효력제한기간 중에는 선박 제조 사업만을 사업 목적으로 하였는데, 효력제한기간이 지난 후 항공기 제조 사업도 사업 목적으로 추가한 경우에는 항공기 제조 사업에는 법정 실시권이 인정되지 아니한다).

5. 대가

공평의 견지보다는 효력제한기간 중 실시를 통한 설비 또는 사업을 보호한다는 산업정책적인 고려에서 인정되는 권리이므로 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자⁴⁰⁸⁾에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 81의3⑥).

V. 선사용에 의한 통상실시권

제103조 【선사용에 의한 통상실시권】

특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

[전문개정 2014.6.11.]

1. 의의

「선사용에 의한 통상실시권」이란 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다(法 103). 이를 강학상 「선사용권(先使用權)」이라 한다.

2. 취지

특허법은 특허권자와 선사용자 사이의 공평을 도모하는 한편 선사용자의 사업설비 등의 이용을 불가능하게 하는 것은 산업정책상 바람직하지 않기 때문에 선사용권을 인정하고 있다.⁴⁰⁹⁾

408) 다만 제81조의3제5항에 따라 특허권에 대하여 통상실시권을 가지니, 전용실시권은 삭제하는 것이 바람직하다고 할 것이다.

409) 선사용권을 인정하는 근거에 대해서는 i) 획일적인 선출원주의의 원칙을 관철함으로써 발생하는 불합리를 시정하고, 선발명자와 선출원자 간의 보호의 균형을 위한 것이라는 선발명자보호설, ii) 특허출원

3. 성립요건

(1) 특허출원 시의 실시일 것

1) 선사용권의 발생이 인정되기 위해서는 그 특허출원 시를 기준으로 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있어야 하므로⁴¹⁰⁾ 과거에 그런 사실이 있었다거나 그 후에 실시가 폐지되어 버린 경우 등과 같이 출원 시 그 실시사업을 지속하고 있지 않으면 선사용권이 발생하지 아니한다.

2) 특허출원 시는 i) 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②), 변경출원(法 53②)의 경우 원출원일, ii) 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 선출원일, iii) 국제특허출원의 경우 우선일의 출원 시를 기준으로 판단한다.

(2) 선의일 것

1) 「선의」란 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 된 것을 말한다.⁴¹¹⁾ 타인으로부터 발명을 알게 된 경우에 그것이 선의라면 그 발명을 알게 된 경로(route)는 문제되지 않으나, 선사용되는 발명의 과도한 보호를 방지하기 위하여 특허출원한 발명자로부터 발명을 알게 된 경우는 제외되는 것으로 해석함이 일반적이다.⁴¹²⁾

2) 한편 정당한 권리자인 발명자 또는 이로부터 발명을 알게 된 자가 실시사업 등을 하고

시에 이미 실시하거나 실시준비를 하는 선의의 사업자가 그 후에 설정등록된 특허권 때문에 실시를 계속할 수 없게 되는 것은 선의의 선사용자를 희생시키고 특허권자를 지나치게 보호하는 것이 되어 현저하게 공평에 반한다는 공평설, iii) 특허출원 시에 이미 실시하고 있거나 실시준비를 하는 사업의 계속을 불가능하게 하는 것은 선의의 사업자에게 지나치게 가혹할 뿐만 아니라 산업정책상 바람직하지 않다는 경제설, iv) 발명자는 국민의 교사라는 이론적 배경하에서 선사용자는 특허권자의 발명으로부터 가르침을 받는 것이 아니므로 특허권에 복종할 필요가 없다는 교사설(教師設), v) 노하우에 대해서도 특허법상 보호가 필요하며 선사용권은 그러한 의지의 표현이라는 노하우보호설 등이 있다. 이 중 선발명자보호설은 후발명자가 먼저 실시사업을 할 때에도 선사용권이 인정된다는 점에서 타당하지 않으며, 교사설은 선사용권의 인정대상에 있어서 모든 선발명자를 대상으로 하지 않고 특허출원 시에 실제로 사업실시나 준비를 하는 자에게만 한정하는 이유를 설명할 수 없는 문제점이 있다. 또한 노하우보호설은 선사용이 비밀로 이루어졌으면 설명할 수 있지만 공공연하게 사용된 경우에는 적용되지 못하는 이론상 문제점이 있다. 따라서 공평설과 경제설을 종합한 공평경제설이 타당하다.

410) 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272.

411) 피고가 본건 디자인등록출원 이전에 타회사로부터 납품의뢰를 받고 그 회사로부터 교부받은 제작도면에 의거하여 본건 제품을 제조납품하였고 한편 위 회사가 교부한 제작도면은 그 소속직원이 유사한 외국 제품을 모방하여 만든 것이라면 피고는 본건 디자인등록 출원 당시에 선의로 국내에서 그 디자인의 실시사업을 한 자라고 할 것이므로 그 사업의 목적범위에서는 통상실시권을 가진다(서울민사지방법원 1984. 4. 26. 선고 83가합7487).

412) 乙이 인용고안에 관한 실용신안등록출원을 하여 그 출원이 공개되었다가 특허거절결정되었다 하더라도, 이 사건 특허발명의 출원일자가 이 사건 인용고안의 출원공개일 이전이므로 이 사건 인용고안이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지된 것이라고 볼 수 없다. 또한 乙은 甲이나 다른 사람이 직조한 편포를 납품받아 사람의 손으로 합성수지 외면에 납품받은 편포를 끼우는 방법으로 호스를 제조하여 판매하던 중 甲의 특허출원 후 甲의 종업원으로부터 이 사건 특허발명을 알게 되어 같은 제조방법으로 호스를 생산하여 전국에 걸쳐 판매하고 있는 경우, 甲의 이 사건 특허발명에 대한 특허출원 전부터 이 사건 특허발명의 실시사업을 하였음을 전제로 하여 乙이 이 사건 특허발명에 대하여 선사용에 의한 통상실시권을 가지고 있다고 할 수 없다(대구고등법원 1992. 6. 26 선고 92라7).

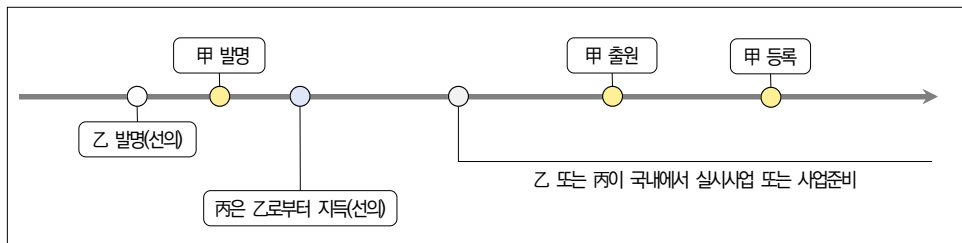
있는데 모인출원하여 등록된 무권리자의 특허가 있는 경우에는 “그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나”의 문언적 해석상 선의를 만족하기 때문에 선사용권이 인정된다. 무권리자의 특허가 제33조제1항 본문의 특허요건 흠결이 있다고 하더라도 특허무효심판에 의한 무효심결이 확정되기 전까지는 유효한 권리이므로 침해주장에 대항하기 위하여 선사용권을 인정할 필요가 있다.⁴¹³⁾

(3) 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있을 것

국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있어야 한다. 이에 대한 구체적인 내용은 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권에서 상술한 바와 같다.

4. 범 위

실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 통상실시권을 갖는다. 이에 대한 구체적인 내용은 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권에서 상술한 바와 같다.



【그림 6-24】 선사용권의 구체적 例

5. 대 가

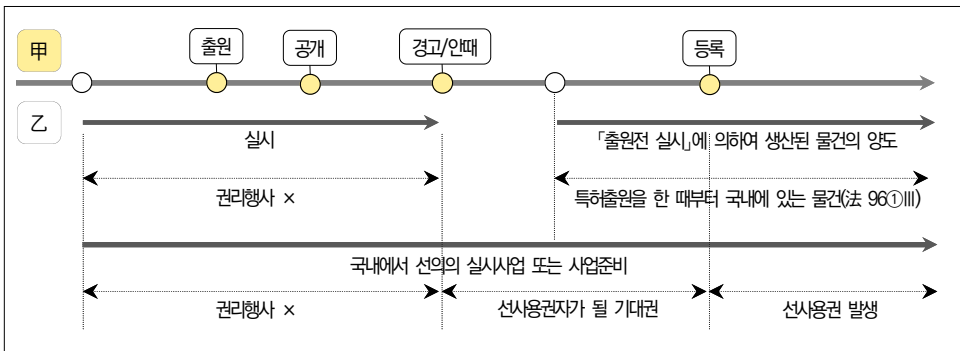
공평의 견지에서 인정되는 권리이므로 특허권자에게 대가의 지급없이 무상으로 특허발명을 실시할 수 있다.

413) 丙이 사용하는 은수저제작방법은 丁 명의로 특허등록된 이 사건 은수저제작방법과 동일한 것이기는 하나 丁 명의의 특허는 甲이 자본을 대고, 丙이 기술을 낸 동업관계이어서 丙에 의하여 발명된 것을 위 甲 내지는 제수인 乙이 일방적으로 특허출원을 한 데 따른 것이고 丁은 위 乙로부터 위 특허권을 양수한 것이므로, 丙이 사용하는 은수저제작방법이 丁 명의로 특허등록된 이 사건 은수저제작방법에서 유래한 것이라고 볼 수 없고, 또한 丙은 위 乙 명의로 특허출원되기 이전부터 이 사건 은수저제작방법과 동일한 방법에 의한 은수저제작판매업을 준비하여 개업한 것이므로, 丙은 이 사건 은수저제작방법에 관하여 선사용에 의한 통상실시권을 갖는다고 할 것이다(부산고등법원 1993. 12. 27. 선고 93라38).

6. 관련문제

(1) 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건과의 관계

특허권의 효력은 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건에 대하여 미치지 아니한다(法 96 ①Ⅲ). 다만 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96 ①Ⅲ)은 동일한 물건일지라도 특허출원 후에는 새로이 생산할 수 없는 데 반해, 선사용권(法 103)이 인정되면 실시자는 선사용권(法 103)에 의하여 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 계속 실시할 수 있으므로 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96 ①Ⅲ)은 선사용권(法 103)이 인정되지 않을 때 실효성이 있다 할 것이다. 이는 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건(法 96 ①Ⅲ)은 단지 기존의 상태를 보호한다는 것에 그 목적이 있는 데 반해 선사용권(法 103)은 특허출원 시 존재하는 기존의 사업설비를 보호한다는 것에 그 목적이 있기 때문이다.



【그림 6-25】 선사용권과 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건과의 관계

(2) 특허권의 발생 전 선사용권자의 지위

특허권이 발생된 후 선사용자는 법정실시권자로서 특허법의 보호를 받는다. 그러나 특허권의 발생 전에는 실시권의 부수성으로 인해 선사용권이 발생하지 않으므로 특허권자가 선사용자의 실시행위에 대하여 보상금청구권을 행사할 수 있는지 문제가 될 수 있다. 선사용권제도의 취지를 고려하여 볼 때 장래 선사용권자로 될 수 있는 자를 특허권의 발생 전이라고 하여 보호하지 아니한 것은 불합리하므로, 특허권의 발생 전이라고 하더라도 선사용권의 요건을 갖춘 자는 선사용권자가 될 기대의 위치에 있는 자로서 선사용권자와 마찬가지로 보호된다고 해석하여야 할 것이다.

VI. 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권

제103조의2 【특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권】

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 제99조의2제2항에 따른 특허권의 이전등록이 있기 전에 해당 특허가 제133조제1항제2호 본문에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 이전등록된 특허의 원(原)특허권자

2. 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.

② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

[본조신설 2016.2.29.]

1. 의 의

「특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권」이란 특허권의 이전청구에 기초하여 특허권의 이전등록이 있기 전에(法 99의2②) 해당 특허가 i) 제33조제1항 본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 ii) 제44조의 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다(法 103의2①).

2. 취 지

특허법은 자신이 등록된 특허의 특허권자라는 것을 신뢰한 자를 보호하는 한편 그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비가 산업발전에의 이바지라는 법 목적에 비추어 보호해 줄 가치가 있으므로 법정실시권을 인정하고 있다.

3. 성립요건

(1) 특허권의 이전청구에 기초하여 특허권의 이전등록이 있기 전의 실시일 것

i) 제33조제1항 본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 ii) 제44조의 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 경우에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 법원에 해당 특허권의 이전(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)을 청구할 수 있고, 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우에는 해당 특허권과 보상금 지급 청구권(法 65②, 207④)은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 보는데(法 99의2①②), 이러한 이전청구에 기초하여 이전등록이 있기 전의 실시이어야 한다.

(2) 선의일 것

「선의」란 해당 특허가 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 것을 알지 못하는 것을 말한다. 결국 선의의 요건을 충족하기 위해서는 법원의 이전청구가 있다는 것을 알기 전부터 실시하고 있어야 할 것이다.

(3) 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있을 것

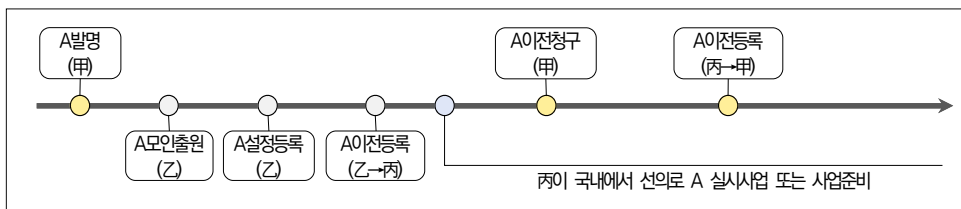
국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있어야 한다. 이에 대한 구체적인 내용은 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권에서 상술한 바와 같다.

4. 주체 및 범위

(1) 주 체

① 이전등록된 특허의 원(原)특허권자(法 103의2①Ⅰ)

특허권이 이전등록된 경우 이전등록된 특허의 원(原)특허권자가 통상실시권을 가진다. 여기서 원특허권자란 최초의 특허를 받은 특허권자만이 아니라 그 특허권을 양도받은 새로운 특허권자도 포함되는 개념이다. 다만 제33조제1항본문 또는 제44조 위반임을 알고 출원한 자나 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 양수한 자는 제103조의2제1항 본문의 「선의」라 할 수 없으므로 통상실시권을 가질 수 없다.



【그림 6-26】 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권의 예1

② 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자(다만 법정실시권의 경우에는 등록 不要)(法 103의2①Ⅱ)

특허권의 이전청구에 기초하여 특허권이 이전등록된 경우 특허권은 처음부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 보므로(法 99의2②) 기존 특허권자로부터 허락받은 전용실시권이나 통상 실시권은 효력이 없다. 그러나 실시권자가 갖추어놓은 산업설비를 보호하기 위해 법정실시권을 인정하고 있다. 한편 원칙적으로 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 등록된 실시권

자만이 통상실시권을 가질 수 있으나 법정실시권은 등록하지 아니하여도 새로운 특허권자 등에게 그 효력을 주장할 수 있으므로 이전등록 당시에 존재하고 있는 법정실시권자 역시 통상 실시권을 가진다.

(2) 범 위

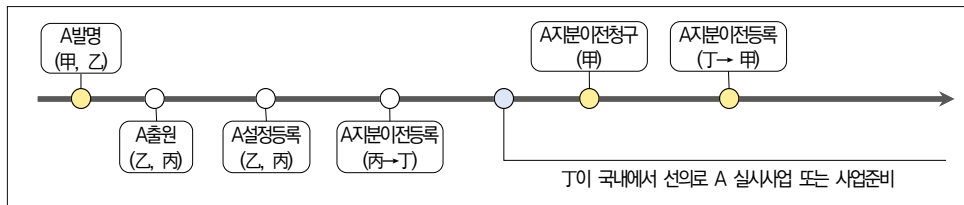
실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 통상실시권을 갖는다. 이에 대한 구체적인 내용은 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권에서 상술한 바와 같다.

5. 대 가

선출원된 특허권자 이익의 고려 및 공평의 견지보다는 무권리자로 된 자의 설비 또는 사업을 보호한다는 산업정책적인 견지에서 인정되는 권리이므로 통상실시권자는 이전등록된 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 103의2②).

6. 관련문제

이전청구에 기초하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록(法 99의2)이 있으면 이전등록된 특허권(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의 이전을 말한다)은 특허무효심판을 청구할 수 있는 대상에서 제외된다(法 133①Ⅱ단서). 이는 이전청구에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록된 특허권이 애초에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 출원이 아니라는 점을 이유로 무효로 되는 것을 방지하기 위함이다.



【그림 6-27】 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권의 예2

VII. 무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권

제104조 【무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권】

① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 통상실시권을 가지거나 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.

1. 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
 2. 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자
 3. 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자
 4. 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자
 5. 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자. 다만, 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다.
- ② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

1. 의 의

「무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권」이란 특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권 또는 그 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다(法 104①). 이를 강학상 「중용권(中用權)」이라 한다.

2. 취 지

특허법은 자신의 등록이 적법한 것으로 믿고 실시하고 있는 자, 즉 지식재산처의 행정처분을 선의로 신뢰한 자를 보호하는 한편 그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비가 산업발전의 이바지라는 법 목적에 비추어 보호해 줄 가치가 있으므로 법정실시권을 인정하고 있다.⁴¹⁴⁾

414) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 257면. 다만 私見으로는 등록이 적법하기 때문에 특허발명을 실시하는 것이 침해가 아니라고 믿는 자를 보호하는 것은 제98조의 이용·저촉에 관한 규정에 비취웠을

3. 성립요건

(1) 무효심판청구 등록 전의 실시일 것

여기에서 등록은 예고등록을 말하는데, 「예고등록」이란 특허권에 대한 무효심판청구 등과 같은 분쟁이 발생한 경우에 그 분쟁사실을 공중에게 알리기 위하여 지식재산청장이 직권으로 특허원부에 그 심판청구사실을 등록하는 것을 말한다(登録令 6).

(2) 선의일 것

「선의」란 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하는 것을 말한다.

(3) 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있을 것

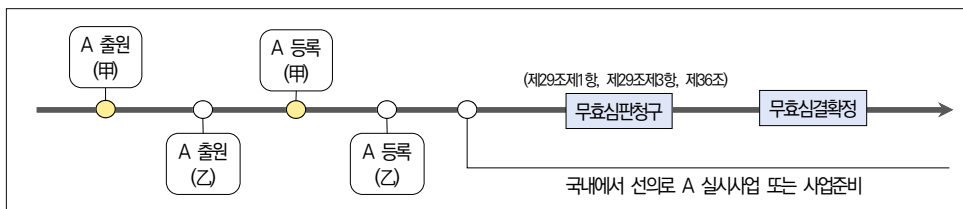
국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있어야 한다. 이에 대한 구체적인 내용은 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권에서 상술한 바와 같다.

4. 주체 및 범위

(1) 주 체

- ① 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자 또는 특허발명과 등록실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原)실용신안권자(法 104① I II)

「동일한 발명」이란 청구범위에 기재된 발명이 동일한 경우를 말한다. 따라서 둘 이상의 특허 중 그 하나를 무효로 한 경우란 신규성(法 29①각호), 확대된 선출원(法 29③④) 또는 선출원주의(法 36)의 위반임에도 불구하고 중복특허된 경우에 그중 하나의 특허에 관하여 제133조의 특허무효심판에 의한 무효심결이 확정된 경우를 말한다. 여기서 원특허권자란 최초의 특허를 받은 특허권자만이 아니라 그 특허권을 양도받은 새로운 특허권자도 포함되는 개념이다.

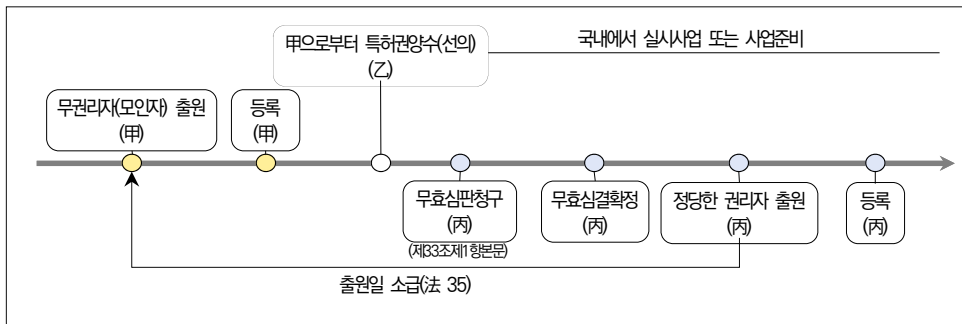


【그림 6-28】 중용권의 예 1

때 타당하지 않다고 생각된다. 오히려 특허발명을 실시하는 것이 침해되더라도 적법하게 등록되었다면 이용발명에 해당하기 때문에 제138조의 통상실시권허락심판의 청구에 의하여 강제실시권을 허락받아 특허발명을 실시할 수 있다는 것을 믿는 자를 보호하는 것이 중용권의 취지로 적당하다고 사료된다.

- ② 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자 또는 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자(法 104①ⅢⅣ)

특허(실용신안)를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 무권리자에 의하여 출원되었음에도 착오로 특허권이 발생하여 특허(실용신안등록)가 무효로 되고 정당한 권리자에게 특허가 된 경우 무권리자인 원특허권자(실용신안권자)가 통상실시권을 가진다. 다만 모인자 혹은 무권리자임을 알고 양수한 자는 제104조제1항 본문의 「선의」라 할 수 없으므로 통상실시권을 가질 수 없다.



【그림 6-29】 중용권의 예 2

- ③ 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권을 취득하고 그 등록을 받은 자(다만 법정실시권의 경우에는 등록 不要)(法 104①Ⅴ)

원칙적으로 무효심판청구 등록 당시에 등록된 실시권자만이 중용권을 가질 수 있으나 법정 실시권은 등록하지 아니하여도 새로운 특허권자 등에게 그 효력을 주장할 수 있으므로 무효심판청구 등록 당시에 존재하고 있는 법정실시권자 역시 중용권을 가진다.

(2) 범 위

실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 통상실시권을 갖는다. 이에 대한 구체적인 내용은 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권에서 상술한 바와 같다.⁴¹⁵⁾

5. 대 가

선사용권의 경우에는 특허권자와 선사용권자 간의 이익조정이라는 공평의 이념이 고려되고 있으므로 무상으로 특허발명을 실시할 수 있으나 중용권의 경우에는 선출원된 특허권자 이익의

415) 무효심판은 복수항의 청구항이 있는 경우 청구항마다 청구할 수 있고, 그중 일부 청구항이 무효가 된 경우에도 제도적 취지상 중용권이 인정된다(法 215).

고려 및 공평의 견지보다는 후출원권리자, 무권리자로 된 자의 설비 또는 사업을 보호한다는 산업정책적인 견지에서 인정되는 권리이므로 중용권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 104②).

VIII. 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권

제181조 【재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한】

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 수출 또는 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다. <개정 2016. 2. 29., 2025. 1. 21.>
 1. 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우
 2. 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우
 3. 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우
 4. 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우
- ② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나의 행위에 미치지 아니한다. <개정 2016.2.29.>
 1. 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 한 해당 발명의 선의의 실시
 2. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
 3. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 청약하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

제182조 【재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권】

제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다.

<개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

1. 의 의

「재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권」이란 제181조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자에게 그 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 인정되는 통상실시권을 말한다(法 182). 이를 강화상 「후용권(後用權)」⁴¹⁶⁾이라 한다.

2. 취 지

특허법은 특허심판원의 확정된 특허취소결정 또는 심결이라는 공권적 판단을 신뢰한 선의의 실시자를 보호하는 한편 그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비가 산업발전에 이바지라는 법 목적에 비추어 보호해 줄 가치가 있으므로 법정실시권을 인정하고 있다.

3. 성립요건

(1) 제181조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전의 실시일 것

1) 「제181조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우」이란 i) 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우, ii) 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우⁴¹⁷⁾, iii) 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우 및 iv) 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

2) 해당 특허취소결정 또는 심결 확정 후 재심청구 등록 전에 발명의 실시사업 등을 하고 있어야 하며 재심에 의하여 상반되는 결정 또는 심결이 확정되어야 한다. 「재심청구 등록」이란 재심청구의 예고등록을 말한다.

(2) 선의일 것

「선의」란 해당 특허취소결정 또는 심결에 재심사유가 있음을 알지 못하는 것을 의미한다.

(3) 국내에서 그 발명의 실시사업 또는 그 사업을 준비하고 있을 것

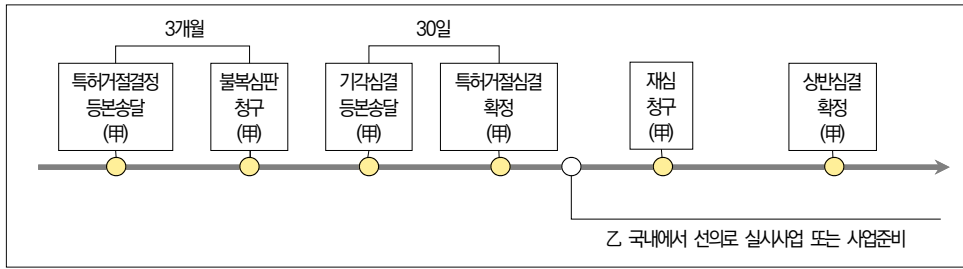
국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있거나 그 사업을 준비하고 있어야 한다. 이에 대한 구체적인 내용은 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권에서 상술한 바와 같다.

4. 범 위

실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 통상실시권을 갖는다. 이에 대한 구체적인 내용은 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권에서 상술한 바와 같다.⁴¹⁸⁾

416) 「선사용권」이 출원 전의 사실에 기초해서 발생하는 것이고, 「중용권」이 출원하고 특허권이 발생한 후에 생긴 사유에 의하여 발생한 것인데 반해, 이 통상실시권은 특허권이 소멸한 후에 생긴 일정한 사유에 의하여 발생한 것이므로 「후용권」이라고 한다.

417) 私見으로는, 권리범위확인심판의 심결은 법원의 기속력이 없어서 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정되었다고 하더라도 법원에서 침해로 인정될 수 있는데, 재심에 의하여 상반된 심결을 확정받아 법원에 침해의 소를 제기한 경우 법정실시권이 인정되어 침해가 되지 아니한다는 것은 논리적으로 모순이므로 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 상반된 심결이 확정된 경우는 법정실시권의 발생사유에서 제외됨이 타당하다고 생각된다.



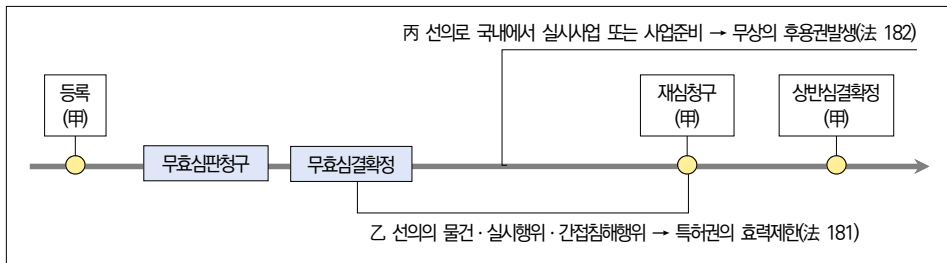
【그림 6-30】 후용권의 例

5. 대 가

산업설비의 보호 측면보다는 확정된 특허취소결정 또는 심결이라는 공권적 판단을 신뢰한 선의의 실시자의 보호 측면이 강하므로 무상으로 특허발명을 실시할 수 있다. 즉 특허권의 소멸이라는 완결된 절차를 밟고 실시한 자에게 대가 지급을 조건으로 실시권이 설정되도록 하면 절차의 안정이 특허권의 효력에 의하여 희생되기 때문에 무상이다.⁴¹⁹⁾

6. 관련문제

제181조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 i) 선의로 수출 또는 수입하거나 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건, ii) 선의의 실시행위 및 iii) 선의의 간접침해행위 중 어느 하나에 대해서는 미치지 아니한다(法 181). 이는 확정된 특허취소결정 또는 심결을 믿고 발명을 실시하였던 자에 대하여 회복된 특허권 등에 관한 효력 제한을 규정함으로써 선의인 자와 특허권자 간에 법적 형평을 도모하고자 한 것이다.



【그림 6-31】 효력제한(法 181)과 후용권(法 182)의 例

418) 청구항별로 무효가 된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우, 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우, 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우에는 제도적 취지상 청구항별로 후용권이 인정된다(法 215).

419) 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 703면.

IX. 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권

제183조 【재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권】

- ① 제138조제1항 또는 제3항에 따라 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에는 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 원(原)통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결이 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

1. 의 의

「재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권」이란 제138조제1항 또는 제3항에 따라 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자에게 원통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결이 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다(法 183). 이것은 강제실시권이 법정실시권으로 전환되는 경우이다.

2. 취 지

특허법은 통상실시권을 허락한다는 확정된 심결을 신뢰한 선의의 실시자를 보호하는 한편 그 실시를 통하여 갖추어진 산업설비가 산업발전에의 이바지라는 법 목적에 비추어 보호해 줄 가치가 있으므로 법정실시권을 인정하고 있다.

3. 성립요건

- (1) 제138조제1항 또는 제3항에 따라 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에 재심청구 등록 전의 실시일 것

통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정되어야 하고 재심청구 등록 전에 발명의 실시사업 등을 하고 있어야 한다. 「재심청구 등록」이란 재심청구의 예고등록을 말한다.

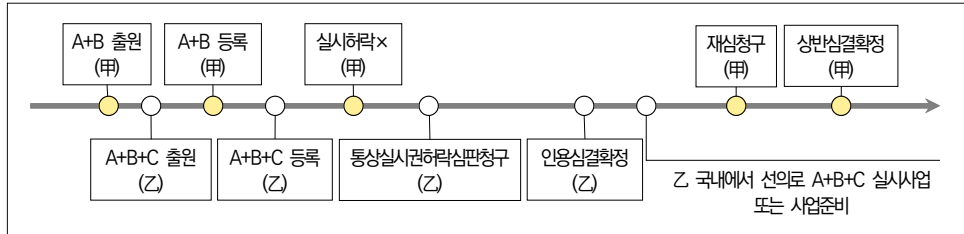
- (2) 선의일 것

「선의」란 통상실시권을 허락한다는 심결에 재심사유가 있음을 알지 못하는 것을 말한다.

- (3) 국내에서 그 발명의 실시사업 또는 그 사업을 준비하고 있을 것

국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있거나 그 사업을 준비하고 있어야 한다. 이에 대한

구체적인 내용은 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권에 대한 통상실시권에서 상술한 바와 같다.



【그림 6-32】 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권의 예

4. 범 위

원통상실시권자의 사업목적 및 발명의 범위에서만 통상실시권을 가진다. 즉 통상실시권의 범위는 원래의 통상실시권허락심판에 의해서 허락된 통상실시권의 범위로 한정된다.

5. 대 가

통상실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 183 ②). 본 조에 따른 통상실시권은 공평의 견지보다는 산업정책적인 측면에서 인정되는 실시권이 고, 통상실시권허락심판에 의하여 강제실시권을 허락받은 경우에 대가를 지급하는데 그 강제 실시권이 재심에 의하여 법정실시권으로 전환되었다고 하여 대가를 지급하지 아니한 것은 논리적으로 맞지 않기 때문이다.

【표 6-16】 제138조에 의한 통상실시권과 제183조의 의한 통상실시권의 차이점 비교

권 리		제138조	제183조
변 동	이 전	실시권의 허락원인이 된 원권리와 함께만 이전가능	1. 실시사업과 함께 2. 상속이나 그 밖의 일반승계 3. 특허권자의 동의
	질권설정	불가	특허권자의 동의 받아야만 가능
	실시권포기	질권설정할 수 없으므로 자유롭게 포기가능	질권자의 동의 받아야만 가능
소 멸		원권리의 소멸	실시사업의 폐지
등 록		지식재산처장이 직권등록을 하여야 대항가능	등록하지 않더라도 대항가능

【표 6-17-(1)】 법정실시권의 요약 정리

권 리		發振法 제10조제1항	제81조의3제5항	제103조	제103조의2
의 의		종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등에게 인정되는 전범위에 대한 통상실시권을 말한다.	특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원 또는 특허권의 효력제한기간 중 국내에서 선의로 특허출원된 발명 또는 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명 또는 특허발명에 대한 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다.	특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허출원된 발명의 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다.	특허권의 이전청구에 기초하여 특허권의 이전등록이 있기 전에(法 99의2②) 해당 특허가 제33조제항본문, 제44조 위반의 특허무효사유(法 133①II)에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다
성립요건	주체적	· 종업원 등이 직무에 관해 발명 · 사용자 등의 업무범위에 속할 것 · 사용자 등이 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업이 아닌 기업인 경우 종업원 등과의 협의를 거쳐 미리 예약승계에 해당하는 계약 또는 근무규정을 체결 또는 작성하였을 것	· 선의 → 특허출원 또는 특허권이 소멸되었음을 신뢰하고 특허출원된 발명 또는 특허발명을 실시한 자	· 선의 → 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 된 자	· 선의 → 제33조제1항 본문, 제44조 위반의 특허무효사유(法 133①II)에 해당하는 것을 알지 못할 것 · 취득할 수 있는 자 원특허권자, 등록된 실시권자(단, 법정실시권자는 등록不要)
	객체적	· 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속할 것	· 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비		
	시기적	· 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받을 것	· 효력제한기간 중	· 특허출원 시	· 특허권의 이전청구에 기초하여 특허권의 이전등록이 있기 전의 실시일 것
	지역적	· 국내			
	발 생	· 법률 규정을 만족하면 발생(등록하지 아니하여도 대항 가능 → 단지 증명책임의 문제)			
효력	범 위	· 특허발명의 범위	· 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위		
	실시금지효	· 없음			
변동	실시권허락	· 설정불가			
	질권설정	· 특허권자의 동의			
	이 전	· 특허권자의 동의, 사업과 함께, 상속이나 그 밖의 일반 승계			
	특허권포기	· 직무발명에 대한 통상실시권자의 경우만 동의가능			
	실시권포기	· 질권자의 동의			
소 멸	· 특허권의 소멸, 실시권의 포기, 특허권의 수용, 혼동, 실시사업폐지(단, 발진법 제10조 제외)				
대 가	· 無	· 有	· 無	· 有	
설정등록효과		· 설정등록하지 않더라도 제3자에게 대항 가능, 그러나 통상실시권의 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한은 등록이 대항요건(法 118)			

【표 6-17-(2)】 법정실시권의 요약 정리

제104조	제105조	제122조	제182조	제183조
특허 또는 실용신안등록에 대한 무효심판청구의 등록 전에 자기의 특허발명 또는 등록실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명 또는 고안의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 또는 고안 및 사업목적의 범위에서 그 특허권 또는 그 특허나 실용신안등록이 무효로 된 당시에 존재하는 특허권의 전용실시권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다.	특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 디자인권이 그 특허권과 저촉되는 경우 그 디자인권의 존속기간이 만료될 때에는 그 디자인권자에게 그 디자인권의 범위에서, 디자인권에 대한 전용실시권자 또는 그 디자인권이나 전용실시권에 관한 등록된 통상실시권을 가진 자에게 원(原)권자의 범위에서 그 특허권 또는 그 디자인권의 존속기간이 만료 당시 존재하는 그 특허권의 전용실시권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다.	특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)가 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다.	제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자에게 원통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결의 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다.	통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자에게 원통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결의 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 인정되는 통상실시권을 말한다.
· 선의 자기의 특허발명 또는 등록 실용신안이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못한 자 · 취득할 수 있는 자 원특허권자 및 원실용신안권자, 무권리자, 등록된 실시권자(단, 법정실시권자는 등록不要)	· 디자인권자 · 등록된 실시권자 (단, 법정실시권자는 등록 不要)	· 전 특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)	· 선의 → 재심사유가 있음을 알지 못한 자	· 선의 → 재심사유가 있음을 알지 못한 자
· 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비	· 특허권과 저촉 · 존속기간 만료로 소멸	· 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시	· 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업의 준비	
· 무효심판청구 등록 전 · 무효사유 → 法 제29조제1항, 제29조제3항 및 제4항, 제36조, 제33조제1항 본문	· 특허출원일 전 또는 특허출원일과 같은 날에 출원되어 등록	· 특허권이 경매 등에 의하여 이전	· i) 무효가 된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우, ii) 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우, iii) 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우 및 iv) 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 심결/결정이 확정된 후 재심청구 등록 전의 사실일 것	· 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정되어야 하고 재심청구 등록 전
· 국내				
· 법률 규정을 만족하면 발생(등록하지 아니하여도 대항 가능 → 단지 증명책임의 문제)				
· 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위	· 디자인권자 디자인권의 범위 · 원실시권자 원권리의 범위	· 특허발명 전체(무제한설이 통설)	· 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위	· 원통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위
· 없음				
· 설정불가				
· 특허권자의 동의				
· 특허권자의 동의, 사업과 함께, 상속이나 그 밖의 일반 승계				
· 없음				
· 질권자의 동의				
· 특허권의 소멸, 실시권의 포기, 특허권의 수용, 혼동, 실시사업폐지(法 제105조, 제122조 제외)				
· 有	· 디자인권자 → 無 · 원실시권자 → 有	· 有	· 無	· 有
· 설정등록하지 않더라도 제3자에게 대항 가능, 그러나 통상실시권의 이전, 변경, 소멸, 처분의 제한은 등록이 대항요건(法 118)				

제5관 강제실시권의 구체적 내용

I. 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권

제106조의2[정부 등에 의한 특허발명의 실시]

- ① 정부는 특허발명이 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적(非商業的)으로 실시할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 그 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다.
- ② 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때에는 제1항에 따른 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 알려야 한다.
- ③ 정부 또는 제1항에 따른 정부 외의 자는 제1항에 따라 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 정당한 보상금을 지급하여야 한다.
- ④ 특허발명의 실시 및 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

1. 의 의

「국가 비상사태 등에 의한 통상실시권」이란 특허발명이 i) 국가 비상사태, ii) 극도의 긴급상황 또는 iii) 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 경우에 정부가 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있는 통상실시권을 말한다(法 106의2①).

2. 취 지

특허법은 국가안보에 큰 영향을 미치는 국가 비상사태와 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우 통상실시권을 허락할 수 있는 규정을 두고 있다. 다만 공권력에 의한 실시권의 부여는 사유재산에 대한 제약이므로 요건 및 절차를 엄격히 규정하고 있다.

3. 성립요건

i) 국가 비상사태, ii) 극도의 긴급상황 또는 iii) 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정되어야 한다. 제107조의 재정에 의한 강제실시권과 별도로 이와 같은 규정을 두고 있는 것은 i) 재정청구에 의하면 긴급사태라 하더라도 재정에 시간이 많이 소요될 수 있으므로 비상사태에 효율적으로 대비할 수 있도록 하기 위함이며, ii) 재정에 의한 강제실시권은 이전에 금지되어 있으므로 정부에 생산시설이 없는 경우 활용할 수 없는 문제점이 있기 때문이다.

4. 절 차

(1) 처분의 신청

주무부장관은 국가 비상사태, 극도의 긴급상황 또는 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 경우 신청서를 보상금 또는 대가의 액의 산출 근거를 적은 서류와 신청의 이유를 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 주무부장관은 처분을 신청하는 경우에는 지식재산처장에게 해당 발명과 관련된 특허조사를 요청할 수 있다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 2, 3).⁴²⁰⁾

(2) 부분의 송달

지식재산처장은 위의 신청서를 받은 때에는 법에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는, 특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자에게 각각 신청서의 부분을 송달하고 기간을 정하여 의견서제출의 기회를 주어야 한다. 이 경우에 의견서의 제출이 있으면 신청인에게 그 부분을 송달하여야 한다. 지식재산처장은 위의 신청서를 받은 때에는 그 뜻을 특허공보에 게재하여야 한다. 다만 특허발명이 국방상 비밀이 필요한 때에는 이를 공고하지 아니할 수 있다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 4).

(3) 처분 및 보상금액의 결정

지식재산처장은 의견서 제출기간이 지난 후에 처분을 하며 처분을 할 때는 그 처분에 대한 보상금 및 대가의 액도 함께 결정하여야 한다. 보상금 및 대가의 액을 결정할 때는 신청인·특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자의 의견을 참작하여야 한다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 5①②③).

(4) 결정서의 등본의 송달 및 공고

지식재산처장은 처분의 결정을 한 때에는 그 결정서의 등본을 신청인·특허권자·전용실시권자·통상실시권자·질권자에게 각각 송달하고 그 결정의 요지를 특허공보에 공고하여야 한다. 다만 국방상 비밀이 필요한 것인 때에는 공고를 하지 아니할 수 있다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 8).

(5) 신청의 예외 등

1) 지식재산처장은 신청 당시 극도의 긴급상황 등 불가피한 사유로 특허권이 존재한다는 사실을 알지 못하거나 알 수 없어 신청서의 기재사항 및 첨부 서류(이하 이 조에서 “서류등”이라 한다) 중 일부를 적을 수 없거나 첨부할 수 없는 것으로 인정하는 경우에는 향후 특허권의 존재가 확인되면 지체 없이 서류등을 보완하는 것을 조건으로 신청을 받을 수 있다. 지식재산처장은 신청을 받은 경우 서류등이 보완되기 전에 신청에 대한 처분을 하여야 할 필요가 있다

420) 전시, 사변 또는 이에 준하는 비상시 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 수용할 필요가 있다고 인정되는 경우에도 이 절차에 따른다.

고 인정하는 때에는 그 처분을 할 수 있다. 지식재산처장은 처분을 한 후 서류등이 보완되면 지체 없이 그 처분에 대하여 보완하는 조치를 하여야 한다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 9).

2) 정부 또는 정부 외의 자는 타인의 특허권이 존재한다는 사실을 알았거나 알 수 있을 때에는 제106조의2 제1항에 의한 실시 사실을 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 신속하게 통지하여야 한다(法 106의2②).

5. 발생 및 범위

본 조의 통상실시권의 경우 지식재산처장의 결정서 등본의 송달에 의하여 발생하며 지식재산처장은 이에 해당하면 직권등록을 하여야 한다. 이 경우 지식재산처장의 결정에 의하여 정해진 범위에서 정부는 직접 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있다.

6. 보상금

정부 또는 정부 외의 자는 특허발명을 실시하는 경우에는 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자에게 대하여 정당한 보상금을 지급하여야 한다(法 106의2③). 지식재산처장은 특허권의 강제실시권 설정의 처분을 할 때에는 그 처분에 대한 보상금 및 대가의 액도 함께 결정하여야 하며 보상금을 결정할 때에는 특허권자의 의견을 참작하여야 한다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 5). 한편 보상금에 대하여 불복이 있는 경우에는 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 법원에 소송을 제기할 수 있다. 이때 보상금을 지급할 중앙행정기관의 장 또는 특허권자 등을 피고로 하여야 한다(法 190, 191).

II. 재정에 의한 통상실시권

제107조 【통상실시권 설정의 재정】

① 특허발명을 실시하려는 자는 특허발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하고, 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의(이하 이 조에서 “협의”라 한다)를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 협의를 할 수 없는 경우에는 지식재산처장에게 통상실시권 설정에 관한 재정(裁定)(이하 “재정”이라 한다)을 청구할 수 있다. 다만, 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하려는 경우와 제4호에 해당하는 경우에는 협의 없이도 재정을 청구할 수 있다.

1. 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우
2. 특허발명이 정당한 이유 없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우
3. 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우
4. 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

5. 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 “수입국”이라 한다)에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우
- ② 특허출원일부터 4년이 지나지 아니한 특허발명에 관하여는 제1항제1호 및 제2호를 적용하지 아니한다.
- ③ 지식재산처장은 재정을 하는 경우 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 한다.
- ④ 지식재산처장은 제1항제1호부터 제3호까지 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우 재정을 받는 자에게 다음 각 호의 조건을 붙여야 한다.
 1. 제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 재정의 경우에는 통상실시권을 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것
 2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것
- ⑤ 지식재산처장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 한다. 이 경우 제1항제4호 또는 제5호에 따른 재정을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 대가 결정에 고려할 수 있다.
 1. 제1항제4호에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지
 2. 제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치
- ⑥ 반도체 기술에 대해서는 제1항제3호(공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시하는 경우만 해당한다) 또는 제4호의 경우에만 재정을 청구할 수 있다.
- ⑦ 수입국은 세계무역기구회원국 중 세계무역기구에 다음 각 호의 사항을 통지한 국가 또는 세계무역기구회원국이 아닌 국가 중 대통령령으로 정하는 국가로서 다음 각 호의 사항을 대한민국정부에 통지한 국가의 경우만 해당한다.
 1. 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량
 2. 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인
 3. 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인
- ⑧ 제1항제5호에 따른 의약품은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한다.
 1. 특허된 의약품
 2. 특허된 제조방법으로 생산된 의약품
 3. 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분
 4. 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트
- ⑨ 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제108조 【답변서의 제출】

지식재산처장은 재정의 청구가 있으면 그 청구서의 부분(副本)을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자, 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제109조 【산업재산권분쟁조정위원회 및 관계 부처의 장의 의견청취】

지식재산처장은 재정을 할 때 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회(이하 “조정위원회”라 한다) 및 관계 부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다. <개정 2021. 8. 17>

[전문개정 2014.6.11.]

제110조 【재정의 방식 등】

- ① 재정은 서면으로 하고, 그 이유를 구체적으로 적어야 한다.

- ② 제1항에 따른 재정에는 다음 각 호의 사항을 구체적으로 적어야 한다.
1. 통상실시권의 범위 및 기간
 2. 대가와 그 지급방법 및 지급시기
 3. 제107조제1항제5호에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 따른 경우는 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소
 4. 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시할 경우 법령 또는 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항
- ③ 지식재산처장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일부터 6개월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다.
- ④ 제107조제1항제5호에 따른 재정청구가 같은 조 제7항 및 제8항에 해당하고 같은 조 제9항에 따른 서류가 모두 제출된 경우에는 지식재산처장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제111조 【재정서등본의 송달】

- ① 지식재산처장은 재정을 한 경우에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서등본을 송달하여야 한다.
- ② 제1항에 따라 당사자에게 재정서등본이 송달되었을 때에는 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

제111조의2 【재정서의 변경】

- ① 재정을 받은 자는 재정서에 적혀 있는 제110조제2항제3호의 사항에 관하여 변경이 필요하면 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 변경청구를 할 수 있다.
- ② 지식재산처장은 제1항에 따른 청구가 이유있다고 인정되면 재정서에 적혀 있는 사항을 변경할 수 있다. 이 경우 이해관계인의 의견을 들어야 한다.
- ③ 제2항의 경우에 관하여는 제111조를 준용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제112조 【대가의 공탁】

제110조제2항제2호에 따른 대가를 지급하여야 하는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 대가를 공탁(供託)하여야 한다.

1. 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우
2. 대가에 대하여 제190조제1항에 따른 소송이 제기된 경우
3. 해당 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우. 다만, 질권자의 동의를 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

제113조 【재정의 실효】

재정을 받은 자가 제110조제2항제2호에 따른 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 경우에는 그 재정은 효력을 잃는다.

[전문개정 2014.6.11.]

제114조 【재정의 취소】

- ① 지식재산처장은 재정을 받은 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이해관계인의 신청에 따라 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 재정을 받은 통상실시

권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우로 한정한다.

1. 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우
 2. 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우
 3. 정당한 사유 없이 재정서에 적혀 있는 제110조제2항제3호 또는 제4호의 사항을 위반하였을 경우
- ② 제1항의 경우에 관하여는 제108조·제109조·제110조제1항 및 제111조제1항을 준용한다.
③ 제1항에 따라 재정이 취소되면 통상실시권은 그때부터 소멸된다.

[전문개정 2014.6.11.]

제115조 【재정에 대한 불복이유의 제한】

재정에 대하여 「행정심판법」에 따라 행정심판을 제기하거나 「행정소송법」에 따라 취소소송을 제기하는 경우에는 그 재정으로 정한 대가는 불복이유로 할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

제116조 삭제 <2011.12.2.>

제117조 삭제 <2001.2.3.>

1. 의 의

「재정(adjudication)에 의한 통상실시권」이란 i) 특허권자가 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나 ii) 불충분하게 실시하는 경우, iii) 공공의 이익을 위하여 특허 실시할 필요가 있는 경우, iv) 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위한 경우 또는 v) 수입국에 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 이를 실시하려는 자의 청구와 지식재산처장의 재정(裁定)에 의하여 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 통상실시권을 말한다(法 107).

2. 취 지

(1) 불실시 또는 불충분한 실시의 경우

특허발명을 국내에서 실시하지 않거나 불충분하게 실시하면서 제3자만의 실시를 금지하는 것은 특허권의 지나친 남용에 해당하며 실시 장려를 통한 산업발전예의 이바지라는 특허법의 목적에도 부합하지 아니한다. 따라서 일정한 요건을 전제로 제3자에게 강제적으로 실시하게 함으로써 산업발전에 기여하고자 함에 그 취지가 있다.

(2) 공공의 이익을 위하여 특허 필요하거나 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위한 경우
공공의 이익이나 불공정 거래행위를 바로잡기 위해서는 특허권자의 실시 여부와 무관하게 공익상 제3자에게 강제적으로 실시하게 할 필요성이 있으므로 강제실시권에 관한 규정을 두고 있다.

(3) 수입국에 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

에이즈나 결핵, 말라리아와 같은 질병으로 심각한 국가적 위기를 당한 개발도상국에서는 90년대 말부터 의약품의 접근성 보장을 위해 특허권을 제한할 필요성을 강하게 주장하였는데, 이는 국내수요를 주목적으로 하도록 규정되어 있는 TRIPs 협정 제31조(f)에 반하여 문제가 되

었다. WTO(세계무역기구)에서는 이를 해결하기 위하여 2001년 11월 카타르 도하에서 개최된 제4차 WTO 각료회의에서 “TRIPs 협정과 공중보건에 관한 도하선언문”을 채택하여 WTO 일반이사회에 해결책을 마련하도록 하였으며, 그 결과로 나온 WTO 결정문은 TRIPs 협정 제 31조(f) 규정이 후진국의 공중보건문제 해결을 위한 의약품의 수출, 수입에 적용될 때 효력을 일정부분 유보하도록 하였다. 국내법은 이를 신속히 반영하여 건강권과 같은 보편적 인권을 지키려는 국제사회의 인도주의적 조치에 능동적으로 참여함과 동시에 국가 이미지를 제고하고 간접적으로 국내 제약산업의 발전에 기여하고자 2005. 12. 1. 시행된 현행법(법률 제07554호, 2005. 5. 31. 개정)에서 「수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우」를 재정사유에 반영하였다.⁴²¹⁾

421) 그동안 우리나라에서 재정에 의한 통상실시권 허락 청구 사례는 총 4건으로 이 중 1건만이 인용, 즉 강제실시권이 허락되었고, 나머지 3건은 기각되었는데 구체적으로 살펴보면 다음과 같다(정연덕, 「신기술분야에서의 강제실시제도의 적용에 관한 연구」, 지식재산처, 2009, 53-54면 참조).

- ① 1978년 비스-티오 벤젠 제조방법에 대해서 우리나라의 제철화학(주)이 특허권자인 일본 소다(주)를 상대로 재정에 의한 통상실시권 허락을 청구하였다. 이에 지식재산처는 1980년 12월, 3년 이상 특허권 불실시가 정당한 이유 없는 특허권의 남용으로 인정되어 통상실시권을 허락하였으며, 실시료는 3%로 하였다.
- ② 1993년, 아렉시스 메디컬 컴퍼니가 정당한 이유없이 3년 이상 국내 불실시를 이유로 프랑스 제약회사 소유인 낙태약(mifepristone) 제조방법에 대한 재정에 의한 통상실시권을 청구하였다. 그러나 지식재산처는 1984년 3월, 낙태목적은 의약품은 국내 제조 불허가 대상 품목으로서 정당한 이유가 있는 불실시로 판단하여 청구를 기각하였다.
- ③ 특허권자인 노바티스사가 글리벡에 대하여 우리 정부의 고시가격과 보험적용을 거부하고 당초 제안한 높은 가격을 고수하자 시민단체가 2002년 1월 30일 지식재산처장을 상대로 강제실시권의 재정을 청구하였다. 2003년 2월 지식재산처장은 “글리벡을 저가로 수입할 경우 글리벡을 복용하지 않으면 안 될 절박한 상황에 있는 환자층의 경제적 부담을 많이 완화해 줄 수 있기는 하나, 만성골수성백혈병의 경우처럼 전염성이나 급박한 국가적, 사회적 위험이 적음에도 불구하고 발명품이 고가임을 이유로 강제실시를 허용할 경우 발명자에게 독점적 이익을 인정하여 일반 공중의 발명의식을 고취하고 기술개발과 산업발전을 촉진하고자 마련된 특허제도의 기본취지를 크게 훼손할 수 있는 만큼 강제실시권 인정 여부는 이러한 두 가지 상충되는 이익을 비교형량하여 신중히 결정하여야 하고, 현재 모든 만성골수백혈병환자에게 보험이 적용되며, 이 경우 환자의 실제부담액은 보건복지부가 책정 고시한 약가의 10% 수준인 점, 글리벡의 공급이 현재 정상적으로 이루어지고 있는 점, 대외무역법 제14조 및 대외무역관리규정 제7조에 따른 자기치료목적의 수입이 가능한 점 등 글리벡의 공급실태와 관련된 상황적 측면을 종합적으로 고려하여 특허법 제107조제1항제3호에 따른 통상실시권 설정을 인정할 정도의 공공의 이익이 있다고 보기 어렵다”라고 하면서 동 청구를 기각하였다.
- ④ 2008년 12월, 에이즈감염연대 “KANOS”와 정보공유연대 “IPleft”는 에이즈 치료제인 “푸제온”에 대해서 재정에 의한 통상실시권을 청구하였다. “푸제온”에 대한 국내 특허권은 미국의 듀크 대학이 소유하고 있고, 실질적으로 국내에서 “푸제온”을 공급하고 있는 제약회사는 스위스의 로슈로서 국내에서 “푸제온”에 대한 통상실시권만을 가지고 있다. 청구인은 로슈와 정부와의 약가협상 결렬로 4년 이상 국내 공급이 거부되어 환자의 의약품 접근권이 심각하게 제한되고 있다는 이유로 특허법 제107조제1항제3호의 “공공의 이익을 위하여 특허 필요한 경우”에 해당된다고 강제실시권을 청구하였다. 이에 대하여 지식재산처는 “푸제온”이 환자의 생명과 밀접한 관계가 있어서 해당 의약품의 공급이 공공의 이익을 위해서 필요하다고 보지만, 국내 제조 혹은 수입 등을 통한 실질적인 접근권 제공의 결여, 통상실시권 재정의 긴급성의 결여 등의 이유로 이에 대한 청구를 기각하였다.

3. 조약과의 관계

(1) 파리조약과의 관계

파리조약 제5조A(2)(3)에서는 “각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타권 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있으며, 강제실시권의 부여가 그러한 남용을 방지하기에 충분하지 아니하면 특허의 몰수 또는 철회를 규정할 수 있다”라고 규정하고 있다. 특허법에서 특허발명의 불실시, 불충분실시에 따른 규제조치로서 재정제도를 두고 있는 것은 파리조약 제5조에 따른 것이다.

(2) WTO/TRIPs 협정과의 관계

WTO/TRIPs 협정 제31조에서도 강제실시권에 관해 규정하고 있으며, 파리조약과 비교하여 볼 때 i) 특허권이 남용되는 경우뿐만 아니라 국가긴급사태나 공적인 비상업적 사용을 위하여 강제실시를 할 수 있도록 하여 범위를 더 넓게 인정한다는 점, ii) 권리자에 대한 명확한 보상규정을 두고 있다는 점, iii) 개량특허의 침해에 대한 특별규정을 두고 있다는 점 등의 차이가 있다.⁴²²⁾

4. 성립요건

(1) 불실시 또는 불충분한 실시의 경우

① 의 의

1) i) 특허발명이 천재지변이나 그 밖의 불가항력 또는 대통령령으로 정하는 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 실시되고 있지 아니한 경우, ii) 특허발명이 정당한 이유없이 계속하여 3년 이상 국내에서 상당한 영업적 규모로 실시되고 있지 아니하거나 적당한 정도와 조건으로 국내수요를 충족시키지 못한 경우이어야 한다(法 107① I II).⁴²³⁾

422) TRIPs 협상에서 선진국과 후진국(개발도상국) 사이의 최대쟁점은 강제실시권을 부여하는 이유를 한정할 것인지 여부였다. 선진국은 강제실시권을 부여하는 이유를 한정적으로 열거할 것을 주장한 반면, 개발도상국은 이유를 한정하지 말 것을 주장하였다. 구체적으로 강제실시를 명하는 경우의 요건에 관해, i) 강제실시를 명할 수 있는 경우를 한정적으로 열거하고 그 밖의 어떠한 상황에서도 강제실시를 명할 수 없도록 하는 방법(선진국의 grounds approach, 사유규제방식), ii) 어떠한 이유에 의하더라도 강제실시를 명할 수 있으나 명하는 경우에 강제실시권 부여의 조건을 다수 열거하고 부여의 적정화를 도모하는 방법(개발도상국의 condition approach, 조건규제방식)이 대립하였으나, TRIPs 협정에서는 개발도상국의 입장이 채택되어 제31조에서 강제실시를 명하는 조건만 정하게 되었다. 유일한 요건의 제한은 반도체 기술에 대해서만 규정되어 있다. 즉 제31조는 어떤 경우에 특허발명의 강제실시를 허락할 수 있는지 그 요건을 정한 것이 아니므로, 어떤 요건에서 특허발명의 강제실시를 허용할 것인지는 개별 국가의 입법재량에 속하는 것이다. 이와 관련하여, 2001년 WTO 각료회의에서 채택된 “TRIPs 협정과 공중보건에 관한 선언문(도하선언문, WT/MIN(01)DEC/2)”에서도 “강제실시를 부여할 권리와 그 요건을 결정할 주권은 각 회원국에게 있다”라고 한 바 있다.

423) 私見으로는 제107조제1항제1호의 불실시가 제107조제1항제2호의 불충분실시에 포함되는 개념임에도 불구하고 별도의 요건으로 규정하고 있었던 이유는 제107조제1항제1호의 불실시에 의한 재정만 제116조의 특허권의 취소사유이었기 때문인데 현재는 제116조가 삭제되었으므로, 이를 별도의 요건으로 규정할 필요가 없는 것으로 여겨진다.

2) 「천재지변」이란 산사태로 인한 산업설비의 파손 등과 같이 인위적인 행위가 개입되지 아니한 상태에서 발생하는 사태를 말하며, 「불가항력」이란 타인의 협박 등과 같이 인위적인 행위가 가미된 상태에서 본인이 극복하지 못할 상태를 말한다. 「천재지변이나 그 밖의 불가항력」의 요건은 객관적인 상태일 것을 필요로 하며, 특허권자 또는 전용실시권자의 여행·질병 등과 같은 주관적인 상태를 가리키는 것은 아니다.⁴²⁴⁾

3) 「대통령령으로 정하는 정당한 이유」란 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제6조에서 열거하고 있는 다음의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

- i) 특허권자가 심신장애로 인한 활동불능의 경우(의료기관장이 증명한 경우에 한함)
- ii) 특허발명의 실시에 필요한 정부기관이나 타인의 인·허가, 동의 또는 승낙을 받지 못한 경우
- iii) 특허발명의 실시가 법령으로 금지 또는 제한된 경우
- iv) 특허발명의 실시에 필요한 원료 또는 시설이 국내에 없거나 수입이 금지된 경우
- v) 물건의 수요가 없거나 그 수요가 적어 이를 영업적 규모로 실시할 수 없는 경우

4) 「계속」이란 연속과 현재의 의미를 포함하고 있다. 즉 특허발명이 연속하여 3년 이상 실시되고 있지 아니하여야 하지, 불실시 기간의 총합계가 3년 이상이라는 의미가 아니다. 특허권의 설정등록 후 계속하여 3년 이상 실시하지 아니함은 물론 일정 기간 실시하다가 그 실시를 중단한 후 계속하여 3년 이상 실시하지 아니한 경우도 포함한다. 그러나 3년 이상 불실시를 했더라도 그 후 다시 실시를 개시하여 현재 실시하고 있다면 여기에 해당되지 아니한다.

5) 외국에서 실시하더라도 「국내」에서 실시하지 아니하면 재정청구의 대상이 된다. 특허권은 국내에서만 미치며 특허법은 국내 산업발전이 주목적이기 때문이다. 다만 수입도 실시의 일 유형이므로 특허권자가 외국에서 제조된 물건을 수입만을 하고 다른 실시행위를 하지 않더라도 불실시라 할 수 없다(조약 5A(1)).

② 협의 필요

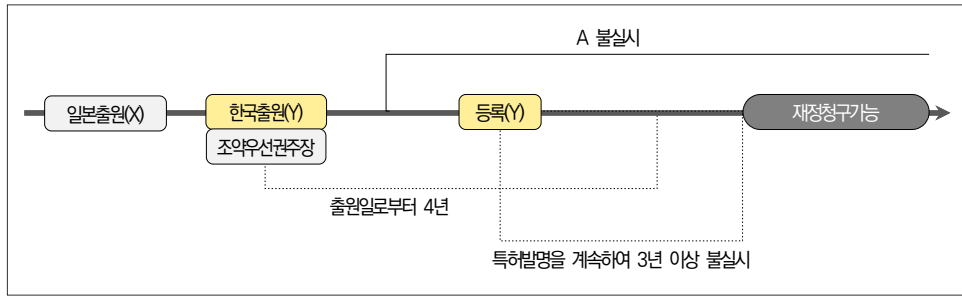
그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적⁴²⁵⁾인 조건으로 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 주소불명 등으로 협의를 할 수 없는 경우에는 지식재산처장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다(法 107①).

③ 기간의 경과 필요

특허발명이 특허출원일로부터 4년이 지나야 한다(法 107②). 이는 특허권자에게 실시를 위한 검토와 준비기간 등을 보장하기 위해서이다. 여기서 「출원일」은 i) 분할출원(法 52②), 분리출원(法 52의2②) 또는 변경출원(法 53)의 경우 원출원일, ii) 조약우선권주장출원(法 54①), 국내우선권주장출원(法 55③)의 경우 우선권주장출원일, iii) 국제특허출원의 경우 국제출원일을 의미한다.

424) 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 741면.

425) 「합리적(resonable)」의 의미는 특허권자에게는 권리남용이 아니어야 하고, 실시하려는 자에게는 상당한 대가를 지급하여야 함을 뜻하는 것으로 생각된다. 즉 객관적으로 합당한 조건을 토대로 상호 간 협의를 위하여 성실히 교섭하여야 한다는 의무를 천명한 것으로 본다(이익희, “특허발명의 권리회복제도와 강제 실시제도”, 지적재산21, 2005년7월, 48면).



【그림 6-33】 불 실시 · 불충분 실시의 경우 재정청구가능시기

(2) 공공의 이익을 위하여 특히 필요하거나 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 필요한 경우

① 의 의

1) i) 특허발명의 실시가 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우, ii) 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다(法 107①ⅢⅣ).

2) 「공공의 이익」이란 국민의 생명, 건강, 재산의 보전, 공공시설의 건축 등 국민생활에 직접 관계가 있는 소위 공공적 산업분야에 속하고 그 발명을 긴급하고 널리 실시할 필요가 높은 경우(예를 들어 전염병의 예방 또는 치료를 위하여 특허받은 의약품이 단기간에 국내에서 대량 필요한 경우⁴²⁶⁾)를 말한다. 「특히 필요한 경우」란 공공의 이익을 위하여 특허발명의 실시가 필요하다고 하더라도 공공의 이익과 강제실시권을 허락함으로써 손실되는 특허권자의 이익을 비교형량하였을 때 공공의 이익이 현저히 클 때를 말하는 것으로 이해된다.⁴²⁷⁾⁴²⁸⁾ 한편 기존에는 공익상 인정되는 강제실시권을 영리목적으로 실시한다면 재정의 취지에 반하기 때문에 비상업적으로 실시할 필요가 있는 경우로 제한을 두었다. 그러나 민간기업이 강제실시의 재정을 받아서 특허발명 제품을 제조·판매하는 경우 상업적 실시에 해당하는데 비상업적 실시를 요건

426) 다만 다수인의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 특허발명에 대한 강제적인 실시를 통하여 생산된 의약품을 수입하고자 재정을 청구하는 경우에는 i) 국내에 그 의약품의 생산시설이 없거나 부족할 것, ii) 전시·사변 또는 이에 준하는 비상사태이거나, 「재난 및 안전관리기본법」 제36조에 따른 재난사태가 선포된 때일 것의 요건을 모두 갖추어야 한다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 2의2).

427) 이익희, “특허발명의 권리회복제도와 강제실시제도”, 지적재산21, 2005년 7월, 50면.

428) 공중보건상 의약품 접근권을 위하여 강제실시권을 사용하는 것이 TRIPs 협정상 법률적으로 문제가 없는 것으로 보이더라도 정책적인 면에서 그 적용이 현실적으로 어려운 것이 사실이다. 재량적으로 자의적인 해석에 의한 강제실시권의 발동이 특허 의약품에 대한 가격 인하라는 단기간의 긍정적인 효과는 있겠지만, 다국적 제약회사의 타 의약품 공급 제한 및 통상마찰이라는 부정적인 효과도 발생하기 때문이다. 따라서 우리나라는 의료보전 정책, 특허 정책, 통상 정책이 조화를 이루도록 TRIPs 협정의 유연성을 활용하는 것이 필요하다(정연덕, 「신기술분야에서의 강제실시제도의 적용에 관한 연구」, 지식재산권, 2009, 135면 참조).

으로 한다면 민간기업이 특허발명을 실시하는 것이 사실상 어렵게 되므로 「비상업적 실시」를 요건에서 삭제하였다.⁴²⁹⁾

3) 「사법적·행정적 절차에 의하여 불공정거래행위라고 판정된 경우」란 반경쟁적인 관행을 바로잡고 거래질서를 확립하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다. 여기서 「불공정거래행위」란 부당하게 거래를 거절하거나 부당하게 거래 상대방의 사업활동을 구속하는 조건으로 거래하는 등의 행위를 말한다(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 23).⁴³⁰⁾

② 반도체 기술의 경우

반도체 기술에 대해서는 i) 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우, ii) 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에만 재정을 청구할 수 있다(法 107⑥). 이는 국가 산업분야에서 중요한 위치를 차지하고 있는 반도체 기술분야의 특수성을 고려한 것이다.⁴³¹⁾

③ 협의나 기간의 경과 필요 여부

출원일로부터 4년이 지나지 아니하여도 된다. 이와 같은 사유는 실시의 시기상 긴급히 필요한 경우가 대부분이기 때문이다. 또한 공공의 이익을 위하여 「비상업적」으로 실시하려는 경우와 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에는 협의를 하지 아니하여도 재정을 청구할 수 있다(法 107①). 다만 공공의 이익을 위한 「비상업적」 실시가 아닌 「상업적」 실시를 위해서는 특허권자와 협의를 하여야 한다.

(3) 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우⁴³²⁾

① 의 의

1) 자국민 다수의 보건을 위협하는 질병을 치료하기 위하여 의약품(의약품 생산에 필요한 유효성분, 의약품 사용에 필요한 진단키트를 포함한다)을 수입하려는 국가(이하 이 조에서 “수입

429) 정상조, “특허발명의 강제실시”, 서울대법학 제40권 1호, 1999년 5월, 264-299면.

430) 불공정거래행위의 사례로는 다음과 같은 경우가 있다. 甲은 특허권자이고, 乙은 甲의 특허권을 실시하려는 실시권자이다. 甲과 乙은 실시권 설정계약을 하면서 「乙은 A사에 실시물품을 판매하지 아니한다」라는 이면계약을 한 바 있다. 그러나 甲의 특허발명은 국내 전체수요의 90% 이상을 A사가 차지하고 있다는 것을 乙이 추후에 알게 되었다. 乙은 특허발명의 실시를 위하여 투자를 한 시설 등의 비용을 회수하기 위해서 A사에 실시물품을 판매하였다. 甲은 계약을 해지시켰다. 그로 인하여 乙은 특허발명의 실시사업을 위해 투자한 비용을 회수하지 못하였다. 이와 같은 경우 甲의 이면계약체결은 乙에 대한 불공정거래행위라고 판단된다. 물론 불공정거래행위라는 판단에는 재판이나 공정거래위원회와 같은 곳에서의 결정이 필요하다. 따라서 乙에 대한 甲의 불공정거래행위를 바로잡기 위해서는 乙이 실시를 하여 A사에 판매함으로써 투자비용을 회수할 수 있도록 하는 것이 필요하다. 한편 甲과 乙의 경우 실시계약에 「국내에서의 판매」만으로 한정된 경우에 그 실시물품이 국내에서는 수요가 없고, 국외에서만 수요가 있어서 乙이 그 물품을 수출하고, 甲이 계약을 해지한 경우도 같은 취지로 볼 수 있다(이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 750면).

431) 반도체 기술의 경우 사유규정방식을 취하고 있는 이유는 WTO/TRIPs 협정 최후단계에 이르러 미국의 반도체 업체가 압력을 행사하였기 때문이다. 이 조항은 기술분야에 의한 차별을 금지하는 TRIPs 협정 제27조제1항제2호에 저촉된다(박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002, 677면).

432) 의약품 수출을 위한 강제실시 절차는 다음과 같다.

국"이라 한다)에 그 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우를 말한다(法 107①V).

2) 「수입국」은 WTO 회원국 중 WTO에 다음의 사항을 통지한 국가 또는 WTO 회원국이 아닌 국가 중 대통령령으로 정하는 국가로서 다음의 사항을 대한민국 정부에 통지⁴³³⁾한 국가의 경우만 해당한다(法 107⑦). 여기서 「대통령령으로 정하는 국가」는 국제연합총회 결의에 따른 최빈개발도상국을 말한다(특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 2의3).

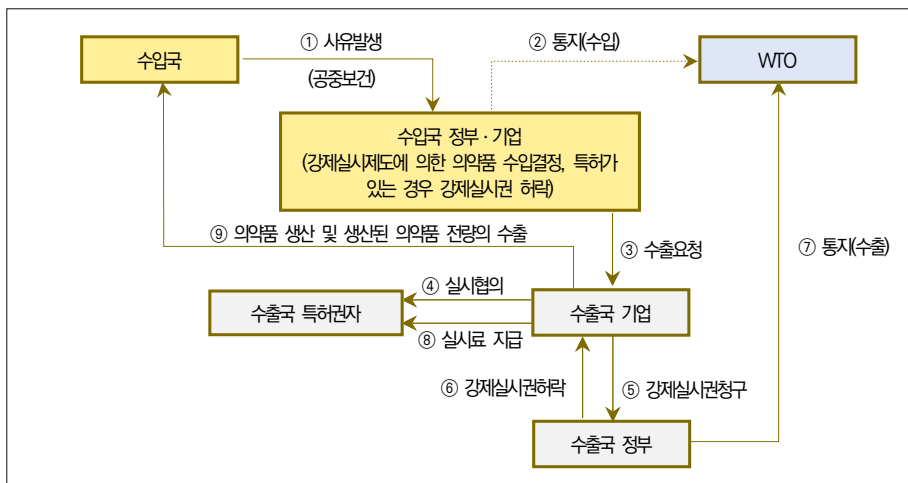
- i) 수입국이 필요로 하는 의약품의 명칭과 수량
- ii) 국제연합총회의 결의에 따른 최빈개발도상국이 아닌 경우 해당 의약품의 생산을 위한 제조능력이 없거나 부족하다는 수입국의 확인
- iii) 수입국에서 해당 의약품이 특허된 경우 강제적인 실시를 허락하였거나 허락할 의사가 있다는 그 국가의 확인

3) 「의약품」은 다음의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다(法 107⑧).

- i) 특허된 의약품
- ii) 특허된 제조방법으로 생산된 의약품
- iii) 의약품 생산에 필요한 특허된 유효성분
- iv) 의약품 사용에 필요한 특허된 진단키트

② 협의나 기간의 경과 필요 여부

출원일로부터 4년이 지나지 아니하여도 된다. 다만 그 특허발명의 특허권자 또는 전용실시권자와 합리적인 조건하에 통상실시권 허락에 관한 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 아니하는 경우 또는 주소불명 등으로 협의를 할 수 없는 경우에는 지식재산처장에게 통상실시권 설정에 관한 재정을 청구할 수 있다(法 107①).



433) 이 제도의 원활한 이용을 위하여 WTO 기구로부터 승인을 요구받지 아니한 것으로 이해된다.

【표 6-18】 재정에 의한 강제실시권 요건(法 107)의 비교

구 분	불 실시	불충분 실시	공공의 이익 실시		불공정거래행위 시정 실시	수입국에 수출 실시
			상업적	비상업적		
협약 (제107조제1항)	○	○	○	×	×	○
기간경과 (제107조제2항)	○	○	×	×	×	×
청구별 검토 (제107조제3항)	○					
조건부과 (제107조제4항)	국내수요충족				-	생산된 의약품 전량을 수입국에 수출
대가참작 (제107조제5항)	-				불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지	그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치
반도체기술 (제107조제6항)	×	×	×	○	○	×
수입국요건 (제107조제7항)	×	×	×	×	×	○
의약품요건 (제107조제8항)	×	×	×	×	×	○

5. 절 차

(1) 재정청구서 제출

1) 특허발명을 실시하려는 자는 특허권자 또는 특허권자와 전용실시권자를 피청구인으로 하여 재정청구서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다(法 107①). 재정청구가 있는 경우 지식재산처장은 직권으로 예고등록을 하고 특허공보에 게재하여야 한다(登錄令 6, 14). 특허발명을 실시하려는 자가 특허권의 범위에서 실시하려는 경우에는 특허권자를 피청구인으로, 전용실시권의 범위에서 실시하려는 경우에는 전용실시권자가 통상실시권을 허락하기 위해서는 특허권자의 동의를 받아야 하므로 특허권자와 전용실시권자를 공동피청구인으로 하여야 할 것이다.

2) 재정을 청구하는 자가 제출하여야 하는 서류, 그 밖에 재정에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다(法 107⑨).⁴³⁴⁾ 구체적인 제출 서류는 법률을 집행하기 위해 필요한 사항이나, 국민의 권리·의무에 관계된 중요한 사항이 아니므로 대통령령으로 위임하여 규정하게 하고 있다.

(2) 부분송달 및 답변서 제출

지식재산처장은 재정의 청구가 있으면 그 청구서의 부분을 그 청구에 관련된 특허권자·전용실시권자, 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 108).

434) 특허권의 수용·실시 등에 관한 규정 제3조에 별도로 규정을 두고 있다.

(3) 산업재산권분쟁조정위원회 등의 의견청취

지식재산처장은 재정을 할 때 필요하다고 인정하는 경우에는 「발명진흥법」 제41조에 따른 산업재산권분쟁조정위원회(이하 “조정위원회”라 한다)⁴³⁵⁾ 및 관계부처의 장의 의견을 들을 수 있고, 관계 행정기관이나 관계인에게 협조를 요청할 수 있다(法 109). 이는 타인의 특허권에 대한 일방적인 실시권의 강제설정이기 때문에 특허권자에게 필요 이상의 불이익이 가지 않도록 신중하게 처리하기 위함이다.⁴³⁶⁾

(4) 재 정

① 청구별 검토 및 조건부과

지식재산처장은 재정을 하는 경우 청구별로 통상실시권 설정의 필요성을 검토하여야 하며, 재정을 받은 자에게 다음의 조건을 부과하여야 한다(法 107③④).

- i) 불 실시, 불충분 실시 또는 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 실시의 경우에는 강제실시권 허락의 취지가 국내 수요의 충족에 있기 때문에 그 통상실시권이 국내수요충족을 위한 공급을 주목적으로 실시할 것⁴³⁷⁾
- ii) 수입국에 의약품의 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에는 생산된 의약품 전량을 수입국에 수출할 것⁴³⁸⁾

② 대가의 지급결정

지식재산처장은 재정을 하는 경우 상당한 대가가 지급될 수 있도록 하여야 하나, 다음의 사항을 대가 결정에 고려할 수 있다(法 107⑤).

- i) 사법적 절차 또는 행정적 절차에 의하여 불공정거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 불공정거래행위를 바로잡기 위한 취지

435) 조정위원회는 지식재산처에 두고 있으며 위원은 지식재산처 공무원·판사·검사·변호사 또는 변리사 등 산업재산권에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 자 중에서 지식재산처장이 위촉하며 위원장은 위원 중에서 지식재산처장이 지명한다(發振法 41).

436) 구법(법률 제07554호, 2005. 5. 31. 개정된 개정법 이전)에서는 지식재산처장이 재정을 하고자 할 때 조정위원회의 의견만을 듣도록 규정하고 있으나 조정위원회는 산업재산권에 대한 사인 간의 분쟁조정을 주된 임무로 하므로 강제실시권 허락과 같은 정책적 판단을 수행할만한 기관으로 보기 어렵고 이해 관계인들의 참여가 어렵다는 문제점이 있는바, 현행법에서는 절차의 투명성이나 공정성을 실질적으로 확보하기 위하여 관계인의 협조를 요청할 수 있도록 규정하고 사안에 따라 관계부처뿐만 아니라 전문 기관 등 다수의 의견을 청취할 수 있도록 하였다.

437) 불공정거래행위를 시정하기 위한 실시(法 107①Ⅳ)의 경우에는 국내수요충족이 미흡하여 발생한 사유가 아니기 때문에 이 조건을 부과할 필요가 없다.

438) WTO결정문 아래서 공급되는 의약품들이 의도했던 시장으로부터 전환되는 것, 즉 국제시장으로 흘러나와 판매되어 특허권의 가치가 훼손되는 것을 특허권자는 가장 우려하고 있다. 공중보건을 위한 강제실시는 특허권자의 이익에 반함에도 불구하고 인도적인 목적을 위하여 허용하는 것이므로 그 목적에 충실하도록 허용되고 이행되어야 된다. 이 규정은 카타르 도하의 WTO결정문 제5조에 따르면 “이 결정 문상의 제도로 생산되었으나 이 결정문의 규정에 배치되어 해당 회원국의 시장으로 전이된 물품이 해당 회원국의 영역 안으로 수입되거나 판매되는 것을 방지하기 위한 효과적인 법적 수단을 확보하여야 한다”라고 규정하고 있는데 이를 반영한 것이다.

- ii) 수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명을 실시함으로써 발생하는 수입국에서의 경제적 가치⁴³⁹⁾

③ 재정의 방식 등

- 1) 재정은 서면으로 하고 그 구체적인 이유와 함께 다음의 사항을 적어야 한다(法 110①②).
 - i) 통상실시권의 범위 및 기간
 - ii) 대가와 그 지급방법 및 지급시기
 - iii) 수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 따른 경우는 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정의 정한 사항을 공시할 인터넷 주소⁴⁴⁰⁾
 - iv) 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시할 경우 법령 또는 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항
- 2) 지식재산처장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 재정청구일부터 6개월 이내에 재정에 관한 결정을 하여야 한다(法 110③).⁴⁴¹⁾ 이는 시의적인 공익적 요청에 부응하여 절차의 신속을 도모하려 함에 그 취지가 있다.
- 3) 수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정청구가 다음의 요건을 만족하는 경우에 지식재산처장은 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 통상실시권 설정의 재정을 하여야 한다(法 110④).⁴⁴²⁾
 - i) 제107조제7항의 수입국의 요건
 - ii) 제107조제8항의 의약품의 요건
 - iii) 제107조제9항에 따른 서류가 모두 제출되었을 요건

439) 카타르 도하 선언문의 WTO결정문 제3조 “이 결정문상의 제도로 수출 회원국에 의하여 강제실시권이 허락된 경우 TRIPS협정 제31조(h)항에 따른 적절한 보상이 사용 승인된 수입회원국에서의 경제적 가치를 고려하여 수출회원국에 의하여 이루어져야 한다”라는 규정에 따른 것이다. 수출국에서의 경제적 가치가 아닌 경제적으로 어려운 수입국에서의 경제적 가치를 고려하는 것은 돈이 없어서 의약품에 대한 접근성이 보장받지 못하는 가난한 국가의 고통받는 사람들을 도와주자는 취지라고 볼 수 있다.

440) 특허권자가 생산하는 의약품과 강제실시권자가 생산하는 의약품이 서로 구분될 수 있어야 함은 당연하다. 이는 수출된 의약품의 전이나 재수출, 특허권자가 생산한 의약품에 대한 신용훼손 등 강제실시권자가 생산한 의약품에 의한 시장질서의 교란을 막기 위해서이다.

441) 「정당한 사유」는 강제실시권의 청구와 관련하여 국제적인 분쟁이 발생할 경우, 강제실시권 청구 대상인 특허권의 유무효에 대한 다툼이 특허심판원 또는 법원에서 진행 중인 경우, 그 밖의 불가피한 사유로 시간이 필요한 경우 등으로 볼 수 있을 것이다.

442) 의약품 수출을 위한 강제실시권 설정의 재정 청구는 수입국의 공중보건문제를 해결하기 위한 것으로, WTO 결정문에 따라 절차적 요건(수입국의 통지)만 충족하면 강제실시권을 허락할 수 있도록 함을 원칙으로 하되, 예외적으로 「정당한 이유」가 있는 경우 강제실시권을 허락하지 않을 수 있도록 하여 실제적 요건도 판단할 수 있도록 함으로써 WTO 결정문을 보완하고 있다. 여기서 「정당한 이유」의 구체적인 예로는, 그 특허의 유무효에 대한 쟁송절차의 진행, 우리나라에서 의약품을 수입하려는 수입국의 의사 명확하지 아니한 경우, 강제실시권 청구와 관련하여 청구내용을 신뢰하기 어려운 객관적인 정황의 존재 등이 있을 수 있다.

(5) 재정서 등본의 송달

지식재산처장은 재정을 한 경우에는 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 재정서 등본을 송달하여야 하며 당사자에게 재정서 등본이 송달되었을 때에는 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 본다(法 111).

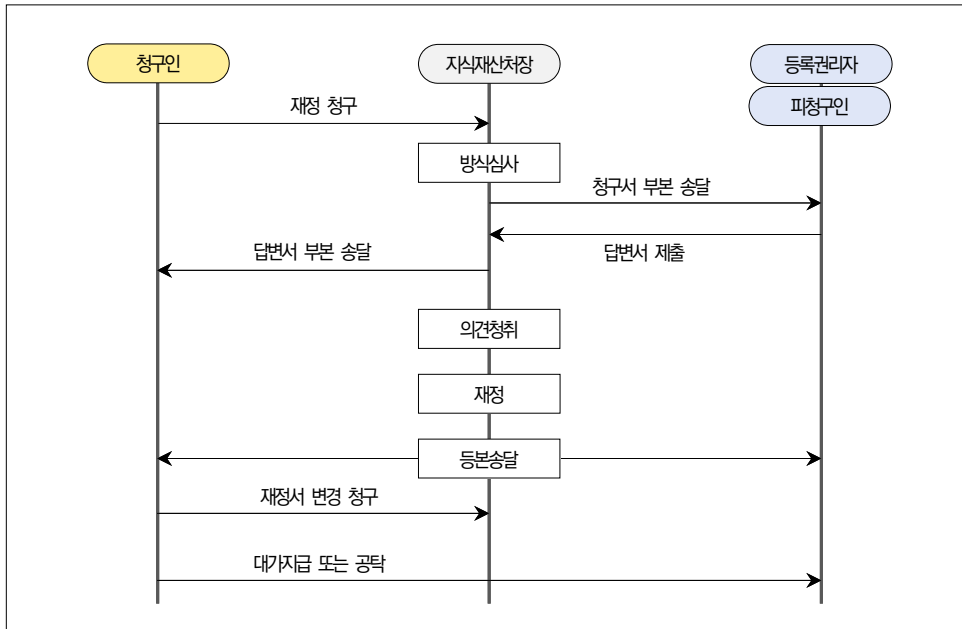
(6) 재정서의 변경

1) 재정을 받은 자는 재정서에 적혀 있는 수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에 i) 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 의한 경우를 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 ii) 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소의 사항에 관하여 변경이 필요하면 그 원인을 증명하는 서류를 첨부하여 지식재산처장에게 변경청구를 할 수 있다(法 111의2①). 이는 강제실시권자에게 부여되는 조건 중 「외관상 구분할 수 있는 포장·표시」나 「인터넷 주소」는 특허권자의 권리제한과 관련이 적고 재정 후에도 자주 변경될 수 있는 사항으로 그 변경사항을 반영하기 위하여 재정절차를 처음부터 다시 거치도록 하는 것은 절차경제의 요청에 반하므로 이를 재정 후에도 변경할 수 있도록 하기 위함이다.

2) 지식재산처장은 청구가 이유 있다고 인정되면 재정서에 적혀 있는 사항을 변경할 수 있다. 이 경우 이해관계인의 의견을 들어야 한다(法 111의2②). 한편 재정서에 적혀 있는 사항의 변경이 있는 경우 지식재산처장은 당사자 및 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 변경된 재정서 등본을 송달하여야 하며 당사자에게 변경된 재정서 등본이 송달되었을 때에는 해당 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 본다(法 111의2 준용 111).

(7) 재정에 대한 불복

재정에 대해서는 행정심판법에 따라 행정심판을 제기하거나 행정소송법에 따라 취소소송을 제기할 수 있으나 그 재정으로 정한 대가를 불복이유로 할 수는 없다(法 115). 이는 대가에 대한 불복을 행정심판에서 다투는 것은 그 대가 산정의 어려움 등으로 인하여 부적당하고 대가와 같은 재정의 부수적인 사항을 가지고 행정심판이나 행정소송을 제기함으로써 행정절차를 지연시키는 것을 방지하기 위함이다. 따라서 대가만의 불복을 하고자 할 경우에는 법원에 소송을 제기하여야 한다(法 190, 191).



【그림 6-34】 재정절차

6. 발생 및 범위

당사자에게 재정서 등본이 송달되었을 때에는 재정서에 적혀 있는 바에 따라 당사자 사이에 협의가 이루어진 것으로 보므로(法 111②), 본 조의 통상실시권의 경우 재정서 등본이 송달될 때 발생한다. 통상실시권자는 지식재산처장의 재정에 의하여 정해진 범위에서 특허발명을 실시할 수 있다. 이때 실시권은 실시사업과 함께 이전하는 경우에만 이전할 수 있으며, 실시권에 대한 질권을 설정할 수 없다(法 102③⑥).

7. 대가의 지급 및 재정의 실효(失効)

(1) 지급 및 공탁

통상실시권자는 재정에서 정한 바에 따라 대가를 지급하거나 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 그 대가를 공탁하여야 한다(法 112).

- i) 대가를 받을 자가 수령을 거부하거나 수령할 수 없는 경우
- ii) 대가에 관한 소송이 제기된 경우
- iii) 해당 특허권 또는 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는 경우(다만 질권자의 동의를 받은 경우에는 공탁하지 아니하여도 된다)⁴⁴³⁾

(2) 재정의 실효

재정을 받은 자가 대가의 지급시기까지 대가(대가를 정기 또는 분할하여 지급할 경우에는 최초의 지급분)를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니한 경우에는 그 재정은 효력을 잃는다(法 113). 즉 재정에 의한 통상실시권은 재정에서 정해진 대가의 지급시기 또는 공탁시기까지 대가의 불지급을 해제조건으로 하여 재정서 등본이 송달된 때에 발생한다.

8. 재정의 취소

(1) 의 의

「재정의 취소」란 개인의 재산권을 제한하면서 재정에 의한 통상실시권을 설정해 주었음에도 그 재정을 받은 통상실시권자가 특허발명을 실시하지 아니한 등의 사유로 인해 재정을 한 목적에 반하게 되는 경우 이미 한 재정을 취소시켜 통상실시권을 장래를 향해 소멸시키는 것을 말한다.

(2) 요 건

1) 지식재산처장은 재정을 받은 자가 다음의 사유 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 이해관계인의 신청에 따라 또는 직권으로 그 재정을 취소할 수 있다(法 114①).

- ① 재정을 받은 목적에 적합하도록 그 특허발명을 실시하지 아니한 경우
- ② 통상실시권을 재정한 사유가 없어지고 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되며 재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우
- ③ 정당한 사유 없이 재정서에 적혀 있는 다음의 사항을 위반하였을 경우⁴⁴³⁾
 - i) 수입국에 그 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우에 따른 재정의 경우에는 그 특허발명의 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자(재정에 따른 경우는 제외한다)가 공급하는 의약품과 외관상 구분할 수 있는 포장·표시 및 재정에서 정한 사항을 공시할 인터넷 주소
 - ii) 그 밖에 재정을 받은 자가 그 특허발명을 실시할 경우 법령 또는 조약에 따른 내용을 이행하기 위하여 필요한 준수사항

2) 「재정한 사유가 없어지거나 그 사유가 다시 발생하지 아니할 것이라고 인정되는 경우」는 특허권자가 재정사유인 불실시, 불충분실시의 요건 등을 극복하고 충분한 실시를 한 경우 등을 말하며, 「재정을 받은 통상실시권자의 정당한 이익이 보호될 수 있는 경우」란 재정에 의한 통상실시권자는 통상적으로 사업설비를 갖추고 실시를 하는 것이 일반적인데 재정에 의한 통상

443) 질권이 설정되어 있는 경우에는 질권자에게 물상대위할 수 있는 기회를 주기 위함임으로 질권자가 물상대위하지 않겠다는 의미로 동의를 한 경우에는 대가를 공탁할 필요가 없다.

444) 재정서에 적혀 있는 사항 중 제110조제2항제1호의 강제실시권의 범위 및 기간을 위반하는 것은 특허권의 침해가 되어 침해죄를 구성하며, 동조제2호의 대가와 그 지급에 대한 사항을 위반하는 경우 특허법 제113조에 따라 자동적으로 재정이 실효하기 때문에 취소사항으로는 규정하지 않고 있다.

실시권자의 책임없는 사유로 재정이 취소될 때 재정에 의한 통상실시권자를 보호하기 위한 것이다. 예를 들면 전염병 치료를 위해 특허발명인 의약을 공익을 위해 비상업적으로 실시한 후에는 특허권자와 다시 협상을 통해 정당한 대가를 지급하고 허락에 의한 통상실시권을 허락받거나, 생산설비를 특허권자가 매수하는 경우 등을 의미한다고 할 것이다.

(3) 절 차

재정의 취소 절차에는 신중하게 처리하기 위하여 답변서 제출(法 108), 산업재산권분쟁조정위원회 및 관계부처의 장의 의견청취(法 109), 재정의 방식 등(法 110①), 재정서 등본의 송달(法 111①) 등 재정절차의 규정이 준용된다(法 114②).

(4) 효 과

재정의 취소가 있으면 통상실시권은 그때부터 소멸된다(法 114③). 즉 통상실시권은 재정이 있는 때로 소급하여 소멸되지 않고 장래를 향해 소멸한다.

Ⅲ. 통상실시권허락심판에 의한 통상실시권

제138조 【통상실시권 허락의 심판】

- ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.
- ③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

1. 의 의

「통상실시권허락심판에 의한 통상실시권」이란 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자가 해당 특허발명이 이용·저축 관계에 해당되어 실시의 허락을 받으려는 경우에 선출된 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자가 정당한 이유없이 실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때에 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권허락심판을 청구할 수 있으며 이 심판에 의하여 허락되는 실시권을 말한다(法 138). 통상실시권허락

심판(法 138)에 의한 통상실시권은 기술전문가로 구성된 심판관 합의체에 의하여 통상실시권이 허락되는 점에서 지식재산처장의 결정에 의하여 통상실시권이 허락되는 재정(法 107)에 의한 통상실시권과 구별된다.

2. 취 지

이용·저촉관계의 기본적인 해결방안은 선출원우위의 원칙에 의한다. 즉 이용·저촉관계에 있는 후출원 권리자는 선출원 권리자의 허락을 받지 않으면 원칙적으로 이용·저촉관계에 있는 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다(法 98). 다만 후출원 권리자에게도 이용·저촉관계에 있는 특허발명을 실시할 수 있는 방안으로서 통상실시권허락심판 제도를 두고 있다. 이는 대다수의 발명이 기존의 발명을 개량한 것임을 고려할 때 선출원 발명을 이용·개량한 발명을 선출원 권리의 침해로만 규정하여 이용·개량발명을 보호하지 아니한다면 기존의 발명을 이용·개량하려는 자는 아무도 없게 될 것이므로 이를 방지하기 위함이다.

3. 종 류

(1) 일반적인 통상실시권허락심판

이용·저촉관계에 있는 후출원 권리자가 선출원 권리자에게 청구하는 심판을 말한다(法 138①②).

(2) 크로스 라이선스(cross license)

심판에 의하여 통상실시권을 허락한 선출원 권리자가 심판에 따라 통상실시권을 허락받은 후출원 권리자에게 청구하는 심판이다(法 138③). 이러한 실시권을 크로스 라이선스라고 하는데, 이는 선출원 특허권자 등과 후출원 특허권자의 이익을 조정하여 형평을 유지하기 위해 인정된다.

4. 성립요건

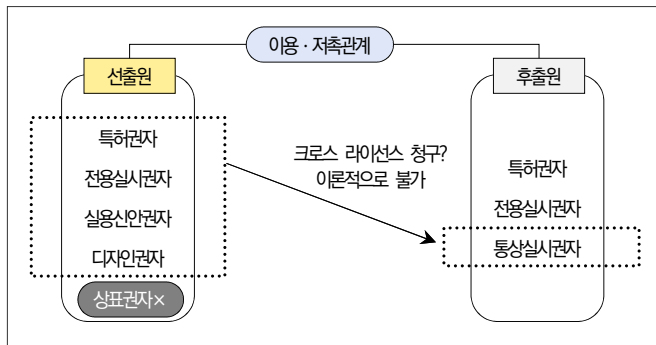
(1) 청구인·피청구인

① 일반적인 통상실시권허락심판의 경우

청구인은 이용·저촉관계의 후출원 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자이며 피청구인은 선출원 특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는 디자인권자이다.

② 크로스 라이선스의 경우

청구인은 통상실시권을 허락해 준 선출원 특허권자·전용실시권자·실용신안권자 또는 디자인권자이며 피청구인은 이용·저촉관계에 있는 후출원 특허권자·전용실시권자이다. 다만 통상실시권자가 피청구인이 될 수 있는가에 대해서는 의문이 있다. 통상실시권은 채권적인 권리이므로 제3자의 침해에 대하여 직접구제조치를 하거나 제3자에게 재실시권을 허락할 수 없다. 따라서 통상실시권자는 이론상 통상실시권허락심판의 피청구인이 될 수 없다고 보는 것이 타당하다.



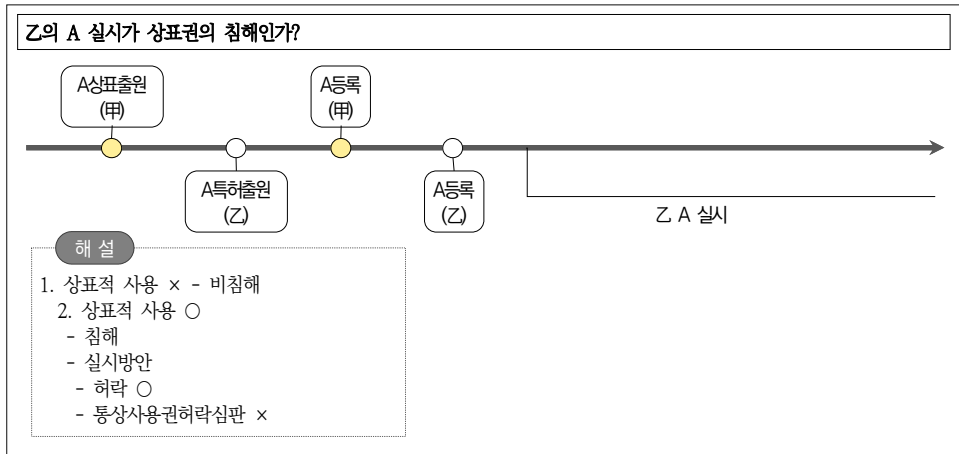
【그림 6-35】 크로스 라이선스의 피청구인 적격

(2) 청구사유

① 이용·저촉관계에 있을 것

1) 특허발명이 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이 나 그 디자인과 유사한 디자인을 이용하거나 특허권이 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권과 저촉관계에 있어야 한다(法 138①).

2) 특허권이 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 상표권과 저촉하는 경우에는 통상사용권허락심판을 청구할 수 없는 것으로 해석된다. 이에 대한 직접적인 규정은 없지만 제138조 제4항에는 “통상실시권허락심판에 의하여 통상실시권을 허락받은 실시권자는 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자에 대하여 대가를 지급하여야 한다”라고 하여 「상표권자」를 제외하고 있는 것으로부터 유추할 수 있다. 따라서 입체상표와 저촉되는 후출원 특허권의 경우 후출원 특허발명을 실시하는 것이 상표법상 사용이라면 선출원 상표권자의 허락을 얻어야 하며 통상사용권허락심판을 청구할 수 없다. 다만 후출원 특허발명을 실시하는 것이 상표법상 사용이 아니라면 선출원 상표권의 침해가 되지 아니하므로 자유롭게 실시할 수 있다.



【그림 6-36】 특허권과 상표권의 저촉관계

② 정당한 이유없이 실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 것

그 타인이 정당한 이유없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없어야 한다(法 138①). 「정당한 이유」란 제3자가 충분히 납득할 수 있을 정도의 객관적인 이유를 말한다. 후출원 권리자는 심판청구 전에 선출원 권리자(타인)와 협의를 통해 실시허락을 받기 위해 노력하여야 한다. 그렇지 아니한 경우 심판은 부적법한 심판청구로서 심판관 합의체에 의하여 심결각하된다(法 142).

③ 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위일 것

자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(法 138①). 예를 들어 선출원 특허발명의 구성요소가 A+B이고, 후출원 특허발명의 구성요소가 A+B+C인 경우 후출원 특허권자가 A+B+C의 실시에 필요한 범위에서만 실시권을 허락해 달라는 심판을 청구할 수 있고, A+B의 실시에 필요한 범위에서 실시권을 허락해 달라는 심판을 청구할 수는 없다.

④ 선출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보가 있을 것

1) 그 특허발명이 그 특허발명의 출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권의 허락을 하여서는 아니 된다(法 138②). 통상실시권허락심판의 남용을 방지하고 선출원인 기본발명의 특허권자 또는 실용신안권자를 보호하기 위함이다. 예를 들어 물질특허를 이용한 제법발명에 대한 후특허권자는 경제적 가치 및 기술상 진보에 관하여, 기존 제조방법들과 비교하여 그의 제법발명이 제조공정수가 현격히 감소하였다는가 아니면 수율이 현격히 증가함으

로써 경제적으로 큰 이익이 발생하였다는 증거 등을 제시하여야 할 것이고, 또한 기술 자체에서도 단순히 제법특허를 받았다는 수준에 그치는 것이 아니라 이전의 제조방법과 비교하여 전혀 예상하지 못하였던 새로운 방법에 의하여 특허를 받았음을 보이는 등 이전의 특허와 현저히 차별화된 특허임을 보이는 것이 필요하다.⁴⁴⁵⁾

2) 본 요건은 이용·저촉관계에 있는 디자인권에는 성격상 적용될 수 없다. 디자인은 물품의 외적 미관에 대한 창작으로서 기술적 사상의 창작인 발명과 비교하여 기술상 진보를 논의할 수 없기 때문이다.

⑤ 크로스 라이선스의 경우

통상실시권허락심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(法 138③).

(3) 청구기간

실시권이란 이용·저촉관계에 있는 권리의 침해가 되지 아니한 정당한 권원으로서 의미가 있으므로 타방의 권리가 존속 중인 경우에만 청구할 수 있다. 타방의 특허권이 소멸했다면 통상실시권허락심판을 청구할 필요도 없이 자유롭게 실시하면 된다.

5. 절 차

(1) 청구서 제출

심판청구인은 수수료를 납부하고 심판청구서에 일반적 기재사항(法 140①) 외에 다음의 사항을 추가로 적어야 한다(法 140④).

- i) 실시하려는 자기의 특허의 번호 및 명칭
- ii) 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록 연월일
- iii) 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가

(2) 부분 송달 및 답변서 제출

심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하고, 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다(法 147①②).

445) 정순성, “물질특허권에 대한 제조방법특허권의 통상실시권허여심판에 관한 소고”, 지적재산21, 2007년 1월, 86면 참조.

(3) 심 리

청구인이 신청한 청구취지의 범위에서 심리하여야 한다. 구체적으로 그 특허발명이 타인의 선출원된 특허발명 등과 이용·저촉관계에 있는지 여부 및 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보 여부, 통상실시권의 범위, 기간, 대가 및 그 지불방법, 지불시기에 대하여 심리하여야 한다.

(4) 심 결

i) 심판청구의 이유가 타당하지 않다고 인정된 때에는 기각심결을 하며, ii) 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때에는 심결의 주문에 통상실시권의 범위, 기간 및 대가를 구체적으로 명시하여 인용심결을 하여야 한다.

(5) 등본의 송달

심판장은 심결이 있으면 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다(法 162⑥).

(6) 불 복

심결등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다(法 186①). 다만 대가에 대하여 불복이 있을 때에는 관할법원에 소를 제기하여야 한다(法 190①).

6. 발생 및 범위

통상실시권을 허락하는 심결이 확정되면 통상실시권이 발생한다. 통상실시권자는 심결에 의하여 정해진 효력범위에서 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 있다. 이때 실시권은 해당 특허권과 함께 이전되고 해당 특허권이 소멸되면 함께 소멸하며, 실시권에 대한 질권을 설정할 수 없다(法 102④⑥).

7. 대 가

통상실시권자는 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만 자기가 책임질 수 없는 사유로 대가를 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 하며 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나 그 디자인과 유사한 디자인을 실시할 수 없다(法 138④⑤).

【표 6-19】 강제실시권의 비교

권 리		제106조의2	제107조	제138조
의 의		특허발명이 i) 국가 비상사태, ii) 국도의 긴급상황 또는 iii) 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요가 있다고 인정되는 경우에 정부가 특허발명을 실시하거나 정부 외의 자에게 실시하게 할 수 있는 통상실시권을 말한다.	특허권자가 정당한 이유없이 특허발명을 실시하지 않거나, 불충분하게 실시하는 경우, 공공의 이익을 위하여 특허 필요한 경우, 사법적·행정적 절차에 의하여 불공정 거래행위로 판정된 사항을 바로잡기 위한 경우 또는 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 지식재산처장의 재정에 의하여 특허발명을 얻으므로 실시할 수 있는 실시권을 말한다.	특허발명이 이용·저촉관계에 해당하여 통상실시권의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유없이 허락을 하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때, 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권허락심판을 청구할 수 있으며 상기 심판에 의하여 허락되는 실시권을 말한다.
성립요건	주제적	· 정부 또는 정부 외의 자	· 불 실시·불충분 실시·공공의 이익을 위하여 특허 필요한 경우 (비상업적 실시 제외)·수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 특허권자등과 협의 불성립	· 일반적 통상실시권허락심판 청구인은 이용·저촉관계의 후출원특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자이며 피청구인은 선출원특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는 디자인권자 · 크로스 라이선스 청구인은 통상실시권을 허락한 선출원특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자, 전용실시권자이며 피청구인은 원특허권자·전용실시권자(통상실시권자의 경우 확실대립)
	객체적	· i) 국가 비상사태, ii) 국도의 긴급상황 또는 iii) 공공의 이익을 위하여 비상업적으로 실시할 필요	· 불 실시·불충분 실시 · 공공의 이익을 위하여 특허 필요, 불공정거래행위 시정 → 반도체 기술은 이 경우에만 해당(단, 상업적 실시는 제외) · 수입국에 의약품을 수출할 수 있도록 특허발명을 실시할 필요	· 이용·저촉관계(法 98) · 협의 불성립 → 위반된 경우 심결각하 · 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술상의 진보(法 138②) · 자기의 특허발명 실시에 필요한 범위일 것 · 크로스 라이선스의 경우(法 138③)
	시기적	-	· 불 실시·불충분 실시의 경우 특허발명이 출원일로부터 4년 경과	· 타방 권리의 존속 중
	지역적	· 국내		
절 차		· 특허권 존재 사실의 통지 · 처분의 신청 · 부분의 송달 · 처분 및 보상금액의 결정 · 등본의 송달 및 공고 · 불복	· 청구 · 부분송달 및 답변서 제출 · 의견청취 · 재정 · 등본의 송달 · 불복	· 청구 · 부분송달 및 답변서 제출 · 심리 · 심결 · 등본의 송달 · 불복
발 생		결정서 등본의 송달	재정서 등본 송달	심결확정
효 력	효력범위	지식재산처장의 결정범위	재정에서 정한 바	자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위
	실시금지효	없음		
변 동	실시권허락	설정불가		
	질권설정	학설의 대립	질권설정 불가	
	이 전	학설의 대립	실시사업과 함께	실시권 허락의 원인되는 원권리와 함께
	특허권포기	동의 불가		
소 멸		질권설정가능한 경우 동의	자유롭게 포기 가능	
대 가		특허권의 소멸, 특허권의 수용, 실시권의 포기, 혼동, 정부의 실시허가의 취소(法 106의2), 재정의 취소(法 114) 및 실효(法 113), 원권리	1. 有 2. 다만 예외적인 경우 공탁	1. 有 2. 다만 예외적인 경우 공탁

제3절 특허법상 질권

제121조 [질권]

특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 때에는 질권자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 해당 특허발명을 실시할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

제122조 [질권행사 등으로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권]

특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 경매 등에 의하여 특허권을 이전받은 자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다. <개정 2021. 10. 19.>[전문개정 2014.6.11.]

제123조 [질권의 물상대위]

질권은 이 법에 따른 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 행사할 수 있다. 다만, 그 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

「질권」이란 채권자가 그 채권의 담보로서 채무자 또는 제3자로부터 받은 물건이나 재산권을 점유하고 채무의 변제가 있을 때까지 유치함으로써 채무의 변제를 간접적으로 강행하는 동시에 채무의 변제가 없을 때에는 그 목적물로부터 우선적으로 변제받는 권리를 말한다.

II. 질권의 설정

1. 질권의 대상

1) 특허에 관한 권리는 재산권으로서 질권의 대상이 될 수 있다. 구체적으로 특허권, 전용 실시권, 허락에 의한 통상실시권 및 법정실시권은 질권의 대상이 된다. 또한 각각의 권리가 공유인 경우에는 그 지분도 질권의 대상이 될 수 있다. 다만 특허를 받을 수 있는 권리는 불확정권리이므로 질권의 대상이 될 수 없다(法 37②).

2) 한편 강제실시권 중 통상실시권허락심판(法 138)에 의한 통상실시권 및 재정에 의한 통상실시권(法 107)은 질권을 설정할 수 없다(法 102⑥). 국가 비상사태 등에 의한 통상실시권(法 106의2)은 제102조제6항의 반대해석상 질권을 설정할 수 있으나 공익을 위하여 인정되는 강제실시권의 취지를 고려해 볼 때 수익행위를 하는 것은 타당하지 않으므로 질권을 설정할 수 없는 것으로 제한하여야 한다.

2. 질권설정의 제한

1) 전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하거나 통상실시권을 허락할 수 있다(法 100④). 또한 통상실시권자는 특허권자 (전용실시권에 관한 통상실시권의 경우에는 특허권자 및 전용실시권자)의 동의를 받아야만 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정할 수 있다(法 102⑥).

2) 특허권, 전용실시권 및 통상실시권이 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 받아야만 질권을 설정할 수 있다(法 99②, 100⑤, 102⑦).

Ⅲ. 질권의 효력

1. 우선변제

등록한 질권자는 질권에 기해 후순위 채권자보다 우선하여 변제받을 수 있다. 다만 특허권은 무체재산권이기 때문에 물건의 인도로 인한 유치적 효력은 없다.

2. 특허발명을 실시할 수 있는 자

특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 목적으로 하는 질권을 설정하였을 때에는 질권자는 계약으로 특별히 약정한 경우를 제외하고는 해당 특허발명을 실시할 수 없다(法 121). 특허발상 질권은 민법상의 동산에 관한 질권과는 달리 유치적 효력이 없으므로 각 권리자는 질권을 설정하였다고 하더라도 채무불이행으로 질권이 실행되기 전까지는 계속하여 실시할 수 있다.

3. 법정실시권의 발생

특허권자(공유인 특허권을 분할청구한 경우에는 분할청구를 한 공유자를 제외한 나머지 공유자를 말한다)는 특허권을 목적으로 하는 질권설정 또는 공유인 특허권의 분할청구 이전에 그 특허발명을 실시하고 있는 경우에는 그 특허권이 경매 등에 의하여 이전되더라도 그 특허발명에 대하여 법정실시권을 가진다. 이 경우 특허권자는 새로운 특허권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 122).

4. 물상대위

1) 「물상대위(物上代位)」란 담보물권 목적물의 멸실·훼손·공용징수에 따라 그 물건의 소유자가 금전 그 밖의 물건을 받을 청구권을 취득한 경우에 그 담보물권이 이 청구권위에 효력이 있는 것을 말한다. 질권은 채무변제의 실효성을 높이기 위해 특허법에 의한 보상금이나 특허발명의 실시에 대하여 받을 대가나 물건에 대해서도 이를 행사할 수 있다. 다만 보상금 등의 지급 또는 인도 전에 압류하여야 한다(法 123).

2) 특허권, 전용실시권을 목적으로 하는 질권이 설정되어 있는데 재정에 의한 강제실시권이 허락된 경우에는 재정에 의한 강제실시권자는 질권자의 동의를 받지 아니한 경우 대가를 공탁하여 질권자가 물상대위할 수 있도록 하여야 한다(法 112Ⅲ).

5. 동의할 권리

특허권자는 질권자의 동의를 받아야만 특허권의 포기(法 119①), 특허의 정정 및 정정심판 청구(다만 질권자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)(法 132의3③, 133의2④, 136⑧)를 할 수 있다. 한편 전용실시권자 및 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 전용실시권 및 통상실시권을 포기할 수 있다(法 119②③).

6. 심판장의 통지의무

특허무효심판, 존속기간연장등록의 무효심판, 정정무효심판이 청구된 경우 등록된 질권자는 심판장으로부터 그 취지를 통지받아 심판에 참가할 수 있다(法 133④, 134③, 137②).

Ⅳ. 질권의 소멸

질권은 채무의 변제, 설정계약의 해제, 특허권 존속기간의 만료, 상속인의 부존재 등에 의하여 소멸한다.

Ⅴ. 등록의 효력

1) 특허권, 전용실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계의 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록하여야만 효력이 발생한다(法 101①Ⅲ). 한편 질권의 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우에는 지체없이 그 취지를 지식재산처장에게 신고하여야 한다(法 101②).

2) 통상실시권을 목적으로 하는 질권의 설정·이전·변경·소멸 또는 처분의 제한은 이를 등록하여야만 제3자에게 대항할 수 있다(法 118③).

【표 6-20】 특허권의 변동과 특허를 받을 수 있는 권리의 변동의 비교

권 리	특허를 받을 수 있는 권리	특허권
이 전	· 이전가능(法 37①), 공유인 경우 다른 공유자모두의 동의를 받아야만 양도가능(法 37③) → 단, 다른 공유자의 동의를 받지 않고도 상속은 가능 · 특허출원 전 이전 → 출원하여야 대항요건취득(法 38①) · 특허출원 후 이전 → 상속이나 그 밖의 일반승계를 제외하고 출원인변경신고를 하여야 효력발생(法 38④)	· 이전가능(法 99①), 공유인 경우 다른 공유자 모두의 동의를 받아야만 양도가능(法 99②) → 단, 다른 공유자의 동의를 받지 않고도 상속은 가능 · 상속이나 그 밖의 일반승계를 제외하고는 이전등록을 하여야 효력발생
실시권 설정	· 실시권설정불가	· 실시권설정가능(法 100, 102), 단 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 받아야만 실시권설정가능(法 99④) · 전용실시권은 등록하여야 효력발생하며, 통상실시권은 설정계약에 의하여 효력발생하나 등록하여야 대항가능
질권 설정	· 질권설정불가(法 37②)	· 질권설정가능(法 121), 단 공유인 경우 다른 공유자의 동의를 받아야만 질권설정가능(法 99②) · 질권설정등록하여야 효력발생
수용 등	· 국방상 필요한 경우 외국에의 출원금지, 비밀취급 명령, 불특허가능 · 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에 수용가능	· 전시·사변 또는 이에 준하는 비상시에 국방상 필요한 경우에 정부가 수용할 수 있음
포 기	· 포기 가능, 지분포기는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 자유롭게 가능 · 포기서를 제출하여 수리된 경우 효력발생	· 포기 가능, 지분포기는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 자유롭게 가능 · 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의 필요 · 포기등록을 하여야 효력발생

제5장

특허권의 소멸 등

제1절 특허권의 소멸

제119조 【특허권 등의 포기의 제한】

- ① 특허권자는 다음 각 호의 모두의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다.
1. 전용실시권자
 2. 질권자
 3. 제100조제4항에 따른 통상실시권자
 4. 제102조제1항에 따른 통상실시권자
 5. 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권자
- ② 전용실시권자는 질권자 또는 제100조제4항에 따른 통상실시권자의 동의를 받아야만 전용실시권을 포기할 수 있다.
- ③ 통상실시권자는 질권자의 동의를 받아야만 통상실시권을 포기할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제120조 【포기의 효과】

특허권·전용실시권 또는 통상실시권을 포기한 때에는 특허권·전용실시권 또는 통상실시권은 그때부터 소멸된다.

[전문개정 2014.6.11.]

제124조 【상속인이 없는 경우 등의 특허권 소멸】

- ① 특허권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 특허권은 소멸된다. <개정 2016.2.29.>
- ② 청산절차가 진행 중인 법인의 특허권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다. 이하 이 항에서 같다)까지 그 특허권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 청산종결등기일의 다음 날에 소멸한다. <신설 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

[제목개정 2016.2.29.]

I. 서 설

「특허권의 소멸」이란 유효하게 발생한 특허권이 일정한 법정사유에 의하여 장래를 향하여 효력이 상실되거나, 소급하여 처음부터 없었던 것으로 보는 것을 말한다. 특허권이 특허발명을 독점적으로 지배할 수 있는 권리로서 개인에게 주어지는 재산권이기는 하지만 이와 같은 특허권은 발명 공개의 대가로서 주어지는 것임에 비추어 그 권리를 어느 특정인에게 무한정으로 독점시킬 수는 없다 할 것이므로 일정한 사유가 있으면 특허권은 이를 소멸시킬 필요가 있다.

특허권의 소멸은 특허권 자체가 없어져 버리는 절대적 소멸이라는 점에서 상대적 소멸인 특허권의 이전과 구별된다.

II. 특허료의 불납

특허권자는 소정 기간에 일정한 특허료를 낼 의무를 지며 이를 게을리한 때에는 특허권이 소멸된다. 추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다(法 81③).

III. 특허권 존속기간의 만료

특허권의 존속기간은 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다(法 88①). 다만 i) 특허발명을 실시하기 위하여 다른 법령에 따라 허가를 받거나 등록 등을 하여야 하고, 그 허가 또는 등록 등을 위하여 필요한 유효성·안전성 등의 시험으로 인하여 장기간이 소요되는 대통령령으로 정하는 발명인 경우에는 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간에서 그 특허권의 존속기간(제92조의5제2항에 의한 등록지연에 따라 특허권의 존속기간의 연장이 등록된 경우에는 그 연장된 날까지를 말한다)을 한 차례만 연장하거나, ii) 특허출원에 대하여 특허출원일부터 4년과 출원심사 청구일부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있다. 따라서 특허권은 설정등록이 있는 날로부터 특허출원일 후 20년(연장된 경우에는 연장기간의 만료일)이 지나면 존속기간이 만료되어 소멸한다.

IV. 특허권의 포기

1. 의 의

「특허권의 포기」란 특허권자의 의사에 의하여 특허권을 장래를 향하여 소멸시키는 것을 말한다. 특허료 납부의 비용보다 특허권의 유지로 인한 이익이 적은 경우 등의 사유가 있는 경우 특허권자의 의사에 따라 특허권을 포기할 수 있다.

2. 포기의 대상

1) 특허권자는 특허권 자체를 포기할 수도 있고, 청구범위에 둘 이상의 청구항이 기재되고 있는 경우에는 청구항별로 포기할 수도 있다(法 215).

2) 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의가 없어도 자기의 지분을 포기할 수 있다. 이때 포기한 공유자의 지분은 다른 공유자에게 그 지분의 비율로 속하게 된다.

3. 포기의 절차

특허권을 포기하려는 자는 특허권 소멸등록 신청서를 지식재산처장에게 제출하여야 한다. 소멸등록신청서에는 등록원인을 증명하는 서류로서 포기서 및 인감증명서를 첨부하여야 한다(登錄令 43). 다만 특허권자는 전용실시권자·질권자·직무발명에 의한 통상실시권자·허락에 의한 통상실시권자의 동의를 받아야만 특허권을 포기할 수 있다(法 119①). 실시권 또는 질권은 특허권의 존속을 전제로 하는 부수적인 성질을 가진 권리이므로 특허권의 소멸에 대하여 이해관계가 있기 때문이다.

4. 포기의 효과

특허권의 포기는 특허원부에 특허권의 소멸등록을 하여야만 포기의 효력이 발생한다(法 101①). 특허권의 포기가 있으면 특허권은 그때부터 소멸된다(法 120).

V. 상속인의 부존재 등

1. 상속인이 없는 자연인의 경우

(1) 의 의

특허권의 상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우에는 그 특허권은 소멸된다(法 124①). 원래 상속인이 없는 경우에 상속재산은 국가에 귀속됨이 원칙이지만(民法 1058) 특허발명에 관하여는 그것을 널리 사회일반에 개방하여 자유로이 실시하게 하는 것이 산업정책상 유리하므로 특허법은 상속인이 없는 경우에 특허권이 소멸되는 것으로 규정하고 있다.

(2) 공유 특허권

특허권이 공유인 경우 공유자 중 1명이 상속인 없이 사망하면, 그 지분이 다른 공유자에게 그 지분비율로 귀속되고 특허권은 소멸되지 아니한다.

(3) 효력발생시기

상속인 부존재에 의한 특허권 소멸의 효력발생시기는 피상속인의 사망시가 되며, 소멸등록이 없어도 효력이 발생한다. 한편 지식재산처장은 상속인의 부존재로 특허권이 소멸된 때에는 그 취지를 특허공보에 공고하여야 한다(施規 55).

2. 청산절차가 진행 중인 법인의 경우

청산중인 법인은 비록 해산되어도 청산의 목적 범위에서는 법인격이 유지된다.⁴⁴⁶⁾ 청산절차가 진행 중인 법인의 특허권은 법인의 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다)까지 그 특허권의 이전등록을 하지 아니한 경우에는 그 다음 날에 소멸한다(法 124②).

VI. 특허취소신청에 의한 특허의 취소

특허취소신청이란 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 제132조의2 제1항 각호의 특허취소사유에 해당하는 경우 특허심판원에 그 특허권의 효력을 소급하여 소멸시켜 줄 것을 요구하는 신청을 말한다(法 132의2). 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 132의13).

VII. 특허무효심판에 의한 특허의 무효

특허무효심판이란 이해관계인 또는 심사관이 유효하게 설정등록된 특허권이 제133조제1항 각호의 무효사유에 해당하는 경우 그 특허권의 효력을 소급하여 또는 장래를 향하여 소멸시켜 줄 것을 청구하는 심판을 말한다. 특허무효심판청구에 대하여 무효심결이 확정된 경우에는 원칙적으로 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만 특허된 후에 특허권자가 외국인의 권리능력의 규정(法 25)에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자가 되거나 그 특허가 조약을 위반하여 무효심판청구에 의한 무효심결이 확정되면 그 사유가 발생하게 된 때부터 장래를 향하여 소멸한다(法 133).

446) 회사정리법에 의한 정리절차개시결정이 있으면 회사사업의 경영과 재산의 관리 및 처분을 하는 권리는 관리인에게 전속하며(회사정리법 제53조제1항), 회사의 재산에 관한 소에서는 관리인이 원고 또는 피고가 되는 것인바(같은 법 제96조), 여기에서 말하는 회사의 재산에 관한 소송 가운데는 회사 명의의 상표등록취소를 구하는 심판도 당연히 포함되므로, 정리회사가 상표권자인 상표에 대한 등록의 취소를 청구하는 심판에서 정리회사는 피심판청구인이 될 수 없고 오로지 관리인만이 피심판청구인 자격이 있는 것이다(대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3371).

【표 6-21】 특허권의 소멸원인과 효과

소멸	장래를 향해 소멸	소급하여 소멸
원인	■ 특허료 불납 ■ 존속기간의 만료 ■ 특허권의 포기 ■ 상속인 부존재(청산절차가 진행 중인 법인의 특허권을 청산종결등기일(청산종결등기가 되었더라도 청산사무가 사실상 끝나지 아니한 경우에는 청산사무가 사실상 끝난 날과 청산종결등기일부터 6개월이 지난 날 중 빠른 날로 한다)까지 이전등록하지 아니한 경우 그 다음 날 소멸)	■ 특허취소신청에 의한 취소결정의 확정 ■ 특허무효심판에 의한 무효심결의 확정(후발적 무효사유는 제외)
효과	1. 특허권 존속기간 만료 후의 디자인보호법상 법정실시권 인정(디자인 103③④) 2. 특허권 존속기간 만료 후의 상표법상 법정사용권 인정(商標 98) 3. 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권의 효력 제한 및 법정 실시권 인정(法 81의3)	1. 보상금청구권의 소멸(法 65⑥) 2. 소급 소멸 전 침해소송은 재심의 대상이며, 특허권자에게는 손해배상책임 또는 부당이득반환 청구 가능 3. 특허취소신청 또는 무효심결 확정 후 재심에 의하여 상반된 결정 또는 심결이 확정된 경우 효력 제한 및 법정실시권 인정(法 181, 182) 4. 무효심결확정된 경우 중용권의 발생(法 104) 5. 무권리자의 특허가 무효심결확정된 경우 정당한 권리자 출원 가능(法 35) 6. 특허취소결정 또는 무효심결이 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분의 반환 청구 가능(法 84)

제2절 특허권자의 의무

제125조 【특허실시보고】

지식재산처장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있다.

I. 서설

특허권은 특허발명을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 권리임과 동시에 사회적·공공적인 성격을 가지고 있는 권리이기도 하다. 따라서 특허법은 산업정책적인 이유로 특허권자에게 일정한 의무를 부과하는 한편 이를 위반할 때 일정한 제재를 가하고 있다.

II. 실시의무

1. 의 의

특허권자가 스스로 특허발명을 실시할 의무를 말한다. 특허발명의 실시의무는 권리남용금지의 특허법상 표현으로서, 특허법은 발명공개의 대가로 특허권을 부여하고 그 공개된 발명의 적절한 실시를 통하여 산업발전에 기여하려는 특허법의 목적을 달성하기 위해 실시하지 아니한 경우 제재조치를 두고 있다. 즉 특허법은 「권리 위에서 잠자는 것」을 묵인하지 아니한다.

2. 불실시에 대한 제재

파리조약에 의하면 특허발명의 실시를 확보하는 방법은 특허발명의 불실시 또는 불충분한 실시에 대하여 강제실시권(compulsory License)을 허락하는 방법과 특허권을 취소(revocation)하는 방법이 있다. 특허법은 이를 반영하여 불실시에 대한 제재인 재정에 의한 강제실시권(法 107)와 특허권의 취소(法 116)⁴⁴⁷⁾를 인정하고 있었다.⁴⁴⁸⁾ 그러나 특허권의 취소(法 116)에 관한 규정은 2012. 3. 15. 시행된 현행법(법률 제11117호, 2011. 12. 2. 개정)에서 삭제하였다. 이는 i) 개인의 재산권을 침해한다는 비판이 있었고, ii) 「대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정 및 대한민국과 미합중국 간의 자유무역협정에 관한 서한교환」을 국내법에 반영하기 위해서이다.

III. 특허발명의 실시협조의무

1. 의 의

특허제도는 발명의 보호와 함께 발명의 이용을 통한 산업발전 이바지를 목적으로 하고 있으므로 특허권자는 그 특허발명을 실시하려는 자에 대하여 정당한 이유가 없는 한 실시협조를 하여야 할 의무가 있다. 실시협조의무 역시 권리남용금지의 특허법상 표현이다.

2. 실시협조의무 위반에 대한 제재

(1) 통상실시권허락심판의 경우

특허발명이 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인이나

447) 특허청장(현재 지식재산청장)은 불실시를 이유로 재정이 있는 날부터 계속하여 2년 이상 그 특허발명이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있다.

448) 파리조약 제5조A(2)(3)에서는 “각 동맹국은 불실시와 같은 특허에 의하여 부여되는 배타권 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있으며, 강제실시권의 부여가 그러한 남용을 방지하기에 충분하지 아니하면 특허의 몰수 또는 철회를 규정할 수 있다”라고 규정하고 있는데, 이를 반영한 규정이 제107조제1항제1호, 제2호 및 제116조이다.

그 디자인과 유사한 디자인과 이용관계에 있거나 특허권이 특허출원일 전에 출원된 타인의 디자인권과 저촉관계에 있을 때 후출원 권리자가 실시권의 허락을 청구하면 선출원 권리자는 정당한 이유가 없는 한 후출원 권리자에게 실시권을 허락하여 실시에 협조하여야 한다. 만약 이용·저촉관계에 있는 선출원 권리자가 정당한 이유없이 실시허락을 하지 않으면 후출원 권리자는 특허권자 실시협조의무의 위반을 이유로 통상실시권허락심판을 청구하여 강제적으로 실시권을 허락받을 수 있다(法 138).

(2) 재정실시권의 경우

재정제도(法 107)와 관련하여서도 특허권자의 실시협조의무가 요구된다. 즉 국내에 특허발명을 실시하려는 자가 있는데도 불구하고 정당한 이유없이 실시협조를 하지 아니함으로써 국내산업에 불이익을 끼칠 때는 특허권자의 권리남용 법리를 원용하여 그 특허권을 재정실시권의 대상으로 하고 있다.

IV. 특허료 납부의무

1. 의 의

특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자는 특허료를 내야 한다(法 79①). 특허료의 납부는 i) 특허권 설정등록의 경우에는 특허권의 발생요건이고, ii) 특허권이 존속하고 있는 경우에는 특허권의 존속요건이다. 특허료의 납부는 이행을 강제할 수 없으므로 법적 의무라고 볼 수 없다. 특허료를 내지 않으면 특허권의 소멸이라는 자기의 불이익을 초래할 뿐이므로 특허료 납부의 법적 성질은 책무 또는 간접의무라고 할 것이다.

2. 위반에 대한 제재

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 이를 포기한 것으로 보며, 특허권자의 특허권은 낸 특허료에 해당되는 기간이 끝나는 날의 다음 날로 소급하여 소멸된 것으로 본다(法 81③).

V. 그 밖의 의무

1. 실시보고

지식재산처장은 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자에게 특허발명의 실시 여부 및 그 규모 등에 관하여 보고하게 할 수 있다(法 125). 이는 지식재산처장이 산업부문의 동향을 파악하고 국가의 산업정책수립 등을 점검·반영토록 하기 위한 것이다. 다만 기존에는 특허발

명의 실시보고 명령에 정당한 이유없이 응하지 아니한 자는 50만원 이하의 과태료를 과하였으나 이는 행정적 편의를 위한 과도한 규제라는 비판이 있었고, 2006. 3. 3. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정)에서는 이를 삭제하였다.

2. 권장사항으로서 특허표시 및 특허출원표시

(1) 특허표시 및 특허출원표시

특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 i) 물건의 특허발명의 경우 그 물건, ii) 물건을 생산하는 방법의 특허발명의 경우 그 방법에 의하여 생산된 물건, iii) 물건에 특허표시를 할 수 없을 경우 그 물건의 용기 또는 포장에 특허표시를 할 수 있다(法 223①③). 구체적으로 물건의 특허발명에 있어서는 그 물건에 「특허」라는 문자와 그 특허번호를, 물건을 생산하는 방법의 특허발명에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 「방법특허」라는 문자와 그 특허번호를 표시한다. 출원인은 물건의 특허출원에 있어서는 그 물건에 「특허출원(심사중)」이라는 문자와 그 출원번호를, 물건을 생산하는 방법의 특허출원에 있어서는 그 방법에 의하여 생산된 물건에 「방법특허출원(심사중)」이라는 문자와 그 출원번호를 표시한다(法 223②).⁴⁴⁹⁾ 특허표시, 특허출원표시는 권장사항이고 의무는 아니다. 특허표시 및 특허출원표시제도는 그 물건이 특허제품, 특허출원제품임을 공시하여 그에 대한 침해를 예방함으로써 특허권자를 보호하고 또한 상품선택의 기준을 제시함으로써 일반 제3자를 보호함에 그 취지가 있다.

(2) 허위표시

1) 「허위표시」란 특허된 것이 아닌 물건이나 특허출원 중이 아닌 물건 등에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 것을 말하는 것으로서 특허법에 규정된 허위표시의 유형은 다음과 같은 행위를 말한다(法 224).

- i) 특허된 것이 아닌 물건, 특허출원 중이 아닌 물건, 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법에 의하여 생산한 물건 또는 그 물건의 용기나 포장에 특허표시 또는 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
- ii) i)의 표시를 한 것을 양도·대여 또는 전시하는 행위
- iii) i)의 물건을 생산·사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 물건이 특허나 특허출원된 것 또는 특허된 방법이나 특허출원 중인 방법에 따라 생산한 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위
- iv) 특허된 것이 아닌 방법이나 특허출원 중이 아닌 방법을 사용·양도 또는 대여하기 위하여 광고·간판 또는 표찰에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 하는 행위

449) 제223조제1항 및 제2항에 따라 특허표시 또는 특허출원의 표시를 하는 경우 특허번호 또는 특허출원번호를 기재한 인터넷주소를 표시함으로써 특허번호 또는 특허출원번호의 표시를 갈음할 수 있다(施規 121).

2) 다만 특허된 것 등으로 표시한 물건의 기술적 구성이 청구범위에 기재된 발명의 구성을 일부 변경한 것이라고 하더라도, 그러한 변경이 통상의 기술자가 보통 채용하는 정도로 기술적 구성을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 효과에 특별한 차이가 생기지도 아니하는 등 공중을 오인시킬 정도에 이르지 아니한 경우에는 물건에 특허된 것 등으로 표시를 하는 행위가 허위표시행위에 해당한다고 볼 수 없다.⁴⁵⁰⁾

(3) 허위표시죄

허위표시의 금지(法 224)에 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다(法 228). 본 죄는 특허제품 또는 특허방법이 아닌 것에 특허표시, 특허출원표시를 하거나 이와 혼동하기 쉬운 표시를 함으로써 특허에 대한 공중의 신뢰를 악용하여 공중을 오인케 하는 행위를 처벌하려는 규정으로써 그 보호법익은 사회의 거래안전이라고 할 수 있다. 본 죄는 비친고죄이며, 양벌규정이 적용된다.

3. 특허 문헌 제출의무

지식재산처장 또는 심사관은 당사자에게 특허취소신청·심판 또는 재심에 관한 절차 외의 절차를 처리하기 위하여 필요한 서류나 그 밖의 물건의 제출을 명할 수 있으며(法 222), 지식재산처장은 국제출원인의 출원에 대하여 기간을 정하여 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 적혀 있는 문헌의 사본을 제출하도록 명할 수 있다(法 211). 다만 이에 불응하는 경우 특별한 제재 규정은 두고 있지 않으므로 상기 문헌제출을 하지 아니한 경우 심사절차상의 불이익을 지는 데 그친다고 해석된다.⁴⁵¹⁾

4. 수수료 납부의무

특허권자가 부담하는 수수료 납부의무의 법적 성질 역시 특허료 납부의 경우와 같이 법적 의무가 아니라 책무 또는 간접의무이다. 지식재산처장 등은 수수료를 내지 아니한 경우 보정명령을 하여야 하고(法 46), 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 그 보정을 하지 아니하면 그 절차를 무효로 할 수 있다(法 16①).

450) 대법원 2015. 8. 13. 선고 2013도10265.

451) 심판의 경우 제147조제3항에 따라 당사자를 심문할 수 있으므로, 별도로 제222조에서 규정하고 있지 않다.

PART 07

심 판

제1장 심판절차 일반

제2장 심판의 주체

제3장 심판의 청구

제4장 심판의 진행

제5장 심판의 종료

제6장 구체적인 심판의 내용

제1장

심판절차 일반

제1절 서설

I. 의의

「특허심판」이란 특허출원에 대하여 심사관이 행한 처분 또는 그 처분에 의하여 부여된 특허권에 관한 분쟁을 해결하기 위하여 특허심판원의 심판관 합의체에 의하여 행해지는 특별행정 심판을 말한다. 특허에 관한 분쟁의 처리에는 보호객체의 특수성에 의하여 전문적 기술지식이 필요하므로 그 심리 판단을 특허심판원의 심판관에 의하도록 하고 있다. 심판절차는 심판의 객관성과 공정성을 확보하기 위하여 민사소송법상의 재판절차를 상당부분 준용하고 있다.¹⁾

II. 법적성질

심판절차는 형식적으로는 특허에 관한 분쟁을 해결하기 위하여 특허심판원의 심판관 합의체에 의하여 심리·결정되는 행정상의 쟁송절차라 할 수 있지만, 사실상 특허법원의 전심절차로서 민사소송에 준하는 엄격한 절차를 거쳐 판단되는 준사법적 성질을 가진다.

1) 특허심판과 민사소송의 주요 차이점에 대하여 정리하면 다음과 같다.

구 분	특허심판	민사소송
신분보장	직무상 독립	직무상, 신분상 독립
심리방법	직권주의	당사자주의
심리진행	구술심리, 서면심리	구술심리
기속력	당사자, 제3자	당사자
재판상 화해, 포기, 인낙	불인정	인정

제2절 심판의 분류

I. 독립적 심판과 부수적 심판

1. 구별기준

1) 「독립적 심판」이란 심판의 청구취지가 독립된 심판으로서 심결이라는 형식으로 판단되는 것을 말하여, 통상적으로 심판이라고 할 때는 독립적 심판을 의미한다. 거절결정에 대한 불복심판(法 132의17), 특허무효심판(法 133), 특허권의 존속기간 연장등록의 무효심판(法 134), 권리범위확인심판(法 135), 정정심판(法 136), 정정의 무효심판(法 137), 통상실시권허락심판(法 138), 재심(法 178-185) 등이 여기에 속한다.

2) 「부수적 심판」이란 그 자체만으로는 독립해서 심판의 대상이 되지 못하고 독립된 본안심판의 청구사항에 부수하거나 본안심판의 청구를 전제로 하는 심판을 말한다. 심판관의 제척·기피심판(法 152①), 참가심판(法 156③), 증거보전심판(法 157), 심판비용심판(法 165) 등이 속한다.

2. 구별실의

독립적 심판은 독립적인 심결이라는 형식으로 판단되므로 독립하여 불복할 수 있으나, 부수적 심판은 독립하여 불복할 수 없다. 이는 독립적 심판의 심결이유에서 판단되고 불복을 허용하여 절차를 공전(空轉)시키는 것은 절차경제의 요청에 반하기 때문이다.

II. 결정계 심판과 당사자계 심판

1. 구별기준

1) 「결정계 심판」이란 독립적 심판 중 심판당사자로서 청구인과 피청구인이 대립구조를 취하지 않고 청구인만 존재하는 심판을 말한다. 거절결정에 대한 불복심판(法 132의17), 정정심판(法 136)이 여기에 속한다.

2) 「당사자계 심판」이란 독립적 심판 중 당사자로서 청구인과 피청구인이 존재하고 그 당사자가 서로 대립구조를 취하는 심판을 말한다. 특허무효심판(法 133), 권리범위확인심판(法 135), 통상실시권허락심판(法 138), 정정무효심판(法 137), 특허권의 존속기간 연장등록무효심판(法 134)이 여기에 속한다.

2. 구별실의

1) 결정계 심판은 당사자계 심판과 달리 참가제도가 인정되지 않고 일사부재리가 적용되지 않는다. 결정계 심판의 심판비용은 청구인이 부담하나, 당사자계 심판의 심판비용은 통상실시권허락심판을 제외하고는 패심자 부담이 원칙이다.

2) 또한 결정계 심판은 당사자계 심판과 달리 피청구인이 없으므로 부분 송달 및 답변서 제출에 관한 규정(法 147①②)이 적용되지 않고 인용심결에 대하여 불복할 수 없다. 따라서 결정계 심판의 인용심결은 심판장으로부터 등본이 송달된 때 확정된다. 그러나 당사자계 심판은 피청구인이 인용심결에 대해 불복할 수 있으므로 불복할 수 있는 기간, 즉 심판장으로부터 인용심결등본이 송달된 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다)이 지나야만 확정된다.

【표 7-1】 심판의 분류

독립적	의의	심판의 청구취지가 독립되어 있는 심판으로서 심결이라는 형식으로 판단하는 심판	
	결정계	종류	1. 의의 당사자로서 청구인과 피청구인의 대립구조를 취하지 아니하고 청구인만 존재하는 심판
			2. 종류 ① 거절결정에 대한 불복심판(法 132의17) ② 정정심판(法 136) 3. 실익 ① 참가제도가 인정 × ② 심판비용은 청구인이 부담(法 165③) ③ 일사부재리 적용 ×(단, 정정심판의 경우 학설대립) ④ 부분 송달 및 답변서 제출(法 147①②) × ⑤ 인용심결에 대한 불복 ×, 등본송달과 동시에 확정
	당사자계	종류	1. 의의 당사자로서 청구인과 피청구인이 존재하고 그 당사자가 서로 대립구조를 취하는 심판
2. 종류 ① 특허무효심판(法 133) ② 특허권의 존속기간 연장등록의 무효심판(法 134) ③ 권리범위확인심판(法 135) ④ 정정의 무효심판(法 137) ⑤ 통상실시권허락심판(法 138) 3. 실익 ① 참가제도가 인정 ○(단, 통상실시권허락심판은 보조 참가만 허용된다는 것이 통설) ② 심판비용은 통상실시권허락심판(청구인 부담)을 제외하고 패심자가 부담 ③ 일사부재리 적용 ○ ④ 부분 송달 및 답변서 제출(法 147①②) ○ ⑤ 인용심결에 대한 불복 ○, 등본송달일로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다)이 지난 후 확정.			
	실익	독립하여 불복 허용	
부수적	의의	그 자체만으로는 독립해서 심판의 대상이 되지 못하고 독립된 본안심판의 청구사항에 부수하거나 본안심판의 청구를 전제로 하는 심판	
	종류	1. 심판관의 제척·기피심판(法 152①) 2. 참가심판(法 156③) 3. 증거보전심판(法 157) 4. 심판비용심판(法 165) 등	
	실익	독립하여 불복 불허	

제2장

심판의 주체

제1절 특허심판원

제132조의16 【특허심판원】

- ① 특허·실용신안·디자인·상표에 관한 심판과 재심 및 이에 관한 조사·연구 사무를 관장하게 하기 위하여 지식재산청장 소속으로 특허심판원을 둔다. <개정 2016.2.29.>
 - ② 특허심판원에 원장과 심판관을 둔다.
 - ③ 특허심판원에 제1항에 따른 조사·연구와 그 밖의 사무를 담당하는 인력을 둘 수 있다. <신설 2021. 8. 17.>
 - ④ 특허심판원의 조직과 정원 및 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2021. 8. 17.>
- [전문개정 2014.6.11.]

제143조 【심판관】

- ① 특허심판원장은 심판이 청구되면 심판관에게 심판하게 한다.
- ② 심판관의 자격은 대통령령으로 정한다.
- ③ 심판관은 직무상 독립하여 심판한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제144조 【심판관의 지정】

- ① 특허심판원장은 각 심판사건에 대하여 제146조에 따른 합의체를 구성할 심판관을 지정하여야 한다.
- ② 특허심판원장은 제1항의 심판관 중 심판에 관여하는 데 지장이 있는 사람이 있으면 다른 심판관에게 심판하게 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제145조 【심판장】

- ① 특허심판원장은 제144조제1항에 따라 지정된 심판관 중에서 1명을 심판장으로 지정하여야 한다.
- ② 심판장은 그 심판사건에 관한 사무를 총괄한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제146조 【심판의 합의체】

- ① 심판은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 한다.
- ② 제1항의 합의체의 합의는 과반수로 결정한다.
- ③ 심판의 합의는 공개하지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제147조 【답변서 제출 등】

- ① 심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고, 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- ② 심판장은 제1항의 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다.
- ③ 심판장은 심판에 관하여 당사자를 심문할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제1관 서 설

「특허심판원」은 행정관청인 지식재산처의 소속기관이며 특허분쟁에 관한 특허심판사무를 담당하는 심판기관이다. 특허심판원은 특허·실용신안에 관한 취소신청, 특허·실용신안·디자인·상표에 관한 심판과 재심 및 이에 관한 조사·연구 사무를 관장한다(法 132의16①).

제2관 특허심판원의 조직과 구성

I. 특허심판원의 조직

특허심판원에 원장과 심판관을 두고, 조사·연구와 그 밖의 사무를 담당하는 인력을 둘 수 있다(法 132의16②③). 특허심판원은 특허분쟁에 관한 심판기관이면서 동시에 지식재산처 내부의 기관인 점에 특색이 있다.

II. 특허심판원의 구성

1. 특허심판원장

특허심판원에 원장 1명을 두되, 원장은 관리관으로 보한다. 원장은 심판관의 자격이 있는 사람으로서 지식재산처장의 명을 받아 심판행정사무를 통할하고 소속공무원을 지휘·감독하며, 특히 중요하다고 인정되는 사건에 대해서는 특허심판원장 스스로 제145조에 따라 심판장이 될 수 있다(令 8④, 지식재산처와 그 소속기관 직제 21).

2. 심판부

(1) 심판관 합의체

1) 특허심판원장은 심판이 청구되면 심판관에게 심판하게 한다(法 143①). 심판관의 자격은 대통령령으로 정한다(法 143②). 심판관은 특허심판원의 소속공무원으로서의 일반 행정사무상에 있어서는 특허심판원장의 지휘감독을 받지만, 심판의 독립성을 확보하기 위하여 심판에 있어서는 직무상 독립하여 심판한다(法 143③). 심판관은 외부로부터의 부당한 압력을 배제하기 위하여 심사·특허취소신청·심판 또는 재심으로 계속 중인 사건의 내용이나 특허여부결정·심결 또는 결정의 내용에 관하여는 감정·증언하거나 질의에 응답할 수 없다(法 217②).

2) 특허심판원장은 각 심판사건에 대하여 합의체를 구성할 심판관을 지정하여야 한다. 심판은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 이를 하는데, 심판관 합의체의 합의는 과반수로 결정하며 공개하지 아니한다(法 144①, 146).

3) 한편 특허심판원장은 심판관 중 심판에 관여하는데 지장이 있는 사람이 있으면 다른 심판관에게 심판하게 할 수 있다(法 144②). 이는 심판관의 교체를 단순히 「심판에 관여하는데 지장이 있는 사람」이라고 하여 특허심판원장의 재량 여지가 크기 때문에 특허심판원장이 그 직위로부터 심판에 대하여 간접적인 영향을 미칠 수 있는 문제점이 있다.

(2) 심판장

특허심판위원장은 지정된 심판관 중에서 1명을 심판장으로 지정하여야 한다. 심판장은 그 심판사건에 관한 사무를 총괄한다(法 145).²⁾

제3관 심판관의 제척, 기피 및 회피

제148조 【심판관의 제척】

심판관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 심판에서 제척된다. <개정 2016.2.29>

1. 심판관 또는 그 배우자이거나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인인 경우
2. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 친족이거나 친족이었던 경우
3. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우
4. 심판관이 사건에 대한 증인, 감정인이거나 감정인이었던 경우
5. 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 대리인이거나 대리인이었던 경우
6. 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우
7. 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우

[전문개정 2014.6.11.]

제149조 【제척신청】

제148조에 따른 제척의 원인이 있으면 당사자 또는 참가인은 제척신청을 할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제150조 【심판관의 기피】

- ① 심판관에게 공정한 심판을 기대하기 어려운 사정이 있으면 당사자 또는 참가인은 기피신청을 할 수 있다.
- ② 당사자 또는 참가인은 사건에 대하여 심판관에게 서면 또는 구두로 진술을 한 후에는 기피신청을 할 수 없다. 다만, 기피의 원인이 있는 것을 알지 못한 경우 또는 기피의 원인이 그 후에 발생한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

제151조 【제척 또는 기피의 소명】

- ① 제149조 또는 제150조에 따라 제척 또는 기피 신청을 하려는 자는 그 원인을 적은 서면을 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 다만, 구술심리를 할 때에는 구술로 할 수 있다.
- ② 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 3일 이내에 소명하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제152조 【제척 또는 기피 신청에 관한 결정】

- ① 제척 또는 기피 신청이 있으면 심판으로 결정하여야 한다.
- ② 제척 또는 기피 신청의 대상이 된 심판관은 그 제척 또는 기피에 대한 심판에 관여할 수 없다. 다만, 의견을 진술할 수 있다.
- ③ 제1항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 결정에 대해서는 불복할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

2) 심판장의 구체적인 권한에 관하여는 제141조(심판청구서 등의 각하), 제147조(답변서 제출 등), 제154조(심리 등), 제157조(증거조사 및 증거보전), 제158조(심판의 진행) 등 총괄적인 지휘감독권을 가진다.

제153조 【심판절차의 중지】

제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다.

[전문개정 2014.6.11.]

제153조의2 【심판관의 회피】

심판관이 제148조 또는 제150조에 해당하는 경우에는 특허심판원장의 허가를 받아 그 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

1) 「심판관의 제척」이란 심판관이 제한열거적인 제척원인에 해당하는 경우 법률상 당연히 그 심판의 관여로부터 배제되는 것을 말한다. 「심판관의 기피」란 심판관에게 심판의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 당사자 또는 참가인의 신청과 결정에 의하여 그 심판에 관여할 수 없게 되는 것을 말한다.

2) 제척은 그 원인이 법정되어 있고 제척원인에 해당되면 당사자 또는 참가인의 제척신청 여부와 관계없이 법률상 당연히 그 직무에서 배제되지만, 기피는 그 원인이 제한적으로 법정되어 있지 않고 당사자 또는 참가인의 기피 신청과 심판에 의한 결정으로써 비로소 그 직무에서 배제되는 점에서 기본적인 차이가 있다.

2. 취 지

심판관이 담당하는 구체적 사건 또는 그 사건의 주체와 심판관이 특수한 관계에 있는 경우 그 사건에 대한 관여를 배제함으로써 심판의 공정성과 객관성을 확보하려는 데에 제척·기피의 의의가 있다.

II. 제척·기피의 요건

1. 제척·기피의 신청자

제척·기피원인이 있으면 당사자 또는 참가인은 제척·기피 신청을 할 수 있다(法 149, 150①). 다만 제척원인이 있으면 심판관은 법률상 당연히 심판관여로부터 배제되어야 하므로³⁾ 제척의 신청은 기피의 신청과는 달리 직권발동을 촉구하는 의미밖에 없다.

3) 대법원 1970. 9. 17. 선고 68후28.

2. 제척·기피원인

(1) 제척원인(法 148)

- ① 심판관 또는 그 배우자이거나 배우자이었던 사람이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인인 경우
- ② 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 친족이거나 친족이었던 경우
- ③ 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 법정대리인이거나 법정대리인이었던 경우
- ④ 심판관이 사건에 대한 증인, 감정인이거나 감정인이었던 경우
- ⑤ 심판관이 사건의 당사자, 참가인 또는 특허취소신청인의 대리인이거나 대리인이었던 경우
- ⑥ 심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 심결에 관여한 경우

1) 이러한 경우를 전심판여(前審關與)라고 하며 예단(豫斷)을 배제하여 심판의 공정성을 유지하고 원래 심급제도의 실효성을 확보하기 위한 것이다. 여기서 「사건」이란 동일사건을 의미한다고 할 것이다. 예를 들어 거절결정불복심판사건에 관여한 심판관은 그 후의 특허무효심판사건에 제척되어야 한다.⁴⁾ 또한 정정심판에 관여한 심판관은 정정무효심판에서 제척되어야 한다.⁵⁾ 그러나 특허에 대한 무효심판과 같은 특허에 대한 정정심판은 서로 동일사건이라 할 수 없으므로 정정심판에 관여한 심판관이 같은 특허에 대한 무효심판에 관여하였다 하더라도 제척원인에 해당한다고 할 수 없다.⁶⁾

2) 특허여부결정 또는 심결에 「관여」한 경우란 최종처분인 특허여부결정, 심결의 합의, 심결의 작성 등 깊이 있게 관여한 경우를 말한다. 그러므로 최종처분이 되기 전 단계의 심사 또는 거절이유통지, 증거조사 또는 심판절차의 일부에만 관여하였으면 최종결정에 관여한 것이 아니므로 제척원인이 되지 아니한다.⁷⁾⁸⁾

- ⑦ 심판관이 사건에 관하여 직접 이해관계를 가진 경우

직접적인 법률상 이해관계를 갖는 경우를 말하며, 간접적인 이해관계 또는 경제적인 이해관계는 이에 해당하지 아니한다. 직접적인 법률상 이해관계를 갖는 경우의 구체적인 예로는 심판관이 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자 또는 권리의 물상보증인 등인 경우가 있다.

(2) 기피원인(法 150)

기피원인은 심판관에게 공정한 심판을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우이다. 「공정한 심판을 기대하기 어려운 사정」이란 통상인의 판단으로서 심판관이 심판사건과의 관계에서 편파적이고 불공정한 심판을 하지 않을까 하는 염려를 일으킬 수 있는 객관적 사정을 말한다. 따

4) 특허법원 2000. 8. 17. 선고 2000허3463.

5) 특허법원 2010. 5. 7. 선고 2009허7680.

6) 특허법원 1998. 9. 3. 선고 98허1822.

7) 대법원 1997. 6. 13. 선고 96다56115.

8) 대법원 1980. 9. 30. 선고 78후3.

라서 당사자 측에서 품는 불공정한 심판을 받을지도 모른다는 주관적인 의혹만으로는 기피원인에 해당되지 아니한다. 구체적인 예를 들면 당사자와 심판관이 약혼관계, 사실혼관계, 친밀한 우정관계, 원한관계, 또는 민법 제777조의 범위를 넘는 친족관계 등에 있을 때 기피원인에 해당된다.

3. 제척·기피신청의 시기

(1) 제척의 경우

신청 여부와 관계없이 법률상 당연히 심판관으로부터 배제되지만 직권발동의 촉구를 위하여 심결 시까지 제척신청을 할 수 있다.

(2) 기피의 경우

사건에 관하여 심판관에게 서면 또는 구술로 진술하기 전까지 기피 신청을 할 수 있다. 기피 신청 시기를 제한하는 이유는 담당 심판관에게 기피의 이유가 있음을 알면서도 진술을 한 것은 그 심판관을 신뢰하고 있었던 것으로 보기 때문이다. 다만 진술 후라도 기피원인이 있는 것을 알지 못한 경우 또는 기피원인이 진술 후에 발생한 경우에는 심판관에 대한 진술이 그 심판관을 신뢰하고 있었다고 할 수 없으므로 진술을 한 후에도 기피신청을 할 수 있다(法 150②).

III. 제척·기피의 절차

1. 신청서 제출

제척 및 기피신청을 하려는 자는 그 원인을 적은 서면을 「특허심판원장」⁹⁾에게 제출하여야 한다. 다만 구술심리를 할 때에는 구술로 할 수 있다. 한편 제척 또는 기피의 원인은 신청한 날부터 3일 이내에 소명하여야 한다(法 151). 심판관의 확신이 필요한 증명과는 달리, 「소명」이란 그보다 낮은 정도의 개연성, 즉 심판관이 일응 확실할 것이라는 추측을 얻은 상태 또는 그와 같은 상태에 이르도록 증거를 제출하는 당사자의 노력을 말한다. 이와 같은 소명기간 제한 규정(法 151②)은 훈시규정이라 할 것이므로, 소명기간에 소명이 없다고 하여 신청을 각하할 것이 아니라 제척이나 기피신청에 대한 결정(法 152)이 있기 전까지 소명을 하는 경우 신청에 대하여 심판을 하여 결정을 하여야 한다.¹⁰⁾

2. 신청에 관한 결정

제척·기피의 신청이 있으면 심판원장에 의하여 별도로 구성된 합의체가 심판으로 결정하여야 한다. 이 경우 제척 또는 기피 신청의 대상이 된 심판관은 그 제척 또는 기피에 대한 심판

9) 이는 심판장도 제척·기피의 대상이 될 수 있기 때문이다.

10) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 78-79면.

에 관여할 수 없다. 다만 의견을 진술할 수는 있다. 한편 결정은 서면으로 하여야 하고 그 이유를 붙여야 하며, 그 결정에 대해서는 부수적 심판이기 때문에 불복할 수 없다(法 152).

3. 심판절차의 중지

제척 또는 기피 신청이 있으면 그 신청에 대한 결정이 있을 때까지 심판절차를 중지하여야 한다. 다만 긴급한 경우에는 그러하지 아니하다(法 153). 예를 들어 i) 증인을 긴급히 심문하지 아니한다면 외국으로 출발한다든가 사망할 우려가 있는 경우, ii) 긴급히 검증을 하지 아니하면 목적물이 변화, 소멸하는 경우에는 절차의 진행을 중지하지 아니하여도 된다.

IV. 제척·기피의 효과

1. 제척의 효과

제척원인이 있는 심판관은 법률상 당연히 그 사건에 대하여 직무집행을 할 수 없다.¹¹⁾ 제척의 효과는 심판 유무와 관계없이 법정의 제척원인이 있을 때에 당연히 발생하므로, 제척의 심판은 확인적 성질(선언적 의미)을 갖는다. 따라서 제척원인이 있는 심판관이 관여한 심리는 절차상 무효로 되어야 하는 것이므로, 심결 전이라면 다시 심리하여야 한다. 한편 심결 후에는 제척원인이 있는 심판관이 행한 심결이 당연무효가 되는 것이 아니며 그렇다고 하여 제척원인의 하자가 치유되는 것도 아니기 때문에 심판의 당사자는 별도로 하자를 다룰 수 있다. 구체적으로 심결 후 확정 전이면 그 심결에 대하여 특허법원에 소를 제기한 후 특허법원에서, 확정 후에는 특허심판원에 재심을 청구하여 다룰 수 있다.

2. 기피의 효과

기피원인이 있는 심판관은 제척원인이 있는 심판관과는 달리 기피결정에 의하여 비로소 직무집행에서 배제된다. 따라서 기피의 심판은 제척과는 달리 형성적 성질을 갖는다.

V. 심판관의 회피

심판관은 제척·기피원인에 해당하는 경우에는 특허심판원장의 허가를 받아 그 사건에 대한 심판을 회피할 수 있다(法 153의2). 「회피」란 심판관이 스스로 제척 또는 기피원인이 있다고 인정하여 자발적으로 직무집행을 피하는 것을 말한다. 한편 심결 시까지 회피의 신고를 받은 특허심판원장은 그 신고가 이유 있다고 인정하면 심판관의 지정을 변경한다.¹²⁾

11) 대법원 1970. 9. 17. 선고 68후28.

12) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 83면.

제2절 심판의 당사자

제1관 서 설

「당사자」란 특허심판절차에 있어서 자기의 이름으로 심판을 요구하거나 요구받는 자이다. 청구인·피청구인이라고 부르며 재심절차에서는 재심청구인·재심피청구인이라고 한다. 적법한 심판절차의 당사자가 되기 위해서는 당사자가 실재(實在)하여야 하고, 당사자능력, 당사자적격 등의 당사자에 관한 심판청구요건¹³⁾을 구비하고 있을 것이 요구된다. 이러한 심판청구요건은 본안심결의 전제요건으로서 직권조사사항이다.

제2관 당사자능력

「당사자능력」이란 일반적인 심판 절차의 주체가 될 수 있는 능력을 말하고, 원칙적으로 권리능력을 가진 자는 당사자능력이 있다(民訴法 51). 다만 비법인 사단·재단의 경우 권리능력이 없다 하더라도 일정한 경우 당사자능력이 인정된다(法 4).

제3관 당사자적격

I. 서

1. 의 의

「당사자적격」이란 그 심판 절차의 주체가 되어 정당한 당사자로서 심판을 수행하고 본안심결을 받기에 적합한 자격을 말하고 당사자적격이 있는 자를 정당한 당사자라고 한다.

2. 구별개념

당사자적격은 i) 누가 정당한 당사자로서 본안심결을 받기에 적합한 자격이 있는가의 문제인 점에서, 현재 계속되어 있는 심판에서 누가 당사자인가를 가리는 당사자의 확정¹⁴⁾ 문제와 다르며, ii) 특정사건과의 관계에서 검토되어야 하는 문제인 점에서, 구체적인 사건을 떠난 일반적 능력의 문제인 당사자능력이나 행위능력과는 구별된다.

13) 심판청구요건은 당사자에 관한 요건 외에 심판기관에 관한 요건(심판권, 특허심판사항 등), 심판의 대상에 관한 요건(심판대상의 특정, 심판의 이익, 일사부재리의 원칙 등), 그 밖의 요건(기간의 준수)으로 구분된다. 민사소송법상의 소송요건에 대응된다.

14) 현실적으로 계속되어 있는 심판사건에서 청구인이 누구이고 피청구인이 누구인가를 명확히 하는 것을 당사자의 확정이라고 한다. 이는 심결을 누구에 대하여 할 것인가를 식별하는 것뿐만 아니라, 심판관의 제척(法 148), 기피(法 150), 회피(法 153의2), 심판절차의 중단 또는 중지(法 20-24), 송달 등의 기준이 되며 당사자능력이나 당사자적격의 유무 판정에 앞서 선행되어야 한다. 당사자의 확정은 심판청구서의 당사자 표시(法 140①, 140의2①)를 기준으로 하나, 거기에 기재된 당사자 표시만이 유일한 자료는 아니고, 심판청구서의 전 취지를 보아 판단하여야 한다(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 88면).

II. 결정계 심판에서의 당사자적격

거절결정불복심판(法 132의17)의 청구인은 특허거절결정을 받은 출원인(존속기간연장의 연장등록거절결정을 받은 경우 특허권자)이며, 정정심판(法 136)의 청구인은 특허권자이다.

III. 당사자계 심판에서의 당사자적격

1. 무효심판

(1) 청구인

1) 특허무효심판(法 133), 존속기간연장등록무효심판(法 134), 정정무효심판(法 137)의 청구인은 이해관계인 또는 심사관이다. 다만 특허무효심판(法 133)과 관련하여, 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하여 제33조제1항본문을 위반한 경우나 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여 제44조를 위반한 경우에는 심사관 또는 이해관계인 중 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 청구할 수 있다. 이는 사적 이유이기 때문에 이해관계인의 범위를 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자로 제한하고 있다. 특허를 받을 수 있는 권리를 가지고 있는지의 판단은 이해관계인인지 판단과 마찬가지로 심결 시를 기준으로 한다.¹⁵⁾

2) 심사관은 공익의 대표자로서 청구인이 될 수 있으며, 심사관이 무효심판을 청구하면 우선심판의 대상이 되고 심판청구료는 면제이다. 심사관은 심판청구 당시 심사를 담당하고 있는 자이면 되고 반드시 무효심판의 대상이 되는 특허의 등록결정(정정심판의 인용심결)을 한 심사관에 한하거나 심결 당시에 그 심사관의 지위에 있어야 하는 것은 아니다.¹⁶⁾

(2) 피청구인

무효심판의 피청구인은 특허권자이다. 특허권자는 현재 특허등록원부에 특허권자로 등록된 자이어야 한다. 한편 심판장은 무효심판의 계속 중일 때 특허권이 이전되면 그 승계인에게 심판절차를 속행하게 할 수 있다(法 19). 심판장은 이처럼 승계인에 대하여 출원·청구 그 밖의 절차를 속행하게 한 때에는 그 사실을 상대방(승계인 외의 당사자)에게 서면으로 통지하여야 한다(施規 18). 다만 승계인에게 속행하게 하는 것은 재량행위이므로 반드시 절차의 속행을 명하여야 하는 것은 아니다. 심판이 종결의 단계에 이르러 권리승계인을 절차에 관여시킬 구체적인 필요성이 거의 없거나, 권리의 특정승계 신고에 관하여 방식심사가 끝나지 아니하여 구 권리자에게 그대로 절차를 수행하게 하는 것이 적당한 경우 등 그 사건에 대한 심판의 상황에 비추어 적당하다고 인정하는 때에는 종전의 당사자에게 절차를 수행하게 할 수 있고,¹⁷⁾ 한편

15) 대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814.

16) 대법원 1989. 3. 14. 선고 86후171.

17) 등록무효심판계속 중 피심판청구인이 그 등록권리를 제3자에게 이전하였다 하더라도 당사자로서의 지위에는 영향을 받지 아니한다(대법원 1967. 6. 27. 선고 67후1).

으로는 심판장이 상당하다고 인정하는 때에는 권리의 승계인에게 절차를 수계하도록 할 수도 있다고 보는 것이 비교적 폭넓게 직권주의를 채택하고 있는 특허법의 원칙에도 부합되기 때문이다.

2. 권리범위확인심판

(1) 적극적 권리범위확인심판

적극적 권리범위확인심판(法 135)은 특허권자, 전용실시권자가 청구인이고, 이해관계인이 피청구인이다. 한편 전용실시권자가 적극적 권리범위확인심판의 청구인이 될 수 있는지에 대해서 기존의 대법원¹⁸⁾은 제135조에서 구체적으로 규정하고 있지 아니함을 이유로 전용실시권자의 청구인 적격을 부정하였다. 그러나 i) 전용실시권자에게 특허발명의 독점배타적 실시가 보장되고¹⁹⁾ ii) 전용실시권자라도 현행법상 특허발명에 대한 분쟁이 발생하였을 때 당사자로서 직접 침해금지청구, 손해배상청구를 할 수 있으며,²⁰⁾ iii) 청구인 적격을 부정하였을 때 특허권자가 재외자이거나 분쟁 개입에 소극적인 경우에는 전용실시권자의 권리행사가 제한된다는 점을 고려하면, 청구인 적격을 인정하는 것이 타당하다. 그 결과 2006. 10. 1. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정)에서는 전용실시권자의 적극적 권리범위확인심판의 청구인 적격을 인정하고 있다.

(2) 소극적 권리범위확인심판

소극적 권리범위확인심판에서는 이해관계인이 청구인이고²¹⁾ 특허권자가 피청구인이다. 한편 특허발명의 보호범위를 객관적으로 공정하게 해석함으로써 분쟁을 신속히 해결하려는 권리범위확인심판의 취지상 전용실시권자는 소극적 권리범위확인심판의 피청구인 적격을 부정함이 타당하다. 오히려 전용실시권자의 피청구인 적격을 인정하면 전용실시권자와 확인대상발명의 실시자가 담합하여 권리범위확인심판을 제기하여 특허권자에게 불리한 결과를 초래하는 예도 상정할 수 있을 것이다. 심판 실무²²⁾도 이와 같은 것으로 해석이 된다.

18) 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3262.

19) 황종환, 「특허법」, 제9판, 한빛지적소유권센터, 2004, 1003면; 천효남, 「특허법」, 제9판, 법경사, 2003, 706면.

20) 박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002, 530면.

21) 특허권이나 디자인권 등 이른바 산업재산권에 관한 소극적 권리범위확인심판의 분쟁 예방적 성격에 착안하여 심판청구인으로서의 이해관계인이라 함은 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하고 있는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다고 보기 때문에, 설사 확인대상발명이 심판청구인의 심판청구 당시 제조·판매해 온 물품이 아니어서 피심판청구인으로부터 경고장을 받게 된 해당 물품이 아니라 하더라도 심판청구인으로서의 장래 실시하려는 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 확인심판을 청구할 이익이 있다(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241; 1990. 2. 9. 선고 89후1431; 1987. 7. 7. 선고 85후46; 1985. 7. 23. 선고 85후51 등).

22) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 537면.

(3) 통상실시권허락심판

1) 일반적인 통상실시권허락심판(法 138①②)은 이용·저촉관계에 있는 후출원 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자가 청구인이며, 선출원 특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는 디자인권자가 피청구인이다. 저촉관계에 있는 선출원 상표권자를 피청구인으로 하여 통상사용권허락심판을 청구할 수는 없다.

2) 크로스 라이선스(法 138③)는 통상실시권을 허락한 선출원 권리자가 청구인이며, 통상실시권을 허락받은 후출원 특허권자, 전용실시권자가 피청구인이다. 다만 통상실시권자의 경우 피청구인이 될 수 있는가에 대해서는 의문이 있다. 통상실시권은 채권적인 권리이므로 제3자의 침해에 대하여 직접구제조치를 하거나 제3자에게 재실시권을 허락할 수 없다. 따라서 통상실시권자는 이론상 통상실시권허락심판의 피청구인이 될 수 없다고 보는 것이 타당하다.

IV. 당사자적격자로서의 이해관계인

1. 서

특허무효심판(法 133), 특허권 존속기간 연장등록무효심판(法 134), 정정무효심판(法 137), 권리범위확인심판(法 135)의 당사자적격자로 이해관계인일 것을 요구하고 있다. 「이해관계인」이란 사실상, 경제상의 이해관계가 아닌 법률상 이해관계가 있는 자를 의미한다.²³⁾ 다만 심판의 특성을 고려하여 무효심판과 권리범위확인심판에서의 이해관계인의 구체적인 의미를 달리보고 있다.

2. 무효심판에서의 이해관계인

(1) 문제의 소재

이해관계인은 특허무효심판(法 133), 존속기간연장등록무효심판(法 134), 정정무효심판(法 137)을 청구할 수 있다. 심판청구의 난립을 방지하고 심판사건의 적체를 해소하는 한편 산업 질서의 안정화를 도모하기 위해 이해관계가 있는 자가 무효심판을 청구할 수 있도록 하고 있다. 비법인단체도 이해관계인에 포함될 수 있다. 이때 비법인 사단·재단은 대표자나 관리인이 정하여져 있음을 전제로 그 사단 또는 재단의 이름으로 무효심판을 청구할 수 있다(法 4). 그런데 이와 같은 무효심판에서의 이해관계인의 구체적인 의미와 관련하여서는 기존에 논란이 있

23) 예를 들어 법인의 대표자 개인이 개인명의로 심판을 청구하고 그 법인이 특허권과 동종의 물품을 생산·판매하는 등의 이유로 이해관계를 주장할 경우 법인으로서 그 영업내용상 이해관계가 있다고 하더라도 그 법인의 대표자는 대표자로서 그 법인의 영업에 관여하고 있는 것이지 개인으로서 관여하는 것이 아니므로 그 대표자 개인은 이해관계가 없다(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 199면). 다만 대표자의 개인 자격으로 이해관계가 있는지 여부를 개별적으로 살펴보아야 한다(대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373 참조). 한편 대법원 1990. 1. 25. 선고 89후1318 판결에서는 “행정관청인 도지사, 철도청장 등도 권리능력이 없기 때문에 이해관계인이라 볼 수 없다”라고 하였으나 권리능력이 없는 비법인 사단·재단이라도 예외적으로 당사자능력을 인정하고 있음에 비춰볼 때 타당하지 아니한 것으로 여겨진다.

었는데 특히 실시권자가 이해관계인에 해당하여 무효심판을 청구할 수 있느냐와 관련된 사건에서 주로 다툼이 있었다.

(2) 판례의 태도

1) 기존의 대법원 판례는 i) 특별한 사정이 없는 한 특허를 무효로 할 구체적 이익이 없다²⁴⁾거나 그 허락기간에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없으므로 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없어²⁵⁾ 실시권자는 이해관계인이 아니라는 소극설의 입장과 ii) 실시계약 후 무효사유를 발견한 경우에 통상실시권에 대가의 지급조건이 붙어 있어 그 의무의 이행을 하여야 한다면 특허를 무효로 함으로써 실시료의 지급의무가 면제되는 이익을 가지므로 실시권자는 이해관계인이라는 적극설의 입장²⁶⁾이 대립하고 있었다.

2) 이에 대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결에서는 “특허무효심판에서 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다. 그 이유는 다음과 같다. 특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다. 그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다. 이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다”라고 판시하였다. 즉 실시권자는 무효심판을 통해 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항을 벗어날 수 있고, 더욱이 실시권을 허락받은 것이 부쟁의 의사를 표시한 것이라고 단정할 수도 없으므로 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람이라면 실시권자도 이해관계인에 해당한다고 하였다.

24) 대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49.

25) 대법원 1981. 7. 28. 선고 80후77.

26) 대법원 1980. 5. 13. 선고 79후74; 1984. 5. 29. 선고 82후30.

(3) 소 결

1) 특허권자와 실시권자 사이에는 기술과 자본의 결합과 같이 강력한 신뢰와 성실을 바탕으로 한 공동체적 관계를 맺은 경우가 대부분이다. 따라서 실시권자가 특허무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지는 대부분의 나라에서의 통설, 판례와 같이 실시권자가 해당 특허로부터 이익을 받으면서 무효심판을 청구하는 것이 신의칙 또는 금반언(estoppel)의 법리에 반하는 것이 아니냐는 관점에서 문제가 되어야 할 것이다. 즉 하자있는 권리를 소멸시켜 법적 안정성을 도모시킨다는 무효심판제도의 근본적인 존재이유와 신의칙의 대립이라는 관점에서 실시권자의 무효심판 당사자적격을 논하여야 한다.

2) i) 특허를 무효로 하여 실시권 효력범위의 제한을 벗어나 자유로이 실시할 수 있는 법률상의 이익이 실시권자에게 있다는 점, ii) 실시권을 허락받았다는 이유만으로 특허권의 유효성을 묵인했다고 말할 수 없는 점, iii) 독일은 이를 공중소송으로 규정하고 있고, 일본은 개정 특허법에서 종전의 청구인 적격을 이해관계인이라고 한정하였다가 이를 삭제하고 오직 일반 소송이론에 맡기고 있는 점 등을 두루 종합해보면 개개 실시권자의 권리발생의 원인, 특허가 무효가 됨으로써 얻어지는 유틸리티를 기준으로 청구인적격을 판단해야 한다. 즉 실시권자는 신의칙에 반하는 특단의 사정이 없는 한 무효심판을 청구할 수 있다고 함이 타당하다고 여겨진다. 여기서 말하는 특단의 사정이란 실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같이하여 불이익이 없다는 등을 말한다.²⁷⁾

3) 문제가 되는 것은 실시계약상의 부쟁의무(不爭義務) 조항이 특단의 사정이 될 수 있는지 여부이다. 부쟁의무조항의 유효성을 인정할 경우 실시권자의 무효심판청구는 사실상 불가능하게 되고 특허받을 수 없는 기술이 존속함으로써 시장에 악영향을 미칠 우려가 있으므로 부쟁의무조항은 위법하여 무효이며, 특단의 사정이 될 수 없다고 보아야 한다.²⁸⁾ 이와 관련하여 공정거래위원회의 「지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침(개정 2016. 3. 23. 공정거래위원회 예규 제247호)」에서는 “무효인 특허의 존속 등을 위하여 부당하게 실시권자가 관련 특허의 효력을 다투는 것을 금지하는 행위”를 불공정거래행위의 유형으로 포함하고 있다.²⁹⁾

3. 권리범위확인심판에서의 이해관계인

(1) 일 반

권리범위확인심판에서 이해관계인이란 특허권자 등으로부터 권리의 대항을 받아 업무상 손

27) 특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허2727 참조.

28) 김동준, “실시권자의 무효심판청구”, 한국특허법학회 편, 「특허판례연구」, 박영사, 2009, 609면.

29) 이와 관련하여, 부쟁합의에 이르게 된 경위, 부쟁합의의 구체적인 내용, 해당 특허권의 성격 및 독점권이 미치는 범위, 시장지배력의 정도, 공중의 이익 등의 제반 사정을 종합적으로 고려하여 그 효력의 유무를 판단하여야 한다는 견해도 있다(이혜진, “실시권자의 무효심판청구에 관한 주요 쟁점 - 이해관계인 및 특허료, 부쟁의무를 중심으로”, 사법 49호, 2019년 가을호, 사법발전재단, 625면).

해를 받고 있거나 손해를 받을 염려가 있는 사람을 말한다.³⁰⁾ 구체적으로 적극적 권리범위확인심판(法 135)에서 피청구인으로서 이해관계인은 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나³¹⁾ 현재 실시하고 있는 자이다. 피청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다.³²⁾ 그에 반해 소극적 권리범위확인심판에서 청구인으로서 이해관계인은 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 자뿐만 아니라 실시하고 있지 않다고 하더라도 실시할 예정이 있는 자도 포함된다.³³⁾ 적극적 권리범위확인심판과는 달리 소극적 권리범위확인심판의 경우에는 확인대상발명을 실시하려고 하는 자도 특허발명의 보호범위에 속한지 아닌지를 확인할 실익이 있으므로 이해관계인에 포함된다.

2) 비법인단체도 이해관계인에 포함될 수 있다. 이때 비법인 사단·재단은 대표자나 관리인이 정하여져 있음을 전제로 그 사단 또는 재단의 이름으로 소극적 권리범위확인심판의 청구인 또는 적극적 권리범위확인심판의 피청구인이 될 수 있다(法 4).

(2) 소극적 권리범위확인심판에서 실시가능성(실시할 예정)

1) 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 확인대상발명을 현재 실시하고 있거나 장래 실시할 가능성이 있는지에 대해서 명확하게 살펴서 권리범위 확인의 이익이 있는지 밝힐 필요가 있다는 견해³⁴⁾가 있다. 즉 실시가능성을 엄격하게 해석하여야 한다는 것이다. 단순히 실시할 가능성을 완화하여 해석하는 경우 실시 계획이 없음에도 불구하고 소극적 권리범위확인심판을 청구하는 방법으로 제도를 악용할 수 있다는 우려가 있기 때문이다. 구체적으로 침해소송의 현재 또는 미래의 피고가 자신이 현재 실시하고 있는 제품 또는 장래 실시하고자 하는 제품과 다르게 확인대상발명을 특정하여 소극적 권리범위확인심판을 청구하여 권리범위에

30) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746.

31) 대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836. 과거의 확인대상발명의 실시가 현재의 분쟁과 관련이 있는 경우에는 확인의 이익이 있다고 보아야 하기 때문이다.

32) 실용신안권자가 어떤 물품이 자신의 등록실용신안권의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 그 심판청구인이 특정한 물품과 피심판청구인이 실시하고 있는 물품 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 아니한 물품이 등록고안의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 물품에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대해서는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것이어서 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419).

33) 특허권이나 디자인권 등 이른바 산업재산권에 관한 소극적 권리범위확인심판의 분쟁 예방적 성격에 착안하여 심판청구인으로서의 이해관계인이라 함은 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조·판매·사용하고 있는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조·판매·사용하리라고 추측이 갈 수 있는 자도 포함된다고 보기 때문에, 설사 확인대상발명이 심판청구인의 심판청구 당시 제조·판매해 온 물품이 아니어서 피심판청구인으로부터 경고장을 받게 된 해당 물품이 아니라 하더라도 심판청구인으로서 장래 실시하려는 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부의 확인심판을 청구할 이익이 있다(대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241; 1990. 2. 9. 선고 89후1431; 1987. 7. 7. 선고 85후46; 1985. 7. 23. 선고 85후51 등).

34) 김승조, 「확인대상발명의 실시와 확인의 이익」, 『특허판례연구』 개정판, 박영사, 2012, 765면.

속하지 않는다는 심결을 받은 후 침해소송의 재판부에 그 심결을 증거로 제출하여 재판부를 기망하고자 할 수 있는 것이다.³⁵⁾ 특히 최근 대법원이 침해소송과 권리범위확인심판은 별개이기 때문에 침해소송이 제기된 후에 소극적 권리범위확인심판을 청구한 경우 심판청구의 이익을 긍정하고 있어 더욱 문제가 될 수 있다.³⁶⁾ 그러나 소극적 권리범위확인심판의 가장 중요한 기능은 분쟁의 예방이고, 실시할 가능성을 너무 엄격하게 적용하면 소극적 권리범위확인심판의 효용성은 크게 떨어질 것이기 때문에 그러한 예방적 기능을 충분히 보장하기 위해서는 장래 실시할 계획이 있다고 주장되는 확인대상발명의 확인의 이익을 폭넓게 인정해야 한다.³⁷⁾ 물론 소극적 권리범위확인심판이라고 할지라도 장래에 실시할 가능성이 없다는 것이 명백하다면 심판청구의 적법성을 인정받기 어렵다.³⁸⁾

2) 침해소송에서 악용과 관련해서는 청구인에게 확인대상발명이 실제 실시 중인 발명인지 또는 장래 실시할 예정인 발명인지를 구분하여 기재하거나 적어도 심결 시까지 밝히도록 하고,³⁹⁾ 심판부는 심결문에 그를 기재하여 민·형사 재판부가 소송에서의 대상물과 권리범위확인심판에서의 대상물이 다르다는 것을 명확하게 알 수 있도록 하여 그러한 악용을 방지할 수 있다. 이에 따라 현재 심판 실무는 청구인이 특허권자로부터 민사침해소송, 형사침해소송으로 권리

35) 박형근 등, 「현대 기술환경에서 지식재산권 침해성립 요건의 운영에 관한 연구」, 지식재산청 연구용역보고서, 2011, 21-23면.

36) 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328.

37) 정차호, “소극적 권리범위확인심판에서 실시 ‘계획’ 또는 ‘예정’인 확인대상발명의 확인의 이익”, 산업재산권 제48호, 한국지식재산학회, 2015, 321면. 대법원도 1985. 10. 22. 선고 85후48, 49 판결에서 “심판청구인들이 실제 사용하고 있는 고안이 실시주장고안임에도 불구하고 이를 은폐하기 위해 확인대상고안을 조작하여 확인대상고안이 등록된 실용신안의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 청구를 해온 것이라든가 그 때문에 확인대상고안의 사용가능성이 없다는 이유로 심판청구인들이 이해관계인이 아니라 하여 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수는 있지만 이 경우에도 그 심판대상은 확인대상고안이 되어야 한다”라고 하여 확인의 이익을 폭넓게 인정하고 있다.

38) 심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상발명이 자신이 현실적으로 실시하고 있는 발명과 다르다면, 설명 발명의 요지가 같아서 동일성이 있는 발명이라고 볼 수 있다. 한들 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 확인대상발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없으므로 심판청구인이 현실적으로 실시하지 않고 실시할 계획도 없는 확인대상발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다(특허법원 2004. 4. 30. 선고 2003허3020).

39) 특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301. 또한 대법판결에서는 “심판청구인이 심결 시까지 자신이 현재 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 밝혔다면 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 심판청구인의 의사대로 실제 실시하고 있는 제품으로 확정되었다고 할 것이다. 또한 확인대상발명이 위와 같이 확정되었다면 그것이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다. 따라서 심판청구인이 실제 실시하고 있는 제품과 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 사실적 관점에서 같지 않다면, 특허심판원으로는 다름을 지적하여 이를 보정할 수 있는 기회를 부여하여야 하고, 심판청구인이 그러한 기회를 제공받았음에도 이를 보정하지 않았다면 장차 위와 같이 잘못 특정된 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되더라도 일사부재리의 효력이 확인대상발명과 다른 심판청구인이 실제 실시하고 있는 발명에 미친다고 볼 수 없으므로 이를 각하하여야 할 것이다. 그리고 특허심판원이 위와 같이 보정기회를 부여하여야 함에도 그러한 기회를 부여함이 없이 실제 실시하고 있는 발명과 다른 확인대상발명에 관하여 심결을 하였다면 그러한 심결은 심판대상이 아닌 발명을 심판한 잘못이 있어 위법하고, 이후 그 심결의 취소를 구하는 소송절차에서 사후적으로 심판청구인이 확인대상발명에 관하여도 확인을 구할 의사가 있다는 의사를 표시하였다고 하여 그 하자가 지워진다고 보기도 어렵다”라고 판시하였다.

의 대항을 받았으면 확인대상발명이 소제기대상발명과 동일성의 것인지 등 관련 여부를 심판 청구서에 기재하도록 하고, 그 심리결과를 심결에 기재하도록 하고 있다.⁴⁰⁾

3) 한편 권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 특허권 권리범위확인심판 청구의 심판대상은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명이다. 소극적 권리범위확인심판에서는 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판청구에서 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다르다고 하더라도 심판청구인이 특정한 발명이 실시가능성이 없을 경우 그 청구의 적법 여부가 문제로 될 수 있을 뿐이고, 여전히 심판의 대상은 심판청구인이 특정한 확인대상발명으로, 이를 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여야 한다.⁴¹⁾ 이때 실시할 가능성이 없다는 것은 심판청구인이 일반적으로 증명을 해야 할 것인데, 심판청구인인 이해관계인이 자인하지 않는다면 증명하기는 쉽지 않을 것이다.⁴²⁾

4) 당사자 사이에 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지만 다툼이 있을 뿐이고, 실시가능성이 있다고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 대하여 아무런 다툼이 없는 경우라면 심판청구의 이익이 없어 심결각하된다.⁴³⁾ 심판 실무는 이해관계인에게 불측의 손해를 끼치지 않기 위해 현재 다투지 않는 것이 명백한 경우를 제외하고는 본안심리를 하고 있다. 예를 들어 i) 과거 다툼 사실이 있으나 다투지 않는다는 의사표시를 한 경우, ii) 피청구인(권리자)으로부터 대응이 없는 경우(다투지 않는다는 의사를 확인할 수 없으면, 심판에서는 자백 간주가 적용되지 않음)에는 본안 심리를 한다.⁴⁴⁾

40) 또한 소제기 대상발명이 불명확하거나 전혀 기재되어 있지 않아 확인대상발명과의 관련 여부를 판단할 수 없는 경우, 심문서, 보충요구서 등을 통해 석명권을 행사하여 심리할 수 있고, 그런데도 그 관련 여부를 판단하기 곤란한 경우 그러한 이유로 판단할 수 없음을 심결문에 기재하고 있다(특허심판원, 「심판 편람」, 제14판, 2024, 556면).

41) 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813.

42) 대법원 2005. 10. 14. 선고 2004후1663 판결에서는 “피고가 현재 실시하지 않고 있으며 장래에도 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상발명으로 삼아 제기한 소극적 권리범위확인심판으로서 설령 피고가 구하는 바대로의 심결을 받는다고 하더라도 피고가 실시하거나 실시하고자 하는 발명에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 피고의 법적불안을 해소하는 데 아무런 도움이 되지 않아 그 심판청구의 이익이 없는 부적절한 것이다”라고 판시하였다. 본 판결은 청구인이 특허법원의 변론준비절차에서 확인대상발명을 장래에 실시할 계획이 없음을 스스로 자인한 사안에 관한 것이다.

43) 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373. 대법원 2016. 9. 30. 선고 2014후2849 판결에서는 특허권자(원고)가 이해관계인(피고) 실시제품에 대해서는 이해관계인에게 경고장을 보내고 형사고소를 하는 등 이 시간 특허발명의 특허권 침해를 주장하면서 다투고 있지만, 이 사건 확인대상발명에 대해서는 특허권 침해를 주장한 적이 없고, 향후에도 이를 주장할 의사가 없다고 진술한 점을 토대로 심판청구의 이익을 부정하였다. 그런데 2014후2849 판결에서와 같이 특허권자의 진술을 토대로 당사자 사이에 다툼이 없는 경우에 해당하기 때문에 심판청구의 이익이 없다고 판단한 것은 특허권자의 진술이 당사자의 합의로 볼 수 없다는 점에서 적절치 않다고 생각된다. 민사소송의 확인의 소에서는 피고가 원고의 청구취지에 대한 주장을 그대로 인정하는 경우 인용판결의 효력을 갖는 인낙조서를 작성하여 소를 종결시키는 데 반해, 권리범위확인심판에서는 인용심결이 아닌 각하심결로서 심판이 종결된다는 점에서 차이가 있다. 특허권자는 자신의 주장을 반복하여 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있는데 일사부재리 효력을 갖지 아니한 각하심결로는 특허권자의 심판청구를 막을 수 없어, 이해관계인에게 불측의 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(김병필, “특허심판에서 당사자 간 다툼이 없는 경우 확인의 이익-소극적 권리범위확인심판을 중심으로-”, 지식과 권리(제16호), 대한변리사회, 2013, 74-89면 참조).

4. 이해관계의 판단

(1) 판단시점

1) 「심결 시」를 기준으로 이해관계의 존부를 판단한다. 따라서 심판청구 시에는 이해관계가 없는 경우라도 심결 시에 이해관계가 있으면 적법한 심판청구로 인정되며, 심판청구 시에는 이해관계가 성립되었던 심판청구도 그 심결 시에 이해관계가 소멸된 경우에는 부적법한 심판청구로서 심결각하된다. 예를 들어 청구인이 심판의 대상인 권리를 양도받음으로써 혼동이 있는 경우 또는 심판계속 중에 당사자의 합의가 있거나 화해를 한 경우⁴⁵⁾에는 이해관계가 소멸된 것으로 본다.

2) 다만 합의가 있었다는 사실만으로 곧바로 이해관계가 소멸하였다고 볼 수는 없고, 각각의 심판별로 합의에 이르게 된 경위, 합의의 내용, 합의 후의 사정 등을 종합하여 이해관계의 소멸 여부를 판단하여야 한다. 합의의 내용을 일례로 들면, 대법원 1979. 3. 13. 선고 77후 50 판결에서는 “특정의 이해관계인이 특허권리자와 간에 특허에 관한 분쟁을 일체 아니하기로 화해한 경우에는 무효심판을 청구할 이해관계인의 지위를 상실한 결과가 된다”라고 판시하였고, 대법원 1996. 12. 6. 선고 95후1050 판결에서는 “등록고안의 실용신안권자 甲과 그로부터 실용신안권 침해의 고소를 당한 乙 사이에 乙이 그 등록고안의 권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 않는다는 내용의 약정을 하였다 하더라도, 문언상으로는 그 합의의 취지를 乙이 甲의 등록고안에 대한 정당한 권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 아니하기로 한 것으로 볼 수 있을 뿐이어서, 그 합의로써 곧바로 乙이 자신이 실시했던 특정 고안이 그 등록고안의 권리범위에 속함을 인정하였다거나 그 등록고안의 권리범위를 확인하는 심판청구권까지를 포기하기로 한 것으로 볼 수 없으므로, 그와 같은 합의가 있었다는 사정만으로 심판청구인의 권리범위확인심판에 관한 이해관계가 소멸하였다고 할 수는 없다”라고 하여 단순히 상대방의 권리를 인정하는 내용의 합의로는 권리범위확인심판청구의 이해관계가 소멸하지 않는다고 하였다. 또한, 대법원 2001. 6. 29. 선고 99후1331 판결에서는 “등록디자인의 디자인권자 甲과 그로부터 디자인권 침해의 고소를 당한 乙 사이의 합의서에 乙이 디자인 등록 제품을 제작한 것에 대하여 사과하고, 추후 디자인등록 제품을 제작하지 않겠으며, 기존 디자인등록 제품을 폐기하겠다는 내용만 포함되어 있을 뿐 당시 계속중이던 디자인등록 무효 심판청구사건의 처리에 관하여는 아무런 기재가 없는 경우, 위 합의의 내용과 경위를 고려할 때, 위 합의는 乙이 자신이 제작하였던 물품이 甲의 등록디자인권의 권리범위에 속한다는 사실을 인정할 것일 뿐 그 등록디자인권의 효력에 대하여도 무효심판절차를 통하여 일체 다투지 않겠다는 취지까지 포함된 것으로 보기 어렵고, 디자인등록의 무효심판의 공익적 성격을 고려하여 위와 같은 합의만으로 그 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없다”

44) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 567면.

45) 대법원 1979. 3. 13. 선고 77후50.

라고 하여 권리범위에 속함을 인정한다는 합의는 권리범위확인심판에서의 이해관계를 소멸시키지만, 이것이 특허무효심판의 이해관계까지 소멸시킨다고 볼 수는 없다고 하였다.

(2) 이해관계의 주장 및 판단 방법

심판청구인은 이해관계가 없는 것으로 판단되는 경우 부적법한 청구로서 각하되므로 심판청구이유 부분에 이해관계에 관한 주장을 적어야 한다. 이해관계의 존재 여부에 관한 판단은 직권조사사항으로서 심판청구서를 통해 이해관계 존부를 판단하기 어려운 경우 이해관계가 있음을 주장하여 증명하도록 보정을 명하고, 이에 의해서도 이해관계의 존부가 불분명할 때는 직권조사를 하여 판단한다.⁴⁶⁾

5. 이해관계의 폐지 논의

심판청구인 적격을 이해관계인으로 제한함으로써 이해관계 존부의 증명과 판단을 위한 시간과 노력이 낭비되고, 심판절차가 지연된다는 문제점이 있다. 이러한 문제점에 대한 대안으로서 공익에 관련되는 사항은 공중소송화하여 누구든지 심판을 청구할 수 있도록 하는 한편 사인간의 이해관계에 관한 사항(무권리자 출원 등)은 현행법과 같이 심판청구인을 제한하는 방안이 있을 것이다.

【표 7-2】 심판의 당사자

구 분		청구인	피청구인
거절결정불복심판(法 132의17)		출원인	-
정정심판(法 136)		특허권자	-
무효심판 (法 133, 134, 137)		이해관계인 또는 심사관 (다만 제33조제1항본문, 제44조를 위반한 경우에는 심사관 또는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자가 특허무효심판(法 133) 청구 가능)	특허권자
권리범위 확인심판 (法 135)	적극적	특허권자, 전용실시권자	과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 이해관계인 (실시할 예정이 있는 이해관계인 제외)
	소극적	과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 자뿐만 아니라 실시할 예정이 있는 이해관계인	특허권자 (전용실시권자 제외)
통상실시권 허락심판 (法 138)	일반적	후출원 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자	선출원 특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는 디자인권자 (상표권자 제외)
	크로스 라이선스	선출원 특허권자, 전용실시권자, 실용신안권자 또는 디자인권자	후출원 특허권자, 전용실시권자 (통상실시권자 제외)

46) 대법원 1981. 7. 28. 선고 80후77.

V. 공동심판에서의 당사자적격

제139조 【공동심판의 청구 등】

- ① 동일한 특허권에 관하여 제133조제1항, 제134조제1항·제2항 또는 제137조제1항의 무효심판이나 제135조제1항·제2항의 권리범위 확인심판을 청구하는 자가 2인 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ② 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다.
- ③ 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다.
- ④ 제1항 또는 제3항에 따른 청구인이나 제2항에 따른 피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

[전문개정 2014.6.11.]

1) 「공동심판」이란 하나의 심판사건에 대하여 심판청구인 또는 심판피청구인이 2명 이상이거나 당사자 양쪽이 다 같이 2명 이상인 심판을 말한다. 특허무효심판(法 133), 특허권의 존속기간 연장등록무효심판(法 134), 정정무효심판(法 137) 또는 권리범위확인심판(法 135①②)을 청구하는 자가 2명 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다(法 139①). 그러므로 모두가 공동으로 심판을 청구할 수도 있고 각자가 개별적으로 심판을 청구할 수도 있다. 민사소송법상 유사필수적 공동소송에 해당된다.⁴⁷⁾ 한편 공동으로 심판을 청구할 때는 청구취지가 동일하여야 한다. 예를 들어 특허무효심판은 청구항별로 청구할 수 있으므로 동일한 특허권에 관하여 甲이라는 자가 청구범위 제1항이 무효임을 주장하고, 乙이라는 자는 청구범위 제2항이 무효임을 주장하는 경우에는 소송물을 합일적으로 확정할 수 없는 경우이므로 공동심판청구는 불가능하다.⁴⁸⁾

2) 공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구할 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여 청구하여야 하며(法 139②), 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法 139③). 그러므로 공유인 경우에는 반드시 공유자 모두가 청구인으로, 또는 공유자 모두를 피청구인으로 하여 심판을 청구하여야 한다. 민사소송법상 고유필수적 공동소송에 해당된다.⁴⁹⁾

3) 위의 공동심판청구인이나 공동심판피청구인 중 1인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다(法 139④). 이는 공동심판의 당사자 간에 분쟁의 합일적인 해결을 꾀할 필요가 있기 때문이다.

47) 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 특허는 제3자와의 관계에서도 무효로 되므로, 동일한 특허권에 관하여 2명 이상의 자가 공동으로 특허의 무효심판을 청구하는 경우 그 심판은 심판청구인들 사이에 합일확정을 필요로 하는 이른바 유사필수적 공동심판에 해당한다(대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510).

48) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 110면.

49) 특허의 공유관계는 민법 제273조에 규정된 합유에 준하는 것이라 할 것이므로 특허권이 공유인 때에는 그 특허권에 관한 심판사건에 있어서는 공유자 모두가 심판의 청구인 또는 피청구인이 되어야 하고, 그 심판절차는 공유자 모두에게 합일적으로 확정되어야 할 필요에서 이른바 필요적 공동소송관계에 있다(대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111).

4) 심판청구인의 실수로 인해 당사자가 누락되거나 잘못 기재되었을 때 심판이 각하되는 사례를 방지하기 위해 심판의 당사자 중 특허권자나 거절결정불복심판의 청구인 기재를 바로 잡기 위한 보정을 자유롭게 허용하고 있다. 다만 단독으로 심판을 청구한 후 청구인 추가는 사후적으로라도 다른 공유자의 동의가 있는 경우에 한해 할 수 있도록 제한하고 있다(法 140② I, 140의② I). 공유자 모두가 청구인이 될 때는 모두의 사전 합의가 있어야 한다는 점에서 공유자 모두가 피청구인이 될 때와 차이가 있기 때문이다.

제4관 흠결의 효과

당사자능력이나 당사자적격은 심판청구요건으로서, 심판청구요건에 흠결이 있고 그 흠결을 보정할 수 없는 경우 심판관 합의체는 심판청구를 심결각하하여야 한다(法 142).⁵⁰⁾

제3절 심판의 참가인

제155조 【참가】

- ① 제139조제1항에 따라 심판을 청구할 수 있는 자는 심리가 종결될 때까지 그 심판에 참가할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 참가인은 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다.
- ③ 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다.
- ④ 제3항에 따른 참가인은 모든 심판절차를 밟을 수 있다.
- ⑤ 제1항 또는 제3항에 따른 참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제156조 【참가의 신청 및 결정】

- ① 심판에 참가하려는 자는 참가신청서를 심판장에게 제출하여야 한다.
- ② 심판장은 참가신청이 있는 경우에는 참가신청서 부분을 당사자 및 다른 참가인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- ③ 참가신청이 있는 경우에는 심판으로 그 참가 여부를 결정하여야 한다.
- ④ 제3항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.
- ⑤ 제3항에 따른 결정에 대해서는 불복할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「심판의 참가」란 타인간의 심판계속 중에 그 심결에 대하여 이해관계 있는 제3자가 자기의 법률상의 이익을 보호하기 위해 심리가 종결될 때까지 어느 한쪽 당사자의 심판을 보조하거나 스스로 심판청구의 당사자가 되어 심판절차에 관여하는 것을 말한다(法 155).

50) 특허법원 2015. 4. 14. 선고 2014허5589.

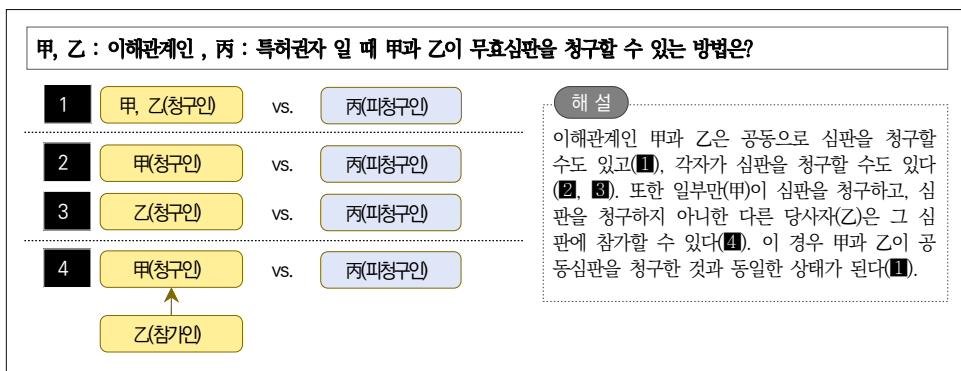
2. 취 지

이해관계 있는 제3자에게 심판에서 자기의 이익을 주장할 기회를 부여하고 이해관계인 간의 합일적인 분쟁해결을 꾀하여 심판의 적정·공평성 및 절차의 신속성과 경제성을 도모하려는데 그 취지가 있다.

3. 종 류

(1) 당사자 참가

「당사자 참가」란 제139조제1항에 따라 공동으로 심판을 청구할 수 있는 자가 타인간의 계속 중인 심판에 참가하는 것을 말하며, 심판청구인 측에만 참가할 수 있다(法 155①). 즉 특허무효심판(法 133), 특허권의 존속기간연장등록무효심판(法 134), 정정무효심판(法 137), 권리범위확인심판(法 135)을 청구하는 자가 2명 이상이면 모두가 공동으로 심판을 청구할 수도 있으나, 일부만이 심판을 청구할 수도 있다. 이 경우에 당사자적격이 있는 나머지 사람은 당사자로서 그 심판에 참가할 수 있다.



【그림 7-1】 복수 당사자의 공동심판청구 및 당사자 참가

(2) 보조 참가

「보조 참가」란 심판의 결과⁵¹⁾에 법률상 이해관계를 가지는 자가 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 심판에 참가하는 것으로서 당사자 참가와는 달리 당사자 중 어느 쪽에도 참가할 수 있다(法 155③).

51) 「심판의 결과」란 심결의 결론인 주문에 나타난 판단을 말하며, 심결의 이유에 나타난 사실에 관한 판단에 지나지 아니하는 것은 심판의 결과는 아니다.

II. 참가의 요건

1. 주체적 요건

(1) 참가의 이익이 있을 것

심판에 참가하려면 법률상의 이해관계가 있어야 한다. 당사자 참가의 경우는 제139조제1항에 의하여 공동으로 심판을 청구할 수 있는 당사자적 지위에 상응하는 이해관계가, 보조 참가의 경우는 그 심판의 결과에 대하여 받을 구체적 이해관계가 요구된다. 법인 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 심판에 참가할 수 있다(法 4).

(2) 행위능력이 있을 것

심판절차에서 자기의 법률상 이익을 주장하기 위해서는 행위능력이 있어야 한다. 따라서 행위제한능력자가 심판에 참가할 경우 법정대리인 등에 의하여야 한다.

2. 객체적 요건

1) 타인 간의 당사자적 심판이 계속 중이어야 한다. 따라서 특허무효심판(法 133), 특허권의 존속기간연장등록무효심판(法 134), 정정무효심판(法 137), 권리범위확인심판(法 135)에 대해서만 참가할 수 있다. 다만 통상실시권허락심판은 당사자 참가가 아닌 보조 참가만이 인정된다고 할 것이다. i) 제155조제1항에는 당사자 참가가 가능한 심판을 제한적으로 열거해 놓고 있는데 통상실시권허락심판은 제외되었다는 점,⁵²⁾ ii) 통상실시권허락심판은 청구인별로 허락받기를 원하는 실시권의 내용이 다르다는 점을 고려해야 하기 때문이다.

2) 한편 결정계 심판인 거절결정불복심판(法 132의17), 정정심판(法 136)은 참가가 허용되지 않지만(法 171, 136⑨),⁵³⁾ 심판에 대하여 이해관계가 있는 자는 정보제공을 할 수 있다.⁵⁴⁾

3. 시기적 요건

타인간의 심판계속 중이어야 하며, 심리종결 전이어야 한다(法 155①③). 심리종결 후에 참가를 허용하면 심리를 재개하여야 하는 등 절차지연의 문제가 야기되므로 그 시기를 제한하고 있다.

III. 참가의 절차

1. 참가신청서의 제출

1) 심판에 참가하려는 자는 참가신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다(施

52) 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 875면.

53) 대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834; 1997. 7. 8. 선고 97후75.

54) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 179면. 거절결정불복심판의 경우 특허심판원장에게 정보제공을 할 수 있음이 제170조제1항에 규정되어 있으나, 정정심판의 경우 심판 실무상 인정하고 있다.

規 62①). i) 「참가의 취지」에는 당사자 참가의 경우에는 어떠한 심결을 구하는지와 어느 쪽에 참가하는가를 표시하고, 보조 참가의 경우에는 어느 쪽을 보조하기 위하여 참가하는가를 표시한다. ii) 「참가의 이유」에는 당사자 참가의 경우에는 그 심판에 청구인적격이 있음을 밝히고, 보조 참가의 경우에는 심판의 결과에 이해관계가 있음을 밝혀야 한다.

2) 참가신청인은 참가신청과 더불어 심판절차를 동시에 수행할 수 있으며(民訴法 72③유추) 참가의 허부가 결정되지 아니한 경우에도 결정이 확정되기까지 심판절차를 수행할 수 있다.

2. 참가 여부의 결정

(1) 방식심사

심판장은 참가신청서가 방식에 위반되었으면 기간을 정하여 보정을 명하고, 그 기간이 지나서도 신청인이 보정을 하지 아니한 때에는 심판청구서 각하와 같이 신청서를 결정으로 각하한다(法 141).

(2) 의견서 제출 기회의 부여

심판장은 참가신청이 있는 경우에는 참가신청서 부분을 당사자 및 다른 참가인에게 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 156①②). 이는 당사자 및 다른 참가인이 참가에 대하여 이익을 가질 수 있기 때문이다.

(3) 결 정

참가신청이 있는 경우에는 심판으로 그 참가 여부를 결정하여야 하고 그 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다(法 156③④). 참가의 요건은 직권조사사항이다. 참가신청이 있는 경우에는 의견서 제출기간이 지난 후 심리종결 전에 즉시 심판에 의하여 그 참가 여부를 결정하여야 한다.⁵⁵⁾ 한편 참가 여부를 결정은 부수적 심판이므로 독립하여 불복할 수 없다(法 156⑤).

3. 참가신청의 취하

(1) 요 건

참가신청의 취하는 심리종결 전까지 할 수 있는 참가신청과는 달리 심결확정 전까지 할 수 있다. 또한 피참가인의 이익을 해하는 것이 아니고 심결의 효력(일사부재리)이 취하한 참가신청인에게도 미치므로 피참가인의 동의를 필요로 하지 아니한다. 다만 당사자 참가를 하였는데 심판청구인(피참가인)이 심판청구를 취하하여 참가인만이 심판절차를 밟게 되는 경우에는 참가인이 홀로 남아서 심판청구인의 지위에 있으므로, 제161조제1항의 심판청구의 취하를 유추적용하여 피청구인의 답변서 제출이 있다면 피청구인의 동의를 받아야 취하할 수 있다.

(2) 절 차

심판참가인이 그 참가를 취하하려는 경우에는 심판참가취하서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다(施規 69③).

55) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 146면.

(3) 효 과

참가신청이 취하되면 참가신청은 없었던 것으로 간주된다.

IV. 참가의 효력

1. 지위와 권한

(1) 당사자 참가인

당사자 참가인은 당사자로서 참가하는 것이므로 피참가인, 즉 심판청구인과 대등한 법적 지위를 갖는다. 그러므로 피참가인의 행위와 모순되는 절차를 밟을 수 있고, 피참가인이 그 심판의 청구를 취하한 후에도 심판절차를 속행할 수 있다(法 155②).

(2) 보조 참가인

1) 보조 참가인은 어느 한쪽 당사자를 보조하기 위하여 심판에 참가한 자이므로 피참가인에게 종속된다. 예를 들어 당사자 참가인과는 달리 피참가인이 그 심판청구를 취하하면 참가인의 지위를 상실한다(法 155②반대해석). 그러나 참가인은 피참가인의 대리인이 아니며 자기의 이익을 주장하기 위해 독자적인 권한으로 심판에 관여하므로 독자성이 인정된다. 즉 보조 참가인은 공격·방어방법의 제출이나 그 밖의 모든 심판절차를 밟을 수 있다(法 155④).

2) 한편 독립하여 심판을 청구할 수 있는 이해관계를 가진 자라도 보조 참가를 한 이상 보조 참가인의 지위만을 가질 뿐이다. 예를 들어 주된 당사자인 심판청구인이 이해관계가 없으면 보조 참가인이 독립하여 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 있더라도 그로써 심판청구인의 심판청구를 적법하게 할 수는 없다.⁵⁶⁾

2. 절차의 정지

참가인에게 심판절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다(法 155⑤). 이는 참가를 허용하는 취지가 이해관계인 간의 합일적인 분쟁해결을 위한 것이기 때문이다.

3. 심결의 효력

참가인에게도 심결의 효력(일사부재리)이 미치기 때문에 심판장은 심결이 있는 경우 당사자, 참가인뿐만 아니라 참가신청을 하였으나 참가가 거부된 자에게도 심결등본을 송달하여야 한다(法 162⑥). 당사자, 참가인 또는 해당 심판이나 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자는 해당 심결에 대하여 특허법원에 취소소송을 제기할 수 있다(法 186②). 참가가 거부된 자가 소를 제기할 수 있는 이유는 참가신청의 거부에는 심판의 지연을 방지한다는 정책적인 이유로 불복할 수 없도록 하고 있지만, 직접 특허법원에 소를 제기하여 법원에서 「이해관계」를 인정받을 때는 본안까지도 다룰 수 있게 하여 우회적으로 참가신청의 거부에 대하여 불복을 인정하고자 함이다.

56) 대법원 1970. 8. 31. 선고 69후13.

제4절 국선대리인, 전문심리위원 및 참고인

제139조의2 【국선대리인】

- ① 특허심판원장은 총리령으로 정하는 요건을 갖춘 심판 당사자의 신청에 따라 대리인(이하 "국선대리인"이라 한다)을 선임하여 줄 수 있다. 다만, 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - ② 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 심판절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있다.
 - ③ 국선대리인의 신청절차 및 수수료 감면 등 국선대리인 운영에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.
- [본조신설 2019. 1. 8.]

제154조의2 【전문심리위원】

- ① 심판장은 직권에 따른 결정으로 전문심리위원을 지정하여 심판절차에 참여하게 할 수 있다.
 - ② 심판장은 제1항에 따라 전문심리위원을 심판절차에 참여시키는 경우 당사자의 의견을 들어 각 사건마다 1명 이상의 전문심리위원을 지정하여야 한다.
 - ③ 전문심리위원에게는 총리령으로 정하는 바에 따라 수당을 지급하고, 필요한 경우에는 그 밖의 여비, 일당 및 숙박료를 지급할 수 있다.
 - ④ 전문심리위원의 지정에 관하여 그 밖에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.
 - ⑤ 제1항에 따른 전문심리위원에 관하여는 「민사소송법」 제164조의2제2항부터 제4항까지 및 제164조의3을 준용한다. 이 경우 "법원"은 "심판장"으로 본다.
 - ⑥ 제1항에 따른 전문심리위원의 제척 및 기피에 관하여는 제148조부터 제152조까지의 규정을 준용한다. 이 경우 "심판관"은 "전문심리위원"으로 본다.
- [본조신설 2021. 4. 20.]

제154조의3 【참고인 의견서의 제출】

- ① 심판장은 산업에 미치는 영향 등을 고려하여 사건 심리에 필요하다고 인정되는 경우 공공단체, 그 밖의 참고인에게 심판사건에 관한 의견서를 제출하게 할 수 있다.
 - ② 국가기관과 지방자치단체는 공익과 관련된 사항에 관하여 특허심판원에 심판사건에 관한 의견서를 제출할 수 있다.
 - ③ 심판장은 제1항 또는 제2항에 따라 참고인이 제출한 의견서에 대하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다.
 - ④ 제1항 또는 제2항에 따른 참고인의 선정 및 비용, 준수사항 등 참고인 의견서 제출에 필요한 사항은 총리령으로 정한다.
- [본조신설 2023. 9. 14.]

제226조 【비밀누설죄 등】

- ① 지식재산처 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원이었던 사람이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처한다. <개정 2021. 4. 20.>
 - ② 전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. <신설 2021. 4. 20.>
- [전문개정 2014. 6. 11.]

제226조의2 【전문기관 등의 임직원에 대한 공무원 의제】

- ① 제58조제2항에 따른 전문기관 또는 제58조제3항에 따른 전담기관의 임직원이거나 임직원이었던 사람은 제226조 제1항을 적용하는 경우에는 지식재산처 소속 직원 또는 직원이었던 사람으로 본다. <개정 2016. 12. 2., 2018. 4. 17., 2021. 4. 20., 2024. 2. 6.>
 - ② 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정을 적용할 때에는 공무원으로 본다. <신설 2021. 4. 20.>
- [전문개정 2014. 6. 11.]

I. 국선대리인

특허심판원장은 총리령으로 정하는 요건을 갖춘 심판당사자의 신청에 따라 대리인(이하 “국선대리인”이라 한다)을 선임하여 줄 수 있다. 다만 심판청구가 이유 없음이 명백하거나 권리의 남용이라고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다(法 139의2①). 지식재산권과 관련된 특허심판의 경우에는 「발명진흥법」에서 규정된 ‘공익변리사 특허상담센터’⁵⁷⁾를 통해 심판과 관련된 상담 및 심결취소소송심판 대리 등을 지원하고 있지만, 공익변리사 인원 및 예산상 한계로 인하여 사회적 약자를 위한 특허심판 지원에는 한계가 있어서 2019. 7. 9. 시행된 현행법(법률 제16208호, 2019. 1. 8. 일부개정)에서는 사회취약계층에 심판 대리 업무를 지원하는 국선대리인 규정을 신설하였다. 또한 국선대리인이 선임된 당사자에 대하여 심판절차와 관련된 수수료를 감면할 수 있도록 하여(法 139의2②), 사회취약계층의 부담을 덜어줄 수 있게 되었다.⁵⁸⁾

II. 전문심리위원

1. 의의 및 취지

심판장은 직권⁵⁹⁾에 따른 결정으로 전문심리위원을 지정하여 심판절차에 참여하게 할 수 있고, 전문심리위원을 심판절차에 참여시키는 경우 당사자의 의견을 들어 각 사건마다 1명 이상의 전문심리위원을 지정하여야 한다. 전문심리위원에게는 총리령으로 정하는 바에 따라 수당을 지급하고, 필요한 경우에는 그 밖의 여비, 일당 및 숙박료를 지급할 수 있다(法 154의2①②③). 최근 특허분쟁 내용이 복잡·고도화되고 디지털 혁신·융복합 등 4차 산업혁명 시대의 일부 첨단기술 또는 현장지식이 필요한 분야에 대하여 심판의 전문성을 확보하기 위해 전문가의 협력 필요성이 증대되고 있음을 고려하여 2021. 10. 21. 시행되는 현행법(법률 제16208호, 2019. 1. 8. 일부개정)에서는 전문심리위원 제도를 도입하였다.⁶⁰⁾

57) 제26조의2(공익변리사 특허상담센터) ① 지식재산처장은 사회적 약자에 대한 특허 관련 상담 등 무료 변리서비스를 제공하기 위하여 공익변리사 특허상담센터(이하 “상담센터”라 한다)를 설치한다.

② 상담센터는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 산업재산권의 출원·심사·등록·심판절차와 관련한 상담 및 서류작성 지원
2. 「변리사법」 제2조에 따라 지식재산처 또는 법원에 대하여 하여야 할 사항의 대리
3. 산업재산권 관련 분쟁조정신청서 검토 및 잠정 합의권고안 작성 지원
4. 특허분쟁 경영컨설팅 및 법률 자문

5. 산업재산권 관련 설명회의 개최 및 상담

6. 그 밖의 산업재산권 관련 법률서비스 지원 및 대통령령으로 정하는 상담센터의 운영 목적에 부합하는 업무

58) 송대호, 특허법 일부개정법률안 검토보고서(조배숙의원 대표발의(의안번호 13111, 13112, 13113)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2018.8. 3-4면.

59) 당사자의 신청을 허용하면 과도한 기술분야의 위원 풀 구성, 많은 신청과 불승인 결정에 대한 민원 등이 우려되어 심판장의 직권으로 전문심리위원을 지정할 수 있도록 하되 기술전문성 차원에서 보완이 필요한 일부 기술에 한정하여 운영하도록 하였다.

2. 참여 및 참여결정의 취소

1) 전문심리위원은 전문적인 지식을 필요로 하는 심판절차에서 설명 또는 의견을 기재한 서면을 제출하거나 기일에 출석하여 설명이나 의견을 진술할 수 있다. 심판장은 전문심리위원이 제출한 서면이나 전문심리위원의 설명 또는 의견의 진술에 관하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다. 다만 심판의 합의에는 참여할 수 없다. 또한 전문심리위원은 기일에 심판장의 허가를 받아 당사자, 증인 또는 감정인 등 소송관계인에게 직접 질문할 수 있다(法 154의2⑤ 준용 민소 164의2).

2) 특허심판원은 상당하다고 인정하는 때에는 직권이나 당사자의 신청으로 전문심리위원의 참여결정을 취소할 수 있다. 한편 당사자가 합의로 전문심리위원의 참여결정을 취소할 것을 신청하는 때에는 특허심판원은 그 결정을 취소하여야 한다(法 154의2⑤ 준용 민소 164의3).⁶¹⁾

3. 제척 및 기피

전문심리위원의 제척 및 기피에 관하여는 심판관의 제척 및 기피에 관한 규정(法 148-152)을 준용한다. 이 경우 “심판관”은 “전문심리위원”으로 본다(法 154의2⑥).

4. 비밀누설죄 등

전문심리위원 또는 전문심리위원이었던 자가 그 직무수행 중에 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하는 경우에는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다(法 226②). 전문심리위원은 「형법」 제129조부터 제132조까지의 규정(수뢰, 제3자뇌물제공)을 적용할 때에는 공무원으로 본다(法 226의2②).

60) 법원은 2007년부터 건축, 의료, 지적권 등 전문적인 지식과 경험을 필요로 하는 사건 심리를 위해 전문심리위원 제도를 도입하여 지식과 경험이 풍부한 전문심리위원이 각 소송절차에서 설명 또는 의견을 제시하고 있으나, 특허심판에서는 이를 도입하고 있지 않았다. 개정된 현행법은 특허심판 사건에 대해서도 전문심리위원이 참여할 수 있는 근거를 특허법에 명시하고 있다(채수근, 특허법 일부개정법률안 검토보고서(송기현의원 대표발의(의안번호 제2104132호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2020.11, 3면).

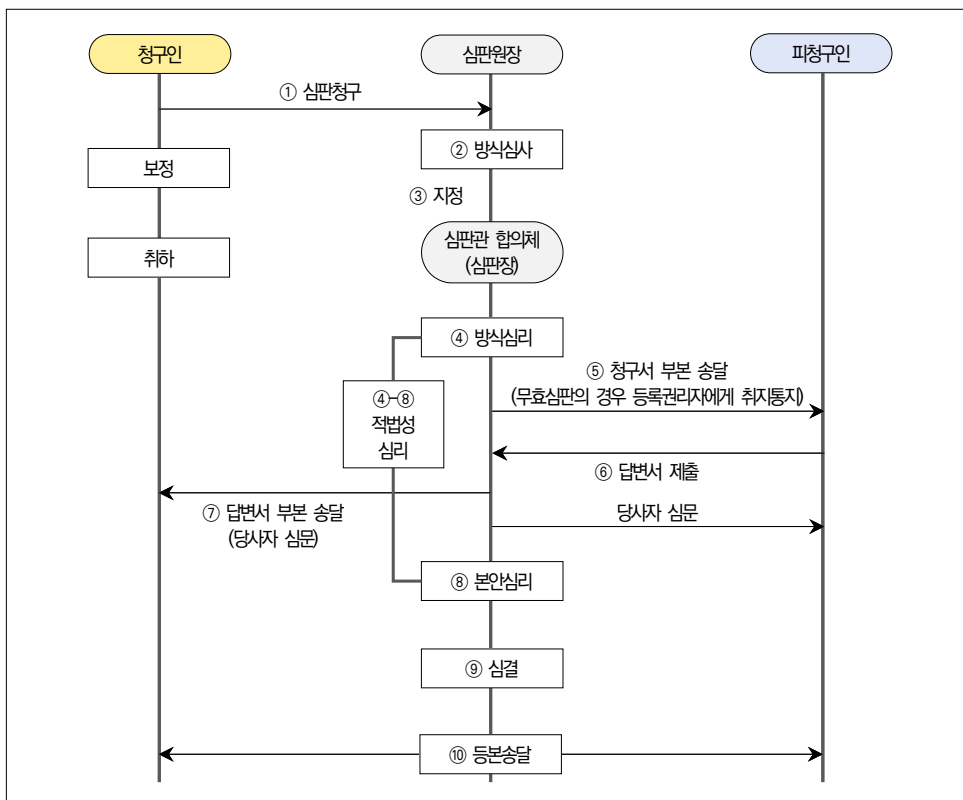
61) 특허법 시행규칙 제65조의4(전문심리위원의 지정 등) ① 심판장은 법 제154조의2제2항에 따라 전문심리위원을 지정할 때에는 특허심판원장이 정한 후보자 중에서 지정해야 한다.

② 심판장은 법 제154조의2제5항에 따라 준용되는 「민사소송법」 제164조의3제1항에 따라 전문심리위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심판절차 참여 결정을 취소할 수 있다. 다만 제1호에 해당하는 경우에는 심판절차 참여 결정을 취소해야 한다. <개정 2022. 7. 1.>

1. 거짓이나 그 밖의 부정한 행위가 있다고 인정되는 경우
2. 심신상의 장애로 전문심리위원의 직무를 수행할 수 없는 경우
3. 전문심리위원으로서 적합하지 않은 행위가 있는 경우
4. 그 밖에 전문심리위원으로 계속 활동하기 어렵다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 경우

Ⅲ. 참고인

심판장은 산업에 미치는 영향 등을 고려하여 사건 심리에 필요하다고 인정되는 경우 공공단체, 그 밖의 참고인에게 심판사건에 관한 의견서를 제출하게 할 수 있다. 또한 국가기관과 지방자치단체는 공익과 관련된 사항에 관하여 특허심판원에 심판사건에 관한 의견서를 제출할 수 있다. 심판장은 참고인이 제출한 의견서에 대하여 당사자에게 구술 또는 서면에 의한 의견진술의 기회를 주어야 한다(法 154의3). 2024. 3. 15. 시행된 현행법(법률 제19714호, 2023. 9. 14. 개정)에서는 특허심판에서의 심리 충실성을 강화하고 사회적 신뢰도를 향상하는데 기여하기 위하여 특허심판에서 심판참고인 제도를 도입하였다.⁶²⁾



【그림 7-2】 심판의 일반적인 절차

62) 참고로 민형사소송에서도 그 규칙에서 의하여 참고인 제도가 운영되고 있는데, 주로 법률의 해석, 적용에 관한 문제를 판단하는 대법원에서 활용하고 있다(이상현 수석전문위원, 특허법 등 일부개정법률안 검토보고(이철규 의원 대표발의(의안번호 제2116852호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2022.8. 9면.

제3장

심판의 청구

제140조 [심판청구방식]

- ① 심판을 청구하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
 1. 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 3. 심판사건의 표시
 4. 청구의 취지 및 그 이유
- ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>
 1. 제1항제1호에 따른 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우
 2. 제1항제4호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우
 3. 제135조제1항에 따른 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명(청구인이 주장하는 피 청구인의 발명을 말한다)의 설명서 또는 도면에 대하여 피 청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피 청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우
- ③ 제135조제1항·제2항에 따른 권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다.
- ④ 제138조제1항에 따른 통상실시권 허락의 심판의 심판청구서에는 제1항 각 호의 사항 외에 다음 사항을 추가로 적어야 한다.
 1. 실시하려는 자기의 특허의 번호 및 명칭
 2. 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록 연월일
 3. 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가
- ⑤ 제136조제1항에 따른 정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제140조의2 [특허거절결정에 대한 심판청구방식]

- ① 제132조의17에 따라 특허거절결정에 대한 심판을 청구하려는 자는 제140조제1항에도 불구하고 다음 각 호의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. <개정 2016.2.29.>
 1. 청구인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 3. 출원일 및 출원번호
 4. 발명의 명칭

5. 특허거절결정일
 6. 심판사건의 표시
 7. 청구의 취지 및 그 이유
- ② 제1항에 따라 제출된 심판청구서를 보정하는 경우에는 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 제1항제1호에 따른 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우
 2. 제1항제7호에 따른 청구의 이유를 보정하는 경우
- [전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1) 심판을 청구하려는 자는 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 특허심판원장은 심판청구서를 수리한 때에는 심판번호를 부여하고 그 사건에 대한 합의체를 구성할 심판관을 지정하여야 하며, 심판관을 지정하거나 지정된 심판관의 변경이 있을 때는 그 사실을 당사자에게 통지하여야 한다. 이 경우 전자문서로 통지 또는 송달을 받으려는 자에게는 전자정보처리조식에서 열람할 수 있게 한 경우 통지한 것으로 본다(施規 58).

2) 심판장은 심판이 청구되면 당사자에게 심판의 경우 청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서를 제출할 기회를 주어야 하며, 피청구인으로부터 답변서를 수리한 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다. 그리고 심판에 관하여 당사자를 심문(석명권의 행사)⁶³⁾할 수도 있다(法 147). 여기서 「심판이 청구되면」이란 심판장의 방식심리 결과 각하 사유가 없는 것으로 판단한 후를 말하며, 심판장은 피청구인이 지정기간에 답변서 부분을 제출하지 아니한 경우에는 답변서 제출 여부와 관계없이 절차를 진행한다(法 158).⁶⁴⁾

II. 심판청구서의 기재사항

1. 일반적 기재사항

1) 심판을 청구하려는 자는 다음의 사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(法 140①).

i) 당사자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)

63) 심문(審問)과 신문(訊問): ‘심문’은 ‘자세히 따져 묻는다’는 뜻으로 법원이 당사자나 그 밖의 이해관계가 있는 사람에게 서면이나 구두로 개별적으로 진술할 기회를 주는 것을 말하고, ‘신문’은 ‘알고 있는 사실을 캐어 묻는다’는 뜻으로 법원 또는 당사자가 증인·반대당사자 등에 말로 물어 조사하는 것을 말한다. 증인 신문, 당사자신문 등이 여기에 해당한다(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 324면). 심문은 주로 청구의 적법요건 구비에 대하여 사실관계를 분명히 하기 위하여 또는 심판청구서 등의 표시를 정확하게 하였는지 확인하기 위하여 또는 본안심리 후 사실관계를 명확하게 할 필요가 있는 때에 심판장이 행한다.

64) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 352면.

- ii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
 - iii) 심판사건의 표시⁶⁵⁾
 - iv) 청구의 취지 및 그 이유
- 2) 여기서 「심판청구이유」의 기재는 그 청구원인이 특정될 수 있는 정도로 기재하면 족한 것이고 반드시 그 청구이유를 도출하게 되는 과정을 상세히 적어야만 하는 것은 아니다.⁶⁶⁾

2. 추가적 기재사항 및 첨부사항

(1) 거절결정불복심판의 경우

거절결정불복심판의 심판청구서에는 일반적 기재사항 외에 다음의 사항을 추가로 적어야 한다(法 140의2①).

- i) 출원일 및 출원번호
- ii) 발명의 명칭
- iii) 특허거절결정일

(2) 권리범위확인심판의 경우

권리범위 확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다(法 140③). 이때 설명서에는 특허발명과 확인대상발명의 구체적인 대비표를 적어야 한다(施規 57①Ⅱ).

(3) 정정심판의 경우

정정심판을 청구할 때에는 심판청구서에 정정한 명세서 또는 도면을 첨부하여야 하며(法 140⑤), 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 대한 통상실시권자 및 질권자의 동의서를 제출하여야 한다. 다만 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다(法 136⑧, 施規 57②Ⅳ).

(4) 통상실시권허락심판의 경우

통상실시권허락심판의 심판청구서에는 일반적 기재사항 외에 다음의 사항을 추가로 적어야 한다(法 140④).

- i) 실시하려는 자기의 특허의 번호 및 명칭
- ii) 실시되어야 할 타인의 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 번호·명칭 및 특허나 등록 연월일
- iii) 특허발명·등록실용신안 또는 등록디자인의 통상실시권의 범위·기간 및 대가

65) 구체적으로 권리번호와 심판의 종류를 표시한다. 예를 들면 「특허 제○○○호의 등록무효심판」, 「특허 제○○○호의 권리범위확인심판」 등과 같이 적는다.

66) 특허법원 1998. 6. 25. 선고 98허1259.

Ⅲ. 심판청구서의 보정

1. 원 칙

심판을 청구하는 자는 심판청구방식의 불비 또는 기재사항의 오기 등이 있을 때 심판청구서를 보정할 수 있다. 다만 요지변경이 되지 아니하는 범위에서만 가능하다(法 140②, 140의2②본문). 만일 요지변경을 함부로 인정하면 심판사무를 쓸데없이 복잡하게 하고 심판절차를 지연케 할 뿐만 아니라 피청구인의 방어에도 곤란을 주기 때문이다.⁶⁷⁾ 여기서 변경할 수 없는 「요지」란 청구의 취지 및 이유 등 심판청구서 전체의 취지를 살펴본다 등록된 권리를 중심으로 하여 적어도 그 동일성을 해하지 아니하는 범위의 것을 말한다.⁶⁸⁾

2. 예 외

- (1) 심판의 당사자 중 특허권자나 거절결정불복심판의 청구인의 기재를 바로잡기 위한 보정(추가하는 것을 포함하되, 청구인이 추가될 때는 특허권자나 거절결정불복심판 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)

심판청구인의 실수로 인해 당사자가 누락되거나 잘못 기재되었을 때 심판이 각하되는 사례를 방지하기 위해 심판의 당사자 중 특허권자나 거절결정불복심판의 청구인 기재를 바로 잡기 위한 보정을 자유롭게 허용하고 있다. 다만 단독으로 심판을 청구한 후 청구인 추가는 사후적으로라도 다른 공유자의 동의가 있는 경우에 한해 할 수 있도록 제한하고 있다(法 140②I, 140의2②I). 공유자 모두가 청구인이 될 때는 모두의 사전 합의가 있어야 한다는 점에서 공유자 모두가 피청구인이 될 때와 차이가 있기 때문이다.⁶⁹⁾

(2) 심판청구이유의 보정

심판청구서의 기재사항 중 청구이유의 보정은 요지변경이 되더라도 상관없다(法 140②II, 140의2②II). 심판청구이유에 대해서는 심판청구인이 적은 범위에 한정되지 않고 직권심리하므로(法 159①) 변경을 자유롭게 허용하고 있다. 또한 심판청구할 수 있는 기간 내 청구취지를 적어 심판청구를 하였다면 추후 청구이유를 추가 또는 보완할 수 있는 기회를 주는 것이 바람직하기 때문이다.

(3) 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 보정

- 1) 적극적 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명(청구인이 주장하는 피청구인

67) 대법원 1990. 1. 23. 선고 89후179.

68) 대법원 1987. 1. 20. 선고 85후119.

69) 이는 다음과 같은 민사소송법 제68조의 내용을 심판에 반영한 것이라고 할 수 있다.

제68조[필수적 공동소송인의 추가]① 법원은 제67조제1항의 규정에 따른 공동소송인 가운데 일부가 누락된 경우에는 제1심의 변론을 종결할 때까지 원고의 신청에 따라 결정으로 원고 또는 피고를 추가하도록 허가할 수 있다. 다만 원고의 추가는 추가될 사람의 동의를 받은 경우에만 허가할 수 있다.

의 발명을 말한다)의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명(실시주장발명)과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우에는 요지변경이 되더라도 허용된다(法 140②Ⅲ).

2) 적극적 권리범위확인심판청구 시 청구인이 확인대상발명을 잘못 특정한 경우, 구법에서는 이에 대한 보정을 요지변경되지 아니하는 범위에서 엄격히 제한하고 있어 동일한 사안에 대하여 다시 심판을 청구하여야 하였는데, 이는 소송경제에 반하고 심판사건 처리는 지연되는 문제가 있었다. 따라서 2007. 7. 1. 시행된 현행법(법률 제8197호, 2007. 1. 3. 개정)에서는 확인대상발명에 대한 보정을 자유롭게 허용함으로써 신속한 분쟁해결이 이루어지도록 하고 있다.⁷⁰⁾ 이는 적극적 권리범위확인심판의 경우 확인대상발명을 특정할 의무가 있는 자와 실제로 실시하는 자가 다르기 때문에 피청구인의 협력이 없다면 청구인이 확인대상발명을 정확히 특정하는 것이 소극적 권리범위확인심판과 비교하여 상당한 어려움이 있을 수 있는 점을 고려하여 확인대상발명 특정에 관한 청구인의 불리함을 보상함으로써 균형을 도모하기 위한 특칙이다. 따라서 위 규정은 확인대상발명의 특정 의무자와 실시자가 동일한 소극적 권리범위확인심판에는 적용되지 아니한다.

3. 요지변경으로 보는 구체적인 사례

(1) 당사자의 보정

청구인과 피청구인의 보정은 잘못된 기재의 정정과 같이 그 동일성을 잃지 아니한 경우를 제외하고는 요지변경이다.⁷¹⁾ 그러나 당사자 중 특허권자나 거절결정불복심판 청구인의 기재를 바로잡기 위한 보정(추가하는 것을 포함한다)은 요지변경이라도 허용된다.

(2) 사건의 표시 및 청구취지의 보정

1) 사건의 표시, 즉 출원번호 또는 특허번호 등 표시의 보정은 잘못된 기재의 정정과 같이 심판청구대상의 동일성을 잃지 아니한 경우를 제외하고는 요지변경이다.

2) 「청구의 취지」란 심판청구인이 어떠한 심결을 구하는가를 특정하여 요구하는 것을 말한다고 하겠고 이를 변경하게 되면 청구자체를 변경하는 것이 되어 이는 허용될 수 없다.⁷²⁾ 예를 들어 정정무효심판의 청구를 특허무효심판의 청구로 하는 보정은 요지변경이다. 또한 특허무효심판의 대상 중 청구항을 변경시키는 보정 역시 요지변경이다. 특허무효심판은 청구항을 달리하면 청구취지를 달리하기 때문이다. 다만 여러 청구항의 무효를 구하다가 그중 일부항의 무효만을 구하는 것은 청구취지의 감축으로 허용된다.⁷³⁾

70) 특허법원 2009. 9. 9. 선고 2009허2227.

71) 증거와 변론취지에 의하여 심판청구인으로 표시한 「박영의」는 「박규제」의 별명에 불과하고 따라서 이 사건 청구는 「박규제」가 제기되었다고 봄이 상당할 것이므로 이 사건에 있어서 청구인으로 「박영의」를 「박규제」로 정정을 하면 족한 것이다(대법원 1967. 8. 29. 선고 67후9).

72) 대법원 1991. 5. 28. 선고 90후854.

(3) 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 보정

1) 확인대상발명은 권리범위확인을 구하는 청구취지의 일부를 구성하므로 요지변경이 되지 아니하는 범위내에서만 보정이 가능하다(法 140②). 확인대상발명의 보정은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우로서 i) 심판청구서에 첨부된 확인대상발명의 불명확한 부분을 구체화하는 것이거나, ii) 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것⁷⁴⁾에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것이라면 요지변경에 해당되지 아니한다. 즉 새로운 사실관계의 심리나 새로운 소송자료의 제공을 필요로 하지 않고 당사자들의 방어권을 과도하게 방해하지 않는다면 그 보정을 인정할 필요가 있다.⁷⁵⁾⁷⁶⁾ 다만 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명(실시주장발명)과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우에는 요지변경이 되더라도 허용된다(法 140③III).

2) 문제가 되는 것은 심결취소소송단계에서도 확인대상발명의 보정이 인정되는지이다. 대법원⁷⁷⁾은 심판원에서 확인대상발명이 특정된 것으로 보아 본안판단을 하였으나 소송단계에서 판단하기에 확인대상발명이 특정되지 아니한 것으로 판단되면 심판청구요건의 흠결이 있고, 소

73) 이 경우 피청구인이 답변서를 제출한 경우라면 동의를 얻어야 한다(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 153면).

74) 예를 들어 1) 도면에 도시된 구성을 설명서에 부가하는 경우(대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344), ii) 특허발명과 대비될 수 있는 구성의 부가하는 경우(특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252), iii) 확인대상발명에 상품명·제품번호 또는 실물사진이 제출되었는데 그와 동일하게 보정하는 경우(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356), iv) 청구이유 및 심판청구서에 첨부된 증거자료에 기재된 구성의 부가하는 경우(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후61) 등이 있다(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 551-552면).

75) 대법원 2000. 9. 8. 선고 97후4039; 2012. 5. 24. 선고 2012후44.

76) 확인대상발명의 보정의 한계를 정하는 기능을 하는 “동일성” 개념은 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있는가라고 하는 견지에서 파악되는 것으로서, 신규성, 선출원주의 등의 특허요건에서의 개념과는 그 고찰의 근거가 다르다. 예를 들어 권리범위확인심판에서 심판청구서의 설명란에 확인대상발명의 작동에 중요한 부분을 이루는 구성에 관한 기재가 생략되었거나 확인대상발명과 대비되는 특허발명의 청구범위에 기재되어 있는 구성요소에 상응하는 구성에 대한 발명의 설명이 없었음에도, 이러한 구성에 관한 기재를 추가하거나 변경하는 보정은, 설사 특허요건에서의 발명의 동일성의 범위를 벗어나거나, 보정이나 정정요건에서의 신규사항을 추가하는 것이라고 하더라도, 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 없는 경우에는 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로서 요지변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다(특허법원 2007. 6. 1. 선고 2006허010661). 결국, 심판단계에서 확인대상발명의 보정이 이루어진 경우, 그 보정이 요지의 변경에 해당하는지의 여부는 보정 전후 확인대상발명에서 변경된 구성요소의 중요도, 보정의 경위(보정의 시기, 보정명령에 따른 것인지), 보정 후 피심판청구인이 방어권을 행사하였는가 등의 여러 사정을 고려하여 규범적으로 판단하여야 할 것이다(한동수, “확인대상고안의 보정시 요지변경의 의미”, 한국특허법학회 편, 「특허판례연구」, 박영사, 2009, 616면).

77) 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372.

송단계에서 심판청구요건의 흠결을 사후에 치유하는 확인대상발명에 대한 보정은 불가능하므로 그 심결은 취소되어야 한다는 입장이다. i) 심판청구요건은 심결 시까지 갖추어야 한다는 점, ii) 심결취소소송에서 확인대상발명의 보정을 인정하면 소송물이 변경되어 심판전치주의(필요적 전치주의)에 반한다는 점⁷⁸⁾ 등을 고려한 것이라 할 수 있다.

(4) 정정심판에서 명세서 또는 도면의 보정

정정한 명세서 또는 도면은 정정심판에서 청구취지의 일부를 구성하므로 요지변경이 되지 아니하는 범위내에서만 보정이 가능하다(法 140②). 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 특허발명에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 특허권자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정심판청구 전체가 인정되지 않게 되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도로써, 실질적으로 새로운 정정심판청구에 해당하는 정정명세서 등의 보정을 허용하게 되면 정정심판청구의 기간을 제한한 특허법의 취지를 몰각시키는 결과가 되고, 정정심판청구가 받아들여질 때까지 정정명세서 등의 보정서 제출이 무한히 반복되어 행정상의 낭비와 심판절차의 지연이 초래될 우려가 있는 점을 고려할 때, 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 심판청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 한다.⁷⁹⁾ 즉 정정심판청구에 있어서는 정정을 구하는 부분(명세서 또는 도면)의 특징은 청구의 취지에 해당하므로 만일 정정심판청구서 중 정정을 구하는 부분이 보정에 의하여 변경됨으로써 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정심판청구서의 요지를 변경하는 것으로서 허용되지 아니한다. 여기서 요지변경이라 함은 청구범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것이라 할 것이다.⁸⁰⁾

4. 요지변경의 취급

심판장은 보정한 사항이 제140조제2항 또는 제140조의2제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다(法 141②). 다만 심판장은 심판청구서의 보정이 요지변경이라고 판단되는 경우 바로 각하하지 말고 석명권을 행사하여 심문서, 보정요구서, 보충요구서 등을 통해 청구인이 다시 심판청구서를 보정할 기회를 주는 것이 바람직하다.⁸¹⁾

78) 특허법원 1999. 3. 25. 선고 98허6162.

79) 대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 참조

80) 대법원 1997. 11. 14. 선고 96후2265 판결 참조

81) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 153면.

IV. 중복심판청구의 금지

1. 의의 및 취지

특허심판이 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구하지 못한다(法 154⑧ 준용 民訴 259). 이미 계속되고 있는 사건에 대하여 다시 심판청구를 허용함은 심판제도의 남용이고, 심판원이나 당사자에게 시간·노력·비용을 이중으로 낭비하게 하는 것이어서 심판경제상 바람직하지 않고, 심결이 서로 모순·저촉될 염려가 있기 때문이다.

2. 적용요건

(1) 전 심판청구의 계속 중에 후 심판청구를 하였을 것

전 심판청구의 계속 중에 후 심판청구를 하여야 한다. 여기서 「전 심판청구의 계속 중」이란 특허심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 특허법원(대법원)에 계속 중인 경우도 포함하는 것으로 해석된다.⁸²⁾

(2) 동일한 당사자일 것

후 심판청구의 당사자와 전 심판청구의 당사자가 동일하여야 한다.

(3) 동일한 심판청구일 것

동일한 심판청구이어야 한다. 동일한 심판청구란 심판청구의 취지가 동일한 것으로서, 심판청구의 취지가 동일하다면 심판청구의 이유나 그 증거가 다르더라도 동일한 심판청구에 해당

82) 특허법 제154조 제7항에서 준용하고 있는 민사소송법 제259조는 “동일한 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다”라고 규정하고 있는데, 그 요건으로는 첫째, 당사자가 동일하고, 둘째, 청구가 동일하여야 하며, 셋째 전소의 계속 중에 후소를 제기하였을 것이다. 위 요건들을 특허권에 관한 중복 심판 청구금지에 대하여 적용할 때 셋째 요건과 관련하여 ‘전 심판의 계속 중에 후 심판을 제기하였을 것’에서 ‘전 심판의 계속 중’을 ‘전 심판이 특허심판원에 계속 중일 것’을 의미하는지, 아니면 ‘전 심판절차에서 내려진 심결이 확정되지 아니한 경우’를 의미하는 지가 문제된다. 살펴보면, 다음과 같은 사정에 비추어 보면 ‘전 심판의 계속 중’을 ‘전 심판에서 내려진 심결이 확정되지 아니한 경우’를 의미하는 것으로 해석하는 것이 타당하다. 즉 i) ‘전 심판의 계속 중’을 ‘전 심판이 특허심판원에 계속 중’으로 좁게 해석하게 되면 심판청구인은 전 심판절차에서 내려진 심결에 대하여 심결취소소송을 제기한 후 그 심결이 확정되기 전에 다시 동일한 심판을 청구하여도 후 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위배되지 않게 되고(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 판결 참조), 특허심판원은 후 심판청구에 대하여 심결을 하여야 하므로 결국 동일한 심판청구에 대하여 2개의 심결이 있게 되어 무용한 절차의 반복을 방지하고자 하는 중복심판청구 금지 규정의 입법취지에 반한다. ii) ‘전 심판이 특허심판원에 계속 중’으로 좁게 해석하게 되면 전 심판절차에서 불리한 심결을 받은 심판청구인은 심결취소소송을 제기한 후 다시 동일한 심판청구를 할 수 있게 되어 피심판청구인은 심결취소소송에 대하여 방어해야 될 뿐만 아니라 새로 제기된 후 심판청구에 대하여도 방어권을 행사해야 되므로 소송경제에 반하고 심판청구권의 남용을 방지하고자 하는 중복 심판청구 금지 규정의 입법목적도 달성할 수 없게 된다. iii) 더구나 전 심판청구에 관한 심결에 대한 취소소송을 제기하고 동일한 심판을 다시 청구한 경우 전 심판절차에서 내려진 심결을 취소하는 판결이 선고되어 확정되면 특허심판원에 후 심판청구가 계속 중임과 동시에 재심리절차가 개시되면서 전 심판청구가 계속되어 동일 당사자 사이에 동일한 심판청구에 대하여 2개의 심판절차가 진행되는 불합리한 결과가 발생할 수 있다(특허법원 2014. 7. 10. 선고 2013허9805).

한다. 한편 확인대상발명이 사실적 관점에서 같은 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판이 중복심판청구금지의 원칙에서 동일한 심판청구인지에 대하여 특허법원의 판단이 일치하지 않고 있다.⁸³⁾ 확인대상발명이 같다면 하나의 심판절차나 심결취소소송절차에서 충분히 다룰 수 있는데 별도의 심판청구를 인정하는 것은 적절하지 않다고 사료되며, 따라서 동일 심판으로 봄이 타당하다.

3. 판단시기

중복심판청구의 금지에 해당하는지는 후 심판의 심결 시를 기준으로 판단한다. 따라서 후 심판청구 시에 동일한 전 심판이 계속 중이었더라도, 후 심판의 심결 시에 전 심판의 계속이 소멸되었으면 후 심판은 중복심판에 해당하지 아니한다. i) 전 심판의 계속 중 후 심판이 청구되었는데 후 심판의 심결 시에는 전 심판이 확정되어 중복상태가 해소된 경우, 중복심판청구에 해당하지 않고 일사부재리 원칙도 적용되지 않아 심결의 모순, 저촉이 발생할 여지가 생기는 것은 일사부재리의 판단기준시를 심판청구 시로 보게 됨으로써 발생하는 불가피한 공백이고,⁸⁴⁾ ii) 이러한 공백을 메우기 위하여 중복심판청구의 판단기준 시점을 심판청구 시로 볼 이익이, 그로 인해 전 심판계속 중 동일 당사자에 의한 후 심판청구가 심결 전에는 전 심판계속이 소멸될 여지가 있음에도 전면적으로 제한되는 문제보다 크다고 할 수 없기 때문이다.⁸⁵⁾

83) 특허법원 2009. 10. 10. 선고 2008허12289 판결에서는 동일심판이 아니라고 하였고, 특허법원 2016. 7. 1. 선고 2016허2249 판결에서는 동일심판이라고 하였다.

84) 후 심판이 청구되는 경우 특허심판원이 심리의 병합 등을 통해 하나의 심판절차로 심리하기 위한 조치를 취한다면 이러한 공백을 메울 수 있는 것이다.

85) 민사소송법 제259조는 “법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다”라고 규정하고, 2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정된 특허법 제154조 제8항은 심판에 관하여 민사소송법 제259조를 준용하고 있다. 이러한 관련 법령의 내용에 다음의 사정을 고려하면, 특허심판원에 계속 중인 심판(이하 ‘전 심판’이라 한다)에 대하여 동일한 당사자가 동일한 심판을 다시 청구한 경우(이하 ‘후 심판’이라 한다), 후 심판의 심결 시를 기준으로 한 전 심판의 심판계속 여부에 따라 후 심판의 적법 여부를 판단하여야 한다.

1) 민사소송에서 중복제소금지는 소송요건에 관한 것으로서 사실심의 변론종결 시를 기준으로 판단하여야 하므로, 전소가 후소의 변론종결 시까지 취하·각하 등에 의하여 소송계속이 소멸되면 후소는 중복제소금지에 위반되지 않는다(대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532 판결, 대법원 2017. 11. 14. 선고 2017다23066 판결 등 참조). 마찬가지로 특허심판에서 중복심판청구 금지는 심판청구의 적법요건으로, 심결 시를 기준으로 전 심판의 심판계속이 소멸되면 후 심판은 중복심판청구 금지에 위반되지 않는다고 보아야 한다.

2) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결은 ‘특허법 제163조의 일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다’라고 하였는데, 이는 선행심결의 확정을 판단하는 기준시점이 갱신이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 인한 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 일사부재리 원칙의 요건 중 선행심결의 확정과 관련하여서만 그 기준시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결 참조). 중복심판청구 금지는 동일 당사자에 의한 심판청구권 남용을 방지함으로써 심결의 모순·저촉을 방지하고 심판절차의 경제를 꾀하기 위한 것이어서, 일사부재리 원칙과 일부 취지를 같이 하지만 그 요건 및 적용범위에 차이가 있으므로, 후 심판이 중복심판청구에 해당하는지 여부까지 위 전원합의체 판결을 들어 후 심판청구 시를 기준으로 판단할 것은 아니다(대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317 판결).

4. 효 과

1) 중복심판청구에 해당하는지는 직권조사사항이며, 이에 해당하면 심판관 합의체는 후 심판청구를 심결각하한다(法 142).⁸⁶⁾ 한편 특허심판원이 이를 간과하고 본안판결을 하였을 때는 심결취소소송으로 이를 다룰 수 있다. 그러나 심결이 확정되었을 때는 당연히 재심사유가 되는 것은 아니며, 그렇다고 하여 당연무효의 판결도 아니다. 다만 전·후 심판청구의 심결이 모두 확정되었으나 서로 모순·저촉이 되었을 때는 어느 심판청구를 먼저 하였는지와 상관없이 후에 확정된 심판에 대한 심결이 재심사유가 될 뿐이다.⁸⁷⁾

2) 한편 중복심판청구가 아니거나 일사부재리가 적용되지 아니하면 여러 번 심판을 청구하였다고 할지라도 특별한 사정이 없는 한 이를 권리남용 또는 심판청구권(소권) 남용으로 보지 않는다. 이는 패소 확정심결(판결)을 받은 당사자가 억울하다고 여기는 부분이 있어 권리구제를 받기 위하여 동일 당사자를 상대로 다시 심판청구를 하는 것을 곧바로 그릇된 심판(재판) 청구권의 행사라고 보기는 어렵기 때문이다.⁸⁸⁾

86) 대법원 1982. 9. 14. 선고 80후114.

87) 이시윤, 「신민사소송법」, 박영사, 2002, 258면.

88) 특허법원 2016. 9. 30. 선고 2016허4405 판결.

제4장

심판의 진행

제1절 방식심리

제141조 【심판청구서 등의 각하】

① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. 다만, 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다. <개정 2023. 9. 14.>

1. 심판청구서가 제140조제1항 및 제3항부터 제5항까지 또는 제140조의2제1항을 위반한 경우
2. 심판에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우

가. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우

나. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우

다. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우

② 심판장은 제1항 본문에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제140조제2항 또는 제140조의2제2항을 위반한 경우에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다. <개정 2016. 2. 29., 2023. 9. 14.>

③ 제2항에 따른 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

④ 심판장은 제1항 단서에 따라 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다. <신설 2023. 9. 14.>

⑤ 청구인은 제1항 단서에 따른 직권보정 사항을 받아들일 수 없으면 직권보정 사항의 통지를 받은 날부터 7일 이내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 심판장에게 제출하여야 한다. <신설 2023. 9. 14.>

⑥ 청구인이 제5항에 따라 의견서를 제출한 경우에는 해당 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2023. 9. 14.>

⑦ 제1항 단서에 따른 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다. <신설 2023. 9. 14.>

[전문개정 2014. 6. 11.]

[제목개정 2016. 2. 29.]

I. 의 의

「방식심리」란 심판장의 심판청구서에 대한 적식심리, 즉 심판청구가 법령에 정한 방식에 적합한지를 심리하는 것을 말한다. 특허심판원장은 심판청구서가 제출되면 방식심사를 한다(法 16, 施規 11). 그 후 특허심판원장이 그 심판사건을 심리할 심판관 합의체 및 심판장을 지정하게 되면 그 사건은 특허심판원장으로부터 심판장에게 넘겨지고 심판장이 다시 방식심리를 하게 된다.

II. 방식심리의 대상

1) 심판장은 다음의 사항 중 어느 하나에 위반된 경우에는 기간을 정하여 그 흠결의 보정을 명하여야 한다(法 141①본문).⁸⁹⁾

- i) 심판청구서가 기재방식에 위반된 경우(法 140①③④⑤, 140의2①)
- ii) 행위능력없는 자가 절차를 밟거나(法 3①) 특별히 권한을 위임받지 아니한 임의대리인이 절차를 밟는 경우(法 6)
- iii) 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우(法 82)
- iv) 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우

2) 다만 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권으로 보정할 수 있다(法 141①단서). 심판장은 직권보정을 하려면 그 직권보정 사항을 청구인에게 통지하여야 한다. 청구인은 직권보정 사항을 받아들일 수 없으면 직권보정 사항의 통지를 받은 날부터 7일 이내에 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 심판장에게 제출하여야 하고, 청구인이 의견서를 제출한 경우에는 해당 직권보정 사항은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 141④⑤⑥). 한편 직권보정이 명백히 잘못된 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 141⑦). 기존에는 심판청구의 경미하고 명확한 흠결조차도 심판청구인에게 보정을 요구해야 하므로 불필요하게 심판 절차가 지연될 수 있고 청구인도 사소한 잘못을 직접 보정을 해야 하는 번거로움이 존재하였으나, 2024. 3. 15. 시행된 현행법(법률 제19714호, 2023. 9. 14. 개정)에서는 경미하고 명확한 심판청구 보정 사항에 대하여 심판장이 직권으로 보정할 수 있는 제도를 도입함으로써 불필요한 심판 지연을 방지하고 청구인의 편의를 도모하고 있다.

III. 심판장의 결정각하

심판장은 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 요지 변경인 경우(法 140②, 140의2② 위반)에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다. 이 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다(法 141②③). 심판청구의 심결각하와는 달리 심판청구서 등의 결정각하는 방식요건의 위반사항 등과 같은 비교적 경미한 것이어서 심판장의 단독결정으로 처리한다.

IV. 불복방법

심판장의 심판청구서의 결정각하에 대하여 불복하려는 자는 결정등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 소를 제기할 수 있다(法 186). 이 경우 지식재산처장을 피고로 한다.

89) 심판원장이 한 보정명령은 심판장이 제141조제2항에 따라 각하결정을 할 요건인 보정명령의 근거가 될 수 없기 때문에 심판장의 보정명령 없이 한 심판청구의 각하결정은 위법하다(특허법원 1999. 11. 11. 선고 99허4538).

제2절 적법성 심리

제142조 【보정할 수 없는 심판청구의 심결각하】

부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고, 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 의 의

「적법성 심리」란 심판관 합의체가 심판청구 자체의 적법성을 심리하는 것을 말한다. 즉 심판청구가 적법해지기 위해 갖추어야 할 요건인 심판청구요건 내지 적법요건에 대한 심리를 말한다. 이러한 심판청구요건의 흠결이 있으면 심판관 합의체는 본안심리를 하여서는 아니 된다.

II. 적법성 심리의 대상

- 1) 심판청구가 부적법해지는 경우로서 다음과 같은 사항 등이 있다.
 - i) 특허심판사항이 아닌 심판청구
 - ii) 실존하지 아니한 자를 당사자로 하는 심판청구
 - iii) 당사자능력이 없는 자의 심판청구
 - iv) 당사자적격이 없는 자의 심판청구, 즉 공유자 중의 일부만을 심판의 당사자로 하거나 이해관계없는 자가 한 심판청구
 - v) 심판청구기간이 지난 후의 심판청구
 - vi) 제척·기피 심판의 불복심판청구
 - vii) 일사부재리의 원칙에 위반된 심판청구
 - viii) 심판청구 시에는 적법한 심판청구였으나 심판청구 후 대상출원이 취하·포기된 경우⁹⁰⁾
 - ix) 심결확정 전의 재심청구
 - x) 중복심판청구금지의 원칙에 위반된 경우
 - xi) 권리범위확인심판에서 확인의 이익이 없는 경우⁹¹⁾

90) 거절결정불복심판 중 출원의 취하와 심판청구의 취하는 다음과 같이 차이가 있다.

구분	출원의 취하	심판청구의 취하
출원	출원이 소급하여 소멸	기간이 지나면 특허거절결정의 확정
심판청구	대상물 소멸로 심결각하	심판청구가 소급하여 소멸

91) 확인의 이익이 없는 경우로는 i) 확인대상발명이 청구취지와 청구원인으로서 특정되지 않은 경우, ii) 실시하고 있는 발명(실시한 적이 있는 발명)을 대상으로 한 심판에서 확인대상발명이 실시하고 있는 발명과 사실적 관점에서 일치하지 않아서 동일성이 없는 경우, iii) 특허권 대 특허권(실용신안권) 간의 저작권계를 확인하는 적극적 권리범위확인심판의 경우, iv) 권리가 소멸한 경우 등이 있다.

xii) 그 밖의 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우

2) 심판청구의 적법요건은 직권조사사항이므로, 그 판단의 기초자료인 사실과 증거를 직권으로 탐지할 의무까지는 없다고 하더라도 이미 제출된 자료들에 의하여 그 요건에 의심이 갈 만한 사정이 보인다면, 상대방이 이를 구체적으로 지적하여 다투지 않더라도 이에 관하여 심라조사할 의무가 있다.⁹²⁾

III. 심판관 합의체의 심결각하

1) 심판관 합의체는 적법성 심리 결과 심판청구가 부적법하고 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다(法 142). 즉 피청구인에게 답변서 제출기회를 준 후에는 물론이거니와 답변서 제출기회를 주기 전에도 심판관 합의체는 심판청구를 심결각하할 수 있다. 다만 이해관계없는 자가 한 심판청구와 같이 심결 시를 기준으로만 판단할 수 있는 대상은 상대방에게 답변서 제출기회를 부여한 후 각하하여야 할 것이다.

2) 한편 심판청구서의 보정은 요지변경이 되지 않는 범위내에서 심결 시까지 할 수 있다. 따라서 부적법한 심판청구이더라도 그것이 보정가능한 것이라면 심판청구인에게 보정을 명한 후에 각하하여야 한다.⁹³⁾

IV. 불복방법

심판관 합의체의 심결각하에 대해서는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 소를 제기할 수 있다(法 186). 이 경우 결정계 심판은 지식재산처장을, 당사자계 심판은 원심판의 피청구인을 피고로 한다.

92) 대법원 2025. 8. 28. 선고 2024후10108 참조.

93) 원고가 법률전문가인 변호사나 변리사를 심판청구의 대리인으로 선임하지 아니한 점 등을 고려하여 보면, 원고가 그 불복심판청구서의 청구취지 란에 기재한 원사정을 파기한다. 1998년 실용신안등록 출원 제0024377호는 이를 등록사정한다라는 심결을 구함이라는 기재는 이 사건 보정각하결정의 취소를 구하는 것으로 볼 수 있을 것임에도 특허심판원이 석명권을 행사하여 원고에게 청구의 취지를 분명히 하도록 하여 이를 바로 잡게 하지 아니하고 위 심판청구서상의 청구취지 기재의 문면에만 치우친 나머지 원고의 이 사건 심판청구가 부적법하다고 하여 각하한 것은 위법하다(대법원 2004. 11. 12. 선고 2002후2822).

【표 7-3】 방식심리와 적법성 심리의 비교

제 도		방식심리(法 141)	적법성 심리(法 142)
의 의		심판장의 심판청구서에 대한 적식심리, 즉 심판청구서가 법령에 정한 방식에 적합한지를 심리하는 것을 말한다.	심판관 합의체가 심판청구 자체의 적법성을 심리하는 것을 말한다.
요 건	주 체	심판장	심판관 합의체
	대 상	1. 심판청구서 기재방식 위반(法 140①③④⑤, 法 140의2①) 2. 심판에 관한 절차가 다음에 해당하는 경우 ① 행위능력(法 3) 위반 ② 대리권범위(法 6) 위반 ③ 수수료 불납 ④ 이 법에서 정한 방식 위반	부적법한 심판청구로서 흠을 보정할 수 없는 경우, 구체적인 예를 들면 1. 특허심판사항이 아닌 심판청구 2. 실존하지 아니한 자를 당사자로 하는 심판청구 3. 당사자능력이 없는 자의 심판청구 4. 당사자자격이 없는 자의 심판청구(이해관계 없는 자나 공유자 중의 일부만을 당사자로 한 심판청구) 5. 심판청구기간이 지난 후의 심판청구 6. 제척·기피 심판의 불복심판청구 7. 일사부재리에 위반된 경우 8. 심판청구 시에는 적법한 심판청구였으나 심판청구 후 대상출원이 취하·포기된 경우 9. 심결확정 전에 재심청구 10. 중복심판청구금지의 원칙에 위반된 경우 11. 권리범위확인심판에서 확인의 이익이 없는 경우 12. 그 밖의 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우
절 차		1. 보정기회부여 2. 보정할 사항이 경미하고 명확한 경우에는 직권 보정가능 ① 심판장이 직권보정 사항 통지 ② 청구인이 받아들일 수 없으면 통지를 받은 날로부터 7일 이내 의견서를 심판장에게 제출하고, 의견서 제출한 경우 해당 직권보정사항은 처음부터 없었던 것으로 간주 ③ 직권보정사항이 명백히 잘못된 경우 처음부터 없었던 것으로 간주	1. 피청구인에게 답변서제출기회(재량) - 언제든지 심결각하 가능 2. 심판청구가 보정가능한 것이라면 보정기회를 주어야 함.
효 과		보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 요지변경인 경우(法 140②, 140의2② 위반)에는 심판청구서 또는 해당 절차와 관련된 청구나 신청 등을 결정각하	심판청구 심결각하
불 복		심판청구서의 각하결정등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 소 제기 / 지식재산처장이 피고	심결등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 소제기 / 결정계 심판은 지식재산처장, 당사자에게 심판은 원심판의 피청구인이 피고

제3절 본안심리

제154조 【심리 등】

- ① 심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만, 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
- ② 삭제 <2001.2.3.>
- ③ 구술심리는 공개하여야 한다. 다만, 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋날 우려가 있으면 그러하지 아니하다. <개정 2014.6.11.>
- ④ 심판장은 제1항에 따라 구술심리로 심판을 할 경우에는 그 기일 및 장소를 정하고, 그 취지를 적은 서면을 당사자 및 참가인에게 송달하여야 한다. 다만, 해당 사건의 이전 심리에 출석한 당사자 및 참가인에게 알렸을 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2014.6.11.>
- ⑤ 심판장은 제1항에 따라 구술심리로 심판을 할 경우에는 특허심판위원장이 지정한 직원에게 기일마다 심리의 요지와 그 밖에 필요한 사항을 적은 조서를 작성하게 하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
- ⑥ 제5항의 조서에는 심판의 심판장 및 조서를 작성한 직원이 기명날인하여야 한다. <개정 2014.6.11.>
- ⑦ 제5항의 조서에 관하여는 「민사소송법」 제153조·제154조 및 제156조부터 제160조까지의 규정을 준용한다. <개정 2014.6.11.>
- ⑧ 심판에 관하여는 「민사소송법」 제143조·제259조·제299조 및 제367조를 준용한다. <개정 2014.6.11.>
- ⑨ 심판장은 구술심리 중 심판정 내의 질서를 유지한다. <신설 2014.6.11.>

[제목개정 2014.6.11.]

제157조 【증거조사 및 증거보전】

- ① 심판에서는 당사자, 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거조사나 증거보전을 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 증거조사 및 증거보전에 관하여는 「민사소송법」 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다. 다만, 심판관은 다음 각 호의 행위는 하지 못한다.
 1. 과태료의 결정
 2. 구인(拘引)을 명하는 행위
 3. 보증금을 공탁하게 하는 행위
- ③ 증거보전신청은 심판청구 전에는 특허심판원장에게 하고, 심판계속 중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다.
- ④ 특허심판원장은 심판청구 전에 제1항에 따른 증거보전신청이 있으면 그 신청에 관여할 심판관을 지정한다.
- ⑤ 심판장은 제1항에 따라 직권으로 증거조사나 증거보전을 하였을 때에는 그 결과를 당사자, 참가인 또는 이해관계인에게 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제158조 【심판의 진행】

심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간에 절차를 밟지 아니하거나 제154조제4항에 따른 기일에 출석하지 아니하여도 심판을 진행할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제158조의2 【적시제출주의】

심판절차에서의 주장이나 증거의 제출에 관하여는 「민사소송법」 제146조, 제147조 및 제149조를 준용한다.

[본조신설 2021. 8. 17.]

제159조 【직권심리】

- ① 심판에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다.
- ② 심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

제160조 【심리·심결의 병합 또는 분리】

심판관은 당사자 양쪽 또는 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제1관 서 설

심판장의 방식심리를 거친 후에 심판관 합의체에 의한 심결각하의 경우를 제외하고는 심판의 본안심리에 들어가게 된다. 「본안심리」란 해당 심판청구가 이유 있는지를 심리하는 것으로서, 보다 구체적으로는 심판청구에 대하여 심결을 하기 위하여 기초가 될 심판자료, 즉 사실과 증거를 수집하는 것을 말한다. 심판의 심리절차는 민사소송의 심리절차를 대부분 준용하나(法 154⑧), 재판의 결과가 당사자 간에만 미치는 민사소송사건과 달리 특허심판의 결과는 당사자 뿐만 아니라 제3자의 이해에도 영향을 미치는 대세적 효력이 있기 때문에 직권주의적 요소가 강화되어 있다.

제2관 심리방식의 선택

I. 서면심리 또는 구술심리

제154조제1항은 “심판은 구술심리⁹⁴⁾ 또는 서면심리⁹⁵⁾로 한다. 다만 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다”라고 하여 서면 또는 구술에 의하여 심리하도록 하였다. 다만 당사자가 구술심리를 신청한 때에는 특별한 사정이 없는 한 구술심리를 열도록 하고 있다. 한편 그 밖에 심리 진행에 필요한 사항은 민사소송법 제143조·제259조·제299조 및 동법 제367조⁹⁶⁾를 준용한다(法 154⑧).

94) 「구술심리」란 당사자가 구술로써 진술한 것만이 심판에 참작되는 방식으로 심리가 활기를 띠고 의문점을 즉시 석명하여 쟁점을 발견, 정리하기가 쉬운 장점이 있다. 그러나 구술심리는 진술이 탈락되기 쉽고 심판정에 나가야 하는 번거로움이 있을 뿐만 아니라 복잡한 사실관계는 구술설명만으로는 이해하기 어렵다는 단점이 있다.

95) 「서면심리」란 심판을 서면에 의하여 진행하는 방식으로 그 내용이 명확하고 이해하기 쉬우며, 일단 제출된 서류는 그대로 보존되기 때문에 언제든지 다시 확인할 수 있으며, 심판정에 나가야 하는 번거로움을 피할 수 있는 장점이 있다. 그러나 서면심리는 서류가 많아지고 서면작성 등에 많은 시간이 소요되는 등의 단점이 있다.

II. 구술심리의 진행

1. 구술심리의 신청

구술심리를 하려는 심판의 당사자는 구술심리 신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 한편 구술심리에 있어서는 국어를 사용하여야 한다(施規 65).

2. 기일의 지정 또는 변경

심판장은 구술심리로 심판을 할 경우에는 그 기일 및 장소를 정하고 그 취지를 적은 서면을 당사자 및 참가인에게 송달하여야 한다. 다만 해당 사건의 이전 심리에 출석한 당사자 및 참가인에게 알렸을 때에는 그러하지 아니하다(法 154④). 한편 심판장은 당사자의 신청에 따라 또는 직권으로 기일을 변경할 수 있다(法 15③).

3. 구술심리의 방식

1) 구술심리는 이를 공개하여야 한다. 다만 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋날 우려가 있으면 그러하지 아니하다(法 154③). 이는 심판에 관하여 그 공평성을 담보하기 위함이다.

2) 한편 심판장은 구술심리 중 심판정 내의 질서를 유지한다(法 154⑨). 2015. 1. 1. 시행된 현행법(법률 제12753호, 2014. 6. 11. 개정)은 최근 구술심리에서 카메라 녹화 등 방청객에 의한 방해 사례가 빈번하게 발생함에 따라 심판정 내의 질서 유지를 위한 규정을 신설하였다.

4. 구술심리조서의 작성

심판장은 구술심리로 심판을 할 경우에는 특허심판원장이 지정한 직원에게 기일마다 심리의 요지와 그 밖에 필요한 사항을 적은 조서를 작성하게 하여야 한다(法 154⑤). 이 경우 조서에는 심판의 심판장 및 조서를 작성한 직원이 기명날인하여야 한다(法 154⑥). 또한 조서에 관하여는 민사소송법 제153조·제154조 및 동법 제156조 내지 제160조⁹⁷⁾까지의 규정을 준용된다(法 154⑦).

96) 제143조【통역】① 변론에 참여하는 사람이 우리말을 하지 못하거나, 듣거나 말하는 데 장애가 있으면 통역인에게 통역하게 하여야 한다. 다만 위와 같은 장애가 있는 사람에게는 문자로 질문하거나 진술하게 할 수 있다.

② 통역인에게는 이 법의 감정인에 관한 규정을 준용한다.

제259조【중복된 소제기의 금지】법원에 계속되어 있는 사건에 대하여 당사자는 다시 소를 제기하지 못한다.

제299조【소명의 방법】① 소명은 즉시 조사할 수 있는 증거에 의하여야 한다.

② 법원은 당사자 또는 법정대리인으로 하여금 보증금을 공탁하게 하거나, 그 주장이 진실하다는 것을 선서하게 하여 소명에 갈음할 수 있다.

③ 제2항의 선서에는 제320조, 제321조제1항·제3항·제4항 및 제322조의 규정을 준용한다.

제367조【당사자신문】법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 당사자 본인을 신문할 수 있다. 이 경우 당사자에게 선서를 하게 하여야 한다.

97) 제153조【형식적 기재사항】조서에는 법원사무관등이 다음 각 호의 사항을 적고, 재판장과 법원사무관등이 기명날인한다. 다만 재판장이 기명날인할 수 없는 사유가 있으면 합의부원이 그 사유를 적은 뒤에 기명

제3관 직권주의에 의한 심리

I. 서 설

「직권주의」란 당사자주의에 대응하는 개념으로서 심판절차를 진행할 때 심판관이 주도권을 갖는 것(직권진행주의) 뿐만 아니라 심판관이 직권으로 심판사건에 대한 자료를 조사·수집하여 심판의 기초로 삼는 것(직권탐지주의)을 의미한다. 특허법은 특허에 관한 절차 및 특허심판이 민사소송과는 달리 공익적 성격이 강하며 대세적 효력이 있어서 직권주의를 채택하고 있다.

II. 직권진행주의

1. 의 의

「직권진행주의」란 심판절차의 진행에 있어 당사자가 아닌 심판관이 직권에 의하여 심판절차의 주도권을 가지는 것을 말한다.

날인하며, 법관 모두가 기명날인할 수 없는 사유가 있으면 법원사무관등이 그 사유를 적는다.

1. 사건의 표시
2. 법관과 법원사무관등의 성명
3. 출석한 검사의 성명
4. 출석한 당사자·대리인·통역인과 출석하지 아니한 당사자의 성명
5. 변론의 날짜와 장소
6. 변론의 공개여부와 공개하지 아니하면 그 이유

제154조【실질적 기재사항】조서에는 변론의 요지를 적되, 특히 다음 각 호의 사항을 분명히 하여야 한다.

1. 화해, 청구의 포기·인낙, 소의 취하와 자백
2. 증인·감정인의 선서와 진술
3. 검증의 결과
4. 재판장이 적도록 명한 사항과 당사자의 청구에 따라 적는 것을 허락한 사항
5. 서면으로 작성되지 아니한 재판
6. 재판의 선고

제156조【서면 등의 인용·첨부】조서에는 서면, 사진, 그 밖에 법원이 적당하다고 인정한 것을 인용하고 소송기록에 붙여 이를 조서의 일부로 삼을 수 있다.

제157조【관계인의 조서낭독 등 청구권】조서는 관계인이 신청하면 그에게 읽어 주거나 보여주어야 한다.

제158조【조서의 증명력】변론방식에 관한 규정이 지켜졌다는 것은 조서로만 증명할 수 있다. 다만 조서가 없어진 때에는 그러하지 아니하다.

제159조【변론의 속기와 녹음】① 법원은 필요하다고 인정하는 경우에는 변론의 전부 또는 일부를 녹음하거나, 속기자로 하여금 받아 적도록 명할 수 있으며, 당사자가 녹음 또는 속기를 신청하면 특별한 사유가 없는 한 이를 명하여야 한다.

② 제1항의 녹음테이프와 속기록은 조서의 일부로 삼는다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 녹음테이프 또는 속기록으로 조서의 기재를 대신한 경우에, 소송이 완결되기 전까지 당사자가 신청하거나 그 밖에 대법원규칙이 정하는 때에는 녹음테이프나 속기록의 요지를 정리하여 조서를 작성하여야 한다.

④ 제3항에 따라 조서가 작성된 경우에는 재판이 확정되거나, 양 쪽 당사자의 동의가 있으면 법원은 녹음테이프와 속기록을 폐기할 수 있다. 이 경우 당사자가 녹음테이프와 속기록을 폐기한다는 통지를 받은 날부터 2주 이내에 이의를 제기하지 아니하면 폐기에 대하여 동의한 것으로 본다.

제160조【다른 조서에 준용하는 규정】법원·수명법관 또는 수탁판사의 신문(訊問) 또는 심문과 증거조사에는 제152조 내지 제159조의 규정을 준용한다.

2. 내 용

(1) 심판의 진행

심판장은 당사자 또는 참가인이 법정기간 또는 지정기간에 절차를 밟지 아니하거나 구술심리 기일에 출석하지 아니하여도 심판을 직권으로 진행할 수 있다(法 158). 민사소송의 경우 당사자 중 어느 한쪽이 출석하지 아니한 경우 다시 기일을 정하는 경우가 많으나 특허심판에서는 절차의 신속·원활한 진행을 위해 당사자주의(변론주의)적 요소를 배제하고 있다. 따라서 민사소송에서와 같은 변론기일 불출석으로 인한 자백간주(民訴法 150③),⁹⁸⁾ 소취하간주(民訴法 268 ②)의 불이익은 적용되지 아니한다.⁹⁹⁾

(2) 적시제출주의

1) 심판절차에서의 주장이나 증거의 제출에 관하여는 「민사소송법」 제146조(적시제출주의), 제147조(제출기간의 제한) 및 제149조(실기한 공격·방어방법의 각하)를 준용한다(法 158의2). 특허심판의 경우 공격 또는 방어방법의 제출시기에 관한 명문의 규정이 없어서 실무상으로 당사자가 심리종결에 이르기까지 언제라도 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 있는 수시제출주의를 취하고 있었는데, 2021. 11. 18. 시행되는 현행법(법률 제18409호, 2021. 8. 17. 일 부개정)에서는 신속하고 경제적으로 심판절차를 진행하기 위하여 「민사소송법」상 적시제출주의의 규정을 준용하고 있다.¹⁰⁰⁾

2) 구체적으로 살펴보면, 공격 또는 방어의 방법은 심판의 정도에 따라 적절한 시기에 제출하여야 한다(法 158의2 民訴法 146). 심판장은 당사자의 의견을 한쪽 또는 양쪽 당사자에 대하여 특정한 사항에 관하여 주장을 제출하거나 증거를 신청할 기간을 정할 수 있다. 당사자가 기간을 넘긴 때에는 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 없다. 다만 당사자가 정당한 사유로 그 기간 이내에 제출 또는 신청하지 못하였다는 것을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다(法 158의2 民訴法 147). 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 공격 또는 방어방법을 뒤늦게 제출함으로써 심판의 완결을 지연시키게 하는 것으로 인정할 때에는 심판장은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다. 당사자가 제출한 공격 또는 방어방법의 취지가 분명하지 아니한 경우에, 당사자가 필요한 설명을 하지 아니하거나 설명할 기일에 출석

98) 「재판상 자백」이란 소송의 변론이나 변론준비절차에서 소송당사자가 상대방이 주장하는 사실과 일치하는, 즉 자기에게 불리한 주요사실을 인정하는 진술을 말한다. 「자백간주」란 소송당사자가 상대방이 주장하는 사실을 자진하여 인정하지 않더라도, 변론에서 상대방이 주장하는 사실을 명백히 다투지 아니하거나, 공시송달에 의하지 아니한 기일통지를 받고도 변론기일에 출석하지 아니하는 경우에 그 사실을 자백으로 간주하는 것을 말한다.

99) 대법원 1965. 7. 27. 선고 65후3, 79후9.

100) 민사소송법은 기존에 변론 종결에 이르기까지 당사자가 어느 때라도 공격 또는 방어의 방법을 제출할 수 있는 수시제출주의를 취하였으나, 당사자가 공격 또는 방어의 방법을 고의로 뒤늦게 제출함으로써 소송을 지연시키는 문제가 발생하였다. 이에 2002년 법 개정을 통하여 신속하고 경제적으로 소송을 진행하기 위하여 공격 또는 방어의 방법을 적절한 시기에 제출하도록 하는 적시제출주의를 택하고 있고, 정해진 기간을 넘긴 경우에는 주장을 제출하거나 증거를 신청할 수 없도록 하고 있다(채수근 수석전문위원, 특허법 등 일부개정법률안 검토보고(양규희 의원 대표발의(의안번호 제2104853호, 제2104854호, 제2104855호 및 제2105856호), 이소영 의원 대표발의(의안번호 제2105441호, 제2105442호, 제2105443호 및 제2105444호)), 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2021.2, 25-26면).

하지 아니한 때에는 심판장은 직권으로 또는 상대방의 신청에 따라 결정으로 이를 각하할 수 있다(法 158의2 民訴法 149).

(3) 심리·심결의 분리 또는 병합

1) 심판관은 당사자 양쪽 또는 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을 병합하거나 분리할 수 있다(法 160). 심리 또는 심결의 병합은 동일한 쟁점이 있는 여러 개의 심판사건을 사건마다 별도로 심판하여야 하는 번잡을 피하고, 사건마다 별도로 심판함으로써 야기될 수 있는 심판의 모순 및 충돌을 피하기 위함이다. 다만 심리병합 후에 현재 심판 사건이 다른 심판사건과 관련성이 없다고 인정되어 동일한 절차로 심판할 필요가 없을 뿐 아니라, 오히려 심리의 복잡화 및 지연의 원인이 되고 있다고 인정될 때는 심리를 분리하여 각각 별개의 절차에 의하여 심리할 수 있다.¹⁰¹⁾ 이와 같은 심리 또는 심결의 병합, 분리는 심판관의 재량이다.¹⁰²⁾

2) 심리·심결의 병합 요건은 당사자의 양쪽 또는 어느 한쪽이 동일한 둘 이상의 심판이어야 한다. 한편 심판 실무¹⁰³⁾상 당사자 한쪽이 동일한 2이상의 심판에 대하여 청구인별로 청구취지가 다른 경우 병합하지 않고 심결하거나, 병합심결을 하더라도 청구취지에 따라 청구인별로 주문을 달리 기재한다.

(4) 기일의 지정·변경 등

그 밖에 심판장은 기일을 지정한 때에는 청구에 따라 또는 직권으로 그 기일을 변경할 수 있으며, 지정기간을 연장할 수도 있다(法 152③, 154④). 또한 심판관은 심판절차의 중지 또는 중단된 절차 등의 수계를 명할 수도 있다(法 22, 23).

Ⅲ. 직권탐지주의

1. 의 의

「직권탐지주의」란 심판관이 당사자의 주장에 구속되지 않고 심판에 있어서 필요한 사실을 적극적으로 탐지할 수 있는 것을 말한다. 이러한 직권탐지주의는 심판자료의 수집책임이 심판관에게 있다는 것일 뿐이므로 당사자는 자기의 이익을 위해 적극적으로 주장과 증거를 제출할 필요가 있다. 한편 이러한 직권탐지주의는 심판부의 관능이지 의무는 아닐 것이어서 직권으로 탐지하거나 증거조사를 하지 않았다고 하여 위법이 되는 것은 아니라 할 것이다.¹⁰⁴⁾ 그러나 심판의 귀추에 영향을 주는 중요한 증거라면 이를 조사하지 아니하면 위법하게 된다.¹⁰⁵⁾

101) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 178면.

102) 대법원 1989. 11. 28. 선고 89후469.

103) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 174면.

104) 심판에서는 신청에 따라 또는 직권으로써 증거조사를 할 수 있다고 되어 있으나 이는 심판의 필요에 따라서 당사자의 신청이 없는 경우라도 직권으로 증거조사를 할 수 있음을 규정한 것일 뿐이고, 모든 경우에 반드시 직권에 의하여 증거조사를 하여야 한다는 취지는 아니다(대법원 1993. 5. 11. 선고 92후2090; 1995. 11. 24. 선고 93후107).

2. 내 용

(1) 증거조사·증거보전

① 의의 및 취지

1) 「증거조사」란 다툼이 있는 사실에 대하여 심판관의 심증형성을 위하여 심판정의 절차에 따라 인적·물적 증거의 내용을 오관의 작용으로 지각하는 심판원의 소송행위를 말하며, 「증거보전」이란 심판계속 전 또는 심판계속 중에 특정의 증거를 미리 조사해 두었다가 본 심판에서 사실인정에 쓰기 위한 증거조사방법으로, 본 심판에서 정상적인 증거조사를 할 때까지 기다리고 있다가는 조사할 수 없게 되거나 곤란하게 될 염려가 있는 증거를 미리 조사하여 그 결과를 보전하여 두려는 별도의 부수절차이다. 심판은 구체적인 사실을 소전제로 하고 법규의 존부와 해석을 대전제로 하여 삼단논법에 따라 권리관계를 판단하는 것이므로 사실관계의 확정이 필수적이다. 심판원이 사실관계를 판단하는 사실인정에 대하여 신뢰성을 확보하기 위해서는 판단의 근거자료로서 증거가 요구되며, 그 조사절차 또한 문제가 된다.¹⁰⁶⁾

② 증거조사

1) 심판에서는 당사자·참가인 또는 이해관계인의 신청에 따라 또는 직권으로 증거조사를 할 수 있다(法 157①). 증거조사 신청에 대하여 증거조사를 하여야 한다고 판단될 때에는 증거조사를 한다는 취지의 결정을 하며, 이에 대해서는 부수적 심판이므로 불복할 수 없다(民訴 380). 한편 심판장은 직권으로 증거조사를 하였을 때에는 그 결과를 당사자·참가인 또는 이해관계인에게 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 157⑤). 이는 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위하여 준수하여야 하는 공익상의 요구에 기대한 강행규정이다.¹⁰⁷⁾

2) 특허심판의 증거조사 및 증거보전에 대해서는 민사소송법 중 증거조사 및 증거보전에 관한 규정을 준용한다. 다만 심판관은 과태료의 결정을 하거나 구인을 명하거나 보증금을 공탁하게 하지 못한다(法 157②). 구체적인 증거조사 방법으로는 증인신문, 감정, 서증, 검증, 당사자신문 등이 있으나, 특허심판은 직권주의에 의한 것이므로 민사소송법 중 당사자주의(변론주의)와 관련된 규정은 준용하지 아니한다. 예를 들어 불요증사실 중 재판상 자백(民訴法 288),¹⁰⁸⁾¹⁰⁹⁾

105) 대법원 1970. 7. 28. 선고 70후26.

106) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 219면.

107) 대법원 1989. 5. 23. 선고 86후90.

108) 특허심판에 있어서는 당사자의 일방이 상대방의 주장을 자인하였다고 하여 그것만으로 심결에 영향을 줄 수 없다(대법원 1965. 7. 27. 선고 65후3).

109) 확인대상고안이 해당 등록실용신안과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있는지 여부는 법적 판단에 관한 사항에 해당한다 할 것이므로, 특허심판원에서의 심판단계에서 이미 피심판청구인이 확인대상고안을 실시하고 있다는 사실을 시인한 적이 있다 하여, 확인대상고안의 특정 여부에 관해서 피심판청구인의 자백이 성립하였다고 볼 수는 없다. 또한 특허심판원에서의 심판절차와 특허법원에서의 심결취소소송은 심급으로 연계된 것도 아니므로, 특허심판원에서의 심판단계에서 피심판청구인이 확인

당사자가 문서를 제출하지 아니한 때의 효력(民訴法 349), 당사자가 사용을 방해한 때의 효과(民訴法 350), 출석·선서·진술의 의무(民訴法 369) 등은 특허법의 심판이 변론주의가 아닌 직권탐지주의를 채택하고 있으므로 준용하지 아니한다고 보아야 한다.

③ 증거보전

1) 심판에서는 당사자·참가인 또는 이해관계인의 신청에 따라 또는 직권으로 증거보전을 할 수 있다(法 157①). 다만 심판청구 전에는 직권으로 증거보전을 할 수는 없으며, 신청에 의한 증거보전은 심판청구 전에는 특허심판원장에게 하고, 심판계속 중에는 그 사건의 심판장에게 하여야 한다(法 157③). 특허심판원장은 심판청구 전에 증거보전 신청이 있으면 그 신청에 관여할 심판관을 지정한다(法 157④). 증거보전 신청에 대하여 증거보전을 하여야 한다고 판단될 때에는 증거보전을 한다는 취지의 결정을 하며, 이에 대해서는 부수적 심판이므로 불복할 수 없다. 한편 심판장은 직권으로 증거조사를 하였을 때에는 그 결과를 당사자·참가인 또는 이해관계인에게 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 157⑤).

2) 증거보전에서의 증거조사 역시 관련 증거조사규정에 따라 행해진다.¹¹⁰⁾

(2) 직권심리

1) 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유 또는 취하한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 예를 들어 특허무효심판에서 있어서 심판청구인이 신규성(法 29①)에 위반됨을 이유로 심판청구를 한 경우 심리과정에서 진보성(法 29②)에 위반됨을 이유로 무효심결을 할 수 있다. 다만 이 경우 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 159①). 이는 당사자 및 참가인이 자기도 모르는 사이에 불리한 자료가 심판관에게 모아지고, 그에 대한 진술의 기회가 부여되지 아니한 상태에서 심판관이 심증을 형성하게 되는 불리함을 구제하기 위함이다. 이 규정은 심판의 적정을 위하여 요구되는 강행규정이라고 해석하는 것이 타당하며 이에 위반한 심결은 위법하게 된다.¹¹¹⁾ 다만 형식적으로는 이러한 의견진술의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼

대상고안을 실시하고 있다는 사실을 시인한 적이 있다 하더라도, 그러한 진술(자백)의 효력(구속력)이 심결취소소송에 그대로 미친다고 볼 수도 없다(특허법원 2012. 6. 14. 선고 2012허412). 한편 특허심판원이 확인대상발명을 실시하지 않고 있다는 이유로 권리범위확인 심판청구를 각하한 심결의 취소를 구하는 특허법원의 심결취소소송절차에서는 심결취소소송절차에서의 소송물이 심결의 실제적·절차적 위법성 여부인 이상(대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1102 판결 등 참조) 피심판청구인이 그러한 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부는 심결의 위법성 여부를 판단하기 위한 본안에 관한 사항에 해당할 뿐, 그 심결취소의 소 자체가 적법하기 위한 소송요건이라 할 수는 없으므로, 일반원칙에 따라 여전히 자백이나 자백간주의 대상이 된다고 보아야 한다(특허법원 2012. 7. 26. 선고 2011허11255).

110) 증거조사 및 증거보전에 대하여 정리하면 다음과 같다.

구 분	증거조사	증거보전
심판청구 전	x	■ 심판원장에게 신청
심판청구 후	■ 심판장에게 신청 ■ 직권 → 의견진술기회 부여	

111) 대법원 1970. 11. 24. 선고 70후50; 1971. 3. 23. 선고 71후1; 1984. 2. 28. 선고 81후10.

수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 심판절차에서의 직권심리에 관한 절차위반의 위법이 없다고 보아야 한다.¹¹²⁾

2) 한편 심판에서는 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 대해서는 심리할 수 없다(法 159②). 청구인이 신청하지 아니한 청구의 취지에 관하여 심리를 하는 것은 청구인의 의사에 반하여 청구의 취지를 변경하는 것으로서, 민사소송법상의 처분권주의에 반하는 것이기 때문이다. 예를 들어 소극적 권리범위확인심판청구가 이유가 없으면 그 청구를 배척함에 그쳐야 하고 나아가 적극적으로 그것이 권리범위에 속한다는 내용의 심결을 한 것은 위법이다.¹¹³⁾ 또한 다항의 청구항 중 하나의 청구항에 대해서 특허무효심판이 청구되었으면 다른 청구항에 대해서 특허무효의 이유가 발견되었다고 하더라도 심판관이 이를 심리할 수는 없다. 특허무효심판의 경우 청구항을 달리하면 청구취지를 달리하기 때문이다. 이는 소송법이 강조하는 「소 없으면 재판없다」는 원칙과 일맥상통한다.¹¹⁴⁾ 한편 정정심판을 청구한 것은 일체불가분의 1개의 정정사항으로 하여 정정심판을 청구한 것으로 본다. 그러므로 명세서 일부에 대하여 정정을 인정 또는 불인정하는 것은 결국 1개의 기술적 사상인 발명을 분리하여 판단하는 것이 되며, 청구인이 신청하지 아니한 취지에 대하여 심리하는 것이 되므로 일부인용 또는 일부기각심결은 인정되지 아니한다고 할 것이다.¹¹⁵⁾

112) 대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387.

113) 대법원 1970. 12. 22. 선고 70후20.

114) 천효남, 「특허법」, 제9판, 법경사, 2003, 680면.

115) 특허법원 2000. 7. 21. 선고 99허2174 등.

제5장

심판의 종료

제1절 서설

「심판의 종료」란 해당 특허심판절차에 있어서 심판의 계속을 소멸시키는 것을 말한다. 심판의 청구에 따라 개시된 심판절차는 일반적으로 심결 및 결정에 의하여 종료되지만, 심판청구인의 심판청구 취하에 의하여 종료되기도 한다. 다만 특허심판절차에서는 심판의 결과가 당사자뿐만 아니라 제3자에게 미쳐서 직권주의가 적용되기 때문에 민사소송의 경우와는 달리 청구의 포기·인낙¹¹⁶⁾ 또는 심판상 화해는 인정되지 아니한다. 한편 심판이 종료되면 심판비용의 부담문제가 발생한다.

제2절 심판청구의 취하에 의한 종료

제161조 【심판청구의 취하】

- ① 심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다. 다만, 답변서가 제출된 후에는 상대방의 동의를 받아야 한다.
- ② 둘 이상의 청구항에 관하여 제133조제1항의 무효심판 또는 제135조의 권리범위 확인심판을 청구하였을 때에는 청구항마다 취하할 수 있다.
- ③ 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

116) 「청구의 포기」란 원고가 스스로 자기의 소송상의 청구가 이유 없음을 인정하는 법원에 대한 일방적 의사표시이고, 「청구의 인낙」이란 피고가 자기에 대한 원고의 소송상의 청구가 이유 있음을 인정하는 법원에 대한 일방적인 의사표시를 말한다.

I. 의 의

「심판청구의 취하」란 심판청구인이 심판청구의 전부 또는 일부를 철회하는 특허심판원에 대한 단독적 의사표시이다. 심판청구가 취하되면 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다.

II. 요 건

1. 주체적 요건

심판청구인은 피청구인의 답변서 제출이 없는 경우에는 피청구인의 동의를 받지 않더라도 취하할 수 있으나 피청구인으로부터 답변서가 제출된 후에는 그의 동의를 받아야 한다(法 161 ①). 이는 피청구인이 답변서를 제출한 이상 피청구인에게도 일사부재리의 효과를 발생시키는 등 심판을 유지하는데 이해관계가 생겨 본안심결(청구기각심결)을 받을 수 있는 권리가 생겼다고 할 수 있기 때문이다. 한편 임의대리인은 특별히 권한을 위임받아야 심판청구의 취하를 할 수 있다(法 6).

2. 객체적 요건

심판청구 전부를 취하의 대상으로 할 수 있음은 물론이고 특허무효심판(法 133) 또는 권리범위확인심판(法 135)의 경우에는 일부 취하도 가능하다. 즉 청구범위에 기재된 둘 이상의 청구항에 관한 특허무효심판 또는 권리범위확인심판청구는 청구항마다 취하할 수 있다(法 161 ②). 한편 이 외의 심판에 대해서는 규정이 없으므로 심판청구 일부를 취하할 수 없다. 다만 둘 이상의 정정사항에 대하여 하나의 정정심판이 청구되었다면 그중 일부사항에 대하여 삭제를 하는 것은 인정한다.¹¹⁷⁾

3. 시기적 요건

심판청구는 심결이 확정될 때까지 취하할 수 있다(法 161 ①). 따라서 심결 후 특허법원 또는 대법원에 해당 심판에 대한 소송이 계속 중인 경우에도 심결이 확정되기 전까지는 심판청구를 취하할 수 있다.

117) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 401면.

III. 절 차

1) 심판청구를 취하하려는 자는 심판청구 취하서에 상대방의 동의가 필요한 경우 동의를 증명하는 서류를 첨부하여 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다. 심판청구의 취하가 있을 때에는 이를 당사자, 참가인 또는 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 통지하여야 한다(施規 69③④). 이는 상대방 등에 취하된 사실을 알림으로써 불필요한 심판절차를 진행하지 않도록 함과 동시에 심판청구의 취하에 대한 동의 여부에 관하여 판단할 기회를 주기 위함이다.

2) 심결취소소송 계속 중에 당사자 사이에 합의가 성립되어 심결 내용과는 달리 분쟁을 종결하고자 할 때는 먼저 심판청구를 취하한 후 소송사건을 취하하여야 한다. 만약 소를 먼저 취하하면 심결이 확정되는 효과가 발생하기 때문이다.¹¹⁸⁾ 한편 심판청구를 제기한 이후 당사자 사이에 심판을 취하하기로 한다는 내용의 합의가 이루어졌다고 하더라도 그 취하서를 심판부에 제출하지 아니한 이상 심판청구취하로 인하여 사건이 종결되지는 아니하나, 당사자 사이에 심판을 취하하기로 하는 합의를 함으로써 특별한 사정이 없는 한 심판을 계속 유지할 법률상의 이익은 소멸되었다 할 것이어서 해당 청구는 각하되어야 한다.¹¹⁹⁾

IV. 효 과

심판청구의 취하가 있으면 그 심판청구 또는 그 청구항에 대한 심판청구는 처음부터 없었던 것으로 본다(法 161③). 심판청구인에 대하여 적법하게 이루어진 심판청구 취하의 효력은 취하서가 제출되어 접수한 접수 시에 발생하는 것이므로 취하는 취소할 수 없다.¹²⁰⁾ 심판청구가 취하되었으면 심판계속은 종료되지만, 처음부터 심판청구가 없었던 것으로 보기 때문에 분쟁이 종국적으로 해결되었다고 볼 수 없고 심판청구의 취하 후 동일내용에 대하여 다시 심판을 청구할 수 있다.¹²¹⁾ 다만 당사자 참가의 경우에는 피참가인이 심판청구를 취하하여도 그 심판은 종료되지 않고 당사자 참가인이 청구인이 되어 홀로 남아 심판절차를 진행한다(法 155②).

118) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 394면.

119) 대법원 1997. 9. 5. 선고 96후1743.

120) 대법원 1970. 6. 30. 선고 70후7.

121) 민사소송에서는 본안에 대한 종국판결이 있을 후 소를 취하한 자는 동일한 소를 제기하지 못하지만(再訴禁止의 원칙, 民訴法 267②), 특허법에는 그와 같은 규정이 없다.

【표 7-4】 참가 및 심판청구 취하의 비교

제 도	참가의 취하		심판청구의 취하
요 건	주체적	1. 참가인이 취하 2. 원칙적으로 상대방 동의를 필요로 하지 않으나 i) 당사자 참가 시 ii) 심판청구인의 심판청구 취하에 의하여 참가인만이 심판절차를 밟으며 iii) 피청구인의 답변서 제출이 있을 때는 피청구인의 동의 必要	1. 심판청구인이 취하 2. 원칙적으로 피청구인의 동의를 필요로 하지 않으나 피청구인의 답변서 제출이 있는 후에는 동의 必要
	객체적	참가	1. 심판청구 2. 특허무효심판·권리범위확인심판 경우 청구항마다 가능
	시기적	심결확정 전	심결확정 전
절 차	취하서의 제출(심판청구를 취하하기로 합의했으나, 취하서를 제출하지 아니한 경우 취하의 효력이 발생하지 아니하지만, 심결 시를 기준으로 이해관계가 없어져 심결각하)		
효 과	참가신청이 없었던 것으로 간주		심판청구가 없었던 것으로 간주

제3절 심결에 의한 종료

제1관 심 결

제162조 【심결】

- ① 심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다.
- ② 제1항의 심결은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 심결을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다.
 1. 심판의 번호
 2. 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 4. 심판사건의 표시
 5. 심결의 주문(제138조에 따른 심판의 경우에는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다)
 6. 심결의 이유(청구의 취지 및 그 이유의 요지를 포함한다)
 7. 심결연월일
- ③ 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다.
- ④ 심판장은 필요하다고 인정하면 제3항에 따라 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다.
- ⑤ 심결은 제3항에 따른 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 한다.
- ⑥ 심판장은 심결 또는 결정이 있으면 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「심결」이란 합의체로서 심판관이 내리는 심판청구에 대한 최종적 판단으로 심리를 통해 인식하게 된 사실에 대한 법의 적용이라 할 수 있다. 심판은 청구의 취하 등 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결된다(法 162①).

2. 종 류

(1) 각하심결

「각하심결」이란 심판청구요건의 불비를 이유로 그 심판청구를 부적법 각하하는 심결을 말한다. 심판청구가 부적법하고 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 그 청구를 각하할 수 있다(法 142).

(2) 본안심결

「본안심결」이란 청구의 당부에 대한 판단, 즉 심판청구취지에 대한 심결을 말한다. 본안심결은 다시 청구인의 주장이 인용되는 「인용심결」과 청구인의 주장이 배척되는 「기각심결」로 나뉜다.

3. 구별개념

(1) 결 정

넓은 의미의 심판은 그 형식에 따라 심결 외에도 결정·명령의 3가지로 나눌 수 있다. 「결정」이란 심판장 또는 심판관 합의체가 심판청구의 본안이 아닌 주로 절차적 신청에 대하여 그 당부를 심리판단하여 내리는 결론을 말한다. 특허법상 결정의 종류로는 i) 방식에 위반한 심판청구서의 결정각하(法 141), ii) 심판관의 제척 또는 기피신청에 관한 결정(法 152), iii) 참가의 신청에 관한 결정(法 156), iv) 그 밖에 증거조사 또는 증거보전신청에 관한 결정 등이 있다.

(2) 명 령

「명령」이란 심판장 또는 심판관이 그 자격으로 심판의 진행을 위하여 행하는 간단한 절차에 대한 조치로서, 그 고지의 방법도 반드시 문서로 할 필요가 없고, 이유를 붙일 것을 필요로 하지 아니한다. 예컨대 방식위반에 대한 심판장의 보정명령, 심판장 또는 심판관의 자료제출명령 등 법률에 명문 규정이 없더라도 심판진행에 있어서 필요한 지시를 할 수 있다.

II. 심결의 절차

1. 심결의 방식

심결은 심판청구에 대한 심판관의 종국적 판단이므로 내용이 명확하여야 한다. 따라서 심결

은 다음의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 심결을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다(法 162②). 한편 심판에 의하여 심판비용부담자를 결정하여야 하면 심판비용부담자도 主文에 함께 적는다.¹²²⁾

- i) 심판번호
- ii) 당사자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- iii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭 및 사무소의 소재지와 지정변리사의 성명)
- iv) 심판사건의 표시
- v) 심결의 결론부분인 심결의 주문(통상실시권허락심판의 경우에는 통상실시권의 범위·기간 및 대가를 포함한다)
- vi) 심판관이 이러한 결론에 이르게 된 사실상 및 법률상의 근거를 나타내는 심결의 이유¹²³⁾
- vii) 심결연월일

2. 심리종결통지 및 심리의 재개

1) 심판장은 사건이 심결을 할 정도로 성숙하였을 때에는 심리의 종결을 당사자 및 참가인에게 통지하여야 한다. 그러나 심판장은 필요하다고 인정하면 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 따라 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다(法 162③④). 이는 심리종

122) 심결주문의 기재예시는 다음과 같다.

1. 거절결정불복심판
 - 각하심결 : 이 건 심판청구를 각하한다.
 - 인용심결 : 원결정을 취소하고 자판할 경우에는 "원 결정을 취소한다. 본원발명은 특허할 것으로 한다."라고 기재하며, 원결정을 취소하고 환송하는 경우에는 "원 결정을 취소하고 지식재산 처 심사국에 환송한다."라고 기재된다.
 - 기각심결: 이 건 심판청구를 기각한다.
2. 특허무효심판
 - 각하심결 : 이 건 심판청구를 각하한다. 심판비용은 청구인의 부담으로 한다.
 - 기각심결 : 이 건 심판청구를 기각한다. 심판비용은 청구인의 부담으로 한다.
 - 인용심결 : 특허 제○○호 발명의 특허를 무효로 한다. 심판비용은 피청구인의 부담으로 한다.
 - 일부인용심결 : 특허 제○○호 발명의 청구범위 제1항에 기재된 발명에 대한 특허를 무효로 한다. 그 나머지 부분에 대한 심판청구를 기각한다. 심판비용은 이를 2분하여 그 1을 청구인의 부담으로 하고 나머지를 피청구인의 부담으로 한다.
3. 정정무효심판
 - 기각심결 : 이 건 심판청구를 기각한다. 심판비용은 청구인의 부담으로 한다.
 - 인용심결 : 특허 제○○호 발명의 명세서(또는 도면)에 대한 (연도) 당 (호)의 확정심결에 의한 정정을 무효로 한다.

123) 심결의 이유는 심결의 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 청구의 취지 외에 그 이유의 요지를 기재하면 충분하고, 더 나아가 민사소송에서와 같이 반드시 당사자의 주장, 그 밖의 공격·방어방법에 관한 판단이 표시되어야 하는 것은 아니다(특허법원 2009. 4. 30. 선고 2008허6482).

결통지 후에 명백한 증거가 확보되었거나 당사자 등이 심판에서 공격·방어를 충분히 다 하지 못한 경우에 새로운 주장·증명의 기회를 주기 위한 취지이다. 심리재개를 신청하려는 당사자 또는 참가인은 심리재개신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다(施規 66의2).

2) 한편 심리의 종결을 통지한 후에 당사자 또는 참가인이 제출한 서류는 이를 심결에 참작하지 아니하며 그 서류는 신청이 있는 경우에만 당사자 또는 참가인에게 반환한다. 다만 그 반환 전에 심리를 재개한 경우에는 그러하지 아니하다. 서류의 반환신청을 하려는 당사자 또는 참가인은 서류반환신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다(施規 66).

3. 심결의 시기

1) 심결은 심리종결통지를 한 날로부터 20일 이내에 함을 원칙으로 한다(法 162⑤). 심리종결통지란 당사자 등이 새로이 공격방어를 위한 자료 및 서류를 제출할 수 없을 뿐만 아니라 이해관계인도 새로이 심판에 참가할 수 없다는 것을 나타내기 위한 것으로 심판장에 의한 심판절차종료의 선언을 의미한다. 심결 전에 당사자 또는 참가인에게 미리 사건이 심결하기에 성숙하였음을 알림으로써 심리의 진행 상황을 주지시켜 심리절차의 공정과 축진을 기하고자 함에 그 취지가 있다.

2) 다만 이 규정은 심리종결 후의 조속한 심결을 촉구하는 훈시적 규정에 불과하므로 심리종결통지를 하지 아니하여도 위법이 아니다.¹²⁴⁾ 또한 심리종결통지 후 20일의 기간을 지나도 위법한 심결이 되는 것은 아니며,¹²⁵⁾ 심리종결통지를 발한 당일 심결을 하였다거나 심리종결통지서와 심결문 등본을 동시에 송달하였다 하여도 그 심결을 위법이라 할 수 없다.¹²⁶⁾

4. 심결등본의 송달

심판장은 심결이 있으면 그 등본을 당사자, 참가인 및 심판에 참가신청을 하였으나 그 신청이 거부된 자에게 특별송달우편으로 송달하여야 한다(法 162⑥). 다만 전자문서이용신고를 한 자에 대해서는 정보통신망을 이용하여 송달할 수 있다.

III. 심결의 효력

심결의 효력에는 i) 심판사건에 대하여 법적 안정성과 심판의 신뢰성을 유지하기 위하여 일단 심결등본이 당사자 등에게 송달되어 심결이 성립하면, 심결한 심판기관 자신도 그 내용을 철회하거나 변경하는 것이 허용되지 아니한 「기속력」,¹²⁷⁾ ii) 그 심결이 확정¹²⁸⁾되어 재심사

124) 대법원 1984. 1. 31. 선고 83후71.

125) 대법원 1979. 10. 10. 선고 79후35; 1976. 9. 14. 선고 76후6.

126) 대법원 1964. 6. 23. 선고 63후25.

127) 특허심판원이 행하는 심결은 준사법적 행위로서 그 절차, 불복방법, 효력 등이 법률에 엄격하게 규정되어 있는 행위이므로 심결이 일단 행하여진 경우에는 설사 그 심결에 어떤 흠이 있다고 하더라도 오기 그 밖

유가 없는 한 그 심결을 취소·변경할 수 없는 「형식적 확정력」, iii) 형식적 확정력이 생긴 이후에 그 「심결의 내용」에 대해서도 더 이상 다룰 수 없게 되는 「실질적 확정력」이 있다. 이러한 실질적 확정력을 특허법에서는 一事不再理라 표현하고 있다. 이에 대해서는 제2판에서 자세히 설명한다. 한편 특허심판에서는 심결의 효력이 당사자·참가인뿐만 아니라 심판과 관련이 없었던 일반 공중에게도 미치는 대세적 효력이 인정된다는 점에서 민사소송의 판결과는 구별되는 특색이 있다.

제2관 일사부재리의 원칙

제163조 【일사부재리】

이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.
[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「일사부재리」란 특허심판의 본안심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없는 것을 말한다.¹²⁹⁾

2. 취 지

민사소송에서는 당사자 간의 사권의 분쟁해결을 목적으로 하고, 그 효과도 원칙적으로 당사자에게만 미치는 것이기 때문에 당사자 주장의 증명을 확인·판단하여 법률적 정의를 실현하면

의 이에 유사한 잘못임이 명백한 것을 바로잡는 경우를 제외하고는 특허심판원 스스로도 이를 취소, 철회 또는 변경하는 것은 허용되지 아니한다(특허법원 2005. 4. 22. 선고 2004허4693).

128) 심결 및 결정은 그것에 대하여 불복이 있는 자에 의하여 법령에서 정하는 기간 내 즉 심결 또는 결정의 등본을 받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다)에 특허법원에 소를 제기하지 않거나 그 후 상고가 제기되지 않고 또한 제기되더라도 종국적으로 그 심결, 결정이 지지되어, 통상의 불복신청방법으로 취소할 수 없는 상태로 된 때 확정된다. 한편 특허(등록)할 것으로 한다는 심결이나 정정심판에서 정정이 인정된 경우의 심결은 심결등본의 송달이 있는 때 확정된다.

129) 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제163조는 “이 법에 의한 심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다”라고 규정하고 있었는데, 현행법은 등록되지 않은 심결에도 일사부재리가 적용되는 것으로 변경하였고, 1998. 3. 1. 특허법원 설립 이후의 특허법원 판결이나 대법원 판결 및 실체 심리가 없는 각하심결에도 일사부재리가 적용되는지에 관한 해석상의 다툼에 대하여 ‘판결이 확정된 때’ 부분을 삭제하고, 단서 규정을 신설함으로써 다툼의 여지가 없게 하였다(김신, “확정심결의 일사부재리”, 「특허소송연구」 제7집, 특허법원, 2017, 154면).

죽한 것이고 그 소송물의 엄격한 동일성의 여부를 확정하기 곤란하여서 일사부재리의 원칙이 적용될 필요성이 없다. 그러나 특허심판은 외양이 私人 대 私人 간의 권리 다툼처럼 보이나 그 효력은 대세적이기 때문에 심판결과의 신뢰성은 상당히 중요하다고 할 수 있다.¹³⁰⁾ 따라서 동일한 심판청구가 반복됨으로써 야기될 i) 절차의 번거로움과 심판상의 불경제를 방지하고, ii) 반복하여 심리함으로써 발생할 수 있는 상호 모순·저촉되는 심결의 발생을 방지하여 법적 안정성을 도모하기 위해 일사부재리의 원칙을 적용하고 있다.

II. 적용요건

1. 특허심판의 본안심결이 확정되었을 것

(1) 본안심결

1) 일사부재리의 원칙은 「본안심결」이 확정된 경우에만 적용된다(法 163). 따라서 참가의 하여 결정 등은 심결이 아니므로 일사부재리에 해당하지 아니한다.¹³¹⁾

2) 한편 확정된 심결이 본안심결이 아닌 각하심결인 경우에는 일사부재리가 적용되지 아니한다. 예를 들어 후행심판이 선행심판의 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되어 동일증거로 인정됨에 따라 일사부재리 위반으로 각하심결이 확정된 경우, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행심판의 확정 심결을 반복할 수 있을지를 심리, 판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 하나 그 후행심판에 대해서는 일사부재리의 효력이 없다. i) 종래 각하심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 제163조단서 규정을 신설함으로써 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다는 점, ii) 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다는 점, iii) 심판청구의 남용을 막고, 모순저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, iv) 현행 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 제163조단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다는 점 등을 고려해야 하기 때문이다.¹³²⁾

130) 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 881면.

131) 대법원 1986. 9. 9. 선고 85후12.

132) 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077.

(2) 확 정

심결에 대하여 통상의 불복방법으로서 더 이상 다룰 수 없는 상태, 즉 형식적으로 「확정」되어야 한다. 심결은 심결등본을 송달받은 날로부터 일정한 기간에 소를 제기하지 않거나 제기하더라도 종국적으로 그 심결이 지지되어 통상의 불복신청방법으로는 취소할 수 없는 상태로 된 때에 확정된다.

2. 누구든지

일사부재리의 원칙의 적용요건에 해당되는 때에는 「누구든지 ... 그 심판을 청구할 수 없다.」라고 규정하고 있다. 일사부재리의 효력은 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에 대해서도 인정된다. 즉 일사부재리의 원칙을 규정한 제163조는 특허심결의 대세적 효력이 인정되는 실정법상의 근거규정이 된다.

3. 동일사실 및 동일증거에 의한 심판청구일 것

(1) 동일사실

「동일사실」이란 청구원인사실의 동일성, 즉 청구취지를 이유있게 하는 구체적인 사실을 말한다. 예를 들어 특허무효심판에서는 무효사유(신규성, 진보성, 선출원주의 등)가 동일한 것을 말한다. 따라서 출원 전 간행물에 게재된 것을 이유(法 29①)로 하여 특허무효심판을 청구하였으나 기각심결이 확정되었으면 같은 이유로는 특허무효심판을 청구할 수 없으나 기재불비, 미완성 발명 등의 이유로 특허무효심판을 청구할 수는 있다.¹³³⁾ 또한 기존에 신규성 위반이라고 무효심판을 청구하여 심결이 확정되었으나 신규성 위반 이외에 진보성 위반이 추가되어 무효심판을 청구하였을 때 동일사실이라고 할 수 없다. 이 경우 진보성 위반에 대해서는 본안심결을 하게 되나, 신규성 위반에 대해서는 동일증거에도 해당한다면 실권효를 인정하여 본안심결을 하지 않게 된다.¹³⁴⁾ 한편 제29조제1항의 신규성 상실사유인 공지, 공연실시, 간행물 게재, 전기통신회선을 통하여 공중의 이용가능은 그 4가지 요건사실이 합하여 동일사실을 구성한다.

133) 특허법원 2007. 12. 5. 선고 2007허1787.

134) 구 특허법 제163조는 “이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는, 확정된 심결이 각하심결이 아닌 이상, 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다”라고 규정하고 있다. 여기서 ‘동일사실’이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, ‘동일증거’라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결, 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조). 그리고 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 참조). 앞서 본 바와 같이, 종전 확정심결에서 청구원인이 된 무효사유는 진보성 부정이었고, 이 사건 심판청구에서는 진보성 부정 외에 신규성 부정의 무효사유가 추가되었다. 그런데 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립된 특허무효사유이다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2000후1177 판결 등 참조). 따라서 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구는 동일사실에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다(특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005).

(2) 동일증거

「동일증거」란 주장 사실을 증명하기 위해 제출된 증거가 동일한 것으로서, 증거의 표시가 다르더라도 중요부가 동일하다면 동일증거로 본다. 따라서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 동일증거에 포함된다.¹³⁵⁾ 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 등으로 그 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 일사부재리 원칙의 취지에 비취 허용되지 않기 때문이다. 그러나 i) 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 않았던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 ii) 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 반복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행심판청구의 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.¹³⁶⁾¹³⁷⁾

(3) 동일사실 「및」 동일증거

동일사실에 의한 심판청구라도 다른 증거에 의한 경우나 동일한 증거에 의한 것이라도 다른 사실에 관하여 새로운 심판청구를 하는 것은 허용된다.

4. 동일한 심판청구일 것

「동일심판」이란 청구취지가 동일한 심판, 즉 청구취지의 대상으로 되어 있는 권리가 같고 그 종류가 동일한 심판을 말한다. 실무상 i) 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판¹³⁸⁾ 또는 ii) 전부무효심판과 일부무효심판의 경우에는 동일심판으로 취급된다.

135) 대법원 1987. 7. 7. 선고 86후107.

136) 대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057.

137) 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지는 아니한다. 그러나 모순저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면, 위와 같은 경우에도 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다. 원심이 그 판시와 같은 이유를 들어, 원고가 이 사건에서 한 주장 중 이 사건 등록고안의 진보성이 부정된다는 부분은 종전에 확정된 심결이 있는 등록무효심판에서 청구원인이 된 무효사유와 공통되는데, 이 사건에서 제출된 비교대상고안 7은 이미 확정된 심결의 이유 중에 거론되어 판단되었던 증거이고, 새로이 제출된 비교대상고안 1 내지 6, 8 내지 12 등은 모두 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거라고 볼 수 없다는 이유로, 이 사건 등록고안의 진보성이 부정된다는 주장을 배척한 것은 위 법리에 따른 것으로서, 거기에 상고이유 주장과 같이 일사부재리 원칙 적용에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체).

138) 대법원 1976. 6. 8. 선고 75후18; 2012. 5. 24. 선고 2012후757.

III. 판 단

1. 대 상

(1) 결정계 심판의 경우

1) 거절결정에 대한 불복심판은 그 결정등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 청구하여야 하므로(法 132의17) 동 심판에 대한 심결이 확정된 후에는 다시 동일한 심판을 청구할 수 없다. 따라서 일사부재리의 원칙이 적용될 여지가 없다.

2) 정정심판(法 136)은 특허권자만이 청구할 수 있으므로 이에 관한 심결에 대하여 특허권자가 동일하게 정정한 명세서 또는 도면을 가지고 다시 심판을 청구하는 일도 없을 것이며, 정정한 명세서 또는 도면을 동일사실로 보기 어려우므로 일사부재리가 적용되지 아니한다고 봄이 타당하다.¹³⁹⁾

(2) 당사자계 심판의 경우

특허무효심판(法 133), 특허권의 존속기간연장등록무효심판(法 134), 권리범위확인심판(法 135), 정정무효심판(法 137), 통상실시권허락심판(法 138)의 심판청구에 대한 심결이 확정되었으면 그 후 심판에 대해서는 일사부재리의 원칙이 적용된다.

2. 시 기

1) 심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(法 140②). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 「심결 시」를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지를 판단하여야 한다. 예를 들어 신규성 위반으로 청구된 무효심판의 기각심결이 확정된 후에 다시 무효심판을 청구한 사건에서 심판청구 당사에서 신규성 위반이라고만 하였으나 심결취소소송단계에서 신규성 위반 이외에 다른 무효사유(진보성 위반)를 주장하는 것은 일사부재리의 판단이 심결 시를 기준으로 하므로 인정될 수 없다.¹⁴⁰⁾

139) 당사자 대립구조에 의한 심리판단이 이루어지지 않는 정정심결이 확정되었다고 하여 특허법 제163조가 규정하는 일사부재리의 효력을 상정하기 어렵다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의제).

140) 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360. 각하 심결에 대한 심결취소소송에서도 각하 심결의 위법 여부를 판단하기 위해 새로운 증거를 제출하고 이를 조사하는 것은 허용된다(무제한설). 심판은 특허심판원에서 진행되는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·증명할 수 있고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있기 때문이다. 다만 각하 심결은 특허·무효에 대한 본안판단이 아닌 심판청구의 적법요건을 결하였다는 취지의 심결이므로, 일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서는 그 본안 전 판단의 실체적·절차적 위법성 여부를 심리·판단하여야 한다. 예를 들어 심결 시까지 제출된 새로운 증거가 종전 확정판결과

2) 다만 선행심결의 확정시점과 관련해서는 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 「심판청구 시」를 기준으로 한다.¹⁴¹⁾ 심결 시를 기준으로 하는 경우 특허권자와 공모한 제3자가 심판에서 기각심결의 확정을 먼저 유도하여 다른 사람의 심판청구의 길을 봉쇄하는 결과를 초래하기 때문이다.

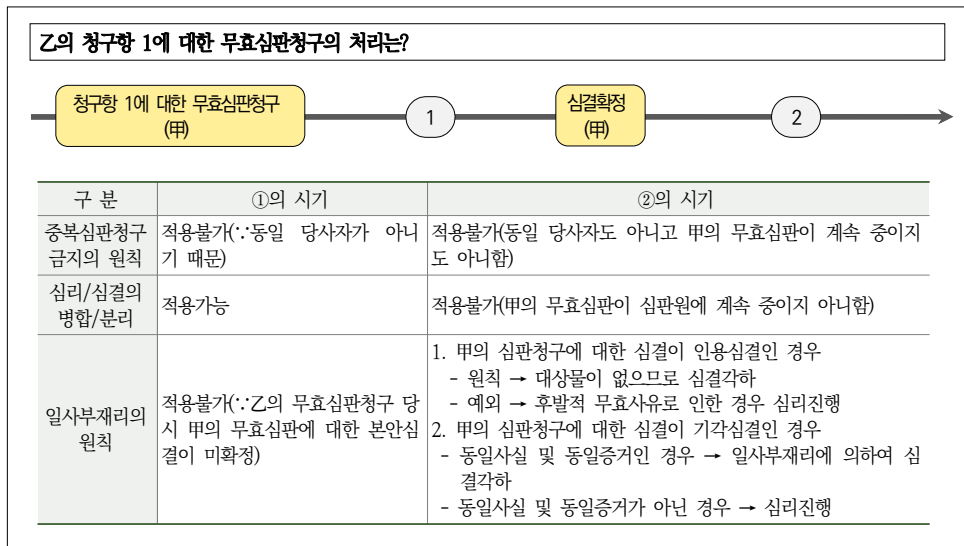
3) 한편 2건의 동일한 심판청구가 있고 그 어떤 사건에 대해서도 심결이 행해지지 아니한 때에는 양 사건의 심리 또는 심결의 병합도 가능하다.

결론을 달리할 수 있는 중요한 증거임에도 심결이 이를 잘못 평가하여 동일증거라고 보아 일사부재리 위반의 각하 심결을 하였다면 이는 위법한 심결이다. 앞서 본 무제한설의 원칙에 따라 이와 같은 심결의 위법성을 증명하기 위한 새로운 증거, 예컨대 통상의 기술자의 기술수준이나 심결 단계에서 제출된 증거의 기술적 의미에 대한 심결의 오해를 바로잡기 위한 기술문헌의 제출이나 전문가 증인 등은 심결취소 소송 단계에서 얼마든지 제출이 가능하다. 심결취소소송을 심리하는 법원으로서의 이와 같이 새롭게 제출된 증거에 기초해서 심결의 위법 여부를 판단할 수 있다. 한편 심결취소소송 단계에서 새롭게 제출된 주장이나 증거로 인해 특허가 무효라고 판단된다고 하더라도 그러한 본안에 대한 사유가 일사부재리를 이유로 한 각하 심결을 위법하게 만드는 사유라고 볼 수는 없다. 각하 심결은 특허 유·무효에 대한 본안판단을 한 것이 아니라 심결 시까지 제출된 주장과 증거가 종전의 확정심결과 동일사실 및 동일증거이므로 심판청구가 부적법하다는 점에 대해 판단한 것일 뿐이기 때문이다. 따라서 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하거나 새로운 무효 증거를 제출하고, 이와 같은 새로운 주장과 증거에 비추어 등록무효 사유가 있는 것으로 보이더라도 법원은 이를 이유로 각하심결을 취소할 수 없다. 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결에서도 같은 취지에서 일사부재리 원칙 위반을 이유로 한 각하 심결에 대한 심결취소소송에서 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않고, 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없으며, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다고 판시하고 있다(김기수 “가상 플랫 시뮬레이션 장치에 대한 발명의 진보성, 대법원판례해설 제124호, 2020, 206-207면).

- 141) 종래의 대법원 판례에 따르면, 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있는 경우에 어느 심판의 심결(이를 ‘제1차 심결’이라고 한다)에 대한 심결취소소송이 계속하는 동안 다른 심판의 심결이 확정 등록된다면, 법원이 해당 심판에 대한 심결취소의 청구가 이유 있다고 하여 제1차 심결을 취소하더라도 특허심판원이 그 심판청구에 대하여 특허법 제189조제1항 및 제2항에 따라 다시 심결을 하는 때에는 일사부재리의 원칙에 의하여 그 심판청구를 각하할 수밖에 없다. 그러나 이는 관련 확정 심결의 등록이라는 우연한 사정에 의하여 심판청구인이 자신의 고유한 이익을 위하여 진행하던 절차가 소급적으로 부적법하게 되는 것으로 헌법상 보장된 국민의 재판청구권을 과도하게 침해할 우려가 있고, 그 심판에 대한 특허심판원의 심결을 취소한 법원의 판결을 무의미하게 하는 불합리가 발생하게 된다. 나아가 특허법 제163조의 취지는 심판청구의 남용을 방지하여 심판절차의 경제성을 도모하고 동일한 심판에 대하여 상대방이 반복적으로 심판에 응하여야 하는 번거로움을 면하도록 하는 데에 있다. 그러나 위 규정은 일사부재리의 효력이 미치는 인적범위에 관하여 “누구든지”라고 정하고 있어서 확정 등록된 심결의 당사자나 그 승계인이외의 사람이라도 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없으므로, 함부로 그 적용의 범위를 넓히는 것은 위와 같이 국민의 재판청구권의 행사를 제한하는 결과가 될 것이다. 그런데 특허법 제163조는 위와 같이 ‘그 심판을 청구할 수 없다’라고 규정하고 있어서, 위 규정의 문언에 따르면 심판의 심결이 확정 등록된 후에는 앞선 심판청구와 동일사실 및 동일증거에 기초하여 새로운 심판을 청구하는 것이 허용되지 아니한다고 해석될 뿐이다. 그 러함에도 이를 넘어서 심판청구를 제기하던 당시에 다른 심판의 심결이 확정 등록되지 아니하였는데 그 심판청구에 관한 심결을 할 때에 이미 다른 심판의 심결이 확정 등록된 경우에게까지 그 심판청구가 일사부재리의 원칙에 의하여 소급적으로 부적법하게 될 수 있다고 하는 것은 합리적인 해석이라고 할 수 없다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234 전원합의체 판결).

IV. 효 력

심결이 확정된 경우에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 동일한 심판을 청구할 수 없다. 따라서 일사부재리에 위반하여 동일심판이 청구되었으면 부적법한 심판청구로서 심결각하의 대상이 된다(法 142).



【그림 7-3】 일사부재리 적용의 구체적 예

V. 유사한 제도

1. 재 심

「재심」은 확정된 심결에 대해서 그 심결에 이르는 과정에서 중대한 절차상의 하자가 있거나 심결이 불공정한 상태에서 확정되었다는 이유를 들어 확정된 심결의 취소를 구하는 심판이다. 재심의 청구는 확정된 심결을 그 전제로 하는 점과 새로운 이유나 증거가 아닌 해당 그 확정심결의 범위에서 이루어진다는 점에서 일사부재리의 원칙과 공통되나, 양자는 심판청구의 이유가 다르므로 상호 모순됨이 없다.

2. 중복심판청구의 금지

특허심판이 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구하지 못한다(法 154⑧ 준용 民訴 259). 이는 이미 계속되고 있는 사건에 대하여 다시 심판청구를 허용함은 심판제도의 남용으로서, 심판원이나 당사자에게 시간·노력·비용을 이중으로 낭비하게 하는 것이어서 심판

경제상 바람직하지 않고, 심결이 서로 모순·저촉될 염려가 있기 때문이다. 중복심판청구는 전 심판이 계속 중이라는 점 및 심판청구의 당사자가 동일하다는 점 등에서 일사부재리의 원칙과 다르다.

3. 재소금지의 원칙

1) 「재소금지」란 본안에 대한 중국판결이 있고 난 뒤에 소를 취하한 자는 다시 동일한 소를 제기할 수 없다(民訴法 267②)는 민사소송법상의 원칙이다. 재소금지 원칙의 제도적 취지는 중국판결이 있는데도 원고가 스스로 소를 취하하였으면 그 자에게 더 이상 심판의 기회를 줄 필요가 없다는 제재적인 의미의 원칙이다. 그러므로 일사부재리 원칙과는 거리가 먼 원칙이다.

2) 특허심판은 재소금지 원칙이 적용되지 아니한다. 특허심판의 경우에는 공익적 요소가 강하기 때문에 일반 민사소송과 비교할 때 당사자의 제재 의미가 강한 재소금지의 원칙을 채택하는 것은 바람직하지 못하다. 따라서 특허심판에 있어서는 심결의 확정 전까지는 청구의 취하를 할 수 있고(法 161①), 초심의 경우에 심판청구의 기간에 문제가 없다면 다시 심판을 청구할 수 있다.

4. 민사소송의 기판력

1) 민사소송의 판결이 확정되면 당사자와 법원을 규율하는 새로운 기준으로서 구속력을 가지며, 뒤에 동일사항이 문제되면 당사자는 그에 반하여 되풀이하여 다투는 소송이 허용되지 아니하며(不可爭), 어느 법원도 다시 재심사하여 그와 모순·저촉되는 판단을 해서는 안 되는 데(不可反) 이를 「기판력」이라 한다.¹⁴²⁾

2) 기판력과 일사부재리는 심결이나 판결의 모순·저촉을 방지한다는 점에서 공통점이 있으나, i) 일사부재리의 원칙이 대세효가 있는데 반해, 기판력은 당사자 사이에만 미친다는 점, ii) 일사부재리는 동일사실 및 동일증거에 기하여 다시 심판청구를 금지하기 때문에 사실 또는 증거 중 어느 하나가 다르다면 재차 심판청구가 가능하나, 기판력은 소송물이 같은 한 다른 증거에 기한 경우라도 재차 소송을 제기할 수 없는 점에서 차이가 있다.

142) 이시윤, 「신민사소송법」, 박영사, 2002, 519면.

제4절 관련문제

제1관 특허심판과 소송과의 관계

제164조 【소송과의 관계】

- ① 심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
 - ② 법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
 - ③ 법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝났을 때에도 또한 같다.
 - ④ 특허심판원장은 제3항에 따른 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 제3항에 해당하는 법원에 통보하여야 한다. 그 심판청구서의 각하결정, 심결 또는 청구의 취하가 있는 경우에도 또한 같다.
- [전문개정 2014.6.11.]

I. 심판 또는 소송절차의 중지

심판장은 심판에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청¹⁴³⁾에 따라 그 심판사건과 관련되는 특허취소신청에 대한 결정 또는 다른 심판의 심결이 확정되거나 소송절차가 완결될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다. 또한 법원은 소송에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결이 확정될 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다(法 164①②). 다른 절차를 무시하고 절차를 진행한다면 전체적으로 보아 소송경제나 심판 경제를 무시한 경우도 있을 수 있으며, 때로는 후일 재심청구의 이유로 될 경우도 발생할 수 있으므로 이를 방지하기 위함이다. 다만 중지 여부는 심판원이나 법원의 재량이지 의무는 아니다.

II. 침해의 소에 대한 통보

법원은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소가 제기된 경우에는 그 취지를 특허심판원장에게 통보하여야 한다. 그 소송절차가 끝났을 때에도 또한 같다. 한편 특허심판원장은 특허권 또는 전용실시권의 침해에 관한 소에 대응하여 그 특허권에 관한 무효심판 등이 청구된 경우에는 그 취지를 그 침해의 소가 제기된 법원에 통보하여야 한다. 그 심판청구서의 각하결정·심결 또는 청구의 취하가 있는 경우에도 또한 같다(法 164③④). 이는 특허분쟁의 효율적인 해결 및 심결과 판결의 저축을 방지하고자 함이다. 다만 이 규정은 강제 규정으로 하면 삼권분립의 원칙에 반하기 때문에 훈시적 규정이라 할 것이다.¹⁴⁴⁾

143) 법 제164조제1항(법 제132조의15에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따라 특허취소신청절차 또는 심판절차의 중지를 신청하려는 자는 별지 제33호의2서식의 절차 중지신청서를 심판장에게 제출하여야 한다(施規 67의2).

제2관 조정위원회 회부

제164조의2【조정위원회 회부】

- ① 심판장은 심판사건을 합리적으로 해결하기 위하여 필요하다고 인정되면 당사자의 동의를 받아 해당 심판사건의 절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 조정위원회에 회부할 수 있다.
- ② 심판장은 제1항에 따라 조정위원회에 회부한 때에는 해당 심판사건의 기록을 조정위원회에 송부하여야 한다.
- ③ 심판장은 조정위원회의 조정절차가 조정 불성립으로 종료되면 제1항에 따른 중지 결정을 취소하고 심판을 재개하며, 조정이 성립된 경우에는 해당 심판청구는 취하된 것으로 본다.

[본조신설 2021. 8. 17.]

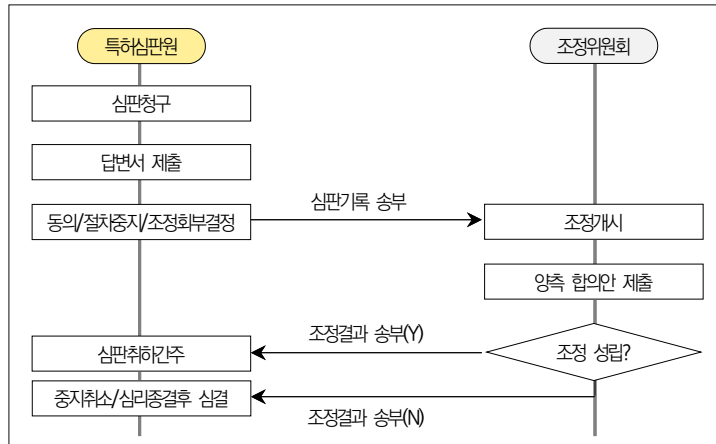
1) 심판장은 심판사건을 합리적으로 해결하기 위하여 필요하다고 인정되면 당사자의 동의를 받아 해당 심판사건의 절차를 중지하고 결정으로 해당 사건을 조정위원회에 회부할 수 있다. 심판장은 조정위원회에 회부한 때에는 해당 심판사건의 기록을 조정위원회에 송부하여야 한다(法 164의2①②). 조정위원회 회부가 결정된 때에는 해당 사건이 위원회에 회부된 날에 조정 신청이 있는 것으로 본다. 조정 신청된 사건으로서 해당 심판장이 필요하다고 인정하고 당사자가 동의하는 경우에는 해당 심판합의체의 전부 또는 일부가 조정부의 일원이 될 수 있다(發振法 49의3).

2) 심판장은 조정위원회의 조정절차가 조정 불성립으로 종료되면 중지 결정을 취소하고 심판을 재개하며, 조정이 성립된 경우에는 해당 심판청구는 취하된 것으로 본다(法 164의2③).

3) 심판단계에서 조정제도를 이용하면 소송 전 분쟁의 조기 해결이 가능하고 침해소송이 결부된 경우에는 소송까지 종결할 수 있으나, 기존에는 「심판-조정 연계제도」 없이 분쟁 당사자의 신청에 의해서만 조정위원회의 조정절차가 진행되고 있어서, 2021. 11. 18. 시행되는 현행 법(법률 제18409호, 2021. 8. 17. 일부개정)에서는 「심판-조정 연계제도」를 통해 조정위원회 조정제도를 활성화하기 위해 심판사건을 조정위원회에 회부할 수 있는 근거(法 164의2)를 마련하고, 더불어 심판사건의 기록도 조정위원회에 반출(法 217① I의II)¹⁴⁵⁾할 수 있도록 하였다.

144) 이종완, 「특허법론」, 대한변리사회, 2004, 876면.

145) 조정을 위하여 특허출원·심사·특허취소신청·심판·재심에 관한 서류 또는 특허원부를 외부로 반출할 수 있다(法 217① I의II).



【그림 7-4】 심판-조정 연계 절차

제3관 심판비용

제165조 【심판비용】

- ① 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조 및 제137조제1항의 심판비용의 부담은 심판이 심결에 의하여 종결될 때에는 그 심결로써 정하고, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종결될 때에는 결정으로써 정하여야 한다.
- ② 제1항의 심판비용에 관하여는 「민사소송법」 제98조부터 제103조까지, 제107조제1항·제2항, 제108조, 제111조, 제112조 및 제116조를 준용한다.
- ③ 제132조의17, 제136조 또는 제138조에 따른 심판비용은 청구인이 부담한다. <개정 2016.2.29.>
- ④ 제3항에 따라 청구인이 부담하는 비용에 관하여는 「민사소송법」 제102조를 준용한다.
- ⑤ 심판비용액은 심결 또는 결정이 확정된 후 당사자의 청구에 따라 특허심판원장이 결정한다.
- ⑥ 심판비용의 범위·금액·납부 및 심판에서 절차상의 행위를 하기 위하여 필요한 비용의 지급에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 「민사소송비용법」 중 해당 규정의 예에 따른다.
- ⑦ 심판의 대리를 한 변리사에게 당사자가 지급하였거나 지급할 보수는 지식재산청장이 정하는 금액의 범위에서 심판비용으로 본다. 이 경우 여러 명의 변리사가 심판의 대리를 한 경우라도 1명의 변리사가 심판대리를 한 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

제166조 【심판비용액 또는 대가에 대한 집행권원】

이 법에 따라 특허심판원장이 정한 심판비용액 또는 심판관이 정한 대가에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행권원과 같은 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정본은 특허심판원 소속 공무원이 부여한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제191조의2 【변리사의 보수와 소송비용】

소송을 대리한 변리사의 보수에 관하여는 「민사소송법」 제109조를 준용한다. 이 경우 “변호사”는 “변리사”로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

「심판비용」이란 심판절차에서 심판관, 당사자 또는 참가인 등이 지출한 비용을 말한다. 심판 비용에 관하여는 일반적으로 민사소송법의 소송비용에 관한 규정이 준용되나 특수한 사안에 대해서는 특허법에서 따로 그 비용부담방법을 정하고 있는바 이하 살펴해보도록 한다.

II. 심판비용의 부담, 범위 및 예납

1. 심판비용의 부담

(1) 당사자계 심판

① 원 칙

1) 당사자계 심판 중 특허무효심판(法 133), 특허권의 존속기간연장등록무효심판(法 134), 권리범위확인심판(法 135), 정정무효심판(法 137)에 관한 심판비용의 부담은 심판에 의하여 정한다. 심판이 심결에 의하여 종결될 때에는 그 심결로써 정하고, 심판이 심결에 의하지 아니하고 종결될 때에는 결정으로써 비용부담자를 정하여야 한다(法 165①). 심결에 따라 정할 때에는 심판관이 직권으로 主文에서 판단한다.

2) 당사자계 심판의 경우에 심판비용은 패심한 당사자가 부담하는 것이 원칙이다. 당사자계 심판의 청구를 취하한 자도 패심자에 준한다. 다만 일부패심의 경우, 예컨대 특허권의 무효심판을 청구했는데 그중 일부항에 대해서만 무효심결이 된 경우에는 각 당사자가 부담할 심판비용은 심판부가 정하여야 한다(法 165②, 民訴法 101). 공동심판의 경우에는 균등하게 부담한다(法 165④, 民訴法 102). 패심자부담의 원칙을 관철하는 것이 공평하지 아니한 경우¹⁴⁶⁾에는 승심자에게 일부부담을 시킬 수 있다(法 165②, 民訴法 99, 100). 심판비용의 부담을 명령받은 당사자는 자기의 지출비용뿐 아니라 상대방의 지출비용도 법정범위에서 변상하여야 한다. 심판비용을 패심자가 아닌 제3자에게 부담시키는 경우도 예외적으로 있다(法 165②, 民訴法 107, 99).

146) 구체적인 예는 다음과 같다(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 1044면).

- ① 심판청구가 화해, 권리이전, 실시권설정을 이유로 심결각하된 경우 심판 비용은 각자 부담으로 할 수 있다.
- ② 소극적 권리범위확인심판에 있어 피청구인(권리자)이 경고등 권리행사가 없고 방어도 하지 아니한 때 또는 피청구인(권리자)이 과거 경고 등 권리행사를 하였으나 심판의 대상인 확인대상발명에 대해서 다투지 않는다는 의사표시를 명확히 한 때에는 청구인(비권리자)이 승소한 경우에도 승소자가 비용을 부담한다.
- ③ 신청에 의한 증인신문 결과 증인, 증언이 증명사항과 관계가 없는 자나 사항인 것이 판명된 경우 그 증인신문에 소요된 비용은 신청한 당사자가 승소자인 경우에도 그 자에게 일부나 전부를 부담시킬 수 있다.
- ④ 특허무효심판 청구 후 특허발명의 명세서가 정정청구에 의하여 정정된 결과 무효사유가 소멸된 경우 피청구인이 승소자인 경우에도 비용을 일부나 전부를 부담시킬 수 있다.
- ⑤ 권리범위확인심판에 있어서 권리자가 일부 청구항을 포기하거나, 일부 청구항의 무효 등이 확정되어 소멸된 경우, 권리자가 승소한 경우에도 심판 비용은 각자 부담으로 할 수 있다.

② 통상실시권허락심판

당사자에게 심판 중 통상실시권허락심판의 경우에는 언제나 청구인이 심판비용을 부담한다(法 165③). 이러한 심판은 언제나 청구인의 이익에 관계되는 것이기 때문이다.

(2) 결정계 심판

거절결정불복심판, 정정심판의 경우에 심판비용은 청구인이 부담한다(法 165③). 역시 언제나 청구인의 이익을 위한 심판이기 때문이다. 공동심판의 경우에는 균등하게 부담한다(法 165④, 民訴法 102).

2. 심판비용의 범위

1) 심판비용의 범위·금액·납부 및 심판에서 절차상의 행위를 하기 위하여 필요한 비용의 지급에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 민사소송비용법 중 해당 규정의 예에 따른다(法 165⑥). 구체적으로 심판비용의 범위는 i) 심판 또는 재심의 청구료, ii) 번역료, iii) 통신 및 운송료, iv) 심판 또는 재심의 청구서나 그 밖의 서류 및 도면의 작성료, v) 출석통지에 의한 감정인 및 통역인 등의 일당·숙박료 또는 여비, vi) 신청에 의하여 비용을 예납시키고 실시한 현지검증에 소요된 일당·숙박료 또는 여비, vii) 출석통지에 의한 당사자 및 증인의 일당·숙박료 또는 여비, viii) 심판의 대리인으로서 위임된 변리사에게 당사자가 지급하였거나 지급할 보수(여러 명의 변리사가 심판의 대리를 한 경우라도 1명의 변리사가 심판대리를 한 것으로 본다.)(法 165⑦), ix) 그 밖의 지급된 여비 중 일반 사회통념에 따라서 인정되는 비용액 등을 말한다.

2) 변리사 보수는 심판비용뿐만 아니라 소송비용에도 포함된다. 구체적으로 소송을 대리한 변리사에게 지급하였거나 지급할 보수는 대법원 규칙이 정하는 금액의 범위에서 소송비용으로 인정한다(法 191의2). 기존에는 변리사와 변호사가 소송대리를 하였을 경우 변호사는 민사소송법 제109조에 소송비용을 지급받았으나, 변리사는 지급근거 규정이 없다는 이유로 소송비용을 지급받지 못하였다.¹⁴⁷⁾ 그 결과 승소자가 변리사 비용을 부담하였는데, 소송대리인이 변호사가 아닌 변리사라는 이유로 승소자가 변리사 보수를 부담하는 것은 형평의 원칙에 위배되므로 2006. 3. 3. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3. 개정)에서는 제191조의2를 신설하여 이를 해결하고 있다.

3. 심판비용의 예납

심판·재심에 있어서 비용을 요구하는 행위에 필요한 비용은 이를 당사자에게 예납하게 할 수 있으며, 예납하지 아니할 때에는 심판 등에서 그 행위를 하지 아니할 수 있다. 그 필요한 행위란, 예를 들면 증거조사와 같은 것이 있다(法 165②, 民訴法 116).

147) 대법원 1995. 6. 23. 선고 95쿠3.

Ⅲ. 심판비용액의 결정 및 집행권원

1. 심판비용액의 결정

1) 「심판비용액」은 심결 또는 결정이 확정된 후 당사자의 청구에 따라 특허심판원장이 결정한다(法 165⑤). 심결이나 결정이 확정됨으로써 심결 이후의 송달비용 등 그때까지 지출한 비용이 특정되기 때문이다. 이때 상대방에게 비용액 결정에 대한 참여절차를 허용하고(法 165②, 民訴法 111), 부담비용이 상계되는 것으로 보는 경우도 있다(法 165②, 民訴法 112).

2) 심판 또는 재심에 관한 비용의 금액결정을 청구하려는 자는 심판비용액 결정청구서에 비용계산서 및 그 증빙서류를 첨부하여 특허심판원장에게 제출하여야 한다(施規 68). 심판비용액 청구서가 방식에 위반된 경우에 특허심판원장은 기간을 정하여 보정을 명하고, 청구서의 흠결이 없거나 치유되면 피청구인에게 비용계산서 부분을 첨부한 최고서를 송달하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준다. 특허심판원장은 의견서 등을 참작하여 구체적인 비용액을 결정하고 그 등본을 당사자에게 송달하여야 한다.

2. 집행권원

「집행권원」이란 강제집행에 의하여 실현되어야 할 급부청구권의 존재와 범위를 명확히 하여 집행기관에 의한 강제집행의 기본이 되는 문서를 지칭한다. 특허심판원장이 정한 심판비용액 또는 심판관이 정한 대가에 관하여 확정된 결정은 집행력 있는 집행권원과 같은 효력을 가진다. 이 경우 집행력 있는 정보는 특허심판원 소속 공무원이 부여한다(法 166). 이 규정의 취지는 심판비용액의 결정에 대하여 당시 집행을 위한 법원의 확인을 거치지 않고 신속·간결하게 강제집행을 실현할 수 있게 하기 위함이다.

Ⅳ. 불 복

심판비용 부담의 심결이나 결정에 대해서는 심결이나 결정에 대한 불복과 함께 그 취소소송을 제기하여 불복할 수 있으나, 독립하여 제186조제1항에 따른 특허법원에 소를 제기할 수 없다(法 186⑦). 한편 심판비용액에 대한 특허심판원장의 결정에 대해서는 행정심판 또는 행정소송으로서 불복할 수 있다.

제6장

구체적인 심판의 내용

제1절 거절결정불복심판

제132조의17 【특허거절결정 등에 대한 심판】

특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 받은 자가 결정에 불복할 때에는 그 결정 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내에 심판을 청구할 수 있다. <개정 2021. 10. 19.>

[전문개정 2014.6.11.]

제170조 【심사규정의 특허거절결정에 대한 심판에의 준용】

- ① 특허거절결정에 대한 심판에 관하여는 제47조제1항제1호·제2호, 같은 조 제4항, 제51조, 제63조, 제63조의2 및 제66조를 준용한다. 이 경우 제51조제1항 본문 중 “제47조제1항제2호 및 제3호에 따른 보정”은 “제47조제1항제2호에 따른 보정(제132조의17의 특허거절결정에 대한 심판청구 전에 한 것은 제외한다)”으로, 제63조의2 본문 중 “지식재산처장”은 “특허심판원장”으로 본다. <개정 2016.2.29.>
- ② 제1항에 따라 준용되는 제63조는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 적용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제171조 【특허거절결정에 대한 심판의 특칙】

특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에는 제147조제1항·제2항, 제155조 및 제156조를 적용하지 아니한다.

[전문개정 2009.1.30.]

제172조 【심사의 효력】

심사에서 밝은 특허에 관한 절차는 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제176조 【특허거절결정 등의 취소】

- ① 심판관은 제132조의17에 따른 심판이 청구된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 심결로써 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소하여야 한다. <개정 2016.2.29.>
- ② 심판에서 제1항에 따라 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소할 경우에는 심사에 부칠 것이라는 심결을 할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 심결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「거절결정불복심판」이란 특허출원에 대하여 특허거절결정(法 62)을 받거나, 특허권의 존속기간연장등록출원에 대하여 연장등록거절결정(法 91, 92의4)을 받은 자가 이에 불복하여 그 거절결정을 취소하여 줄 것을 요구하는 심판을 말한다(法 132의17).

2. 취 지

특허법은 i) 당사자에게는 권리구제의 기회를 주는 한편 ii) 지식재산처에게는 자기시정의 기회를 부여함으로써 심사관이 하는 행정처분의 적정성과 공정성을 확보하기 위해 거절결정불복심판 제도를 두고 있다.

3. 법적성질

특허출원에 대한 심사절차와 심판절차는 별개의 절차이고 심급구조가 존재하지 아니한다. 그러나 특허출원에 대한 심사에서 밝은 특허에 관한 절차는 특허거절결정, 특허권의 존속기간연장의 연장등록거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있기 때문에(法 172), 특허거절결정, 특허권의 존속기간연장등록출원의 거절결정불복심판은 심사에 대한 속심적 성격을 갖는다고 할 수 있다.

II. 심판의 요건

1. 청구인

특허출원에 대하여 특허거절결정을 받은 경우 특허출원인, 존속기간연장등록출원에 대하여 연장등록거절결정을 받은 경우 존속기간연장등록출원인(특허권자)이 거절결정불복심판을 청구할 수 있다. 임의대리인은 특별히 권한을 위임받아야만 그 절차를 밟을 수 있다(法 6).

2. 청구대상

특허거절결정을 받은 특허출원, 연장등록거절결정을 받은 존속기간연장등록출원을 그 대상으로 한다. 한편 심판청구 전 최후거절이유통지에 대한 보정 또는 재심사를 청구할 때의 보정이 부적법하여 보정각하된 경우 심판청구이유에 기재함으로써 이에 대하여 불복할 수 있다(法 51③).

3. 청구시기

1) 거절결정등본을 송달받은 날로부터 3개월 이내에 청구할 수 있다. 거절결정불복심판은 거절결정등본의 송달 후에만 청구될 수 있으므로, 거절결정 전에 청구된 거절결정에 대한 심

판은 그 청구를 심결로써 각하한다. 한편 상기의 기간은 법정기간이지만 지식재산처장은 청구에 따라 또는 직권으로 30일 이내에서 한 차례만 연장할 수 있다. 다만 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다(法 15①).

2) 또한 책임질 수 없는 사유로 청구기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 및 그 기간의 만료일로부터 1년 이내에만 그 지키지 못한 절차를 추후보완할 수 있다(法 17).

III. 심판의 절차

1. 심판청구서의 제출

심판청구인은 법정사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(法 140의2 ①). 다만 결정계 심판이어서 피청구인이 존재하지 않으므로 심판청구 시 피청구인에 대한 청구서 부분의 송달 및 답변서에 관한 제147조제1항, 제2항과 참가에 관한 규정인 제155조, 제156조가 적용되지 아니한다(法 171).¹⁴⁸⁾

2. 심 리

(1) 심리의 범위

① 거절결정의 타당 여부

심판관은 거절결정처분의 당부, 즉 심판청구인이 원결정의 부당성을 지적하는 새로운 이유나 추가하는 증거방법의 타당성 여부를 포함하여 심사절차에서의 거절이유의 적정성 여부를 심리한다. 또한 원결정의 거절이유에 한정되지 않고 특허출원이 제62조 각호의 다른 거절이유 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 제91조 각호 또는 제92조의4 각호의 다른 거절이유에 해당하는지 여부 등을 전면적으로 재심리한다.

② 심사단계에서의 보정각하처분

1) 심사단계에서 최후거절이유통지에 대한 보정 또는 재심사를 청구할 때 보정이 부적법함을 이유로 각하되어 거절결정불복심판에서 함께 불복한 경우에는 그 타당성 역시 심리범위에 포함된다(法 51③). 그 결과 심사단계에서의 보정각하가 부당한 경우에는 보정을 인정하고 거절이유의 해소 여부를 판단하게 된다. 다만 보정각하가 정당한 경우에는 보정 전의 명세서 또는 도면이 심리의 대상이 된다. 심사단계에서의 보정각하가 적법한지 여부는 심사단계에서의 보정각하사유가 아닌 다른 사유에 의하여 판단될 수 있으며, 이 경우 청구인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 아니하여도 된다.¹⁴⁹⁾

148) 한편 특허심판원장은 심판을 위하여 필요한 경우 지식재산처장에게 그 심판청구서 부분을 송부하고, 관계 심사관의 의견을 제출하도록 지식재산처장에게 요청할 수 있다(施規 64).

2) 다만 i) 직권 재심사를 하는 경우 취소된 특허결정 전에 한 보정각하결정과 ii) 재심사의 청구가 있는 경우 그 청구 전에 한 보정각하결정은 거절결정불복심판에서 다룰 수 없다(法 51③팔호). 이는 직권 재심사 또는 재심사 청구가 있었다면 직권 재심사 또는 재심사단계에서 취소된 특허결정 전 또는 재심사의 청구 전 보정각하결정에 대하여 충분히 다룰 수 있는 기회를 주었기 때문이다.

(2) 심사규정의 준용 및 심사절차의 효력

① 최초·최후 거절이유통지 및 보정

1) 심판관은 원거절결정의 이유에 대해서는 심판청구인에게 다시 거절이유를 통지하지 않고, 원거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에만 심판청구인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 170②, 法 170① 준용 法 63 ①).¹⁵⁰⁾ 위 규정은 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여하여 출원인 또는 심판청구인의 절차적 권리를 보호하고, 심사 및 심판의 적정을 기하여 심사 및 심판 제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다. 따라서 위 규정에 따라 거절이유통지를 하지 아니한 채 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 예를 들어 심사단계에서 미리 거절이유를 통지한 사유라고 하더라도 그 사유를 거절결정에서 거절이유로 삼지 않았다면 이와 같은 사유는 거절결정에 대한 심판절차에서는 「거절결정의 이유와 다른 거절이유」에 해당하므로, 심판단계에서 심판청구인이 위 사유에 대하여 실질적으로 의견서 제출 및 보정의 기회를 부여받았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한 이를 심결의 이유로 하기 위해서는 다시 그 사유에 대하여 거절이유를 통지하여야 한다.¹⁵¹⁾ 한편 특허거절결정의 이유 중에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있다 하더라도, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관

149) 첫째, 특허법상 지식재산청가 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하하는 경우에는 특허거절결정의 경우와 달리 미리 그 이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주지 아니하여도 되는 점(특허거절결정에 관한 제63조제1항 본문, 보정각하에 관한 제51조제1항, 제63조는 제1항 단서 참조), 둘째, 심판절차에서 출원인에게 의견 제출의 기회를 주지 아니한 채 보정각하결정에 명시하지 아니한 다른 사유를 내세워 보정각하결정이 적법하다고 판단하더라도 출원인으로서, 이 사건에서와 같이, 그 불복절차인 소송절차에서 그 사유와 관련하여 보정이 적법함을 주장할 충분한 기회가 있을 뿐만 아니라, 셋째, 가령 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대하여 심리하면서 그 이유에 대한 의견제출 기회를 주지 않았다고 하여 심결이 취소된다고 하더라도 취소 후 새로 진행되는 심판절차에서 출원인이 보정의 부적법한 사유를 치유하기 위하여 다시 명세서 등 보정서를 제출할 수 있는 절차가 없어 사실상 심결취소의 필요성이 없다고 할 수 있는 점 등에 비추어 보면, 특허심판원이 심판절차에서 출원인인 원고에게 의견진술의 기회를 부여하지 않고 지식재산청가 든 보정각하결정의 이유와 다른 이유로 그 보정각하결정이 적법하다고 판단하였다고 하더라도 그러한 사정만으로는 이 사건 심결이 특허법 제159조제1항을 위반하여 심결을 취소하여야 할 위법이 있다고 볼 수는 없다(특허법원 2009. 4. 24. 선고 2008허11064; 2009. 7. 10. 선고 2008허10764).

150) 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757.

151) 대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779.

이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 경우가 아니라면, 그와 같은 사유만으로 거절이유통지를 하지 않고 한 심결을 위법하다고 할 수 없다.¹⁵²⁾

2) 새로이 발견한 거절이유가 원시적으로 발생한 거절이유라면 최초거절이유를 통지하고, 최초거절이유통지에 대한 보정에 의하여 다시 새로운 거절이유가 발생한 경우에는 최후거절이유를 통지한다(法 170① 준용 法 47① I II). 심판청구인은 이 기간에 보정할 수 있으며, 최초 거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① I) 또는 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① II)에 보정을 하는 경우에는 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전에 한 모든 보정은 취하된 것으로 본다(法 170① 준용 法 47④).

② 보정각하

1) 심판관은 심판청구 후 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① II) 보정이 보정의 범위(法 47②③)를 벗어나거나 그 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생하여 부적법한 경우에는 보정각하결정을 하여야 한다(法 170① 준용 法 51①). 그리고 보정각하를 함으로써 거절이유를 해소할 수 없게 되는 경우 심판관은 다시 거절이유를 통지할 필요는 없으며 각각심결을 한다.

2) 한편 심판청구 전 최후거절이유통지에 따른 의견서 제출기간(法 47① II) 또는 재심사를 청구할 때(法 47① III) 보정이 부적법함에도 불구하고 심사단계에서 심사관이 보정각하결정을 하지 아니하고 이를 간과하여 추후 불복심판단계에서 심판관 합의체가 발견한 경우에는 보정을 인정하고 심리를 진행한다(170① 괄호). 이는 해당 보정이 인정되었음을 전제하고 심판절차를 밟은 청구인을 보호하기 위함이다.¹⁵³⁾

③ 정보제공

특허출원에 관하여 누구든지 그 특허출원이 거절이유(단, 法 42③ II · 42⑧ · 45 제외)에 해당하여 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 특허심판원장에게 제공할 수 있다(法 170 준용 法 63의2). 거절결정불복심판단계에서는 참가가 허용되지 않기 때문에 제3자에게 정보제공을 할 수 있는 기회를 부여하고 있는 것이다.

④ 특허심결

심판관은 원거절이유가 해소되고 자판 결과 더 이상 새로운 거절이유가 없는 경우 원거절결정을 취소하고 특허를 허락한다는 취지의 심결을 할 수 있다(法 170① 준용 法 66).

152) 대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820.

153) 한편 최후거절이유통지에 대응해 제출된 보정을 각하하였다가 그 각하결정이 심결에서 취소된 경우, 보정각하결정에서 거론하지 않았던 각하 사유로서 거절결정불복심판 절차에서 심리·판단되지 않았던 사유를 발견한 경우에는 그 사유를 들어 다시 보정각하 할 수 있는 것으로 해석되나, 특허법 제170조에서 거절결정불복심판 청구 전에 행해진 부적법한 보정에 대해서는 심판절차에서 보정각하하지 못하도록 하는 취지, 심사관이 간과하였던 사유를 다시 들어 보정각하하는 것은 출원인에게 불측의 손해를 줄 수 있는 점을 고려하여 보정을 다시 각하하지 않고 심사한다(지식재산처, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 4305-4306면).

⑤ 심사절차의 효력

심사에서 밝은 특허에 관한 절차는 특허거절결정, 특허권의 존속기간연장의 연장등록거절결정에 대한 심판에서도 그 효력이 있다(法 172). 이는 거절결정불복심판(法 132의17)에 있어서는 심사와 심판이 속심적인 성질이 있음을 규정한 것이다. 따라서 거절결정불복심판에 있어서 그 심리의 범위는 원결정에 이르기까지의 관련 자료를 기초로 하여 심리를 속행하고, 심판청구 이후에 청구인이 새로이 주장한 사실이나 보충한 자료를 더하여 심사관의 판단 당부를 조사하여야 한다.¹⁵⁴⁾

3. 심 결

(1) 심결내용

1) 심판관은 i) 심판청구가 타당하지 아니하고 원결정이 타당하다고 인정할 때는 기각심결을 하며, ii) 원결정이 위법·부당하여 심판청구가 이유 있다고 인정할 때는 심결로서 특허거절결정·존속기간연장의 연장등록거절결정을 취소하여야 한다. 이때 심판관은 그 사건을 자판하여 특허심결하거나 심사에 부칠 것이라는 심결을 할 수 있다(法 176①②). 즉 심사국으로 환송할 수도 있다.¹⁵⁵⁾

2) 심판에 의하여 심사국으로 환송할 경우 심결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속한다(法 176③). 기속력은 취소심결의 실효성을 도모하기 위하여 인정된 효력이므로 심결의 주문 및 그 전제로 된 요건사실의 인정과 효력의 판단에만 미치고 심결의 결론과 직접 관계없는 방론이나 간접사실의 판단에는 미치지 아니한다. 즉 거절결정 등의 취소심결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 심사관을 기속하므로 심사관은 취소심결에 원칙적으로 기속되지만, 거절결정 등의 이유와 다른 새로이 발견한 이유에 의하여 거절결정을 다시 할 수 있다. 예를 들어 신규성이 없음을 이유로 한 심사관의 거절결정이 취소된 경우라도 다시 진보성이 없다고 하여 거절결정을 하는 것도 가능하고, 심결에서 취소된

154) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 397면.

155) 자판을 할 것인지 환송을 할 것인지 여부는 민사소송법(民訴法 418)과는 달리 원칙적으로 심판관의 자유재량에 맡겨져 있다. 이에 대하여 심판 실무상 다음과 같이 분류의 기준을 제시하고 있다(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 908면).

1. 자판을 하는 경우

원 거절결정이유에 의하여는 거절할 수 없다고 판단되고, 취소환송하여 다시 심사에 부치는 것이 심판에서 행할 수 있는 판단 및 절차를 심사에서 행하도록 하는 것이 되어, 행정경제상 바람직스럽지 않은 경우

2. 환송을 하는 경우

다음의 경우에는 자판하는 것이 타당하지 아니하거나 또는 자판할 수 없기 때문에 원 결정을 취소하고 지식재산처 심사국에 환송한다.

i) 특허심판원에서 등록결정하면 심사-심판이라고 하는 심급을 두고 있는 실질적 의의가 상실되는 경우(추가검색 후 자판(自判) 등)

ii) 보정기회 부여 등 심판관이 의견제출통지서를 송부해야 하는 경우

iii) 주지부합 등 심사관이 법리를 잘못 적용하여 출원인에게 실질적인 의견제출기회를 부여되지 않은 경우

거절결정의 인용대상과는 다른 인용대상에 의하여 신규성 내지 진보성을 부정하여 또 다시 거절결정을 할 수도 있다.

3) 취소환송된 출원은 거절결정 또는 보정각하결정만 취소되었을 뿐 그 결정에 앞서 행해진 심사에서 많은 특허에 관한 절차 및 심사관이 행한 절차는 모두 유효하므로 거절결정이나 보정각하결정만 없던 것으로 보고 통상의 심사와 동일하게 심사한다. 다만 취소환송 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 거절이유통지를 할 때는, i) 심사관의 잘못된 거절결정으로 절차의 지연이라는 불이익을 감수하였던 출원인에게 다시 보정의 범위를 제한하는 것이 가혹하다는 점, ii) 제66조의3에 따른 직권 재심사에서도 취소통지 전의 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유에 대하여 최초거절이유를 통지한다는 점을 고려하여, 통지하는 거절이유를 최초거절이유로 한다.

(2) 불 복

1) 기각심결에 대해서 특허출원인이 불복할 경우에는 심판장으로부터 심결등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 취소소송을 제기할 수 있다(法 186①③). 다만 특허심결 또는 환송에 의한 재심사 결과 심사관의 특허결정이 확정된 경우에는 그 특허심결 또는 특허결정의 당부를 다툴 수 없다.

2) 한편 출원인은 기각심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 특허출원의 일부를 새로운 특허출원으로 분리할 수 있다. 이 경우 새로운 특허출원의 청구범위에는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 청구항만을 적을 수 있다(法 52의2).

- i) 그 심판청구의 대상이 되는 특허거절결정에서 거절되지 아니한 청구항
- ii) 거절된 청구항에서 그 특허거절결정의 기초가 된 선택적 기재사항을 삭제한 청구항
- iii) i) 또는 ii)에 따른 청구항을 제47조제3항 각호(같은 항 제4호는 제외한다)의 어느 하나에 해당하도록 적은 청구항
- iv) i)부터 iii)까지 중 어느 하나의 청구항에서 그 특허출원(원출원)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 부분을 삭제한 청구항

3) 원출원에 대한 심결취소소송과 원출원에서 특허가능한 청구항에 대한 분리출원이 동시에 계속 중인 경우 협의제의 적용이 문제이다. 심사 실무¹⁵⁶⁾는 분리출원은 원출원의 거절결정에서 거절되지 아니한 청구항만을 청구항에 기재한 것이므로, 원출원의 거절결정불복심판의 심결취소소송이 제기되더라도 특별한 이유가 없는 한 심결취소소송의 결과를 기다릴 필요 없이 분리출원에 대해 심사보류하지 않고 심사를 진행하고 있다. 그 결과 원출원의 특허결정 전이고 원출원을 인용발명으로 하는 선출원주의 위반(法 36②)의 거절이유를 제외한 거절이유를 발견할 수 없는 때에는 분리출원에 대해 특허결정하고 있다.

156) 지식재산청, 「특허·실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025, 5601면 이하 참조.

IV. 심결확정의 효과

1. 인용심결확정의 효과

인용심결의 결과 특허결정 또는 심결이 확정되고 출원인이 특허결정 또는 심결 등본송달일로부터 3개월 이내 최초 3년분의 특허료를 낸 경우 특허권이 발생한다(法 79③, 87①②). 한편 지식재산처장은 존속기간연장등록출원의 연장등록결정이 있으면 특허권 존속기간의 연장을 특허원부에 등록하고 특허공보에 게재하여야 한다(法 92, 92의5).

2. 기각심결확정의 효과

출원인이 기각심결등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내 특허법원에 소를 제기하지 않거나 제기하더라도 종국적으로 그 심결이 지지되어 통상의 불복신청방법으로는 취소할 수 없는 상태로 된 때에 기각심결은 확정된다. 기각심결이 확정되면 취지의 심결이 확정된 것이고, 이로 인해 특허출원절차 또는 연장등록출원절차가 종료된다.

제2절 특허무효심판

제133조 【특허의 무효심판】

- ① 이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016. 2. 29., 2021. 10. 19.>
1. 제25조, 제29조, 제32조, 제36조제1항부터 제3항까지, 제42조제3항제1호 또는 같은 조 제4항을 위반한 경우
 2. 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반한 경우. 다만, 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.
 3. 제33조제1항 단서에 따라 특허를 받을 수 없는 경우
 4. 특허된 후 그 특허권자가 제25조에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우
 5. 조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우
 6. 제47조제2항 전단에 따른 범위를 벗어난 보정인 경우
 7. 제52조제1항에 따른 범위를 벗어난 분할출원 또는 제52조의2제1항 각 호 외의 부분 전단에 따른 범위를 벗어난 분리출원인 경우
 8. 제53조제1항에 따른 범위를 벗어난 변경출원인 경우
- ② 제1항에 따른 심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다.
- ③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제1항제4호에 따라 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 특허권은 그 특허가 같은 호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.
- ④ 심판장은 제1항에 따른 심판이 청구된 경우에는 그 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「특허무효심판」이란 이해관계인 또는 심사관이 유효하게 설정등록된 특허권이 제133조제1항 각호의 특허무효사유에 해당하는 경우 그 특허권의 효력을 소급하여 또는 장래를 향하여 소멸시켜 줄 것을 청구하는 심판을 말한다(法 133).

2. 취 지

심사절차를 거친 이후에도 출원의 하자를 발견하지 못하거나 특허권 설정등록 후에 발생한 새로운 사유로 부실�특허가 존재하는 경우 이러한 하자있는 특허권을 그대로 존속시키는 것은 특허권자를 부당하게 보호하고 산업발전을 저해시키는 결과를 초래하게 된다. 그러므로 특허법은 공중의 피해방지와 행정처분의 적정성과 공정성을 확보하기 위해 특허무효심판제도를 두고 있다.

3. 법적성질

특허무효심결 중 기각심결은 단지 무효가 아님을 확인하는 확인적 행정행위이지만 인용심결은 새로운 법률관계를 형성시키는 형성적 행정행위라 할 수 있다. 특허에 무효사유가 존재한다고 하더라도 그 자체로서 특허가 당연히 무효로 되는 것은 아니며 무효라는 인용심결의 확정에 의해서만 비로소 특허권이 소멸하기 때문이다.¹⁵⁷⁾ 한편 법정무효사유에 해당할 때는 이를 반드시 무효시켜야 한다는 점에서 기속적 행정행위이며 전체적으로 준사법적 행정행위이다.

II. 특허무효사유

1. 주체적 사유

- ① 외국인으로서 특허에 관한 권리를 누릴 수 없는 자가 특허출원한 경우(法 25)
- ② 제33조제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여 제44조를 위반한 경우. 다만 제99조의2제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외한다.

i) 제33조제1항 본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 ii) 제44조의 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하였음에도 불구하고 등록된 특허라 하더라도 특허권의 이전청구에 기초하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록(法 99의2)이 있으면 이전등록된 특허권(특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 경우에는 그 지분의

157) 대법원 1992. 6. 2. 선고 91마540.

이전을 말한다)은 특허무효심판을 청구할 수 있는 대상에서 제외된다(法 133①Ⅱ단서). 이는 이전청구에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에게 이전등록된 특허권이 애초에 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 출원이 아니라는 점을 이유로 무효되는 것을 방지하기 위함이다.

- ③ 지식재산처 직원 및 특허심판원 직원이 상속이나 유증(遺贈)의 경우를 제외하고 재직 중 특허출원한 경우(法 33①단서)

2. 실체적 사유

- ① 특허요건(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성, 소위 확대된 선출원)에 위반된 경우(法 29)
- ② 특허를 받을 수 없는 발명에 해당하는 경우(法 32)
- ③ 선출원 규정(法 36①-③)을 위반한 경우
- ④ 일반적인 발명의 설명의 기재불비의 경우(法 42③Ⅰ)
- ⑤ 청구범위 기재불비의 경우(法 42④)
- ⑥ 신규사항추가인 보정의 경우(法 47②전단)

명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 하여야 한다. 이 경우, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문(제42조의3제6항 전단에 따른 정정이 있는 경우에는 정정된 국어번역문을 말한다) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외한다)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(法 47②). 외국어특허출원(외국어국제특허출원 포함)은 원문(외국어 명세서 또는 도면)과 국어번역문 중 어느 하나의 범위를 벗어난 보정을 하면 거절이유(法 62Ⅴ), 정보제공사유(法 63의2)이다. 다만 특허등록 후에는 제47조제2항전단의 원문 범위를 벗어난 보정만 특허무효사유에 해당한다(法 133①Ⅵ). 국어번역문의 제출은 실체적인 문제라기보다는 심사관과 일반 공중이 정확한 내용을 알기 위한 절차적인 문제에 해당하므로 원문 기준의 보정을 하였다면 국어번역문을 벗어났다고 할지라도 이를 굳이 무효로 시킬 이유가 없다.

- ⑦ 분할출원의 범위를 벗어난 경우(法 52①)

- ⑧ 분리출원의 범위를 벗어난 경우(法 52의2①각호 외의 부분 전단)

1) 분리출원의 명세서 또는 도면에 기재된 발명은 원출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 이내이어야 한다(法 52의2①각호 외의 부분 전단). 또한 분리출원의 청구범위에는 제52조의제1항 각호에 해당하는 특허가능한 청구항만을 적을 수 있다(法 52의2①후단).

2) 분리출원의 명세서 또는 도면의 요건을 만족하지 않거나(法 52의2①각호 외의 부분 전단 위반) 분리출원의 청구범위 요건을 만족하지 않은 경우(法 52의2①후단 위반) 거절이유(法 62Ⅵ), 정보제공사유(法 63의2)이다. 다만 등록 후에는 분리출원의 명세서 또는 도면의 요건을

만족하지 않은 경우(法 52의2①각호 외의 부분 전단 위반)에만 특허무효사유(法 133)이다. 분리출원의 청구범위 요건(法 52의2①후단)은 심사의 신속성을 위해 필요한 규정이어서 등록 후에는 이를 다룰 필요가 없기 때문이다.

⑨ 변경출원의 범위를 벗어난 경우(法 53①)

3. 조약 위반

조약을 위반하여 특허를 받을 수 없는 경우이다. 특허제도의 국제화 경향에 따라 조약, 협정, 약정 등은 특허실체법의 중요한 부분을 구성하고 있으므로 조약을 위반하였는데 특허된 경우를 특허무효사유로 하고 있다.

4. 후발적 무효사유

특허권 설정등록 시에는 무효사유가 존재하지 않았으나 특허된 후에 특허권자가 제25조(외국인의 권리능력)에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자가 되거나 그 특허가 조약을 위반한 경우이다. 예를 들어 특허권자 자신이 국적을 변경한 경우 또는 특허권자가 속한 국가가 산업재산권의 보호에 관한 파리조약을 탈퇴하거나 상호 조약을 폐지한 경우가 이에 속한다.

III. 심판의 요건

1. 청구인·피청구인

(1) 청구인

이해관계인 또는 심사관이 심판을 청구할 수 있다(法 133①). 다만 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하여 제33조제1항 본문을 위반한 경우나 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인데 공동출원하지 아니하여 제44조를 위반한 경우에는 심사관 또는 이해관계인 중 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 청구할 수 있다.

(2) 피청구인

무효심판의 피청구인은 특허권자이다. 특허권자는 현재 특허등록원부에 특허권자로 등록된 자이어야 한다.

2. 청구대상

1) 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 제133조제1항 각호의 무효사유에 해당함을 이유로 청구할 수도 있다(法 133①단서). 즉 일부무효심판의 청구가 가능하다.

2) 한편 특허처분은 하나의 특허출원에 대하여 하나의 특허권을 부여하는 단일한 행정행위

이므로, 설령 그러한 특허처분에 의하여 수인을 공유자로 하는 특허등록이 이루어졌다고 하더라도, 그 특허처분 자체에 대한 무효를 청구하는 제도인 특허무효심판에서 그 공유자 지분에 따라 특허를 분할하여 일부 지분만의 무효심판을 청구하는 것은 허용할 수 없다.¹⁵⁸⁾ 이 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자는 무효심판을 청구하지 않고 무권리자를 상대로 공유 특허권의 지분을 이전을 직접 청구할 수 있다(法 99의2).

3. 청구시기

1) 특허권의 존속기간 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 청구의 이익이 있는 한 특허무효심판을 청구할 수 있다(法 133②). 즉 존속기간의 만료, 특허권의 포기 등 특허권이 장래를 향해 소멸하였다면 특허권이 소멸된 후라도 소멸되기 전의 제3자의 실시에 대해서는 특허권자가 손해배상청구를 할 수 있으므로 특허를 무효시킬 실익이 있다. 이때 제3자가 특허무효심판 청구에 의하여 무효심결이 확정되면 손해배상을 할 필요가 없어진다.¹⁵⁹⁾

2) 다만 특허권이 취소결정확정, 무효심결확정에 의하여 소급하여 소멸한 경우에는 무효로 구할 대상물이 없어서 특허무효심판을 청구할 실익이 없으며 청구한 무효심판은 심결각하된다. 한편 후발적 사유에 의하여 무효가 된 경우에는 그 사유에 해당하게 된 때부터 장래를 향해 특허권이 소멸하므로 소멸되기 전의 것에 대해서는 무효심판을 청구할 수 있다.

IV. 심판의 절차

1. 심판청구서의 제출

심판청구인은 법정사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(法 140①).

2. 부분 송달 및 답변서 제출기회의 부여

심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서

158) 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432. 원심판결인 특허법원 2012. 6. 22. 선고 2011허11750 판결에서는 i) 특허법은 제133조제1항에서 '청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 무효심판을 청구할 수 있다'고 규정하면서도, 공유인 특허권의 일부 지분권에 대하여는 무효심판청구가 가능하다는 취지의 규정을 두고 있지 않고 있는 점, ii) 특허법 제139조제2항은 '공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 전원을 피심판청구인으로 하여 청구하여야 한다'고 규정하는 있는 점, iii) 특허법 제44조, 제62조제1호, 제133조제1항제2호 등의 규정에 의하면, 특허법은 다수가 특허권을 공유하는 경우에도 그 특허권이 일체로서 발생, 소멸하는 것을 전제로 권리관계를 규정하고 있다고 볼 수 있는 점, iv) 특허법 제139조제2항에도 불구하고 공유자 중 일부가 나머지 공유자를 상대로 하는 특허권의 지분권에 대한 무효심판청구를 허용할 경우, 무효심판이 확정된 지분권은 소급적으로 그 효력이 소멸될 뿐이고 무효심판이 확정되지 아니한 다른 지분권의 권리자에게 그 소멸된 지분권이 귀속된다고 보기 어려우며, 소멸된 지분권에 대해서는 권리가 새로이 특허출원을 하더라도 특허법 제44조를 위배한 것이어서 거절결정이 될 수밖에 없게 되는 등 복잡한 문제가 발생하는 점 등을 그 근거로 하고 있다.

159) 특허법원 2007. 8. 22. 선고 2006허10135.

제출기회를 주어야 하며, 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다(法 147①②). 또한 심판장은 무효심판이 청구되었다는 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다(法 133④). 이것은 이러한 자들에게 미리 알려 참가의 기회를 주는 등 등록권리자를 보호하기 위한 규정이다.

3. 특허의 정정청구

특허무효심판절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 i) 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 특허무효심판에 대한 답변서 제출기간(심판장이 답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있는데 그 기간) 또는 심판관의 직권심리에 의한 의견서 제출기간에 정정청구를 할 수 있다(法 133의 2①). 특허가 무효로 될 우려가 있는 경우 무효심결을 회피하기 위해 특허권자에게 정정청구를 인정하고 있다.

4. 심 리

청구인이 신청한 청구취지의 범위에서는 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 이를 심리할 수 있다. 예를 들어 특허무효심판청구인이 청구항 1 내지 청구항 3이 신규성에 위반되어 무효로 되어야 한다는 취지의 무효심판을 청구한 경우 심판관은 신청하지 아니한 청구취지인 청구항 4에 대해서는 직권으로 심리할 수 없지만, 청구항 1 내지 청구항 3이 신규성 위반이 아닌 진보성 위반이라고 할 수 있다. 다만 당사자 또는 참가인이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리하는 경우에는 당사자 및 참가인에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 159).

5. 심 결

(1) 심결내용

심판관은 i) 특허무효사유에 해당되지 아니하여 심판청구의 이유가 타당하지 않다고 인정될 때는 기각심결을 하며, ii) 특허무효사유에 해당되어 심판청구의 이유가 타당하다고 인정될 때는 인용심결을 하여야 한다. 한편 심판관은 특허무효심판을 청구한 여러 청구항 중 일부 청구항에 대해서만 특허무효사유가 있는 경우 일부인용·일부기각심결을 할 수 있다.¹⁶⁰⁾ 다만

160) 특허출원에 있어 청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 그 하나의 항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 전부가 거절되어야 하나, 특허무효심판에 있어서는 청구항마다 무효사유의 유무를 판단하여야 하는바, 청구범위가 2개의 독립항으로 되어 있는 특허발명의 무효심판에 있어서 제1항이 무효

하나의 청구항에 여러 개의 발명이 포함되어 있고 그중 일부가 무효라면 그 청구항 전체를 무효로 하여야 하지 청구항에 포함된 일부 발명만을 무효로 할 수는 없다.¹⁶¹⁾

(2) 심결에 대한 불복

심판의 당사자는 심판장으로부터 심결등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 취소소송을 제기할 수 있다(法 186①).

V. 심결확정의 효과

1. 인용심결확정의 효과

(1) 특허권 및 그에 부수적인 권리의 소멸

1) 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되면 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 133③본문). 따라서 보상금청구권도 처음부터 발생하지 아니한 것으로 보며(法 65⑥), 전용실시권 등 특허권에 부수하는 모든 권리도 소멸하게 된다. 한편 일부인용·일부 기각심결이 확정된 경우에는 인용심결된 부분의 청구항만이 소급하여 소멸한다(法 215).

2) 그러나 후발적 무효사유, 즉 특허된 후에 특허권자가 제25조(외국인의 권리능력)에 따라 특허권을 누릴 수 없는 자가 되거나 그 특허가 조약을 위반하여 무효심결이 확정된 경우에는 그 특허가 무효사유에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다(法 133③단서).

(2) 특허무효심결확정 전에 행해진 특허권을 둘러싼 행위의 법률관계

1) 특허요건의 흠결이 있음에도 착오로 등록된 경우라도 원칙적으로 타인의 특허발명 침해에 대하여 특허권에 기한 민·형사상 조치를 취할 수 있다. 다만 무효심결이 확정된 경우 특허권이 소급하여 소멸하므로 권리침해소송 등 민사소송의 확정판결 혹은 침해죄의 확정판결에 대하여 재심의

라고 하여 제2항도 무효라고 할 수 없다(대법원 2001. 12. 24. 선고 99후2181). 특허요건의 등록 전후에서의 검토 및 처리 단위는 다음과 같다.

구 분	검토	처리	비고
등록 전	발명 단위	출원 단위	심사의 무결성 추구
등록 후	발명 단위	청구항 단위(일부무효)	특허권자의 보호 추구

- 161) 청구범위에 관하여 다항제를 채택하고 있는 우리나라에 있어서 청구범위의 항이 둘 이상인 경우 그 청구범위의 항마다 무효로 할 수 있으나, 이와는 달리 1개의 청구범위의 항의 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등 특허무효의 사유가 있는 경우에는 그 공지기술 등이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 아니하는 한 그 항 전부에 관하여 무효로 하여야 하고, 그 청구범위의 항 중 일부에 관하여만 무효라 할 수는 없다(대법원 1994. 6. 14. 선고 90후1420 등). 예컨대, 청구범위가 【청구항1】…장치, 【청구항2】제1항에 있어서, … 장치, 【청구항3】제1항 또는 제2항에 있어서, …장치와 같이 기재된 사례에서, 청구항 제1항은 진보성이 인정되지 아니하나, 청구항 제2항은 그 특징부에 의하여 진보성이 인정되고, 청구항 제3항 중 제1항을 인용하는 부분은 진보성이 인정되지 아니하고 그 부분이 청구항 제3항 중 제2항을 인용하고 있는 부분과 유기적으로 결합되었다고 볼 수도 없으므로, 결국 청구항 제3항은 전부 무효로 된다(특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 122면).

소를 제기할 수 있다(民訴法 451①, 刑訴法 420⑥). 한편 특허권자가 무효심결의 확정 전에 특허권을 행사하여 고의 또는 과실로 타인에게 손해를 입혔으면 그 손해를 배상하여야 하며, 고의 또는 과실에 의하지 아니한 때에도 부당이득은 반환하여야 한다.

2) 다만 특허가 무효임이 명백한데도 다른 절차에서 그 특허의 권리행사를 인정하여야만 한다면 오로지 침해 여부에만 관심을 갖는 당사자에게 공익의 대표자로서 특허무효심판을 청구할 것을 강요하는 결과가 될 뿐만 아니라 절차가 부당하게 지연되는 등의 문제점이 있어 학설과 판례는 일정한 경우에 특허권의 권리범위나 그 행사를 제한하는 방법 등으로 합리적인 해결을 모색하고 있다.

(3) 특허무효심결확정 후 재심이 있는 경우의 법률관계

무효가 된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우에 특허권의 효력은 해당 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 i) 선의로 수출 또는 수입하거나 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건, ii) 선의의 실시행위 및 iii) 선의의 간접침해행위 중 어느 하나에 대해서는 미치지 아니한다(法 181). 또한 무효가 된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우에 해당 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 무상의 통상실시권(소위 後用權)을 갖는다(法 182).

(4) 기 타

① 무권리자의 특허에 대한 정당한 권리자의 출원

무권리자의 특허가 무효심결이 확정된 경우 그 날로부터 30일 이내 정당한 권리자의 출원이 있으면 정당한 권리자의 출원일은 무권리자의 출원일로 소급한다(法 35).

② 특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권

다음의 어느 하나에 해당하는 자가 특허권의 이전청구에 기초하여 특허권의 이전등록이 있기 전에(法 99의2②) 해당 특허가 제33조제1항 본문의 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 제44조를 위반하여 특허무효사유(法 133①Ⅱ)에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 해당 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비를 하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대하여 유상의 통상실시권을 가진다(法 103의2).

i) 이전등록된 특허의 원(原)특허권자

ii) 이전등록된 특허권에 대하여 이전등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자(다만 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다)

③ 중용권의 발생

1) 특허에 대한 무효심판청구 등록 전에 제104조제1항 각호에 해당하는 자가 자기의 특허발명이 무효사유에 해당하는 것을 알지 못하고 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를

준비하고 있는 경우에는 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 유상의 중용권을 가진다(法 104).

2) 여기서 「제104조제1항 각호에 해당하는 자」란 i) 동일한 발명에 대한 둘 이상의 특허 중 그 하나의 특허를 무효로 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자, ii) 특허발명과 등록 실용신안이 동일하여 그 실용신안등록을 무효로 한 경우 그 무효로 된 실용신안등록의 원(原) 실용신안권자, iii) 특허를 무효로 하고 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 특허의 원특허권자, iv) 실용신안등록을 무효로 하고 그 고안과 동일한 발명에 관하여 정당한 권리자에게 특허를 한 경우 그 무효로 된 실용신안의 원실용신안권자 및 v) 제1호부터 제4호까지의 경우에 있어서 그 무효로 된 특허권 또는 실용신안권에 대하여 무효 심판청구 등록 당시에 이미 전용실시권이나 통상실시권 또는 그 전용실시권에 대한 통상실시권을 취득하고 등록을 받은 자(다만 제118조제2항에 따른 통상실시권을 취득한 자는 등록을 필요로 하지 아니한다)를 말한다.

3) 즉 특허무효사유 중 신규성(法 29①각호), 선출원주의(法 36), 확대된 선출원(法 29③④) 및 특허를 받을 수 있는 자(法 33①본문) 중 어느 하나에 해당하는 위반의 경우에 중용권(法 104)이 발생한다.¹⁶²⁾

④ 실시(금지) 계약의 효력

1) 특허권자와 실시권자 사이에 실시계약(실시권 허락 계약)에서 실시료 불반환 합의와 같은 특약이 없는 경우 무효심결이 확정되었을 때 실시권자가 특허권자에게 지급된 실시료를 부당 이득으로써 반환청구할 수 있는지와 관련하여 견해의 대립¹⁶³⁾이 있었으나, 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666, 42673 판결은 “특허발명 실시계약에 의하여 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없게 될 뿐만 아니라 특허가 무효로 확정되기 이전에 존재하는 특허권의 독점적·배타적 효력에 의하여 제3자의 특허발명 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를

162) 私見으로는 중용권의 취지가 등록된 것을 믿고 실시한 자를 보호하는 것이라면 제한된 무효사유에 한해서만 중용권을 인정하는 것은 입법불비라고 보여진다.

163) i) 실시료를 지불한 자가 발명을 실시하여 이익을 얻은 경우 실시료를 지불하였다고 하더라도 손해입은 것이 아니므로 부당이득의 법리를 적용할 것이 아니라는 견해(전효남, 「특허법」, 제9판, 법경사, 2003, 697면), ii) 실시자가 발명의 실시로 인해 얻은 이익은 누구나 실시할 수 있는 공공영역(public domain)의 실시로 인해 얻은 이익이므로 부당이득반환청구를 할 수 있는 견해(이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 907면; 황중환, 「특허법」, 제9판, 한빛지적소유권센터, 2004, 733면; 이종완, 「특허법론」, 대한변리사회, 2004, 900면), iii) 실시권자는 특허가 무효로 되기 전까지는 실시권에 의하여 경쟁에서 보호 내지는 이익을 받고 있었으므로 실시료 상당의 손해를 입었다고 단정하기는 어렵다는 점을 고려하면, 특허권자가 자신의 특허가 명백히 무효라거나 유명무실한 사정을 알고 있었다는 등의 사정이 있었고, 그와 같은 사정 때문에 실시권자가 아무런 보호를 받지 못했다는 특별한 사정이 없는 한 부당이득 반환의무는 이를 부정하여야 한다는 견해(최정열, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 399면) 등이 있었다.

대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 앞서 본 바와 같이 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다”라고 판시하여 무효심결확정된 때부터 계약이 이행불능 상태이기 때문에 특별한 사정이 없는 한 부당이득의 반환 의무를 부정하였다. 또한 대상판결에서는 특허가 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 고려할 때, 계약체결 이후 무효로 확정되었더라도 그 특허의 유효성이 계약체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수 없다고 하였다. 한편 동일한 판단법리를 적용하여 대법원 2019. 4. 25. 선고 2018다287362 판결에서는 무효심결이 확정되더라도 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 실시료의 지급을 청구할 수 있다고 판시하였다.

2) 한편, 특허권자와 제3자 사이의 실시금지계약도 동일한 법리가 적용된다. 이 계약도 특허가 무효로 확정된 때부터 이행불능 상태에 빠지게 되므로 특허발명 실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 위 계약에 따른 특허발명 실시금지의무가 유효하게 존재하는 기간 동안 특허발명을 실시한 계약상대방에 대하여 채무불이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다. 이때 계약상대방이 특허발명을 실시한 구체적인 형태가 자유실시기술에 해당한다고 하더라도, 그러한 사정만으로 계약상대방이 특허권자와의 의사 합치에 따른 특허발명 실시금지계약의 구속력에서 벗어나게 된다고 볼 수는 없다.¹⁶⁴⁾

2. 기각심결확정의 효과

기각심결이 확정된 경우에 특허권은 유지된다. 이 경우 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일한 무효심판을 청구할 수 없으며 동일한 무효심판을 청구하면 심결각하된다(法 163). 이때 전부무효심판과 일부무효심판은 동일한 심판으로 본다.

¹⁶⁴⁾ 대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105.

【표 7-5】 정보제공과 특허무효심판의 비교

제 도		정보제공(法 63의2)	특허무효심판(法 133)
서	의 의	특허출원이 있으면 누구든지 해당 발명이 法 제62조 각호의 거절이유(단, 法 42③II·42⑧·45 제외)에 해당되어 특허될 수 없다는 취지의 정보를 증거와 함께 지식 재산처장에게 제공할 수 있는 제도를 말한다.	유효하게 설정등록된 특허권이 제133조제1항 각호의 무효사유에 해당하는 경우 이해관계인 또는 심사관의 심판청구에 의한 심판절차에 의하여 그 특허권의 효력을 소급하여 또는 장래를 향하여 소멸시킬 수 있는 제도를 말한다.
	취 지	심사관에 의한 심사의 신속성 및 정확성을 높여 심사의 질적 향상에 기여	하자있는 권리를 소멸시켜 공중의 피해방지와 행정처분의 적정성과 공정성을 확보
요건	주 체	누구든지	■ 이해관계인 또는 심사관 ■ 단, 제33조제1항 본문 위반, 제44조 위반은 이해관계인일지라도 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만이 청구 가능
	시 기	출원 계속 중 (거절결정불복심판단계에서도 가능)	특허권의 존속기간 중에는 물론 특허권이 장래를 향해 소멸된 후라도 가능
	대 상	출원된 발명	설정등록된 특허발명
	사유	공통점	■ 주체적 사유 외국인의 권리능력(法 25), 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는 자(法 33①본문), 특허를 받을 수 없는 자(法 33①단서), 공동출원(法 44) ■ 실체적 사유 산업상 이용가능성(法 29①본문), 신규성(法 29①각호), 진보성(法 29②), 확대된 선출원(法 29③④), 불특허발명(法 32), 선출원주의(法 36), 일반적인 발명의 설명 기재(法 42③I), 청구범위 기재(法 42④), 신규사항추가금지(원문의 범위를 벗어난 경우)(法 47②전단), 분할출원의 범위를 벗어난 경우(法 52①), 분리출원의 범위를 벗어난 경우(法 52의2①각호 외의 부분 전단), 변경출원의 범위를 벗어난 경우(法 53①) ■ 조약에 위반된 경우
		차이점	■ 신규사항추가금지(외국어특허출원, 외국어국제특허출원의 번역문의 범위를 벗어난 경우)(法 47②후단) ■ 분리출원의 경우 청구범위의 요건(法 52의2①후단) 후발적 무효사유(法 133④IV)
절차 / 효과	심사(심리) 주체	심사관이 단독으로 참고	3명 또는 5명의 심판관 합의체가 심리
	심사(심리) 구조	당사자 지위×. 제공 자료를 심사에 활용하여야 한다는 의무×	특허무효심판청구인과 특허권자의 대립구조
	제3자의 지위	법률상 응답할 의무×, 실무상 정보제공자에게 통보	결정 또는 심결로 응답
	불 복	불복불가	심결(결정)등본 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내 특허법원에 심결취소소송 제기하여 불복 가능

제3절 특허권의 존속기간연장등록무효심판

제134조 【특허권 존속기간의 연장등록의 무효심판】

- ① 이해관계인 또는 심사관은 제92조에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2025. 1. 21.>
1. 특허발명을 실시하기 위하여 제89조에 따른 허가 등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
 2. 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조에 따른 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
 3. 연장등록에 따라 연장된 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하는 경우
 4. 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
 5. 제90조제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
 6. 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우
- ② 이해관계인 또는 심사관은 제92조의5에 따른 특허권의 존속기간의 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 무효심판을 청구할 수 있다.
1. 연장등록에 따라 연장된 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우
 2. 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
 3. 제92조의3제3항을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 심판의 청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다.
- ④ 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 연장등록이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다. <개정 2025. 1. 21.>
1. 연장등록이 제1항제3호에 해당하여 무효로 된 경우: 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간
 2. 연장등록이 제2항제1호에 해당하여 무효로 된 경우: 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간
- ⑤ 연장등록이 제1항제6호에 해당하여 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 본다. <산설 2025. 1. 21.>

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「특허권의 존속기간연장등록무효심판」이란 이해관계인 또는 심사관이 존속기간이 연장등록된 특허권이 제134조제1항 또는 제2항 각호의 무효사유에 해당하는 경우 그 연장등록의 효력을 소급하여 소멸시켜 줄 것을 청구하는 심판을 말한다(法 134). 특허무효심판은 특허권 자체의 무효를 청구하는 심판이지만, 특허권의 존속기간연장등록무효심판은 원래의 특허권의 존속기간은 인정하되 연장된 존속기간만을 무효시키는 점에서 차이가 있다.

2. 취 지

존속기간연장등록출원의 심사에 대한 사후적 보장제도로서 선의의 제3자를 보호하는 한편

부당한 연장등록을 규제 및 정리하여 산업발전에의 이바지라는 특허제도의 목적에 부합하기 위해 특허권의 존속기간연장등록무효심판 제도를 두고 있다.

II. 연장등록무효사유¹⁶⁵⁾

- 1) 허가 등에 따른 특허권 존속기간의 연장등록무효사유(法 134①)는 다음과 같다.
 - i) 그 특허발명을 실시하기 위하여 제89조에 따른 허가 등을 받을 필요가 없는 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
 - ii) 그 특허권자 또는 그 특허권의 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가진 자가 제89조에 따른 허가 등을 받지 아니한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
 - iii) 연장등록에 따라 연장된 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하는 경우
 - iv) 해당 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
 - v) 제90조제3항(특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 출원)을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
 - vi) 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우
- 2) 등록지연에 따른 특허권 존속기간의 연장등록무효사유(法 134②)는 다음과 같다.
 - i) 연장등록에 따라 연장된 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과한 경우
 - ii) 특허권자가 아닌 자의 출원에 대하여 연장등록이 된 경우
 - iii) 제92조의3 제3항(특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 출원)을 위반한 출원에 대하여 연장등록이 된 경우

III. 심판의 요건

1. 청구인·피청구인

청구인은 이해관계인 또는 심사판이다(法 134①). 피청구인은 현재 특허등록원부에 등록된 특허권자이다.

2. 청구대상

특허무효심판은 청구범위의 청구항이 둘 이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있으나(法 133①후단), 존속기간연장등록무효심판의 청구대상은 「연장등록」 자체이다.

165) 연장등록 무효사유(法 134①②)는 연장등록출원의 거절이유(法 91, 92의4)와 동일하다.

3. 청구시기

특허권의 존속기간이 연장등록된 후 언제든지 청구할 수 있음은 물론 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다(法 134③ 준용 133②). 특허권이 소멸된 후라도 소멸되기 전의 제3자의 실시에 대해서는 특허권자가 권리행사를 할 수 있으므로 연장등록을 무효로 시킬 실익이 있다. 다만 연장등록무효심판에 의하여 연장등록된 존속기간이 소급하여 소멸한 경우나 원래의 존속기간이 만료될 때까지 특허권이 유지되지 아니한 사유가 발생한 경우에는 청구할 수 없다.¹⁶⁶⁾

IV. 심판의 절차

1. 심판청구서의 제출

심판청구인은 법정사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(法 140①).

2. 부분 송달 및 답변서 제출기회의 부여

심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회를 주어야 하며, 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다(法 147①②). 또한 심판장은 무효심판이 청구되었다는 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다(法 134③ 준용 133④). 이것은 이러한 자들에게 미리 알려 참가의 기회를 주는 등 등록권리자를 보호하기 위한 규정이다.

3. 심 리

심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다(法 154①). 구체적 내용은 특허무효심판의 경우와 동일하다.

4. 심 결

(1) 심결내용

심판관은 i) 특허권의 존속기간연장등록무효사유에 해당되지 아니하여 심판청구의 이유가 타당하지 아니한다고 인정된 때는 기각심결을 하며, ii) 특허권의 존속기간연장등록무효사유에 해당되어 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때는 인용심결을 하여야 한다.

166) 원래의 존속기간이 만료될 때까지 특허권이 온전히 유지되지 않는다면 연장된 존속기간의 특허권도 같이 소멸된 것으로 이해된다. 따라서 원래의 존속기간이 만료되기 전 특허료 불납, 특허권의 포기, 상속인 부존재, 무효심결의 확정, 취소결정의 확정으로 특허권이 소멸되었으면 연장된 존속기간의 특허권도 같이 소멸되므로 연장등록무효심판을 청구할 실익이 없는 것이다.

(2) 불 복

심판의 당사자는 심판장으로부터 심결등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 취소소송을 제기할 수 있다(法 186①).

V. 심결확정의 효과

1. 인용심결확정의 효과

1) 연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 해당 기간에 대해서만 연장이 없었던 것으로 본다(法 134④).

- i) 허가 등에 따라 특허권의 존속기간이 연장등록되었는데, 연장등록에 따라 연장된 기간이 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 무효로 된 경우에는 제89조에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간¹⁶⁷⁾
- ii) 등록지연에 따라 특허권의 존속기간이 연장등록되었는데, 연장등록에 따라 연장된 기간이 제92조의2에 따라 인정되는 연장기간을 초과하여 무효로 된 경우에는 제92조의2에 따라 인정되는 연장의 기간을 초과하여 연장된 기간

2) 한편 연장등록이 제90조제7항을 위반하여 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우에 해당하여 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허권의 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 134⑤). 이는 복수의 특허권에 대해 무효심판이 청구된 경우 모든 특허권이 무효로 되는 경우가 발생할 수 있으므로 이를 보완함으로써 특허권자의 피해를 최소화하려는 것이다. 구체적으로 지식재산처의 착오로 복수의 연장등록출원이 등록결정되어 이해관계인 등이 무효심판을 청구할 때 출원인이 등록결정된 복수의 특허권 중 하나를 선택하여 등록결정을 유지하고자 하는 경우 출원인이 선택한 하나의 특허권에 대해서만 무효심판단계에서 적극적으로 대응하고, 나머지 특허권에 대해서는 대응을 하지 않으면 나머지 특허권은 모두 무효가 되고(法 134④), 제134조제5항에 의해 연장등록출원의 지위도 없어지게 된다. 그 결과 출원인이 선택한 특허권은 무효사유가 없어지게 되어 최종적으로 연장등록결정이 유지가 될 수 있다.¹⁶⁸⁾

167) 예를 들어 불실시 기간이 3년이었는데 연장등록된 기간이 5년인 경우에는 2년의 기간은 연장이 없었던 것으로 본다. 그 밖의 인용심결확정의 효과는 특허무효심판의 인용심결확정의 효과와 거의 동일하다.

168) 박희석 수석전문위원, “특허법 일부개정법률안 심사보고서(고동진 의원 대표 발의(의안번호 2204182))”, 산업통상자원중소벤처기업위원회, 2024.12. 22면.

2. 기각심결확정의 효과

기각심결이 확정된 경우에 연장등록된 특허권은 유지된다. 이 경우 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일한 특허권의 존속기간연장등록무효심판을 청구할 수 없으며 동일한 특허권의 존속기간연장등록무효심판을 청구하면 심결각하된다(法 163).

제4절 권리범위확인심판

제135조 【권리범위 확인심판】

- ① 특허권자 또는 전용실시권자는 자신의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ② 이해관계인은 타인의 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다. <신설 2016.2.29.>
- ③ 제1항 또는 제2항에 따른 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「권리범위확인심판」이란 특허발명의 보호범위, 즉 확인대상발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말한다)과의 관계에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확인하기 위하여 청구하는 심판을 말한다(法 135). 권리범위확인심판은 단순히 특허발명 자체 발명의 범위라고 하는 「사실관계」를 확정하는 것이 아니라, 구체적으로 문제된 실시 형태에 대하여 특허권의 효력이 미치는지를 확인하는 「권리관계」의 확정을 목적으로 한다.¹⁶⁹⁾

2. 취 지

무체적인 특허권의 내용은 추상적이고 권리의 한계를 명확하게 확정을 지을 수 없으므로 보호범위(권리범위)가 문제가 되어 당사자 간의 분쟁이 생긴다. 특허권자는 자기의 권리범위를 최대한 넓게 해석하려고 하지만, 제3자는 그 권리범위를 축소하여 제한적으로 해석하려고 하기 때문이다. 권리범위확인심판제도는 특허권을 둘러싼 이러한 당사자 간의 분쟁에 있어서 기술 전문가로 구성된 심판관 합의체에 의하여 미리 보호범위, 즉 특허권의 효력이 미치는 범위를 확인하여 복잡한 소송절차에 앞서서 분쟁을 조기해결하고, 침해소송에서 법원의 판단기준을 제공하는 데에 그 취지가 있다.

169) 대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431; 1991. 3. 27. 선고 90후373 등.

3. 법적성질

권리범위확인심판의 법적 성질에 대해서는 「형성행위설」과 「확인행위설」의 대립이 있으나 권리범위확인심판은 특허권을 특정대상물과 대비하여 특허발명의 보호범위의 한계를 확인함으로써 분쟁을 해결·조정함에 그 목적이 있고 새로운 권리관계를 형성시키려는 것이 아니므로 「확인행위설」이 타당하다.

4. 종 류

(1) 대상에 따른 종류

대상에 따라 i) 권리 대 비권리 간의 권리범위확인심판과 ii) 권리 대 권리의 권리범위확인심판이 있다.

(2) 청구방식에 따른 종류

청구방식에 따라 확인대상발명의 실시가 i) 자신의 특허발명의 권리범위에 「속한다」는 심결을 구하는 적극적 권리범위확인심판과 ii) 타인의 특허발명의 권리범위에 「속하지 아니한다」는 심결을 구하는 소극적 권리범위확인심판이 있다.

II. 심판의 요건

1. 청구인·피청구인

(1) 적극적 권리범위확인심판

적극적 권리범위확인심판(法 135)은 특허권자, 전용실시권자가 청구인이고, 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 이해관계인이 피청구인이다.

(2) 소극적 권리범위확인심판

소극적 권리범위확인심판에서는 과거에 확인대상발명을 실시한 적이 있거나 현재 실시하고 있는 자뿐만 아니라 실시하고 있지 않다고 하더라도 실시할 예정이 있는 이해관계인이 청구인이고, 특허권자가 피청구인이다.

2. 청구대상

청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있다(法 135③).

3. 청구시기

대법원¹⁷⁰⁾은 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로 특허권이 소멸된 후에는 확인의 이익이 없다고 하여 특허권의 존속기간 중에만 가능하다고 하고 있다. 다만 특허권이 소급하여 소멸하는 경우와 장래를 향해 소멸하는 경우는 구별될 필요가 있다. 특허권이 장래를 향해 소멸하였다면 소멸된 후라도 특허권자가 소멸되기 전의 실시에 대해 손해배상청구 등을 할 수 있어서, 이에 대한 확인의 이익이 있을 수 있기 때문이다. 따라서 일괄적으로 확인의 이익이 없다는 대법원의 입장은 적절하지 않은 것으로 사료된다.

Ⅲ. 심판의 절차

1. 심판청구서의 제출

(1) 청구서의 제출

심판청구인은 법정사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(法 140①). 이때 특허발명과 대비할 수 있는 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다(法 140③). 설명서에는 특허발명과 확인대상발명의 구체적인 대비표를 적어야 한다(施規 57③ I).¹⁷¹⁾

(2) 보 정

확인대상발명은 권리범위확인을 구하는 청구취지의 일부를 구성하므로 요지변경이 되지 아니하는 범위내에서만 가능하다(法 140②). 다만 특허권자 또는 전용실시권자가 청구인으로서 청구한 권리범위 확인심판에서 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명(실시주장발명)과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우에는 요지변경이 되더라도 허용된다(法 140②Ⅲ).

2. 부분 송달 및 답변서 제출기회의 부여

심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회를 주어야 하며, 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다(法 147①②).

170) 특허권의 권리범위확인심판의 청구는 현존하는 특허권의 범위를 확정하려는 데 그 목적이 있으므로, 특허권이 무효로 되었다면 그에 대한 권리범위확인을 구할 이익이 없어지고, 나아가 권리범위확인심판의 심결 이후에 특허권이 무효로 된 것이라면 그 심결을 취소할 법률상 이익도 소멸된다(대법원 2008. 6. 26. 선고 2007후4120 판결, 대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결 등 참조).

171) 다만 확인대상발명의 설명서에 대비표를 기재하지 않더라도 청구이유와 설명서를 전체적으로 참작하여 특허발명의 구성과 대비되는 확인대상발명의 구성을 특정하는 데 별다른 어려움이 없다면 보정을 명하지 않고 심리를 진행할 수 있다(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 539면).

3. 심 리

(1) 원 칙

1) i) 특허발명의 특성과 ii) 확인대상발명의 특성을 한 후, iii) 특허발명과 확인대상발명을 대비하여 구성요소완비의 원칙과 균등론을 적용함으로써 특허발명의 실시인지 판단하고 iv) 법률의 제한 및 확장을 고려하여 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는지를 판단한다. 특허발명은 청구범위를 중심으로 발명의 설명·도면의 참작과 함께 출원 당시의 기술수준, 출원 경과 및 특허권 하자 등을 참작하여 특정하여야 한다. 특허권의 하자과 관련하여, 권리범위확인심판 또는 침해소송에서 특허권의 권리의 대항을 받는 실시자가 할 수 있는 항변으로는 무효의 항변(특허권 하자의 항변)이 있다. 「무효의 항변」이란 특허발명이 i) 공지기술과 동일하여 신규성 위반이거나 ii) 선행특허와 동일하여 선출원주의, iii) 확대된 선출원에 위반 또는 iv) 특허발명이 명세서의 기재불비 등으로 인하여 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우이거나 v) 실시가 불가능한 경우이기 때문에 무효심판 여부와 관계없이 특허권의 권리범위를 인정할 수 없어 특허권의 효력이 미치지 아니함을 이유로 항변하는 것을 말한다. 한편 제3자는 특허권의 권리범위를 부정하지 않고, 확인대상발명의 실시가 공공영역에 속한다는 자유기술의 항변을 할 수도 있다. 「자유기술의 항변」이란 확인대상발명이 공지기술이거나 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 기술이기 때문에 특허발명과는 대비할 필요도 없이 특허권의 효력이 미치지 아니함을 이유로 항변하는 것을 말한다.¹⁷²⁾ 자유기술의 범위에서 확인대상발명의 구성은 특허발명과 대응되는 부분의 구체적인 구성 이외에 대응되지 아니한 구성을 포함한 설명서 및 도면에 기재된 구성 전체를 말하는 것이다.¹⁷³⁾ 다만 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하는 항변¹⁷⁴⁾, 권리소진이 적용되거나 실시권이 있어서

172) 권리범위확인심판은 침해의 성립요건 중 보호범위에 속하는지 여부를 심리범위로 하지만, 침해소송은 침해의 성립요건 전체와 침해가 성립됨을 전제로 권리행사를 할 수 있는지 여부를 심리범위로 한다. 그 결과 권리범위확인심판과 침해소송에서 제3자가 할 수 있는 항변은 차이가 있으며, 주요한 항변을 비교하면 다음과 같다.

제3자의 항변	침해소송	권리범위확인심판
특허권 당연무효의 항변	불인정	불인정
실시권의 항변	인정	불인정
권리소진의 항변	인정	불인정
업이 아니라는 항변	인정	불인정
특허권 하자(무효)의 항변	인정	인정
자유기술의 항변	인정	인정
효력 제한(法 81의3④, 96, 181)의 항변	인정	인정
권리남용의 항변	인정	불인정

173) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64.

174) 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에 별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할 수 있도록 규정하고 있으므로, 특허는 일단 등록이 되면 비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수는 없다. 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심

권리범위에 속하지 않는다는 항변은 인정되지 아니 된다.¹⁷⁵⁾¹⁷⁶⁾

2) 확인대상발명이란 권리범위확인심판에서 특허발명의 권리범위에 속하는지의 판단대상이 되는 구체적인 실시형태를 말하며, 침해소송에서는 대상 제품, 피고 제품, 피고 실시제품 등으로 표시된다. 확인대상발명은 대상물을 주관적으로 가공하여 심판청구서에 첨부된 설명서 또는 도면에 의하여 기재되고, 청구취지의 일부를 구성한다.¹⁷⁷⁾ 이하 확인대상발명의 특정 정도,

판은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에 속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그 절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은 특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을 벗어나고 그 제도의 본질에 맞지 않다. 특허법이 심판이라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로 특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여 진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할 수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는 것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도 바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안된다. 다만 대법원은 특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우까지 청구범위에 기재되어 있다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다고 보고 있으나(대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결 등 참조), 이러한 법리를 공지공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것뿐이어서 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다. 위와 같은 법리는 실용신안의 경우에도 마찬가지로 적용된다. 이와 달리 특허발명 또는 등록실용신안이 신규성은 있으나 진보성이 없는 경우 이에 관한 권리범위확인심판에서 당연히 그 권리범위를 부정할 수 있다는 취지로 판시한 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결, 대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1468, 1475(병합) 판결, 대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699 판결, 대법원 1998. 2. 27. 선고 97후 2583 판결 등을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결). 한편 대법원은 특허권침해소송에서 특허권자의 침해금지 또는 손해배상 등의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다는 법리를 선언한 바 있다(위 2010다95390 전원합의체 판결 참조). 그런데 특허권침해소송에서 권리남용의 항변을 받아들여 특허권 침해를 부정하는 것은 권리의 부존재나 무효가 아닌 권리행사의 제한사유를 이유로 하여 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 판단하는 것이고, 그 판결의 효력도 소송 당사자 사이에서만 미친다. 반면에 권리범위확인심판은 어디까지나 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 대세적으로 확인하는 제한적인 의미를 가질 뿐 특허권침해를 둘러싼 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확인해주는 것이 아니고, 그 심결이 확정되면 심판의 당사자뿐만 아니라 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치는 대세적 효력을 가진다. 따라서 특허권침해소송에서 권리남용의 항변의 내용으로서 진보성이 없다는 주장을 인정하더라도 이는 특허의 대세적 효력을 특허무효심판에 의해서만 부정할 수 있도록 한 특허법의 기본 구조와 상충되지 않지만, 심결에 대세적 효력이 있는 권리범위확인심판에서 진보성 결여를 이유로 무효사유 주장을 인정하게 되면 이는 위와 같은 특허법의 기본 구조와 상충된다. 그러므로 권리범위확인심판에서는 특허권 침해소송에서와는 달리 진보성 여부를 특허무효사유로 주장할 수 없고, 이로 인하여 권리범위확인심판과 특허권침해소송에서의 결론이 마치 상반되는 듯이 보인다고 하여 서로 모순될 수 없다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체).

175) 대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24; 2010. 12. 9. 선고 2010후289.

176) 소극적 권리범위확인심판을 청구하면서 권리소진이나 실시권의 존재를 그 이유로 한 경우에는 확인의 이익이 없어서 각하되어야 한다.

177) 통상적으로 청구범위는 기술적 사상의 창작을 문자로 표현한 것이어서 확인대상발명, 즉 현실적인 침해 물건이나 침해 방법을 그 자체로서 대비하는 것은 불가능하다. 따라서 특허발명과 침해 물건이나 침해 방법을 비교하여 그 권리범위의 귀속 여부를 판단하기 위해서는 침해 물건이나 침해 방법에 존재하는 기술적 사상을 정확히 파악하여 이를 문장화하여 묘사함으로써 특정하여야 하는 것이다(강기중, “특허

설명서 또는 도면의 해석을 통한 확인대상발명 특정 여부의 판단, 확인대상발명 특성의 증명 책임 등에 대하여 자세히 살펴본다.

(2) 확인대상발명의 특정 정도

① 청구취지와 청구원인으로서 특성의 구별

1) 침해소송에서 청구취지에는 원고 승소 시에 판결의 주문에 적을 것을 표시하는 것으로서, 원고가 어떠한 대상에 대하여 어떠한 종류(이행확인·형성)와 내용의 판결을 구하는가가 간결하고 명확하게 기재되어야 하고,¹⁷⁸⁾ 청구원인에는 원고의 청구취지를 이유있게 하기 위하여 원고가 주장증명할 사실관계를 적는다. 실무상 침해소송에서 원고가 소장 말미에 침해 제품의 구성이 설명서 및 도면으로 표현된 ‘침해 제품목록’ 등을 별지로 첨부하여 이를 청구취지에서 인용하여 침해 제품의 특징에 이용함과 동시에, 청구원인사실에서도 인용하여 이를 특허발명의 구성과 대비하는 방식이 일반적으로 사용되고 있다. 그런데 이러한 청구취지로서의 침해 제품의 특징과 청구원인으로서 침해 제품의 특징은 구별되어야 한다. 청구취지로서의 특징은 기판결의 객관적 범위, 집행력의 범위를 정하는 것과 동시에 특허권침해를 이유로 하는 손해배상청구권 등에 대한 소의 제기에 의하여 소멸시효중단의 효력이 미치는 범위를 정한다는 점에서 의미가 있는 반면, 청구원인으로서의 특징은 특허발명의 구성과 침해 제품의 구성을 비교하여 권리침해의 여부를 판단하기 위한다는 점에서 의미를 갖는다.

2) 권리범위확인심판에서는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하도록 법률에 규정되어 있고(法 140③), 판결의 집행 문제가 발생하지 않는다는 점 등에서 침해소송에서의 침해 제품의 특징과는 다른 측면이 있다.¹⁷⁹⁾ 그러나 권리범위확인심판에서도 침해소송과 마찬가지로 청구취지에 있어서 확인대상발명의 특징과 청구원인에 있어서 확인대상발명의 특징을 구별할 필요가 있다. 양자의 구별실익은 청구취지로서 특징이 명확하다면 일사부재리의 효과가 미치는 범위가 명확하므로 청구원인으로서 특징이 다소 불명확하다고 할지라도 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 각하심결하지 않고 본안심결을 할 수 있다는 점이다.¹⁸⁰⁾ 다만 청구취지로서 특징이 불명확하다면 침해소송과 마찬가지로 특허심판원에서는 요지변경이 되지 아니한 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 하여야 할 것이고, 그런데도 그와 같은 특징에 미흡함이 있다면 심판의 심결이

발명의 권리범위확인심판 청구에 있어서 심판청구의 대상이 되는 (가)호 발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다고 한 사례”, 대법원판례해설 제41호, 법원도서관, 2002, 516면).

178) 대법원 1981. 9. 8. 선고 80다2904.

179) 이현, “특허권침해로 인한 특허법위반 사건에서의 공소사실 특정 여부에 관한 판단 기준”, 대법원판례해설 제108호, 법원도서관, 2016, 337면.

180) 확인대상발명의 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상발명의 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명은 특정된 것으로 보아야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296 판결 등 참조)(대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291).

확정되더라도 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라도 심판청구를 각하하여야 한다.¹⁸¹⁾¹⁸²⁾

② 청구취지로서의 특정

청구취지에서의 확인대상발명의 특징은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있도록 기재되어야 한다.¹⁸³⁾ 확인대상발명을 식별할 수 있는 제품명, 제품번호 등이 있는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 이를 기재하는 것만으로도 확인대상발명을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정한 것으로 볼 수 있다. 또한 설명서 및 도면(사진) 등을 이용하여 확인대상발명의 구성을 기재하는 방법 역시 확인대상발명을 구체적으로 특정하는 방법으로서 적절하다고 할 것이다. 이때 확인대상발명의 특징을 위해서 특허발명의 구성과 대응되는 부분의 구성을 명확하게 기재하여야 한다.¹⁸⁴⁾ 다만 확인대상발명의 특정 방법은 일률적으로 정하기 어렵고, 요구되는 특정의 정도도 사안에 따라 달라질 수 있으므로, 확인대상발명을 특정하는 방법이 반드시 위에서 언급한 방법들로 제한된다고 보기 어렵다.

③ 청구원인으로서의 특정(원칙)

1) 청구원인에서의 확인대상발명의 특징은 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 기재하여야 한다. 이는 특허발명의 구성과 확인대상발명의 구성을 비교하여 권리범위에 속하는지 여부를 판단하기 위한 것이기 때문이다.¹⁸⁵⁾ 일반적으로 특허발명의 구성과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 대응되는 부분의 구체적인 구성이 기재된 경우에 충분히 서로 대비할 수 있을 정도로 특정한 것으로 볼 수 있다.¹⁸⁶⁾ 다만 권리범위에 속하는지 판단할 수 없게 모호하게 기재되어 있거나¹⁸⁷⁾ 확인대상발명의 특정결과에 따라 결론이 달라질 때는 청구원인으로서 특정되었다고 할 수 없다.¹⁸⁸⁾ 한편 소극적 권리범위확인심판의

181) 전지원, “확인대상발명의 특정”, 대법원판례해설 제90호, 법원도서관, 2011, 717-718면 참조.

182) 대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356.

183) 침해소송에서도 마찬가지이다. 관련 판결을 살펴보면, 특허권침해금지의 소에서 금지청구의 대상이 되는 침해 제품의 특정과 관련하여 대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090 판결은 “민사소송에서 청구취지는 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하므로, 특허권에 대한 침해의 금지를 청구하는 경우 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다”라고 하여 청구취지로서 특정은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도이어야 한다고 판시하였다. 형사침해소송에서도 대법원 2016. 5. 26. 선고 2015도17674 판결은 “공소사실 특정 여부와 관련하여, ‘특허발명의 특허권을 침해하였는지가 문제로 되는 특허법위반 사건에서 다른 사실과 식별이 가능하도록 범죄 구성요건에 해당하는 구체적 사실을 기재하였다고 하기 위해서는, 침해의 대상과 관련하여 특허등록번호를 기재하는 방법 등에 의하여 침해의 대상이 된 특허발명을 특정할 수 있어야 하고, 침해의 태양과 관련하여서는 침해 제품 등의 제품명, 제품번호 등을 기재하거나 침해 제품 등의 구성을 기재하는 방법 등에 의하여 침해 제품 등을 다른 것과 구별할 수 있을 정도로 특정할 수 있어야 한다’라고 하여 민사침해소송과 유사한 기준을 제시하고 있다.

184) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746.

185) 전지원, “확인대상발명의 특정”, 대법원판례해설 제90호, 법원도서관, 2011, 708-709면 참조.

186) 대법원 2025. 9. 11. 선고 2024후10436.

187) 대법원 2002. 4. 23. 선고 2000후2323.

경우 심판청구인이 스스로 확인대상발명의 실시자에 해당하기 때문에 확인대상발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 더 높다.¹⁸⁹⁾

2) 확인대상발명의 구성을 기재할 때 심판대상물(실시 제품)의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없다. 심판대상물에 특허발명과 대응되지 않은 구성이 추가적으로 포함되어 있다고 할지라도 사정만으로는 권리범위의 판단에 영향을 미치지 않기 때문이다.¹⁹⁰⁾¹⁹¹⁾

④ 청구원인으로서 특정(예외): 독립항과 종속항의 관계에 있어서 특정

1) 복수의 청구항에 대하여 권리범위확인심판을 청구할 때 특허심판원이나 법원은 청구항별로 독립적으로 권리범위에 속하는지를 판단하게 된다.¹⁹²⁾ 청구범위가 복수 개의 청구항으로 된 경우에 있어서 각 청구항은 그것이 독립항이든 종속항이든 관계없이 상호 독립되어 청구항마다 권리범위가 정하여지는 것이기 때문이다.¹⁹³⁾ 따라서 독립항과 종속항의 관계에서 특별한 사정이 없는 한 광범위하게 규정된 독립항의 기술내용을, 독립항보다 구체적으로 한정하고 있는 종속항으로 제한하여 해석할 수 없다.¹⁹⁴⁾ 여기서 특별한 사정이란 진실로 발명하지 아니한 부분까지 광범위하게 해석할 수 없는 사정을 말한다고 할 것이다. 예를 들어 청구범위에 기재된 문언으로부터 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없어서 발명의 설명과 도면을 보충한 결과 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성이 종속항의 구성과 일치하게 되는 경우에는 독립항의 권리범위가 제한해석되어 종속항의 권리범위와 동일하게 될 수 있다.¹⁹⁵⁾

2) 종속항은 독립항을 구체화한 청구항이기 때문에 독립항의 권리범위가 종속항의 권리범위보다 더 넓은 수밖에 없다. 그 결과 권리범위확인심판에서 독립항과 대응되는 확인대상발명의 구성이 차이점을 판단함에 필요할 정도로 기재되어 있으나 종속항과 대응되는 구성이 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있을지라도 독립항과 대비하여 권리범위에 속하지 아니한다고 판단되면 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화한 종속항의 권리범위에도 속하지 아니한다고 할 것이고, 따라서 확인대상발명은 종속항과 대비할 수 있을 정도로 특정된 것으로 봄이 타당하다.¹⁹⁶⁾ 독립항의 권리범위에 속하지 않는다고 판단되는 경우 종속항에 대응되는 부분의 구

188) 대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372.

189) 특허법원 2004. 4. 30. 선고 2003허3020.

190) 대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746.

191) 구체적으로 대응되는 구성이 모두 동일하면 구성요소완비의 원칙에 의하여 권리범위에 속하게 되고, 구성의 변경이 있더라도 균등하면 권리범위에 속하게 된다. 한편 특허발명의 구성과 대응되지 아니한 구성은 자유기술의 법리를 적용할 때를 제외하고 구성요소완비의 원칙, 균등론을 적용함에 있어서는 영향을 미치지 않는다. 예를 들어 특허발명의 구성이 A+B+C인데, 제3자가 A1+B1+C1+D1을 실시하고 있는 경우 A와 A1, B와 B1, C와 C1이 동일하거나 균등하다면 D1의 존재 여부와 무관하게 실시하고 있는 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하게 된다.

192) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후17.

193) 특허법원 2004. 7. 2. 선고 2003허6043.

194) 대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후934.

195) 대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57.

196) 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296. 2010후296 판결은 확인대상발명이 독립항의 권리범위에 속하지

성 기재를 모두 요구할 필요가 없는 것이다. 어차피 종속항에 대응되는 부분의 구성 기재를 하더라도 종속항의 권리범위에 속하지 않게 되기 때문이다.

3) 그러나 이는 독립항의 권리범위가 인정됨을 전제로 하는 것으로서 만일 독립항이 신규성 위반 등으로 권리범위가 인정되지 않는다면 독립항의 권리범위에 속하지 않더라도 종속항의 권리범위에 속할 수도 있으므로 종속항의 권리범위에 속한지 아닌지를 개별적으로 판단하여야 한다. 또한 확인대상발명이 독립항의 권리범위에 속하는 경우 종속항의 권리범위에 속한지를 개별적으로 판단되어야 한다. 따라서 이와 같은 경우에는 종속항에 대해서도 권리범위확인을 구하는 심판을 청구한 것이라면 종속항에 대응되는 부분의 구성이 차이점을 판단함에 필요한 정도까지 반드시 기재되어야 하고, 만약 기재되지 아니한 경우 보정명령을 하여야 한다.¹⁹⁷⁾

⑤ 청구원인으로서 특정(예외): 발명의 범주가 다른 확인대상발명의 특정

1) 물건발명과 방법발명은 실시의 유형이 달라짐에 따라 특허권의 효력범위에 차이가 있으나 서로 대비할 수 없는 별개의 발명이라 할 수 없다. 구체적으로 물건발명의 권리범위에서는 그 물건에 관련된 방법발명(예컨대 제법발명, 사용방법발명)이 포함되고, 제법발명의 권리범위는 그 제조방법에 따라 생산된 물건에까지 미치므로, 결국 양 발명은 그 효력범위의 광협(廣狹)에 있어 차이가 있는 것이다. 따라서 권리범위확인심판을 청구할 때 특허발명과 발명의 범주가 다른 확인대상발명을 특정할 수 있다.

2) 특허발명이 제법발명인 경우를 먼저 살펴보면, 대법원¹⁹⁸⁾에서는 특허발명이 물건을 생산하는 방법의 발명(제법발명)인 경우 물건을 특정하여 권리범위확인심판을 청구하는 것을 긍정 하되, 확인대상발명을 특정한 생산방법에 의하여 생산된 물건으로 한정하여 권리범위확인심판을 청구하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에는 그 특정한 생산방법을 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 기재되어야 한다고 하여 그 요건을 설시하고 있다.¹⁹⁹⁾²⁰⁰⁾ 즉 특허발명이 제법발명이면 어떤 제법발명에 의하여 생산된 물건인지에 따라 권리범위에 속하는지가 달라지므로 확인대상

아니하면 종속항에 대응되는 부분의 구성이 기재되어 있지 않거나 불명확한 부분이 있다고 하더라도 나머지 구성(독립항의 구성)만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한지 아닌지를 판단할 수 있는 경우에는 확인대상발명이 특정된 것으로 볼 수 있고, 그 결과 종속항의 권리범위에도 속하지 아니한다고 판단한 최초의 사례이다(전지원, “확인대상발명의 특정”, 대법원판례해설 제90호, 법원도서관, 2011, 716면). 2010후296 판결은 확인대상발명의 청구취지로서의 특정과 청구원인으로서의 특정의 구별에서 그 의미를 찾을 수도 있다. 확인대상발명의 심판대상물로서 특정 자체는 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있도록 기재하여 적법하게 이루어진 것이어서 적어도 일사부재리의 효력이 미치는 객관적 범위는 정할 수 있음을 전제로, 나아가 청구원인으로 특허발명의 구성과 대비할 수 있도록 설명서 및 도면에 의하여 구체적인 구성을 기재하면서 그 특정의 정도를 완화할 수 있다는 의미이다.

197) 특허법원 2004. 3. 5. 선고 2003허1284 참조

198) 대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164.

199) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 177-179면.

200) 물건의 생산방법에 관한 특허발명에 대한 적극적 권리범위확인심판에서 당초 물건만으로 특정된 확인대상발명에 특허발명의 생산방법과 같은 생산방법을 추가로 기재한 보정은 요지변경에 해당하지 아니한다(특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252).

발명이 어떤 제법발명에 의하여 생산되었는지를 구체적으로 특정하여야 한다. 다만 제법발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 출원 전에 공지되지 않았다면 그 물건은 그 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정된다(法 129). 이 경우 특허권자는 확인대상발명의 물건이 특허된 제법발명에 의하여 생산된 것이라는 것을 증명할 필요없이 i) 특허된 제법발명에 의하여 생산된 물건이 출원 전 공지되지 않았다는 점, ii) 확인대상발명의 물건이 구성요소완비의 원칙, 균등론을 적용한 결과 특허된 제법발명에 의하여 생산된 물건의 실시라는 점을 증명하면 된다.²⁰¹⁾

3) 다음으로, 특허발명이 물건발명이고 확인대상발명이 제법발명인 경우 설명서에 제법발명에 의하여 생산된 물건의 구성이 구체적으로 특정되어야만 한다. 그 물건의 구성이 특정되어야만 특허발명의 구성과 대비하여 구성요소완비의 원칙, 균등론에 의하여 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단할 수 있기 때문이다. 이와 직접적으로 관련된 판결례는 없으나, 특허법원 1998. 11. 6. 선고 98허2498 판결²⁰²⁾에서는 특허발명이 물건인 경우 확인대상발명을 방법발명을 특정하여 권리범위확인심판을 청구하는 것을 인정하고 있다. 대상판결은 확인대상발명이 방법발명으로서 범주가 다른 문제라기보다는 확인대상발명을 실시하면서 물건발명을 사용하는 발명의 하나의 유형이라고 할 수 있다. 또한 대법원 2022. 01. 14. 선고 2019후11541 판결에서는 특허발명이 물건발명, 확인대상발명이 물건발명이고, 설명서에 부가적으로 확인대상발명의 제조방법을 기재하였는데, 이해관계인이 그 제조방법에 의해서는 확인대상발명이 생산되지 않으므로 확인대상발명이 특정되었다고 볼 수 없다고 주장한 사안에 대하여, 물건발명인 특허발명의 효력은 제조방법과 상관없이 물건에 미치므로, 물건발명의 특징이 명확하다면 부가적으로 기재한 제조방법으로 물건을 생산할 수 없다고 할지라도 적절한 심판청구라고 하였다. 마찬가지로 특허법원 2024. 4. 4. 선고 2023허11944 판결에서는 물건발명의 특허권자가 적극적 권리범위 확인심판을 청구하면서 확인대상발명의 설명서 등에 피심판청구인이 실시한 물건을 사용하는 구체적 방법을 부가적으로 기재했다고 하더라도 그 물건을 그러한 방법으로 사용하는 경우만이 심판대상으로서 확인대상발명이 되는 것은 아니라고 하였다.

201) 이에 대해서 2003후2164 판결의 취지는 특허발명이 제법발명인 경우, 확인대상발명의 설명서 및 도면에 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 제법발명이 특정된 경우에 한하여 확인대상발명을 물건으로 특정하여 권리범위확인심판을 청구할 수 있다고 판단한 것으로 보이고, 확인대상발명의 특징은 생산방법의 추정에 관한 특허법 제129조의 적용 이전의 문제로서 심판청구의 적법요건에 해당하는 점 등을 고려하면, 확인대상발명의 설명서 및 도면에 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 제법발명이 기재되지 아니하고 단지 물건의 구성에 대하여만 기재된 경우에는, 확인대상발명이 제법발명에 관한 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되지 아니한 것으로 보는 것이 타당하다는 부정설도 있다(최정열, “권리범위확인심판에 관한 소고”, 「특허소송연구」 제3집, 특허법원, 38-45면 참조).

202) 이 사건 제3항 발명은 프레스 성형장치에 관한 것인데 비하여, 확인대상발명은 세라믹필터의 제조방법에 관한 것이어서 양 발명은 대비 대상이 될 수 없는 듯 보이나, 만일 확인대상발명의 일 구성요소로서 이 사건 제3항 발명의 프레스 성형장치가 사용된다면 확인대상발명은 이 사건 제3항 발명을 이용한 발명으로서 그 권리범위에 속한다고 아니할 수 없다.

(3) 설명서 및 도면의 해석을 통한 확인대상발명 특정 여부의 판단

① 원 칙

특허심판원이나 법원이 설명서 및 도면의 해석을 통해 확인대상발명이 특정되었는지 파악하는 방법은 청구범위의 해석을 통해 특허발명이 특정되었는지 파악하는 방법과 다르지 않다. 따라서 설명서를 중심으로 확인대상발명의 구성을 파악해야 하고, 기술적 의미를 정확히 알 수 없는 경우에는 도면 등의 기재를 참작하여 파악해야 하지만,²⁰³⁾ 특별한 사정이 없는 한 도면에 의하여 설명서에 기재된 확인대상발명의 구성이 제한되거나 확장되어 해석되는 것은 허용되지 않아야 한다.²⁰⁴⁾ 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건이므로, 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀야 할 사항이다.²⁰⁵⁾

② 설명서와 도면의 불일치가 있는 경우의 해석방법

확인대상발명의 특정 대상은 설명서와 도면이다. 설명서와 도면이 일치하지 아니한 경우 확인대상발명의 설명서를 기준으로 확인대상발명의 기술적 구성을 파악하는 것이지만,²⁰⁶⁾ 이와 달리 확인대상발명의 설명서와 도면 사이에 불일치가 없는 경우에 확인대상발명의 도면이 예시적인 것에 불과하다는 별도의 기재가 없는 한, 확인대상발명의 도면을 단지 참고도면 정도로만 이해하여서는 아니 되고, 확인대상발명의 설명서와 도면을 일체로 해석하여 확인대상발명의 기술적 구성을 확정하여야 한다.²⁰⁷⁾²⁰⁸⁾ 다만 확인대상발명의 설명서에 기재되어 있지 아니한 구성은 이에 대한 기재가 없다고 하더라도 그 설명서의 전체 기재 내용과 기술상식에 비추어 볼 때 확인대상발명의 구성임이 자명하다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명의 구성요소로 파악해서는 안 되며,²⁰⁹⁾ 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다.²¹⁰⁾

③ 설명서에 확인대상발명의 구성이 기능적 표현으로 기재된 경우의 해석방법

1) 확인대상발명의 구성이 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재되어 있는 경우에는, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이

203) 특허법원 2009. 11. 25. 선고 2008허6314.

204) 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478.

205) 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725.

206) 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478.

207) 대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725.

208) 확인대상발명에서 사용되는 용어의 의미가 명확하지 아니하면 확인대상발명의 설명서뿐만 아니라 필요한 경우 특허발명의 명세서나 출원경과도 참작될 수 있다(특허법원 2009. 11. 25. 선고 2008허6314).

209) 특허법원 2009. 10. 9. 선고 2009허3732.

210) 대법원도 2005. 11. 25. 선고 2004후3478.

구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없다.²¹¹⁾ 이와 같은 해석은 특허발명의 청구항이 기능적 표현으로 기재될 때의 해석방법과 다르지 않다. 기능적 표현으로 기재된 청구항도 발명의 설명을 참작한 결과 발명이 전제로서 명료하다고 보일 때에 허용될 수 있으며,²¹²⁾ 그렇지 않으면 명확성 요건(法 42④Ⅱ) 위반이 된다.

2) 일반적으로 확인대상발명의 설명서를 작성할 때, 특허발명의 청구항 구성과 대비할 수 있도록 확인대상발명의 구성을 기재하는 경우 확인대상발명 구성의 불특정 문제가 발생하지 않으나, 청구항의 구성이 기능적 표현으로 기재되어 있다고 하여, 설명서에 특허발명과 대비되는 구성을 기능적 표현으로 기재하면 확인대상발명의 불특정 문제가 발생할 수 있다.²¹³⁾ 따라서 설명서에 청구항과 대비되는 구성을 기재할 때 기능적 표현보다는 구체적이고 직접적인 구성을 기재하여야 하고, 기능적 표현으로 기재하는 것을 최대한 지양하여야 한다. 그리고 어쩔 수 없이 전자상거래 관련 발명(BM 발명)과 같이 직접적인 구성을 기재할 수 없어 기능적 표현으로 구성을 기재할 때는 설명서의 나머지 부분과 도면에 의하여 그 기능적 표현의 기술적 의미가 명확하게 확정될 수 있어야 한다.

④ 설명서와 도면에 기재된 발명이 실시하고 있는 발명과 다른 경우의 해석방법

1) 적극적 권리범위확인심판에서는 청구인인 특허권자 또는 전용실시권자가 주장한 실시 형태가 피청구인이 실제로 실시하고 있는 형태와 동일성이 인정되지 않으면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다.²¹⁴⁾ 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 때에만 그 동일성을 인정하여야 하며,²¹⁵⁾ 요지가 동일하여 균등관계에 있다고 할지라도 확인대상발명이 특정되었다고 볼 수 없다.²¹⁶⁾

2) 소극적 권리범위확인심판에서 심판의 대상이 되는 확인대상발명에는 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 장래 실시 예정인 발명도 포함되나,²¹⁷⁾ 그러한 경우에도 확인대상발명의 적

211) 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후149.

212) 대법원 1998. 10. 13. 선고 97후1344 ; 1998. 10. 2. 선고 97후1337 등.

213) 기능식 기재는 겉보기에 불과하고, '그와 같은 기능식 기재와 발명의 설명 또는 확인대상발명의 설명서의 조합'에 의해 비로소 그 기술내용이 확정된 청구범위 또는 확인대상발명으로 성립하는 것이기 때문이다. 대상판결은 이러한 바탕 위에, 기능적 표현으로 기재되어 있는 확인대상발명의 특정 여부 판단 기준을 명확히 제시한 최초의 판결이라는 점에서 그 의의가 크다(유영선, "기능적 표현으로 기재되어 있는 확인대상발명의 특정 여부 판단 기준", 대법원판례해설 제94호, 법원도서관, 2012, 568-569면 참조).

214) 대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419.

215) 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626.

216) 대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247.

법한 특정 여부, 심결절차의 안정성 및 효율성, 심결의 효력 범위를 명확히 하기 위하여 권리 범위의 확인을 구하는 심판을 청구한 자는 확인대상발명을 현재 실시하고 있는지 또는 장래 실시할 예정인지 여부를 적어도 심결 시까지 명확히 밝혀야 하고, 심판청구인이 심결 시까지 자신이 현재 실시하고 있는 제품이 확인대상발명이라고 밝혔다면 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 심판청구인의 의사대로 실제 실시하고 있는 제품으로 확정되었다고 할 것이다. 또한 확인대상발명이 위와 같이 확정되었다면 그것이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법 요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다.²¹⁸⁾ 따라서 심판청구인인 이해관계인이 심결절차를 통하여 확인을 받으려고 한 대상인 실제 실시하고 있는 제품과 심판청구인이 특정한 확인대상발명이 사실적 관점에서 같지 않다면, 특허심판원로서는 다름을 지적하여 이를 보정할 수 있는 기회를 부여하여야 하고, 심판청구인이 그러한 기회를 제공받았음에도 이를 보정하지 않았다면 잘못 특정된 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되더라도 그 효력이 확인대상발명과 다른 청구인이 실제 실시하고 있는 발명에 미친다고 볼 수 없으므로 이를 각하하여야 할 것이다.²¹⁹⁾²²⁰⁾

3) 한편 소극적 권리범위확인심판에서 심판의 대상이 실시 예정 제품인 경우, 즉 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 심판의 대상으로 삼은 구체적인 발명과 다른 경우라도 실시할 가능성이 있다면 심판청구의 적법성을 인정받을 수 있다. 이때 현재 실시 형태가 아닌 심판청구인이 특정한 확인대상발명을 기준으로 특허발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단한다.²²¹⁾

⑤ 설명서와 도면에 기재된 확인대상발명이 복수 개로 파악된 경우의 해석방법

1) 설명서와 도면에 기재된 확인대상발명이 복수 개로 파악되었을 때 이를 적법한 심판청구로 볼 것인가에 대하여 최초의 대법원 1971. 6. 22. 선고 69후18 판결은 권리범위확인심판은 한 개의 확인대상발명이 한 개의 특허권의 권리범위에 속하는지의 확인을 구하는 청구라고 실시하였다. 심판 실무는 확인대상발명이 1개이어야 하며(다만 하나의 확인대상발명의 하위개념에 속하는 복수의 실시예가 기재될 수 있다), 여러 개인 것이 명백하거나 확인대상발명이 하나인 것으로 인정하기에는 불명확한 점이나 모순이 있는 경우 석명권 등을 행사하여 그 흠결을 보정하도록 보정명령을 하고, 그 흠결이 해소되지 아니하였을 때는 심판청구를 심결각하한다는 입장이다.

217) 대법원 2000. 4. 11. 선고 7후3241.

218) 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 참조

219) 대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결 참조.

220) 그리고 특허심판원이 위와 같이 보정기회를 부여하여야 함에도 그러한 기회를 부여함이 없이 실제 실시하고 있는 발명과 다른 확인대상발명에 관하여 심결을하였다면 그러한 심결은심판대상이 아닌 발명을 심판한 잘못이 있어 위법하고, 이후 그 심결의 취소를 구하는 소송절차에서 사후적으로 심결에서승소한 일방 당사자가 위 확인대상발명에 관하여도 확인을 구할 의사가 있다는 의사를 표시하였다고 하여 그 하자가 치유된다고 보기도 어렵다(특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301).

221) 대법원 2023. 1. 12. 선고 2020후11813.

2) 그러나 최근 특허법원은 복수 개의 확인대상발명의 특징을 부정하는 견해²²²⁾와 긍정하
는 견해²²³⁾로 나뉘어 있다. i) 기존에는 청구범위에 하나의 청구항만을 기재하는 단항제를
채택하였으나, 다항제를 인정하고 있는 현행 제도에 맞추어 복수의 청구항에 대한 권리범위확
인심판을 인정하고 있는 점(法 135②)²²⁴⁾, ii) 청구범위의 작성에 있어서 이른바 ‘마쿠쉬’ 형
식과 같은 선택적 기재를 인정하고 있으므로 확인대상발명도 복수 개를 인정하는 것이 타당하
다는 점,²²⁵⁾ iii) 동일한 당사자 사이에서 실시하고 있는 제품의 기술내용이 유사할 때 하나의
심판청구를 허용하는 것이 분쟁의 신속한 해결과 소송경제라는 측면에서 바람직하다는 점²²⁶⁾
등을 고려할 때 복수 개의 확인대상발명을 특정한 권리범위확인심판을 인정하는 것이 적절하
다고 생각된다. 다만 복수 개의 확인대상발명의 특징을 인정할지는 정책적인 면이고, 허용이
된다면 명확한 근거 규정을 두고 있음이 타당할 것이다. 그리고 복수의 확인대상발명의 특정
함에 있어서는 2가지 사항을 고려해야 하는 것으로 보인다.

2) 첫째, 병합청구의 문제이다. 확인대상발명이 복수 개인 경우에는 이해관계를 서로 달리하는
2인 이상이 공동으로 하나의 심판을 청구하는 것이 아니라 복수 개의 다른 청구취지를 가진
복수 개의 심판을 하나의 심판으로 청구하는 경우에 해당한다. 따라서 원칙적으로 별도의 심
판청구를 해야 하고, 심판관은 청구취지가 다른 둘 이상의 심판에 대하여 심리 또는 심결을
병합하거나 분리할 수 있으나(法 160), 이는 심판관의 재량사항이다. 특허심판은 민사소송과는

222) 특허법원 2010. 11. 3. 선고 2010히111 판결에서는 “이 사건 적극적 권리범위확인심판청구는 형식적
으로는 한 개의 확인대상발명을 심판대상물로 삼고 있으나, 실질적으로 복수 개의 심판대상물을 그 판
단의 대상으로 구하고 있는 것이므로 그 자체로서 부적법하고, 가사 원고들이 선택적인 세 가지 구성으
로 어느 하나를 실시하고 있다 하더라도, 그 가운데 원고들이 실제로 실시하고 있지 아니한 것을 확인
대상발명의 구성에 포함시켜 특정하여 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 것에도 해당하므로, 그 역
시 확인의 이익이 없어서 부적법함을 면치 못한다 할 것이다”라고 판시하였다. 또한 특허법원 2007. 1
1. 23. 선고 2007히4816 판결 등에서도 “청구범위의 청구항과 이와 대비되는 확인대상발명이 복수여서
확인대상발명과 대비하고자 하는 특허발명의 청구항의 관계가 불분명한 경우, 특허심판원은 요지변경이
되지 않는 범위 내에서 심판청구서의 청구취지와 청구이유 또는 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한
보정을 명하는 등의 조치를 취해야 하며, 그럼에도 불구하고 그 특징이 미흡하다면 그 부분에 관한 심판
청구를 각하하여야 한다”라고 하여 대법원 판결을 지지하였다.

223) 권리범위확인심판에서 확인대상발명은 한 개여야 한다는 특허심판원의 심판편람규정은 그 규정의 성질과
내용상 행정기관 내부의 사무처리준칙을 정한 것에 불과하여 대내적으로 행정기관을 기속한은 별론으로
하고 대외적으로 법원이나 일반 국민을 기속하는 효력은 없는 점, 특허법은 특허권자·전용실시권자 또는
이해관계인은 특허발명의 권리범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다고
규정하고 있을 뿐, 특허권의 권리범위를 확인하기 위한 확인대상발명의 개수를 특별히 제한하고 있지는
아니한 점, 확인대상발명을 복수로 하여 권리범위확인심판을 청구하는 것은 결국 두 개의 청구를 병합하
는 것인데, 특허법상의 심판절차와 성질이 유사한 일반 행정심판 절차를 규정하고 있는 행정심판법은 관
련 청구의 병합을 인정하고 있는 점(행정심판법 제37조 참조), 관련되는 복수의 청구를 하나의 심판절차
에서 해결하는 것이 분쟁의 일회적 해결이나 심판경제상 바람직한 점 등을 종합하여 보면, 특별한 사정
이 없는 한 확인대상발명이 복수라는 것만으로 바로 권리범위확인심판청구가 위법하다고 볼 수는 없다
(특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013히4954).

224) 전지원, “확인대상발명의 특정”, 대법원판례해설 제90호, 법원도서관, 2011, 723면; 정차호·이혜라, “특허
권리범위확인심판에서 복수 확인대상발명의 허용”, 법학연구 26(2), 충남대학교 법학연구소, 2015, 279면.

225) 전지원, “확인대상발명의 특정”, 대법원판례해설 제90호, 법원도서관, 2011, 724면.

226) 서영철, “구성요소가 선택적으로 기재된 확인대상고안”, 「특허소송연구」 제4집, 특허법원, 2008, 570면.

달리 공익적 성격이 강하여 그 결과가 제3자에게도 효력이 있으므로 직권진행주의를 채택하고 있다. 따라서 복수 개의 확인대상발명을 특정하여 청구취지가 다른 권리범위확인심판의 청구는 병합하여 심리 또는 심결할 필요가 있는지에 따라 그 적법성 여부를 달리 보는 것이 적절해 보인다. 구체적으로 병합할 필요가 있다면 당사자에게 원래는 별도로 심판청구를 해야 하나 병합한다는 취지의 통지를 하고, 병합할 필요가 없다면 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하면 될 것이다. 그러나 복수 개의 확인대상발명의 선택적 또는 예비적 병합 형태로 청구하면서 일부만이 특허발명의 권리범위에 속한다는 취지로 청구하는 것은 심판의 대상 자체가 불명확하고, 상대방에게 심판의 대상을 특정할 책임을 전가하는 결과에 이르게 되기 때문에 부적법하다고 할 것이다.²²⁷⁾

4) 둘째, 이해관계의 문제이다. 확인대상발명이 복수 개일 때 병합심리를 하더라도 소극적 권리범위확인심판은 현재 실시하고 있는 발명뿐만 아니라 실시할 예정이 있는 발명도 이해관계가 있어서 적법성 여부가 문제 되지 않으나, 적극적 권리범위확인심판은 확인대상발명의 일부가 현재 실시하고 있는 발명이 아니라면 현재 실시하고 있는 확인대상발명으로 보정을 명하는 등의 석명권을 행사해야 한다. 정리하면 권리범위확인심판의 확인대상발명이 복수 개일 때 병합할 필요가 있다면 병합한다는 취지의 통지를 한 후 심판절차를 진행하고 병합할 필요가 없거나 이해관계가 없다면 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 석명권을 행사하여 확인대상발명을 한 개로 특정하는 것이 바람직하다고 사료된다. 이 경우 심판청구인은 확인대상발명을 한 개로 줄이는 보정을 하되, 다른 확인대상발명에 대해서도 이해관계가 있다면 별도의 심판을 청구할 수 있을 것이다.

(4) 확인대상발명 특정의 증명책임

1) 증명책임이란 소송상 어느 요증사실의 존부가 확정되지 않을 때(진위불명) 당해 사실이 존재하지 않는 것으로 취급되어 법률판단을 받게 되는 당사자 일방의 위험 또는 불이익을 말한다.²²⁸⁾ 특허심판에서는 직권탐지주의를 채택하고 있으므로 당사자에게 주장책임²²⁹⁾이 없지만, 증명책임의 문제는 여전히 발생하고 있다. 심판의 기초가 되는 사실이 진위불명일 때 일방 당사자의 불이익은 여전히 문제되는 것이고, 당사자는 자신에게 불리한 결과를 회피하기 위하여 소송과 마찬가지로 법률요건분류설에 따라 증명활동을 해야 한다.²³⁰⁾

2) 법률요건분류설이란 객관적인 법규의 구조 즉 조문의 형식이나 관계조문의 상호관계 속에서 증명책임 분배의 기준을 찾으려는 견해로서, 법률요건 분류설에 의하면 각 당사자는 자기에게 유리한 법규의 요건사실의 존부에 대해 증명책임을 지게 된다. 법률요건 분류설에 의

227) 특허법원 2006. 10. 20. 선고 2006허1438.

228) 이시윤, 「신민사소송법」 제12판, 박영사, 2018, 541면.

229) 주장책임이란 변론주지에서 자기에게 유리한 법규적용의 기초가 되는 요건사실이 어느 쪽 당사자에 의하여서도 주장되지 아니하면 법원이 이 사실을 판결의 기초로 삼을 수 없고 이로 인하여 생기는 일방 당사자의 불이익을 말한다(이시윤, 「신민사소송법」 제12판, 박영사, 2018, 541면).

230) 이미옥, “특허사건의 주장입증책임”, 재산법연구 제27권 제3호, 한국재산법학회, 2011. 658-659면 참조.

하면, 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특징에 대한 증명책임은 청구인인 특허권자 또는 전용실시권자에게 있고, 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특징에 대한 증명책임은 청구인인 이해관계인에게 있다. 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특징과 관련되어 증명책임이 문제되는 것은 적극적 권리범위확인심판이라고 할 수 있다. 적극적 권리범위확인심판의 경우 청구인인 특허권자는 피청구인이 실제로 확인대상발명을 실시하고 있음을 증명하여야 한다. 만약, 피청구인이 확인대상발명을 실시한 사실 등이 없어 증명에 실패한다면, 본안 심리를 할 확인의 이익이 없으므로 심판청구는 심결각하된다.²³¹⁾ 즉 확인대상발명을 실시하고 있는지 실시주장발명을 실시하고 있는지에 대한 증명자료는 대부분 이해관계인의 지배영역에 있음에도 불구하고, 이에 대한 증명책임은 특허권자에게 있고, 증명에 실패한다면 심결각하된다.²³²⁾

3) 그러나 특허권자의 증명 실패로 인해 권리범위확인심판에서 특허권자의 본안심리를 받을 기회를 박탈하는 것은 민사침해소송과의 형평성 측면에서 맞지 않는다. 2019년 1월 8일 시행된 개정법(법률 제16208호)은 제126조의2를 신설하여 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 내용·방식·형태를 부인하는 당사자는 자기의 구체적 행위의 내용·방식·형태를 제시하여야 하도록 하였다. 이는 i) 침해행위는 침해자의 영역에서 주로 발생하므로 특허권자 등이 침해사실을 증명하기는 매우 어렵다는 점, ii) 특허권자 등이 침해행위의 구체적인 태양을 제시하며 침해사실을 증명하고자 할 때 피고가 단순히 부인만으로 방어할 수 없도록 하고 자기의 구체적인 행위의 내용·방식·형태를 제시하도록 하는 것은 해당 소송의 적정성과 신속성을 제고하는 데 기여할 수 있다는 점 등을 고려한 것이다.²³³⁾

4) 권리범위확인심판은 그 심결의 효력이 당사자 이외의 제3자에게도 미치는 일사부재리의 효과가 있으므로 민사소송과는 달리 직권주의적 요소가 강화되어 있다. 그 결과 당사자가 절차에 대하여 미숙함이 있을지라도 실제적 진실관계에 의한 본안심결을 받아볼 수 있다는 점에서 권리범위확인심판의 존재의의가 있다. 또한 증명책임 분배의 근본이념은 진실에 가까이 가려고 하는 것과 공평의 이상이다. 즉 어떻게 증명책임을 분배하면 진실에 가깝게 되는 것이며, 쌍방 당사자에게 공평한 심판이 되는가 하는 것이다.²³⁴⁾ 따라서 심판의 존재의의 및 증명책임 분배의 근본이념을 고려할 때 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 특징이 문제가 된 경우 증명책임의 전환에 관한 규정을 신설하여 이해관계인에게 증명책임을 전환해야 한다. 구체적

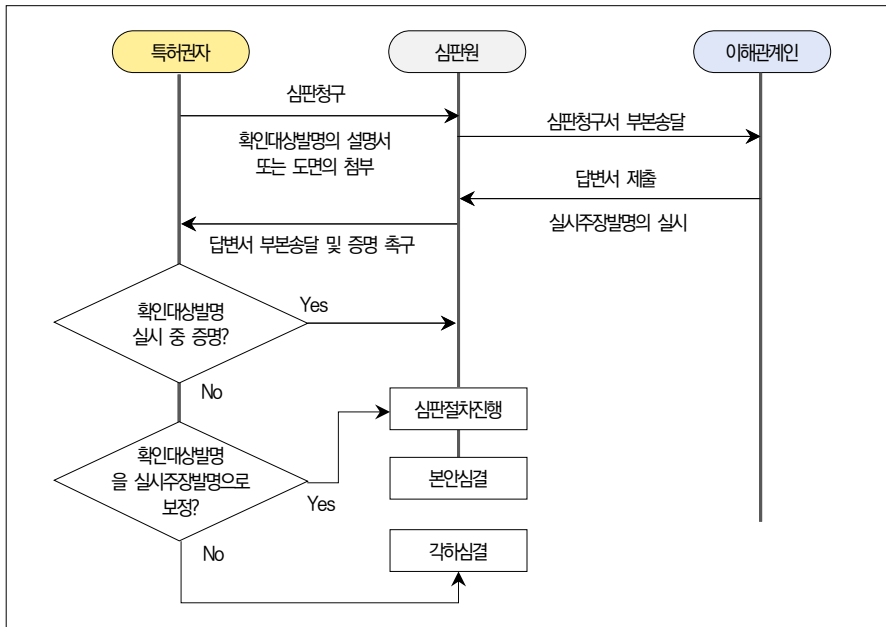
231) 대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419.

232) 다만 확인대상발명이 실시주장발명과 일치하지 아니한 경우 요지변경이라도 특허권자는 보정을 통해서 이를 일치시킬 수 있다.

233) 또한 2016년 2월 29일 일부 개정 특허법(법률 제14035호)은 제132조를 개정하여 기존의 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료뿐만 아니라 침해의 증명에 필요한 자료 제출을 명할 수 있도록 하였고, 자료제출을 거부하면 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있도록 하였다. 이와 같은 규정이 손해액 산정이 아닌 침해사실의 증명에 필요한 자료까지 제출하도록 하고, 그렇지 않으면 제재를 가하는 것은 실질적으로 실시자인 피고에게 증명책임을 전환한 것이라고 할 수 있다.

234) 권중철, “입증책임분배에 있어서 법률요건 분류설의 문제점에 관한 연구-적극적 채권침해를 중심으로-”, 연세대학교 대학원 의로법윤리학협동과정 법학전공, 연세대학교 박사학위, 2008, 136-139면.

으로 적극적 권리범위확인심판에서 이해관계인이 특허권자가 특정한 확인대상발명의 실시를 부인하거나, 다른 발명을 실시하고 있다고 주장하는 경우 특허권자에게 확인대상발명을 실시하고 있다는 것에 대한 증명을 촉구하는 것이 아니라 이해관계인이 다른 발명을 실시하고 있다는 것을 증명하도록 해야 한다. 그렇게 하는 것이 이해관계인에게 부담이 되지 않을뿐더러 실체적 진실관계에 더 가까이 다가갈 수 있기 때문이다.



【그림 7-5】 확인대상발명의 특성과 증명책임

4. 심 결

(1) 심결내용

1) 심판청구의 이유가 타당하지 않다고 인정될 때는 기각심결²³⁵⁾을 하여야 하며, 청구취지에 반하는 심결을 하여서는 아니 된다(法 159②). 예를 들어 심판청구인이 소극적 권리범위확인 심판을 청구하였을 때 확인대상발명이 상대방의 권리범위에 속한다고 심결함은 심판청구인이 신청하지 아니한 청구를 심결한 것이어서 위법하다. 한편 심판청구의 이유가 타당하다고 인정될 때는 「확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다」 또는 「확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다」라는 형식의 인용심결을 하여야 한다.

235) 대법원 1970. 12. 22. 선고 70후20; 1992. 6. 26. 선고 92후148.

2) 복수의 청구항을 가진 특허발명에 대하여 청구항을 특정하지 않고 권리범위확인심판을 청구하였을 때 그 판단의 대상이 무엇인지 문제이다. 권리범위확인을 구하는 청구항이 구체적으로 특정되지 않았더라도, 심판청구인의 의사를 합리적으로 해석한다면, 소극적 권리범위확인심판의 경우에는 모든 청구항 중 어느 하나의 권리범위에도 속하지 않는다는 확인을 구하는 것(단순 병합)으로 보아야 한다.²³⁶⁾ 모든 청구항에 대해서 인용심결이 되어야만 확인대상발명이 상대방의 권리범위에 속하지 않는다는 심판의 목적을 달성할 수 있기 때문이다.²³⁷⁾

3) 적극적 권리범위확인심판의 경우에는 모든 청구항의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것(단순 병합)으로 보거나 그 중 어느 하나에라도 속한다는 확인을 구하는 것(선택적 병합)이라 볼 수 있을 것이다. 단순 병합은 선택적 병합과 달리 일부인용·일부기각을 할 수 있다는 점에서 차이가 있다. 특허법원 실무는 청구인이 병합된 여러 개의 청구 가운데 어느 하나만 인용되어도 좋다는 등 선택적 병합의 의사를 명백히 밝히지 아니한 이상 단순병합으로 보고, 심결에서 청구항별로 판단하고, 그 주문에도 청구항을 특정하여 확인대상발명이 그 권리범위에 속한다는 내용을 표시하며, 속하지 아니한 청구항에 대해서는 일부 기각의 표시를 하고 있다.²³⁸⁾²³⁹⁾

(2) 불 복

심판의 당사자는 심판장으로부터 심결등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 취소소송을 제기할 수 있다(法 186①).

236) 심판청구인의 이 사건 심판청구는 확인대상발명이 이 사건 제2, 4항 발명뿐만 아니라 이 사건 제1, 3항 발명의 권리범위에도 속하지 아니함을 확인하여 달라는 취지라고 할 것인바, 이 사건 심결의 주문란에는 “이 건 심판청구를 기각한다”라고 기재되어 있으므로, 이 사건 심결은 확인대상발명이 이 사건 제1, 3항 발명을 포함한 이 사건 특허발명 전부의 권리범위에 속함을 주문에서 판단하였다고 할 것이다. 그러나, 그 이유란에는 이 사건 제2, 4항 발명의 권리범위에 확인대상발명이 속하는지 여부를 판단하고 있을 뿐 이 사건 제1, 3항 발명의 권리범위에 확인대상발명이 속하는지 여부에 관하여는 전혀 기재가 없고, 확인대상발명이 이 사건 제2, 4항 발명의 권리범위에 속한다고 하여 이 사건 제1, 3항 발명의 권리범위에도 당연히 속한다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 제1, 3항 발명에 관하여는 그 이유의 기재가 누락한 위법이 있다고 할 것이다(특허법원 2010. 5. 20. 선고 2009허7031).

237) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」 제3판, 박영사, 2014, 380면.

238) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」 제3판, 박영사, 2014, 381면. 장차 일부 청구항이 무효로 될 수도 있으므로 이런 경우에 대비하여 모든 청구항에 대하여 청구항별로 권리범위에 속하는지 여부를 판단받고자 함이 특허권자의 일반적 의사로 보이는 점, 청구인이 어느 하나의 청구항에 대하여 속한다는 인용심결을 받았으나 다른 청구항에 속한다는 확인을 받기 위한 필요가 있는 경우 다시 적극적 권리범위확인심판을 청구하여야 하는 불합리가 있는 점 등을 고려하고 있다.

239) 심판 실무도 i) 장차 일부 청구항이 무효심판에 의하여 일부 무효로 될 수 있으므로 이러한 경우를 대비하여 청구항별로 속부 판단이 요구되는 점, ii) 청구인이 전체 청구항에 대하여 심판 수수료를 지불한 점, iii) 어느 하나의 청구항에 속한다는 인용심결을 받았으나 다른 청구항에 속한다는 확인을 받을 필요가 있는 경우 재차 심판을 청구해야 한다는 점 등을 고려할 때, 모든 청구항에 대하여 속부 여부를 판단해야 한다는 입장이다(특허심판원, 「심판판례」, 제14판, 2024, 569면).

IV. 심결확정의 효과

1. 인용심결확정의 효과

1) 권리범위확인심판의 심결이 확정되면 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하는지가 전문관청인 특허심판원에 의하여 공적으로 확인된 결과가 된다. 그러나 법원은 순수한 기술적 범위에서의 권리범위확인을 넘어서 사실관계를 고려한 사법적 판단에 준하는 권리범위확인심결은 법원이 판단하는 사항을 심판관이 판단한 것으로 보아 이에 구속되지 아니한다는 입장이다. 즉 권리범위에 속한다(또는 속하지 아니한다)라는 권리범위확인심판의 심결이 확정된 후 법원에서 침해가 아니다(또는 침해이다)라고 판결하여도 위법한 판결이 아닌 것으로 보고 있다.²⁴⁰⁾ 결국 권리범위확인심판은 분쟁의 근본적 해결수단이 되지 못하고, 침해관련소송에 있어서 감정의 역할 정도에 그치고 있는 것이 현실이다.²⁴¹⁾

2) 다만 특허법원, 대법원에 불복하지 않아서 심결이 확정된 경우에는 당사자가 스스로 법원에 의해 재판받을 권리를 포기한 선택이므로 이를 존중하여 침해소송을 담당하는 법원에 구속력(기판력)을 인정하여야 한다. 또한 특허법원, 대법원에 불복하여 권리범위확인심판의 심결이 판결에 의해 확정된 경우에도 그 확정판결을 존중(기판력 인정)하는 것이 사법제도의 신뢰성을 확보하는데 더 부합한다고 할 수 있다.²⁴²⁾ 더욱이 최근에는 침해민사본안소송의 항소심을 특허법원에서 전속 관할하게 되어, 권리범위확인심판의 심결취소소송을 심리하는 특허법원과 일원화됨에 따라 침해소송과 권리범위확인심판의 심결취소소송이 다른 결론을 내리는 것이 현실적으로도 다소 힘들게 되었다고 볼 수 있다.

240) 민사재판에 있어서 이와 관련된 다른 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서 인정된 사실은 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되는 것이나, 그 민사재판에서 제출된 다른 증거내용에 비추어 관련 권리범위확인심판사건 등의 확정심결에서의 사실판단을 그대로 채용하기 어렵다고 인정될 경우에는 이를 배척할 수 있다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320).

241) 일본과 독일은 권리범위확인심판에 갈음하여 다음과 같은 제도를 두고 있다.

1. 일본에 있어서의 판정제도

일본의 경우 어떤 기술이 특허발명의 기술적 범위에 속하는가 여부에 관하여 다툼이 있는 경우에 특허 부여의 전문기관인 지식재산처에 대하여 공평한 입장에서 감정을 하여 달라고 청구하는 이른바 판정제도를 마련하고 있다. 일본의 경우에도 우리나라처럼 과거에 권리범위확인심판제도가 있었지만 그 법적 성격이 모호하여 1959년 이를 폐지하고 판정제도를 두게 되었다(일본특허법 71). 판정은 지식재산처가 행하는 감정이며 법적 구속력이 없고 따라서 판정에 대하여 불복을 신청할 수도 없다(裁判 1968. 4. 18). 또한 법원에서 판정과 다른 판단을 하는 것도 자유이다.

2. 독일에 있어서의 특허해석

독일에 있어서 특허는 행정처분에 의한 사권의 창설로서 특허의 부여는 창설적 행정행위에 근거하는 것이며 지식재산처의 관할에 속한다고 보고, 특허권리범위의 해석은 법원의 고유의 관할에 속한다는 권한분배의 원리를 대전제로 한다. 그러므로 지식재산처는 권리범위확정에 대하여 법원에 관여할 수 없고, 마찬가지로 법원은 지식재산처의 특허부여, 즉 신규성, 진보성에 대한 새로운 심사로서 이에 관여할 수 없다. 즉 지식재산처는 발명을 확정하고 법원은 보호범위를 결정한다.

242) 조준련, 정차호, “권리범위확인심판의 확정심결 및 후속 확정판결의 기판력 인정”, 산업재산권(제79호), 한국지식재산학회, 2024.12, 61-63면 참조.

2. 기각심결확정의 효과

권리범위확인심판의 심결이 확정되면 일사부재리의 원칙이 적용된다. 즉 기각심결이 확정되면 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일심판을 청구할 수 없다. 이에 위반되면 부적법한 심판청구를 이유로 심결각하된다. 적극적 권리범위확인심판이 청구되어 그 기각심결이 확정된 이후 소극적 권리범위확인심판을 청구한 때도 실질적으로 동일한 심결을 구하는 것으로 보아 일사부재리의 원칙이 적용된다(法 163).

V. 관련문제

1. 권리 대 권리의 권리범위확인심판可否

(1) 문제의 소재

권리범위확인심판은 권리 對 비권리의 대립구조로 되어 있는 것이 일반적이다. 그런데 권리 대 권리 상호간에 권리범위에 대해서 다툼이 발생할 경우가 있다. 이때 동종의 권리 사이에서 일방의 권리가 타방의 권리범위에 속하는지를 확인하는 소위 특허권(실용신안권) 상호간의 권리 대 권리의 권리범위확인심판이 허용되는지가 문제이다. 나아가 권리의 종류를 달리하는 이종의 권리(특허권 對 디자인권(상표권)) 사이에서 권리범위확인심판이 허용되는지도 문제이다.

(2) 판례의 태도

① 동종의 권리 사이의 소극적 권리범위확인심판의 경우

일방의 특허권이 타 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 취지의 심결을 하더라도 그 심결의 결과는 어느 한쪽의 권리도 부정하는 것이 아니므로 부적법한 것이 아니다.²⁴³⁾

② 동종의 권리 사이의 적극적 권리범위확인심판의 경우

1) 후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상 고안으로 하여 선출원에 의한 등록고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고, 다만 예외적으로 양 고안이 구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률) 제11조제3항에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다.²⁴⁴⁾ 저촉관계를 확인하는

243) 대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19; 1996. 12. 20. 선고 95후1920 등

244) 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 등. 나아가 위 판결은 “이용관계에 있는 경우 후등록 권리가 무효라고 주장한 것은 단순한 주장에 불과하므로 그로 인하여 심판청구의 적격에 위배하였다고 볼 수는 없으므로 원심은 권리범위확인심판에 있어서의 청구적격에 관한 법리를 오해한 위법이 있다”는 취지의 상고이유에 대해서는 “원고가 확인대상고안이 진보성이 없는 개악고안으로서 무효라는 취지로 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구한 이상, 확인의 이익이 인정될 수 없어 부적법한 청구로 귀결될 수

적극적 권리범위확인심판에서 후등록 권리가 신규성이 부정되어 권리범위를 인정할 수 없는 경우라고 할지라도 마찬가지이다.²⁴⁵⁾

2) 당사자 일방 또는 쌍방이 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판을 주장하거나 권리 대 권리임이 정황상 의심되는 경우, 확인대상발명과 후등록 발명과의 동일성 여부가 쟁점이 될 수 있다. 확인대상발명과 후등록 발명의 동일 여부는 확인대상발명과 후등록 발명의 구성요소가 서로 빠짐없이 대응되고 대응되는 구성끼리 표현의 차이 정도에 불과하다면, 양 발명은 동일한 것으로 보아 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판으로 본다.²⁴⁶⁾ 한편 권리범위 확인심판에서 확인의 이익 유무는 심판청구의 적법 요건에 관한 것으로서 직권조사사항이므로, 법원은 그 판단의 기초자료인 사실과 증거를 직권으로 탐지할 의무까지는 없다고 하더라도 이미 제출된 자료들에 의하여 그 확인의 이익이 있는지 의심이 갈 만한 사정이 보인다면, 상대방이 이를 구체적으로 지적하여 다투지 않더라도 이에 관하여 심라조사할 의무가 있다.²⁴⁷⁾

③ 이종의 권리 사이의 적극적 권리범위확인심판의 경우

동일한 종류의 등록권리 사이에는 이용관계 등에 해당하지 않는 한 원칙적으로 적극적 권리범위확인심판이 허용되지 않을 것이나, 보호대상과 등록요건에 차이가 있는 다른 종류의 등록권리 사이에는 권리범위확인심판의 판단 결과에 의해 바로 확인대상고안의 해당등록권리자의 등록 효력을 부인하는 결과가 되는 것이 아닌 경우에만 일률적으로 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판에 해당한다는 이유로 확인의 이익이 부정된다고 볼 수 없다.²⁴⁸⁾

(3) 소 결

권리 사이의 권리범위확인심판의 가부는 인용심결이 타방의 권리를 부정하는지 여부에 따라 달라진다. 타방의 권리를 부정한다면 확인적 성격을 벗어나고, 무효심판의 전권사항을 권리범위확인심판이 하게 되는 결과가 되어 인정될 수 없다. 이에 의하면, 소극적 권리범위확인심판의 인용심결은 「권리범위에 속하지 아니한다」는 것으로서 타방의 권리를 부정하지 않기 때문에

밖에 없다”는 취지로 판시한 바 있다. 즉 원고가 뒤에 출원된 특허의 무효를 주장하면서 권리범위확인심판을 청구하는 경우에는 확인의 이익(심판청구의 요건)이 결여되었기 때문에 뒤에 출원된 특허가 먼저 출원된 특허의 이용관계에 있는지 살펴볼 필요 없이 주장 자체로 원고의 심판청구를 각하하여야 한다는 것이다. 또한 위 판결의 원심판결(특허법원 1999. 9. 2. 선고 99허1720)은, “심판단계에서 이용관계에 관한 주장을 하지 아니하다가 심판청구를 각하하는 심결이 있는 후 그 심결의 취소를 구하는 소송단계에 와서 비로서 그러한 주장을 하는 것은 그 주장으로 인하여 부적법한 심판청구가 심판청구 시로 소급하여 적법하게 되는 것은 아니어서 허용될 수 없다”라고 판시하였다. 이는 특허심판절차와 특허소송절차는 별개의 절차로서 특허소송은 본질적으로 행정처분의 당부를 다투는 행정소송의 일종이라는 점에 중점을 두어 심판청구의 요건은 심판절차의 심결 시까지 갖추어야 한다고 본다면, 심결취소소송에서야 새로운 주장을 추가함으로써 심판청구의 요건을 사후에 보완하는 것은 허용되지 않기 때문이다(최정열, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 450면~451면 참조).

245) 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965.

246) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 534-535면.

247) 대법원 2025. 9. 11. 선고 2024후10436.

248) 특허법원 2024. 4. 18. 선고 2023허13100.

허용되는 것이고, 적극적 권리범위확인심판의 인용심결은 「권리범위에 속한다」는 것으로서 원칙적으로는 타방의 권리를 부정하기에 허용되지 않지만, 이용관계는 타방의 권리를 부정하지 않고 확인을 구할 수 있기에 허용되는 것이다. 즉 이용관계의 확인은 상대방의 권리의 존부에 어떤 변동을 가져오는 것이 아니며, 그 심판결과가 양 등록 권리 사이에 통상실시권 허락 및 실시로 지급 등의 문제해결을 위한 전제가 될 수 있으므로, 확인의 이익이 있는 것이어서 인정될 수 있는 것이다.²⁴⁹⁾ 그러나 이는 동종의 권리 사이의 문제이고, 만일 이종의 권리 사이라면 이종의 권리 사이에서는 보호대상으로 상이로 인해 선출원주의가 적용되지 않으므로 인용심결을 하더라도 타방의 권리를 부정하지 않으면서 확인을 구할 수 있어서 허용되는 것이다.²⁵⁰⁾

【표 7-6】 권리 사이의 권리범위확인심판의 인정 여부

청구방식		적극적	소극적
대상	권리 대 비권리	허용	허용
권리 대 권리	동종 권리	원칙은 불허. 단 이용관계에 있어 인용심결이 등록권리의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에 허용	인용심결이 타방의 권리의 효력을 부정하지 않기 때문에 허용
	이종 권리	인용심결이 등록권리의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에 허용	

2. 간접침해 물품에 대한 권리범위확인심판 가부

특허발명의 권리범위가 간접침해 물건 또는 그 물건을 양도하는 행위 등에 미치기 때문에 간접침해 물건에 대해서도 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.²⁵¹⁾

249) 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161 판결에서 특허등록된 확인대상발명이 선 특허발명인 제30항 발명과 이용관계에 있는가가 문제되었다. 위 판결의 사안에서 제30항 발명은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대 등의 효과를 위하여 선재를 한 방향으로만 형성한 것인 데 비하여, 확인대상발명은 하나의 석쇠틀에서 가로, 세로 방향으로 선재가 교차되는 양방향 구성을 채택하고 있었다. 심결과 원심은 이용관계에 있다고 판단하여 일단 본안판단으로 나아간 후 막상 권리범위 속부 실체 판단에서는 확인대상발명의 구성이 제30항 발명의 권리범위에서 의식적 제외된 구성이라고 보아 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 그러나 대법원은, 이용관계 해당 여부에 관한 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결의 판단기준을 인용한 다음, 하나의 석쇠틀에서 가로, 세로 방향으로 선재가 교차되는 확인대상발명의 양방향 구성은 구이의 늘어붙음 방지, 열원 노출면적 확대와 같은 한 방향 구성의 효과를 나타낼 수 없어 제30항 발명과 상이한 구성이라고 할 것이고, 확인대상발명 내에서 제30항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 볼 수도 없어 두 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 권리범위확인심판 청구는 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적절하다고 판단하였다.

250) 한편 당사자 일방 또는 쌍방이 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판을 주장하거나 권리 대 권리임이 정황상 의심되는 경우, 확인대상발명과 후등록 발명과의 동일성 여부가 쟁점이 될 수 있다. 확인대상발명과 후등록 발명의 동일 여부는 확인대상발명과 후등록 발명의 구성요소가 서로 빠짐없이 대응되고 대응되는 구성거리 표현의 차이 정도에 불과하다면, 양 발명은 동일한 것으로 보아 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판으로 본다(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 534-535면).

251) 대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580; 2004. 10. 14. 선고 2003후2164.

3. 무효심판과 권리범위확인심판의 모순된 주장에 대한 금반언 적용 여부

동일한 특허에 관한 종전 무효사건에서 했던 청구범위의 해석 주장과 그 내용과 범위를 달리하는 주장을 후속 권리범위확인 사건에서 한 경우 금반언 원칙 또는 신의칙에 위반되는 행위라고 볼 수 있는지 문제이다. 신의성실의 원칙에 위배된다는 이유로 당사자의 소송상 주장을 허용하지 않기 위해서는 그 주장과 관련하여 상대방에게 신의를 공여하였거나, 객관적으로 보아 상대방이 신의를 가짐이 정당한 상태에 있어야 하고, 이러한 상대방의 신의에 반하여 모순된 주장을 하는 것이 정의관념에 비추어 용인될 수 없는 정도의 상태에 이르러야 한다. 그런데 i) 무효 사건에서의 주장을 상대방이 신뢰하였다거나, 주장에 대한 입장을 바꾸지 않을 것이라고 상대방이 정당한 신뢰를 가지게 되었다고 볼 근거가 없다는 점, ii) 법원(심판원)이 소송에서의 청구범위 해석에 관한 당사자의 주장에 기속되지 않는다는 점, iii) 특허법에서 인정하는 금반언의 원칙의 이론적 근거 중 하나가 심사과정 및 정정절차 등이 특허권의 보호범위를 공시하고 있으므로 이를 신뢰한 자를 보호해야 한다는 것인데 소송과정에서 당사자의 주장이 특허권의 보호범위를 공시하는 역할을 한다고 볼 근거도 없다는 점 등을 고려하였을 때 소송(심판)절차에서의 당사자의 주장에 신의성실이나 금반언을 적용하기는 어렵다.²⁵²⁾

252) 특허법원 2023. 11. 30. 선고 2023허11593.

제5절 정정심판

제136조 【정정심판】

- ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
 1. 청구범위를 감축하는 경우
 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
- ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다. <신설 2016.2.29.>
 1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.
 2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간
- ③ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. <개정 2016.2.29.>
- ⑤ 제1항에 따른 정정 중 같은 항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다. <개정 2016.2.29.>
- ⑥ 심판관은 제1항에 따른 심판청구가 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정하는 경우에는 청구인에 게 그 이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. <개정 2016.2.29.>
 1. 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 경우
 2. 제3항에 따른 범위를 벗어난 경우
 3. 제4항 또는 제5항을 위반한 경우
- ⑦ 제1항에 따른 정정심판은 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만, 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(제133조제1항제4호에 의한 무효는 제외한다)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>
- ⑧ 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 제100조제4항·제102조제1항 및 「발명진흥법」 제10조제1항에 따른 통상실시권을 갖는 자의 동의를 받아야만 제1항에 따른 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2016.2.29.>
- ⑨ 제1항에 따른 정정심판에는 제147조제1항·제2항, 제155조 및 제156조를 적용하지 아니한다. <신설 2016.2.29.>
- ⑩ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다. <개정 2016.2.29.>
- ⑪ 청구인은 제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)에 제140조제5항에 따른 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ⑫ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 지식재산처장에게 알려야 한다. <개정 2016.2.29.>
- ⑬ 지식재산처장은 제12항에 따른 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재하여야 한다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「정정심판」이란 특허권자가 특허권이 설정등록된 후에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 구하는 심판을 말한다(法 136). 정정심판은 독립한 심판에 의한 정정이라는 점에서 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판절차에서의 특허의 정정제도와 구별된다.253)

2. 취 지

청구범위에 기재된 내용은 대세적 효력을 가지므로 임의적으로 변경되어서는 안 되나 i) 제한적 범위에서 특허발명의 내용을 명확히 함으로써 제3자와의 분쟁의 소지를 미리 방지하는 한편 ii) 특허권의 무효를 방지하여 특허권자를 보호하기 위하여 정정심판제도를 두고 있다. 이러한 정정심판은 특허무효심판 또는 정정무효심판이 청구되었을 때 소송단계에서의 대응책으로서 의미가 있다.

II. 심판의 요건

1. 청구인

특허권자만이 정정심판을 청구할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法 139③). 또한 특허권자는 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의를 받아야만 특허의 정정심판청구를 할 수 있다. 다만 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다(法 136⑧).

2. 정정청구사유

(1) 청구범위의 감축 등에 해당할 것

① 의 의

특허권자는 i) 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, iii) 분명

253) 등록 후 정정제도인 특허의 정정과 정정심판은 다음과 같은 차이가 있다.

구 분	독립적 청구	독립적 처분	독립적 불복
특허의 정정청구 (기생제도)	× (특허취소신청·특허무효심판·정정무효심판에 기생)	× (심결문의 주문 및 이유란에 기재)	× (불복의 대상이 없기 때문)
특허정정심판의 청구 (독립제도)	○	○	○

하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다(法 136①).²⁵⁴⁾

② 청구범위를 감축하는 경우

청구범위를 감축하는 경우로서는 다음과 같은 예를 들 수 있다.

- i) 택일적으로 기재된 선택요소의 삭제
- ii) 상위개념의 기재로부터 하위개념의 기재로의 변경
- iii) 구성요소의 직렬적 부가
- iv) 청구항의 삭제(다만 감축이 정정 후 청구항 일부가 남아 있는 것을 전제로 하는 것이기 때문에 청구범위 전체의 삭제는 불인정)
- v) 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항수의 감소

③ 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우

잘못 기재된 사항을 정정하는 경우란 특허발명의 명세서 또는 도면 중 오기를 명확한 내용의 자구(字句)나 어구(語句)로 고치는 것을 말한다.²⁵⁵⁾ 잘못된 기재의 정정으로 인정되기 위해서는 정정전의 기재내용과 정정후의 기재내용이 동일한 의미를 표시하는 것이라고 객관적으로 인정될 수 있어야 한다.²⁵⁶⁾

④ 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우

분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우로서는 다음과 같은 예를 들 수 있다.

- i) 문리(文理)상 의미가 명확하지 아니한 기재를 바로잡는 경우²⁵⁷⁾
- ii) 그 자체의 기재내용이 다른 부분의 기재와 관련하여 불합리한 관계를 바로 잡는 경우
- iii) 발명의 신규성, 진보성을 명확히 하기에 불충분한 기재를 정정하여 특허결정 시의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 명확히 하는 경우
- iv) 청구범위의 기재 내용 자체의 의미는 명백하더라도 발명의 카테고리나 분명하지 아니하여 발명의 내용을 명백히 확정할 수 없는 경우²⁵⁸⁾
- v) 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순이 없게 하는 경우²⁵⁹⁾

254) 물질과 용도를 구성요소로 하는 의약용도발명에 있어서 약리기전을 부가하는 정정은 용도를 2번 기재한 것에 지나지 않기 때문에 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 것을 정정하는 경우, 또는 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238).

255) 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2451 참조.

256) 특허심판원, 「심판판람」, 제14판, 2024, 782면.

257) 특허법원 2014. 7. 3. 선고 2014허744.

258) 특허법원 2012. 10. 25. 선고 2012허6342.

259) 청구범위는 발명의 설명에 기재된 기술적 사상의 전부 또는 일부를 특허발명의 보호범위로 특정한 것이고, 발명의 설명에 기재된 모든 기술적 사상이 반드시 청구범위에 포함되어야 하는 것은 아니므로, 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재되어 있지 아니한 사항이 발명의 설명에 포함되어 있다고 하여 발명의 설명과 청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우라고 보기는 어렵다(대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184).

(2) 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위일 것

1) 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다(法 136③본문). 이는 특허권이 등록된 후 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위내에서 청구범위의 감축이나 잘못 기재된 사항을 없애 바르게 하는 정정을 허용하기 위함이다. 따라서 등록되기 이전의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면이나 보정서의 기재에 대상으로 하여서는 아니 된다.²⁶⁰⁾ 한편 「명세서 또는 도면에 기재된 사항」이라 함은 명시적으로 기재되어 있는 것뿐만 아니라 기재되어 있지는 않지만 출원 시의 기술상식으로 볼 때 통상의 기술자이면 명시적으로 기재되어 있는 내용 자체로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함한다. 따라서 상위개념을 하위개념으로 정정하였다고 하더라도 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다.²⁶¹⁾

2) 다만 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 가능하다(法 136③단서). 이는 특허발명의 명세서 또는 도면, 즉 등록된 명세서 또는 도면을 기준으로 다수의 정정심판청구를 할 경우 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 최종적으로 명세서 또는 도면에 기재된 발명이 변경될 개연성이 상당하기 때문이다. 또한 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면을 기준으로 한 경우에만 신규사항추가금지(法 47②전단) 위반으로 착오로 등록된 경우 정정심판청구를 통해 특허무효사유(法 133①)를 극복할 수 있기 때문이다.

(3) 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않을 것

① 의 의

명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(法 136④). 등록된 명세서와 도면을 신뢰하여 권리 관계를 형성한 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 있기 때문이다. 「청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경한다」란 청구범위에 적혀 있는 발명에 대하여 그 내용, 범위, 성질 등을 확장하거나 변경하는 것으로서, 정정 전과 정정 후에 특허권의 효력이 미치는 한계에 차이가 발생하는 것을 말한다.²⁶²⁾

② 실질적 확장·변경의 판단 시 비교대상

1) 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지 여부는 청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 설명을 포함하여 명세서 전체의 내용과 관련하여 그 정정 전후의 청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단되어야 한다. 청구범위의 정정이 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 명세서 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로

260) 특허법원 2012. 6. 28. 선고 2012허436. 또한 정정심판청구의 대상인 명세서나 도면과는 전혀 별도인 우선권 증명서류나 우리나라와 법제를 달리 하는 외국 등록특허들의 명세서 기재는 통상적으로 제3자가 그 내용을 알기 상당히 어려우므로 정정심판을 청구할 수 있는 사유의 존재 여부 등을 판단하기 위한 자료로 삼기는 더더욱 어렵다.

261) 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404.

262) 특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허5966.

반영한 것이어서 후출원인이나 그 밖의 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려가 없는 경우에는 청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다고 할 것이다.²⁶³⁾ 이는 청구범위를 해석할 때 발명의 설명을 참작하여야 한다는 원칙과 같은 맥락이다.

2) 실질적 변경 여부를 판단함에 있어서는, 청구항 대 청구항이 아니라 전체로써 판단하기 때문에, 정정 후 청구범위에서 가장 근접한 청구항을 찾고 이 청구항을 기준으로 추가되거나 변경된 내용이 실질적으로 변경된 것인지를 판단한다.²⁶⁴⁾²⁶⁵⁾

③ 청구범위의 감축과 실질적 변경

1) 청구범위의 감축이란 청구항을 삭제하거나 청구항을 한정 또는 부가하는 경우를 말한다. 청구항을 삭제하는 경우는 실질적 변경이 아니지만, 청구항을 한정(상위개념의 기재를 하위개념의 기재로 변경하는 내적부가) 또는 부가(구성요소의 직렬적 부가인 외적부가)하는 경우는 청구범위의 감축일지라도 새로운 목적 및 효과를 갖게 되어 실질적 변경에 해당한다면 정정을 허용할 수 없다.

2) 청구항을 한정(내적부가)하는 경우 상위개념을 하위개념으로 정정하되 하위개념의 발명이 선택발명이 되어 특허성을 가지게 되고 또 그 하위개념의 발명이 특허명세서에 기재가 되어 있지 아니한 경우에는 그러한 정정은 청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당한다 할 것이나, 그렇지 아니하고 청구범위에 기재된 상위개념의 발명을 명세서에 기재된 하위개념의 발명으로 감축하여 정정하는 것은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니하고 제3자에게 예측하지 못하는 손해를 줄 염려가 없으므로 허용되어야 할 것이다.²⁶⁶⁾

263) 이와 관련된 대법원 판례로는 대법원 1989. 3. 28. 선고 87후63; 2001. 12. 11. 선고 99후2815; 2005. 4. 15. 선고 2003후2010; 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 등이 있다. 구체적으로 아래의 대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결의 판시내용을 살펴보면, 실질적으로 상위개념의 것을 하위개념으로 정정하는 것으로 보고, 정정하려는 내용이 명세서 본문에 있는 사항이라는 점에서 그 청구범위 감축을 허용한 사례로 보인다.

“이 사건에서 특허발명은 처리될 모발을 가열 및 건조시키기 위하여 인체모발을 향해 적외선을 조사(照射)하는 적외선 형식의 모발처리촉진장치에 관한 것이었는데, 청구범위 제1항 중 「① 상부에 상기 반사기가 배치되어 상기 반사기의 피벗지지 운동을 위해 회전 가능하게 지지된 회전부재 및 ② 상기 회전부재를 작동시키는 구동부재로 구성되어 있는 것을 특징으로 하는 모발처리촉진장치」 구성을, 「② 상부에 상기 반사기의 일단이 피벗 가능하게 지지되어 있는 회전부재 및 ④ 상기 회전부재를 작동시키는 구동부재를 구비하며, ④ 상기 반사기가 상기 회전부재의 회전시 피스슬자의 머리의 정상부, 양측부 및 후부를 따라 이동하도록 상기 회전부재의 회전축을 중심으로 편심회전되는 것을 특징으로 하는 모발처리촉진장치」 구성으로 정정하고자 한 사안이었다. 이에 대해 판결은 ①을 ②로 정정하는 것은 정정 전에는 반사기의 어느 부분이 지지되는지가 불분명한데 반하여 정정에 의하여 분명하게 되고, 그 운동 경로를 보다 구체화한 것이며, ②를 ④로 정정하는 것은 실질적인 변화가 없는 것이고, ④는 정정 전의 ① 또는 정정 후의 ② 구성으로 인한 결과를 구체적으로 부연한 것에 불과하므로, 이 사건 정정은 청구범위 감축에 해당하고, 명세서 본문에 있는 내용을 그대로 반영한 것이므로 제3자에게 불측의 손해를 줄 염려도 전혀 없어 실질적인 변경에 해당하지 아니한다”라고 판시하였다.

264) 특허심판원, 「심판판람」, 제14판, 2024, 766면.

265) 정정 전의 청구범위 제8항 및 발명의 설명 등을 참작하지 아니한 채 정정 전후의 청구범위 제1항만을 그 비교대상으로 하여 그 청구범위가 실질적으로 변경되었다고 판단한 원심 판결에는 구 특허법 제63조의 법리를 오해하여 판결의 결과에 영향을 미친 위법이 있다(대법원 2004. 12. 24. 선고 2002후413).

3) 청구항을 부가(외적부가)하는 경우 새로이 부가된 구성요소에 의하여 정정 후 새로운 발명의 목적·효과가 생겨 그 청구범위가 내용상에 있어 다소간의 성질과 범위가 변하게 되므로, 실질적 변경에 해당하는지 여부에 대한 판단이 극히 어렵다. 이 경우, 정정에 따라 외견상 청구범위가 감축되는 것이라도 정정 전의 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 구성되는 발명의 「구체적인 목적의 범위」를 일탈하여 그 기술적 사항을 변경시키는 경우의 정정은 허용될 수 없고, 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 구성되는 발명의 구체적인 목적범위에서 명세서에 기재된 사항을 근거로 하여 기술적 사항을 부가하는 것은 제3자에게 불측의 피해를 가하지 아니하면 청구범위의 감축으로 허용되어야 할 것이다.²⁶⁷⁾

【표 7-7】 청구범위의 실질적 변경 여부에 대한 구체적 예

정정 전 명세서	정정 후 명세서	
	사례1	사례2
【발명의 설명】 A, A+B, A+C, A+B+C		
【청구범위】 1. A 2. A+B 3. A+C	【청구범위】 1. A+B 2. 삭제 3. A+C	【청구범위】 1. A+B+C 2. 삭제 3. 삭제

해설 【사례 1】은 청구항 1이 정정 전 'A'에서 정정 후 'A+B'로 변경되었으나, 'A+B'는 정정 전에 이미 발명의 설명 부분에 기재되어 있었던 사항이고, 정정 전 청구항 2에 기재되어 있던 기술 구성을 그 청구항만을 달리하여 정정한 것이므로 형식적으로 감축된 것일 뿐만 아니라, 청구항은 정정 전후에 달라졌다 하더라도 그 청구범위의 실질적인 내용은 동일한 것이어서 그 정정은 인정되어야 할 것이다. 그런데 위의 경우와는 달리, 【사례 2】는 청구항 1의 경우에 정정 전 'A'에서 'A+B+C'로 변경된 것으로, 'A+B+C'가 정정 전에 명세서에 없던 새로운 기술적 사항을 청구범위에 새로 추가한 것은 아니나, 정정 전 청구범위에 기재되어 있지 않았던 기술적 사항이 청구항 1에 부가된 것이어서 정정된 청구항 1이 새로운 목적 및 효과를 갖는지 여부를 판단하여 최종적으로 실질적 변경 여부가 결정되어야 하는 것이다. 즉 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 기술적 사항이 비록 정정 전의 명세서 또는 도면에 기재되어 있었던 기술적 사항이라 할지라도, 새로운 목적 및 효과를 갖는 것으로 인정될 경우에는 그 정정은 인정될 수 없는 것이다.

266) 특허법원 1999. 7. 1. 선고 98허9840.

267) 대법원 2004. 12. 24. 선고된 2002후413 판결은 “외적부가 정정 ㉔는 정정 전의 이 사건 특허명세서 부분에 그 기술구성이 자세히 기재되어 있던 것으로서 정정 전의 명세서에 없던 신규의 기술적 사항을 청구범위에 새로 추가한 것이 아닐 뿐만 아니라, 정정 전의 청구범위 제8항에 존재하고 있던 기술 구성을 그 청구항만을 달리하여 정정 후의 청구범위 제1항에 부가 감축한 것에 지나지 아니하므로, 비록 형식적으로는 그 감축되는 대상인 청구범위가 정정 전후에 달라졌다 하더라도 그 청구범위의 실질적인 내용은 동일하다 할 것이어서, 이 사건 정정 ㉔로 인하여 정정 전후의 이 사건 청구범위의 효력 범위가 확장되거나 변경된 것은 아니라고 할 것이다”라고 하여 명세서에 개시되어 있는 구성요소를 외적부가하는 정정을 인정하였다.

(4) 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것

1) 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에는 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다(法 136⑤). 정정 후의 청구범위에 기재된 발명이 제62조의 거절이유에 해당하지 않아야 한다. 다만 거절이유 중 배경기술의 기재(法 42③Ⅱ), 다항제 기재방법(法 42⑧), 하나의 특허출원의 범위(法 45)는 심사의 신속성을 위한 절차적 특허요건이고, 특허무효사유가 아니므로 이 요건을 적용하지 않는 것이 타당하다.

2) 한편 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에만 본 요건에 해당하는지 여부를 판단하고, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에는 본 요건에 해당 하는지 여부를 판단하지 아니한다. 따라서 정정대상으로 삼지 아니한 다른 부분에 분명하지 아니한 기재가 있다고 하더라도, 이는 원칙적으로 별도의 정정심판이나 특허무효심판절차에서 다룰 사항에 불과하고 해당 정정을 불인정할 사유는 되지 못한다.²⁶⁸⁾ 이는 정정한 명세서 또는 도면의 전체에 의하여 정정의 인정 여부를 판단하는데, 정정대상으로 삼지 아니한 다른 부분에 분명하지 아니한 기재가 본 요건을 만족하지 못해 정정을 인정해 줄 수 없게 된다면, 정정의 인정범위를 너무 좁혀 특허권자의 입장에서 실효적인 대응수단으로 작동할 수 없게 되기 때문인 것으로 사료된다.

3. 청구기간

(1) 원 칙

정정심판은 특허권 존속 중에는 물론 특허권이 소멸된 후에도 청구할 수 있다. 다만 특허취소결정이 확정되거나 특허를 무효(후발적 무효사유는 제외)로 한다는 심결이 확정된 후에는 그러하지 아니하다(法 136⑦).

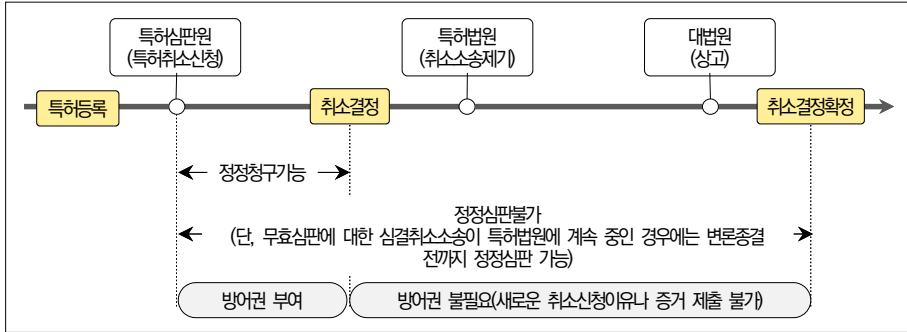
(2) 예 외

① 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간

1) 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다(法 136②Ⅰ 본문). 이는 특허취소신청에 대한 심판의 신속한 처리를 위한 것으로, 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 경우에는 특허권자가 특허의 정정청구를 할 수 있으므로 특허권자에게 방어권이 주어지고, 특허법원, 대법원에 계속 중인 경우에는 지식재산청장이 특허심판원에 제출하지 않았던 새로운 특허취소신청의 이유나 증거를 제출할 수 없을 것이므로 정정심판을 청구하지 못하더라도 특허권자의 방어권 행사를 제한하는 것은 아니기 때문이다.

²⁶⁸⁾ 특허법원 2012. 10. 25. 선고 2012허6342.

2) 다만 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고)을 말한 다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다(法 136② I 단서). 이는 특허취소신청과 특허무효심판(정정무효심판)이 겹쳐서 계속 중인 경우로서 특허무효심판(정정무효심판)의 심결에 대한 특허법원의 심리범위가 무제한설을 채택하고 있어 무효심판청구인의 새로운 이유나 증거 제출이 허용되므로 특허권자에게 방어적 기회를 주기 위함이다.



【그림 7-6】 특허취소신청의 단계에 따른 정정심판의 청구시기

② 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간

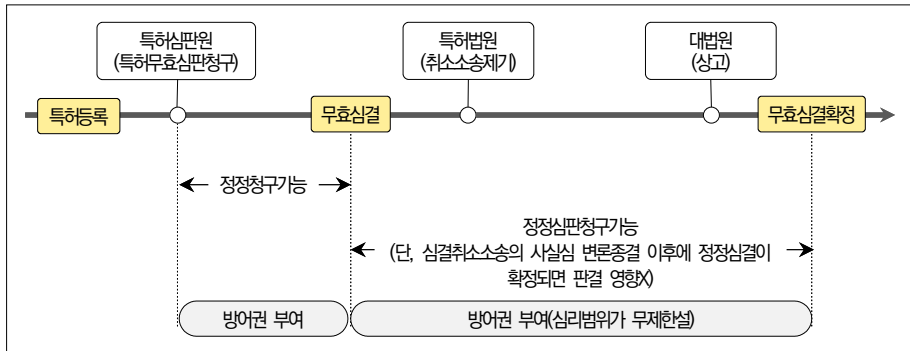
1) 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다(法 136② II). 이는 해당 절차 내에서 인정되는 특허의 정정청구를 하는 것이 절차의 신속한 진행과 심결 또는 결정의 모순·저축을 피할 수 있기 때문이다.²⁶⁹⁾ 그러나 특허법원 또는 대법원에 계속되어 있는 경우에는 정정심판을 청구할 수 있다. 이는 특허법원의 심리범위는 원칙적으로 무제한설을 채택하고 있기 때문에 무효심판청구인은 소송단계에서 그 전에 제출하였던 증거보다 더 확실한 새로운 증거를 제출할 수 있으므로 특허권자에게도 그 새로운 증거에 대한 대응방법으로서 정정심판을 제기할 수 있도록 한 것이다.²⁷⁰⁾

269) 특허의 정정과 정정심판은 시기에 따라 다음과 같이 구분될 수 있다.

시기	종류	정정청구	정정심판청구
심판원 계속 중	특허취소신청	○(法 132의3)	△*
	특허무효심판	○(法 133의2)	×
	정정무효심판	○(法 137③④)	×
특허법원 / 대법원 계속 중	특허취소신청	×	△*
	특허무효심판	×	○
	정정무효심판	×	○
계속 중이지 아니한 경우		×	○

* 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판청구 가능

2) 「특허심판원에 계속 중」인 경우란 특허무효심판의 청구서 부분이 특허권자에게 송달된 때부터 심결까지의 기간을 말한다. 심결 이후부터 심결에 대한 제소 가능 기간까지는 법원에 특허무효심판에 대한 소 제기가 가능하므로 특허심판원에 계속 중이라고 해석되지 않는다. 한편 특허를 무효로 한다는 특허법원 판결(취소환송)이 대법원에 의하여 심리불속행 확정된 후²⁷¹⁾ 청구된 정정심판은 해당 특허무효심판이 특허심판원에 계속 중인 상태에서 청구된 것으로 보아 부적법하다.²⁷²⁾



【그림 7-7】 무효심판의 단계에 따른 정정심판의 청구시기

III. 심판의 절차

1. 심판청구서의 제출

심판청구인은 법정사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(法 140①). 이때 정정한 명세서 또는 도면 및 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 대한 통상실시권자 및 권결자의 동의서를 첨부하여야 한다(法 140⑤). 구체적으로 명세서의 정정시에는 정정된 명세서 전문을 첨부하여야 하며, 명세서만을 정정할 때에는 도면을 첨부할 필요가 없고 반대로 도면만을 정정할 때에는 명세서를 첨부할 필요는 없다. 다만 결정계 심판이어서 피청구인이 존재하지 않으므로 심판청구 시 피청구인에 대한 청구서 부분의 송달 및 답변서에 관한 제147조제1항, 제2항과 참가에 관한 규정인 제155조, 제156조가 적용되지 아니한다(法 136⑨).

270) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 329면 참조.

271) 상고심결자에 관한 특례법 제5조제2항에 의하면, 심리불속행기간 판결은 선고가 필요하지 않으며, 상고인에게 송달됨으로써 그 효력이 생긴다.

272) 특허심판원, 「심판판람」, 제14판, 2024, 762면.

2. 심 리

(1) 의견서 제출 기회의 부여

정정심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다(法 154①). 심판관은 심리결과 심판청구가 정정청구사유(法 136①③④⑤)를 만족하지 아니한다고 인정하는 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 136⑥).

(2) 명세서 또는 도면의 보정

청구인은 심리종결의 통지가 있기 전(심리가 재개된 경우에는 다시 심리의 종결이 통지되기 전)까지 심판청구서에 첨부한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다(法 136⑩). 정정한 명세서 또는 도면은 청구 취지의 일부를 구성하므로 그 요지를 변경할 수 없다(法 140②). 정정명세서 등에 관한 보정은 당초의 정정사항을 삭제하거나 정정청구의 내용이 실질적으로 동일하게 되는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 심판청구취지의 요지를 변경하지 않는 것으로서 허용된다고 보아야 한다.²⁷³⁾ 즉 정정심판청구에 있어서는 정정을 구하는 부분(명세서 또는 도면)의 특징은 청구의 취지에 해당하므로 만일 정정심판청구서 중 정정을 구하는 부분이 보정에 의하여 변경됨으로써 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정심판청구서의 요지를 변경하는 것으로서 허용되지 아니한다. 여기서 요지변경이라 함은 청구범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것이라 할 것이다.²⁷⁴⁾

3. 심 결

(1) 심결내용

심판청구의 이유가 타당하지 아니한다고 인정된 때에는 기각심결을 하며, 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때에는 인용심결을 하여야 한다.

(2) 일부인용 또는 일부기각심결의 不可

특허발명의 명세서 또는 도면의 여러 곳에 걸쳐서 정정을 한 경우 일부인용·일부기각심결이 허용되는지 문제이다. 정정심판을 청구한 것은 일체불가분의 1개의 정정사항으로 하여 정정심판을 청구한 것으로 본다. 그러므로 명세서의 일부에 대하여 정정을 인정 또는 불인정하는 것은 결국 1개의 기술적 사상인 발명을 분리하여 판단하는 것이 되고, 이는 청구인이 신청하지 아니한 취지에 대하여 심리하는 것이 되므로 일부인용 또는 일부기각심결은 인정되지 아니한다(法 159②).²⁷⁵⁾ 다만 상술한 바와 같이 심리종결통지 전까지는 정정한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있도록 함으로써 일부사항이 부적법하여 전체 심판청구가 배척되는 것을 보완하고 있다.

273) 대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 참조

274) 대법원 1997. 11. 14. 선고 96후2265 판결 참조

275) 특허법원 2002. 3. 15. 선고 2001허2894; 2000. 7. 21. 선고 99허2174 등.

(3) 불 복

기각심결에 대해서 특허권자가 불복할 경우에는 심판장으로부터 심결등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 취소소송을 제기할 수 있다(法 186①③). 다만 인용심결은 불복할 수 없기 때문에 등본송달시 확정된다. 이 경우 인용심결에 대하여 불만이 있는 이해관계인 또는 심사관은 정정무효심판을 청구할 수 있다(法 137①).

IV. 심결확정의 효과

1. 인용심결확정의 효과

(1) 소급효

특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다(法 136⑩).

(2) 특허공보에 게재

특허심판원장은 정정인용심결, 즉 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 그 내용을 지식재산처장에게 알려야 하며(法 136⑫), 지식재산처장은 특허심판원장으로부터 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재하여야 한다(法 136⑬).

(3) 새로운 특허증의 발급

지식재산처장은 정정심판의 심결이 확정된 경우에는 그 심결에 따른 새로운 특허증을 발급하여야 한다(法 86③).

(4) 정정심결 이전의 심결의 효력

사실심 변론종결이전에 정정심결이 확정되었는데 정정 전의 명세서 또는 도면에 의거하여 행하여진 심결 또는 판결은 정정심결의 소급효로 인하여 재심의 대상이 될 수 있다(法 178). 예를 들어 특허권이 설정등록된 후에 보상금청구권 행사에 관한 민사상 소를 제기하여 상대방에게 손해를 입혔는데 상기 보상금청구권의 행사 대상의 청구항이 정정심판에 의하여 삭제된 경우에는 민사상 판결은 재심사유에 해당한다. 다만 이 경우 특허권자가 상대방의 손해에 대하여 무과실 배상책임을 지는 것은 아니다.

2. 기각심결확정의 효과

기각심결이 확정된 경우에는 정정이 인정되지 아니한다.

V. 관련문제

1. 정정심판과 특허취소신청, 무효심판과의 관계

(1) 정정심판과 특허취소신청, 특허무효심판이 동시에 계속 중인 경우

특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간에는 정정심판을 청구할 수 없지만 특허무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다(法 136② I). 특허무효심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원이나 대법원에 계속 중인 경우에는 독립하여 그 정정심판을 청구할 수 있다(法 136② II). 또한 특허취소신청, 특허무효심판청구 전에 정정심판이 청구된 때는 특허취소신청, 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에서 동시에 계속되게 된다. 이 경우 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허취소신청, 특허무효심판에 우선하여 심리·판단하는 것이 바람직하나,²⁷⁶⁾ 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심리·판단하여야 하는 것은 아니다. 한편 특허취소신청, 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에는 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이다.²⁷⁷⁾

(2) 특허취소신청, 특허무효심판계속 중에 정정심판을 인정하는 심결이 확정된 경우

① 특허취소신청, 특허무효심판이 특허법원에 계속 중인 경우

1) 특허법원에 특허무효심결에 대한 취소소송이 계속 중 정정심결이 확정된 경우에는 특허심판원의 심결이 심판 대상을 잘못 정한 흠결이 있지만, 특허법원은 법률심이 아닌 사실심이고 심리범위에 제한을 받지 않기 때문에 정정된 청구범위를 기준으로 특허무효사유가 있는지 여부를 판단하여 그에 따라 심결의 적법성 여부를 판단하면 된다.²⁷⁸⁾ 한편 특허법원에 특허취소결정에 대한 취소소송이 계속 중 정정심결이 확정된 경우에는 특허법원이 사실심이기거나 하나 지식재산처장이 특허심판원에 제출하지 않았던 새로운 특허취소신청의 이유나 증거를 제출할 수 없을 것이기 때문에, 결정을 취소하고 특허심판원으로 환송함이 타당하다.

2) 다만 특허법원에 특허취소신청, 특허무효심판이 계속 중인데 청구항을 삭제하는 정정심결이 확정된 경우에는 정정된 내용대로 소급효가 인정되므로 취소소송을 구할 실익이 없어져 소각하된다.²⁷⁹⁾

276) 정정심판을 우선 심리하여 판단하는 경우 특허취소신청, 특허무효심판은 정정심판의 심결이 확정될 때까지 재량으로 중지될 수 있다(法 164①②).

277) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713.

278) i) 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없는 점, ii) 등록무효심판 청구사건에 대한 심결취소소송의 심리범위에 제한이 없는 점(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 등), iii) 정정요건에 위반된 정정심결이 확정된 경우에도 정정무효심판을 청구할 수 있어서 특허법원에서 정정된 특허발명을 기초로 그 무효 여부를 판단하더라도 무효심판청구인에게 특별히 불리하다고 볼 수 없는 점 등에 비추어 볼 때, 등록무효심판의 심결 후에 청구범위가 정정되었다고 하더라도 심결취소소송에서 특허법원이 정정된 청구범위를 심결의 기초로 하여 특허발명에 무효사유가 존재하는지 여부를 판단할 수 있다(특허법원 2007. 7. 12. 선고 2005허10213; 2000. 11. 16. 선고 99허7971 참조).

② 특허취소신청, 특허무효심판이 대법원에 계속 중인 경우

1) 특허취소결정이나 무효심결에 대한 취소소송에 있어 특허법원의 변론 종결 후 정정에 대한 심결이 확정된 경우에, 기존의 대법원 판례²⁸⁰⁾는 민사소송법 제451조제1항제8호의 재심사유인 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀔 때에 해당하기 때문에 파기환송한다는 입장이었으나, 최근의 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결에서 “특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다”라고 판시하면서 종래의 판례를 변경하였다. 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”라는 재심사유는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, i) 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 ii) 확정적· iii) 소급적으로 변경된 경우를 말하는 것인데, i) 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 하는 대상이지 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없다는 점, ii) 정정이 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것이고, 정정심결이 확정되더라도 일사부재리가 적용되지 않고, 정정무효심판에 의하여 다룰 수 있으므로 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없는 점, iii) 제136조제10항에서 규정한 정정의 소급효는 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 특허심사심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사심판절차와 조화를 유지하면서 정정 제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다는 점, iv) 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차와 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것인데, 민사소송법 제1조제1항에서 “법원은 소송절차가 공정하고 신속하며 경제적으로 진행되도록 노력하여야 한다”라고 규정한 공정·신속·경제라는 민사소송의 이상에 비취 당사자에 의한 소송지연을 적절히 방지할 필요성이 있다는 점을 그 근거로 하고 있다.

2) 이러한 법리는 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용된다고 할 것이다. 따라서 특허무효심판이나 권리범위확인심판 등에 대한 심결취소소송과 별개로 진행되던 특허무효심판 절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 판결에 민사소송법 제451조제1항제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

3) 또한 2016후2522 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용된다. 특히 특허권에 기초한 침해금지 또는

279) 특허법원 2007. 7. 12. 선고 2005허10213.

280) 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후437; 2001. 10. 12. 선고 99후598; 2008. 7. 24. 선고 2007후852 등

손해배상 등을 구하는 소송에서 그 특허가 무효로 될 것이 명백하여 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특허권자로서는 특허권에 대한 정정심판청구, 정정청구를 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소했거나 해소할 수 있다는 사정을 그 재항변으로 주장할 수 있다. 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 종국판결이 확정되거나 그 확정 전에 특허권자가 정정의 재항변을 제출하지 않았음에도 사실심 변론종결 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실심 법원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다.

4) 다만 특허권자의 방어적 기회 확보를 위하여 특허권자가 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하면서 정정 후 명세서 등에 따라 판단해 달라고 요청한 경우 사실심 법원으로서의 정정 청구사유의 구체적 내용, 정정이 받아들여질 경우 심결취소소송의 결론에 영향을 미치는지 여부, 과거 정정내역, 정정할 기회가 보장되었는지 여부, 정정심판을 청구한 주된 목적이 소송을 지연하기 위한 것인지 여부 등을 종합적으로 고려하여 변론을 종결할지 여부를 합리적으로 결정해야 할 것이다.²⁸¹⁾

(3) 정정심판 계속 중에 특허취소신청에 대한 취소결정이나 특허무효심판에 대한 인용심결이 확정된 경우

특허발명의 전체 청구항에 대한 취소결정이나 무효심결이 확정되어 소급하여 소멸하면 정정을 구하는 정정심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정심판을 구할 이익도 없게 되고, 특허발명이 소급하여 취소, 무효로 된 이상 정정심결의 취소를 구할 법률상의 이익도 없게 되기 때문에 특허법원에 계속 중이거나 대법원에 계속 중이면 심결취소소송의 소는 각하된다.²⁸²⁾ 한편 정정심판이 특허심판원에 계속 중일 때 특허취소신청에 대한 취소결정이나 특허무효심판에 대한 인용심결이 확정되어 소급하여 소멸하면 정정심판은 심결각하된다.

【표 7-8】 정정심판과 특허취소신청, 특허무효심판의 관계

구 분	특허심판원에 계속 중	특허법원에 계속 중	대법원에 계속 중
정정심판에 대한 인용심결이 확정된 경우	정정된 특허발명에 의하여 특허취소사유, 특허무효사유를 심리	1. 특허취소신청의 경우(사실심 변론종결 전 한함) - 취소환송 2. 특허무효심판의 경우(사실심 변론종결 전 한함) - 정정된 특허발명에 의하여 특허무효사유를 심리	정정 전 특허발명에 의하여 법령 위반이 존재하는지 판단(특허법원의 사실심 변론 종결 후 포함)
특허무효심판에 대한 인용심결/특허취소신청에 대한 취소결정이 확정되어 소급소멸한 경우	정정심판은 심결각하	정정심판은 소각하	정정심판은 파기소각하

281) 이는 본 판결에서 이기택 대법관의 보충의견이다.

282) 특허법원 2009. 10. 12. 선고 2008허9498 등.

2. 정정심판과 침해죄

청구범위에 기재불비의 하자가 있어 권리범위를 인정할 수 없었던 특허발명에 대하여 그 청구범위를 정정하는 심결이 확정된 경우, 정정 전에 행하여진 피고인의 제품 제조, 판매행위가 특허권 침해죄에 해당하는지를 판단하면서 정정 전의 청구범위를 침해대상 특허발명으로 하여야 한다. 이와 같은 정정심결이 확정되었으면 그 정정이 별도의 정정무효심판절차에 의하여 무효로 되지 아니하는 한, 그 특허발명은 처음부터 정정된 청구범위에 따라 특허권 설정등록이 된 것으로 보아야 하지만, 헌법 제13조제1항, 형법 제1조제1항의 입법 취지 및 특허발명의 청구범위는 특허권자가 독점하여 실시할 수 있는 영역과 제3자가 침해해서는 아니 되는 영역을 객관적으로 확정하여 대외적으로 공시하는 규범적 효력이 있는 점에 비추어 보면, 피고인의 행위가 특허권 침해죄에 해당하는지를 판단하면서 정정 후의 청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수는 없기 때문이다.²⁸³⁾

3. 정정심판과 과실의 추정

특허권을 침해하는 제품을 생산·판매한 후에 정정하는 심결이 확정된 경우에도 정정으로 인해 청구범위의 실질적 변경이 있다고 할 수 없으므로 제130조에 따라 특허권 침해행위에 과실이 있는 것으로 추정하는 법리는 정정을 전후하여 그대로 유지된다고 봄이 타당하다.²⁸⁴⁾

4. 정정심판에서의 정보제공

정정심판에서는 제3자가 정보제공을 할 수 있다는 근거 규정이 명확하지 아니하나, 정정불인정요인이 있는 증거가 제출되어 직권심리가 가능한데도 이를 살피지 아니한다면 공익에 반하는 결과를 초래하므로 정정심판에서도 정보제공을 할 수 있다. 예를 들어 정정심판의 대상이 되는 권리에 대하여 무효심판의 심결취소소송이 계속되고 있는 경우 무효심판청구인에게 정정심판 사실을 통지하여, 무효심판청구인이 소송단계에서 새로 제출된 무효 증거를 기초로 정정심판에 대한 정보제공할 수 있는 기회를 부여한다.²⁸⁵⁾

283) 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262.

284) 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다19925.

285) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 179면.

【표 7-9】 특허의 정정과 정정심판의 비교

제 도		특허의 정정	정정심판
의 의		특허의 정정이란 특허권자가 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구하는 것을 말한다.	정정심판이란 특허권자가 특허권이 설정등록된 후에 특허발명의 명세서 또는 도면의 내용을 정정하는 심판을 말한다.
요 건	주체적	1. 특허권자만이 할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 하여야 함 2. 전용실시권자, 직무발명 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 집권자의 동의 없이(다만 특허권자가 정정청구를 하려면 동의를 받아야 하는 자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)	
	객체적	1. 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 및 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나 2. 특허발명의 명세서·도면의 범위 이내이어야 하며, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위일 것 3. 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위의 실질적 확장·변경× 4. 청구범위의 감축이나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 정정 후의 청구범위 기재사항이 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있을 것(단, 특허취소신청, 특허무효심판에 대한 정정청구에 있어서 특허취소신청, 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 판단×)	
	시기적	1. 답변서 제출기간(답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정되는 경우에 심판장이 정한 기간) 2. 직권심리에 대한 의견서 제출기간(특허취소신청의 경우는 취소결정하려고 취소이유통지하고 의견서 제출기간을 준 경우 이 기간에만)	1. 원 칙 특허권 소멸 후에도 가능 2. 예 외 ① 특허가 취소되거나 무효(단, 후발적 사유는 제외)된 경우 ② 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간 (다만 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고로 말한다)된 날까지 정정심판을 청구가능) ③ 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간
절 차	부본송달	무효심판절차에서 청구인에게 송달 (취소신청은 제외)	-
	정정명세서 등의 보정	정정청구를 할 수 있는 기간 또는 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간에 보정가능	심리종결통지 전에 보정가능
	취하	i) 정정청구를 할 수 있는 기간(法 132의3①, 133의2①, 137③)과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간, ii) 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간 중 어느 하나에 해당하는 기간	심결확정전
효 과	적법	원 칙	인용심결
		소급효	정정된 내용으로 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권이 설정등록된 것으로 간주
		특허공보 게재	특허의 정정 또는 적법한 정정심판에 대해서는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 지식재산처장에게 알려야 하며 지식재산처장은 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재
	부적법	기 간	불수리 심판청구를 심결각하
		범 위	원칙 별도의 각하결정없이 결정, 심결의 「이유판」에 특허의 정정 불채택이유 기재 기간과 정정무효사유에 해당 기각심결
		불 복	독립하여 불복× 특허법원에 기각심결에 대하여 불복

제6절 정정무효심판

제137조 [정정의 무효심판]

- ① 이해관계인 또는 심사관은 제132조의3제1항, 제133조의2제1항, 제136조제1항 또는 이 조 제3항에 따른 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정을 위반한 경우에는 정정의 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
 1. 제136조제1항 각 호의 어느 하나의 규정
 2. 제136조제3항부터 제5항까지의 규정(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)
- ② 제1항에 따른 심판청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다.
- ③ 제1항에 따른 무효심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ④ 제3항에 따른 정정청구에 관하여는 제133조의2제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제133조의2제3항 중 “제133조제1항”은 “제137조제1항”으로 보고, 같은 조 제4항 후단 중 “제133조의2제1항”을 “제137조제3항”으로 보며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 “제1항”을 각각 “제3항”으로 본다. <개정 2016.2.29.>
- ⑤ 제1항에 따라 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「정정무효심판」이란 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정(특허취소신청, 특허무효심판 절차 또는 정정무효심판에서의 정정, 정정심판에 의한 정정)이 부적법한 경우에 그 정정을 소급하여 소멸시켜 줄 것을 청구하는 심판을 말한다(法 137). 특허무효심판은 특허에 무효사유가 있는 경우에 그 특허 자체를 성립 당초까지 소급하여 효력을 상실시키는 것임에 반하여 정정무효심판은 특허 자체에 대한 무효가 아니라 정정청구 또는 정정심판청구에 의하여 정정된 명세서 또는 도면에 대하여서만 무효시키는 것이다. 한편 특허발명의 정정이 부적법한 것이라고 하더라도 정정의 무효심판에서 그 위법 여부를 다룰 수 있음은 별론으로 하고 정정된 특허발명을 당연무효라고 할 수 없다.²⁸⁶⁾

286) 대법원 2003. 1. 10. 선고 2002후1829.

2. 취 지

정정에 의하여 특허권의 권리범위가 사후적으로 확장되거나 특허될 수 없는 것이 유효한 특허로 됨으로써 일반의 제3자가 입게 될 불측의 손해를 방지하려는 데에 제도의 의의가 있다.

II. 정정무효사유

1. 제136조제1항 각호의 어느 하나의 규정에 위반된 경우

명세서 또는 도면에 대한 정정이 i) 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 및 iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 위반된 경우에는 정정무효사유이다.

2. 제136조제3항부터 제5항(제132조의3제2항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용하는 경우를 포함한다)에 위반된 경우

특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판에서의 절차나 정정심판 절차에서의 i) 명세서 또는 도면의 정정이 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우(잘못 기재된 사항을 정정하는 경우는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위를 벗어난 경우)(法 136③), ii) 명세서 또는 도면의 정정이 청구범위의 실질적 확장 또는 변경인 경우(法 136④), iii) 청구범위를 감축하는 경우나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 없는 경우(法 136⑤)는 정정무효사유이다.

III. 심판의 요건

1. 청구인·피청구인

정정무효심판은 이해관계인 또는 심사관이 청구할 수 있으며, 특허권자가 피청구인이다. 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두를 피청구인으로 하여야 한다(法 139②).

2. 청구대상

특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판에서의 특허의 정정(法 132의3①, 133의2①, 137③)이나 정정심판에서의 정정(法 136)이 대상이다.

3. 청구시기

정정무효심판은 정정심결이 확정된 이후이면 특허권의 존속 중에는 물론 특허권의 소멸 후에도 청구할 수 있다(法 137② 준용 法 133②).²⁸⁷⁾ 다만 정정된 명세서 또는 도면에 의하여 특허 무효심결이 확정이나 취소결정이 확정되어 특허권이 소급소멸한 경우에는 청구할 수 없다.

IV. 심판의 절차

1. 심판청구서의 제출

심판청구인은 법정사항을 적은 심판청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(法 140①).

2. 부분 송달 및 답변서 제출기회의 부여

심판장은 심판이 청구되면 심판청구서 부분을 피청구인에게 송달하고 기간을 정하여 답변서 제출기회를 주어야 하며, 답변서를 받았을 때에는 그 부분을 청구인에게 송달하여야 한다(法 147①②). 또한 심판장은 무효심판이 청구되었다는 취지를 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다(法 137② 준용 法 133④).

3. 특허의 정정청구

정정무효심판절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 i) 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 정정무효심판에 대한 답변서 제출기간(심판장이 답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있는데 그 기간) 또는 심판관의 직권심리에 의한 의견서 제출기간에 정정청구를 할 수 있다(法 137 ③). 이는 정정이 무효로 될 우려가 있는 경우 무효심결을 회피하기 위함이다.

287) 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 무효로 된 특허에 대한 정정의 무효를 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 된 결과 정정 자체의 무효를 구할 이익도 없어진다고 할 것이다. 특허법 제136조 제8항에 의하여 정정심결이 확정된 때에는 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원되고 이후 이에 입각하여 특허권 설정등록까지의 절차가 이루어진 것으로 간주하는 것은 무효부분을 포함하는 특허를 본래 유효로 되어야 할 범위 내에서 존속 시키기 위한 것이므로, 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 최초의 출원서 또는 출원공개된출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 그 후 정정되었다 하더라도, 그 정정내용이 조약에 의한 우선권 주장의 기초가 된 발명의 내용 또는 신규성·진보성 판단에 제공되는 선행기술로서의 발명의 내용에 영향을 미칠 수 없다. 따라서 이와 다른 전제에서 특허가 무효로 된 이후에도 여전히 그 정정의 무효심판을 청구할 이익이 있다는 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후620).

4. 심 리

정정무효심판은 구술심리 또는 서면심리로 한다. 다만 당사자가 구술심리를 신청하였을 때에는 서면심리만으로 결정할 수 있다고 인정되는 경우 외에는 구술심리를 하여야 한다(法 154①). 한편 정정무효심판은 당사자에게 심판으로서 심판의 참가가 허용된다.

5. 심 결

(1) 심결내용

i) 심판청구의 이유가 타당하지 아니한다고 인정된 때에는 기각심결을 하며, ii) 심판청구의 이유가 타당하다고 인정된 때에는 인용심결을 하여야 한다.

(2) 불 복

심판장으로부터 심결등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 취소소송을 제기할 수 있다(法 186①).

V. 심결확정의 효과

1. 인용심결확정의 효과

정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 137② 준용 法 133③).

2. 기각심결확정의 효과

기각심결이 확정된 경우에 정정은 유지된다. 이 경우 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 동일한 무효심판을 청구할 수 없으며 동일한 무효심판을 청구하면 심결각하된다(法 163).

제7절 통상실시권허락심판

제138조 【통상실시권 허락의 심판】

- ① 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 청구가 있는 경우에 그 특허발명이 그 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이 아니면 통상실시권을 허락하여서는 아니 된다.

- ③ 제1항에 따른 심판에 따라 통상실시권을 허락한 자가 그 통상실시권을 허락받은 자의 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우 그 통상실시권을 허락받은 자가 실시를 허락하지 아니하거나 실시의 허락을 받을 수 없을 때에는 통상실시권을 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다.
- ④ 제1항 및 제3항에 따라 통상실시권을 허락받은 자는 특허권자, 실용신안권자, 디자인권자 또는 그 전용실시권자에게 대가를 지급하여야 한다. 다만, 자기가 책임질 수 없는 사유로 지급할 수 없는 경우에는 그 대가를 공탁하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 통상실시권자는 그 대가를 지급하지 아니하거나 공탁을 하지 아니하면 그 특허발명, 등록실용신안 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 실시할 수 없다.

[전문개정 2014.6.11.]

1) 「통상실시권허락심판」이란 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자가 해당 특허발명이 이용·저촉 관계에 해당되어 실시의 허락을 받으려는 경우에 선출원 특허권자·실용신안권자·디자인권자 또는 그 전용실시권자가 정당한 이유없이 실시허락을 아니하거나 실시허락을 받을 수 없을 때 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권의 허락을 구하기 위하여 청구하는 심판을 말한다(法 138).

2) 오늘날 기술이 점점 고도화·복잡화해가면서 대다수의 발명이 기존의 발명을 이용하여 완성되는 경우가 허다하다. 이러한 경우에 선출원 발명의 보호에만 치우친 나머지 선출원 발명을 기초로 하여 완성한 이용·개량발명의 실시를 타인 특허권의 침해로만 규정하여 이용·개량발명을 보호하지 아니한다면 기존의 발명을 이용·개량하려 하는 자는 아무도 없을 것이므로 이는 결과적으로 기술개발과 산업발전에 이바지하려는 특허제도의 목적에도 반하는 것이 된다. 따라서 이처럼 선후발명 간에 이용관계가 있으면 i) 선출원우위의 원칙에 따라 이용·저촉관계에 있는 당사자 간의 권리관계를 조정하되 ii) 후출원 특허발명에 대해서도 심판에 의하여 실시할 수 있는 방안을 마련해 두기 위해 통상실시권허락심판 제도를 두고 있다.

【표 7-10】 심판각론의 비교 (1)

제 도		거절결정불복심판	정정심판	권리범위확인심판
요 건	청구인	출원인	특허권자	1. 적극적 - 특허권자 또는 전용 실시권자 2. 소극적 - 실시한 적/하고 있거나 예정이 있는 이해관계인
	피 청구인	×	×	1. 적극적 - 실시한 적/실시하고 있는 이해관계인 2. 소극적 - 특허권자
	대상	거절결정	1. 청구범위의 감축, 잘못 기재된 사항의 정정 및 분명하지 아니하게 기재된 사항의 명확화 중 어느 하나 2. 특허발명의 명세서·도면(단, 잘못 기재된 사항의 정정은 최초 명세서·도면) 3. 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니할 것 4. 청구범위의 감축, 잘못 기재된 사항의 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허 출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있을 것	청구항마다 가능
	시기	등본송달받은 날로부터 3개월 이내(연장, 추후보완 가능)	1. 존속기간 중은 물론 장래를 향해 소멸한 경우도 가능 2. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간(단, 특허/정정무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고를 말한다)된 날까지 가능)과 특허/정정무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 불가	특허권 존속기간 중에만 가능
절 차	청구	출원일 및 출원번호, 발명의 명칭, 특허거절결정일을 추가 기재	1. 정정한 명세서 또는 도면의 첨부 2. 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 대한 통상실시권자 및 질권자의 동의서를 첨부(단, 동의받아야 하는 자가 무효심판청구한 경우 제외)	1. 확인대상발명의 설명서 및 필요한 도면의 첨부 2. 부분 송달 및 답변서 제출기회 부여
	진행	1. 보정각하도 함께 불복한 경우 심리범위 포함 2. 심사에서 밝은 절차의 효력이 심판에도 미침 3. 거절이유 전면적 심리	1. 정정청구사유를 만족하는지 직권심리 후 의견서를 제출할 수 있는 기회 부여 2. 심리종결통지 전까지 정정명세서 또는 도면의 보정	확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 심리
	종료	1. 심판청구가 타당한 경우 원거절결정을 취소하고 재판(특허심결) 또는 환송 2. 환송 시 심사관의 기속	일부인용·기각 불가	1. 심판청구가 타당하지 않은 경우 기각한다고 하여야 되며, 청구취지에 반하는 심결을 해서는 안됨 2. 청구항별 취하 가능
확 정 효 과	인용	1. 특허결정된 경우 특허료 내면 특허권 발생 2. 연장등록결정된 경우 지식재산처장이 특허원부 등록/특허공보 게재	1. 정정된 내용대로 출원·공개·결정·심결·등록된 것으로 간주 2. 심판원장이 지식재산처장에게 알리면, 지식재산처장이 특허공보에 게재 3. 침해되는 정정 전 청구범위 기준 판단 4. 정정전후 과실 추정 불변	보호범위의 공적 확인/단, 법원의 기속력 불인정
	기각	거절결정 확정	정정의 불인정	
심판비용		청구인		패십자
일사부재리		부작용		적용(적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판)
참가 여부		불허(단, 정보제공 가능)		허용
비 고			정정심판과 특허취소신청/특허무효심판의 관계	권리 사이의 권리범위확인심판

【표 7-11】 심판각론의 비교 (2)

제 도		특허무효심판	연장등록무효심판	정정무효심판	통상실시권허락심판
요건	청구인	이해관계인(제2호 본문의 경우 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자) 또는 심사관	이해관계인 또는 심사관		1. 일반적 - 후출원 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자 2. 크로스 라이선스 - 통상실시권을 허락한 선출원 권리자
	피 청구인	특허권자			1. 일반적 - 선출원 특허권자, 전용실시권자, 실용실안권자, 디자인권자 2. 크로스 라이선스 - 통상실시권을 허락받은 후출원 특허권자, 전용실시권자
	대상	청구항마다 특허무효사유에 해당함을 이유로 청구	허가 등/등록지연에 따른 연장등록이 연장등록무효사유(거절이유와 동일)에 해당함을 이유로 청구	특허취소신청에서의 정정, 특허무효심판 또는 정정무효심판에서의 정정, 정정심판에서의 정정이 정정무효사유(정정청구사유와 동일)에 해당함을 이유로 청구	1. 이용·저촉관계 2. 실시허락 x 3. 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위 이내일 것 4. 선출원된 타인의 특허발명 또는 등록실용신안과 비교하여 기술상의 진보가 있을 것
	시기	존속기간 중은 물론 장래를 향해 소멸한 경우도 가능			타방 권리 존속 중에만 가능
절차	청구	1. 부분 송달 및 답변서 제출기회 부여 2. 등록된 권리자에게 취지 통지			1. 청구서에 자기의 권리, 타인의 권리 특정과 범위·기간·대가의 추가 기재 2. 부분 송달 및 답변서 제출기회 부여
	진행	신청한 청구항에 대해서 특허무효사유가 있는지 심리	연장등록무효사유가 있는지 심리	정정무효사유가 있는지 심리	이용·저촉관계에 있는지, 기술적 진보 여부, 범위·기간·대가·지급시기·지급방법 등에 관해 심리
	종료	1. 청구항마다 일부인용·기각 가능 2. 청구항별 취하 가능			심결의 주문에 통상실시권의 범위, 기간 및 대가를 구체적으로 명시하여 인용심결
확정효과	인용	특허권이 처음부터 없었던 것으로 간주(단, 후발적 무효사유는 발생 시부터 장래효)	1. 연장등록이 처음부터 없었던 것으로 간주(단, 연장기간을 초과하여 등록된 경우에는 초과된 기간에 대해서만 연장등록 불인정) 2. 하나의 허가 등에 대하여 둘 이상의 특허권의 존속기간이 연장등록된 경우 존속기간의 연장등록출원은 처음부터 없었던 것으로 간주	정정이 처음부터 없었던 것으로 간주	1. 통상실시권 허락 2. 실시권은 해당 특허권과 함께 이전하며, 함께 소멸 3. 대가 지급하지 않거나 공탁하지 않으면 실시불가
	기각	특허권의 유지	연장등록의 유지	정정의 유지	통상실시권 불허
심판비용		패십자			청구인
일사부재리		적용(전부무효심판과 일부무효심판)	적용		
참가 여부		허용			보조 참가만이 허용
비 고		특허무효심판이 심판원에 계속 중 정정청구 가능		정정무효심판이 심판원에 계속 중 정정청구 가능	크로스 라이선스 요건 - 통상실시권허락심판에 의하여 실시권허락 - 후출원 권리자가 실시허락 x - 허락받아 실시하려는 특허발명의 범위 이내일 것

제8절 특허취소신청 및 특허의 정정청구

제1관 특허취소신청

제132조의2 【특허취소신청】

- ① 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허심판원장에게 특허취소신청을 할 수 있다. 이 경우 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다.
 1. 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)에 위반된 경우
 2. 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우
- ② 제1항에도 불구하고 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다.

[본조신설 2016.2.29.]

[종전 제132조의2는 제132조의16으로 이동 <2016.2.29.>]

제132조의3 【특허취소신청절차에서의 특허의 정정】

- ① 특허취소신청절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제132조의13제2항에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 특허취소신청절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.
- ③ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항, 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다. 이 경우 제136조제11항 중 “제162조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)”은 “제132조의13제2항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에”로 본다.
- ④ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.
 1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간
 2. 제3항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간
- ⑤ 제3항을 적용할 때 제132조의2에 따라 특허취소신청이 된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

[본조신설 2016.2.29.]

[종전 제132조의3은 제132조의17로 이동 <2016.2.29.>]

제132조의4 【특허취소신청의 방식 등】

- ① 특허취소신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다.
 1. 신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 2. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
 3. 특허취소신청의 대상이 되는 특허의 표시
 4. 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시
- ② 제1항에 따라 제출된 특허취소신청서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 제132조의2제1항에 따른 기간(그 기간 중 제132조의13제2항에 따른 통지가 있는 경우에는 통지한 때까지로 한정한다)에 제1항제4호의 사항을 보정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 신청서의 부분을 특허권자에게 송달하여야 한다.

- ④ 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 사실을 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다.

[본조산설 2016.2.29.]

제132조의5【특허취소신청서 등의 보정·각하】

- ① 심판장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다.
1. 특허취소신청서가 제132조의4제1항(같은 항 제4호는 제외한다)을 위반한 경우
 2. 특허취소신청에 관한 절차가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
가. 제3조제1항 또는 제6조를 위반한 경우
나. 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식을 위반한 경우
다. 제82조에 따라 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우
- ② 심판장은 제1항에 따른 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 제132조의4제2항을 위반한 경우에는 특허취소신청서 또는 해당 절차와 관련된 청구 또는 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다.

[본조산설 2016.2.29.]

제132조의6【보정할 수 없는 특허취소신청의 각하결정】

- ① 제132조의7제1항에 따른 합의체는 부적법한 특허취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 제132조의4제3항에도 불구하고 특허권자에게 특허취소신청서의 부분을 송달하지 아니하고, 결정으로 그 특허취소신청을 각하할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다.

[본조산설 2016.2.29.]

제132조의7【특허취소신청의 합의체 등】

- ① 특허취소신청은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 심리하여 결정한다.
- ② 제1항의 합의체 및 이를 구성하는 심판관에 관하여는 제143조부터 제145조까지, 제146조제2항·제3항, 제148조부터 제153조까지 및 제153조의2를 준용한다. 이 경우 제148조제6호 중 “심결”은 “특허취소결정”으로 본다.

[본조산설 2016.2.29.]

제132조의8【심리의 방식 등】

- ① 특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 한다.
- ② 공유인 특허권의 특허권자 중 1인에게 특허취소신청절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다.

[본조산설 2016.2.29.]

제132조의9【참가】

- ① 특허권에 관하여 권리를 가진 자 또는 이해관계를 가진 자는 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 있다.
- ② 제1항의 참가에 관하여는 제155조제4항·제5항 및 제156조를 준용한다.

[본조산설 2016.2.29.]

제132조의10【특허취소신청의 심리에서의 직권심리】

- ① 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다.
- ② 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다.

[본조산설 2016.2.29.]

제132조의11【특허취소신청의 병합 또는 분리】

- ① 심판관 합의체는 하나의 특허권에 관한 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리를 병합하여 결정하여야 한다.
- ② 심판관 합의체는 특허취소신청의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 제1항에 따라 병합된 심리를 분리할 수 있다.

[본조신설 2016.2.29.]

제132조의12【특허취소신청의 취하】

- ① 특허취소신청은 제132조의14제2항에 따라 결정등본이 송달되기 전까지만 취하할 수 있다. 다만, 제132조의13제2항에 따라 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없다.
- ② 둘 이상의 청구항에 관하여 특허취소신청이 있는 경우에는 청구항마다 취하할 수 있다.
- ③ 제1항 또는 제2항에 따른 취하가 있으면 그 특허취소신청 또는 그 청구항에 대한 특허취소신청은 처음부터 없었던 것으로 본다.

[본조신설 2016.2.29.]

제132조의13【특허취소신청에 대한 결정】

- ① 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취지의 결정(이하 “특허취소결정”이라 한다)을 하여야 한다.
- ② 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다.
- ③ 특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다.
- ④ 심판관 합의체는 특허취소신청이 제132조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하거나 같은 조 제2항을 위반한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다.
- ⑤ 제4항에 따른 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다.

[본조신설 2016.2.29.]

제132조의14【특허취소신청의 결정 방식】

- ① 특허취소신청에 대한 결정은 다음 각 호의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 결정을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다.
 1. 특허취소신청사건의 번호
 2. 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
 3. 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
 4. 결정에 관련된 특허의 표시
 5. 결정의 결론 및 이유
 6. 결정연월일
- ② 심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 그 특허취소신청에 대한 심리에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다.

[본조신설 2016.2.29.]

제132조의15【심판규정의 특허취소신청에의 준용】

특허취소신청의 심리·결정에 관하여는 제147조제3항, 제157조, 제158조, 제164조, 제165조제3항부터 제6항까지 및 제166조를 준용한다.

[본조신설 2016.2.29.]

I. 서 설

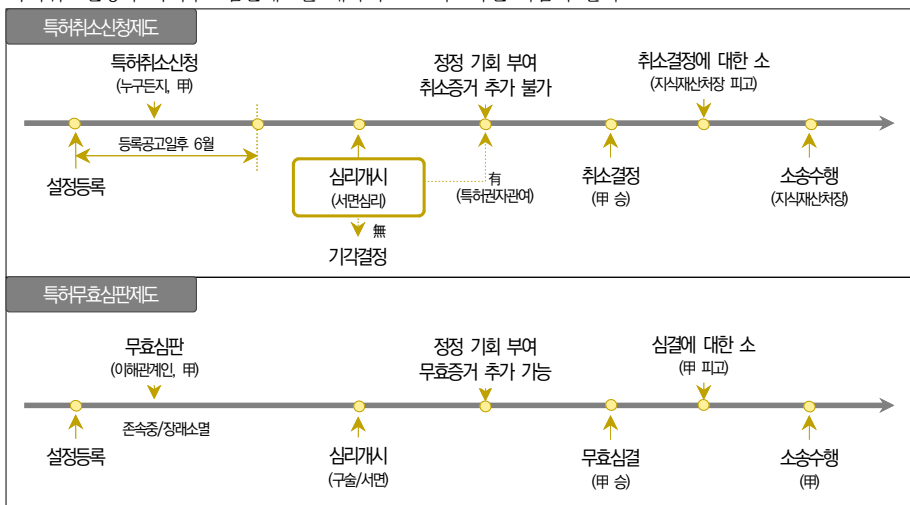
1. 의 의

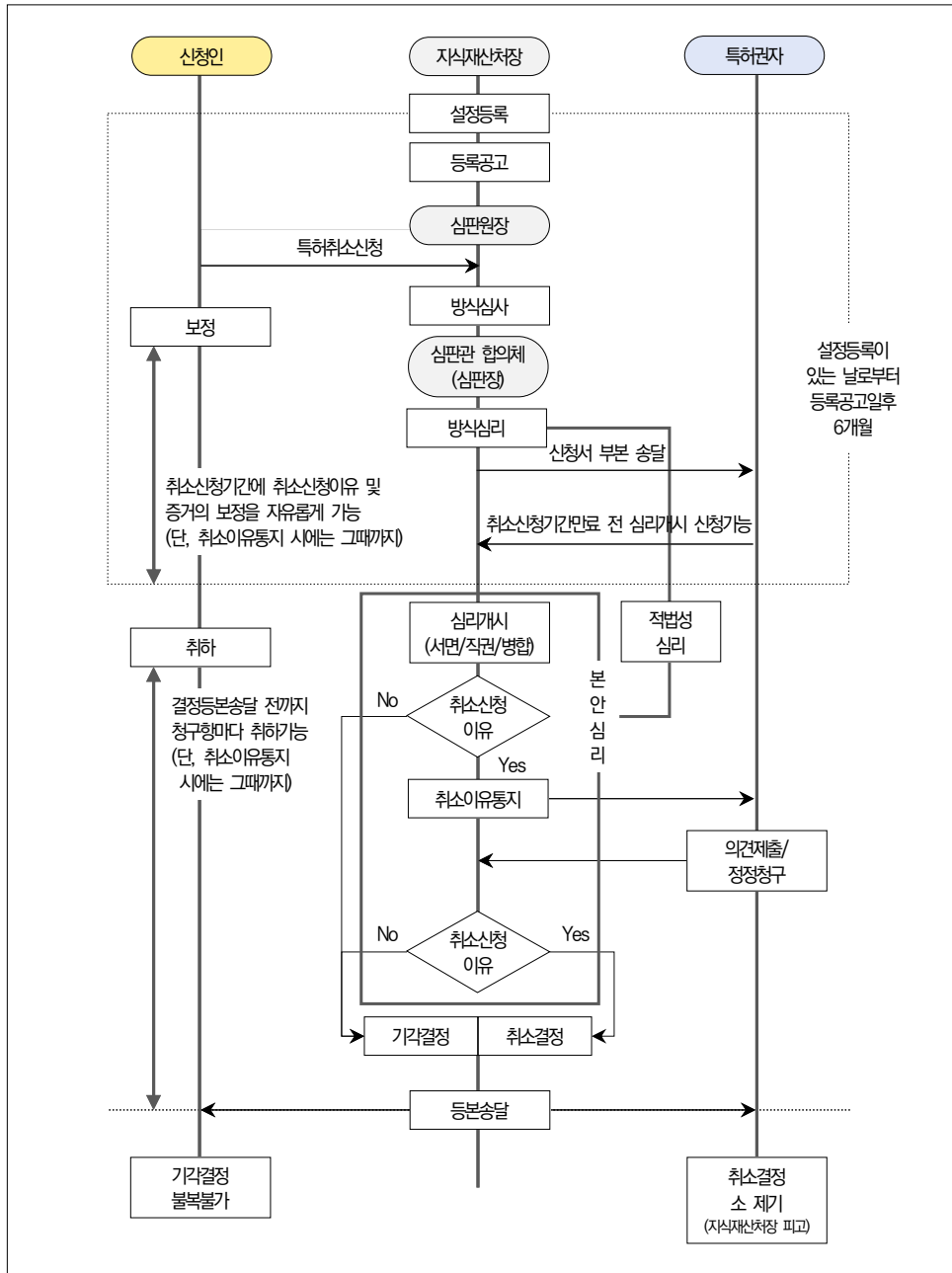
「특허취소신청」이란 누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 제132조의2제1항 각호의 특허취소사유에 해당하는 경우 특허심판원에 그 특허권의 효력을 소급하여 소멸시켜 줄 것을 요구하는 신청을 말한다(法 132의2).

2. 취 지

등록된 특허에 대한 공중의 심사기능을 강화함으로써 부실특허를 방지하고, 등록특허의 권리안정성을 확보하려는 것이다. 기존에 공중심사기능을 담보하는 제도로는 정보제공제도와 특허무효심판제도가 있는데, 정보제공제도의 경우 최근에 심사처리기간의 단축으로 출원공개 전에 특허결정이 되는 비율이 증가하면서 활용이 저조하게 되었고, 특허무효심판제도의 경우 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 3개월 이내에는 누구든지 특허무효심판을 청구하여 부실한 특허를 조기에 무효로 할 수 있었으나, 특허무효심판은 분쟁 당사자가 이용하는 제도로서 절차가 복잡하고 법원에 불복하면 소송절차도 당사자가 직접 수행하여야 하며, 비용에 대한 부담도 많아 제3자가 활용하기 어려운 단점이 있었다. 이에 따라 2017. 3. 1. 시행된 현행법(법률 제14035호, 2016. 2. 29. 개정)에서는 특허무효심판제도에서 공중심사기능을 삭제하는 대신 조기에 간단하고 신속한 절차로 등록특허를 재검토할 수 있는 새로운 절차인 특허취소신청제도를 마련하였다.²⁸⁸⁾

288) 특허취소신청과 특허무효심판제도를 개략적으로 비교하면 다음과 같다.





【그림 7-8】 특허취소신청제도의 절차 흐름도

II. 특허취소사유

1. 원 칙

(1) 제29조(같은 조 제1항제1호에 해당하는 경우와 같은 호에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 경우는 제외한다)에 위반된 경우

1) 제29조의 신규성(法 29①각호), 진보성(法 29②) 및 확대된 선출원에 위반된 경우를 말한다. 다만 제29조제1항제1호의 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명에 해당되어 신규성에 위반되거나, 특허출원 전 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성에 위반된 경우는 제외한다. 공지 또는 공연실시되었다는 것을 취소신청인이 주장증명하여야 하는데 이에 대한 증명과 심리에 상당한 시간이 소요될 수밖에 없고, 이는 조기에 신속하게 등록특허를 검토한다는 취소신청제도에 부합하지 않기 때문이다.

2) 한편 제29조제1항본문의 산업상 이용가능성 위반이 취소신청이유에 포함되는지와 관련하여, 심판 실무²⁸⁹⁾는 심사관이 특허등록 전 검토하지 못한 선행기술로 인해 부실특허가 발생하는 것을 방지하겠다는 취소신청제도의 취지에 비춰 봤을 때 취소신청이유에서 제외되는 것으로 해석된다고 하고 있으나, 명확한 법적인 근거를 두지 않고 이를 제외하는 것은 적절치 않다고 여겨진다.

(2) 제36조제1항부터 제3항까지의 규정에 위반된 경우
선출원주의에 위반된 경우를 말한다.

2. 예 외

특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로는 특허취소신청을 할 수 없다(法 132의2②). 그러나 다른 선행기술과 결합하여 진보성을 부정하는 경우에는 특허취소신청을 할 수 있을 것이다.

III. 특허취소신청의 요건

1. 신청인

누구든지 특허취소신청을 할 수 있다. 따라서 비법인 사단·재단이라도 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 특허취소신청을 할 수 있다(法 4).

289) 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 947면. 산업상 이용가능성 위반의 사유인 경우 기각한다.

2. 신청대상

청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 특허취소신청을 할 수 있다(法 132의 2①후단). 즉 일부취소신청이 가능하다.

3. 신청시기

특허권의 설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 특허취소신청을 할 수 있다. 이 기간이 경과한 특허취소신청에 대해서는 소명기회를 준 후 반려한다.²⁹⁰⁾

IV. 특허취소신청의 절차

1. 특허취소신청서의 제출

(1) 신청서의 제출

특허취소신청을 하려는 자는 다음의 사항을 적은 특허취소신청서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(法 132의4①).

- i) 신청인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- ii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명)
- iii) 특허취소신청의 대상이 되는 특허의 표시
- iv) 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시

(2) 신청서의 보정

특허취소신청서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만 취소신청기간(그 기간 중 심판장의 특허취소이유통지가 있는 경우에는 통지한 때까지로 한정한다)에 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시(法 132의4①Ⅳ)를 보정하는 경우에는 그러하지 아니하다(法 132의4②). 당사자 간의 분쟁해결을 목적으로 하는 특허무효심판에서는 심판청구이유에 대한 보정을 심결 시까지 자유롭게 할 수 있도록 하고 있으나, 특허취소신청에서는 취소신청이유 및 증거의 보정을 취소신청기간의 만료일 또는 취소이유통지 시까지로 제한함으로써 신속한 절차의 진행을 담보하고 있다.

290) 특허권 소멸 후의 특허취소신청에 대해서는 그 흠을 보정할 수 없는 부적법한 신청으로서 합의제가 결정으로 특허취소신청을 각하한다. 다만 특허취소신청이 먼저 신청된 후, 권리소멸사유 발생시점부터 권리가 소멸하는 이유(예를 들면 권리 포기, 외국인의 권리능력 등)에 의하여 특허권이 소멸한 경우에는, 취소결정의 소급효에 의하여 권리의 설정등록 시부터 권리소멸 시까지의 특허권의 효력을 없앨 수 있는 실익이 있으므로, 특허취소신청을 각하하지 않고 심리를 진행하여 취소신청에 대하여 결정을 한다(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 951면).

2. 부분 송달

1) 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 신청서의 부분을 특허권자에게 송달하여야 한다(法 132의4③). 다만 절차의 간소화를 위해 특허무효심판의 절차와 같이 즉시 특허권자에게 답변서 등을 제출토록 하는 것이 아니라 특허취소이유가 있다고 인정되는 경우에만 특허권자에게 특허취소이유를 통지하고 의견서 제출 및 정정청구의 기회를 부여하고 있다.

2) 심판장은 특허취소신청이 있으면 그 사실을 해당 특허권의 전용실시권자나 그 밖에 그 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 알려야 한다(法 132의4④). 이는 이해관계가 있는 등록된 권리자에게 특허권자 측에 보조 참가의 기회를 주기 위해서이다.

3. 특허의 정정청구

특허취소신청절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 i) 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 심판장이 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주었을 때 그 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다(法 132의3①). 이는 해당 특허권이 취소될 우려가 있는 경우 특허권자에게 이를 회피할 기회를 주기 위함이다.

4. 참 가

(1) 요 건

특허권에 관하여 권리를 가진 자(예를 들어 전용실시권자 또는 통상실시권자) 또는 이해관계를 가진 자는 특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자를 보조하기 위하여 그 심리에 참가할 수 있다(法 132의9①). 즉 특허취소신청에 있어서 특허권자 측에 보조 참가가 허용되고, 취소신청인 측의 참가는 허용되지 않는다.

(2) 절 차

특허취소신청에 참가하려는 자는 참가신청서를 특허심판원장 또는 심판장에게 제출하여야 한다(施規 62①). 심판장은 참가신청이 있는 경우에는 참가신청서 부분을 당사자 및 다른 참가인에게 송달하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 참가신청이 있는 경우에는 심판으로 그 참가 여부를 결정하여야 한다. 그 결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다. 한편 참가신청에 대한 결정에 대해서는 불복할 수 없다(法 132의9② 준용 156).

(3) 효 과

참가인은 모든 취소신청절차를 밟을 수 있고, 참가인에게 취소신청절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 그 중단 또는 중지는 피참가인에 대해서도 그 효력이 발생한다(法 132의9② 준용 155④⑤).

5. 방식심리 및 적법성 심리

(1) 방식심리

1) 심판장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다(法 132의5①).

- i) 특허취소신청서가 기재방식에 위반된 경우(단, 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시는 제외한다)
- ii) 행위능력없는 자가 절차를 밟거나(法 3①) 특별히 권한을 위임받지 아니한 임의대리인이 절차를 밟는 경우(法 6)
- iii) 이 법 또는 이 법에 따른 명령으로 정하는 방식에 위반된 경우
- iv) 내야 할 수수료를 내지 아니한 경우(法 82)

2) 심판장은 보정명령을 받은 자가 지정된 기간에 보정을 하지 아니하거나 보정한 사항이 요지변경(法 132의4②위반)인 경우에는 특허취소신청서 또는 해당 절차와 관련된 청구 또는 신청 등을 결정으로 각하하여야 한다. 이때 각하결정은 서면으로 하여야 하며, 그 이유를 붙여야 한다(法 132의5②③).

(2) 적법성 심리

심판관 합의체는 부적법한 특허취소신청으로서 그 흠을 보정할 수 없을 때에는 특허권자에게 특허취소신청서의 부분을 송달하지 아니하고, 결정으로 그 특허취소신청을 각하할 수 있다. 이 각하결정에 대해서는 불복할 수 없다(法 132의6).

6. 본안심리

(1) 심판관 합의체

특허취소신청은 3명 또는 5명의 심판관으로 구성되는 합의체가 심리하여 결정한다(法 132의7①). 심판관 합의체 및 이를 구성하는 심판관에 관하여는 심판관, 심판장의 자격 및 지정(法 143-145), 심판관 합의체의 합의(法 146②③), 심판관의 제척, 기피 및 회피(法 148-153의2)에 관한 규정을 준용한다(法 132의7②). 이 경우 심판관의 제척 중 제148조제6호의 전심관여는 “심판관이 사건에 대하여 심사관 또는 심판관으로서 특허여부결정 또는 특허취소결정에 관여한 경우”를 말한다.

(2) 심리의 개시

특허취소신청에 관한 심리는 특허취소신청 기간이 지난 후에 개시된다. 다만 특허취소신청 기간이 지나기 전이라도, 특허권자가 서면으로 심리개시를 신청하면 심리를 개시할 수 있다.

(3) 서면심리

특허취소신청에 관한 심리는 서면으로 한다. 공유인 특허권의 특허권자 중 1인에게 특허취소신청절차의 중단 또는 중지의 원인이 있으면 모두에게 그 효력이 발생한다(法 132의8). 구술심리 또는 서면심리를 선택하는 특허무효심판과 달리 특허취소신청의 심리를 서면으로 하도

록 하는 것은 절차를 간소화하여 신속한 결정을 내릴 수 있도록 할 뿐만 아니라 신청인의 부담도 가볍게 하여 공중의 심사기능을 강화하기 위함이다.

(4) 직권심리

심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인, 특허권자 또는 참가인이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다. 심판관은 특허취소신청에 관하여 특허취소신청인이 신청하지 아니한 청구항에 대해서는 심리할 수 없다(法 132의10).

(5) 병합심리

1) 심판관 합의체는 하나의 특허권에 관한 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리를 병합하여 결정하여야 한다(法 132의11①). 병합심리에 대하여 재량권이 인정되는 특허무효심판과 달리 특허취소신청은 특허취소신청기간이 만료된 후 복수의 특허취소신청을 일괄 병합하여 심리를 진행하고 있다. 한편 「특별한 사정」이란 i) 조기에 특허취소신청의 심리를 진행하여 결정 단계에 있을 때 별도의 특허취소신청이 있는 경우, ii) 복수의 특허취소신청서의 일부가 기재방식의 하자로 인하여 결정으로 각하되고 해당 결정에 대한 소송이 제기되는 경우 등의 사정을 말한다.

2) 심판관 합의체는 특허취소신청의 심리에 필요하다고 인정하는 경우에는 병합된 심리를 분리할 수 있다(法 132의11②).

7. 취소신청의 종류

(1) 특허취소신청의 취하

① 시 기

특허취소신청은 취소신청에 대한 결정등본이 송달되기 전까지만 취하할 수 있다. 다만 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유가 통지된 후에는 취하할 수 없다(法 132의12①). 이는 심리결과 특허의 취소이유가 규명되어 특허권자 등에게 통지된 후에는 취하할 수 없도록 하는 것이 특허 재검증을 통해 부실특허를 조기에 해소하려는 특허취소신청제도의 취지와 부합하는 것이기 때문이다.

② 범 위

둘 이상의 청구항에 관하여 특허취소신청이 있는 경우에는 청구항마다 취하할 수 있다(法 132의12②).

③ 효 과

취소신청의 취하가 있으면 그 특허취소신청 또는 그 청구항에 대한 특허취소신청은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 132의12③).

(2) 특허취소신청에 대한 결정

① 결정내용

1) 심판관 합의체는 특허취소신청이 이유 있다고 인정되는 때에는 그 특허를 취소한다는 취

지의 결정(이하 “특허취소결정”이라 한다)을 하여야 한다. 심판장은 특허취소결정을 하려는 때에는 특허권자 및 참가인에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 기회를 주어야 한다(法 132의13①②). 특허취소신청이 심사를 거쳐 등록된 초기단계에 공중의 심사기능을 활용하기 위한 제도라는 점에서 심사주체인 지식재산청가 우선 검토하도록 하고, 특허취소의 이유가 있다고 인정될 때만 특허권자가 자신의 권리를 위해서 대응할 수 있도록 하고 있다.

2) 한편 심판관 합의체는 특허취소신청이 특허취소사유(法 132의2①각호)에 해당하지 아니하거나 등록공고의 특허공보에 게재된 제87조제3항제7호에 따른 선행기술에 기초한 이유로 특허취소신청을 한 것으로 인정되는 경우에는 결정으로 그 특허취소신청을 기각하여야 한다(法 132의13④).

② 결정방식

1) 특허취소신청에 대한 결정은 다음의 사항을 적은 서면으로 하여야 하며, 결정을 한 심판관은 그 서면에 기명날인하여야 한다(法 132의14①).

- i) 특허취소신청사건의 번호
- ii) 특허취소신청인, 특허권자 및 참가인의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- iii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지[대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭, 사무소의 소재지 및 지정된 변리사의 성명]
- iv) 결정에 관련된 특허의 표시
- v) 결정의 결론 및 이유
- vi) 결정연월일

2) 심판장은 특허취소신청에 대한 결정이 있는 때에는 그 결정의 등본을 특허취소신청인, 특허권자, 참가인 및 그 특허취소신청에 대한 심리에 참가를 신청하였으나 그 신청이 거부된 자에게 송달하여야 한다(法 132의14②).

③ 결정에 대한 불복

심판장의 특허취소신청서 각하결정이나 심판관 합의체의 특허취소신청에 대한 특허취소결정에 대해서는 지식재산청장을 피고로 하여 특허법원에 불복할 수 있으나, 심판관 합의체의 특허취소신청 각하결정이나 기각결정에 대해서는 불복할 수 없다(法 132의13⑤, 186①, 187).

8. 심판규정의 특허취소신청에의 준용

특허취소신청의 심리·결정에 관하여는 심판장의 당사자 심문(法 147③), 증거조사 및 증거보전(法 157), 심판의 진행(法 158), 소송과의 관계(法 164), 청구인의 심판비용 부담(法 165③④⑤⑥) 및 심판비용액 또는 대가에 대한 집행권원(法 166)에 관한 규정을 준용한다(法 132의15).

V. 결정확정의 효과

1. 취소결정확정의 효과

(1) 특허권 및 그에 부수적인 권리의 소멸

특허취소결정이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 132의13①③). 따라서 보상금청구권도 처음부터 발생하지 아니한 것으로 보며(法 65⑥Ⅲ), 전용실시권 등 특허권에 부수하는 모든 권리도 소멸하게 된다. 한편 일부취소·일부기각결정이 확정된 경우에는 취소결정된 부분의 청구항만이 소급하여 소멸한다(法 215).

(2) 취소결정확정 전에 행해진 특허권을 둘러싼 행위의 법률관계

1) 특허요건의 흠결이 있음에도 착오로 등록된 경우라도 원칙적으로 타인의 특허발명 침해에 대하여 특허권에 기한 민·형사상 조치를 취할 수 있다. 다만 취소결정이 확정된 경우 특허권이 소급하여 소멸하므로 권리침해소송 등 민사소송의 확정판결 혹은 침해죄의 확정판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다(民訴法 451①, 刑訴法 420⑥). 한편 특허권자가 취소결정의 확정 전에 특허권을 행사하여 고의 또는 과실로 타인에게 손해를 입혔으면 그 손해를 배상하여야 하며, 고의 또는 과실에 의하지 아니한 경우에도 부당이득은 반환하여야 한다.

2) 다만 특허가 취소될 것이 명백한데도 다른 절차에서 그 특허의 권리행사를 인정하여야만 한다면 오로지 침해 여부에만 관심을 갖는 당사자에게 공익의 대표자로서 특허취소신청을 청구할 것을 강요하는 결과가 되기 때문에 학설과 판례는 일정한 경우에 특허권의 권리범위나 그 행사를 제한하는 방법 등으로 합리적인 해결을 모색하고 있다.

(3) 취소결정확정 후 재심이 있는 경우의 법률관계

취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우에 특허권의 효력은 특허취소결정이 확정된 후 재심청구 등록 전에 i) 선의로 수출 또는 수입하거나 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건, ii) 선의의 실시행위 및 iii) 선의의 간접침해행위 중 어느 하나에 대해서는 미치지 아니한다(法 181). 또한 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우에 특허취소결정이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 무상의 통상실시권(소위 後用權)을 갖는다(法 182).

(4) 실시료 반환 여부

취소결정이 확정된 특허권에 대하여 지급된 실시료는 특허무효심판의 무효심결확정과 마찬가지로 반환받을 수 없는 것으로 해석된다.

2. 기각결정확정의 효과

기각결정이 확정된 경우에 특허권은 유지된다. 특허취소신청과 특허무효심판은 일사부재리가 적용되지 않기 때문에 기각결정은 받은 특허취소신청인은 특허무효심판을 통해 다시 다룰 수 있다.²⁹¹⁾

291) 제163조의 일사부재리가 적용되기 위해서는 본안「심결」이 확정되어야 하는데, 취소신청의 경우 합의체에 의한 처분일지라도 「결정」이라고 하여 제163조가 적용되지 않도록 하고 있다.

【표 7-12】 특허취소신청제도와 특허무효심판제도의 비교

제 도		특허취소신청	특허무효심판
서	의 의	누구든지 특허권의 설정등록일부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 그 특허가 제132조의2제1항각호의 특허취소사유에 해당하는 경우 특허심판원에 그 특허권의 효력을 소급하여 소멸시켜 줄 것을 요구하는 신청을 말한다(法 132의2).	유효하게 설정등록된 특허권이 제133조제1항각호의 무효사유에 해당하는 경우 이해관계인 또는 심사관의 심판청구에 의한 심판절차에 의하여 그 특허권의 효력을 소급하여 또는 장래를 향하여 소멸시킬 수 있는 제도를 말한다(法 133).
	취 지	특허심사결과의 재검토	당사자 간의 분쟁해결
	성 격	공중심사, 항고심판(결정제)	당사자 심판
요건	주 체	누구든지	이해관계인(단, 제33조제1항본문, 제44조 위반은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자) 또는 심사관
	객 체	■ 산업상 이용가능성, 제29조제1항제2호와 관련된 신규성, 진보성, 확대된 선출원 및 선출원주의 위반 ■ 단, 특허공보에 게재된 선행기술에 기초하여不可	제133조제1항 각호의 무효사유
	청구항마다 청구가능	청구항마다 청구가능	
시 기	특허권의 설정등록일로부터 등록공고일 후 6개월이 되는 날까지 가능	특허권의 존속기간 중에는 물론 특허권이 장래를 향해 소멸된 후라도 가능	
신청 / 청구	신청서 제출	신청인만 특정(결정제)	청구인, 피청구인 특정(당사자제)
	신청서 보정	결정시까지 요지변경이 되지 않는 범위에서 보정. 단, 취소신청기간의 만료일 또는 취소이유의 통지 시까지 특허취소신청의 이유 및 증거의 표시 보정은 예외	심결시까지 요지변경이 되지 않는 범위에서 보정. 단, 특허권자의 기재를 바로 잡기 위한 보정과 심판청구 이유의 보정은 예외
	부분송달/ 취지통지	부분송달 및 등록권리자 취지통지	
	답변서 제출기회 미부여	답변서 제출기회 미부여	답변서 제출기회 부여
	참가	특허취소신청에 대한 결정이 있을 때까지 특허권자 측에 보조 참가만 가능	심리종결 전까지 당사자참가, 보조 참가 모두 가능
	정정청구	의견서 제출기간(원칙적으로 1회 기회 부여)	답변서 제출기간/의견서 제출기간/심판장이 정한 기한(복수의 기회 부여)
진행	방식심리	직권보정 불가	직권보정 가능
	적법성심리	불복불가	불복가능
	서면심리	서면심리	서면심리 또는 구술심리
	본안심리	- 둘 이상의 특허취소신청에 대해서는 특별한 사정이 있는 경우를 제외하고는 그 심리와 결정을 필요적 병합 - 직권심리하여 특허취소결정을 하고자 할 경우에만 취소이유통지하고 의견제출기회 부여	- 둘 이상의 특허무효심판에 대해서는 심리 또는 심결의 임의적 병합 - 직권심리한 경우 의견제출기회 부여
종료	취하	■ 취소신청에 대한 결정등본이 송달되기 전까지 청구항마다 ■ 단, 특허취소이유가 통지된 후에는 불가	■ 심결확정 전까지 청구항마다 ■ 단, 피청구인의 답변서가 제출된 후에는 동의없이 불가
	결정/심결	■ 특허취소결정만 불복(각각결정 불복 불가) ■ 지식재산처장이 피고	■ 인용/각각심결에 대한 불복 ■ 심판의 당사자가 피고
확정 효과	인용	■ 특허권 및 부수적인 권리의 소멸 ■ 보상금청구권의 소멸(法 65⑥) - 단, 후발적 사유에 의하여 무효가 된 경우는 제외 ■ 확정 전 침해소송은 재심사유 ■ 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력 제한과 후유권(法 181, 182) ■ 심의로 불반환 ■ 확정된 해의 다음 해부터의 특허료 해당분 반환(法 84)	
		중용권(法 104)의 불인정	중용권(法 104)의 인정
	기각	특허무효심판청구하더라도 일사부재리 부적용	다시 특허무효심판청구 시 일사부재리 적용
심판비용부담		신청인	패심자

제2관 특허의 정정청구

제132조의3【특허취소신청절차에서의 특허의 정정】

- ① 특허취소신청절차가 진행 중인 특허에 대한 특허권자는 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제132조의13제2항에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 특허취소신청절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.
- ③ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항, 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다. 이 경우 제136조제11항 중 “제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)”에 “제132조의13제2항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에”로 본다.
- ④ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다.
 1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간
 2. 제3항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간
- ⑤ 제3항을 적용할 때 제132조의2에 따라 특허취소신청이 된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다.

[본조신설 2016.2.29.]

[충전 제132조의3은 제132조의17로 이동 <2016.2.29.>]

제133조의2【특허무효심판절차에서의 특허의 정정】

- ① 제133조제1항에 따른 심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
- ② 제1항에 따른 정정청구를 하였을 때에는 해당 무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다.
- ③ 심판장은 제1항에 따른 정정청구가 있을 때에는 그 청구서의 부분을 제133조제1항에 따른 심판의 청구인에게 송달하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 정정청구에 관하여는 제136조제3항부터 제6항까지, 제8항 및 제10항부터 제13항까지, 제139조제3항 및 제140조제1항·제2항·제5항을 준용한다. 이 경우 제136조제11항 중 “제162조제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전(같은 조 제4항에 따라 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 같은 조 제3항에 따른 심리의 종결이 통지되기 전)”에 “제133조의2제1항 또는 제136조제6항에 따라 지정된 기간에”로 본다. <개정 2016.2.29.>
- ⑤ 제1항에 따른 정정청구는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다. <신설 2016.2.29.>
 1. 제1항에 따라 정정을 청구할 수 있도록 지정된 기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간
 2. 제4항에서 준용하는 제136조제6항에 따라 지정된 기간
- ⑥ 제4항을 적용할 때 제133조제1항에 따른 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 제136조제5항을 준용하지 아니한다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제137조 【정정의 무효심판】

- ① 이해관계인 또는 심사관은 제132조의3제1항, 제133조의2제1항, 제136조제1항 또는 이 조 제3항에 따른 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 다음 각 호의 어느 하나의 규정을 위반한 경우에는 정정의 무효심판을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
1. 제136조제1항 각 호의 어느 하나의 규정
 2. 제136조제3항부터 제5항까지의 규정(제132조의3제3항 또는 제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다)
 - ② 제1항에 따른 심판청구에 관하여는 제133조제2항 및 제4항을 준용한다.
 - ③ 제1항에 따른 무효심판의 피청구인은 제136조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 제147조제1항 또는 제159조제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다. 이 경우 심판장이 제147조제1항에 따라 지정된 기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정의 청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
 - ④ 제3항에 따른 정정청구에 관하여는 제133조의2제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다. 이 경우 제133조의2제3항 중 “제133조제1항”은 “제137조제1항”으로 보고, 같은 조 제4항 후단 중 “제133조의2제1항”을 “제137조제3항”으로 보며, 같은 조 제5항 각 호 외의 부분 및 같은 항 제1호 중 “제1항”을 각각 “제3항”으로 본다. <개정 2016.2.29.>
 - ⑤ 제1항에 따라 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「특허의 정정청구」란 특허권자가 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구하는 것을 말한다. 정정청구는 이와 같은 독립된 심판 절차 중에 이루어진다는 점에서 독립적인 심판청구에 의하여 이루어지는 정점심판과 구별된다.

2. 취 지

특허법은 i) 일반 공중에게 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판의 기회를 부여함으로써 부실특허 또는 부실�특허에 대한 정정을 소멸시켜 권리의 안정성을 도모하는 한편 ii) 특허권자에게는 명세서 또는 도면을 정정할 수 있는 방어적 기회를 줌으로써 양자의 형평성을 도모하기 위해 본 규정을 두고 있다. 다만 특허권의 대세적 효력에 비추어 그 내용에 변동이 생기면 제3자에게 불측의 피해를 줄 수 있으므로 정정이 허용되는 범위를 엄격히 제한하고 있다.

II. 정정의 요건

1. 청구인

특허권자만이 정정을 청구할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다(法 132의3③ 및 133의2④ 준용 法 139③, 法 137④ 준용 法 133의2④). 또한 특허권자는 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의(다만 특허권자가 정정청구를 하려면 동의를 받아야 하는 자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)를 받아야만 정정청구를 할 수 있다(法 132의3③ 및 133의2④ 준용 136⑧, 137④ 준용 133의2④).

2. 정정청구사유

(1) 청구범위의 감축 등에 해당할 것

특허권자는 i) 청구범위를 감축하는 경우, ii) 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 및 iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나에 해당하는 경우에만 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다(法 132의3①, 133의2①, 137③).

(2) 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위일 것

명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 해당 정정심판의 심결 전에 다른 정정심판의 심결 또는 특허의 정정이 확정된 경우에는 그 정정된 명세서 또는 도면이 정정심판의 대상이 된다. 다만 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다(法 133의2④ 준용 136③, 137④ 준용 133의2④).

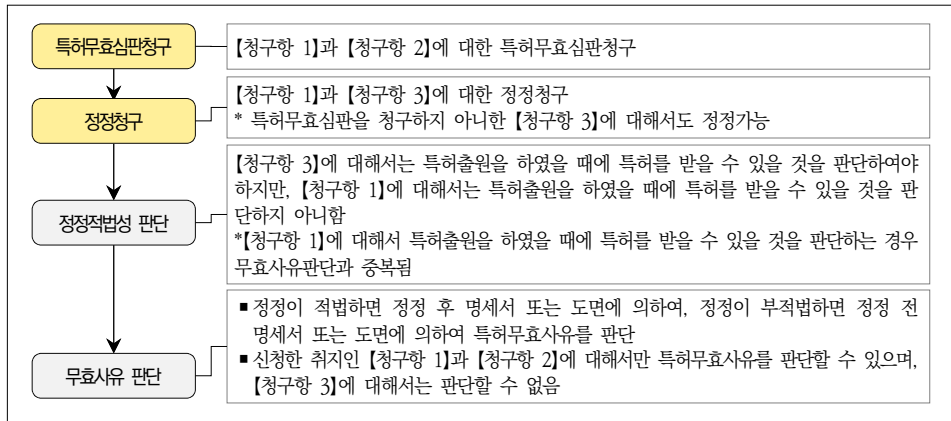
(3) 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않을 것

명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다(法 132의3③ 및 133의2④ 준용 136④, 137④ 준용 133의2④).

(4) 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것

청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우에는 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다(法 132의3③ 및 133의2④ 준용 136⑤, 137④ 준용 133의2④). 다만 특허취소신청, 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 「특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것」은 적용되지 아니한다(法 132의3⑤, 133의2⑥). 이는 특허취소신청, 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대하여 해당 청구항의 「특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것」을 판단한 후 특허취소신청, 특허무효심판 대상 청구항에 대하여 다시 특허취소사유, 특허무효사유의 유무를 판단하는 것은 실질적으로 동일한 내용을 중복적으로 판단하여 심리의 부담이 가중되고, 특허취소

신청, 특허무효심판의 최종적 판단사항인 취소이유, 무효이유를 심결(결정) 전에 미리 알려주는 결과가 되어 이로 인하여 심리의 지연이 초래되는 문제점이 있기 때문이다.²⁹²⁾ 한편 특허 취소신청, 특허무효심판이 청구되지 아니한 청구항을 정정하는 경우에는 이와 같은 요건을 판단하여야 함은 자명하다.



【그림 7-9】 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것의 판단

3. 청구시기

1) 특허취소신청절차에서, 특허권자는 심판장이 특허취소결정을 하려고 취소이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 주었을 때 그 지정된 기간에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정청구를 할 수 있다(法 132의3①).

2) 특허무효심판, 정정무효심판절차에서, 특허권자는 심판청구에 대한 답변서 제출기간 또는 심판관의 직권심리에 의한 의견서 제출기간에 명세서 또는 도면의 정정청구를 할 수 있다. 또한 답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정되는 경우에 심판장이 정한 기간에 정정청구를 할 수 있다(法 133의2①, 137③).²⁹³⁾

292) 특허법원 2008. 8. 28. 선고 2007허10101.

293) 무효심판 청구인은 제140조제2항에 따라 요지변경 여부와 관계없이 청구이유를 자유롭게 보정할 수 있어 무효심판 청구 시 제출하지 않았던 새로운 무효증거를 청구서의 보정 또는 의견서를 통해 제출할 수 있으나, 피청구인은 특허법 제133조의2 제1항에 따라 무효심판 청구서에 대한 답변서 또는 의견서 제출기간에 특허의 정정청구를 하도록만 규정되어 있어 답변서 제출기간 후에 청구인으로부터 새로운 무효증거가 제출되는 경우 자신의 특허권을 정정할 수 있는지에 대한 논란이 있어 왔다. 이에 2007. 7. 1. 시행된 현행법(법률 제8197호, 2007. 1. 3. 개정)은 이를 명문화하여 피청구인의 정정청구에 대한 논란을 없애는 한편 당사자 간에 공격·방어기회를 평등하게 부여하고 있다. 다만 심리지연 목적으로 새로운 증거를 계속하여 제출하는 경우 등의 특별한 사유가 있는 경우에는 별도의 정정기회를 부여하지 않을 수도 있다.

3) 정정청구의 횟수에 대해서는 제한 규정이 없으므로 상기 기간에는 몇 번이고 특허의 정정청구를 할 수 있다. 이 경우 해당 특허취소신청절차, 특허무효심판절차, 정정무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하된 것으로 본다(法 132의3②, 133의2②, 137④ 준용 133의2②). 이는 피청구인이 정정코자 하는 사항이 무엇인지를 분명히 함으로써 심리대상을 명확히 확정하여 소송상 발생할 수 있는 혼란을 사전적으로 예방하기 위한 것이다.

Ⅲ. 정정의 절차

1. 정정청구서의 제출

1) 특허권자는 다음의 사항을 적은 정정청구서를 제출하여야 한다.

- i) 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)
- ii) 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지(대리인이 특허법인·특허법인(유한)인 경우에는 그 명칭 및 사무소의 소재지와 지정변리사의 성명)
- iii) 청구사건의 표시
- iv) 청구의 취지 및 그 이유

2) 또한 정정을 청구하는 때에는 정정청구서에 정정한 명세서 또는 도면과 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 대한 통상실시권자 및 질권자의 동의가 필요한 경우(다만 특허권자가 정정청구를 하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판을 청구한 경우에는 제외)에는 그 동의를 증명하는 서류를 첨부하여야 한다(法 132의3③ 및 133의2④ 준용 140①②⑤, 136⑧, 137④ 준용 133의2④). 제출된 정정청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유에 대해서는 그러하지 아니하다.

2. 부분의 송달

심판장은 특허무효심판, 정정무효심판 절차 중에 특허권자의 정정청구가 있을 때에는 그 부분을 심판청구인에게 송달하여야 한다(法 133의2③, 137④ 준용 133의2③). 이는 심판청구인에게 특허권자의 정정내용을 파악하게 하여 절차의 원활한 진행을 위함이다.

3. 심 리

(1) 의견서 제출 기회의 부여

심판관은 직권심리하여 정정청구사유를 만족하지 아니하면 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(法 132의3③ 및 133의2④ 준용 136⑥, 137④ 준용 133의2④). 이는 강행규정이기 때문에 특허권자에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 바 없는 별개의 사유를 들어 정정청구를 받아들이지 아니한 것은 위법하다.²⁹⁴⁾

(2) 명세서 또는 도면의 보정

1) 특허권자는 정정청구를 할 수 있는 기간(法 132의3①, 133의2①, 137③) 또는 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간에 정정청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 할 수 있다(法 132의3③, 133의2④, 137④). 이는 상술한 바와 같이 정정청구는 횟수에 무관하게 할 수 있는데 여러 번 정정을 청구하는 것보다 한 번 정정청구를 하였을 때 적법하게 정정을 하도록 하는 것이 시간적, 절차적인 측면에서 타당하기 때문이다. 정정한 명세서 또는 도면은 청구취지의 일부를 구성하므로 그 요지를 변경할 수 없다(法 132의3③, 133의2④, 137④ 준용 法 140②).

2) 보정서 제출할 때는 보정서뿐만 아니라 보정사항이 반영된 전체 명세서 및 도면을 첨부하여 제출하여야 한다. 보정서에 의한 보정사항이 정정명세서 등을 요지변경한 것이면 심판장은 보정서를 결정으로 각하한 후(法 141②), 그 이전의 정정명세서 등을 대상으로 정정의 인정 여부를 판단한다.

4. 정정청구의 취하

정정청구는 i) 정정청구를 할 수 있는 기간(法 132의3①, 133의2①, 137③)과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간, ii) 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간 중 어느 하나에 해당하는 기간에만 취하할 수 있다(法 132의3④, 133의2⑤, 137④ 준용 133의2⑤). 이는 인정된 정정청구를 취하하면 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판의 심리대상이 바뀌어 심리 지연의 문제가 발생하기 때문에 취하의 시기를 제한하는 것이다.

IV. 정정의 효과

1. 적법한 정정청구의 효과

(1) 정정의 소급효

1) 정정청구가 적법한 경우에는 명시적인 중간결정 없이 정정한 명세서 또는 도면에 의하여 특허취소신청, 심판청구에 대한 심리를 진행하게 되며,²⁹⁵⁾ 최종적으로 결정문, 심결문의 주문 및 이유란에 적는다.

2) 정정의 인정 여부는 특허취소신청, 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 특허취소신

294) 대법원 2012. 7. 12. 선고 2011후934.

295) 대법원 2009. 7. 9. 선고 2007후4472.

청에 대한 결정이나 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다.²⁹⁶⁾ 따라서 무효심판이 확정되지 않고 취하된 경우에는 그 정정을 인정할 수 없다.²⁹⁷⁾²⁹⁸⁾

3) 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 결정이 확정되었을 때에는, 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 의하여 특허출원·출원공개·특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정 등록이 된 것으로 본다(法 132의3③ 및 133의2④ 준용 136¹⁰⁾, 137⁴⁾ 준용 133의2④).

(2) 특허공보에 게재

특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 있는 경우에 특허심판원장은 그 내용을 지식재산처장에게 알려야 하며 지식재산처장은 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재하여야 한다(法 132의3③ 및 133의2④ 준용 136^{12)⑬)}, 137⁴⁾ 준용 133의2④).

2. 부적법한 정정의 효과

(1) 이유란에 기재

정정청구가 부적법한 경우에는 별도의 결정 또는 심결이 없이 결정문, 심결문의 이유란에 정정청구를 채택할 수 없는 이유를 함께 기재하고 정정청구를 채택하지 아니한다. 특허발명은 하나의 기술사상에 기초한 것인만큼 비록 복수항에 걸친 정정을 구하였다고 하더라도 이는 일체로서 정정을 구하는 취지라고 해석되므로, 그 일부항에 정정불허사유가 존재하는 한 정정청구 전체가 모두 허용될 수 없다.²⁹⁹⁾

296) 대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912. 또한 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결은 “특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다 할 것인바(대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912 판결 참조), 위에서 본 바와 같이 원심판결 중 이 사건 정정청구 및 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 특허무효에 관한 부분에 대한 피고들의 상고는 이유 없다 할 것이나, 원심판결 중 이 사건 제3항 발명의 특허무효에 관한 부분에 대한 피고들의 상고를 받아들이는 이상, 이와 함께 확정되어야 할 이 사건 정정청구에 관한 부분도 파기를 면할 수 없다. 한편 특허의 등록무효 여부는 청구항별로 판단하여야 하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 할 것인데, 이 사건 정정청구는 그 정정사항이 이 사건 제1항 내지 제5항 발명 전체에 걸쳐 있으므로, 원심판결 중 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 특허무효에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 파기되어야 할 것이어서, 결국 원심판결 전부가 파기되어야 할 것이다”라고 판시하였다.

297) i) 해당 심판이 취하되면 그 자체로서 처음부터 없는 것으로 본다는 점, ii) 정정청구의 인정 여부를 해당 심판의 심결에서 판단하므로 해당 심판이 취하되었으면 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정의 적법 여부를 판단할 수 없다는 점, iii) 특허권자의 답변서 제출 후에는 특허권자의 동의가 없으면 심판청구를 취하할 수 없으므로 동의를 하지 아니함으로써 방어를 할 수 있다는 점에 비추어 볼 때 무효심판이 취하되었으면 정정청구가 적법하더라도 그 정정은 인정할 수 없다 할 것이다.

298) 한편 취소신청의 경우에는 취소이유가 통지된 후에 정정청구를 할 수 있는데 취소이유가 통지된 후에는 취소신청을 취하할 수 없다(法 132의12①).

299) 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053.

(2) 불복 여부

부적법한 정정에 대하여 독립적인 처분(결정, 심결)을 하지 않기 때문에 불복의 대상이 없다. 따라서 독립적인 불복은 허용되지 않으며 특허취소결정, 무효심판의 심결에 대한 불복의 소에서 함께 다룰 수 있을 뿐이다.

(3) 간과된 경우

1) 부적법한 정정이 간과되어 특허취소신청의 기각결정, 특허무효심판 또는 정정무효심판의 기각심결이 확정된 경우에 부적법한 정정은 정정무효사유(法 137①)에 해당하고, 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다(法 137⑤).

2) 다만 정정 부분에 대한 결론이 잘못되었다면 특허취소, 무효판단의 대상을 잘못 정한 것으로 결정, 심결을 취소하여야 함이 원칙이지만, 특허취소, 무효라고 판단한 결론 자체가 정당하다면 특허취소, 무효의 소급효에 따라 이제는 정정을 유지할 근거도 없어지게 되므로, 굳이 정정 부분에 관한 판단 잘못을 바로잡기 위하여 결정, 심결을 취소할 실익은 없다.³⁰⁰⁾

300) 특허법원 2008. 11. 21. 선고 2008허5137.

【표 7-13】 특허취소신청, 특허무효심판 및 정정무효심판에서 정정청구의 비교

제 도		특허취소신청	특허무효심판	정정무효심판
서	의 의	특허의 정정이란 특허권자가 특허취소신청, 특허무효심판 또는 정정무효심판이 특허심판원에 계속 중에 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정을 청구하는 것을 말한다.		
	취 지	명세서 또는 도면을 정정할 수 있게 하여 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판에 대한 방어적 기회를 줌		
요 건	주체적	1. 특허권자만이 할 수 있으며, 특허권이 공유인 경우 공유자 모두가 하여야 함 2. 전용실시권자, 직무발명 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 집권자의 동의 땀(다만 특허권 자가 정정청구를 하려면 동의를 받아야 하는 자가 특허취소신청, 무효심판을 청구한 경우는 제외)		
	객체적	1. 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 및 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우 중 어느 하나 2. 특허발명의 명세서·도면의 범위 이내이어야 하며, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위일 것 3. 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위의 실질적 확장·변경× 4. 청구범위의 감축이나 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우 정정 후의 청구범위 기재사항이 특허출원을 하였을 때 특허를 받을 수 있을 것		
		단, 특허취소신청, 특허무효심판에 대한 정정청구에 있어서 특허취소신청, 특허무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 4번의 판단×		-
	시기적	취소결정하려고 취소이유를 통지하고 준 의견서 제출기간	1. 답변서 제출기간 2. 답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거서류를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정되는 경우에 심판장이 정한 기간 3. 무효심판의 직권심리에 의한 의견서 제출기간	
		해당 특허취소신청절차, 특허무효심판절차, 정정무효심판절차에서 그 정정청구 전에 한 정정청구는 취하		
절 차	제출	1. 정정청구서를 제출 2. 정정을 청구하는 때에는 정정청구서에 정정한 명세서 또는 도면과 전용실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 대한 통상실시권자 및 집권자의 동가 필요한 경우(다만 특허권자가 정정청구를 하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 특허취소신청, 특허무효심판, 정정무효심판을 청구한 경우에는 제외)에는 그 동의를 증명하는 서류를 첨부		
	부분송달	-	심판장은 특허무효심판, 정정무효심판 절차 중에 특허권자의 정정청구가 있을 때에는 그 부분을 심판청구인에게 송달	
	정정명세서 등의 보정	정정청구를 할 수 있는 기간 또는 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간에 정정명세서 등을 다시 보정가능		
	취하	i) 정정청구를 할 수 있는 기간과 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간과 ii) 정정청구의 직권심리에 의한 의견서 제출기간 중 어느 하나에 해당하는 기간		
효 과	적법	원칙	정정한 명세서 또는 도면에 의하여 특허취소신청, 심판청구에 대한 심리를 진행하게 되며, 최종적으로 결정문, 심결문의 주문 및 이유란에 기재	
		소급효	1. 정정된 내용으로 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권이 설정등록된 것으로 간주 2. 정정만이 따로 확정되지 않고 특허취소신청의 결정 또는 무효심판의 심결이 확정된 때 함께 확정	
	특허공보 게재	특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정을 한다는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 지식재산처장에게 알려야 하며 지식재산처장은 통보가 있으면 이를 특허공보에 게재		
	부적법	원칙	별도의 각하결정없이 결정, 심결의 「이유란」에 특허의 정정 불채택이유 기재	
		간과	정정무효사유에 해당	
	불복	독립하여 불복×		

제9절 재심

제178조 【재심의 청구】

- ① 당사자는 확정된 특허취소결정 또는 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
 - ② 제1항의 재심청구에 관하여는 「민사소송법」 제451조 및 제453조를 준용한다.
- [전문개정 2014.6.11.]

제179조 【제3자에 의한 재심청구】

- ① 심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리나 이익을 사해(詐害)할 목적으로 심결을 하게 하였을 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다.
 - ② 제1항의 재심청구의 경우에는 심판의 당사자를 공동피청구인으로 한다.
- [전문개정 2014.6.11.]

제180조 【재심청구의 기간】

- ① 당사자는 특허취소결정 또는 심결 확정 후 재심사유를 안 날부터 30일 이내에 재심을 청구하여야 한다.
- <개정 2016.2.29.>
- ② 대리권의 흠을 이유로 재심을 청구하는 경우에 제1항의 기간은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다. <개정 2016.2.29.>
 - ③ 특허취소결정 또는 심결 확정 후 3년이 지나면 재심을 청구할 수 없다. <개정 2016.2.29.>
 - ④ 재심사유가 특허취소결정 또는 심결 확정 후에 생겼을 때에는 제3항의 기간은 그 사유가 발생한 날의 다음 날부터 기산한다. <개정 2016.2.29.>
 - ⑤ 제1항 및 제3항은 해당 심결 이전의 확정심결에 저촉된다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 적용하지 아니한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제181조 【재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한】

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 수출 또는 수입하거나 국내에서 생산 또는 취득한 물건에는 미치지 아니한다. <개정 2016. 2. 29., 2025. 1. 21.>
 - 1. 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우
 - 2. 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우
 - 3. 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권의 존속기간의 연장등록이 된 경우
 - 4. 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우
- ② 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우의 특허권의 효력은 다음 각 호의 어느 하나의 행위에 미치지 아니한다. <개정 2016.2.29.>
 - 1. 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 한 해당 발명의 선의의 실시
 - 2. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
 - 3. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 선의로 생산·양도·대여·수출 또는 수입하거나 양도 또는 대여를 청약하는 행위

[전문개정 2014.6.11.]

제182조 【재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권】

제181조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심 청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 통상실시권을 가진다.

<개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제183조 【재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권】

- ① 제138조제1항 또는 제3항에 따라 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에는 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 원(原)통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결이 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다.
- ② 제1항에 따라 통상실시권을 가진 자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제184조 【재심에서의 심판규정 등의 준용】

특허취소결정 또는 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 특허취소신청 또는 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제185조 【「민사소송법」의 준용】

재심청구에 관하여는 「민사소송법」 제459조제1항을 준용한다.

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

「재심」이란 확정된 특허취소결정 또는 확정된 심결에 재심사유에 해당하는 중대한 하자가 있는 경우 특허취소결정이나 그 심결의 취소와 그 사건의 재심판을 구하는 비상의 불복신청방법을 말한다.

2. 취 지

특허취소결정 또는 심결이 확정되면 법적 안정성을 확보하기 위해 그 특허취소결정이나 심결에 대하여 통상의 불복방법으로는 다룰 수 없다. 그러나 절차에 중대한 하자나 특허취소결정이나 심결의 기초에 잘못이 있는 경우에도 법적 안정성만 고집하다 보면 심판의 적정성과 신뢰성을 지킬 수 없을뿐더러 당사자의 권리구제라는 구체적 정의에 반하게 된다. 이에 특허법은 법적 안정성의 바탕 위에 구체적 타당성의 확보라는 상반되는 요청을 조화시키기 위해 재심제도를 두고 있다.

II. 재심사유

1. 일반재심사유

1) 특허법은 일반재심사유에 대하여 민사소송법 제451조를 준용하고 있다(法 178②). 구체적으로 살펴보면, 다음 중 어느 하나에 해당하면 확정된 특허취소결정 또는 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다. 다만 당사자가 상소에 의하여 그 사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다(民訴法 451①). 이를 재심의 보충성이라 한다. 여기에서 「이를 알고 주장하지 아니한 때」란 당사자가 재심사유의 존재를 알았음에도 불구하고 특허소송에서 이를 주장하지 아니한 경우뿐만 아니라, 특허소송을 제기하지 아니하여 특허취소결정 또는 심결을 확정시킨 경우도 포함된다.³⁰¹⁾

i) 심판의 합의체를 구성하지 아니한 때³⁰²⁾

ii) 특허법상 그 특허취소결정 또는 심결에 관여할 수 없는 심판관이 관여한 때³⁰³⁾

iii) 대리인이 출원·심사·심판절차에서의 대리행위를 하는 데에 필요한 권한의 수여에 흠이 있는 때³⁰⁴⁾

iv) 심판에 관여한 심판관이 그 사건에 관하여 직무에 관한 죄를 범한 때³⁰⁵⁾

v) 형사상 처벌을 받을 다른 사람의 행위로 말미암아 자백을 하였거나 특허취소결정 또는 심결에 영향을 미칠 공격 또는 방어방법의 제출에 방해를 받은 때³⁰⁶⁾

vi) 특허취소결정 또는 심결의 증거가 된 문서나 그 밖의 물건이 위조 또는 변조된 것인 때³⁰⁷⁾

vii) 증인·감정인·통역인의 거짓 진술 또는 당사자신문에 따른 당사자나 법정대리인의 거짓 진술이 특허취소결정 또는 심결의 증거가 된 때

viii) 특허취소결정 또는 심결의 기초로 된 민사 또는 형사의 판결이나 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판 또는 행정처분에 따라 바뀐 때³⁰⁸⁾

301) 대법원 1985. 10. 22. 선고 84후68.

302) 예를 들어 심판관이 정족수를 갖추지 못한 심판부를 구성한 경우 등을 말한다.

303) 예를 들어 제척사유가 있는 심판관이 심결에 관여한 경우 등을 말한다.

304) 다만 당사자나 법정대리인의 추인이 있는 경우에는 예외로 한다.

305) 예를 들어 수뢰죄 등을 말한다.

306) 예를 들어 형법상의 협박 또는 강요된 행위에 의한 경우 등을 말한다.

307) 재심사유인 「판결의 증거로 된 문서나 그 밖의 물건이 위조나 변조된 것인 때」라 함은, 그 위조된 문서 등이 판결 주문의 이유가 된 사실인정의 직접적 또는 간접적인 자료로 제공되어 법원이 그 위조문서 등을 참작하지 않았더라면 해당 판결과는 다른 판결을 하였을 개연성이 있는 경우를 말한다(대법원 1997. 7. 25. 선고 97다15470).

308) 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다. 이는 판결의 심라판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다. 여기서 ‘사실인정의 자료가 되었다’는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확

- ix) 특허취소결정 또는 심결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 때³⁰⁹⁾
 - x) 특허취소결정 또는 심결이 전의 확정심결과 저촉되는 때³¹⁰⁾
 - xi) 당사자가 상대방의 주소 또는 거소를 알고 있었음에도 있는 곳을 잘 모른다고 하거나 주소나 거소를 거짓으로 하여 소를 제기한 때
- 2) 여기서 iv) 내지 vii)의 경우에는 처벌받을 행위에 대하여 유죄의 판결이나 과태료부과의 재판이 확정된 때 또는 증거부족 외의 이유로 유죄의 확정판결이나 과태료부과의 확정재판을 할 수 없을 때만 재심의 소를 제기할 수 있다(民訴法 451②).

2. 사해심결에 대한 재심사유

심판의 당사자가 공모하여 제3자의 권리나 이익을 사해할 목적으로 심결을 하게 하였을 때에는 제3자는 그 확정된 심결에 대하여 재심을 청구할 수 있다(法 179①).

Ⅲ. 재심의 요건

1. 청구인·피청구인

(1) 일반재심의 경우

1) 특허취소결정 또는 심결의 확정에 의하여 불이익을 받는 자가 청구인이 된다. 따라서 특허취소신청에 대한 특허취소결정에 있어서는 특허권자가 재심청구인이 되고, 결정계 심판의 심결에 대한 재심에 있어서는 심판청구인이 재심청구인이 된다. 한편 당사자계 심판의 심결에 대한 재심을 청구할 때는 기각심결이 확정된 경우에는 심판청구인이 재심청구인, 심판피청구인이 재심피청구인이 되고, 인용심결이 확정된 경우에는 심판피청구인이 재심청구인, 심판청구인이 재심피청구인이 된다.

2) 법인이 아닌 사단 또는 재단으로서 대표자나 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 재심의 청구인 및 피청구인이 될 수 있다(法 4).

정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조).

- 309) 당사자가 적법하게 소송상 제출한 공격방어방법으로서의 판결의 결론에 영향이 있는 것에 대하여 판결 이유 중에서 판단을 표시하지 아니한 경우를 말하는 것이고, 그 판단을 내린 이상 당사자 주장을 배척한 근거에 대하여 개별적으로 일일이 설명하지 아니하였거나, 그 판단 내용에 실형 잘못이 있다 하더라도 이를 위 법조에서 말하는 판단누락이라고 볼 수는 없다(대법원 1987. 4. 14. 선고 86사38). 또한 당사자가 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이 판결 이유에 표시되어 있지 않았더라도 판결 결과에 영향이 없다면 판단누락의 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903).
- 310) 재심대상이 될 수 있는 「그 심결 이전에 행하여진 확정심결과 저촉한다.」는 그 확정심결이라 함은 청구의 동일성 및 당사자의 동일성이 인정되는 경우라야 할 것이다(대법원 1972. 3. 28. 선고71후32).

(2) 사해심결에 대한 재심의 경우

확정심결에 의하여 권리나 이익의 침해를 받는 제3자가 청구인이 되며, 심판의 당사자가 공동피청구인이 된다(法 179①②). 예를 들면 특허권자 甲이 그의 특허권에 관하여 乙에게 질권을 설정하고 그 후 丙이 무효심판을 청구하였을 때, 특허권자 甲이 丙과 공모하여 거짓 진술 또는 자료로써 심판관을 기망하여 특허를 무효로 하는 취지의 심결을 얻어 확정되었을 경우, 이는 질권자 乙의 이익에 해가 되므로 乙은 甲과 丙을 공동피청구인으로 하여 재심을 청구할 수 있다.³¹¹⁾

2. 청구대상

재심청구의 대상은 확정된 취소결정 또는 중국심결이다. 그러므로 미확정된 취소결정 또는 심결은 재심의 대상이 될 수 없다.³¹²⁾ 적법한 송달이 없는 취소결정 또는 심결은 확정된 것이 아니므로 재심의 대상이 되지 아니하며, 사자(死者)를 상대로 한 취소결정 또는 심결은 무효이므로 이에 대하여 재심을 청구할 필요가 없다.

3. 청구시기

(1) 원 칙

당사자는 재심 사유를 안 날부터 30일 이내 및 특허취소결정 또는 심결 확정 후 3년 이내에 재심을 청구하여야 한다(法 180①③).³¹³⁾ 재심청구인이 책임질 수 없는 사유로 30일의 재심의 청구기간을 지키지 못한 경우에는 그 사유가 소멸한 날부터 2개월 이내에 지키지 못한 절차를 추후 보완할 수 있다. 다만 그 기간의 만료일부터 1년이 지났을 때에는 그러하지 아니하다(法 17).

(2) 제한 및 확장

① 대리권 흠의 경우

재심청구인은 대리권의 흠을 이유로 재심을 청구하는 경우에 안 날로부터 30일은 청구인 또는 법정대리인이 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다(法 180②). 즉 청구인이나 법정대리인이 이 재심의 사유가 있었다는 것을 안 날은 무권대리인에게 송달된 날이 아니라 그 특허취소결정등본 또는 심결등본의 송달에 의하여 특허취소결정 또는 심결이 있는 것을 안 날을 기준으로 하여야 한다.³¹⁴⁾

311) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 409면.

312) 대법원 1980. 7. 8. 선고 80다1131.

313) 심결이 대리인에게 송달되었을 때에는 그 대리인은 특별한 사정이 없는 한 그 송달을 받을 당시에 그 심결에 판단유탈(누락)이 있는 여부를 알았다고 할 것이고 그 대리인이 판단유탈 유무를 안 경우에는 특별한 사정이 없는 한 당사자도 그 판단유탈의 유무를 알았던 것이라고 보아야 할 것이므로 확정심결에 대하여 판단유탈이 있음을 이유로 한 재심청구의 제기기간은 대리인이 심결의 송달을 받은 때에 안 것으로 하여 계산하여야 할 것이다(대법원 1982. 8. 24. 선고 81사11; 1987. 7. 21. 선고 87후55).

② 재심사유가 심결 확정 후 생긴 경우

재심사유가 특허취소결정 또는 심결 확정 후에 생겼을 때에는 특허취소결정 또는 심결 확정 후 3년은 그 사유가 발생한 날의 다음 날부터 기산한다(法 180④).³¹⁵⁾

③ 전의 확정 심결과 저촉되는 경우

해당 심결 이전의 확정 심결에 저촉된다는 이유로 재심을 청구하는 경우에는 기간의 제한이 없다(法 180⑤). 이는 심결의 통일을 확보하기 위하여 특례를 규정한 것이다.

IV. 재심의 절차

1. 재심의 관할 및 청구서 제출

(1) 재심의 관할

재심은 특허취소결정 또는 심결한 특허심판원의 전속관할이므로 재심을 청구하려는 자는 재심청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다(法 178② 준용 民訴法 453). 다만 재심사유가 특허법원 단계에서 발생한 경우나 대법원 단계에서 발생하였다면 각 단계의 법원에 재심청구서를 제출하여야 한다.³¹⁶⁾

(2) 재심청구서의 제출

재심청구인은 당사자와 대리인, 재심을 할 특허취소결정 또는 심결의 표시와 그 특허취소결정 또는 심결에 대하여 재심을 구하는 취지와 재심의 이유를 적은 재심청구서를 특허심판원장에게 제출하여야 한다. 한편 재심청구서에서 주장한 재심사유는 후에 변경할 수 없는 것으로 해석된다. 이는 제185조에서 민사소송법 제459조제1항을 준용하나, 제2항을 준용하지 않기 때문이다.

314) 심결이 있는 것을 「안 날로부터 기산」한다고 하면 기간의 계산에 있어서 첫날을 계산에 넣지 아니하기 때문에 「안 날의 다음 날」이 기산일이 된다. 한편 「안 날의 다음 날부터 기산」한다고 하면 안 날의 다음 날은 오전 0시부터 시작하기 때문에 역시 「안 날의 다음 날」이 기산일이 된다. 따라서 「심결이 있는 것을 안 날부터 기산한다」고 하는 것이나 「심결이 있는 것을 안 날의 다음 날부터 기산한다」고 하는 것이나 기산일은 다 같이 「안 날의 다음 날」이다(이종완, 「특허법론」, 대한변리사회, 2004, 934면).

315) 예를 들어 심결의 확정 후에 그 심판에 관련한 심판관에 대하여 수뢰죄의 판결이 확정된 경우가 있다.

316) 재심사유는 위 대법원판결에 영향을 미칠 사항에 관하여 판단을 유탈(누락)하였다는 것이고 원심심결에 재심사유가 있다는 아무런 주장을 찾아 볼 수 없으니 이 사건 재심대상은 위 원심심결이 아니라 위 대법원판결임이 명백하다 할 것이므로 이 재심의 소는 위 대법원판결을 재심대상 판결로 하여 민사소송법 제424조제1항에 따라 그 전속관할 법원인 당원에 제기하였어야 옳았을 것이다. 그러함에도 위 대법원판결을 재심대상으로 하여 당원에 재심의 소를 제기하지 아니하고, 대법원판결에 재심사유있음을 이유로 재심대상으로 삼을 수 없는 원심심결을 재심대상으로 하여 원심에 한 이 사건 재심청구는 부적법하여 각하하였어야 할 것임에도 불구하고 원심이 이를 간과하고 재심사유의 유무를 심리한 후 그 이유 없다 하여 이 건 재심청구를 기각(재심불성립)하였음은 부당하다 할 것이나 이 사건 재심청구를 배척한 점에 있어서는 타당하므로 원심결은 결과적으로 정당하다(대법원 1982. 12. 14. 선고 81후53).

2. 방식심리와 적법성 심리

심판장·심판관 합의체는 먼저 청구로서의 일반적 절차요건과 재심의 적법요건을 심리하여야 하며, 재심의 일반적 절차요건과 재심의 적법요건에 흠결이 있는 경우에 보정하지 않거나 보정을 할 수 없을 때는 본안심리에 들어가지 않고 결정 또는 심결로써 각하한다. 예를 들어 심결확정 전에 특허무효심판에 대한 재심청구가 있는 경우에는 심판관 합의체는 재심의 피청구인에게 답변서 제출기회를 주지 아니하고 심결로써 심판청구를 각하할 수 있다.

3. 재심의 본안심리

(1) 서

재심은 확정된 특허취소결정 또는 심결의 취소와 본안사건에 대하여 이에 갈음한 특허취소 신청에 대한 결정 또는 심결을 구하는 두 가지 목적이 있으므로, 이론상으로는 재심의 허부(許否)와 재심이 허용됨을 전제로 한 본안심판 등 두 가지 단계로 구성되나, 실무상으로는 양자를 명확히 구별하지 아니하고 하나의 심판절차에서 병합심리하는 것이 일반적이다. 한편 재심에 대한 심리는 재심청구이유의 범위에서 하여야 한다(法 185 준용 民訴法 459①). 이는 통상 심판의 경우에 직권심리주의의 입장에서 당사자가 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있는 것과는 현저하게 다르다. 그 이유는 재심은 당사자가 청구하는 취지와 이유가 명확하고 또한 확정된 특허취소결정 또는 심결에 대한 급조된 불복신청방법이므로 심리의 범위를 한정해도 부당하지 않기 때문이다.³¹⁷⁾

(2) 재심사유의 존부확인

재심의 청구가 적법하면 재심사유의 존부를 조사하여야 한다. 확정된 원특허취소결정 또는 심결의 취소는 사익을 넘어서는 것이고 당사자의 의사로 좌우할 수 없으므로 직권으로 사실탐지를 할 수 있으며, 청구의 포기·인락·자백은 인정되지 않는다. 그 결과 재심사유가 없는 것으로 인정되면 재심청구를 기각하여야 한다.

(3) 본안심리

재심사유가 있는 것으로 인정되면 원특허취소결정 또는 심결을 취소하고 본안에 대한 심리에 들어가게 된다. 특허취소결정 또는 심판에 대한 재심의 절차에 관하여는 그 성질에 반하지 아니하는 범위에서 특허취소신청 또는 심판의 절차에 관한 규정을 준용한다(法 184). 예를 들어 특허무효심판에 대한 재심에 있어서는 특허무효심판과 같은 심리를 하고 거절결정불복심판에 대한 재심에 있어서는 거절결정불복심판과 같은 심리를 하여야 한다.

317) 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001, 957면.

4. 심결(결정)

(1) 심결(결정)내용

확정된 원특허취소결정 또는 심결을 유지할 수 없을 때는 특허취소신청에 대한 기각결정 또는 새로운 심결을 하여야 하고, 유지할 수 있을 때는 원특허취소결정 또는 심결과 같은 내용의 결정 또는 심결을 하여야 한다. 즉 재심사유가 존재하는 경우에는 원특허취소결정 또는 심결의 결과가 정당하더라도 바로 재심청구를 기각하는 취지의 결정 또는 심결을 하여서는 아니 된다.

(2) 불 복

심판장으로부터 특허취소결정 또는 심결등본을 송달받은 날로부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내에 특허법원에 취소소송을 제기할 수 있다(法 186①).

V. 심결(결정)확정의 효과

1. 일반적 효과

재심의 결정 또는 심결이 확정되면 원특허취소신청 또는 심판에 있어서 결정 또는 심결이 있는 경우에 인정되는 기속력과 형식적 확정력, 실질적 확정력(일사부재리(취소신청은 제외))이 동일하게 적용된다.

2. 특유의 효과

(1) 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한

1) 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에 특허권의 효력은 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 i) 선의로 수출 또는 수입하거나 또는 국내에서 생산하거나 취득한 물건, ii) 선의의 실시행위 및 iii) 선의의 간접침해행위 중 어느 하나에 대해서는 미치지 아니한다(法 181).

i) 무효가 된 특허권(존속기간이 연장등록된 특허권을 포함한다)이 재심에 의하여 회복된 경우

ii) 특허권의 권리범위에 속하지 아니한다는 심결이 확정된 후 재심에 의하여 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우

iii) 거절한다는 취지의 심결이 있었던 특허출원 또는 특허권의 존속기간의 연장등록출원이 재심에 의하여 특허권의 설정등록 또는 특허권 존속기간의 연장등록이 된 경우

iv) 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우

2) 특허발명이 무효된 것으로 믿고 발명을 실시하였던 자 등에 대하여 무조건 침해자로 인

정하는 것은 공평의 원칙에 반하므로 선의의 자에 대해서는 회복된 특허권 등에 관한 효력 제한을 규정함으로써 선의의 자와 특허권자 간에 법적 형평을 도모하고자 한 것이다. 선의를 요건으로 하는 것은 악의의 실시자에 대해서는 소급하여 침해자로 하여도 부당하지 않기 때문이다. 또한 재심청구 등록 전으로 시점을 한정하는 것은 재심의 청구가 있을 때는 제3자에게 공시하려는 목적으로 예고등록을 하고 있으므로 그 이후의 실시자는 악의로 실시한 것으로 보아도 가혹하지 않기 때문이다.

(2) 재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자의 통상실시권

제181조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해당 특허취소결정 또는 심결이 확정된 후 재심청구 등록 전에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 실시하고 있거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 관하여 무상의 통상실시권을 가진다(法 182). 이 통상실시권은 법정실시권이므로 등록을 하지 않더라도 효력이 발생한다.

(3) 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권

제138조제1항 또는 제3항에 따라 통상실시권을 허락한다는 심결이 확정된 후 재심에서 그 심결과 상반되는 심결이 확정된 경우에는 재심청구 등록 전에 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자 또는 그 사업을 준비하고 있는 자는 원(原)통상실시권의 사업목적 및 발명의 범위에서 그 특허권 또는 재심의 심결이 확정된 당시에 존재하는 전용실시권에 대하여 통상실시권을 가진다. 이 통상실시권은 법정실시권이므로 등록을 하지 않더라도 효력이 발생하지만, 통상실시권자는 특허권자 또는 전용실시권자에게 상당한 대가를 지급하여야 한다(法 183).

PART 08

소 송

제1장 특허소송

제2장 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소

제1장

특허소송

제186조 【심결 등에 대한 소】

- ① 특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다. <개정 2016.2.29.>
- ② 제1항에 따른 소는 다음 각 호의 자만 제기할 수 있다. <개정 2016.2.29.>
 1. 당사자
 2. 참가인
 3. 해당 특허취소신청의 심리, 심판 또는 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자
- ③ 제1항에 따른 소는 심결 또는 결정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.
- ④ 제3항의 기간은 불변기간으로 한다.
- ⑤ 심판장은 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 제4항의 불변기간에 대하여 부가기간을 정할 수 있다.
- ⑥ 특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다. <개정 2016.2.29.>
- ⑦ 제162조제2항제5호에 따른 대가의 심결 및 제165조제1항에 따른 심판비용의 심결 또는 결정에 대해서는 독립하여 제1항에 따른 소를 제기할 수 없다.
- ⑧ 제1항에 따른 특허법원의 판결에 대해서는 대법원에 상고할 수 있다.

[전문개정 2014.6.11.]

제187조 【피고적격】

제186조제1항에 따라 소를 제기하는 경우에는 지식재산처장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조제1항, 제134조제1항·제2항, 제135조제1항·제2항, 제137조제1항 또는 제138조제1항·제3항에 따른 심판 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다. <개정 2016.2.29.>

[전문개정 2014.6.11.]

제188조 【소 제기 통지 및 재판서 정보 송부】

- ① 법원은 제186조제1항에 따른 소 또는 같은 조 제8항에 따른 상고가 제기되었을 때에는 지체 없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 한다.
- ② 법원은 제187조 단서에 따른 소에 관하여 소송절차가 완결되었을 때에는 지체 없이 그 사건에 대한 각 심급(審級)의 재판서 정보를 특허심판원장에게 보내야 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제188조의2 【기술심리관의 제척·기피·회피】

- ① 「법원조직법」 제54조의2에 따른 기술심리관의 제척·기피에 관하여는 제148조, 「민사소송법」 제42조부터 제45조까지, 제47조 및 제48조를 준용한다.
- ② 제1항에 따른 기술심리관에 대한 제척·기피의 재판은 그 소속 법원이 결정으로 하여야 한다.

③ 기술심리관은 제척 또는 기피의 사유가 있다고 인정하면 특허법원장의 허가를 받아 회피할 수 있다.
[전문개정 2014.6.11.]

제189조 【심결 또는 결정의 취소】

- ① 법원은 제186조제1항에 따라 소가 제기된 경우에 그 청구가 이유 있다고 인정할 때에는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다.
 - ② 심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다.
 - ③ 제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다.
- [전문개정 2014.6.11.]

제1절 서 설

I. 의 의

1) 「광의의 특허소송」이란 i) 특허침해소송, 즉 금지청구소송(法 126), 손해배상청구소송(法 128), 신용회복조치청구소송(法 131) 등의 민사소송 및 특허권의 침해죄(法 225) 등에 기한 형사소송, ii) 지식재산처장 또는 특허심판원장이 한 행정상의 처분에 관한 소송(法 224의2), iii) 제186조제1항의 특허취소결정 또는 심결에 대한 소송이나 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소송(法 186-189), iv) 보상금 또는 대가에 대한 불복의 소송(法 190, 191)을 말한다.¹⁾

2) 이러한 광의의 특허소송 중 특허법원의 전속관할에 속하는 것으로서, 제186조제1항의 소송만을 심결취소소송 또는 「협의의 특허소송」이라 한다(法 186①). 일반적으로 특허소송이란 협의의 특허소송을 지칭하며 이하에서는 이를 중심으로 설명한다.

II. 법적성질

심결취소소송은 기본적으로 행정소송의 일종으로 보는 것이 통설·판례²⁾의 입장이다. 심결취소소송 중 지식재산처장을 피고로 하는 결정계 사건은 행정소송법 제3조제1호 소정의 항고

1) 광의의 특허소송을 표로 정리하면 다음과 같다.

종 류	관 할	관련조문
침해소송	민·형사법원 (특허법원)	法 제126조 내지 제132조 法 제225조 내지 제232조
행정처분(무효, 불수리, 재정 등)에 대한 소송	행정법원/행정심판원	法 제224조의2
특허취소결정, 심결 또는 각하결정에 대한 소송	특허법원	法 제186조 내지 제189조
보상금에 대한 소송	민사법원/행정법원	法 제190조 및 제191조

2) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1306.

(취소)소송이라는 데 다툼이 없으나, 특허권자 또는 이해관계인을 상대로 하는 당사자계 사건에 관하여는 결정계 사건과 마찬가지로 항고소송이라고 보는 견해와 당사자소송에 속한다고 보는 견해가 나뉜다. 당사자계 사건은 소송의 외양을 보면 양 당사자가 서로 대립하는 민사소송의 구조와 크게 다를 바가 없어 항고소송이라기보다는 당사자소송에 속한다고 보아야 할 것이나, i) 지식재산처의 결정·심결은 이른바 행정처분에 속하는 것으로 당사자계 사건도 그 실질을 보면 지식재산처 처분의 위법성을 다투는 것이어서 당사자 대립의 구조는 편의상의 것에 불과하다는 점, ii) 직권증거조사 등 심리에 있어서 민사소송과 다른 특수성을 인정할 필요가 있다는 점 등을 고려하였을 때 항고소송으로 보고 있다.³⁾⁴⁾

III. 행정소송 · 민사소송과의 관계

1. 특허소송 사건과 민사소송 · 행정소송 사건의 구분

1) 특허법 등에서 특허법원의 전속관할에 속하는 사건으로 특별히 규정한 것만이 특허소송 사건으로 되고 나머지 사건은 일반원칙에 따라 해결된다. 예컨대 소위 특허침해소송이라고 불리는 금지청구소송, 손해배상청구소송 및 신용회복청구소송 등은 일반 민사소송사건이 되고 절차의 무효와 불수리, 특허권의 수용, 재정에 관한 불복 등에 관하여는 특허법에 특별한 불복규정이 없으므로 일반 행정소송법의 절차에 의한 행정소송사건이 된다.

2) 제190조 소정의 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소는 그 성질에 따라 행정소송(法 41 ③④, 106③, 106의2③) 혹은 민사소송(法 110②Ⅱ, 138④)이 된다.

2. 행정소송 · 민사소송절차의 준용

특허소송에 대해서는 절차법인 특허소송법이 아직 존재하지 아니한다. 그러므로 i) 우선 특허법이 적용되고 ii) 특허법에 규정이 없는 사항의 경우에는 특허소송이 기본적으로 행정소송적인 성질을 가지므로 행정소송법이 준용되고, 다시 iii) 행정소송법에 특별한 규정이 없는 경우에는 행정소송법 제8조에 따라 민사소송법이 준용될 것이다.⁵⁾

IV. 특허소송과 특허심판의 관계

1. 심판전치주의

제186조제6항에서는 “특허취소를 신청할 수 있는 사항 또는 심판을 청구할 수 있는 사항에 관한 소는 특허취소결정이나 심결에 대한 것이 아니면 제기할 수 없다”라고 규정하여 심판전치주의를 강제하고 있다. 특허소송은 특허취소결정, 심결 또는 청구서의 각하결정에 대한 소송

3) 대법원 2005. 7. 28. 선고 2003후922; 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 등.

4) 법원행정처, 「특허소송실무」, 1998, 3면.

5) 법원행정처, 「특허소송실무」, 1998, 4면.

만을 허용하기 때문에 이와 같은 처분이 아닌 것에 대해서는 특허법원에 소를 제기할 수 없다. 예를 들어 특허거절결정에 대하여 소를 제기하기 위해서는 특허심판원에 불복하여 기각심결을 받은 경우이어야 한다.⁶⁾ 이처럼 소송의 심판전치주의를 취하는 이유는 발명의 성질상 판단에 특수한 전문지식이 필요하기 때문이다.

2. 절차의 중지

법원은 소송절차에서 필요하면 직권 또는 당사자의 신청에 따라 특허출원에 대한 특허여부 결정, 특허취소신청에 대한 결정이나 특허에 관한 심결의 확정기 있을 때까지 그 소송절차를 중지할 수 있다(法 78②, 164②). 소송절차의 중지 여부는 법원의 재량이지만 소송 실무에서는 변론기일을 추후지정(기일추정이라고 한다)하는 형식에 의한다.

3. 심판 및 소송기록의 송부

특허법원에 소가 제기되더라도 특허심판원은 특허법원의 하급심 법원이 아니므로 심판 기록을 특허법원에 이관할 의무가 없고, 당사자는 특허심판원에 제출한 것과 동일한 자료라고 하더라도 특허법원에 다시 제출하여야 한다. 즉 심판절차와 특허법원 소송절차 사이에는 그 절차의 연속성을 인정할 수 없으므로 특허취소결정 또는 심결원본이나 그 밖의 일건 기록서류는 특허법원에 소가 제기된다고 하더라도 심판원에서 특허법원으로 당연히 송부되는 것이 아니다. 이 경우 특허법원은 심리의 편의상 필요하다고 인정하면 지식재산처장 또는 심판원장에게 심사·심판·등록서류 등본의 송부를 촉탁하거나 당사자에게 그 등본을 제출하게 할 수 있다.

제2절 소송요건

I. 주 체

1. 원 고

(1) 원고적격의 제한

1) 특허소송에 있어서는 당사자, 참가인 또는 해당 특허취소신청의 심리, 심판 또는 재심에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자만 소를 제기할 수 있다(法 186②). 구체적으로 특허취소신청의 특허취소결정에 대한 불복인 경우에는 특허권자만이, 결정계 심판의 심결에 대한 불복인 경우에는 심판청구인이, 당사자계 심판의 심결에 대한 불복인 경우에는 패심자가 원고가 된다. 그 외 특허취소신청서, 심판청구서 및 재심청구서의 각하결정에 대한 불복인 경우에는 특허취소신청인, 심판청구인이 원고가 된다.

2) 특허권은 대세효가 있어서 이해관계가 있는 제3자의 범위가 매우 넓어서 이들 모두에게

6) 특허법원 2000. 3. 17. 선고 99허5401; 2000. 11. 3. 선고 2000허2620 등.

원고적격을 인정하면 소송이 지연될 우려가 있는 반면에, 당사자에게만 원고적격을 인정하고 특허취소결정, 심결에 의하여 권리를 침해당하였음에도 당사자 이외에는 권리 구제를 받을 수 없도록 하는 것은 “모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다”라고 규정한 헌법 제27조제1항에 저촉될 소지가 있으므로, 특허법은 그 절충안을 채택하고 있다.⁷⁾ 다만 특허무효심판과 같은 당사자계 심판임에도 불구하고 등록받지 아니하여 심판장으로부터 취지를 통지받지 못하고 참가의 기회를 상실한 미등록 통상실시권자 등이 심결취소소송을 제기할 수 없는 것이 타당한지 의문이다. 따라서 이러한 문제점을 고려하여 일응 원고적격을 현행법의 테두리 안에서 제한적으로 인정하되 이해관계인에게 원고적격 취득을 위한 참가기회를 부여하거나 참가기회가 완전히 박탈된 이해관계인의 경우에 원고적격을 인정할 수 있는 제도적 근거 마련을 위한 노력도 병행하는 것이 바람직할 것이다.⁸⁾

(2) 공유자 중 1명의 소 제기

제139조제3항은 특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다고만 규정하고 있을 뿐 심결취소소송의 제기에 관하여는 아무런 규정을 두고 있지 않다. 따라서 특허권의 공유자가 패소하였을 때 그 심결취소소송을 심판청구와 같이 공유자 모두가 공동으로 제기하여야 하는지 아니면 공유자 중의 1명만이라도 제기할 수 있는지가 문제가 된다. 이에 대법원⁹⁾은 공유자 모두가 공동으로 제기하여야만 하는 고유필수적 공동소송이라고 할 수 없고, 공유자의 1명이라도 그 등록을 무효로 하거나 권리행사를 제한·방해하는 심결이 있으면 그 권리의 소멸을 방지하거나 그 권리행사방해배제를 위하여 단독으로 그 심결의 취소를 구할 수 있다고 판시하였다. 1명이 소송을 제기한 경우에 그 소송에서 승소할 경우에는 그 취소판결의 효력은 행정소송법 제29조제1항에 의하여 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개됨으로써 충족되고, 그 소송에서 패소하더라도 이미 심판절차에서 패소한 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 아니하므로, 어느 경우에도 합일확정의 요청에 반한다거나 다른 공유자의 권리를 해하지 않기 때문이라는 것이다. 또한 심결취소소송을 공유자 모두가 제기하여야만 한다면 합일확정의 요청은 이룰지언정, 공유자의 1명이라도 소재불명이나 파산 등으로 소의 제기에 협력할 수 없거나 이해관계가 달라 의도적으로 협력하지 아니한 경우에는 나머지 공유자들은 출소기간의 만료와 동시에 그 권리행사에 장애를 받거나 그 권리가 소멸되어 버려 그 의사에 기하지 않고 재산권이 침해되는 부당한 결과에 이르게 되기 때문이라는 것이다.

7) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 15면.

8) 김종일, “실시권자의 심결취소소송에 대한 원고적격취득에 대한 소고”, 제15기 변리사 실무수습논문.

9) 대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 판결에서 심판에서 패소한 상표권의 공유자 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있는지와 관련하여 판시한 내용이고, 최근의 대법원 2024. 12. 22. 선고 2024후10825 판결에서는 거절결정불복심판에서 패소한 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자 1인이 심결취소소송을 제기할 수 있는지와 관련하여 2002후567 판결과 동일한 취지로 판시하였다.

(3) 공동심판청구인 중 1명의 소 제기¹⁰⁾

제139조제1항은 동일한 특허권에 관하여 무효심판, 권리범위확인심판을 청구하는 자가 2명 이상이 있으면 그 모두가 공동으로 심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 위 규정에 의한 공동심판청구인의 청구를 기각하는 심결이 있는 경우 공동심판청구인 중 1명이 심결취소소송을 제기할 수 있는지의 문제이다. 이와 관련하여 아직 우리나라의 대법원 판례는 없다. 다만 제139조제1항에 의한 공동심판청구는 유사필수적 공동심판의 성격을 가지므로, 심결이 있고 난 뒤 공동심판청구인 모두에 대하여 출소기간이 지나야 심결이 확정되므로 1명이라도 심결취소소송을 제기하면 심결은 확정되지 않고, 출소기간을 지난 공동심판청구인은 스스로 심결취소소송을 제기할 수는 없지만, 심결이 확정되지는 않았으므로 승소의 확정판결에 의하여 다시 심판이 계속되면 그 심판에서 심결취소소송을 제기하지 아니한 공동심판청구인도 심판청구인의 지위를 유지한다고 볼 것이다.¹¹⁾

2. 피 고

(1) 서

특허취소결정, 결정계 심판의 심결 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서 각하결정에 대한 소를 제기하는 경우에는 지식재산처장을 피고로 하여야 한다(法 187본문). 원칙상 행정처분의 주체인 심판관 합의체 또는 심판장이 피고가 되어야 하나, 소송의 통일적, 효율적인 수행 등을 위해 지식재산처장을 피고로 하고 있다. 한편 당사자계 심판의 심결 또는 그 재심의 심결에 대한 소를 제기하는 경우에는 그 심판의 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다(法 187단서).

【표 8-1】 심판당사자의 원고·피고적격

심판의 종류	결정/심결	원고	피고
특허취소신청	각하결정(심판장)	특허취소신청인	지식재산처장
	각하결정(심판관 합의체)	불복×	
	취소결정	특허권자	지식재산처장
	기각결정	불복×	
당사자계 심판	각하결정	심판청구인	지식재산처장
	각하심결	심판청구인	심판피청구인
	인용심결	심판피청구인	심판청구인
	기각심결	심판청구인	심판피청구인
결정계 심판	각하결정	심판청구인	지식재산처장
	각하심결	심판청구인	지식재산처장
	인용심결	불복×	
	기각심결	심판청구인	지식재산처장

10) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 22면.

11) 이상경, “공동심판과 심결취소소송의 당사자적격”, 인권과 정의, 277호, 1999.9, 102-104면 참조.

(2) 공유자의 피고적격

제139조제2항에 의하면, 심판청구의 경우에 공유인 특허권자 모두를 피청구인으로 하여야 하는바, 특허권자를 피고로 하여야 하는 심결취소소송도 공유자 모두를 피고로 하여야 하는 고유필수적 공동소송이라고 해석한 것에 별 이론이 없다.¹²⁾ 공유자가 피고로 될 때는 원고로 될 때와 달리 다른 공유자의 협력이 있어야 하는 것은 아니므로, 공유자의 재산권이 침해되는 부당한 결과가 발생하지 않기 때문이다. 만일 원고가 공유자 중 일부를 피고에서 누락한 경우 민사소송법 제68조에 따라 피고를 추가할 수 있다.¹³⁾

(3) 공동심판청구인 중 1명의 피고적격

공동심판청구인의 청구를 인용하는 심결이 있는 경우 심판피청구인이 공동심판청구인 중 1명을 피고로 하여 심결취소소송을 제기할 수 있는지가 문제이다. 이와 관련하여 특허법원 판결은 i) 합일확정의 요청에 따라 심결문이 형식적 및 실질적으로 하나이기 때문에 분리확정될 수 없다는 것¹⁴⁾과 ii) 공동심판의 청구는 반드시 공동으로 하여야 하는 것도 아니고 변론의 병합과 분리 모두 임의적이어서 공동심판청구인 별로 별개로 진행되고 별도의 심결이 내려져 각각 확정되는 것이 원칙인바, 공동심판으로 하나의 심결이 작성되었다고 할지라도 제소기간에 제기되지 아니한 심판청구인 부분의 심결 확정을 차단할 근거가 없으므로 공동심판청구인 사이에 별개로 심결이 분리 확정될 수 있다는 것¹⁵⁾으로 나뉘어 있었다. 이에 대법원¹⁶⁾은 청구인들이 공동으로 특허발명의 무효심판을 청구한 이상 청구인들은 유사필수적 공동심판관계에 있으므로, 비록 위 심판사건에서 패소한 특허권자가 공동심판청구인 중 일부만을 상대로 심결

12) 실용신안법 제56조에 따라 준용되는 특허법 제139조제2항은 “공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 모두를 피청구인으로 청구하여야 한다”라고 규정하고 있고 또 같은 법 제139조제3항은 “특허권 또는 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자가 그 공유인 권리에 관하여 심판을 청구하는 때에는 공유자 모두가 공동으로 청구하여야 한다”라고 규정함으로써 공유인 실용신안권 등에 관한 심판은 공유자 모두에 대하여 합일적으로 확정될 것을 반드시 요구하고 있는 점에 비추어 공유자 중 일부 당사자에 대하여 분리하여 심결을 하는 것은 허용되지 아니한다고 할 것이고, 나아가 공유인 실용신안권 등에 관한 심결에 관하여 실용신안권자 등을 상대로 심결취소소송을 제기할 때에도 공유자 모두를 피고로 하여야 할 것이다 (특허법원 2005. 4. 22. 선고 2004허4693).

13) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 30면.

14) 제139조제1항에 의한 공동심판청구는 유사필수적 공동소송의 성격을 가진다고 보는 것이 상당하므로 위 공동심판에 있어서의 심결의 개소는 합일확정의 필요에 따라 형식적 및 실질적으로 하나라고 보아야 할 것이며, 심판피청구인이었던 원고가 공동심판청구인 중 1명인 피고를 상대로 심결의 취소소송을 제기함으로써 그 심결은 확정되지 아니한 것으로 되었다고 할 것이다. 유사필수적 공동소송의 경우에는 고유필수적 공동소송과는 달리 소송을 공동으로 할 것이 강제되지 아니하여 공동소송인의 1명이 탈루되더라도 제소기간이 지나면 탈루된 공동소송인의 추가 등의 방법으로 이를 보정할 수 없다 할 것이다. ……탈루된 공동소송인도 심판청구인으로서의 지위는 유지하는 것이므로 예컨대 심결이 취소되는 경우에는 다시 심리가 속행되는 심판절차에 당사자로서 참여할 수 있다 할 것이고, 만일 심결취소소송에서 원고가 패소하는 것이 확정된 경우, 다시 말하면 심결이 취소되지 않게 된 경우에는 그 때 비로소 심결이 확정되게 되는 것이다 (특허법원 2000. 10. 12. 선고 99허9571).

15) 특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5294

16) 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510.

취소소송을 제기하였다 하더라도 그 심결은 청구인 전부에 대하여 모두 확정이 차단되며, 이 경우 심결취소소송이 제기되지 아니한 나머지 청구인에 대한 심결만 제소기간이 지나서 그대로 분리·확정되지 않는다고 하여 후자의 입장을 지지하고 있다. 따라서 공동심판청구인 중 1명만을 피고로 하여 심결취소소송을 제기할 수 있는 유사필수적 공동소송이고, 고유필수적 공동소송이 아니므로 당사자의 변경을 가져오는 당사자추가신청은 허용되지 않는다고 판시하고 있다.

【표 8-2】 복수당사자의 원고·피고적격

구 분	원 고	피 고
공유특허권자 중 1명	判例가 긍정 → 다른 공유자의 이익을 해한다거나 합일확정의 요청에 반하는 사태가 생긴다고 볼 수 없기 때문(승소할 경우에는 그 취소판결의 효력은 행정소송법 제29조 제1항에 의하여 다른 공유자에게도 미쳐 특허심판원에서 공유자 모두와의 관계에서 심판절차가 재개됨으로써 충족되고, 그 소송에서 패소하더라도 이미 심판절차에서 패소한 다른 공유자의 권리에 영향을 미치지 아니함)	判例가 부정 → 모두를 대상으로 하여야 한다고 해석하더라도 공유자가 원고인 경우와 달리 특별히 부당한 결과가 발생하는 것이 아니기 때문
공동심판청구인 중 1명	학설이 긍정 → 심결이 있는 후 공동심판청구인 모두에 대하여 출소기간이 지나야 심결이 확정되므로 1명이라도 심결취소소송을 제기하면 심결은 확정되지 않고, 출소기간을 지난 공동심판청구인은 스스로 심결취소소송을 제기할 수는 없지만, 심결이 확정되지는 않았으므로 승소의 확정판결에 의하여 다시 심판이 계속되면 그 심판에서 심결취소소송을 제기하지 아니한 공동심판청구인도 심판청구인의 지위를 유지	判例가 긍정 → 1명의 피고를 상대로 심결취소소송을 제기함으로써 그 심결은 확정되지 아니한 것이 되고, 원고가 패소판결이 확정된 경우에만 비로소 심결이 확정됨(분리확정할 수 없는 유사필수적 공동소송으로, 당사자변경은 불허)

3. 소송참가

특허소송은 행정소송이며 행정소송법 및 민사소송법의 참가규정이 준용된다. 그러므로 성격상 독립된 당사자 참가는 허용될 수 없으나, 보조 참가 또는 공동소송참가는 허용된다.¹⁷⁾ 공유의 특허권에 관한 심결 및 공동심판에 의한 심결에 대하여 일단 공유자나 공동심판청구인 중 1명만이 심결취소소송을 제기하였는데 그 후 다른 공유자나 공동심판청구인도 심결취소소송을 제기하려는 경우 제소기간 내라면 공동소송참가를 하면 되고, 이렇게 하지 아니하고 별도로 소를 제기하면 특허법원은 변론을 병합하여 유사필수적 공동소송으로 심리하여야 한다. 그러나 제소기간이 지나면 다른 공유자나 공동심판청구인은 공동소송참가도 할 수 없고 보조 참가를 할 수 있을 뿐이다.¹⁸⁾¹⁹⁾²⁰⁾

17) 특허법원 1999. 10. 7. 선고 98허7592 참조.

18) 이상경, “공동심판과 심결취소소송의 당사자적격”, 인권과 정의, 277호, 1999.9, 103면 및 104면 참조.

19) 한편 결정제 심판사건의 경우 심판단계에서는 법률에 의하여 참가가 허용되지 아니하나, 심결취소소송에는 특허법상의 참가규정이 적용되지 아니하고 민사소송법상의 참가제도에 관한 규정이 적용되므로 심결에 이해관계를 가지고 있는 자는 참가가 허용되고 있다(특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024, 141면).

4. 소송대리인

「소송대리인」이란 소송당사자 또는 참가인의 이름으로 이러한 자의 대리인임을 표시하고 그들을 대신하여 자신의 의사에 기하여 소송행위를 하거나 받는 자를 말한다. 현행법은 변호사 강제주의를 채택하고 있지 않으므로 본인은 소송대리인을 선임하지 않고 스스로 법정에 나와서 소송수행을 할 수 있다. 한편 소송대리인에 의할 경우 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 소송대리인은 변호사 또는 변리사가 될 수 있다(辨理士法 8).

II. 객 체

1. 소송물

(1) 의 의

심결취소소송은 항고소송의 일종이며, 항고소송의 소송물은 행정처분의 위법성 일반(행정처분의 주체, 내용, 절차, 형식의 모든 면에서 위법)이라고 하는 것이 통설·판례²¹⁾이다. 즉 심결취소소송의 소송물은 해당 심판 실체상의 위법과 절차상의 위법, 판단누락의 유무 등이다.²²⁾ 여기서 「실체상의 위법」이란 발명의 요지파악, 인용대상의 채택, 신규성 또는 진보성 판단 등 심결의 실체적 판단에 위법이 있는 것을 말하고, 「절차상의 위법」이란 절차상의 하자가 심결 또는 심사의 결과에 영향을 미친 경우, 예를 들어 특허거절결정을 하면서 거절이유통지를 하지 아니한 경우를 말하고,²³⁾ 「판단누락」이란 심결의 결론에 영향을 주는 중요한 쟁점 또는 증거물에 관하여 판단이 미진하거나 중요한 당사자의 주장 및 반박에 관하여 판단을 하지 아니한 경우를 말한다.²⁴⁾²⁵⁾

20) 원고 보조 참가인은, 자신은 이 사건 심판절차의 당사자임과 동시에 피고들이 청구한 특허심판원 2007당879호 적극적 권리범위확인심판의 피심판청구인이므로 이 사건 특허발명의 무효 여부에 관하여 이해관계가 있다고 주장하면서 원고에 대한 보조 참가신청을 하였고, 피고들은, 이 사건 심판절차의 당사자로서 그 불복소송도 제기하지 아니한 보조 참가인이 뒤늦게 보조 참가신청을 한 것은 신의칙에 위반되거나 이미 참가적격을 상실하여 부적당한 신청이라며 보조 참가신청에 대한 이의신청을 하였다. 살피건대, 소송의 결과에 대하여 법률상의 이해관계가 있는 제3자는 당사자 일방을 보조하기 위하여 보조 참가를 할 수 있으므로(대법원 2000. 9. 8. 선고 99다26924 판결 등 참조), 이 사건 심결의 패소한 당사자였을 뿐만 아니라, 피고들이 이 사건 특허발명의 실시자로 자목하여 제기한 적극적 권리범위확인 사건의 당사자인 원고 보조 참가인은 당연히 이 사건 소송 결과에 대하여 법률상의 이해관계가 있는 자이고, 피고들의 주장과 같은 사유만으로 그 보조 참가신청이 신의칙에 위반되거나 이미 참가적격을 상실한 자의 신청으로 볼 수는 없으므로, 이 사건 보조 참가신청은 적법하다고 할 것이다(특허법원 2008. 8. 22. 선고 2007허4649).

21) 대법원 1990. 11. 27. 선고 90누4938 등.

22) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290; 2003. 10. 24. 선고 2002후1102 등.

23) 출원발명의 청구범위 제1항 발명이 통상의 기술자가 인용대상으로부터 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 특허거절결정이 정당하다고 하여 심판 청구를 기각하고, 이에 대하여 출원발명자는 출원발명이 진보성이 있어 심결이 위법하다는 이유로 심결취소소송을 제기한 경우, 그 심결취소소송에서는 출원발명이 진보성이 없다고 한 심결의 위법 여부를 심리판단할 수 있을 뿐이고, 비록 출원발명의 명세서 기재가 특허법상 기재요건에 위배되는 것으로 인정된다 하더라도 진보성 판단에 앞서 명세서 기재요건에 대한 거절이유를 통지하지 않았다는 이유로 심결을 위법하다고 판단할 수는 없다(대법원 2003. 2. 11. 선고 2002후2303).

(2) 심판물과의 관계

심판에서 심판물은 청구이유가 아닌 청구취지에 의하여 결정된다. 예컨대, 특허무효심판이나 권리범위확인심판의 경우 청구항마다 심판을 청구할 수 있고, 청구항마다 취할 수 있으므로 청구항별로 별개의 심판물로 보아야 한다. 그러나 거절결정불복심판의 경우에는 하나의 청구항이라도 거절이유가 있는 경우 출원 전체를 거절결정하므로 청구항마다 별개의 심판물로 보기 어렵다. 1개의 심판절차에서 수 개의 심판물에 대하여 심결을 하였을 때는 심판물의 수에 따라 수 개의 소송물을 인정하는 것이 타당하다. 예컨대, 청구범위 제1항과 제2항에 대한 특허무효 심판청구 전부에 대하여 무효심결이 있는 경우, 제1항과 제2항에 대하여 각각 별개의 심결취소소송을 제기할 수 있다. 다만 제소기간에 제1항에 대해서만 심결취소소송을 제기하였다면 제2항에 대해서는 심결이 확정된 것으로 취급한다.²⁶⁾

2. 소의 이익

(1) 의 의

1) 「소의 이익」은 당사자가 소송을 이용할 정당한 이익 또는 필요성을 말하는 것으로 중요한 소송요건이다. 심결취소소송 역시 소의 이익이 있어야 하고, 소의 이익이 없다면 그 소송은 부적법한 것으로 소각하 판결을 받게 된다. 다만 심결취소소송은 실질적으로 특허심판원의 심결에 대한 항소심적 역할을 한다고 볼 수 있으므로, 심결취소소송에 있어서 소의 이익은 결국 민사소송법상의 일반적인 소의 이익보다는 항소의 이익이라는 측면이 강하다고 할 수 있다.²⁷⁾

2) 심판절차에서 불리한 심결을 받은 당사자로서는 원칙적으로 심결취소소송으로써 해당 심결을 취소하여 자신에게 불리한 심결이 그대로 효력을 발생하고 있는 현재의 법적 상태를 그것이 없었던 상태로 되돌리는 원상복구를 청구할 수 있다고 할 것이고, 그에 따라 심결의 취소를 구할 소의 이익도 긍정되어야 할 것이다.²⁸⁾ 다만 예외적으로 심결의 효력이 그대로 존속하고 있기는 하나, i) 다른 사정으로 심결 자체가 이제는 무의미하게 되거나 ii) 심결을 취소하더라

24) 판결서의 이유에는 주문이 정당하다는 것을 인정할 수 있을 정도로 당사자의 주장, 그 밖의 공격방어 방법에 관한 판단을 표시하면 되고 당사자의 모든 주장이나 공격방어 방법에 관하여 판단할 필요가 없으며 (민사소송법 제208조 제2항 참조), 판결에 당사자가 주장한 사항에 대한 구체적·직접적인 판단이 표시되어 있지 않더라도 판결이유의 전반적인 취지에 비추어 그 주장을 인용하거나 배척하였음을 알 수 있는 정도라면 판단누락이라고 할 수 없고, 설령 실제로 판단을 하지 아니하였다고 하더라도 그 주장이 배척될 경우임이 분명한 때에는 판결 결과에 영향이 없어 판단누락의 위법이 있다고 할 수 없다(대법원 2012. 4. 13. 선고 2010다9320).

25) 유일한 증거방법이라 하더라도 이를 채용하지 아니할 합리적인 이유가 있을 때에는 예외적으로 이를 조사하지 아니할 수 있다(대법원 1971. 7. 27. 선고 71다1195). 다만 유일한 증명방법임에도 불구하고 특별한 사정에 관한 심리판단도 없이 청구인의 주장을 배척하였음은 심리미진과 법리오해의 위법이 있다.

26) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 6-8면 참조.

27) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 9면 참조.

28) 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301 참조.

도 이제는 유리한 심결을 받을 가능성이 없게 된 경우 등에는 원고가 심결취소소송으로써 자신에게 불리한 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없다고 하여야 한다.²⁹⁾

(2) 판 단

소의 이익의 유무는 변론종결 시를 기준으로 판단한다. 따라서 소 제기 시에 소의 이익이 있더라도 변론종결 시에 소의 이익이 소멸하였다면 그 소송은 부적법한 것으로 각하된다. 다만 상고심 계속 중에 소의 이익 등 소송요건이 흠결되는 경우에는 그러한 사정도 고려하여 소의 이익이 없다고 보는 것이 대법원의 일반적인 경향이다. 예컨대 대법원 2001. 5. 8. 선고 98후1921 판결은 특허를 무효로 한 심결에 대한 심결취소소송에서 원고의 청구가 기각되어 상고심에 계속 중, 제3자가 제기한 특허무효심판에서 특허를 무효로 하는 심결이 확정되었을 때는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 존재하지 아니한 특허를 대상으로 판단한 심결은 위법하게 되나, 특허가 무효로 확정된 이상 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하여 이 사건 소는 부적법하게 되었다는 이유로 원심판결을 파기하고, 직접 판결하여 소를 각하하였다.³⁰⁾ 대법원이 심결의 위법성을 이유로 파기환송하고 특허법원에서 소각하를 할 수도 있으나, 대법원이 직접 파기소각하를 하는 것은 어차피 각하될 것이 분명하므로 절차경제의 요청에 부응하기 위함이다.

(3) 심판의 이익과의 관계

1) 심판단계에서의 심판의 이익과 심결취소소송에서의 소의 이익은 별개이므로 이를 구분하여야 한다. 심판의 이익과 소의 이익의 흠결은 모두 심판청구각하 또는 소각하사유이나 그 판단시점이 심결 시와 사실심 변론종결 시(예외적으로 상고심 종결 시)로 다를 뿐 아니라, 그 이익을 흠결하게 되는 사유도 각각 살펴보아야 한다. 즉 어떤 사유로 인해 심결 시에 심판의 이익이 없음에도 불구하고 본안심결을 한 경우에는 심결취소소송에서 원심결을 취소하고 심판원으로 환송한 후 심판원의 심판관 합의체에 의하여 심판청구를 심결각하하여야 하고, 어떤 사유로 인해 사실심 변론종결 시에 소의 이익이 없는 경우에는 심결취소소송을 각하하여야 한다. 예를 들면 소멸된 특허권 등의 권리에 대한 권리범위확인심판에 있어서 심판단계에서 그 권리가 소멸된 경우에는 심판청구를 각하하지 아니한 심결은 위법하므로 취소되어야 하고,³¹⁾ 그 권리가 심결취소소송단계에서 소멸한 경우에는 소의 이익이 없으므로 소를 각하하여야 한다.³²⁾ 또한 당사자 간의 합의가 심결 이후에 있으면 소의 이익이 없으므로 소를 각하하여야 하나,³³⁾ 심판단계에서 당사자 간의 합의가 이루어질 경우에는 심판의 이익이 없으므로 심판청

29) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 50면.

30) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 10면.

31) 특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허6292.

32) 특허법원 2009. 1. 2. 선고 2009허4513.

33) 그러나 당사자 사이의 합의 내용이 원고가 심결취소소송을 포기하고 특허심판원의 심결을 그대로 받아들여 이를 확정시키겠다는 취지라면 소각하 판결을 하여도 별 문제가 없을 것이나, 만일 합의의 전체적인 취지가 심결을 포함한 심판절차까지 처음부터 없었던 것으로 하겠다는 취지인 경우도 있을 수 있고, 이러한 경우에는 원고가 소취하서를 제출하지 아니하면 합의가 있었다는 이유만으로 곧바로 소각하를 하는 데에는 주의를 요한다(김철환, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 756면.).

구를 각하하여야 함에도 실제 판단을 한 심결은 위법하므로 그 심결은 취소되어야 한다. 다만 심판의 이익이 없음에도 권리범위확인심판청구를 기각한 심결의 취소소송에서는 소의 이익을 인정하기가 곤란할 것이다. 법원에서 원고 청구를 인용하여 심결을 취소하더라도 특허심판원은 어차피 원고의 권리범위확인심판청구를 각하할 것이므로, 굳이 기각심결의 취소를 구할 이익이 없기 때문이다.³⁴⁾

2) 한편 심결취소소송 계속 중에 이미 특허권의 등록무효심결이 확정된 경우와 같이 어떤 구체적 사정이 심판청구의 이익과 소의 이익에 공통되는 경우에는 심판청구도 부적법하게 되고 소 자체도 부적법하게 되는바, 이러한 경우에도 심판절차와 소송절차는 나누어 심판청구의 이익 판단에 앞서 소의 이익 유무를 먼저 판단하여야 할 것이다. 이는 소의 이익은 본안판결을 받기 위하여 먼저 갖추어야 할 소의 적법요건으로서, 만일 소의 이익이 흠결된 경우에는 심결의 위법성이라는 본안의 판단에 나아갈 여지도 없이 소 각하되어야 하기 때문이다.³⁵⁾

(4) 침해소송과 권리범위확인심판의 관계

① 소의 이익

소극적 권리범위확인심판의 기각심결이 내려진 후 원고(이해관계인)가 제기한 심결취소소송의 상고심 계속 중에 피고(특허권자)가 제기한 침해에 대한 민사소송(침해소송)의 승소판결이 확정된 경우에 아직 심결을 취소할 이익, 즉 소의 이익이 있는지와 관련하여, 대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486 판결에서는 i) 여전히 원고에게 불리한 이 사건 심결이 유효하게 존속하고 있는 점, ii) 확정된 위 민사판결은 이 사건 심결취소소송을 담당하는 법원에 대하여 법적 기속력이 없으므로 원고는 위 민사판결이 확정되었음에도 불구하고 자신에게 불리한 이 사건 심결을 취소할 법률상 이익이 있다는 점, iii) 이 사건 심결 이후 권리가 소멸되었다거나 당사자 사이의 합의로 이해관계가 소멸되었다는 등 이 사건 심결 이후 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되었다는 사정도 보이지 아니하는 점 등에 비추어 원고의 소의 이익을 긍정하고 있다. 즉 권리범위확인심판과 침해소송은 서로 간에 법적 기속력이 없으므로 침해소송의 확정판결이 소의 이익을 부정하는 사정변경에 해당하지 않는다는 것이다.

② 심판의 이익(권리범위확인심판에서 확인의 이익)

침해소송이 제기된 후에 소극적 권리범위확인심판을 청구한 경우 심판에 대한 확인의 이익이 있는지와 관련하여, 대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328 판결에서는 i) 권리범위확인심판은 침해소송과 같이 침해금지청구권이나 손해배상청구권의 존부와 같은 분쟁 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 기속력을 미치는 것도 아니지만(대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결의 다수의견에 대한 보충의견 등 참조), 간이하고 신속하게

34) 김철환, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 754면.

35) 김철환, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 728면.

확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가지고 있다는 점(권리범위확인심판 제도의 성질과 기능), ii) 제164조는 심판과 소송절차 중 어느 한 절차를 중지할 수 있다고 규정되어 있는데 이는 특허법이 권리범위확인심판과 소송절차를 각 절차의 개시 선후나 진행경과 등과 무관하게 별개의 독립된 절차로 인정됨을 전제로 규정하고 있다는 점(특허법 제164조의 규정내용과 취지) 등을 고려하였을 때, 심판의 이익을 긍정하고 있다. 한편 소극적 권리범위확인심판은 실시하고 있는 제품뿐만 아니라 실시할 가능성이 있는 제품을 특정하여 청구할 수 있는데, 실시할 가능성이 있는 제품을 특정하여 심판청구를 한 후 인용심결을 받아서 침해소송에 증거로 제출함으로써 재판부를 기망하고자 할 수도 있으므로, 특허심판원에서는 심결문에 실제 실시하고 있는 제품인지 아니면 실시할 가능성이 있는 제품 인지를 기재하여 이러한 악용을 방지하고 있다.

3. 관 할

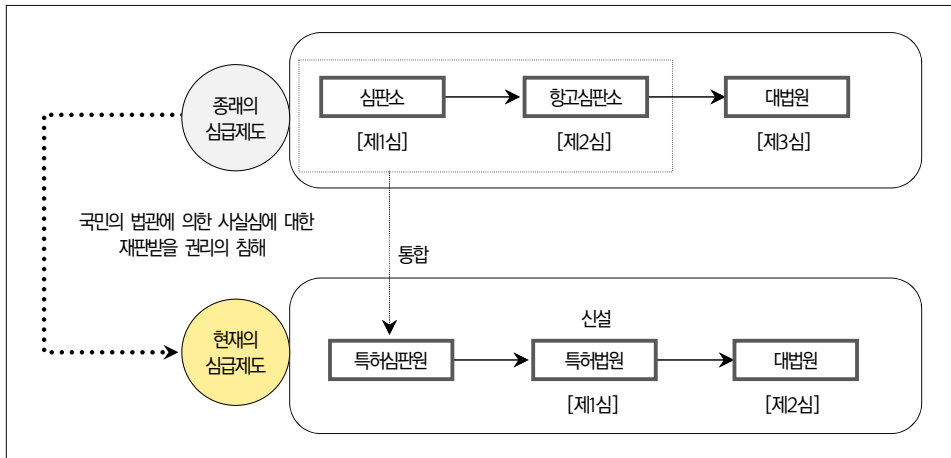
(1) 심급관할

1998년 3월 1일부터 고등법원급의 전문법원인 특허법원이 설치되고, 지식재산처의 항고심 판소와 심판소를 통합한 특허심판원이 설치됨으로써, 지식재산처 내에서의 2단계 심판은 1단계로 줄어들고, 특허심판원의 심결에 대한 불복의 소는 특허법원의 전속관할로 하고, 특허법원의 판결에 대한 불복은 대법원에 상고하게 되었다.³⁶⁾ 이 경우 특허심판원의 심결은 재판이 아니기 때문에 특허법원이 제1심이 되고, 특허법원의 소송절차와 지식재산처의 심판절차 사이에 심급관계가 있는 것은 아니다.³⁷⁾ 따라서 특허소송에 관하여는 특허법원 → 대법원으로 이루어지는 2심제가 채택되었다.³⁸⁾ 특허사건에 대하여 그 지위가 고등법원급인 특허법원이 1심인 이유는 준사법기관인 지식재산처의 심판을 거쳤는데 이를 다시 지방법원의 관할로 하고 그 위에 2심, 3심을 거치게 하는 것은 소송경제의 면에서 바람직하지 않기 때문이다.

36) 종전의 특허심판제도는 지식재산처 내의 심판소와 항고심판소에서 1심과 2심이 이루어지고 상고심만 대법원에서 이루어지고 있었는데, 이에 대하여 헌법상의 3권분립의 원칙(헌법 101) 위반 및 사실심에 관한 국민의 법관에 의한 재판을 받을 권리(헌법 27①)의 침해를 이유로 헌법소원이 제기된 바 있고, 이에 대하여 헌법재판소는 헌법불합치결정(1995. 9. 28, 선고 92헌가11, 93헌가8,9,10(병합))을 선고하였다. 그 결과 특허심판제도의 개혁을 위하여 법원조직법을 개정(1994. 7. 27. 법률 제4765호, 1998. 3. 1. 시행)하게 되었다.

37) 다만 일반행정소송은 제1차적 처분 자체를 심판의 대상으로 하는 것이지만 특허소송은 그 처분의 대상이 제1차적 처분이 아닌 심결이라는 제2차적 처분을 그 대상으로 하고 있고, 제2차적 처분인 심결이 준사법적 절차를 거친 것이라는 점에서 비록 소송법적 심급관계는 아니더라도 실질적으로 항소심적 성격을 강하게 지니게 된다(사법연수원, 「특허법」, 2001, 290면).

38) 법원행정처, 「특허소송실무」, 1998, 8면.



【그림 8-1】 심급 제도의 변화

(2) 전속관할

1) 「전속관할」이란 재판의 적정·공정 등 고도의 공익적 요구에 기하여 특정법원만이 배타적으로 관할권을 갖게 한 것을 말한다. 특허법원은 i) 제186조제1항, 실용신안법 제33조, 디자인보호법 제166조제1항 및 상표법 제85조의3제1항에서 정하는 제1심 사건과, ii) 민사소송법 제24조제2항 및 제3항에 따른 사건의 항소사건 및 iii) 다른 법률에 따라 특허법원의 권한에 속하는 사건³⁹⁾을 담당한다(法院組織法 28의4). 제186조제1항은 “특허취소결정 또는 심결에 대한 소 및 특허취소신청서·심판청구서·재심청구서의 각하결정에 대한 소는 특허법원의 전속관할로 한다”라고 규정하고 있다.

2) 한편 2016년 1월 1일부터는 지식재산권(특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 품종보호권) 침해 민사본안소송의 관할을 1심은 고등법원 소재지가 있는 6개 지방법원(서울중앙지방법원, 대구지방법원, 대전지방법원, 광주지방법원, 부산지방법원, 수원지방법원)이 전속적으로 맡고, 2심은 특허법원으로 집중하게 되도록 민사소송법(제24조, 제36조) 및 법원조직법(제28조, 제28조의4, 제32조)이 개정되었다.⁴⁰⁾ 기존에는 침해소송의 1심을 58개 지방법원과 지원에서, 2심을 고등법원과 지방법원 항소부에서 맡는 한편 심결취소소송을 특허법원에서 맡고 있어서

39) 식물신품종보호법에 의한 품종보호심판위원회의 심결 등에 대한 취소소송 외에 다른 법률에 의하여 특허법원의 권한에 속하는 사건은 없다.

40) 다만 위와 같이 전속관할이 정해져 있는 지식재산권 침해소송의 경우에도 현저한 손해 또는 지연을 초래할 우려가 있는 경우에는 관할법원의 직권 또는 당사자의 신청에 따른 결정으로 소송의 전부 또는 일부를 지방법원으로 이송할 수 있도록 하여 소송수행의 편의성과 접근성 등 소송당사자의 재판받을 권리를 보장하고 있다.

관할이 분산되어 있었다. 이번 개정은 특허소송의 관할을 특허법원으로 집중해 특허권 등의 분쟁 해결에 있어 법원의 전문성, 효율성 및 신속성을 제고하는 한편 소송당사자에게 보다 신속하고 전문적인 재판을 보장함으로써 지식재산권 보호의 실효성을 높이고자 하는 취지를 담고 있다.⁴¹⁾

3) 다만 통상실시권 허락의 심결에서 정한 대가의 심결 및 심판비용의 심결 또는 결정에 대해서는 독립하여 특허법원에 의한 소를 제기할 수 없다(法 186⑦). 구체적으로 대가의 심결만 불복하고자 할 때는 특허법원이 아닌 별도의 민사법원에 소를 제기하여야 하고(法 190), 심판비용의 심결 또는 결정은 원심결과 함께 불복할 수 있고, 독립하여 특허법원에 소를 제기할 수 없다.

Ⅲ. 시 기

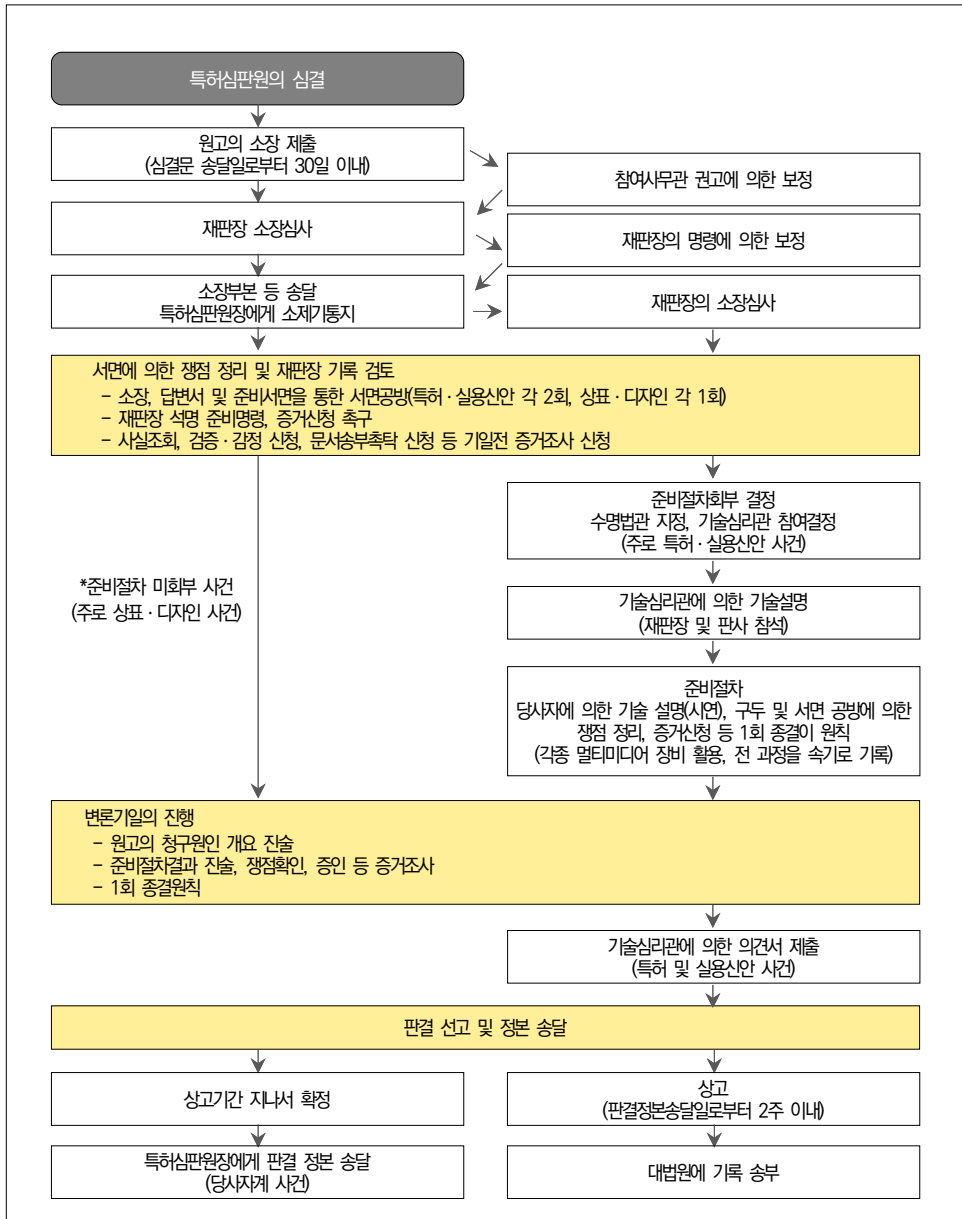
특허법원에 소를 제기하려는 자는 심결 또는 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 소장을 특허법원에 제출하여야 한다(法 186③). 이 기간은 불변기간이지만 심판장은 심결 또는 결정등본을 송달할 때 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자를 위하여 직권으로 1개월 범위에서 부가기간을 정할 수 있다(法 186④⑤). 다만 제소기간의 연장을 위한 부가기간의 지정은 제소기간에 이루어져야만 효력이 있고, 단순히 부가기간지정 신청이 제소기간에 있었다는 점만으로는 불변기간인 제소기간이 당연히 연장되는 것이라고 할 수 없다.⁴²⁾⁴³⁾

41) 대법원 2019. 4. 10.자 2017마6337.

42) 대법원 2008. 9. 11. 선고 2007후4649.

43) 법정기간의 연장과 부가기간을 비교하면 다음과 같다.

구 분	법정기간의 연장(法 15①)	부가기간(法 186⑤)
주 체	■ 지식재산처장	■ 심판장
대 상	■ 거절결정불복심판(法 132의17)	■ 심결취소의 소 제기기간(法 186③)
사 유	■ 1회 연장은 30일 이내에서 사유 무관 (단, 도서·벽지 등 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 총리령으로 정하는 바에 따라 그 횟수 및 기간을 추가로 연장)	■ 주소 또는 거소가 멀리 떨어진 곳에 있거나 교통이 불편한 지역에 있는 자
방 법	■ 신청 또는 직권	■ 직권



【그림 8-2】 심결취소소송의 절차

제3절 소송의 제기

I. 소장의 제출

당사자가 소장을 특허법원에 제출하여 소를 제기함으로써 심결취소소송이 개시된다.

II. 특허심판원장에게 통지

법원은 심결취소소송 또는 상고가 제기되었을 때에는 지체 없이 그 취지를 특허심판원장에게 통지하여야 한다(法 188①). 심결이 확정되면 지식재산처장은 확정심결을 등록하고, 또 심결의 내용에 따라 소멸변경 등의 등록을 하지만, 소가 제기되면 심결의 확정이 차단된다. 따라서 법원은 소가 제기되었거나 상고가 있는 경우에는 지식재산처에서 확정심결의 등록절차가 행하여지는 것을 중지시키기 위해 심결이 미확정이라는 취지의 통지를 특허심판원장에게 하고 있다.⁴⁴⁾

제4절 소송의 심리

I. 소장의 심사

소장의 필요적 기재사항을 심사하여 당사자, 법정대리인, 청구의 취지 및 청구원인의 불비가 있으면 보정을 명하고, 보정기간에 그 흠결을 보정하지 아니한 경우에는 재판장은 명령으로 그 소장을 각하하여야 한다. 소장에 필요한 인지를 첨부하지 아니한 경우에도 마찬가지이다.

II. 소송요건의 심리

「소송요건의 심리」는 해당 소가 소송요건을 갖춘 적법한 것인지를 심리하는 것을 말한다. 심리의 결과, 특허소송의 제기요건을 갖추지 못한 것이라고 인정되는 때에는 판결로서 각하한다. 소송요건은 법원의 직권조사사항이다. 소송요건의 존부를 판정하는 기준시점은 원칙적으로 변론종결 시이다. 따라서 제소 당시에는 소송요건이 부존재하여도 변론종결 시까지 이를 갖추면 된다. 다만 제소기간의 준수 여부는 제소 당시를 기준으로 판단한다.

44) 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007, 1004면.

III. 본안심리

1. 서

소송요건을 갖춘 것이라고 인정되면 본안심리에 들어가게 되는데, 본안심리는 원고의 청구를 인용할 것인지 아니면 기각할 것인지를 판단하기 위하여 사건의 본안, 예컨대 심결의 위법 여부를 원·피고의 공격·방어와 이에 대한 증거조사를 통하여 실제로 심사하는 것이다. 한편 특허소송은 제1심에 해당하므로 특허심판과 관련하여 밟는 절차가 당연히 특허소송에서 효력을 갖는 것은 아니다. 예를 들면 특허무효심판에서 청구인이 비록 그 특허를 무효로 하는 심결을 받았다 하더라도 피청구인이 심결취소의 특허소송을 제기한다면 피고 즉 청구인은 다시 이 건 특허발명의 신규성이나 진보성 등의 무효사유를 주장하고 증명하여야 한다.

2. 변론주의의 원칙

1) 일반 민사소송과 마찬가지로 처분권주의, 변론주의가 적용되어 공개심리주의, 쌍방심리주의, 구술심리주의에 의하여 당사자가 판결의 기초가 될 소송자료를 제출하는 방법으로 소송절차를 진행하지만, 행정소송은 공익과 관련이 있으므로 경우에 따라 법원이 개입하여 실제적 진실을 밝혀내어 적절한 재판이 되도록 하는 것이 필요하므로, 행정소송법 제26조는 “법원은 필요하다고 인정할 때에는 직권으로 증거조사를 할 수 있고, 당사자가 주장하지 아니한 사실에 대하여도 판단할 수 있다”라고 규정하여 직권심리주의를 인정하고 있다.

2) 대법원⁴⁵⁾은 이와 관련하여 “이는 행정소송의 특수성에 연유하는 당사자주의, 변론주의에 대한 일부 예외규정일 뿐 법원이 아무런 제한없이 당사자가 주장하지 아니한 사실을 판단할 수 있는 것은 아니고, 일견 기록에 현출되어 있는 사항에 관하여서만 직권으로 증거조사를 하고 이를 기초로 하여 판단할 수 있을 따름이고, 그것도 법원이 필요하다고 인정할 때에 한하여 청구범위에서 증거조사를 하고 판단할 수 있을 뿐이다”라고 하여 직권심리의 범위를 한정적으로 인정함으로써 원칙적으로 직권탐지주의를 채택한 것은 아니고, 직권증거조사도 보충적으로만 인정하고 있는 것이라는 취지로 판시하고 있다. 구체적인 사례로는 i) 당사자가 주장하지 아니하였고 기록상 그러한 자료가 나타나 있지 아니한 사실에 대하여 심리·판단할 의무가 없다는 사례(대법원 1995. 2. 24. 선고 94누9146; 2011. 3. 24. 선고 2010후3509), ii) 기록상 자료가 나타나 있으면 당사자가 주장하지 아니하였더라도 판단할 수 있다는 사례(대법원 2001. 1. 19. 선고 99두967; 2010. 1. 28. 선고 2007후3752 등)가 있다.⁴⁶⁾ 한편 변론종결 후 제출된 참고자료는 기록에 나타난 자료에 포함되지 아니한다.⁴⁷⁾

45) 대법원 1995. 2. 24. 선고 94누9146; 1994. 10. 11. 선고 94누4820 등.

46) 최성준, 「특허법 주해II」(정상조·박성수 共編), 박영사, 2010, 809-811면.

47) 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후436.

3. 위법판단의 기준시점

1) 항고소송에 있어서 소송의 대상인 처분의 위법성을 어느 시점의 법규와 사실 상태를 기준으로 할 것인지에 관하여 처분시설과 판결시설이 대립하고 있으나 통설과 판례⁴⁸⁾는 처분시설을 취하고 있다.⁴⁹⁾ 따라서 심결취소소송에서도 심결의 위법 여부는 심결 당시의 법령과 사실 상태를 기준으로 판단하여야 하고, 원칙적으로 심결이 있는 이후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 하여서는 아니 된다.⁵⁰⁾ 예컨대, 심결 시 이후에 발생한 확인대상발명의 특허등록사실을 고려하여 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 위법 여부 판단의 근거로써 활용될 수 없다. 즉 심판계속 중 확인대상발명이 등록된 경우에는 특허권(실용신안권) 사이의 저촉관계를 확인하는 적극적 권리범위확인심판은 부적법한 것으로 되지만, 인용심결이 있는 후에 그 심결에 대한 취소소송 계속 중에 확인대상발명이 등록된 경우에는 그 심판 자체가 부적법한 것으로 되는 것은 아니게 된다.⁵¹⁾ 이 경우 특허법원에서 심결의 위법성 여부에 대한 실체판단 후 심결이 위법하면 그 심결을 취소환송하게 되고, 심판원에서 심판청구를 심결각하하게 된다. 만약 심결이 위법하지 않으면 기각판결을 하게 되고 그 결과 최종적으로 심판원의 인용심결이 확정될 수 있다. 이는 의도치 않게 특허권 사이의 저촉관계를 확인하는 적극적 권리범위확인심판의 인용심결이 확정된 경우로서 어쩔 수 없는 상황이라 할 것이다. 다만 적극적 권리범위확인심판을 기각하는 심결인 경우에 소의 이익을 긍정할 것인지에 대하여 소의 이익이 부정된다고 하면 기각심결이 확정되는데, 기각심결이 일사부재리의 효력을 갖게 되어 더 이상 다룰 수 없게 되는 문제가 발생하므로, 소의 이익이 긍정된다는 견해⁵²⁾가 있으나, 특허법원⁵³⁾은 단순히 각하되어야 할 것이 기각된 것에 불과하여 심결취소를 구할 법률상 이익이 인정되지 아니하여 소의 이익이 부정된다는 입장이다.

2) 여기서 심결 시라고 하는 의미는 심결 후의 법령의 개폐나 사실 상태의 변동에 영향을 받지 아니한다는 뜻일 뿐이다. 즉 심결 당시의 사실 상태에 대한 증명은 심결취소소송의 변론종결 당시까지 할 수 있으며, 법원은 심결 시까지 제출된 자료뿐만 아니라 변론종결 시까지 제출된 모든 자료를 종합하여 심결 당시 존재하였던 객관적 사실을 확정하고 그 사실에 기초하여 처분의 위법성 여부를 판단할 수 있다.⁵⁴⁾ 그러나 위법판단의 기준시점과 소의 이익의 문제는 서로 구분되어야 하는 것으로서, 심결 이후라도 소의 이익이 없어진 경우에는 소각하 판결을 하여야 한다. 예를 들어 특허를 무효로 한 심결에 대한 심결취소소송에서 원고의 청구가 기각되어 상고심에 계속 중, 제3자가 제기한 특허무효심판에서 특허를 무효로 하는 심결이 확

48) 대법원 1987. 8. 18. 선고 87누235; 1996. 12. 20. 선고 96누9799; 2002. 10. 25. 선고 2002두4464.

49) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 33면.

50) 대법원 1995. 11. 10. 선고 95누8461; 2002. 4. 12. 선고 99후2211; 2004. 11. 12. 선고 2003후1420 등.

51) 대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2211.

52) 심준보, 「특허법원 판례(특허·실용신안) 및 심결취소소송의 개요」, 특허심판원, 2009년 5월, 127면 참조.

53) 특허법원 2008. 7. 9. 선고 2007허13896.

54) 특허법원 1999. 4. 22. 선고 98허9567; 1999. 6. 18. 선고 99허1836 등 참조.

정되었을 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 존재하지 아니한 특허를 대상으로 판단한 심결은 위법하게 되나, 특허가 무효로 확정된 이상 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌기 때문에 소각하된다.⁵⁵⁾

4. 심리범위

(1) 문제의 소재

특허법원의 심리범위가 어느 정도까지 인정되는가에 대해서는 명문의 규정이 없어서 문제이다. 예컨대 특허소송에 있어서 심판단계에서 주장한 거절이유 또는 무효사유와 다른 사유가 주장되고 이 주장을 증명하기 위한 새로운 증거가 제출될 때 이를 어떻게 취급할 것인가의 문제이다. 이에 대해서는 소송단계에서 새로운 주장과 증거도 심리범위에 포함된다는 학설(이를 「무제한설」이라 함)⁵⁶⁾과 심판단계에서 다루었던 사항에 한정된다는 학설⁵⁷⁾이 있다.

(2) 판례의 태도

① 무제한설의 채택

권리범위확인심판의 심결취소소송,⁵⁸⁾ 무효심결의 취소소송⁵⁹⁾ 등 다수의 판례의 태도는 “심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있

55) 대법원 2001. 5. 8. 선고 98후1921.

56) 심결취소소송의 소송물은 심결에 존재하는 위법성 일반으로 파악하여 행정처분에 대한 항고소송과 마찬가지로 사실심리의 범위에 대한 제한이 없고, 당사자는 심결에 포함되지 않았던 일체의 위법사유를 주장·증명할 수 있고, 법원도 이를 채용하여 판결의 기초로 할 수 있으며, 새로운 증거를 포함한 일체의 증거를 제출할 수 있다는 견해이다(本間崇 審判と 審決取消訴訟の 關係, 日本工業所有權法學會 年報 제6호, 1983, 126면 이하 참조).

57) 제한설은 i) 실질적 증거에 의한 사실인정이라고 판단되는 한 법원은 심결의 사실인정에 구속되기 때문에 소송절차에서 새로운 증거를 제출하는 것은 허용되지 아니한다는 실질적 증거법칙설(兼子一, 審決の 司法審査, 訴訟と 裁判, 457면 이하), ii) 심결취소소송의 형태를 심판에 대한 속심적 구조로 보는 견해와 그 기초를 같이하는 것으로서 법조가 규정하고 있는 특정한 거절이유 또는 무효사유의 범위를 넘어서 심판에서 쟁점이 되지 않았던 다른 법조에 규정된 거절이유 또는 무효원인에 관해서는 심리를 할 수 없고 동일한 법조의 범위에서라면 새로운 주장도 새로운 증거제출도 인정된다는 동일법조설(失野邦雄, 「最高裁判所判例解説 民事篇(上)」, 日本法學會, 1968, 335면), iii) 심결의 이유에서 판단이 된 주장과 증거만 법원이 심리할 수 있다는 견해로서 무효심결의 취소소송에 있어서 특허법에 규정된 무효사유는 추상적으로 열거하고 있을 뿐이고, 각 무효원인은 그 성질과 내용을 달리 하는 것이므로 법조문이 같다 하여도 각각 별개 독립의 무효원인으로 보아야 하고, 제163조에서 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 동일사실과 동일증거에 의하여 한정되고 있는 점과 관련하여 볼 때 취소소송의 심판범위도 심판에서 다루어진 구체적인 공지기술의 범위에 한정되어야 하고, 그것을 보충하는 주장·증명은 가능하지만, 심판에서 판단되지 아니한 새로운 주장 및 증거의 제출은 허용되지 아니한다는 동일사실·동일증거설(高林克巳, 「特許訴訟との理論と 實務」, 社團法人 發明協會, 1991, 147면) 등이 있다.

58) 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410.

59) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1306.

고, 심결취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있으며, 이와 같이 본다고 하여 심급의 이익을 해한다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다”라고 판시하여 무제한설을 채택하고 있다.

② 결정계 심판의 심결과 특허취소결정에 대한 취소소송의 경우

1) 거절결정불복심판의 기각심결에 대한 심결취소소송과 관련하여, 대법원 2013. 9. 26. 선고 2013후1054 판결은 “특허출원에 대한 심사단계에서 거절결정을 하려면 그에 앞서 출원인에게 거절이유를 통지하여 의견제출의 기회를 주어야 하고, 거절결정에 대한 특허심판원의 심판절차에서 그와 다른 사유로 거절결정이 정당하다고 하려면 먼저 그 사유에 대해 의견제출의 기회를 주어야만 이를 심결의 이유로 할 수 있다(특허법 제62조, 제63조, 제170조 참조). 위와 같은 절차적 권리를 보장하는 특허법의 규정은 강행규정이므로 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들어서 거절결정이 결과에 있어 정당하다는 이유로 거절결정불복심판청구를 기각한 심결은 위법하다. 같은 취지에서 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서도 지식재산처장은 심사 또는 심판단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 지식재산처장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다”라고 하면서, 지식재산처장이 심사 또는 심판단계에서 의견제출기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 들면서 특허거절결정 및 기각심결이 정당하다고 주장할 수 없다고 판시하였다. 이는 특허법원에서는 심사 또는 심판단계와 달리 의견제출기회를 주어 출원인의 의견서나 보정서를 제출할 수 있는 절차가 없는데, 지식재산처장이 새로운 거절이유를 주장할 수 있다면 그 거절이유에 대한 출원인의 의견서나 보정서를 제출할 수 있는 기회를 박탈당하는 결과가 되기 때문이다. 다만 지식재산처장이 거절결정의 이유가 아닌 심사나 심판단계에서 의견제출기회를 부여한 사유 및 이와 주요한 취지가 부합하는 사유를 해당 심결의 결론을 정당하게 하는 사유로 주장한다면 출원인의 절차적 권리를 보장하였기 때문에, 심결취소소송의 법원은 이를 심리·판단하여 심결의 당부를 판단하는 근거로 삼을 수 있다.⁶⁰⁾

2) 한편 대법판결은 “다만 거절결정불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 지식재산처장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것 이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다”라고 판시하고 있다. 예를 들어 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술

60) 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997.

의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택할 수 있는 것이다.⁶¹⁾ 다만 주지관용기술이라고 할지라도 비교대상발명을 보충하는 자료가 아니라면 주장이 허용되지 아니한다.⁶²⁾

3) 그러나 법원은 특허거절결정을 유지한 심결의 위법성 여부를 판단하는 것일 뿐 특허출원에 대하여 직접 특허결정 또는 특허거절결정을 하는 것은 아니다. 따라서 심사관이 특허출원의 보정에 대한 각하결정을 한 후 「보정 전의 특허출원」에 대하여 거절결정을 하였고, 그에 대한 불복심판 절차에서 위 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 심판청구를 기각하는 특허심판원의 심결이 있었던 경우, 그 심결취소소송에서 법원은 위 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 「보정 이후의 특허출원」에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니다.⁶³⁾ 즉 법원이 행정권을 행사하여 직접 특허여부결정을 하는 삼권분립의 원칙에 반한다고 할 수 있으며, 보정 이후에 특허출원에 대하여 거절결정의 위법성 여부를 판단하는 것은 출원인의 의견서 또는 보정서 제출기회를 박탈하는 결과를 초래하기 때문이다.

4) 한편 지식재산청가 출원인의 명세서 등에 대한 보정을 각하할 때는 특허거절결정의 경우와 달리 그 결정 이전에 출원인에게 의견제출기회를 주지 않아도 되므로(法 63①단서), 심결취소소송 단계에 이르러 지식재산청가 보정각하결정이나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 사유를 내세워 보정이 부적법함을 주장하더라도 출원인으로서의 이에 대응하여 소송절차에서 그 심리의 방식에 따라 충분히 그 다른 사유와 관련하여 보정의 적법 여부에 대하여 다툴 수 있으므로 출원인의 방어권 또는 절차적 이익이 침해된다고 할 수 없어, 지식재산청은 특허거절결정에 대한 심결취소소송 단계에서 보정각하결정에 부치거나 심판절차에서 다루지 아니한 다른 이유를 들어 보정의 부적법을 주장할 수 있다.⁶⁴⁾⁶⁵⁾

61) 심결취소소송절차에서는 주지관용기술이 소송상 공지 또는 현저한 사실이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있지 아니한 경우에 증명을 필요로 한다(변론주의 원칙). 다만 법원은 자유로운 심증에 의하여 증거 등 기록에 나타난 자료를 통하여 주지관용의 기술을 인정할 수 있으나(직권주의 가미), 변론종결 후 제출된 참고자료까지 여기의 증거 등 기록에 나타난 자료에 포함된다고 볼 수는 없다(대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후436 참고).

62) 특허법원 2015. 1. 22. 선고 2014허4449.

63) 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121. 이는 i) 명세서 등의 보정은 명세서 등의 서류에 흠결이 있거나 불비한 점이 있는 경우에 이를 명료하게 정정하여 명세서 등의 명확화를 기하기 위한 것으로서 보정의 시기와 내용에 일정한 제한을 부가하는 것을 전제로 하여 출원인의 선출원의 이익을 도모하려는 제도이므로 보정된 명세서 등에 기재된 발명에 대하여 심사 및 심판을 받을 출원인의 이익을 침해하거나 보정에 대한 적법한 심판절차를 회피하는 해석을 할 수는 없는 점, ii) 보정에 대한 판단을 생각하는 상태를 용인하는 것은 명세서 보정의 제도적 의의를 잠탈하는 결과를 초래할 수 있는 점을 고려한 것이다.

64) 특허법원 2007. 7. 11. 선고 2006허9197; 2009. 4. 24. 선고 2008허11064; 2009. 4. 2. 선고 2008허3452 등.

65) 다만 사견으로는 심결취소소송에서 지식재산청장이 보정각하사유와 다른 사유를 들어서 보정각하가 타당하다고 주장하는 것은 출원인의 분할출원, 분리출원할 수 있는 기회를 박탈하는 것으로서 적절하지 않다고 여겨진다. 기존과 달리 현행법에서는 거절결정등본송달일로부터 3개월 이내 분할출원할 수 있도록 하는

5) 정정심판의 기각심결에 대한 심결취소소송과 관련하여 대법원 2019. 7. 25. 선고 2018 후12004 판결은 “실용신안법 제33조에서 준용하는 특허법 제136조 제6항은 정정심판에서 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여함으로써 정정심판청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지한다는 공익상의 요구에 기인하는 강행규정이다. 따라서 정정심판이나 그 심결취소소송에서 정정의견제출 통지서를 통하여 심판청구인에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없는 사유를 들어 정정심판청구를 기각하는 심결을 하거나, 심결취소청구를 기각하는 것은 위법하다. 특히 정정심판을 기각하는 이유가 선행고안에 의하여 고안의 진보성이 부정된다는 취지라면 지식재산처장이 취소소송절차에 이르러 비로소 제출한 자료들은, 선행고안을 보충하여 출원 당시 해당 고안과 동일한 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술을 증명하기 위한 것이거나, 정정의견제출 통지서에 기재된 선행고안의 기재를 보충 또는 뒷받침하는 것에 불과한 경우라고 인정될 때 판단의 근거로 삼을 수 있다”라고 하여 출원인의 의견서제출기회(또는 정정한 명세서 또는 도면의 재보정 기회)를 박탈하지 않기 위해 지식재산처장이 새로운 정정불인정 사유를 들면서 기각심결이 정당하다고 주장할 수 없다고 판시하였다.

6) 한편 특허취소결정에 대한 취소소송과 관련하여 아직 대법원 판결례는 찾아볼 수 없으나 피고인 지식재산처장이 특허취소결정 당시 취소신청이유로 삼지 아니한 새로운 사유를 주장할 수 있다면 특허권자는 새로운 취소신청이유에 대하여 의견서를 제출하거나 정정청구를 할 수 있는 기회를 박탈당하는 결과가 되므로, 이를 제한함이 바람직할 것이다.

(3) 소 결

1) 심리범위에 대한 문제는 특허심판원의 선행판단 없이도 특허법원이 충분하고도 적절한 기술적 판단을 할 수 있는지에 대한 시각에서 비롯된다고 할 수 있다. 특허법원의 기술판단능력에 대하여 충분히 신뢰하면 법원의 심리범위에 대하여 제한을 두지 아니함으로써 쓸데없는 절차의 반복이나 지연을 방지하여 신속한 재판의 이점을 살리려 할 것이고, 그렇지 못하면 가급적 심리범위를 제한하여 특허심판원의 판단을 먼저 받아보도록 하는 입장에 서게 될 것이다.⁶⁶⁾ 그런데 특허법원에는 기술분야에 대한 전문성을 보좌하기 위하여 기술심리관제도를 두고 있으므로 기술적 난이도를 이유로 소송단계에서 소송관계인에게 새로운 공격방어방법을 사용하지 못하도록 제한하는 것은 국민의 사실심에 관한 법관에 의한 정당하고 신속한 재판을 받을 권리를 침해하는 결과가 되어 오히려 특허법원의 설립취지에 반한다고 할 것이다. 또한 심판은 지식재산처에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적, 절차적 위법성 여부라 할 것이

한편(法 51①Ⅲ), 2022. 4. 20. 시행된 현행법(법률 제18505호, 2021. 10. 19. 일부개정)에서는 거절결정불복심판청구가 기각된 경우 그 심결의 등본을 송달받은 날부터 30일(제186조제5항에 따라 심판장이 부가기간을 정한 경우에는 그 기간을 말한다) 이내 분리출원할 수 있도록 하여(法 52의2①) 출원인의 절차적 이익을 보호해 주고 있기 때문이다.

66) 이재환, 심결취소소송의 심리범위, 정보법판례백선(1), 박영사(2006), 713면.

어서 심결취소소송의 법원은 그 사실심리에 아무런 제한없이 스스로 심리하여 판결할 수 있다 할 것이다. 따라서 특허법원에서의 심리에 어떠한 제한을 가할 합리적인 이유가 없으며, 무제한설을 채택함이 타당하다. 다만 무제한설에 의하더라도 동일한 소송물의 범위에서 새로운 공격방어방법만을 추가할 수 있을 뿐이다. 예를 들어 특허무효심판에서 주장하지 않았던 새로운 청구항에 대한 무효를 주장하는 것은 허용될 수 없다.⁶⁷⁾

2) 한편 결정제 심판의 심결과 취소결정에 대한 취소소송에서는 출원인 또는 특허권자에게 불리한 처분을 하기 전에 의견제출기회(法 63, 170, 136⑥, 132의13②)를 주어 절차적 대응 기회(보정, 정정)를 확보해 주는 것이 강행규정이기 때문에, 그러한 의견제출기회를 주지 않는 채 소송단계에서 지식재산처장의 새로운 주장을 제한하는 것으로 이해된다. 한편 이에 대해서 결론론적으로 지식재산처장이 새로운 주장을 하지 못하기 때문에 심리범위가 제한된다고 설명할 수도 있으나(제한설), 심리범위는 무제한이되 강행규정에 위반되지 않기 위해서 지식재산처장의 주장에 제한을 가하고 있다고 설명하는 것이 더 적절해 보인다.

5. 주장 · 증명책임

(1) 서

심결취소소송과 같은 행정소송에 있어서 주장 · 증명책임⁶⁸⁾의 분배에 대하여 민사소송과 같이 법률요건분류설에 입각하고 있다.⁶⁹⁾ 법률요건분류설이란 객관적인 법규의 구조 즉 조문의 형식이나 관계조문의 상호관계 속에서 증명책임 분배의 기준을 찾으려는 견해로서, 법률요건 분류설에 의하면 각 당사자는 자기에게 유리한 법규의 요건사실의 존부에 대해 증명책임을 지게 된다. 이에 따르면 실체법규를 일정한 권리발생을 규정한 권리근거규정과 그 권리발생을 방해하는 권리장애규정 및 권리의 소멸사유를 규정한 권리소멸규정으로 나누어, 권리의 존재를 주장하는 자는 권리근거규정의 요건사실을, 그 부존재를 주장하는 자는 권리장애규정과 권리소멸규정의 요건사실을 증명하여야 한다.

(2) 특허발생요건과 특허장애요건

① 특허발생요건

i) 산업상 이용할 수 있는 발명을 하였다는 사실(法 29①본문, 法 2 I), ii) 출원서에 첨부

67) 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006, 42면.

68) 「주장책임」이란 주요사실을 변론에서 주장하지 아니하면 없는 것으로 취급되어 유리한 법률효과의 발생이 인정되지 않을 당사자의 위험 또는 불이익을 말하며, 「증명책임」이란 변론종결 시에 이르러서도 판결의 기초가 되는 사실이 존재하는지 여부가 불분명한 경우에 그 사실이 존재하지 아니한 것으로 취급되어 판단을 받게 될 당사자 일방의 위험 또는 불이익을 말한다(송상현 · 박익환, 「민사소송법」, 박영사(2008), 543면).

69) 민사소송법의 규정이 준용되는 행정소송에 있어서 증명책임은 원칙적으로 민사소송의 일반원칙에 따라 당사자 간에 분배되고 항소소송의 성질에 따라 해당 적법을 주장하는 피고에게 그 적법사유에 대한 증명책임이 있다(대법원 1984. 7. 24. 선고 84누124).

된 명세서의 기재방법이 적법하다는 사실(法 42③-⑤), iii) 1발명 1출원이라는 사실(法 45), iv) 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니한 외국인일 때는 특허관리인이 선임되어 있다는 사실(法 5), v) 특허를 받을 수 있는 권리가 공유인 때는 다른 공유자 모두와 공동으로 출원한 사실(法 44), vi) 신규성상실사유(法 29①각호)가 있으면 이에 대한 예외사유(法 30①각호)가 존재한다는 사실 등은 특허발생요건에 해당한다.

② 특허장애요건

vii) 특허출원 전에 국내외에서 공지된 발명이라는 사실(法 29①각호), viii) 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제29조제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 발명이라는 사실(法 29②), ix) 특허출원 후 출원 공개 또는 등록공고된 선출원에 첨부된 원명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 발명인 사실(法 29③④본문), x) 선출원 발명과 동일한 사실(法 36①②③), xi) 해당 특허가 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명이어서 특허를 받을 수 없는 사실(法 32) 등은 특허장애요건에 해당한다.

③ 거절심결취소소송과 주장·증명책임

거절심결취소소송에 있어서, 심결의 거절이유가 위 i) 내지 vi)인 경우 처분장애요건이므로 i) 내지 v)의 사유가 있음을 원고가 주장·증명책임을 지고, 거절이유가 vii) 내지 xi)인 경우 처분발생요건이므로 vii) 내지 xi)의 사유가 있음을 이유로 지식재산처장이 주장·증명책임을 지고, 거절이유가 vi)인 경우 신규성상실사유에 대한 처분장애요건이므로 vi)사유가 존재함을 원고가 주장·증명책임을 진다.

④ 무효심결 또는 무효심판기각심결의 취소소송과 주장·증명책임

1) 무효심결의 경우에는 vii) 내지 xi)의 특허장애요건은 처분발생요건이므로 지식재산처에 대신하여 무효심판청구인(피고)이 주장·증명책임을 부담하고, i) 내지 vi)의 특허발생요건은 처분장애요건이므로 무효심판의 피청구인(원고, 특허권자)이 주장·증명책임을 부담한다.

2) 한편 무효심판기각심결의 경우에는 vii) 내지 xi)의 특허장애요건은 처분장애요건이므로 그 기각심결의 취소를 구하는 무효심판청구인(원고)이 주장·증명책임을 지고, i) 내지 vi)의 특허발생요건은 처분발생요건이므로 피청구인(피고)이 지식재산처를 대신하여 주장·증명책임을 부담한다.

(3) 거절이유통지 등의 결여

결정계 사건의 경우 심사관의 거절이유통지(法 63), 당사자계 사건의 경우 심판관이 직권으로 심리한 사항의 통지(法 159①)가 없는 때에는 심결취소사유가 되지만, 위 통지가 있었음의 주장·증명책임은 심결이 적법하다고 주장하는 측에 있다고 해석하여야 할 것이다. 따라서 결정계 사건의 경우에는 피고인 지식재산처장이 부담하고, 당사자계 사건의 경우(무효심결의 경우에 문제가 될 수 있다)에는 피고인 피청구인이 부담한다.

(4) 판단누락 등 심결에 나타나 있지 아니한 위법

무효심판청구에서 청구인이 주장한 여러 가지 무효사유 중 일부에 대하여 특허심판원이 판단을 누락하여 무효심판기각심결을 한 경우, 특허심판원이 당사자가 신청한 증거를 전부 각하하고 증명이 없다는 이유로 그 당사자에게 불리한 심결을 한 경우 등과 같이 심결 자체에 나타나 있지 아니한 판단누락, 심리미진 등의 위법을 취소사유로서 주장하는 경우에는 원고가 주장책임을 부담하고 피고가 증명책임을 부담한다고 보아야 할 것이다.

6. 자백과 자백간주

1) 특허심판원에서는 직권주의가 적용되므로 자백 또는 자백간주⁷⁰⁾가 인정되지 아니한다. 그러나 행정소송인 심결취소소송에서는 원칙적으로 변론주의가 적용되고, 따라서 자백 또는 자백간주도 인정되나, 자백의 대상은 사실이고 이러한 사실에 대한 법적 판단 내지 평가는 자백의 대상이 되지 아니한다.⁷¹⁾ 다만 어떤 개념이 사실개념인지 아니면 평가개념인지에 대한 구별은 쉽지 아니하다. 구체적인 예를 들면 특허발명과 확인대상발명의 동일 또는 균등 여부(대법원 2022. 01. 27. 선고 2019다277751), 신규성 또는 진보성이 있는지 여부(특허법원 2000. 3. 31. 선고 99허6640), 청구항의 해석(특허법원 2000. 9. 21. 선고 99허5654), 정정 요건에 해당하는 여부(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238)는 평가개념으로 보아 자백의 대상이 아니라고 한 반면, 특허발명의 진보성 판단에 제공되는 선행발명이 어떤 구성요소를 가지고 있는지 여부(대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905), 피심판청구인의 확인대상발명 실시 여부(특허법원 2012. 7. 26. 선고 2011허11255), 확인대상발명(피고 제품)이 어떤 구성을 가지고 있는지 여부(대법원 2022. 01. 27. 선고 2019다277751)는 사실개념으로서 자백의 대상이라고 보고 있다.

2) 사실에 대한 진술인지, 아니면 그 구성요소가 특허발명의 구성요소와 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술인지는 당사자 진술의 구체적 내용과 경위, 변론의 진행 경과 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 그리고 일단 재판상 자백이 성립하면 그것이 적법하게 취소되지 않는 한⁷²⁾ 법원은 이에 구속되므로 법원은 자백과 배치되는 사실을 증거에 의하여 인정할 수 없다.⁷³⁾

70) 「자백」이란 소송의 변론이나 변론준비절차에서 소송당사자가 상대방이 주장하는 사실과 일치하는, 자기에게 불리한 주요사실을 인정하는 진술을 말한다. 한편 「자백간주」란 상대방이 주장하는 사실을 자진하여 인정하지 않더라도, i) 변론에서 상대방이 주장하는 사실을 명백히 다투지 아니하거나, ii) 공시송달에 의하지 아니한 기일통지를 받고도 변론기일에 출석하지 아니하는 경우에는 그 사실을 자백한 것으로 보는 것을 말한다(民訴法 150).

71) 대법원 2000. 12. 12. 선고 2000후1542.

72) 진실에 어긋나는 자백은 그것이 착오로 말미암은 것임을 증명한 때에는 취소할 수 있다(民訴法 288).

73) 대법원 2022. 01. 27. 선고 2019다277751.

IV. 기술심리관의 관여

1. 의 의

특허법원은 기술분야에 대한 전문성을 보좌하기 위하여 기술심리관을 둔다(법원조직법 54의 2①). 법원은 필요하다고 인정하는 경우 결정으로 기술심리관을 제186조제1항의 소송의 심리에 참여하게 할 수 있으며, 소송의 심리에 참여하는 기술심리관은 재판장의 허가를 받아 해당 기술분야에 대하여 질문할 수 있고, 재판의 합의에 의견을 진술할 수 있다(법원조직법 54의 2②③). 그러나 기술심리관은 재판의 결론에 대한 의견을 개진할 수는 없고 기술적인 쟁점에 관하여 보고서 형태의 서면 등을 통하여 자신의 의견을 진술할 수 있을 뿐이며, 합의에서 의견을 진술하였다고 하더라도 판결에는 서명하지 아니한다.

2. 기술심리관의 제척·기피 및 회피

기술심리관도 엄격한 소송의 중립·공정성을 유지하기 위해 제척·기피의 대상이 된다. 따라서 제148조, 민사소송법 제42조 내지 제45조, 제47조 및 제48조의 규정⁷⁴⁾은 기술심리관의 제척·기피에 관하여 준용하며, 기술심리관에 대한 제척·기피의 재판은 그 소속법원이 결정으로 한다. 한편 기술심리관은 제척 또는 기피사유가 있다고 인정하면 특허법원장의 허가를 받아 회피할 수 있다(法 188의2).

74) 제42조[제척의 재판] 법원은 제척의 이유가 있는 때에는 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 제척의 재판을 한다.

제43조[당사자의 기피권] ① 당사자는 법관에게 공정한 재판을 기대하기 어려운 사정이 있는 때에는 기피신청을 할 수 있다.

② 당사자가 법관을 기피할 이유가 있다는 것을 알면서도 본안에 관하여 변론하거나 변론준비기일에서 진술을 한 경우에는 기피신청을 하지 못한다.

제44조[제척과 기피신청의 방식] ① 합의부의 법관에 대한 제척 또는 기피는 그 합의부에, 수명법관(受命法官)·수탁판사(受託判事) 또는 단독판사에 대한 제척 또는 기피는 그 법관에게 이유를 밝혀 신청하여야 한다.

② 제척 또는 기피하는 이유와 소명방법은 신청한 날부터 3일 이내에 서면으로 제출하여야 한다.

제45조[제척 또는 기피신청의 각하 등] ① 제척 또는 기피신청이 제44조의 규정에 어긋나거나 소송의 지연을 목적으로 하는 것이 분명한 경우에는 신청을 받은 법원 또는 법관은 결정으로 이를 각하(却下)한다.

② 제척 또는 기피를 당한 법관은 제1항의 경우를 제외하고는 바로 제척 또는 기피신청에 대한 의견서를 제출하여야 한다.

제47조[불복신청] ① 제척 또는 기피신청에 정당한 이유가 있다는 결정에 대하여는 불복할 수 없다.

② 제45조 제1항의 각하결정(却下決定) 또는 제척이나 기피신청이 이유 없다는 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다.

③ 제45조 제1항의 각하결정에 대한 즉시항고는 집행정지의 효력을 가지지 아니한다.

제48조[소송절차의 정지] 법원은 제척 또는 기피신청이 있는 경우에는 그 재판이 확정될 때까지 소송절차를 정지하여야 한다. 다만 제척 또는 기피신청이 각하된 경우 또는 종국판결(終局判決)을 선고하거나 긴급을 요하는 행위를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제5절 소송의 종료

I. 당사자에 의한 종료

1. 소의 취하

「소의 취하」란 원고가 제기한 소의 전부나 일부를 철회하는 법원에 대한 단독적 소송행위로서, 이에 의하면 소송계속이 소급하여 소멸되므로 소송이 종료된다. 소의 취하는 소의 전부나 일부에 대하여 할 수 있으므로 특허소송에서도 수 개의 청구항에 대하여 소송이 계속되고 있는 경우에 원고는 일부 청구항에 대하여 소를 취하할 수 있다.

2. 재판상 화해 및 청구의 포기·인낙 不可

1) 「재판상 화해」란 당사자 쌍방이 소송물인 권리관계의 주장을 서로 양보하여 소송을 종료시키기로 하는 합의를 말한다. 이 합의내용을 적은 조서를 화해조서라고 하며, 화해조서에 기재된 화해의 내용은 판결과 동일한 효력이 있다. 「청구의 포기」란 원고가 소송물에 대한 자기의 주장을 부정하고 그것이 이유 없다는 것을 스스로 인정하는 법원에 대한 일방적인 의사표시를 말하고, 청구의 인낙이란 피고가 원고의 소송상 청구가 이유있음을 자인하는 법원에 대한 일방적인 의사표시를 말한다. 조서에 기재되면 확정판결과 동일한 효력을 가지며 이에 의하여 소송이 종료된다.

2) 그러나 판결의 대세효가 있는 특허소송의 경우에는 재판상 화해 및 청구의 포기 또는 인낙은 인정될 수 없다고 봄이 타당하다.

II. 종국판결에 의한 종료

1. 심결 또는 결정의 취소

법원은 특허소송이 제기된 경우에 그 청구가 이유없을 때는 청구기각판결을 하며, 청구가 이유있다고 인정할 때는 판결로써 해당 심결 또는 결정을 취소하여야 한다(法 189①). 다만 법원이 자판하여 구체적인 행정처분의 판결을 내리는 것은 법원이 행정권을 행사하는 것이 되어 권력분립의 원칙에 반하므로 허용되지 아니한다. 예를 들면 특허를 무효로 하는 취지의 청구를 기각한 심결에 대한 소송에서 심결의 잘못이 발견된 경우, 법원은 특허를 무효로 하는 심결을 할 수 없고, 심결을 취소한다는 형성판결만을 할 수 있을 뿐이다. 즉 특허소송에 있어서는 자판하지 않고 특허심판원에 필요적으로 환송한다.

2. 확정된 판결의 효력

1) 특허법원의 심결취소소송에서 해당 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 심판관은 그 사건을 다시 심리하여 심결 또는 결정을 하여야 한다. 이 경우 판결에 있어서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(法 189②③). 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거가 제출되어 판결 취소의 기본이 된 이유와 모순되지 않는 범위 내에서 기속적 판단의 기초가 되는 주장이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다.⁷⁵⁾

2) 여기에서 「새로운 증거」란 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택·조사되지 아니한 것으로서 사실심 변론 종결 이후에 발생한 심결취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 한다.⁷⁶⁾ 예를 들어 새로운 거절이유나 무효사유에 의하여 다시 특허거절결정이나 무효심결을 할 수 있다.⁷⁷⁾

3) 취소된 심결이 행하여진 심판절차에서 채택·조사된 증거는 해당 법률의 규정이 정하는 바에 따라서 거절이유를 통지하고 이에 대한 의견서를 제출할 기회를 부여하고서 적법하게 채택·조사된 증거를 뜻하는 것으로 보아야 한다. 그렇지 않고 이와 달리 어떤 증거가 특허거절결정 또는 그에 대한 불복심판의 심결에 단순히 기재되어 있다는 점만을 들어서 그 증거를 취소된 심결이 행하여진 심판절차에서 채택·조사된 것으로 본다면, 그러한 증거는 나중에 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우에 특허심판원의 재심리 절차에서조차 이를 전혀 사용할 수 없게 되는 결과가 된다. 그런데 이러한 해석은 어떤 증거가 실제로는 독립된 증명력을 가지는 새로운 공지의 증거임에도 불구하고, 심판절차에서 이를 단순히 주지관용기술에 해당하거나 선행기술의 기재를 보충하는 정도의 증명력을 가지는 증거에 불과한 것으로 오인하고서 특허거절결정 또는 심결 시에 사전에 의견서 제출 기회 등을 부여하지 아니한 절차상의 잘못을 저질렀다는 사정만으로, 등록요건 등의 실제 판단에 결정적인 자료를 전혀 사용할 수 없게 배제함으로써, 결국 심판 및 소송의 적정을 해치는 해석이 되어 부당하므로 받아들일 수 없다.⁷⁸⁾⁷⁹⁾

75) 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007; 2021. 1. 14. 선고 2017후1830.

76) 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96.

77) 특허법원 2005. 7. 21. 선고 2005허2724; 2000. 12. 14. 선고 2000허976 등.

78) 특허법원 2007. 7. 20. 선고 2006허10548.

79) 한편 특허심판원으로서 심결취소판결이 확정되어 다시 심리하게 되었을 때는 심판절차에 관한 특허법 규정에 따라 심판청구인에게 새로운 증거를 제출할 수 있도록 기간을 부여하고, 새로운 증거가 제출되면 피청구인에게도 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 할 것이고, 만약 특허심판원이 심결취소판결확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들에게 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다(특허법원 2018. 1. 1. 선고 2018허4201).

3. 소송의 불복

(1) 재판서 정보의 송부

당사자계 심판의 불복에 대한 소에 관하여 소송절차가 완결되었을 때에는 지체없이 그 사건에 대한 각 심급의 재판서 정보를 특허심판원장에게 보내야 한다(法 188②). 다만 당사자계 심판에 대한 소송과 달리 특허취소신청, 결정계 심판에 대한 소송은 지식재산처장이 피고로 되므로 소송이 종료된 사실을 별도로 통지하지 아니하여도 알 수 있게 되므로 통지하지 아니한 것으로 하였다.

(2) 상 고

① 의의 및 성질

특허소송에 대하여 특허법원의 판결을 받은 자가 불복이 있으면⁸⁰⁾ 그 판결이 법령에 위반된 것을 이유로 대법원에 상고할 수 있다(法 186⑧).⁸¹⁾ 상고심은 원심의 사실인정을 전제로 재판하는 사후심이며, 특허소송의 판결에 대한 당부를 법률적 측면에서 심리하기 때문에 특허소송의 판결에 대한 불복은 그 판결이 법령에 위반된 것을 이유로 하는 경우에만 상고할 수 있다.

② 상고기간

특허법원의 판결에 불복하는 자는 판결이 송달된 날로부터 2주일 이내에 상고장을 원심법원인 특허법원에 제출하여야 한다.

80) 상소는 자기에게 불이익한 재판에 대하여 자기에게 유리하도록 그 취소·변경을 구하는 것이므로 전부 승소한 원심판결에 대한 상고는 상고를 제기할 이익이 없어 허용될 수 없고, 이 경우 비록 그 판결의 이유에 불만이 있더라도 역시 상고의 이익이 없다고 할 것이다(대법원 2009. 7. 23. 선고 2008후2770).

81) 상고는 판결에 영향을 미친 헌법·법률·명령 또는 규칙의 위반이 있다는 것을 이유로 드는 때에만 할 수 있다(民訴法 423).

제2장

보상금 또는 대가에 관한 불복의 소

제190조 【보상금 또는 대가에 관한 불복의 소】

- ① 제41조제3항·제4항, 제106조제3항, 제106조의2제3항, 제110조제2항제2호 및 제138조제4항에 따른 보상금 및 대가에 대하여 심결·결정 또는 재정을 받은 자가 그 보상금 또는 대가에 불복할 때에는 법원에 소송을 제기할 수 있다.
- ② 제1항에 따른 소송은 심결·결정 또는 재정의 등본을 송달받은 날부터 30일 이내에 제기하여야 한다.
- ③ 제2항에 따른 기간은 불변기간으로 한다.

[전문개정 2014.6.11.]

제191조 【보상금 또는 대가에 관한 소송에서의 피고】

제190조에 따른 소송에서는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 피고로 하여야 한다.

1. 제41조제3항 및 제4항에 따른 보상금에 대해서는 보상금을 지급하여야 하는 중앙행정기관의 장 또는 출원인
2. 제106조제3항 및 제106조의2제3항에 따른 보상금에 대해서는 보상금을 지급하여야 하는 중앙행정기관의 장, 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자
3. 제110조제2항제2호 및 제138조제4항에 따른 대가에 대해서는 통상실시권자·전용실시권자·특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자

[전문개정 2014.6.11.]

I. 서 설

1. 의 의

특허출원된 발명이 국방상 필요하여 비밀취급을 명하거나 특허하지 아니하거나 수용한 경우(法 41③,④), 특허권의 수용(法 106③), 국가 비상사태 등에 의한 강제실시권의 허락(法 106의2③), 裁定에 대한 대가·지급방법·지급시기(法 110②ii), 통상실시권허락심판(法 138④) 등에 따른 보상금 및 대가에 대하여 심결·결정 또는 재정을 받은 자가 그 보상금 또는 대가에 불복할 때에는 법원에 소송을 제기할 수 있다(法 190①).

2. 성 질

지식재산처장 또는 심판관의 보상금액 등의 결정은 일종의 행정처분에 해당되지만, 그 처분의 전부에 대한 불복이 아니라 그 처분 중의 「금액」만에 대한 불복일 경우에는 실질적으로 대가를 지급하거나 수령할 당사자 간의 문제가 된다. 그러므로 제190조 소정의 보상금 또는 대가에 관한 불복의 소는 경우에 따라 그 소송의 성질이 달라지게 된다.⁸²⁾

II. 제소기간과 관할법원

1. 제소기간

이 소송은 통지나 심결·결정 또는 재정의 등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 제기하여야 한다. 이 기간은 불변기간이다(法 190②③). 다만 민사소송법 제172조제2항의 부가기간이 준용되는 경우는 예외이다.

2. 관할법원

보상금 또는 대가에 대한 소송의 성질이 행정소송에 해당하면, 즉 제41조제3항, 제4항 및 제106조제3항의 국방상 필요한 발명의 특허권 수용 등의 보상금, 제106조의2의 국가의 비상사태 등에 의한 강제실시권 허락 시의 보상금에 관한 소는 행정법원의 관할이 되며, 동 소송의 성질이 민사소송에 해당하면, 즉 제110조제2항제2호 및 제138조제4항의 통상실시권 설정 재청 및 허락 시의 대가에 관한 소는 민사법원의 관할이 된다.

III. 소송당사자

1. 원 고

이 소송에 있어서 원고는 보상금액 또는 대가에 대한 심결·결정 또는 재정을 받은 자이다(法 190①). 2명 이상 대립하는 당사자가 있는 경우, 예컨대 특허발명 불실시로 인한 재정에 있어서 실시허락을 받은 자와 특허권자 또는 전용실시권자는 쌍방이 모두 원고로서의 적격자이다. 즉 실시권을 허락받은 자는 실시 대가의 감액을, 특허권자측은 그의 증액을 각각 요구할 입장에 서기 때문이다.

2. 피 고

본 소송의 피고는 보상금이나 대가를 지급하여야 할 각 경우에 다음과 같은 자를 각각 피고로 하여야 한다(法 191).

- i) 제41조제3항 및 제4항(국방상 필요한 발명에 대한 외국에의 출원금지, 비밀취급명령, 불특허, 특허를 받을 수 있는 권리의 수용)에 따른 보상금에 대해서는 보상금을 지급하여야 할 중앙행정기관의 장 또는 출원인
- ii) 제106조제3항(국방상 필요한 특허권의 정부에 의한 수용) 및 제106조의2제3항(국가 비상사태 등의 이유로 특허발명의 정부 또는 정부 외의 자의 실시)에 따른 보상금에 대해서는 보상금을 지급하여야 할 중앙행정기관의 장, 특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자

82) 이시윤·이상정, “특허법원의 신설과 특허심판구조의 개편”, 사법행정, 1996, 12면.

- iii) 제110조제2항제2호 및 제138조제4항의 규정(재정이나 통상실시권허락심판에 의한 실시권에 대한 대가)에 의한 대가에 대해서는 통상실시권자·전용실시권자·특허권자·실용신안권자 또는 디자인권자

IV. 소송절차의 중지

보상금 또는 대가의 목적이 된 특허발명에 대하여 무효심판의 청구가 계속 중에 있는 경우에는 그 보상금 또는 대가에 대한 소송은 무효심판의 심결이 확정될 때까지 그 절차를 중지할 수 있다(法 164②). 왜냐하면 그 특허가 무효가 된 경우에는 보상금이나 대가결정에 대한 불복소송은 무의미하게 되기 때문이다.

PART 09

조약

제1장 파리조약

제2장 WIPO 설립조약

제3장 무역관련 지식재산권에 관한 협정

제4장 특허협력조약

제5장 부다페스트 조약

제6장 스트라스부르그 협정

제7장 특허법 조약

제8장 특허실체법 조약

제1장

파리조약

제1절 서설

I. 파리조약의 설립배경

1) 산업재산권은 각국의 경제발전에 직접적으로 영향을 미치기 때문에 속지주의의 원칙이 강하게 지배하고 있었다. 즉 각국은 자국의 법률에 의한 산업재산권만을 보호해 왔으며, 각국 산업재산권법의 적용은 그 국가의 영역 내의 경우만 해당한다. 한편 각국은 자국산업의 이익에 합치되는 독자적인 제도를 영위하면서 보편적이고 국제적인 특허법을 만들기 위해 노력했으나 각국의 산업정책이나 이데올로기의 차이로 말미암아 산업재산권에 관한 세계 공통의 보편적인 통일법의 제정은 현실적으로 극히 곤란하다는 인식을 하게 되었다. 이러한 현실적인 판단하에 각국에 제도적인 차이는 차이로서 이를 시인하고, 그 위에 서서 국제협조주의, 보편성의 요구를 어느 정도 충족시키는 타협점을 찾아 이에 의하여 산업재산권의 국제적 보호를 도모하려는 것이 바로 「산업재산권의 보호를 위한 파리조약(paris convention for the protection of industrial property)」이다.

2) 파리조약은 1883년 3월 20일에 파리에서 체결되었으며, 1900년 12월 14일 브뤼셀, 1911년 6월 2일 워싱턴, 1925년 11월 6일 헤이그, 1934년 6월 2일 런던, 1958년 10월 31일 리스본, 1967년 7월 14일 스톡홀름에서 각각 개정되었으며, 후속 개정조약은 이전 조약을 대체한다(條約 22). 한편 우리나라는 1967년 스톡홀름 개정조약의 당사국이며, 동 조약은 이후 1979년 9월 28일 개정안이 채택되어 1984년 6월 3일에 발효된 바 있다.

3) 한편 스톡홀름 개정 조약에서는 분쟁의 해결수단을 마련하였다. 본 조약의 해석 또는 적용에 관한 둘 이상의 동맹국 간의 분쟁으로서 교섭에 의하여 해결되지 아니하는 것은 분쟁 당사국이 다른 해결 방법에 합의하는 경우를 제외하고는 국제사법재판소에 이를 제기할 수 있다. 분쟁을 국제사법재판소에 제기하는 국가는 국제사무국에 이를 통보하고 국제사무국은 여타의 동맹국에 이에 관한 주의를 환기시킨다. 다만 각국은 본 개정조약에 서명할 때 또는 비준서나 가입서를 기탁할 때 이를 이용하지 아니한다는 것을 선언할 수 있으며 그 선언을 한 국가와 타 동맹국 간의 분쟁에는 적용되지 아니한다(條約 28).

II. 파리협약의 특색

1. 동맹(union)조약

이러한 파리조약은 국제간의 산업관련 조약으로서는 보기 드물게 체약국에게 산업재산권의 보호를 위한 동맹을 구성하고 있다(條約 1(1)). 여기에서 「동맹」이란 조약의 목적에 따라 산업재산권의 국제적 보호라는 공동목적을 달성하기 위해 합목적적으로 동일행동을 취할 것을 약속하는 복수 국가의 집단으로서 유기적인 활동을 하는 통일체를 말한다. 즉 산업재산권의 국제적 보호를 위한 계속적인 활동을 가능하게 하는 다자간조약(多者間條約)이다.

2. 기본조약의 존속

각각의 개정조약은 상호 독립적이므로 개정조약을 적용하는 동맹국 상호간에 있어 그것이 적용되는 한도 내에서 1883년 3월 20일자의 「파리」 조약 및 그 후의 제 개정조약을 대체한다(條約 27(1)). 즉 각각의 개정조약은 독립적이며 어느 단계를 비준하거나 가맹할 것인지는 각 동맹국의 자유이다.

3. 특별협정

동맹국은 본 협약의 규정에 배치되지 아니하는 한 별도로 상호간에 산업재산권의 보호에 관한 특별한 협정을 체결할 권리를 유보한다(條約 19). 이에 유럽특허조약, 국제특허분류에 관한 스트라스부르그 협정, 특허협력조약, 미생물의 기탁분양에 관한 부다페스트조약 등이 만들어졌다. 한편 체결된 특별협정은 대부분 파리조약 준수의무와 파리조약상의 권리·의무의 훼손금지를 명확히 밝히고 있다.

III. 국내법과의 관계

1. 국내법의 내용을 이루는 경우

파리조약의 중요 규정 중 대다수가 보호가 요구되는 나라의 헌법이 이를 인정한다는 것을 요건으로 하여 각 동맹국의 국내법의 내용을 이룬다. 즉 보호되는 나라의 국내법을 거치지 않고도 이해관계인에 대하여 직접적으로 적용이 된다. 이러한 의미에서 이러한 조약의 규정은 체약국의 국내법 규정을 변경하거나 보충 또는 국내법의 예외를 이룬다. 구체적인 예를 들면 특허와 관련하여서는 i) 내·외국인 평등의 원칙(條約 2, 3), ii) 우선권제도(條約 4, 단, 4B 후단, 4D(1)후단, 4G(2)후단 제외), iii) 특허독립의 원칙(條約 4의2), iv) 발명자 게재권(條約 4의3), v) 판매 제한품에 대한 발명의 보호(條約 4의4), vi) 특허권의 침해로 되지 아니하는 경우(條約 5의3), vii) 방법특허에 대한 발명의 보호(條約 5의4) 등의 규정이 모두 이 범주에 속한다.

2. 국내법의 제정을 요구하거나 허용하는 경우

파리조약에는 대다수 규정이 국내법의 내용을 이루고 있는 반면 조약의 규정의 일정사항을 각 동맹국의 국내법에서 규정하도록 요구하거나 허용하는 규정도 존재한다. 예를 들면 특허와 관련하여서는 i) 우선기간 이전에 제3자가 취득한 권리(條約 4B후단), ii) 우선권 주장기간(條約 4D(1)후단), iii) 우선권형식 위반 시 우선권 상실을 초과하지 아니함(條約 4D(4)후단), iv) 특허출원의 분할인정요건(條約 4G(2)후단), v) 불실시에 대한 제재(條約 5), vi) 요금납부의 유예기간(條約 5의2) 등의 규정이 모두 이 범주에 속한다.

3. 행정적 또는 국제법적 성격의 규정

행정적 성격의 규정은 동맹의 최고의사결정기관인 총회, 그 내부기관인 집행위원회, 재정 및 수중에 관하여 규정한 관리규정(條約 13-17)이 있으며, 국제법적 성격의 규정에는 운영규정(條約 18-30)이 속한다.

제2절 파리조약의 적용범위

I. 적용지역

“본 조약에 의하여 적용되는 국가는 산업재산권의 보호를 위하여 동맹을 형성한다(條約 1(1))”라고 규정되어 있다. 여기서 파리조약의 「체약국」이라고 표현하지 않고 「본 조약에 의하여 적용되는 국가」라고 표현하는 이유는 식민지, 보호령, 위임통치 지역 등 조약의 체약국이 될 자격이 없는 지역에 대해서도 체약국의 국가가 대외관계에 대하여 책임을 지는 영역의 전부 또는 일부인 경우 본 협약을 적용한다는 뜻을 비준서 또는 가입서에서 영역을 지정하여 선언하거나 서면에 의하여 통고하면 「본 조약에 의하여 적용되는 국가」가 될 수 있기 때문이다(條約 24).

II. 보호대상

1) 파리조약에서 보호되는 「산업재산권」이란 저작권을 제외한 특허, 실용신안, 디자인, 상표, 서비스 마크, 상호, 원산지 표시 또는 원산지 명칭 및 부정경쟁의 방지를 그 대상으로 한다(條約 1(2)). 이 산업재산권은 최광의로 해석되며 본래의 공업 및 상업뿐만 아니라 농업 및 채취 산업과 포도주, 곡물, 연초염, 과일, 가축, 광물, 광수, 맥주, 꽃 및 곡분과 같은 모든 제조 또는 천연상품에 대해서도 적용된다(條約 1(3)).

2) 다만 상술한 모든 활동과 산품을 산업재산권인 특허나 상표로 보호할 의무는 없으며, 본 규정은 산업본래의 것에 준하여 취급되지 않을 위험이 있는 활동과 산품이 산업재산권의 보호로부터 배제되지 않게 하려고 존재한다.¹⁾

III. 적용기간

파리조약은 무기한으로 효력을 가진다(條約 26(1)). 다만 각 동맹국의 자유의사를 존중하기 위하여 어떤 동맹국을 불문하고 사무국장에게 통고함으로써 본 조약을 폐기할 수 있다. 그러한 폐기는 종전의 모든 개정조약의 폐기를 수반하는 것으로 폐기를 한 국가에 대하여만 효력을 발생하며, 다른 동맹국에 대해서는 본 조약은 계속 효력을 가진다(條約 26(2)). 폐기는 사무국장이 그 통고를 접수한 날로부터 1년 후에 효력을 발생한다(條約 26(3)). 다만 어느 국가도 동맹의 구성국이 된 날로부터 5년의 기간이 만료될 때까지는 폐기의 권리를 행사할 수 없다(條約 26(4)).

제3절 파리조약의 실체규정

I. 서 설

1) 파리조약상 특허의 보호에 관한 규정은 i) 산업재산권의 보호대상으로 정함에 따른 보호규정(條約 1), ii) 내·외국인 평등의 원칙(條約 2, 3), iii) 우선권의 원칙(條約 4), iv) 특허독립의 원칙(條約 4의2), v) 발명자 게재권(條約 4의3), vi) 판매 제한품의 특허성(條約 4의4), vii) 불실시에 대한 제재(파리조약 5A), viii) 특허표시(條約 5D), ix) 요금납부의 유예기간, 특허의 회복(條約 5의2), x) 특허권의 침해로 되지 아니하는 경우(條約 5의3), xi) 방법특허에 대한 발명의 보호(條約 5의4), xii) 박람회 출품물의 가보호(條約 11) 등이 있다.

2) 특히 파리조약은 속지주의에 따라 각국의 산업재산권제도상의 차이를 그대로 시인하고, 그 위에 i) 내·외국인평등(內外國人平等)의 원칙, ii) 우선권의 원칙 및 iii) 특허독립의 원칙을 3개의 기둥으로 하여 외국출원을 하는 자를 보호하고 있으며 이를 파리조약의 3대 원칙이라 한다.

II. 내·외국인 평등의 원칙

1. 의 의

「내·외국인 평등의 원칙(principle of assimilation with nationals)」이란 파리조약 동맹국이 산업재산권의 보호에 관하여 다른 동맹국 국민 또는 준동맹국 국민에 대하여 내국민과 차별없이 평등한 대우를 하는 것을 말한다(條約 2, 3). 파리조약은 속지주의를 전제로 하면서 산업재산권의 국제적 보호라는 조약의 목적을 유효하게 달성하기 위해 상호주의를 배제하여 동맹국 국민 또는 준동맹국 국민에 대하여 예외적으로 내국민과 동일한 보호를 하고 있다.

1) 천효남, 「특허법」, 제9판, 법경사, 2003, 809면.

2. 적용대상

(1) 동맹국 국민

「동맹국 국민」이란 본 조약이 적용되는 국가의 자연인과 법인을 말하며, 자연인인지 는 해당국의 국적에 의하여, 법인인지는 설립준거법에 따라 판단한다. 한편 이중국적자는 적어도 하나가 동맹국의 국민이면 족하나, 공유관계인 경우에는 모두가 동맹국 국민이어야 한다.

(2) 준동맹국 국민

1) 파리조약은 동맹국 국민뿐만 아니라 비동맹국의 국민이더라도 어느 동맹국의 영역 내에 주소 또는 진정하고 실효적(實效的)인 공업상 또는 상업상의 영업소를 가진 경우, 즉 「준동맹국 국민」의 경우 동맹국의 국민과 동일하게 취급하도록 규정하고 있다(條約 3). 즉 준동맹국의 국민이더라도 동맹국의 실질적인 거주자는 동맹국의 국민과 같이 동맹국의 산업발전에 기여한 다는데 착안하여 동맹국의 국민으로 간주하여 동맹국의 국민과 같이 내국민대우를 받을 수 있도록 하고 있다.

2) 한편 어떤 나라의 국적도 가지지 아니한 무국적자가 어느 동맹국에 주소 또는 진정하고 실효적(實效的)인 영업소를 가진 경우 파리조약 제3조에 포함되어야 할지 의문이나, 파리조약 이 내·외국인평등의 원칙을 준동맹국 국민에게까지 확대하는 것에 비추어 볼 때 동맹국 내에 주소나 영업소를 가진 무국적자도 동맹국 국민과 동일한 취급을 받는 것으로 해석된다. 즉 무국적자는 준동맹국 국민에 준하여 취급한다.

3. 적용조건

동맹국의 국민 또는 준동맹국 국민은 국내에 주소 또는 영업소를 가질 것을 조건으로 하지 아니한다(條約 2(2)). 그러나 동맹국의 국민은 사법상 또는 행정상의 절차, 재판 관할권 및 산업재산권에 관한 법령상 필요로 하는 주소의 선정 또는 대리인의 선임에 대해서는 각 동맹국의 법령이 정하는 바에 따라야 한다(條約 2(3)). 각국이 신속한 절차수행을 위하여 필요로 하는 사항은 각국에 위임하는 것이 바람직하다는 취지에 이를 허용하고 있다.²⁾ 예를 들어 국내법은 제5조에서 대리인 선임에 관한 규정을, 제13조에서 재판관할권에 관한 규정을 두고 있다.

4. 적용효과

동맹국의 국민 또는 준동맹국 국민은 모든 동맹국에서 산업재산권의 보호에 관하여 본 조약에서 특별히 정하는 권리를 침해하지 아니하고 각 동맹국의 법령이 내국민에 대하여 현재 부여하고 있거나 또한 장래 부여할 이익을 향유한다. 따라서 동맹국의 국민 또는 준동맹국 국민은 내국민에게 과해지는 조건 및 절차에 따르는 한 내국민과 동일한 보호를 받으며, 또한 자기의 권리의 침해에 대하여 내국민과 동일한 법률상의 구제를 받는다(條約 2(1)(2)).

2) 박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002, 574면.

Ⅲ. 우선권제도

1. 의의 및 취지

어떠한 동맹국에서 정식으로 특허출원을 하거나 실용신안, 디자인, 상표 또는 발명자증 출원을 한 자 또는 그 승계인은 타 동맹국에서 출원의 목적상 우선권을 가진다(條約 4A(1), 4I). 「우선권(right of priority)」이란 어떤 동맹국에서 최선의 정규출원을 한 자 또는 그 승계인이 우선 기간에 다른 동맹국에 동일한 내용에 대하여 출원하는 경우, 선출원주의 및 특허요건 등의 판단에 있어 그 최선 출원의 출원일을 기준으로 할 수 있는 파리조약상의 권리를 말한다(條約 4). 우선권제도는 속지주의 원칙에 의하여 국가마다 산업재산권의 보호를 요구하는 체제하에서 시간과 비용이 드는 외국에의 출원절차를 용이하게 하고 발명자나 출원인에게 외국에서 산업재산권을 취득하기 쉽게 함으로써 산업재산권의 국제적인 보호를 도모하는데 그 취지가 있다.

2. 우선권의 성질

(1) 독립성

우선권은 최초 출원행위로부터 발생되지만 그 발생과 함께 그 최초출원으로부터 분리되어 독립적으로 된다. 이를 우선권의 독립성이라 하는데, 이러한 독립성 때문에 우선권만의 양도가 가능하므로 제1국 출원의 승계인은 우선권을 별도로 승계하여야 우선권주장출원을 할 수 있다. 또한 우선권의 독립성으로 말미암아 제1국 출원은 정규성만 인정되면 된다.

(2) 복수성

동맹국에의 최초 정규출원에 의하여 일단 발생된 우선권은 하나의 불가분적인 것이 아니라 파리조약의 동맹국 수와 같은 복수의 집합($n-1$; 여기서 n 은 전체 파리조약 동맹국 수)을 내포하고 있다. 이를 우선권의 복수성이라 한다.

(3) 잠재성

우선권은 다수의 동맹국에 미치는 복수의 집합개념이나 모든 동맹국에 항상 행사되는 것은 아니고 전혀 행사되지 아니한 채 소멸하거나, 행사되더라도 일부 동맹국에 그치는 것이 일반적이다. 즉 우선권이란 현실화할 가능성이 있는 권리인 동시에 현실화하지 아니한 채 소멸될 가능성도 있는 잠재적인 것이다. 이를 우선권의 잠재성이라 한다.

(4) 부속성

우선권은 동맹국의 최초 정규출원으로부터 독립된 것이라고 하더라도 그 독립성은 어디까지나 제2국 출원의 기초로서 사용될 때까지 성립되는 것이다. 따라서 제2국 출원의 기초로서 일단 행사된 때에는 독립성을 잃는 것이며, 그 후에는 제2국 출원의 부속물로서 제2국 출원국의 특허법에서의 출원과 그 운명을 함께 한다. 이를 우선권의 부속성이라고 한다.

3. 우선권주장의 요건

(1) 주체적 요건

1) 우선권의 이익을 향유하기 위해서는 출원인의 동일성이 요구된다. 즉 출원인은 출원 시에 동맹국 국민 또는 준동맹국 국민으로서 어느 동맹국 국내에 주소 또는 영업소를 가진 자 또는 그 승계인이어야 한다(條約 2, 3, 4). 따라서 출원인은 「어떤 동맹국」(in one of the countries or the union)에 출원을 하면 반드시 자국에 최초로 출원을 할 필요는 없다.

2) 또한 출원인은 어떤 동맹국에서 「출원을 한 자 또는 그 승계인」(his successor in title)이어야 한다. 여기에서 말하는 「그 승계인」이란 동맹 제1국에서 출원을 한 자로부터 동맹 제2국에서의 특허 또는 등록을 받을 수 있는 권리를 승계한 자를 가리킨다. 어떤 동맹국에서 최선이고 정규의 출원을 한 자가 그 나라에서 그 출원에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도하였다고 하더라도 양수인이 제2국에서의 우선권을 주장할 수 있는 권리까지 당연히 승계하였다고 볼 수 없다. 왜냐하면 우선권제도는 어떤 동맹국에서의 최선이고 정규의 출원을 한 자를 제2국에서 보호하기 위한 제도인바 속지주의 원칙하에서 적용되어야 하는 특허를 받을 수 있는 권리의 양도에 파리조약이 부여하는 우선권의 효과까지 당연히 승계된 것으로 해석하는 것은 무리가 있기 때문이다. 따라서 어떤 동맹국에서의 출원인이 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자에게 양도하였다고 하더라도 그 출원인은 다른 동맹국에서 우선권을 주장하여 출원할 수 있음은 물론 타인에게 다른 동맹국에서의 우선권주장을 수반한 특허를 받을 수 있는 권리를 양도할 수 있다. 이것은 우선권의 속성 중 하나인 우선권의 독립성에 기인한 것이다.

(2) 객체적 요건

① 동맹 제1국에의 최선의 정규출원을 하였을 것

1) 우선권을 주장하기 위해서는 파리조약상의 어떤 동맹국의 국내법령 또는 동맹국 간에 체결된 양자 간 또는 다국간의 조약(예를 들면 PCT, EPC 등)에 따라 인정된 최선의 정규출원을 하여야 한다. 여기서 제1국의 출원은 정규출원이면 족하고, 제1국 출원에 대한 결과 여부는 불문한다(條約 4A(2)(3)). 따라서 제1국 출원이 취하나 포기 또는 무효가 되더라도 이를 기초로 우선권주장을 할 수 있다.

2) 동맹 제1국에서의 최선의 출원이어야 하는 이유는 우선기간의 실질적 연장을 방지하기 위해서이다. 다만 예외적으로 최선의 출원이 출원인의 의도를 반영하지 못하는 경우가 발생할 수 있으므로 다음과 같은 요건을 모두 만족할 때는 후속출원을 기초로 우선권주장을 할 수 있다(파리조약 4C(4)).

- i) 후속출원이 최선출원과 동일한 대상에 대하여 동일 동맹국에 출원될 것
- ii) 최선출원이 공중의 열람에 제공되지 않을 것
- iii) 최선출원이 어떠한 권리도 존속시키지 아니할 것
- iv) 후속출원 당시에 취하, 포기, 거절되어 있을 것
- v) 그 최선출원이 아직 우선권주장의 기초로 되어 있지 않을 것

② 동맹 제1국에의 특허, 실용신안, 디자인 또는 발명자증 출원일 것

동맹 제1국에서의 정식으로 특허출원을 하거나 실용신안, 디자인출원을 한 자 또는 그 승계인이야 한다(條約 4A(1)). 다만 상표출원을 기초로 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 우선권을 주장하는 것은 성격상 부합하지 아니한다. 한편 출원인이 재량으로 특허 또는 발명자증³⁾ 중 어느 하나를 신청할 수 있는 국가에서 행하여진 발명자증의 출원을 기초로도 우선권 주장을 할 수 있다(條約 I(1)).

③ 출원의 목적물이 동일할 것

1) 우선권을 주장하기 위해서는 출원의 목적물이 동일성을 가져야 한다. 목적물이 동일성을 가지는 경우란 동맹 제1국에서의 출원의 목적물이 동맹 제2국에서의 목적물과 그 실질적인 요지에 있어서 동일성을 가지는 경우를 말한다.

2) 특허에 있어서는 각국의 특허요건 등의 相異가 있으므로 파리조약은 특허출원에 관하여는 엄밀하게 형식적인 동일성이 요구되는 것이 아니라 실질적인 동일성을 확보할 수 있으면 족하다는 취지의 일종의 완화규정을 두고 있는데(條約 4H), 목적물의 동일성 판단은 청구범위의 기재(claims)뿐만 아니라 출원서·명세서 및 도면 등 출원서류(application document) 전체의 기재에 의하여 거기에 개시된 기술적 사상을 바탕으로 하여 실질적으로 판단하여야 하며, 비록 우선권의 주장에 관련된 것이 동맹 제1국의 출원에서 청구범위에 기재되어 있지 않더라도 출원서류 전체에 의하여 그 구성 부분(elements)이 개시되어 있기만 하면 우선권을 부인하여서는 아니 된다는 의미이다.

(3) 시기적 요건

1) 우선권을 주장하기 위해서는 우선기간에 출원하여야 한다. 「우선기간(the periods of priority)」이란 어떤 동맹국에서 정규의 최선출원을 한 자 또는 그 승계인이 다른 동맹국에서 우선권의 이익을 수반한 출원을 할 수 있는 기간을 말한다. 우선기간은 우선권을 주장할 수 있는 우선권주장기간과 반드시 일치하는 것은 아니다(條約 4D(1)후단). 그러나 우리나라는 일치한다(法 54③). 이러한 우선기간에 대해서는 출원인의 이익과 일반 제3자의 이익과의 조화라는 점에서 특허 및 실용신안에 대해서는 12개월, 디자인 및 상표에 대해서는 6개월로 규정하고 있다(條約 4C(1)).

2) 한편 실용신안등록출원을 기초로 디자인등록출원으로 우선권주장을 하는 경우 우선기간은 6개월이며, 특허출원을 기초로 실용신안등록출원으로 우선권주장을 하는 경우 우선기간은

3) 발명자증이란 발명과 관련된 권리를 국가에 귀속시키는 대신 발명자에게 일정한 보상을 주기 위한 제도를 말한다. 발명자증도 i) 발명의 보호를 내용으로 하며, ii) 출원일의 특징이 가능하며, iii) 사회주의 국가의 동맹가입 촉진과 동서 기술교류 확대에 이바지하기 위해 파리조약에 의하여 보호되고 있다. 발명자증이 보호되기 위해서는 자기의 선택에 의하여 특허 또는 발명자증 중의 어느 출원이라도 할 수 있는 동맹국(병유국)이어야 한다. 이는 발명자증은 특허보다 이용하기 어려운 경우가 많으므로 발명자증만을 인정하는 나라가 출현하는 것을 방지하기 위해 규정한 것이다.

12개월이다(條約 4E(1)(2)). 문제가 되는 경우는 디자인등록출원을 기초로 실용신안등록출원으로 우선권주장을 하는 경우인데 이 경우 파리조약에 직접적인 규정이 없어서 디자인등록출원을 기준으로 6개월로 하여야 한다는 제1국설과 실용신안등록출원을 기준으로 12개월로 하여야 한다는 제2국설이 있으나, 실무는 제1국설을 지지한다.

3) 이러한 우선기간은 최초의 출원일로부터 개시하며, 출원일은 이 기간의 계산에 넣지 아니한다(條約 4C(2)). 또한 우선기간의 마지막 날이 보호의 청구를 할 국가에서 법정의 휴일이거나 또는 관할청이 출원을 접수할 수 없는 날이면 그 기간은 다음 최초의 근무일까지 연장된다(條約 4C(3)).

4. 우선권주장의 절차

(1) 우선권의 주장

우선권을 이용하려는 자는 그 출원의 일부 및 그 출원을 한 동맹국의 국명을 명시한 선언을 할 것이 요구된다. 이 경우 각 동맹국은 그러한 선언을 하여야 할 최종일을 결정한다(條約 4D(1)). 즉 우선권의 이익을 향유하기 위해서는 출원인은 동맹 제2국에 우선권주장을 신청하여야 한다. 그 이유는 동맹 제1국 및 동맹 제2국에서의 출원의 사실만으로는 우선권은 아직 관념적 이익에 불과하며 우선권의 이익을 누릴 수가 없기 때문이다. 한편 「일부 및 국명」은 권한 있는 당국이 발행하는 간행물 특히 특허 및 명세서에 관한 간행물에 게재한다(條約 4D(2)).

(2) 우선권증명서류의 제출

동맹국은 우선권을 신청하는 자에 대하여 최초의 출원에 관한 출원서류(명세서, 도면 등을 포함)의 등본의 제출을 요구할 수 있다. 그러한 출원을 접수한 당국에 의하여 인증된 등본은 여하한 공증도 필요로 하지 않으며 여하한 경우에도 해당 우선권주장출원일로부터 3개월의 기간에 언제든지 무료로 제출될 수 있다. 동맹국은 그 등본에 같은 당국이 발급하는 출원 일부를 표시하는 증명서 및 국어번역문을 첨부하도록 요구할 수 있다(條約 4D(3)).

(3) 다른 절차의 요구 불가

우선권주장출원을 할 때는 우선권의 선언에 대하여 여타의 형식적 요건을 요구할 수 없다. 각 동맹국은 이 조항에 정하는 형식을 따르지 아니하였을 경우의 효과에 대하여 정한다. 다만 그 효과는 우선권의 상실을 초과하지 아니한다(條約 4D(4)). 그러나 우선권의 선언 이후에는 다른 증거서류가 요구될 수 있다. 예를 들어 출원번호를 언제나 알 수 있는 것은 아니기 때문에 우선권주장선출원의 출원번호를 명시하도록 요구할 수 있다(條約 4D(5)).

5. 우선권주장의 효과

1) 우선권주장이 적법한 경우 i) 우선권주장기간 중에 행하여진 행위, 특허, 다른 출원, 해당 발명의 공표 또는 실시, 해당 디자인으로 된 물품의 판매 또는 해당 상표의 사용으로 인하여

무효로 되지 아니하며 또한 ii) 이러한 행위는 제3자의 권리 또는 여하한 개인 소유의 권리를 발생시키지 아니한다. 다만 우선권의 기초가 되는 최초의 출원일 전에 제3자가 취득한 권리는 각 동맹국의 국내법령에 따라 유보된다(條約 4B). 여기서 주의할 점은 파리조약 제4조 B는 i) 특허요건(法 29), ii) 선출원(法 36), iii) 이용·저촉관계(法 98), iv) 생산방법 추정(法 127), v) 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96), vi) 선사용권(法 103) 등을 판단할 때 선출원을 기준으로 한다는 것을 의미하는 것이지 우선권주장의 출원일이 선출원일로 소급함을 나타내는 것은 아니라는 것이다.

2) 그러나 우선권의 혜택으로 획득된 특허는 각 동맹국에서 우선권의 혜택없이 출원 또는 부여된 특허와 같은 존속기간을 갖는다(條約 4의2(5)). 또한 특허출원에 관한 출원심사청구기간의 기산일은 우리나라에서의 실제 특허출원일이며, 특허발명의 불실시의 경우에서의 불실시기간은 「특허출원일로부터 4년」에 관하여도 우리나라의 특허출원일로부터 기산한다(條約 4의2(2)).

6. 관련문제

(1) 복합우선·부분우선의 인정

「복합우선」이란 하나의 출원에 관하여 복수의 우선권(둘 이상의 국가에서 한 출원에 기한 것을 포함한다)을 주장하는 것을 말하며, 「부분우선」이란 일 또는 그 이상의 우선권을 주장하는 출원이 그 우선권이 주장되는 출원에 포함되지 아니한 일 또는 그 이상의 구성요소를 포함하는 것을 말한다. 어느 동맹국도 특허출원인이 복합우선 또는 부분우선권을 주장한다는 것을 이유로 해당 우선권 또는 해당 특허신청을 거절할 수 없다. 다만 이 두 경우 해당 동맹국의 법령상 발명의 단일성이 있는 경우에만 해당한다. 우선권이 주장되는 선출원에 포함되지 않았던 구성요소에 대해서는 후출원이 통상의 조건에 따라 우선권을 발생시킨다. 즉 후출원일을 기준으로 특허요건 등을 판단하게 한다(條約 4F).

(2) 우선권의 이익을 보유한 채 출원분할 가능

1) 심사에 의하여 하나의 특허를 위한 우선권주장출원이 1이상의 발명을 포함하고 있음이 밝혀지면 출원인은 그 출원을 수 개의 출원으로 분할시킬 수 있으며 또한 당초 출원일을 그 각각의 출원일로 유지하고, 우선권의 혜택이 있는 경우에 이를 보유할 수 있다(條約 4G(1)). 즉 파리조약 제4조 G(1)은 특허출원의 심사를 하여 출원이 둘 이상의 발명을 포함하는지를 확인하는 나라에만 적용되는 규정이다.

2) 한편 출원인 또한 그 스스로 우선권주장출원을 분할시킬 수 있으며 당초의 출원일을 각 분할출원의 일부로 하여 우선권의 혜택이 있는 경우에 이를 보유할 수 있다. 각 동맹국은 그러한 분할이 인정될 수 있는 조건을 정한다. 이는 자발적 분할출원을 말하는 것으로 무심사주의 국가를 고려한 규정이다(條約 4G(2)).

IV. 특허독립의 원칙

1. 의의 및 취지

「특허독립의 원칙」이란 동맹국 국민이 각 동맹국에 출원한 특허는 타국에서 동일발명에 관하여 취득한 특허와 독립적이라는 것을 말한다(條約 4의2). 산업재산권은 각국의 산업정책과 밀접한 관련이 있는 것이므로 각국에서는 자국이 인정한 산업재산권만을 보호하고 있다. 따라서 산업재산권법은 해당국의 영역 내에서만 적용되고, 산업재산권은 해당국의 법령에 의하여 성립하고 효력을 가지는 것이 원칙이다.

2. 내 용

1) 동맹국의 국민에 의하여 여러 동맹국에서 출원된 특허는 동일한 발명에 대하여 동맹국 또는 비동맹국과 관계없이 타국에서 획득된 특허와 독립적이다(條約 4의2(1)). 이러한 규정은 비제한적(절대적)인 의미로 이해되며, 특허 우선기간에 출원된 특허는 무효 또는 몰수의 근거에 관하여 그 리고 통상의 존속기간에 관하여 서로 독립적이라는 의미로서 이해된다(條約 4의2(2)).

2) 본 규정은 그것이 효력을 갖게 되는 때에 존재하는 모든 특허에 적용되며,⁴⁾ 그것은 신규 국가 가입의 경우에 있어 양측에 존재하는 특허에도 동일하게 적용된다(파리조약 4의2(3)(4)). 한편 우선권의 혜택으로 획득된 특허는 각 동맹국에서 우선권의 혜택없이 출원 또는 부여된 특허와 같은 존속기간을 갖는다(條約 4의2(5)).

V. 그 밖의 실체규정

1. 발명자 제재권

발명자는 특허증에 발명자로서 기재될 권리를 갖는다(條約 4의3). 이는 발명자의 인격권을 보호하기 위한 규정으로서 발명자의 권리행사는 국내법령에 의한다. 발명자 제재권은 일신전속적인 인격권이기 때문에 권리로서 양도할 수 없으며, 다만 포기할 수 있다. 이 경우 출원인은 발명자표시의무를 지지 아니한다.

2. 판매 제한품의 특허성

특허된 상품 또는 특허된 공정에 의하여 생산된 상품의 판매가 국내법으로 인한 제약이나 제한을 받고 있음을 근거로 하여 특허의 부여를 거절하거나 무효로 할 수 없다(條約 4의4). 이는 현재 판매가 제한되어 있다고 하더라도 판매 제한품 등에 대한 사고방식의 변화로 인한

4) 본 원칙 발효 시의 특허는 현재 모두 소멸하였기 때문에 실효성이 없다고 할 것이다.

여 향후에 판매 제한의 해제가 가능하기 때문이다. 즉 특허요건판단과 타법의 인허가는 무관하다. 다만 이 규정이 공서양속에 반할 때 특허를 받을 수 없도록 하는 것을 금하는 것은 아니라고 할 것이다.

3. 불실시에 대한 제재

(1) 강제실시권의 설정

각 동맹국은 불실시와 같이 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 강제실시권의 부여를 규정하는 입법조치를 취할 수 있다(條約 5A(2)). 실시권의 강제적 설정은 실시되고 있지 아니하거나 실시가 충분하지 아니한 것을 이유로 할 때는 특허출원의 날로부터 4년의 기간 또는 특허가 허락된 날로부터 3년의 기간에 어느 것이고 늦게 만료되는 것이 만료하기 전에는 청구할 수 없는 것으로 본다. 또한 특허권자가 그 불실시에 대하여 정당한 이유를 분명히 한 경우에는 강제할 수 없다. 강제적으로 설정된 실시권은 배타적이어서는 아니 되며, 또한 기업 또는 영업의 구성 부분으로서의 해당 실시권은 기업 또는 영업과는 같이 이전하는 경우를 제외하고는 해당 실시권의 이전에 대한 허락만으로도 이전할 수 없다(條約 5A(3)).⁵⁾

(2) 특허권의 몰수

각 동맹국은 불실시와 같이 특허에 의하여 부여되는 배타적 권리의 행사로부터 발생할 수 있는 남용을 방지하기 위하여 실시권의 강제적 설정으로서는 충분하지 아니한 때에만 특허의 효력을 상실시키는 규정을 정할 수 있다. 특허권의 소멸 또는 특허의 취소에 대한 절차는 실시권의 최초의 강제적 설정일로부터 2년의 기간이 만료하기 전에는 할 수 없다(條約 5A(3)). 다만 특허는 특허권자가 어느 동맹국내에서 제조된 상품을 그 특허를 부여한 국가로 수입함으로써 인하여 몰수되지 아니한다(條約 5A(1)). 여기서 수입의 주체는 특허권자뿐만 아니라 실시권자가 포함되는 것으로 해석되며, 비동맹국에서 제조된 물건을 수입하면 몰수할 수 있는 규정을 둘 수 있다.

(3) 실용신안의 준용

강제실시권의 설정 또는 특허권의 몰수는 실용신안에도 적용된다(條約 5A(5)).

4. 특허표시

보호받을 권리를 인정할 조건으로써 특허, 실용신안, 상표의 등록 또는 디자인등록을 상품에 표시 또는 언급할 것으로 요구할 수 없다(條約 5D). 이는 특허표시가 의무가 아님을 나타내고 있으며 특허표시의 불이행에 대한 효과는 각국의 국내법령에 일임하고 있다.

5) 이러한 강제실시권 문제는 WTO/TRIPs 협정에서 더 구체화하고 있다.

5. 요금납부의 유예기간, 특허의 회복

산업재산권의 유지(maintenance)를 위하여 정하여진 요금의 납부에 대해서는 적어도 6개월의 유예기간이 인정된다. 다만 국내법령에 할증요금의 납부를 정하고 있는 경우는 그 납부를 요건으로 한다(條約 5의2(1)). 동맹국은 요금의 불납으로 인하여 효력이 상실된 특허의 회복에 관하여 정할 수 있다(條約 5의2(2)).

6. 특허권의 침해로 되지 아니하는 경우

1) 타 동맹국의 선박이 일시적 또는 우발적으로 해당 동맹국의 領水에 들어온 경우에 그 선박 상에서 그의 특허의 대상을 이루는 장치를 선체·기계·선원·장비나 그 밖의 부속물에 관한 해당 특허권자가 특허의 대상인 발명을 그 선박 내에서 오로지 그 선박의 필요를 위하여 사용할 때는 특허권자의 권리에 대한 침해로 간주되지 아니한다(條約 5의3(1)). 여기서 「동맹국의 선박」에 한정해석되기 때문에 비동맹국의 선박은 대상에서 제외되며, 「領水」란 영해, 내수로, 항만 등을 포함한다. 한편 「선박의 필요」 범위 이외에는 특허권의 침해이며 「사용」에 한정하는 이유는 선박 내에서의 제조·판매를 금지하려는 취지이다.

2) 타동맹국의 항공기 또는 차량이 일시적으로 또는 우발적으로 해당 동맹국에 입국한 경우에 그 항공기 혹은 차량 또는 그의 부속물의 구조 혹은 기능에 관한 해당 특허권자 특허의 대상을 이루는 장치를 사용하는 경우에는 특허권자의 권리에 대한 침해로 간주되지 아니한다(條約 5의3(2)). 여기서 「구조 또는 기능」에 관계없는 사용 등은 특허권의 침해이며, 「사용」에 한정되므로 항공기 또는 차량 내에서의 제조 역시 특허권의 침해이다.

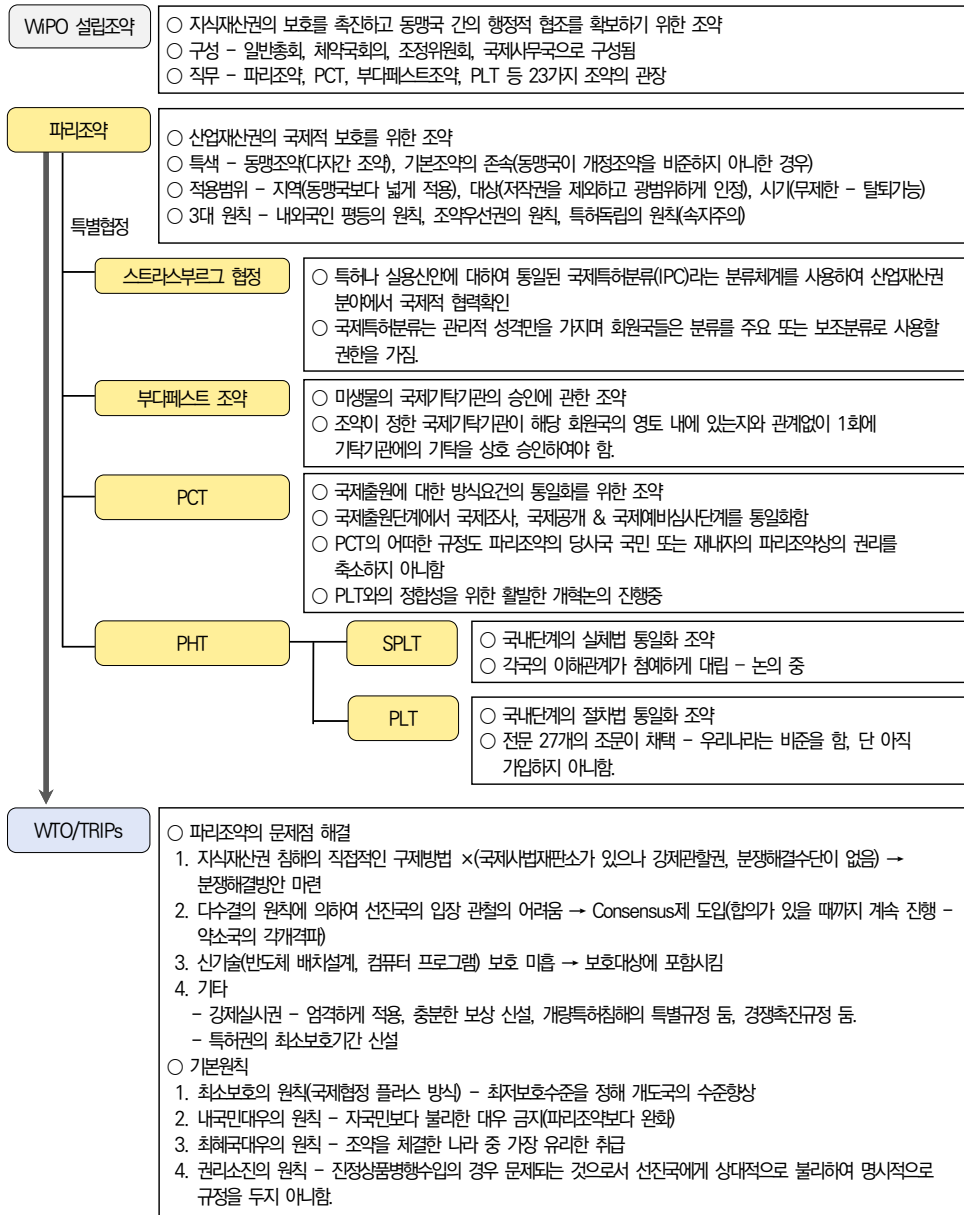
7. 방법특허에 대한 발명의 보호

어느 물건의 생산방법에 대한 특허를 받은 동맹국에서 해당 물건의 생산방법에 대한 특허를 보호하는 규정이 존재하는 다른 동맹국으로 그 물건이 수입된 경우에는 특허권자는 수입된 동맹국에서 생산하는 물건에 관하여 해당 특허에 기하여 그 국가의 법령에 의하여 부여되는 모든 권리를 그 수입된 물건에 관하여 향유한다(條約 5의4). 이는 수입을 실시의 유형으로 규정하고 있으면서도 물건의 생산방법에 대한 특허권의 효력이 국내 생산물에만 미치고 수입된 물건에는 미치지 아니한 국가에서 규정의 실익이 있다. 한편 우리나라는 제2조제3호(가)목에서 「물건을 생산하는 방법의 발명인 경우」에는 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위가 실시라고 규정하여 수입된 물건에도 물건의 생산방법에 대한 특허권의 효력이 미치도록 규정하고 있어 규정의 실익이 없다.

8. 박람회 출품물의 가보호

1) 동맹국은 어느 동맹국의 영역 내에서 개최되는 공적(official) 또는 공적으로 인정된(officially recognized) 국제박람회에 출품되는 상품에 관하여 특허를 받을 수 있는 발명, 실용신안, 디자인 및 상표에 대하여 국내법령에 따라 가보호(temporary protection)를 부여한다(條約 11(1)). 여기서 「공적」이란 정부, 공법인이 개최하는 것을 말하며, 「공적으로 인정된」이란 사법인 등이 정부와의 합의로 지휘·감독되어 개최한 것을 말한다. 한편 가보호의 내용은 자유이며 우선권과 동일한 보호, 공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우에 의한 보호, 출원일 소급에 의한 보호 등을 할 수 있다.

2) 이러한 가보호는 파리조약 제4조에서 정하는 우선기간을 연장하는 것은 아니며, 후에 우선권이 주장되는 경우 각 동맹국의 당국은 그 상품을 전람회에 반입한 날로부터 우선기간이 개시되는 것으로 규정할 수 있다. 각 동맹국은 해당 상품이 전시된 사실 및 반입의 일자를 증명하는 데 필요하다고 인정되는 증거서류를 요구할 수 있다(條約 11(2)(3)).



【그림 9-1】 조약의 개요

제2장

WIPO 설립조약

I. 설립배경

1) 「WIPO(World Intellectual Property Organization ; 세계지식재산권기구)」는 세계적으로 지식재산권, 특히 산업재산권의 보호에 관한 중심적 역할을 담당하고 있는 정부 간 국제기구이자 또한 UN산하의 전문기관(specialized agency) 중 하나이다. 이 WIPO 설립에 관한 조약은 파리조약 및 베른조약의 개정과 함께 산업재산권과 저작권을 하나의 국제기구에 의하여 보호하기 위해 1967년 7월 14일 스톡홀름에서 체결되었으며, 그 정식명칭은 「1967년 7월 14일에 스톡홀름에서 서명된 세계지식재산권기구를 설립하는 조약」(convention establishing the world intellectual property organization signed at stockholm on july 14, 1967)이다. 이 조약은 전문 제21조로 이루어졌으며 기관의 목적 및 임무, 가맹국의 지위, 일반총회, 체약국 회의, 조정위원회 및 국제사무국 등의 WIPO의 내부기구, 재정 등에 관한 규정으로 이루어졌다.

2) WIPO는 UN과의 협정(유엔헌장 57, 63, WIPO설립조약 6(3)(f), 13)에 기해 1974년 12월 17일부터 UN의 전문기관으로 인정되는 것과 함께 WIPO의 기본문서 및 WIPO가 관리할 조약 및 협정에 따라 적절한 조치를 취할 책임, 특히 창작적·지적 활동을 촉진하고 경제적·사회적·문화적 발전을 추진하기 위하여 산업재산권에 관한 기술이전을 쉽게 할 책임을 지게 되어 있다. 이에 대응되는 민간차원의 세계적인 조직으로는 산업재산권보호협회(AIPPI ; Association Internationals pour la protection de la Propriété Industrielle)를 들 수 있다. 우리나라는 이 조약에 1979년 3월 1일 가입하였다.

II. 목적, 구성 및 직무

1. 목 적

WIPO의 목적은 그 명칭에서 알 수 있는 바와 같이 국가간의 협조를 통하여 그리고 적당한 경우에는 그 밖의 모든 국제기구와 공동으로 전 세계를 통한 산업재산권(industrial property)뿐만 아니라 저작권(copyright) 등을 포함한 지식재산권의 보호를 촉진하고 제 동맹간의 행정적 협조를 확보함에 있다(條約 3).

2. 구 성

WIPO는 i) 일반총회(條約 6), ii) 체약국회의(條約 7), iii) 조정위원회(條約 8) 및 iv) 국제 사무국(條約 9)과 같은 4가지 기구에 의하여 구성되어 있다.

3. 직 무

1) WIPO는 이상의 목적을 달성하기 위하여 그의 적절한 기관을 통해서 또는 제 동맹 각각의 관할권에 따를 것을 조건으로 하여 다음과 같은 직무를 수행한다(條約 4).

- i) 전 세계를 통한 지적재산권의 효율적 보호를 촉진하고 이 분야에서의 국가 입법을 조화시킬 것을 목적으로 하는 제반조치의 발전을 증진시키며
- ii) 파리동맹, 이 동맹과 관련하여 설립된 특별동맹 및 베른동맹의 행정적 업무를 수행하며
- iii) 지식재산권 보호의 증진을 목적으로 하는 그 밖의 모든 국제협정의 관리를 담당하거나 이에 참여하기로 동의할 수 있으며
- iv) 지식재산권 보호의 증진을 목적으로 하는 국제협정의 체결을 장려하며
- v) 지식재산권 분야에 있어서 법률적, 기술적 원조를 요청하는 국가에 협조를 제공하며
- vi) 지식재산권 보호에 관한 정보를 수집·배포하고 이 분야의 연구를 수행, 촉진하며 동 연구의 결과를 공포하며
- vii) 지식재산권의 국제적 보호를 촉진하는 역무를 유지하며 적절한 경우에는 이 분야에 있어서 등록과 등록에 관한 자료의 공포를 위한 준비를 하며
- viii) 그 밖의 적절한 모든 조치를 취한다.

2) 한편 WIPO는 산업재산권 보호를 위한 파리조약(paris convention for the protection of industrial property), 특허의 국제출원절차에 관한 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty; PCT), 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트 조약(budapest treaty on the international recognition of the deposit of microorganisms for the purposes of patent procedure), 특허법 조약(Patent Law Treaty; PLT) 등 23가지의 조약을 관장하고 있다.

제3장

무역관련 지식재산권에 관한 협정

I. 설립배경

「무역관련 지식재산권에 관한 협정(WTO/TRIPs⁶⁾ 협정)」이란 1978년 GATT⁷⁾의 8차 협상인 UR(Uruguay Round)의 타결과 함께 세계무역기구(World Trade Organization : WTO) 체제로 이행⁸⁾되는 과정에서 지식재산권 보호의 강화를 하여야 한다는 미국의 주장에 의하여 i) 파리조약, 특허협력조약(PCT) 등 속지주의 원칙을 채택하는 기존의 국제조약의 체제하에서 효과적인 발명의 국제적 보호 수단 및 분쟁해결수단⁹⁾이 없는 점을 보완하고¹⁰⁾ ii) 최근에 등장

6) TRIPs : agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property rights

7) GATT : The General Agreement on Tariffs and Trade(관세와 무역에 관한 일반협정)의 약칭이다. 관세 기타 무역장벽의 경감 및 무역에서의 차별적 취급 금지를 목적으로 한다.

8) 「관세 및 그 밖의 무역장벽의 실질적인 삭감과 국제무역에 있어서의 차별대우의 폐지를 지향하는 상호 호혜적인 약정의 체결을 통하여 이러한 목적에 기여하기를 희망하며, 관세및무역에관한일반협정(GATT), 과거의 무역자유화 노력의 결과 및 우루과이 라운드 다자간 무역협상 결과 전체를 포괄하는 통합되고 보다 존속가능한 항구적인 다자간 무역체제를 발전시켜 나갈 것을 결의하는」 WTO 협정은 1994년 4월 15일에 마라케쉬에서 체결되었다. 그 결과 세계거래에 관한 조약은 WTO로 통합되어 여기에 가입하면 모든 조약에 가입한 효과를 가진다. 따라서 각국은 국제거래에 관련한 다수 조약을 쉽게 가입할 수 있게 되었다. 한편 기술선진국은 개도국에 대한 조약 가입 강제를 위하여 여러 가지 조약에의 가입을 강제하는 대신에 WTO에의 가입만을 강제하는 것으로 그 원하는 바를 얻을 수 있는 편리함을 가지게 되었다. 즉 세계의 거래관계는 WTO 체제가 지배하게 된 것이다. TRIPs는 WTO 설립협정의 부속서의 형태로 포함되어 WTO 설립협정의 일부이다(이종완, 「특허법론」, 대한변리사회, 2004, 1056면).

9) 파리조약에서 권고하는 국제사법재판소에 의한 분쟁해결은 강제관할권이 없어 분쟁의 해결에 실질적인 도움이 되지 못하고 있다. 이에 반해 WTO/TRIPs 협정은 제41조부터 제64조까지 민사 및 행정절차와 규제, 잠정조치, 국경조치에 대한 관한 특별요건, 형사절차 등 분쟁해결절차를 규정하고 있다.

10) 이러한 미비점들은 WIPO관장의 기존협약들의 개정을 통하여 해결을 모색할 수도 있었고 개발도상국들은 실제로 WIPO를 통한 논의를 희망했지만 의사결정 방식이 만장일치여서 이로 인한 개정의 어려움이 있었다. 일 예로 파리조약 역시 현재 계속적으로 개정되지 못하고 1967년 스톡홀름에서 마지막으로 개정된 상태로 유지되고 있다. 더욱이 지식재산권분야에서 절대적 비교우위에 있는 미국을 중심으로 한 선진제국들은 WIPO보다는 협상과정에서 영향력을 행사할 수 있고 분쟁해결절차와 제재수단이 잘 정비되어 있는 GATT 체제 내에서 논의를 희망하였다(Friedrich-Karl Beier & Gerhard Schricker(eds), "GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property" IIC Studies, vol.1 1.). 선진제국들이 WIPO보다 GATT에서 영향력을 더 잘 행사할 수 있는 이유는 WIPO는 다수결의 원칙에 의하여 의사결정을 하므로 수가 많은 개도국에서 유리하나, GATT에서는 컨센서스(consensus)제를 취하고 있기 때문이다. 컨센서스제란 표결에 의하는 것이 아니라 회원국 중 누구도 명시적 반대를 표명하지 아니하면 합의된 것으로 보는 제도이다. 표결에 의할 경우 표결로 사안이 종결되나, 컨센서스제에 있어서는 컨센서스(합의)가 이루어질 때까지 그 사안은 계속된다. 의제의 철회를 할 때에도 공식적인 반대가 있는 한 그 의제는 철회되지 아니한다. 그 결과 컨센서스에 의하면 누군가가 고집을 부리는 경우 그 의제는 영속한다. 이는 반대하는 약소국을 각개격파(各個擊破)해 내가면 결국 컨센서스에 이를 수 있기 때문에 강대국이 고집을 부리기에 편리한 제도이다(이종완, 「특허법론」, 대한변리사회, 2004, 1037면).

한 컴퓨터 프로그램, 데이터베이스, 바이오 기술(bio technology), 반도체집적회로 등 신기술 분야의 보호를 위해 1993년 12월 15일에 타결된 협정을 말한다. WTO/TRIPs 협정은 거의 모든 지식재산권에 관련된 국제무역질서를 규율하는 多者間 조약이며, 저작권·상표권·지리적 표시·디자인·특허·반도체 집적회로·영업비밀 및 반경쟁적 행위의 통제에 관한 내용을 담고 있다.¹¹⁾ WTO/TRIPs 협정은 우리나라가 1994년 12월 30일 WTO 설립협정 가입 수락서를 GATT 사무총장에게 기탁하여 1995년 1월 1일자로 발효되었다.

II. 구 성

WTO/TRIPs 협정은 총 7장 73개의 조항으로 구성되어 있으며, 제1장은 일반규정과 기본 원칙을, 제2장은 지식재산권의 효력, 범위 및 이용에 관한 규정으로서 주요 내용으로 컴퓨터 프로그램의 보호, 대여권의 설정, 색채상표나 등록 여부와 관계없이 널리 알려진 유명상표의 보호, 디자인 및 실용신안의 보호, 지리적 표시의 보호, 물질특허를 포함한 특허의 보호, 반도체 집적회로 배치설계의 보호, 미공개정보(영업비밀)의 보호, 반경쟁적 행위에 대한 조치 등에 관하여 규정하고 있다. 그리고 제3장 내지 제7장은 형식적인 사항들을 규정하고 있다.

III. 기본원칙

1. 최소보호의 원칙

본 협정 제1조에서는 “회원국은 이 협정의 제규정을 실시한다. 회원국은 이 협정의 규정에 위배되지 아니하는 경우, 자기나라의 법을 통해 이 협정에 의해서 요구되는 것보다 더 광범위한 보호를 실시할 수 있으나, 그렇게 할 의무를 지지는 아니한다. 회원국은 자기나라의 고유한 법제도 및 관행내에서 이 협정의 제규정에 대한 적절한 이행방법을 자유로이 결정한다.”라고 규정하고 있다. WTO/TRIPs 협정은 소위 「국제협정 플러스 방식」을 채택하였다. 즉 국제협정을 최저보호수준으로 하여 그 이상의 보호를 해 주도록 하자는 것이다. 따라서 체약국은 WTO/TRIPs 협정에 위배되지 아니하는 범위에서 국내법으로 더욱 강화된 보호를 실시할 수 있으며 이는 각국의 재량사항이다. 체약국은 자신들의 고유한 법 제도나 관행을 토대로 본 협정의 모든 규정을 이행하는 적절한 방법들을 자유롭게 결정할 수 있다(協定 1).¹²⁾ 이처럼 WTO/TRIPs 협정은 「기존의 국제협정 플러스 방식」을 채용하고 있으므로 이를 불완전협정이라고 부른다. 이 원칙은 보호수준이 낮은 국가의 지식재산권법을 지식재산권 보호를 위해 일정 수준 이상으로 향상시키는데 기여하고 있다.

11) WTO/TRIPs 협정 제2조에서는 “파리협약, 베른협약, 로마협약, 그리고 집적회로에 관한 지적재산권조약에 따라 회원국 상호간에 존재하는 의무를 면제하지 아니한다”라고 규정하여 기존의 조약 준수 의무를 천명하고 있다.

12) 정진섭 외 1명, 「국제지식재산권법」, 육법사, 1995, 188면

2. 내국민대우의 원칙

본 협정 제3조제1항에서는 “각 회원국은 파리협약(1967년), 베른협약(1971년), 로마협약 또는 집적회로에관한지적재산권조약이 각각 이미 규정하고 있는 예외의 조건에 따라, 지적재산권 보호에 관하여 자기나라 국민보다 불리한 대우를 다른 회원국의 국민에게 부여하여서는 아니 된다”라고 하여 내국민대우의 원칙을 규정하고 있다. 여기서 「보호」는 협정 제3조 및 제4조의 목적상 이 협정에서 구체적으로 언급된 지식재산권의 사용에 영향을 미치는 사항뿐 아니라 지식재산권의 취득가능성, 취득, 범위, 유지 및 시행에 영향을 미치는 사항을 포함한다. 한편 자국민보다 「불리하지 아니한 대우(treatment no less favorable than)」는 유리한 대우로도 해석될 수 있으므로 파리조약의 자국민과 「동등한 이익(same advantage)」보다 과보호(過保護)를 한다고 할 수 있다.

3. 최혜국대우의 원칙

본 협정 제6조에서는 “지적재산권의 보호와 관련, 일방 회원국에 의해 다른 회원국의 국민에게 부여되는 이익, 혜택, 특권 또는 면제는 즉시, 그리고 무조건적으로 다른 모든 회원국의 국민에게 부여된다”라고 하여 최혜국대우의 원칙을 제시하고 있다. 「최혜국」이란 통상·항해 조약을 체결한 나라 중 가장 유리한 취급을 받는 나라를 말한다. 체약국은 지식재산권의 보호와 관련하여서 한 체약국이 다른 체약국의 국민에 대하여 허용하는 모든 이익, 혜택, 특권 또는 면책 혜택은 「즉시 조건없이(immediately and unconditionally)」 다른 모든 체약국 국민에게 부여되어야 한다(協定 4). 여기에서 「특혜 조치」는 회원국 간의 쌍무 또는 다자간 협약에서 발생하는 모든 특혜를 포함하는 것이며, 지식재산권 관련 협약에서 최혜국대우의 원칙이 규정된 것은 WTO/TRIPs 협정이 처음이다.¹³⁾

4. 권리소진의 원칙

1) 본 협정 제6조에서는 “이 협정에 따른 분쟁해결의 목적을 위하여 제3조(내국민대우의 원칙)와 제4조(최혜국대우의 원칙)의 규정을 조건으로, 본 협정의 어떠한 규정도 지식재산권의 소진문제를 다루기 위하여 사용되지 아니한다”라고 규정되어 있다. 권리소진의 원칙(exhaustion doctrine)은 「first-sale doctrine」이라고도 하는데 적법하게 만들어진 특허제품 등을 일단 판매하면 그 권리자는 원권리자의 독점적인 배포권에도 불구하고 이를 재판매하거나 다른 방법으로 처분할 수 있다는 원칙이다. 즉 제1의 판매로써(특허권, 저작권 등) 권리자의 권리는 소진된다는 것이다.

2) 이 원칙의 적용 시 병렬수입과 대여권이 문제되며 본 원칙에 대한 협상할 때 국가간의 이견이 많았기 때문에 본 협정 문안에는 권리소진을 인정 또는 금지한다는 명시적 규정을 두고 있지 않다.

13) 정진설 외 1명, 「국제지식재산권법」, 육법사, 1995, 190면

IV. 특허와 관련된 내용

1. 특허대상

(1) 원 칙

모든 기술분야에서 물질 또는 제법에 관한 어떠한 발명도 신규성, 진보성 및 산업상 이용가능성이 있으면 특허획득이 가능하다.¹⁴⁾ 한편 발명지¹⁵⁾·기술분야·제품의 수입 또는 국내생산 여부에 따른 차별없이 특허가 허여되고 특허권이 향유된다(協定 27.1).

(2) 불특허대상

i) 체약국은 체약국 영토 내에서의 발명의 상업적 이용의 금지가 i) 인간, 동물 또는 식물의 생명 또는 건강의 보호를 포함하여 필요한 경우, ii) 공공질서 또는 공서양속을 보호하거나, 또는 iii) 환경에의 심각한 피해를 회피하기 위하여 동 발명을 특허대상에서 제외할 수 있다. 단, 이러한 제외는 동 이용이 자기 나라 법에 의하여 금지되어 있다는 이유만으로 취해서는 아니 된다(協定 27.2).

2) 또한 체약국은 아래 사항을 특허대상에서 제외할 수 있다(協定 27.3).

- i) 인간 또는 동물의 치료를 위한 진단 방법, 요법 및 외과적 방법
- ii) 미생물 이외의 동물과 식물, 그리고 비생물학적 및 미생물학적 제법과는 다른 본질적으로 생물학적인 식물 또는 동물의 생산을 위한 제법. 그러나 회원국은 특허 또는 효과적인 독자적 제도 또는 양자의 혼합을 통해 식물변종의 보호를 규정한다. 이 호의 규정은 세계무역기구협정의 발효일로부터 4년 후 재검토된다.

2. 허여된 권리

1) 특허는 i) 특허대상이 물질인 경우, 제3자가 특허권자의 동의를 받지 아니하고 동 물질을 제조, 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 이러한 목적을 위하여 수입하는 행위의 금지,¹⁶⁾ ii)

14) 이 조의 목적상 진보성, 산업상 이용가능성이라는 용어는 회원국에 의하여 각각 비자명성, 유용성이라는 용어와 동의어로 간주될 수 있다.

15) 발명지에 대한 차별문제는 특허에 있어서 미국의 선발명주의와 관련된 것으로 미국이 선발명주의를 적용하는 경우 자국민의 발명에 대해서는 발명일을 인정하는 데 반하여, 외국인의 특허출원에 대해서는 발명일을 인정하지 않고 출원일을 발명일로 적용하는 것에 비롯한 문제이다. 이에 미국을 제외한 대부분의 국가에서는 명시적으로 선출원주의의 채택을 협정에서 규정하도록 주장하였다. 기술분야에 따른 차별은 주로 권리향유에 관한 것으로, 정책적인 이유로 차별을 상정하는 것을 금지하는 것이며, 제품의 수입 또는 국내생산 여부에 따른 차별금지는 대부분의 개발도상국이 특허권자의 의무로서 국내에서 그 발명을 실시하여야 한다고 규정한 가운데, 국내에서 직접 특허발명을 사용하여 생산하지 않고 수입을 통한 국내수요를 충족하는 것도 불실시로 보야 강제실시권을 발동하겠다는 의도를 막기 위한 것이다(윤선희, 「특허법」, 세창출판사, 2003, 910면).

16) 이 권리는 상품의 사용, 판매, 수입이나 그 밖의 유통에 관하여 이 협정에 따라 부여되는 모든 다른 권리와 같이 제6조에 따른다.

특허대상이 제법인 경우, 제3자가 특허권자의 동의를 받지 아니하고 제법사용행위 및 최소한 그 제법에 의하여 직접적으로 획득되는 상품의 사용, 판매를 위한 제공, 판매 또는 이러한 목적을 위한 수입행위에 대하여 특허권자에게 배타적 권리를 부여한다(協定 28.1). 즉 권리자에게는 수입을 허가·금지할 수 있는 권리를 부여하되, 이를 TRIPs 협정 제6조의 권리소진과 관계지어 병행수입을 인정할 것인지는 체약국의 재량사항으로 하였다.

2) 한편 특허권자는 또한 특허권을 양도, 또는 상속에 의하여 이전하고, 사용허가를 체결할 권리를 갖는다(協定 28.2).

3. 허여된 권리에 대한 예외

회원국은 특허에 의하여 허여된 배타적 권리에 대하여 제한된 예외를 규정할 수 있다. 단, 이와 같은 예외는 제3자의 정당한 이익을 고려하여, 특허권의 정상적인 이용에 불합리하게 저촉되지 아니하고 특허권자의 정당한 이익을 불합리하게 저해하지 아니하여야 한다(協定 30). 이와 관련하여 우리나라 특허법은 i) 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(法 96), ii) 재심에 의하여 회복된 특허권의 효력 제한(法 181), iii) 특허료의 추가납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허출원과 특허권의 효력 제한(法 81의3④) 규정을 두고 있다.

4. 특허출원인의 조건

회원국은 특허출원인이 기술분야의 전문가에 의하여 발명이 실시될 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완전하게 발명을 공개하도록 요구하며, 출원일 또는 우선권주장이 있을 경우 우선권주장일 당시에 발명자가 알고 있는 발명의 최적실시형태를 특허출원인이 제시하도록 요구할 수 있다(協定 29.1). 회원국은 특허출원인에게 출원인의 해당되는 외국출원 및 허여에 관한 정보를 제공하도록 요구할 수 있다(協定 29.2). 우리 특허법에서는 최적실시형태를 공개하여야 한다는 규정은 없지만, 이는 임의규정이므로 문제되는 것은 아니다.¹⁷⁾

5. 강제실시권

(1) 적용요건

회원국의 법률이 정부 또는 정부의 승인을 받은 제3자에 의한 사용을 포함하여 권리자의 승인없이 특허대상의 다른 사용¹⁸⁾을 허용하는 경우, 아래의 규정이 준수된다(協定 31).

- a) 이러한 사용의 승인은 개별적인 사안의 내용에 따라 고려된다.
- b) 이러한 사용은, 동 사용에 앞서 사용 예정자가 합리적인 상업적 조건하에 권리자로부터 승인을 얻기 위한 노력을 하고 이러한 노력이 합리적인 기간에 성공하지 아니하는 때에만

17) 지식재산처, 「무역관련지식재산권(TRIPs) 협정」, 1993, 126면.

18) 「다른 사용」은 제30조에 따라 허용되는 것 이외의 사용을 지칭한다.

허용될 수 있다. 이러한 요건은 국가 비상사태, 극도의 긴급 상황 또는 공공의 비상업적 사용의 경우에 회원국에 의하여 면제될 수 있다. 그럼에도 불구하고 국가 비상사태 또는 그 밖의 극도의 긴급상황의 경우 권리자는 합리적으로 가능한 빠른 시간 내에 통보를 받는다. 공공의 비상업적 사용의 경우 정부 또는 계약자가 유효한 특허가 정부에 의하여 또는 정부를 위해서 사용되거나 사용될 것이라는 사실을 특허검색 없이 알거나 알만한 증명할 수 있는 근거가 있는 경우 권리자는 신속히 통보받는다.

- c) 이러한 사용의 범위 및 기간은 동 사용이 승인된 목적에 한정되며, 반도체기술의 경우에는 공공의 비상업적 사용, 또는 사법 혹은 행정절차의 결과 반경쟁적이라고 판정된 관행을 교정하는 것에 한정된다.
- d) 이러한 사용은 비배타적이어야 한다.
- e) 이러한 사용은 양도될 수 없으나, 동 사용을 향유하고 있는 기업 또는 영업권의 일부분과 함께 양도하는 경우에는 예외로 한다.
- f) 이러한 사용은, 동 사용을 승인하는 회원국의 국내시장에 대한 공급을 위해서만 승인된다.
- g) 이러한 사용의 승인은, 그렇게 사용승인을 받은 자의 정당한 이익의 적절한 보호를 조건으로 사용을 허용하게 한 상황이 종료하고 재발할 것 같지 아니하면 종료될 수 있다. 권한있는 당국은 이유있는 신청에 따라 이러한 상황의 계속적인 존재 여부를 심사할 권한을 갖는다.
- h) 권리자는 각 사안의 상황에 따라 승인의 경제적 가치를 고려하여 적절한 보상을 받는다.
- i) 이러한 사용의 승인에 관한 모든 결정의 법적 유효성은 사법심사 또는 회원국 내의 별개의 상위당국에 의한 독립적 심사대상이 된다.
- j) 이러한 사용에 대하여 제공된 보상에 관한 어떠한 결정도 사법심사 또는 회원국 내의 별개의 상위당국에 의한 독립적 심사대상이 된다.
- k) 회원국은 이러한 사용이 사법 또는 행정절차의 결과 반경쟁적인 것으로 판정된 관행을 교정하기 위해서 허용될 때는 b)호 및 f)호에 규정된 조건을 적용할 의무가 없다. 이럴 때 보상액을 결정하는데 반경쟁적 관행의 교정 필요성이 고려될 수 있다. 권한있는 당국은 이러한 승인사유가 재발할 우려가 있으면 이러한 사용승인의 종료를 거부할 권한을 갖는다.
- l) 이러한 사용이 다른 특허(제1차 특허)의 침해없이 이용될 수 없는 특허(제2차 특허)의 이용을 허용하도록 승인되는 때에는 「① 제2차 특허에서 청구된 발명은 제1차 특허에서 청구된 발명과 관련, 상당한 경제적 중요성이 있는 중요한 기술적 진보를 포함한다. ② 제1차 특허권자는 합리적인 조건하에 제2차 특허에서 청구된 발명을 사용할 수 있는 교차특허를 받을 수 있는 권리를 갖는다. 그리고 ③ 제1차 특허와 관련하여 승인된 사용은 제2차 특허의 양도와 함께하는 경우를 제외하고는 양도되지 아니한다.」의 추가적인 조건이 적용된다.

(2) 수입국에 의약품의 수출하기 위하여 특허발명을 실시할 필요가 있는 경우

에이즈나 결핵, 말라리아와 같은 질병으로 심각한 국가적 위기를 당한 개발도상국에서는 90년대 말부터 의약품의 접근성 보장을 위해 특허권을 제한할 필요성을 강하게 주장하였는데,

이는 국내수요를 주목적으로 하도록 규정되어 있는 TRIPs 협정 제31조(f)에 반하여 문제가 되었다. WTO에서는 이를 해결하기 위하여 2001년 11월 카타르 도하에서 개최된 제4차 WTO 각료회의에서 “TRIPs 협정과 공중보건에 관한 도하선언문”을 채택하여 WTO 일반이사회에 해결책을 강구하도록 하였으며, 그 결과로 나온 WTO 결정문은 TRIPs 협정 제31조(f)와 (h) 규정이 후진국의 공중보건문제 해결을 위한 의약품의 수출, 수입에 적용될 때 효력을 일정부분 유보하도록 하였다.

6. 특허의 취소 또는 몰수

특허의 취소 또는 몰수 결정에 대해서는 사법심사의 기회가 주어진다(協定 32). 이는 특허권을 취소하거나 몰수하는 것을 제약하기 위한 규정으로서 특허권의 취소와 몰수에 관한 구체적인 요건 및 절차는 파리조약을 준용하기 때문에 파리조약 제5조 A(1)(2)에 따라 강제실시권만으로 권리자의 권리남용을 규제할 수 없고 최초 강제실시권의 발동 후 2년 후에야 특허권을 행정심판에 의하여 취소 또는 몰수할 수 있다.

7. 보호기간

보호기간은 출원일로부터 20년이 지나기 전에는 종료되지 아니한다(協定 33). 이 규정은 출원일로부터 보호기간을 기산함으로써 특허등록일로부터 기산하는 경우 발생하는 폐해, 즉 심사청구의 의도적 지연이나 장기간 분쟁을 거친 진부한 기술에 대하여 과도한 기간에 특허가 유지되는 것을 방지할 수 있는 측면도 있다.¹⁹⁾

8. 제법특허의 증명책임

1) 특허권자의 권리침해에 관한 민사소송절차를 위하여 특허대상이 물질을 취득하는 제법인 경우, 사법당국은 피고에게 동일 물질을 취득하는 제법이 이미 특허된 제법과 다름을 증명하도록 명령할 권한을 갖는다. 따라서 제약국은 다음 중 최소한 하나의 경우에는 동일한 물질이 특허권자의 동의를 받지 아니하고 생산되었으면 반대의 증거가 없는 한, 이미 특허된 제법에 의해서 취득된 것으로 간주된다고 규정하며, 증명책임이 주장된 침해자에게 있다고 자유로이 규정한다(協定 34.1).

- i) 특허된 제법에 의하여 취득된 물질이 신규인 경우
- ii) 동일물질이 그 제법에 의해서 만들어졌을 상당한 가능성이 있고 특허권자가 합리적인 노력에 의해서도 실제로 사용된 제법을 판정할 수 없는 경우

2) 반대되는 증거의 제시에 있어서 제조 및 영업비밀보호에 대한 피고인의 정당한 이익이 고려된다(協定 34.3). 이와 관련하여 우리나라 특허법은 서류제출(法 130)에 관한 규정을 두고 있다.

19) 박희섭·김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002, 614면.

제4장

특허협력조약

1) 「특허협력조약(Patent Cooperation Treaty; PCT)」은 파리조약 제19조에 따른 특별협정의 하나로서 국제특허출원에 대한 방식요건의 통일화에 주안점을 두고 1970년 워싱턴에서 개최된 외교회의에서 채택되어 1978년 1월 24일부터 효력이 발생하였다. PCT의 당사국은 발명의 보호를 위한 출원의 제출, 조사 및 심사에서의 협력 및 특별한 기술용역의 제공을 위한 동맹을 구성하는데 이를 국제특허협력동맹이라고 한다. 한편 PCT의 어떠한 규정도 파리조약 당사국 국민 또는 거주자의 협약상의 권리를 축소하는 것으로 해석되지 아니한다(PCT 제1조).

2) 우리나라는 1984년 5월 10일에 36번째로 PCT의 가입국이 되었으며 1997년 9월에 개최된 PCT 동맹 총회에서 세계적으로 10번째의 국제조사기관(International Searching Authority; ISA) 및 9번째의 국제예비심사기관(International Preliminary Examining Authority; IPEA)으로 지정되어 1999년 12월부터 업무를 수행하고 있다. 또한 PCT 국제특허출원의 국제 공개할 때 사용되는 언어로 기존에는 영어, 프랑스어, 독일어, 일본어, 러시아어, 스페인어, 중국어, 아랍어 총 8개 언어였으나 2007년 10월 제43차 WIPO 총회에서 한국어 및 포르투갈어가 추가로 채택되었다.

3) 특허협력조약이 체결되기 전에는 발명자가 외국에 특허출원을 하려면 특허를 받으려는 국가마다 요구하는 방식이나 절차에 따라 출원을 하였다. 이는 파리조약에 의한 우선권을 주장할 때도 마찬가지였다. 또한 심사주의를 취하는 각국 특허담당 정부기관(지식재산처, 지식재산처)은 이러한 외국에서의 출원이 있는 경우 국가별로 선행기술을 조사하고 심사를 하여야 하였다. 이와 같은 중복출원 및 중복심사의 실상에 비추어, 출원방식을 통일함과 아울러 중복출원을 하여야 하는 출원인의 노력·비용 및 각국 특허담당 정부기관의 심사를 위한 중복부담을 적극적으로 경감시키기 위한 것이 PCT의 목적이다. 한편 PCT는 그 이외에도 특허문헌을 중심으로 한 기술문헌의 확산 및 제공과 개발도상국의 원조를 그 주된 목적으로 하고 있다. 이에 대한 구체적인 내용은 제5편 「특허협력조약에 의한 국제출원」에서 설명한 바와 같다.

제5장

부다페스트 조약

I. 설립배경

1) 미생물(microorganism)에 관련되는 발명특허를 출원하여 공개할 때는 그 미생물을 특허 출원서에 설명하기보다는 그 미생물의 샘플을 기탁하는 것이 더 효과적이므로 각국의 특허법은 미생물 발명에 대해서는 미생물의 기탁분양을 의무화하고 있으며 이것이 국제적 추세이다. 그런데 종래에는 여러 국가에 출원할 때 국가마다 그 국가에서 지정한 기관에 미생물을 기탁하여야 하는 불편이 있었다. 이러한 불편을 해소하고 특허제도의 국제화를 위하여 국제기탁기관을 정하여 미생물을 기탁하면 조약 동맹국은 따로 각국의 지정 기관에 미생물을 기탁할 필요 없이 각국에 미생물을 기탁한 것으로 인정하자는 취지에서 이루어진 것이 부다페스트 조약이다. 부다페스트 조약이란 「특허절차상 미생물 기탁의 국제적승인에 관한 부다페스트 조약(budapest treaty on the International recognition of the deposit of microorganisms for the purposes of patent procedure)」을 약칭한 것으로서, 1977년 4월 28일에 부다페스트에서 체결되었으며, 1988년 3월 28일에 우리나라도 이 조약에 가입한 바 있다. 현재, 국내미생물 기탁기관으로는 「한국생명공학연구원 미생물자원센터」, 「사단법인 한국중균협회 부설 한국미생물보존센터」와 「재단법인 한국세포주연구재단」으로 3곳이 있다.

2) 이 조약은 특허절차를 목적으로 하는 미생물의 기탁을 허용하거나 필요로 하는 계약국은 그 목적을 달성하기 위하여 조약이 정한 국제기탁기관이 해당 계약국의 영토 내에 있거나 없거나 관계없이 1회에 기탁기관에의 기탁을 상호 승인하여야 한다는 것을 주요내용으로 한다(條約 3(1)). 이 조약에 가입하면 국제기탁기관에 1회만 기탁하면 조약 계약국에 모두 출원할 수 있으므로 비용이 절감되며, 기탁미생물의 보관 및 분양이 보장되는 이점이 있다.

II. 주요내용

1. 국제기탁기관의 지위

국제기탁기관의 지위를 획득하기 위해서는 어떠한 기탁기관도 계약국의 영토에 있어야 하며 동 기관이 다음의 요건을 충족하며 계속하여 충족할 것이라는 계약국 또는 정부 간 산업재산권기관의 보증을 얻어야 하며, 계약국 등으로부터 사무국장에게 서면에 의한 통고가 됨으로써 국제기탁기관으로서의 지위를 획득한다(條約 6, 7).

- i) 영속적으로 존재할 것
- ii) 이 조약에 따라 과학적이며 관리적인 업무를 수행하기 위하여 규칙에 정한 필요한 직원 및 시설을 갖추어 것
- iii) 공평하며 객관적일 것
- iv) 미생물 기탁의 목적상 어떠한 기탁자에 대해서도 동일한 조건하에서 이용이 가능할 것
- v) 모든 또는 특정 종류의 미생물을 수탁하며 그 미생물에 대하여 생존시험을 하고 보관할 것
- vi) 기탁자에게 수탁증을 발행하며 필요한 경우에 생존에 관한 증명서를 발행할 것
- vii) 기탁된 미생물에 대하여 비밀의 유지요건을 충족시킬 것
- viii) 기탁된 미생물의 시료를 분양할 것

2. 미생물의 기탁

(1) 원기탁

특허절차상 미생물의 기탁을 허용 또는 요구하고 있는 체약국은 그러한 목적을 위하여 국제 기탁기관에 대한 미생물의 기탁을 승인하여야 한다. 또한 이 조약과 규칙에서 규정된 사항에 대해서는 어떠한 체약국도 조약과 규칙에서 규정한 요건과 상이한 요건 또는 추가하는 요건을 만족시켜줄 것을 요구하여서는 아니 된다(條約 3). 재기탁의 경우를 제외하고는 기탁자가 국제 기탁기관에 미생물을 기탁하고자 송부할 때에는 다음 사항을 적은 서면에 기탁자가 서명하여 이를 제출한다(條約 규칙 6.1).

- i) 기탁이 조약에 의하여 이루어지며 규칙 제9.1에 규정된 기간(최소 30년)동안 취하지 않겠다는 약속의 표시
- ii) 기탁자의 성명과 주소
- iii) 미생물의 배양, 보관 및 생존시험에 필요한 조건의 상세와 함께 혼합미생물을 기탁하는 경우에는 해당 혼합미생물의 조성과 각 미생물의 존재를 확인하는 최소한 한가지 방법의 설명
- iv) 기탁자가 미생물에 부여한 식별을 위한 표시 (번호, 기호 등)
- v) 건강 또는 환경에 대하여 해를 끼치거나 끼칠 염려가 있는 미생물의 성질 표시 또는 기탁자가 그러한 성질을 알지 못하고 있다는 표시

(2) 재기탁

국제기탁기관은 어떠한 이유 특히 i) 미생물이 생존하고 있지 않거나, ii) 시료의 분양을 위해서는 외국에 송부하는 것이 필요한데 외국으로 송부 또는 수령이 수출 또는 수입의 규제에 의하여 금지되어 국제기탁기관이 시료를 분양할 수 없는 경우에 의하여 기탁된 미생물의 시료를 분양할 수 없는 경우에는 즉시 이유를 지칭하여 기탁자에게 분양할 수 없음을 통지하여야 하며, 기탁자는 원국제기탁기관 또는 다른 국제기탁기관에 미생물을 재기탁하여야 한다.

재기탁을 하는 경우는 재기탁된 미생물이 원기탁 미생물과 동일한 것임을 진술하고 있는 기탁자가 서명한 진술서를 동봉하여야 한다(條約 4).

(3) 수탁증의 발행

기탁자가 국제기탁기관에 대하여 미생물을 기탁하거나 이송할 경우에는 그 국제기탁기관은 그 미생물을 수령하여 수탁하였음을 증명하는 수탁증을 기탁자에게 발행하여야 한다(條約 규칙 7.1). 한편 재기탁에 의하여 수탁증을 발행할 때는 수탁증에 선행기탁에 대한 수탁증의 사본과 선행기탁된 미생물이 생존하고 있음을 표시하는 최신의 생존에 관한 증명서의 사본을 첨부하여야 한다(條約 施規 7.4).

3. 미생물의 보관

(1) 보관기간

국제기탁기관은 수탁한 미생물을 오염시키지 않고 생존시키는 데 필요한 모든 주의를 기울이며 수탁한 미생물의 분양에 대한 가장 최근의 요청이 접수된 후 최소한 5년간 동 미생물을 보관하여야 하며 어떠한 경우에도 수탁일로부터 최소한 30년간은 이를 보관하여야 한다(條約 규칙 9.1).

(2) 비밀유지

국제기탁기관은 어떤 미생물이 조약에 의하여 그 국제기탁기관에 기탁되었는지에 관한 정보를 여하한 자에게도 누설하여서는 아니 된다. 또한 국제기탁기관은 규칙 제11에 의하여 미생물의 시료를 입수할 자격을 가지며 동 규칙에 정하는 조건을 따르는 기관, 자연인 또는 법인을 제외하고는 국제기탁기관에 기탁된 미생물에 관한 정보를 어떤 자에게도 누설하여서는 아니 된다(條約 규칙 9.2)

4. 생존시험 및 생존증명서

(1) 시험의 의무

국제기탁기관은 수탁한 미생물의 생존시험을 다음과 같이 하여야 한다(條約 규칙 10.1).

- i) 국제기탁기관에 원기탁하거나, 재기탁한 경우 또는 국제기탁기관의 업무정지로 다른 국제기탁기관으로 이송된 경우
- ii) 미생물의 종류 및 보관의 조건에 비추어 상당한 간격으로 또는 기술적인 이유에 의하여 필요한 때 언제든지
- iii) 기탁자의 요청이 있을 때 언제든지

(2) 생존증명서

국제기탁기관은 기탁된 미생물에 대한 생존증명서를 다음과 같이 발행한다(條約 규칙 10.2).

- i) 국제기탁기관에 원기탁하거나, 재기탁한 경우 또는 국제기탁기관의 업무정지로 다른 국제기탁기관으로 이송된 경우 즉시
- ii) 요청이 있을 때 기탁 또는 이송 후 언제든지 기탁자에게
- iii) 기탁자를 제외하고 요청이 있을 때 제11규칙에 따라 기탁된 미생물 시료의 분양을 받은 산업재산권청, 기관, 자연인 또는 법인에게 시료의 분양과 동시 또는 시료의 분양 후 언제든지

5. 시료의 분양

1) 국제기탁기관은 계약국 또는 정부 간 산업재산권기구의 산업재산권청, 기탁자 또는 기탁자의 승낙을 얻은 자 그리고 법령상 자격을 가진 자에 대하여 미생물 시료를 분양하여야 한다. 구체적으로 국제기탁기관은 계약국 또는 정부 간 산업재산권기구의 산업재산권청으로부터 요청이 있을 때는 다음의 내용을 선언하는 조건으로 해당 산업재산권청에 대하여 수탁한 미생물의 시료를 분양하여야 한다(條約 규칙 11.1).

- i) 특허 부여를 위하여 미생물의 기탁과 관련된 특허출원이 해당 산업재산권청에 행하여 있으며 해당 출원의 대상이 그 미생물 또는 그의 이용에 관한 것일 것.
- ii) 해당 출원이 해당 산업재산권청에 계속되고 있거나 특허가 허여된 것일 것.
- iii) 해당 계약국 또는 정부 간 산업재산권기구 또는 그 구성국의 특허절차상 유효한 시료를 입수할 필요가 있을 것.
- iv) 시료와 시료에 관련된 정보는 특허절차만을 목적으로 사용될 것.

2) 또한 국제기탁기관은 다음의 경우 기탁된 미생물의 시료를 분양하여야 한다(條約 규칙 11.2).

- i) 기탁자가 요청하는 때 그 기탁자에게
- ii) 기관, 자연인 또는 법인(이하 “승낙을 얻은 자”라 한다)이 요청하는 때 그들에게, 다만 요청에는 기탁자가 시료분양 요청을 승낙한다고 하는 선언이 포함되어 있어야 한다.

제6장

스트라스부르그 협정

1) 「국제특허분류에 관한 스트라스부르그 협정(strasbourg agreement concerning the international patent classification)」은 특허나 실용신안에 대한 통일된 분류체계의 채택을 통해 산업재산권 분야에서 더욱 긴밀한 국제적 협력을 확인하고 이 분야에서 각국의 법령을 조화시키는 데 기여할 목적으로 1971년 3월 24일 스트라스부르그에서 체결된 국제협정이다. 이는 발명특허의 국제분류를 창설하는데 기초가 된 1954년 12월 19일의 발명특허의 국제분류에 관한 유럽협약에 바탕을 두고 있으며 파리조약 당사국이면 이 협정에 가입할 수 있게 되어 있다. 우리나라는 1998년 10월 8일 가입서를 기탁하였으며, 가입서 기탁일로부터 1년 후인 1999년 10월 8일부터 발효되었다.

2) 이 협정이 적용되는 국가는 특별동맹을 구성하며, 발명특허·발명자증·실용신안 및 실용증에 대해서는 「국제특허분류」로 알려진 공통의 분류를 채택한다(條約 1). 국제특허분류는 관리적 성격만을 가지며 특별동맹의 각 회원국은 분류를 주요 또는 보조 분류체계로써 사용할 권리를 가진다(條約 4).

3) 특허분류를 부여하는 것은 심사관이 출원된 발명의 기술내용을 파악하여, 해당 기술이 속하는 기술분류를 명확히 정함으로써 심사관이나 특허정보를 이용하려는 자가 특허정보를 쉽게 검색할 수 있게 하며, 심사관의 심사담당분야를 정하는 기준을 제공함으로써 전문적인 심사를 가능하게 한다. 우리나라 지식재산처는 1948년부터 1979년까지는 일본특허분류를 참고한 한국특허분류(KPC:Korean Patent Classification)를 사용하여 오다가 1980년부터 국제특허분류(IPC: International Patent Classification) 제3판을 도입하여 사용하기 시작하여 현재 IPC 제7판을 사용하고 있는데 이러한 IPC 제7판은 우리나라뿐만 아니라 100여개국이 사용하고 있다. 한편 IPC는 기술진보 등을 고려하여 매 5년마다 개정되고 있다.

제7장

특허법 조약

I. 설립배경

1) 경제와 기술의 탈 국경화에 따라 많은 출원인이 그들의 발명을 외국에서 특허권으로 보호받아야 할 필요성이 높아졌다. 그러나 파리조약에 의하여 각국에서 특허권을 획득하는 것은 각국의 특허법이 서로 달라 그 과정에 어려움을 많이 겪어 왔고, 이러한 어려움을 최소화하려는 방안으로 1970년 특허협력조약(PCT)이 채택된 바 있다. PCT는 기본적으로 하나의 국제출원으로 여러 나라에 출원하는 효과를 거두기 위한 것으로서 그 효과에 한계가 있었다. 즉 PCT는 국제출원이 국제단계에 있을 때 국제사무국, 국제조사기관, 국제예비심사기관, 출원인 등이 지켜야 할 규범을 정할 뿐, 일단 국내단계로 진입하면 그 후 각국 지식재산처에서 진행되는 절차는 규율하지 못하는 것이다. 특히 국내단계에 진입한 국제출원의 절차 및 각국 특허담당 정부기관 내에서의 특허행정절차는 국가마다 속지주의의 원칙에 기초하여 각국 국내법에 따라 수행되도록 하는 문제점이 있다. 따라서 1985년에 들어서서 WIPO를 중심으로 파리조약을 보충하는 조약을 체결하는 방법에 의한 제약국 간의 특허법 통일화 작업을 시도하였고, 1995년 12월부터 약 5년간 5회의 전문가 회의 및 3회의 특허법상설위원회(Standing Committee on the law of Patents, SCP)에서 각국 특허법의 절차적 내용에 한정하여 통일화를 기하려는 구체적인 검토가 되어, 전문 27개 조문의 특허법조약(Patent Law Treaty; PLT)이 2000년 6월 외교회의에서 채택되었다. 한편 현재는 PLT에의 가입·시행이 확산할 것을 대비하여 PCT 제도의 국제실무의 효율화 및 단순화뿐만 아니라 PLT와의 조화를 위한 PCT 개혁에 대한 논의가 활발히 진행되고 있다.

2) 2002년 현재 조약과 최종 의정서에 동시 서명한 국가는 미국, 독일, 스위스, 북한 등 44개 국가이고, 최종의정서에만 서명한 국가는 한국, 일본, 중국, 영국, 프랑스 등 60개 국가와 3개 정부간기구(EPO, 유라시아특허청, 아프리카지역 산업재산권청)이며, 10번째 국가(정부 간 기구제외)가 비준서 또는 가입서를 기탁한 3개월 이후부터 조약이 발효(2002년 10월 현재, 몰도바, 슬로베니아 2개국만 가입) 된다. 여기서 조약에 서명은 동 조약의 내용에 동의함을, 최종의정서에 서명은 조약채택사실을 공식인증함을 의미한다. 우리나라는 현재 논의되고 있는 특허실체법조약(SPLT)이 2~3년내에 타결될 경우 SPLT의 타결을 기다려 PLT와 SPLT에 동시에 가입함으로써 잦은 법개정 및 전산시스템 수정에 따르는 출원인 등의 불편을 최소화하되 SPLT 논의가 장기화될 경우에는 PLT의 가입을 우선 추진할 예정이다.

II. 특 정

PLT는 각국 특히 절차법의 통일화(harmonization) 및 단순화(streamlining)를 통하여, 출원인에게 예측할 수 있고, 일관되며 간소한 특허절차를 제공하기 위하여 총 27개의 조문(article)과 부속하는 21개의 규칙(rule) 및 6항의 합의선언문(agreed statement)으로 구성되어 있으며, 주요내용은 출원일 요건의 완화(제5조), 출원서식의 표준화(제6조), 출원서 기재요건의 완화(제6조), 전자출원제도의 도입(제8조), 실수에 의한 권리의 상실 방지 (제11조, 제12조, 제13조) 등을 규정하고 있다.

III. 주요내용²⁰⁾

1. PLT의 기본원칙(조약 2)

1) PLT는 최대요건(maximum requirements)을 설정하며, 각국은 그 최대요건하에서 출원인의 입장에서 보아 더 유리한(more favorable) 제도를 택할 수 있다. 예를 들어 실용신안은 PLT의 적용대상이 아니나, 각국이 PLT를 실용신안에 적용하는 것은 자유이다. 그러나 출원일 설정 방식의 통일을 위해 출원일 설정을 규정하는 제5조는 본 원칙의 예외이다.

2) 또, 기본적인 원칙으로서, PLT는 각국의 실체적인(substantive) 특허법은 규율하지 아니한다. 상기 PLT의 논의 과정에서 언급되었듯이, PLT는 신규성, 진보성, 명세서 기재요건 등의 실체적 사항에는 적용되지 아니한다. 이는 PLT의 조문 해석에 있어서 중요한 원칙으로서 PLT 조문 해석이 실체를 포함하는 것으로 해석되어서는 아니 된다는 것을 의미한다.

2. 간편한 출원일 설정(조약 5)

1) 특허출원의 첫 단계로서 출원일을 조기에 손쉽게 확보하는 것은 매우 중요하다. 특히 우선권주장을 할 수 있는 시기가 종료되기 직전에는 더욱 그러하다. 우선권을 주장할 수 있는 마지막 날 오후에 출원인이 찾아와 수 개국에 우선권을 주장하여 출원하도록 요청하는 경우에 대리인으로서의 여간 난감한 일이 아니다. PLT에 의하면, 대리인이 이러한 경우에 쉽게 대처할 수 있다. 출원일 설정을 쉽게 하려고 PLT는 출원일 설정과 상대적으로 기재가 까다로운 출원을 분리하였다. 출원일 설정은 먼저 쉽게 하고 차후에 출원하도록 한 것이다.

2) 출원일 설정을 위해서는 제5조의 규정에 의하여, i) 제출되는 서류가 출원을 목적으로 한다는 취지의 명시적 또는 묵시적 표시, ii) 출원인의 신원을 확인할 수 있는 표시 또는 특허담당 정부기관에서 출원인에게 연락할 수 있는 표시 및 iii) 명세서로 간주되는 부분을 제출하면 일단 출원일을 확보할 수 있고, 조약 제6조에 의한 정식의 출원은 시간을 두고(2개월 이상) 천천히 제출하면 되는 것이다.

20) 정양섭, “특허법 조약 : 통일화와 단순화의 추구”, 지식재산21. 2000년 7월호, 전체 참조.

3) 더욱이, 「명세서로 간주되는 부분」은 해당 특허담당 정부기관이 인정하지 아니한 어떤 언어로도 작성될 수 있고 청구항을 포함할 필요도 없다. 만약, 「명세서로 간주되는 부분」을 제출할 여유도 없다면, 이미 출원된 선출원이나 이전출원의 출원번호와 동 출원이 출원되었던 특허담당 정부기관의 이름만을 기재하는 참조(reference) 절차를 통하여 「명세서로 간주되는 부분」의 제출에 갈음할 수도 있다. 또, 출원일 설정을 위해서는 출원료도 낼 필요가 없으며, 출원일 설정 이후 2개월 이내에 천천히 납부하면 되는 것이다.

3. 통일화된 출원양식(조약 6)

1) 출원인은 출원일을 확보한 후 해당 특허담당 정부기관이 정하는 기간에 정식의 출원서를 작성하여 특허담당 정부기관에 제출하여야 하는데 이때에도 각국이 PCT의 출원서 양식에 상응하는 표준화된 양식을 사용하므로 해당 특허담당 정부기관의 다양한 양식을 숙지하고 기재하는 수고를 덜게 된다.

2) 출원인이 해당 특허담당 정부기관이 사용하는 PCT 출원신청서에 상응하는 신청서 외에 PCT 출원신청서 그 자체에 해당 특허담당 정부기관의 국내출원임을 표시하여 제출하여도 동 신청서를 접수하여야 한다. 출원인은 WIPO의 인터넷 사이트에서 해당 특허담당 정부기관이 인정하는 언어로 작성된 PCT 출원신청서를 다운받아 간단히 적을 수 있는 것이다.

3) 또, 우선권주장이 있는 경우 우선권서류의 국어번역문의 제출을 요구하는 현행 각국의 규정과는 달리 PLT는 우선권주장의 진실성이 관련 발명의 특허성 여부를 판단하는데 관련되는 경우에만 국어번역문의 제출을 요구할 수 있도록 하여 출원인의 편의를 증진할 뿐 아니라 특허담당 정부기관의 관리부담도 경감시키고 있다. 나아가서, PLT는 향후 우선권서류를 제출하지 않을 수 있는 여지도 열어 놓고 있다. 즉 WIPO가 구축하려는 지식재산권 디지털도서관(Intellectual Property Digital Library - IPDL)이 완성되면 각 특허담당 정부기관은 타 특허담당 정부기관의 출원관련 서류를 동 도서관에서 조회할 수 있으므로 우선권서류의 제출을 요구할 필요가 없어지는 것이다.

4. 대리인 선정의 비강제(조약 7)

현행 다수 국가의 특허법에 의하면 외국에 출원하기 위해서는 해당 특허담당 정부기관에 등록된 대리인을 통하여 모든 절차를 밟는 것이 일반적이나, PLT에 의하면 많은 절차에 대리가 강제되지 않으므로 일일이 대리인을 선정하여야 하는 불편을 덜게 되고 당연히 대리인에 대한 서비스로 지불이 줄어든다. 앞서 말한 출원일 설정을 위한 서류의 제출은 어떤 경우에도 대리가 강제되지 않을 뿐 아니라, 단순한 수수료의 지불이나 선출원서의 사본 제출 등에도 대리가 강제되지 아니한다.²¹⁾

5. 의사표시(조약 8)

기본적으로 특허담당 정부기관은 출원일 설정 및 지정기간 준수를 위한 서류가 서면으로 제출되는 것으로 접수하여야 하는 의무를 진다. 각국의 각종 서류 양식이 서로 상이하여 출원인이 쉽게 구하기가 어렵다는 것을 감안하여, PLT는 각 특허담당 정부기관이 WIPO가 제안하는 국제표준양식에 의한 서류를 접수하는 의무를 지워 출원인의 편의를 증진하고 있다. 즉 조약 제8조는 출원인이 각종 의사표시를 위해 특허담당 정부기관에 제출하는 서류의 양식(form)과 제출하는 방식(means)에 관하여 규정하면서, 기본적으로 특허담당 정부기관은 출원일 설정 및 지정기간 준수를 위한 서류가 서면으로 제출되는 것으로 접수하여야 하는 의무를 지도록 하였다.

6. 기간 경과의 구제(조약 11)

출원인이 특허담당 정부기관이 정한 지정기간을 준수하지 못하였을 때도 구제의 기회를 제공한다. 출원인이 각종 서류제출의 기간을 준수하지 못하여 귀중한 권리를 상실하는 경우를 최소화하기 위한 배려이다. 하지만, 출원인이 기간 경과에 대한 구제를 받는 것이 상대방에게 피해를 줄 수 있는 경우와 출원인의 실수라고 인정되지 아니한 경우 등은 구제가 허용되지 아니한 것으로 한다.²²⁾ 그 외, 구제가 이미 이루어진 후 재차 구제를 신청하는 것도 허용되지 아니한다.

7. 권리의 복원(조약 12)

본 조항은 출원인이 특허담당 정부기관에 대한 절차와 관련하여 준수하여야 할 기간에 대하여 상당한 주의를 기울였음에도 불구하고 과실없이 준수하지 못하여 출원 또는 특허관련 권리의 상실이 초래되는 경우, 계약국의 권리복원 의무를 규정한다. 권리복원 신청 시에는 신청서에 그 신청이유가 기재되어야 하고 계약국은 신청이유를 지지할 수 있는 서약서 또는 증거를 제출하도록 요구할 수 있다. 다만 상기 기간 경과의 구제(제11조)에서 언급한 바와 같은 이유로 제3자가 불측의 손해를 입을 수 있는 경우 등에는 권리의 복원을 인정하지 않도록 규정하고 있다. 즉 재심기관에서의 절차나 당사자 간 소송에 대한 절차 등에는 권리의 복원을 인정하지 아니한다.

21) 특허 등록유지료의 납부는 대리인의 도움에 대한 필요성이 극히 낮다고 판단되어 대리가 강제되지 않을 뿐만 아니라 제3자도 납부를 대리할 수 있다. 즉 외국의 특허권자는 자국의 은행에 등록유지료 납부를 요청할 수가 있는 것이다. 이론적으로는 변리에 관한 자격증이 없이도 특허담당 정부기관을 상대로 등록유지료 납부만 전담하는 업무를 할 수가 있게 된 것이다. 번역문의 제출도 대리가 강제되지 않도록 하자는 제안에 대하여 외교회의에서 많은 논란이 있었으나, 번역문이 많은 경우 특허의 실체와 관련되는 경우가 있고 개도국 변리사의 양성을 저해하는 측면이 있다는 반발이 있어 채택이 거부되었다.

22) 즉 당사자 간 소송이나 재심기관에서의 절차가 진행 중인 경우에는 상대방이 소송의 결과를 기다리고 있으므로 출원인이 기간 경과의 구제를 소송 지연의 방책으로 악용할 우려가 있으므로 기간 경과를 구제의 대상에서 제외하였다.

8. 우선권주장의 정정 또는 추가 등(조약 13)

우선권주장 기한이 지난 후 2개월 이내에는 우선권주장의 내용을 정정 또는 추가할 수 있는 근거를 제공한다. 또, 우선권주장 기한이 지난 후 2개월 이내에는 후출원하여 우선권을 주장할 수도 있다. 이 경우에는 주어진 상황에서 요구되는 정당한 주의를 기울였음에도 불구하고 우선권주장 기간에 후출원을 제출하지 못하였거나, 또는 체약국의 선택에 따라, 그것이 의도적이 아니었다는 것을 특허담당 정부기관이 발견한 경우에만 해당한다.

제8장

특허실체법 조약

1) 1984년 6월부터 1994년 1월까지 8차에 걸친 전문가 회의를 통해 기본안(draft Patent Harmonization Treaty, PHT)이 작성되었으나 미국의 선발명주의 입장 고수로 조약체결을 위한 외교회의 개최가 무산되고 1995년 이후 「실체」에 관한 부분을 제외하고 「절차」에 관한 사항에만 논의를 진행한 끝에 2000년 6월에 특허법조약(PLT)이 체결되었으며, 현재 특허실체에 관한 사항을 통일화시키기 위한 특허실체법조약(Substantial Patent Law Treaty : SPLT)의 논의가 진행되고 있으며, 현재까지 특허실체법조약(안) 총 16개 조문과 규칙(안) 총 16개 조문 및 실무지침이 제안되어 다루어지고 있다.

2) 구체적인 내용으로는 특허대상, 출원의 내용, 명세서의 내용 및 순서, 청구범위 기재방법, 1출원의 범위, 선행기술, 특허요건(특허대상, 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성), 청구범위 및 보호범위, 보정 및 정정, 의견 및 재심 등에 관한 문제이다. 이 중 선출원주의 채택(미국의 선발명주의 포기), 특허대상의 확대(기술분야 → 인간의 모든 활동분야), 유예기간(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우의 기간)의 확대, 선행기술의 국제주의를 채택, 청구범위 해석 등에 관한 사항이 주요 쟁점이 되고 있다.

PART 10

실용신안법

제1장 서론

제2장 특허제도와 실용신안제도의 비교

제1장

서론

제1절 실용신안제도 일반

1) 실용신안제도는 인간생활에 유용한 새로운 물품을 창작하였지만, 특허부여에 필요한 기술적 진보 또는 발명의 고도성 기준에 달하지 못한 소발명(小發明)을 짧은 기간 동안 간이·신속하게 보호하기 위하여 입법화된 것으로 특허·디자인 및 상표제도와 함께 산업재산권제도의 하나에 속한다. 즉 실용신안제도는 신규의 실용품에 대한 고안자에게 특허보다 단기이지만 일정 기간 그 고안을 독점·배타적으로 실시할 수 있는 권리를 보장함으로써 중소기업자와 기술자를 격려하여 적은 비용으로 낮은 수준의 기술개발이라도 이를 촉진, 유인할 수 있는 인센티브를 주고 중소기업 간의 기술경쟁을 촉진, 조정하는 역할을 하게 하는 것이다. 동시에 실용신안제도에 의한 소발명의 보호는 특허제도의 보호대상인 발명수준의 저하를 방지하는 역할도 하게 되는 것이다.

2) 우리나라는 국가산업정책적인 측면에서 실용신안제도를 특허제도와 함께 병존시키고 있다. 우리나라의 실용신안제도의 발전사는 특허제도의 역사와 그 궤를 같이하여 왔는데, 실제심사를 하던 우리나라의 실용신안법은 특허법과 크게 다를 바가 없었다. 그러나 1990년대에 이르러 특허 및 실용신안 출원건수가 증가함에 따라 심사적체가 심화되어 특허 및 실용신안의 심사처리기간이 약 37개월까지 소요되고, 기술의 생명주기(life-cycle)가 단축됨에 따라 조기 권리화의 필요성이 제기되어 1999. 7. 1. 시행된 구법(법률 제5577호 1998. 9. 23. 개정)에서 실용신안 무심사선등록제도를 도입하였다. 이러한 선등록제도를 통하여 조기권리화가 필요한 출원인은 권리행사시점을 상당기간 단축시킬 수 있었지만 향후 무효 또는 취소될 가능성이 커 권리로서 불안정하며 안정적 사업실시가 곤란하다는 어려움이 있을 뿐만 아니라 권리행사가 제한되는 선등록권리를 특허권 처럼 오용하거나 남용하는 경우 선의의 제3자가 피해를 볼 수 있다는 문제점이 있었다. 또한 지식재산처에서는 심사인력의 충원을 통해 특허출원에 대하여 2004년 21개월에서 2006년 말 약 10개월 수준으로 심사처리기간의 단축을 추진함에 따라 특허출원 후 1차 심사처리기간까지의 기간과 실용신안 선등록출원 후 기술평가착수까지의 기간(약 9.9개월)의 차이가 없어지고, 긴급처리가 요구되는 특허출원을 포함한 우선심사 대상의 대폭 확대로 조기권리화가 필요한 출원인 대부분이 우선심사의 활용이 가능해지면서 실용신안선등록제도의 효용성이 저하되었다.

3) 이에 따라, 실용신안제도를 다시 2006. 10. 1. 시행된 현행법(법률 제7871호, 2006. 3. 3 개정)에서 심사 후 등록제도로 전환하는 한편 특허제도와 통일된 절차를 통한 제도운영으로 민원인의 편의를 도모하고 있다.

제2절 실용신안법의 보호대상

I. 서 설

「실용신안법의 보호대상」은 물품의 형상·구조·조합에 관한 고안(utility model)이다. 여기서 「고안」이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작을 말한다(實用 2 I). 특허의 대상인 발명과 기술적 사상의 창작이라는 면에서는 본질적으로 동일하나, 창작이면 족하고 특허법상의 발명과 같이 창작의 고도성이 필요하지 않다는 점에서 특허법상의 발명과 비교된다. 이하에서는 실용신안법의 보호대상인 「물품의 형상·구조·조합」에 관하여 상세히 살펴보기로 한다.

II. 물품의 형상·구조·조합

1. 「물품」의 의의

「물품」이란 공간적으로 일정한 형태를 가진 것으로서 일반 상거래의 대상이 되는 자유롭게 운반 가능한 상품으로서 사용목적이 명확한 것을 말한다. 따라서 물건일지라도 일정한 형태를 갖지 아니한 의약, 화학물질 등은 실용신안의 보호대상이 아니다. 한편 물품은 독립적 사용가치를 가지는 것만이 아니라 부분적 사용가치를 가지는 부품 등도 포함된다.

2. 물품의 「형상」

「형상」이란 선이나 면 등으로 표현된 외형적 형상을 의미하며, 그것이 입체적인지 평면적인지를 불문한다. 예컨대, 캠의 형상, 톱니바퀴의 치형, 공구의 날과 같은 것이 이에 해당한다.

3. 물품의 「구조」

「구조」란 공간적, 입체적으로 조립된 구성으로서 물품의 외관만이 아니고 평면도와 입면도에 의하여, 경우에 따라서는 측면도나 단면도를 이용하여 표현되는 것을 말한다. 구조상의 특징은 외관상 명료할 것을 필요로 하지 아니한다. 시각적으로 보아 동일구조라고 인정되는 것이라도 절단함으로써, 또는 물리적·화학적 분석에 의하여 구별할 수 있는 경우(재료가 상이한 면도칼, 가열 자성을 갖는 면도칼의 날과 자성을 갖지 아니한 날)는 구조상의 차이가 있는 것으로 본다.

4. 물품의 「조합」

「물품의 조합」이란 물품의 사용 시 또는 불사용 시에 있어서 그 물품의 2개 또는 그 이상의 것이 공간적으로 분리된 상태에 있고 또한 그것들은 독립하여 일정한 구조 또는 형상을 가지고 있어 사용에 의하여 그것들이 기능적으로 서로 관련하여 사용가치를 발휘하는 것을 말한다. 즉 일정한 형상 또는 구조로서의 가치와 기능을 가진 2개 이상의 물품이 결합하여 1개의 물

품으로서 새로운 효과를 낳게 하는 것을 말한다. 예를 들어 라이터와 담배통, 볼트와 너트, 트럼프, 바둑판과 바둑돌 등이 그 예이다.

5. 물품의 형상·구조 또는 조합이 아닌 것

(1) 방법, 제조방법

실용신안법상 물품이라고 말할 수 있으려면 적어도 일정한 형태를 갖는 「물건」이어야 한다. 따라서 「방법」과 같이 물건과 다른 카테고리에 속하는 것은 실용신안법의 보호 대상이 되지 아니한다.

(2) 기능적 표현만으로 기재된 것

예를 들어 ~하는 것, ~하는 방식 등으로 기능적 표현만으로 기재되어 형상·구조를 특정할 수 없는 것은 실용신안법의 보호대상이 되지 아니한다.

(3) 조성물, 합금, 화합물 등 물질에 관한 것

조성물, 합금, 화합물 등은 일정한 형상 또는 구조를 갖는 것으로 인정되지 아니하므로 실용신안등록을 받을 수 없다.

(4) 삼차원의 것이 아닌 것

예를 들어 모양, 마크, 선, 기호 등은 물품의 형상, 구조, 조합에 관한 것이 아니다.

(5) 시퀀스(sequence)

시퀀스(sequence)¹⁾는 형상·구조를 갖는 것이 아니기 때문에 실용신안법의 보호대상이 될 수 없다.

(6) 기능, 게임 등

「기능」, 「게임」 등은 그 자체로는 실용신안법의 보호대상이 되지 아니한다. 이와 같은 경우에는 「...을 갖는 장치」, 「게임기」와 같이 고안의 대상이 물품이라는 것을 명확히 하여야만 실용신안등록을 받을 수 있다.

(7) 일정한 형상 또는 구조를 갖는 것으로 인정되지 아니한 것

일반적으로 토양, 점토, 모래, 액체(물, 우유 등), 분체 등은 일정한 형상 또는 구조를 갖는 것으로 인정되지 아니하므로 실용신안등록을 받을 수 없다.

1) 시퀀스(sequence)란 컴퓨터용어로서 데이터 배열을 의미한다.

제2장

특허제도와 실용신안제도의 비교

구분		특허법	실용신안법
보호대상		발명(방법, 물질, 용도발명도 특허 가능)	물품의 형상·구조·조합에 관한 고안(·:물품성질, 방법 또는 물질에 관한 고안은 등록불가)
성립요건		고도성 필요	고도성 불필요
등록요건	진보성	용이성	「극히 용이성」(즉 낮은 수준의 진보성)
	부등록사유	공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명	* +국기 또는 훈장과 동일하거나 유사한 고안
출원 및 심사	도면첨부	필요한 경우에만 첨부	필수적으로 첨부/미첨부시 불수리
	우선심사사유의 상이	녹색기술과 직접 관련된 특허출원	공해방지에 유용한 실용신안등록출원
		1. 인공지능 또는 사물인터넷 등 4차 산업혁명과 관련된 기술을 활용한 특허출원 2. 반도체 등 국민경제 및 국가경쟁력 강화에 중요한 첨단기술과 관련된 특허출원(지식재산처장이 우선심사의 구체적인 대상과 신청 기간을 정하여 공고하는 특허출원으로 한정한다) 3. 제198조의2에 따라 지식재산처가 「특허협력조약」에 따른 국제조사기관으로서 국제조사를 수행한 국제특허출원 4. 지식재산처장이 외국 특허담당 정부기관장과 우선심사하기로 합의한 특허출원 5. 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법 제36조의8에 따라 규제특례가 적용된 특허사업과 직접 관련된 특허출원 6. 첨단의료복합단지 육성에 관한 특별법 제26조에 따라 규제 특례가 적용되는 입주의료연구개발기관이 제출한 첨단의료복합단지 안 의료연구개발과 관련한 특허출원	-
효력	존속기간	특허권 설정등록을 한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지	실용신안권 설정등록을 한 날부터 실용신안등록출원일 후 10년이 되는 날까지
	존속기간연장	허가등에 따른 연장 + 등록지연에 따른 연장	등록지연에 따른 연장만 가능
	효력범위제한	의약, 의약제법방법 적용 可(法 96②)	의약, 의약제법방법 적용 不可
	간접침해	물건발명, 방법발명 모두 적용 可能	방법발명 / 물질발명은 적용 不可
	생산방법추정	규정 有	규정 無
PCT	도면의 제출	필요적 물수	임의적 물수
	도면의 제출	도면의 설명부분에 대한 국어번역문을 제출하지 아니한 경우 도면의 설명부분에 대한 기재가 없었던 것으로 본다(法 201⑤)	1. 국제실용신안등록출원이 도면(도면에 간단한 설명을 포함)을 포함하지 아니한 경우 「기준일」까지 이를 제출(實用 36①) 2. 제출시 지식재산처장은 기간을 정하여 도면 및 도면의 설명부분의 국어번역문의 제출을 명령(實用 36②) 3. 지식재산처장의 명령에도 불구하고 도면을 제출하지 아니한 경우 그 국제실용신안등록출원을 무효로 할 수 있다(實用 36③). 4. 제출된 도면 및 도면의 설명부분의 국어번역문은 「특허법」 제47조제1항에 따른 보정으로 간주(단, 보정기간은 부적용)(實用 36④).

Index

색 인

- 일반 색인
- 판례 색인
- 표, 그림 색인

일반 색인

➔ 1

1기관의 범위 838

➔ I

IPC 510

➔ P

PBP 339

PCT 571

PCT 제19조 보정 598

PCT 제34조 보정 609

PCT 제8조 631

PLT 1174

product - by - process 339

➔ U

UPOV 58

➔ W

WTO/Trips 1160

➔ ㄱ

가변기간 89

가보호 566, 599, 1156

각자대리의 원칙 84

각하심결 988

간접침해 783, 802

간행물 169

감면 662

감정 140

감정사항 설명의무 814

강제실시권 667, 856, 1154, 1164

강제집행 254

개량발명 63, 454

개량확장설 762

개별대리 81

거절결정 389, 531

거절결정불복심판 1005, 1006

거절이유 155, 516

거절이유통지 516, 518, 524, 1008

거짓행위죄 827

계재 169, 171

견해서 596, 597, 607

결정 988

결정각하 971

결정계 심판 930

결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원 648

결정중지 132

결합발명 65, 765

경고 561, 797

경제설 872

경제성 163

계산방법	90	과제의 해결원리	749
고도성	32, 189	과태료	829
고안	1182	관할	1119, 1138
고유번호	102	관할법원	1138
고유필요적 공동소송	950	교부송달	141
공개특허공보	559	교사설	872
공동발명	68, 237	교체	81
공동심판	950	구성	323
공동절차수행	256	구성요건의 일체성	763
공동직무발명	270	구성요소	323
공동출원	85, 256	구성요소완비의 원칙	745
공무원의 직무발명	279	구성의 곤란성	184
공서양속	222, 224, 558	구술심리	976
공시송달	142	구조	1182
공시의 효과	670	구체적인 행위태양 제시 의무	813
공신력	670	국가 비상사태 등에 의한 통상실시권	888
공연	168	국내 진입 의사 표시 서면	622
공연실시	168	국내단계	576
공용성	805	국내우선권주장출원	453
공유	255	국방상 필요한 발명	228, 229, 558
공유물	841	국선대리인	84, 957
공유물의 분할 청구	841	국유특허권	280
공익상 필요	897	국제공개	565, 598
공익성	654	국제교류설	14
공증	171	국제기탁기관	1168
공증의 영역	213, 754	국제단계	576
공증의 위생	224	국제예비보고서	600
공증의 이용가능성	171	국제예비보고서(특허협력조약 제2장)	608
공지	167	국제예비보고서(특허협력조약 제1장)	598, 600
공지기술	173, 180	국제예비심사	603
공지기술참작의 원칙	63, 740	국제예비심사기관	602
공지예외적용	356, 630	국제예비심사보고서	608, 609
공탁	904	국제예비심사보고서 작성전의 보정	627
공평설	872	국제적 성격	18
과도한 실험	305	국제조사	592
과실의 추정	815, 1064	국제조사기관	592

국제조사보고서	593, 596, 647	기능	35
국제조사보고서 받은 후 보정	598	기본발명	63, 454
국제조사보고서 받은 후의 보정	625	기본원칙	26
국제조사용 번역문	589	기본적 수익권설	13
국제주의	175	기본적 재산권설	13
국제출원서류	581	기산일	90
국제출원의 보완	584	기속력	990
국제출원의 보정	584	기속적 행정행위	119, 122
국제출원의 취하	588	기술	30
국제출원일	583	기술문헌	303
국제출원일의 인정요건	584	기술분야	309
국제출원절차	580	기술상의 진보	909
국제특허분류	510, 1172	기술심리관	1129, 1133
국제특허출원	576, 618	기술적 사상	30
국제특허출원의 특례	618	기재방법요건	307
권리남용	728	기재불비	332
권리능력	235	기준일	300, 623
권리능력상실	255	기탁기관	53
권리능력자	235	기판력	998
권리범위	721, 734	기피	934
권리범위확인심판	1027		
권리서	303	➡ L	
권리소진	706, 1162	납부기간	659
권리요구서	303	내·외국인 평등의 원칙	1146
권리적격	236	내국민대우의 원칙	1162
권리해설서	303	내국인	235
권리행사의 제한	723	내재적 동일성	470
균등론	748	내적부가	327
균등침해	778	노하우	40, 41
그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을		노하우보호설	872
가진 사람	179, 304	누락 부분	585
그대로설	762		
극히 용이	428	➡ C	
기각심결	988	다기재 협범위의 원칙	327
기간의 연장	90, 94		
기간해태의 구제	1176		

다중청구항	330	동맹국 국민	1147
다항제	326, 349	동맹조약	1144
단독발명	68	동물발명	58
단순한 발견	35	동의권	268
단일성	346, 594, 606	동일발명에 대한 심사의 보류	511
단항제	326	동일사실	993
당사자 참가	952	동일심판	994
당사자계 심판	930	동일증거	994
당사자능력	939	동일출원	201
당사자적격	939	둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 관한 특칙	138
당연무효	720	뒷받침	315
당연충지	131	등록공고	558
대리권의 불소멸	80	등록금지적 효력	218, 551
대리권의 증명	79	등록된 통상실시권자	684
대리인	75, 580	등록주의	666
대리인번호	103	등록지연에 따른 특허권의 존속기간연장	690
대발명	69	등록청구권	851
대세적 효력	993	디자인	6
대여	702	디자인권의 존속기간 만료 후의 법정실시권	770
대응특허	822	디자인권의 존속기간 만료 후의 통상실시권	862
대표도	292		
대표자	83, 580		
대학교수발명	282		
대항요건	250		
데이터베이스	8		
도달주의	104		
도면	291		
도면의 간단한 설명	312		
독립발명	64		
독립설	807		
독립성	439, 562, 1148		
독립적 심판	930		
독립항	326		
독점규제및공정거래에관한법률	16		
독점대가설	658		
독점적	700		

무권리자의 특허에 대한 정당한 권리자의 출원	반환	663
1019	발견	35, 42
무심사주의	발명완성사실	267
485, 486	발명을 실시하기 위한 구체적인 내용	313
무역위원회	발명의 내용	311
817	발명의 동일성	469
무체성	발명의 명칭	309
654	발명의 보호	22
무체재산권설	발명의 설명	304, 582
653	발명의 설명 참작의 원칙	739
무효사유	발명의 성립성	28
117	발명의 이용	24
무효심판청구 등록 전의 실시에 의한 통상실시권	발명의 장려	25
878	발명자	237, 287
무효처분의 취소	발명자 게재권	247, 1153
95, 121	발명자권	247
문언적 동일	발명자주의	266
470	발명자증	442
문언침해	발명자표시의무	247, 1153
777	발명장려보조금	25
물건	발명장려설	13
806	발신주의	104, 203
물건발명	방법 사용의 청약	703
59, 701	방법발명	59, 701
물건을 생산하는 방법발명	방식심리	970
701	방식심사	115, 488, 970
물권적 권리	방어출원	209
844	방위사업청	230
물상대위	배경기술	310
914	번역문	294, 620
물질발명	범주	176
59	법률상 추정	62
물품	법률요건분류설	1130
1182	법인	235
미생물	법정기간	89
52	법정대리인	77
미생물 발명		
35, 52		
미성년자		
71		
미완성발명		
35, 173, 210		
미적 창작물		
35		
밀접불가분		
363		
→ B		
반공개 의사		
358		
반도체 기술		
898		
반도체 배치설계		
9		
반려		
121		
반려요청서		
125		
반의사불벌죄		
799		
반출		
140		
반포		
169		

법정실시권	667, 855	부정경쟁방지설	14
변경가능성	751	부품	714
변경용이성	752	부호의 설명	313
변경출원	646	분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확	
변론주의	1124		385, 1052
병합설	246	분산 실시	774
보상규정	276	분양	564
보상금	229	불공정거래행위	897
보상금 또는 대가에 관한 불복의 소	1137	불공정무역행위	817
보상금액	562	불변기간	89
보상금청구권	276, 560, 641	불복의 제한	148
보완사유	584	불성립발명	33, 39, 163
보완의 취하	586	불수리	121
보전	660	불 실시	895
보정	643	불완전이용침해	779
보정각하	389, 398, 1009	불충분한 실시	895
보정명령	119	불특정인	167
보정사유	584	불특허발명	221
보정의 취하간주	388	비밀공개설	13
보조 참가	952	비밀누설죄	825
보호범위	734	비밀유지	600, 608
복대리인	83	비밀유지명령	149
복수 주체	774	비밀유지명령 위반죄	827
복수 회에 걸친 공지	363	비밀유지의무	167, 267
복수당사자의 대표	84	비밀취급명령	229
복수성	439, 1148	비발명	33
복합우선	440, 1152	비법인 사단·재단	72
본안심결	988		
본안심리	975, 1124	➡ 人	
부가기간	90	사상	30
부가의 원칙	746	사상상의 이용	764
부당이득반환청구권	796	사상설	870
부분우선	440, 1152	사업목적의 범위	871
부속성	439, 1148	사업준비	870
부수적 심판	930	사용	702
부작위청구권	844		

사용사실설	805	선발명자보호설	871
사용자	264	선발명주의	200
사용자주의	266	선사용권	871
사적독점보장법으로서의 성격	16	선사용에 의한 통상실시권	871
사적자치의 원칙	846	선의의 무권리자	370
사정계심판	1003	선임	81
사해심결	1098	선출원주의	199
사후적 고찰	182	선택발명	66, 766, 780
산업	157	선택침해	780
산업발전	26	선행기술	180
산업상 이용가능성	156, 313	선행기술문헌	311
산업상 이용할 수 있는 발명	37	선행기술조사	596
산업입법으로서의 성격	16	설명서	598
산업재산권	6	설정등록료	659
산업재산권분쟁조정위원회	901	설정적 승계	250
산업정책설	13	성(보조)기구	223
상·하위개념	175	세계지적재산권기구	1158
상고	1136	소극적 권리범위확인심판	1028
상속인의 부존재	919	소멸시효	563
상업적 성공	185	소명기회	124
상위개념	175	소명서	125
상위개념 추출형	454	소발명	69, 1181
상표	7	소송대리인	1115
상하위개념	175	소송물	1110
상호주의	236	소송요건	1110
생략의 원칙	746	소송요건의 심리	1123
생략침해	779	소송절차의 중지	1139
생산	702, 803	소송참가	1114
생산방법의 추정	61, 814	소유권설	653
서류제출방식	104	소의 이익	1116
서면에 의한 제출	104	소의 취하	1134
서면주의	101, 287	소장	1123
서면주의의 보완	53	속심적 성격	1006
서브컴비네이션	347	속지주의	713
서비스업	157	손해배상청구권	787
서열목록 자유텍스트	313	손해배상청구소송	1108

손해액의 추정	788	실질적인 확장·변경	1053, 1088
송달	141	실체보정	378
수계	130	실체심사	488, 514
수리	714	실효	905
수리관청	580	심결	987
수수료	110, 583	심결각하	973
수수료설	658	심결등본	990
수용	232	심결전치주의	1109
수입	703	심결취소소송	1108
수치한정발명	193	심리·심결의 분리 또는 병합	980
수탁번호	313	심리범위	1126
승계여부의 통지	272, 273	심리종결통지	989
승계인	238	심사	485
승계취득	250	심사관	490
식물발명	35, 57	심사의 보류	511
식물신품종	9	심사의 종료	529
신규사항	381, 645	심사주의	485
신규성	165, 166	심사청구료의 반환	498
신용회복조치청구소송	1108	심사청구제도	209, 492
신용회복청구권	796	심판 또는 소송절차의 중지	999
실시	561, 701	심판관합의체	933
실시가능요건	304	심판물	1116
실시권	843	심판부	933
실시료	1020	심판비용	1000, 1001
실시보고의무	923	심판비용액	1004
실시사업	847, 870	심판의 분류	930
실시상의 이용	766	심판의 종료	984
실시에	313	심판의 진행	979
실시에 보충형	454	심판의 참가	951
실시의무	922	심판장	934
실시태양설	870	심판절차의 중지	938
실시행위의 독립성	704	심판청구서	961
실시협조의무	729, 922	심판청구의 취하	984
실용신안	1181	심판청구이유의 보정	963
실질적 동일성	471		
실질적 확정력	991		



악의의 무권리자	370	용어	344
약리기전	45	용어책임설	739
양도	702	우선권 제도	1148
양도·대여의 청약	703	우선권서류	589
양별규정	800, 828	우선권주장	444, 458, 589, 631
엄격한 기준의 입장	743	우선권주장기간	443, 1150
업	699	우선권주장의 보정	444, 458
업무	828	우선권주장의 취하금지	464
업무발명	263	우선권증명서류	446, 629
업무범위	264	우선기간	443, 457
역균등론	757	우선변제	914
역법적 계산방법	90	우선심사	500
역일주의	218	우선심사제도	499
연결부	335	우선일	299, 621
연구	716	우편물의 지연·망실	105
연혁	14	우편송달	141
열람	140, 150, 564	우회방법발명	781
예고등록	879	우회침해	781
예약승계	269	원고	1138
오역	296, 624	위법판단의 기준시점	1125
오인특허	768	위증죄	826
온라인	107	유럽특허조약	736
외국어특허출원	294, 392	유사필요적 공동소송	950
외국에의 출원권	238	유연한 기준의 입장	743
외국에의 특허출원금지	229	유효성	820
외국의 심사결과	448	의견서	380, 525
외국인	236	의료업	159, 222
외적부가	327	의사에 의한 보정	377
요부공개	559	의약	719
요식주의	287	의약발명	44
요약	292	의약품	898
요약서	292	이용	705, 762, 908
요지변경	963	이용·저촉침해	778
용도발명	36, 42, 60, 176	이용가능성	158
		이일출원	201
		이전적 승계	250

이전청구	244, 374, 375, 834	자의적 판단	182
이중양도	270	자진보정	379
이중우선	461, 462	잘못 기재된 사항을 정정	384, 1052
이중특허	767	잘못된 번역	296, 624
이해관계인	659, 942	잠재성	439, 1148
인격권	247	재내자	71
인격권설	653	재산권	249
인용심결	988	재소금지	998
인용형식	328	재심	1095
일 군의 발명	346, 454	재심사	380, 542
일물일어주의	344	재심사유	1097
일반승계	250, 832, 847	재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권	884, 1103
일부이전	832	재심에 의하여 회복한 특허권에 대한 선사용자 의 통상실시권	881, 1103
일부인용	1059	재심에 의하여 회복한 특허권의 효력 제한	1102
일부취하	549	재외자	72, 639
일사부재리	991	재외자에 대한 송달	143
일실이익	788	재외자와 재내자의 공동출원	87
일정한 확실성	30	재정에 의한 통상실시권	890
일체성 유지	746	재정의 취소	905
임의대리인	77	재판상 화해	1134
입증책임	62, 1041	재판서 정본	1136
→ ㅈ		재현	305
자기지정	454, 631	저작권	6, 10
자동선택제도	604	저작물	7
자료의 제출	816	저촉	705, 762, 763, 778, 864, 908
자백	1132	적극적 권리범위확인심판	1028
자연권설	13	적법성 심리	972
자연법칙의 이용	29	전기통신회선	171
자연인	235	전매조례	15
자연적 계산방법	90	전문공개	559
자유기술	726	전문기관	491
자유기술영역	1020	전부이전	832
자유기술의 항변	1030	전속관할	1120
자유발명	263	전심판여	490, 936

전용성	805	조약우선권주장	634
전용실시권	844	조합	1182
전자문서에 의한 제출	105	조합발명	65, 190
전자상거래 관련 발명	48	존립근거	13
전자서명	106	존속기간	674
전자적 기록매체	108	존속기간연장	677
절차능력(행위능력)	71	존속기간연장등록무효심판	1023
절차보정	117	존속기간연장등록제도	487
절차수행동점	86	중국판결	1134
절차의 무효	116	중속발명	64
절차의 불수리	121	중속설	807
절차의 속행	127, 833	중속항	326
절차의 정지	128	종업원	263
절차의 중단	129	종업원 발명	262
절차의 중지	131, 1110	주발명	595
절차의 효력 승계	126	주변한정주의	735
절차의 효력의 승계	833	주장 · 입증책임	1130
접수번호	112	주지관용기술	187
정규성	442	주합발명	65, 190
정당한 보상	275	준동맹국 국민	1147
정보제공	1009, 1064	중단	130
정보제공제도	552	중복기재	332
정보통신망	108, 142	중복심판청구	967, 997
정정무효심판	1066	중심한정주의	736
정정심판	1050	중용권	370, 878
정정청구	1017, 1068, 1086	중재	822
정지	129	증거보전	798, 981
제법발명	60, 64	증거조사	981
제소기간	1121, 1138	증명서류	446
제척	490, 934	지분	255, 836
제출명령	145	지식재산권의 목적	4
접스 청구항	337	지식재산권의 분류	6
조건부 판매	710	지정국	588
조기공개	559	지정기간	89
조세설	658	지정기일	89
조약	18	지정료	583



탄력성	654
택일적 기재	330
토지경제침범	304
통상실시권	267, 851
통상실시권허락심판	771, 1069
통상실시권허락심판에 의한 통상실시권	906
통상의 기술자	179, 305
통상의 위임대리인	78
퇴보적 발명	187
투여용량	45
투여용법	45
특별송달	141
특별수권	78
특수한 지식	305
특정승계	250, 832
특허결정	532
특허고객번호	102
특허공보	144
특허관리인	78, 639
특허권	653
특허권 공유	705
특허권 포기	706
특허권 하자 참작의 원칙	744
특허권의 공유	255, 835, 836
특허권의 몰수	1154
특허권의 본질	653
특허권의 소멸	917
특허권의 이전	831
특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시	
에 의한 통상실시권	376, 834, 875, 1019
특허권의 특성	654
특허권의 포기	918
특허권의 하자	720
특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위	716

특허권자의 의무	921
특허독립의 원칙	696, 1153
특허등록	666
특허료	655
특허료 납부	536
특허료 추가납부기간경과 후에 납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허권 또는 특허출원에 대한 통상실시권	868
특허료의 추가납부 또는 보전에 의한 특허출원과 특허권의 회복 등	661
특허를 받을 수 있는 권리	245, 246
특허를 받을 수 있는 권리의 승계	250
특허를 받을 수 있는 권리의 이전	250
특허무효심판	1076
특허문서전자화업무	141
특허문헌 제출의무	925
특허발명	700
특허발명의 보호범위	734
특허발생요건	1130
특허법과 타법의 관계	19
특허법상설위원회	574
특허법의 구성	20
특허법의 목적	22
특허법의 성격	16
특허부여 요구권	247
특허분류	510
특허심결	1009
특허심판	929
특허심판원	932
특허심판원 직원	239
특허심판원장	933
특허여부결정	529
특허여부결정의 보류	511
특허요건	155
특허유지료	659
특허이의신청제도	688, 693
특허장	15

특허장애요건	1131
특허제도	13
특허증	670
특허청 직원	239
특허청구범위	735
특허출원	285
특허출원 등에 의한 우선권주장	635
특허출원 전의 승계	250
특허출원 후의 승계	252
특허출원분류	510
특허출원심사의 유예	512
특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것	1056, 1088
특허출원의 취하	548
특허출원의 포기	548
특허출원의 회복	97, 498, 546
특허출원일전	173, 769
특허출원전	173
특허출원표시	146, 924
특허취소신청	1073
특허침해소송	1109
특허표시	146, 924
특허협력조약	571, 1167

➔ Ⅱ

파라미터발명	195
파리조약	1143
판매 제한품	1153
평등주의	236
폐기 · 제거청구	785
포괄위임	79
포대	510
피고	1138
피성년후견인	71
피한정후견인	71

➔ ㅎ

하나의 특허출원의 범위	345
하위개념	175
학술서	225
학위논문	170
학회지	167
합리적 의심	226
합유	836
해태	95
행위능력	70
허가 등에 따른 특허권의 존속기간연장	680
허락에 의한 통상실시권	852
허위표시	146, 826
허위표시의 유형	146
허위표시죄	148, 826
협의명령	201, 251
협의를 물건발명	59, 63
협의를 특허소송	1108
협의제	201, 251
형상	1182
형성행위설	1028
형식적 확정력	991
형식적인 기재방법	307
혼동	848
혼재적 성격	17
화해	822
확대된 선출원의 지위	498
확인대상발명의 보정	963
확인대상발명의 특정	745, 1032
확인행위설	1028
환송	1010, 1134
회색의 기술영역	754
회피	934
회피설계	822
효과	311

효과의 현저성	184
효력이 미치는 범위	696
효력제한기간	98, 662, 869
후견인	77
후발적 무효사유	1015
후용권	881

판례 색인

➔ 대법원

대법원 1960. 10. 26. 선고 4293형상326	799	대법원 1977. 2. 8. 선고 76다2822	269
대법원 1963. 2. 28. 선고 62후14	167	대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7	943
대법원 1964. 6. 23. 선고 63후25	990	대법원 1977. 12. 27. 선고 76후33	127
대법원 1964. 10. 22. 선고 63후45	721	대법원 1978. 9. 5. 선고 78마233	119
대법원 1965. 7. 27. 선고 65후3	979, 981	대법원 1979. 3. 13. 선고 77후50	948
대법원 1965. 7. 27. 선고 79후9	979	대법원 1979. 4. 10. 선고 77후49	943
대법원 1967. 6. 27. 선고 67후1	127, 940	대법원 1979. 10. 10. 선고 79후35	990
대법원 1967. 8. 29. 선고 67후9	964	대법원 1980. 2. 26. 선고 79다2139	786
대법원 1968. 8. 30. 선고 68후10	169	대법원 1980. 5. 13. 선고 79후74	943
대법원 1969. 5. 13. 선고 67후13	171	대법원 1980. 9. 30. 선고 78후3	936
대법원 1970. 6. 30. 선고 70후7	986	대법원 1981. 7. 28. 선고 80후77	943, 949
대법원 1970. 7. 28. 선고 70후26	981	대법원 1982. 8. 24. 선고 81사11	1099
대법원 1970. 8. 31. 선고 69후13	955	대법원 1982. 9. 14. 선고 80후114	969
대법원 1970. 9. 17. 선고 68후28	935, 938	대법원 1982. 9. 28. 선고 80누414	244
대법원 1970. 11. 24. 선고 70후50	982	대법원 1982. 10. 26. 선고 82후24	756, 1031
대법원 1970. 12. 22. 선고 70후20	983, 1043	대법원 1982. 12. 14. 선고 81후53	1100
대법원 1970. 12. 29. 선고 70후64	169	대법원 1983. 2. 8. 선고 81후64	167
대법원 1971. 3. 23. 선고 71후1	982	대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56	177, 721, 1031
대법원 1971. 7. 27. 선고 71다1195	1116	대법원 1983. 11. 22. 선고 83후42	32
대법원 1971. 11. 23. 선고 71후18	169	대법원 1983. 12. 27. 선고 82도3238	827
대법원 1972. 3. 28. 선고 71후32	1098	대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58	943
대법원 1972. 5. 23. 선고 72후4	737	대법원 1984. 1. 31. 선고 83후71	990
대법원 1973. 7. 10. 선고 72후42	737	대법원 1984. 2. 28. 선고 81후10	982
대법원 1973. 8. 31. 선고 72후43	737	대법원 1984. 5. 29. 선고 82도2834	799
대법원 1974. 8. 30. 선고 73후8	756	대법원 1984. 5. 29. 선고 82후30	943
대법원 1976. 4. 27. 선고 74후61	236	대법원 1984. 7. 24. 선고 84누124	1130
대법원 1976. 6. 8. 선고 75후18	994	대법원 1984. 12. 26. 선고 82도1799	799
대법원 1976. 9. 14. 선고 76후6	990	대법원 1985. 4. 23. 선고 84후19	769, 1046
		대법원 1985. 5. 28. 선고 84후14	201

대법원 1985. 5. 28. 선고 84후43	342	대법원 1991. 11. 8. 선고 91후110	226
대법원 1985. 7. 23. 선고 83후26	416	대법원 1991. 11. 12. 선고 90후960	
대법원 1985. 7. 23. 선고 85후51	941, 945		67, 766, 781, 782
대법원 1985. 10. 22. 선고 84후68	1097	대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499	172
대법원 1985. 11. 12. 선고 84후9	180	대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1468	1031
대법원 1985. 12. 24. 선고 85후47	170	대법원 1991. 12. 27. 선고 90후1857	740
대법원 1986. 9. 9. 선고 84후71	411	대법원 1991. 12. 27. 선고 91후1113	265
대법원 1986. 9. 9. 선고 85후12	992	대법원 1992. 2. 25. 선고 91후578	326
대법원 1987. 1. 20. 선고 85후119	963	대법원 1992. 3. 31. 선고 90후1260	53
대법원 1987. 4. 14. 선고 86사38	1098	대법원 1992. 5. 8. 선고 91후1656	39, 210
대법원 1987. 7. 7. 선고 85후46	941, 945	대법원 1992. 6. 2. 선고 91마540	
대법원 1987. 7. 7. 선고 86후107	994		182, 724, 1013
대법원 1987. 7. 21. 선고 87후55	1099	대법원 1992. 6. 26. 선고 92후148	1043
대법원 1987. 8. 18. 선고 87누235	1125	대법원 1992. 7. 28. 선고 92후49	306
대법원 1987. 9. 29. 선고 84후54	342	대법원 1992. 10. 27. 선고 92후377	170
대법원 1987. 12. 8. 선고 87후111	836, 950	대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563	786
대법원 1987. 12. 8. 선고 97다41298	836	대법원 1993. 2. 23. 선고 92도3350	810
대법원 1989. 3. 14. 선고 86후171	940	대법원 1993. 5. 11. 선고 92후1387	181
대법원 1989. 3. 28. 선고 85후109	740	대법원 1993. 5. 11. 선고 92후2090	980
대법원 1989. 3. 28. 선고 87후63	1054	대법원 1994. 5. 13. 선고 93후657	194
대법원 1989. 5. 23. 선고 86후90	981	대법원 1994. 5. 24. 선고 93후381	745
대법원 1989. 8. 8. 선고 88후950	533	대법원 1994. 6. 14. 선고 90후1420	1018
대법원 1989. 11. 28. 선고 89후469	980	대법원 1994. 6. 28. 선고 92후1066	533
대법원 1990. 1. 23. 선고 89후179	963	대법원 1994. 10. 11. 선고 94누4820	1124
대법원 1990. 1. 25. 선고 89후1318	942	대법원 1994. 12. 27. 선고 93후1810	32
대법원 1990. 2. 9. 선고 89후1431		대법원 1995. 1. 12. 선고 93후1414	235
	941, 945, 1027	대법원 1995. 2. 24. 선고 94누9146	1124
대법원 1990. 3. 23. 선고 89후2168	132	대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834	953
대법원 1990. 8. 14. 선고 89후1103	206	대법원 1995. 6. 23. 선고 95쿠3	1003
대법원 1990. 11. 27. 선고 90누4938	1115	대법원 1995. 9. 26. 선고 94후1558	
대법원 1991. 2. 8. 선고 90후1680	91		205, 332, 476
대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250	161	대법원 1995. 11. 10. 선고 95누8461	1125
대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823	1031	대법원 1995. 11. 24. 선고 93후107	980
대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373	738, 1027	대법원 1995. 11. 28. 선고 94후1817	185
대법원 1991. 5. 28. 선고 90후854	964	대법원 1995. 12. 5. 선고 92후1660	65, 765
대법원 1991. 10. 8. 선고 91후59	142	대법원 1995. 2. 24. 선고 94누9146	1124
대법원 1991. 10. 25. 선고 90후2225	724	대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688	168

대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247	1038	대법원 1998. 12. 22. 선고 97후990	65, 190
대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19	170	대법원 1999. 1. 26. 선고 97후3371	235, 920
대법원 1996. 6. 28. 선고 95후95	305	대법원 1999. 3. 12. 선고 97후2156	184
대법원 1996. 10. 29. 선고 95후1302	185	대법원 1999. 3. 26. 선고 97다41295	840
대법원 1996. 11. 22. 선고 96후177	519, 533	대법원 1999. 4. 9. 선고 97후2033	183
대법원 1996. 12. 6. 선고 96후1050	948	대법원 1999. 4. 13. 선고 98다52513	723, 786
대법원 1996. 12. 20. 선고 95후1920769,	1046	대법원 1999. 5. 25. 선고 98다41216	841
대법원 1996. 12. 20. 선고 96누9799	1125	대법원 1999. 6. 11. 선고 99다9622	96
대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658	53	대법원 1999. 10. 22. 선고 97후3203	175
대법원 1997. 4. 11. 선고 96후1217	519, 522	대법원 1999. 11. 12. 선고 98후300	519, 533
대법원 1997. 6. 13. 선고 96다56115	936	대법원 2000. 1. 14. 선고 97후3494	533
대법원 1997. 6. 27. 선고 97도516	268	대법원 2000. 1. 21. 선고 97후2576	362
대법원 1997. 7. 8. 선고 97후75	953	대법원 2000. 4. 11. 선고 97후3241	941, 945
대법원 1997. 7. 22. 선고 96후1699	724, 1031	대법원 2000. 7. 4. 선고 97후2194	781, 782
대법원 1997. 7. 25. 선고 96후2531	58	대법원 2000. 7. 21. 2000다27718	708
대법원 1997. 7. 25. 선고 97다15470	1097	대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200	754
대법원 1997. 8. 22. 선고 97후68	724	대법원 2000. 9. 8. 선고 97후4039	965
대법원 1997. 8. 26. 선고 96후1514	173	대법원 2000. 9. 8. 선고 99다26924	1115
대법원 1997. 9. 5. 선고 96후1743	986	대법원 2000. 11. 10. 선고 2000후1283	720
대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119	791	대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351	737, 745, 777, 779, 782
대법원 1997. 9. 26. 선고 96후825	235	대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270	39, 169, 173
대법원 1997. 10. 10. 선고 96다35484	73, 133	대법원 2000. 12. 12. 선고 2000후1542	1132
대법원 1997. 10. 24. 선고 96후1798	184	대법원 2001. 1. 19. 선고 99두967	1124
대법원 1997. 11. 14. 선고 96후1804	167	대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580	716, 804, 805, 806, 809, 1048
대법원 1997. 11. 14. 선고 96후2135	782	대법원 2001. 5. 8. 선고 98후1921	1117, 1126
대법원 1997. 11. 28. 선고 96후1972	184	대법원 2001. 5. 29. 선고 98후515	521
대법원 1997. 12. 9. 선고 97후44	183	대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617	722, 779, 782
대법원 1998. 2. 27. 선고 97다45532	968	대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836	777, 782
대법원 1998. 2. 27. 선고 97후 2583	1031	대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402	993
대법원 1998. 4. 24. 선고 96후2364	184	대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2252	186
대법원 1998. 6. 26. 선고 97다42823	730	대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522	65, 747, 763, 765, 777, 782, 1048
대법원 1998. 9. 4. 선고 98후744	33		
대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337	324, 342, 1038		
대법원 1998. 10. 13. 선고 97후1344	39, 291, 334, 342, 723, 1038		
대법원 1998. 10. 27. 선고 97후2095	188, 720, 724		

대법원 2001. 8. 21. 선고 99후2372	737, 777, 782, 1034	대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171	744
대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393	763, 782	대법원 2002. 9. 24. 선고 2000다46184	786
대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584	782	대법원 2002. 10. 11. 선고 2002다 33175	793
대법원 2001. 9. 7. 선고 99후437	1062	대법원 2002. 10. 25. 선고 2002두4464	1125
대법원 2001. 9. 7. 선고 99후734	758	대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602	804, 806
대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598	1062	대법원 2002. 11. 8. 선고 2001후2238	52
대법원 2001. 10. 30. 선고 99후710	726	대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후2375	472
대법원 2001. 11. 30. 선고 97후2507	36	대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96	1135
대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815	1054	대법원 2003. 1. 10. 선고 2001후2269	65, 190
대법원 2001. 12. 11. 선고 99후62	726	대법원 2003. 1. 10. 선고 2002후1829	1066
대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513; 98후 235	737	대법원 2003. 2. 11. 선고 2002후2303	1115
대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513 745, 777		대법원 2003. 2. 14. 선고 2002다62319	730
대법원 2001. 12. 24. 선고 99후2181 745, 1018		대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272	731, 793, 815
대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973	291, 334, 723	대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272	872
대법원 2001. 12. 27. 선고 99후1973	39	대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801	158
대법원 2002. 1. 11. 선고 99다59320	1045, 1118	대법원 2003. 3. 25. 선고 2001후1044	549
대법원 2002. 4. 12. 선고 99후2211	1125	대법원 2003. 4. 11. 선고 2002도3445 716, 804	
대법원 2002. 4. 23. 선고2000후2323	1033	대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740	192
대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235	291, 318, 334, 723, 740	대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149	36, 49
대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후2712	339, 741, 758	대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3262	941
대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후235	39	대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419	945, 1038, 1042
대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290	1061, 1115	대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757	1008
대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1306	1108, 1126	대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1102	982, 1115
대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433	769, 1046	대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935	44, 184, 192
대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234	67, 185, 193	대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218	375
대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713	1061	대법원 2004. 6. 11. 선고 2002다18244	792, 793
대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689	170	대법원 2004. 7. 22. 선고 2003후2836	945
대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후17	1034	대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164	1035, 1048
		대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472	175
		대법원 2004. 11. 12. 선고 2002후2822	973

대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1420	1125	대법원 2006. 10. 13. 선고 2005다36830	
대법원 2004. 11. 26. 선고 2002후1775	186		790, 792
대법원 2004. 11. 26. 선고 2002후2105	742	대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776	315
대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567	836	대법원 2006. 10. 26. 선고 2004두14274	
대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496	172		148, 536
대법원 2004. 12. 9. 선고 2002후567 841, 1111		대법원 2006. 10. 30. 선고 2005다36830	789
대법원 2004. 12. 24. 선고 2002후413		대법원 2006. 11. 23. 선고 2005후18	320
	1054, 1055	대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072	
대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218			304, 335, 336
	241, 243, 479	대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240	
대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42	993		739, 757
대법원 2005. 3. 25. 선고 2003후373	942	대법원 2007. 1. 12. 선고 2005후3017	
대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010	1054		204, 206, 476
대법원 2005. 4. 15. 선고 2004후448	194	대법원 2007. 1. 25. 선고 2005다67223	730
대법원 2005. 5. 27. 선고 2003후182	73, 142	대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후3130	
대법원 2005. 7. 28. 선고 2003후922	1109		382, 383, 477
대법원 2005. 9. 28. 선고 2003후2003	55	대법원 2007. 2. 23. 선고 2005도4210	742
대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486	345	대법원 2007. 3. 15. 선고 2006후3588	318
대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2451	1052	대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660	174
대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553	745	대법원 2007. 5. 11. 선고 2007후449	340
대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262	1064	대법원 2007. 6. 4. 선고 2006마907	786
대법원 2005. 10. 28. 선고 2005다45827	731	대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후807	342, 758
대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후3546		대법원 2007. 7. 2. 자 2005마944	785
	185, 329	대법원 2007. 8. 24. 선고 2006후138	182
대법원 2005. 11. 24. 선고 2003후2515	758	대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후1486	323, 342
대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478	1037	대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3277	65, 191
대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031		대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3338	472
	310, 338	대법원 2007. 9. 20. 선고 2006후1100	340
대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006		대법원 2007. 10. 11. 선고 2007후1442	
	795, 793, 815		336, 337
대법원 2006. 5. 11. 선고 2004후1120	315	대법원 2007. 10. 26. 선고 2007다37219	96
대법원 2006. 6. 27. 선고 2004후387	983	대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002	792
대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416	340	대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308	742
대법원 2006. 8. 24. 선고 2004후905	1132	대법원 2008. 4. 24. 선고 2007다44744	777
대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후1936	159	대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052	185
대법원 2006. 10. 12. 선고 2006다1831	792	대법원 2008. 5. 29. 선고 2006후3052	185
대법원 2006. 10. 13. 선고 2004후776 342, 758		대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912	1092

대법원 2008. 6. 26. 선고 2007후4120	1029	대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660	
대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059	181		182, 183
대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57	1034	대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후5215	45
대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후64		대법원 2009. 11. 12. 선고 2007후3660	198
	723, 726, 1030	대법원 2009. 12. 10. 선고 2007후3820	
대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852	1062		534, 1009
대법원 2008. 8. 21. 선고 2006후3472	340	대법원 2010. 1. 14. 선고 2008도639	799
대법원 2008. 9. 11. 선고 2007후4649	1121	대법원 2010. 1. 28. 선고 2007후3572	1124
대법원 2008. 12. 11. 선고 2007후494	49	대법원 2010. 1. 28. 선고 2008후26	342, 758
대법원 2008. 12. 24. 선고 2007다37370	278	대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3520	
대법원 2008. 12. 24. 선고 2007후265	522		66, 192, 472
대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053		대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081	1054
	340, 1092	대법원 2010. 5. 27. 선고 2010후296	
대법원 2009. 1. 30. 선고 2007다65245	815		1032, 1034
대법원 2009. 3. 26. 선고 2006후3250	340	대법원 2010. 6. 10. 선고 2010다5373	73
대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후1510		대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후934739, 1034	
	950, 1113	대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후4998	194
대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후2926	45	대법원 2010. 9. 9. 선고 2009후1897	65, 190
대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후293	45	대법원 2010. 10. 28. 선고 2009도4949	798
대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후3301	1116	대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후289756, 1031	
대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806	755	대법원 2010. 12. 23. 선고 2009후436	345
대법원 2009. 7. 9. 선고 2007후4472	1091	대법원 2011. 2. 24. 선고 2008후4486	
대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3377	65, 191		1029, 1118
대법원 2009. 7. 23. 선고 2008후2770	1136	대법원 2011. 3. 24. 선고 2010후3509	1124
대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977342, 758		대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179	
대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356			198, 212, 474
	702, 804, 805	대법원 2011. 5. 13. 선고 2010다58728	795
대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후2827		대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후620	1068
	204, 205, 474, 475, 723	대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후 2865	44
대법원 2009. 9. 24. 선고 2007후4328	340	대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178	
대법원 2009. 10. 15. 선고 2007다45876	785		68, 242, 276, 277, 479
대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743		대법원 2011. 7. 28. 선고 2010도12834	269
	192, 472	대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507	277
대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736	66, 192	대법원 2011. 9. 8. 선고 2009후2371	478, 522
대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다19925		대법원 2011. 9. 8. 선고 2010후3356	
	816, 1064		965, 1032, 1033
대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다46712	132	대법원 2011. 9. 8. 선고 2011다17090	1033

대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463
 241, 243, 246, 370, 479
 대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다26769 277
 대법원 2011. 10. 13. 선고 2009후4322 44
 대법원 2011. 10. 13. 선고 2010후2582
 195, 303, 304, 315
 대법원 2011. 12. 13. 선고 2011도10525 213
 대법원 2012. 1. 19. 선고 2009후2234
 967, 968, 996
 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390
 188, 724, 726, 730, 821
 대법원 2012. 4. 13. 선고 2010다9320 1116
 대법원 2012. 4. 16. 선고 2011마2412 839
 대법원 2012. 5. 24. 선고 2012후344 965
 대법원 2012. 7. 12. 선고 2011후934 1091
 대법원 2012. 8. 23. 선고 2010후3424
 67, 192, 193
 대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 1038
 대법원 2012. 11. 15. 선고 2011후1494 1038
 대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676
 269, 270, 271
 대법원 2012. 11. 29. 선고 2012후2586 305
 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705
 242, 250, 479
 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 849
 대법원 2013. 2. 14. 선고 2012후3312 37
 대법원 2013. 4. 11. 선고 2012후436
 187, 1124, 1128
 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 475
 대법원 2013. 8. 22. 선고 2012다68279 235
 대법원 2013. 9. 13. 선고 2012후1057 994
 대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후61 965
 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후1573 92
 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 17, 733
 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012후3404
 477, 1053
 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162
 1031, 1118

대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후238
 45, 1052, 1132
 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후3664 44
 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 375
 대법원 2014. 7. 10. 선고 2012후3121
 401, 1128
 대법원 2014. 7. 10. 선고 2013후2101 401
 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361
 749, 752, 780
 대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578
 842, 866
 대법원 2014. 9. 4. 선고 2012후832 318
 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313
 244, 271
 대법원 2014. 11. 13. 선고 2012다42666 1020
 대법원 2014. 12. 11. 선고 2014후1181
 212, 474
 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2999 457, 477
 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012후2432 1016
 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 340
 대법원 2015. 2. 12. 선고 2013후1726 341
 대법원 2015. 4. 9. 선고 2015후31 223
 대법원 2015. 4. 23. 선고 2013후730 44
 대법원 2015. 4. 23. 선고 2015후727 44
 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788
 749, 751, 780
 대법원 2015. 5. 21. 선고 2014후768 44, 45
 대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110
 697, 702, 805, 807, 808
 대법원 2015. 8. 13. 선고 2013도10265
 146, 479, 827, 925
 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후518 306
 대법원 2015. 9. 24. 선고 2013후525 303
 대법원 2016. 1. 28. 선고 2013후1887 67, 193
 대법원 2016. 3. 24. 선고 2015후1997 1127
 대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 1047

대법원 2016. 4. 28. 선고 2015후161	746, 750, 751
746, 763, 1048	
대법원 2016. 5. 26. 선고 2014후2061	
37, 305, 306	
대법원 2016. 5. 26. 선고 2015도17674	1033
대법원 2016. 5. 26. 선고 2015후2061	315
대법원 2016. 11. 25. 선고 2014후2184	
315, 1052	
대법원 2016. 12. 29. 선고 2014후713	235
대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37	
174, 310, 338, 758, 993, 994	
대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347	277
대법원 2017. 4. 7. 선고 2014후1563	
45, 319, 336, 337	
대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638	744
대법원 2017. 4. 28. 선고 2014두42490	621
대법원 2017. 5. 11. 선고 2014후1631	193
대법원 2017. 8. 29. 선고 2014후2702	46
대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366	727
대법원 2017. 11. 14. 선고 2017다23066	968
대법원 2017. 11. 23. 선고 2015후321	252
대법원 2017. 11. 29. 선고 2017후844	684
대법원 2018. 2. 8. 선고 2016후328	
821, 946, 1118	
대법원 2018. 6. 28. 선고 2014후553	401
대법원 2018. 7. 12. 선고 2015후2259	402
대법원 2018. 7. 20. 선고 2015후1669	249
대법원 2018. 8. 30. 선고 2016두36000	676
대법원 2018. 10. 25. 선고 2016후601	306
대법원 2019. 1. 17. 선고 2017다245789	689
대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후523	
33, 37, 57	
대법원 2019. 1. 31. 선고 2016후502	46
대법원 2019. 1. 31. 선고 2017다289903	
706, 709	
대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424	
746, 750, 751	
대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252	752
대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819414, 943	
대법원 2019. 4. 10. 자 2017마6337	1121
대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004	1129
대법원 2019. 10. 17. 선고 2017후1274	
252, 455	
대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782, 2227	
99(병합)	697
대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782	
702, 780, 808	
대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222799	
780, 808	
대법원 2019. 10. 31. 선고 2015후2341	522
대법원 2019. 10. 17. 선고 2019다222782	698
대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522	725
대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446	707
대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360968, 995	
대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2317	968
대법원 2020. 5. 14. 선고 2020후10087	250
대법원 2020. 5. 28. 선고 2017후2291	1032
대법원 2020. 11. 12. 선고 2017후1779	1008
대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830	1135
대법원 2021. 2. 25. 선고 2019후10265	
442, 478	
대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444	768
대법원 2021. 4. 8. 선고 2019후10609	
47, 67, 184, 190, 192, 193	
대법원 2021. 4. 29. 선고 2017후1854	306
대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077	992
대법원 2021. 6. 30. 선고 2021다217011	757
대법원 2021. 9. 16. 선고 2017후2369, 2017후	
2376(병합)	212
대법원 2021. 10. 28. 선고 2021도10010	799
대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1298	
195, 470	

대법원 2021. 12. 30. 선고 2017후1304	471
대법원 2022. 01. 14. 선고 2019후11541	
	62, 1036
대법원 2022. 01. 27. 선고 2019다277751	1132
대법원 2022. 04. 05. 선고 2018후10923	47
대법원 2022. 08. 31. 선고 2020후11479	416
대법원 2022. 11. 17. 선고 2019후11268	243
대법원 2023. 2. 2. 선고 2020후11738	193
대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210	
	744, 753
대법원 2023. 2. 23. 선고 2022후10012	728
대법원 2023. 7. 13. 선고 2021두63099	79, 119
대법원 2023. 7. 13. 선고 2022후10180	194
대법원 2023. 12. 28. 선고 2021후10725	1037
대법원 2024. 1. 11. 선고 2020후10292	306
대법원 2024. 5. 30. 선고 2021다258463	276
대법원 2024. 7. 25. 선고 2021후11070	683
대법원 2024. 11. 20. 선고 2024다270105	1021
대법원 2025. 1. 9. 선고 2022후10814	940
대법원 2025. 3. 27. 선고 2024다306691	858
대법원 2025. 5. 15. 선고 2022다265123	745
대법원 2025. 5. 15. 선고 2022후10746	
	945, 1033, 1034
대법원 2025. 5. 15. 선고 2025다202970	
	697, 698, 717, 808, 809
대법원 2025. 5. 29. 선고 2023후10712	
	359, 363
대법원 2025. 6. 26. 선고 2023후11562	
	361, 728
대법원 2025. 7. 17. 선고 2023후11340	
	343, 742, 759
대법원 2025. 8. 28. 선고 2024후10108	
	973
대법원 2025. 9. 11. 선고 2024후10436	
	1033, 1047
대법원 2025. 9. 29. 자 2025마6304	786

➔ 특허법원

특허법원	1119	특허법원 2000. 11. 16. 선고 2000허2453	337
특허법원 1991. 10. 8. 선고 91후59	142	특허법원 2000. 11. 16. 선고 99허7971	1061
특허법원 1998. 6. 25. 선고 98허1259	962	특허법원 2000. 12. 14. 선고 2000허976	1135
특허법원 1998. 7. 9. 선고 98허3767	171	특허법원 2001. 8. 17. 선고 2000허6387	222
특허법원 1998. 7. 16. 선고 98허5145	346	특허법원 2001. 9. 13. 선고 2001허89	534
특허법원 1998. 9. 3. 선고 98허1822	936	특허법원 2001. 9. 13. 선고 2001호1433	331
특허법원 1998. 9. 4. 선고 98허4722	726	특허법원 2001. 12. 20. 선고 2000허7748	30
특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허2757	235	특허법원 2002. 1. 17. 선고 2001허3453	33
특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허6292	1117	특허법원 2002. 3. 15. 선고 2001허2894	1059
특허법원 1998. 10. 1. 선고 98허2405	243	특허법원 2002. 8. 30. 선고 2002허635	742
특허법원 1998. 10. 29. 선고 98허5312	779	특허법원 2002. 10. 10. 선고 2001허4722	58
특허법원 1998. 11. 6. 선고 98허2498	1036	특허법원 2003. 6. 13. 선고 2002허420	164
특허법원 1998. 11. 26. 선고 98허1747	358, 779	특허법원 2003. 11. 21. 선고 2002허6251	320
특허법원 1998. 12. 10. 선고 98허676	781	특허법원 2004. 3. 5. 선고 2003허1284	1035
특허법원 1999. 4. 16. 선고 98허8014	779	특허법원 2004. 4. 30. 선고 2003허3020	946, 1034
특허법원 1999. 4. 22. 선고 98허9567	1125	특허법원 2004. 5. 21. 선고 2002허3962	719
특허법원 1999. 6. 3. 선고 99허1027	167	특허법원 2004. 7. 1. 선고 2003허6104	159, 163, 222
특허법원 1999. 6. 18. 선고 99허1836	1125	특허법원 2004. 7. 2. 선고 2003허6043	1034
특허법원 1999. 7. 1. 선고 98허9840	1055	특허법원 2004. 10. 15. 선고 2003허6524	163
특허법원 1999. 8. 26. 선고 99허2389	779	특허법원 2004. 11. 4. 선고 2004허3980	142
특허법원 1999. 9. 2. 선고 99허1720	1047	특허법원 2004. 11. 25. 선고 2004허2239	726
특허법원 1999. 10. 7. 선고 98허7592	1114	특허법원 2004. 12. 17. 선고 2004허2314	324
특허법원 1999. 11. 11. 선고 99허4538	971	특허법원 2005. 2. 3. 선고 2004허1984	210
특허법원 2000. 3. 17. 선고 99허5401	1110	특허법원 2005. 3. 31. 선고 2004허4518	337
특허법원 2000. 3. 31. 선고 99허6640	1132	특허법원 2005. 4. 22. 선고 2004허4693	841, 991, 1113
특허법원 2000. 7. 21. 선고 99허2174	983, 1059	특허법원 2005. 5. 20. 선고 2004허5160	173
특허법원 2000. 8. 17. 선고 2000허3463	936	특허법원 2005. 6. 24. 선고 2004허3478	756
특허법원 2000. 9. 7. 선고 99허9755	779	특허법원 2005. 7. 8. 선고 2004허5894	242
특허법원 2000. 9. 21. 선고 99허5654	1132	특허법원 2005. 7. 15. 선고 2004허8671	635
특허법원 2000. 9. 21. 선고 99허6596	168	특허법원 2005. 7. 21. 선고 2005허2724	1135
특허법원 2000. 10. 12. 선고 99허9571	1113	특허법원 2006. 2. 9. 선고 2004허8749	441
특허법원 2000. 10. 26. 선고 2000허273	327		
특허법원 2000. 11. 3. 선고 2000허2620	1110		

특허법원 2006. 10. 20. 선고 2006허1438	1041	특허법원 2009. 1. 2. 선고 2009허4513	1117
특허법원 2006. 12. 21. 선고 2005허11094	29	특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허3018	
특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282	271		241, 271
특허법원 2007. 3. 14. 선고 2006허5294	1113	특허법원 2009. 1. 23. 선고 2008허4523	
특허법원 2007. 3. 28. 선고 2006허6143	241		726, 811
특허법원 2007. 4. 20. 선고 2006허510	726	특허법원 2009. 1. 26. 선고 2008허12180	473
특허법원 2007. 5. 23. 선고 2006허6679	807	특허법원 2009. 2. 18. 선고 2007허12961	721
특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허5966	1053	특허법원 2009. 4. 2. 선고 2008허3452	1128
특허법원 2007. 5. 31. 선고 2006허6280	266	특허법원 2009. 4. 24. 선고 2008허11064	
특허법원 2007. 6. 1. 선고 2006허010661	965		1008, 1128
특허법원 2007. 6. 22. 선고 2007허1008		특허법원 2009. 4. 30. 선고 2008허6482	989
	63, 750	특허법원 2009. 5. 22. 선고 2008허1722	194
특허법원 2007. 6. 27. 선고 2006허8910		특허법원 2009. 7. 1. 선고 2008허7706	478
	29, 49	특허법원 2009. 7. 10. 선고 2008허10764	1008
특허법원 2007. 7. 11. 선고 2006허9197		특허법원 2009. 9. 9. 선고 2009허2227	964
	388, 1128	특허법원 2009. 9. 18. 선고 2009허2432	
특허법원 2007. 7. 12. 선고 2005허10213			212, 723
	1061, 1062	특허법원 2009. 10. 9. 선고 2009허3732	1037
특허법원 2007. 7. 13. 선고 2006허3496	803	특허법원 2009. 10. 10. 선고 2008허12289	968
특허법원 2007. 7. 20. 선고 2006허10548	1135	특허법원 2009. 10. 12. 선고 2008허9498	1063
특허법원 2007. 8. 22. 선고 2006허10135	1016	특허법원 2009. 10. 16. 선고 2009허351	30
특허법원 2007. 8. 24. 선고 2007허1541	726	특허법원 2009. 11. 25. 선고 2008허6314	1037
특허법원 2007. 10. 5. 선고 2007허2469	338	특허법원 2009. 12. 18. 선고 2008허13299	
특허법원 2007. 11. 23. 선고 2007허4816	1040		708, 709, 710, 811
특허법원 2007. 12. 5. 선고 2007허1787	993	특허법원 2010. 3. 19. 선고 2009허1965	179
특허법원 2007. 12. 26. 선고 2007허2957	51	특허법원 2010. 5. 7. 선고 2009허7680	936
특허법원 2008. 4. 17. 선고 2007허7624	322	특허법원 2010. 5. 20. 선고 2009허7031	1044
특허법원 2008. 4. 24. 선고 2007허5765	320	특허법원 2010. 6. 11. 선고 2009허9693	167
특허법원 2008. 5. 2. 선고 2007허8252		특허법원 2010. 11. 3. 선고 2010허111	1040
	965, 1035	특허법원 2011. 4. 27. 선고 2010허2612	522
특허법원 2008. 6. 26. 선고 2007허10743	187	특허법원 2011. 11. 24. 선고 2011허4240	225
특허법원 2008. 6. 26. 선고 2007허13827	159	특허법원 2012. 6. 14. 선고 2012허412	982
특허법원 2008. 7. 9. 선고 2007허13896	1125	특허법원 2012. 6. 20. 선고 2011허10306	522
특허법원 2008. 8. 22. 선고 2007허4649	1115	특허법원 2012. 6. 22. 선고 2011허11750	1016
특허법원 2008. 8. 28. 선고 2007허10101	1089	특허법원 2012. 6. 28. 선고 2012허436	1053
특허법원 2008. 11. 21. 선고 2008허5137	1093	특허법원 2012. 7. 26. 선고 2011허11255	
특허법원 2008. 12. 30. 선고 2008허4936	718		982, 1132

특허법원 2012. 8. 24. 선고 2012허2166	42, 43	특허법원 2018. 11. 8. 선고 2018나1275, 1282	
특허법원 2012. 10. 25. 선고 2012허6342			791
	1052, 1056	특허법원 2018. 11. 8. 선고 2018나1275	793
특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허4954	1040	특허법원 2018. 11. 8. 선고 2018나1282	793
특허법원 2014. 7. 3. 선고 2014허744	1052	특허법원 2018. 12. 14. 선고 2018허3062	159
특허법원 2014. 7. 10. 선고 2013허9805	967	특허법원 2019. 7. 5. 선고 2018허2250, 2018허	
특허법원 2014. 12. 4. 선고 2014허4555		2267	682
	223, 225	특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나1893	792
특허법원 2015. 1. 22. 선고 2014허4449	1128	특허법원 2020. 2. 14. 선고 2019허4833	167
특허법원 2015. 4. 14. 선고 2014허5589	951	특허법원 2023. 11. 30. 선고 2023허11593	
특허법원 2016. 9. 22. 선고 2016허2072	167		741, 1049
특허법원 2016. 10. 20. 선고 2015허7308	357	특허법원 2024. 4. 4. 선고 2023허11944	1036
특허법원 2017. 2. 3. 선고 2016허830	46	특허법원 2024. 4. 18. 선고 2023허13100	1047
특허법원 2017. 5. 25. 선고 2016허7305	806	특허법원 2024. 9. 26. 선고 2023나11399	795
특허법원 2017. 9. 15. 선고 2017허4853	97	특허법원 2024. 10. 31. 선고 2023나11276	795
특허법원 2017. 10. 12. 선고 2017허1021		특허법원 2024. 12. 3. 선고 2023나10914	
	204, 475		717, 718
특허법원 2017. 10. 27. 선고 2017허2727	944	특허법원 2025. 5. 28. 선고 2023나11078	838
특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1001		특허법원 2025. 6. 19. 선고 2024허14162	47
	716, 804		
특허법원 2017. 11. 16. 선고 2016나1455	717		
특허법원 2017. 11. 17. 선고 2017허4501			
	30, 163		
특허법원 2017. 12. 21. 선고 2016허9035			
	44, 682		
특허법원 2018. 2. 1. 선고 2017허1519	172		
특허법원 2018. 1. 11. 선고 2017나1247			
	46, 168		
특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017나2332			
	846, 853		
특허법원 2018. 2. 8. 선고 2017허4228	191		
특허법원 2018. 6. 29. 선고 2017허7005	993		
특허법원 2018. 8. 24. 선고 2018허1301	946		
특허법원 2018. 10. 11. 선고 2018허4874			
	60, 473		
특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4201	1135		

➔ 기타

광주지방법원 2012. 2. 2. 선고 2011가합13793	서울중앙지방법원 2006. 8. 23. 선고 2005가합
270	48548 715, 804
대구고등법원 1976. 11. 12. 선고 76나590	서울중앙지방법원 2008. 1. 31. 선고 2006가합
269	58313 708, 709
대구고등법원 1992. 6. 26 선고 92라7	서울중앙지방법원 2009. 1. 8. 선고 2008가합
872	1588 704, 792, 809
대전지방법원 2009. 12. 4. 선고 2008가합7844	서울중앙지방법원 2009. 1. 23. 선고 2007가합
797	101887 278
부산고등법원 1993. 12. 27. 선고 93라38	서울중앙지방법원 2009. 2. 18. 선고 2007가합
873	77557 870
부산지방법원 2003. 8. 20. 선고 2002가합11918	서울중앙지방법원 2009. 10. 7. 선고 2007가합
271	33960 850
서울고등법원 1988. 7. 4. 선고 88나7745	서울중앙지방법원 2010. 1. 20. 선고 2009가합
785	97210 375
서울고등법원 1990. 9. 5. 선고 90나3166	서울중앙지방법원 2012. 8. 24. 선고 2011가합
659	39552 732, 807
서울고등법원 1992. 7. 29. 선고 91나53298	서울중앙지방법원 남부지원 2002. 8. 22. 선고
815	2001가합13977 265
서울고등법원 1999. 9. 21. 선고 98나41072	서울지방법원 남부지원 제3민사부 2003. 2. 13.
805	선고 96가합6616 789
서울고등법원 2000. 5. 2. 선고 99나59391	서울지방법원 남부지원 제4민사부 2003. 2. 7.
708, 709	선고 2001가합8692 789
서울고등법원 2006. 7. 10. 자 2005라726	서울지방법원 동부지원 1981. 7. 30. 선고 81가
775	합466 713
서울고등법원 2009. 10. 7. 선고 2009나26840	서울행정법원 2011. 11. 4 선고 2011구합21942
275	248
서울고등법원 2012. 4. 19. 선고 2011나45820	수원지방법원 2002. 3. 15. 선고 2001가합3821
748	848
서울고등법원 2016. 3. 24., 선고 2015라20318	헌법재판소 1995. 9. 28, 선고 92헌가11 1119
780	헌법재판소 1995. 9. 28, 선고 93헌가8,9,10(병합)
서울남부지방법원 2001. 6. 15. 선고 2001카합	1119
1074 718	헌법재판소 2007. 11. 29. 선고 2005헌가10 829
서울동부지방법원 2007. 7. 13. 선고 2006가합	
16244 265	
서울민사지방법원 1984. 4. 26. 선고 83가합	
7487 872	
서울민사지방법원 1991. 5. 8. 선고 90가합	
92251 700, 850	
서울중앙지방법원 2003. 7. 3. 선고 2002가합	
3727 276	
서울중앙지방법원 2003. 12. 2. 선고 2002가단	
109162 788	
서울중앙지방법원 2004. 2. 13. 선고 2002가합	
30683호 791	

『표』 『그림』 색인

【표 1-1】 지식재산법의 목적	5
【표 1-2】 지식재산법 체계도	21
【표 1-3】 발명의 보호	24
【표 1-4】 특허법상 諸 원칙	27
【표 1-5】 발명 정의 규정의 필요성	29
【표 1-6】 특허와 노하우의 구별	41
【표 1-7】 식물발명의 특허법과 식물신품종보호법에 의한 보호의 비교	57
【표 1-8】 권리능력과 행위능력의 구별	74
【표 1-9】 포괄위임제도	80
【표 1-10】 대리권의 소멸/불소멸 사유의 구별	81
【표 1-11】 자연적/역법적 계산방법의 구체적인 例	91
【표 1-12】 기간연장·단축 및 기일변경의 비교	95
【표 1-13】 추후보완 및 특허출원의 회복	97
【표 1-14】 특허법상 주요 법정기간(1)	99
【표 1-15】 특허법상 주요 법정기간(2)	100
【표 1-16】 특허출원의 심사	116
【표 1-17】 둘 이상의 청구항이 있는 특허 또는 특허권에 대한 특칙(法 215-215의2)	139
【표 2-1】 선출원주의와 선발명주의의 비교	200
【표 2-2】 선출원주의와 확대된 선출원의 비교	217
【표 2-3】 국방상 필요한 발명 등의 취급	233
【표 2-4】 종업원 발명의 법적 취급	262
【표 2-5】 종업원 발명에 대한 승계	270
【표 2-6】 명세서의 역할	304
【표 2-7】 발명(A, B, C)과 발명의 구성요소(a, b, c, d)의 구별	316
【표 2-8】 미국과 한국에서 연결부의 취급	336
【표 2-9】 잼스 청구항, PBP 청구항 및 기능적 표현 청구항의 비교 분석	343
【표 2-10】 하나의 특허출원의 범위 판단의 구체적 예	350
【표 3-1】 공지에외적용주장을 수반하는 분할출원, 분리출원, 변경출원 및 우선권주장출원의 관계	367
【표 3-2】 보정의 종류	378

【표 3-3】	외국어특허출원에 대한 신규사항추가(法 47②) 판단방법의 예시	393
【표 3-4】	지절이유통지 등의 개념정리	404
【표 3-5】	보정범위가 부적법한 경우의 취급	406
【표 3-6】	발명의 설명 또는 도면에만 기재된 발명의 특허법상 보호방안	409
【표 3-7】	분할출원, 분리출원 및 변경출원의 비교	436
【표 3-8】	우선기간과 우선권주장기간의 비교	444
【표 3-9】	조약우선권주장출원과 국내우선권주장출원의 비교	468
【표 3-10】	특허요건 판단에서 동일성 인정 여부	477
【표 3-11】	규정별 판단대상의 비교	481
【표 4-1】	심사주의와 무심사주의의 비교	487
【표 4-2】	지절이유, 정보제공사유, 특허무효사유 및 특허취소사유의 비교	518
【표 5-1】	PCT에 의한 해외출원과 일반해외출원의 비교	575
【표 5-2】	국제출원의 방식심사	587
【표 5-3】	국제조사기관의 견해서와 국제예비심사기관의 견해서의 비교	608
【표 5-4】	국제조사와 국제예비심사의 비교	610
【표 5-5】	PCT 제19조 보정과 PCT 제34조 보정의 비교	628
【표 5-6】	국내우선권주장과 국제특허출원의 특례	638
【표 5-7】	국제공개와 국내공개의 비교	642
【표 5-8】	국제출원의 보정	646
【표 6-1】	등록의 효력	667
【표 6-2】	출원공개제도와 등록공고제도의 비교	673
【표 6-3】	허가 등과 등록지연에 따른 존속기간연장등록제도의 비교	695
【표 6-4】	주변한정주의와 중심한정주의의 비교	738
【표 6-5】	특허요건과 보호범위 판단 시 청구범위에 기재된 발명 특정의 비교	759
【표 6-6】	甲이 A+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중이고, 乙이 A+B+C+D로 구성된 발명을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부	765
【표 6-7】	甲이 A+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중이고, 乙이 a1(A의 하위구성요소)+B+C로 구성된 발명을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부	766
【표 6-8】	甲이 물건발명(物)을 출원 후 실시중이고, 乙이 물건을 제조하는 방법(方1)을 출원 후 실시중인 경우 후출원의 등록가능성 및 실시가 침해인지 여부	767
【표 6-9】	특허권의 침해에 대한 특허권자의 구체적인 조치	801
【표 6-10】	A, A의 제조장치 및 A의 제조방법과의 관계	812
【표 6-11】	벌칙의 구별	830
【표 6-12】	특허권의 이전에 따른 부수적 권리(실시권, 질권)의 취급	833
【표 6-13】	실시권의 종류	844
【표 6-14】	실시권의 비교	860

【표 6-15】 저촉관계에 있는 경우 존속기간 만료에 의한 법정실시권의 발생 여부	864
【표 6-16】 제138조에 의한 통상실시권과 제183조의 의한 통상실시권의 차이점 비교	885
【표 6-17-(1)】 법정실시권의 요약 정리	886
【표 6-17-(2)】 법정실시권의 요약 정리	887
【표 6-18】 재정에 의한 강제실시권 요건(法 107)의 비교	900
【표 6-19】 강제실시권의 비교	912
【표 6-20】 특허권의 변동과 특허를 받을 수 있는 권리의 변동의 비교	916
【표 6-21】 특허권의 소멸원인과 효과	921
【표 7-1】 심판의 분류	931
【표 7-2】 심판의 당사자	949
【표 7-3】 방식심리와 적법성 심리의 비교	974
【표 7-4】 참가 및 심판청구 취하의 비교	987
【표 7-5】 정보제공과 특허무효심판의 비교	1022
【표 7-6】 권리 사이의 권리범위확인심판의 인정 여부	1048
【표 7-7】 청구범위의 실질적 변경 여부에 대한 구체적 예	1055
【표 7-8】 정정심판과 특허취소신청, 특허무효심판의 관계	1063
【표 7-9】 특허의 정정과 정정심판의 비교	1065
【표 7-10】 심판각론의 비교 (1)	1071
【표 7-11】 심판각론의 비교 (2)	1072
【표 7-12】 특허취소신청제도와 특허무효심판제도의 비교	1085
【표 7-13】 특허취소신청, 특허무효심판 및 정정무효심판에서 정정청구의 비교	1094
【표 8-1】 심판당사자의 원고·피고적격	1112
【표 8-2】 복수당사자의 원고·피고적격	1114

【그림 1-1】 지식재산의 보호 체계	4
【그림 1-2】 특허법 목적의 개념도	22
【그림 1-3】 발명의 실체적 보호	23
【그림 1-4】 기술적 사상의 의미	31
【그림 1-5】 발명의 설명 기재요건과 미완성 발명과의 관계	38
【그림 1-6】 국내기탁기관과 국제기탁기관의 비교	54
【그림 1-7】 일반출원과 미생물출원의 비교	56
【그림 1-8】 물건발명, 제법발명 및 용도발명의 상관도	61
【그림 1-9】 제법발명과 물건발명의 실시 및 효력범위	62
【그림 1-10】 기간계산의 구체적인 例	93
【그림 1-11】 특허에 관한 절차 일반	101
【그림 1-12】 출원절차의 개괄	109
【그림 1-13】 무효처분의 대상 및 효과	120
【그림 1-14】 특허무효심판계속 중 권리가 이전된 경우의 취급	127
【그림 1-15】 비밀유지명령제도	152
【그림 2-1】 신규성 일반	166
【그림 2-2】 상태와 인식의 구별	168
【그림 2-3】 특허출원 및 출원공개의 공지기술 지위 인정 여부	170
【그림 2-4】 특허출원일 전과 특허출원 전의 구별	174
【그림 2-5】 독립항과 종속항의 관계	176
【그림 2-6】 진보성 일반	178
【그림 2-7】 심사 실무상 진보성 판단절차	183
【그림 2-8】 발명과 고안의 창작수준에 따른 법적 취급의 비교	189
【그림 2-9】 결합발명의 신규성, 진보성 판단	191
【그림 2-10】 협의 불성립으로 특허거절결정이 확정된 경우의 취급	202
【그림 2-11】 확대된 선출원 일반	208
【그림 2-12】 확대된 선출원과 출원공개제도를 활용한 심사청구제도의 운영	209
【그림 2-13】 최초 명세서 또는 도면의 의미	210
【그림 2-14】 그 특허출원의 출원일과 다른 출원의 출원일 또는 공개일이 동일자인 경우 적용	211
【그림 2-15】 발명자가 동일한 경우의 구체적인 例	213
【그림 2-16】 그 특허출원한 때의 출원인이 동일한 경우의 구체적인 例	214
【그림 2-17】 비밀취급절차	231
【그림 2-18】 특허를 받을 수 있는 권리의 이전	253
【그림 2-19】 종업원 발명의 종류	263
【그림 2-20】 직무발명의 이중양도	272
【그림 2-21】 직무발명 절차 규정에 따른 권리관계	275

【그림 2-22】 특허를 받을 수 있는 권리의 승계한 사용자 등의 전략	279
【그림 2-23】 특허출원에 필요한 서류(法 42, 42의2)	293
【그림 2-24】 명세서 기재 양식(별지 제15호 서식)	308
【그림 2-25】 청구항의 구성요소 기재방법의 예시	324
【그림 2-26】 다기재 협범위의 원칙	327
【그림 2-27】 종속항의 기재방법	328
【그림 2-28】 개별 특허출원과 하나의 특허출원의 선택	348
【그림 3-1】 공지의예외적용주장출원 일반	357
【그림 3-2】 지식재산처장이 착오로 공개특허공보를 발행한 경우	358
【그림 3-3】 공지사유(法 29①각호)와 공지의예외적용사유(法 30①각호)의 관계	359
【그림 3-4】 공지의예외적용주장과 특허요건의 관계	362
【그림 3-5】 공지의예외적용사유에 해당하는 복수회의 걸친 공지가 있는 경우의 취급	364
【그림 3-6】 공지의예외적용주장을 수반하는 분할출원	365
【그림 3-7】 공지의예외적용주장을 수반하는 우선권주장출원	366
【그림 3-8】 정당한 권리자의 출원 일반	371
【그림 3-9】 정당한 권리자의 출원에 새로운 발명이 기재된 경우의 취급	374
【그림 3-10】 제47조제2항의 신규사항추가 판단	383
【그림 3-11】 제47조제3항제4호의 구체적인 예	387
【그림 3-12】 최후거절이유통지이후 보정의 적법성에 대한 판단 흐름도	390
【그림 3-13】 심사단계에서 보정의 처리절차	391
【그림 3-14】 재심사 청구 전의 보정각하에 대한 불복	405
【그림 3-15】 분할출원 일반	408
【그림 3-16】 분할출원 당시 출원인의 동일성	410
【그림 3-17】 분할출원가능시기	412
【그림 3-18】 조약우선권주장을 수반하는 분할출원	415
【그림 3-19】 분리출원 일반	420
【그림 3-20】 변경출원 일반	428
【그림 3-21】 변경출원 가능시기	431
【그림 3-22】 조약우선권주장을 수반하는 변경출원	433
【그림 3-23】 조약우선권주장출원 일반	438
【그림 3-24】 조약우선권주장의 필요성	439
【그림 3-25】 우선권주장의 보정 또는 추가	445
【그림 3-26】 조약우선권주장출원의 증명서류 제출기간	447
【그림 3-27】 공지의예외적용주장을 수반하는 조약우선권주장출원	450
【그림 3-28】 국내우선권주장출원 일반	453
【그림 3-29】 공지의예외적용주장을 수반하는 국내우선권주장출원	460

【그림 3-30】 누적적 우선권주장출원의 판단시점	461
【그림 3-31】 국내우선권주장 및 국내우선권주장출원의 취하	465
【그림 3-32】 창작수준에 따른 발명 동일성의 유형	470
【그림 3-33】 판례에 의한 규정별 동일성의 인정범위	480
【그림 4-1】 심사청구제도 일반	493
【그림 4-2】 심사청구제도의 취지	493
【그림 4-3】 우선심사제도 일반	500
【그림 4-4】 우선심사절차흐름도	506
【그림 4-5】 심사절차 일반	509
【그림 4-6】 특허여부결정의 보류	512
【그림 4-7】 특허출원심사의 유예	512
【그림 4-8】 맞춤형 심사처리제도	513
【그림 4-9】 외국의 심사결과 제출명령(法 63의3)	523
【그림 4-10】 거절이유통지를 받은 출원인의 대응방안	525
【그림 4-11】 특허거절결정등본을 송달받은 출원인의 대응방안	535
【그림 4-12】 특허거절결정의 확정시기	536
【그림 4-13】 직권보정제도	541
【그림 4-14】 재심사 청구의 시기	544
【그림 4-15】 특허거절결정에 대한 재심사 청구의 심사절차도	547
【그림 4-16】 출원공개제도 일반	556
【그림 4-17】 보상금청구권의 발생 및 행사	563
【그림 5-1】 PCT에 의한 해외출원절차와 일반해외출원절차의 비교	573
【그림 5-2】 우리나라 특허법 규정(法 199-214)에 반영된 PCT	576
【그림 5-3】 국제출원의 개략적인 절차도	577
【그림 5-4】 누락 부분 등에 대한 보완 효과	586
【그림 5-5】 국제조사 및 국제공개 절차	591
【그림 5-6】 국제예비심사 절차	601
【그림 5-7】 국제조사와 국제예비심사의 비교	611
【그림 5-8】 국어번역문 제출 절차도	620
【그림 5-9】 기준일의 정의	623
【그림 5-10】 외국어로 국제특허출원한 경우 PCT 제19조 보정의 국어번역문 제출	626
【그림 5-11】 공지에외적용주장을 수반하는 국제특허출원	630
【그림 5-12】 자기지정의 유형	632
【그림 5-13】 PCT 제8조의 해석	633
【그림 5-14】 해외출원의 방법	634
【그림 5-15】 PCT 선출원의 취하간주시기	637

【그림 5-16】	외국어로 국제특허출원한 경우의 국내공개	640
【그림 5-17】	국제단계에서의 보정에 대한 국어번역문 제출시기와 국내단계에서의 보정시기	643
【그림 5-18】	국제특허출원의 보정범위 제한	645
【그림 5-19】	국제특허출원에 대한 심사청구시기	647
【그림 5-20】	결정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원	648
【그림 6-1】	특허료 납부 절차	665
【그림 6-2】	출원공개되지 않고 등록공고된 특허의 등록금지적 효력	672
【그림 6-3】	허가 등을 받은 날로부터 14년의 상한 설정의 예시	685
【그림 6-4】	허가 등과 연장횟수	686
【그림 6-5】	허가 등에 따른 특허권의 존속기간이 연장된 경우의 특허권의 효력	690
【그림 6-6】	실시와 침해의 구별	704
【그림 6-7】	특허발명이 공지기술과 동일한 경우 침해 판단의 예시	722
【그림 6-8】	하자있는 특허권에 의한 권리행사	725
【그림 6-9】	공지기술과 관련된 무효의 항변과 자유기술의 항변의 비교	727
【그림 6-10】	일체성 유지	747
【그림 6-11】	구성요소완비의 원칙과 균등론의 적용	755
【그림 6-12】	선·후출원 권리의 침해	771
【그림 6-13】	직접침해의 유형별 검토	782
【그림 6-14】	특허에 관한 분쟁 진행의 관할	787
【그림 6-15】	간접침해에 대한 특허권자의 조치	810
【그림 6-16】	특허침해시 대응절차	820
【그림 6-17】	경고장 수령시 제3자의 대응방안	823
【그림 6-18】	1기관의 범위인지에 따른 법률관계	839
【그림 6-19】	통상실시권의 대항요건취득 여부에 따른 법률관계	859
【그림 6-20】	등록의 선·후에 따른 전용실시권과 통상실시권의 관계	859
【그림 6-21】	저촉된 디자인권과 특허권의 취급	865
【그림 6-22】	질권행사로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권의 예	867
【그림 6-23】	공유특허권의 분할청구로 인한 특허권의 이전에 따른 통상실시권의 예	868
【그림 6-24】	선사용권의 구체적 예	873
【그림 6-25】	선사용권과 특허출원을 한 때부터 국내에 있던 물건과의 관계	874
【그림 6-26】	특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권의 예1	876
【그림 6-27】	특허권의 이전청구에 따른 이전등록 전의 실시에 의한 통상실시권의 예2	877
【그림 6-28】	중용권의 예 1	879
【그림 6-29】	중용권의 예 2	880
【그림 6-30】	후용권의 예	883
【그림 6-31】	효력제한(法 181)과 후용권(法 182)의 예	883

【그림 6-32】 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권의 예	885
【그림 6-33】 불실시·불충분실시의 경우 재정청구가능시기	897
【그림 6-34】 재정절차	904
【그림 6-35】 크로스 라이선스의 피청구인 적격	908
【그림 6-36】 특허권과 상표권의 저촉관계	909
【그림 7-1】 복수 당사자의 공동심판청구 및 당사자 참가	952
【그림 7-2】 심판의 일반적인 절차	959
【그림 7-3】 일사부재리 적용의 구체적 예	997
【그림 7-4】 심판-조정 연계 절차	1001
【그림 7-5】 확인대상발명의 특징과 증명책임	1043
【그림 7-6】 특허취소신청의 단계에 따른 정정심판의 청구시기	1057
【그림 7-7】 무효심판의 단계에 따른 정정심판의 청구시기	1058
【그림 7-8】 특허취소신청제도의 절차 흐름도	1077
【그림 7-9】 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있을 것의 판단	1089
【그림 8-1】 심급 제도의 변화	1120
【그림 8-2】 심결취소소송의 절차	1122
【그림 9-1】 조약의 개요	1157

주요참고문헌

- 박성수, 「특허침해로 인해 손해배상액의 산정」, 경인문화사, 2007
- 박희섭 · 김원오, 「특허법원론」, 세창출판사, 2002
- 법원행정처, 「특허소송실무」, 1998
- 사법연수원, 「특허법」, 2009
- (사)한국지식재산학회, 「특허 침해소송의 이론과 실무」, 법문사, 2016
- 손경한, 「신평특허법론」, 박영사, 2005
- 송영식 · 이상정 · 황종환, 「지식재산권법(상)」, 육법사, 1999
- 윤선희, 특허법, 세창출판사, 2003
- 윤선희, 「특허법」, 제5판, 법문사, 2012
- 이시윤, 「신민사소송법」, 박영사, 2002
- 이종완, 「특허법론」, 대한변리사회, 2004
- 이종일, 「특허법」, 제4판, 한빛지적소유권센터, 2001
- 이창훈 · 김인순, 「미국청구범위 작성과 해석」, 한빛지적소유권센터, 2005
- 정상조 · 박성수 共編, 「특허법 주해 I」, 박영사, 2010
- 정상조 · 박성수 共編, 「특허법 주해 II」, 박영사, 2010
- 천효남, 「특허법」, 제9판, 법경사, 2003
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 「지적재산소송실무」, 박영사, 2006,
- 특허법원, 「특허재판실무편람」, 2002
- 특허심판원, 「심판편람」, 제14판, 2024
- 지식재산처, 「등록업무편람」, 2022
- 지식재산처, 「출원방식심사지침서」, 2015
- 지식재산처, 「특허 · 실용신안 심사기준(예규 제140호)」, 2025
- 지식재산처, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 조문별 해설서」, 2008
- 지식재산처, 「조문별 특허법 해설」, 2007
- 지식재산처, 「직무발명제도」, 2012
- 지식재산처, 「PCT 국제조사/국제예비심사 매뉴얼」, 2015
- 한국특허법학회, 「특허판례연구」, 박영사, 2009
- 한빛지적소유권센터 연구실 편저, 「특허법의 제문제(上)」, 한빛지적소유권센터, 1993
- 황종환, 「특허법」, 제9판, 한빛지적소유권센터, 2004

- 竹田和彦 著, 김관식 외 共譯, 「特許の知識 理論と實際」, 제6판, 다이아몬드社, 1999
- 中山信弘 編, 「註解特許法(上卷)」, 第3版, 青林書院, 2000
- 中山信弘, 『공업소유권법상, 제2판·증보판』, 홍문당, 2000
- 中山信弘, 「註解 特許法」, 제2판, 青林書院, 1994
- 吉藤幸朔 著, 유미특허법률사무소 譯, 「특허법개설」, 제13판, 대광서림, 2000.

저자소개

임 | 병 | 용

저자약력

- 한양대학교 전자전기공학부 학사 졸업
- 한양대학교 법학과 석사 졸업
- 한양대학교 법학과 박사 졸업
- 37회 변리사 시험 합격
- (前)이지특허법률사무소 근무
- (前)엠텍비전주식회사 근무
- (前)주식회사 이지팩스 근무
- (前)특허그룹 인사이트플러스 대표변리사
- (前)특허법인 이지 대표변리사
- (現)특허법인 리담 대표변리사

주요저서

- 이지특허법 사례연구 《2002, (주)한빛지적소유권센터》
- 理智 특허법서브 《2009, 한빛지적소유권센터》
- 반도체설계재산 관련 지식재산권 《2009, 지식재산처》
- 특허법의 이론과 판례 《2013, 국제지식재산연수원》
- 지식재산의 정석 《2015, 박문각》
- 특허법의 이론과 실제 《2016, 국제지식재산연수원》
- 특허법 《윤선희 저/ 임병용, 박태일, 강명수 교정저자, 2019, 법문사》
- 음식레시피, 보호와 공유에 관한 이야기
《김성민, 임병용 공저, 2025, 특허법인 리담》
- 理談 특허법 《2026, 특허법인 리담》
- 도해 특허법 《2026, (주)리담지식재산교육원》
- 理談 특허법 객관식I(기출문제편) 《2026, (주)리담지식재산교육원》
- 理談 특허법 객관식II(예상문제편) 《2026, (주)리담지식재산교육원》
- 理談 특허법 강의노트 《2026, (주)리담지식재산교육원》
- 理談 특허법 판례 《2026, (주)리담지식재산교육원》
- 理談 특허법 조문 《2026, (주)리담지식재산교육원》

저자 임 병 응 발행처 특허법인 리담 등록 제2025-000033호

理談 특허법

2002. 04. 04. 초 판	발행
2002. 05. 31. 초 판 2쇄	발행
2002. 11. 02. 초 판 3쇄	발행
2003. 07. 05. 제2판	발행
2004. 01. 25. 제2판 2쇄	발행
2004. 10. 25. 제3판	발행
2005. 10. 01. 제4판	발행
2006. 05. 06. 제5판	발행
2007. 05. 08. 제6판	발행
2008. 04. 05. 제6판 증보판	발행
2008. 09. 20. 제6판 증보판 2쇄	발행
2009. 04. 11. 제7판	발행
2010. 04. 17. 제8판	발행
2010. 10. 05. 제8판 2쇄	발행
2011. 04. 02. 제9판	발행
2012. 04. 20. 제10판	발행
2013. 03. 22. 제11판	발행
2014. 03. 22. 제12판	발행
2014. 07. 25. 제13판	발행
2015. 03. 20. 제14판	발행
2016. 03. 25. 제15판	발행
2017. 03. 17. 제16판	발행
2018. 03. 03. 제17판	발행
2019. 03. 08. 제18판	발행
2020. 03. 27. 제19판	발행
2021. 03. 06. 제20판	발행
2022. 03. 12. 제21판	발행
2023. 03. 11. 제22판	발행
2024. 03. 08. 제23판	발행
2025. 02. 18. 제24판	발행
2026. 02. 27. 제25판	발행